

GUSTAVO TEPEDINO
ANA FRAZÃO
MILENA DONATO OLIVA
COORDENADORES

Lei Geral de **PROTEÇÃO** DE **DADOS PESSOAIS**

e suas repercussões no Direito Brasileiro

2ª edição

De acordo com
a Lei 13.853/2019

THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

PRIMEIRAS PÁGINAS
PRIMEIRAS PÁGINAS

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SUAS REPERCUSSÕES NO DIREITO BRASILEIRO

Coordenadores

Ana Frazão

Gustavo Tepedino

Milena Donato Oliva

© desta edição [2020]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono
Diretora responsável

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 – 13º andar - Vila Olímpia
CEP 04548-005, São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. Violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Os autores gozam da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhes a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

Central de Relacionamento Thomson Reuters Selo Revista dos Tribunais
(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)

Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com

Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso eComm

www.livrariart.com.br

Impresso no Brasil [07-2020]

Profissional

Fechamento desta edição [12.06.2020]



ISBN 978-65-5614-007-0

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Gerente de Conteúdo

Milisa Cristine Romera

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiários: Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

Produção Editorial

Coordenação

Andréia R. Schneider Nunes Carvalhaes

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thaís Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfourri

Estagiárias: Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastro Rosa Pedro

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

Mauricio Alves Monte

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

Ficha catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Lei geral de proteção de dados pessoais e suas repercussões no direito brasileiro [livro eletrônico] / Ana Frazão, Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva, coordenação. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

6 Mb ; ePUB

Vários autores.

2. ed. e-book baseada na 2. ed. impressa.

Bibliografia

ISBN 978-65-5614-007-0

1. Direito à privacidade - Brasil 2. Direito de privacidade 3. Direitos fundamentais - Brasil 4. Personalidade (Direito) 5. Proteção de dados - Direito - Brasil 6. Proteção de dados - Leis e legislação I. Frazão, Ana. II. Tepedino, Gustavo. III. Oliva, Milena Donato.

20-36154 CDU-342.721(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Proteção de dados pessoais : Direito 342.721(81)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Sumário

Apresentação	5
---------------------------	----------

PARTE I ASPECTOS ESTRUTURAIS DA LGPD E DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

Capítulo 1 – Fundamentos da proteção dos dados pessoais – Noções introdutórias para a compreensão da importância da Lei Geral de Proteção de Dados	23
---	-----------

Ana Frazão

1. Introdução	24
2. A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar os efeitos nefastos do capitalismo de vigilância: a violação da privacidade como um negócio	26
3. A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar os riscos que os algoritmos representam às liberdades individuais e à própria democracia.....	31
4. A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar o problema da opacidade e da ausência de <i>accountability</i> da economia movida a dados.....	38
5. A regulação de dados pessoais como forma de endereçar os riscos do poder crescente das grandes plataformas sobre os cidadãos	43
6. Conclusões.....	48
7. Referências bibliográficas	49

Capítulo 2 – Os princípios norteadores da proteção de dados pessoais no Brasil e sua otimização pela Lei 13.709/2018 53*Marco Aurélio Bellizze Oliveira e Isabela Maria Pereira Lopes*

Introdução.....	53
1. O sistema legal de proteção de dados no Brasil e seus princípios	61
2. A concretização dos princípios na Lei de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018	71
3. Conclusão	80
Referências bibliográficas.....	81

Capítulo 3 – A proteção de dados pessoais na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 83*Ricardo Villas Bôas Cueva*

1. Introdução	83
2. Do conceito tradicional de privacidade à proteção de dados pessoais ...	84
3. Um novo conceito de privacidade reconhecido na análise dos cadastros negativos e positivos de crédito	86
4. Os sistemas de avaliação de risco de crédito (<i>credit score</i>)	88
5. Remoção de conteúdos da internet e o direito ao apagamento de dados pessoais.....	91
6. Considerações finais	95
Referências bibliográficas.....	96

Capítulo 4 – Objetivos e alcance da Lei Geral de Proteção de Dados..... 97*Ana Frazão*

1. Introdução	97
2. Os objetivos da LGPD: o que proteger e por que proteger?	98
2.1. Os direitos tutelados pela LGPD e a sua dimensão existencial...	98
2.2. Uma nova compreensão da privacidade	102
2.3. A racionalidade econômica da proteção dos dados pessoais ...	108
3. O alcance da LGPD: como proteger?	114
3.1. A LGPD no contexto das alternativas de autorregulação ou correção	114
3.2. A LGPD no contexto das alternativas de regulação pela tecnologia.....	116

3.3. A LGPD e a questão da regulação pelo mercado: consentimento ou dominação?	120
3.4. A LGPD como fio condutor das demais formas de regulação ...	123
4. Considerações finais	124
5. Referências bibliográficas	125

Capítulo 5 – A titularidade de dados pessoais prevista no art. 17 da LGPD: direito real ou pessoal?

127

Roberta Mauro Medina Maia

1. Introdução	127
2. Ainda sobre direitos reais e pessoais: sua distinção estrutural e funcional	129
3. A titularidade dos dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a teoria da apropriação (<i>propertization</i>)	139
4. Titularidade x propriedade: distinção terminológica e a opção adotada pelo legislador	144
5. Conclusão	148
Referências	149

Capítulo 6 – Quando a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica?

153

Joyceane Bezerra de Menezes e Hian Silva Colaço

Introdução	154
1. Sociedade da informação e tutela da privacidade: emergência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, de 14.08.2018)	157
2. Tensão entre Privacidade, Informação e Segurança	161
3. Matérias que não sofrem incidência da LGPD	166
3.1. Tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos	168
3.2. Tratamento de dados para fins jornalísticos e artísticos	172
3.3. Tratamento de dados para fins acadêmicos	179
3.4. Tratamento de dados realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou de atividades de investigação e repressão das infrações penais	182
3.5. Dados coletados, tratados e utilizados fora do território nacional	187
Conclusão	190

Capítulo 7 – Diálogos entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação	195
<i>Ana Carla Harmatiuk Matos e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk</i>	
1. Introdução	196
2. Do caráter jusfundamental do direito à informação e do direito à privacidade	197
3. Das diretrizes fundamentais da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e do sigilo como exceção.....	198
4. Dos princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e de sua vinculação expressa à proteção à privacidade	199
5. Da disciplina da Lei de Acesso à Informação a respeito dos dados pessoais.....	200
6. Da definição de dados pessoais na Lei 13.709/2018 e das diretrizes quanto à sua coleta e ao seu tratamento.....	202
7. Possíveis controvérsias advindas da aplicação conjunta de ambos os diplomas legais, e da necessidade de sua harmonização	204
Conclusão	212
Referências bibliográficas.....	214
 Capítulo 8 – Término do Tratamento de Dados.....	217
<i>Gisela Sampaio da Cruz Guedes e Rose Melo Vencelau Meireles</i>	
1. Introdução	217
2. Término do tratamento de dados.....	219
3. Direito ao esquecimento: distinção necessária.....	223
4. Responsabilidade civil pelas operações de dados após o término do seu tratamento	226
5. Considerações Finais	234
Referências	235
 Capítulo 9 – Direitos do titular de dados pessoais na Lei 13.709/2018: uma abordagem sistemática	237
<i>Eduardo Nunes de Souza e Rodrigo da Guia Silva</i>	
1. Introdução	237
2. Direitos e remédios na tradição de <i>civil law</i>	242
3. A pretensa atribuição de direitos ao titular de dados pela LGPD: enunciação de remédios.....	253
4. O risco da suposta taxatividade dos remédios previstos pela LGPD....	263

5. Considerações finais	274
6. Referências bibliográficas	275

Capítulo 10 – Consentimento e proteção de dados pessoais na LGPD 281

Gustavo Tepedino e Chiara Spadaccini de Teffé

1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: notas introdutórias.....	282
2. O consentimento do titular dos dados.....	292
3. Tratamento de dados pessoais sensíveis: requisição de consentimento específico e destacado	301
4. Dados pessoais de crianças e adolescentes: considerações sobre a norma relativa ao consentimento.....	306
Considerações finais.....	315
Referências	316

Capítulo 11 – Potencialidades do direito de acesso na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) 319

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho e Diana Paiva de Castro

1. Introdução	320
2. Redefinição do conceito de privacidade na legalidade constitucional ...	321
3. Efetividade do direito de acesso na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.....	323
3.1. Procedimento do acesso: gratuito, facilitado e tutelado por meio individual ou coletivo.....	325
3.2. Funcionamento do acesso: informações a respeito de todo o processo de tratamento, tutela do princípio da não discriminação e gama de direitos do titular	327
3.3. Âmbito de incidência do acesso: integralidade dos dados tratados por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado	334
4. Considerações finais	339
5. Referências bibliográficas	340

Capítulo 12 – O direito à portabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados..... 343

Daniela Copetti Cravo

1. Introdução	343
2. Natureza da portabilidade de dados.....	345

3. Fundamentos da portabilidade de dados	346
4. A portabilidade de dados na nova Lei	355
5. Considerações finais	359
6. Referências bibliográficas	360

Capítulo 13 – Direito ao Esquecimento e Proteção de Dados Pessoais na Lei 13.709/2018: distinções e potenciais convergências..... 363

Anderson Schreiber

1. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o chamado direito ao esquecimento	363
2. O que é, afinal, o direito ao esquecimento?	366
3. Direito à eliminação de dados <i>versus</i> direito ao esquecimento	372
4. Conclusão: perspectivas para o direito ao esquecimento a partir da LGPD	376
Referências bibliográficas.....	379

Capítulo 14 – Os direitos de explicação e de oposição diante das decisões totalmente automatizadas: comparando o RGPD da União Europeia com a LGPD brasileira..... 381

Alexandre Veronese

1. Introdução	382
1.1. Dados e informações	382
1.2. Do processamento regular ao processamento ampliado (<i>Big Data</i>).....	385
2. O marco jurídico da União Europeia: o RGPD.....	391
2.1. A proteção em face de decisões automatizadas.....	393
2.2. O direito à oposição em face de decisões automatizadas	396
2.3. O direito à explicação sobre a lógica subjacente às decisões automatizadas.....	400
2.4. Procedimentos de controle sobre sistemas de decisão automatizados no RGPD	402
3. O marco jurídico brasileiro	404
4. Considerações finais	407
5. Referências.....	408

Capítulo 15 – Segurança e Sigilo dos Dados Pessoais: primeiras impressões à luz da Lei 13.709/2018 413*Carlos Affonso Pereira de Souza*

1. Introdução	414
2. Segurança e sigilo de dados na legislação brasileira	415
3. O tratamento da segurança e do sigilo de dados na LGPD (arts. 46-49)...	419
3.1. <i>Privacy by design</i>	423
3.2. Incidentes de segurança e dever de notificação	426
3.2.1. O que são incidentes de segurança	426
3.2.2. Implementação de medidas de segurança pelos agentes de tratamento de dados	429
3.2.3. A notificação de incidentes de segurança.....	432
4. Conclusão	435
Bibliografia	436

Parte II**Diversos Tipos de Tratamento de Dados e Questões Específicas****Capítulo 1 – O tratamento de dados sensíveis à luz da Lei 13.709/2018** 441*Carlos Nelson Konder*

1. Introdução	441
2. Privacidade, identidade e não discriminação: a chave de leitura dos dados sensíveis.....	442
3. A qualificação de dados pessoais como sensíveis.....	447
4. Disciplina normativa aplicável ao tratamento de dados sensíveis.....	452
5. Considerações finais	455
6. Referências.....	456

Capítulo 2 – Tratamento de dados pessoais por “legítimo interesse do controlador”: primeiras questões e apontamentos 459*Daniel Bucar e Mario Viola*

1. Introdução	460
2. Legítimo interesse do controlador: um breve contexto.....	462

2.1.	Origem e controvérsias na legislação da União Europeia	462
2.2.	A “privacidade-instrumento” e o legítimo interesse do controlador no ordenamento jurídico brasileiro: fixação e lições preliminares.....	465
3.	A “ponderação de interesses”: provocações metodológicas e parâmetros de aplicação.....	468
3.1.	Quem controla o controlador?	468
3.2.	Afinal, como ponderar? Uma proposição civil-constitucional... ..	469
3.3.	Ponderação de interesses <i>stricto sensu</i> : pressupostos, <i>modus operandi</i> e alguns parâmetros	470
4.	Proposta aberta de sistematização dos conflitos: análise funcional da proteção de dados	471
4.1.	Conflito entre situações patrimoniais: a obrigação polarizada ao adimplemento.....	472
4.2.	O legítimo interesse existencial: autonomia privada, influência sobre terceiros	473
4.3.	Ponderação (ou superposição) das situações existenciais às patrimoniais?.....	474
5.	Conclusão	475
6.	Referências.....	477

Capítulo 3 – Primeiras impressões sobre o tratamento de dados pessoais nas hipóteses de interesse público e execução de contratos

479

Luciana Pedroso Xavier, Marília Pedroso Xavier e Mayara Guíbor Spaler

1.	Introdução	480
2.	A proteção dos dados pessoais	484
3.	Análise dos requisitos para tratamento de dados	489
4.	Tratamento de dados pelo Poder Público.....	490
5.	Considerações Finais	494
6.	Referências Bibliográficas	496

Capítulo 4 – A autoridade parental e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes.....

499

Ana Carolina Brochado Teixeira e Anna Cristina de Carvalho Rettore

1.	Introdução	499
2.	O conteúdo do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente na sociedade de informação	505

3. O conteúdo da autoridade parental e dos dados pessoais da criança e do adolescente.....	510
4. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes.....	517
5. Considerações finais	520
Referências	521

Capítulo 5 – Proteção dos dados pessoais da pessoa com deficiência.....

525

Heloisa Helena Barboza, Paula Moura Francesconi de Lemos Pereira e Vitor Almeida

Considerações iniciais.....	526
1. Vulnerabilidade e privacidade: proteção no caso de deficiência	527
2. Proteção dos dados pessoais da pessoa com deficiência	533
3. Dados sensíveis médicos, discriminação e consentimento	543
Considerações finais.....	550
Referências	552

Capítulo 6 – Tratamento de dados para a concessão de crédito....

555

Milena Donato Oliva e Francisco de Assis Viégas

1. Introdução: impacto da LGPD no mercado de concessão de crédito...	555
2. Tratamento de dados para a formação de cadastros de inadimplentes: o cadastro negativo	560
3. Tratamento de dados para a formação de histórico de crédito e atribuição de <i>rating</i> de crédito.....	571
3.1. Cadastro positivo.....	571
3.2. O sistema <i>credit scoring</i>	583
4. Notas conclusivas	593

Capítulo 7 – A utilização econômica de rastreadores e identificadores *on-line* de dados pessoais.....

595

Aline de Miranda Valverde Terra e Caitlin Mulholland

Introdução: um caso emblemático	596
1. A proteção de dados e o conceito de autodeterminação informativa...	598
2. Dos <i>cookies</i> ao Google Analytics: o que são identificadores e rastreadores <i>on-line</i>	603
3. <i>Data as the new oil</i> : precificação dos dados e o novo insumo da relação de consumo.....	609

4. Considerações finais	611
5. Bibliografia.....	612

Capítulo 8 – Transferência internacional de dados na Lei Geral de Proteção de Dados – Força normativa e efetividade diante do cenário transnacional

615

Angelo Gamba Prata de Carvalho

I. Introdução	616
II. A transferência internacional de dados na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira	617
II.1. Transferência internacional para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei brasileira.....	618
II.2. Garantias de cumprimento dos preceitos da LGPD.....	620
II.3. Derrogações específicas	623
III. <i>Exceptio probat regulam?</i> Percalços e perspectivas da garantia de proteção adequada na transferência internacional de dados.....	626
IV. Considerações finais a um tema em aberto: projeto de construção da força normativa transnacional da LGPD	632
Referências	635

Capítulo 9 – Fluxo de informação no âmbito dos grupos societários e proteção dos dados pessoais

639

Raul Murad e Rodrigo Requena

1. Introdução	640
2. Restrições ao compartilhamento de dados <i>intercompany</i>	646
3. Potencialidades do grupo empresarial no tratamento de dados pessoais	653
4. Gestão de dados pessoais e operações de reorganização societária ...	658
5. Breves reflexões a respeito do possível impacto concorrencial provocado pelo compartilhamento de dados <i>intercompany</i>	659
6. Conclusão	663
7. Bibliografia.....	664

Capítulo 10 – Compliance de dados pessoais

669

Ana Frazão, Milena Donato Oliva e Vivianne da Silveira Abilio

I. Introdução: características gerais da LGPD e o papel da concretização prática da tutela dos dados pessoais.....	669
--	-----

II. Breves considerações sobre função e conteúdo de programas de <i>compliance</i>	675
III. <i>Compliance</i> de dados pessoais	685
IV. À guisa de conclusão: complexidade, custos e necessidade de efetivo estímulo à adoção de programas de <i>compliance</i> de dados pessoais ...	702
V. Referências.....	704

Capítulo 11 – A Autoridade Nacional de Proteção de Dados: origem, avanços e pontos críticos à luz das mudanças recentes... 707

Beto Vasconcelos e Felipe de Paula

1. Nota à Segunda Edição	708
2. Introdução	708
3. A Relevância dos Arranjos Institucionais: por quais motivos se defendeu a criação de uma Autoridade Nacional e de um Conselho Nacional de Proteção de Dados?	712
4. O Debate no Executivo e a Construção da Autoridade Nacional.....	716
5. A Tramitação Legislativa	718
6. O Veto Presidencial: a questão do vício de iniciativa	720
7. A Criação de Autoridade Nacional via Medida Provisória n. 869/2018: riscos envolvidos e oportunidades perdidas	723
8. A Aprovação da MP 869: base legal da Autoridade, atraso na implementação e questões ainda pendentes	727
9. Conclusão	729
Bibliografia	731

Capítulo 12 – A tutela processual dos dados pessoais na LGPD ... 735

Andre Vasconcelos Roque, Bernardo Barreto Baptista e Henrique de Moraes Fleury da Rocha

1. Introdução	736
2. Competência para as medidas judiciais fundadas na LGPD	737
2.1. Jurisdição do Poder Judiciário brasileiro (competência internacional)	737
2.2. Competência doméstica	741
3. Direito probatório e a LGPD	743
3.1. Produção antecipada de prova.....	744
3.2. Ônus da prova na tutela de dados pessoais.....	746
4. Tutela coletiva dos dados pessoais	751
4.1. Categorias de direitos coletivos e a LGPD	752

4.2.	Legitimados para a tutela coletiva de dados pessoais	759
4.3.	Decisões estruturantes e a tutela coletiva de dados pessoais ...	761
5.	Conclusão	764
6.	Referências bibliográficas	765

Capítulo 13 – Repercussões do RGPD sobre a responsabilidade civil

771

A. Barreto Menezes Cordeiro

1.	Introdução	771
§ 1º	Elementos	773
2.	Illicitude.....	773
3.	Danos.....	774
4.	Causalidade.....	777
§ 2º	Sujeitos.....	778
5.	Lesados	778
6.	Agentes prevaricadores: enquadramento	780
7.	A responsabilidade do responsável pelo tratamento	782
8.	A responsabilidade do subcontratante	783
§ 3º	Aspetos probatórios	784
9.	O afastamento da culpa.....	784
10.	Responsabilidade solidária e direito de regresso	785
11.	Conclusões.....	787
	Bibliografia	787

Capítulo 14 – Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e a Lei Geral brasileira de Proteção de Dados: mapeando convergências na direção de um nível de equivalência

791

Bruno R. Bioni e Laura Schertel Mendes

1.	Introdução	792
2.	Instrumentos de direito internacional e convergência regulatória: uma tensão permanente no campo da proteção de dados.....	793
3.	LGPD vs. RGPD: desafios e perspectivas para uma análise de equivalência	797
3.1.	Divergência na técnica legislativa.....	797
3.2.	LGPD vs. GDPR: racionalidades regulatórias convergentes.....	799
3.2.1.	FIPPs: práticas justas e direitos dos titulares como pilares	799

3.2.2.	Racionalidade <i>ex ante</i> de proteção.....	804
3.2.3.	A guinada da <i>accountability</i>	806
3.2.4.	Arranjo institucional: do texto frio da lei ao sistema de <i>enforcement</i>	809
3.2.5.	Conclusão – Voltando ao básico: qual é o sentido de equivalência?	812
	Bibliografia	813

Apresentação

É com grande alegria que apresentamos ao público a obra “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no Direito Brasileiro”, fruto da necessidade imperiosa de maior reflexão sobre o tratamento de dados pessoais, preocupação que foi potencializada com a edição da LGPD.

Vistos já como o novo petróleo, os dados são hoje insumos essenciais para praticamente todas as atividades econômicas e tornaram-se, eles próprios, objeto de crescente e pujante mercado. Não é sem razão que se cunhou a expressão *data driven economy*, ou seja, economia movida a dados, para designar o fato de que a fase atual do capitalismo está baseada na extração e no uso de dados pessoais.

Obviamente que o fenômeno, longe de se restringir à seara econômica, apresenta inúmeras repercussões nas esferas individuais dos cidadãos, além de levar à total reestruturação das relações sociais e políticas. Consequentemente, os dados ganharam uma importância transversal, tornando-se vetores das vidas e das liberdades individuais, assim como da sociedade e da própria democracia.

É diante desse contexto que o livro pretende oferecer as bases fundamentais para a reflexão em torno da proteção de dados na atualidade, bem como sobre o papel e o alcance da Lei Geral de Proteção de Dados, em sua delicada e complexa missão de encontrar um equilíbrio entre inovação e eficiências econômicas, por um lado, e preservação dos direitos dos indivíduos e da própria sociedade, por outro.

Para cumprir os objetivos da publicação, foram convidados os maiores especialistas sobre a matéria, que reúnem o conhecimento teórico e a experiência prática, a fim de que pudessem compartilhar com o público os seus pontos de vista sobre os temas mais importantes da LGPD. Estes foram agrupados em duas grandes partes: a primeira dedica-se ao estudo dos aspectos estruturais da LGPD e dos direitos dos titulares de dados e a segunda explora os diversos tipos de tratamento de dados e questões específicas relevantes.

Embora seja um livro coletivo, houve a preocupação de oferecer ao leitor um conjunto harmônico e sistematizado, que possibilite uma incursão sobre o tema a partir de abordagem que concilie profundidade com didática e aplicabilidade prática. Por essa razão, a estrutura foi decidida inicialmente pelos organizadores, tendo os autores sido convidados para escrever sobre os temas previamente definidos. Somente assim seria possível que o livro pudesse ser um “Curso sobre LGPD” e não uma mera coletânea sobre tópicos específicos.

Houve também a preocupação de se concentrar nas questões fundamentais da LGPD, conectando-a com as principais discussões já existentes sobre o assunto na Europa - especialmente à luz do GDPR - e também de outras nações. Daí o

cuidado com a abordagem dos temas sob perspectivas que reforçaram os pressupostos e finalidades dos institutos analisados.

É também importante ser ressaltado que o livro foi pensado para atrair a atenção da academia, mas sem desconsiderar a necessidade de atender ao público de estudantes, advogados e profissionais que já perceberam o quanto a LGPD transformará a sociedade e as relações jurídicas. Daí a preocupação com o tratamento geral e sistemático das principais questões, a fim de que o leitor, ao final, possa ter os subsídios necessários para compreender e aplicar as principais soluções da LGPD.

Organizar um livro com essas pretensões obviamente não foi uma tarefa simples, até porque tínhamos realmente a ambição de que ele fosse publicado rapidamente, antes mesmo de a LGPD entrar em vigor, até para que pudesse cumprir a sua função de auxiliar na fase de transição e adaptação pela qual empresas, governo, organizações e mesmo os cidadãos terão que passar.

Isso não teria sido possível sem a colaboração dos nossos autores, os quais, mesmo com a agenda atribulada, abraçaram o nosso projeto com grande esforço e dedicação. Para eles, fica o registro do nosso mais profundo agradecimento e a grande satisfação de ver que o resultado final do livro superou todas as nossas expectativas.

Brasília, junho de 2019.

Ana Frazão

PARTE I - ASPECTOS ESTRUTURAIS DA LGPD E DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

Capítulo 1. Fundamentos da proteção dos dados pessoais – Noções introdutórias para a compreensão da importância da Lei Geral de Proteção de Dados

Ana Frazão¹

“We do not have to live in a world where hidden scores determine people’s fates, or human manipulations of the stock market remain as inscrutable as the “invisible hand”. We should not have to worry that fates of individuals, businesses, and even our financial systems are at the mercy of hidden databases, dubious scores, and shadowy bets”. (Frank Pasquale)²

1. Introdução

A manchete da capa da revista *The Economist* de 06.05.2017³ – *The world’s most valuable resource* –, ao apontar os dados pessoais como os principais recursos econômicos da nossa época, revela importante ponto de partida para a compreensão da necessidade de proteção dos dados pessoais.

Vistos já como o novo petróleo, os dados são hoje insumos essenciais para praticamente todas as atividades econômicas e se tornaram, eles próprios, objeto de crescente e pujante mercado. Não é sem razão que se cunhou a expressão *data-driven economy*, ou seja, economia movida a dados, para designar o fato de que, como aponta Nick Srnicek, o capitalismo do século XXI passou a centrar-se na extração e no uso de dados pessoais⁴.

Obviamente que o fenômeno, longe de se restringir à seara econômica, apresenta inúmeras repercussões nas esferas individuais dos cidadãos, além de levar à total reestruturação das relações sociais e políticas. Consequentemente, os dados ganharam uma importância transversal, tornando-se vetores das vidas e das liberdades individuais, assim como da sociedade e da própria democracia.

É verdade que a coleta de dados pessoais não é algo propriamente novo, sendo a história da humanidade marcada por inúmeras experiências e avanços na tarefa de obter, coletar, registrar e acessar dados. Entretanto, o *Big Data* e o *Big Analytics* possibilitaram que tais atividades ocorressem de maneira muito mais eficiente, com mais veracidade, velocidade, variedade e volume⁵. Mais do que isso, o *Big Data* e o *Big Analytics* permitiram que, a partir da coleta e do registro de dados, fossem a eles atribuídas utilizações e aplicações que não seriam sequer imagináveis há pouco tempo e que, na ausência de uma regulação adequada, passaram a ser realizadas sem limites e com resultados que podem se projetar para sempre.

Por mais que ainda não seja possível compreender a total extensão do poder econômico, político e social que decorre dos dados e da sua utilização, já se percebe quão grande ele pode ser. Daí a afirmação de Alec Ross⁶ de que as escolhas sobre como vamos gerenciar e administrar os dados na atualidade são tão importantes quanto as decisões sobre o gerenciamento da terra durante a era agrícola ou da indústria durante a era industrial.

Em sentido próximo, mas com a preocupação de ressaltar que a importância dos dados transcende à esfera econômica, Yuval Harari⁷ aponta que: “Se quisermos evitar a concentração de toda a riqueza e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a propriedade dos dados.” Daí a provocação que apresenta⁸:

Assim, faríamos melhor em invocar juristas, políticos, filósofos e mesmo poetas para que voltem sua atenção para essa charada: como regular a propriedade de dados? Essa talvez seja a questão política mais importante da nossa era. Se não formos capazes de responder a essa pergunta logo, nosso sistema sociopolítico poderá entrar em colapso.

É, portanto, diante dessa problemática que o presente artigo tem por objetivo oferecer bases introdutórias para a reflexão em torno dos fundamentos que justificam a proteção de dados na atualidade, com o que certamente se compreenderá melhor o papel e o alcance da Lei Geral de Proteção de Dados e da sua missão de encontrar um equilíbrio entre inovação e eficiências econômicas, por um lado, e preservação dos direitos dos indivíduos e da própria sociedade, por outro.

2.A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar os efeitos nefastos do capitalismo de vigilância: a violação da privacidade como um negócio

Do ponto de vista econômico, dados importam na medida em que podem ser convertidos em informações necessárias ou úteis para a atividade econômica. Consequentemente, os dados precisam ser processados para que possam gerar valor.

Tal constatação obviamente não afasta a importância dos dados isolados ou “crus” (*raw data*), mas mostra que, sem o devido tratamento, dificilmente se poderá deles extrair o seu adequado potencial. Daí a interpenetração necessária entre *Big Data* e *Big Analytics*⁹ e a priorização crescente da qualidade e da profundidade do processamento dos dados¹⁰.

Entretanto, o ponto de partida de toda essa engrenagem é a coleta de dados, cada vez mais maciça e muitas vezes realizada sem o consentimento e até sem a ciência dos titulares desses dados. Se os cidadãos não conseguem saber nem mesmo os dados que são coletados, têm dificuldades ainda maiores para compreender as inúmeras destinações que a eles pode ser dada e a extensão do impacto destas em suas vidas.

Aliás, de acordo com a pesquisa empírica realizada por Chris Hoofnagle e outros¹¹, hoje se pode dizer que é impossível evitar o rastreamento digital (*on-line tracking*), em razão da utilização crescente de tecnologias e mecanismos que os usuários não têm nem mesmo como evitar.

Apenas para se ter uma dimensão do risco para os usuários, o professor Martin Hilbert¹², especialista em *Big Data*, afirma que, com 150 “curtidas”, determinados algoritmos podem saber mais sobre uma pessoa do que o seu companheiro e que, com 250 “curtidas”, os algoritmos podem saber mais sobre uma pessoa do que ela própria.

Como bem descreve Frank Pasquale¹³, os dados pessoais têm sido utilizados por governos e grandes *players* econômicos para a criação do que chama de *one-way mirror*, possibilitando que tais agentes saibam tudo dos cidadãos, enquanto estes nada sabem dos primeiros. E tudo isso acontece por meio de um monitoramento e vigília constantes sobre cada passo da vida das pessoas, o que leva a um verdadeiro capitalismo de vigilância, cuja principal consequência é a constituição de uma sociedade também de vigilância¹⁴.

As preocupações a respeito da relação entre *Big Data* e a crescente consolidação de uma sociedade de vigilância não são recentes. Ian Lloyd¹⁵ lembra-nos de que, em 2004, Richard Thomas, então *Information Commissioner* do Reino Unido, já alertava para os perigos do fenômeno que via ocorrendo em seu país e que descrevia como um “*sleepwalking into a surveillance society*”.

Tais apreensões foram consolidadas em relatório publicado em 2006 pela ICO, intitulado *A Report on the Surveillance Society*¹⁶, e passaram a acompanhar a evolução e a crescente penetração do *Big Data* em nossas vidas. Não é sem razão que é recorrente na literatura sobre violação de dados a referência aos problemas decorrentes do excesso de vigilância que caracteriza os nossos tempos¹⁷.

Um dos principais e mais recentes estudos sobre o tema é o de Shoshana Zuboff¹⁸, para quem o capitalismo de vigilância utiliza-se de toda a experiência humana, incluindo vozes, personalidades e emoções, como matéria-prima gratuita para ser traduzida em dados comportamentais. Embora o que esteja em jogo seja a nossa própria autonomia individual, essas pretensões invasivas são alimentadas pela ausência de leis para conter o fenômeno, pela mutualidade de interesses entre capitalistas e agências de inteligência estatais e pela tenacidade com que as corporações defendem seus novos territórios¹⁹. Como tal vigilância é pulverizada e não centralizada, a autora caracteriza os nossos tempos a partir da expressão *Big Other*²⁰, em contraposição a *Big Brother*.

Para Frank Pasquale²¹, o *one-way mirror* já mencionado, além de esvanecer a distinção entre estado e mercado, faz com que sejamos crescentemente governados pelo que Jeff Connaughton chamou de *The Blob*, ou seja, um *network* de atores que age às sombras, mobilizando dinheiro e mídia para ganhos privados, mesmo quando agem oficialmente em nome do negócio ou do governo. Tais ideias são também exploradas por John Gilliom e Torin Monahan²², para quem a vigilância está relacionada a um poder desbalanceado e que age somente em favor da parceria público-privada a quem interessa.

Essa forma íntima de vigilância, segundo Bruce Schneier²³, espraia-se facilmente porque é feita em massa e de forma barata, escondida, automática e ubíqua. Daí a sua conclusão de que o ambiente por causa disso decorrente assemelha-se menos a um *Big Brother* e mais a centenas de *little brothers* “linguárudos”.

Consequentemente, é possível verificar que a economia movida a dados e o capitalismo de vigilância são as duas faces da mesma moeda pois, quanto maior a importância dos dados, mais incentivos haverá para o aumento da vigilância e, por conseguinte, maior será a coleta de dados. Daí a conclusão de Bruno Bioni²⁴ de que, no cenário descrito, têm-se uma economia de vigilância e um verdadeiro varejo de dados pessoais.

Esse varejo, como visto, tem como mola propulsora a extração ampla e sem controles de dados pessoais. E fala-se em extração porque, como explica Shoshana Zuboff²⁵, esta expressão traduz, de forma mais fidedigna, a circunstância de que os dados são normalmente retirados dos titulares sem o seu consentimento, sem a sua ciência e sem a devida contrapartida.

A violação da privacidade e dos dados pessoais torna-se, portanto, um lucrativo negócio que, baseado na extração e na monetização de dados, possibilita a acumulação de um grande poder que se retroalimenta indefinidamente, como se observa pelo esquema a seguir:



A figura utilizada é uma mera simplificação do mercado de dados na perspectiva privada, seja porque o poder que decorre dos dados não é apenas econômico, seja porque o próprio mercado é composto por diversos e distintos agentes, que vão desde as poderosas plataformas digitais, em relação às quais o negócio de dados concorre com outros serviços que, a partir deste, são prestados diretamente aos usuários, até agentes cuja atividade única é a coleta e o processamento de dados ou a venda, a revenda ou o compartilhamento de dados (os *data brokers*), sem qualquer interação com os titulares desses dados.

Em instigante relatório de 2014, *Data Brokers: A Call for Transparency and Accountability*²⁶, a *Federal Trade Commission* norte-americana teve a oportunidade de fazer um mapeamento da indústria de dados e do papel dos *data brokers*, o que possibilitou que chegasse às seguintes conclusões:

- (i) os *data brokers* coletam informações sobre os consumidores de diversas e numerosas fontes comerciais, governamentais e públicas (incluindo nesta última mídias sociais, *blogs* e internet);
- (ii) os *data brokers* não usam apenas os dados crus (*raw data*), mas também os chamados dados derivados, que são as inferências já realizadas a partir dos dados crus;
- (iii) os *data brokers* combinam dados obtidos *on-line* e *off-line* para atingirem os consumidores *on-line*;
- (iv) as principais utilizações comerciais dos dados são *marketing*, serviços de mitigação de riscos e serviços de busca de pessoas;
- (v) parte expressiva da coleta de dados ocorre sem o conhecimento dos consumidores;
- (vi) a indústria dos dados é complexa, com muitas camadas de *data brokers* que oferecem e trocam dados uns com os outros, sendo frequentes o intercâmbio e a compra e venda de informações entre eles;
- (vii) os *data brokers* coletam e armazenam bilhões de dados que, na época da pesquisa, já cobriam praticamente todos os consumidores norte-americanos²⁷;
- (viii) qualquer que seja a metodologia utilizada, os *data brokers* coletam mais informações do que usam;
- (ix) uma das maiores aplicações dos dados é o desenvolvimento de modelos complexos para prever o comportamento dos consumidores e para extrair inferências potencialmente sensíveis a respeito deles;
- (x) apesar dos benefícios da atividade de tratamento de dados, muitos dos propósitos pelos quais os *data brokers* coletam e usam dados apresentam riscos para os consumidores;
- (xi) as escolhas que os *data brokers* oferecem aos consumidores sobre os seus dados são invisíveis e incompletas, com grande ausência de transparência.

Apesar da indústria de dados ter se alicerçado em um ativo que não é dela – os dados pessoais – e que, muitas vezes, tem sido explorado de forma ilícita, tal modo de proceder sempre foi acompanhado de justificativas relacionadas às eficiências geradas e aos benefícios e vantagens que, de maneira “gratuita” ou acessível, são disponibilizados aos usuários, os quais muitas vezes não percebem que, ao “pagarem” pelos serviços com seus dados pessoais, são o

verdadeiro produto nesse tipo de negócio. Aliás, em alguns tipos de negócios, como o dos *data brokers*, tal argumento não é sequer pertinente, uma vez que os agentes não interagem diretamente com os titulares de dados e, consequentemente, não lhes oferecem nenhum tipo de benefício.

Da mesma forma, o mercado de dados em geral cresce a partir da difusão de visões como a de que o modelo de negócios é justo, já que os usuários receberiam contrapartidas adequadas pelos seus dados, ou mesmo necessário, visto que haveria um verdadeiro *trade off* entre inovação e privacidade, de maneira que a violação desta última seria o preço a pagar ou o mal necessário para o progresso tecnológico e os novos serviços que daí decorrem. Até a forma como a questão é apresentada já reflete a perspectiva utilitarista que permeia a análise, pois se parte da premissa de que, em nome da inovação, é justificável o sacrifício de direitos fundamentais elementares.

O excesso de otimismo das próprias pessoas em relação a muitos dos modelos de negócios da economia digital e os benefícios diretos que eles lhes proporcionam, aliado às próprias dificuldades de compreensão dos seus efetivos impactos, são também fatores que criam ônus adicionais para os reguladores que, premidos entre a assimetria informacional e os benefícios das inovações, muitas vezes, não sabem o que fazer para conter esse processo e proteger minimamente os cidadãos. Foi esse o cenário que possibilitou que vários desses negócios evoluíssem em um ambiente no qual o suposto vácuo regulatório fosse convenientemente preenchido pela autorregulação criada pelos agentes em seu próprio benefício.

Portanto, não se tem como compreender o advento da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira senão no contexto já descrito, o que já evidencia o seu importante papel de reforçar a autonomia informativa dos titulares dos dados e o necessário e devido controle que estes precisam exercer sobre os seus dados, a fim de se colocar um freio nas vicissitudes que possibilitaram a consolidação do estágio atual da economia movida a dados.

Mais do que uma mera proteção da individualidade ou da intimidade, a tutela dos dados pessoais constitui importante medida para endereçar outros dos graves problemas decorrentes do capitalismo de vigilância, como se abordará melhor a seguir.

3.A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar os riscos que os algoritmos representam às liberdades individuais e à própria democracia

É inequívoco que a proteção de dados, tal como inclusive deixa claro a LGPD, não se restringe ao meio virtual, mas a todos os meios pelos quais os dados podem ser coletados e utilizados. Entretanto, também não há dúvida de que é no meio virtual que se concentram as maiores preocupações e os maiores desafios da proteção de dados.

Se os dados são os insumos e os *inputs* da economia digital, os algoritmos são os instrumentos por meio dos quais os dados são processados e podem ser revertidos em resultados (*outputs*) a serem utilizados para as mais diversas finalidades²⁸. Muito além de aperfeiçoar estratégias econômicas já existentes, como seriam os casos do *marketing* personalizado (*target marketing*) e das classificações ou perfilizações (*profiling*), tais aplicações podem levar à total modificação do cenário econômico, político e social.

Com efeito, entre as principais tarefas da chamada *Data Science*, estruturada a partir dos algoritmos, estão (i) a agregação ou segmentação de informações (*clustering* ou *segmentation*); (ii) a identificação de fraudes ou anomalias; (iii) a busca de associações e complementaridades (*association-rule mining* e *cross-selling*); e (iv) as predições²⁹.

Com base nessas funcionalidades, os algoritmos estão hoje sendo programados para a extração de padrões e inferências a partir dos quais serão tomadas, de forma automatizada, decisões sobre questões objetivas, mas que estão atreladas a importantes dados sensíveis, assim como decisões sobre questões subjetivas e que envolvem complexos juízos de valor, tais como (i) avaliar as características, a personalidade, as inclinações e as propensões de uma pessoa, inclusive no que diz respeito à sua orientação sexual; (ii) analisar o estado de ânimo ou de atenção de uma pessoa; (iii) identificar estados emocionais, pensamentos, intenções e mesmo mentiras; (iv) detectar a capacidade e a habilidade para determinados empregos ou funções; (v) analisar a propensão à criminalidade; (vi) antever sinais de doenças, inclusive depressão, episódios de mania e outros distúrbios, mesmo antes da manifestação de qualquer sintoma.

Como se vê, algoritmos vêm sendo utilizados para análises complexas, que abarcam as respostas para nossas perguntas mais difíceis³⁰, como decisões e diagnósticos que, além de representarem uma verdadeira devassa na intimidade das pessoas, ainda terão impactos nas possibilidades e no acesso destas a uma série de direitos e oportunidades. Não é novidade que algoritmos hoje podem decidir quem terá crédito e a que taxa de juros, quem será contratado para trabalhar em certa empresa, qual a probabilidade de reincidência de determinado criminoso, quem deve ser atropelado em determinadas situações, entre inúmeras outras circunstâncias.

O mais preocupante é que tudo isso é feito a partir de uma série de dados que podem até parecer irrelevantes para o cidadão comum, tais como suas buscas na internet, tempo gasto em redes sociais, “curtidas” sobre determinadas questões, músicas e locais de sua preferência, entre outros. É com base nesses dados, que depois são convertidos em novos dados, que a inteligência artificial age para nos trazer um componente crítico da própria inteligência: a predição, considerada um *input* central para os processos decisórios³¹.

Todavia, se são muitos os benefícios decorrentes das predições e dos processos de decisão automatizadas, também são inúmeras as preocupações a eles relativas, a começar pela forma como isso é feito. Como bem explica Shoshana Zuboff³², o capitalismo de vigilância baseia-se no *behavioral surplus*, ou seja, na extração de dados além do que seria necessário para a melhoria dos serviços que justificaram a sua coleta. É esse *surplus* que alimenta os processos de *machine learning* – vistos como os novos meios de produção – que “fabricarão” predições cada vez melhores sobre o

comportamento dos usuários; predições essas que serão os produtos a serem vendidos nos novos mercados comportamentais.

Por outro lado, o estabelecimento de padrões a partir da regularidade de determinados acontecimentos e a ampla utilização de estatísticas também têm suas limitações, ainda mais quando as decisões algorítmicas são totalmente automatizadas e sem qualquer controle humano. Afinal, algoritmos são criados por seres humanos, com todos os seus vieses e falibilidades, bem como com todas as possibilidades de desvirtuamento, a fim de privilegiar os interesses daqueles para quem foram programados. No entanto, mesmo que os dados e o processamento sejam de qualidade, várias correlações podem não corresponder a relações de causalidade³³.

Dai a acertada observação de Dawn Holmes³⁴ de que a interação humana e a interpretação são necessárias para decidir quais das correlações encontradas por algoritmos são realmente úteis e adequadas. Tal preocupação, ainda segundo o autor³⁵, é fundamental diante do cenário decorrente do *Big Data*, pois, quanto maiores a base de dados e o número de variáveis utilizadas no processamento, maior será o número de correlações espúrias.

Como também advertem Agrawal, Joshua Gabs e Avi Goldfarb³⁶, há limites para a habilidade das máquinas na predição de julgamentos humanos, até porque o poder preditivo das máquinas é ruim em se tratando de eventos raros ou que não tenham ocorrido muitas vezes no passado.

Mesmo quando o raciocínio estatístico estiver certo, é forçoso concordar em que este, em si, não deixa de representar uma espécie de discriminação, na medida em que o julgamento a respeito de uma pessoa é feito a partir de critérios gerais que desconsideram a sua individualidade. Por essa razão, em que pesem a utilidade e a importância da estatística, há que se tomar cuidado com o seu emprego amplo e absoluto, sem que existam mecanismos ou válvulas de escape para a correção dos resultados.

É o que aponta, com precisão, Julie Cohen³⁷, para quem o problema dos algoritmos é que o modelo se baseia em padrões que são tidos como verdadeiros em todos os casos e para todos os propósitos, privilegiando sistematicamente um tipo de informação – estática e quantificável – e um tipo de conhecimento – mais “racionalizante” e “objetificante” – ao custo de outras formas de conhecimento que são também importantes para os assuntos humanos. E a consequência disso é uma perda – não um ganho – de liberdade, já que tais práticas procuram moldar e prever o comportamento dos indivíduos de acordo com trajetórias de oportunidades e desejos que são determinadas externamente.

Consequentemente, os algoritmos preocupam tanto quando acertam como quando erram. Preocupam quando acertam, pois podem revelar aspectos íntimos da nossa personalidade que gostaríamos de manter em segredo, até porque podem ser utilizados para nos tolher o exercício de direitos e oportunidades. Preocupam quando erram, pois desconfiguram a nossa individualidade, atribuindo-nos características que não temos e que também podem ser utilizadas para nos tolher direitos e oportunidades, com o agravante de que tais decisões são baseadas em juízos totalmente equivocados.

Entretanto, a indústria dos dados tem utilizado os algoritmos sem as preocupações ora mencionadas, especialmente para fins de classificações, perfilizações e predições, fenômeno que também é reflexo do fato de que a utilização da inteligência artificial em várias searas vem ocorrendo sem o correspondente e necessário debate ético e jurídico.

Caminhamos, portanto, para uma sociedade da classificação, como diria Stefano Rodotà³⁸, ou para um cenário em que os perfis se transformam em verdadeiras representações virtuais, corpos digitais ou mesmo sombras das pessoas, como diria Danilo Doneda³⁹. No relatório da *Federal Trade Commission* já mencionado⁴⁰, há inusitados exemplos de perfis de consumidores, tal como *Bible lifestyle*.

Ao refletir sobre esse processo, John Cheney-Lippold⁴¹ aponta para o fato de que os algoritmos hoje agregam e controlam nossas identidades datificadas (*datafied selves*) e nossos futuros algorítmicos, já que o processo de classificação em si já é uma importante demarcação de poder, assim como a organização do conhecimento e da vida molda as condições e as possibilidades daqueles que serão classificados. Afinal, são as categorias para as quais nossas vidas datificadas serão convertidas que passarão a definir não apenas quem somos, mas também quem seremos, na medida em que os dados nos representam ao mesmo tempo que nos regulam⁴².

É nesse ponto que se entende como os algoritmos são indispensáveis para a estruturação completa do capitalismo de vigilância. Ainda segundo John Cheney-Lippold, os algoritmos traduzem conceitos como gênero, raça, classe e mesmo cidadania para formas típicas quantitativas e mensuráveis, que reconfiguram nossas concepções de controle e poder em um mundo digitalmente conectado⁴³. Em verdade, a regulação pelos algoritmos seria uma espécie de “controle sem controle”, pelo menos no sentido de controle evidente, fenômeno que o autor chama de *soft biopolitics*⁴⁴.

De forma semelhante, John Kelleher e Brendan Tierney⁴⁵ destacam que, sendo gerados por processos de abstrações, os dados não são e nunca corresponderão a uma descrição objetiva do mundo, sendo sempre parciais e enviesados. Dai por que decisões algorítmicas podem resultar em tratamento preferencial para uns e marginalização para outros⁴⁶.

Logo, a empolgação e o *marketing* em torno da ideia de que uma *data-driven approach* é o melhor jeito de endereçar problemas sociais complexos, como crime, pobreza e educação, não leva em consideração que as consequências desse processo são as de tornar a sociedade cada vez mais tecnocrática e ainda de favorecer o *control creep*, por meio do qual dados reunidos para um propósito podem receber novos propósitos, o que, embora possa ser positivo do ponto de vista da eficiência do sistema, é extremamente preocupante à luz das liberdades civis⁴⁷.

Vale ressaltar a conclusão dos autores sobre os riscos inerentes a tais concepções⁴⁸:

Vigilância aumentada, integração de dados vindos de múltiplas fontes, *control creep* [utilizar dados coletados para uma finalidade para outra que não podia ser nem mesmo esperada pelo titular no momento em que abriu mão dos dados] e governança antecipada (como os programas de polícia preditiva) podem resultar em uma sociedade na qual o indivíduo pode ser tratado como suspeito simplesmente porque uma sequência de ações inocentes e não relacionadas ou encontros se ajustam a um padrão considerado suspeito por algum sistema regulatório movido a dados. Viver nesse tipo de sociedade mudaria a condição de cidadãos de cada um de nós para internos no Panopticon de Bentham, constantemente auto-disciplinando nossos comportamentos pelo medo das inferências que poderiam ser desenhadas a partir deles. A distinção entre indivíduos que acreditam e agem como se estivessem livres de vigilância e indivíduos que se auto-disciplinam por medo de habitem um Panopticon é a primária diferença entre uma sociedade livre e um estado totalitário. (sic)

Logo, é fácil compreender que, se não houver maior cuidado em relação à proteção dos dados pessoais, é possível a consolidação do cenário descrito por Yuval Harari⁴⁹, em que o algoritmo segue o próprio caminho e vai aonde humanos nunca foram antes e nem poderão ir. Daí o autor se referir ao dataísmo – verdadeira religião dos dados –, que pode subjugar o *homo sapiens* assim como este subjuguou todas as outras espécies⁵⁰.

A utilização da expressão subjugação nesse contexto não é exagerada, uma vez que os algoritmos – ou aqueles que os criam e os utilizam – tanto podem determinar os destinos das pessoas como também podem ser desenhados para influenciar e modificar o comportamento humano. O conhecimento profundo das características do usuário, inclusive no que diz respeito às suas fragilidades, pode ser utilizado para toda sorte de discriminações e abusos, além da manipulação de suas emoções, crenças e opiniões para os fins mais diversos, inclusive políticos.

É contra esse tipo de modificação comportamental que se insurgem vários autores, como Shoshana Zuboff⁵¹, que inclusive mostra a sua estupefação ao verificar que uma série de técnicas de entorpecência psicológica que foram consideradas inaceitáveis nas décadas passadas, por ameaçarem a autonomia individual e a ordem democrática, hoje encontram pouca resistência ou discussão, uma vez que são rotineira e pervasivamente empregadas por vários agentes econômicos na marcha em busca dos ganhos decorrentes da vigilância.

Portanto, os riscos inerentes à economia movida a dados e ao capitalismo de vigilância, já vistos na seção anterior, são potencializados diante da cada vez mais ampla utilização de algoritmos sem limites éticos e jurídicos, assim como sem qualquer transparência, como se passará a abordar no próximo item.

Muito mais do que um problema apenas de privacidade no sentido do direito à intimidade ou de ser deixado só, a proteção de dados, nesse contexto, é fundamento para a preservação da individualidade, da liberdade e da própria democracia.

4.A proteção dos dados pessoais como forma de endereçar o problema da opacidade e da ausência de *accountability* da economia movida a dados

No contexto de uma sociedade de vigilância, o *Big Data* tudo vê, sendo capaz de capturar todas as pegadas digitais dos usuários para, a partir daí, utilizar seus “poderes” não apenas para registrar e processar o passado e o presente, mas também para antecipar e decidir o futuro das pessoas. E o mais preocupante é que faz tudo isso sem a devida transparência e *accountability*, já que os algoritmos utilizados por governos e grandes agentes empresariais são normalmente considerados segredos, respectivamente de Estado ou de negócios.

Ora, para que se pudesse ter um mínimo de confiança e tranquilidade em relação a tais processos, seria necessário haver algum tipo de controle tanto sobre (i) a qualidade dos dados, a fim de se saber se atendem aos requisitos da veracidade, exatidão, precisão, acurácia e sobretudo adequação e pertinência diante dos fins que justificam a sua utilização, quanto sobre (ii) a qualidade do processamento de dados, para se saber se, mesmo a partir de dados de qualidade, a programação utilizada para o seu tratamento é idônea para assegurar resultados confiáveis.

Basta a descrição do problema para se observar que são muitas as variáveis sobre as quais se precisaria ter um mínimo de supervisão e *accountability* a fim de assegurar que os *outputs* sejam fidedignos e confiáveis. Entretanto, não havendo transparência, não se tem como avaliar nem a qualidade dos dados nem a qualidade do processamento. Daí a triste conclusão de que os resultados algorítmicos, na atualidade, correspondem a uma verdadeira *black box*.

É o que concluiu a *Federal Trade Commission*, ao examinar a indústria dos dados em 2014⁵²:

Muitas dessas descobertas apontam para uma fundamental ausência de transparência sobre as práticas da indústria dos dados. *Data brokers* adquirem um vasto volume de informações detalhadas e específicas sobre os consumidores; analisam tais informações para fazer inferências sobre os consumidores, muitas das quais podem ser considerada sensíveis; e compartilham informação com clientes das mais diversas indústrias. Toda essa atividade acontece nos bastidores, sem o conhecimento dos consumidores.

Ora, sem a devida transparência, é muito provável que a programação possa estar permeada de vieses e preconceitos dos programadores, intencionais ou não, que podem levar a erros de diagnóstico ou a graves discriminações. Mais do que isso, é possível que as correlações encontradas no processamento sejam consideradas equivocadamente causalidades, fator que pode reforçar discriminações.

A falta de transparência torna-se ainda mais preocupante quando se sabe que tais algoritmos são aperfeiçoados a partir da inteligência artificial, por meio da qual, com a aprendizagem de máquina (*machine learning*) e com as redes neurais artificiais, mais e mais algoritmos se desenvolvem independentemente, aprimorando a si mesmos e aprendendo com os próprios “erros”. Como não é possível entender completamente esse processo, diante da sua complexidade e multiplicidade de passos ou etapas, fala-se até mesmo na chamada “eficácia irracional dos dados”.

O mais preocupante é que, como observam John Kelleher e Brendan Tierney⁵³, os perfis dos indivíduos decorrentes desses processos são tratados como produtos e vendidos para companhias. Apesar de serem verdadeiras *black boxes*, tais perfis ainda podem persistir por muito tempo, ainda que o indivíduo não saiba que dados foram utilizados, onde e quando foram coletados e como a decisão foi tomada.

Daí a conclusão de que os algoritmos podem perpetuar injustiças, preconceitos e discriminações⁵⁴. Em verdade, segundo John Kelleher e Brendan Tierney⁵⁵, como os algoritmos atuam de uma maneira mais amoral do que propriamente objetiva, quanto mais consistente for determinado preconceito em dada sociedade, mais forte será o padrão que aparecerá nos dados a respeito dessa sociedade e mais provável será que o algoritmo extraia e ainda replique esse padrão de preconceito.

Por essa razão, John Gilliom e Torin Monahan⁵⁶ destacam o fato de que tais sistemas, que são novas expressões de poder, fazem muito mais do que vigiar; efetivamente, trabalham para moldar nossas identidades e nos categorizar por meio de padrões sociais existentes e ainda vinculados a desigualdades de raça, classe e gênero para que, a partir daí, passemos a ser tratados diferentemente e a ter nossas escolhas e comportamentos alterados mediante premiações e punições.

No mesmo sentido, Bruce Schneier⁵⁷ ressalta a consolidação de um controle institucional, com parceria entre companhias e governos. Como muito dos dados são coletados e usados em segredo, as pessoas não podem refutar ou mesmo saber as evidências que são usadas contra elas, com o que se inibe o dissenso e a mudança social⁵⁸ e ainda se abre margem para enorme potencial de manipulação⁵⁹.

Não é sem razão a farta literatura já existente a respeito dos riscos representados pelas decisões algorítmicas, inclusive no que se refere aos seus efeitos nefastos sobre as minorias e sobre os mais pobres, aumentando ainda mais a desigualdade⁶⁰. Cathy O'Neil⁶¹ chega a se referir aos algoritmos como armas matemáticas de destruição, na medida em que, longe de serem neutros e objetivos, embutem em seus códigos uma série de decisões e opiniões que não podem ser contestadas, até porque não são conhecidas. Daí o seu potencial de destruição silenciosa, dado que podem basear seus julgamentos em preconceitos e padrões passados que automatizam o *status quo* e ainda podem ser utilizados para toda sorte de discriminações e violações de direitos.

A conclusão não se diferencia muito da de Frank Pasquale⁶², para quem as corporações dependem hoje de julgamentos automatizados que podem ser errados, enviesados e destrutivos. Aliás, o autor insurge-se precisamente contra as distorções do *one-way mirror* pois, diante dele, não há como saber se as aplicações algorítmicas são justas ou movidas por interesses econômicos ou escusos dos agentes que delas se utilizam⁶³.

Todavia, Frank Pasquale⁶⁴ avança na reflexão para apontar que a opacidade e a falta de transparência, longe de serem características intrínsecas aos mercados digitais, são na realidade o resultado da ação deliberada dos agentes econômicos ou estatais a quem a ausência de controle aproveita⁶⁵. Por meio de uma série de estratégias jurídicas (como a proteção do segredo de negócios) e não jurídicas, é criado um ambiente de ofuscação que permite aos atores poderosos ordenar, ranquear e avaliar as pessoas, mantendo suas técnicas em segredo, inclusive para o fim de proteger sua valiosa propriedade intelectual⁶⁶.

O problema é que essa estratégia compromete todo o potencial de liberdade e difusão de informação inerente à internet, colocando em risco os direitos individuais e o próprio crescimento econômico, na medida em que se torna instrumento para consolidar o poder e a riqueza dos grandes agentes, cujas atividades não são nem monitoradas nem reguladas⁶⁷. Vale ressaltar trecho culminante das reflexões de Frank Pasquale⁶⁸:

No seu livro *Turing's Cathedral*, George Dyson afirma com ironia que o Facebook define quem somos, a Amazon define o que queremos e o Google define o que pensamos. Nós podemos estender esse epigrama para incluir as finanças, que definem o que temos (pelo menos materialmente) e nossa reputação, o que crescentemente define nossas oportunidades. Líderes em cada setor aspiram tomar essas decisões sem regulação, impugnação ou explicação. Se eles forem bem sucedidos, nossas liberdades fundamentais e oportunidades serão terceirizadas para sistemas com poucos valores discerníveis além do enriquecimento de altos executivos e acionistas. (*sic*)

A opacidade atinge tal nível que não se sabe nem mesmo como fazer as diferenciações básicas que deveriam ser realizadas nos mercados, como se observa por mais um trecho de Frank Pasquale⁶⁹: “Nós dizemos que valorizamos quem faz (*makers*) sobre quem toma (*takers*) e finge (*fakers*). Mas nós precisamos de uma sociedade inteligível se quisermos ser capazes de dizer quem é quem.”

Dessa maneira, é urgente a necessidade de se introduzir mecanismos de transparência e *accountability* nas decisões algorítmicas. Por mais que existam limitações naturais à transparência das decisões – que muitas vezes são baseadas em um número imenso de dados, processados por sistemas que adotam um número enorme de passos, de forma a tornar praticamente impossível uma regressão absoluta –, há que se buscar alternativas para lidar com essa realidade.

Por essa razão, no relatório *Preparing for the future of artificial intelligence*, produzido no final do Governo Obama⁷⁰, ficou claro que, diante dos problemas para a compreensão exata de cada um dos passos das decisões algorítmicas, o jeito mais efetivo para minimizar o risco de resultados não desejados é por meio de testes extensivos, a fim de se fazer uma longa lista dos tipos de maus resultados que podem ocorrer e tentar excluí-los sempre que se mostrarem presentes.

A grande discussão, portanto, é saber, entre o que não é conhecido, o que pode e deve ser conhecido, como pressuposto mínimo da proteção de direitos individuais e da própria democracia. Somente assim será possível avaliar minimamente os riscos das crescentes categorizações e perfilizações, inclusive para o fim de delimitar que listas ou categorias não deveriam ser nem mesmo criadas⁷¹.

Retomando mais uma vez o pensamento de Frank Pasquale⁷², a transparência é pressuposto de inteligibilidade não apenas dos negócios, mas do próprio mundo. Sem isso, não será possível controlar minimamente os algoritmos e impedir que eles, na sua trajetória natural de reproduzir os padrões do passado, congelem o futuro e façam com que discriminações não apenas persistam como ainda possam ser intensificadas.

5.A regulação de dados pessoais como forma de endereçar os riscos do poder crescente das grandes plataformas sobre os cidadãos

Como se viu, o mercado de dados é sofisticado e composto por muitos agentes que não têm nem mesmo contato direto com os titulares de dados. Daí por que as preocupações relacionadas à economia movida a dados são abrangentes. Entretanto, um dos focos especiais diz respeito às plataformas digitais, que vem protagonizando a economia digital, na medida em que possibilitam expressiva redução de custos de transações em mercados de dois ou mais lados⁷³.

Como reiteram Moazed e Johnson⁷⁴, quando o mundo se torna mais conectado, o que uma companhia tem em termos de patrimônio importa menos do que os recursos que ela pode conectar. É, portanto, em decorrência do grande poder de conexão que as plataformas acabam assumindo o papel de verdadeiros *gatekeepers* dos tempos atuais.

Gatekeepers, como bem explica Karine Barzilai-Nahon⁷⁵, são agentes que, em razão da sua centralidade, exercem todas as formas de controle de informação no *network* que criam – tais como seleção, moldagem, *timing*, repetição, sonegação, entre outros – e ainda têm grandes poderes sobre os membros do *network*, na medida em que podem (i) “prender” usuários dentro da rede; (ii) proteger normas, informações, usuários e comunidades de entradas não desejadas; e (iii) ainda manter atividades em curso dentro da rede sem distúrbios.

O poder de controle da informação, ínsito aos *gatekeepers*, pode ser analisado a partir de diversas perspectivas que não apenas a econômica tradicional, como (i) no sentido weberiano mais positivista, referente à habilidade de fazer com que os outros façam o que você quer que eles façam mesmo contra a sua vontade; (ii) no sentido de Bachrach e Baratz, que destacam a capacidade de determinado agente de dedicar suas energias para criar ou reforçar valores sociais e políticos ou práticas institucionais que restringem o debate político, levando ao público apenas o que lhe interessa; e (iii) também no sentido de Lukes, Foucault e Gramsci, cujo foco é a capacidade de mobilizar, recriar e reforçar vieses do sistema, de forma que não sejam conscientemente escolhidos nem o resultado intencional da decisão das pessoas⁷⁶.

Daí a importância das plataformas digitais, que, exatamente por muito conhecerem sobre nós, muito podem fazer em relação a nós e até contra nós. Todo esse conhecimento, associado ao poder da comunicação, hoje também embasado nos estudos da biologia, neurociência e psicologia, pode ser facilmente utilizado para manipular as pessoas, bem como tentar modificar suas crenças e opiniões⁷⁷.

Daí a afirmação de Tim Wu⁷⁸ de que o verdadeiro negócio de muitas plataformas é, por meio da disputa pela atenção e o tempo das pessoas, influenciar consciências. Têm-se aí todas as condições para exercer aquela que, segundo Castells⁷⁹, é a forma mais fundamental de poder: a habilidade de moldar a mente humana, a partir da capacidade relacional que um ator social tem de influenciar, de forma assimétrica, as decisões de outros atores sociais em favor dos seus próprios interesses e valores.

No mesmo sentido, Noam Chomsky⁸⁰ mostra que moldar a ideologia é uma das principais formas de atuação da elite econômica para a manutenção do seu poder, o que envolve as estratégias de educação e doutrinação. Sob essa perspectiva, o *Big Data* simplesmente expandiu as formas pelas quais se pode moldar a opinião pública, bem como potencializou vários dos seus efeitos.

E não se trata de meras especulações ou receios injustificados. Entre as inúmeras pesquisas sobre o tema, com foco no papel dos motores de busca, vale ressaltar o importante trabalho de Robert Epstein⁸¹ que, a partir de pesquisa empírica, demonstra os efeitos do que chama de *search engine manipulation effect (SEME)* e *search engine suggestion effect (SESE)*.

A situação não é diferente nas chamadas redes sociais. Ronaldo Lemos⁸² mostra como a esfera pública da internet brasileira está literalmente à venda, já que robôs, fantoches e *sock puppets* hoje disseminam qualquer conteúdo por parte de quem pretenda pagar por isso. Daí a sua preocupante conclusão de que, se antes era possível comprar políticos, agora é possível comprar a opinião pública ou, pelo menos, a aparência dela.

É dentro desse contexto que artigo recente de Roger McNamee⁸³ retoma o alerta que Marc Andreessen já havia dado em 2011, para advertir que os gigantes da internet estão engolindo a economia mundial. Alerta o autor para os dois principais tipos de riscos: (i) os relacionados aos usuários, considerando que plataformas como *Facebook*, *Google*, *Amazon*, *Alibaba* e *Tencent* usaram técnicas comuns em propaganda e cassinos para promover o vício psicológico; e (ii) os geopolíticos, considerando os danos que podem ser causados na esfera política – de que os casos Brexit e eleição presidencial norte-americana de 2016 são exemplos.

Esse último aspecto é de grande relevância, por ressaltar que as plataformas conseguem acumular uma significativa dimensão de poder político, já que podem usar o seu poder de manipulação para interferir em processos políticos e mesmo no resultado de eleições. Em recente palestra proferida no Stigler Center, Luigi Zingales⁸⁴ resumiu essa dimensão de poder de uma maneira bem simples: ao contrário dos demais agentes econômicos, que sempre puderam oferecer dinheiro para os agentes políticos, as plataformas podem também oferecer diretamente votos. No mesmo sentido, Martin Moore⁸⁵ destaca que as grandes plataformas adquiriram enorme poder de influenciar a ação coletiva e mesmo o voto das pessoas.

As recentes suspeitas de manipulação do resultado de eleições, como no caso do Brexit, Donald Trump e mesmo Jair Bolsonaro no Brasil ajudam a compreender a dimensão de poder político que pode ser exercida, direta ou indiretamente – por intermédio de seus parceiros comerciais – pelas plataformas digitais. Isso sem contar nas inúmeras outras formas de influência política praticada por tais agentes, tais como *lobby*, captura de agências reguladoras e mesmo de pesquisas e resultados acadêmicos, entre outros.

Em recente livro, Yochai Benkler, Robert Faris e Hal Roberts⁸⁶ tratam do tema a partir do exame do que ocorreu com as eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

Os autores partem da premissa de que o debate a respeito das informações erradas e das desinformações (*misinformation e disinformation*) em plataformas digitais têm interseção com a crescente preocupação em torno do grau de concentração desses entes, pois, quando as plataformas falham ou se tornam maus atores, os efeitos negativos são imensos⁸⁷.

A partir daí, os autores concluem que a segunda década do século XXI trouxe muitas tensões para o projeto democrático, já que processos tecnológicos que estão fora do controle humano estão esmagando nossa capacidade de encontrar sentido no mundo e de nos governar como democracias mais razoáveis⁸⁸. Entretanto, os autores recusam-se a culpar a tecnologia pois esta, longe de ser destino, interage com instituições e ideologia para moldar como conseguimos encontrar sentidos, como organizamos nossos interesses ao longo dos domínios econômico, político e pessoal e como criamos nossa cultura e identidade⁸⁹.

No entanto, alguns ecossistemas de comunicação têm sido caracterizados pela radicalização e pela desestabilização da habilidade de diferenciar ficção da verdade, com o resultado de minar a confiança nas instituições⁹⁰. Daí por que os autores, embora reconheçam que não há evidências concretas de que a *Cambridge Analytics* ou mesmo o *Facebook* foram determinantes para os resultados das eleições norte-americanas de 2016, em razão das bem-sucedidas capacidades de *microtargeted advertising*, entendem que os *pequenos efeitos* documentados na trajetória do mercado de dados pessoais podem ter *significativos efeitos* no futuro próximo⁹¹.

O fato de tais efeitos serem extremamente difíceis de serem mensurados não os torna menos preocupantes, motivo pelo qual há necessidade de regulação e transparência sobre a propaganda política, assim como diversas medidas de prevenção⁹², ainda que se tenha que reconhecer que, se as origens da crise decorrem da manipulação intencional de amplas partes da população pelos seus próprios líderes políticos e pela mídia, há pouco que as soluções tecnocráticas possam fazer para assegurar a liberdade de expressão⁹³.

Dessa maneira, é inequívoco que o poder acumulado pelas plataformas digitais vai muito além das definições mais tradicionais de poder econômico, normalmente centradas na capacidade de aumentar preços de produtos ou serviços ou reduzir ofertas. A variedade, a extensão e o impacto do poder econômico das plataformas é de tal grau que muitos já as colocam em patamar semelhante ao dos Estados (*net states*)⁹⁴. A partir da ótica da informação e do conhecimento como poder, é possível vislumbrar o papel que determinados agentes podem ter para o atual cenário da pós-verdade.

Vale ressaltar que, não obstante as inúmeras inovações e benefícios que justificaram a expansão das plataformas, pelo menos parte do poder de muitas delas foi conquistada de forma ilícita, como resultado da exploração indevida dos dados dos usuários, muitas vezes, sem o consentimento ou até mesmo sem a ciência destes.

Como já antecipava Harari⁹⁵: “A ilusão de livre-arbítrio provavelmente se desintegrará quando nos depararmos diariamente com instituições, corporações e órgãos do governo que compreendem e manipulam o que era, até então, nosso inacessível reino interior.” Daí concluir que ditaduras digitais não são o único perigo que nos aguarda, considerando que as ameaças se projetam não só sobre a liberdade, mas também sobre a igualdade⁹⁶.

É importante ressaltar que muito do poder desses agentes decorreu da ausência de uma regulação de dados, cujo vácuo foi preenchido por uma autorregulação abusiva e sem limites, estabelecida apenas em favor dos interesses das próprias plataformas. Daí por que não há dúvidas de que um dos meios de conter o poder desses agentes, assim como de todos os demais que atuam na indústria de dados, é o reconhecimento e o reforço dos direitos dos titulares de dados, inclusive no que impõem padrões de segurança, transparência e *accountability* para todas as formas de tratamento de dados.

Verdade seja dita que, em se tratando de agentes detentores de posições dominantes ou quase monopolistas nos mercados em que atuam, tal como é o caso das grandes plataformas digitais, a LGPD certamente não será suficiente para, sozinha, endereçar todos os problemas decorrentes da atuação desses entes. Certamente que se espera do Direito da Concorrência e das respectivas autoridades esforços no endereçamento do problema, na parte em que ele estiver relacionado ao abuso de poder econômico.

Entretanto, não há dúvidas de que uma lei geral de proteção de dados, como é o caso da LGPD, tem papel crucial e estratégico, até por oferecer uma base comum de regras e princípios que poderá ser utilizada por outras áreas, sempre que tiverem que lidar com a problemática dos dados.

6. Conclusões

O presente artigo teve por objetivo mostrar como a coleta e a utilização maciça de dados acabaram levando à constituição de uma nova forma de capitalismo, fundado na vigilância constante e no controle disperso sobre os cidadãos, a fim de possibilitar uma geração crescente de mais dados e de mais aplicações a partir desses dados. Criou-se o que

Frank Pasquale chama de *one-way mirror*, em que agentes governamentais e privados sabem tudo dos indivíduos, enquanto os indivíduos nada sabem deles.

Não obstante a ausência de transparência e *accountability*, os sistemas de inteligência artificial que movem a economia digital são programados para produzirem inferências e previsões, com as quais se pode classificar as pessoas e, a partir daí, determinar os seus destinos, inclusive no que diz respeito ao seu acesso a direitos e oportunidades. Ocorre que tais processos, ainda mais se forem totalmente automatizados e sem nenhum tipo de controle humano, podem ser fontes inesgotáveis de julgamentos equivocados e que reproduzam e intensifiquem ainda mais desigualdades e discriminações.

Por essas razões, todas as modificações apontadas, longe de se restringirem apenas à economia, apresentam importantes consequências também para a política, à sociedade e às próprias dimensões existenciais dos cidadãos, que passam a sofrer permanente ataque em diversas perspectivas, inclusive naquelas que dizem respeito à própria individualidade, cada vez mais comprometida diante do crescente poder de manipulação que decorre do processamento de dados.

Fica claro, assim, que não é exagerada a citação de Yuval Harari, mencionada na introdução, de que a questão da proteção dos dados talvez seja a mais importante da nossa época. É nesse contexto que deve ser compreendida a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e seus objetivos principais de proteger os dados pessoais e de reforçar a autonomia informativa e a dignidade dos titulares dos dados, bem como a própria democracia.

Se é verdade que, como dizia Rodotà⁹⁷, “a forte proteção dos dados pessoais continua a ser uma “utopia necessária” (S. Simitis) se se deseja garantir a natureza democrática de nossos sistemas políticos”, também é verdade que os tempos atuais têm mostrado que não basta a utopia. Ou começamos a colocar em ação estratégias efetivas para a proteção dos dados pessoais ou seremos sugados para um processo cujo resultado pode ser a própria negação da nossa humanidade.

7.Referências bibliográficas

AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. *Prediction machines*. The simple economics of artificial intelligence. Boston: Harvard Business Review Press, 2018.

BARZILAI-NAHON, Karine. Toward a theory of network gatekeeping: a framework for exploring informational control. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, v. 59, p. 1493-1512, 2008.

BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. *Network Propaganda*. Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics. New York: Oxford University Press, 2018.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. A função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BROUSSARD, Meredith. *Artificial unintelligence*. How computers misunderstand the world. Cambridge: The MIT Press, 2018.

CASTELLS, Manuel. *O poder da comunicação*. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

CHENEY-LIPPOLD, John. *We are data*. Algorithms and the making of our digital selves. New York: New York University Press, 2017.

CHOMSKY, Noam. *Réquiem para o sonho americano*. Os 10 princípios de concentração de riqueza & poder. Trad. Milton Chaves de Almeida. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

COHEN, Julie E. Examined lives: informational privacy and the subject as object. *Stanford Law Review*, v. 52, p. 1373-1438, 2000.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

EPSTEIN, Robert; ROBERTSON, Ronald E. The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections. *PNAS*. Disponível em: [https://papers-gamma.link/static/memory/pdfs/9-Epstein_Search_Engine_Manipulation_Effect_2015.pdf]. Acesso em: 18.11.2018.

EUA. FEDERAL TRADE COMMISSION. *Data Brokers. A Call for transparency and accountability*. Disponível em: [www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf]. Acesso em: 22.02.2019.

EUA. OBAMA WHITE HOUSE. *Preparing for the future of artificial intelligence*. Disponível em: [obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf]. Acesso em: 22.02.2019.

EUBANK, Virginia. *Automating inequality*. How high-tech tools profile, police, and punish the poor. New York: St. Martin's Press, 2017.

FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais, *big data* e riscos para os direitos da personalidade. In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane. *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais e os desafios para a regulação jurídica. In: PARENTONI, Leonardo. *Direito, Tecnologia e Inovação*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018. v. I.

FRAZÃO, Ana. Dados, estatísticas e algoritmos. Perspectivas e riscos da sua crescente utilização. *Jota*, 28.06.2017. Disponível em: [www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/dados-estatisticas-e-algoritmos-28062017].

FRAZÃO, Ana. Algoritmos e Inteligência Artificial. *Jota*, 16.05.2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/algoritmos-e-inteligencia-artificial-15052018].

GILLIOM, John; MONAHAN, Torin. *Supervision*. An introduction to the surveillance society. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.

HARARI, Yuval Noah. *21 Lições para o Século 21*. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

HARARI, Yuval Noah. *Homo Deus*: uma breve história do amanhã (edição eletrônica). São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

HOLMES, Dawn E. *Big Data*. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017.

HOOFNAGLE, Chris Jay; SOLTANI, Ashkan; GOOD, Nathaniel; WANBACH, Dietrich J. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. *Harvard Law & Policy Review*, v. 6, p. 273-296, 2012.

ICO. *A Report on the Surveillance Society*. Disponível em: [https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042390/surveillance-society-full-report-2006.pdf]. Acesso em: 20.02.2019.

KELLEHER, John D.; TIERNEY, Brendan. *Data Science*. Cambridge: The MIT Press, 2018.

LEMOES, Ronaldo. Redes sociais não são opinião pública. Confundir *timeline* de rede social com opinião pública é um erro crasso. *Folha de São Paulo*, 04.02.2019. Disponível em: [www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2019/03/redes-sociais-nao-sao-opiniao-publica.shtml]. Acesso: 04.03.2019.

LISSARDY, Gerardo. 'Despreparada para a era digital, a democracia está sendo destruída', afirma guru do 'big data'. *BBC*. Disponível em: [www.bbc.com/portuguese/geral-39535650].

LLOYD, Ian J. *Information Technology Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

MAYER-SHÖNBERGER, Viktor; RAMGE, Thomas. *Reinventing capitalism in the age of big data*. New York: Basic Books, 2008.

MCNAMEE, Roger. Viciados e traficantes nas mídias sociais. *Valor Econômico*, 29 jan. 2018.

MOAZED, Alex; JOHNSON, Nicholas. *Modern monopolies*: what it takes to dominate the 21st century economy (edição eletrônica). Nova York: St. Martin's Press, 2016.

MOORE, Martin. *Tech Giants and Civic Power*. Disponível em: [www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/cmcp/tech-giants-and-civic-power.pdf]. Acesso em: 14.06.2018.

O'NEIL, Cathy. *Weapons of math destruction*: how big data increases inequality and threatens democracy (edição eletrônica). New York: Crown, 2016.

PASQUALE, Frank. *The black box society*. The secret algorithms that control money and information. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. A privacidade hoje. Trad. Danilo Doneda e Laura Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

ROSS, Alec. *The industries of the future*. Nova York: Simon & Schuster, 2016.

SCHNEIER, Bruce. *Data and Goliath*. The hidden battles to collect your data and control your world. New York: W. W. Norton & Company, 2015.

SRNICEK, Nick. *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2018.

THE ECONOMIST. The world's most valuable resource is no longer oil but data. Disponível em: [www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data]. Acesso em: 10.01.2019.

WACHTER-BOETTCHER, Sara. *Technically Wrong*. Sexist Apps, biased algorithms, and other threats of toxic tech. New York: W. W. Norton & Company, 2017.

WICHOWSKI, Alexis. Net states rule the world; we need to recognize their power. *Wired*. Disponível em: [www.wired.com/story/net-states-rule-the-world-we-need-to-recognize-their-power/]. Acesso em: 20.11.2018.

WIRED. Amazon Alexa and the search for the one perfect answer. Disponível em: [www.wired.com/story/amazon-alexa-search-for-the-one-perfect-answer/]. Acesso em: 20.02.2019.

WU, Tim. *The attention merchants: the epic scramble to get inside our heads*. Nova York: Knopf, 2016.

ZINGALES, Luigi. Digital platforms and concentration. In: STIGLER CENTER. *2018 Antitrust and Competition conference*. Disponível em: [www.youtube.com/watch?v=O_pxLvKQBE8]. Acesso em: 20.11.2018.

ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism*. The fight for a human future at the new frontier of power. New York: Public Affairs, 2019.

1

.Advogada e Professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília – UnB.

2

.PASQUALE, Frank. *The black box society*. The secret algorithms that control money and information. Cambridge: Harvard University Press, 2015. p. 16.

3

.Disponível em: [www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data]. Acesso em: 10.01.2019.

4

.SRNICEK, Nick. *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2018. p. 39.

5

.Esses são os chamados “4 V” do *Big Data*.

6

.ROSS, Alec. *The industries of the future*. Nova York: Simon & Schuster, 2016.

7

.HARARI, Yuval Noah. *21 Lições para o Século 21*. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 107.

8

.Idem, p. 110-111.

9

.Ver FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais, *big data* e riscos para os direitos da personalidade. In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane. *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 333-349.

10

.Nesse sentido, ver MAYER-SHÖNBERGER, Viktor; RAMGE, Thomas. *Reinventing capitalism in the age of big data*. New York: Basic Books, 2008.

11

.HOOFNAGLE, Chris Jay; SOLTANI, Ashkan; GOOD, Nathaniel; WANBACH, Dietrich J. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. *Harvard Law & Policy Review*. v. 6, p. 273-296, 2012.

12

.LISSARDY, Gerardo. 'Despreparada para a era digital, a democracia está sendo destruída', afirma guru do 'big data'. *BBC*. Disponível em: [www.bbc.com/portuguese/geral-39535650].

13

.PASQUALE, Frank. *The black box society*. The secret algorithms that control money and information. Cambridge: Harvard University Press, 2015. p. 9.

14

.PASQUALE, Frank. Op. cit., p. 42-45.

15

.LLOYD, Ian J. *Information Technology Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 9.

16

.ICO. *A Report on the Surveillance Society*. Disponível em: [https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042390/surveillance-society-full-report-2006.pdf]. Acesso em: 20.02.2019.

17

.Ver, por todos, RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. A privacidade hoje. Trad. Danilo Doneda e Laura Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

18

.ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism*. The fight for a human future at the new frontier of power. New York: Public Affairs, 2019. p. 8.

19

.Idem, p. 19.

20

.Idem, p. 20.

21

.PASQUALE. Op. cit., p. 9-10.

22

.GILLIOM, John; MONAHAN, Torin. Supervision. *An introduction to the surveillance society*. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. p. 130-131.

23

.SCHNEIER, Bruce. *Data and Goliath*. The hidden battles to collect your data and control your world. New York: W.W. Norton & Company, 2015. p. 57.

24

.BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. A função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 48.

25

.Op. cit., p. 17-25.

26

.FEDERAL TRADE COMMISSION. *Data Brokers. A Call for transparency and accountability*. Disponível em: [www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf]. Acesso em: 22.02.2019.

27

.Entre as conclusões mais pontuais do relatório, estão as de que alguns dos *data brokers* analisados agregaram e modelaram a história de compras de 190 milhões de consumidores individuais a partir de dados de mais de 2.600 empresas.

28

.Para maiores discussões sobre os algoritmos, ver FRAZÃO, Ana. Dados, estatísticas e algoritmos. Perspectivas e riscos da sua crescente utilização. *Jota*. Disponível em: [www.anafracao.com.br/files/publicacoes/2017-06-28-Dados_estatisticas_e_algoritmos_Perspectivas_e_riscos_da_sua_crescente_utilizacao.pdf] e Algoritmos e Inteligência Artificial. *Jota*. Disponível em: [www.anafracao.com.br/files/publicacoes/2018-05-16-Algoritmos_e_inteligencia_artificial.pdf].

29

.Ver KELLEHER, John D.; TIERNEY, Brendan. *Data Science*. Cambridge: The MIT Press, 2018. p. 151.

30

.WIRED. Amazon Alexa and the search for the one perfect answer. Disponível em: [www.wired.com/story/amazon-alexa-search-for-the-one-perfect-answer/]. Acesso em: 20.02.2019.

31

.AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. *Prediction machines*. The simple economics of artificial intelligence. Boston: Harvard Business Review Press, 2018. p. 4.

32

.Op. cit., p. 97.

33

.Ver FRAZÃO, Ana. *Dados, estatísticas e algoritmos. Perspectivas e riscos da sua crescente utilização*, cit.

34

.HOLMES, Dawn E. *Big Data*. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 57.

35

.Op. cit., p. 58.

36

.Op. cit., p. 102.

37

.COHEN, Julie E. Examined lives: informational privacy and the subject as object. *Stanford Law Review*, v. 52, p. 1376, 2000.

38

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. A privacidade hoje. Trad. Danilo Doneda e Laura Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 111-139.

39

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 174-175.

40

.FEDERAL TRADE COMMISSION. *Data Brokers. A Call for transparency and accountability*. Disponível em: [www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf]. Acesso em: 22.02.2019.

41

.CHENEY-LIPPOLD, John. *We are data*. Algorithms and the making of our digital selves. New York: New York University Press, 2017. p. xiii e 7.

42

.Idem, p. 14-19.

43

.Idem, p. 33.

44

.Idem, p. 35.

45

.Op. cit., p. 46.

46

.Idem, p. 189.

47

.KELLEHER, John D.; TIERNEY, Brendan. Op. cit., p. 196-197.

48

.KELLEHER, John D.; TIERNEY, Brendan. Op. cit., p. 198. Tradução livre da autora.

49

.HARARI, Yuval Noah. *Homo Deus*: uma breve história do amanhã (edição eletrônica), cit.

50

.Idem.

51

.Op. cit., p. 19-20.

52

.FEDERAL TRADE COMMISSION. *Data Brokers. A Call for transparency and accountability*. Disponível em: [www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf]. Acesso em: 22.02.2019.

53

.Op. cit., p. 190-191.

54

.Ver, sobre o tema, entre inúmeros outros, AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. Op. cit., p. 205.

55

.Op. cit., p. 191.

56

.Op. cit., p. 129-139.

57

.Op. cit., p. 109.

58

.Op. cit., p. 115-116.

59

.Op. cit., p. 133-135.

60

.Ver, sobre o tema, entre inúmeros outros, EUBANK, Virginia. *Automating inequality*. How high-tech tools profile, police, and punish the poor. New York: St. Martin's Press, 2017; BROUSSARD, Meredith. *Artificial unintelligence*. How computers misunderstand the world. Cambridge: The MIT Press, 2018; WACHTER-BOETTCHER, Sara. *Technically Wrong*. Sexist Apps, biased algorithms, and other threats of toxic tech. New York: W. W. Norton & Company, 2017.

61

.O'NEIL, Cathy. *Weapons of math destruction*: how big data increases inequality and threatens democracy (edição eletrônica). Nova Iorque: Crown, 2016.

62

.Op. cit., p. 17.

63

.Op. cit., p. 9.

64

.Frank Pasquale (Op. cit., p. 6-7) parte da premissa de que as decisões algorítmicas são determinadas por complexas fórmulas equipadas por legiões de engenheiros e protegidas por advogados, que escondem as ações dos agentes sob acordos de confidencialidade, métodos proprietários e o que chama de *gag rules*. Para o autor, há três estratégias para manter as *black boxes* fechadas, além do segredo real: o segredo jurídico (quando há o acesso, mas aqueles que o têm estão obrigados a manter a informação secreta) e a ofuscação, que envolve a tentativa deliberada de dissimulação do segredo. O resultado desses três tipos de segredo é a opacidade, o que leva à incompreensão. É importante ressaltar que a crítica do autor não se dirige apenas aos mercados digitais, mas também aos mercados financeiros, em relação aos quais, além da opacidade, o excesso de complexidade das operações também seria mais um fator a impedir a transparência.

.Como bem coloca o autor (PASQUALE, Frank. Op. cit., p. 2): “*But what if the “knowledge problem” is not an intrinsic aspect of the market, but rather is deliberately encouraged by certain businesses? What if financiers keep their doings opaque on purpose, precisely to avoid or to confound regulation? That would imply something very different about the merits of deregulation.*”

.Op. cit., p. 10.

.Op. cit., p. 14.

.Op. cit., p. 15. Tradução livre da autora.

.Op. cit., p. 202. Tradução livre da autora.

.Disponível em: [\[https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf\]](https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf). Acesso em: 20.02.2019.

.Essa provocação é lançada por PASQUALE, Frank. Op. cit., p. 147.

.Op. cit., p. 8.

.FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais e os desafios para a regulação jurídica. In: PARENTONI, Leonardo. *Direito, Tecnologia e Inovação*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018. v. I, p. 636-669.

.MOAZED, Alex; JOHNSON, Nicholas. *Modern monopolies: what it takes to dominate the 21st century economy* (edição eletrônica). Nova York: St. Martin Press, 2016.

.BARZILAI-NAHON, Karine. Toward a theory of network gatekeeping: a framework for exploring informational control. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, v. 59, p. 1496, 2008.

.Idem, p. 1499-1500.

.FRAZÃO, Ana. Premissas para a reflexão sobre a regulação da tecnologia. *Jota*. Disponível em: [\[https://jota.info/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/premissas-para-a-reflexao-sobre-a-regulacao-da-tecnologia-16112017\]](https://jota.info/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/premissas-para-a-reflexao-sobre-a-regulacao-da-tecnologia-16112017).

.WU, Tim. *The attention merchants: the epic scramble to get inside our heads*. Nova York: Knopf, 2016.

.CASTELLS, Manuel. *O poder da comunicação*. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

.CHOMSKY, Noam. *Réquiem para o sonho americano*. Os 10 princípios de concentração de riqueza & poder. Trad. Milton Chaves de Almeida. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

.EPSTEIN, Robert; ROBERTSON, Ronald E. The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections. *PNAS*. Disponível em: [\[https://papers-gamma.link/static/memory/pdfs/9-Epstein_Search_Engine_Manipulation_Effect_2015.pdf\]](https://papers-gamma.link/static/memory/pdfs/9-Epstein_Search_Engine_Manipulation_Effect_2015.pdf). Acesso em: 18.11.2018.

.LEMOES, Ronaldo. Redes sociais não são opinião pública. Confundir *timeline* de rede social com opinião pública é um erro crasso. *Folha de São Paulo*, 04.03.2019. Disponível em: [\[www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2019/03/redes-sociais-nao-sao-opiniao-publica.shtml\]](http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2019/03/redes-sociais-nao-sao-opiniao-publica.shtml). Acesso em: 04.03.2019.

.MCNAMEE, Roger. Viciados e traficantes nas mídias sociais. *Valor Econômico*, 29 jan. 2018.

.ZINGALES, Luigi. Digital platforms and concentration. In: STIGLER CENTER. *2018 antitrust and competition conference*. Disponível em: [\[www.youtube.com/watch?v=O_pxLvKQBE8\]](https://www.youtube.com/watch?v=O_pxLvKQBE8). Acesso em: 20.11.2018.

.MOORE, Martin. *Tech Giants and Civic Power*. Disponível em: [\[www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/cmcp/tech-giants-and-civic-power.pdf\]](http://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/cmcp/tech-giants-and-civic-power.pdf). Acesso em: 14.06.2018.

.BENKLER, Yochai, FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. *Network Propaganda*. Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics. New York: Oxford University Press, 2018.

87

.Op. cit., p. 360-361.

88

.Op. cit., p. 380-381.

89

.Op. cit., p. 381.

90

.Op. cit., p. 381-383.

91

.Op. cit., p. 385.

92

.Op. cit., p. 385-386.

93

.Op. cit., p. 386.

94

.WICHOWSKI, Alexis. Net states rule the world; we need to recognize their power. *Wired*. Disponível em: [www.wired.com/story/net-states-rule-the-world-we-need-to-recognize-their-power/]. Acesso em: 20.11.2018.

95

.HARARI, Yuval Noah. *21 lições para o século 21*, cit., p. 74.

96

.Op. cit., p. 101.

97

.Op. cit., p. 15.

Capítulo 2. Os princípios norteadores da proteção de dados pessoais no Brasil e sua otimização pela Lei 13.709/2018

Marco Aurélio Bellizze Oliveira¹

Isabela Maria Pereira Lopes²

Introdução

O breve século XX já estava quase atingindo a sua metade quando Eric Blair escreveu, sob o pseudônimo de George Orwell, o livro *1984*. A obra expressa uma profunda descrença com o futuro da humanidade, fruto da decepção que as Guerras Mundiais do início do século representaram para as otimistas expectativas dos Oitocentos.

No enredo dessa ficção distópica, George Orwell descreve a supressão da individualidade como método de manutenção do poder. As estratégias iam desde a repressão aos sentimentos, instintos, memória, relações pessoais, até a imposição de uma forma de pensar incoerente – o duplipensar – e o empobrecimento da língua – a novilíngua – a fim de reduzir a capacidade de formulação de ideias. Aos cidadãos de 1984, também era imposto um rígido controle de pensamento, hábitos e relações, inclusive com a supressão da privacidade, pois seu comportamento era monitorado por teletelas instaladas em locais públicos e privados.

O livro provoca muitas reflexões sobre a sociedade e, embora muitas das previsões de Orwell felizmente não tenham se concretizado no ano de 1984 e nas décadas seguintes³, sua contribuição literária ainda se presta a inspirar reflexões e pesquisas em diversas áreas. Um exemplo é o artigo do professor Eduardo Tomasevicius, publicado em 2014, para discutir o direito à privacidade na era da internet, e as insuficiências da Lei 12.737/2012 (Lei Carolina Dickmann) e da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), à época ainda recentes, para concretizar esse direito⁴.

A preocupação com a privacidade, contudo, é bem mais antiga do que a rede mundial de computadores e do que a própria história de Orwell. Ela foi expressa por Samuel Warren e Louis Brandeis no artigo *The right to privacy*, publicado na *Harvard Law Review* em 1890. Esses autores questionam se haveria, no *common law*, um fundamento para a proteção à privacidade dos indivíduos, e qual seria sua natureza e extensão.

No artigo, os autores expõem que a quebra de um contrato e da confiança foi utilizada para solucionar muitos casos, porém, a violação da vida privada nem sempre será atribuível a um contratante. Também o direito de propriedade, invocado para proteger os bens imateriais, não mais seria suficiente no mundo moderno⁵, e terminam por indicar que a proteção da vida privada repousa sobre o direito à privacidade que, por sua vez, é afeto ao direito mais amplo de personalidade⁶. Embora o artigo seja usualmente considerado precursor do tema, os próprios autores dão notícia de sua ocupação pelo direito francês na nota 41. Também são abundantes na doutrina episódios de violação da intimidade de personalidades ocorridos no século XIX antes que ele fosse redigido⁷.

Se é certo que a preocupação com a proteção da privacidade e da intimidade dos indivíduos tem raízes profundas no tempo, é de se notar que a intensidade e o fundamento dessa proteção sofreram variações. Nessa perspectiva, não há como afastar os efeitos da Segunda Revolução Industrial, iniciada no século XIX, e da Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Tecnológica, com início na segunda metade do século XX. Essa última, acelerada pela disputa da Guerra Fria, propiciou, entre outras novidades, o surgimento da Rede Mundial de Computadores, que modificou profundamente a velocidade e a capacidade de captação e processamento de dados⁸.

No mundo jurídico, essa mudança fortaleceu as discussões doutrinárias sobre a privacidade, pois, a partir da década de 1960⁹, e nas que se seguiram, a proteção de dados foi tratada na legislação de vários países. O objetivo, em primeiro momento, era assegurar a privacidade dos indivíduos perante o Estado¹⁰, porém, a pulverização dos centros de processamento de dados exigiu que fossem estabelecidos meios de proteção da privacidade também contra terceiros¹¹. Outra mudança importante, que favoreceu a proteção dos dados pessoais como garantia de privacidade, foi o reconhecimento da pessoa, e não de sua propriedade, como objeto de proteção desse direito¹².

Das várias leis editadas, foi possível extrair um núcleo de princípios comuns, que orientou iniciativas internacionais, entre elas a Convenção de Estrasburgo e as Diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esses documentos contribuíram para a edição das Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE e, portanto, para a formação do sistema europeu de proteção de dados, que foi recentemente

aprimorado pelo Regulamento UE 2016/679. Para Danilo Doneda, o sistema europeu é coeso, pois organizado a partir das diretivas editadas pelo Parlamento do Conselho Europeu e, embora cada estado-membro tenha legislado sobre a matéria, inclusive por exigência da própria normativa, manteve-se o núcleo de proteção¹³. Por outro lado, o sistema americano é difuso, tanto pelas peculiaridades de seu modelo federativo como pela normatização setorial da proteção de dados naquele país¹⁴.

No Brasil, pode-se considerar que a privacidade há muito é objeto de proteção tanto pela legislação ordinária – a Lei do *Habeas Data*, a Lei de Arquivos Públicos, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, Lei do Cadastro Positivo e, mais recentemente, o Marco Civil da Internet – como constitucional – inciso X do art. 5º. Não obstante, uma legislação específica sobre a proteção de dados foi muito desejada por nossos juristas¹⁵ e necessária do ponto de vista de uma estratégia internacional¹⁶.

A Lei 13.709, editada em 14 de agosto de 2018, foi uma resposta não apenas aos juristas, mas à própria Lei 12.965/2015 – Marco Civil da Internet – que indicou a proteção de dados pessoais, na forma de lei específica, como um princípio do uso da internet no Brasil¹⁷. Portanto, a edição da Lei de Proteção de Dados pode ser compreendida como a concretização de um dos princípios do uso da internet.

Contudo, o entusiasmo com a edição da nova lei não pode cegar os juristas a ponto tratarem o assunto apenas sob o prisma dos dispositivos novos, e, com isso, limitarem a proteção de dados a esse diploma legal. Isso porque a lei faz parte de um sistema que já estava em formação e, sem olvidar da boa nova e de muitos dos seus méritos, será mais interessante que seja recebida e aplicada como parte do sistema que é, e não a panaceia de todos os males virtuais¹⁸.

Outrossim, a aplicação correta e segura da lei – sobretudo que trata de tema tão sensível quanto os dados pessoais, considerados o ouro do século XXI – é favorecida quando seus dispositivos conseguem dar concretude aos princípios por ela abraçados¹⁹. Em outras palavras, não basta conhecer e indicar os princípios de proteção aos dados pessoais²⁰. As forças do mercado e da administração pública reclamam que a lei contenha meios de proteção tangíveis, em disposições específicas e explícitas, para assegurar a proteção de dados pessoais, além de favorecer a segurança jurídica em seu tratamento²¹.

Assim, em atenção ao tema que generosamente nos confiou o organizador desta importante obra, esse texto tem a pretensão de tratar dos princípios que norteiam a proteção de dados pessoais no Brasil. Com efeito, é de rigor que sejam, primeiramente, indicadas as leis que compõem esse sistema de proteção, explicitando os princípios que as direcionam. Em seguida, serão expostos os princípios contidos da Lei 13.907/2018 e, dada a sua novidade, tentar-se-á indicar como eles se concretizam pelos dispositivos dessa lei. Para tanto, emprega-se a revisão bibliográfica e a análise legal, pelo método indutivo.

1. O sistema legal de proteção de dados no Brasil e seus princípios

Os dados pessoais constituem importante aspecto da privacidade e também da personalidade dos indivíduos. Muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD) tenha sido publicada no final de 2018, a privacidade do cidadão não esteve desamparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal como é possível verificar não apenas do arcabouço legal anterior à LGPD²², mas pela atuação dos tribunais superiores, de agências reguladoras (ANATEL)²³ e por disposições da própria Constituição Federal.

No plano constitucional, os incisos X e XII do art. 5º tratam da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como do sigilo de correspondência e comunicações telefônicas. Também é bastante festejada a ação constitucional do *habeas data* (art. 5º, LXXII), regulamentada pela Lei 9.507/1997, em cujo art. 7º estão estampadas as hipóteses de cabimento²⁴. Delas é possível perceber que o manejo da ação se destina ao conhecimento, retificação e esclarecimento sobre dado ou informação do impetrante constante em banco de dados público. Anote-se, ainda, observação sobre o art. 19 da referida lei, que cuida de estabelecer a prioridade de tramitação do *habeas data*, subordinada apenas aos *habeas corpus* e mandados de segurança²⁵.

Não obstante, as medidas de proteção de dados não ficaram adstritas às previsões constitucionais – e nem poderiam. O avanço tecnológico fez-se sentir nos tribunais superiores, ainda na década de 1990. Menciona-se, aqui, o julgamento do Recurso em *Habeas Data* 22/DF, quando os Ministros Celso de Mello e Sepúlveda Pertence reforçaram a importância do *habeas data* na concretização do direito material, em especial, à personalidade, intimidade e proteção de dados pessoais²⁶. Outro julgado paradigmático para o tema é o Recurso Especial 22.337/RS, de relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. A discussão acerca do tempo de prescrição da inscrição no cadastro do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) deu a oportunidade para que o relator registrasse sua preocupação com a crescente utilização de bancos de dados sem controle de finalidade, e advertisse que tais registros devem ser feitos depois de ciência prévia do consumidor²⁷.

Em termos de proteção de dados, o Superior Tribunal de Justiça continua a dar sua contribuição à sociedade, a partir do aparato legal que foi se desenvolvendo. Apenas como exemplo, registre-se o julgamento do Recurso Especial 1.168.547/RJ, no qual o Ministro Luis Felipe Salomão reconheceu no direito de privacidade o “dispor com exclusividade sobre as próprias informações”²⁸; o Recurso Especial 306.570/SP, reforçando a independência da

proteção dos dados pessoais com relação ao sigilo bancário²⁹ e, mais recente, o Recurso Especial 1.419.698/RS representativo de controvérsia, quando a Segunda Seção apreciou a licitude do cadastro no modelo *credit scoring*, que confere uma nota ao consumidor a partir da análise de dados referentes à operações de crédito contratadas por ele anteriormente. A metodologia do cadastro foi considerada legal pela Corte que, oportunamente, reforçou os limites da tutela do consumidor e de sua privacidade, consagrados no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei do Cadastro Positivo, ao determinar que o consumidor tem direito de ser informado sobre as fontes utilizadas para coleta de seus dados e a natureza das informações levadas em consideração. Além disso, ressaltou-se que a utilização de informações sensíveis, incorretas ou desatualizadas configura abuso de direito, e que a responsabilidade civil dos envolvidos é objetiva e solidária³⁰.

Os Estados Unidos e os países europeus que legislaram sobre a proteção de dados na década 1970 tinham como principal objetivo assegurar a privacidade dos cidadãos diante do Estado. No Brasil, as primeiras leis ordinárias sobre proteção de dados também foram de caráter público³¹. Trata-se da Lei de Arquivos Públicos (Lei 8.159/1991), além da já mencionada Lei do *Habeas Data* (Lei 9.507/1997).

A Lei de Arquivos Públicos consagra o direito do cidadão de acesso à informação de seu interesse particular ou de interesse público, assim como a proteção do sigilo, da intimidade e da vida privada³², sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa³³ logo nos primeiros artigos. Não obstante os dispositivos sobre acesso e sigilo de documentos públicos estarem revogados pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), arquivos cuja divulgação violasse a intimidade ou a vida privada, assim como ameaçasse a segurança da sociedade, eram considerados sigilosos e, portanto, submetidos a regras especiais previstas nos parágrafos do art. 23³⁴.

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) tem por objetivo assegurar o direito fundamental encampado no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição³⁵. Sua contribuição para a proteção dos dados pessoais, além do reforço ao equilíbrio entre acesso, qualidade da informação, proteção à privacidade e sigilo, é a diversificação de categorias – ultrassecreta, secreta e reservada –, além do detalhamento dos critérios para classificação das informações. A lei dedicou, ainda, uma seção especial para tratar das informações privadas, conferindo a elas um tempo de sigilo máximo de cem anos, que é bastante superior às demais categorias³⁶. Também estabeleceu como regra a exigência do consentimento para sua divulgação³⁷, que só pode ser afastada em casos específicos³⁸. O uso indevido das informações privadas acarreta a responsabilidade civil, nos termos dessa lei³⁹.

Todavia, sendo a proteção de dados um aspecto da privacidade e, esta, por sua vez, um dos direitos da personalidade⁴⁰, sua proteção não poderia escapar aos domínios do Direito Privado. Nesse aspecto, o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990 – é indicado como o pioneiro, seguido pelo Código Civil – Lei 10.406/2002⁴¹. A proteção conferida por este último decorre dos arts. 12⁴² e 21⁴³, isto é, da proteção da vida privada e da pretensão imediata de fazer cessar ameaça ou lesão a este direito, bem como das medidas cabíveis, entre as quais a responsabilidade de reparar as perdas e os danos causados.

No Código de Defesa do Consumidor, a Seção VI do Capítulo V é dedicada aos bancos de dados e cadastros de consumidores e tem no art. 43 o seu principal dispositivo. Ele garante o acesso às informações arquivadas sobre o consumidor e de suas respectivas fontes, além de estabelecer o prazo máximo da permanência delas no cadastro, o dever de informar sua abertura e de proceder à imediata correção de informações falsas ou equivocadas, a pedido do consumidor. Mencione-se, ainda, o § 6º, acrescentado pela Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – para tratar de modo mais específico do acesso dos portadores de necessidades especiais⁴⁴. Da leitura desse artigo, a doutrina⁴⁵ extrai: i) o direito de acesso; ii) o princípio da qualidade dos dados; iii) o princípio da transparência; iv) o direito de retificação e cancelamento; e v) o princípio do esquecimento.

Não se pode deixar de mencionar nesse estudo o esforço legislativo, já aprovado pelo Senado e remetido à Câmara dos Deputados, consubstanciado no PL 3.541/2015. Entre outras medidas, ele propõe acrescentar entre os direitos básicos do consumidor: i) a privacidade e a segurança de informações e de seus dados pessoais coletados, inclusive, no meio eletrônico; e ii) a liberdade de escolha, vedados a discriminação e o assédio do consumo⁴⁶.

Os cadastros e bancos de dados de consumidores estão também sob a regulação da Lei do Cadastro Positivo – Lei 12.414/2011, cujo escopo é disciplinar a formação e a consulta aos bancos de dados com informações de adimplemento, para a formação do histórico de crédito. A proposta dessa lei é permitir que o mercado identifique os bons pagadores e, com isso, reduza a taxa de juros, sem descuidar, porém, da proteção dos dados pessoais⁴⁷.

Referida lei reforça o princípio da qualidade dos dados pessoais⁴⁸ e os direitos de acesso, retificação e cancelamento de informações⁴⁹, a responsabilidade objetiva e solidária pelos danos⁵⁰, que já constavam no Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, a lei estabelece com maior rigor a finalidade da coleta e uso dos dados, que fica limitada à análise de risco de crédito do cadastrado, além de estipular formas de controle mais precisas do cadastrado em relação aos seus dados⁵¹, inclusive reconhecendo o direito de o cadastrado solicitar uma revisão de decisão baseada exclusivamente em dados automatizados⁵².

A Lei do Cadastro Positivo também inova ao atentar-se para a classe das informações sensíveis – que revelam origem social, étnica, saúde, informações genéticas, convicções pessoais e orientação sexual – conferindo-lhes

um tratamento diferenciado.⁵³

O Marco Civil da Internet – Lei 12. 965/2014 – também abordou a proteção de dados em alguns aspectos, sendo o principal deles no inciso III do art. 3º, elegendo-o como um princípio do uso da internet no Brasil. Entre os direitos do usuário, estão a inviolabilidade de sua vida privada – condição para pleno exercício do direito de acesso⁵⁴ –; o sigilo de suas comunicações; as informações claras, inclusive sobre a proteção de dados pessoais, cujo uso é restringido à finalidade informada; e o necessário consentimento prévio para coleta e armazenamento de dados pessoais e exclusão desses sob requerimento⁵⁵. O art. 11 assegura a aplicação da legislação brasileira para proteção dos dados quando ao menos uma das atividades de tratamento seja realizada no Brasil⁵⁶.

A breve análise supra demonstra que o sistema de proteção de dados brasileiro vem se formando há algumas décadas, e já dispõe, inclusive, de normas específicas. Não obstante, a necessidade de uma lei própria e exclusiva sobre o tema foi percebida e inserida de forma expressa nesse sistema, com o inciso III, do art. 3º do Marco Civil da Internet. Cabe, pois, na seção seguinte, analisar o papel dessa nova lei no sistema, em especial, dos princípios que elenca para nortear a proteção de dados no país.

2.A concretização dos princípios na Lei de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018

Ao analisar as fases de desenvolvimento da legislação sobre proteção de dados no mundo, Danilo Doneda observou que regras de caráter predominantemente procedimental, inscritas no *Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data System*, de 1973, foram repetidas em importantes instrumentos internacionais de proteção de dados, como nas Diretivas para Proteção da Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais (1980) e na Convenção de Estrasburgo (1981), que estiveram na base da formação do sistema europeu de proteção de dados. Essa repetição acabou favorecendo a consolidação de princípios comuns às normas de proteção de dados⁵⁷.

No Brasil, muito embora já houvesse disciplina sobre a proteção de dados, conforme tratado em tópico anterior, sua setorização e pulverização em leis e decretos esparsos, por certo, obstaculiza a visualização de um sistema⁵⁸. A edição da Lei 13.709/2018, significa, nesse contexto, uma orientação para organização formal desse sistema, a partir da cristalização e reprodução de muitos desses dispositivos esparsos, inclusive com *status* principiológico em alguns casos. Confira-se, nesse sentido, o rol de princípios do art. 6º da lei:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
- II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
- III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
- IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais;
- V – qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
- VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
- IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

À guisa de exemplo, recorde-se que a necessidade de prévia informação sobre a abertura do cadastro estava contida no Código de Defesa do Consumidor, e foi repetida na Lei do Cadastro Positivo e no Marco Civil da Internet. De forma semelhante, o livre acesso às informações já estava abrigado na Lei de Arquivos Públicos, de 1991, e foi repetido nas legislações subsequentes⁵⁹.

Também a limitação da coleta de informações àquelas estritamente necessárias, ou princípio da necessidade, já estava previsto no inciso I do § 3º do art. 3º da Lei 12.414/2011; tal como a qualidade dos dados e a transparência encontram eco no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 5º da Lei 12.414/2011 e no art. 7º, VIII, da Lei 12.965/2015. O primado da responsabilização acompanhou a disciplina legal da proteção dos dados por toda a legislação pertinente, embora tenha adquirido um viés preventivo pela redação do inciso X anteriormente reproduzido.

Não obstante, além do papel estrutural que a LGPD representa no chamado “sistema brasileiro de proteção de dados”, é interessante que os princípios indicados encontrem graus de concretude na própria lei. Essa é, pois, a última e mais importante tarefa a que se dedica este estudo.

O princípio da finalidade exige que seja respeitada a correlação entre o tratamento dos dados e a finalidade informada. Esse princípio guarda estreita ligação com os princípios da adequação e da necessidade⁶⁰. Sua realização pressupõe que haja prévia informação e consentimento daquele que fornece os seus dados. Nesse aspecto, merecem menção: o art. 7º, I⁶¹; o art. 7º, § 3º⁶²; o art. 8º, em especial, o § 4º⁶³; o art. 9º, § 2º⁶⁴; e o art. 10⁶⁵.

O princípio da necessidade, por sua vez, está estampado no § 1º do art. 10⁶⁶, no art. 16⁶⁷ e no art. 18, VI⁶⁸, os quais restringem os dados coletados ao estritamente necessário para cumprimento da finalidade informada, assim como estabelecem a eliminação dos dados mediante requisição do titular ou quando cessado o tratamento, ou seja, quando eles deixam de ser necessários.

O livre acesso está expresso no *caput* do art. 9º⁶⁹, mas está implícito nos arts. 18⁷⁰, 19⁷¹ e 20⁷². Todos esses dispositivos tratam de formas de requisição e acesso do titular às informações que lhe digam respeito, assim como as prerrogativas de solicitar a correção de equívocos ou revisão de decisões subsidiadas em procedimentos exclusivamente automatizados sobre seus dados. Relembre-se que essa última previsão já estava contida no art. 5º, VI, da Lei 12.414/2011.

O princípio da qualidade dos dados exige que os dados sejam objetivos, exatos e atualizados. Esse princípio se relaciona, em grande medida, com os princípios da transparência e do livre acesso, na medida em que esses asseguram o conhecimento e os meios de correção de informações equivocadas. Considera-se, porém, que a essência desse princípio está no inciso III do art. 18⁷³.

Talvez um dos princípios mais presentes ao longo da LGPD seja a transparência. Ela transparece no art. 9º⁷⁴, no art. 10, § 2º⁷⁵; no art. 18, I, II, VII e VIII⁷⁶; e no art. 20⁷⁷. Isso porque ela não está adstrita ao momento, por exemplo, da coleta de informações, mas a todo o processo de tratamento de dados.

Os princípios da segurança, da prevenção e da responsabilidade, ou prestação de contas, também são bastante próximos. Isso porque o primeiro visa a evitar situações ilícitas, ao passo que o segundo pretende evitar o dano à pessoa por causa do tratamento inadequado dos dados pessoais. Não obstante, o ilícito e o dano são conceitos clássicos da responsabilidade civil. Com efeito, não é espantoso que a concretização desses princípios na lei ocorra, muitas vezes, por um mesmo dispositivo.

Ainda assim, e com algum esforço, é possível separar aqueles que guardam maior identidade com um ou outro desses princípios. Da segurança, mais se aproximam os arts. 33⁷⁸, 46⁷⁹, 47⁸⁰ e 48⁸¹, justamente por envolver medidas ligadas à prevenção do ilícito. Ao princípio da prevenção, ajustam-se os arts. 32⁸², 49⁸³ e 50⁸⁴. Por fim, relacionam-se ao princípio da responsabilidade nos termos delineados na LGPD o art. 10, § 3º⁸⁵; o art. 31⁸⁶; o art. 32⁸⁷; o art. 42⁸⁸; o art. 44⁸⁹; e, finalmente, o art. 45⁹⁰.

A não discriminação é um princípio que há tempos já tinha conquistado espaço nas legislações internacionais⁹¹, com a identificação e o tratamento diferenciado da categoria dos dados sensíveis. Esses são identificados como os dados que contêm informações que podem levar à discriminação da pessoa, como origem étnica, religião, orientação sexual e posição política⁹².

A primeira lei brasileira a atentar-se para a proteção diferenciada de dados sensíveis foi a Lei 12.414/2011 – Lei do Cadastro Positivo. Não obstante, na LGPD, a proteção dos dados sensíveis ocupa a Seção II do Capítulo II, composta pelos arts. 11⁹³, 12⁹⁴ e 13⁹⁵, e também encontra amparo no §2º do art. 20⁹⁶.

Com efeito, percebe-se, no que se refere aos princípios, que a LGPD tem o relevante papel de consolidar os preceitos que já estavam em outras leis que, embora de modo não exclusivo, tratavam da proteção dos dados pessoais. É com base nessa observação que se reforça a importância formal da lei, em especial, do rol de princípios do art. 6º, para o sistema de proteção de dados no país.

Isso não significa que a lei não tenha implementado novas medidas interessantes, como é o caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou mesmo do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Não obstante, com a recente instituição dessas figuras, pela Lei n. 13.853/2019, não é possível aferir, com razoável substrato, a concretização dos princípios da LGPD. Registre-se, contudo, que a institucionalização da proteção de dados na figura de uma autoridade ou de um conselho foi o caminho trilhado pela maioria dos países, além de ser medida fundamental para o funcionamento de muitos mecanismos de proteção estabelecidos na própria lei.

Para a proposta dos esforços aqui empreendidos, por ora, a análise dos dispositivos legais que contêm esses mecanismos de proteção é suficiente para afirmar que os princípios elencados no art. 6º da LGPD transparecem ao longo da lei, conferindo-lhe um nível de coerência e organização que é sempre bem-vindo em uma legislação.

3. Conclusão

Muitos foram os motivos para almejar uma lei que cuidasse especificamente da proteção de dados no Brasil, mas considerar que os dados pessoais estiveram em situação de absoluta desproteção até sua edição é incorrer em equívoco. O ordenamento brasileiro se ocupou, por meio de leis de caráter público e privado, em assegurar algum nível de proteção à privacidade das pessoas.

Nesse sentido, as raízes da proteção de dados estão ligadas aos direitos da personalidade abrigados no Código Civil e perpassam pela Lei do *Habeas Data*, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei de Acesso à Informação, pela Lei do Cadastro Positivo e pelo Marco Civil da Internet. Com efeito, o Brasil foi desenvolvendo um sistema de proteção de dados, que também se refletiu na atuação de tribunais superiores e órgãos da administração pública.

Os princípios indicados na LGPD refletem a formação desse sistema, pois nenhum deles representa uma novidade em si, mas a cristalização de avanços que foram alcançados pelas leis anteriores, muitas vezes com viés mais pragmático do que principiológico. Nota-se, portanto, certa semelhança ao que ocorreu com a legislação de muitos países na década de 1980, consoante Danilo Doneda teve a oportunidade de observar. A lei, então, não representa mera inovação, mas a consolidação e a organização de um sistema em formação, o que já constitui razão suficiente para que seja festejada.

Outrossim, a LGPD não apenas repete esses princípios no rol do art. 6º, pois a presença deles pode ser identificada ao longo de seus dispositivos. Essa configuração fortalece a coerência da lei e a unidade do sistema, ao qual ela se integra formal e materialmente. Por fim, tal estrutura é também vantajosa sob a óptica de concretização dos princípios, que podem ser mais satisfatoriamente realizados a partir da aplicação dos dispositivos legais que impõem condutas e obrigações diretas aos envolvidos no tratamento dos dados pessoais.

Portanto, conclui-se que os princípios da LGPD são, em verdade, princípios do sistema brasileiro de proteção de dados e que a nova lei não supera às anteriores. Ao contrário, ela muito se inspira e, portanto, se integra às predecessoras, consagrando muito de seus preceitos e fortalecendo a ideia de um sistema legal de proteção de dados no Brasil.

Referências bibliográficas

CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, ano 4, out.-dez. 2017, p. 59-67.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

GEDIEL, José Antônio Peres; CORRÊA, Adriana Espínola. Proteção jurídica de dados pessoais: a intimidade sitiada entre o Estado e o mercado. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, n. 47, 2008, p. 141-153.

LEMONS, A. N. L. E. O Judiciário como Ator Regulador da Internet: seu papel no esquema de forças do Estado moderno. *Revista de Direito Setorial e Regulatório*, v. 4, n. 1, maio 2018, p. 169-188.

MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul.-set. 2011, p. 45-82.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Marco jurídico para a cidadania digital: uma análise do Projeto de Lei 5.276/2016. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, out.-dez. 2016, v. 9, ano 3, p. 35-48.

PAESANI, Liliana Minardi. *Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SARTORI, Ellen Carina Mattias. Privacidade e dados pessoais: a proteção contratual da personalidade do consumidor na internet. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 49-104.

TEIXEIRA, Tarcisio; PASSI, Renata Caprioli Zocatelli Queiroz. Privacidade na internet: a formação de bancos de dados e a transformação das pessoas em mercadorias. *Revista dos Tribunais*, v. 990, ano 107, abr. 2018, p. 109-125.

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Em direção a um novo 1984? A tutela da vida privada entre a invasão de privacidade e a privacidade renunciada. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 109, jan.-dez. 2014, p. 129-169.

VENTURA, Leonardo Henrique de Carvalho. Considerações sobre a nova lei geral de proteção de dados. *Revista Síntese: Direito Administrativo*, v. 13, n. 155, nov. 2018, p. 56-64.

VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, ano 5, jan.-mar. 2018, p. 71-99.

WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. *Harvard Law Review*, v. IV, n. 5, dec. 1890, p. 193-220.

1

.Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá.

2

.Mestranda em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP).

3

.Nas palavras de José Antônio Peres Gediel e Adriana Espínola Correia: "A realidade se apresenta menos terrível do que a descrita por Orwell ou Huxley. Menos terrível e mais sutil. Todavia, não menos preocupante." GEDIEL, José Antônio Peres; CORRÊA, Adriana Espínola. Proteção jurídica de dados pessoais: a intimidade sitiada entre o Estado e o mercado. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*, n. 47, 2008, p. 141-153.

4

.TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Em direção a um novo 1984? a tutela da vida privada entre a invasão de privacidade e a privacidade renunciada. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 109, jan.-dez. 2014, p. 129-169.

5

."[...] *The right of property in its widest sense, including all possession, including all rights and privileges, and hence embracing the right to an inviolate personality, affords alone that broad basis upon which the protection which the individual demands can be rested.*" WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. *Harvard Law Review*, v. IV, n. 5, dec. 1890. Disponível em: [http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm]. Acesso em: 07.01.2019.

6

."The principle which protects personal writings and all other personal productions, not against theft and physical appropriation, but against publication in any form, is in reality not the principle of private property, but that of an inviolate personality [...] We must therefore conclude that the rights, so protected, whatever their exact nature, are not rights arising from contract or from special trust, but are rights as against the world; and, as above stated, the principle which has been applied to protect these rights is in reality not the principle of private property, unless that word be used in an extended and unusual sense. The principle which protects personal writings and any other productions of the intellect or of the emotions, is the right to privacy, and the law has no new principle to formulate when it extends this protection to the personal appearance, sayings, acts, and to personal relation, domestic or otherwise." WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. *Harvard Law Review*, v. IV, n. 5, dec. 1890. Disponível em: [http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm]. Acesso em: 07.01.2019.

7

."A preocupação com efetiva dos juristas e dos tribunais com a privacidade surgiu a partir do século XIX, com as transformações da sociedade, de agrário-manufatureiras, para urbano-industriais. Nessa época, ampliavam-se os núcleos urbanos, ao mesmo tempo em que as pessoas tornavam-se em anônimas em meio à multidão. A imprensa escrita ampliava as tiragens diárias e a fotografia possibilitava a reprodução da imagem das pessoas. Dessa forma, vários dissabores relacionados à revelação de fatos da vida privada trouxeram incômodos pouco experimentados. Em 1819, Royer-Collard, na discussão da lei de imprensa francesa, afirmou que '*voilà donc la vie privée muree*'. Por exemplo, em 1854, Alexandre Dumas queria construir um monumento em homenagem a Balzac. Porém, a viúva se opôs a isso, alegando que cabia só a família o direito de construir uma tumba para seu parente. Em 1858, a atriz francesa Rachel foi retratada em seu leito de morte. Em 1886, o Presidente Cleveland passou a lua de mel sendo perseguido por jornalistas. Outro caso polêmico foi a divulgação não autorizada da fotografia de Otto von Bismarck, líder da unificação alemã, em seu leito de morte, em 1898." TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Em direção a um novo 1984? A tutela da vida privada entre a invasão de privacidade e a privacidade renunciada. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 109, jan.-dez. 2014, p. 129-169.

8

."A questão dos dados pessoais é uma das mais tormentosas quando se fala em internet, porquanto tudo na rede mundial de computadores são dados. Dados são coletados, armazenados e, principalmente, não são relacionados em mercadoria, por possuir valor econômico. [...] A disciplina dos dados pessoais, obviamente, não é novidade, pois não se relaciona apenas ao processamento de dados pessoais realizado na internet, englobando também cadastros de indivíduos com os mais diversos fins, como estatísticos, censos estatais e arquivos de consumo, automatizados ou não. Todavia, a problemática envolvendo a tutela de dados pessoais ganhou, e ganha diariamente, novas nuances com a internet e a onipresença da tecnologia." SARTORI, Ellen Carina Mattias. Privacidade e dados pessoais: a proteção contratual da personalidade do consumidor na internet. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 49-104. "O direito à proteção dos dados pessoais, que nasce com o direito de defesa perante o Estado, hoje tem alcance muito maior. Os milhares de registros eletrônicos gerados em catracas automatizadas, pedágios eletrônicos, câmeras, aparelhos de GPS, eletrodomésticos (a 'internet das coisas'), bem como inúmeras outras transações diariamente mediadas pela informática com técnicas avançadas de análise ('big data', por exemplo), deixam claro que o tratamento desarrazoado de dados pessoais pode fomentar a criação de pequenos Leviatãs, cujo potencial ofensivo à vida privada e à dignidade humana pode se igualar ou até mesmo exceder aquele representado pelo Estado." CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, ano 4, out.-dez. 2017, p. 59-67. Segundo o determinismo tecnológico e o pensamento desenvolvimentista, a infraestrutura resultaria em uma sociedade melhor e os imperativos do desenvolvimento tecnológico seriam determinantes para as transformações sociais. Critica-se a abordagem que coloca a tecnologia em primeiro lugar, como se só a tecnologia tivesse protagonismo. A Revolução não é somente tecnológica, mas institucional e política. A ideia de que a revolução da informação irá trazer a melhoria para o mundo sem pensar em uma revolução social que acompanhe é um pouco utópica." LEMOS, A. N. L. E. O Judiciário como Ator Regulador da Internet: seu papel no esquema de forças do Estado moderno. *Revista de Direito Setorial e Regulatório*, v. 4, n. 1, maio 2018, p. 169-188. "O desenvolvimento da informática colocou em crise o conceito de privacidade, e, a partir dos anos 80, passaram a ter um novo conceito de privacidade que corresponde ao direito que toda pessoa tem de dispor com exclusividade sobre as próprias informações mesmo quando disponíveis em bancos de dados." PAESANI, Liliana Minardi. *Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 34.

9

.Registre-se que em 1968 Alan Westin lançou o livro *Privacy and Freedom*, considerado um marco nesse ao tratar das violações da privacidade advindas do desenvolvimento tecnológico.

10

.Na Alemanha, o Land de Hesse editou uma lei em 1970; na Suécia, surgiu o Estatuto para bancos em 1973; e o Privacy Act de 1974 nos EUA. Essas leis são classificadas por Danilo Doneda como de primeira geração. O mesmo autor, ainda, dá notícias das legislações de “segunda geração”. São elas: *Informatique et Libertés*, de 1978, em França; a lei austríaca de proteção de dados e as Constituições de Espanha e Portugal; e de terceira geração, marcada pelas leis de Noruega e Finlândia, as emendas promovidas nas leis já existentes na Áustria e na Alemanha, além de decisão de 1983 do Tribunal Constitucional Alemão sobre a Lei de Recenseamento DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 207-211.

11

.“Hoje, não é o governo que ameaça a privacidade – é o comércio pela *Internet*. A *Web* transformou-se num mercado e, nesse processo, fez a privacidade passar de um direito a uma *commodity*” PAESANI, Líliliana Minardi. *Direito e internet*: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 36. E ainda: “Em razão de modificações sociais e da evolução tecnológica, a discussão sobre os danos causados pelo processamento e fluxo de dados na sociedade não se restringe mais à ameaça do enorme poder do Estado, expresso na figura do Big Brother de Orwell, mas abrange hoje também o setor privado, que utiliza massivamente dados pessoais para atingir os seus objetivos econômicos. Assim, a ameaça passa a ser representada pelos ‘pequenos irmãos’ (Büchner, 2006, p. 26), isto é, pelas milhares de empresas que coletam, armazenam e processam dados de seus clientes, consumidores finais ou não.” MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul.-set. 2011, p. 45-82. Para compreensão mais detalhada das características legislativas próprias de cada “fase” de proteção indica-se: DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 206-213.

12

.“O *right to privacy* fundamentado na quarta emenda é certamente o que mais se identifica com a proteção de dados pessoais, conforme se observa na casuística. Nela, uma noção de segredo e isolamento que parecia proteger os domínios da pessoa representada pelas suas propriedades foi transmutada em uma proteção de natureza pessoal, o que favorece a superposição de uma estrutura que compreende os dados pessoais.” DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 284. Lembre-se, ainda, de que Warren e Brandeis já tinham apontado essa questão no artigo referenciado nas notas 3 e 4.

13

.“O sistema de proteção de dados pessoais nos estados-membros da União Européia é unificado em torno de um núcleo composto basicamente da Diretiva 46/95/CE (relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) e, posteriormente, da Diretiva 2002/58/CE (relativa à privacidade e às comunicações eletrônicas); núcleo este que na sua transposição pode ser modificado em aspectos assessorios ou nos pontos nos quais os estados-membros estejam autorizados a fazê-lo. Este sistema representa um padrão mínimo de proteção em toda a área da União Européia, desenvolvido tendo como base a experiência de alguns países europeus que já haviam legislado sobre a matéria.” DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 227.

14

.O autor identifica dois modelos de legislação de proteção de dados, o europeu e o norte-americano, que são por ele assim descritos: “Cada um destes modelos se apresenta com roupagem diversa. O europeu, sistemático, estrutura-se em torno de uma Diretiva, uma disciplina ampla e detalhada que é transposta para a legislação interna de cada estado-membro. O modelo norte-americano, por outro lado, apresenta-se fracionado, com disposições legislativas e jurisprudenciais concorrentes em plena estrutura federativa, o que torna sua leitura em chave sistemática – e até mesmo em compensação geral de seu conjunto – uma tarefa difícil para os próprios juristas norte-americanos.” DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 224.

15

.“Como se viu, a Constituição Federal tutela a intimidade e a vida privada, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, X e XII) e assegura a concessão de *habeas data* (art. 5º, LXIX e LXXII). Além disso, o Código de Defesa do Consumidor contém regras específicas sobre bancos de dados e cadastros de consumidores, a Lei 12.414/2011 disciplina o cadastro positivo e a Lei 12.527/2011 regula o acesso a informações públicas. Há, portanto, alguma proteção aos dados pessoais. Mas a limitada aplicabilidade da lei consumerista, nesse aspecto, a jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal acerca do *habeas data* e o sigilo de dados, bem como a ausência de princípios claros a nortear a proteção de dados pessoais indicam que ainda há muito a fazer nos planos doutrinário, legislativo e jurisprudencial para que a proteção de dados pessoais se torne efetiva no Brasil. A edição de lei nacional de proteção de dados é essencial para suprir as omissões hoje existentes e garantir um nível adequado de proteção.” CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, ano 4, out.-dez. 2017, p. 66.

16

.“Certamente a pressão internacional, especialmente da GPDR, rígida legislação europeia que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 e que prevê que só será permitida a troca livre de informações e dados com outras nações que tenham legislação específica e equivalente, foi fundamental para que a versão brasileira fosse finalizada. Hoje 126 países possuem leis de proteção de dados pessoais, mas na América do Sul apenas Argentina e Uruguai possuem legislação nos moldes mínimos exigidos pela GPDR. O Brasil deve ser o próximo dessa lista.” VENTURA, Leonardo Henrique de Carvalho. Considerações sobre a nova lei geral de proteção de dados. *Revista Síntese: Direito Administrativo*, v. 13, n. 155, nov. 2018, p. 56-64.

17

.Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: [...] III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei. (BRASIL, 2014).

18

.“É evidente que um quadro regulatório completo exige o diálogo com as normas que regem as atividades do setor de telecomunicações, de comunicação social e de tecnologias da informação. Qualquer quadro normativo que não produza diálogo com esses segmentos da vida social será incompleto.” VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, ano 5, jan.-mar. 2018, p. 71-99.

19

“Sunstein (1990) propõe, ainda, complementando as ideias apresentadas acima, que haja uma interpretação das regras regulatórias que seja guiada por princípios, os quais devem ser utilizados para uma leitura geral das regras. Eles não devem ser considerados como elementos negativos para a discricionariedade das decisões administrativas, tão pouco mitigadores da legitimidade dos gestores.” LEMOS, A. N. L. E. O Judiciário como Ator Regulador da Internet: seu papel no esquema de forças do Estado moderno. *Revista de Direito Setorial e Regulatório*, v. 4, n. 1, maio 2018, p. 169-188. “Não podemos esquecer que há complexos desafios impostos pela sociedade da informação, para os quais se faz necessária a regulamentação pela via legislativa. Sem isso, pode-se comprometer tanto a segurança jurídica das atividades empresariais que envolvam o processamento de dados, como a tutela da personalidade e dos dados pessoais dos indivíduos. Nesse sentido, cumpre estabelecer, por meio da edição de uma lei geral de proteção de dados pessoais, uma arquitetura regulatória, capaz de fazer emergir o tema da proteção de dados pessoais como um verdadeiro setor de políticas públicas, composto por instrumentos estatutários, sancionatórios, bem como por um órgão administrativo, responsável pela implementação e aplicação da legislação.” MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul.-set. 2011, p. 45/81.

20

“Na presente análise, ciente de que isso não esgota outras perspectivas de apreciação necessárias, pretendemos chamar atenção não só para a insuficiência, mas também a conformidade da regulação jurídica no que concerne à lógica do mercado e da sociedade de controle. Em outras palavras, o modelo de regulação jurídica não só não impede o aprofundamento dos mecanismos de controle que caracterizam a sociedade contemporânea, como também os viabilizam e legitimam. A combinação da regra da autonomia privada com a exceção justificada pelo interesse público, sobretudo na área de segurança e saúde públicas (com hipóteses cada vez mais vagas e amplas), faz convergir a lógica das razões de Estado e a lógica de mercado.” GEDIEL, José Antônio Peres; CORRÊA, Adriana Espinola. Proteção jurídica de dados pessoais: a intimidade sitiada entre o Estado e o mercado. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, n. 47, 2008, p. 141-153.

21

“Nos países europeus, a preocupação com o equilíbrio entre a proteção da pessoa e os interesses da coletividade e do Estado levou à opção por uma regulação detalhada, na qual foram consagrados, ao lado do consentimento para coleta, alguns princípios que informam o tratamento de dados, constantes de forma exemplar na Diretiva Europeia n. 95/46/CE, que podem ser assim esquematizados: a) princípio da transparência: toda pessoa tem direito à informação por parte do responsável pelo tratamento de dados que lhe digam respeito, inclusive no que tange ao modo, à finalidade, período de conservação etc.; isso implica, também, o direito ao acesso aos próprios dados e ao resultado do tratamento; b) princípio da finalidade: os dados devem ser utilizados para a finalidade especificamente designada no momento da recolha; a finalidade, por óbvio, deve ser legítima e estar em conformidade com o ordenamento jurídico; c) princípio da qualidade dos dados: c.1. princípio da legalidade e lealdade (observância da lei e do princípio da boa-fé); c.2. princípio da adequação, pertinência e proporcionalidade em função da finalidade de cada tratamento; c.3. princípio da retidão e atualização dos dados, que assegura ao titular o direito de retificação, apagamento ou bloqueio de seus dados”. GEDIEL, José Antônio Peres; CORRÊA, Adriana Espinola. Proteção jurídica de dados pessoais: a intimidade sitiada entre o Estado e o mercado. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, n. 47, 2008, p. 141-153.

22

“Destarte, embora no Brasil não existe uma lei geral sobre a proteção de dados pessoais, há diversos diplomas legais que procuram regular a matéria. A regulamentação brasileira pode ainda não ser a ideal, mas já é possível falar em proteção legal de dados pessoais através da interpretação sistemática dessas normas, com a finalidade de construir um sistema de proteção de dados que proteja efetivamente os direitos dos cidadãos, mais especificamente os usuários da internet.” SARTORI, Ellen Carina Mattias. Privacidade e dados pessoais: a proteção contratual da personalidade do consumidor na internet. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 49-104. “No Brasil, a primeira fonte, ou origem, da proteção de dados pessoais está relacionada às informações pessoais armazenadas nos sistemas de registro estatal e ao direito dos cidadãos de conhecerem quais de seus dados estão arquivados junto ao Estado, bem como a exatidão deles. Portanto, a proteção de dados pessoais no Brasil remonta à Lei Federal 8.159/1991, legislação mais antiga, ainda em vigor, sobre arquivos. A segunda fonte de proteção de dados pessoais é uma evolução do direito à privacidade e dos direitos civis de personalidade com base em leituras constitucionais. Da projeção dos direitos de personalidade – previstos no Código Civil de 1916 (Lei Federal 3.071/1916) e, depois, no Código Civil de 2002 (Lei Federal 10.406/2002) – constrói-se uma frágil proteção de dados pessoais.” VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, ano 5, jan.-mar. 2018, p. 71-99.

23

Tarcisio Teixeira e Renata Passi mencionam o art. 57 da Resolução 272/2001-ANATEL Regulamento do Serviço de Comunicação e Multimídia; arts. 52 e 56, V, da Resolução 614/2013 e art. 3º, V, da Resolução 632/2014. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. TEIXEIRA, Tarcisio; PASSI, Renata Capriolli Zocatelli Queiroz. Privacidade na internet: a formação de bancos de dados e a transformação das pessoas em mercadorias. *Revista dos Tribunais*, v. 990, ano 107, abr. 2018, p. 109-125.

24

Art. 7º Conceder-se-á *habeas data*: I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. (BRASIL, 1997)

25

Art. 19. Os processos de *habeas data* terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto *habeas corpus* e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. (BRASIL, 1997)

26

RHD 22/DF, Pleno, j. 19.09.1991, m. v., rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Ministro Celso de Mello, DJ 01.09.1995.

27

STJ, REsp 22.337-9/RS, 4ª T., j. 13.02.1995, v. u., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 20.03.1995.

28

STJ, REsp 1.168.547/RJ, 4ª T., j. 11.05.2010, v. u., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.02.2011.

29

.STJ, REsp 306.570/SP, 2ª T., j. 18.10.2001, v. u., rel. Min. Eliana Calmon, *DJ* 18.02.2002.

30

.STJ, REsp 1.419.697/RS, 2ª S., j. 12.11.2014, v. u., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJ* 17.11.2014.

31

“O centro do debate brasileiro estava dirigido às informações públicas. Tal panorama somente foi alterado com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/1990). Todavia, com a expansão do uso de dados pessoais por empresas privadas, as prescrições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor se mostraram insuficientes para lidar com o mundo contemporâneo, no qual o processamento maciço de dados apresenta (ou representa/institui) um risco real e evidente aos cidadãos.” VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, ano 5, jan.-mar. 2018, p. 71-99.

32

.Art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. (BRASIL, 1991)

33

.Art. 6º Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. (BRASIL, 1991)

34

.Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. § 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. § 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período. § 3º O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção. (BRASIL, 1991)

35

“A base de um sistema de proteção de dados pessoais está, portanto, inicialmente desenhada na Lei de Acesso à Informação, ainda que esta esteja relacionada com um contexto diverso: a transparência nas ações estatais e a definição clara do sigilo que pode ser imposto aos documentos públicos, com base na razão do Estado.” VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, ano 5, jan.-mar. 2018, p. 71-99.

36

.Art. 31. [...] § 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; [...] (BRASIL, 2011)

37

.Art. 31. [...] § 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

[...] II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. (BRASIL, 2011)

38

.Art. 31. [...] § 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias: I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; III – ao cumprimento de ordem judicial; IV – à defesa de direitos humanos; ou V – à proteção do interesse público e geral preponderante. § 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. (BRASIL, 2011)

39

.Art. 31. [...] § 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. (BRASIL, 2011)

40

“Fundamental é perceber que tal tutela visa à proteção da pessoa e de sua personalidade e não dos dados *per se*.” MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Marco jurídico para a cidadania digital: uma análise do Projeto de Lei 5.276/2016. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 35-48.

41

“A primeira lei, entretanto, que tratou da privacidade e da proteção de dados pessoais de forma contemporânea e com o fim de lidar com novas tecnologias de processamento de dados foi o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que será analisado na sequência. Na sequência, o Código Civil de 2002, determinou em seu art. 21, que a vida privada da pessoa natural é um direito da personalidade. A partir de então, advieram outros diplomas legais que contemplam a proteção à privacidade e de dados pessoais, como a Lei do cadastro positivo (Lei 12. 414/2011), a lei do acesso à informação pública (Lei 12.525/2011), o Decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (Dec. 6.523/2008), o Decreto que regula o cadastro único para programas sociais do Governo Federal (Dec. 6.135/2007), o Decreto do Censo Anual da Educação (Dec. 6.425/2008), entre outros. No âmbito da regulamentação da

internet, podem ser ressaltadas três normas de grande importância: a Lei 'Carolina Dieckmann' (Lei 12.737/2012), que inseriu no Código Penal o 'crime de invasão de dispositivo informático'; o Dec. 7.962/2013, que dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico; e o Marco Civil da internet (Lei 12.965/2014)." (sic) SARTORI, Ellen Carina Mattias. Privacidade e dados pessoais: a proteção contratual da personalidade do consumidor na internet. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out-dez. 2016, p. 49-104.

42

.Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. (BRASIL, 2002)

43

.Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (BRASIL, 2002)

44

.Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. § 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. § 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. § 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. § 6º Todas as informações de que trata o *caput* deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. (BRASIL, 1990)

45

."Da leitura do dispositivo (art. 43 do CDC) depreende-se que o Código autoriza o funcionamento dos bancos de dados e cadastros de consumidores, desde que atendidos determinados preceitos para a proteção da privacidade dos consumidores, quais sejam: (a) possibilidade de acessar todas as informações existentes sobre o consumidor (direito de acesso); (b) os dados arquivados devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão (princípio da qualidade dos dados); (c) necessidade de comunicação da abertura de cadastro ou registro de dados pessoais de consumo (princípio da transparência); (d) obrigação de banco de dados de corrigir os dados de forma imediata (direito de retificação e cancelamento); e (e) limite temporal para o armazenamento de dados pessoais (princípio do esquecimento). Como se pode perceber, esse artigo, inspirado nas normas americanas do *National Consumer Act* e do *Fair Credit Reporting Act*, está em consonância com importantes princípios internacionais de proteção de dados pessoais." MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul.-set. 2011, p. 45-81.

46

.O PL 3.514/2015 teve origem no PLS 281/2012, de autoria do Senador José Sarney PMDB/AP e atualmente está na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O seu teor pode ser consultado em: [www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D89C4075A7213370D943E25F33D5904C.proposicoesWebExterno2?codteor=1408274&filename=PL+3514/2015]. Acesso em: 22.01.2019.

47

.Consta no item 4 da exposição de motivos da MP 518/2010: "Ao disciplinar a formação do histórico de crédito, esta medida provisória estabeleceu regras claras sobre as garantias e os direitos dos cidadãos em relação às suas informações pessoais, de modo a permitir a adequada proteção da privacidade do cidadão e possibilitar o tratamento de dados pessoais sob um patamar de licitude e boa-fé. Os dados pessoais merecem uma tutela importante pelo ordenamento jurídico, pois eles representam a própria pessoa e o seu tratamento influencia diretamente a sua vida, modelando e vinculando a sua privacidade e também as suas oportunidades, escolhas e possibilidades. A sua utilização, portanto, deve ter como fundamento a autodeterminação de cada pessoa em relação à utilização de suas próprias informações, permitindo que o cidadão possa escolher livremente a sua entrada no cadastro, bem como o seu cancelamento."

48

.Art. 3º Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado. (BRASIL, 2011)

49

.Art. 5º São direitos do cadastrado: I – obter o cancelamento do cadastro quando solicitado; II – acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes no banco de dados, inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta para informar as informações de adimplemento; III – solicitar impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 7 (sete) dias, sua correção ou cancelamento e comunicação aos bancos de dados com os quais ele compartilhou a informação. (BRASIL, 2011)

50

.Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado. (BRASIL, 2011)

51

."Além disso, ela delimita a finalidade pela qual os dados podem ser coletados e usados (arts. 2º, I, 5º, VII, e 7º, da Lei 12.414/2011), ao determinar que as informações armazenadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para a 'realização de análise de risco de crédito do cadastrado' ou para 'subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente'. Nesse sentido, resta clara a vedação desses dados para *marketing* direto ou qualquer outra atividade não mencionada na lei. [...] É de se destacar também que a referida lei consolida a evolução de um conceito de autodeterminação informativa no nosso ordenamento, ao estabelecer mecanismos de controle do indivíduo sobre os seus dados, atribuindo a ele o poder de decidir se tem interesse ou não em formar esse histórico e de decidir quando deseja

cancelá-lo. É o que se depreende dos seguintes dispositivos (art. 4º, art. 5º, art. 9º) que erigem o princípio do consentimento à pedra de toque do sistema do cadastro positivo.” MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul.-set. 2011, p. 45/81.

52

.Art. 5º São direitos do cadastrado: [...] VI – solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados. (BRASIL, 2011)

53

.Art. 3º [...] § 3º Ficam proibidas as anotações de: I – informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor; e II – informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. (BRASIL, 2011)

54

.Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. (BRASIL, 2014).

55

.Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; IV – não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização; V – manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; VI – informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; XI – publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; XII – acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e XIII – aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. (BRASIL, 2014)

56

.Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. (BRASIL, 2014)

57

.O autor identifica como princípios comuns originados desse processo: i) o princípio da publicidade; ii) o princípio da exatidão; iii) o princípio da finalidade; iv) o princípio do livre acesso; e v) o princípio da segurança física e lógica. DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 214-217.

58

.”No Brasil, além da Constituição Federal, já tínhamos diversas legislações especiais que tratavam do assunto em áreas específicas, setorizadas, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei do Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, entre outros. Apesar desse arcabouço, há vários anos se discutia no Brasil um marco legal na proteção de dados pessoais, capaz de englobar todas as atividades relacionadas, tendo em vista a importância e a relevância de seu objeto, que tem amplo reflexo inclusive nos direitos constitucionais do cidadão.” VENTURA, Leonardo Henrique de Carvalho. Considerações sobre a nova lei geral de proteção de dados. *Revista Síntese: Direito Administrativo*, v. 13, n. 155, nov.-2018, p. 56-64.

59

.Art. 6º da Lei 12.527/2011; art. 43 *caput* da Lei 8.078/1990; e art. 5º, II, da Lei 12.414/2011.

60

.”Um princípio fundamental que todas as atividades de processamento de dados devem seguir é o princípio da finalidade, que indica a correlação necessária que deve existir entre o uso dos dados pessoais e a finalidade comunicada aos interessados quando da coleta dos dados. Esse princípio é essencial para se limitar o acesso de terceiros ao banco de dados. De forma semelhante, ele também serve como parâmetro para julgar se determinado uso dos dados pessoais é adequado e razoável, de acordo com a finalidade informada no primeiro momento ao interessado (Doneda, 2006, p. 216). Por fim, esse princípio exige que o responsável pelo tratamento de dados estabeleça de forma expressa e limitada a finalidade do tratamento de dados, sob pena de se considerar ilegítimo o tratamento realizado com base em finalidades amplas ou genéricas (Rossangel, 2003, p. 140)”. MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 20, n. 79, jul./set. 2011, p. 45/81.

61

.Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; [...] (BRASIL, 2018)

62

.Art. 7º [...] § 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. (BRASIL, 2018)

63

.Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei. § 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. (BRASIL, 2018)

64

.Art. 9º [...] § 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações. (BRASIL, 2018)

65

.Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: I – apoio e promoção de atividades do controlador; e II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei. (BRASIL, 2018)

66

.Art. 10 [...] § 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. (BRASIL, 2018)

67

.Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades: I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. (BRASIL, 2018)

68

.Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: [...] VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; [...] (BRASIL, 2018)

69

.Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: I – finalidade específica do tratamento; II – forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial; III – identificação do controlador; IV – informações de contato do controlador; V – informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade; VI – responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e VII – direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei. (BRASIL, 2018)

70

.Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I – confirmação da existência de tratamento; II – acesso aos dados; III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; V – portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX – revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. (BRASIL, 2018)

71

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular: I – em formato simplificado, imediatamente; ou II – por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular. (BRASIL, 2018)

72

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. (BRASIL, 2018)

73

.Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: [...] III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; [...] (BRASIL, 2018)

74

.Ver nota 71.

75

.Art. 10. [...] § 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. (BRASIL, 2018)

76

.Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I – confirmação da existência de tratamento; II – acesso aos dados; [...] VII – informação das entidades

públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; [...] (BRASIL, 2018)

77

.Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. (BRASIL, 2019)

78

.Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: I – para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei; II – quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de: a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; b) cláusulas-padrão contratuais; c) normas corporativas globais; d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos; III – quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; IV – quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; V – quando a autoridade nacional autorizar a transferência; VI – quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional; VII – quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do *caput* do art. 23 desta Lei; VIII – quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou IX – quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei. (BRASIL, 2018)

79

.Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. (BRASIL, 2018)

80

.Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. (BRASIL, 2018)

81

.Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. (BRASIL, 2018)

82

.Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público. (BRASIL, 2018)

83

.Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares. (BRASIL, 2018)

84

.Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. (BRASIL, 2018)

85

.Art. 10. [...] § 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. (BRASIL, 2018)

86

.Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. (BRASIL, 2018)

87

.Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público. (BRASIL, 2018)

88

.Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2018)

89

.Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo pelo qual é realizado; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. (BRASIL, 2018)

90

.Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. (BRASIL, 2018)

91

."O Direito europeu, na esteira da orientação do Conselho da Europa e, em especial, da referida Diretiva, confere especial proteção a determinados dados que denotam maior suscetibilidade e potencialidade discriminatória, por revelarem informações sobre a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, a vida sexual e os dados de saúde, inclusive genéticos." GEDIEL, José Antônio Peres; CORRÊA, Adriana Espínola. Proteção jurídica de dados pessoais: a intimidade sitiada entre o Estado e o mercado. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, n. 47, 2008, p. 141-153. "O estabelecimento de um regime especial para os dados sensíveis está presente na legislação da maioria dos países europeus e na Diretiva Europeia 95/46/CE e continuou a ser regulado por meio do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu (art. 9º) [...] Uma análise das normas internacionais mencionadas e do dispositivo proposta pelo PL 5.276, é possível inferir que os países (Suécia, França, Dinamarca, Noruega e Luxemburgo) estabeleceram nas suas legislações uma lista exemplificativa de dados de caráter especial ou sensível, com o objetivo de lhes garantir uma proteção mais adequada. Embora as listas variem de país para país, há várias categorias que se repetem, como os dados relativos à origem racial, vida sexual e convicções religiosas e políticas. Desse modo, para os fins de sistematização dogmática, pode-se afirmar que a categoria dos dados sensíveis está relacionada à percepção de que o armazenamento, processamento e circulação de alguns tipos de dados podem se constituir em um risco maior à personalidade individual, especialmente, se utilizados com intuito discriminatório. Os dados referentes à raça, opção sexual, saúde e religião, são exemplos desse tipo." MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Marco jurídico para a cidadania digital: uma análise do Projeto de Lei 5.276/2016. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 35-48.

92

."Quando se fala em proteção de dados pessoais deve ser trazida à baila a questão dos dados sensíveis, que são aqueles caracteres pessoais que revelam a origem racial, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou outras, bem como os relativos à saúde, à vida sexual, às condenações penais, etc. [...] A distinção dessa categoria de dados, segundo Doneda, é fruto de uma observação pragmática de diferença que a divulgação deste tipo de informação merece em relação as demais, pois revelam a presença de outros valores dignos de tutela além da privacidade, como a igualdade material. A diferenciação é realizada tendo em vista que determinados dados possibilitariam uma utilização ainda mais discreta da informação pessoal, sendo devida a sua proteção não só em consagração ao direito à privacidade, mas também para proteger a dignidade da pessoa humana e os direitos à liberdade e à igualdade." SARTORI, Ellen Carina Mattias. Privacidade e dados pessoais: a proteção contratual da personalidade do consumidor na internet. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, ano 3, out.-dez. 2016, p. 49-104,.

93

.Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I – quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; II – sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. (BRASIL, 2018)

94

.Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. (BRASIL, 2018)

95

.Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. (BRASIL, 2018)

96

"§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais". (BRASIL, 2018)

Capítulo 3. A proteção de dados pessoais na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Ricardo Villas Bôas Cueva¹

1. Introdução

Discute-se, neste artigo, a transformação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à proteção de dados pessoais, desde o reconhecimento, na década de 1990, de um novo sentido de privacidade que a tutela da autodeterminação informativa passou a lhe emprestar – na Europa, sobretudo, mas, também, entre nós –, até a edição da Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPD.

Parte-se da análise da evolução do conceito de privacidade, que inicialmente era relacionado à ideia de exclusão de terceiros, para a atual acepção do termo como a possibilidade de cada indivíduo determinar as informações sobre si que merecem ser protegidas. Prossegue-se com o exame dos julgados do STJ que interpretaram o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e sua incidência sobre os cadastros negativos de crédito. Em seguida, dirige-se o foco para os cadastros positivos objeto da Lei 12.414/2011, a qual serve de importante fundamento para as teses aprovadas nos recursos repetitivos que cuidaram dos sistemas de avaliação de risco de crédito, ou *credit scoring*, que têm em seu núcleo a preocupação de proteger adequadamente os dados pessoais, a fim de evitar discriminações injustas e indevidas.

Por fim, estuda-se a jurisprudência a respeito da remoção de dados pessoais da internet, antes e depois do Marco Civil da Internet, bem como a emergência, em um único caso, de discussão acerca da possibilidade de se reconhecer, entre nós, a despeito da ausência de norma legal específica, a existência de um direito ao esquecimento, no sentido de um direito à desindexação de conteúdos da internet, ao modo daquele positivado no Regulamento Geral de Proteção de Dados, editado pela União Europeia em 2016.

A propósito, em 2013, o STJ julgou dois casos, com resultados diametralmente opostos, nos quais se discutia se a divulgação televisiva de matérias jornalísticas sobre crimes de grande repercussão, ocorridos há muito tempo, poderia comprometer o direito ao esquecimento dos interessados. Nessa acepção, o direito ao esquecimento não se confunde com o direito à desindexação ou ao apagamento de dados pessoais. Por isso, tais casos não foram incluídos no presente texto.

2. Do conceito tradicional de privacidade à proteção de dados pessoais

O direito à privacidade foi, primeiramente, definido em clássico artigo publicado em 1890, por Samuel Warren e Louis Brandeis, no qual se identificou, a partir de precedentes da *common law*, o direito a ser deixado só (*right to be let alone*), tanto mais relevante quando se consideravam as crescentes ameaças à personalidade humana decorrentes da massificação da mídia e do abuso da imagem e de informações pessoais.² Tal direito foi integrado paulatinamente à maior parte dos ordenamentos jurídicos nacionais e reconhecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 12).

A partir da década de 1970, a rápida evolução da informática e as crescentes ameaças à intimidade e à vida privada conduzem a normas de proteção de dados pessoais de primeira geração, como a lei de dados da Suécia (1973) e a lei federal de proteção de dados da Alemanha (1977). Nos EUA, foi editado, em 1970, o *Fair Credit Reporting Act* e, em 1974, o *Privacy Act*. Em 1976, Portugal foi o primeiro país a prever em sua constituição o direito à proteção de dados pessoais (art. 35). Em 1983, a Corte Constitucional da República Federal da Alemanha, em julgamento de reclamação acerca da inconstitucionalidade da lei do recenseamento (*Volkszählungsgesetz*), reconheceu a existência de um direito fundamental à autodeterminação informativa a partir dos direitos fundamentais à dignidade humana e ao livre desenvolvimento da personalidade.

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000, definiu, em seu art. 8º, que “todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito”. Antes disso, a tutela dos dados pessoais no âmbito europeu foi consolidada com a Diretiva 95/46, revogada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, publicado em 04 de maio de 2016, para aplicação a partir de 25 de maio de 2018, que unifica o direito europeu quanto à matéria, aplicando-se diretamente a todos os Estados-membros. Entre várias inovações, o regulamento impõe multas que podem chegar a 4% do faturamento das empresas ou a 20 milhões de euros e introduz o dever de *accountability*, a realização de análises de impacto sobre a privacidade e a notificação obrigatória às autoridades de proteção de dados em caso de vazamento. O diploma define, ainda, novos direitos, como a portabilidade de dados, o direito ao esquecimento e o direito de se opor à criação de perfil informacional.

Também são relevantes as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que definem como princípios básicos da proteção de dados pessoais: a) o princípio da limitação da coleta; b) o princípio da qualidade dos dados; c) o princípio da finalidade; d) o princípio da limitação do uso; e) o princípio da segurança; f) o princípio da transparência; g) o princípio da participação individual, que confere ao indivíduo o direito de ser informado a respeito da existência de dados a seu respeito, bem como de contestá-los perante o controlador do banco de dados e, sendo tal pretensão acolhida, eliminá-los, retificá-los, completá-los ou emendá-los; e h) o princípio da responsabilidade do controlador do banco de dados pelo respeito aos princípios precedentes.³

Para Canotilho, o direito ao conhecimento dos dados pessoais informatizados se desdobra em vários direitos:

(a) o direito de acesso, ou seja, o direito de conhecer os dados constantes de registros informáticos, quaisquer que eles sejam (públicos ou privados); (b) o direito ao conhecimento da identidade dos responsáveis, bem como o direito aos esclarecimentos sobre a finalidade dos dados; (c) o direito de contestação, ou seja, direito à rectificação dos dados e sobre identidade e endereço do responsável; (d) o direito de actualização (cujo escopo fundamental é a correcção do conteúdo dos dados em caso de desactualização); (e) finalmente, o direito à eliminação dos dados cujo registro é interdito.⁴

Entre nós, a Constituição Federal de 1988 tutela a intimidade e a vida privada, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, X e XII) e assegura a concessão de *habeas data* (art. 5º, LXIX e LXXII). Além disso, o Código de Defesa do Consumidor contém regras específicas a respeito de bancos de dados e cadastros de consumidores, a Lei 12.414/2011 disciplina o cadastro positivo e a Lei 12.527/2011 regula o acesso a informações públicas. Há, portanto, alguma proteção aos dados pessoais, mas em grau insuficiente. A ausência de legislação específica sobre o tema, contudo, não tem impedido a consolidação de parâmetros estritos para a remoção da internet de conteúdo ofensivo inserido por terceiros.

3. Um novo conceito de privacidade reconhecido na análise dos cadastros negativos e positivos de crédito

Muito antes de se cogitar, no Brasil, a adoção de lei específica destinada à proteção de dados pessoais, já se fazia referência em julgados do Superior Tribunal de Justiça à emergência de um novo conceito de privacidade, a merecer tutela distinta daquela tradicionalmente reservada à privacidade como exclusão de terceiros. Já em 1995, o Ministro Ruy Rosado, no REsp 22.337-8/RS, fazia alusão ao direito fundamental à autodeterminação informativa, tal como reconhecido na Alemanha, no contexto de uma crescente vulnerabilidade do indivíduo ante a coleta e o armazenamento de informações que invadem sua intimidade sem o seu consentimento e sem dispor de meios eficazes para ter acesso a essa informação, retificá-la ou cancelá-la.

É bem verdade que os primeiros acórdãos a mencionar esse novo conceito de privacidade diziam respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos cadastros negativos de crédito. Foram as primeiras oportunidades em que o STJ se debruçou sobre o tema. Como se sabe, o art. 43 do CDC garante ao interessado o direito de acesso a seus registros, bem como o direito de corrigir a informação neles existentes, além de conter regra de prescrição. Assim é que o Ministro Ruy Rosado, no julgamento do mencionado recurso especial, associou expressamente a tutela consumerista do direito de acesso e retificação de registros (art. 43 do CDC) à matriz constitucional da proteção da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da Constituição Federal), indicando o avanço significativo de nosso ordenamento rumo a uma proteção adequada a essa outra dimensão da privacidade.

Em 2001, no julgamento do REsp 306.570/SP, Relatora a Ministra Eliana Calmon, reconheceu-se que o “contribuinte ou o titular da conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais”. No REsp 1.168.547/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 2010, assentou-

se a existência de um novo conceito de privacidade, bem como a necessidade de consentimento do interessado para a divulgação de informação pessoal a seu respeito, pois, com o desenvolvimento da tecnologia, a tutela da privacidade passa a ter por ponto de referência o consentimento do interessado para “dispor com exclusividade sobre as próprias informações, nelas incluindo o direito à imagem”.

Posteriormente, o STJ passa a examinar questões atinentes ao cadastro positivo de crédito, instituído pela Lei 12.414/2011, que ampliou o alcance das normas referentes aos bancos de dados e aos cadastros de consumidores, visto que, além do direito de acesso e do direito à correção da informação, já previstos no CDC, incluiu, expressamente, entre os direitos do cadastrado: a) o direito de obter o cancelamento do cadastro; b) o direito de conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de risco; c) o direito de ser informado previamente sobre o armazenamento, a identidade do gestor do banco de dados, o objetivo do tratamento dos dados pessoais e os destinatários dos dados em caso de compartilhamento; d) o direito de solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados e) o direito de ter os seus dados pessoais utilizados de acordo com a finalidade para a qual foram coletados.

Vale destacar, a propósito, o REsp 1.348.532/SP, rel. o Ministro Salomão, de cuja ementa se extrai que

3. É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras, assim como com entidades mantenedoras de cadastros positivos e negativos de consumidores, sem que seja dada opção de discordar daquele compartilhamento. 4. A cláusula posta em contrato de serviço de cartão de crédito que impõe a anuência com o compartilhamento de dados pessoais do consumidor é abusiva por deixar de atender a dois princípios importantes da relação de consumo: transparência e confiança. A impossibilidade de contratação do serviço de cartão de crédito, sem a opção de negar o compartilhamento dos dados do consumidor, revela exposição que o torna indiscutivelmente vulnerável, de maneira impossível de ser mensurada e projetada. De fato, a partir da exposição de seus dados financeiros, abre-se possibilidade para intromissões diversas na vida do consumidor. Conhecem-se seus hábitos, monitoram-se a maneira de viver e a forma de efetuar despesas. Por isso, a imprescindibilidade da autorização real e espontânea quanto à exposição.⁵

4. Os sistemas de avaliação de risco de crédito (*credit score*)

O grande desafio, no que tange ao cadastro positivo e aos direitos dos cadastrados, apareceu quando o STJ foi levado a analisar a enorme gama de processos nos quais se discutia os sistemas de avaliação de risco de crédito (*escore de crédito* ou *credit score*), tema que originou dois recursos repetitivos e uma súmula.

No primeiro dos recursos repetitivos sobre a questão, REsp 1.457.199/RS⁶, foram aprovadas as seguintes teses:

1) O sistema *credit scoring* é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito) 2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo

art. 7º, I, da Lei 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema *credit scoring*, configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.

Na ocasião, o relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de maneira inovadora – já que anteriormente à edição do novo Código de Processo Civil não havia previsão legal a respeito –, realizou a primeira audiência pública no STJ, o que muito contribuiu para o exame de todos os pontos de vista envolvidos, assim como para o aprofundamento da discussão acerca das lacunas existentes em nosso ordenamento no que tange à proteção de dados pessoais, em contraste com o que já se via em outros países.

Em meu voto-vogal, enfatizei a importância daquele julgamento para consolidar, no Brasil, a partir dos poucos dispositivos existentes em nosso ordenamento, especialmente no CDC e na lei do cadastro positivo, alguma proteção à privacidade dos consumidores, a fim de evitar que sejam injustamente discriminados no acesso ao crédito. Ademais, com lastro na doutrina de Laura Mendes⁷, que citei extensamente, procurei demonstrar que os sistemas de avaliação de crédito têm por finalidade identificar os melhores consumidores, ou seja, aqueles que apresentam menor risco, e que isso pressupõe, por outro lado, a identificação daqueles que poderiam ser considerados os piores consumidores, os quais, por essa razão, supostamente teriam negado seu acesso a bens e serviços. A ausência de uma adequada proteção dos dados pessoais pode, assim, causar graves danos aos consumidores. Não é à toa que, em regra, os sistemas automatizados de decisão somente são admitidos se existirem medidas que assegurem que o titular dos dados possa apresentar sua defesa e se a decisão se relacionar à celebração ou à execução de um contrato.

Os sistemas de avaliação de risco de crédito, muitas vezes, funcionam como verdadeiras “caixas pretas”, sem transparência quanto aos parâmetros e critérios utilizados para chegar à nota que informará a decisão de conceder ou não o crédito. Para que o sistema se legitime perante as autoridades de proteção de dados, é fundamental que se baseie em critério matemático-estatístico reconhecido e auditável. Além disso, o titular dos dados deve ter acesso não apenas à nota que lhe é atribuída, mas, também, ao próprio algoritmo utilizado, ou seja, à lógica do sistema e aos fatores que influem positiva e negativamente para que se alcance tal ou qual valor.

Não é admissível, por exemplo, que o exercício de direitos pelo titular dos dados seja usado contra ele, como na situação em que empresa de cadastro de crédito categorizava como fator negativo o pedido do consumidor de acesso aos próprios dados, o que levou à mudança da legislação alemã para impedir abusos

dessa natureza. O uso de geolocalização pode, também, conduzir a discriminações injustas, se o endereço, isoladamente, gerar suposição quanto à solvabilidade do consumidor.

Em arremate, concluí que o voto condutor

contempla, a partir dos esparsos dispositivos normativos encontrados em nosso ordenamento sobre a matéria, alguns cuidados que, na União Europeia, por exemplo, já vigoram quando se trata de *credit score*, ao proteger a privacidade e evitar que se cometam abusos e garantir, ao mesmo tempo, que os atingidos possam ter acesso aos critérios utilizados na fórmula matemática. Por outro lado, fica também claro que não há falar em consentimento prévio do consumidor, pois o sistema de avaliação de crédito não se confunde com um banco de dados, mas se vale de informações contidas em vários bancos de dados.

A seu turno, no REsp 1.304.736/RS, rel. o Ministro Salomão, julgado em 2016, também de acordo com o rito dos repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

Em relação ao sistema *credit scoring*, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema *Scoring*.

A discussão acerca do *escore* de crédito, que foi objeto dos recursos repetitivos acima discutidos, julgados pela Segunda Seção do STJ, resultou na Súmula 550:

A utilização de *escore* de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.

5. Remoção de conteúdos da internet e o direito ao apagamento de dados pessoais

No Brasil, o chamado Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) consagrou a reserva de jurisdição para a remoção da rede mundial de computadores de conteúdo ilícito, ou seja, somente o Poder Judiciário pode determinar a retirada do conteúdo infringente. O controle da ilicitude do conteúdo bem como a ordem para seu bloqueio ou exclusão ocorrem no âmbito do processo, por provocação do interessado, e *a posteriori*.

O Marco Civil da Internet estabelece, como regra geral, que o provedor de conexão à internet não pode ser civilmente responsabilizado por conteúdo gerado por terceiros (art. 18). Para garantir a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações na internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, em descumprimento a ordem judicial específica, deixe de tornar indisponível o conteúdo apontado como ofensivo (art. 19). Em se tratando de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, o provedor pode ser responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade se deixar de atender a notificação que contenha indicação precisa do conteúdo a ser removido (art. 21).

Quanto à possibilidade de remoção do conteúdo da internet, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido que os provedores de pesquisa não respondem pelo conteúdo inserido por terceiros e não podem ser obrigados a exercer controle prévio das buscas efetuadas por usuários. No Recurso Especial 1.407.271/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou assentado que

não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

Mais recentemente, no REsp 1.342.640/SP, também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07.02.2017, a Terceira Turma assentou que

(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso.

Na sessão do dia 08.05.2018, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.660.168/RJ, concluiu, por maioria, vencidos os Ministros Nancy Andrighi e Ricardo Cueva, que o direito ao esquecimento, conquanto não previsto no ordenamento, deve ser o fundamento para a remoção de conteúdo considerado ofensivo.

Veja-se excerto da ementa:

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhes atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes.

4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas, em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção de dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca.

6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionam sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido.⁸

Tratava-se de situação em que, ao ser realizada uma busca pelo nome da autora da ação na internet, as primeiras referências dos resultados sempre aludiam a antigo concurso público sobre o qual foram levantadas suspeitas, não confirmadas em investigações subsequentes. Embora as informações não fossem ofensivas ou inverídicas, prevaleceu o entendimento de que deveriam ser removidas dos mecanismos de busca. Interpretação, portanto, divergente daquela que se vinha emprestando ao Marco Civil da Internet, no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão, e em afronta ao § 1º do art. 19 do Marco Civil da Internet, pois referido dispositivo de lei dispõe expressamente que a ordem judicial de remoção de conteúdo dessa espécie (gerado por terceiros) padece de nulidade quando desacompanhada da “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.

Ingo Sarlet e Arthur Ferreira Neto criticaram a referida decisão, ponderando que

o fato de a autora da demanda ser pessoa exercendo cargo público relevante (promotora de Justiça) e a natureza do fato investigado pelo CNJ (possível fraude em concurso público para a Magistratura) indicam – ao contrário do que referido na posição majoritária – que diferentemente da situação de Mario Costeja (Caso Google Europeu) – o interesse público no acesso à informação a respeito dos fatos tem um peso significativo que deveria ter sido considerado.⁹

Ademais, o que restou reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Google Spain SL, Google inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González* foi que, à luz da Diretiva 95/46/CE, os provedores de busca na internet praticam atividade que se qualifica como tratamento de dados e, portanto, são responsáveis por esse tratamento no âmbito de um Estado-membro, sempre que criem, nesse território, uma filial ou sucursal que promova venda de espaços publicitários, incumbindo-lhes, em consequência de suprimir os respectivos *links* que remetiam ao interessado, ainda que a divulgação da informação fosse em si lícita. Ou seja, mesmo na hipótese em comento, o que se determinou foi a remoção de conteúdo específico. Não há no referido precedente ordem para que o provedor de pesquisa promovesse a criação de filtros ou mecanismos capazes de realizar o controle prévio de conteúdo virtual.

Seja como for, é importante destacar, para o propósito deste artigo, que a Lei 12.965/2014 disciplina o uso da internet no Brasil de modo genérico e não contempla especificamente as redes sociais. A remoção de conteúdos ilícitos é tratada de modo abrangente, sem uma definição expressa do que seja conteúdo infringente e sem a imposição de prazos para sua remoção. O legislador parece ter-se fiado em amplíssima discricionariedade judicial para assegurar a observância dos princípios e das garantias associados ao uso da internet, entre eles, a garantia das liberdades de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Recentemente, a Terceira Turma do STJ reafirmou a jurisprudência assentada sobre o tema, no sentido de que, anteriormente ao Marco Civil da Internet, bastava a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo para que o provedor se tornasse responsável por sua remoção em prazo razoável. O novo diploma introduz a

reserva de jurisdição, ou seja, a responsabilidade do provedor pela retirada do conteúdo infringente tem início a partir da notificação judicial, que deve determinar claramente o conteúdo a ser removido, mediante a indicação específica da URL, sob pena de nulidade.¹⁰

A reforçar o caráter excepcional da decisão da Terceira Turma proferida no REsp 1.660.168/RJ, convém lembrar, ainda, que a Segunda Seção do STJ, antes mesmo do Marco Civil da Internet, já havia fixado que

a filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de modo que não se pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle sobre o resultado das buscas. Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde estiver inserido. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação assegurado pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.¹¹

Anteriormente, ao julgar caso emblemático que envolvia conhecida apresentadora de televisão que pretendia retirar da rede mundial de computadores qualquer menção à sua alcunha, idêntica, aliás, à de renomado jogador de tênis, a Terceira Turma já havia decidido que a filtragem prévia das buscas é inadmissível por se confundir com atividade censória.¹²

Vale notar que essas duas últimas decisões são anteriores ao Marco Civil da Internet. Após sua entrada em vigor, passou-se a reconhecer que

a atividade dos provedores de busca, por si própria, pode causar prejuízos a direitos de personalidade, em razão da capacidade de limitar ou induzir o acesso a determinados conteúdos. Como medida de urgência, é possível determinar que os provedores de busca retirem determinados conteúdos expressamente indicados pelos localizadores únicos (URLs) dos resultados das buscas efetuadas pelos usuários.

Assentou-se, porém, que, “mesmo em tutela de urgência, os provedores de busca não podem ser obrigados a executar monitoramento prévio das informações que constam nos resultados das pesquisas”.

É que a única exceção à reserva de jurisdição prevista no Marco Civil da Internet está contida em seu art. 21, que diz respeito a vídeos ou a outros materiais que contenham cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado.¹³

6. Considerações finais

Como se viu, há um significativo escólio jurisprudencial que alude ao novo conceito de privacidade e à proteção de dados pessoais, que tem origem na discussão acerca do alcance do art. 43 do CDC, no tocante aos cadastros negativos de crédito, e também, posteriormente, aos cadastros positivos de crédito.

Além disso, o STJ tem se debruçado há vários anos – antes mesmo da edição do chamado Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que não trata especificamente da proteção de dados pessoais, embora guarde inequívoca relação com esse novo campo do direito – sobre a remoção de conteúdos inseridos por terceiros e considerados infringentes pelo Poder Judiciário da rede mundial de computadores.

Pode-se dizer, assim, que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a remoção da internet de conteúdo infringente deve obedecer à reserva de jurisdição, mediante a indicação precisa de sua localização na rede mundial de computadores, vedada a imposição aos provedores de um monitoramento que implique cerceamento à liberdade de informação e de expressão, com exceção das situações que envolvam cenas de nudez ou de sexo, mas, ainda assim, também somente a partir da indicação precisa de URLs. A exigência de que os envolvidos indiquem precisamente os conteúdos a serem removidos tem dupla função: impedir, por um lado, que os provedores exerçam atividade de censura e, por outro, permitir a controlabilidade das decisões de exclusão de conteúdo.

Em princípio, ao menos até fevereiro de 2019, não se pode dizer que o REsp 1.660.168/RJ tenha sido um divisor de águas, ainda que tenha acolhido, por maioria, pedido de desindexação e que, em seus votos, tenha sido amplamente discutido o direito ao esquecimento.

Referências bibliográficas

CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa anotada*. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. 1.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

SARLET, Ingo Wolfgang; FERREIRA NETO, Arthur M. *O direito ao “esquecimento” na sociedade da informação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. *Harvard Law Review*, v. IV, n. 5, dezembro de 1890.

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Disponível em: [www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf]. Acesso em: 06.03.2019.

.Ministro do Superior Tribunal de Justiça, é mestre e doutor em Direito.

2

.WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. *Harvard Law Review*, v. IV, n. 5, dezembro de 1890. p. 193 e ss.

3

.*OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Disponível em: [www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf]. Acesso em: 06.03.2019.

4

.CANOTILHO, J. J. Gomes. *Constituição da República Portuguesa anotada*. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. 1. p. 550 e ss.

5

.REsp 1.348.532/SP, rel. Min Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.10.2017, *DJe* 30.11.2017, especialmente, os itens 3 a 6 da ementa.

6

.REsp 1.457.199/RS, rel. Min., Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª S., j. 12.11.2014, *DJe* 17.12.2014.

7

.MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um direito fundamental, p. 112 e ss.

8

.REsp 1.660.168/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 08.05.2018, *DJe* 05.06.2018.

9

.SARLET, Ingo Wolfgang; FERREIRA NETO, Arthur M. *O direito ao “esquecimento” na sociedade da informação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019. p. 181.

10

.REsp 1.694.405/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 19.06.2018, *DJe* 29.06.2018.

11

.Rcl 5.072/AC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 11.12.2013, *DJe* 04.06.2014.

12

.REsp 1.316.921/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 26.06.2012, *DJe* 29.06.2012.

13

.REsp 1.679.465/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 13.03.2018, *DJe* 19.03.2018.

Capítulo 4. Objetivos e alcance da Lei Geral de Proteção de Dados

Ana Frazão¹

1. Introdução

O propósito do presente artigo é explorar quais são os objetivos e o efetivo alcance da LGPD, para o fim de mostrar que, longe de ser um instrumento de proteção apenas da privacidade, pelo menos no sentido tradicional a ela atribuído, a lei pretende proteger diversas situações existenciais da mais alta importância.

No intuito de descortinar os amplos e ambiciosos objetivos da LGPD, o artigo buscará cumprir essa missão sem se furtar a refletir sobre em que medida a lei será realmente capaz para implementá-los, considerando as drásticas mudanças que isso implicará não apenas para o cenário econômico, mas também para o cenário social e político.

É por essa razão que o ponto de partida do presente artigo é a reflexão sobre as perspectivas de eficácia da LGPD diante do papel que lhe cabe nos tempos atuais e da necessária interação com a autorregulação ou correção, com a própria tecnologia e com a autodeterminação informativa dos cidadãos potencialmente traduzida no consentimento.

2. Os objetivos da LGPD: o que proteger e por que proteger?

2.1. Os direitos tutelados pela LGPD e a sua dimensão existencial

Os problemas que decorrem da exploração dos dados pessoais são muito mais extensos do que a mera violação da privacidade, especialmente se tal direito for compreendido sob a sua acepção clássica, ou seja, no sentido de intimidade e do direito de ser deixado só. Além da privacidade, há vários outros desdobramentos da personalidade que são colocados em risco pela economia movida a dados, como a própria individualidade e autonomia. Mais do que isso, não é exagero afirmar que a própria democracia também passa a estar sob ameaça².

Como afirma Frank Pasquale³, os controladores de dados criaram um sistema desenhado não para tratar os titulares de dados decentemente, mas sim para maximizar seus lucros ou colocar a inovação acima de qualquer outro valor. Nesse contexto, pode-se dizer o objetivo central da LGPD é resgatar a dignidade dos titulares de dados e seus direitos básicos relacionados à autodeterminação informativa.

Não é sem razão que a lei, logo em seus artigos iniciais, tem o cuidado de prever expressamente os seus propósitos e valores principais, nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I – o respeito à privacidade;

II – a autodeterminação informativa;

III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Logo depois, no art. 6º, a LGPD estabelece os seguintes princípios para o tratamento de dados no Brasil:

(i) *boa-fé objetiva*, mencionado logo no *caput*;

(ii) *princípio da finalidade*, descrito como a “realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades” (inciso I);

(iii) *princípio da adequação*, descrito como a “compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento” (inciso II);

(iv) *princípio do mínimo necessário*, descrito como a “limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados” (inciso III);

(v) *princípio do livre acesso*, descrito como a “garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais” (inciso IV);

(vi) *princípio da qualidade dos dados*, descrito como a “garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento” (inciso V);

(vii) *princípio da transparência*, descrito como a “garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial” (inciso VI);

(viii) *princípio da segurança*, que exige “utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão” (inciso VII);

(ix) *princípio da prevenção*, traduzido na “adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais” (inciso VIII);

(x) *princípio da não discriminação*, que consiste na “impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos” (inciso IX); e

(xi) *princípio da responsabilização e prestação de contas*, que exige “demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.” (inciso X)

Como se pode observar, além da privacidade e dos direitos dos consumidores, são mencionados expressamente, entre outros, a autodeterminação informativa, os direitos humanos, o livre-desenvolvimento da personalidade, a cidadania e a dignidade. Dessa maneira, fica claro que o objetivo da LGPD é o de conferir uma ampla proteção ao cidadão e às situações existenciais mais importantes que são afetadas pelo tratamento de dados, assim considerada

“toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, X).

Com efeito, a LGPD pretende regular todas as formas de tratamento de dados pessoais, que são definidos como quaisquer informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I), incluindo até mesmo aqueles considerados públicos ou tornados públicos pelos titulares. Estes últimos, apesar de estarem sujeitos a previsões diferenciadas, estão claramente sob a proteção da lei, que prevê, no art. 7º, § 3º, que

“O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização”. O art. 7º, § 4º, por sua vez, determina que “É dispensada a exigência do consentimento previsto no *caput* deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.”

Logo, seja em razão do amplo alcance da LGPD, seja em razão da sua preocupação com a tutela das situações existenciais dos titulares de dados, pode-se dizer que foi acolhida concepção convergente com a daqueles que, a exemplo de Rodotà⁴, sustentam que a proteção de dados consiste corresponde a verdadeiro direito fundamental autônomo, expressão da liberdade e da dignidade humana, que está intrinsecamente relacionada à impossibilidade de transformar os indivíduos em objeto de vigilância constante.

Veja-se que, sob essa perspectiva, a LGPD pode, igualmente, ser vista como um freio e um agente transformador das técnicas atualmente utilizadas pelo capitalismo de vigilância, a fim de conter a maciça extração de dados e as diversas aplicações e utilizações que a eles podem ser dadas sem a ciência ou o consentimento informado dos usuários⁵.

Tal aspecto é fundamental para a compreensão da LGPD, porque os valores e objetivos por ela reconhecidos representam um importante contraponto à tendência de monetização dos dados, considerando-os como *commodities* e objeto de livre-extração ou negociação. De forma contrária, os princípios da LGPD mostram que dados pessoais não são meros bens de cunho patrimonial, o que revela a insuficiência das soluções de mercado para qualquer disposição a respeito deles.

Daí o acerto da conclusão de Danilo Doneda,⁶ no sentido de que a adoção da solução de mercado para o problema dos dados não é adequada, diante da multiplicidade de situações e interesses a eles relacionadas, que não se limitam a vetores patrimoniais. Por essa razão, prossegue o autor, a disciplina do consentimento não deve ser tratada sob viés negocial, mas sim a partir do poder de autodeterminação e a consideração dos direitos fundamentais em questão.

Também contrária à concepção “proprietária” de dados pessoais, Laura Mendes⁷ adverte que tal visão poderia comprometer a igualdade, pois, provavelmente, apenas a parte mais rica da sociedade iria dele se beneficiar; a individualidade, já que as pessoas poderiam ter que moldar sua personalidade para produzir os dados considerados adequados; e a própria democracia.

Tais considerações não chegam ao ponto de impedir que os dados pessoais possam ser vistos como bens jurídicos, assim como não implicam negar que existem desdobramentos patrimoniais dos dados que podem ser objeto de negociação. O que a principiologia da LGPD impede é a redução dos dados pessoais ao aspecto meramente patrimonial, uma vez que priorizou claramente a sua dimensão existencial e impôs uma série de cuidados e restrições ao tratamento de dados, como fica muito claro ao se observar os princípios do art. 6º, que não podem ser afastados nem mesmo pelo consentimento do titular.

Ademais, as previsões da LGPD ainda dialogam com os princípios constitucionais e direitos fundamentais pertinentes, bem como com a proteção que tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor dispensam às situações existenciais dos usuários.

Daí por que renúncias e transações sobre os dados, ainda mais quando realizadas sem as informações necessárias e sem contrapartida minimamente razoável, não são válidas não apenas em razão das disposições específicas da LGPD, mas, também, à luz das disposições de outros diplomas legislativos, tais como o art. 11 do Código Civil.

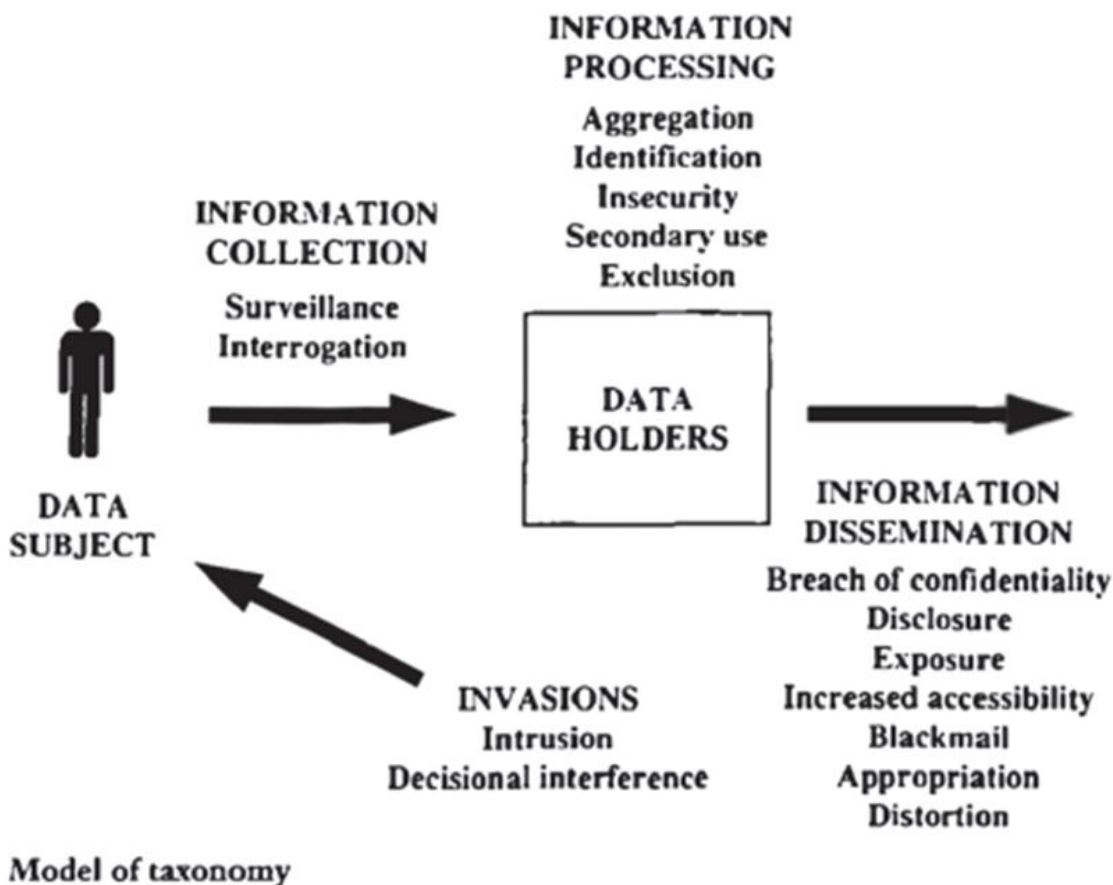
Afinal, o eixo valorativo da LGPD é a proteção da pessoa humana e de suas situações existenciais relevantes, o que deve ser levado em consideração para a interpretação de todas as suas demais disposições.

2.2. Uma nova compreensão da privacidade

A seção anterior procurou mostrar que a proteção dos dados pessoais pode ser vista hoje como um direito fundamental autônomo, até porque a privacidade não é a única referência axiológica do regime instituído pela LGPD. Não obstante, é inequívoco que a privacidade continua a ser importante referencial para o endereçamento do problema do tratamento dos dados pessoais, o que torna necessária a reflexão sobre o seu real sentido na atualidade.

A literatura atual sobre privacidade tem destacado, quase que de forma unânime, que a noção tradicional de privacidade, restrita à intimidade e ao direito de ser deixado só, não é mais compatível com a complexidade dos desafios inerentes à economia movida a dados e à vigilância. Daí a advertência de Rodotà, de que “o problema da circulação das informações pessoais, portanto, não pode ser solucionado somente a partir das noções correntes de privacidade”⁸ e que “privacidade não mais se confunde com o que é secreto”, motivo pelo qual “(...) pode-se dizer que hoje a sequência quantitativamente mais relevante é “pessoa-informação-circulação-controle”, e não mais apenas “pessoa-informação-sigilo”, em torno da qual foi construída a noção clássica de privacidade.”⁹

Tais observações convergem com as conclusões de Daniel Solove¹⁰, para quem não há nem mesmo um conceito essencial ou um denominador comum para a definição de privacidade. Daí defender uma abordagem mais pragmática e atenta às necessidades da nossa época, sustentando que o ponto focal de uma teoria da privacidade deveria ser os problemas que se quer que a lei enderece¹¹. Para isso, o autor propõe uma taxonomia em que a privacidade é segmentada em quatro grupos principais de atividades, cada qual com vários desdobramentos, como se observa pela representação gráfica criada pelo próprio autor¹²:



No primeiro grupo, que diz respeito à coleta de dados, encontram-se as preocupações com (i) a vigilância, que abarcam a observação, a escuta e o registro de atividades, bem como com (ii) a interrogação, que diz respeito às diversas formas de questionar as pessoas¹³.

O segundo grupo envolve o jeito que a informação é armazenada, manipulada e usada, o que abrange a (i) agregação, que é a combinação de várias partes de informações sobre uma pessoa, o que é capaz de revelar dados sobre elas muito além de qualquer expectativa que poderiam ter quando abriam mão de seus dados, (ii) a identificação, que é o processo de relacionar uma informação a indivíduos particulares, (iii) a insegurança, que diz respeito à falta de cuidado em proteger a informação de vazamentos e acessos impróprios, (iv) o uso secundário, que é a utilização da informação coletada para propósito distinto daquele pelo qual foi coletada com o consentimento do usuário e a (v) exclusão, que corresponde à falha em permitir que o titular saiba dos dados que outros têm a seu respeito e de participar do seu manejo e uso¹⁴.

No terceiro grupo, o da disseminação de informação, estão os casos de (i) quebra de confidencialidade, (ii) *disclosure*, que seria a revelação de informação verdadeira sobre uma pessoa que pode afetar sua reputação, (iii) exposição, que

corresponde aos casos de revelação de aspectos da intimidade, como nudez, (iv) *inn-eased accessibility*, que seria a ampliação da acessibilidade da informação, (v) *blackmail*, que seria a ameaça para desvelar informação pessoal, (vi) apropriação, que é o uso da identidade do titular dos dados para servir a outros propósitos e interesses, (vii) distorção, que seria a disseminação de informação falsa ou enganosa e (viii) disseminação, que diz respeito a ampliar ou transferir dados pessoais ou ameaçar fazê-lo¹⁵.

No quarto grupo, o da invasão, encontram-se os casos de (i) intrusão, que correspondem aos atos invasivos que perturbam a tranquilidade ou solidão e (ii) interferência decisional, que é a incursão nas decisões do titular dos dados sobre seus assuntos privados¹⁶. É interessante notar que *spams*, *junk mails* e mesmo *telemarketing* e outras situações similares são consideradas formas de intrusão, na medida em que sugam o tempo e a atenção das pessoas e interrompem suas atividades¹⁷.

A taxonomia de Daniel Solove é importante para se ter ideia da complexidade das discussões que se colocam hoje em dia em torno do que considera privacidade. Em vários aspectos, a questão transcende às noções tradicionais de privacidade e/ou exige a sua compreensão em conexão com outros direitos ou garantias fundamentais. Um exemplo claro é a questão da interferência decisional, que mostra claramente como a proteção da privacidade está ligada também à tutela da liberdade e à preservação da própria individualidade.

Por outro lado, é importante considerar, também, que, diante das preocupações com os efeitos discriminatórios das decisões algorítmicas, especialmente quando totalmente automatizadas e sem qualquer tipo de controle ou intervenção humana, as discussões sobre privacidade também passam a estar conectadas cada vez mais com a igualdade.

A própria definição de dados pessoais sensíveis, como mostra Rodotà¹⁸, está ligada muito mais à proteção da igualdade e da não discriminação do que propriamente à intimidade. Basta ver que a LGPD considera dado pessoal sensível qualquer dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II).

Tais discussões, ao serem integradas no contexto do capitalismo de vigilância, mostram que a discussão sobre a proteção de dados abrange igualmente o direito à transparência e à *accountability* no que diz respeito ao tratamento de dados, o que se reflete na necessidade de explicações e mesmo na adoção de padrões de justiça nos julgamentos algorítmicos.

No contexto dos riscos trazidos pelos julgamentos algorítmicos, marcados pela opacidade e falta de transparência, Frank Pasquale¹⁹ chega a mencionar a necessidade do resgate da nossa presunção de inocência. Aliás, o autor²⁰ é um dos que sustentam que a autoridade algorítmica deveria ser limitada apenas a ambientes nos quais pudesse promover justiça, honestidade, liberdade e racionalidade. Daí a importância da preocupação constante com a transparência, sem a qual não é possível discernir o uso justo do uso injusto da informação²¹. Mais do que isso, o fato de a ausência de transparência ser intencional compromete os próprios méritos das teorias que defendem ausência de regulação²².

Isso é especialmente importante no âmbito das decisões totalmente automatizadas, motivo pelo qual a LGPD, a exemplo do GDPR europeu, acolheu, em seu art. 20, o direito à explicação e revisão de decisões totalmente automatizadas por pessoa natural, como parte indispensável do conjunto de proteções que precisam ser destinadas aos titulares de dados²³. Infelizmente a redação do artigo foi modificada pela superveniente Lei 13.853/2019, que excluiu a referência à pessoa natural, o que certamente pode contribuir para a ineficácia prática da garantia.

Ademais, há, também, aspectos de proteção da cidadania e da democracia envolvidos na tutela dos dados pessoais, pois cada vez mais o conhecimento excessivo que alguns agentes possuem dos titulares de dados pode ser utilizado para todo tipo de manipulação, inclusive para efeitos políticos²⁴.

Com efeito, a partir de estudos empíricos feitos a partir das eleições presidenciais norte-americanas de 2016, Yochai Benkler, Robert Faris e Hal Roberts²⁵, embora reconheçam que não há evidências concretas de que a Cambridge Analytics ou mesmo o Facebook foram determinantes para os resultados das eleições norte-americanas de 2016, entendem que os *pequenos* efeitos documentados na trajetória do mercado de dados pessoais podem ter *significativos* efeitos no futuro próximo²⁶. O fato de tais efeitos serem extremamente difíceis de serem mensurados não os torna menos preocupantes, motivo pelo qual há necessidade de regulação e transparência sobre a propaganda política, assim como diversas medidas de prevenção²⁷.

Logo, a privacidade hoje, longe de se restringir à intimidade e ao direito de ser deixado só, ampliou seus domínios para abranger o controle sobre as informações que digam respeito ao sujeito, a autodeterminação informativa, o direito à não discriminação, a liberdade, a igualdade, o direito ao acesso e acompanhamento dos dados pessoais quando se tornam objeto de disponibilidade de outros, dentre outros.

Se fosse possível tentar representar uma linha evolutiva das discussões sobre privacidade, poder-se-ia afirmar que a ideia inicial vinculada à intimidade se expande para abarcar, em um primeiro momento, a autodeterminação informativa e, em um segundo momento, importantes direitos e garantias fundamentais, incluindo a dignidade e a cidadania:



É claro que a ampliação do direito à privacidade e a sua maior imbricação com outros direitos fundamentais não afasta, de forma alguma, a importância do sentido clássico de privacidade como intimidade. Tanto é assim que Daniel Solove²⁸ reitera que as pessoas continuam precisando de um “santuário”, onde estejam livres do controle da sociedade, possam deixar as máscaras e exercer suas verdadeiras identidades. No mesmo sentido, Shoshana Zuboff²⁹ defende o *right to sanctuary*, que seria aquele espaço de refúgio inviolável que hoje está sob ataque pelo capitalismo de vigilância.

Consequentemente, as discussões sobre os objetivos da proteção dos dados pessoais, longe de afastarem a conexão dessa tutela com a proteção da intimidade e do direito de ser deixado só, apenas ampliam a problemática e a tornam mais complexa, na medida em que a conectam com importantes direitos e garantias fundamentais e com a democracia.

2.3.A racionalidade econômica da proteção dos dados pessoais

Não obstante as preocupações com a privacidade e demais situações existenciais dos titulares de dados, o mercado de dados cresceu e se consolidou a partir da difusão da ideia de que seria eficiente e justo e, exatamente por isso, dispensaria qualquer tipo de regulação estatal.

Tal visão é alimentada por argumentos de que a regulação jurídica é desnecessária, pois os usuários já receberiam contrapartidas adequadas pelos seus dados, ou mesmo prejudicial à economia, partindo da premissa de que haveria um verdadeiro *trade-off* entre inovação e privacidade, de forma que a violação desta última seria o preço a pagar ou o mal necessário para o progresso tecnológico e os novos serviços que daí decorrem. Já se observa, nesse tipo de argumentação, forte viés utilitarista, a partir do qual se sustenta a possibilidade de que, em nome da inovação, seja possível o sacrifício de direitos fundamentais elementares.

Por outro lado, o excesso de otimismo das próprias pessoas em relação a muitos dos modelos de negócios da economia digital e os benefícios diretos que eles lhes proporcionam, aliado às próprias dificuldades de compreensão dos seus efetivos impactos, são, também, fatores que criam ônus adicionais para os reguladores que, premidos entre a assimetria informacional e os benefícios das inovações, muitas vezes, não sabem o que fazer para conter esse processo e proteger minimamente os cidadãos. É esse o cenário que possibilitou que vários desses negócios evoluíssem em um ambiente no qual o suposto vácuo regulatório foi convenientemente preenchido pela autorregulação criada pelos próprios agentes em seu próprio benefício.

Entretanto, tais argumentos não resistem a uma reflexão mais aprofundada. Em primeiro lugar, direitos fundamentais não podem estar sujeitos, exclusivamente, a juízos de custo-benefício, uma vez que são deontológicos e vinculantes. Em segundo lugar, não necessariamente existe o *trade-off* entre eficiência e privacidade, diante da multiplicidade de técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para movimentar a economia digital, mas preservando as situações existenciais dos titulares de dados. Em terceiro lugar, ainda que sempre houvesse o *trade-off*, seria preciso ponderar que a inovação não é um valor absoluto e que, exatamente por isso, não pode ser perseguida de forma irrestrita e à custa do sacrifício das situações existenciais mais elementares dos titulares de dados.

Daí por que as seções anteriores mostraram algumas das inúmeras razões que justificam a regulação jurídica com a finalidade de proteção dos dados pessoais, já que não se pode imaginar que o problema seja endereçado, exclusivamente, pelas soluções de mercado, ainda mais diante da vulnerabilidade dos titulares de dados e das limitações naturais que se projetam sobre a disposição de direitos que estão conectados a situações existenciais. Consequentemente, é indispensável que a heterorregulação, assim entendida a regulação pelo Estado, possa endereçar os problemas apontados, tal como é a razão de ser da própria LGPD.

Entretanto, cumpre ressaltar que a exigência da heterorregulação na questão da proteção dos dados pessoais também se justifica sob a racionalidade econômica, a partir da qual também é possível concluir no sentido da existência de diversos indícios e motivos pelos quais as soluções de mercado não são idôneas para, sozinhas, levarem a soluções minimamente adequadas.

Com efeito, muitos dos argumentos refratários à regulação jurídica estatal decorrem do fato de adotarem a premissa de que o mercado é a melhor forma para que os agentes econômicos, por meio das negociações privadas (contratos), enderecem o problema da incerteza e aloquem adequadamente os seus riscos.

Essa é uma das razões pelas quais Hayek³⁰, por exemplo, é contra a regulação jurídica dos mercados, uma vez que considera que a economia e a sociedade são ordens espontâneas, insuscetíveis de conhecimento, planejamento e

controlabilidade, na medida em que resultam da interação de diversos indivíduos que visam aos interesses próprios e que não detêm todas as informações.

Ocorre que, na atual fase do capitalismo de dados e de vigilância, a premissa da diluição do conhecimento – ou da inexistência de conhecimento absoluto por qualquer dos agentes – deixou de ser sustentável, pelo menos por parte daqueles que protagonizam os mercados de dados. Como bem descreve Frank Pasquale³¹, os dados pessoais dos cidadãos têm sido utilizados por governos e grandes *players* econômicos para a criação do *one way mirror*, possibilitando que tais agentes saibam tudo dos cidadãos, enquanto estes nada sabem dos primeiros. E tudo isso acontece por meio de um monitoramento e vigília constantes sobre cada passo da vida das pessoas, o que leva a um verdadeiro capitalismo de vigilância, cuja principal consequência é a constituição de uma sociedade também de vigilância³².

Ora, se os agentes econômicos, hoje, sabem tudo do consumidor, consequentemente, não mais trabalham com a perspectiva de incerteza ou mesmo de risco. Por essa razão, Frank Pasquale³³ afirma que a questão da distribuição do conhecimento pelo mercado, tão preconizada por Hayek, não pode ser utilizada apenas contra o Estado, mas precisa ser, também, utilizada contra qualquer agente que pretenda concentrar tal grau de conhecimento que acabe inviabilizando as trocas de mercado, fazendo com que estas percam o seu fundamento de administração recíproca de incertezas.

De forma semelhante, Shoshana Zuboff³⁴ também aborda a necessidade da regulação jurídica sob a racionalidade econômica, ao tratar do crescimento de um poder instrumental no que a autora chama de *Big Other*, expressão que busca traduzir uma vigilância pulverizada e não centralizada, como seria a do *Big Brother*. Para ela, o *Big Other* sinaliza a transformação do mercado em um projeto de total certeza, desviando o capitalismo da sua própria história, na medida em que requer liberdade ilimitada com conhecimento total por parte dos grandes agentes. Como tal abordagem implica no abandono de todas as reciprocidades que sempre justificaram o capitalismo, a autora refere-se a tal processo como um verdadeiro golpe vindo de cima (*coup from above*)³⁵.

Com efeito, Shoshana Zuboff³⁶ parte da premissa de que os fundamentos do capitalismo sempre foram os de que os mercados são intrinsecamente insuscetíveis de conhecimento e a de que a ignorância produzida pela falta de conhecimento requer um considerável espaço de liberdade para os atores econômicos. Para a autora³⁷, Planck, Meyer, Skinner, Hayek e mesmo Adam Smith inequivocamente uniram liberdade à ignorância.

Ocorre que, na atualidade, ainda segundo Shoshana Zuboff³⁸, o mercado não é mais invisível, pois a informação total caminha no sentido da certeza e da promessa de retornos garantidos, em razão do fato de que a oferta e a demanda em mercados comportamentais são traduzidas em detalhes infinitos. Logo, a sua conclusão é a de que o capitalismo de vigilância substitui mistério por certezas, previsões e modificações comportamentais, o que compromete a premissa clássica do mercado como algo intrinsecamente insuscetível de conhecimento³⁹.

Portanto, no contexto descrito, a regulação jurídica dos dados se apresenta como importante contraponto para, ao equacionar minimamente a total assimetria informacional existente, possibilitando que persistam as razões econômicas que justificam as próprias negociações de mercado.

Analizada a questão sob a perspectiva específica dos contratos, as conclusões se mantêm. Como igualmente mostra Shoshana Zuboff⁴⁰, as transações nos mercados digitais não são propriamente uma nova forma de contrato, mas sim um “não contrato”, já que, nos termos de Williamson, contratos existem exatamente para mitigar a inevitabilidade e a incerteza. Entretanto, os “novos contratos”, por se basearem na certeza, não precisam mais da confiança. Mais do que isso, tais contratos passam a ser processos de máquinas, em que a autoridade é suplantada pela técnica e sistemas impessoais de disciplina e controle produzem certos conhecimentos do comportamento humano que são independentes do consenso.

Consequentemente, o problema principal desse novo regime, como aponta a própria autora⁴¹, é que ele aniquila a liberdade promovida pela *rule of law*, assim como suplanta a necessidade de contratos, de governos e mesmo do dinamismo inerente à economia de mercado. Na verdade, o contrato, a confiança social e a *rule of law* são suplantados por recompensas e punições de uma nova forma de mão invisível.

Dessa maneira, também sob a racionalidade econômica, a necessidade da intervenção legislativa na questão da proteção dos dados justifica-se sob o prisma da garantia da liberdade e da autodeterminação, que são pressupostos econômicos da própria existência dos mercados.

Friedman, por exemplo, alicerçava a defesa dos livres-mercados na valorização da liberdade humana. Como teve oportunidade de lecionar em seu *Free to Choose*⁴², a liberdade econômica é um requisito essencial para a liberdade política. Daí por que a cooperação existente nos mercados, sem coerção ou autoridade central, teria a finalidade de reduzir a área sobre a qual o poder político é exercido. Acresce que, ao dispersar o poder, os mercados livres acabam sendo um contraponto à concentração de poder político, já que a combinação de poder econômico e poder político nas mesmas mãos é uma receita certa para a tirania.

As premissas de Friedman também estavam fortemente assentadas não apenas na observação empírica que supostamente corresponderia ao seu método de trabalho, mas, também, na avaliação valorativa do tipo de sociedade que ele considerava ideal: aquela em que os livres-mercados seriam um contraponto ao poder político e o consumidor seria soberano⁴³.

A peculiaridade da visão de Friedman fica clara, na medida em que sustenta que certo grau de desigualdade será desejável em qualquer sistema econômico funcional, sendo inevitável no sistema de livre-mercado, em que vence o agente econômico mais eficiente. O que importa ressaltar é que Friedman não descarta a possibilidade de o Estado intervir na economia para garantir a igualdade de oportunidades necessária para que se obtenha, de fato, uma situação de livre mercado que, segundo o autor, fatalmente redundaria em maior igualdade material⁴⁴.

Como se pode observar, é nítida, na obra de Friedman, a conexão entre livres-mercados, liberdade econômica e igualdade de oportunidades, bem como de diluição do poder político. Ocorre que o cenário atual desafia diretamente tais expectativas, pois é marcado por um constante entrelaçamento entre o poder político e o poder econômico e pela concentração da liberdade econômica nas mãos de poucos agentes, e não de todos.

Ainda é preciso lembrar da lição de Kahneman⁴⁵, quando afirma que não há, propriamente, divergência entre a Escola de Chicago e os economistas comportamentais na questão da necessidade de se proteger a liberdade econômica dos indivíduos; a divergência está presente em como assegurar tal objetivo:

Há então muita coisa em jogo no debate entre a escola de Chicago e os economistas comportamentais, que rejeitam a forma extrema do modelo de agente racional. Liberdade não é um valor contestado; todos os participantes no debate são a favor disso. Mas a vida é mais complexa para os economistas comportamentais do que para os adeptos ferrenhos da racionalidade humana. (...)

A decisão de proteger ou não os indivíduos contra seus erros apresenta desse modo um dilema para os economistas comportamentais. Os economistas da escola de Chicago não enfrentam esse problema, pois os agentes racionais não cometem enganos. Para os defensores dessa escola, a liberdade não apresenta custo algum.

Se há algo que a experiência vem mostrando é que a liberdade econômica apresenta custos e que as premissas idealizadas pela Escola de Chicago não são realizáveis em um cenário econômico cada vez mais concentrado e marcado pela presença de agentes com grande posição dominante, que sabem tudo dos usuários enquanto estes não sabem nada desses agentes. De fato, as modificações recentemente introduzidas pelo *Big Data* mostram como o poder econômico, hoje associado ao poder da informação, da comunicação e mesmo ao poder político, apresenta riscos e custos ainda maiores para a preservação da competição nos mercados e para assegurar a liberdade econômica de todos os agentes envolvidos.

Até mesmo Hayek, por ter consciência da necessidade de uma estrutura legal que dê respaldo à economia e em face de sua preocupação com os direitos individuais, mostrava-se favorável à intervenção do Estado na economia, desde que seja em favor da manutenção dos mercados e da livre-concorrência⁴⁶:

É importante não confundir a oposição a essa espécie de planejamento com uma dogmática atitude de laissez-faire. A doutrina liberal é a favor do emprego mais efetivo das forças da concorrência como um meio de coordenar os esforços humanos, e não de deixar as coisas como estão. Baseia-se na convicção de que, onde exista a concorrência efetiva, ela sempre se revelará a melhor maneira de orientar os esforços individuais. Essa doutrina não nega, mas até enfatiza que, para a concorrência funcionar de forma benéfica, será necessária a criação de uma estrutura legal cuidadosamente elaborada, e que nem as normas legais existentes, nem as do passado, estão isentas de falhas graves. (...) O bom uso da concorrência como princípio de organização social exclui certos tipos de intervenção coercitiva na vida econômica, *mas admite outros que às vezes podem auxiliar consideravelmente seu funcionamento, e mesmo exige determinadas formas de ação governamental.* (grifos nossos)

Logo, todos os pontos aqui mencionados justificam a necessidade da regulação jurídica sobre a questão dos dados pessoais, diante de caso evidente em que a heterorregulação é indispensável para viabilizar os pressupostos de existência do próprio mercado, mantendo a liberdade dos participantes e o cenário de pulverização do conhecimento que é essencial para que o contrato continue a ser instrumento de administração e alocação de riscos e incertezas.

3.O alcance da LGPD: como proteger?

3.1.A LGPD no contexto das alternativas de autorregulação ou correção

Esclarecida a importância da heterorregulação no que diz respeito à proteção de dados, cumpre advertir que a LGPD, assim como qualquer outra lei geral de tratamento de dados, obviamente endereça apenas o núcleo central do problema, sem prejuízo de que outras áreas ou leis – como o Direito do Consumidor, o Direito da Concorrência, o Direito Civil (especialmente na parte relativa aos direitos da personalidade), o Direito Eleitoral, o Marco Civil da Internet, as leis de cadastro positivo e negativo etc. – mantenham seus importantes papéis de especificar aspectos da tutela dos dados em suas respectivas searas.

Consequentemente, evidencia-se, desde logo, a importância do diálogo entre essas diversas fontes, a fim de se assegurar a unidade do sistema, bem como o reconhecimento de que a LGPD oferece eixo valorativo que facilitará a interpretação e a aplicação das demais legislações na problemática dos dados.

É importante ressaltar, também, que, embora a heterorregulação – aqui traduzida pela LGPD e todas as demais leis e atos normativos estatais que se destinam a regular o tratamento de dados no Brasil – seja fundamental para endereçar o problema do tratamento de dados pessoais, isso não quer dizer que ela, sozinha, seja suficiente para tal propósito. Projetam-se, aqui, como não poderia deixar de ser, todas as discussões sobre as deficiências da heterorregulação para a disciplina dos mercados, ainda mais quando esta é baseada no modelo de comando e controle, ou seja, alicerçada na previsão de comportamentos obrigatórios e sanções pelo seu descumprimento⁴⁷.

Consequentemente, é grande a importância da autorregulação e dos programas de *compliance*, reforçando o protagonismo dos agentes econômicos na tarefa de efetiva proteção dos dados pessoais. Não é sem razão que a LGPD tem seção específica sobre as chamadas “boas práticas e governança”, prevendo, o art. 50, que

Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Sob essa perspectiva, a relação entre heterorregulação e autorregulação é crucial para a efetividade da LGPD, pois, por mais atenta que possa ser a futura autoridade nacional responsável pela proteção de dados, inclusive no que diz

respeito à aplicação de sanções por todos aqueles que descumprirem as obrigações respectivas, ela pouco poderá fazer sem a adesão voluntária dos agentes econômicos ao cumprimento das suas regras.

Para entender a importância da autorregulação, é importante fazer referência à obra de Colin Bennet e Charles Raab⁴⁸, na qual se mostra, a partir da constatação da insuficiência da heterorregulação baseada no modelo comando e controle para a questão dos dados pessoais, que a autorregulação pode ter pelo menos quatro papéis: (i) evitar a legislação, (ii) antecipar a legislação, (iii) implementar a legislação e (iv) suplementar a legislação. Desses papéis, chamam a atenção os dois últimos, até diante do fato consumado relativo ao advento da LGPD.

No que diz respeito ao papel de implementar a legislação, é inequívoco que a importância da autorregulação decorre do fato de que, diante da complexidade do tema, a LGPD é uma lei fundamentalmente principiológica, baseada em princípios, cláusulas gerais, *standards* de comportamento e conceitos abertos que, mais do que densificação, precisam ser adaptados à situação específica de cada agente de tratamento e dos riscos dos respectivos tratamentos.

Já no que diz respeito ao papel de suplementar a legislação, tem-se aqui importante papel da autorregulação, uma vez que a LGPD pretende ser a base normativa para o tratamento de dados, sem prejuízo de que os agentes de tratamento, por iniciativa própria, possam ir além dos padrões de cuidado e segurança previstos pela lei.

Todavia, para que possa atingir esses importantes objetivos e, ainda, ser fator de estímulo a uma cultura de respeito de dados, reforçando o viés preventivo da LGPD, é importante considerar que a autorregulação não ocorre no vazio. Daí a importância da autoridade nacional para suprir e regulamentar matérias e criar incentivos para o cumprimento das obrigações legais e até mesmo o seu aperfeiçoamento. Um exemplo disso é o que pretende o art. 51 da LGPD, segundo o qual “a autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais”.

É importante lembrar, também, que, diante da necessária interação entre heterorregulação e autorregulação, Diane Rowland, Uta Kohl e Andrew Charlesworth⁴⁹ mostram que o problema da regulação, especialmente no ambiente digital, não é, na prática, uma escolha rígida entre o modelo “comando-controle” e a autorregulação, até porque os dois não são polos extremos que se excluem mutuamente. Daí a discussão atual sobre um terceiro gênero – o da corregulação – que combinaria diferentes categorias de práticas regulatórias e exigiria o envolvimento central dos agentes privados e dos governos, a fim de propiciar muitas vantagens da autorregulação sem as mesmas desvantagens.

Apesar das controvérsias a respeito das eventuais distinções entre autorregulação e corregulação, o que importa é que, na seara do *compliance* de dados, a atuação complementar entre a iniciativa privada e o Estado seja intensa, consistente e frutífera. Daí por que a autorregulação e a corregulação têm papel central para dar concretude à lei e, se for o caso, até ir além dela.

3.2.A LGPD no contexto das alternativas de regulação pela tecnologia

As seções anteriores trataram da importância da heterorregulação e da autorregulação para a tutela dos dados pessoais. Entretanto, também é importante levar em consideração a crescente importância da regulação pela própria tecnologia, especialmente nos mercados digitais.

Nesse sentido, Lawrence Lessig⁵⁰ já destaca, há bastante tempo, a importância da tecnologia como importante regulador de comportamentos, de forma que, ao lado do controle hierárquico (lei), do controle baseado na competição (mercado) e do controle baseado na comunidade (normas sociais), haveria, também, o controle baseado no *design* ou na arquitetura (tecnologia). É importante advertir que, ao assim propugnar, o autor não adere a uma concepção estritamente determinista, até por entender que a arquitetura da rede não é definida apenas por questões técnicas, mas sobretudo políticas e valorativas. Dessa maneira, assim como o desenvolvimento de uma tecnologia por um engenheiro pode ser capturado por atores externos, incluindo os próprios reguladores, também podemos construir, arquitetar ou codificar o ciberespaço para proteger valores que consideramos fundamentais.

Reidenberg⁵¹, por sua vez, popularizou o conceito de *lex informatica* para explorar os vários caminhos por meio dos quais a tecnologia pode atuar como um verdadeiro regulador, com arquitetura, jurisdição, conteúdo, conjunto de regras e processos e mesmo mecanismos de *enforcement* automático. O aspecto mais importante do fenômeno é que a *lex informatica* pode substituir o direito ou constranger a habilidade do direito para lidar com um problema.

Um ponto comum na reflexão dos autores mencionados é a de atribuírem uma importância diferenciada à tecnologia como meio de regulação, cujo poder é tal que pode tornar ineficaz a regulação jurídica. Em outras palavras, pouco adianta uma regulação de comportamentos – seja pela via da heterorregulação, seja pela via da autorregulação ou corregulação – se a “arquitetura” é incompatível com os comportamentos buscados pela primeira.

Por outro lado, é preciso dar especial atenção às relações entre o mercado e a tecnologia, na medida em que podem ser mais próximas do que muitos estudos supõem e, juntas, neutralizarem os outros vetores de regulação. Com efeito, a escolha da tecnologia não é neutra e, se ficar a cargo apenas dos agentes dominantes, certamente que serão adotadas apenas as tecnologias que se ajustem aos seus interesses, independentemente das repercussões sobre a sociedade e sobre os titulares de dados.

Esse aspecto é de fundamental importância e, inclusive, dá um novo colorido à analogia normalmente feita entre *lex informatica* e *lex mercatoria*. Longe de compartilharem as características da naturalidade e espontaneidade, ambas podem ser vistas como expressões de poder. Afinal, assim como a *lex mercatoria* foi produzida na Idade Média pela classe mercantil em prol dos seus interesses, com toda a estrutura das corporações de mercadores para lhe assegurar eficácia,

também se pode dizer que a *lex informatica* tem sido produzida pelos grandes *players* dos mercados digitais em prol dos seus interesses e com soluções estruturais, inclusive tecnológicas, para assegurar a sua eficácia⁵².

Logo, é preciso entender adequadamente esses fenômenos para, nos termos da advertência de Colin Bennet e Charles Raab⁵³, evitar o determinismo tecnológico, uma vez que é possível desenvolver políticas estratégicas para construir a proteção da privacidade.

Para isso, é inequívoco que a regulação jurídica terá que disciplinar, entre outros, alguns aspectos da escolha da tecnologia a ser utilizada, situação que obviamente não pode ficar a cargo apenas dos agentes interessados.

É diante desse contexto que crescem as perspectivas da implementação do que se chama de *privacy by design* e *privacy by default*. A primeira diz respeito ao fato de que, quando algum agente decide realizar qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, deve pensar na privacidade em cada passo, o que inclui projeto, desenvolvimento de produtos e *softwares*, sistemas de informática, dentre outros, a fim de assegurar que a privacidade será garantida durante todo o ciclo do tratamento. Já a segunda diz respeito ao fato de que, ao lançar qualquer produto ou serviço ao público, as regras mais protetivas de tutela da privacidade devem ser aplicadas, sem que se exija do usuário qualquer iniciativa para tal propósito.

Daí a importância das tecnologias reforçadoras da privacidade ou *PETs* – *Privacy Enhancing Technologies*, que são exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada em prol da privacidade, o que se projeta desde a configuração de equipamentos eletrônicos, como *tablets* e *smartphones*,⁵⁴ até mesmo à estruturação de produtos e serviços.

Segundo Colin Bennet e Charles Raab⁵⁵, as funções da tecnologia, especialmente das *PETs*, são muitas, podendo ser importante complemento útil para as abordagens regulatórias e autorregulatórias, ainda que relatório da OCDE de 2001 as aponte como ferramentas secundárias. De toda sorte, conforme proliferaram, têm sido encorajadas como uma alternativa, mais do que um complemento, à legislação.

Desde que orientada para a consecução de valores importantes, e desde que seja compatível com os direitos dos que serão afetados, a regulação pela tecnologia tem muitas vantagens, até porque evita o problema do *moral agency*, na medida em que o comportamento das pessoas deixa de ser propriamente uma escolha entre cumprir determinado comando ou não e se torna uma decisão forçada por meio de restrições físicas. Se isso é bom por um lado, também tem repercussões sobre a liberdade das pessoas, porque elas perdem o direito de escolher⁵⁶.

Por outro lado, a regulação pela tecnologia também tem seus riscos, pois, como lembram Diane Rowland, Uta Kohl e Andrew Charlesworth⁵⁷, como o código não necessita de visibilidade para ser efetivo, pode-se facilmente influenciar o código – e, conseqüentemente, o comportamento – sem atrair tanta atenção. Essa mesma característica da regulação pela tecnologia pode trazer déficits de transparência e *accountability* democrática.

Essas advertências ressaltam que a tecnologia, em si, não é nem boa nem ruim. Tudo depende dos seus propósitos, da forma como foi desenhada para atingir tais propósitos e do grau de transparência que possibilite o controle sobre esses fatores. Daí por que a tecnologia pode, sim, ser poderoso instrumento para a tutela dos dados pessoais.

Todavia, no cenário atual, a tecnologia tem sido pautada prioritariamente – senão exclusivamente – pelo mercado, sem maiores preocupações com os direitos dos titulares de dados. A título de exemplo, pesquisa empírica de Chris Hoofnagle e outros⁵⁸, realizada em 2009 e 2011, com vários dos principais *sites*, descobriu que anunciantes estão usando persistentes tecnologias de rastreamento relativamente desconhecidas dos consumidores em volume cada vez maior, de forma a se tornarem inevitáveis.

Isso ressalta, como mostra Julie Cohen⁵⁹, o papel complementar do direito e da tecnologia, na construção de um regime de proteção da privacidade centrado na autonomia. Em um mundo digital e conectado, a lei sozinha não conseguirá proteger a privacidade, mas continua tendo importância na medida em que pode determinar ou incentivar o desenvolvimento de tecnologias protetivas da privacidade.

Ciente disso, a LGPD, em diversos momentos, centra na escolha da tecnologia o núcleo central de eficácia de várias de suas soluções, como ocorre em relação à anonimização e à segurança de dados. Há, também, grande preocupação com o papel da autoridade nacional para regulamentar as tecnologias que podem ou devem ser usadas pelos agentes de tratamento, o que evidencia o entrelaçamento entre a heterorregulação e a regulação pela tecnologia.

É preciso aceitar, como ressaltam Colin Bennet e Charles Raab⁶⁰, que os problemas relacionados à privacidade são tanto políticos e jurídicos como, também, tecnológicos, motivo pelo qual o seu endereçamento requer o equacionamento entre todas essas dimensões. Daí a advertência dos autores⁶¹ de que a governança da proteção de dados é um complexo regime, que inclui vários e múltiplos atores e estruturas e muitas ferramentas, o que se torna ainda mais complexo com o impacto da globalização.

Por essa razão, assim como não se pode negligenciar o papel da tecnologia na regulação dos mercados digitais, não se pode imaginar a tecnologia como o único ou o principal vetor dessa regulação, impondo-se a necessária interação com a heterorregulação, inclusive para o fim de evitar o determinismo tecnológico desenhado e imposto pelos agentes econômicos mais poderosos.

3.3.A LGPD e a questão da regulação pelo mercado: consentimento ou dominação?

Como se viu na primeira seção do presente artigo, se os dados pessoais estão relacionados a importantes situações existenciais, constituindo, inclusive, objeto de direito fundamental autônomo, é inequívoco que a disponibilidade sobre eles tem limitações naturais, tal como acontece em relação a todos os direitos da personalidade, nos termos do art. 11 do

Código Civil. Apesar das controvérsias em torno do alcance deste⁶², não há dúvidas sobre a conclusão de que não é livre a disposição sobre direitos da personalidade.

Não obstante, a LGPD atribui grande importância à solução de mercado, traduzida pelo consentimento, como fator de legitimação do tratamento de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis (arts. 7º, I, e 11, I). É até compreensível que assim seja, pois, segundo Rodotà⁶³, além de ser íntima a relação entre consentimento e autodeterminação informativa, o primeiro se mostra como uma alternativa entre regulação e desregulação, diante das dificuldades de se estabelecer um sistema completo de autorizações e vedações pela via legislativa.

O próprio Lawrence Lessig⁶⁴, ao defender o regime proprietário ou de mercado, baseado na negociação dos dados, utilizava o argumento de que tal solução protegeria melhor o usuário do que o regime de responsabilidade. Obviamente que o autor partia da premissa de que a arquitetura da internet poderia possibilitar aos indivíduos discriminar entre os diferentes níveis de privacidade oferecidos pelos *sites*⁶⁵. Ademais, não considerou que, em se tratando de situações existenciais, tanto o regime proprietário como o de responsabilidade são insuficientes, pois o que se pretende é a proteção efetiva dos direitos, o que nem sempre poderá ser alcançado pela via da negociação.

Independentemente do grau de adequação da solução de mercado, é preciso advertir que a sua implementação não é fácil, até porque o cenário atual é muito distinto do imaginado por muitos dos seus defensores, em que a livre-escolha do usuário seria assegurada pela existência de uma efetiva concorrência.

Os próprios requisitos legais para a validade do consentimento não são de fácil atendimento, já que a LGPD somente considera como tal a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (art. 5º, XII). Acresce que o consentimento ainda precisa estar submetido a todos os princípios previstos no art. 6º, com destaque para (i) o princípio da finalidade, que condiciona a realização do tratamento aos propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades (inciso I), (ii) o princípio da adequação, que impõe a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento e (iii) o princípio da necessidade, que exige a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

Como se vê, em que pese a LGPD exigir um consentimento qualificado, diversas características das negociações com dados dificultam o atendimento desse requisito, como já se viu anteriormente. Daí o ceticismo de alguns em relação a tais negociações, pois, como aponta Pasquale⁶⁶, não deixa de ser uma ficção achar que os consumidores podem e irão barganhar por privacidade ou simplesmente deixarem de contratar quando entenderem que seus direitos não estão sendo assegurados (o chamado *opt out*). Pelo contrário, em contextos de ausência de rivalidade e em que a aceitação da política de privacidade é condição *sine qua non* para o acesso ao serviço (as chamadas cláusulas *take it or leave it*), a legitimidade do consentimento sempre será discutível, mesmo que ele tenha sido informado.

Por essa razão, diante da assimetria informacional que parece ser insolúvel, indaga-se em que medida vale a pena ainda valorizar tanto o consentimento, quando haveria outros mecanismos mais idôneos e exequíveis para assegurar os valores agasalhados pela LGPD, entre os quais as soluções tecnológicas, como o *privacy by design*, ou mesmo a transparência e a *accountability*.

Com efeito, a racionalidade limitada dos consumidores e uma série de fatores os colocam em uma situação de tal vulnerabilidade que é difícil imaginar o consentimento legítimo em uma série de situações. Como assevera Ronaldo Porto Macedo Jr.⁶⁷,

Estudos sobre o conceito de racionalidade limitada (*bounded rationality*) e sobrecarga de informação (*overloaded information*) têm evidenciado que a equação: maior informação – maior capacidade de decisão consciente (e, portanto, livre) frequentemente não corresponde à realidade.

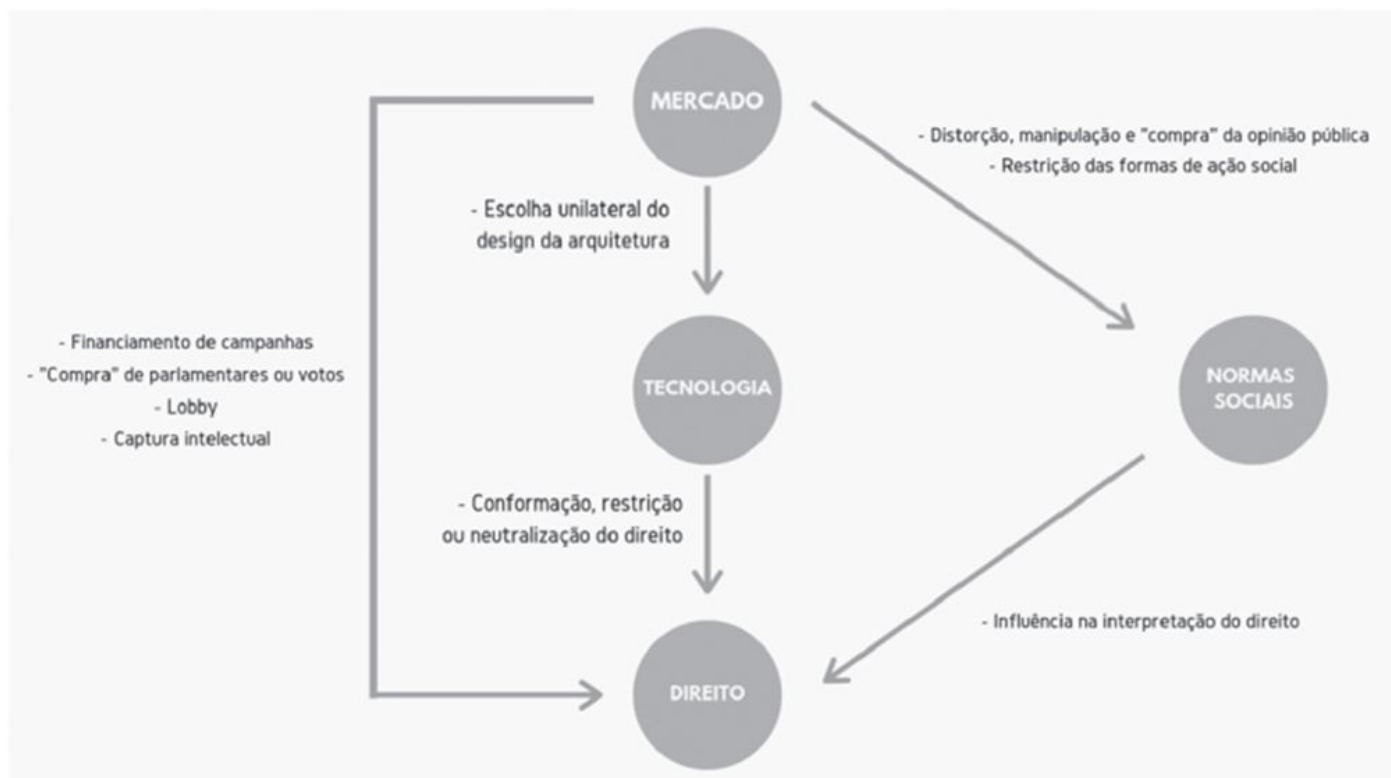
Daí a necessária e indispensável relação entre a heterorregulação e as soluções de mercado pois, como apontam Chris Hoofnagle e outros⁶⁸, a regulação jurídica, nessa hipótese, nada tem de paternalismo ou exagero, já que, diante das tecnologias que praticamente tornam impossível evitar o rastreamento *online*, as intervenções regulatórias são necessárias exatamente para possibilitar a escolha do consumidor, uma vez que puras alternativas de mercado negam, na prática, a possibilidade de os consumidores exercerem sua autonomia.

Na verdade, a heterorregulação, nesse caso, tem a precisa finalidade de assegurar que as soluções de mercado decorram legitimamente do consentimento dos titulares de dados e não da dominação dos agentes de tratamento.

3.4.A LGPD como fio condutor das demais formas de regulação

Como se pode observar, a heterorregulação do mercado de dados pessoais precisa levar em consideração as outras fontes de regulação, tais como a autorregulação, a tecnologia e as soluções de mercado. Para isso, embora deva existir uma influência recíproca entre todos esses fatores, a relação entre eles deve ser intermediada e conformada pela heterorregulação, a quem cabe preservar os direitos básicos dos titulares de dados, inclusive por meio da delimitação do alcance dos demais meios de regulação.

Se assim não for, é grande o risco de que as soluções de mercado sejam aquelas impostas unilateralmente pelos agentes econômicos mais poderosos e que acabem dominando todos os outros meios de integração social, inclusive, o direito. Essa colonização tanto pode ocorrer direta como indiretamente, por meio da tecnologia e da própria manipulação da opinião pública, como representado pela seguinte figura:



Fonte: Elaborado pela autora.

Logo, o advento da LGPD envolve a superação de abordagens simplistas ou excessivamente ingênuas, no sentido de que a lei resolveria todos os problemas. Diante dos riscos envolvidos, é necessária reflexão profunda sobre como a lei deve dialogar com as demais formas de integração social e que cuidados devem ser tomados para que suas previsões não sejam descumpridas ou neutralizadas.

Nos termos da advertência de Habermas⁶⁹, se a política e a economia possuem abordagens específicas e diferenciadas, cabe ao direito, aqui entendido como heterorregulação, atuar como mediador entre estas, possibilitando que a racionalidade específica de ambos os sistemas não se transforme em obstáculo para o cumprimento das liberdades fundamentais nem para a integração social efetuada a partir das relações jurídicas.

4. Considerações finais

O presente artigo procurou mostrar o cenário econômico, político e social que torna a proteção dos dados pela via da heterorregulação não apenas necessária, como imprescindível e urgente. Com efeito, a economia movida a dados expandiu-se muito rapidamente a partir da comoditização de dados pessoais dos usuários e da violação desses dados de forma maciça. Priorizaram-se a inovação e as vantagens dos agentes econômicos, sob o fundamento de perigoso *trade-off* entre os direitos dos titulares de dados e eficiências econômicas.

É nesse sentido que uma lei geral de proteção de dados, tal como a LGPD brasileira, pretende reequilibrar essas forças, aumentando o protagonismo por parte do titular de dados pessoais. Vale ressaltar que, como se procurou demonstrar ao longo das várias seções deste artigo, o que está em jogo não é apenas a privacidade no sentido da intimidade, mas, também, a autonomia informativa e o controle sobre a informação, assim como uma série de questões relacionadas à igualdade e à própria liberdade, cuja tutela é imprescindível tanto sob a ótica individual, como sob a ótica social, considerando que as bases da democracia hoje dependem igualmente da regulação de dados.

Para tal complexidade, a LGPD brasileira, com forte inspiração no GDPR europeu, adota as premissas e fundamentos necessários para que a proteção dos dados seja instrumento de preservação dos direitos fundamentais e valores mencionados, a fim de contornar, dentro do possível, os efeitos nefastos de um capitalismo cada vez mais baseado na vigilância e na opacidade.

Entretanto, não se pode imaginar que a lei, sozinha, possa resolver todos os problemas relacionados à proteção de dados pessoais. Afinal, a heterorregulação sobre os dados pessoais é matéria complexa e exigirá esforços de todas as searas que lidam com o problema, tal como é o caso do Direito Eleitoral e do Direito Antitruste.

Por outro lado, ainda que ocorra um profícuo e harmônico diálogo entre as diferentes fontes normativas, é importante ter em mente as limitações naturais da heterorregulação, de forma que todas as suas normas e garantias só ganharão efetividade caso haja a concorrência proveitosa da autorregulação ou corregulação, da regulação pela tecnologia e, também, das soluções do mercado, quando estas reforcem o protagonismo do próprio titular, valorizando o seu consentimento sempre que este for, de fato, livre, informado e compatível com a natureza existencial do objeto da negociação.

Portanto, na questão da tutela dos dados pessoais, sem prejuízo do papel das normas sociais ou instituições não formais, a proteção de dados pessoais envolve complexo e delicado regime que se baseia na interação de diversos atores e que, para ser eficaz, depende de uma combinação adequada e eficiente entre heterorregulação, autorregulação ou corregulação, tecnologia e soluções de mercado, traduzidas no consentimento efetivamente livre e informado do titular.

Na combinação apontada, o papel da heterorregulação é de ser o fio condutor que deve orientar e conformar as demais formas de regulação, até para evitar que as regras do mercado, impostas unilateralmente pelos agentes mais poderosos, de forma direta ou pela via da tecnologia, dominem todas as outras formas de regulação dos dados, tornando inócua ou sem sentido a proteção de dados pessoais implementada pela lei.

5. Referências bibliográficas

BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. *Network Propaganda. Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press, 2018.

BENNETT, Colin J.; RAAB, Charles D. *The governance of privacy. Policy instruments in global perspective*. Cambridge: The MIT Press, 2006.

COHEN, Julie E. Examined lives: informational privacy and the subject as object. *Stanford Law Review*, v. 52, 2000, p. 1373-1438.

COLE, Julio H. Milton Friedman on income inequality. *Journal of markets & morality*. v. 11, n. 2, p. 239-253, 2008.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio: Renovar, 2006.

FRAZÃO, Ana. *Direito da concorrência. Pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017.

FRAZÃO, Ana. *Fundamentos para a proteção dos dados pessoais. Noções introdutórias para a compreensão da LGPD*. Capítulo de livro desta coletânea.

FRAZÃO, Ana. Nova LGPD. Balanço preliminar da MP 869/2018. *Jota*. Disponível em: [www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019]. Acesso em: 20.02.2019.

FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose D. *Free to choose: a personal statement*. Orlando: Harvest, 1990.

HABERMAS, Jürgen. *Facticidad y Validez*. Trad. Manuel Jiménez Redondo. 3. ed. Madri: Editorial Trota S/A, 2001.

HAYEK, Friedrich A. *Direito, legislação e liberdade*. Trad. Henry Maksoud. São Paulo: Visão, 1985.

HAYEK, Friedrich A. *O caminho da servidão*. Trad. Anna Maria Capovilla, José Ítalo Stelle e Liane de Moraes Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora Biblioteca do Exército, 1994.

HOOFNAGLE, Chris Jay; SOLTANI, Ashkan; GOOD, Nathaniel; WANBACH, Dietrich J. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. *Harvard Law & Policy Review*. v. 6, 2012, p. 273-296.

KAHNEMAN, Daniel. *Rápido e devagar. Duas formas de pensar*. Trad. Cassio Arantes Leite. São Paulo: Objetiva, 2012.

LESSIG, Lawrence. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

MACEDO JR., Ronaldo Porto. Privacidade, mercado e informação. *Justitia*. São Paulo, 61 (185/188), p. 247. jan.-dez. 1999.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor. Linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014.

PASQUALE, Frank. *The black box society. The secret algorithms that control money and information*. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

REIDENBERG, J. Lex informatica: the formulation of information policy rules through technology. *Texas Law Review* 76, p. 552-593, 1998.

RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância. A privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Laura Cabral Doneda. Rio: Renovar, 2008.

ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. *Information Technology Law*. New York: Routledge, 2017.

SOLOVE, Daniel. *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

WALDMAN, Ari Ezra. Designing without privacy. *Houston Law Review* 55:3, p. 659-727.

ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *Journal of Information Technology*, 30, p. 75-89, 2015.

ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: Public Affairs, 2019.

1

.Advogada e Professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília – UnB.

2

.Ver FRAZÃO, Ana. *Fundamentos para a proteção dos dados pessoais*. Noções introdutórias para a compreensão da LGPD. Capítulo de livro desta coletânea.

3

.PASQUALE, Frank. *The black box society. The secret algorithms that control money and information*. Cambridge: Harvard University Press, 2015. p. 146.

4

.RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância. A privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Laura Cabral Doneda. Rio: Renovar, 2008. p. 18-19.

5

.As discussões sobre o capitalismo de vigilância são mapeadas por FRAZÃO, Ana. *Fundamentos para a proteção dos dados pessoais. Noções introdutórias para a compreensão da LGPD*. Op. cit.

6

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio: Renovar, 2006. p. 410.

7

.MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, Proteção de dados e defesa do consumidor. Linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 122-123.

8

.Op. cit., p. 77.

9

.Op. cit., p. 93.

10

.SOLOVE, Daniel. *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008. p. 8.

11

.Op. cit., p. 75.

12

.Op. cit., p. 104.

13

.Idem.

14

.Idem.

15

.Idem.

16

.Op. cit., p. 105.

17

.Op. cit., p. 163.

18

.Op. cit., p. 96.

19

.Op. cit., p. 57.

20

.Op. cit., p. 16. Vale ressaltar que o autor (Op. cit., p. 17) sustenta que, da mesma forma como passamos a acreditar nos “titãs” da reputação, das buscas e das finanças para entender o sentido do mundo, agora é o tempo no qual os responsáveis pelas políticas públicas nos ajudem a entender o sentido desses *sensemakers*.

21

.PASQUALE, Op. cit., p. 57.

22

.Op. cit., p. 2

23

.É importante ressaltar que a redação original do art. 20 da LGPD previa que “O titular dos dados tem direito a solicitar revisão, por pessoa natural, de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de

decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade” (grifos nossos). A Medida Provisória 869/2018, depois convertida na Lei 13.853/2019, suprimiu a referência à pessoa natural, de forma que o art. 20 passou a ter a seguinte redação: “O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.” Obviamente que se tratou de manifesto retrocesso pois, como explica Frank Pasquale (op. cit., p. 213), accountability impõe julgamento humano, pois somente homens podem cumprir a função crítica de ter certeza de que, na medida em que nossas relações sociais tornam-se cada vez mais automatizadas, aspectos de dominação e discriminação não são construídos invisivelmente dentro do código. Sobre os efeitos nefastos da MP 869, ver também FRAZÃO, Ana. Nova LGPD. Balanço preliminar da MP 869/2018. Jota. Disponível em: [www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019]. Acesso em: 20.02.2019.

24

.Ver FRAZÃO, Ana. *Fundamentos para a proteção dos dados pessoais. Noções introdutórias para a compreensão da LGPD*. Op. cit.

25

.BENKLER, Yochai, FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. *Network Propaganda. Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press, 2018. p. 381-383.

26

.Op. cit., p. 385.

27

.Op. cit., p. 385-386.

28

.Op. cit., p. 164.

29

.ZUBOFF, Shoshana. *The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: Public Affairs, 2019. p. 21.

30

.HAYEK, Friedrich A. *Direito, legislação e liberdade*. Trad. Henry Maksoud. São Paulo: Visão, 1985.

31

.PASQUALE, Frank. *The black box society. The secret algorithms that control money and information*. Cambridge: Harvard University Press, 2015. p. 9.

32

.PASQUALE, Frank. Op. cit., p. 42-45.

33

.Op. cit., p. 214.

34

.Op. cit., p. 20.

35

.Op. cit., pp. 20-21.

36

.Op. cit., p. 495.

37

.Op. cit., p. 496.

38

.Op. cit., p. 497.

39

.Op. cit., p. 497.

40

.ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *Journal of Information Technology*, 30, 2015, p. 75-89, p. 80-81.

41

.Op. cit., p. 81-83.

42

.FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose D. *Free to choose: a personal statement*. Orlando: Harvest, 1990.

43

.FRIEDMAN; FRIEDMAN. Op. cit.

44

.Nesse sentido: COLE, Julio H. Milton Friedman on income inequality. *Journal of markets & morality*. v. 11, n. 2, p. 239-253, 2008.

45

.KAHNEMAN, Daniel. *Rápido e devagar. Duas formas de pensar*. Trad. Cassio Arantes Leite. São Paulo: Objetiva, 2012. p. 515-516.

46

.HAYEK, Friedrich. *O caminho da servidão*. Trad. Anna Maria Capovilla, José Ítalo Stelle e Liane de Moraes Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora Biblioteca do Exército, 1994. p. 58.

47

.Sobre as diferentes formas de regulação, diante de mercados cada vez mais complexos, ver FRAZÃO, Ana. *Direito da concorrência. Pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 67-71.

48

.BENNETT, Colin J.; RAAB, Charles D. *The governance of privacy. Policy instruments in global perspective*. Cambridge: The MIT Press, 2006. p. 151-152.

49

.ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. *Information Technology Law*. New York: Routledge, 2017. p. 20-21.

50

.LESSIG, Lawrence. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

51

.REIDENBERG, J. Lex informatica: the formulation of information policy rules through technology. *Texas Law Review* 76, 1998, p. 552-593.

52

."Não é exagerada, portanto, a afirmação de Galgano de que o Direito Comercial nasceu como direito criado diretamente pela classe mercantil, sem mediação da sociedade política, como direito imposto em nome de uma classe e não em nome da comunidade. Daí por que a *lex mercatoria* medieval foi, essencialmente, um fenômeno de poder e não o resultado da mera interação espontânea dos agentes econômicos." (FRAZÃO, Ana. *Direito da concorrência*. Op. cit., p. 74).

53

.BENNETT, Colin J.; RAAB, Charles D. Op. cit., p. 187.

54

.Ver, sobre a questão, WALDMAN, Ari Ezra. Designing without privacy. *Houston Law Review* 55:3, pp. 659-727.

55

.Op. cit., p. 198-200.

56

.ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. *Information Technology Law*. New York: Routledge. Op. cit., p. 14.

57

.Op. cit., p. 12.

58

.HOOFNAGLE, Chris Jay, SOLTANI, Ashkan, GOOD, Nathaniel; WANBACH, Dietrich J. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. *Harvard Law & Policy Review*, v. 6, 2012, p. 273-296.

59

.COHEN, Julie E. Examined lives: informational privacy and the subject as object. *Stanford Law Review*, v. 52, 2000, p. 1377.

60

.Op. cit., p. XV.

61

.Op. cit., p. 233.

62

.A controvérsia é bem exemplificada por dois Enunciados das Jornadas de Direito Civil. Enquanto o Enunciado 4 previa que "O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária", o 139 previu que "Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes."

63

.Op. cit., pp. 75-76.

64

.Op. cit., pp. 160-161.

65

.Op. cit., p. 149.

66

.Op. cit., p. 143.

67

.MACEDO JR., Ronaldo Porto. Privacidade, mercado e informação. *Justitia*. São Paulo, 61 (185/188), jan.-dez. 1999. p. 247.

68

.HOOFNAGLE, Chris Jay, SOLTANI, Ashkan, GOOD, Nathaniel; WANBACH, Dietrich J. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. Op. cit.

.HABERMAS, Jürgen. *Facticidad y Validez*. Trad. Manuel Jiménez Redondo. 3. ed. Madri: Editorial Trota S/A, 2001. p. 120.

Capítulo 5. A titularidade de dados pessoais prevista no art. 17 da LGPD: direito real ou pessoal?

Roberta Mauro Medina Maia¹

1. Introdução

Em 1876, ao editar sua *Consolidação das Leis Civis*, Augusto Teixeira de Freitas afirmou que na distinção entre direitos reais e obrigações “repousaria todo o Direito Civil”². Com efeito, embora os direitos subjetivos também pudessem ser divididos entre absolutos e relativos, e patrimoniais e extrapatrimoniais, a subdivisão por ele mencionada sempre mereceu, dos civilistas, a atenção e o respeito próprios de um arcabouço teórico que começou a ser construído ainda na Roma Antiga³.

Hoje, a inequívoca desmaterialização dos bens – propiciada por avanços tecnológicos – tem posto à prova o conceito de propriedade – direito real por excelência – tanto quanto a sua necessária funcionalização ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. A partir do processo de industrialização e da paulatina ascensão dos direitos fundamentais, o direito das coisas, que, até então, gozava de proteção prioritária e peculiar, destinando-se à tutela do que havia de mais valioso, foi perdendo destaque por diversas razões: fosse porque a Revolução Industrial obrigou o direito das obrigações a servir de base a novas ramificações, como as que regulavam as relações societárias ou trabalhistas⁴, enquanto os direitos reais, presos às amarras impostas por um sistema *numerus clausus*⁵, pouco evoluíam, fosse porque a preocupação do legislador se voltou de forma mais consistente à tutela de direitos extrapatrimoniais, como os relacionados à personalidade humana ou, por fim, porque bens mais valiosos que os bens de raiz surgiram a partir do processo de industrialização, tirando das coisas tangíveis seu *status* de parcela patrimonial mais relevante.

Nesse contexto, tratados como o novo petróleo – por assumir, no século atual, papel semelhante ao desempenhado por esse recurso natural no último⁶ –, os dados pessoais e a informação, de um modo geral, diante de sua coleta e estocagem, representam hoje uma “nova mercadoria”, cujo comércio pode impor risco efetivo à privacidade⁷. Protegê-la, nesse novo cenário, é tarefa das mais desafiadoras para as legislações modernas. Por isso, diante da tutela reforçada que sempre foi conferida ao direito de propriedade – graças à oponibilidade de tal direito subjetivo perante terceiros –, o presente artigo destina-se a demonstrar se a ideia de transformar dados pessoais em objeto de propriedade⁸, na intenção de melhor protegê-los, foi de fato adotada pelo legislador brasileiro.

Para tanto, o art. 17 da Lei Geral de Proteção de Dados merecerá detida análise, no intuito de esclarecer-se, ao final, se a titularidade de dados pessoais ali prevista é, segundo as características atribuídas a um e outro campo, um direito de natureza real ou pessoal. Por ora, deve ser ressaltado que, ao determinar que “toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei”, o legislador evidencia a opção de, ao contrário do tempo de Teixeira de Freitas, considerar que a distinção mais relevante para o Direito Civil nos tempos atuais não é a que divide os direitos subjetivos entre reais ou pessoais, mas sim a que aparta os de caráter patrimonial – único traço comum entre aqueles dois campos – e os de caráter extrapatrimonial⁹.

2. Ainda sobre direitos reais e pessoais: sua distinção estrutural e funcional

Durante muitos séculos, a evolução dogmática dos dois institutos mais importantes do direito privado patrimonial – a propriedade e o contrato – evoluiu para que ambos pudessem ter sua estrutura pormenorizadamente descrita. Assim, sem maiores variações nos sistemas jurídicos que floresceram a partir do Direito Romano, os direitos reais – ou, segundo a terminologia adotada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, os direitos das coisas¹⁰ – refletiriam, para a chamada doutrina realista ou clássica, uma relação entre pessoa e coisa, sem que ninguém pudesse se interpor entre esta e o seu titular¹¹. Diversamente, o direito obrigacional ou de crédito¹² traduziria uma relação entre pessoas, irradiando “pretensões pessoais, isto é, pretensões a que alguém possa exigir de outrem, *debitor*, que dê, faça ou não faça, em virtude de relação jurídica só entre eles”¹³ existente.

Em virtude de tal estruturação, as obrigações são definidas como vínculos pessoais e mediatos, pois, necessariamente, dependem da atuação do sujeito passivo¹⁴ e, unindo somente as partes envolvidas, produziram efeitos apenas relativos¹⁵, sem beneficiar ou prejudicar terceiros¹⁶. A eficácia atribuída aos direitos reais, por sua vez, irradiaria efeitos *erga omnes*, criando, segundo a “teoria personalista”¹⁷, uma relação entre o seu titular e toda a coletividade, a quem caberia o dever negativo de não impedir o livre-exercício do direito¹⁸. Daí sua qualificação como absolutos, já que ao poder de seus titulares corresponderia um dever de “todos os outros”¹⁹.

Nos direitos reais, diversamente do que ocorreria com as obrigações, o poder de seu titular é exercido imediatamente sobre a coisa, sem qualquer intervenção de outras pessoas sobre o vínculo²⁰. Assim, enquanto o poder imediato sobre o objeto do vínculo jurídico revela o modo por meio do qual o titular do direito persegue a realização do seu interesse, temos outra característica peculiar aos direitos reais, reveladora da relação indissociável que se cria entre o poder exercido pelo titular do direito e o seu objeto: a inerência ou aderência²¹.

Permitindo que o direito real incida diretamente sobre a própria coisa²², a inerência é, justamente, a característica capaz de conferir ao titular do direito real o poder direto sobre o bem, sem depender da atuação de interposta pessoa para que possa satisfazer seus interesses. E do caráter absoluto e de tal aderência à coisa decorreriam, segundo Gustavo Tepedino, todas as demais características

dos direitos reais: a ambulatoriedade, a sequência, a publicidade, a especialidade, a preferência e a tipicidade²³.

Sendo consequência lógica da inerência (ou aderência) do direito à coisa, a ambulatoriedade garante ao titular que o vínculo com a mesma irá acompanhá-la por onde quer que se encontre²⁴, permitindo-se, portanto, que as ações criadas para proteger os direitos reais sejam propostas contra quem quer que eventualmente os viole²⁵. Tal prerrogativa de recuperar a coisa das mãos de quem injustamente a possui – corolário processual da ambulatoriedade – é chamada de direito de sequência²⁶, sem o qual, segundo Shalev Ginossar, os direitos reais não existiriam²⁷.

Sendo, por natureza, desprovidos de tal poder, os direitos obrigacionais, quando violados, dariam ensejo apenas a pretensões dirigidas contra o devedor, seus sucessores ou representantes²⁸, e não em face de qualquer pessoa indeterminada. Consequentemente, em virtude da diversidade da tutela que lhes é conferida, diz-se que os direitos obrigacionais são “direitos fracos”, enquanto os direitos reais correspondem a “direitos fortes”²⁹, por serem oponíveis perante terceiros.

Ainda a respeito dos direitos reais, a publicidade é definida como um de seus princípios norteadores³⁰, impondo, para que possam produzir efeitos *erga omnes*, a “ampla divulgação de todos os atos concernentes à constituição e à transferência dos direitos reais, de molde a que todos possam conhecer a relação jurídica a que estão adstritos a respeitar”³¹. A publicidade não seria imposta aos vínculos obrigacionais justamente porque seus efeitos seriam apenas relativos, não vinculando terceiros.

A especialidade, por sua vez, reflete a ideia de que os direitos reais só poderiam ter por objeto coisa certa e determinada³², exigindo-se, portanto, a existência atual do bem sobre o qual incidem, enquanto o objeto dos vínculos obrigacionais poderia ser coisa futura³³.

Com relação à preferência, esta não seria, para Orlando Gomes, um atributo de todos os direitos reais, mas uma qualidade a eles conferida por lei para que possam atender de modo mais eficaz a sua função específica³⁴. Partindo de tal premissa, é possível perceber que, relativamente aos direitos reais de garantia, se não lhes fosse assegurada preferência, em detrimento de qualquer outro direito sobre o bem, os mesmos tornar-se-iam inúteis. Na lição de Gustavo Tepedino, além desse viés, a preferência corresponderia, ainda, a um aspecto temporal, consagrando o princípio “segundo o qual a prioridade no registro oferece preferência no direito”³⁵ – *prior in tempore potior in iure*.

A tipicidade, por sua vez, seria um corolário lógico da regra do *numerus clausus*, que impede os particulares de constituírem direitos reais diversos dos previstos em lei, impondo-lhes sua taxatividade. Desse modo, se apenas ao legislador seria dado criar figuras de direito real, a tipicidade impediria qualquer atuação da autonomia privada que contrariasse o conteúdo estrutural dos poderes conferidos, por lei, “ao titular da situação jurídica de direito real”³⁶.

No Brasil, os direitos reais elencados pelo legislador encontram-se, em sua maioria³⁷, no rol do art. 1.225 do Código Civil de 2002: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje³⁸.

A enumeração taxativa impediria, por força do *numerus clausus*³⁹ imposto aos institutos de direito real, que figuras diversas daquelas expressamente previstas em lei pudessem ser consideradas direitos reais. Como consequência de tal vedação, a tipicidade imporá aos particulares o dever de respeitar, integralmente, o conteúdo estrutural de cada uma dessas figuras, quando de sua adoção. E é por força, sobretudo das características típicas fornecidas pelo Código Civil de 2002, que se discute a possibilidade de considerar dados pessoais como objeto de propriedade e, conseqüentemente, de um vínculo real: a estrutura ali proposta pelo legislador, embora descreva um direito de uso, gozo, disposição e reivindicação da coisa (art. 1.228), revelaria a intenção de fazê-los recair apenas sobre objetos tangíveis, ou seja, aqueles passíveis de serem possuídos.

Relativamente às obrigações, estas seriam definidas como uma relação de cooperação, pautada na iniciativa dos indivíduos ou em sua imposição pela ordem jurídica, enquanto os direitos reais corresponderiam a uma relação ordenadora, atributiva ou subordinativa, pois eles estariam destinados à atribuição, ao seu titular, de poderes específicos sobre a coisa, sem que terceiros pudessem exercer qualquer ingerência sobre o destino da mesma. Desse modo, as normas pertinentes ao direito das obrigações seriam normas de relação, enquanto as relativas aos direitos das coisas seriam normas de ordenação ou com uma função ordenadora⁴⁰.

Postas, em linhas gerais, as bases nas quais se erige a estrutura proposta para os direitos reais, é possível observar que, ao sobre elas dispor, o legislador absteve-se, em nossa Codificação vigente, de perquirir qual a função desempenhada por tal subsistema em nosso Ordenamento Jurídico. E, independentemente das funções constitucionais a serem perseguidas pelo direito de propriedade, precisamos dela e dos demais direitos reais, basicamente, porque é necessário alocar bens de modo estável e seguro, ou seja, o legislador deve, diante da finitude dos recursos disponíveis, fornecer informações sobre as escolhas legislativas a respeito “de quem deve ser o titular de quê, em que momento, em que medida e por que motivo”⁴¹. Não é à toa, portanto, que Gustavo Tepedino os define, atualmente, como “a categoria de relações jurídicas que regula a apropriação e a utilização dos *bens jurídicos*”⁴², expressão consideravelmente mais ampla que “coisa”, termo adotado pelo Código Civil em vigor.

No que concerne, portanto, ao seu aspecto funcional, o direito de propriedade existe por ser necessário definir a posição de cada indivíduo diante da utilização de recursos que são escassos⁴³. Em relação ao mesmo aspecto, a posse, sendo universalmente definida como um estado de fato protegido pelo direito⁴⁴, tem como função precípua publicizar e revelar para o mundo certas circunstâncias acerca do modo como são exercidos os direitos subjetivos⁴⁵. Se, em relação ao direito de propriedade, o aspecto funcional revela que cabe ao instituto assegurar e discriminar o acesso a bens considerados escassos⁴⁶ – e, portanto, valiosos – o

mesmo aspecto revela, em relação à posse, ser a ostensividade de tais vínculos jurídicos a missão precípua por ela desempenhada em qualquer sistema legal.

Partindo de tal premissa, é possível considerar que direitos reais e obrigações correspondem a faces diversas de um mesmo sistema de alocação de bens: enquanto o conteúdo dos primeiros revela a atribuição em si – podendo ser alguma forma de utilização, fruição ou disposição, os aspectos obrigacionais do mesmo vínculo jurídico devem refletir, primordialmente, a causa da atribuição de um bem a alguém, podendo revelar, ainda, uma expectativa em relação à futura e legítima atribuição de um direito de uso, gozo ou disposição⁴⁷.

Com efeito, relativamente ao aspecto estrutural, o traço que tornava os direitos reais tão distintos das demais categorias de direitos subjetivo de viés patrimonial era, desde a sua origem, o tipo de tutela a eles conferida. Assim, inclusive, os romanos explicavam a diferença entre os dois campos de relações patrimoniais⁴⁸: o poder de controlar o acesso – excluindo terceiros de ingerências indevidas sobre o bem –, oponível perante terceiros (*erga omnes*), é o traço mais comumente atribuído ao direito de propriedade. Na lição de Ebert Chamoun, na sua essência estaria “a exclusão máxima que a relação jurídica atinge”⁴⁹, residindo nesse aspecto a vinculação do direito de propriedade à expressão “coisa”, segundo o mesmo autor:

O conteúdo econômico do direito real, a senhoria sobre a coisa, aparece integrado por todas as suas faculdades, de uso, de gozo e de disposição. Destarte, em face da absoluta ausência de devedores determinados, a coisa aflora à tona da relação jurídica de forma tão impressionante que o leigo confunde o direito com a própria coisa. Assim entenderam erroneamente os romanos e ainda hoje a palavra propriedade é vulgarmente empregada para designar a coisa.⁵⁰

E quando se diz que era essa a forma de os romanos explicarem a diferença entre direitos reais e obrigações, tem-se em mente a distância abissal que o campo adjetivo então impunha às duas categorias: enquanto ao credor caberia apenas a faculdade de exigir do devedor o cumprimento da prestação (*actio in personam*), a partir da *Lex Poetelia Papiria de Nexis*⁵¹, ao proprietário usurpado da posse do bem era dado o direito de demandar ao pretor que impusesse a sua restituição (*actio in rem*)⁵².

Hoje, já afastados do tempo em que os bens mais escassos e valiosos eram os imóveis, tal distância foi drasticamente reduzida. Mesmo antes de chegarmos à “Era da Virtualidade”⁵³, os grandes conglomerados empresariais já haviam deslocado o foco da propriedade tangível, voltando-o para a propriedade imaterial, dada a sua valorização, em detrimento dos bens imóveis. Por isso, a tutela destinada a estes últimos por meio das ações possessórias e da ação reivindicatória deixou de ser tão peculiar quanto antes em virtude da disseminação da execução específica e das medidas cautelares, por exemplo.

A ascensão dos direitos da personalidade, por sua vez, deu outro sentido à propriedade, que, por meio da posse, “traduz os modos pelos quais visualizamos os bens da vida, as chamadas ‘coisas’”⁵⁴. Tome-se, por exemplo, o direito à imagem, cuja proteção ganhou especial interesse a partir da invenção da fotografia: se era razoável concluir que celebridades ou figuras políticas teriam

consentido com a captação de sua imagem ao posarem para a foto, isso não necessariamente autorizaria o fotógrafo a reproduzi-la em larga escala e lucrar com tais reproduções⁵⁵.

Para além da ostensividade ou exteriorização do direito – função precípua da posse – surge, relativamente ao direito de propriedade, a função de explicar a tutela patrimonial destinada a direitos da personalidade como o nome ou a imagem por ser o único instituto capaz de fornecer algum sentido de pertencimento ou atribuição: de quem é a imagem? A quem pertence o nome? Quem o ostenta perante o mundo? E relativamente a aspectos patrimoniais notadamente atrelados aos direitos da personalidade, conforme observado por Marco Comporti, os vínculos jurídicos que recaem sobre bens imateriais vêm se desenvolvendo de maneira análoga ao direito de propriedade: a relação sujeito-bem também representa uma relação de utilização em regime de exclusividade⁵⁶.

Daí a dificuldade de se encontrar outro instituto capaz de explicar a atual “comoditização”⁵⁷ dos dados pessoais, fenômeno observado com maestria por Stefano Rodotà: dada a riqueza e a confiabilidade com que são coletados hoje por meio de tecnologias interativas – tais como *smartphones*, *smart TVs*, empresas de *streaming* ou mesmo redes sociais – surge a possibilidade de usos secundários, com a criação de verdadeira mercadoria, “que consiste sobretudo na produção de ‘perfis’ individuais, familiares ou de grupo, cedíveis a terceiros”⁵⁸.

Diante de tais considerações, extrai-se que a propriedade, sendo uma resposta à finitude dos bens considerados mais valiosos, representa as relações jurídicas travadas entre as pessoas no que concerne ao controle desses bens⁵⁹. É, no âmbito estrutural, a possibilidade de usar, gozar e dispor das coisas, bem como de reavê-las de quem as usurpe. Já na seara funcional, a propriedade e os direitos reais revelam que seu papel é resolver “um problema de atribuição de bens”⁶⁰.

Por tais motivos, como se não bastasse a inócua tarefa de tentar identificar, indistintamente, em todos os direitos reais, todas as características que fariam deles uma categoria – tome-se, por exemplo, a completa diversidade estrutural dos direitos reais de garantia, que impede sua aquisição por usucapião –, a mudança da natureza dos bens hoje considerados mais valiosos não tira do direito de propriedade a função de alocá-los e discriminar seus usos⁶¹. Pelo contrário, a desmaterialização dos bens ou sua virtualização impõe apenas uma adequação estrutural do direito de propriedade, embora a disciplina por este disposta já entre eventualmente em choque com as características originais daquilo que eventualmente lhe sirva de objeto⁶².

Na velocidade da Era Digital, é inimaginável que o legislador consiga acompanhar o surgimento de novos bens jurídicos. E é justamente o que ocorre, hoje, com a informação: segundo Stefano Rodotà, a era do *direct marketing*, na qual é possível, por meio de verdadeiro “comércio” de dados pessoais, atingir de maneira eficiente público que poderia se interessar por um determinado produto ou serviço, tais dados ingressam de modo inequívoco no mundo das mercadorias, operando-se o que o autor chamava de “comodificação” (*commodification*)⁶³.

E para quem ainda não se convenceu de que os bens mudaram – impondo alterações nos sistemas que cuidam de sua atribuição e modos de disposição – os Termos de Serviço de uma conhecida rede social assim já definiu seus usuários: “você é proprietário do conteúdo que cria e compartilha no Facebook, e nada nestes Termos afasta os direitos que você tem sobre o próprio conteúdo”⁶⁴. Portanto, a ascensão do *marketing* como estratégia comercial moderna transformou os dados pessoais em novo bem jurídico, dotado de valor patrimonial. Como se verá a seguir, o legislador brasileiro não estava alheio a tal fenômeno.

3.A titularidade dos dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a teoria da apropriação (propertization)

Embora o debate em torno da possibilidade de dados pessoais serem considerados objeto de propriedade não seja novo⁶⁵, o tema foi explorado no país em pouquíssimas oportunidades⁶⁶ até o advento da LGPD. O debate se intensificou não apenas em razão do valor econômico hoje atrelado aos dados pessoais e à informação, de um modo geral, mas, também, por força do gigantesco afluxo de dados coletados a partir do advento da Internet das Coisas, na qual, ao contrário da troca de informações entre pessoas – viabilizada pela internet –, tem-se o intercâmbio de informações entre objetos, que captam dados de seus usuários diariamente.

Essa intensa troca despertou, na doutrina estrangeira, nos anos que antecederam o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa (GDPR) e a LGPD, preocupação pertinente à possibilidade de se controlar a transmissão a terceiros dos dados coletados por quem originalmente os captou, sem o consentimento ou mesmo a ciência de seu titular. Portanto, dois fatores principais têm contribuído para a defesa, em sede doutrinária, de que dados pessoais seriam objeto de propriedade: a insuficiência da responsabilidade civil para apresentar soluções a problemas modernos como a prática de *profiling*, sem consentimento do titular dos dados⁶⁷, e a necessidade de recorrer ao direito de sequência, atributo do direito de propriedade e dos direitos reais, na intenção de reaver dados indevidamente transmitidos a terceiros.

Em que pese a discussão em torno do assunto tenha se intensificado com a entrada em vigor do GDPR⁶⁸, em 2018, o recurso aos *property rights* como mecanismo de proteção do direito à privacidade já era aventado por Samuel Warren e Louis Brandeis desde o século XIX⁶⁹, por inexistir, à época, tutela consistente endereçada aos direitos da personalidade, sendo forçoso recorrer ao direito de propriedade para justificar tal proteção. Assim, a matriz constitucional da inviolabilidade de domicílio nos Estados Unidos – prevista na Quarta Emenda da Constituição Americana e destinada à tutela da propriedade – serviu de ponto de partida para o desenvolvimento da proteção conferida ao direito à privacidade pela Suprema Corte daquele país, revelando, portanto, a relação inicial entre os dois institutos. E, ainda a respeito de tal vínculo, para alguns autores americanos, a propriedade teria, na privacidade, um dos fundamentos para a tutela tão especial que lhe é destinada pelos Ordenamentos Jurídicos modernos⁷⁰.

Também serviu para ampliar o debate a crescente demanda por informação – seja para fins mercadológicos ou de segurança nacional – tendo, como contrapartida, o surgimento dos chamados construtores de bases de dados, que podem ser *sites* ou aplicativos por meio dos quais indivíduos trocam suas informações pessoais por bens, descontos ou serviços. Esses dispõem de seus dados voluntariamente, no intuito de obter serviços que não são de fato gratuitos, por haver o chamado *trade off*, ou seja, o efetivo intercâmbio dos dados pessoais pela possibilidade de, exemplificativamente, utilizar e participar de redes sociais.

A preocupação exposta doutrinariamente, ao menos até o advento do GDPR, seria a de cessão, pelos controladores dos dados, destes a terceiros, sobretudo para a condução de *profiling*, que envolve a construção de perfil no qual determinado indivíduo se encaixaria, de acordo com suas características ou padrões de conduta. Trata-se, em termos práticos, da opinião emitida por algoritmos a respeito de alguém.

Diante de tal cenário, acompanhando processo previamente identificado por Margaret Jane Radin em relação à mercantilização de aspectos da personalidade humana⁷¹, Paul Schwartz partiu, em artigo sobre propriedade e privacidade, do conceito de mercadoria – tipo de construção social, algo passível de ser reduzido a pecúnia sem modificação de valor, e intercambiável com outras mercadorias – para expor que dados pessoais comodificados seriam um pacote de informações que pode ser trocado por outra coisa⁷². A comodificação aconteceria, segundo o autor, a partir do cruzamento de dados agrupados da seguinte forma: 1) pessoas dispostas a mercantilizá-los (*trade off*); 2) empresas ou pessoas físicas que precisam fornecer anúncios sob medida; 3) atividades transnacionais, tais como hábitos de consumo; e 4) preferências particulares de cada indivíduo⁷³.

Com tal cruzamento, cria-se a chamada “metadata”, definida por Paul Schwartz como “a informação sobre a informação”⁷⁴. Assim, o autor defendeu, naquela ocasião, que uma vez transferidos os dados a alguém, seria difícil impedir a sua transmissão a terceiros⁷⁵, propondo a ideia de que dados pessoais seriam objeto de propriedade em virtude do direito de sequência, por meio do qual o vínculo ostentado acompanha o bem (*runs with the asset*) assegurando-se, com isso, a sua oponibilidade *erga omnes*⁷⁶.

Partindo de tal premissa, Paul Schwartz sugeriu, naquela oportunidade, um modelo que combinasse limitações de uso e limitações na transferência dos dados⁷⁷, à semelhança do controle ofertado, no Brasil e fora dele, por meio da instituição de direitos reais sobre um bem. Desse modo, assim como a propriedade segue o seu objeto, por meio da ambulatoriedade e da sequência, as restrições de uso e transferência seguiriam os dados pessoais mesmo quando houvesse interesse de terceiros sobre estes⁷⁸.

Também abordando o tema antes do advento do GDPR, Nadezhda Purtova, observando a natureza fluida do direito de propriedade e o fato de que os objetos a ela sujeitos não seriam estáticos – variando com base na evolução econômica, tecnológica e social –, considerou a tese da apropriação dos dados pessoais (*propertization*) uma boa alternativa ao regime de tutela baseado na responsabilidade civil, pois enquanto os remédios processuais conferidos ao

proprietário lhe permitem reaver o bem das mãos de quem injustamente o possua ou detenha, os direitos fundamentais, aos quais se deveria atribuir tutela tão ou mais consistente, fatalmente se resolverão em perdas e danos⁷⁹.

A principal semelhança entre o direito de propriedade e a privacidade dos dados pessoais talvez resida no fato de que, conforme exposto por Charles Fried, “a privacidade não seria apenas a ausência de informações sobre nós mesmos na mente dos outros; é, sobretudo, o controle que temos sobre a informação a respeito de nós mesmos”⁸⁰. Em ambos os casos, tem-se, portanto, a possibilidade de controlar o destino de algo que é considerado bem jurídico, dotado de valor econômico ou mesmo afetivo. No entanto, na intenção de melhor compreender a opção adotada pelo legislador brasileiro, é necessário admitir que, conforme já observado por Daniel Solove, o controle sobre as próprias informações é, eventualmente, identificado como uma forma de propriedade destas⁸¹. E, segundo o mesmo autor, a visão do direito de privacidade apenas como objeto de um direito de propriedade seria insuficiente, pois aquela não envolveria somente o controle individual, mas a regulação social da informação como bem jurídico, daí a insuficiência de tal modo de explicar o direito à privacidade⁸².

Na verdade, a posição adotada pelo legislador brasileiro no art. 17 da LGPD é a de perseguir tutela que abranja aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais ligados aos dados pessoais. E, relativamente à teoria da apropriação (*propertization*), no Brasil, seria desnecessário recorrer ao direito de propriedade no intuito de assegurar oponibilidade *erga omnes* à privacidade e, conseqüentemente, direito de seqüela. A Constituição Federal de 1988 define como invioláveis a vida privada e a intimidade (art. 5º, X), considerando igualmente invioláveis o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvadas, no último caso, as decorrentes de ordem judicial (art. 5º, XII).

No que tange à eficácia dos direitos elencados no rol fornecido pelo art. 5º da Constituição Federal, conforme já pontuado por Daniel Sarmento, esta vincularia não apenas os entes públicos, mas, também, os entes privados, irradiando a sua eficácia nas relações travadas entre particulares⁸³. Ao contrário do que ocorre em outros países, os direitos fundamentais são, aqui, dotados de eficácia direta e imediata, conforme evidenciado pelo art. 5º, § 1º⁸⁴. Portanto, a oponibilidade *erga omnes* como suposta exclusividade dos direitos reais foi inequivocamente superada pelo legislador constituinte.

Por outro lado, a despeito do acerto de Daniel Solove, ao reconhecer a insuficiência da percepção da privacidade dos dados pessoais apenas como objeto de um direito de propriedade, é importante observar que, esta, a exemplo do que se viu anteriormente em relação ao direito à imagem e ao nome, bem como a outros atributos da personalidade humana, não se restringe apenas a aspectos extrapatrimoniais. Portanto, qualquer mecanismo de tutela proposto pelo legislador deverá contemplar estas duas facetas, sob pena de tornar-se insuficiente. Ao que parece, foi esse o cuidado contemplado pelo art. 17, *caput*, da LGPD.

4. Titularidade x propriedade: distinção terminológica e a opção adotada pelo legislador

Enquanto a era do *marketing* direto deu margem ao surgimento de verdadeiro comércio de dados pessoais, transformando-os em bens jurídicos e operando a sua “comodificação”⁸⁵, o direito de propriedade, instituto mais relevante da “categoria de relações jurídicas que regula a apropriação e a utilização dos bens jurídicos”⁸⁶, é, na esfera funcional, como se viu anteriormente, mecanismo destinado a resolver “um problema de atribuição de bens”⁸⁷. Em outras palavras, a função do direito de propriedade, e dos direitos reais, de um modo geral, é descrever uma relação de pertencimento.

Sendo a função do direito de propriedade a alocação de bens escassos⁸⁸ ou dotados de valor – seja econômico ou afetivo –, é possível observar que ela representa as relações jurídicas travadas entre as pessoas, no que concerne ao controle de tais bens⁸⁹. Portanto, sem outro instrumento que desempenhe com mais eficiência a função de alocar recursos, é forçoso reconhecer, seguindo a orientação esposada por Pietro Perlingieri, que a noção de titularidade não está restrita ao direito de propriedade, abrangendo-o: na lição do autor, a propriedade seria apenas uma das formas deste amplíssimo conceito⁹⁰. No Brasil, o direito de propriedade é a espécie de titularidade descrita no art. 1.228 do Código Civil Brasileiro, o qual, em virtude da expansão dos bens jurídicos rumo à esfera do intangível, revela sua insuficiência e incapacidade de descrever todas as relações de atribuição ou pertencimento, que, novamente na lição de Pietro Perlingieri, refletem “o direito à aquisição de determinada situação jurídica subjetiva”⁹¹.

Espécie do gênero titularidade, a propriedade destina-se a regulamentar interesses que recaem sobre os bens de modo indistinto, definindo a medida da interferência de terceiros na situação subjetiva em questão⁹². Também em viés funcional ou promocional, a propriedade é instituto destinado a assegurar ou controlar a acessibilidade aos bens, por meio da acomodação de interesses proprietários a centro de interesses não proprietários. Por tal motivo, na lição de Joseph William Singer, inexistindo regulação de tais centros de interesses contrapostos, é impossível tutelar o direito de propriedade, independentemente de qual seja o seu objeto, por ser indispensável contar com regras claras a respeito do que pode pertencer a quem⁹³.

O conceito de titularidade exprime, portanto, não apenas a ideia de poder de controle sobre um bem jurídico mas, também e consequentemente, o sentido de atribuição do mesmo, com regras claras disponíveis acerca de seus modos de utilização e disposição. Se dados pessoais são hoje bem jurídico – daí a inequívoca necessidade de tutelá-los –, precisava o legislador determinar a quem pertencem, fosse acerca de seus aspectos extrapatrimoniais – principal justificativa da crítica dirigida por Daniel Solove aos que enxergavam a privacidade dos dados pessoais apenas como o objeto de um direito de propriedade –, fosse relativamente a seus aspectos patrimoniais, decorrentes do valor econômico que lhes foi atribuído pela sociedade digital.

Feitas tais considerações, e cientes da insuficiência do tratamento dispensado pelo Código Civil de 2002 a todas as relações jurídicas passíveis de serem

descritas como propriedade⁹⁴, é possível perceber que o legislador brasileiro optou por adotar terminologia que reflete o gênero do qual o direito de propriedade é espécie, apartando claramente os aspectos patrimoniais daqueles de cunho extrapatrimonial, ambos atrelados ao exercício da privacidade, constitucionalmente positivada como um direito fundamental.

Mas fez mais que isso: resta claro que manifestou o legislador a intenção de não apenas assegurar o controle dos dados pessoais ao seu titular – o que reflete, de algum modo, a ideia moderna de privacidade –, mas tutelá-los por meio de sua efetiva atribuição à pessoa física a quem estão atrelados, criando com isso um vínculo direto e imediato, antes peculiar aos direitos reais. Tal opção serve para demonstrar aos estudiosos do direito civil que, embora os direitos fundamentais tenham expandido o espectro das relações jurídicas que gozam de tutela prioritária, por meio da oponibilidade *erga omnes*, mesmo antes do advento da LGPD, muitos parecem não ter percebido que o pretense caráter absoluto de alguns vínculos jurídicos não é mais privativo dos direitos reais.

Portanto, a pergunta feita no título deste artigo deveria ser reformulada: ao contrário de se perquirir se a titularidade dos dados pessoais prevista no art. 17 da LGPD é um direito real ou pessoal, o correto seria indagar se se trata de relação jurídica direta, imediata e absoluta ou relação jurídica mediata e relativa, já que os direitos reais não são mais a única categoria que se enquadra na primeira opção.

Feitas tais considerações, é forçoso reconhecer que, embora, no Brasil, a propriedade seja espécie do gênero titularidade, prevista no art. 1.228 do Código Civil – reconhecendo-se, aqui, a necessidade de expandir tal conceito, ante a insuficiência dos outros disponíveis –, a titularidade prevista no art. 17 da LGPD descreve relação de pertencimento que se enquadra no mesmo gênero, recaindo diretamente sobre os dados pessoais e atribuindo ao seu titular o direito de deles dispor e o poder de controlá-los, à semelhança do que ocorre nas relações proprietárias.

A expansão da oponibilidade *erga omnes* rumo à tutela dos direitos fundamentais – categoria na qual a privacidade se insere – faz com que a distinção entre direitos reais e obrigações perca a sua relevância, pois, se aquela era o único traço verdadeiramente comum a todos os direitos reais, capaz de unificá-los e identificá-los como categoria, a sua extensão a outros ramos do direito mostra que permanecem como distinções mais relevantes as que apartam direitos absolutos dos relativos e direitos patrimoniais dos extrapatrimoniais.

Em relação a essa última, observe-se que o legislador fez questão de refleti-la no *caput* do art. 17, separando textualmente a titularidade dos dados pessoais dos direitos fundamentais a eles atrelados (liberdade, intimidade e privacidade). Com isso, consagrada está a diversidade de tutela a ser destinada a cada um destes aspectos. Ressalte-se, a respeito da proteção extrapatrimonial conferida ao direito à privacidade, que serve o referido dispositivo legal para atribuir, aos cidadãos brasileiros, um poder de controle sobre suas informações pessoais, com base no que o Tribunal Constitucional Alemão chamou, pioneiramente, de “autodeterminação informativa”. Essa expressão, conforme exposto pela referida

Corte naquela oportunidade, remete ao direito individual de controlar os próprios dados pessoais, admitindo-se, ou não, sua coleta e armazenamento⁹⁵.

No que concerne ao viés patrimonial, a defesa da privacidade deve pautar-se no lucro da intervenção, que reflete o aumento patrimonial obtido por quem, sem autorização, interfere indevidamente em situação jurídica subjetiva alheia, acarretando um acréscimo em seus ativos, diminuição no passivo ou poupança de despesas⁹⁶. A respeito deste e de sua aplicação aos aspectos patrimoniais atrelados aos direitos da personalidade, vale transcrever o entendimento já esposado pelo STJ:

O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico⁹⁷.

E ainda acerca do viés extrapatrimonial, a responsabilidade civil, por meio da reparação por danos morais – ao lado de medidas cautelares destinadas a evitar, por exemplo, o vazamento dos dados e abalos na reputação de alguém –, continuará a servir como mecanismo usual de tutela⁹⁸, nas hipóteses nas quais da coleta e utilização não autorizada de dados, advier um dano ao seu titular.

Em tempos de relações fugazes, travadas em segundos, e avanços tecnológicos que impõem aos indivíduos uma vida em ritmo frenético, a necessidade de proteger a pessoa humana em tais condições impede o civilista de manter em caixinhas apartadas categorias estanques que, por séculos a fio, permaneceram quase imutáveis. A lógica do “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa” dá lugar, hoje, à necessidade de recorrer aos institutos que se mostram mais adequados em cada situação concreta, independentemente de qual seja a sua fonte ou origem.

Como se não bastasse, a era dos bens digitais, tais como, *e.g.*, milhagens de companhias aéreas, livros em formato digital e contas eventualmente lucrativas em redes sociais, escancara a anacrônica insuficiência da propriedade descrita no Código Civil para abarcar todos os ativos patrimoniais que, hoje, em virtude da função por ela desempenhada no Ordenamento Jurídico, deveria ser capaz de abranger. Além de sua expansão rumo aos bens intangíveis ser inconteste, características antes tidas como peculiaridades do direito de propriedade são hoje atribuídas a outras espécies de direitos subjetivos. É pena, portanto, que o legislador codificado, já no início do século XXI, tenha se preocupado mais em preservar a estrutura original de um instituto tão maleável às intempéries do tempo – por “dever de ofício” – e menos em adequá-lo à sua função moderna.

Relativamente ao sistema proposto pela LGPD, se o consentimento para o uso dos dados equivale a uma forma de deles dispor, e a realidade mostra ser possível a sua cessão a terceiros sem a devida autorização, é razoável, com base nas observações antes feitas, considerar que o direito de controlá-los, assegurado por lei ao seu titular, é oponível *erga omnes*. Se acaso vivesse neste admirável mundo novo, Teixeira de Freitas certamente concordaria.

5. Conclusão

Durante muito tempo, os direitos reais foram a única categoria de direitos subjetivos que refletia um poder imediato e direto sobre o objeto da relação jurídica, bem como a oponibilidade *erga omnes*, que permitia ao titular do vínculo dirigir sua pretensão em face de qualquer pessoa que eventualmente o violasse, era espécie de tutela a eles exclusivamente destinada.

E era, justamente, a oponibilidade perante terceiros a característica efetivamente apta a unir as figuras de direito real como categoria e, além disso, apartá-las das obrigações, que tinham a irradiação de sua força obrigatória delimitada pela relatividade como máxima: estas envolveriam apenas as partes, de modo que as pretensões de qualquer uma delas só poderia ser manejada face à outra, não beneficiando ou prejudicando terceiros em nenhuma hipótese.

Com a ascensão dos direitos da personalidade e, logo após, dos direitos fundamentais, temos o surgimento de uma nova categoria de bens jurídicos que, sem apresentar qualquer semelhança com o que o legislador definia como coisa, mereciam tutela especialíssima, apta a contemplar os aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do exercício desta nova modalidade de direitos subjetivos. Tais direitos, por sua vez, à semelhança do que antes ocorria apenas com os direitos reais, também são exercidos de modo direto e imediato sobre o bem jurídico em questão – imagem, nome, privacidade etc. –, inexistindo intervenção de qualquer outra pessoa sobre o vínculo.

Diante de tal fenômeno, o legislador constituinte assegurou aos direitos fundamentais – dentre os quais figura a privacidade – a mesma oponibilidade *erga omnes* que antes destacava e identificava os direitos das coisas. Com isso, mostra-se inócua, por aqui, a preocupação da doutrina estrangeira relativamente à identificação dos dados pessoais como objeto de um direito de propriedade, no intuito de assegurar ao titular desses o direito de sequência, permitindo-lhe reaver de terceiros os dados indevidamente transferidos.

Portanto, a opção legislativa, manifestada no *caput* do art. 17 da LGPD, de tratar a pessoa física a quem os dados se vinculam como seu titular, denota a intenção de refletir que o exercício do direito ali descrito se dará de modo direto e imediato, empregando-se termo que corresponde ao gênero do qual a propriedade é espécie. Tal passagem da lei evidencia, ainda, a preocupação em demonstrar que a tutela ali conferida tem dupla natureza, restando contemplados os aspectos patrimoniais decorrentes da disposição dos dados – atribuída ao seu titular – e os extrapatrimoniais. Portanto, o referido dispositivo legal serve de exemplo da constatação, por parte do legislador, de que a distinção mais relevante para o direito civil, hoje, não é a que aparta direitos reais e obrigações, mas sim as que separam as relações jurídicas absolutas das relativas e as patrimoniais daquelas extrapatrimoniais.

Referências

ANTUNES VARELA, João de Matos. *Das obrigações em geral*. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1.

ASCENSÃO, José Oliveira de. *A tipicidade dos direitos reais*. Lisboa: Livraria Petrony, 1968.

BANNER, Stuart. *American property: a history of how, why and what we own*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento: teoria do estabelecimento comercial na internet, aplicativos, websites, segregação patrimonial, trade dress eletrônico, concorrência on line, ativos intangíveis cibernéticos e negócios jurídicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2016.

BELL, Abraham; PARCHOMOVSKY, Gideon. Property as the right to be left alone. Penn Law Legal Scholarship Repository, fev. 2018, p. 4-58.

BETTI, Emilio. *Dovere giuridico. Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1958. v. 14. p. 53-58.

CHAMOUN, Ebert. *Instituições de direito romano*. Rio de Janeiro: Forense, 1951.

CARVALHO, Orlando. *Direito das coisas*. Coimbra: Coimbra Editora, 2012.

COMPORTI, Marco. Contributo alla teoria della proprietà. Napoli: ESI, 1967.

COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das obrigações*. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2006.

DEMSETZ, Harold. *The American Economic Review*, v. 57, n. 2, maio 1967.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

FONSECA, Arnaldo Medeiros da. *Direito de retenção*. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957.

FRIED, Charles. Privacy. *Yale Law Journal*, v. 77, 1968, p. 475-493.

GINOSSAR, Shalev. *Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux*. Paris: L.G.D.J: 1960.

GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 21. ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2012.

GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório. *Direitos reais e autonomia privada: o princípio da tipicidade dos direitos reais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

HARDIN, Garret. The tragedy of the commons. In: *Science Magazine*, 13.12.1968. Disponível em: [garrethardinsociety.org]. Acesso em: 25.05.2018.

LÓPEZ. José Maria Pena. *Concepto de derecho real*. La Coruña: Tórculo Edicións, 1998.

MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria geral dos direitos reais*. São Paulo: Ed. RT, 2013.

MAIA, Roberta Mauro Medina. Vivendo nas Nuvens: dados pessoais são objeto de propriedade? In: TEPEDINO, Gustavo e MENEZES, Joyceanne Bezerra. *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema sempre novo. In: TEPEDINO, Gustavo *et alli*. *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

MESQUITA, José de Andrade. *Direitos pessoais de gozo*. Coimbra: Almedina, 1999.

MESQUITA, Manoel Henrique. *Obrigações reais e ônus reais*. Coimbra: Almedina, 2000.

MOREIRA ALVES, José Carlos. *Direito romano*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. I.

NEVES, Gustavo Kloh Muller. O princípio da tipicidade dos direitos reais ou a regra do *numerus clausus*. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Coord.). *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

NONATO, Orosimbo. *Curso de obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1.

NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1

PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil: direitos reais*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 4.

PEREIRA, LAFAYETTE RODRIGUES. *Direito das coisas*. Brasília: Senado Federal, 2004, ed. Fac-similar. v. 1.

PERLINGIERI, Pietro. *Introduzione alla problematica della proprietà*. Napoli: ESI, 1970.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2003. t. 22.

PURTOVA, Nadezhda Nickolayevna. *Property rights in personal data: a European Perspective*. Oisterwijk: Uitgeverij Box Press, 2011.

RADIN, Margareth Jane. *Contested commodities: the trouble with trade in sex, children, body parts and other things*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *El terrible derecho: estudios sobre la propiedad privada*. Trad. Luis Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 1986.

SALLEILLES, M. Raymond. *La théorie possessoire du Code Civil Allemand*. Paris: Librairie Cotillon, 1904.

SANDEL, Michael J. *What money can't buy: the moral limits of markets*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012.

SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Diritti assoluti e relativi. *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1958. v. 12.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

SARMENTO, Daniel. *Direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SOLOVE, Daniel. *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008. E-book.

SCHWARTZ, Paul. Property, Privacy and Personal Data. *Harvard Law Review*, v. 117, n. 7, 2004, p. 2056-2128.

SINGER, Joseph William. *No freedom without regulation: the hidden lesson of the subprime crisis*. New Haven and London: Yale University Press, 2015.

TARELLO, Giovanni. Il diritto e la funzione di distribuzioni dei beni. In: RODOTÀ, Stefano et alli (Org.). *Analisi economica del diritto privato*. Milão: Giuffrè, 1998.

TEPEDINO, Gustavo. *Comentários ao Código Civil: direito das coisas*. São Paulo: Saraiva, 2011.

TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, t. 1.

TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens e situações subjetivas reais: esboço de uma introdução. In: *Temas de Direito Civil* Rio de Janeiro: Renovar, 2006. t. 2.

TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. *Consolidação das leis civis*. Brasília: Senado Federal, 2003 (1876). v. 1.

TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Considerações acerca da exclusão do lucro ilícito do patrimônio do ofensor. *Revista da Faculdade de Direito – RFD – Uerj*, n. 28, p. 1-24.

VARGAS, Daniela Trejos. O princípio da publicidade. In: BODIN DE MORAES, Maria Celina. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar,

2006.

VICTOR, Jacob M. The EU General Data Protection Regulation: Toward a property regime for protecting data privacy. *Yale Law Journal*, v. 123, n. 2, p. 1. nov. 2013. Disponível em: [www.yalelawjournal.org/comment/the-eu-general-data-protection-toward-a-property-regime-for-protecting-data-privacy]. Acesso em: 22.05.2018.

WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. *Harvard Law Review*, v. 4, n. 5, p. 193-220. dec. 15, 1890.

WESTIN, A. F. *Privacy and freedom*. London: The Bodley Head, 1967.

1

.Mestre e Doutora em Direito Civil pela UERJ. Professora dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC-Rio. Advogada.

2

.TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. *Consolidação das leis civis*. Brasília: Senado Federal, 2003 (1876). v. I. p. LXII.

3

.Segundo José Carlos Moreira Alves, os romanos não definiram o direito de propriedade, dando início à distinção entre esta e o crédito apenas no campo adjetivo, ou seja, com base na tutela destinada a um e a outro. A propriedade só foi definida por juristas medievais, que partiram da distinção romana entre *actio in rem* e *actio in personam* para definir os contornos e as características do direito de propriedade (MOREIRA ALVES, José Carlos. *Direito romano*, 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. I. p. 282).

4

.Sobre o círculo vicioso no qual caiu este ramo do Direito Civil, vide a melancólica constatação de José de Oliveira Ascensão: “O Direito das Coisas, porque vai definindo, não desperta a atenção dos estudiosos; e como não desperta a atenção dos estudiosos, não se renova” (*A tipicidade dos Direitos Reais*. Lisboa: Livraria Petrony, 1968. p. 13).

5

.Diz-se que o rol de direitos reais é *numerus clausus*, por não ser conferida aos particulares a prerrogativa de criar figuras atípicas, diversas das criadas pelo legislador, única fonte criadora de tais direitos, portanto (nesse sentido, v. GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório. *Direitos reais e autonomia privada*: o princípio da tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 16).

6

.Disponível em: [www.economist.com/news/briefing/21721634-how-is-shaping-up-data-giving-rise-new-economy]. Acesso em: 20.12.2017.

7

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância*: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 62.

8

.Tal orientação doutrinária será exposta mais à frente.

9

.Sobre tal mudança de perspectiva, seja-nos consentido remeter a MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria geral dos direitos reais*. São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 302: “A distinção entre direitos reais e obrigações perde a posição central que lhe foi anteriormente atribuída, dando lugar à divisão feita

entre as situações jurídicas patrimoniais e as existenciais, resultando, de tal dicotomia, técnicas legislativas e interpretativas completamente diversas, apartando ‘o direito do ter do direito do ser’”.

10

.Em que pese a expressão direitos reais ter sido bastante difundida a partir da obra de Savigny, o Código Civil Brasileiro de 1916 empregava a denominação clássica “Direito das Coisas”, opção que foi mantida na codificação atual (nesse sentido, v. PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 4. p. 1).

11

.MESQUITA, José de Andrade. *Direitos pessoais de gozo*. Coimbra: Almedina, 1999. p. 112.

12

.As expressões são utilizadas indiscriminadamente para denominar o mesmo instituto. Enquanto o termo “obrigação” faz referência ao lado passivo do vínculo (o débito), a expressão “direito de crédito” reflete o seu lado ativo (COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das obrigações*. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2006. p. 73).

13

.PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2003. t. 22. p. 32.

14

.TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. *Consolidação das leis civis*, cit., p. LXVIII-LXIX.

15

.Tal assertiva é consequência da sujeição de tais vínculos ao princípio da relatividade das obrigações ou dos contratos, disseminado a partir da máxima disposta no art. 1165 do Código Civil Francês nos seguintes termos: “As convenções só produzem efeitos em relação às partes contratantes; elas não prejudicam terceiros e elas não lhes aproveitam, salvo no caso previsto no art. 1121” (esse dispositivo refere-se à estipulação em favor de terceiro).

16

.Daí a definição do princípio da relatividade das obrigações por meio do brocardo *res inter alios acta aliis nec nocet nec prodesse potest*.

17

.Como veremos adiante, a doutrina personalista contrapunha-se à doutrina realista ou clássica justamente por considerar inadmissível a existência de relações jurídicas entre pessoas e coisas, razão pela qual definiam os direitos reais como a relação jurídica entre o seu titular e toda a coletividade.

18

.GIORGIANI, Michele. Diritti reali (diritto civile). In: AZARA, Antonio e EULA, Ernesto. *Novissimo Digesto Italiano*. Torino: UTET. p. 748. Como veremos mais à frente, esta relação entre o titular do direito real e toda a coletividade é fruto de crítica dirigida à concepção dos direitos reais como relação direta entre pessoa e coisa.

19

.SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Diritti Assoluti e Relativi. In: *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1958. v. 12. p. 748.

20

.TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens e situações subjetivas reais: esboço de uma introdução. In: *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. t. 2. p. 139.

21

.LÓPEZ. José Maria Pena. *Concepto de Derecho Real*. La Coruña: Tórculo Edicións, 1998. p. 66-67.

22

.Diz-se que o direito adere à coisa como a lepra ao corpo (*uti lepra cuti*).

23

.TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens cit., p. 140.

24

.NONATO, Orosimbo. *Curso de obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1. p. 20.

25

.FONSECA, Arnaldo Medeiros da. *Direito de retenção*. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957. p. 12-13.

26

.No ordenamento jurídico brasileiro, tal direito encontra-se materializado no art. 1.228, *caput* do Código Civil de 2002.

27

.GINOSSAR, Shalev. *Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux*. Paris: L.G.D.J: 1960. p. 12.

28

.FONSECA, Arnaldo Medeiros da. Ob. cit., p. 13.

29

.Nesse sentido, v. NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1. p. 286.

30

.VARGAS, Daniela Trejos. O princípio da publicidade. In: BODIN DE MORAES, Maria Celina. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 394.

31

.TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens cit., p. 141-142.

32

.GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 16-17.

33

.PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições*, v. 4, cit., p. 5.

34

.GOMES, Orlando. *Direitos reais* cit., p. 16.

35

.TEPEDINO, Gustavo. Ob. cit., p. 142. No mesmo sentido, v. ANTUNES VARELA, João de Matos. *Das obrigações em geral*. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. v. 1. p. 169: “a preferência consiste no facto de o direito real sacrificar toda a situação jurídica posteriormente constituída sobre a mesma coisa, sem o concurso da vontade do titular daquele, na medida em que uma e outra sejam incompatíveis entre si (*prior tempore potior iure*)”.

36

.GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório. *Direitos reais e autonomia da vontade (o princípio da tipicidade dos direitos reais)*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 16.

37

.Há outras figuras que recebem da lei tratamento que corresponde aos direitos reais sem que, para tanto, encontrem previsão no art. 1.225, tais como a alienação fiduciária em garantia que, nos termos do art. 1.368-B, confere direito real de aquisição ao fiduciário.

38

.As duas últimas figuras passaram a integrar o rol do art. 1.225, por força da Lei 11.481/2007. Apenas a propriedade seria considerada um direito real pleno, ou direito real por excelência. As demais figuras se dividiriam entre direitos reais limitados de fruição e gozo (como o direito de superfície, o usufruto, a habitação, a concessão do direito real de uso, entre outros), direitos reais de garantia (penhor, hipoteca, anticrese e propriedade fiduciária) e direito real de aquisição (promessa irrevogável de venda). Ao explicar tal classificação, Caio Mario da Silva Pereira entende que também a posse integraria os direitos reais (*Instituições*, cit., v. 4, p. 6). O problema relativo à inclusão da posse neste rol será enfrentado oportunamente.

39

.Em que pese a adoção generalizada da expressão “princípio do *numerus clausus*”, diz-se que teríamos aqui verdadeira regra, já que, na lição de Gustavo Kloh, ele não serviria de fundamento para a estruturação do subsistema dos direitos reais, não seria aplicado por meio da ponderação e teria conteúdo pré-determinado, escapando, portanto, de uma das características mais marcantes dos princípios, que é a variabilidade de conteúdo (NEVES, Gustavo Kloh Muller. O princípio da tipicidade dos direitos reais ou a regra do *numerus clausus*. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Coord.). *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 432). A questão será enfrentada com maior riqueza de detalhes no capítulo oportuno.

40

.A respeito de tal classificação, v. MESQUITA, Manuel Henrique. *Obrigações reais e ônus reais*. Coimbra: Almedina, 2000. p. 59-60.

41

.Nesse sentido, seja-nos consentido remeter novamente a MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria* cit., p. 273.

42

.TEPEDINO, Gustavo. *Comentários ao Código Civil: direito das coisas*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 23. Grifos nossos.

43

.RODOTÀ, Stefano. *El terrible derecho: estudios sobre la propiedad privada*. Trad. Luis Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 1986. p. 57.

44

.SALLEILLES, M. Raymond. *La théorie possessoire du Code Civil Allemand*. Paris: Librairie Cotillon, 1904. p. 6.

45

.MAIA, Roberta Mauro Medina. Ob. cit., p. 217.

46

.SINGER, Joseph William. *No freedom without regulation: the hidden lesson of the subprime crisis*. New Haven and London: Yale University Press, 2015. p. 23.

47

.MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria* cit., p. 274.

48

.CHAMOUN, Ebert. *Instituições de direito romano*. Rio de Janeiro: Forense, 1951. p. 201.

49

.Ibidem, p. 200.

50

.Ibidem, p. 201. Não custa lembrar que o Professor ora citado integrou a comissão de juristas que elaborou o Anteprojeto do Código Civil de 2002, ficando responsável justamente pelo Livro III (Direito das Coisas).

51

.MESQUITA, Manoel Henrique. *Obrigações reais e ônus reais*. Coimbra: Almedina, 2000. p. 41.

52

.CHAMOUN, Ebert. *Instituições cit.*, p. 33.

53

.MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema sempre novo. In: TEPEDINO, Gustavo *et al.* *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 632.

54

.Ibidem, p. 632.

55

.Sobre a origem do problema, v. BANNER, Stuart. *American Property: a history of how, why and what we own*. Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 132.

56

.COMPORTI, Marco. *Contributo alla teoria della proprietà*. Napoli: ESI, 1967. p. 138.

57

.A expressão é empregada por SANDEL, Michael J. *What money can't buy: the moral limits of markets*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012. p. 113.

58

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância cit.*, p. 82. Nessa passagem, o autor se refere à prática identificada como *profiling*, que será mencionada mais adiante.

59

.Tal modo de enxergar o direito de propriedade disseminou-se com maior velocidade a partir de dois artigos publicados em datas muito próximas nos Estados Unidos. O primeiro, de Harold Demsetz, parte da premissa de que, no mundo de Robinson Crusoe, sem finitude ou disputa pelos bens, a propriedade não teria sentido, para, em seguida expor que a mesma pode ser definida como um feixe de direitos, cuja finalidade é organizar o controle sobre bens escassos (DEMSETZ, Harold. *The American Economic Review*, v. 57, n. 2, maio 1967, p. 347 e ss.). Tal artigo, considerado “um divisor de águas” no estudo do direito de propriedade por alguns autores (nesse sentido, v. BELL, Abraham e PARCHOMOVSKY, Gideon. Property as the right to be left alone. *Penn Law Legal Scholarship Repository*, fev. 2018, p. 13. Disponível em <scholarship.law.upenn.edu>. Acesso em 24.05.2018), foi seguido pelas considerações publicadas por Garret Hardin em artigo publicado na Revista *Science* em 1968. Na ocasião, o famoso biólogo ilustrou as ideias de um matemático chamado William Forster Lloyd a respeito do controle de natalidade por meio de parábola que denominou de *Tragédia dos Comuns* (“The tragedy of the commons”): Imagine-se um pasto aberto a todos. Cada pastor, com o tempo, percebe que quanto maior for seu rebanho, maiores serão seus ganhos. E aí está o aspecto trágico, pois, num cenário

de total liberdade, sem controle externo, só se torna possível maximizar os lucros com condutas que conduzirão à escassez. Findo o pasto, de nada terá adiantado aumentar os rebanhos (The tragedy of the commons. In: *Science Magazine*, 13.12.1968. Disponível em: [garrethardinsociety.org]. Acesso em: 25.05.2018). A parábola tem sido usada por juristas desde então no intuito de explicar que a formalização do uso de um bem nas mãos de um só por meio da propriedade torna a sua utilização mais eficaz (BELL, Abraham e PARCHOMOVSKY, Gideon. Property as the right to be left alone. Ob. cit., p.13).

60

.BETTI, Emilio. Dovere Giuridico. *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1958. v. 14. p. 58. No mesmo sentido, e a respeito dos critérios adotados para tanto, v. TARELLO, Giovanni. Il diritto e la funzione di distribuzioni dei beni. In: RODOTÀ, Stefano et alli (Org.). *Analisi economica del diritto privato*. Milão: Giuffrè, 1998. p. 55-58.

61

.A impossibilidade de possuir não é óbice à qualificação de algo intangível como bem jurídico, como se pode extrair da seguinte passagem: “Se há, atualmente, quem considere que a informação ou mesmo o tempo são bens jurídicos, não é mais possível esperar que o instituto da posse seja capaz de explicar todos os desdobramentos de tais vínculos, sendo necessário, portanto, recorrer a outras alternativas” (MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria* cit., p. 283).

62

.RODOTÀ, Stefano. *El terrible derecho* cit., p. 58.

63

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância* cit., p. 132.

64

.Disponível em: [https://pt-br.facebook.com/legal/terms]. Acesso em: 01.12.2018.

65

.A esse respeito, v. WESTIN, A.F. *Privacy and freedom*. London: The Bodley Head, 1967, *passim* e POSNER, Richard. Privacy, Secrecy and Reputation. *Buffalo Law Review*, n. 28, v. 1, 1978-1979, p. 7-9.

66

.Sobre o tema, v. DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 363 e MAIA, Roberta Mauro Medina. Vivendo nas Nuvens: dados pessoais são objeto de propriedade? In: TEPEDINO, Gustavo e MENEZES, Joyceanne Bezerra. *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 669-698.

67

.Sobre o tema, v. PURTOVA, Nadezhda Nickolayevna. *Property rights in personal data: a European Perspective*. Oisterwijk: Uitgeverij. Box Press, 2011. p. 93-94.

68

.Há, inclusive, quem defenda que o GDPR adotou a tese da apropriação ou “propertização” dos dados pessoais. Nesse sentido, é possível remeter a VICTOR, Jacob M. The EU General Data Protection Regulation: Toward a property regime for protecting data privacy. *Yale Law Journal*, v. 123, p. 1, nov. 2013. Disponível em: [www.yalelawjournal.org/comment/the-eu-general-data-protection-toward-a-property-regime-for-protecting-data-privacy]. Acesso em: 20.10.2018.

69

.WARREN, Samuel D. e BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. *Harvard Law Review*, v. 4, n. 5, p.194.

70

.BELL, Abraham e PARCHOMOVSKY, Gideon. Property as the right to be left alone. *Penn Law Legal Scholarship Repository*, fev. 2018, p. 13. Disponível em: [scholarship.law.upenn.edu]. Acesso em: 24.05.2018.

71

.RADIN, Margaret Jane. *Contested commodities: the trouble with trade in sex, children, body parts and other things*. Cambridge: Harvard University Press, 1996, *passim*.

72

.SCHWARTZ, Paul. Property, Privacy and Personal Data. *Harvard Law Review*, v. 117, n. 7, 2004, p. 2056.

73

.Ibidem, p. 2070.

74

.Ibidem, p. 2070.

75

.Ibidem, p. 2090-2091.

76

.Alguns atributos dos direitos reais apresentam certa relação de causa e efeito: como o direito recai sobre a própria coisa, este lhe é inerente, a ela aderindo e com ela caminhando independentemente de onde se encontre (ambulatoriedade). A consequência dessa aderência é a sequele (poder de reivindicar), corolário processual da oponibilidade perante terceiros. Nesse sentido, v. MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria cit.*, p. 264.

77

.SCHWARTZ, Paul. Property cit., p. 2097.

78

.Ibidem, p. 2097.

79

.PURTOVA, Nadezhda Nickolayevna. *Property rights* cit., p. 59 e ss. Exemplo da insuficiência da responsabilidade civil para a efetiva tutela do direito à privacidade seria o caso Dwyer v. American Express, quando a Corte do Estado de Illinois entendeu que inexistiria dano decorrente da prática de *profiling* (N. 1-92-3944 Appellate Court of Illinois, First District, First Division, June 30, 1995).

80

.FRIED, Charles. Privacy. *Yale Law Journal*, v. 77, 1968, p. 482. No original: "Privacy is not simply an absence of information about us in the minds of others; rather it is in the control we have over information about ourselves".

81

.SOLOVE, Daniel. *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008. E-book, pos. 327/3424.

82

.Ibidem, pos. 350/3424.

83

.SARMENTO, Daniel. *Direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 279.

84

.O referido dispositivo legal determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

85

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 132.

86

.TEPEDINO, Gustavo. *Comentários ao Código Civil: direito das coisas*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 23.

87

.BETTI, Emilio. Dover Giuridico. *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1958. v. 14, p. 58.

88

.O conceito de escassez abrange a ideia de infungibilidade.

89

.DEMZETZ, Harold. Toward a theory of property rights. *The American Economic Review*, v. 57, n. 2, maio 1967, p. 347.

90

.PERLINGIERI, Pietro. *Introduzione alla problematica della proprietà*. Napoli: ESI, 1970. p. 92.

91

.Ibidem, p. 92.

92

.Ibidem, p. 154.

93

.SINGER, Joseph William. *No freedom without regulation: the hidden lessons of the subprime crisis*. New Haven: Yale University Press, 2015. p. 21.

94

.A esse respeito, v. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento: teoria do estabelecimento comercial na internet, aplicativos, websites, segregação patrimonial, trade dress eletrônico, concorrência on line, ativos intangíveis cibernéticos e negócios jurídicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 113 e ss.

95

Sobre o tema, v. VIEIRA, Tatiana Malta. *O direito à privacidade na sociedade da informação, efetividade desse direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 27.

96

.TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Considerações acerca da exclusão do lucro ilícito do patrimônio do ofensor. *Revista da Faculdade de Direito – RFD – UERJ*, n. 28, p. 2.

97

.STJ, 3ª T., REsp 1.698.701/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08.10.2018.

98

.Sobre tal diversidade de caminhos, vale transcrever a seguinte passagem: “Assim, enquanto a divulgação de dados pessoais poderia destruir a reputação de uma pessoa e causar-lhe danos materiais ou morais – sendo o dano, nas hipóteses que dão ensejo à responsabilidade civil, 'o elemento que determina a medida da indenização' – a sua mera utilização para fins diversos dos autorizados pelo titular poderia acarretar um enriquecimento ilícito por parte de quem processa ou controla os dados. Em tais hipóteses, não se exigiria, portanto, uma efetiva diminuição no patrimônio da vítima, como ocorre na responsabilidade civil, bastando que alguém enriqueça às custas de outrem sem causa capaz de justificar tal enriquecimento, nos termos do art. 885 do Código Civil” (MAIA, Roberta Mauro Medina. *Dados pessoais* cit., p. 692).

Capítulo 6. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica?

Joyceane Bezerra de Menezes ¹

Hian Silva Colaço ²

Introdução

Seguindo a esteira dos países que se anteciparam em tutelar os dados pessoais,³ o Brasil, com certo atraso, promulgou a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, cuja vigência foi postergada para maio de 2021.⁴ Visa à regulamentação das atividades de coleta e tratamento dos dados pessoais – material que constitui um verdadeiro ativo comercial em uma economia baseada em dados (*data driven economy*)⁵. A todo instante, somos chamados a depositar as informações pessoais, inclusive aquelas de cunho mais íntimo, para que possamos interagir em rede,⁶ firmar negócios jurídicos ou mesmo completar as pesquisas sobre matérias do nosso interesse.

A informação se tornou uma moeda de troca nas interações sociais e comerciais na *sociedade da informação*, expressão cunhada por Robert Castells.⁷ Conjugadas, a evolução da internet e da sociedade provocaram uma profunda e inquestionável transformação na dimensão política de nossas vidas. O poder é exercido para produzir e difundir conteúdos de informação, sob o controle de interesses específicos, mostrando que a *internet* não é um instrumento de liberdade.⁸ Assim é que a sociedade em rede se imbrica com o designado Estado de Vigilância, ameaçando a democracia pela intrusão dos governos e das grandes empresas nos domínios da privacidade de terceiros, sejam eles atores públicos, sejam privados.⁹ Episódios recentes, a exemplo do escândalo envolvendo a rede social *Facebook* e o fornecimento de informações de usuários para a empresa de *big data* e *marketing* político *Cambridge Analytica*,¹⁰ deram conta do quão necessária é a regulamentação do tratamento dos dados pessoais em todo o mundo.

Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, nacionais e estrangeiras criam, quotidianamente, “perfis de personalidade que permitem classificar e discriminar os indivíduos consoante seus hábitos, características biológicas, preferências e convicções, em flagrante ameaça não só à privacidade, mas, também, à própria dignidade humana.”¹¹ Uma vez que o tratamento de dados pessoais é um fenômeno mundial praticado,¹² a proteção desses dados também tem merecido atenção especial e muitos países tem reconhecido novas dimensões do direito à privacidade como o direito à autodeterminação informativa,¹³ assim considerado como a faculdade de o indivíduo decidir, por si só, sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais. A totalidade dessas informações que circulam sobre a pessoa acaba por configurar um verdadeiro corpo virtual – extensão da personalidade que deve receber idêntica proteção.¹⁴

Ainda que houvesse, no Brasil, alguns dispositivos esparsos voltados a tutela dos dados pessoais sob algum aspecto,¹⁵ não havia uma especialidade e uma coesão suficiente capaz de atender aos princípios internacionalmente aceitos. Foi a partir da LGPD que a matéria passou a receber disciplina exaustiva, inclusive quanto ao tratamento de dados nos meios digitais, com o objetivo primordial de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A despeito da preocupação com a tutela dos dados pessoais, continua havendo espaços nos

quais a abordagem da LGPD não se aplica, como os casos previstos pelo art. 4º – nos quais não se vislumbram os riscos iminentes à sociedade de rede.

Cumpra ao presente texto analisar as hipóteses de não incidência da LGPD, observando as razões dessa não aplicação e o modo como se pode, naquelas situações, garantir a tutela da pessoa.

1. Sociedade da informação e tutela da privacidade: emergência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, de 14.08.2018)

Seguindo o modelo proposto pela lei, inexistem dados pessoais irrelevantes, diante do processamento eletrônico e ubíquo de dados na sociedade da informação.¹⁶ Todos esses dados são projeções da personalidade e como tais devem ser considerados e tutelados. Sob essa perspectiva, a LGPD trará impacto significativo para as empresas que terão de ajustar suas atividades à lei.

Conquanto sejam projeções da personalidade humana, os dados pessoais são elementos fundamentais para o desenvolvimento das empresas. Facilitam o planejamento de suas atividades, a concepção, a execução e o fornecimento de seus produtos e serviços, de modo a alcançar o público alvo mais eficientemente. Nessa medida, foram considerados verdadeiros ativos empresariais, comumente comercializados sem qualquer satisfação ao titular.

No âmbito do poder público, também são muito utilizados, em especial, para a formulação de políticas públicas. A coleta e o tratamento de dados pelo poder público é, inclusive, prática anterior à do setor privado.¹⁷ Não seria possível idealizar e executar as políticas públicas sem o conhecimento do perfil da população e suas demandas. Nos dias atuais, as chamadas *smartcities*,¹⁸ qualificadas pelo elevado grau de automação e conexão com os administrados por meio da *internet*, seriam inimagináveis sem o recurso a esses dados.¹⁹ Portanto, o uso das informações pessoais pelo poder público também não pode ser autorizado de modo indiscriminado e, por essa razão, está sujeito aos imperativos da LGPD.

Doravante, os dados pessoais, ou seja, as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, inciso I), só serão manejados pelo setor público ou privado, mediante autorização do respectivo titular que, na dicção da lei, é a própria pessoa a quem os dados se referem (art. 5º, inciso V). A lei também criou as figuras do controlador e do operador como agentes que atuam no processo de tratamento dessas informações. O controlador é aquele que decide sobre o tratamento, enquanto o operador é aquele o executa sob sua ordem (art. 5º, incisos VI e VII).

O modelo de tratamento de dados instituído pela LGPD se ampara nas seguintes características básicas: a ampliação do conceito de dado pessoal; o respeito à base legal; e o legítimo interesse como hipótese autorizativa e necessidade de realização de um teste de balanceamento de interesses.

Conceitua dados pessoais como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.” Destaca os dados sensíveis como aquelas informações sobre “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (art. 5º, II). No conceito de dados, inclui até aquelas informações que não se prestam a identificar a pessoa quando usadas isoladamente (IP, faixa etária, altura etc.), mas que poderão fazê-lo se conjugadas com outros dados, são, portanto, identificáveis”. Diferente do que chama de dado anonimizado, que é aquele que não implicará, em definitivo, a identificação do seu titular, considerando a

utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento (art. 5º, III).

O tratamento desses dados corresponde a “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, inciso X). E, segundo a LGPD, todo e qualquer tratamento de dados deve respeitar a base legal definida no art. 7º.

Anteriormente à lei, essa prática estava situada no vasto campo da licitude, sendo integralmente permitida até que esbarrasse nos limites do que estivesse expressamente proibido por lei. Agora a situação se inverteu e o tratamento dos dados passa a se sujeitar a objetivos, finalidades, interesses e princípios próprios. Somente será possível quando autorizado pelo titular e se estiver em conformidade com as dez exigências ou bases legais, assinaladas no art. 7º²⁰ que, relativamente aos dados sensíveis, serão ampliadas pelo art. 11.²¹

O legítimo interesse seria a terceira inovação do modelo de proteção dos dados que acaba por flexibilizar o sistema de tratamento aparentemente restrito (art. 7º, IX). Trata-se de uma categoria aberta capaz de albergar qualquer interesse protegido pela ordem jurídica, que, uma vez sopesado com os direitos do titular dos dados, poderão produzir solução mais aberta. Se, na técnica de sopesamento, os interesses do titular superarem o interesse do controlador, o tratamento de dados não poderá operar com suporte nessa base legal.²²

Algumas poucas matérias não sofrem a incidência da LGPD e estão restritamente arroladas no art. 4º da lei, quais sejam, o tratamento de dados pessoais por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; e aquele que se realiza para fins a) jornalístico, artístico ou acadêmico (embora, nesse caso, continue a exigir o consentimento); b) de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais ou c) dados em trânsito, ou seja, “aqueles que não tem como destino Agentes de Tratamento no Brasil”.

2. Tensão entre Privacidade, Informação e Segurança

A tensão entre privacidade e segurança acompanha o surgimento da internet quando, cedo, perceberam-se os riscos da utilização de dados pessoais na formulação de decisões automatizadas pelo Estado.²³ Atualmente, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da Internet das Coisas (IoT)²⁴ potencializou ainda mais essa tensão. À medida que a hiperconectividade entre os diversos dispositivos, objetos e sensores suscita riscos à privacidade dos titulares dos dados manipulados e tratados, a heterogeneidade dos meios de circulação da informação impulsiona os Estados-nação ao desenvolvimento de novas estratégias de vigilância e de segurança.

Com a pulverização dos ataques terroristas, em geral reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), e as decisões da Apple e do Google em habilitar a criptografia de ponta a ponta nos dispositivos móveis, multiplicaram-se os questionamentos envolvendo os interesses colidentes: de um lado, a garantia da privacidade e o desenvolvimento de sofisticados mecanismos de criptografia das informações; e, de outro, a preocupação com os limites que tais tecnologias imporão aos sistemas de vigilância e de segurança.

O Estado Vigilância avança²⁵ e a tecnologia responde com novas formas de criptografia para ampliar a proteção das informações dos cidadãos. De igual modo, a legislação também tenta estabelecer-lhe novos limites, deixando o governo vigilante em uma “zona de

obscurcimento”²⁶ que pode dificultar os serviços de inteligência necessários ao enfrentamento do *cyber* terrorismo e à investigação dos crimes.

A segurança das redes e da informação é um outro ponto que merece atenção. Destaca a posição vanguardista da União Europeia em regular a matéria por meio de legislação específica e instituir uma agência voltada especificamente para coordenar as ações tendentes a garantir a segurança da informação, em benefícios dos cidadãos, do setor privado e do setor público.²⁷ Pelo Regulamento 526/2013, a segurança das redes é compreendida como “a capacidade de uma rede ou de um sistema de informação para resistir, com um determinado nível de confiança, a eventos acidentais ou a ações ilícitas ou maliciosas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados armazenados ou transmitidos e dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através dessa rede ou desse sistema.” (art. 1º, item 3, Regulamento 526/2013).

Grosso modo, o regulamento visa à proteção da privacidade por meio de uma política de segurança das informações capazes de inspirar a confiança daqueles que interagem em rede, notadamente o cidadão comum.²⁸ Sob esse escopo as cortes europeias têm avançado na garantia da proteção da privacidade, transbordando do direito à autodeterminação informativa, para cunhar um direito à confidencialidade e à integridade dos sistemas informáticos que ficou conhecido como *direito fundamental informático*.²⁹

Voltando ao debate sobre criptografia, essa temática foi objeto de audiências públicas, no Brasil, em especial no Supremo Tribunal Federal, em virtude do processamento da ADPF 403³⁰ e da ADI 5.527³¹, quando se discutiu sobre a possibilidade de acesso, mediante interceptações, às conversas e às mensagens enviadas por meio do aplicativo *WhatsApp*, protegidas pela criptografia de ponta a ponta (*end to end*)³². Na oportunidade, indagava-se sobre a possibilidade de imposição, por ordem judicial, da obrigação do espelhamento dos conteúdos das comunicações (criação de *back-door*).³³

Conquanto seja complexa a tensão entre privacidade e segurança, o estado de vigilância terá que conviver com o sistema de direitos humanos e fundamentais e os limites que são impostos. Nos estados democráticos de direito não haverá lugar para uma solução panóptica *benthamiana*, na qual todas as pessoas são tratadas como um *homem de vidro* sob vigilância permanente e universal quanto aos seus dados, seu comportamento, suas comunicações, suas escolhas, e até mesmo quanto ao seu próprio corpo, no tocante às informações biométricas.

Ainda que o legislador faça a mediação dos valores segurança e privacidade para sobrepor um ao outro em determinadas hipóteses, estima-se que considere, nessa tarefa, a unidade dos valores constitucionais e a importância do princípio dignidade da pessoa humana para que a solução tenha validade material e formal. No plano abstrato, os valores em jogo, privacidade ou segurança, possuem igual peso axiológico; somente numa dada situação concreta, quando estiverem em colisão, o intérprete determinará qual deles prevalecerá. Poderá, inclusive, recorrer à técnica de juízo valorativo dos atos particulares ou apreciação do *merecimento de tutela*,³⁴ buscando garantir, tanto quanto possível, a ambos os interesses.³⁵

Fato é que as transformações promovidas pela IoT avançam em um cenário repleto de incertezas que certamente produzirão muitos conflitos envolvendo os interesses mencionados.³⁶ Estima-se que, em 2020, a quantidade de objetos conectados e em possível interação com a inteligência artificial – AI e com a *Big Data*,³⁷ poderá chegar a 50 bilhões³⁸ e com uma enorme capacidade para coletar, transmitir, armazenar e compartilhar informações. Nesse processo de virtualização da vida,³⁹ é fundamental ajustar as bases conceituais do direito à privacidade que ultrapassou as tradicionais esferas de proteção à vida privada (segredo, sigilo e intimidade).⁴⁰ A LGPD se ocupou de tratar do direito à autodeterminação

informativa (art. 2º, II, LGPD)⁴¹ e nisto acompanhou as reflexões de Rodotà⁴² sobre a tutela da privacidade como o “direito de manter o controle sobre as próprias informações e de determinar as modalidades de construção da própria esfera privada”. Ampliou a tutela tradicional da privacidade do trinômio “pessoa-informação-sigilo” para uma tutela que envolve “pessoa-informação-circulação-controle”.

Curioso observar que a lei menciona o termo *privacidade* em 8 (oito) dispositivos, enquanto a palavra *segurança* é referida em 22 (vinte e duas) passagens. Porém, na maior parte das vezes que menciona o termo *segurança*, refere-se à proteção dos dados. Somente em 2 (duas) passagens, o vocábulo é usado como um interesse possivelmente colidente à privacidade – tal como se verifica no art. 4º, inciso III, alíneas *a* e *c*, quando excepciona a aplicação da lei. Passemos a analisar as hipóteses em que a privacidade não recebe a tutela da LGPD.

3. Matérias que não sofrem incidência da LGPD

Premissa básica do constitucionalismo moderno informa que os direitos não são absolutos. Por essa razão, a privacidade não se sobrepõe, aprioristicamente e em abstrato, aos demais direitos e valores constitucionalmente positivados. No Brasil, ao tempo em que o texto constitucional acolhe a privacidade (art. 5º, X), também prevê, promove e garante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito à informação e a segurança (art. 5º, IV IX e XIV; art. 220). No âmbito da segurança, destaca a segurança pública que se estabelece como um direito social no art. 6º, e como responsabilidade de todos no art. 144.

No vasto campo das liberdades, a Constituição Federal também reservou espaço necessário à liberdade de aprender e ensinar (art. 206, inciso II) para assegurar condições mínimas à criatividade tão essencial ao processo de conquista e expansão do conhecimento.

Considerando a importância de todos esses valores constitucionais e o aspecto finalístico da LGPD, que é a tutela da privacidade em face do tratamento de dados das pessoas naturais no contexto da sociedade de informação e do Estado de vigilância, haverá espaços infensos à sua incidência. Em termos mais gerais, a lei protege⁴³ a pessoa dos agentes do mercado de consumo e da vigilância dos governos, deixando a sua margem exceções que primam pelo interesse privado ou por um interesse público relevante, quando a matéria seguirá disciplina própria de outras leis especiais⁴⁴ ou será objeto de apreciação na unidade do ordenamento jurídico.

Nessa medida, o art. 4º⁴⁵ excepciona a sua aplicação, dispondo que não se prestará à regulação do tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico ou acadêmicos; ou ainda àqueles que se fazem para fins exclusivos de segurança e repressão penal. Também não se aplica aos dados coletados e tratados fora do país que não sejam manejados no território nacional.

3.1. Tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos

De acordo com o art. 4º, inciso I, a LGPD não incidirá no manejo de dados pessoais realizado por pessoa natural, sem fins econômicos e para finalidade exclusivamente particular.

A comunicação humana não se faz sem a troca de informações e, quando essa interação se dá entre sujeitos paritários, no âmbito das relações pessoais, sem finalidade econômica ou profissional, estima-se que não haverá grande assimetria de informações. Ainda que seja possível a violação à privacidade nesses casos, não haverá a necessidade de aplicação de

uma lei cujo fim primordial é o de tutelar a privacidade da pessoa natural em relações profundamente díspares como aquelas que se estabelecem no âmbito da sociedade de redes, na qual o poder informacional é dominado pelos agentes econômicos e/ou pelo próprio Estado, organizados como pessoas jurídicas de direito privado ou público.

A cada vez que se conhece alguém, é possível concluir a conversa com a troca de informações pessoais como nome, endereço de *e-mail* ou o número do telefone. Se o relacionamento avançar um pouco mais, é possível que essa troca se intensifique por meio de mensagens eletrônicas, *e-mails*, bilhetes, cartas que carregarão novos dados, muitos dos quais qualificados como sensíveis: orientação religiosa, sexual, opiniões políticas etc.

Independentemente do veículo que conduz as informações, poderão ser equiparados às antigas (mas não extintas) cartas que, segundo Roland Rixecker, constituem um “meio de comunicação confidencial das ideias e sentimentos indispensável para o tráfego do Mundo e da vida (...) o direito às cartas é um dos lados mais importantes do direito das pessoas, ainda que se saiba muito pouco sobre ele (...)”.⁴⁶ A carta escrita em papel e enviada ao destinatário passa a ser propriedade deste, ainda que o teor ali registrado envolva o direito autoral do remetente e outros aspectos da sua intimidade, tutelados como direitos de personalidade.⁴⁷

No Brasil, as cartas-missivas constavam expressamente no rol das obras intelectuais protegidas pelo direito autoral na Lei 5.988/1973. Com a Lei 9.610/1998, embora já não estejam enumeradas no rol do art. 7º como uma obra intelectual protegida, refletem a criatividade do seu autor e, por essa razão, a sua publicação está condicionada a sua autorização (art. 34).⁴⁸ Como dispõe Carlos Alberto Bittar, a autoria do texto implica a titularidade de um direito autoral moral, justificando a tutela de todos os aspectos da personalidade ali consignados.⁴⁹

Embora não haja na nossa legislação uma referência expressa às cartas confidenciais, o segredo continua merecendo a devida proteção como uma das esferas da privacidade.⁵⁰

Assim, para determinar se a carta é ou não confidencial, teorias distintas podem ser aplicadas:⁵¹ a primeira, de orientação subjetivista, diz que a confidencialidade dependerá da vontade declarada do autor; a segunda, de orientação objetivista, diz que a confidencialidade se deduz do teor da carta, independentemente da vontade declarada de quem escreveu o texto. Uma terceira e última teoria, a do direito de personalidade, impõe a confidencialidade a partir do seu teor e de alguma intervenção do autor.

A declaração expressa do remetente em considerar a carta confidencial não poderá vincular o destinatário se nele criar alguma adstrição injusta, como no exemplo da correspondência injuriosa, ofensiva; que trouxer um conteúdo difamatório contra terceiros; ou anunciar a prática de um crime etc. Nessas hipóteses, o destinatário poderá tomar as providências necessárias, ainda que impliquem a quebra do sigilo.

Portanto, a confidencialidade dependerá de um conjunto de elementos a serem considerados igualmente e não pode ser um trunfo do autor da comunicação para esconder a prática de ilícitos, manietando o destinatário de qualquer possibilidade de reação. Por outro lado, admitindo-se a sua natureza confidencial, uma divulgação indevida implicará a possibilidade de reparação de eventuais danos patrimoniais e a compensação de danos morais, além das medidas judiciais pertinentes para fazer cessar ameaça ou lesão de direitos.

Às cartas podem ser comparados os *e-mails*, mensagens e outros escritos sobre a pessoa que tenham esse tom da confidencialidade ou possam resvalar negativamente na esfera da sua intimidade e vida privada.

Todo material pertinente aos dados do interlocutor pode ser colecionado, intencionalmente ou não, por aquele que o recebe. Há pessoas que mantêm gravadas as conversas de *Whatsapp* e nunca apagam as mensagens recebidas em suas caixas de e-mail, mantendo um rico acervo sobre a vida pessoal (e profissional) dos seus interlocutores. Além desse material que fica disponível nos dispositivos informáticos pessoais (computadores ou aparelho de telefonia celular), é possível que também colecionem material impresso, findando por reunir condições para formar um verdadeiro dossiê sobre o outro. Mesmo que detenha lícitamente essas informações, não poderá delas fazer uso indevido, tal como se orienta quanto às cartas. Será lícito ao destinatário, porém, o uso desse material para instruir processos administrativos e judiciais relativos a seu interesse (art. 34, Lei de Direitos Autorais).

Além das cartas, e-mails e mensagens, os casais de namorados ou cônjuges e companheiros realizam, não raro, uma narrativa de sua história em álbuns físicos ou virtuais, a tudo ilustrando com fotos e/ou vídeos. Os pais fazem verdadeiras biografias dos filhos nessas novas espécies de álbuns, assentando, por vezes, prosaicas e sensíveis informações. Até no momento final da vida, quando se fazem livretos sobre o falecido, para distribuição na missa de sétimo dia, compilam-se informações pessoais. Fora tudo isso, as pessoas mantêm e alimentam seus perfis em redes sociais com informações sobre si e sobre aqueles que lhes são próximos sem muita preocupação.

Considerando que o conceito de tratamento de dados envolve “a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (art. 5º, X, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018), pode-se inferir que a pessoa natural realiza esse tipo de operação com os dados dos seus interlocutores em todas as situações acima citadas.

Embora essa compilação e “tratamento” de dados não esteja sujeita à LGPD, não poderá ser usada para gerar lesão à personalidade do titular, malferindo-lhe a privacidade, a imagem ou a honra, sem sujeitar o agente às consequências previstas no ordenamento jurídico.⁵² *Grosso modo*, a malversação desse material poderá resultar em dano moral e até mesmo em ilícito penal.

Conforme se lê no art. 20 do Código Civil, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou publicação, exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas por ela própria, sem prejuízo da indenização cabível se houver ofensa à honra, à boa fama, à respeitabilidade ou se forem dirigidas a fins comerciais.⁵³ Em se tratando da pessoa morta ou ausente, a legitimidade para requerer a proteção recairá sobre o cônjuge, ascendentes ou descendentes. De igual modo, a Constituição Federal reconhece o direito fundamental à vida privada (art. 5º, X).

Após o episódio sofrido pela atriz Carolina Dieckmann, que teve imagens íntimas suas vazadas do seu *notebook*, um problema recorrente sofrido por muitas pessoas foi posto em evidência, precipitando a alteração do Código Penal Brasileiro para incluir o tipo penal específico. A Lei 12.737/2012 incluiu o artigo 154-A, definindo o crime de invasão de dispositivo informático, que consiste na intrusão desautorizada em dispositivos móveis (*smartphones*, computadores, *notebooks*, *tablets*) do titular. Ainda que essa operação venha a ser realizada pelo cônjuge ou pelos pais de filho maior, a conduta será considerada um ilícito penal nominado por *invasão de dispositivo informático*.⁵⁴

3.2. Tratamento de dados para fins jornalísticos e artísticos

A liberdade de imprensa ou liberdade jornalística é uma atividade indispensável à sociedade democrática. É corolário dos direitos fundamentais a *liberdade de pensamento e liberdade de expressão*, indispensáveis à ampla tutela da personalidade.⁵⁵ Mas tem previsão

autônoma no art. 220 e segs., da CF, englobando as dimensões de informar, buscar informação e de ser informado, mediante uma atuação crítica e investigativa.⁵⁶ De acordo com o texto constitucional, envolve “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo”, não podendo sofrer restrições ou censura prévia, seja ela de natureza política, ideológica ou artística (CF, art. 220, § 2º). Não haverá liberdade de imprensa pela metade ou sob censura prévia, seja aquela originária do legislativo, do executivo ou mesmo do poder judiciário.

É pela liberdade de imprensa que se consolidam os espaços de comunicação social e o amplo debate sobre as mais variadas matérias de interesse do cidadão. Na busca pela verdade factual, a imprensa não apenas promove a consolidação da cidadania como exerce importante função fiscalizadora dos agentes que exercem o poder político, oferecendo uma alternativa à narrativa oficial do governo sobre os temas que interferem na esfera política e jurídica de todos. Segundo se extrai do voto do Ministro Ayres Britto na ADPF 130, a liberdade de imprensa é profundamente imbricada com o exercício da vida democrática,

a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Falo da democracia como categoria jurídico-positiva (não simplesmente filosófico-política), que em toda Constituição promulgada por uma Assembleia Constituinte livremente eleita consubstancia o movimento, o fluxo ascendente do poder de governar a pólis; quer dizer, o poder de governar toda a coletividade como aquele que vem de baixo para cima, e não de cima para baixo da escala social. A implicar, por evidente, prestígio das bases governadas e limitação das cúpulas governantes. Um tirar o povo da plateia para colocá-lo no palco das decisões que lhe digam respeito.

Embora a imprensa não esteja sujeita a embaraço e controle prévio no Brasil, a liberdade de informação e expressão que lhes são concernentes não são valores absolutos. Exige-se que a atividade de informar siga o dever de objetividade, sem distorções ou falsidades movidas por inclinações pessoais e ideológicas, procurando fontes diversificadas e idôneas de informação. Na hipótese de erro, espera-se a imediata retificação da informação equivocada, com o mesmo destaque antes atribuído.”⁵⁷ Trecho da ementa da decisão que julga a ADPF 130 dispõe que “A liberdade de informação é tratada pela Constituição Federal como expressão sinônima da pertinente à atividade jornalística *não se superpõe à esfera existencial das pessoas*, continua cedendo ao respeito dos direitos de personalidade.” (grifo nosso).

No contexto da sociedade de rede, na qual todas as pessoas lançam informações e emitem opiniões, nem todas serão consideradas atividade jornalística para o fim de merecer tanta imunidade. Entende-se por atividade jornalística aquela que é desenvolvida pelo profissional do jornalismo e dos órgãos de comunicação na divulgação das notícias.⁵⁸ No conceito de informação jornalística, e, portanto, com a mesma imunidade da liberdade de imprensa, o STF considerou os programas humorísticos, as charges e as caricaturas que põem ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos em circulação.⁵⁹ É nesse sentido que muitos tribunais não têm considerado como ofensivos à imagem da pessoa pública a expressão de determinados programas humorísticos ou charges.⁶⁰

Enquanto a liberdade de informar está mais vinculada à persecução e à divulgação da verdade factual, pautada em informações corretas e verossímeis,⁶¹ a liberdade de expressão pode envolver um certo juízo crítico ou valorativo. O direito ao exercício de crítica é ínsito à liberdade de imprensa, como se deduz do voto do Ministro Cales Ayres Britto, no ADI 4.452, julgado em 2 de setembro de 2010, sobre o conceito e a importância do pensamento crítico:

que é aquele mentalmente elaborado ou fruto de uma profunda reflexão. O pensamento crítico não é aquele pensamento açodado, superficial, arbitrário. E exatamente por ser elaborado é que ele tem um efeito emancipatório, tem um efeito libertador. De sorte que falar de pensamento crítico e imprensa livre é falar da mesma coisa. Não há imprensa livre senão a partir de um pensamento crítico. O pensamento crítico, de tão essencial à imprensa, não é nem uma característica; é uma inerência. Não é algo que pertence à imprensa. É da compostura dela. Faz

De acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a informação é definida como “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato” (art. 4º, I). Em se tratando de processamento de informações pessoais, há que se resguardar a total transparência e o respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais (art. 31).

Consequentemente, a divulgação de informações pessoais que tocam a esfera da intimidade, vida privada e a imagem está sujeita à prévia autorização do respectivo titular ou responsável, sob pena de responsabilização pelo uso e aplicação indevidos (art. 31, §§ 1º e 2º). Se as informações tratarem de crianças e adolescentes, a legislação pertinente deverá ser observada, assim como a autorização do responsável.

É bem certo que a notícia dependerá, por vezes, da divulgação de certos elementos personalíssimos, a exemplo do nome e da imagem. Porém, de acordo com a Constituição, a restrição quanto ao acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido (art. 220, § 4º, da Lei 12.527/2011). Nas hipóteses específicas nas quais houver grave tensão entre os interesses confrontados, caberá a justa ponderação do intérprete e aplicador do Direito para identificar e acolher o merecimento de tutela de cada um.⁶²

Em todo caso, a opção do Estado Brasileiro é tratar o abuso da liberdade de imprensa por meio de um controle *a posteriori*, fazendo emergir providências como o direito de resposta do agravado, sem prejuízo de eventuais danos morais e materiais causados a terceiros. Restrições *a priori* à liberdade de imprensa somente poderiam ser aplicadas em caso de estado de sítio (art. 139 da CF/88). Esse é o entendimento que se extrai do julgamento da ADPF 130,

Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevivendo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras.

Ainda assim, as balizas para esse controle estão assentadas na Constituição Federal e a mitigação da liberdade da imprensa será também para benefício do regime democrático e de alguns direitos igualmente fundamentais, como a vedação do anonimato (CF, art. 5º, parte final do inciso IV); direito à resposta (CF, art. 5º, V); indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (CF, art. 5º, inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (CF, art. 5º, inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (CF, art. 5º, inciso XIV) e, por fim, a proscrição do monopólio e oligopólio dos veículos de comunicação (CF, art. 220, § 5º), além da responsabilidade penal por ofensas à honra.

A ADPF culminou por declarar a não recepção da antiga Lei de Imprensa, advertindo que a Constituição Brasileira de 1988 optou por um modelo de autorregulação da imprensa como “mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil”. Para o STF,

Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor

do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País após o rótulo de “plena” (§ 1º do art. 220).

Disso se deduz que são *irregulamentáveis* os interesses da personalidade como o substrato da liberdade de informação jornalística, pois uma interdição prévia do Estado na atuação jornalística importaria sua própria aniquilação. Nessa medida, justifica-se sua imunidade à Lei Geral de Proteção de Dados em face da atividade jornalística propriamente dita.⁶³ Não obstante, se a atividade jornalística for desenvolvida por órgão ou empresa integrante de conglomerado econômico que vier a formar um banco de dados cuja destinação não estiver clara quanto ao uso, o tratamento das informações ali empreendido estará comprometido e se sujeitará à LGPD.⁶⁴

Relativamente às atividades voltadas para fins artísticos, também se preserva a imunidade prevista no art. 4º da LGPD. Atividades artísticas ou de fins artísticos podem ser classificadas como aquelas que resultam do engenho e criatividade da pessoa. Segundo a lei de direitos autorais, Lei 9.610/1998, a obra artística se inclui no rol daquelas que resultam do espírito criativo humano – sejam elas literárias, musicais, coreográficas, cinematográficas, pinturas, desenhos, esculturas, ilustrações, fotografias etc.⁶⁵

Para os fins da exceção proposta pela LGPD, entende-se por obra artística ou de fins artísticos aquela que se fez como fruto da capacidade criativa, que também constitui uma expressão do direito de personalidade.

Conquanto não estejam sujeitas à sindicância da LGPD, também não poderão causar lesão ou ameaça aos direitos de personalidade de terceiros, sujeitando-se o seu autor à disciplina geral do ordenamento jurídico para a tutela desses bens.

3.3. Tratamento de dados para fins acadêmicos

A semântica do termo *acadêmico* evoca aquilo que é próprio ou é desenvolvido na academia, assim compreendida como aquela sociedade de fins artísticos, científicos ou literários. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação⁶⁶ usa o vocábulo *acadêmico* no art. 47, em referência ao trabalho que se desenvolve na educação superior; e no art. 66, *parágrafo único*, quando dispõe sobre a exigência de título acadêmico para o magistério superior em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Disso se infere que o trabalho acadêmico está correlacionado às atividades voltadas para o desenvolvimento do conhecimento e da pesquisa científicas realizadas primordialmente no âmbito das universidades, cuja autonomia é constitucionalmente assegurada.⁶⁷ Tais atividades, segundo o art. 218 do texto constitucional, são de interesse fundamental do Estado brasileiro, que tem o dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a tecnológica e a inovação. Para tanto e, conforme o § 3º desse mesmo dispositivo, é que o Estado deve apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Afinal, a ciência é uma atividade indispensável ao desenvolvimento da sociedade e à própria segurança e soberania do Estado.

Não obstante a atividade acadêmica seja permitida e até mesmo fomentada pelo Estado, haverá que respeitar outros interesses igualmente tutelados pela ordem constitucional. Embora a LGPD exclua o tratamento de dados para fins de acadêmicos do âmbito de sua incidência, não implica a desproteção das pessoas envolvidas. Mantenhamos afastada a possibilidade de repetição das gravíssimas experiências nazistas, quando grupos humanos eram seviciados em nome da ciência. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde, e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe da participação da comunidade no SUS, trazem alguma referência às pesquisas na área de saúde com a imposição de limites éticos.

Ao contrário da LGPD, que excluiu a temática de sua incidência, o Regulamento Europeu abordou o tratamento de dados em pesquisas científicas, ainda que de modo geral e fragmentado.⁶⁸ Por meio de diretrizes abertas e, em certa medida, confusas, deixou para cada Estado a tarefa de regular a matéria, adaptando a sua legislação àquela normativa.

No Brasil, dois episódios recentes trouxeram a liberdade acadêmica à pauta das discussões da sociedade e do Supremo Tribunal Federal. O primeiro teve origem no pleito eleitoral do ano de 2018. Considerando os humores da sociedade brasileira à época, alguns juízes entenderam que o art. 37 da Lei 9.504/1997, autorizava-lhes a proibição da temática eleitoral nas salas de aula ou no âmbito das universidades. Em vista disso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, propôs a ADPF 548 perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade daqueles atos. Por meio de tutela provisória de urgência, o STF mandou sustar aquelas proibições, priorizando a defesa da liberdade de pensamento e expressão de alunos e professores bem como da necessária autonomia das universidades.

Na decisão concessiva da medida liminar,⁶⁹ a Relatora Ministra Carmen Lúcia sustentou que os atos questionados pela ADPF “desatendem aos princípios assecuratórios da liberdade de manifestação do pensamento e desobedecem às garantias inerentes à autonomia universitária”. Asseverou que as liberdades de informação, de ensino e de aprendizado e as escolhas políticas fazem com que haja “perfeita compatibilidade entre os princípios constitucionais e a legislação eleitoral que se adota no Brasil e que tem de ser cumprida”. Conforme se lê na ementa da decisão, “fazer incidir restrição no ambiente de informação, ensino e aprendizagem como é o universitário, que tem o reforço constitucional da garantia de autonomia, assegurado de maneira específica e expressa constitucionalmente, para se blindar esse espaço de investidas indevidas restritivas de direitos, a demonstração da nulidade faz-se mais patente e também mais séria.”

Chamou-nos atenção o voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, para quem “a universidade como um ambiente de livre circulação de ideias deve ser protegida de qualquer policiamento político-ideológico da rotina acadêmica”. De modo mais enfático, sustentou que: “A política encontra na universidade uma atmosfera favorável que deve ser preservada. Eventuais distorções na atuação política realizada no âmbito das universidades mereceriam ser corrigidas não pela censura, mas pela ampliação da abertura democrática”.

Outro episódio que reforçou a autonomia das Universidades e a liberdade de cátedra também chegou ao STF, em sede recursal. Na origem, uma Ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina com o objetivo de garantir a liberdade de aprender e ensinar nas escolas catarinenses, em oposição às investidas da Deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL), que estimulava o patrulhamento ideológico dos professores pelos alunos. Em primeira instância, o MP obteve liminar favorável e a referida deputada foi impedida de “implementar e/ou manter de qualquer modalidade de serviço, formal ou informal, de controle ideológico das atividades dos professores e alunos das escolas públicas e privadas”. Porém, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reformou a decisão de primeira instância, dando provimento ao recurso da Deputada. Por meio de Reclamação (RCL) 33137, o caso chegou ao STF e, sob relatoria do Ministro Luiz Edson Fachin, coube a este relembrar a decisão do Plenário dessa Corte na ADPF 548, reafirmando a liberdade de pensamento, de expressão e a necessária autonomia no ambiente de ensino. Para o Ministro Fachin,

Ao conclamar os alunos a exercerem verdadeiro controle sobre manifestações de opinião de professores, a deputada transmite a ideia de que isso é lícito. Estimula-os, em consequência, a se sentirem legitimados a controlarem e a denunciarem manifestações político-partidárias ou ideológicas contrárias às suas.

Embora as decisões não tenham conexão imediata com a regulamentação do tratamento dos dados para fins acadêmicos, ressaltam a necessidade de se reconhecer a liberdade para os fins de pesquisa e a autonomia no ambiente da academia – lugar propício ao florescimento das ideias e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Prestigia-se o controle e a fiscalização na pesquisa pelos próprios comitês de ética e, pelas vias comuns, sem a necessária submissão da matéria à lei especial de proteção de dados que realiza um controle prévio sobre como os dados devem ser tratados.

3.4. Tratamento de dados realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou de atividades de investigação e repressão das infrações penais

A restrição a sua incidência relativamente ao manejo de dados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado visa à garantia desses interesses públicos e o combate às infrações penais, ao crime organizado, à fraude digital e ao terrorismo.⁷⁰ Nesse aspecto, seguiu a mesma orientação do Regulamento Europeu de proteção de dados,⁷¹ excetuando essas hipóteses no art. 4º, III.

Quanto às demais operações de manipulação de dados desenvolvidas pelo Poder Público, a LGPD se aplicará integralmente. Incidirá, inclusive, no âmbito da atividade fiscal do Estado quando este, mediante combinação das informações do sistema integrado, descobrir a prática de um determinado crime tributário. A LGPD dedica capítulo específico ao tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público na execução de suas competências legais.⁷² Todavia, a partir do momento em que se identificar a prática de um crime, a operação de tratamento utilizada com a finalidade exclusiva de investigação não será mais tutelada, de forma plena, pela referida lei.

A inaplicabilidade da LGPD às matérias arroladas no art. 4º, inciso III, não chega a ser absoluta, pois, de acordo como § 1º⁷³ do mesmo dispositivo, os princípios gerais de proteção ao titular dos dados continuarão sendo imperativos (art. 6º e arts. 17 e 18), sejam eles: finalidade; adequação; necessidade; transparência e não discriminação. O titular dos dados também terá como invocar o direito de acesso, correção, anonimização e eliminação das informações inadequadas.

Considerando a iminente possibilidade de criação do Banco Nacional de Perfil Genético e do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, por alteração à Lei 12.037/2009⁷⁴ proposta pelo Projeto da *Lei Anticrime* – será premente observarem-se os direitos dos titulares das informações colecionadas, ainda que venham a ser tratadas para fins de segurança pública e investigação de infrações. Afinal, o direito à privacidade (art. 17, LGPD) e os princípios conexos à proteção dos dados devem ser o escudo protetor da pessoa em face do Estado de Vigilância.

Além da incidência dos princípios gerais da LGPD, o manejo de dados para fins de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado também se sujeitará a uma *legislação específica* como se estabelece na própria lei. O legislador anteviu a necessidade de regular o tratamento de dados até mesmo quando em face desses interesses fundamentais à soberania e paz social.

A despeito da importância de uma regulamentação específica, a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011⁷⁵ – e o respectivo regulamento, Decreto 7.724/2012,⁷⁶ aplicam-se ao tratamento de dados pelo Poder Público quando age nas hipóteses do art. 4º, inciso III, da LGPD. Apenas pelo teor do art. 31 da LAI⁷⁷ já se estabelece o princípio da transparência e o respeito às liberdades e garantias individuais dos titulares dos dados objeto de tratamento, lançando balizas que limitarão eventuais abusos.

Aspecto polêmico da LGPD quanto à matéria em questão, diz respeito à personalidade jurídica do operador e do controlador do tratamento dos dados. Nessa parte, o texto original da LGPD, tal como aprovado pelo Congresso Nacional, foi profundamente alterado pela Medida Provisória (MP) de 869/2018,⁷⁸ que condensou os §§ 2º, 3º e 4º nos §§ 2º e 3º.⁷⁹ Em síntese, a MP permitiu o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do *caput* por pessoa jurídica de direito privado, naqueles procedimentos em que esta estiver sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Ou seja, se a pessoa jurídica de direito privado for controlada pelo Poder Público, poderá tratar, na integralidade, as informações pessoais disponíveis nos bancos de dados cuja finalidade seja exclusiva para fins de vigilância e de segurança.

Já é usual a contratação de empresas especializadas pela administração pública para a realização de atividades conectas a serviços estratégicos. Há diversas unidades da federação que contratam empresas privadas para atuarem no sistema de monitoramento de veículos para fins de controle da exação fiscal (IPVA), por exemplo. De igual forma, os órgãos de fiscalização de trânsito municipais passaram a terceirizar o serviço de controle do tráfego por meio de empresas que oferecem os chamados semáforos inteligentes. O próprio Poder Judiciário aderiu ao desenvolvimento de sistemas inteligentes de gerenciamento de processos, até para identificar demandas repetitivas.

Todavia, bem mais arriscado é confiar o controle de complexos sistemas de vigilância correlacionados à segurança pública/estatal, de investigação e de repressão penal, às pessoas jurídicas de direito privado sujeitas às livres regras de mercado. A título de exemplo, cita-se a parceria celebrada, nesse ano de 2019, entre o Estado do Rio de Janeiro e a empresa telefônica Oi, para a instalação e monitoramento de algumas câmeras no bairro Copacabana, visando identificar pessoas procuradas pela Justiça⁸⁰. No ano de 2014, o relatório “Quem Defende seus Dados”, publicado anualmente pelo InternetLab⁸¹, mostrou que essa mesma empresa foi autuada por violar a privacidade de seus consumidores ao monitorar hábitos de navegação. *Estaríamos confiando a segurança dos ovos à raposa?*

Outro aspecto importante diz respeito à autoridade encarregada do controle e fiscalização das empresas que operam e controlam os dados, tal como estabelecido pela LGPD. Uma vez que o manejo de dados para fins de segurança pública não está sujeito a essa lei, as empresas que operam os dados para esses fins serão fiscalizadas por qual autoridade? Estarão sujeitas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada pela citada MP? Como garantir que tais empresas não passem a utilizar os dados para outras finalidades?

Frank La Rue defende que os sistemas tecnológicos de vigilância sejam supervisionados por uma autoridade independente, de modo a garantir plena transparência quanto às técnicas utilizadas e à extensão dos poderes.

A vigilância nas comunicações deve ser considerada como um ato altamente intrusivo que, potencialmente, interfere com os direitos à liberdade de expressão e privacidade, e ameaçam as bases de uma sociedade democrática. A legislação deve estipular que a vigilância do Estado nas comunicações só deve ocorrer nas circunstâncias mais excepcionais e exclusivamente sob a supervisão de uma autoridade judicial independente. Salvaguardas devem ser articuladas em legislação, relativa à natureza, âmbito e duração das medidas possíveis, bem como os fundamentos necessários para requisitá-la, as autoridades competentes para as autorizar, realizar e supervisionar, e o tipo de recurso previsto pela legislação nacional.⁸²

Uma vez que a LGPD não é aplicável à matéria, não se pode presumir que a ANPD desenvolva o tal controle e, nesse aspecto, há uma perigosa lacuna deixada pela lei. Confia-se à pessoa jurídica de direito público controladora a missão de fiscalizar o procedimento de tratamento realizado pela pessoa jurídica operadora. Mas quem atuará em defesa dos demais interesses envolvidos, notadamente do titular das informações? Pelo visto, ele

próprio, o Judiciário e as instituições encarregadas da tutela coletiva é que deverão assumir essa tarefa.

3.5. Dados coletados, tratados e utilizados fora do território nacional

Para compreender a hipótese restritiva de inaplicabilidade da LGPD relativamente à coleta e tratamento de informações no exterior (art. 4º, inciso IV), é necessário delimitar as regras gerais de aplicabilidade presentes no art. 3º.⁸³

Segundo o *caput* do art. 3º da LGPD, sua aplicação recai sobre qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural e/ou pessoa jurídica, enquanto controladora ou operadora, seja de direito privado ou público, independentemente do meio no qual esses dados estejam sendo processados. Ou seja, a lei se aplica até mesmo ao tratamento de dados *off-line*, sendo mais abrangente que o Marco Civil da Internet – MCI (Lei 12.965/2014) –, que regula tão somente o uso da Internet.

Não obstante a LGPD ter passado a regular mais amiúde a matéria sobre o tratamento de informações, instituindo até uma base legal para o tratamento, o MCI continua vigente e aplicável quando esse tratamento ocorrer na Internet. O diálogo de fontes, entre as legislações incidentes (LAI, CDC, MCI e LGPD), deverá ser utilizado de forma a garantir ampla tutela aos titulares de dados submetidos a processamento no meio virtual.⁸⁴

A incidência da LGPD independará, ainda, da sede da empresa controladora ou operadora ou da localização geográfica de proveniência dos dados, desde que a operação de *tratamento seja realizada no território nacional*. Portanto, se quaisquer das fases de tratamento tiver sido realizada, no Brasil, seja a coleta, o acesso, o processamento e/ou transferência das informações, incidirá a regulamentação legal da lei de proteção.

Consequentemente, percebe-se que as hipóteses dos incisos I e III do art. 3º são comunicáveis, pois a coleta de dados, no território nacional, já configura hipótese de tratamento necessária a invocar a aplicabilidade da LGPD. Destaque-se que a nacionalidade do titular dos dados é critério irrelevante para os fins legais. Assim, um estrangeiro não residente no país, mas em trânsito ou em simples conexão, por exemplo, em aeroporto brasileiro, será tutelado pela legislação brasileira no que tange ao tratamento de dados que eventualmente forneceu para utilizar dos serviços de *wi-fi* da concessionária do aeroporto, por exemplo.

Para além da regra do local do tratamento, a localização geográfica dos titulares dos dados a serem tratados ou destinatários do fornecimento de bens e serviços atrairá a incidência da lei. Mais uma vez, infere-se que a nacionalidade não foi utilizada como critério, mas tão somente o fato de a atividade de tratamento amplo de dados ou para fins de fornecimento de bens ou serviços terem como objeto as informações de “indivíduos localizados no território nacional”.

Caso determinada empresa estrangeira, sem sede no Brasil, como a *Amazon*, processar informações de titulares que estão, temporária ou definitivamente, estabelecidos no território brasileiro, terá que obedecer às regras da LGPD quanto ao tratamento dos dados.

O General Data Protection Regulation – GDPR adota critério distinto dos aderidos pela LGPD. Para aquele regulamento (art. 3º)⁸⁵ é irrelevante o local de tratamento das informações, importando o fato de a empresa responsável ser estabelecida na União Europeia. E, de forma semelhante à legislação brasileira, tutela os dados daquele titular que estiver no território da UE, independentemente de sua nacionalidade.

Em linhas gerais, mesmo que a operadora não tenha sede, no Brasil, e os dados manuseados sejam provenientes do exterior, aplicar-se-ão as regras da LGPD se uma das

fases de tratamento ocorrer no território nacional, à exceção do tratamento de dados previsto no inciso IV do *caput* do art. 4º desta Lei (§ 2º). Essa exceção poderia beneficiar as empresas brasileiras que, na qualidade de operadoras, tratem dados de pessoas localizadas fora do território nacional, oriundos do exterior, quando essas informações também não forem compartilhadas com outros agentes brasileiros. Na hipótese não se aplicaria a LGPD.⁸⁶ Porém, se essas informações forem transferidas para o país de proveniência e ali inexistir norma adequada para a proteção dos dados pessoais, a LGPD será aplicada.

Observe-se, porém, que o legislador acompanhou a tendência instituída pela GDPR⁸⁷, ao ressaltar que a lei brasileira só não se aplicará se o país de proveniência proporcionar grau de proteção de dados pessoais adequados para os fins da própria lei. Quando não houver legislação análoga para proteção dos dados naquele país, ainda assim, a LGPD será aplicada. Dessa forma, o tratamento de dados cuja coleta tenha sido feita fora do território nacional só não será regido pela LGPD se não tiver sido objeto de qualquer comunicação ou uso compartilhado com outros agentes de tratamento brasileiros ou, ainda, se não for objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência.

Se o país de proveniência não for avaliado pela autoridade nacional (ANPD) como de nível adequado em matéria de proteção de dados⁸⁸, aplicar-se-á a lei nacional. Percebe-se que a hipótese de inaplicabilidade só vige na circunstância de o país de proveniência proporcionar grau adequado de proteção de dados, pois eventual compromisso com a adoção de garantias de adequação (art. 35, LGPD) não suscitará a restrita exceção legal.

Conclusão

1.O desenvolvimento da economia baseada em dados (*data driven economy*), a hiperconectividade imanente à Internet das Coisas (IoT) e a estruturação do Estado de Vigilância potencializaram a tensão existente entre os valores segurança e privacidade. Ainda que o legislador faça a mediação desses interesses para sobrepor um ao outro em determinadas hipóteses, estima-se que considere, nessa tarefa, a unidade dos valores constitucionais e a importância do princípio dignidade da pessoa humana para que a solução tenha validade material e formal. Sob essa expectativa, o estado de vigilância não poderá, em defesa da segurança, solapar a privacidade das pessoas sob pena de atacar-lhes frontalmente a dignidade.

2.A lei não incide sobre situações que escapam os signos da sociedade de rede – como as que se verificam entre as pessoas naturais quando colecionam informações umas das outras. Embora essa compilação e esse “tratamento” de dados não estejam sujeitos à LGPD, não poderão ser usados para gerar lesão à personalidade do titular, malferindo-lhe a privacidade, a imagem ou a honra, sem sujeitar o agente às consequências previstas no ordenamento jurídico. *Grosso modo*, a malversação desse material poderá resultar em dano moral e até mesmo em ilícito penal.

3.A LGPD não se aplica à liberdade de imprensa, tampouco ao engenho criativo do artista e à pesquisa científica. Nesses casos, a tutela da privacidade também seguirá a solução genérica do ordenamento. O valor que se atribui à liberdade de expressão e de informação, corolários da liberdade de imprensa, afasta uma regulamentação prévia que possa importar em censura – daí a não incidência da LGPD. Porém, se a atividade jornalística for desenvolvida por órgão ou empresa integrante de conglomerado econômico que vier a formar um banco de dados cuja destinação não estiver clara quanto ao uso, o tratamento das informações ali empreendido estará comprometido e se sujeitará à LGPD.⁸⁹

4.Para os fins da exceção proposta pela LGPD, entende-se por obra artística ou de fins artísticos aquela que se fez como fruto da capacidade criativa, que também constitui uma

expressão do direito de personalidade. Conquanto não estejam sujeitas à sindicância da LGPD, também não poderão causar lesão ou ameaça aos direitos de personalidade de terceiros, sujeitando-se o seu autor à disciplina geral do ordenamento jurídico para a tutela desses bens.

5.A lei também não incide relativamente aos dados coletados para fins de pesquisas científicas. Prestigia-se o controle e a fiscalização na pesquisa pelos próprios comitês de ética e, pelas vias comuns, realiza-se um controle prévio, exigindo-se termo de consentimento informado. Eventual malversação das informações também justificará a aplicação das medidas ordinárias em favor da privacidade das pessoas envolvidas na pesquisa.

6.Entre a formulação de normas protetivas dos dados e a previsão de hipóteses de sua inaplicabilidade, a LGPD acolheu os interesses potencialmente colidentes da privacidade e da segurança. Ao utilizar a expressão *segurança* em sentidos plurívocos, suscitou um possível paradoxo da segurança, ora usando a expressão como segurança-proteção, ora aplicando-a como segurança-vigilância. Em nome desta é que excepciona a sua aplicação, conforme se verifica no art. 4º, inciso III.

7.As exceções à incidência da LGPD são justificadas de forma particular no interesse privado ou no interesse público e tais hipóteses, em geral, são disciplinadas por meio de outras leis especiais, como a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011 – e o respectivo regulamento, Decreto 7.724/2012, que se aplicam ao tratamento de dados pelo Poder Público, a despeito do legislador ter expresso a necessidade de legislação específica. A restrição a sua incidência relativamente ao manejo de dados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado visa à garantia desses interesses públicos e ao combate às infrações penais, ao crime organizado, à fraude digital e ao terrorismo. Nesse aspecto, seguiu a mesma orientação do Regulamento Europeu de proteção de dados. À exceção de situações muito específicas previstas no art. 4º, III), a LGPD se aplicará integralmente a quaisquer outras operações de manipulação de dados desenvolvidas pelo Poder Público.

8.A inaplicabilidade da LGPD às matérias arroladas no art. 4º, inciso III, não chega a ser absoluta, pois, de acordo com o § 1º do mesmo dispositivo, os princípios gerais de proteção ao titular dos dados continuarão sendo imperativos (art. 6º e arts. 17 e 18), assim como o titular dos dados poderá invocar o direito de acesso, correção, anonimização e eliminação.

9.No que diz respeito à personalidade jurídica do operador e controlador do tratamento dos dados, o texto original da LGPD, tal como aprovado pelo Congresso Nacional, foi profundamente alterado pela Medida Provisória de 869/2018, que condensou os §§ 2º, 3º e 4º nos §§ 2º e 3º, de modo a permitir o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do *caput* por pessoa jurídica de direito privado, naqueles procedimentos que esta estiver sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. Se a supracitada pessoa jurídica de direito privado for controlada pelo Poder Público, poderá tratar, na integralidade, as informações pessoais disponíveis nos bancos de dados cuja finalidade seja exclusiva para fins de vigilância e de segurança.

10.Há uma perigosa lacuna deixada pela lei quanto à autoridade responsável pelo controle e fiscalização das atividades de tratamento realizadas por pessoas jurídicas de direito privado relacionadas à vigilância, uma vez que não se pode presumir que a ANPD assim o faça, já que a LGPD não é aplicável à matéria. Assim, confia-se à pessoa jurídica de direito público controladora a missão de fiscalizar o procedimento de tratamento realizado pela pessoa jurídica operadora. Provavelmente, caberá ao Judiciário e às instituições encarregadas da tutela coletiva a tarefa de garantir o direito dos titulares das informações manipuladas.

11.A exceção do inciso IV deve ser interpretada, de forma restritiva, pois a regra é que, se uma das fases de tratamento ocorrer, em território nacional, aplicar-se-á a LGPD, mesmo que os dados sejam oriundos do exterior. Contudo, é pertinente não aplicar a legislação nacional e sim a do país de proveniência quando as empresas controladoras estrangeiras contratarem as operadoras brasileiras única e exclusivamente para tratar os dados provenientes desse país e, após, transferirem os resultados desse tratamento para este, desde que o país de proveniência proporcione adequadamente a proteção de dados pessoais consoante avaliação pela ANPD.

1

.Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Professora titular da Universidade de Fortaleza, vinculada ao Programa de Pós-Graduação *Strictu Sensu* em Direito (Mestrado/Doutorado), na Disciplina Tutela da Pessoa na Sociedade das Incertezas. Professora adjunto da Universidade Federal do Ceará. E-mail: joyceane@unifor.br.

2

.Mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Especialista em Direito e Processo Constitucionais pela UNIFOR. Pesquisador do Grupo de Pesquisa – CNPQ em Direito Constitucional nas Relações Privadas. E-mail: hiancolaco@hotmail.com.

3

.Mais de 109 países, em todo o mundo, possuem leis gerais de proteção dos dados pessoais.

4

.Essa lei resulta de um esforço de quase oito anos de debates e duas consultas públicas, que se iniciaram desde a elaboração da primeira versão do anteprojeto de lei pelo Ministério da Justiça em 2010. MENDES, Laura Schertel Mendes e DONEDA, Danilo. Comentário à nova lei de proteção de dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120/2018, 2018, p. 555-587.

5

.A *data driven economy* caracteriza-se pela economia da Internet das Coisas, na qual a conexão inteligente de produtos e serviços é movida pelo tratamento dos dados pessoais dos consumidores. Estabelece-se uma troca entre os serviços e produtos personalizados e os dados oferecidos. MOREY, T.; KRAJECKI, K. Personalisation, data and trust: The role of brand in a data-driven, personalised, experience economy. *Journal of Brand Strategy*, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 178-185, 2016. Disponível em: [<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=120015362&lang=pt-br&site=ehost-live>]. Acesso em: 12.02.2019.

6

.A expressão sociedade de rede designa o modelo de sociedade de informação cuja infraestrutura é fundamentalmente organizada por redes sociais e meios de comunicação que viabilizam a hiperconexão de todos os seus níveis e seguimentos (individual, grupal e organizacional, público e privado). Cunhada originalmente pelo Professor Stein Braten, a expressão foi mais difundida com Manuel Castells. CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. Trad. Roneide Venâncio Majer. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2005. Sociedade de rede e sociedade de informação são expressões que se prestam a designar uma sociedade marcada pelo elevado valor atribuído ao capital informacional e cuja infraestrutura organizacional é caracterizada pela hiperconectividade entre indivíduos e grupos, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros. Até mesmo os Estados passam a se valer dos recursos que a tecnologia disponibiliza para exercer um poder informacional e interagir com um governo vigilante. Nesse contexto global, no qual entidades privadas e governos exercem forte controle informacional, a pessoa se torna cada mais vulnerável e exposta em sua privacidade. MOLINARO, Carlos Alberto; SARLET, Ingo. Sociedade em rede, internet e estado de vigilância: algumas aproximações. *Revista da AJURIS*, v. 40, n. 132, Dez. 2013. Disponível em: [www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/249/184]. Acesso em: 21.02.2019.

7

“Nos últimos anos, a comunicação em ampla escala tem passado por profunda transformação tecnológica e organizacional, com a emergência do que denominei autocomunicação de massa, baseada em redes horizontais de comunicação multidirecional, interativa, na internet; e, mais ainda, nas redes de comunicação sem fio, atualmente a principal plataforma de comunicação em toda parte. Esse é o novo contexto, no cerne da sociedade em rede como nova estrutura social”. CASTELLS, Manuel. *Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet*. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2017. p. 153.

.CASTELLS, Manuel. *A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade*. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges, Revisão de Paula Vaz. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 135.

.MOLINARO, Carlos Alberto; SARLET, Ingo. Sociedade em rede, internet e estado de vigilância: algumas aproximações. *Revista da AJURIS*, v. 40, n. 132, Dez. 2013. Disponível em: [www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/249/184]. Acesso em: 21.02.2019.

.Sobre a análise do escândalo envolvendo o compartilhamento de dados dos usuários do Facebook com a Cambridge Analytica: HANNA, Mina J.; ISAAK, Jim. *User data privacy: facebook, cambridge analytica, and privacy protection*. Computer, v. 51, Issue 8. August, 2018. Disponível em: [https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8436400]. Acesso em: 13.02.2019.

.CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de direito civil contemporâneo*. Vol. 13, 2017. p. 59-67. Disponível em: [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/113436/insuficiente_protecao_dados_cueva_JC.pdf]. Acesso em: 09.02.2019.

.O Regulamento Geral de Proteção de Dados, publicado em 4 de maio de 2016, em substituição à Diretiva 95/46, consolida a tutela dos dados pessoais entre os países europeus e se aplica diretamente a todos os Estados-membros. Entre as inovações introduz o dever de *accountability*, a realização de análises de impacto sobre a privacidade e a notificação obrigatória às autoridades de proteção de dados em caso de vazamento e institui multas que podem chegar a 4% do faturamento das empresas. Regulamento Geral sobre a proteção de dados. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT]. Acesso em: 13.02.2019. Igualmente relevantes são as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que trazem princípios básicos de proteção aos dados pessoais. OECD. Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Disponível em: [www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheProtectionofPrivacyandTransborderFlowsOfPersonalData.htm]. Acesso em: 13.02.2019.

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 109.

.“As imagens se multiplicam e representam o corpo em múltiplas facetas e decomposições, revelando o chamado corpo eletrônico que representa o conjunto de informações existentes sobre as pessoas”. RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 19, jul.-set. 2004, p. 91.

.A Constituição Federal e o Código Civil preveem a tutela da vida privada nos arts. 5º, X, CRFB/88 e art. 21, CC/02, respectivamente. Exemplificativamente, tem-se a Lei 9.296/96 (Lei da Interceptação Telefônica) determinando que a interferência na privacidade das comunicações seja o mínimo necessário para apuração do caso investigado, devendo-se excluir o conteúdo desnecessário; a Lei 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, que dispõe sobre o respeito à privacidade e proteção aos dados pessoais (Art. 3º, IX); o Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei 8.078/90); a disciplina do Habeas Data (LHD, Lei 9.507/97); a Lei de Acesso à Informação (LAI, Lei 12.527/11); a Lei do Cadastro Positivo de Dados (LCP, Lei 12.414/11); o Marco Civil da Internet (MCI, Lei 12.965/14); e o Decreto regulamentar do MCI (DRMCI, Decreto 8.771/16).

.MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova lei de proteção de dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. Comentário à nova lei de proteção de dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120/2018, 2018, p. 555-587.

.GONCALVES, Tânia Carolina Nunes Machado; VARELLA, Marcelo D. Os desafios da Administração Pública na disponibilização de dados sensíveis. *Rev. direito GV*, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 513-536, ago. 2018. Disponível em: [www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322018000200513&lng=en&nrm=isso]. Acesso em: 11.02.2019.

18

“[...] uma comunidade que fez um esforço consciente para usar a tecnologia da informação para transformar a vida e o trabalho dentro de seu território de forma significativa e fundamental, em vez de seguir uma forma incremental”. KOMNINOS, Nicos. *The architecture of intelligent cities*. 2006, p. 13. Disponível em: [https://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/11/2006-The-Architecture-of-Intel-Cities-IE06.pdf]. Acesso em: 11.02.2019.

19

.OLIVEIRA, Ricardo Alexandre de. Lei geral de proteção de dados pessoais e seus impactos no ordenamento jurídico. *Revista dos tribunais*. vol. 998, p. 241-261, 2018. Disponível em: [www.cots.adv.br/artigo/lei-geral-de-protecao-de-dados-e-seus-impactos-no-ordenamento-juridico?s=0&blog=1&o=Direito%20eletr%C3%B4nico%20aplicado%20ao%20meio%20corporativo&a=&k=]. Acesso em: 10.02.2019.

20

.Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII – para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; Inciso VIII com redação determinada por Art. 2º Lei 13.853/2019.

IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

21

.Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I – quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

II – sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou (Inciso II, f com redação determinada por Art. 2º Lei 13.853/2019.)

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

22

.MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova lei de proteção de dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120/2018, 2018, p. 555-587.

23

.CITRON, Danielle Keats. Technological due process. *Washington University Law Review*. St. Louis, v. 85, 2008, p. 1259.

24

.“Existem fortes divergências em relação ao conceito de IoT, não havendo, portanto, um conceito único que possa ser considerado pacífico ou unânime. De maneira geral, pode ser entendido como um ambiente de objetos físicos interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um ecossistema de computação onipresente (ubíqua), voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia. O que todas as definições de IoT têm em comum é que elas se concentram em como computadores, sensores e objetos interagem uns com os outros e processam informações/dados em um contexto de hiperconectividade”. MAGRANI, Eduardo. *A internet das coisas*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. p. 20.

25

.Na reflexão de Molinaro e Sarlet, o enfrentamento dos ataques terroristas é apenas uma das razões que fortalecem o Estado de vigilância, sem representar sequer a mais importante. No governo de vigilância a prática de mineração de dados tem sido um fato em ascensão na acelerada evolução da tecnologia da informação. Usando os recursos de tecnologia cada vez mais poderosos, os governos e as grandes corporações alcançam maior influência e poder para descobrir o que está acontecendo no mundo, identificar potenciais ameaças e otimizar a prestação de seus serviços. A questão é saber se tais entidades públicas e privadas exerceram esse poder nos limites do Estado democrático de direito ou se avançarão em detrimento dos direitos fundamentais dos cidadãos. MOLINARO, Carlos Alberto; SARLET, Ingo. Sociedade em rede, internet e estado de vigilância: algumas aproximações. *Revista da AJURIS*, v. 40, n. 132, Dez. 2013. Disponível em: [www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/viewFile/249/184]. Acesso em: 21.02.2019.

26

.Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University. *Não entre em pânico: avançando no debate sobre “obscuramento” (Going Dark)*. Tradução brasileira por Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), 2019. p. 16.

27

.“A Agência deverá exercer as atribuições que lhe são conferidas pelos atos jurídicos da União no domínio das comunicações eletrônicas e, de um modo geral, contribuir para aumentar o nível de segurança das comunicações eletrônicas e da proteção da vida privada e dos dados pessoais, notadamente oferecendo competências especializadas e aconselhamento, promovendo intercâmbio das melhores práticas e formulando propostas quanto às políticas a seguir.” MENDES, Laura Schertel. Segurança da informação, proteção de dados pessoais e confiança. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 90, p. 245-260, nov.-dez. 2013.

28

.MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 3.

29

.Com fundamento último no direito constitucional ao desenvolvimento da personalidade, o direito fundamental passa a ser o próprio sistema informático pessoal, conforme construção realizada pela Corte Alemã. A decisão demonstra que não é suficiente garantir o direito de o titular conhecer e controlar as informações que circulam sobre si, é necessário garantir a confidencialidade, a autenticidade e a integridade dos sistemas informáticos, inclusive quanto à gestão dos riscos de vazamento de informações, para ampliar a confiança que a pessoa

tem nesses sistemas. MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

30

.Tem por objeto a impugnação à decisão a qual determinou a suspensão judicial do aplicativo *WhatsApp*, em todo o território nacional, fundamentada em suposto descumprimento à ordem de interceptação judicial do conteúdo das comunicações. A arguição de descumprimento de preceito fundamental consubstancia-se na violação ao direito à comunicação bem como ao princípio da proporcionalidade.

31

.Pleiteou-se a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais do MCI, os quais hipoteticamente permitiriam a aplicação da sanção de suspensão do aplicativo, em razão do descumprimento à ordem judicial, e, de forma alternativa, a interpretação conforme a Constituição dos dispositivos apontados para excluir a possibilidade de fundamentação de decisões em tal sentido, por considerar violação aos direitos de comunicação, à livre-iniciativa, à defesa do consumidor, entre outros.

32

.Considerando a lacuna legislativa quanto à possibilidade da ordem judicial de interceptação de comunicações incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos armazenados, o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou à Câmara dos Deputados esboço do chamado *Projeto de Lei Anticrime* que prevê a autorização para a interceptação desse conteúdo, sobrelevando o valor segurança à privacidade. Adicionalmente, determina a criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, para reunir dados como íris, face e voz de investigados, bem como a ampliação do Banco Nacional de Perfis Genéticos com o objetivo de permitir a coleta do DNA dos condenados por crimes dolosos mesmo antes do cumprimento definitivo da pena.

33

.Sobre a discussão ver: SCORSIM, Ericson M. A questão da criptografia do WhatsApp: julgamento do caso pelo STF sob a perspectiva da segurança das comunicações. *Migalhas*, 2017. Disponível em: [www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI259918,71043-A+questao+da+criptografia+do+WhatsApp+julgamento+do+caso+pele+STF+sob]. Acesso em: 14.02.2019.

34

.O juízo valorativo dos atos particulares não se subsume mais ao exercício de direitos subjetivos dentro dos limites legais, ou, ainda, ao controle negativo de ilicitude e não abusividade do ato, outrossim, passa-se a estabelecer um controle de legitimidade de todos os atos conforme a axiologia do sistema. Daí surge o conceito de merecimento de tutela, advindo do “controle valorativo dos atos de autonomia e apresentando-se como importante instância de legitimação dos atos privados na perspectiva civil-constitucional”. SOUZA, Eduardo Nunes de. In: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Coord.). Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. *Revista de Direito Privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr.-jun., 2014. Ver também: COLAÇO, Hian Silva; RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Merecimento de tutela na sociedade da informação: reedificando as fronteiras do direito civil. *Revista Quaestio Iuris*, Rio de Janeiro, v. 10, 2, 2017, p. 1134.

35

.“Com a evolução da realidade social, sobretudo após a ascensão das novas tecnologias da informação, a pessoa humana tornou-se mais vulnerável frente à intensificação de riscos e danos decorrentes das ditas tecnologias”. “Neste contexto, a reformulação das técnicas de controle da atividade interpretativa torna-se objeto central do debate doutrinário e, com isso, a noção de segurança jurídica (giusto processo) adquire conteúdo substancial inserido numa perspectiva de desenvolvimento de ferramentas hermenêuticas funcionais para garantir a efetividade da proteção da pessoa”. TEPEDINO, Gustavo. Teoria da interpretação e relações privadas: a razoabilidade e o papel do juiz na promoção dos valores constitucionais. In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 285.

36

.Comparam-se as incertezas a serem vivenciadas pelo advento da IoT à sociedade de riscos ou sociedade pós-industrial de Ulrich Beck, na qual destacaram-se os riscos imperceptíveis para os sentidos e para o conhecimento científico. BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*, 1997, p. 17.

37

.“Big data é mais que um emaranhado de dados, pois é essencialmente relacional”. Embora não seja um fenômeno recente, “o que a internet fez foi dar uma nova dimensão, transformando-o”. “Para bem entender

essas transformações precisamos compreender que o big data somos nós”. SANTOS, Maike Wile dos. *O big data somos nós: a humanidade de nossos dados*. Jota, 16 mar. 2017.

38

.BARKER, Colin. 25 billion connected devices by 2020 to build the internet of things. *ZDNet*, 11 nov. 2014.

39

.Pode-se definir a virtualização da vida em relação como um novo processo de condução da vida real com limitações temporais e espaciais diferenciadas. É traço marcante do virtual “não estar presente” (LEVY, 2011, p. 19). Esse fenômeno da vida virtualizada exige uma nova compreensão em torno das clássicas noções envolvendo a tutela do corpo e identidade, para o Direito, assim como do texto e da economia, para as respectivas ciências. LÉVY, Pierre. *O que é o virtual?* Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2011.

40

.Em 2010, O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre o direito à autodeterminação informativa no Recurso Especial 1.168.547/RJ, julgado em 2010. O Marco Civil da internet – MCI também havia tratado de algumas nuances desse direito, especificamente no que tange ao controle de dados pessoais. Mas a sua abordagem ainda não era suficiente para disciplinar o tratamento das informações pessoais. COLAÇO, Hian Silva; MENEZES, Joyceane Bezerra de. Facebook como o novo big brother: uma abertura para a responsabilização civil por violação da autodeterminação informativa. *Revista Quaestio Iuris*, Rio de Janeiro, v. 10, 4, p. 2319-2338, 2017. Disponível em: [www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/22579/21888]. Acesso em: 13.02.2019.

41

.“A garantia de controle do indivíduo sobre as próprias informações é, de fato, uma característica generalizada das diversas legislações nacionais sobre o tema, conforme se percebe a partir das expressões ‘autodeterminação informativa’, consolidada no direito alemão, e ‘liberdade informática’, utilizada no direito espanhol, que expressam a importância que a dimensão da autonomia alcançou na temática da proteção de dados pessoais”. MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 46.

42

.Nessa linha, a evolução da noção de privacidade pode ser resumida a partir de quatro tendências: “1) do direito a ser deixado só ao direito de manter controle sobre as informações que lhe digam respeito; 2) da privacidade ao direito à autodeterminação informativa; 3) da privacidade à não-discriminação e 4) do sigilo ao controle”. RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*: a privacidade hoje. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 97-98.

43

.Como se infere do art. 3º: “aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados”.

44

.“As poucas exceções à aplicação da Lei são localizadas e justificadas de forma particular, seja pela sua fundamentação em um direito fundamental (liberdade de informação, como no caso da exceção à atividade jornalística) ou interesse público relevante (como nas exceções à segurança pública e defesa nacional), nos termos do art. 4º da LGPD. Tais exceções, no entanto, são moldadas de forma a não comprometer a integridade da Lei, sendo que para diversas delas refere-se à existência de legislação específica sobre proteção de dados que compreenda os princípios da LGPD”. MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Reflexões iniciais sobre a nova lei geral de proteção de dados. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120/2018, p. 469-483.

45

.Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I – realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

II – realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III – realizado para fins exclusivos de:

- a) segurança pública;
- b) defesa nacional;
- c) segurança do Estado; ou
- d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV – provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

46

.Citado por António Menezes Cordeiro (In: *Tratado de Direito Civil*. v. IV, Parte Geral, Pessoas. Coimbra, Almedina, 2011. p. 235).

47

.MENEZES CORDEIRO, António. *Tratado de Direito Civil*. v. IV, Parte Geral, Pessoas. Coimbra, Almedina, 2011. p. 236.

48

.Lei 9.610/1998, art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais.

49

“Os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza humana e desde que a obra é emanação da personalidade do autor – que nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais –, esses direitos constituem a sacração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu criador. Esses direitos nascem com a criação da obra, manifestando-se alguns (como o direito ao inédito), com a simples materialização, ou seja, com a sua inserção na ordem fática, e produzindo efeitos por toda a existência daquela, na função básica que exerce de manter aceso o seu liame com o criador (e, enquanto a obra existir, mesmo falecido o seu autor), e isso, no sistema unionista, independentemente de qualquer formalidade: o direito flui do ato criativo.” BITTAR, Carlos Alberto. *Direito do autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 47.

50

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 91.

51

.MENEZES CORDEIRO, António. *Tratado de Direito Civil*, v. IV, Parte Geral, Pessoas. Coimbra, Almedina, 2011. p. 237.

52

.Responsabilidade civil. Fotos e vídeos íntimos. Divulgação. Redes sociais. Dano moral. A intimidade e a vida privada constituem direitos fundamentais da pessoa (CF, art. 5º, X). Como regra, os dados pessoais encontram proteção no direito à intimidade e privacidade. O dano moral está presente na violação de direito da personalidade causador de séria ofensa à vítima. O sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão. Do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar. Na espécie, foram divulgados fotos e vídeos íntimos da autora nas redes sociais, sem sua autorização. Situação do caso concreto que enseja o dever de reparação. A prova dos autos confirma ter o réu recebido as fotografias e compartilhado. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o valor arbitrado pela sentença. Apelação não provida. (Apelação Cível 70078201167, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS, AC: 70078201167 RS, rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.08.2018, 10ª Câmara Cível, DJe 17.09.2018).

53

.Ressalva-se aqui a solução do STF sobre as biografias não autorizadas, na sentença que julgou a ADI 4.815.

.Lei 12.737/2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, alterando o Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal). “Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa”.

.Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, manejada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, contra dispositivos da Lei federal 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Carlos Ayres Brito. (STF, ADPF 130 DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 30.04.2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-208 Divulg 05.11.2009, Public 06.11.2009, Ement vol-02381-01 PP-00001).

.GADELHO JUNIOR, Marcos Duque. *Liberdade de imprensa e a mediação estatal* / Marcos Duque Gadelho Junior, São Paulo: Atlas, 2015. p. 62.

.GADELHO JUNIOR, Marcos Duque. *Liberdade de imprensa e a mediação estatal* / Marcos Duque Gadelho Junior, São Paulo: Atlas, 2015. p. 79.

.COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. p. 83.

.Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de “informação jornalística” (§ 1º do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. [STF, ADI 4.451 MC-REF, rel. Min. Ayres Britto, P, j. 02.09.2010, DJe de 01.07.2011, republicação no DJe de 24.08.2012.].

.Processual civil e constitucional. Ação civil pública. Suspensão da exibição de quadro humorístico do programa “Zorra Total”. Alegado conteúdo homofóbico. Liberdade de expressão da emissora de televisão. Ausência de ilicitude. Sentença mantida. 1. Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e a TV Globo Ltda objetivando coibir exibição de programa humorístico com alegadas alusões discriminatórias a gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros – GLBT, sob pena de multa diária, bem como assegurar imediato monitoramento de demais programas que possam ser ofensivos a direitos das minorias mencionadas, o juízo monocrático julgou improcedente o pedido. 2. A instrução processual demonstrou que o programa “Zorra Total”, veiculado pela TV Globo Ltda, reveste-se de conteúdo humorístico, cuja finalidade consiste em apresentar entretenimento a telespectadores mediante representação cômica da realidade. 3. A mera conjectura quanto à repercussão eventualmente nociva à imagem dos grupos de minoria, cujos direitos se alegam violados, não se revela suficiente ao amparo da pretensão deduzida, sobretudo quando evidenciado o “animus jocandi” na produção dos quadros satíricos. Confira-se: TRF2, AG 200802010011931, Rel. Desembargador Federal Jose Antonio Lisboa Neiva, 6ª Turma Especializada, DJU 02.09.2008 p. 183. 3. Impõe-se observar o entendimento, uniforme na doutrina e na jurisprudência, de que “o humor poderia ser considerado imprensa, sendo aplicáveis, à espécie, as diretrizes firmadas no julgamento da ADPF 130/DF (republicada no DJE de 26.2.2010), relativamente à liberdade de imprensa. Aduziu-se que tal liberdade, também denominada liberdade de informação jornalística, não seria uma bolha normativa, uma fórmula prescritiva oca, porquanto possuiria conteúdo, sendo este formado pelo rol de liberdades contidas no art. 5º da CF: livre manifestação do pensamento, livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e livre acesso à informação. Mencionou-se o que disposto no art. 220 da CF, o qual seria uma extensão dos direitos fundamentais do seu referido art. 5º, de modo a reforçar esses sobredireitos. Assim, a comunicação social – que era livre no país – teria se tornado plena (CF, art. 220, § 1º).” Confira-se: Supremo Tribunal Federal, ADI 4451 Referendo-MC/DF, rel. Min. Ayres Britto, 1º e 2.9.2010. (ADI-4451). 4. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC, 14101 DF 0014101-52.2006.4.01.3400, rel. Des. Federal José Amílcar Machado, j. 24.09.2012, 6ª T., Data de Publicação: e-DJF1 p. 278 de 09.10.2012).

.O acesso à informação tem previsão constitucional no art. 5º, inciso XXXIII, art. 37, § 3º, inciso II e no art. 216, § 2º.

.Responsabilidade civil. Indenização por danos morais Matéria veiculada pelo programa humorístico CQC (Custe o Que Custar) sobre estação elevatória de esgoto da Sabesp – Informação de interesse da comunidade – Autora, assessora de imprensa da Sabesp, alega que foi humilhada pela equipe de jornalismo da ré e que a notícia veiculada ofendeu sua honra Matéria jornalística, com tom humorístico, limitou-se a informar e criticar – Ausência de propósito difamatório abusividade do direito de liberdade de pensamento Inexistência – Sentença mantida – RITJSP 252 – Inteligência – Recurso improvido. A responsabilidade civil na área da comunicação pressupõe o exercício abusivo da liberdade de pensamento que viole direito da personalidade de outrem, dano – que pode ser material ou moral – e nexo causal entre ambos. (TJ-SP, APL: 90837182420098260000 SP 9083718-24.2009.8.26.0000, rel. João Pazine Neto, j. 05.02.2013, 3ª Câmara de Direito Privado, DJ 07.02.2013).

63

.A observar o julgamento da ADPF 130, extrai-se o seguinte trecho “11. Efeitos jurídicos da decisão. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replica ou de retificar material publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, “de eficácia plena e de aplicabilidade imediata”, conforme classificação de José Afonso da Silva. “Norma de pronta aplicação”, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.”

64

.COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 83.

65

.Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I – os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II – as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III – as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V – as composições musicais, tenham ou não letra;

VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII – os programas de computador;

XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

66

.Lei 9.394/1996, art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...)

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.

67

.CF/88, art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

68

.DOVE, Edward S. The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 46 (2018): 1013-1030. 2018. DOI: 10.1177/1073110518822003.

69

.ADPF 548. Disponível em: [<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5576416>]. Acesso em: 25.02.2019.

70

.PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 57-58.

71

.Pode-se afirmar que a LGPD acompanhou as hipóteses de inaplicabilidade previstas no Regulamento Europeu de proteção de dados, à exceção dos dados de pessoas falecidas, expressamente excepcionados por este. Por isso, dada à influência do GDPR sobre a edição da normativa nacional, parece ser possível a aplicação desta ao acervo de dados do *de cuius*. Vide: GDPR – General Data Protection Regulation. Disponível em: [<https://gdpr-info.eu/>]. Acesso em: 23.02.2019.

72

.Art. 23, LGPD. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:

I – sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos.

73

.Art. 4º, § 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

74

.Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12037.htm]. Acesso em: 28.02.2019.

75

.Regula o acesso à informação perante o Poder Público. Regulamentou a norma constitucional de eficácia contida do art. 5º, XXXIII, CRFB/88 que, por sua vez, ressalva as informações submetidas a *sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado*. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm]. Acesso em: 28.02.2019.

76

.Regula a LAI. Foi recentemente alvo de sucessivas alterações, no tocante à delegação dos legitimados para classificar documentos em grau reservado, mediante os decretos de nºs 9.690/19 e 9.716/19, editados respectivamente pelo Vice-Presidente da República Hamilton Mourão, enquanto Presidente em exercício, e

77

.Art. 31, LAI. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de *forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais*.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III – ao cumprimento de ordem judicial;

IV – à defesa de direitos humanos; ou

V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

78

.Essa MP, de autoria do então Presidente Michel Temer, “alterou alguns dispositivos da LGPD e criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, sanando assim a lacuna deixada pelo veto presidencial quando da sanção da lei”. BONFIM, Natália Bertolo. MP 869/18 e alterações na LGPD. *Migalhas*, 2019. Disponível em: [www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI293658,71043-MP+86918+e+alteracoes+na+LGPD]. Acesso em: 23.02.2019.

79

Seguem os parágrafos e as respectivas alterações propostas pela citada Medida Provisória:

§ 2º O tratamento dos dados a que se refere o inciso III do *caput* por pessoa jurídica de direito privado só será admitido em procedimentos sob a tutela de pessoa jurídica de direito público, hipótese na qual será observada a limitação de que trata o § 3º. (Redação dada pela Medida Provisória 869, de 2018)

§ 3º Os dados pessoais constantes de bancos de dados constituídos para os fins de que trata o inciso III do *caput* não poderão ser tratados em sua totalidade por pessoas jurídicas de direito privado, não incluídas as controladas pelo Poder Público. (Redação dada pela Medida Provisória 869, de 2018)

80

.Ver: [https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/01/cameras-com-reconhecimento-facial-sao-instaladas-em-copacabana-durante-o-carnaval.ghtml]. Acesso em: 06.03.2019.

81

.SOUZA, Carlos Affonso. *Abram alas para o Carnaval com reconhecimento facial*. Tecfrotn, Uol, 2019. Disponível em: [https://itsrio.org/pt/comunicados/abram-alas-para-o-carnaval-com-reconhecimento-facial/].

Acesso em: 01.03.2019.

82

.LA RUE, Frank. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, p. 2.

83

.Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

I – a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II – a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Inciso II com redação determinada por Art. 2º Lei 13.853/2019.)

III – os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.

84

.“Entendemos não ser aplicável a revogação tácita do Marco Civil da Internet (MCI), tendo em vista que ele trata de outros temas, com fundamentos, objetivos e princípios da utilização da rede mundial no Brasil, bem como estabelece diretrizes governamentais. Ademais, a LGPD realizou alteração em dois artigos do MCI, ou seja, o legislador não tinha a intenção da revogação”. COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 78.

85

.GDPR. Disponível em: [<https://gdpr-info.eu/art-3-gdpr/>]. Acesso em: 08.03.2019.

86

.COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 90.

87

.“Em regra, a transferência de dados para países fora da União Europeia ou organizações internacionais pode ocorrer para países que asseguram um nível adequado de proteção de dados. A avaliação sobre a adequação é realizada pela Comissão Europeia levando em conta diversos elementos. Uma vez que a adequação do país terceiro é reconhecida, a transferência de dados pessoais pode ocorrer sem autorização específica da autoridade de proteção de dados, tampouco serão necessárias medidas protetivas posteriores. A relação de países com adequação reconhecida é avaliada periodicamente, a cada quatro anos, e divulgada pela Comissão Europeia”. FERREIRA, Ricardo Barretto; BRANCHER, Paulo; TALIBERTI, Camila; CUNHA, Vitor Koketu. Entra em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. *Migalhas*, 2018. Disponível em: [www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI281042,81042-Entra+em+vigor+o+Regulamento+Geral+de+Protecao+de+Dados+da+Uniao]. Acesso em: 08.03.2019.

88

.Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:

I – para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração:

I – as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;

II – a natureza dos dados;

III – a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;

IV – a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;

V – a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e

VI – outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

89

.COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 83.

Capítulo 7. Diálogos entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação

Ana Carla Harmatiuk Matos¹

Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk²

1. Introdução

As relações existentes entre o direito à privacidade e o direito à informação têm ocupado posição destacada nos recentes debates jurídicos. O tema comporta análises por distintas perspectivas – sociológica, econômica, centrada na tecnologia da informação, por exemplo. Mesmo quando predominantemente tratado sob o viés jurídico, é possível vislumbrá-las sob a ótica do direito constitucional, do direito administrativo ou como manifestação de um direito de personalidade.

No Brasil, há a peculiaridade desses direitos possuírem *status* constitucional, dotados de jusfundamentalidade. Assim, vê-se que a proteção dos dados pessoais, como elemento do direito à privacidade, encontra-se assegurada no artigo 5º, inciso X, da Constituição. Nesse sentido, inclusive, tem-se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 17/2019), que expressamente dispõe do direito à proteção de dados pessoais como de direitos fundamentais. Igualmente, o direito de acesso a informações de interesse particular do cidadão ou de interesse coletivo recebe respaldo no artigo 5º, inciso XXXIII, da Carta Fundamental.

No âmbito infraconstitucional, o direito à informação foi regrado pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), que tem como principal diretriz a concepção do sigilo como elemento excepcional e a transparência como regra. Contudo, os dados pessoais – regulados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP) – inserem-se, precisamente, nas hipóteses de exceção à transparência. Por sua vez, a LGDP edifica-se tomando a privacidade como pilar fundamental, o que revela uma diferença de enfoque e a existência de possíveis conflitos – reais ou aparentes – entre as disposições dessas leis.

Em se tratando de direitos fundamentais, não é possível interpretação que os restrinja. Deve-se, portanto, cotejar quais elementos podem ou devem ser considerados como integrantes desse âmbito de transparência inerente à satisfação do direito fundamental, associado à noção de interesse público – apto a justificar o acesso a dados pessoais por terceiros.

Nesse sentido, compreende-se o interesse público como importante chave hermenêutica para a harmonização desses direitos, devendo, ele mesmo, estar

vinculado à compreensão dos direitos fundamentais.

Partindo de tal premissa, aborda-se, no presente trabalho, a temática dos dados cadastrais, da filiação partidária e do compartilhamento de dados sobre saúde com operadoras de planos de saúde.

2. Do caráter jusfundamental do direito à informação e do direito à privacidade

A relevância do debate acerca das balizas que informam a relação entre privacidade e direito a informações detidas por entes públicos se evidencia na constatação de que ambos os direitos aqui versados emergem diretamente da Constituição.

Com efeito, a proteção aos dados pessoais, como integrantes da privacidade dos indivíduos, é cabalmente assegurada pelo artigo 5º da Constituição da República, em seu inciso X, que assim dispõe: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Os dados pessoais integram o âmbito de proteção desse inciso, como ensina Danilo Doneda, ao afirmar que

O aumento de eficiência proporcionado pela utilização de dados pessoais deve ser balanceado com a necessidade de proteger a pessoa, evitando que esta se submeta à devassa de sua privacidade e ao controle por meio do tratamento de seus dados pessoais e permitindo que mantenha intacta sua dignidade, integridade, autonomia e liberdade pessoal.³

São os dados pessoais expressões da personalidade humana, sendo que o controle sobre o acesso e o tratamento de dados pessoais é parte de um espaço de liberdade constitucionalmente assegurado aos indivíduos, integrando a compreensão sobre a sua privacidade.⁴

Não há dúvida, pois, do *status* constitucional de que se reveste a proteção dos dados pessoais, seja quanto à sua coleta, seja quanto ao seu tratamento.

Ocorre que o acesso a informações de interesse particular do cidadão e de interesse coletivo ou geral é assegurado constitucionalmente como direito fundamental, dotado do mesmo *status* constitucional que a privacidade, como se pode aferir do disposto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Como se observa, o direito individual à obtenção das informações referidas no inciso XXXIII do artigo 5º está situado na mesma seara de relevância constitucional, dotada de caráter jusfundamental, de que se reveste a proteção aos dados pessoais.

O direito à informação, nesses termos, é reforçado pelo inciso II do § 3º do artigo 37, a assegurar “o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo”, bem como pelo § 2º do artigo 216 da Constituição, que assegura a consulta de informações pertinentes ao patrimônio cultural brasileiro.

Inexiste, pois, qualquer hierarquia ou juízo de prevalência *a priori* a respeito de qualquer desses direitos, sendo o papel do legislador assegurar, simultaneamente, seu exercício. Ao intérprete, a seu turno, cabe apreender as possibilidades de conjugação de tais direitos, e, em situações-limite, de colisão, levar a efeito, se e quando efetivamente necessário, sua ponderação.

A ponderação, diga-se, é, aqui, apontada como uma última *ratio* interpretativa, sendo reconhecido como mister principal daquele que se defronta com o desafio da relação entre esses direitos aferir a harmonização possível – especialmente com suporte nas opções legislativas que visam a definir os baldrames à luz dos quais o gozo desses direitos pode ser levado a efeito.

3. Das diretrizes fundamentais da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e do sigilo como exceção

Em linha com o que se discorreu anteriormente, veio à lume a Lei de Acesso à Informação, com o declarado escopo de regular o direito fundamental previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição.

Esse diploma legal enuncia um conjunto do que denomina de diretrizes fundamentais, a imantar a disciplina jurídica do acesso a informações detidas por entes públicos ou por entidades privadas que, no atendimento ao interesse público, têm acesso a esses dados.

Essas diretrizes são arroladas no artigo 3º da Lei e consistem em: “I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V – desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Destaca-se, de modo especial, o disposto no inciso I, que define o sigilo de informações como exceção e a publicidade como regra.

Como se observa, a regra é a transparência, é o acesso pleno às informações, devendo as hipóteses legais de sigilo – previstas, inclusive, na própria lei em comento – ser compreendidas como exceções. Isso se deve ao necessário atendimento do escopo expresso no mesmo artigo, de assegurar o controle social da administração pública, o que está em linha com os comandos constitucionais já apontados.

Ocorre que, do modo como se expressa a diretriz do inciso I, a interpretação sobre as hipóteses de sigilo deve ser estrita, haja vista tratar-se o sigilo de

exceção, o que poderia fazer pensar, em linha com as regras clássicas de hermenêutica, que não seria de se admitir qualquer interpretação extensiva.

A questão que se apresenta como relevante, porém, é que, entre as exceções, estão os dados pessoais, disciplinados, hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Cabe, pois, examinar pressupostos sobre os quais se erige a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para, na sequência, em cotejo com a Lei de Acesso à informação, aferir os pontos de contato e complementaridade, bem como possíveis elementos de conflito (real ou aparente) entre as normas.

4. Dos princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e de sua vinculação expressa à proteção à privacidade

Assim como a Lei de Acesso à informação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também enuncia seus fundamentos, e o faz em seu artigo 2º.

O respeito à privacidade avulta como primeiro fundamento arrolado, ao qual se segue a autodeterminação informativa – vale dizer, espaço de liberdade no qual a escolha do indivíduo sobre a publicização e o tratamento de seus dados pessoais deve prevalecer, como integrante do desenvolvimento de sua personalidade.

O inciso IV, por sua vez, assegura a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, sendo que o inciso VII vincula a proteção de dados pessoais aos “direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais”.

A mesma norma, porém, deixa claro que o tratamento e a divulgação de dados pessoais não são vedados de modo peremptório, sendo que, entre os fundamentos enunciados, há aqueles que podem balizar – e, efetivamente, o fazem, nos termos da própria lei – a autodeterminação informativa.

Assim, afere-se do inciso III a expressa afirmação da relevância da liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Como integrante da liberdade individual, a autodeterminação informativa não poderia, por evidente, ser pensada de modo a aniquilar outras dimensões do mesmo princípio da liberdade, que tem a liberdade de expressão como pilar essencial tanto à compreensão da dimensão privada do princípio como, sobretudo, à própria democracia.

Não descarta a lei, da mesma forma, do desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação – admitindo, em seu artigo 4º, inciso II, alínea “b”, a sua não aplicação ao tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos.

Na mesma linha, princípios constitucionais da ordem econômica são definidos como fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – ou seja, “livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor”.

O que se destaca, de modo especial, para as finalidades do presente estudo, é a ênfase oferecida à privacidade e à autodeterminação informativa, notadamente

em cotejo com as diretrizes da Lei de Acesso à Informação.

A Lei de Acesso à Informação não é, por evidente, alheia à privacidade – tampouco à autodeterminação informativa –, mas seu pressuposto básico é a transparência, que se reflete no acesso, tomando o sigilo como exceção.

Quando se trata de privacidade, porém, o controle a respeito daquilo que deve ou não ser sigiloso consiste no conteúdo essencial desse direito fundamental, pelo que, nesse âmbito, o sigilo não é exceção.

Há, portanto, no plano dos pressupostos sobre os quais se erigem as leis em comento, uma clara diferença de enfoque: enquanto a Lei de Acesso à Informação prestigia a disseminação dos dados e informações, de modo ativo ou passivo, sendo o sigilo uma exceção (a ser compreendida de modo estrito), a Lei de Proteção aos Dados Pessoais toma o sigilo – ou, ao menos, a escolha do titular dos dados sobre o sigilo – como pilar fundamental.

Ocorre que, como se verá a seguir, os dados pessoais são expressamente definidos na Lei de Acesso à Informação como hipóteses em que o sigilo pode se impor – ou seja, estão os dados pessoais no campo das exceções ao acesso público.

5. Da disciplina da Lei de Acesso à Informação a respeito dos dados pessoais

A Lei de Acesso à Informação, em seu artigo 31, contém comando que impõe, no tratamento de dados pessoais, a transparência diante do seu titular, bem como o respeito “à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”.

Entre os dados pessoais, o § 1º destaca aqueles que seriam, na *ratio* desse diploma legal, relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, os quais são reputados de acesso exclusivo a agentes públicos legalmente autorizados e ao seu próprio titular, e cujo conhecimento por terceiros depende, em regra, de autorização do titular – salvo as exceções enumeradas no § 3º, que dispensam a autorização⁵.

A rigor, o que emerge desses comandos normativos é uma restrição ao acesso a determinados dados pessoais – sem, porém, uma criteriosa distinção que especifique quais seriam tais dados especialmente protegidos, e quais seriam aqueles de amplo acesso e tratamento.

A referência à vida privada não é bastante, uma vez que a própria autodeterminação informativa – que, *prima facie*, se refere, genericamente, a quaisquer dados pessoais, e não apenas a dados sensíveis (dados especialmente protegidos pela Lei, como os dados relativos à origem étnica ou vinculados à saúde e dados biométricos) – integra o âmbito de proteção da vida privada.

Evidencia-se a insuficiência da Lei de Acesso à Informação para a delimitação de quais dados pessoais se sujeitam, efetivamente, a consentimento para o seu

tratamento.

A dúvida que sempre esteve presente desde a vigência da Lei de Acesso à Informação foi, mesmo, sobre o que se pode compreender como dados pessoais, e, entre esses, quais podem ser considerados públicos – sendo que a própria anonimização de dados e sua divulgação se apresentava como passível de controvérsia.

Ilustrativo dessa dificuldade é o acórdão 2904-2016 do TCU, que traz considerações sobre as dificuldades enfrentadas pelos agentes públicos na identificação correta sobre o que pode ser compreendido como dado pessoal:

274. Um deles se refere ao marco regulatório de dados abertos no Brasil. A ausência de definição de licença de uso de dados abertos pode trazer limitações à sua utilização por potenciais consumidores. Além disso, a falta de legislação específica sobre o que deveria ser considerado dado pessoal pelo Poder Público pode causar insegurança nos gestores quando da abertura de determinados conjuntos de dados. Dessa forma, apesar dos avanços normativos promovidos pelo recém-editado Decreto 8.777/2016, as citadas deficiências no arcabouço jurídico que regulamenta a abertura de dados no país podem tornar menos efetiva a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. (Achado 1, Seção 3.1). (Acórdão TCU 2904-2016)

A compreensão expressa nesse acórdão do TCU parecia se vincular, a rigor, a conceitos que acabaram por não ser adotados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – como o constante do projeto de Lei 4.060/2012, que definia dado pessoal como “qualquer informação que permita a identificação exata e precisa de uma pessoa determinada”.

Ocorre que a Lei de Proteção aos Dados Pessoais traz conceito mais abrangente, definindo como dado pessoal a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.

6.Da definição de dados pessoais na Lei 13.709/2018 e das diretrizes quanto à sua coleta e ao seu tratamento

Como exposto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 5º, inciso I, define dados pessoais como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”.

Ou seja: são abrangidas pelo conceito não apenas as informações sensíveis, mas, também, quaisquer outras informações pertinentes à pessoa, incluindo dados cadastrais, não sendo essencial para a definição de dados pessoais a precisa e definitiva identificação da pessoa.

Assim, em princípio, aplicada a regra do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação associada a esse conceito da Lei de Proteção aos Dados Pessoais, seriam de acesso restrito quaisquer informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável – e não apenas os dados que permitam a identificação exata e precisa de uma pessoa determinada.

O conflito de direitos na seara jusfundamental seria, se prevalecesse essa interpretação, inevitável. Daí porque se impõe mister hermenêutico que assegure a correta compreensão de quais são os dados pessoais passíveis de sigilo, e quais – e em que contextos – podem integrar o âmbito do atendimento ao direito fundamental à transparência pública.

Ocorre que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais define baldrames diversos para o tratamento dos dados pessoais, como se verá a seguir, buscando a evitar essa exegese que se afirma, de antemão, equivocada.

O grau de sujeição do tratamento de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, diferentemente do desenho pouco técnico constante da Lei de Acesso à Informação, demanda a especificação, entre os dados pessoais, daqueles que são reputados sensíveis.

Já se constatou que, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, são dados pessoais toda “a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável”.

A regra geral para o tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 7º, é o consentimento, admitindo-se, porém, entre as hipóteses que dispensam consentimento, as seguintes, que têm pertinência possível no cotejo com a Lei de Acesso à Informação – quando o detentor da informação for ente público ou ente privado em atendimento a função ou interesse público:

Art. 7º (...)

(...)

II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

(...)

VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII – para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Ademais, em consonância com o artigo 4º, os dados manifestamente públicos dispensam consentimento do titular.

Observa-se, do exame das hipóteses do artigo 7º, que o acesso a quaisquer dados pessoais que não sejam manifestamente públicos depende de autorização

do titular, devendo as demais hipóteses de dispensa de autorização demandar justificativa à luz dos incisos anteriormente transcritos.

Regime especial se aplica, porém, aos denominados dados sensíveis, que são definidos pelo artigo 5º, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais os relativos a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Quanto a esses, a forma de consentimento prevista no artigo 11, inciso I, é especial, devendo se expressar de “forma específica e destacada, para finalidades específicas”.

Também são definidas exceções à necessidade de autorização, que se assemelham às hipóteses gerais referentes aos demais dados pessoais.

Há, porém, quanto a esses dados, especial preocupação do legislador quanto ao compartilhamento para fins econômicos, que pode ser vedada ou limitada, conforme o artigo 11, § 3º. Sobre esse tema, há especial destaque aos dados relativos à saúde, que serão objeto de análise específica ao longo deste estudo.

No que é pertinente, especificamente, ao tratamento de dados pelo poder público, a regra fundamental constante da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais reside no artigo 23, que vincula esse tratamento ao atendimento de sua “finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público”, o que se condiciona, expressamente, à mais ampla prestação de informações sobre as hipóteses em que ocorre o tratamento dos dados, com previsão legal, indicação de finalidade, bem como dos procedimentos e práticas para esse tratamento – tudo com a indicação de um encarregado.

Ou seja: o tratamento de dados pessoais pelo poder público não é irrestrito, não sendo possível afirmar que, aqui, a publicidade dos dados coletados seja a regra.

A despeito do cuidado do legislador, há, como exposto, a necessidade de compreensão harmonizada da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Lei de Acesso à Informação.

7. Possíveis controvérsias advindas da aplicação conjunta de ambos os diplomas legais, e da necessidade de sua harmonização

Já se apontou, neste capítulo, que a Lei de Acesso à Informação define o sigilo como exceção e a publicidade como regra. Entre as exceções, a impor sigilo, estariam as informações pessoais. Ocorre que a hermenêutica clássica, de interpretação estrita das exceções, não é adequada ao caso, uma vez que aqui está-se a tratar, necessariamente, de interpretação constitucional, aplicável a um diploma legal – uma vez que ambas as normas em comento se referem a direitos fundamentais.

Direitos fundamentais não se interpretam restritivamente. Assim, não se pode pensar no sigilo referente aos dados pessoais como algo passível de interpretação estrita, como a hermenêutica clássica poderia apontar na leitura isolada do inciso I do artigo 3º da Lei de Acesso à Informação.

De outro lado, sendo o direito à informação também um direito fundamental, é necessário compreender, na seara dos dados pessoais, quais podem ou devem ser reputados como integrantes desse âmbito de transparência inerente à satisfação do direito fundamental.

Ambas as leis aqui examinadas empregam, em momentos diversos, o conceito indeterminado de interesse público a justificar o acesso de terceiros a dados pessoais – inclusive, em certas hipóteses, de dados sensíveis.

São exemplos disso: (a) o disposto no inciso II do artigo 3º da Lei de Acesso à Informação, ao definir a divulgação de informações de interesse público como diretriz da lei; (b) o inciso V do § 3º do artigo 31 da mesma lei, ao versar sobre dispensa de consentimento para tratamento de informações pessoais; (c) o § 3º do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, que vincula o tratamento de dados pessoais de acesso público ao interesse público que justifica sua disponibilização; (d) o artigo 23 da mesma lei, ao autorizar o tratamento de dados pessoais pelo poder público – com referência expressa, na norma, ao escopo da Lei de Acesso à informação – para a persecução do interesse público.

A chave hermenêutica para uma possível harmonização dos direitos fundamentais em jogo pode ser um conceito de interesse público, vinculado, ele próprio, a direitos fundamentais.

Esse conceito, conforme Marçal Justen Filho, não é unívoco, havendo, em uma sociedade plural, vários interesses públicos, por vezes, conflitantes, propondo, assim, a tese de que a consecução desses interesses públicos deve ser compreendida, a rigor, como a proteção e o atendimento a direitos fundamentais⁶.

Para o autor, inclusive, o mais adequado seria substituir o termo interesse público por interesses coletivos⁷, expressão que também é empregada nos diplomas legais objetos do presente capítulo.

Com base nessa compreensão restritiva de interesse público, que não o legitima pela coletivização abstrata, mas o assenta na proteção aos direitos fundamentais – que chegam a transcender, em sua relevância estrutural para a ordem jurídica, os interesses dos próprios titulares –, é possível definir uma premissa: são passíveis de veiculação e conhecimento dados pessoais não anonimizados que sejam indispensáveis ao atendimento da transparência pública, afastando-se do conhecimento público os demais. Quanto aos dados anonimizados, sua veiculação e seu acesso são possíveis, desde que o tratamento seja levado a efeito de tal forma que não permita a retomada da identificação de seus titulares por meio de esforço razoável, nos limites do disposto pelo artigo 12 da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais.

Alguns temas relevantes podem ser objeto de reflexão a partir dessa premissa.

(a) Dados cadastrais

Um primeiro exemplo pode residir no debate sobre a natureza dos dados cadastrais.

O TCU, em pareceres exarados pela sua Consultoria Jurídica, previamente à Lei de Dados Pessoais, definiu dados cadastrais atinentes a CPF e endereço como não integrantes do conceito de dados pessoais:

Informação constante do *website* do TCU dá conta de pareceres exarados pela consultoria jurídica do órgão para afirmar que “dados cadastrais, em processos de controle externo, de endereço de responsáveis, seja pessoa física ou jurídica, de interessados, de sócios de pessoa jurídica, e de seus respectivos procuradores, para fins de comunicação processual, não deve ser considerado informação pessoal, haja vista que não constitui qualquer ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem dos jurisdicionados”.⁸

Ocorre que, à luz do conceito do inciso I do artigo 5º da Lei de Proteção aos Dados Pessoais, os dados cadastrais são, inequivocamente, dados pessoais. É irrelevante, para essa classificação, sua vinculação ou não à honra ou à imagem dos seus titulares. A questão reside em saber quais deles, mesmo sendo dados pessoais, são passíveis de veiculação, e em que contexto e extensões.

O endereço residencial pode ser compreendido como integrante de um espaço de privacidade que não pode ser exposto sem autorização do titular.

Inexiste interesse público em sua divulgação, uma vez que a identificação de quem integra a administração pública ou com ela celebra negócios ou pratica atos administrativos, ou, ainda, deles se beneficia, não é indispensável ao controle, pelos cidadãos, do exercício do seu direito à transparência dos atos da Administração. Ademais, sua exposição irrestrita pode colocar em risco um espaço de inviolabilidade que a Constituição assegura à vida privada.

O mesmo não se pode afirmar, genericamente, sobre números cadastrais de documentos como RG, CPF e cadastros profissionais.

Ainda que sejam dados pessoais, tais números cadastrais são necessários à precisa identificação dos indivíduos que integram a Administração, com ela contratam, celebram convênios, ou, ainda, se beneficiam individualmente – e voluntariamente – de atos administrativos.

Aqueles que contratam com a administração pública ou a ela se vinculam como agentes públicos, sujeitam-se, voluntariamente, a uma limitação ao espaço de reserva desses dados – corolário da autorresponsabilidade inerente ao exercício da liberdade individual –, uma vez que a identificação precisa desses agentes deve integrar a transparência pública, assegurada constitucionalmente como direito fundamental titularizado por todos os cidadãos.

Os dados referentes a cadastros profissionais, em entidades de classe (como OAB, CRM ou CREA), também se inserem nesse âmbito, haja vista que o próprio

exercício dessas profissões está vinculado à demonstração pública de regular vinculação às entidades de classe.

O mesmo não se pode afirmar, porém, quanto ao RG e ao CPF de cidadãos em contextos nos quais não estão a contratar com a administração ou a beneficiar-se direta e individualmente de políticas públicas ou atos administrativos singularmente considerados, ou não a integram como agentes públicos. Nessas situações, afasta-se o interesse público imediato – conceito, como visto, a ser interpretado restritivamente – no conhecimento desses dados, uma vez que a identificação precisa do cidadão é irrelevante para o exercício do direito fundamental ao acesso a informações atinentes ao Estado e à Administração, em todas as suas esferas.

Por interesse público em matéria de dados pessoais, reitere-se, deve-se compreender, aqui, aquilo que atende ao direito fundamental assegurado no inciso XXXIII do artigo 5º, conjugado com o artigo 37 da Constituição, ou seja, aquilo que é necessário para o controle social da transparência pública.

Como conceito indeterminado, que serve para restringir direitos fundamentais, não pode ele ser compreendido extensivamente sob pena se solapar a liberdade individual, que se expressa, entre outras formas, também pelo controle sobre os dados pessoais, como escolha oponível (liberdade positiva) a ser assegurada aos cidadãos em um espaço de não coerção (liberdade negativa).

Assim, sob a égide desse raciocínio, no âmbito do tratamento de dados pessoais, limitações podem ser impostas, seja à publicização, seja ao compartilhamento.

Ainda mais enfáticas são as restrições no âmbito dos dados sensíveis. Ocorre que, mesmo quanto aos dados sensíveis, há situações em que a publicização pelo poder público, mesmo não expressamente autorizada, se impõem.

(b) Filiação partidária

A filiação à organização política, por exemplo, é definida, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como dado sensível. Ocorre que, entre as formas de filiação à organização política, a filiação partidária é informação que não pode ser mantida em sigilo.

A Lei 9.096/1995 dispõe o seguinte sobre a coleta e o tratamento de dados atinentes à filiação partidária:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

A Resolução TSE – 23.596/2019, a seu turno, com acerto, regula a disponibilidade dessas informações:

Art. 26. A publicação das relações oficiais de que trata o parágrafo único do art. 19 desta resolução será feita no sítio eletrônico do TSE, permanecendo os dados disponíveis para consulta por qualquer interessado, juntamente com o serviço de emissão de certidão de filiação partidária.

A filiação partidária não é apenas expressão da liberdade de consciência, mas, sim, objetiva a atuação no âmbito da defesa da “autenticidade do sistema representativo”, o que implica dizer que se destina a viabilizar a candidatura do filiado a cargos eletivos.

Está-se, aqui, não apenas diante de expressão de vinculação à programa político-ideológico, mas, também, de atendimento de requisito à participação política dentro do Estado, em órgãos de governo, no exercício da representação democrática.

Trata-se de informação derivada de livre e voluntário direcionamento do cidadão à condição de potencial postulante a cargo eletivo, que, ao assim proceder, sujeita-se ao efeito imediato de sua escolha, que é o conhecimento público de sua vinculação partidária, inerente à pretensão que ela, conceitualmente, encerra.

Outros dados reputados como sensíveis, podem, inclusive, receber proteção especial diante do próprio consentimento para sua divulgação ou seu compartilhamento – ou, ao menos, quanto ao modo pelo qual esse consentimento é conferido.

(c) Compartilhamento de dados sobre saúde com operadoras de planos de saúde

Questão passível de controvérsia, que pode demandar análise de constitucionalidade, é o compartilhamento, pela ANS, de dados relativos a usuários de planos de saúde com as respectivas operadoras.

Art. 11. (...)

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de portabilidade de dados quando consentido pelo titular.

Todavia, mediante Medida Provisória MP 869/2018, pretendeu-se inserir nova hipótese de compartilhamento, no inciso II do referido parágrafo 4º: II - necessidade de comunicação para a adequada prestação de serviços de saúde suplementar.

A redação que acabou por ser incorporada à LGPD, por meio da Lei 13.853/2019, foi a seguinte:

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou

II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.

Incluiu-se, como se observa, uma condicionante à comunicação e ao uso compartilhado ao disposto no parágrafo 5º, com o seguinte comando:

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.

Com efeito, a redação que constava da Medida Provisória trazia regra, no inciso II, que não se adequava à ratio do parágrafo 4º. É que, se, efetivamente, tratar-se de prestação do serviço em favor do usuário, não se estará no âmbito da obtenção de vantagem econômica em proveito da operadora, o que levava à conclusão de que a exceção que se pretendia inserir no inciso II do parágrafo 4º não fazia sentido em relação ao caput.

A redação que acabou por prevalecer no inciso II é mais limitada e, por certo, mais adequada ao escopo das exceções à vedação ao compartilhamento.

Muito oportuna, ainda, a inserção do parágrafo 5º, que impede às operadoras o tratamento de dados sensíveis para a eleição de seus usuários e beneficiários, assegurando a higidez da limitação pretendida pelo artigo 11 e seu parágrafo 4º.

Por certo, não se poderia admitir como congruente com o caráter jusfundamental da proteção de dados sensíveis, mesmo à luz da redação prevista na MP, seria uma interpretação que considerasse a operadora autorizada a receber os dados da ANS ou de outros controladores para a realização genérica da prestação de seus serviços, sem que se trate do atendimento específico do interesse exclusivo do próprio usuário titular dos dados.

A imprópria vinculação dessa autorização de compartilhamento a “vantagem econômica” poderia ser interpretada como ampla admissão de tratamento e compartilhamento de dados em proveito da operadora, inclusive para, se for o caso, negar coberturas, ou limitá-las. Daí ser elogiável a redação que acabou por prevalecer, especialmente, ressalte-se, com a expressa adoção do comando do artigo 5º, que assegura a harmonia entre o comando legal e a proteção de dados que emerge da própria Constituição.

Já há, nessa linha de necessária proteção aos usuários, exemplo de pronunciamento jurisprudencial afastando esse compartilhamento de dados entre ANS e operadoras, como no caso abaixo ementado:

Constitucional. Administrativo. Ação civil pública. Resolução normativa da ANS n. 153/2007. Compartilhamento de informações sobre pacientes entre operadoras de plano de saúde. Divulgação de diagnósticos médicos independente de autorização do paciente. Violação do direito à intimidade e do dever de sigilo médico. Nulidade da resolução.

– Ação ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que objetiva a declaração de nulidade da Resolução Normativa RN ANS n. 153/2007, por entender que a referida resolução instituiu sistema de “trocas de informações em

saúde suplementar” (TISS), permitindo compartilhamento de diversas informações de pacientes entre as operadoras de planos de saúde. Entre as informações compartilhadas, algumas se referem à classificação da doença (CID-10), informação íntima do paciente, fato que viola sigilo médico, privacidade e intimidade dos usuários de plano de saúde.

– A Resolução n. 153/2007 contraria a Resolução n. 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina que estabelece que é vedado ao médico “revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo motivo de justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente”.

– O compartilhamento de diagnósticos médicos entre as operadoras de plano de saúde, sem autorização do paciente, ofende direito fundamental à intimidade e à privacidade dos usuários dos serviços de saúde (art. 5º, X, da Constituição Federal). Apelação da Agência Nacional De Saúde Suplementar – ANS improvida. (Rel. Des. Monica Nobre, Apelação Cível 0021345-89.2007.4.03.6100/SP, DJ 17.07.2018)

A fundamentação, em linha com a *ratio* constitucional – em decisão anterior à própria Lei Geral de Dados Pessoais –, merece transcrição, quanto ao seguinte excerto:

O conflito, acreditamos, deve ser resolvido a partir da livre manifestação de vontade do paciente e para que esta seja livre, é evidente que não haja qualquer ônus para quem pretenda exercer seu direito à intimidade, ou seja, em se impondo uma restrição ao não pagamento de despesas médicas caso não haja tal permissão, há de se tida a vontade manifestada pelo paciente como viciada por coação.

Examinando-se este ponto observa-se que nos casos de informação da CID não ser fornecida, segundo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, as operadoras de planos privados de assistência à saúde podem negar cobertura aos procedimentos, exames, consultas e tratamentos, e legitimadas exatamente pela Resolução da ANS aqui hostilizada.

Conforme concluiu o Juízo Federal da Primeira Vara Federal de Pernambuco, na prática, os pacientes se vêem obrigados ou coagidos a autorizar a indicação da CID, a fim de que as operadoras de planos privados de assistência à saúde, não se neguem a custear as consultas, procedimentos, exames, tratamentos.

Isto não pode ser admitido na medida em que permite que o exercício de um direito constitucional pelo cidadão - direito à intimidade - seja objeto de sanção (não custeio das despesas médicas) sob beneplácito da ANS a quem caberia, exatamente, coibir esta prática.

Neste contexto fático impossível não concluir como ilegal e indevida a obrigação de indicação do CID em fichas de informação do sistema TISS, por violar o direito à intimidade e o dever de sigilo decorrente da relação médico-paciente e caracterizar a informação uma infração ética.

Em outras palavras: somente com autorização do paciente, e em proveito deste, é que será possível o compartilhamento de dados de saúde, jamais em benefício da operadora.

Conclusão

A Lei de Acesso à Informação, como se vê, numa primeira leitura, guarda similitudes e divergências com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Cada qual possui diversos fundamentos e matrizes sobre as quais se estruturam. No entanto, esta última acrescenta pontos essenciais, não regulados pela primeira.

Ainda que seja relevante a garantia da transparência, igualmente importante é a tutela dos dados pessoais – principalmente em um cenário globalizado, em que os dados pessoais se tornaram importantes elementos comerciáveis.

Os dados pessoais, frequentemente definidos como “o petróleo do século XXI”, clamam, há muito tempo, por regulação à altura. Em razão da sua importância, social e econômica, não pôde ser ignorado pelos legisladores, devendo-se tomar em consideração a jusfundamentalidade da temática. É inegável que a lei veio em momento necessário, em sincronia com posicionamento internacional de inevitável regulação do tratamento de dados pessoais.

Verificam-se dificuldades enfrentadas pelos agentes públicos na identificação correta sobre o que pode ser compreendido como dado pessoal, e a Lei de Proteção aos Dados Pessoais trouxe conceito mais abrangente, definindo-o como a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Desse modo, são abrangidas pelo conceito não apenas as informações sensíveis, mas, também, quaisquer outras informações pertinentes à pessoa, incluindo dados cadastrais, não sendo essencial para a definição de dados pessoais a precisa e definitiva identificação da pessoa.

Assim, em princípio, aplicada a regra do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação associada a esse conceito da Lei de Proteção aos Dados Pessoais, seriam de acesso restrito quaisquer informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável – e não apenas os dados que permitam a identificação exata e precisa de uma pessoa determinada.

O conflito de direitos na seara jusfundamental seria, se prevalecesse essa interpretação, inevitável. Daí porque se impõe mister hermenêutico que assegure a correta compreensão de quais são os dados pessoais passíveis de sigilo, e quais – e em que contextos – podem integrar o âmbito do atendimento ao direito fundamental à transparência pública.

Contudo, mister se faz a superação de uma interpretação tradicional em direção à harmonização de ambos os direitos – tomando como ponto de reflexão a compreensão de interesse público, trazida pelas leis em comento, em diversos momentos, e que está apta a justificar o acesso de terceiros a dados pessoais e, em certas hipóteses, a dados sensíveis.

No entanto, a concepção de interesse público não se legitima pela coletivização abstrata, deve estar assentada, ela própria, na proteção aos direitos fundamentais, tornando-se, assim, importante guia hermenêutico para a resolução dessas questões.

Tomando tal ponto como premissa, conclui-se que são passíveis de veiculação e conhecimento dados pessoais não anonimizados que sejam indispensáveis ao atendimento da transparência pública, afastando-se do conhecimento público os que fujam a este escopo. Quanto aos dados anonimizados, sua veiculação e seu acesso são possíveis, conquanto que o tratamento seja levado a efeito de tal forma que não seja possível da identificação de seus titulares por meio de esforço razoável.

Sobre o debate acerca da natureza dos dados cadastrais, há a questão que reside em saber quais deles, mesmo sendo dados pessoais, são passíveis de veiculação, e em que contexto e extensões.

O endereço residencial pode ser compreendido como integrante de um espaço de privacidade que não pode ser exposto sem autorização do titular. Inexiste interesse público em sua divulgação, uma vez que a identificação de quem integra a administração pública ou com ela celebra negócios ou pratica atos administrativos, ou ainda, deles se beneficia, não é indispensável ao controle, pelos cidadãos, do exercício do seu direito à transparência dos atos da Administração. Ademais, sua exposição irrestrita pode colocar em risco um espaço de inviolabilidade que a Constituição assegura à vida privada. O mesmo não se pode afirmar, genericamente, sobre números cadastrais de documentos como RG, CPF e cadastros profissionais.

A filiação à organização política, por exemplo, é definida, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como dado sensível. Ocorre que, entre as formas de filiação à organização política, a filiação partidária é informação que não pode ser mantida em sigilo.

Questão também passível de controvérsia, que pode demandar análise de constitucionalidade, é o compartilhamento, pela ANS, de dados relativos a usuários de planos de saúde com as respectivas operadoras. Conclui-se que somente com autorização do paciente, e em proveito deste, é que será possível o compartilhamento de dados de saúde, jamais em benefício da operadora.

Por interesse público em matéria de dados pessoais, portanto, deve-se compreender aquilo que atende ao direito fundamental assegurado no inciso XXXIII do artigo 5º, conjugado com o artigo 37 da Constituição, ou seja, aquilo que é necessário para o controle social da transparência pública.

Referências bibliográficas

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo. Proteção da Privacidade na Era Digital. In: Clèmerson Merlin Clève. (Org.). *Direito Constitucional Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2014. v. 1, p. 437-450.

DONEDA, Danilo. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. In: Ana Carla Harmatiuk Matos. (Org.). *A construção dos novos direitos*. Porto Alegre: Núria Fabris, 2008. v. 1, p. 44-77.

DONEDA, Danilo. Privacidade e transparência no acesso à informação pública. In: MEZZAROBÀ, O.; GALINDO, F. (Org.). *Democracia eletrônica*. Zaragoza: Prensas Universitárias de Zaragoza, 2010, p. 179-216. Disponível em: [www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/lefis11-09.pdf]. Acesso em: 06.06.2019.

DONEDA, Danilo; SCHERTEL MENDES, Laura. Marco jurídico para a cidadania digital: uma análise do projeto de lei 5.276/2016. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 9, p.35- 48, out-dez. 2016.

FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais, grandes dados e riscos para o direito da personalidade. In: TEPEDINO, GUSTAVO; MENEZES, Joyceanne Bezerra (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2019.

JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “Personalização” do Direito Administrativo. In: *Revista Trimestral de Direito Público*, 26/1999, São Paulo, Malheiros, p. 115-136.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo*. 7. ed. Rev. e Atual. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011.

RODOTA, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

1

.Professora na graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná. Professora Colaboradora do Mestrado profissional em Direito da UNIFOR. Diretora da Região Sul do IBDFAM. Vice-Presidente do IBDCivil. Advogada.

2

.Professor de Direito Civil nos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da UFPR. Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela UFPR. Diretor Regional Sul do IBDCIVIL. Advogado.

3

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

4

.RODOTA, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

5

.§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias: I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; III – ao cumprimento de ordem judicial; IV – à defesa de direitos humanos; ou V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

6

.JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “Personalização” do Direito Administrativo. In: *Revista Trimestral de Direito Público*, 26/1999, São Paulo, Malheiros, p. 115-136.

7

.JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. 7. ed. Rev. e Atual. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. p. 35.

8

.Entretanto, parecer da Consultoria Jurídica deste TCU (Conjur) indeferiu pedido de retirada do número do CPF do Portal do TCU, opinando no sentido de que a informação quanto ao CPF em deliberação proferida pelo TCU e, portanto, na base de dados disponível na Internet, não constitui informação pessoal nos termos do art. 4º, IV, da Lei 12.527/2011 (TC 014.610/2014-0).No mesmo sentido, a Conjur consignou que dados cadastrais, em processos de controle externo, de endereço de responsáveis, seja pessoa física, seja jurídica, de interessados, de sócios de pessoa jurídica, e de seus respectivos procuradores, para fins de comunicação processual, não devem ser considerados informação pessoal, haja vista que não constituem qualquer ofensa à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem dos jurisdicionados (TC 034.351/2014-0).

Capítulo 8. Término do Tratamento de Dados

Gisela Sampaio da Cruz Guedes ¹

Rose Melo Vencelau Meireles ²

1. Introdução

O direito à proteção dos dados pessoais nasce como direito de defesa perante o Estado, mas atualmente encontra alcance em todos os espaços, públicos e privados. Chegou-se a afirmar que o potencial ofensivo do tratamento de dados pessoais pode se igualar ou mesmo exceder aquele representado pelo Estado.³ Importa assim, inicialmente, compreender qual o objeto dessa proteção. Os dados pessoais são projeções diretas da personalidade. Assim, “qualquer tratamento de dados, por influenciar na representação da pessoa na sociedade, pode afetar a sua personalidade e, portanto, tem o potencial de violar os seus direitos fundamentais”.⁴ O tratamento de dados é conceituado no art. 5º, inciso X, da Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”):

X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.⁵

Trata-se, portanto, de situação das mais corriqueiras: cadastros *on-line* e *off-line*, *login* em redes sociais, compras no cartão de crédito, isto é, operações que sempre envolvem o fornecimento de algum dado pessoal (LGPD, art. 5º, inciso I), a exemplo do Cadastro de Pessoa Física (CPF), *e-mail*, número do cartão de crédito, endereço residencial ou número de telefone, registros eletrônicos gerados em catracas automatizadas, pedágios eletrônicos, câmeras, aparelhos de GPS, eletrodomésticos (a “internet das coisas”).

O tratamento de dados, entretanto, não transfere aos agentes de tratamento⁶ a titularidade dos dados. O titular será a “pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento” (LGPD, art. 5º, inciso V). Por serem aspectos da personalidade da pessoa humana, constituem situações subjetivas personalíssimas e intransmissíveis.

Desse modo, o tratamento de dados tem natureza ambulatoria, a depender de certas circunstâncias para a sua continuidade. Nessa seara, exsurge a questão do término do tratamento de dados. Se as operações realizadas com dados pessoais não transferem aos agentes de tratamento a titularidade deles, qual o limite para sua utilização?

2. Término do tratamento de dados

A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) previu a exclusão dos dados pessoais como um direito do usuário da internet no seu art. 7º, inciso X:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

[...]

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei.

A finalidade do dispositivo é a de permitir ao usuário o controle das suas informações, conferindo-lhe o direito de solicitar a exclusão definitiva dos seus dados pessoais ao final da relação entre as partes, caso entenda conveniente.⁷ A previsão do Marco Civil da Internet traz dois aspectos fundamentais, repetidos na LGPD: i) o consentimento; e ii) a finalidade específica. A eficácia do consentimento condiciona-se à finalidade das operações envolvendo os dados pessoais. Dessa forma, atribui-se maior controle dos dados.⁸ O término do tratamento de dados pessoais (em geral) foi regulamentado nos artigos 15 e 16 da LGPD:

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I – verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II – fim do período de tratamento;

III – comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou

IV – determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

O art. 15 da LGPD enuncia as hipóteses de término do tratamento de dados pessoais, que podem ser organizadas da seguinte forma: i) pelo esgotamento funcional da utilização dos dados; ii) pelo término do prazo; iii) pela autodeterminação do titular; e iv) por ilegalidade.

Uma das preocupações centrais da LGPD consiste na finalidade específica do tratamento de dados. O art. 6º da Lei enuncia os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade, a nortear as atividades de tratamento de dados. Ora, a realização do tratamento de dados deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; de forma compatível ou adequada com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; e ainda no limite do mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Utiliza-se do princípio da proporcionalidade, ou seja, o tratamento dos dados é protegido na medida em que o meio é adequado e necessário para o fim almejado.

Por um lado, tem-se o respeito à função (para que serve) do tratamento de dados. Assim, se a finalidade consiste em coleta de dados para acesso a conteúdos gratuitos de um *blog* ou jornal eletrônico, não podem os mesmos dados serem utilizados para envio de material de *marketing* não especificado. A finalidade pode ser continuada ou não. O tratamento de dados para uma compra *on-line*, por exemplo, esgota-se com a finalização da própria compra, salvo se o titular autorizar o armazenamento dos dados para compras futuras. Por outro lado, caso o tratamento de dados esteja vinculado a lapso temporal, ao seu fim haverá o seu término, a obstar qualquer operação de dados pessoais. Pode-se afirmar assim que poderá haver um lapso funcional ou um lapso temporal, ao término dos quais devem ser finalizadas as operações dos dados pessoais respectivos.

As duas primeiras hipóteses decorrem do princípio do consentimento ou autodeterminação informativa, como foi nomeado na seara da proteção de dados. A finalidade e o tempo constituem limites estabelecidos pela autodeterminação. Para os fins da LGPD, considera-se consentimento a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (LGPD, art. 5º, inciso XII). Significa dizer que o consentimento desvinculado da finalidade ou tempo para o qual foi dado não é consentimento e, portanto, não merece proteção.

Veja-se, por exemplo, o consentimento oferecido quando criança para determinada pesquisa científica, sem estar ciente de todos os riscos inerentes. Nesse caso, os dados pessoais poderão ser mais tarde suprimidos, inclusive na internet. Por envolver direitos da personalidade, portanto, personalíssimos, ainda antes da maioridade, poder-se-á requerer o término do tratamento.⁹ Em contrapartida, a conservação dos dados pessoais ocorre em situações específicas, nas quais o legislador limitou a autodeterminação do sujeito para tutelar outro interesse que, sopesado com a autonomia, no caso concreto, haveria de prevalecer.

Ao mesmo tempo, a terceira hipótese consagra o que se chamou de princípio do consentimento qualificado.¹⁰ A respeito da importância do consentimento na disciplina dos atos de conteúdo não patrimonial, sublinha-se constantemente a exigência – mais que isso, a necessidade – de que o consenso do autor do ato seja pleno, efetivo, nunca presumido, atual, espontâneo, consciente, informado: características, essas, nem sempre requeridas com a mesma intensidade para a

validade dos contratos, nos quais se registra uma impositação prevalentemente objetiva. Assim, o princípio do consentimento qualificado atribui à vontade interna do declarante uma relevância que nas situações patrimoniais não tem. Usa-se o termo qualificado a fim de evidenciar a maior importância dada à vontade subjetiva do declarante. Como corolário do princípio do consentimento qualificado, tem-se especialmente as seguintes consequências para o regulamento das situações jurídicas subjetivas existenciais: i) a vontade interna deve prevalecer sobre a declarada; ii) a manifestação de vontade é pessoal; e iii) a manifestação de vontade é revogável. A revogabilidade decorre do princípio do consentimento qualificado, sobretudo, quando da disposição resulte limitação ao exercício de direito da personalidade, pois somente a limitação voluntária é admissível. A revogabilidade do consentimento é marcante na LGPD, prevista como uma das hipóteses de término do tratamento de dados pessoais.

Finalmente, a quarta hipótese é a determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD.

A eliminação é consequência do término do tratamento dos dados pessoais. Admite-se a sua conservação apenas para se alcançar as finalidades dispostas na Lei. Por ser regra de exceção, a interpretação deve ser restritiva, de molde a não admitir outras hipóteses, ainda que análogas. A primeira exceção é a conservação para o cumprimento de dever legal ou regulatório pelo controlador. Também para estudo em pesquisa científica os dados podem ser mantidos, garantida a anonimização. Veja-se, nesse caso, o exemplo da pesquisa clínica para desenvolvimento de novos medicamentos, cujos dados pessoais de determinado indivíduo não podem ser removidos do conjunto de dados da pesquisa sem afetar seu resultado estatístico e, portanto, a própria comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento em fase de testes. Se os dados são transferidos a terceiros, da mesma forma, não há eliminação, desde que respeitados os requisitos para tratamento de dados. Por fim, não são eliminados os dados para uso exclusivo do controlador, condicionada à anonimização dos dados.

Não previu o legislador prazo para a conservação dos dados pessoais nas hipóteses do art. 16 da LGPD. O Marco Civil da Internet, por outro lado, determina a guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses ou regulamento específico, por exemplo. Com efeito, na ausência de lapso temporal para a guarda desses dados pessoais, poder-se-ia aplicar o prazo previsto no Marco Civil da Internet¹¹ ou entender que não há limitação temporal.

Em síntese, a regra é a eliminação dos dados pessoais quando seu tratamento se encerra, nos moldes do referido art. 16 da LGPD. Trata-se de modelo que visa a diminuir os riscos do uso não autorizado ou indevido dos dados pessoais.

3. Direito ao esquecimento: distinção necessária

Alguns autores vinculam o direito de o usuário da internet, a partir do término do tratamento dos dados, ter os seus dados pessoais excluídos com o denominado direito ao esquecimento.¹² Assim parecem fazer com a finalidade de se extrair de

uma expressa norma jurídica a possibilidade de proteção do direito ao esquecimento no âmbito virtual,¹³ tendo em vista que não há no ordenamento jurídico brasileiro disciplina específica que tutele tal proteção.¹⁴ No entanto, é necessário refletir se realmente o que se costuma buscar com a aplicação do chamado direito ao esquecimento no sistema jurídico brasileiro tem estrita relação com a necessidade de se excluir os dados pessoais do usuário após o término do tratamento desses dados, nos termos do previsto pelo Marco Civil da Internet e pela LGPD.

Apesar de não haver disciplina expressa no ordenamento jurídico nacional que tutele especificamente o denominado “direito ao esquecimento”, no Brasil, o seu reconhecimento é fruto de construções doutrinárias e jurisprudenciais. Principalmente por meio de uma interpretação axiológica dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal brasileira, em especial o da dignidade da pessoa humana, estabeleceu-se que existe um direito de não ser lembrado eternamente por equívocos pretéritos ou situações constrangedoras que digam respeito à vida privada do indivíduo. Trata-se, então, de um direito essencial ao livre desenvolvimento da personalidade humana, que consiste no direito de o sujeito impedir que sua memória pessoal seja revirada a todo instante, por força da vontade de terceiros.¹⁵

O direito ao esquecimento surgiu como um aspecto da privacidade,¹⁶ com o principal objetivo de proteger o indivíduo da eterna circulação e divulgação pública de fatos pretéritos relacionados à sua vida privada que, de alguma forma, o impedissem de desenvolver livremente sua identidade pessoal. Também conhecido como “direito de estar só”, “direito de ser deixado em paz”, ou mesmo *right to be let alone*, no direito americano, e *derecho al olvido*, no direito espanhol, esse direito tornou-se uma das mais relevantes e indispensáveis formas de proteger a pessoa humana, pois permite que o indivíduo não tenha que suportar indefinidamente a divulgação de fatos ou informações passadas cuja lembrança indesejada seja também irrelevante para a coletividade e potencialmente comprometedora do seu livre desenvolvimento.

Objeto de análise pelos tribunais brasileiros, o direito ao esquecimento é normalmente reconhecido e examinado em situações trazidas por indivíduos que desejam se defender contra a publicidade de uma memória negativa ou constrangedora de fatos pretéritos de sua vida, cuja eterna divulgação se mostra capaz de impedir o livre e pleno desenvolvimento de sua identidade pessoal.¹⁷ A doutrina assim também aborda o campo de abrangência da proteção perseguida pelo direito ao esquecimento. Nesse sentido, Stefano Rodotà explica que

[...] o direito ao esquecimento apresenta-se como o direito de governar a própria memória, restituir a cada pessoa a possibilidade de se reinventar, de construir personalidade e identidade, libertando-se da tirania das gaiolas em que uma memória onipresente e total quer cercar a todos.¹⁸

Como se pode observar, a proteção normalmente perseguida com a aplicação do direito ao esquecimento no sistema jurídico brasileiro refere-se à possibilidade de a pessoa humana se opor à recordação opressiva de determinados fatos perante a sociedade. Isso porque a reprodução de tais fatos dificulta o pleno

desenvolvimento de sua identidade pessoal, por enfatizar, perante terceiros, aspectos de sua personalidade que não refletem mais a sua pessoa.

Assim, a aplicação e a conceituação que se vem atribuindo propriamente ao chamado “direito ao esquecimento” não parece equiparar-se à específica situação da exclusão dos dados pessoais como efeito do término do tratamento de dados estabelecido tanto pelo Marco Civil da Internet quanto pela LGPD. Na jurisprudência, a aplicação do direito ao esquecimento no âmbito da internet é normalmente realizada para desindexar determinados termos ou frases de forma a dificultar o acesso a certas informações. Já a previsão de exclusão dos dados estabelecida pelo Marco Civil da Internet e pela LGPD foi feita para tornar total ou parcialmente indisponíveis, a depender do pedido, os dados pessoais de um usuário, independentemente de serem dados sensíveis ou não.

O direito ao esquecimento, tal qual vem sendo entendido pela jurisprudência, concentra-se no tratamento de fatos pretéritos que envolvem o indivíduo e na possibilidade desses fatos não serem objeto de uma eterna divulgação pública quando não haja qualquer interesse legítimo para tal permanência. Assim, os artigos 7º do Marco Civil da Internet e 16 da LGPD, ao tratarem do descarte e efetivo apagamento dos dados dos usuários, não parecem propriamente fazer referência ao direito ao esquecimento nos moldes de como esse direito é atualmente entendido e exercido na prática. O verdadeiro fundamento do direito ao esquecimento está na Constituição.

4. Responsabilidade civil pelas operações de dados após o término do seu tratamento

Salvo nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, em que o legislador expressamente autoriza a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento, o controlador deve descartá-los tão logo ocorra o encerramento do tratamento, nos termos do art. 15 da LGPD. Se, após o término do tratamento, o controlador não descartar os dados pessoais, como determina a LGPD, ele poderá vir a ser responsabilizado, presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Na Seção III, sob o título “Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos”, a LGPD traz as principais regras de responsabilidade civil que irão reger as relações que envolvem tratamento de dados pessoais. Inspirada no Regulamento Europeu,¹⁹ a seção é composta por apenas quatro dispositivos (arts. 42 a 45) que, infelizmente, não deixam claro qual foi a espécie de responsabilidade adotada pelo legislador na LGPD, se objetiva ou subjetiva, sendo essa, aliás, uma das principais críticas dirigidas à LGPD.

A LGPD deveria ter sido explícita em relação à natureza da responsabilidade, porque isso evitaria uma série de controvérsias que inevitavelmente vão surgir em razão dessa falta de clareza. Ao invés disso, limitou-se o legislador a estabelecer, nos artigos 42 e 43, o seguinte:

“Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou

coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I – o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II – os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

I – que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II – que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III – que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

Embora a LGPD seja recente, a partir da interpretação desses dispositivos, já se observa a formação de duas correntes. De um lado estão os defensores da responsabilidade objetiva, que argumentam, com base em analogia ao CDC, que a LGPD adotou o modelo de responsabilidade objetiva. De fato, a LGPD tem mesmo várias disposições que são inspiradas no CDC, a exemplo da possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova (art. 42, § 2º, da LGPD).

Além disso, o próprio texto do art. 43 da LGPD assemelha-se à redação do art. 12, § 3º, do CDC (e essa, por sua vez, é parecida com a do art. 14, § 3º, do CDC²⁰). As semelhanças são muitas, a começar pelo *caput* do art. 43 da LGPD, que é muito parecido com o § 3º do art. 12 do CDC, já que ambos começam com uma redação na negativa (“só *não* serão responsáveis quando”). O inciso III do art. 43 da LGPD é quase idêntico ao art. 12, § 3º, inciso III, do CDC, e o inciso I do art. 43 da LGPD é, no mínimo, inspirado no art. 12, § 3º, inciso I, do CDC. A analogia com o CDC é, portanto, compreensível, tanto mais se se considerar que muitas vezes a guarda dos dados integra o próprio serviço. Comparando-se os dois dispositivos, a diferença está, a nosso ver, no inciso II, cuja análise será feita mais à frente, sendo imprescindível para demonstrar a diversidade de regimes.

A favor da responsabilidade objetiva, argumenta-se, ainda, que o escopo da LGPD foi limitar o tratamento dos dados para diminuir o risco de vazamentos, considerando que o próprio tratamento de dados, em si, apresenta “risco intrínseco aos seus titulares”:

Essas limitações ao tratamento de dados, conjuntamente com a verificação de que a LGPD assume como regra a eliminação dos dados quando seu tratamento esteja encerrado (art. 16) e igualmente o aceno que faz em diversas oportunidades à necessidade de se levar em conta o risco presente no tratamento de dados, indicam que a Lei procura minimizar as hipóteses de tratamento àqueles que sejam, em um sentido geral, úteis e necessárias, e que mesmo essas possam ser limitadas quando da verificação de risco aos direitos e liberdades do titular de dados. Trata-se, dessa forma, de uma regulação que tem como um de seus fundamentos principais a diminuição do risco, levando-se em conta que o tratamento de dados apresenta risco intrínseco aos seus titulares.²¹

De outro lado, no extremo oposto, estão os defensores da responsabilidade subjetiva e da culpa como fundamento do regime estabelecido pela LGPD.²² Aqui também há vários argumentos consistentes. A estrutura da LGPD é toda pautada na criação de deveres. O legislador criou uma série de deveres de cuidado que devem ser seguidos pelo controlador e pelo operador, sob pena de virem a ser responsabilizados.

Assim, não faz muito sentido – nem do ponto de vista lógico, nem do jurídico – o legislador criar uma série de deveres de cuidado se não for para implantar um regime de responsabilidade subjetiva. Se o que se pretende é responsabilizar os agentes, independentemente de culpa de fato, não faz sentido criar deveres a serem seguidos, tampouco responsabilizá-los quando tiverem cumprido perfeitamente todos esses deveres. A lógica da responsabilidade objetiva é outra, completamente diferente: não cabe discutir cumprimento de deveres,²³ porque, quando se discute cumprimento de deveres, o que no fundo está sendo analisado é se o agente atuou ou não com culpa.

Apesar de a LGPD não ser explícita em relação à natureza da responsabilidade dos agentes de tratamento de dados, há na LGPD diversas pistas que, a nosso ver, levam à conclusão de que o regime adotado pela LGPD, como regra, foi mesmo o da responsabilidade subjetiva.

A primeira pista é o próprio histórico de tramitação do Projeto de Lei que deu origem à LGPD, que mostra a opção do legislador pela responsabilidade subjetiva. A versão inicial do PL 5.276/2016 trazia no Capítulo sobre “Transferências internacionais de dados”, uma regra geral expressa de responsabilidade solidária e objetiva desses agentes pelos danos causados em virtude do tratamento de dados (art. 35). Além disso, na Seção sobre “Responsabilidade e Ressarcimento de danos”, havia uma abordagem ampla sobre os sujeitos obrigados a reparar o dano (“todo aquele que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais causar a outrem dano”) (art. 42), e outra regra igualmente ampla prevendo a solidariedade entre todos os agentes da cadeia de tratamento, sem qualquer distinção entre controlador e operador:

[...] [n]os casos que envolvem a transferência de dados pessoais, o cessionário ficará sujeito às mesmas obrigações legais e regulamentares do cedente, com quem terá responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados (art. 44).

Diferentemente desse primeiro texto, todas as versões subsequentes do Projeto, até a versão finalmente sancionada da LGPD, passaram a não mais mencionar, como regra geral, um regime de solidariedade ou objetividade na responsabilidade pelos danos decorrentes do tratamento de dados pessoais. A referência expressa à responsabilidade objetiva foi completamente eliminada do texto legal.

A segunda pista é o fato de a LGPD ter todo um capítulo dedicado à “segurança e boas práticas”. Trata-se do Capítulo VI, que é dividido em duas seções: (i) Seção I – Da segurança e do sigilo de dados; e (ii) Seção II – Das Boas Práticas e da Governança. Nessas seções, a LGPD criou uma série de deveres que devem ser observados pelos agentes de tratamento de dados, estabelecendo verdadeiro *standard* de conduta que deve ser seguido pelos agentes de tratamento de dados, chegando mesmo ao ponto de determinar, na Seção II, que os agentes poderão, no âmbito de suas competências, traçar as normas de boas práticas e de governança. Também na Seção II é possível notar a preocupação do legislador com a conduta dos agentes, assim como com o cumprimento de programas, políticas internas, procedimentos, mecanismos de supervisão (internos e externos), padrões técnicos etc.

Tudo isso está a indicar que, na sistemática da lei, o modelo adotado foi o da responsabilidade subjetiva, pelo menos como regra geral. Afinal, por qual razão o legislador teria imposto tantos deveres e fixado um padrão de conduta se fosse para responsabilizar os agentes, independentemente de terem esses agido ou não com culpa?

O próprio art. 6º da LGPD, ao estabelecer os princípios que deverão ser observados nas atividades de tratamento de dados, elegeu como princípios a “responsabilização” e a “prestação de contas”. Segundo o art. 6º, inciso X, da LGPD, os agentes deverão demonstrar a “adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas”. Do ponto de vista do controlador, do que adianta “prestar contas”, se, ao final, se houver incidente, por mais diligente que tenha sido, ele será responsabilizado da mesma forma e independentemente de culpa?²⁴

Ao criar verdadeiro *standard* de conduta, a LGPD se aproximou mais do regime de responsabilidade fundado na culpa. Afinal, a noção atual de “culpa” envolve mesmo a análise dos *standards* de conduta socialmente aceitos. Nos últimos tempos, a noção clássica de culpa cedeu lugar para um conceito mais objetivado, que tem sido designado de culpa normativa. A culpa passou a ser analisada a partir da ideia de desvio de conduta, que leva em conta apenas o comportamento exigível diante das especiais circunstâncias do caso concreto.²⁵ Por outras palavras: significa dizer que não se investiga mais o direcionamento da vontade do agente para o descumprimento da ordem jurídica em termos abstratos, mas, sim, a sua adequação (ou não) ao padrão de comportamento esperado naquelas circunstâncias concretas.

A LGPD parece indicar qual é o padrão de conduta socialmente esperado – o *standard* – que deve ser seguido pelos agentes de tratamento de dados, sob pena

de virem a ser responsabilizados. Tais profissionais precisam adotar uma série de medidas de segurança e mesmo preventivas. Se ocorrer algum incidente, a sua conduta não será examinada apenas no plano abstrato, mas, sim, em concreto, avaliando-se também o que tais agentes fizeram para evitar o dano e mesmo para conter os seus efeitos e, quando possível, remediá-los.

Para além disso, há ainda uma terceira pista na LGDP, que aponta para o regime de responsabilidade subjetiva: o inciso II do art. 43. De acordo com esse dispositivo, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, entre outros fatores, “que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados”. Ao contrário dos incisos I e III do art. 43, que nitidamente se referem à relação de causalidade, o inciso II remete à ideia de culpa como fundamento da responsabilidade civil e sua redação é diferente da empregada pelo legislador no art. 12, § 3º, inciso II, do CDC.

No inciso I do art. 43, o legislador isenta de responsabilidade os agentes que provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Essa excludente de responsabilidade está, nitidamente, afastando o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Como se refere à relação causal, é excludente que poderia existir ainda que a responsabilidade consagrada pela LGPD fosse a objetiva. É muito parecida com a hipótese prevista no art. 12, § 3º, inciso I, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor que provar “que não colocou o produto no mercado”.

No inciso III do art. 43, o legislador isenta de responsabilidade os agentes que provarem “que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro”. Embora o legislador tenha usado a expressão “culpa exclusiva”, quando há fato exclusivo da vítima, ensina a doutrina que “o agente que causa diretamente o dano é apenas um instrumento do acidente, não se podendo, realmente, falar em liame de causalidade entre seu ato e o prejuízo por aquela experimentado”.²⁶ A conduta da vítima absorve totalmente a atuação do agente, que funcionará como mera ferramenta na produção do evento danoso.²⁷

A “culpa exclusiva da vítima” é, portanto, uma excludente de responsabilidade civil que interfere no liame que vincula a conduta do agente ao dano. Dessa forma, até mesmo na responsabilidade civil objetiva, com essa excludente, o agente fica isento do dever de indenizar. Isso é assim porque, embora a responsabilidade objetiva independa de culpa, a ação exclusiva da vítima afeta, frise-se, o nexo causal que a associa ao dano. Exatamente por isso, faz todo sentido que a “culpa exclusiva do consumidor” também constitua causa de exclusão da obrigação de indenizar do fornecedor, tanto na responsabilidade pelo fato do produto (art. 12, § 3º, inciso III, do CDC) quanto na responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), mesmo o CDC tendo adotado o modelo objetivo.

Diferentemente dos incisos I e III do art. 43 da LGPD, o inciso II nada tem a ver com nexo de causalidade. No inciso II do art. 43, o legislador isenta de responsabilidade os agentes que provarem “que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à

legislação de proteção de dados”. Aqui está, a nosso ver, a pista mais importante que indica o regime adotado pela LGPD em matéria de responsabilidade civil.

Nesse inciso II, o legislador afirma, *grosso modo*, que, ainda que exista nexo causal entre a conduta do agente e o dano, se ele conseguir provar que cumpriu todos os deveres impostos pela LGPD, tomando as medidas de segurança recomendadas (cumprindo programas, políticas internas, procedimentos, mecanismos de supervisão, internos e externos, padrões técnicos etc.), não será responsabilizado. Nessas circunstâncias, o agente terá demonstrado que observou o *standard* esperado e, se o incidente ocorreu, não foi em razão de sua conduta culposa.

O inciso II reflete, portanto, o regime subjetivo de responsabilidade, adotado pela LGPD, porque está intrinsecamente vinculado ao elemento culpa e, exatamente por isso, sua redação *não* se assemelha à do CDC. Enquanto o CDC isenta de responsabilidade o fornecedor que demonstrar que o defeito inexistiu, que é um parâmetro mais objetivo, a LGPD exige do dever de indenizar o agente de tratamento que não tiver violado a lei.

5. Considerações Finais

A LGPD tem a finalidade de permitir o controle do tratamento de dados pessoais pelo próprio titular, eis que o consentimento desse não implica transferência da titularidade dos dados para os agentes de tratamento, que passam a ter limites. O art. 15 da Lei enuncia as hipóteses de término do tratamento de dados pessoais, que podem ser organizadas da seguinte forma: i) pelo esgotamento funcional da utilização dos dados; ii) pelo término do prazo; iii) pela autodeterminação do titular; e iv) por ilegalidade. Em síntese, a regra é a eliminação dos dados pessoais quando seu tratamento se encerra, nos moldes do art. 16. Trata-se de modelo que visa a diminuir os riscos do uso não autorizado ou indevido dos dados pessoais.

O término do tratamento dos dados pessoais não se confunde com a tutela do chamado “direito ao esquecimento”. Esse concentra-se no tratamento de fatos pretéritos que envolvem o indivíduo e na possibilidade desses fatos não serem objeto de uma eterna divulgação pública quando não haja qualquer interesse legítimo para tal permanência. A eliminação dos dados pessoais, por manifestação de vontade do titular, independe de qualquer motivação, eis que a revogação do consentimento retira a legitimidade do tratamento dos dados. Assim, os artigos 7º do Marco Civil da Internet e 16 da LGPD, ao tratarem do descarte e efetivo apagamento dos dados dos usuários, não parecem propriamente fazer referência ao direito ao esquecimento nos moldes de como esse direito é atualmente entendido e exercido na prática, cujo fundamento é extraído da própria Constituição Federal.

Uma vez que o término do tratamento de dados não é seguido da sua eliminação, há de se verificar a repercussão na seara da responsabilidade civil. Observa-se, desde já, a existência de dois posicionamentos, opostos, quanto à natureza da responsabilidade civil, se objetiva ou subjetiva. A leitura sistemática da

LGPD parece indicar pistas segundo as quais a responsabilidade seria subjetiva. Isso porque, além de outros argumentos, a norma impõe, por meio da previsão de deveres específicos, um padrão de conduta socialmente esperado – o *standard* –, que deve ser seguido pelos agentes de tratamento de dados, sob pena de virem a ser responsabilizados.

Ainda outras questões podem surgir no enfrentamento do tema, que permanecem em aberto, a exemplo dos dados pessoais em sistema de dados corporativos (*e-mails* corporativos, imagens de pessoal em atividades da empresa, cópias de documentos e exames médicos em posse de empregadores) que, sem dúvida, interessam à pessoa humana, mas, também, à atividade corporativa pública ou privada; ou mesmo a possibilidade de se manterem os dados pessoais enquanto não consumado eventual prazo prescricional, por serem necessários à produção de qualquer defesa de direitos ou prova do cumprimento de obrigações. Demonstra-se, assim, que a LGPD iniciou necessária e contínua discussão sobre o tempo e o tratamento dos dados pessoais.

Referências

AGUIAR DIAS, José de. *Da responsabilidade civil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 2.

BITELLI, Marcos Alberto Sant'Anna. A Lei 12.965/2014 – O marco civil da internet. *Revista de Direito das Comunicações*, São Paulo, Ed. RT, v. 7, jan./jun. 2014.

BODIN DE MORAES, Maria Celina. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, Ed. RT, v. 854, dez. 2006.

CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, Ed. RT, v. 13, out./dez. 2017.

CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexa causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. In: *Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional*. São Paulo: Ed. RT, ago. 2015. v. 8.

LLAMBÍAS, Jorge Joaquín. *Tratado de derecho civil*. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1973. t. III.

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. *Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

MENDES, Jorge Barros. O novo regulamento de proteção de dados. *Revista Luso-Brasileira de direito do consumo*, Curitiba: Bonijuris, n. 7, v. 27, set. 2017.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, Ed. RT, v. 120, nov./dez. 2018.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, Ed. RT, v. 120, nov./dez. 2018.

MONTENEGRO, Antônio Lindbergh C. *Responsabilidade civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de Direitos Fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Estado de Direito e Tecnologia*, edição temática, Vitória, FDV publicações, v. 19, set./dez. 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Proteção de dados pessoais: comentários à Lei 13.709/2018*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

RAMOS, André de Carvalho. Direito ao esquecimento e o controle indireto dos bancos de dados de consumo. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 104, São Paulo, Ed. RT, mar./abr. 2016.

RIBEIRO, Juliana Tedesco Racy. Proteção dos dados pessoais no direito brasileiro. In: CASCAES, Amanda Celli et al. *Panorama legal sobre as relações de consumo no Brasil*. São Paulo: Editora Singular, 2017.

RODOTÀ, Stefano. *Dai ricordi ai dati l' oblio è un diritto?* Disponível em: [\[ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html?ref=search&refresh_ce\]](http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html?ref=search&refresh_ce). Acesso em: 01.03.2019.

RODRIGUES, Silvio. *Direito civil: responsabilidade civil*. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4.

SILVA, Paula Jaeger da. Direito ao esquecimento: aumento do problemática com o advento da internet. *Revista Jurídica*, São Paulo, Síntese, n. 491, set. 2018.

1

.Doutora e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Professora Adjunta de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ. Professora dos cursos de pós-graduação *lato sensu* da PUC-RJ, do CEPED/UERJ e da EMERJ. Advogada e parecerista.

2

.Doutora e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Professora Adjunta de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ. Procuradora da UERJ. Advogada.

3

.CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, Ed. RT, v. 13, out./dez. 2017. p. 4.

4

.MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, Ed. RT, v. 120, nov./dez. 2018. p. 22.

5

.A LGPD define os principais termos utilizados na regulamentação da proteção dos dados pessoais.

6

.De acordo com a LGPD, a cadeia de tratamento de dados pessoais encontra-se centralizada em dois agentes de tratamento (controlador e operador), que são definidos conforme as funções que desempenham. Enquanto o inciso VI do art. 5º da Lei estabelece que o controlador é “a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais”, o inciso VII do mesmo artigo determina que o operador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”.

7

.BITELLI, Marcos Alberto Sant’Anna. A Lei 12.965/2014 – O marco civil da internet. *Revista de Direito das Comunicações*, São Paulo, Ed. RT, v. 7, jan./jun. 2014. p.11.

8

.“Este consentimento pode ser concedido, basicamente, de duas maneiras: por meio do *opt-in* (sistema por meio do qual o titular tem de dar seu consentimento expressamente antes de haver a coleta e uso de dados) ou o *opt-out* (sistema por meio do qual o titular opta por não dar o consentimento, após coleta ou eventual uso dos dados)” (RIBEIRO, Juliana Tedesco Racy. Proteção dos dados pessoais no direito brasileiro. In: CASCAES, Amanda Celli et al. *Panorama legal sobre as relações de consumo no Brasil*. São Paulo: Singular, 2017. p. 89). O legislador brasileiro optou pelo sistema *opt-in*, conforme artigo 8º da LGPD.

9

.MENDES, Jorge Barros. O novo regulamento de proteção de dados. *Revista Luso-Brasileira de direito do consumo*, Curitiba, Bonijuris, v. 7, n. 27, set. 2017. p. 26.

10

.Sobre o ponto, vide MEIRELES, Rose Melo Vencelau. *Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, passim.

11

.Nesse sentido, consulte-se RIBEIRO, Juliana Tedesco Racy. Op. cit., p. 89.

12

.Nesse sentido: LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito ao esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito italiano e no direito brasileiro. *Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional*, São Paulo, Ed. RT, v. 8, p. 511-543, ago. 2015; SILVA, Paula Jaeger da. Direito ao esquecimento: aumento do problemática com o advento da internet. *Revista Jurídica*, São Paulo, Síntese, n. 491, pp. 63-70, set. 2018; PINHEIRO, Patrícia Peck. *Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

13

.Nessa linha: “De tais normas pode-se extrair uma possibilidade de proteção ao direito ao esquecimento no âmbito virtual, levando em consideração a ponderação que necessariamente é de ser feita tendo em vista o direito à informação” (SILVA, Paula Jaeger da. Op. cit., p. 70).

14

.A vinculação também pode estar relacionada ao fato de o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 do direito europeu, que serviu de inspiração para a elaboração da LGPD,

denominar, em seu art. 17, o direito do usuário da internet de ter os seus dados pessoais excluídos de “direito a ser esquecido”.

15

.Ressalta-se que a análise do direito ao esquecimento será casual, devendo-se examinar as peculiaridades do caso concreto, ponderando-se a utilidade informativa na divulgação da notícia com os riscos trazidos pela recordação do fato à pessoa envolvida.

16

.Acerca da compreensão desse direito, a doutrina explica que: “Surge, então, como desdobramento do direito à privacidade, o direito ao esquecimento que consiste na faculdade de se exigir a não publicização de fato relacionado ao titular, cujo interesse público esvaneceu-se pelo decurso dos anos. Há o choque entre o direito à privacidade e autodeterminação informativa com o direito de informação, em um contexto da passagem do tempo” (RAMOS, André de Carvalho. Direito ao esquecimento e o controle indireto dos bancos de dados de consumo. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, Ed. RT, v. 104, mar./abr. 2016. p. 141).

17

.No Brasil, o direito ao esquecimento já foi objeto de análise por grande parte dos tribunais, nos quais costuma-se questionar seu reconhecimento nos âmbitos cível e penal, bem como o seu impacto na internet, especialmente em casos que tratam de pedidos de desindexação de páginas e conteúdos direcionados a provedores de aplicações. Em precedente emblemático, o STJ reconheceu o direito ao esquecimento em caso envolvendo indivíduo absolvido pelo Tribunal do Júri por envolvimento na “Chacina da Candelária”, o qual reclamou reparação pelo direito de não ver seu nome incluído em programa de televisão que reconstituía a tragédia. Com base no direito ao esquecimento, o pedido de indenização do autor foi acolhido pelo Tribunal (STJ, 4ª T., REsp 1.334.097/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.05.2013, *DJe* 10.09.2013). No âmbito virtual, diversos casos analisados pelo STJ envolvem pedidos de aplicação do direito ao esquecimento em buscadores de pesquisa da internet, isto é, pedidos de desindexação de informações constrangedoras ou que de alguma forma afetem o livre desenvolvimento da identidade pessoal do autor. Exemplificativamente: STJ, 3ª T., REsp 1.660.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2018, *DJe* 05.06.2018; STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1.599.054/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.04.2017, *DJe* 11.05.2017; STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1.593.873/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2016, *DJe* 17.11.2016.

18

.RODOTÀ, Stefano. “*Dai ricordi ai dati l’ oblio è un diritto?*”. Disponível em: [\[ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html?ref=search&refresh_ce\]](https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html?ref=search&refresh_ce). Acesso em: 01.03.2019. Tradução livre. No original: “*Il diritto all’ oblio si presenta come diritto a governare la propria memoria, per restituire a ciascuno la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipotente e totale vuole rinchiudere tutti*”.

19

.MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, Ed. RT, v. 120, nov./dez. 2018. p. 469. Embora a Lei de Proteção de Dados brasileira não seja uma cópia fiel do GDPR, esse Regulamento foi especialmente muito relevante e serviu de inspiração a diversos dispositivos da lei nacional.

20

.CDC, art. 14: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

21

22

.Em artigo sobre dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais, ainda que não analisando propriamente a natureza jurídica da responsabilidade civil, ao examinar um caso específico, que tratou de uma falha de segurança no tratamento de dados ocasionando a divulgação de hábitos sexuais de doadores de sangue, Caitlin Sampaio Mulholland utiliza a expressão “ato ilícito”. Pode-se inferir, a partir desse trecho, então, que a opinião da autora é no sentido de que a lei adotou o regime da responsabilidade subjetiva. Nas palavras da autora, no caso analisado, haveria “uma evidente violação no dever de segurança no tratamento de dados, caracterizando um ato ilícito” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de Direitos Fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Estado de Direito e Tecnologia*, edição temática, Vitória, FDV publicações, v. 19, set./dez. 2018. p. 175-176).

23

.A doutrina explica, no que se refere à responsabilidade objetiva, que sua concretização “independe completamente de negligência, imprudência, imperícia ou mesmo da violação de qualquer dever jurídico por parte do agente. São danos (injustos) causados por atos lícitos, mas que, segundo o legislador, devem ser indenizados” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, Ed. RT, v. 854, dez. 2006. p. 25 – grifou-se).

24

.A prestação de contas é normalmente exigida de quem age por conta e/ou em nome de outrem (a exemplo, do mandatário, do administrador, do tutor, do curador etc.), a fim de que se possa averiguar se o agente está observando todos os seus deveres legais (e contratuais, se for o caso), e a sua responsabilidade costuma seguir o modelo subjetivo.

25

.Nesse sentido, explica-se o seguinte: “O conceito de culpa também se encontra em estado de indefinição no atual direito da responsabilidade civil. Originalmente, culpa era apenas a situação contrária ao direito, porque negligente, imprudente, imperita ou dolosa, que acarretava danos aos direitos de outrem. Modernamente, todavia, diversos autores abandonaram esta conceituação, preferindo considerar a culpa o descumprimento de um *standard* de diligência razoável, diferenciando esta noção, dita ‘normativa’ ou ‘objetiva’, da outra, dita ‘psicológica’” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Op. cit., p. 21, nota de rodapé 48).

26

.RODRIGUES, Silvio. *Direito civil: responsabilidade civil*. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. p. 165.

27

.Não se trata, em realidade, de culpa exclusiva da vítima, mas de ato ou fato exclusivo da vítima, conforme observa Aguiar Dias: “Admite-se como causa de isenção de responsabilidade o que se chama de culpa exclusiva da vítima. Com isso, na realidade, se alude a ato ou fato exclusivo da vítima, pela qual fica eliminada a causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso. É fácil de ver a vantagem que resulta de tal concepção, mais ampla que a da simples culpa, mediante um simples exemplo. Não responde, decerto, uma empresa de carris urbanos, pela morte do indivíduo que se atira voluntariamente sob um bonde. Aí, é possível menção à culpa da vítima. Suponhamos, entretanto, que esse indivíduo é louco. Não se pode cogitar de culpa de louco. Mas, por isso, responderá a empresa, quando o fato foi de todo estranho a sua atividade? É claro que não” (AGUIAR DIAS, José de. *Da responsabilidade civil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 2. p. 693-694). Além disso, “referir-se à culpa da vítima já revela imprecisão técnica, pois a culpa supõe um ato ilícito para outrem” (MONTENEGRO, Antônio Lindbergh C. *Responsabilidade civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996. p. 327). No mesmo sentido: LLAMBIAS, Jorge Joaquín. *Tratado de derecho civil*. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1973. t. III. p. 718. A expressão “culpa exclusiva da vítima” é imprópria, sobretudo porque confunde dois elementos da responsabilidade civil absolutamente distintos: culpa e nexo causal. Quando ocorre “culpa

exclusiva da vítima”, a responsabilidade do agente é afastada por falta de nexo causal entre a sua conduta e o dano. Nesse sentido, seja-nos consentido citar: CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 165-176.

Capítulo 9. Direitos do titular de dados pessoais na Lei 13.709/2018: uma abordagem sistemática

Eduardo Nunes de Souza¹

Rodrigo da Guia Silva²

1. Introdução

A edição de diplomas legislativos voltados à regulamentação abrangente de um inteiro setor econômico, ou à proteção de um grupo social específico, não corresponde a um fenômeno recente. Na experiência brasileira, a proliferação dos chamados *estatutos* se intensificou particularmente com a promulgação da Constituição de 1988, diante da necessidade que então se colocava ao legislador, de implementar a tutela proporcional e adequada determinada pelo constituinte a certos grupos de pessoas vulneráveis (os exemplos mais emblemáticos foram o Código de Defesa do Consumidor – CDC – e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – e, mais recentemente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD).³ Desde então, novas situações fáticas passaram a apresentar novos desafios à ordem jurídica brasileira (muitas vezes fomentadas pelo vertiginoso avanço tecnológico observado após a virada do século, a suscitar controvérsias concretas simplesmente impensáveis poucos anos antes). Dessas questões tem tratado, em geral, primeiramente, a jurisprudência, à espera do naturalmente mais lento tratamento legislativo, o qual por vezes tarda a chegar e nem sempre atende, quando finalmente implementado, à expectativa social e às necessidades efetivas do setor então regulamentado.

Em matéria de dados pessoais, a atuação legislativa no Brasil tem sido fragmentada e bastante controvertida. Entre as principais normas sobre o tema, vale destacar: a pioneira disciplina proposta pelo CDC aos bancos de dados e cadastros de consumidores (arts. 43-44); a Lei 12.527/2011, que trata do acesso à informação em face de entes públicos, em regulamentação da garantia estabelecida pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal; a Lei 12.737/2012, muito criticada pela abordagem exclusivamente criminal de ilícitos cibernéticos, bem como por refletir uma resposta legislativa “de ocasião” (tendo o diploma ficado conhecido como Lei Carolina Dieckmann, após caso de repercussão nacional envolvendo a atriz); e, editada pouco tempo depois, a Lei 12.965/2014, que instituiu o Marco Civil da Internet, igualmente controverso, em particular pela proteção deficitária que seu art. 19 conferiu às vítimas de conteúdos lesivos postados por terceiros, na medida em que substituiu o sistema de *notice and take down* que até então era aplicado pela jurisprudência a hipóteses semelhantes).⁴

A edição da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018), nesse cenário, acena em direção à já longa demanda por um estatuto mais abrangente da matéria, capaz de conferir certa sistematicidade ao seu tratamento legislativo.⁵ Como ocorre com qualquer estatuto, porém, sua edição traz à tona o risco, há muito denunciado pela doutrina civil-constitucional, da interpretação fragmentária e setorial do diploma, na lógica dos muito aludidos *microssistemas*.⁶ Impõe-se, nesse sentido, compreender que, por um lado, as disposições contidas na LGPD se presumem corresponder à medida da tutela suficiente e adequada para os dados pessoais, conforme a ponderação democrática do legislador (não se admitindo a busca desordenada de dispositivos mais protetivos em outros diplomas normativos, na prática por vezes designada como “diálogo de fontes”)⁷ e, por outro lado, que, em respeito ao caráter sistemático da ordem jurídica, cuja unidade se funda na tábua axiológica consagrada pela Lei Maior, a nova lei deve implementar e promover os valores do ordenamento (sob pena de se revelar inconstitucional), bem como ser interpretada de forma coerente com as demais normas e institutos do sistema.

Mais do que isso, a entrada em vigor de um novo estatuto, claramente voltado à tutela de uma particular vulnerabilidade do mundo contemporâneo (nomeadamente, a constante ameaça representada pelo avanço tecnológico aos dados sociais) suscita reflexões sobre o juízo valorativo efetuado pelo legislador ao atribuir, expressamente, certos direitos ao grupo vulnerável – os titulares de dados pessoais. Desse tema cuida um inteiro capítulo da LGPD (o Capítulo III – arts. 17 a 22), intitulado de forma inequívoca como “Dos Direitos do Titular”. A análise das normas ali contidas, porém, como se buscará demonstrar, permite afirmar que as escolhas políticas refletidas na nova lei não se extinguem na atribuição de direitos, alcançando também a delicada calibragem do nível de tutela que o legislador pretendeu conferir a tais direitos. Nesse sentido, ao se deparar com um caso concreto e lançar seu primeiro olhar sobre a lei, não basta ao intérprete questionar: “O exercício da situação jurídica ora reconhecida é merecedor de tutela?”. Impende que, ato contínuo, pergunte: “Qual é a exata medida da tutela conferida ao exercício da situação jurídica em exame?”. A rigor, a decisão sobre o merecimento de tutela⁸ não se completa de sentido sem a delimitação da medida da tutela a que se faz jus no caso concreto,⁹ e a disciplina prevista pela LGPD apenas destaca essa constatação.

A preocupação com a disponibilização de meios de tutela dos direitos parece se refletir na tradicional formulação segundo a qual a ordem jurídica atribuiria ao titular do direito diversas medidas destinadas à sua conservação ou defesa. A classificação dessas medidas variará de acordo com o critério de análise: quanto ao conteúdo, serão preventivas ou repressivas, conforme visem, respectivamente, a evitar ou a reprimir uma lesão; quanto à forma de realização, serão judiciais ou extrajudiciais, conforme dependam ou não, respectivamente, da intervenção judicial.¹⁰ O estudo dos chamados *remédios*, isto é, dos instrumentos voltados à tutela dos direitos, situa-se no âmago dessa discussão.

A maior parte dos estudos sobre o tema costuma se dedicar aos remédios que se voltam contra a lesão ou a ameaça às situações jurídicas subjetivas.¹¹ Daí não se deve extrair, todavia, uma escusa para que o intérprete deixe de atentar também ao aspecto fisiológico do exercício das situações jurídicas,

independentemente da instauração de uma lide, em particular quanto ao merecimento de tutela de certas formas de exercício pelo titular.¹² Reduzir a análise ao aspecto patológico do exercício findaria por diminuir a importância da tutela assegurada pela ordem jurídica aos direitos.¹³ A investigação dos remédios assume, nessa direção, relevância central não apenas para se solucionarem hipóteses de perturbação (como a acepção coloquial da expressão *remédio* poderia levar a crer), mas, também, para se assegurar a efetividade do juízo positivo que o ordenamento faça recair sobre certo exercício de situações jurídicas. Assim, da indissociabilidade entre exercício e tutela dos direitos decorre a imprescindibilidade do estudo dos remédios tanto para as manifestações fisiológicas de exercício quanto para as patológicas.¹⁴

Diante da particular escolha, efetuada pelo legislador da LGPD, de prever extenso rol de remédios voltados à tutela dos direitos por ele mencionados, um breve comentário acerca da relevância dos remédios na tradição romano-germânica mostra-se oportuno, após a qual será possível compreender, com maior precisão, o nível de proteção efetivamente conferido pela lei aos dados pessoais.

2. Direitos e remédios na tradição de civil law

A doutrina usualmente converge, se não a propósito da definição precisa da expressão, ao menos no que tange à polissemia do termo *remédio*. Aponta-se, inicialmente, que a etimologia da palavra (*remedium*, do latim)¹⁵ remete à noção de cura ou reparo.¹⁶ Trata-se de noção amplamente difundida na doutrina especializada, em relevante coincidência com a acepção mais coloquial da expressão.¹⁷

A polissemia é identificada, também, no âmbito da doutrina do *common law*,¹⁸ à qual se costuma atribuir relativo pioneirismo – em comparação com a doutrina do *civil law* – no próprio estudo técnico dos remédios.¹⁹ Não causa espanto, assim, a consagração de expressões como “remedies for wrongs” ou “cure for wrongs”²⁰ para se fazer menção, entre outros aspectos, à problemática que a tradição romano-germânica designa como responsabilidade civil.²¹ Sem se ignorarem as divergências referentes à própria expressão “remedies for wrongs”,²² o que se pretende destacar é que o longo período de desenvolvimento da matéria na tradição anglo-saxã não teve o condão de afastá-la da polissemia que a doutrina do *civil law* tem nela igualmente identificado.²³

Afirma-se que os sistemas da família romano-germânica, tradicionalmente, dedicam grande atenção à enunciação e atribuição dos direitos, com particular destaque para a categoria do direito subjetivo.²⁴ Tal característica parece estar diretamente relacionada, ao menos, a dois pontos comumente identificados nesses sistemas: de um lado, a competência exclusiva (ou, ao menos, prioritária) do Poder Legislativo para a inovação na ordem jurídica, reservando-se tanto ao Executivo quanto ao Judiciário funções cujo traço comum seria a execução das leis, mas não a sua criação ou alteração;²⁵ de outro lado, a proeminência da lei como fonte do direito objetivo, ao que se associaria a histórica resistência (paulatinamente revisitada) ao reconhecimento de alguma relevante eficácia jurígena a fontes como os costumes e a jurisprudência.²⁶

No que diz respeito aos sistemas jurídicos da família anglo-saxã, de outra parte, historicamente se nega relevância à categoria do direito subjetivo e identifica-se a centralidade da atenção dispensada aos remédios.²⁷ Nesse sentido, em oposição ao modelo de atribuição abstrata dos direitos pela lei, pautado por acentuado formalismo jurídico, prevaleceria a atribuição de remédios específicos pelo juiz em cada caso concreto, em busca da máxima efetividade.²⁸ O ideal de efetividade da tutela jurisdicional não seria compatível com a enunciação abstrata dos direitos, razão pela qual se chega a afirmar que, nos países dessa família, a relevância da categoria do direito subjetivo se resumiria à indicação do grau de probabilidade da obtenção de um pronunciamento judicial favorável à parte.²⁹ A centralidade dos remédios (*remedies*) relegaria a um papel secundário a atribuição formal de direitos (*rights*)³⁰ ou, em formulação diversa, de posições jurídicas de vantagem (*entitlements*).³¹

As distinções antes apontadas poderiam ser sintetizadas pela oposição entre os brocardos que se costumam associar a cada uma das famílias de sistemas jurídicos: “ubi remedium ibi ius” *versus* “ubi ius ibi remedium”.³² De uma parte, nos países de *common law*, o destaque da jurisprudência (ou, mais precisamente, dos precedentes)³³ como fonte principal do direito e a centralidade da tutela judicial efetiva conduziriam ao reconhecimento de que “onde houver remédio, haverá direito”.³⁴ De outra parte, nos sistemas de *civil law*, a proeminência da lei como fonte do direito e a centralidade da enunciação e atribuição abstratas dos direitos conduziriam ao reconhecimento de que “onde houver direito, haverá remédio”.³⁵ Eis, em síntese, alguns dos principais contornos da diferenciação, concebida por parte da doutrina, entre a linguagem dos direitos (associada ao *civil law*) e a linguagem dos remédios (associada ao *common law*).³⁶

A partir do quadro comparativo exposto, destacam-se, em sede doutrinária, questões supostamente relevantes para se ilustrarem as repercussões da diferenciação entre a linguagem dos direitos e a linguagem dos remédios. Uma primeira questão diz respeito à possibilidade ou não de reconhecimento, pelo juiz, de razões diversas daquelas que determinaram o reconhecimento de certo interesse como juridicamente protegido e a correlata atribuição de um direito.³⁷ Afirma-se, ao propósito, que o julgador nos países de *civil law* teria a responsabilidade de se manter fiel às escolhas valorativas do legislador,³⁸ ao passo que o julgador nos sistemas de *common law* não se apresentaria rigidamente comprometido com as razões tidas como relevantes pelo legislador, podendo, ao revés, reconhecer em cada caso posto à sua apreciação os interesses dignos de proteção, ainda que alheios às razões inspiradoras das previsões legais.³⁹

Uma segunda questão diz respeito à discricionariedade do julgador, colocando-se em oposição um modelo de prevalência dos poderes *ex ante* do legislador em face de um modelo de prevalência dos poderes *ex post* do magistrado.⁴⁰ A esse respeito, afirma-se que os sistemas da família romano-germânica imporiam ao julgador o dever de estrita observância dos preceitos legais, sem maiores possibilidades de manobra para a proteção efetiva de interesses ao arrepio da previsão legal.⁴¹ Nos sistemas da família anglo-saxã, diversamente, seria reconhecida ao magistrado uma expressiva esfera de discricionariedade para uma

atuação criativa com vistas à atribuição de remédios efetivos aos interesses que se revelassem dignos de proteção em cada caso concreto.⁴²

Uma terceira questão, ainda, refere-se à argumentação jurídica.⁴³ Enuncia-se, a esse propósito, a prevalência de um modelo dito lógico-sistemático de interpretação nos sistemas de *civil law*, pelo reconhecimento de que subjacente à dogmática do direito subjetivo estaria o respeito à exclusividade do legislador para as definições e atribuições das posições jurídicas a serem protegidas.⁴⁴ Prevaleceria, nos sistemas de *common law*, por outro lado, um modelo dito teleológico, em que incumbiria ao julgador, mediante a atribuição concreta de remédios, a definição última dos interesses dignos de proteção.

A enunciação desses caracteres distintivos não impediu, contudo, que a própria doutrina empenhada na diferenciação ressalvasse a existência de uma expressiva similitude de resultados entre as referidas famílias de sistemas jurídicos.⁴⁵ Precisamente nesse sentido, já se sustentou que o *civil law* tenderia a se aproximar do *common law* a partir de construções teóricas que permitissem maior flexibilidade por parte do julgador na busca pela atribuição efetiva de remédios.⁴⁶ Assim sucederia com o desenvolvimento, por exemplo, da boa-fé objetiva, da cláusula *rebus sic stantibus*, da teoria da pressuposição, da *culpa in contrahendo*, do abuso do direito e da *exceptio doli generalis*.⁴⁷

Como se nota, embora reste clara a diferenciação abstrata entre *civil law* e *common law*, impõe-se reconhecer que muitos dos atributos acima mencionados sobre os sistemas da família romano-germânica podem não restar verificados na prática, a depender da metodologia adotada pelo intérprete. Por exemplo, há muito se afirma, na doutrina do *civil law*, a perda de centralidade da categoria do direito subjetivo.⁴⁸ Com efeito, reconhece-se cada vez mais que as relações jurídicas traduzem uma vasta diversidade de situações jurídicas, para além dos limites conceituais do direito subjetivo,⁴⁹ modelo insuficiente para explicar a complexidade relacional.⁵⁰ Destaca-se, ademais, a impropriedade da adoção do direito subjetivo para a compreensão e a tutela das relações existenciais.⁵¹

Também a suposta prevalência da enunciação abstrata dos direitos em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional concreta parece não corresponder, necessariamente, ao modo pelo qual se pode enxergar um sistema jurídico do *civil law*.⁵² Nesse sentido, tem crescido a defesa da impossibilidade de uma completa atividade hermenêutica sem a consideração dos valores tangenciados por cada caso concreto.⁵³ A expressividade de tal tendência se manifesta, em ocorrência emblemática, na construção doutrinária que critica a própria distinção estanque e abstrata entre as duas famílias de sistemas jurídicos a partir dos brocardos “ubi jus, ibi remedium” e “ubi remedium, ibi jus”. De uma parte, destaca-se que não raramente os remédios encontram fundamento direto em textos legislativos; de outra parte, a atribuição de um remédio em um sistema do *common law* se justifica em função da tutela de um interesse cuja juridicidade tenha sido reconhecida a partir da análise do ordenamento (reconhecida, por certo, a primazia que cada sistema conferir internamente às possíveis fontes do direito).⁵⁴ Percebe-se, em suma, o risco na exasperação da dicotomia: tanto é verdade que o direito justificador de remédios nos sistemas do *civil law* não se resume à categoria do direito subjetivo quanto parece improvável, do ponto de vista lógico-jurídico, que a

atribuição de um remédio pela autoridade estatal nos sistemas do *common law* possa se operar sem que se identifique um interesse reputado merecedor de proteção pela ordem jurídica.⁵⁵

Por fim, de melhor sorte não desfruta a enunciação segundo a qual o modelo do *civil law* aprisionaria o magistrado nos limites rígidos da legislação ordinária⁵⁶ e da técnica subsuntiva.⁵⁷ Compreende-se, de fato, a atual insuficiência da técnica da subsunção,⁵⁸ identificando-se no cenário contemporâneo, ao revés, uma “reconstrução do Direito a partir de princípios – que representam valores estabelecidos na Constituição”.⁵⁹ Desse modo, em superação do monopólio do pensamento subsuntivo, destaca-se a importância central da ponderação, técnica idônea a promover o sopesamento de todas as normas (e, sobretudo, dos princípios) para a solução de cada caso concreto.⁶⁰ Liberta-se o intérprete dos limites estreitos da lei ordinária,⁶¹ impondo-se a ele, por outro lado, a contrapartida de demonstrar fundamentadamente a compatibilidade de cada decisão (e do respectivo processo argumentativo) com a tábua axiológica constitucional.⁶²

3.A pretensa atribuição de direitos ao titular de dados pela LGPD: enunciação de remédios

Como referido anteriormente, o regime inaugurado pela LGPD dispensa capítulo próprio à enunciação dos “direitos do titular” de dados pessoais. O uso do termo “titular”, embora criticado por parte da doutrina (que identifica na referência à titularidade uma remissão à ótica proprietária, de todo inadequada em matérias que dizem respeito diretamente à pessoa humana),⁶³ parece, ainda, oportuno, tendo em vista a necessidade de identificar com clareza os sujeitos a que se refere a lei. A rigor, considerando que a *titularidade* consiste no vínculo que une o indivíduo a toda situação jurídica, de qualquer natureza (patrimonial ou existencial), o uso do termo em matéria extrapatrimonial mostra-se tão adequado quanto a referência a situações jurídicas nesse setor (e a lei, nesse particular, remete claramente à estipulação de *direitos*).

Nos termos do art. 17 da lei, “toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei”.⁶⁴ Trata-se de rol pouco inovador de direitos,⁶⁵ os quais foram inseridos no elenco de direitos fundamentais da Constituição Federal (art. 5º, *caput* e inciso X) e já decorreriam, segundo entendimento bastante consolidado, da própria cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1º, III da CF).⁶⁶ Com efeito, há muito já se destaca na doutrina civil-constitucional a desnecessidade da enunciação legislativa dos chamados direitos da personalidade, isto é, de direitos existenciais típicos, na medida em que todo e qualquer interesse decorrente da dignidade humana há de ser tutelado (sem dúvida, em ponderação com eventuais outros interesses contrapostos), independentemente de sua enunciação na forma de situações jurídicas específicas.⁶⁷

Dos três direitos citados pelo dispositivo em questão, o mais inusitado (diante da abertura excessiva de seu conteúdo) é o de “liberdade”; com efeito, a autonomia está no cerne de todas as questões atinentes às relações privadas

(ainda que contemporaneamente funcionalizada a interesses de ordem supraindividual, como os vinculados à solidariedade social). Já no que tange às relações entre indivíduo e Estado, as liberdades civis consistem nos direitos fundamentais há mais tempo reconhecidos, ditos de primeira geração, o que faz parecer despidiêda sua remissão legislativa, exceto para a finalidade de afirmar o norte valorativo que o legislador tinha em mente quando da elaboração da lei.

No que diz respeito à intimidade, sua distinção em relação à privacidade mostra-se cada vez mais incomum, sendo os termos utilizados contemporaneamente como sinônimos.⁶⁸ Na doutrina tradicional, em que se conferia grande importância à gradação entre a esfera privada e a pública, a intimidade representava o âmbito mais reservado da vida individual, um espaço frequentado apenas pela própria pessoa, ao passo que a privacidade correspondia a uma proteção mais ampla, referente à relação do indivíduo com o mundo e sua prerrogativa de não ser importunado com o acesso indevido de terceiros a fatos de sua vida cotidiana.⁶⁹ Justamente por sua definição mais abrangente, a privacidade costuma responder, contemporaneamente, também pelas noções de intimidade e vida privada. A respeito, já se identificou uma “inclusão progressiva de novos aspectos de liberdade num conceito ampliado de privacidade”.⁷⁰

A própria concepção de privacidade, como se sabe, passou por relevante ressignificação nas últimas décadas, sendo hoje associada à noção de autodeterminação informativa. Vale aludir, nesse ponto, à célebre lição de Stefano Rodotà, para quem a privacidade, em sua acepção mais contemporânea, deve ser compreendida, também, como o “direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular”.⁷¹ Não é difícil compreender, nesse sentido, por que a privacidade assume particular protagonismo em um diploma legislativo voltado à proteção de dados pessoais – embora, reafirme-se, sua previsão pelo legislador ordinário, dada a consagração do direito pela própria Constituição, revela mais uma declaração de intenções da LGPD (papel que já é desempenhado, de modo mais técnico, pelo art. 2º da lei) do que uma mudança efetiva na atribuição de direitos à pessoa humana.

Seria de se esperar que os dispositivos normativos previstos em seguida pela LGPD, ultrapassada a previsão (por assim dizer, panorâmica) do art. 17, tratassem da atribuição de efetivos novos direitos aos titulares de dados pessoais, dessa vez voltados de modo mais específico aos problemas postos pelas *fattispecie* disciplinadas pela lei. As disposições dos arts. 18 e ss., no entanto, contrariando tal expectativa (criada, antes de tudo, pela designação conferida ao Capítulo III), tratam predominantemente de questões procedimentais ou instrumentais.⁷² Ilustrativamente, no que diz respeito ao art. 18, cuida ele do “direito” do titular de obter do controlador a confirmação da existência de tratamento dos seus dados, o acesso a esses dados, a possibilidade de correção ou atualização deles, bem como de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados de forma incorreta, entre outros possíveis requerimentos.

Como se percebe, tais prerrogativas nada mais representam do que especificações do conteúdo que tradicionalmente se atribui à noção contemporânea de privacidade. De fato, a concepção de autodeterminação informativa, pela sua própria designação, converte a privacidade, em larga medida,

no direito atribuído a cada pessoa de *controlar* a circulação dos seus próprios dados, por meio de uma série de *medidas e procedimentos*. Em outros termos, trata-se, precipuamente, do balizamento, pelo titular, do tratamento de seus dados por terceiros, e não propriamente da mera preservação desses dados contra o conhecimento público (como no conceito tradicional de privacidade). Esse sentido contemporâneo de privacidade, segundo a mais autorizada doutrina,⁷³ implementa-se por meio de garantias reconhecidas há décadas, entre as quais são normalmente mencionadas:

i) *Correção na coleta e no tratamento das informações*: questão abordada prioritariamente em outros setores da lei, como aqueles que preveem a possibilidade da imposição de medidas corretivas aos agentes de tratamento de dados (art. 52, I e § 1º, X);

ii) *Segurança física e lógica da coletânea dos dados*: garantia de que trata o Capítulo VII da LGPD;⁷⁴

iii) *Publicidade dos bancos de dados pessoais*: exigência que se reflete, por exemplo, no dever dos agentes de tratamento de dados de confirmarem a existência do tratamento (art. 18, I) e no dever de informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados (art. 18, VII);

iv) *Acesso aos dados pessoais, diretamente acionável pelo titular interessado*: expressamente aludido pelo inciso II do art. 18, além de referenciado como princípio orientador das atividades de tratamento de dados pessoais pelo art. 6º, IV;

v) *Exatidão dos dados coletados e obrigatoriedade de sua atualização*: essa garantia se efetiva, entre outros instrumentos, pela prerrogativa, prevista no inciso III do supramencionado art. 18, de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados a pedido do titular, e é reforçada pela norma do § 6º do mesmo dispositivo, que determina ao agente que recebe o pedido de retificação, atualização ou supressão de dados que informe imediatamente a outros agentes com os quais tenha realizado o uso compartilhado dessas informações, para que eles possam repetir o mesmo procedimento, sem que se imponha ao titular a (muitas vezes impossível) tarefa de rastrear todos os agentes com os quais seus dados tenham sido compartilhados;

vi) *Respeito à finalidade para a qual os dados foram coletados e tratados*: enunciada no rol de princípios do art. 6º (inciso I), essa garantia pode ser compreendida tanto como a pertinência entre a finalidade perseguida e os dados colhidos como a própria especificação da finalidade (vedando-se o uso abusivo dos dados em outras hipóteses).⁷⁵ Segundo alguns autores, aqui também estaria compreendido o direito ao esquecimento.⁷⁶

Dada a deliberada abertura conceitual dessas garantias (não por acaso frequentemente denominadas *princípios*), são frequentes as interpenetrações entre elas. Afirma-se, por exemplo, que o “direito” de acesso abrange a prerrogativa de revisão, retificação, atualização e supressão dos dados pessoais.⁷⁷ Sustenta-se,

ainda, que o livre acesso, que por muito tempo esteve em posição de proeminência na tutela dos dados pessoais, cede cada vez mais espaço ao princípio da finalidade, diante da necessidade de controle dos propósitos a que se presta a elaboração de certos bancos de dados, especialmente aqueles voltados à construção de perfis pessoais.⁷⁸ A enumeração dessas garantias, de todo modo, contribui para a atividade hermenêutica, na medida em que ajuda a exemplificar o conteúdo do princípio da privacidade. Ademais, tais garantias representam pontos de certo consenso em uma longa tradição da disciplina jurídica dos dados pessoais, ao menos no sistema continental,⁷⁹ remontando a documentos internacionais como a Convenção n. 108 do Conselho da Europa de 28 de janeiro de 1981 para a Proteção das Pessoas Singulares no que diz respeito ao Tratamento Automatizado de Dados Pessoais e à Recomendação da OCDE de 23 de setembro de 1980, que estipulou as Diretrizes para a Proteção da Privacidade e dos Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais.

A leitura dos incisos do art. 18, nesse sentido, permite inferir que a LGPD não inova na atribuição de direitos ao titular de dados pessoais, na medida em que apenas reproduz conteúdos que já eram atribuídos de longa data ao direito à privacidade. Em vez disso, consagra medidas e procedimentos que podem ser adotados pelo titular de dados ou que devem ser implementados pelo agente de tratamento, com vistas a efetivar a tutela da privacidade e, mais do que isso, mensurar a extensão da tutela desse direito.⁸⁰ Trata-se, na perspectiva antes exposta, da previsão de *remédios* para a tutela da privacidade – os quais, como visto, voltam-se não apenas a sanar violações como, igualmente, a prevenir lesões e viabilizar o próprio exercício do direito. A privacidade, nesse ponto, mostra-se particularmente exemplar para o estudo dos remédios, já que seu conteúdo contemporâneo tem sido deliberadamente referido como um conjunto de medidas e procedimentos (voltados ao acesso e ao controle de finalidade do tratamento de dados), atuantes, em sua maior parte, independentemente da existência de uma violação.⁸¹

A principal diferença em relação à definição mais tradicional de remédios, evidentemente, reside no fato de que, à diferença do que ocorre na experiência do *common law*, no caso da LGPD os remédios são previstos em abstrato pelo legislador, e não demarcados concretamente pelo juiz. Em princípio, nada mais natural, já que, a despeito do protagonismo assumido pela atividade judicante no direito brasileiro (não isento de muitas críticas, as quais transbordariam o escopo deste estudo), a lei remanesce como a fonte primária do Direito no sistema pátrio. O risco na enumeração legislativa de remédios em um país de *civil law*, porém, reside, justamente, em se tratar de procedimento ainda pouco compreendido pela cultura jurídica dessa família, mais habituada à enumeração de direitos – e, de fato, o próprio legislador denomina como “direitos” os instrumentos por ele concebidos.

O inconveniente na confusão entre remédios e direitos está no risco de difusão de uma concepção segundo a qual mecanismos eminentemente instrumentais, voltados a viabilizar a tutela de direitos e a mensurar a extensão dessa tutela, seriam situações jurídicas subjetivas próprias, autônomas e merecedoras de tutela *per se*. Nesse sentido, poder-se-ia supor, equivocadamente, que “direitos” como o de livre acesso aos dados pessoais pelo titular corresponderiam a um fim em si

mesmo, interesses particulares aos quais o ordenamento confere exigibilidade jurídica após um juízo valorativo prévio (como se presume a partir do reconhecimento de qualquer situação jurídica subjetiva dita “ativa”).⁸² Ao contrário, a ancoragem das medidas e procedimentos previstos no rol do art. 18 ao direito de privacidade (vale dizer, sua instrumentalização a esse direito) mostra-se imprescindível, pois é o direito que, traduzindo valores e interesses, é passível de um juízo de merecimento de tutela. Em outros termos, é possível funcionalizar direitos à axiologia do sistema, mas não remédios legais isoladamente considerados. Estes, se dissociados do direito que se voltam a tutelar, tornam-se estruturas vazias de conteúdo – daí decorrendo o risco de serem interpretados como prerrogativas absolutas.

Nesse sentido, como se vem de afirmar, a doutrina destaca que o exercício concreto do “direito” de acesso (inclusive da prerrogativa de obter a correção, integração ou eliminação dos dados coletados)

pressupõe a violação de um outro princípio, por exemplo, o da correção, da exatidão ou da finalidade: o princípio do acesso coloca-se, portanto, em um plano diferente e surge como um instrumento para a atuação direta de um interesse individual e para garantir a efetividade de um (outro) princípio geral.⁸³

Por sua vez, a violação desses outros princípios, notadamente o da finalidade, há de ser aferida com referência ao valor da privacidade, a qual, a seu turno, encontra-se naturalmente funcionalizada à dignidade humana. Esse imprescindível encadeamento – eminentemente dialético – de valores, com diversos graus de especificidade, é fundamental para que se possa aferir o merecimento de tutela do exercício dos remédios previstos pela LGPD.

Essa parece ser, também, a chave de leitura mais adequada para os deveres de informação previstos em lei, em geral, e especificamente aquele decorrente da previsão do inciso VIII do art. 18, que assegura ao titular de dados o direito a obter do controlador “informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa”.⁸⁴ Com efeito, tal dever apenas se justifica quando se compreende que alguns dos principais óbices à efetividade do livre acesso, há muito denunciados em doutrina, eram a falta de informação acerca das prerrogativas e procedimentos abertos ao titular de dados, bem como o excesso de burocracia envolvida.⁸⁵ Buscar o direito ao qual se volta o remédio, e os valores e interesses aos quais o direito se encontra funcionalizado, permite compreender a extensão e os limites desse e de tantos outros deveres de informação com fonte legal: assim, por exemplo, o dever de informação no contrato de seguro deve ser aquele necessário à correta delimitação do risco,⁸⁶ os deveres de informação decorrentes da boa-fé objetiva devem ser aqueles necessários a garantir a utilidade das prestações buscadas pelas partes (aferida a partir da noção de causa contratual)⁸⁷ e assim por diante.

Do mesmo modo, os “prazos e termos previstos em regulamento” para o exercício de requerimentos pelo titular de dados pessoais em face de controladores e operadores, a que alude o § 5º do art. 18, devem ser entendidos como funcionalizados a uma tutela efetiva do direito à privacidade, afastando-se, assim, a legitimidade de eventual regulamentação setorial que esvazie a utilidade, para o titular, dos mecanismos previstos pela LGPD.

Vale destacar, ainda, a prerrogativa prevista pelo inciso IX do art. 18 no sentido da revogação do consentimento, pelo titular de dados pessoais, para o tratamento deles. A possibilidade de revogação das manifestações de vontade é considerada ínsita a todo tipo de exercício de autonomia existencial.⁸⁸ A faculdade prevista pela lei, portanto, há de ser interpretada como parte do conteúdo do direito extrapatrimonial à privacidade, o que contribuiu para balizar os limites ao seu exercício.

Nesse sentido, o único limite declarado pela LGPD à revogação prevista pelo inciso IX do art. 18 é a norma do art. 8º, § 5º, que determina a irretroatividade da revogação (confirmando, assim, a legitimidade do tratamento realizado desde o consentimento original até o momento em que o titular revoga sua anuência), para além das hipóteses de dispensa de consentimento (por exemplo, aquela prevista pelo art. 7º, § 4º) e dos casos em que se autoriza a conservação dos dados pessoais mesmo após o término do tratamento (art. 16). Como todo exercício de situações jurídicas, porém, inclusive aquelas de natureza existencial, o recurso à revogação sujeita-se a um juízo valorativo, sendo possível, ao menos em tese e com a devida cautela, que certos casos de revogação venham a se revelar, em concreto, como exercício disfuncional da prerrogativa do inciso IX, passível de repressão total ou parcial, na medida da abusividade verificada.⁸⁹ Se a análise criteriosa das circunstâncias fáticas, à luz dos interesses e valores relevantes no caso concreto, indicar o exercício abusivo do direito à revogação do consentimento, a subsequente repressão consistirá, via de regra, na deflagração do dever de indenizar, não parecendo razoável cogitar, no mais das vezes, da ineficácia da revogação. A advertência afigura-se particularmente adequada para os dados pessoais sensíveis, em razão da maior intensidade da tutela que lhes deve ser dispensada.⁹⁰

Lamenta-se, neste particular, portanto, que a LGPD, embora tenha acertadamente atentado, em diversos dispositivos, à distinção entre dados sensíveis e dados econômicos (notadamente na Seção II de seu Capítulo II), não tenha feito qualquer gradação da tutela dispensada a essas duas categorias de dados no Capítulo III, onde dispôs sobre os “direitos” do titular.⁹¹ De fato, como se sabe, os dados ditos econômicos, isto é, aqueles que não traduzem informações que possam expor o indivíduo a discriminações (ao contrário dos dados sensíveis), costumam receber uma tutela menos intensa, situando-se em uma zona periférica do direito à privacidade,⁹² o que talvez permitisse afastar ou, ao menos, restringir a liberdade de revogação do consentimento quanto ao tratamento dos mesmos.

Como se extrai das considerações anteriores, a compreensão dos instrumentos previstos no Capítulo III da LGPD como remédios legais e não como direitos autônomos preenche de conteúdo valorativo esses mecanismos (conteúdo esse herdado do direito à privacidade e de sua inserção do tecido axiológico do sistema), o que evita que tais prerrogativas, eminentemente procedimentais ou instrumentais, passem a ser interpretadas como poderes absolutos. Torna-se possível, assim, não apenas uma compreensão mais minuciosa acerca do funcionamento de tais instrumentos, mas também um controle valorativo eficaz do exercício dessas prerrogativas pelo titular de dados pessoais. Impõe-se, por outro lado, analisar uma outra dúvida hermenêutica que pode exsurgir da qualificação de tais previsões como remédios – a saber, a da suposta taxatividade das previsões

legais de tutela da privacidade do titular de dados pessoais. É o que se passa a expor.

4.O risco da suposta taxatividade dos remédios previstos pela LGPD

No intuito de ilustrar a questão de fundo sobre os contornos do sistema remedial – destacadamente, a sua suposta taxatividade –, parece válido o recurso a um dos exemplos mais emblemáticos da questão, consistente no regime processual da tutela inibitória no direito brasileiro. Como se sabe, a tutela inibitória pode ter por escopo impedir a prática de atos antijurídicos, ou inibir a sua repetição ou continuação.⁹³ Em qualquer dessas manifestações, distingue-se da tutela dita repressiva, a qual se caracteriza pelo escopo de remoção dos efeitos de uma antijuridicidade já perpetrada.⁹⁴ Sua relevância reside, precisamente, na possibilidade de promoção da tutela das situações jurídicas subjetivas na sua fase fisiológica, e não somente naquela patológica, em razão da aptidão das medidas inibitórias para evitar a consumação ou renovação da lesão a um interesse reputado merecedor de tutela.⁹⁵ Avulta, assim, a importância da tutela inibitória (sobretudo aquela efetivada em caráter preventivo à consumação de qualquer ato antijurídico) para a promoção do próprio ideal de efetividade da tutela dos direitos.⁹⁶

Por tais razões, resultaria contraditória a enunciação de uma suposta taxatividade das medidas inibitórias.⁹⁷ Uma formulação de tal natureza acarretaria o risco de diminuição considerável da efetividade da tutela prometida pelo intérprete-operador do direito ao término do processo de individualização da normativa do caso concreto. A doutrina tem reconhecido, ao revés, que um modelo rígido de taxatividade da tutela inibitória não se compatibiliza com o projeto constitucional de efetividade da tutela a ser dispensada aos direitos.⁹⁸ Com efeito, o campo de abrangência das ações inibitórias há de ser tão amplo quanto à esfera de situações jurídicas subjetivas que venham a ser concretamente reputadas merecedoras de tutela.⁹⁹

Na contramão de tais observações, a jurisprudência brasileira tende a resolver muitas questões em torno da tutela inibitória, em alguma medida, a partir da assunção da taxatividade dos remédios no direito privado – embora tal atributo seja mais implícita do que explicitamente enunciado.¹⁰⁰ Um bom exemplo se extrai de caso paradigmático envolvendo, justamente, uma questão de merecimento de tutela do exercício do direito à privacidade¹⁰¹ (embora não propriamente de tratamento de dados pessoais). Trata-se do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal sobre as biografias não autorizadas, em que a Corte reconheceu um

(A)parente conflito entre princípios constitucionais: liberdade de expressão, de informação, artística e cultural, independente de censura ou autorização prévia (art. 5º, incs. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º e 2º) e inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, inc. X).¹⁰²

Ao reconhecer uma suposta primazia da liberdade de expressão,¹⁰³ a Corte concluiu pela absoluta desnecessidade de autorização prévia do biografado ou de seus familiares.¹⁰⁴ Destacou-se, assim, que nem mesmo o risco iminente de lesão

aos direitos da personalidade justificaria a concessão de ordem judicial proibitiva, relegando-se à via ressarcitória a reparação dos possíveis danos sofridos pela vítima.¹⁰⁵

Em termos metodológicos, como se percebe, a discussão sobre o cabimento ou não da tutela inibitória não se pode perfazer sem uma investigação da correlata questão de fundo atinente à operatividade dos mecanismos inibitórios no sistema remedial brasileiro, bem como uma investigação da concreta adequação dos remédios (entre eles, os inibitórios) à efetiva tutela dos interesses reputados merecedores de tutela à luz das circunstâncias de cada caso. Tais conclusões não se restringem aos remédios de índole inibitória, sendo imperativo revisitar a suposta taxatividade de todas as espécies remediais no direito privado.¹⁰⁶ Avulta, nesse paradigma, a insuficiência dos modelos legais predefinidos em matéria de remédios.¹⁰⁷ Sequer parece possível, em realidade, conceber uma categoria remedial em termos rígidos, uma vez que somente em perspectiva funcional se pode reconhecer o interesse merecedor de tutela e, assim, se perquirir o instrumento mais efetivo para a implementação dessa tutela no caso concreto.¹⁰⁸ Eis os contornos gerais de uma renovada concepção metodológica sobre a flexibilidade do sistema remedial.¹⁰⁹

A variabilidade e a flexibilidade ora atribuídas aos remédios encontram fundamento positivo mais imediato na garantia constitucional de efetividade da tutela jurisdicional dos direitos.¹¹⁰ Tal garantia corresponde ao substrato material extraído da previsão, contida no artigo 5º, inciso XXXV, da CF acerca da inafastabilidade do controle jurisdicional.¹¹¹ Cumpre notar, ainda, que uma série de dispositivos do CPC/2015 busca promover o ideal de efetividade da tutela jurisdicional, valendo destacar, exemplificativamente, a previsão do artigo 6º do diploma processual, segundo a qual “(T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Semelhante ordem de preocupação se reflete na disciplina de diversas questões, tais como os poderes do juiz (artigo 139, inciso VI), os instrumentos gerais para a tutela provisória (artigo 297), os instrumentos para a tutela provisória de urgência (artigo 301), a exibição de documentos (artigo 403), o cumprimento de sentença (artigo 536), entre outras.

O imperativo de efetividade parece ser a razão subjacente à própria disciplina dispensada pelo CPC ao julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Verifica-se, com efeito, uma expressiva preocupação do diploma processual com a garantia da tutela das situações jurídicas creditícias sem a previsão de um rol supostamente taxativo. Em realidade, o estatuto processual contém previsões emblemáticas no sentido de resguardar a situação jurídica creditícia não só pela tutela específica (no sentido de cumprimento coercitivo da própria obrigação inadimplida), mas igualmente pela tutela pelo resultado prático equivalente (no sentido¹¹² de promoção da finalidade útil do contrato sem o cumprimento da obrigação nos termos pactuados).

Nesse cenário, nota-se que o atendimento aos comandos legais e constitucionais dependerá, necessariamente, não apenas da possibilidade de acesso ao Poder Judiciário ou mesmo da previsão abstrata de instrumentos de tutela, mas sim da disponibilização dos remédios mais idôneos à tutela efetiva dos

interesses reputados merecedores de tutela em cada caso concreto.¹¹³ Impende, assim, evitar ao máximo o risco de que a variabilidade e a flexibilidade do sistema remedial sejam afetadas por uma interpretação formalista das regras sobre o processo civil, bem como dos remédios não processuais legislativamente previstos.¹¹⁴ Compreende-se, enfim, a necessidade de se analisar o inteiro sistema remedial em perspectiva axiológico-funcional, que permita conceber a noção de remédio como todo instrumento idôneo a efetivar um interesse, na constante busca pela efetividade e adequação da tutela das situações juridicamente relevantes.¹¹⁵

Parece ser o caso de se reconhecer, como anunciado, a impossibilidade de cisão entre a definição do interesse merecedor de tutela e a individualização do remédio respectivo. Com efeito, o raciocínio do intérprete não pode se perfazer apenas com a identificação dos interesses merecedores de tutela, afigurando-se essencial a investigação sobre os mecanismos de concretização dessa chancela jurídica. O estudo dos remédios serve, precisamente, a investigar os mecanismos mais adequados de proteção e promoção dos interesses no caso concreto. Salta aos olhos, nesse contexto, a relação indissociável entre normas instrumentais ou procedimentais e normas materiais (ou seja, aquelas que atribuem efetivas situações jurídicas às partes): as primeiras servem justamente a concretizar a proteção dos interesses reputados merecedores de tutela pelas segundas, razão pela qual não se afigura aconselhável um estudo das medidas legalmente previstas (como aquelas do Capítulo III da LGPD), de modo totalmente dissociado ao direito material.

Advirta-se, por oportuno, que o raciocínio pautado no projeto constitucional de efetividade da tutela dos direitos não autoriza o intérprete a desconsiderar, *ipso facto*, a disciplina estabelecida na legislação processual pelo legislador ordinário. Em realidade, tal como se verifica a propósito das normas substanciais, também a legitimidade das normas procedimentais e instrumentais decorre da constante investigação da sua compatibilidade, em cada caso concreto, com a tábua axiológica constitucional. Os dispositivos legais refletem, assim, relevantes escolhas legislativas, escolhas essas presumivelmente conformes à Constituição e fruto de uma ponderação prévia abstrata pelo legislador. O que não se pode perder de vista, como ora sustentado, é que tanto normas de conteúdo substancial quanto normas eminentemente procedimentais remontam à tábua axiológica constitucional e devem convergir para a efetividade da tutela aos interesses concretamente considerados merecedores de proteção pelo ordenamento.¹¹⁶

Desconsideradas tais premissas, vislumbrar-se-ia um pernicioso cenário, puramente formalista, em que a técnica regulamentar adotada pelo legislador da LGPD, em vez de contribuir para concretizar a tutela que se pretendeu conferir à privacidade, passaria a figurar como verdadeira camisa-de-força para essa tutela. Nesse sentido, o “direito” de petição do titular de dados pessoais, contra o controlador, perante a recém-criada autoridade nacional ou perante organismos de defesa do consumidor (art. 18, §§ 1º e 8º), não pode ser lido como a exclusão legal da possibilidade de peticionamento direto ao próprio operador ou controlador (previsto pelo próprio *caput* do art. 18) ou de qualquer outro agente responsável pelo tratamento de dados que, não tendo sido abrangido pela lei, mostre-se relevante para a tutela dos dados pessoais do interessado.¹¹⁷ A possibilidade de o titular de dados pessoais opor-se ao tratamento realizado com dispensa de

consentimento, caso ele ocorra em descumprimento da lei (art. 18, § 2º), não afasta a mesma possibilidade em casos de lesão ao direito à privacidade do titular que não tenham sido expressamente tipificados pelo diploma, muito menos exclui a possibilidade de oposição nos casos em que houve consentimento do titular.

A previsão de que os “direitos” previstos no art. 18 devem ser exercidos mediante requerimento expresso do titular (art. 18, § 3º) não afasta o dever dos agentes que realizam tratamento de dados de adotarem todas as práticas necessárias para respeitarem tais garantias, independentemente de provocação, nem impede que o titular interessado formule reclamações não contempladas no dispositivo normativo, nem afasta a legitimidade do Ministério Público ou de entidades voltadas à tutela de interesses supraindividuais de peticionarem em favor de grupos determinados ou não de titulares de dados. Nesse sentido, quando o art. 22 reconhece que “a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva”, não se há de entender que eventual contencioso administrativo, por não estar mencionado na norma, fique restrito à esfera individual. Ao contrário, como já ressaltado em doutrina, embora se celebre a ampliação de instrumentos individuais de tutela (sobretudo o livre acesso), a atuação de tais entes pode ajudar de forma significativa a suprir os déficits que reduzem a efetividade da tutela individual buscada pelo próprio titular (notadamente, o déficit informacional).¹¹⁸

Na mesma direção, a prerrogativa de portabilidade dos dados pessoais, a pedido do titular, para “outro fornecedor de serviço ou produto”, “de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial”, de que trata o art. 18, V e § 7º, não impede eventuais pedidos de portabilidade para agentes que não se enquadrem na qualificação de “fornecedor”, que é ínsita às relações de consumo (art. 3º do CDC). Ao contrário, trata-se apenas de mais uma manifestação do conteúdo da autodeterminação informativa, que permite ao titular controlar o destino conferido às informações que circulam sobre ele próprio. Do mesmo modo, a negativa de atendimento ao requerimento do titular pelo controlador, admitida pelo § 4º do art. 18, sob alegação de não ser o agente responsável pelo tratamento dos dados em questão, ou de haver razões de fato ou de direito que impeçam a adoção imediata da medida requerida, não pode ser interpretada como um salvo-conduto autorizador de negativas arbitrárias pelos agentes, aos quais se impõe delicado ônus probatório, sobretudo diante do déficit informacional verificado em relação ao titular dos dados pessoais, que quase sempre carecerá de meios para avaliar se a negativa foi ou não infundada (e, consequentemente, ilícita).¹¹⁹

A previsão do conteúdo da declaração de existência de tratamento ou acesso a dados pessoais pelo art. 19, II (“por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial”) não deve excluir a exigibilidade de outras informações pelo titular que se mostrem merecedoras de tutela no caso concreto – sendo, sempre, necessária, portanto, uma ponderação entre os interesses do titular e os do agente, inclusive quanto ao ônus (relevante ou não) criado para este pelo pedido de informações.¹²⁰ A ressalva quanto aos segredos comercial e industrial, feita também pelos arts. 19, § 3º, e 20,

§ 1º, no que diz respeito aos pedidos de informações, e pelo art. 18, V, no que diz respeito aos pedidos de portabilidade, deve ser interpretada cuidadosamente, evitando a invocação disfuncional dessas escusas pelo agente, que deve demonstrar de que modo o pedido formulado pelo titular prejudicaria sua atividade econômica. Mostra-se muito bem-vinda, nesse sentido, a previsão do art. 20, § 2º, segundo a qual, em caso de negativa fundada no sigilo comercial ou industrial, “a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais”. A previsão, que visa a coibir negativas abusivas, deve ser estendida analogicamente a todos os casos de negativa fundada em tais alegações, e não apenas aqueles contemplados pelo art. 20 (“decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais”).

Mais ainda, vale destacar que o fato de o art. 19 prever, em seu § 3º, que, “quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais” não pode excluir, por evidente, o livre acesso a dados cujo tratamento não tenha sido originado pela vontade do titular, inclusive com o fornecimento de cópia integral dos mesmos, sempre que o agente responsável pelo tratamento não apresentar qualquer motivo legítimo para eventual negativa. Analogamente, a previsão do art. 20, no sentido de que “o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses”, evidentemente, não exclui o direito amplo de revisão de decisões tomadas com base em seus dados pessoais, se caracterizado uso discriminatório desses dados, desvio de finalidade do tratamento dos mesmos, dentre outras irregularidades.

5. Considerações finais

As considerações anteriores, de cunho meramente ilustrativo (entre as muitas interpretações equivocadas que poderiam ser conferidas ao rol de remédios previsto pela LGPD), buscam tão somente evidenciar o risco de uma perspectiva formalista, que atribuisse ao sistema remedial da lei um indevido caráter taxativo. Tendo o legislador brasileiro optado por uma técnica regulamentar minuciosa para tratar da matéria (e não uma via predominantemente principiológica, a partir da enunciação de cláusulas gerais), impõe-se a particular cautela do intérprete, que não deve olvidar da ampla diversidade dos remédios adequados à proteção dos interesses do titular de dados que se mostrem legítimos no caso concreto. Impõe-se, ainda, particular cuidado na compatibilização dos remédios previstos pela LGPD com as disposições, ainda vigentes, dos diplomas que a antecederam, como o CDC, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, na medida em que a nova lei não avocou para si o papel de sistematizar o inteiro sistema remedial brasileiro na matéria, preservando, ao menos parcialmente, sua fragmentação.

Invoca-se, aqui, a reflexão de Stefano Rodotà, que indagava:

Será que se poderia afirmar, neste momento, que uma determinada maneira de encarar a proteção dos dados estaria irremediavelmente superada e que o único caminho a seguir seria, de fato, o das disciplinas pontuais, setoriais, estruturadas com

base em proibições e procedimentos rígidos, renunciando a uma perspectiva (ou ilusão) de controle?

Respondia o autor:

O abandono da disciplina das cláusulas gerais efetivamente aumentaria a rigidez do sistema e, logo, o tornaria ainda menos apropriado para acompanhar a rapidez das mudanças tecnológicas. E o consequente enfraquecimento do momento do controle tornaria ainda mais precária a perspectiva de uma distribuição de poderes mais equilibrada.¹²¹

Renova-se, uma vez mais e sempre, a importância central da doutrina para o enfrentamento das questões atuais e daquelas que se tornarão antigas tão logo deixem de ser futuras.

6. Referências bibliográficas

ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Moraes. *Introdução ao direito comparado*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2017.

AMARAL, Francisco. *Direito civil: introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARKER, Kit. Rescuing Remedialism in Unjust Enrichment Law: Why Remedies are Right. *Cambridge Law Journal*, v. 57, n. 2, item IV, 1998.

BIRKS, Peter. Adjudication and interpretation in the common law: a century of change. *Legal Studies*, v. 14, n. 2, jul. 1994.

BIRKS, Peter. Three kinds of objection to discretionary remedialism. *Western Australian Law Review* 1, v. 29, 2000.

BODIN DE MORAES, Maria Celina. A caminho de um direito civil-constitucional. *Na medida da pessoa humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

BODIN DE MORAES, Maria Celina. Ampliando os direitos da personalidade. *Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

BODIN DE MORAES, Maria Celina. Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação-interpretação do direito no início do Século XXI. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 14, v. 56, out.-dez. 2013.

BODIN DE MORAES, Maria Celina; SOUZA, Eduardo Nunes de. Educação e cultura no Brasil: a questão do ensino domiciliar. *Civilistica.com*, ano 6, n. 2, 2017.

BUSNELLI, Francesco Donato. *La lesione del credito da parte di terzi*. Milano: Giuffrè, 1964.

CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*, v. 85, n. 6, 1972.

CASTRONOVO, Carlo. L'avventura delle clausole generali. *Rivista Critica del Diritto Privato*, ano IV, mar. 1986.

CUNHA, Antônio Geraldo da. *Dicionário etimológico da língua portuguesa*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo; MENDES, Laura. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120: Revista dos Tribunais, nov.-dez. 2018.

DONEDA, Danilo; MENDES, Laura. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa*. 4. ed. Atual. Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira et alii. Curitiba: Positivo, 2009.

FRAZÃO, Ana de Oliveira. Nova LGPD: demais direitos previstos no art. 18. *Jota*, 28.11.2018.

FRAZÃO, Ana de Oliveira. Nova LGPD: os direitos dos titulares de dados pessoais. Parte IX. *Jota*, 17.10.2018.

FRIEDMAN, Barry. When rights encounter reality: enforcing federal remedies. *Southern California Law Review*, v. 65, 1992.

FRIEDMANN, Daniel. Rights and remedies. In: COHEN, Nili; MCKENDRICK, Ewan (Org.). *Comparative Remedies for Breach of Contract*. Pittsburgh: Hart, 2005.

GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil*. 21. ed. Atual. Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. *Remedies in Contract & Tort*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

KONDER, Carlos Nelson. The range of the right to personal identity in Brazilian civil law. *Pensar*, Fortaleza, v. 23, n. 1, jan.-mar. 2018.

LAYCOCK, Douglas. How remedies became a field: a history. *The Review of Litigation*, v. 27, n. 2, 2008.

LEWICKI, Bruno. Realidade refletida: privacidade e imagem na sociedade controlada. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coord.). *O direito e o tempo: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

LUPOLI, Maurizio. Il dolo del debitore: 'dolus' e 'fraud': dal diritto romano all'*equity* inglese. In: VISINTINI, Giovanna (Coord.). *Trattato della responsabilità contrattuale*. Padova: CEDAM, 2009. v. I – inadempimento e rimedi.

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida; DIVINO, Sthéfano Bruno Santos. A proteção de dados e o direito de personalidade da pessoa jurídica. *Revista de Direito Empresarial*, São Paulo, ano 15, n. 3, set.-dez. 2018.

MAJO, Adolfo di. Clausole generali e diritto delle obbligazioni. *Rivista Critica del Diritto Privato*, ano II, n. 3, set. 1984.

MAJO, Adolfo di. La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale. *Rivista Critica del Diritto Privato*, ano VII, n. 3, p. 363-392, set. 1989.

MAJO, Adolfo di. *Le tutele contrattuali*. Torino: G. Giappichelli, 2009.

MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*. Torino: G. Giappichelli, 2012.

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. *Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

MESSINETTI, Davide. La sistematica rimediale. In: MAZZAMUTO, Salvatore (Coord.). *Le tutele contrattuali e il diritto europeo*: scritti per Adolfo di Majo. Napoli: Jovene, 2012.

MONTEIRO, Renato Leite. Existe um direito à explicação na lei geral de proteção de dados do Brasil? *Artigo estratégico*, n. 39, dez. 2018.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18). *Revista de Direito e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, set.-dez. 2018.

NIVARRA, Luca. I nuovi orizzonti della responsabilità contrattuale. Torino: G. Giappichelli, 2015.

NIVARRA, Luca. Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico? *Europa e Diritto Privato*, n. 3, 2015.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 137, jul. 2006.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*, vol. I. 24. ed. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

PERLINGIERI, Giovanni. *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

PERLINGIERI, Pietro. Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto". *Rivista di Diritto Privato*, ano XV, n. 4, p. 7-28, out.-dez. 2010.

PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile. *Il Giusto Processo Civile*, n. 1, 2011.

PERLINGIERI, Pietro. Il principio di legalità nel diritto civile. *Rassegna di Diritto Civile*, ano 31, n. 1, 2010.

PERLINGIERI, Pietro. *La persona e i suoi diritti*: problemi del diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2005.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PERLINGIERI, Pietro. Regole del mercato e tutela dell’investitore: riflessioni a margine della MiFID. In: ADAMO, S.; CAPOBIANCO, Ernesto; CUCURACHI, P. (a cura di). *Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.

PETERSEN, Luiza Moreira. *O risco no contrato de seguro*. São Paulo: Roncarati, 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck Garrido. Nova lei brasileira de proteção de dados e o impacto nas instituições públicas e privadas. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 1000, fev. 2019.

PITERMAN, Marcel. Direito e processo: tutela dos direitos e tutela jurisdicional na perspectiva dos direitos fundamentais. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, n. 472, fev. 2017.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*: a privacidade hoje. Org. Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. Il tempo delle clausole generali. *Rivista Critica del Diritto Privato*, n. 4, 1987.

SACCO, Rodolfo. *Introdução ao direito comparado*. Trad. Vera Jacob de Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

SANTOS, Fabíola; TALIBA, Rita. Lei geral de proteção de dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018.

SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SCHREIBER, Anderson. Marco civil da internet: avanço ou retrocesso? A responsabilidade civil por dano derivado do conteúdo gerado por terceiro. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de Lima (Org.). *Direito e internet III*: marco civil da internet (Lei 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. II.

SILVA, Rodrigo da Guia. A revisão do contrato como remédio possível para o inadimplemento. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 995, set. 2018.

SILVA, Rodrigo da Guia. Em busca do conceito contemporâneo de (in)adimplemento contratual: análise funcional à luz da boa-fé objetiva. *Revista da AGU*, v. 16, n. 2, abr.-jun. 2017.

SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado: tutela das situações jurídicas subjetivas em perspectiva civil-constitucional. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 20, v. 98, mar.-abr. 2019.

SILVA, Rodrigo da Guia. Um olhar civil-constitucional sobre a “inconstitucionalidade no caso concreto”. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 18, v. 73, jan. 2017.

SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi. In: GRAZIADEI, Michele; POZZO, Barbara (Coord.). *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*. Milano: Giuffrè, 2015.

SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”. *Europa e Diritto Privato*, n. 1, 2014.

SOUZA, Allan Rocha de; DONEDA, Danilo; NASCIMENTO, Francisco José Tavares do; GUANAES, Paulo. In: GUANAES, Paulo (Org.). *Marcos legais nacionais em face da abertura de dados para pesquisa em saúde: dados pessoais, sensíveis, ou sigilosos e propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Abuso do direito em relações existenciais. *Revista Eletrônica Direito e Política*, Itajaí, v. 10, n. 4, set.-dez. 2015.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Dano à honra pela opinião do entrevistado ou do leitor. In: SCHREIBER, Anderson (Org.). *Direito e mídia*. São Paulo: Atlas, 2015.

SOUZA, Eduardo Nunes de. *Do erro à culpa na responsabilidade civil do médico: estudo na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 15, v. 58, abr.-jun. 2014.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Nexo causal e culpa na responsabilidade civil: subsídios para uma necessária distinção conceitual. *Civilistica.com*, ano 7, n. 3, 2018.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Situações jurídicas subjetivas: aspectos controversos. *Civilistica.com*, ano 4, n. 1, 2015.

SOUZA, Eduardo Nunes de. *Teoria geral das invalidades do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade no direito civil contemporâneo*. São Paulo: Almedina, 2017.

TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. *Temas de direito civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. *Problemas de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

VICENTE, Dário de Moura. *Direito comparado*, Coimbra: Almedina, 2017. v. I e II.

1

.Doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor Adjunto de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ.

2

.Doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Advogado.

3

.Remete-se, por todos, ao relato fornecido por TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 8 e ss.; e BODIN DE MORAES, Maria Celina. A caminho de um direito civil-constitucional. *Na medida da pessoa humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 8 e ss.

4

.Para o desenvolvimento da crítica, v. SCHREIBER, Anderson. Marco Civil da Internet: avanço ou retrocesso? A responsabilidade civil por dano derivado do conteúdo gerado por terceiro. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de Lima (Org.). *Direito e internet III: marco civil da internet* (Lei 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. II, passim. Permita-se remeter, ainda, a SOUZA, Eduardo Nunes de. Nexo causal e culpa na responsabilidade civil: subsídios para uma necessária distinção conceitual. *Civilística.com*, a. 7, n. 3, 2018. p. 52-53.

5

.“O ordenamento jurídico brasileiro já contava com algumas normas setoriais de proteção de dados (Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei do Cadastro Positivo e Marco Civil da Internet), mas não havia ainda uma lei aplicável horizontalmente a todos os setores econômicos e também ao setor público, como é o caso da LGPD” (DONEDA, Danilo; MENDES, Laura. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. item 2). Sobre o cenário legislativo brasileiro, cf. PINHEIRO, Patrícia Peck Garrido. Nova lei brasileira de proteção de dados e o impacto nas instituições públicas e privadas. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 1000, fev. 2019; e SOUZA, Allan Rocha de; DONEDA, Danilo; NASCIMENTO, Francisco José Tavares do; GUANAES, Paulo. In: GUANAES, Paulo (Org.). *Marcos legais nacionais em face da abertura de dados para pesquisa em saúde: dados pessoais, sensíveis, ou sigilosos e propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018.

6

.Nesse sentido, cf. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 209 e ss.; e, na doutrina brasileira, TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. *Problemas de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. passim.

7

.Para uma crítica sobre a tese do diálogo das fontes, permita-se remeter a SOUZA, Eduardo Nunes de. *Do erro à culpa na responsabilidade civil do médico*: estudo na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 85-92.

8

.Sobre a noção de merecimento de tutela, tanto em sua acepção ampla de juízo valorativo sobre exercícios privados quanto em seu possível sentido particular, cf. SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 15, v. 58, abr.-jun. 2014.

9

.Perspectiva primeiramente apresentada em SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado: tutela das situações jurídicas subjetivas em perspectiva civil-constitucional. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 20, v. 98, mar.-abr. 2019. item 1.

10

.Cf. AMARAL, Francisco. *Direito civil*: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 247.

11

."Se todos os homens cumprissem espontaneamente seus deveres jurídicos, seria inútil a sanção que as normas de Direito contêm. Mas, se é certo que a maioria observa, 'por virtude, por disciplina, por hábito ou por temor', as regras jurídicas, não é pequeno o número de desobedientes. Para obrigá-los a comportamento conforme ao Direito, são proporcionados aos titulares de direitos os meios necessários para defendê-los. [...] A autodefesa e o direito de invocar a proteção jurídica do Estado são as duas modalidades principais de proteção. Outra modalidade de proteção é o nascimento automático de uma nova situação jurídica para eliminar a violação ou o perigo de lesão do direito" (GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil*. 21. ed. Atual. Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 393).

12

.A destacar a relevância do aspecto fisiológico para a compreensão dos institutos jurídicos, sustenta-se a relevância de "[...] um critério metodológico fundamental [...], segundo o qual, para descobrir a essência de um instituto, é necessário referir-se às suas características fisiológicas e não já deixar-se atrair pelo seu eventual aspecto patológico" (BUSNELLI, Francesco Donato. *La lesione del credito da parte di terzi*. Milano: Giuffrè, 1964. p. 23. Tradução livre). A propósito da importância da análise do momento fisiológico e não apenas do patológico, v., ainda, PERLINGIERI, Pietro. Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto". *Rivista di Diritto Privato*, ano XV, n. 4, out.-dez. 2010. p. 27-28.

13

.Cf. PERLINGIERI, Pietro. Il "giusto rimedio" nel diritto civile. *Il Giusto Processo Civile*, n. 1, 2011. p. 6-7.

14

.Cf. SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado, cit., item 1.

15

.Cf. CUNHA, Antônio Geraldo da. *Dicionário etimológico da língua portuguesa*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, p. 555.

16

."A etimologia da palavra remédio, do latim *remedium*, remete a cura ou medicamento ou, em sentido figurado, a ajuda ou reparo" (MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*. Torino: G. Giappichelli, 2012. p. 13. Tradução livre).

17

.Colhem-se da lexicografia nacional as seguintes definições de *remédio*: “1. Aquilo que combate mal, dor ou doença. 2. Aquilo que serve para curar ou aliviar dor ou enfermidade. 3. Recurso, expediente, solução. 4. Ajuda, auxílio, socorro, proteção. 5. Correção, retificação, emenda” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa*. 4. ed. Atual. Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira *et alii*. Curitiba: Positivo, 2009. p. 1730). Digna de nota, ainda, a indicação da definição “jurídica” do vocábulo, mais consentânea com a proposição do presente estudo: “6. Meio adequado e lícito para se alcançar determinando fim de direito” (idem).

18

.Destaca-se, nesse sentido, a polissemia da expressão “remédio” na doutrina americana: “De resto, a confusão linguística e conceitual da noção é denunciada também pela literatura americana, a qual ressalta polemicamente a utilização poliédrica da expressão ‘remédio’, que induz a desperdiçar cada especificidade. [...] A heterogeneidade das exigências de proteção, especialmente se a caráter existencial, induziu a doutrina a elaborar uma categoria de medidas protetivas tão ampla a resultar em concreto de escassa utilidade” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 7-8. Tradução livre). Para uma análise da referida polissemia nos sistemas do *common law*, v., ainda, BIRKS, Peter. Three kinds of objection to discretionary remedialism. *Western Australian Law Review* 1, v. 29, 2000. p. 3-6; FRIEDMAN, Barry. When Rights Encounter Reality: Enforcing Federal Remedies. *Southern California Law Review*, v. 65, 1992. p. 741 e ss.; e LAYCOCK, Douglas. How remedies became a field: a history. *The Review of Litigation*, v. 27, n. 2, 2008, passim.

19

. “[...] na tradição do *common law* inglês a acepção é já técnico-jurídica e – como já se recordou precedentemente – a situação de necessidade ou de crise à qual se põe, precisamente, reparo é individualizada no *torto* (*cure for wrongs*). O remédio é, portanto, o instrumento para reparar a violação de um preceito e, então, se diferencia seja da norma atributiva de um direito seja da sanção” (MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*, cit., p. 13-14. Tradução livre).

20

.A propósito, v., por todos, MAJO, Adolfo di. *Le tutele contrattuali*. Torino: G. Giappichelli, 2009. p. 3; e MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*, cit., p. 1.

21

.Pertinente, a propósito, a lição de Dário Moura Vicente sobre o desenvolvimento histórico da noção de *tort* no direito inglês: “Os *writs* delimitaram assim historicamente os tipos de ilícitos determinantes da obrigação de indenizar: os *torts*. Por *tort* entende-se um ‘ilícito civil distinto da violação de um contrato’ (*a civil wrong, other than a breach of contract*). Os *torts* só em parte correspondem, no entanto, aos delitos dos Direitos continentais, pois compreendem também certas situações, como o *tort of trespass to land*, que podem não dar lugar à obrigação de indenizar, mas antes fundamentar outro tipo de pretensões, como a manutenção ou a restituição da posse através de *injunctions* (correspondentes aos meios possessórios dos Direitos alemão e português” (*Direito comparado*. Coimbra: Almedina, 2017. v. II. p. 399). Para uma análise da noção de *tort* no *common law*, v., ainda, MAJO, Adolfo di. *Le tutele contrattuali*, cit., p. 51; e HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. *Remedies in Contract & Tort*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 289 e ss.

22

.A destacar que a usual conceituação de “remedy” como “cure for wrongs” não desfruta de aceitação pacífica, afirma-se: “Se o remédio como ‘cure for wrongs’ deixa perplexos os intérpretes, também as outras definições não satisfazem. Considerado sinônimo, volta e meia, de acionabilidade em juízo, de direito nascido de um ilícito (ou, de qualquer modo, de outras formas de injustiça), de provimento judicial (em geral ou somente de tipo discricionário), ou mesmo como ‘qualquer coisa que uma corte pode fazer por quem sofreu um *tort* ou está por sofrê-lo’ (*Anything a court can do for a litigant who has been wronged or is about to be wronged*)”, a pluralidade de significados do termo ‘remedy’ se reflete na vagueza das definições” (SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi. In: GRAZIADEI, Michele; POZZO, Barbara (Coord.).

23

.Cf. MESSINETTI, Davide. La sistematica rimediale. In: MAZZAMUTO, Salvatore (Coord.). *Le tutele contrattuali e il diritto europeo*: scritti per Adolfo di Majo. Napoli: Jovene, 2012. p. 103-105.

24

“Historicamente, o *Civil Law*, em especial modo aquele de derivação germânica, põe ao centro do próprio quadro a consistência das situações jurídicas subjetivas através da teoria do direito subjetivo. Os ordenamentos da Europa continente confiam a individualização dos interesses tutelados – a denominada função atributiva – à relação entre direito subjetivo e ação” (SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 187. Tradução livre). V., ainda, NIVARRA, Luca. *I nuovi orizzonti della responsabilità contrattuale*. Torino: G. Giappichelli, 2015. p. 18; e, do mesmo autor, NIVARRA, Luca. Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico? *Europa e Diritto Privato*, n. 3, 2015. p. 601.

25

.Cf., por todos, SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”. *Europa e Diritto Privato*, n. 1, 2014. p. 182; e SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 188-189. Adverte-se, contudo: “Em qualquer destes sistemas jurídicos [romano-germânicos], as assembleias parlamentares são referidas como os órgãos legislativos por excelência, mas este corolário do princípio da separação de poderes vem sofrendo sucessivas atenuações. As regras e a prática constitucionais procedem na realidade a uma partilha do poder legislativo, em que a parcela pertencente aos Governos tem progressivamente aumentado [...]” (ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. *Introdução ao direito comparado*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2017. p. 49). No mesmo sentido, VICENTE, Dário Moura. *Direito comparado*, cit., v. I, p. 154. Em defesa da importância da ressignificação da separação de poderes para o estudo do sistema remedial, cf. FRIEDMAN, Barry. *When Rights Encounter Reality*, cit., p. 770 e ss.

26

.Para um desenvolvimento crítico da questão, v., por todos, VICENTE, Dário Moura. *Direito comparado*, cit., v. I, p. 161 e ss.

27

“Os ordenamentos de *common law* tradicionalmente não conhecem a ordem conceitual dos direitos subjetivos e organizam as próprias formas de tutela em torno da noção de remédio” (SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 189. Tradução livre).

28

“Nestes sistemas a seleção dos interesses merecedores de tutela ocorre diretamente mediante a individualização das tutelas e não é necessário identificar uma posição subjetiva para que se possa dar resposta a um interesse lesado. A efetividade das tutelas prevalece sobre a enunciação abstrata dos direitos. Segundo um modelo de análise orientado aos remédios, de fato, para oferecer um quadro preciso e completo da consistência da proteção dos interesses é necessário verificar a efetividade das tutelas” (SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 190. Tradução livre).

29

“Nas suas expressões mais radicais, o discurso sobre os remédios sustenta que falar de direitos não signifique outra coisa que fazer predições sobre as futuras decisões judiciais. Nesta perspectiva, direito subjetivo se torna ‘expressão linguística’ através da qual se indica simplesmente um outro grau de probabilidade de obter um juízo favorável, hipótese de um argumento retórico dotado de um certo grau de idoneidade a persuadir quem tomará a decisão” (SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 190, nota de rodapé n. 14. Tradução livre).

30

.Acerca da noção de *right*, remete-se, por todos, a FRIEDMAN, Barry. When Rights Encounter Reality, cit., *passim*; e FRIEDMANN, Daniel. Rights and Remedies. In: COHEN, Nili; MCKENDRICK, Ewan (Org.). *Comparative remedies for breach of contract*. Pittsburgh: Hart, 2005. *passim*.

31

.Acerca da noção de *entitlement*, remete-se, por todos, a CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property Rules, Liability rules and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*, v. 85, n. 6, 1972. p. 1.090 e ss. A propósito da centralidade dos *remedies* em detrimento dos *rights* e *entitlements*, afirma-se, ao se analisar a disciplina do enriquecimento sem causa no direito inglês: “O ponto central da análise é que um nível de atribuição (direito) [*entitlement (right)*] é substituído por outro (remédio) [*remedy*]” (BARKER, Kit. Rescuing remedialism in unjust enrichment law: why remedies are right. *Cambridge Law Journal*, v. 57, n. 2, 1998, item IV. Tradução livre).

32

.Cf. SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi, cit., p. 192.

33

.Refere-se, nesse sentido, aos ordenamentos do sistema do *common law* como “[...] ordenamentos em cuja base está o precedente judicial. Assim, por exemplo, embora atualmente seja frequente a referência a ‘precedente’, especialmente pelo STJ, não se trata da mesma coisa: o nosso precedente, necessariamente plural e relativo ao direito, denota, na verdade, o comportamento da ‘jurisprudência’, enquanto o ‘precedente’ em sua acepção original, de matriz anglo-americana, com frequência é único e refere-se aos fatos principais da demanda” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação-interpretação do direito no início do século XXI. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 14, v. 56, out.-dez. 2013. p. 13-14). Para uma análise da centralidade dos precedentes nos sistemas do *common law*, v., ainda, BIRKS, Peter. Adjudication and interpretation in the common law: a century of change. *Legal Studies*, v. 14, n. 2, jul. 1994. *passim*.

34

.A propósito, v., por todos, FRIEDMANN, Daniel. Rights and Remedies, cit., p. 3-4; e MAJO, Adolfo di. *Le tutele contrattuali*, cit., p. 4. Não por acaso, afirma-se que no sistema de *common law* a definição das posições jurídicas funcionaria como um *posterius* em relação à prévia individualização da tutela mediante remédios: “A lógica dos remédios, levada às suas consequências últimas, conduz a sustentar a irrelevância dos direitos: afirmar que existe um direito – se sustenta – é apenas um modo para dizer que o ordenamento concede um remédio, porque é apenas pelo remédio que é possível definir o interesse tutelado. Se realmente quisermos falar de direito, a definição das posições subjetivas de vantagem é, portanto, um *posterius* em relação à individualização dos remédios” (SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi, cit., p. 191-192. Tradução livre).

35

.A propósito, v., por todos, FRIEDMANN, Daniel. Rights and Remedies, cit., p. 8 e ss. Tal formulação parece estar associada ao desenvolvimento conferido pela doutrina ao debate acerca da relação entre direito e ação, como se depreende, por exemplo, das análises críticas de MAJO, Adolfo di. *Le tutele contrattuali*, cit., p. 4; e MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*, cit., p. 1.

36

.Vale destacar que a metodologia civil-constitucional chega a criticar, embora por fundamentos diversos, ambos os brocardos mencionados. De uma parte, a ideia de *ubi remedium, ibi ius* pecaria por antepor os remédios à própria definição dos interesses concretamente merecedores de tutela jurídica. De outra parte, a ideia de *ubi ius, ibi remedium*, embora adequada no que tange à anteposição dos interesses a serem tutelados face à individualização dos remédios, pecaria por sugerir que o reconhecimento dos interesses merecedores de tutela necessariamente haveria de conduzir à identificação de um remédio judicial. Nesse sentido se posiciona a crítica de Pietro Perlingieri: “Não convence, antes de tudo, o assumido segundo o qual as necessidades de tutela

são ‘qualificadas’ somente se reconduzíveis a interesses judicializáveis. [...] Assim, na passagem de uma dogmática dos direitos a uma dogmática dos remédios, o interesse assumiria relevância somente no momento patológico. Afirmar que a previsão de um remédio é medida da relevância jurídica de um interesse (*ubi remedium ibi ius*) não é operação lógico-jurídica diversa do afirmar que uma situação é merecedora de tutela somente se qualificada pelo ordenamento como direito (*ubi ius ibi remedium*)” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 6-7).

37

.Ao propósito, v. SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”, cit., p. 174 e ss.

38

.Digna de nota a observação acerca da tendência à maior importância da jurisprudência no bojo dos sistemas romano-germânicos com códigos mais antigos, “[...] que os tribunais tiveram de adaptar a novas necessidades sociais” (VICENTE, Dário Moura. *Direito comparado*, cit., v. I, p. 168).

39

.“Adotando o léxico dos remédios, as tutelas às vezes ‘replicam’, outras vezes ‘transformam’, os direitos, e a escolha entre remédios que replicam e remédios que transformam direitos não depende da natureza do direito violado, mas de considerações de todo estranhas à conformação da posição subjetiva, de *rationes* novas e diversas daquelas relativas à atribuição da posição subjetiva” (SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”, cit., p. 176-177. Tradução livre).

40

.A propósito, v. SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”, cit., p. 180 e ss.

41

.Para uma análise crítica de tal atributo historicamente associado aos sistemas romano-germânicos, v. SACCO, Rodolfo. *Introdução ao direito comparado*. Trad. Vera Jacob de Fradera. São Paulo: Ed. RT, 2001. p. 93 e ss.

42

.“O *Common Law* reconhece, portanto, que as lógicas que presidem a administração da justiça *ex post* possam divergir daquelas que confluem na formulação da posição de vantagem e atribui ao juiz, no exercício da própria discricionariedade, a tarefa de colmatar essa distância. A linguagem dos remédios o reconhece e afirma que as tutelas às vezes ‘replicam’, outras vezes ‘transformam’; outras, ainda, ‘criam’ os direitos” (SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi, cit., p. 206. Tradução livre). V., ainda, LUPOLI, Maurizio. Il dolo del debitore: ‘*dolus*’ e ‘*fraud*’: dal diritto romano all’*equity* inglese. In: VISINTINI, Giovanna (Coord.). *Trattato della responsabilità contrattuale*. Padova: CEDAM, 2009. v. I – inadempimento e rimedi. p. 177-178; e PERLINGIERI, Pietro. Il principio di legalità nel diritto civile. *Rassegna di Diritto Civile*, a. 31, n. 1, 2010, p. 196.

43

.Cf. SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”, cit., pp. 185 e ss.

44

.Veja-se, ao propósito, a análise crítica de PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*, cit., p. 674 e ss.

45

.“À distância entre as respectivas ordens conceituais corresponde, sobre o plano funcional, uma (parcial) identidade de perspectiva. Todos os ordenamentos, tanto de *Civil Law* quanto de *Common Law*, conhecem a exigência de uma redefinição dos interesses em jogo à luz do caso singular, são conscientes do fato de que o sopesamento dos interesses não se pode dizer de todo exaurido com a atribuição de propriedades normativas em abstrato e elaboram instrumentos voltados a fazer frente a essa exigência” (SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi, cit., p. 202. Tradução livre).

“Também a jurisprudência de *Civil Law* sempre realizou, embora com sensibilidade e atenção variáveis, a tarefa de rever em sede aplicativa a consistência dos direitos subjetivos que o legislador havia definido na sua natureza absoluta (*dura lex sed lex*). Deste modo deu resposta à exigência de estender o próprio controle além dos estreitos limites da verificação de abstrata conformidade do exercício do direito à norma atributiva, e de verificar a legitimidade de comportamentos à luz do caso concreto, sem considerá-lo tais aprioristicamente pela abstrata conformidade ao direito conferido. A linguagem utilizada pelo legislador não pode mais que manter-se dentro de limites vagos e a regra finda por completar-se à luz das circunstâncias do caso concreto, segundo cânones hermenêuticos que não se exaurem na mecânica aplicação do ditado normativo postulada pela tradicional dicotomia direito/ação” (SMORTO, Guido. Sul significato di “rimedi”, cit., p. 178. Tradução livre).

.Nesse sentido, v. SMORTO, Guido. Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi, cit., p. 209-210.

“O direito subjetivo – figura controvertida desde sempre – perde centralidade definitivamente e aflui a exigência de diversificar os interesses e de dar formas e técnicas de tutela das pessoas asseguradas por novos órgãos e por novos instrumentos, individualizados segundo o tipo de interesse a ser tutelado e a ponderação de valores a ser realizada” (PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*, cit., p. 678). Digna de nota a lição de Mazzamuto e Plaia: “O percurso marcado pela precedência do remédio em relação ao direito é um traço característico dos sistemas de *common law* caracterizados pela cristalização dos direitos em torno dos remédios, mas não pode ser considerado estranho aos sistemas de *civil law*” (*I rimedi nel diritto privato europeo*, cit., p. 3. Tradução livre).

.Cf. SOUZA, Eduardo Nunes de. Situações jurídicas subjetivas: aspectos controversos. *Civilistica.com*, a. 4, n. 1, 2015. passim.

.Cf. SOUZA, Eduardo Nunes de. *Teoria geral das invalidades do negócio jurídico*: nulidade e anulabilidade no direito civil contemporâneo. São Paulo: Almedina, 2017. p. 114 e ss.

.V., por todos, PERLINGIERI, Pietro. *La persona e i suoi diritti*: problemi del diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2005. p. 14 e ss.; TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. *Temas de direito civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. passim; e BODIN DE MORAES, Maria Celina. Ampliando os direitos da personalidade. *Na medida da pessoa humana*: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. item 2.

.Perlingieri destaca: “É impossível, portanto, construir uma teoria das fontes sem interpretação. A teoria da interpretação é parte integrante da teoria das fontes e é inconcebível que a primeira seja exaurida na individuação do significado do dado literal. O direito tem por objeto fatos concretos. Objeto da interpretação não é a norma, mas sim a norma unida ao fato. É necessário ter a força intelectual e cultural de recuperar a normatividade da factualidade, a valência normativa dos fatos, o que implica que a hermenêutica jurídica não se possa exaurir em uma ciência da linguagem” (Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”, cit., p. 27. Tradução livre). Justifica-se, portanto, a cautela para com as formulações que apontem uma suposta menor importância do dado fático para a interpretação no *civil law*: “As distâncias entre *Civil Law* e *Common Law* permanecem tantas e significativas. O *Common Law* reconhece de modo mais claro a exigência de uma análise que leve em consideração tanto a posição subjetiva reconhecida em abstrato quanto o remédio concedido em concreto, e sobretudo a relativa independência das duas

questões” (SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 204. Tradução livre).

53

“Longe de aderir a lógicas formalistas, a busca pela medida mais adequada deve concentrar-se sobre o interesse juridicamente relevante: é necessário, em suma, privilegiar não a declamação dos direitos, mas a efetividade das soluções concretamente oferecidas pelo ordenamento diante da violação a um específico interesse” (PERLINGIERI, Pietro. *Il “giusto rimedio” nel diritto civile*, cit., p. 4. Tradução livre). No mesmo sentido, cf. SMORTO, Guido. *Il linguaggio dei diritti e il linguaggio dei rimedi*, cit., p. 203.

54

Eis a lição de Luca Nivarra: “Francamente, não posso dizer se simplificações deste gênero são confiáveis, e em que medida. De qualquer modo, gostaria de salientar que: (i) os remédios de que se fala encontram a própria fonte nos textos do direito comunitário derivado que, embora questionáveis sob o perfil da técnica redacional, são textos legislativos e, portanto, colocam no sistema enunciados muito mais gerais e abstratos do que individuais e concretos; (ii) os ‘remédios’ de que se fala remontam a um interesse cuja juridicidade já foi afirmada por uma norma diversa daquela atributiva do remédio” (*I nuovi orizzonti della responsabilità contrattuale*, cit., p. 19-20. Tradução livre). Cf., ainda, NIVARRA, Luca. *Rimedi*, cit., p. 602-603.

55

Cf. SILVA, Rodrigo da Guia. *Remédios no direito privado*, cit., item 3.

56

“É verdade, porém, que o argumento orientado às consequências teve historicamente pouco espaço no *civil law*, em que a atividade hermenêutica do juiz sempre foi concebida como o produto da interpretação de normas de decisão formuladas de modo condicional e aplicadas mecanicamente ao caso concreto por parte do juiz” (SMORTO, Guido. *Sul significato di “rimedi”*, cit., p. 187. Tradução livre).

57

A ilustrar a formulação doutrinária de uma associação (indevida, vale frisar) entre o *civil law* e a técnica da subsunção, chega-se a se afirmar que a superação desse (suposto) paradigma representaria um “acolhimento ao menos parcial daquela arraigada flexibilidade própria do plano dos remédios” (SMORTO, Guido. *Sul significato di “rimedi”*, cit., p. 179-180. Tradução livre).

58

Permita-se remeter a SOUZA, Eduardo Nunes de. *Merecimento de tutela*, cit., p. 79 e ss.; e, ainda, SILVA, Rodrigo da Guia. *Um olhar civil-constitucional sobre a “inconstitucionalidade no caso concreto”*. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, ano 18, v. 73, jan. 2017. p. 53.

59

BODIN DE MORAES, Maria Celina. *Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz*, cit., p. 19.

60

V., por todos, PERLINGIERI, Giovanni. *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015. p. 68.

61

Tal tendência é destacada pela doutrina que se ocupa de analisar o maior espaço de criatividade (sempre reconduzida à legalidade constitucional e sujeita à fundamentação detida) atribuído ao julgador pelas cláusulas gerais (CASTRONOVO, Carlo. *L'avventura delle clausole generali*. *Rivista Critica del Diritto Privato*, ano IV, mar. 1986. passim; e MAJO, Adolfo di. *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*. *Rivista Critica del Diritto Privato*, ano II, n. 3, set. 1984. p. 545-552). Para uma análise mais detida acerca da expansão dessa técnica legislativa, embora sem superação absoluta da técnica regulamentar, cf., por todos, RODOTÀ, Stefano. *Il tempo delle clausole generali*. *Rivista Critica del Diritto Privato*, n. 4, 1987. passim.

“Daí o papel essencial que assume, sob o paradigma pós-positivista, a argumentação. O recurso aos princípios deflagra hipóteses em que dois princípios, ambos válidos e legítimos, entram em colisão ao oferecerem soluções opostas ao caso concreto: nessas hipóteses, a aplicação do Direito impõe o recurso à chamada ponderação, para encontrar qual deles é o mais adequado àquele caso, qual tem sua aplicação mais justificada. Este procedimento é essencialmente argumentativo e vem inspirado pela construção de uma teoria da argumentação, calcada na existência de uma lógica informal, que se aparta da racionalidade matemática, sem abrir mão dos processos de verificação de razoabilidade que lhe garantem legitimidade” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Do juiz boca-da-lei à lei segundo a boca-do-juiz, cit., p. 19-20).

.Sobre a inadequação da lógica proprietária nesse setor, cf. RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Org. Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 98 e ss.

.Para uma análise crítica – de que não se partilha – do enfoque da LGPD sobre a tutela da pessoa humana (aspecto explicitado, entre tantos outros, pelos arts. 1º e 17), v. MAGALHÃES, Rodrigo Almeida; DIVINO, Sthéfano Bruno Santos. A proteção de dados e o direito de personalidade da pessoa jurídica. *Revista de Direito Empresarial*, São Paulo, ano 15, n. 3, set.-dez. 2018. p. 40 e ss.

.Afirma-se, em comentário ao art. 17 da LGPD: “Trata-se de artigo que, na verdade, apenas repete vários dos direitos anteriormente já mencionados, com a desvantagem de não se referir expressamente a todos” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: os direitos dos titulares de dados pessoais. Parte IX. *Jota*, 17.10.2018).

.A propósito da cláusula geral de proteção à pessoa humana, v., por todos, BODIN DE MORAES, Maria Celina. Ampliando os direitos da personalidade, cit., p. 125 e ss.; e TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro, cit., p. 50 e ss.

.Cf., por todos, KONDER, Carlos Nelson. The range of the right to personal identity in Brazilian civil law. *Pensar*, Fortaleza, v. 23, n. 1, jan.-mar. 2018, p. 2-3.

.Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 24. ed. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. I. p. 217.

“A este período remonta o paradigma da privacidade como uma *zero-relationship*, como a ausência de comunicação entre um sujeito e os demais” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 8-9).

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 15. E também em relação a outros chamados direitos da personalidade tem-se observado certa absorção pela noção de privacidade. Assim se sustentou a respeito da honra em SOUZA, Eduardo Nunes de. Dano à honra pela opinião do entrevistado ou do leitor. In: SCHREIBER, Anderson (Org.). *Direito e mídia*. São Paulo: Atlas, 2015. p. 307 e ss. Já no que diz respeito à imagem, Bruno LEWICKI faz referência à “vocaç o expansiva de um conceito cada vez mais insepar vel do direito   pr pria imagem” (Realidade refletida: privacidade e imagem na sociedade controlada. In: TEPEDINO, Gustavo e FACHIN, Luiz Edson (Coord.). *O direito e o tempo: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 111).

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 15. Para um relato da difusão da referida linha de entendimento no direito brasileiro, v. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18). *Revista de Direito e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, set.-dez. 2018. p. 171 e ss.

72

.Aponta-se, por exemplo, o caráter procedimental dos incisos do art. 18 da LGPD: “Já o inciso VIII pode ser considerado uma especificação do direito à informação, diante da importância do consentimento do titular como regra geral para a utilização dos seus dados pessoais. Daí mencionar o direito à ‘informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa’. Com efeito, apenas se pode cogitar de consentimento inequívoco do titular de dados se ele souber as repercussões tanto da sua aceitação como da sua recusa” (FRAZÃO, Ana de Oliveira. Nova LGPD: demais direitos previstos no art. 18. *Jota*, 28.11.2018).

73

.Cf. RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 60 e ss. No direito brasileiro, cf. DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*, cit., p. 216-217.

74

.Ao propósito, v. DONEDA, Danilo; MENDES, Laura. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. item 2.

75

.Com base no princípio da finalidade “fundamenta-se a restrição da transferência de dados pessoais a terceiros, além do que é possível a estipulação de um critério para valorizar a razoabilidade da utilização de determinados dados para uma certa finalidade (fora da qual haveria abusividade)” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*, cit., p. 216). V., ainda, DONEDA, Danilo; MENDES, Laura. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, cit., item 2.

76

.Cf. SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 172-174.

77

.Exatamente nessa linha de sentido, Stefano Rodotà alude ao caráter instrumental do *princípio de acesso* (nominalmente tratado como *direito de acesso* pelo art. 18, II, da LGPD): “Bem diversa é a situação do princípio de acesso. Este é, antes de tudo, um instrumento diretamente acionável pelos interessados, que podem utilizá-lo não somente com a finalidade de simples conhecimento, mas também para promover propriamente a efetividade de outros princípios. Saliente-se, de fato, que entre os poderes atribuídos pelo direito de acesso existe também o de obter a correção, a integração ou a eliminação dos dados coletados” (*A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 60). No direito brasileiro, cf. DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*, cit., p. 217.

78

.Assim destaca RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 104.

79

.Conforme anota Danilo DONEDA: “Estes princípios, mesmo que fracionados, condensados ou então adaptados, podem ser identificados em diversas leis, tratados, convenções ou acordos entre privados. Eles são o núcleo das questões com as quais todo ordenamento deve se deparar ao procurar fornecer sua própria solução ao problema da proteção dos dados pessoais” (*Da privacidade à proteção de dados pessoais*, cit., p. 217).

80

.Emblemática, nessa linha de sentido, a associação esquemática, proposta por Ana FRAZÃO, entre os *direitos* dos titulares de dados e os *princípios* dos quais aqueles decorreriam (Nova

LGPD: os direitos dos titulares de dados pessoais, cit.).

81

“Desta forma verifica-se a passagem de uma enunciação negativa e passiva da proteção dos dados para uma positiva e dinâmica. A técnica jurídica utilizada não é mais a da atribuição ao sujeito privado de um direito acionável diante de um órgão *ad hoc* somente depois da sua violação. Agora é concedido ao privado um poder de controle direto e contínuo sobre os coletores de informações, independentemente da existência real de uma violação. Muda assim a técnica de proteção da privacidade e a atenção se desloca para o bom funcionamento das regras sobre a circulação das informações” (RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 60).

82

.Como afirma Pietro PERLINGIERI, o interesse “é o fundamento justificador da situação” (*O direito civil na legalidade constitucional*, cit., p. 669). Para um desenvolvimento do estudo das situações jurídicas subjetivas, remete-se a SOUZA, Eduardo Nunes de. *Situações jurídicas subjetivas*, cit., passim.

83

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 60.

84

.Em comentário ao inciso VIII do art. 18 da LGPD, afirma-se: “Já o inciso VIII pode ser considerado uma especificação do direito à informação, diante da importância do consentimento do titular como regra geral para a utilização dos seus dados pessoais. [...] Com efeito, apenas se pode cogitar de consentimento inequívoco do titular de dados se ele souber as repercussões tanto da sua aceitação como da sua recusa” (FRAZÃO, Ana de Oliveira. *Nova LGPD: demais direitos previstos no art. 18*, cit.).

85

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 68.

86

.O art. 759 do Código Civil estabelece, nesse sentido, ao tratar da declaração inicial do risco, que a proposta deve conter “[...] a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco”. Para o maior desenvolvimento da questão atinente ao conteúdo da declaração inicial do risco, v., por todos, na doutrina contemporânea, PETERSEN, Luiza Moreira. *O risco no contrato de seguro*. São Paulo: Roncarati, 2018. p. 131 e ss.

87

.No que tange especificamente à identificação do parâmetro de análise dos deveres de informação decorrentes da boa-fé objetiva e a promoção, já se pôde afirmar: “Seja qual for a denominação atribuída à manifestação concreta do dever de informação, o fato é que da cláusula geral de boa-fé objetiva decorre a necessidade de oportunização, a todos os envolvidos, do conhecimento das informações relevantes ao desenvolvimento e deslinde de uma dada relação obrigacional. A menção à *relevância* das informações faz-se de sensível destaque, no que tange ao objeto precípua do presente estudo, uma vez que nem toda omissão ou má prestação de informação será suficiente à caracterização de inadimplemento contratual” (SILVA, Rodrigo da Guia. Em busca do conceito contemporâneo de (in)adimplemento contratual: análise funcional à luz da boa-fé objetiva. *Revista da AGU*, v. 16, n. 2, abr.-jun. 2017. p. 303-304. Grifos no original).

88

.A respeito da autonomia existencial, esclarece Rose Melo Vencelau Meireles que “a revogabilidade decorre do princípio do consentimento qualificado, sobretudo, quando da disposição resulte limitação ao exercício de direito da personalidade, pois somente a limitação voluntária é admissível. Permite-se que o disponente se arrependa da declaração de vontade que expressou e a revogue, até o momento anterior ao da execução material do ato” (*Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 246).

“Nesse diapasão, o instituto do abuso fornece valioso instrumento para a ainda frágil disciplina jurídica dos atos de autonomia existencial. Embora nem sempre se identifique parte legítima para alegar o abuso nas situações dessa natureza, o controle funcional do exercício mostra-se essencial nos casos em que houver interesse legítimo contraposto. Esse interesse pode integrar a função da situação subjetiva desde sua gênese (é o caso do abuso do poder familiar), ou especificar-se pela violação da regra geral de não lesar ninguém (ilustrativamente, na hipótese da revogação de certas escolhas existenciais que venha a ocasionar dano a terceiros). Em qualquer caso, se outro interesse, além daquele do titular, estiver integrado à *função* da situação jurídica, não será sua natureza existencial a impedir o controle de abusividade do exercício” (SOUZA, Eduardo Nunes de. Abuso do direito em relações existenciais. *Revista Eletrônica Direito e Política*, Itajaí, v. 10, n. 4, set.-dez. 2015. p. 2295).

.Cf. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais, cit., p. 165 e ss.

.Para uma análise do tratamento especial dispensado aos chamados dados sensíveis pela referida Seção II do Capítulo II da LGPD, v. SANTOS, Fabíola; TALIBA, Rita. Lei geral de proteção de dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018. item 4.

.Sobre essa tutela menos intensa dos dados econômicos e sua relevância para o conteúdo contemporâneo da noção de privacidade, veja-se a lição de Stefano Rodotà: “Procura-se individuar o ‘núcleo duro’ da privacidade em torno dos dados relativos a opiniões políticas, sindicais ou de qualquer outro gênero, fé religiosa, raça, saúde, hábitos sexuais. Ao mesmo tempo, tende-se a liberalizar a circulação de informações pessoais de cunho econômico” (*A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 78).

.Afirma-se: “A tutela inibitória possui três modalidades. A primeira [...] visa a impedir a prática do ilícito, podendo atuar antes que qualquer ilícito tenha sido praticado. As outras duas visam a inibir a repetição e a continuação do ilícito, nos casos de ilícito já praticado. Exemplo de ação ilícita continuada é a atividade que gera fumaça poluente e de ação ilícita repetida o despejo de lixo tóxico no ambiente” (PITERMAN, Marcel. Direito e processo, cit., p. 45).

“Enquanto a tutela inibitória visa a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, a tutela de remoção do ilícito ou reintegratória, por sua vez, destina-se a remover os efeitos de uma ação ilícita que já ocorreu, como, por exemplo, aprender produtos nocivos à saúde de consumidores já expostos à venda” (PITERMAN, Marcel. Direito e processo, cit., p. 45). Cumpre registrar que se está tomando, neste ponto do estudo, a noção de “ilícito” no sentido amplo de ato contrário à ordem jurídica e, portanto, não necessariamente correlacionado ao fenômeno da responsabilidade civil.

“A prospectada leitura teleológico-funcional do sistema remedial permite reconhecer na ação inibitória uma técnica a ser ativada especialmente na via preventiva, na fase fisiológica da realização de interesses juridicamente relevantes e não somente naquela patológica da lesão dos interesses. Pressuposto da inibitória, de fato, não é o ilícito – que pode até mesmo faltar –, mas o dano, seja apenas temido e ainda mais se potencialmente irreparável” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 20. Tradução livre).

“É necessário admitir que um modelo de tutela civil dos direitos, que queira ser efetivo e não virtual, deveria abandonar o seu tradicional caráter agnóstico voltado para o ilícito e a violação dos

direitos, caráter ínsito no fato de que ele intervém apenas para reprimir violações já ocorridas e remover, se possível, as suas consequências. Deveria exercer também uma função preventiva das violações e isso em situações de fato que as deixem ser presumidas” (MAJO, Adolfo Di. La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale, cit., p. 377. Tradução livre).

97

“O campo de aplicação de tal medida [inibitória] é usualmente limitado às *fattispecie* para as quais é expressamente prevista *ex lege*, embora às vezes as relativas disposições normativas sejam consideradas suscetíveis de interpretação analógica. No entanto, essa orientação não convence. Há interesses que, à luz [...] do complexo dos princípios fundamentais do ordenamento, não podem ficar sem proteção devido à ausência de uma norma específica que permita o recurso à inibitória ou dos pressupostos para a aplicação analógica da mesma” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 18-19. Tradução livre). O autor arremata: “Para concluir, a idoneidade de qualquer instrumento de proteção para atender à necessidade específica de tutela impõe a superação do pseudo-princípio da tipicidade, que parece informar o ordenamento em todas as áreas (desde as disposições sobre o tema da publicidade até aquelas sobre os remédios)”. Semelhante conclusão é também corroborada, à luz do direito brasileiro, por SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado, cit., item 4.

98

“A preocupação é direcionada para o futuro e não para o passado, o leva à afirmação de que as ordens inibitórias dos juízes, disseminadas no código ou em outras leis, não representam uma espécie ‘isolada’, mas sim a expressão de um remédio mais geral, de fato inibitório, que encontra o seu fundamento na exigência de prevenir as violações [...]” (MAJO, Adolfo Di. La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale, cit., p. 378. Tradução livre).

99

“[...] o remédio inibitório é admissível em todas as hipóteses nas quais se consinta a efetiva implementação de um interesse merecedor de tutela: ‘a extensão da inibitória é efetuada não por meio de uma interpretação ampliativa ou analógica, mas baseando-se no princípio de adequação do remédio em relação ao interesse substancial’” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 19, nota de rodapé n. 49). O autor arremata: “O remédio, se encontrar justificativa no merecimento de tutela da situação jurídica subjetiva lesada e nos valores que merecem prevalência, deve sempre ter aplicação” (Ibidem, p. 19-20).

100

.Ilustrativamente: “[...] A concessão de tutela inibitória em face de jornalista, para que cesse a postagem de matérias consideradas ofensivas, se mostra impossível, pois a crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não pode ser aprioristicamente censurada. 5. Sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do autor e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião. [...] Mesmo para casos extremos como o dos autos – em que há notícia de seguidos excessos no uso da liberdade de imprensa – a mitigação da regra que veda a censura prévia não se justifica” (STJ, 3ª T., REsp 1.388.994/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.09.2013, DJe 29.11.2013).

101

.Para uma análise do exemplo das biografias como um problema de merecimento de tutela envolvendo o direito à privacidade, remete-se a SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela, cit., p. 97 e ss.

102

.STF, Tribunal Pleno, ADI 4.815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2015, DJe 01.02.2016.

103

.Trata-se de tendência que parece remontar, ao menos, ao julgamento da ADPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela não recepção da Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967), por considerá-la atentatória àquilo que a Corte reconheceu como “superiores bens de personalidade”: “A plenitude da liberdade de imprensa como reforço ou sobretutela das liberdades de manifestação

do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relações de imprensa e que se põem como superiores bens de personalidade” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 130/DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 30.04.2009, *DJe* 06.11.2009). Para uma crítica a essa concepção, cf. BODIN DE MORAES, Maria Celina; SOUZA, Eduardo Nunes de. Educação e cultura no Brasil: a questão do ensino domiciliar. *Civillistica.com*, ano 6, n. 2, 2017. p. 7 e ss.

104

.Colhe-se da ementa: “A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular” (STF, Tribunal Pleno, ADI 4.815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2015, *DJe* 01.02.2016).

105

.Colhe-se da ementa: “Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem” (STF, Tribunal Pleno, ADI 4.815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2015, *DJe* 01.02.2016). Cumpre registrar, ainda, o dispositivo do acórdão, conforme resumido na ementa da decisão: “Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes)” (STF, Tribunal Pleno, ADI 4.815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2015, *DJe* 01.02.2016).

106

.Precisamente nesse sentido, Pietro Perlingieri afirma que se afigura útil “[...] refletir sobre a conveniência de conceber o remédio como uma reação taxativamente ligada à violação de um interesse típico [...]. O remédio é uma ferramenta que se adapta ao interesse que se pretende tutelar e que é reconhecido pelo ordenamento” (PERLINGIERI, Pietro. *Regole del mercato e tutela dell’investitore: riflessioni a margine della MiFID*. In: ADAMO, S.; CAPOBIANCO, Ernesto; CUCURACHI, P. (a cura di). *Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010. p. 315. Tradução livre).

107

.Assim conclui PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 7. A ilustrar a relevância da presente reflexão em matéria de proteção de dados, pode-se mencionar o questionamento sobre a consagração ou não de um *direito à explicação* pela LGPD. Ao propósito, v. MONTEIRO, Renato Leite. Existe um direito à explicação na lei geral de proteção de dados do Brasil? *Artigo estratégico*, n. 39, dez./2018, passim.

108

.“Uma ‘categoria’ dos remédios, derivada do direito positivo, se fosse possível construí-la, se revelaria totalmente inútil. A questão deve ser abordada, antes de tudo, em chave funcional, rejeitando esquemas rígidos. Como antecipado, não é o interesse a estruturar-se em torno do remédio, mas o remédio a encontrar modulação em função dos interesses considerados pela *fattispecie* concreta. Deve-se, em suma, discutir a flexibilidade do sistema remedial” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 4-5. Tradução livre). O autor arremata: “Em definitivo, as tentativas de reconstrução do complexo remedial operadas pela doutrina resultam, na maior parte, contraditórias e incertas” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 7. Tradução livre).

109

.Conforme já proposto previamente em SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado, cit., item 4. Exemplo de aplicação das referidas premissas se encontra, na disciplina dos remédios ao inadimplemento contratual, em SILVA, Rodrigo da Guia. A revisão do contrato como remédio possível para o inadimplemento. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 995, set. 2018. passim.

110

.V., na doutrina italiana, PERLINGIERI, Pietro. Il principio di legalità nel diritto civile, cit., pp. 196-197; e MAZZAMUTO, Salvatore; PLAIA, Armando. *I rimedi nel diritto privato europeo*, cit., p. 16.

111

.Assim conclui a doutrina processualista nacional “A sua vez, a efetividade está consagrada no art. 5º, XXXV, da CF/1988, pois não é suficiente tão somente abrir a porta de entrada do Poder Judiciário, mas prestar jurisdição tanto quanto possível eficiente, efetiva e justa [...]. Advirta-se, além disso, que a efetividade vigora seja em relação ao direito já lesionado seja quanto aquele simplesmente ameaçado (art. 5º, XXXV, da CF/1988), abrangendo assim a tutela preventiva substancial e definitiva, além da meramente provisória ou temporária” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo, cit., item 3). No mesmo sentido, v., na doutrina civilista, BODIN DE MORAES, Maria Celina. Prescrição, efetividade dos direitos e danos à pessoa humana, cit., p. 7. Ao identificar fundamento constitucional da garantia de efetividade dos remédios no âmbito do direito italiano, Adolfo di Majo faz referência à “[...] prescrição constitucional segundo a qual ‘todos podem agir em juízo para a proteção dos próprios direitos e interesses legítimos’ (artigo 24 da Constituição), prescrição que, segundo alguns (Andrioli), é um sinal claro de uma garantia de efetividade, mas não já no sentido de uma abstrata ‘justiciabilidade’ do direito e/ou interesse, mas da existência de um remédio concreto que garanta a sua satisfação ou que, de qualquer forma, desencoraje a sua insatisfação” (MAJO, Adolfo Di. La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale, cit., p. 372. Tradução livre). O autor prossegue: “A este respeito, é útil mencionar a opinião (Taruffo) de quem entende que a exigência, constitucionalmente garantida, de efetividade da tutela não pode se considerar satisfeita com a previsão de um qualquer remédio judicial, mas um remédio em função do conteúdo que é próprio do direito” (La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale, cit., p. 372. Tradução livre).

112

.Precisamente nesse sentido, o artigo 497 estabelece que, “(N)a ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. No que diz respeito à obrigação de entrega de coisa, o artigo 498 igualmente faz referência à concessão judicial da tutela específica. Ainda mais emblemática é a previsão geral do artigo 499, no sentido da denominada prioridade da execução específica e da tutela pelo “resultado prático equivalente” em detrimento da medida (supostamente subsidiária) de resolução do contrato (com os seus efeitos ordinariamente esperados). Para uma crítica às imprecisões técnicas do art. 499 do diploma processual à luz da dogmática civilista, sem embargo da louvável preocupação de enunciação do cabimento amplo (e não taxativo) das medidas de tutela específica, permita-se remeter a SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado, cit., item 4.

113

.“O que deve ser reiterado é que a adequação da tutela não pode ser avaliada em abstrato, no que diz respeito à postulação de um juízo, qual que então seja o seu resultado prático, mas à congruência do concreto remédio subministrado (ao êxito do juízo) com o interesse de cuja tutela se trata” (MAJO, Adolfo Di. La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale, cit., p. 372-373. Tradução livre). Pertinente, ainda, a conclusão alcançada na doutrina processualista: “[...] numa perspectiva dinâmica, a efetividade qualificada implica o direito da parte de obter uma decisão de mérito, adaptada às situações materialmente tuteláveis, levando em conta a crise sofrida pelo direito material e sua adequação às formas diferenciadas de tutela e a segurança, que não pode mais ser vista sob a ótica do Estado Liberal, quando prevalecia como valor; significa o direito da parte ao processo justo, pois, mesmo atendido o formalismo do sistema, o processo pode ser injusto ou conduzir a um resultado injusto” (PITERMAN, Marcel. Direito e processo, cit., p. 52). O autor prossegue: “[...] para coordenar e equacionar ambos os planos, visando à concretização de um processo justo, existe, no plano material, o direito à tutela dos direitos e, no plano processual, o direito à tutela jurisdicional. Esta deverá ser sempre uma resposta adequada e efetiva àquela, para

que se viabilize a tutela de toda a sorte de direitos (individuais e coletivos)” (PITERMAN, Marcel. Direito e processo, cit., p. 42).

114

.Assim adverte PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 10.

115

.“A rejeição das tentativas de conceituação e uma perspectiva axiológico-funcional podem induzir a definir remédio como todo instrumento idôneo para implementar um interesse. Isso não apenas justifica a sua previsão, mas também oferece a sua medida: a proteção das situações juridicamente relevantes deve sempre ser adequada e efetiva” (PERLINGIERI, Pietro. Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit., p. 8. Tradução livre). V., ainda, MESSINETTI, Davide. La sistematica rimediale, cit., p. 104-105.

116

.Assim se pôde sustentar em SILVA, Rodrigo da Guia. Remédios no direito privado, cit., item 5.

117

.“É interessante notar que, nos termos do art. 18, os direitos dos titulares são direcionados ao controlador, o que pode ser considerado uma falha técnica, pois, como se verá adiante, ao se tratar dos deveres e responsabilidades dos agentes de tratamento, vários deles também serão oponíveis aos operadores e encarregados. Melhor teria sido se o legislador brasileiro, a exemplo do Regulamento Europeu, tivesse identificado como titular dos deveres os responsáveis pelo tratamento de dados, categoria mais ampla que abrange, mas não se restringe, ao controlador, nos termos das definições constantes do próprio art. 5º, da LGPD” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: os direitos dos titulares de dados pessoais, cit.).

118

.Veja-se, a esse propósito, a lição de Stefano RODOTÀ, que destaca a relevância de que, para tornar mais eficaz o acesso, os indivíduos contem com um acesso “assistido” por especialistas, e remata: “Ainda mais importante revela-se o reconhecimento de um direito de acesso individual ‘integrado’ pela presença de um sujeito coletivo (sindicato, associação de direitos civis, associação de tutela de consumidores e assim por diante). Seria necessária, aliás, a previsão de uma legitimação autônoma de acesso de tais sujeitos coletivos, mesmo se temperada pelo consentimento do interessado: tais sujeitos, de fato, poderiam assumir, entre as suas funções institucionais, a do exercício sistemático do direito de acesso, realizando assim um efetivo controle sobre os coletores das informações” (*A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 68).

119

.Aluda-se, ainda uma vez, à lição de Stefano RODOTÀ, que, ao ponderar sobre a construção ideal de um sistema normativo de proteção de dados pessoais, adverte: “uma análise correta do problema requer uma reflexão realista sobre os sujeitos e os interesses em questão, especialmente para verificar se os sujeitos implicados nas transações relacionadas às informações não revelam excessiva disparidade de poder, visto que a intervenção legislativa teria justamente a função de reconstruir as condições de base para o funcionamento adequado das próprias regras de mercado” (*A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 57).

120

.Para uma análise do art. 19, II, da LGPD, v. FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: os direitos dos titulares de dados pessoais, cit.

121

.*A vida na sociedade da vigilância*, cit., p. 89.

Capítulo 10. Consentimento e proteção de dados pessoais na LGPD

Gustavo Tepedino ¹

Chiara Spadaccini de Teffé ²

1.A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: notas introdutórias

A proteção dos dados pessoais compõe uma das partes essenciais da tutela da dignidade da pessoa humana, mostrando-se essencial para a garantia das liberdades fundamentais, da igualdade, da solidariedade e da integridade psicofísica. O desenvolvimento de mecanismos destinados a regular o tratamento dos dados auxilia a evitar discriminações que não encontrem fundamento constitucional, como aquelas que possam dificultar o acesso ao crédito ou a empregos por determinados grupos. Além disso, afasta práticas que possam reduzir a liberdade e autonomia dos indivíduos, como decisões a partir de análises de dados não informadas ao titular e sob critérios não transparentes. A tutela dos dados relativos à pessoa natural mostra-se hoje vital para que ela se realize integralmente e se relacione na sociedade, representando garantia de maior segurança às informações dos cidadãos e impedindo práticas autoritárias e de vigilância por parte de instituições públicas e privadas.

É necessário compreender que não só importantes instituições e empresas estão sujeitas a ter suas informações e bancos de dados violados. Grande parte das pessoas, muito provavelmente, já teve seus dados tratados indevidamente e, inclusive, vazados em algum episódio de vulnerabilidade³ de determinada empresa. Tal constatação intensifica a demanda por normas nacionais, regionais e internacionais atentas aos novos desafios tecnológicos e que estabeleçam tanto mecanismos efetivos para a proteção e reparação das pessoas quanto deveres e responsabilidades específicas para todo aquele que realizar o tratamento de dados pessoais.⁴

Nas últimas décadas, a defesa da autonomia da proteção dos dados pessoais e sua consideração como direito fundamental restaram presentes em diversos ordenamentos e documentos internacionais. Em 1981, foi aberta para assinatura a Convenção para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal (Convenção 108).⁵ Em âmbito europeu, ela foi seguida pela Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que, além de garantir o respeito à vida privada e familiar (art. 7º) e o direito à integridade do ser humano (art. 3º), tutelando o corpo físico, consagrou também o direito à proteção dos dados pessoais (art. 8º), garantindo assim o corpo eletrônico e elevando essa proteção à condição de direito fundamental.

No Brasil, até agosto de 2018, não se dispunha de lei específica para a proteção dos dados pessoais. Entretanto, sua tutela já poderia ser pleiteada com base em determinadas previsões estabelecidas na Constituição Federal, como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X); a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, XII); e a ação de *habeas data* (art. 5º, LXXII). Como aponta a doutrina,⁶ o País já contava com mais de 40 normas que direta ou indiretamente tratavam de questões relacionadas à privacidade e aos dados pessoais, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação e a Lei do Cadastro Positivo. Todavia, esse arcabouço regulatório mostrava-se pouco preciso e não oferecia garantias adequadas às partes, o que, além de gerar insegurança jurídica, acabava tornando o País menos competitivo no contexto de uma sociedade cada vez mais movida a dados.

Levando em conta a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil (Lei 13.709/18 – LGPD), no presente artigo visa-se analisar o tratamento oferecido ao consentimento do titular dos dados. Para tanto, será realizado o estudo das normas gerais para a expressão do consentimento válido para o tratamento de dados pessoais. Em seguida, passa-se para a estrutura protetiva desenvolvida para os dados sensíveis e, por fim, para a norma relativa ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, com ênfase na disposição relativa ao consentimento para o tratamento dessas informações. A partir do tema proposto, busca-se levantar indagações e avaliar possibilidades de interpretação e aplicação da LGPD, sempre em favor da pessoa humana e de suas situações existenciais. Adicionalmente, serão realizados alguns paralelos entre a LGPD e o Regulamento europeu de proteção de dados (GDPR - *General Data Protection Regulation*).

A partir do desenvolvimento de tecnologias cada vez mais sofisticadas para o tratamento de dados, da maior aplicação da inteligência artificial em sistemas e processos e da ampliação da capacidade de armazenamento de informações, mostrou-se urgente a edição e a atualização de normas para tratar de maneira mais específica as questões enfrentadas no que concerne à proteção da privacidade e dos dados pessoais, especialmente no que tange aos dados sensíveis e aos dados de crianças e adolescentes.

A tecnologia expande o alcance da memória humana, registrando o paradeiro, o itinerário, as referências geográficas e biomédicas, a origem e o destino de cada um, bem como as pessoas com quem se estabelece qualquer tipo de relacionamento, as preferências de consumo, as peculiaridades pessoais. Para a melhor tutela dos

direitos fundamentais, há que se definir quando, onde, como e para que fins poderão ser colhidas informações pessoais, havendo restrições e limites ao seu tratamento se utilizadas como ativo comercial ou expressão de poder do Estado.⁷

Nas últimas décadas, a privacidade vem sendo gradualmente compreendida como direito de manter controle sobre as próprias informações⁸, passando a fazer referência à possibilidade de a pessoa natural conhecer, controlar, endereçar e, até mesmo, interromper o fluxo das informações a ela relacionadas. Abriu-se, assim, espaço para a chamada autodeterminação informativa, que representa a faculdade de o particular controlar a obtenção, a titularidade, o tratamento e a transmissão de dados relativos a ele.

Nessa perspectiva, a atenção voltou a se dirigir para o consentimento dos interessados, havendo uma evolução do consentimento implícito (situação em que se entende que uma pessoa consentiu com algo em razão da conduta que assume) para o consentimento informado, o qual orienta inclusive normas relativas à circulação de informações, “visto que se manifesta em uma série de disposições que prescrevem quais devem ser as informações fornecidas ao interessado para que seu consentimento seja validamente expresso.”⁹ No momento atual, o consentimento livre e informado vem ganhando cada vez mais prestígio, por tornar o usuário participante ativo no processo de consentimento.

Nessa esteira, não se mostra mais suficiente, para proteger a privacidade, a garantia de não ingerência alviçada por Warren e Brandeis, em seu *right to be left alone*, do final do Século XIX. A aproximação da privacidade como a autodeterminação informativa demonstra que a liberdade, em especial nas relações existenciais, não implica ausência do Direito, mas, ao contrário, pressupõe que o Direito atue de maneira a proteger a parte mais vulnerável, fornecendo-lhe meios para efetivamente poder discernir, decidir e agir. O oferecimento aos cidadãos de instrumentos para que eles possam assumir efetivamente controle sobre o uso e a integridade de suas informações representa garantia de liberdade e igualdade, tendo em vista o papel predominante da informação para as escolhas do ser humano.¹⁰

A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados 2016/679¹¹ representam no contexto atual instrumentos para a proteção e garantia da pessoa humana, uma vez que facilitam o controle dos dados tratados, impõem deveres e responsabilidades aos agentes de tratamento e proporcionam segurança para que as informações circulem. Os dois sistemas encontram-se fortemente alinhados, como desejou o legislador brasileiro, para que a norma nacional, nos próximos anos, seja reconhecida como adequada ao sistema europeu, uma vez que isso facilitará a realização de transações e cooperações com países do bloco. Na América Latina¹², apenas Argentina e Uruguai até o momento conseguiram tal reconhecimento.¹³

Levando isso em conta, foi estabelecido modelo legislativo no Brasil que apresenta caráter preventivo.¹⁴ Busca-se antecipar os riscos de violação à privacidade, além de evitar danos à pessoa humana, tratamentos abusivos de informações e vazamentos de dados.

Foram incorporados e positivados, aqui, assim como ocorreu no Regulamento europeu¹⁵, os pilares da chamada proteção da privacidade e dos dados pessoais por *design* e por padrão. A partir desses paradigmas, entende-se que a proteção dos dados deve ser pensada desde a concepção do produto ou serviço disponibilizado, devendo ser implementadas medidas técnicas e organizacionais pelas empresas e organizações. Há de se obter a garantia de que os dados pessoais serão processados com a mais alta proteção da privacidade do titular (por exemplo, apenas os dados necessários devem ser tratados, o período de armazenamento deve ser curto e o acesso aos dados deve ser limitado), de forma que os dados sejam automaticamente (como padrão) protegidos em qualquer sistema de TI ou prática de negócios. A privacidade se torna componente essencial da funcionalidade principal do que está sendo entregue. Atua-se, assim, no sentido de incorporar fortes medidas de segurança ao ciclo dos dados para se garantir o gerenciamento seguro das informações do começo ao fim. Seja qual for a prática ou tecnologia envolvida, ela deverá colocar em primeiro lugar os interesses dos titulares dos dados e operar de acordo com as promessas e objetivos declarados, estando sujeita inclusive a uma verificação independente.¹⁶

Na lei brasileira de proteção de dados, parte-se da ideia de que todo dado pessoal tem relevância e valor. Por essa razão se adotou conceito amplo de dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável¹⁷. Dados que pareçam não relevantes em determinado momento ou que não façam referência a alguém diretamente, uma vez transferidos, cruzados e/ou organizados, podem resultar em dados bastante específicos sobre determinada pessoa, trazendo informações inclusive de caráter sensível sobre ela. Diante do cuidado com o tema, foi estabelecido como regra geral (art. 1º) que qualquer pessoa que trate dados, seja ela natural ou jurídica, de direito público ou privado, inclusive na atividade realizada nos meios digitais, deverá ter uma base legal para fundamentar sua atividade.

O estabelecimento de um amplo rol de princípios na LGPD e a referência à boa-fé objetiva revelam a preocupação do legislador com as atividades de tratamento de dados pessoais. Vive-se em ambiente marcado por elevada assimetria informacional: uma parte, geralmente grandes empresas e Estados, detém mais poder, recursos e melhores informações do que o cidadão comum, por vezes consumidor nas relações desenvolvidas. Esse cenário enseja diversos questionamentos acerca, por exemplo, da validade do consentimento do titular dos dados nos contratos celebrados, principalmente quando eles são de adesão. A assimetria informacional não se revela apenas no poder que o agente dispõe sobre os dados pessoais de terceiros, mas também nas novas modalidades de

negócio, em que informações pessoais de seus usuários representam uma das bases centrais do sistema desenvolvido.¹⁸

A posição de destaque que o tratamento de dados pessoais pode ter nos produtos e serviços oferecidos ao público por empresas de tecnologia – as quais, por vezes, não exigem uma remuneração direta dos usuários, mas o preenchimento de cadastro, a criação de perfil e/ou o acesso aos contatos e mensagens trocadas¹⁹ – revela a importância fundamental dos dados na criação, desenvolvimento e manutenção do próprio modelo de negócio. Tendo-se como exemplo as mídias sociais, sua estrutura revela a necessidade da constante inserção de dados pessoais por parte de seus usuários. É essencial ao negócio a existência de uma massa substancial de usuários, os quais são estimulados a inserir de forma ininterrupta diversas informações sobre si e terceiros. Posteriormente, parte-se para a exploração e monetização dos dados inseridos no sistema, por meio, por exemplo, da venda de espaços para publicidade e anúncios, do desenvolvimento de perfis para o direcionamento de produtos e informações e da possibilidade de acesso aos dados de seus usuários por parte de parceiros comerciais.

A evolução funcional dos bens jurídicos, no cenário desenhado pelas tecnologias, nem sempre é bem compreendida pela *praxis*, sendo indispensável separar as lógicas da propriedade e das relações existenciais, cujos conflitos de interesse exigem ponderação entre valores não patrimoniais. Dessa forma, critica-se a compreensão da privacidade como espaço de poder (“proprietário”) do indivíduo, que se encastela em seu território intransponível contra ingerências externas, por transportar a lógica proprietária para a solução de questões atinentes às relações existenciais. O direito à proteção de dados tem a ver com a tutela da personalidade e não da propriedade,²⁰ de forma que certas categorias de dados, especialmente os de natureza médica e genética, não deverão ser utilizados para fins meramente negociais.²¹

Para superar a constrangedora incompatibilidade funcional daí decorrente, mostra-se útil a invocação do que se tem designado como *razoável expectativa de privacidade*, a ser construída caso a caso, como meio de proteção da pessoa humana e incentivo à lealdade recíproca e mútua confiança nas relações. Todavia, a adoção do critério da legítima expectativa somente se justifica se a ponderação conseguir se desprender da lógica proprietária que, tradicionalmente, acaba por associar a liberdade existencial à prerrogativa de murar-se contra agressões alheias ou interferências externas. Do contrário, reproduzir-se-iam critérios funcionalmente inaptos ao exame de bens jurídicos próprios de relações existenciais.

A defesa da privacidade deve também integrar os controles individuais e coletivos de proteção aos direitos fundamentais. Quando se controla o tratamento de dados, não se resguarda apenas o indivíduo cujos dados estão relacionados, mas também o grupo social do qual ele faz parte, interesses coletivos e as futuras gerações. Nesse sentido, entende-se que também às coletividades devem ser garantidos meios jurídicos, técnicos e sociais que aumentem seu poder e controle sobre os dados.²²

O impacto da LGPD será efetivo nos mais diversos setores da sociedade, trazendo direitos aos titulares e deveres e responsabilidades aos agentes de tratamento. Todos os sujeitos terão que se adaptar a uma nova cultura de tutela dos dados pessoais, cabendo à doutrina, ao Judiciário e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados²³ harmonizarem a interpretação e aplicação da Lei.

2. O consentimento do titular dos dados

A base legal do consentimento para o tratamento de dados do titular representa instrumento de autodeterminação e livre construção da esfera privada. Permite diferentes escolhas e configurações em ferramentas tecnológicas, o que pode ter reflexos diretos na personalidade do indivíduo. Ainda que represente figura de grande relevância nas leis de dados, o consentimento não é a única hipótese para o tratamento de dados pessoais nem é hierarquicamente superior às demais bases legais dispostas na Lei 13.709/18.

Uma análise minuciosa dos princípios da LGPD – que têm grande parte de seu centro gravitacional baseado na tutela integral do ser humano – revela a preocupação da norma com a participação do indivíduo no fluxo de suas informações pessoais.²⁴ Verifica-se no texto legal uma cuidadosa caracterização do consentimento, seguindo a linha do GDPR e das normas mais atuais sobre o tema, além de uma série de disposições que oferecem regramento específico para concretizar, orientar e reforçar o controle dos dados através do consentimento.^{25 - 26}

No que diz respeito ao tratamento dos dados, ele deverá ocorrer, como regra, de acordo com as hipóteses estabelecidas no artigo 7º da LGPD, sendo certo que no caso de dados sensíveis e de dados de crianças e adolescentes foram positivadas normas mais rígidas, conforme se verá mais adiante. Como restou estabelecido, mesmo nos casos de dispensa da exigência do consentimento, os agentes de tratamento continuarão obrigados com as demais disposições previstas na lei, especialmente com os princípios gerais e os direitos do titular. Ou seja, as proteções conferidas ao titular permanecem e são de observância obrigatória.

O maior cuidado com o consentimento do titular mostra-se de grande relevância no cenário tecnológico atual, no qual se verifica a coleta em massa de dados pessoais, a mercantilização desses bens por parte de uma série de sujeitos e situações de pouca transparência e informação no que tange ao tratamento de dados pessoais de usuários de serviços online. Nesse sentido, defende-se que a interpretação do consentimento deverá ser realizada de forma cuidadosa, não podendo o agente estender a autorização concedida para o tratamento dos dados para

outros meios além daqueles pactuados, para momento posterior, para fim ou contexto diverso ou, ainda, para pessoas distintas daquelas informadas aos titular.²⁷

O consentimento representa instrumento de manifestação individual no campo dos direitos da personalidade e tem o papel de legitimar que terceiros utilizem, em alguma medida, os dados de seu titular.²⁸ Ele compreende a liberdade de escolha, sendo meio para a construção e delimitação da esfera privada. Associa-se, portanto, à autodeterminação existencial e informacional do ser humano, mostrando-se imprescindível para a proteção do indivíduo e a circulação de informações.²⁹ Nessa direção, entende-se inadequada a caracterização de natureza negocial para o consentimento, visto que tal entendimento reforçaria o sinalagma entre o consentimento para o tratamento dos dados pessoais e determinada vantagem econômica obtida por aquele que consente – a reforçar indesejada índole contratual e de fomento à utilização de esquemas proprietários para o trato dos dados pessoais.³⁰

Segundo a LGPD, o consentimento é caracterizado como “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”.

Livre no sentido de o titular poder escolher entre aceitar ou recusar a utilização de seu dado, sem intervenções ou situações que viciem o seu consentimento. Nessa linha, estabeleceu-se de forma expressa a vedação ao tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. A respeito dessa característica, mostra-se relevante que se analise a assimetria entre as partes e a eventual vulnerabilidade de algum contratante, para se garantir que o consentimento realmente se deu de forma livre, informada e inequívoca. Como observado em doutrina, “deve-se verificar qual é o ‘poder de barganha’ do cidadão com relação ao tratamento de seus dados pessoais, o que implica considerar quais são as opções do titular com relação ao tipo de dado coletado até os seus possíveis usos.”³¹

No sentido de fortalecer o indivíduo, a lei também estabelece que, se o tratamento dos dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer seus direitos enumerados no art. 18 da Lei. Regula-se, assim, a lógica binária das chamadas políticas de “tudo ou nada”³², em que o usuário ou aceita todas as disposições e termos do serviço ou não pode utilizá-lo.³³ Dessa forma, visa-se oxigenar processos de tomada de decisão, além de incentivar configurações de privacidade personalizáveis e a possibilidade da manifestação do consentimento de forma granular, podendo o cidadão emitir autorizações fragmentadas no tocante ao fluxo de seus dados: “Abre-se espaço, assim, para que o controle dos dados seja fatiado de acordo com cada uma das funcionalidades que são ofertadas e se deseja ter e que demandam, respectivamente, tipos diferentes de dados.”³⁴

Na linguagem legislativa, o vocábulo *informado* significa que o titular do bem tem de ter ao seu dispor as informações necessárias e suficientes para avaliar corretamente a situação e a forma como seus dados serão tratados. A informação é fator determinante para a expressão de um consentimento livre e consciente, circunscrito, portanto, a certo tratamento, para determinado agente e sob determinadas condições. Para diminuir a assimetria técnica e informacional existente entre as partes, exige a lei que ao cidadão sejam fornecidas informações transparentes, adequadas, claras e em quantidade satisfatória acerca dos riscos e implicações do tratamento de seus dados.

Na lógica do consentimento informado, o artigo 9º da LGPD dispõe que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca da: finalidade específica do tratamento (I); forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial (II)³⁵; identificação do controlador (III); informações de contato do controlador (IV); informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade (V); responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento (VI); e direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 (VII).³⁶

Na hipótese em que o consentimento é requerido, ele será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência e de forma clara e inequívoca. Quando o consentimento for necessário, havendo mudanças em relação à finalidade para o tratamento dos dados não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo este revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

A manifestação de vontade deve ser também *inequívoca*, ou seja, não ambígua, evidente e ocorrer de forma clara. A validade do consentimento relaciona-se também com o princípio da finalidade, que dispõe que a realização do tratamento de dados deverá se dar para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

A manifestação deverá referir-se a finalidades determinadas, de modo que autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Observa-se que a informação é fator determinante para a expressão do consentimento livre e consciente, de forma que se deve destacar a importância do princípio da finalidade para restringir a generalidade na utilização do bem: o consentimento, como já registrado, valerá para certo tratamento, para determinado agente e sob determinadas condições.

A *finalidade da coleta* dos dados deve ser previamente conhecida. O princípio em questão diz respeito à relação entre os dados colhidos e a finalidade perseguida pelo agente, apresenta relação também com a finalidade da coleta e a utilização dos dados (princípio da utilização não abusiva) e com a recomendação de eliminação ou

transformação em dados anônimos das informações que não sejam mais necessárias.³⁷ Defende-se também que, a depender do tipo de informação, seria possível desmembrar o consentimento em algumas categorias, com requisitos menos ou mais rígidos, conforme a natureza dos interesses.

O consentimento do titular apresenta-se na LGPD como a primeira possibilidade para a realização do tratamento de dados pessoais (art. 7º, I), sendo que ele, nesse caso, deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular (art. 8º). A lei não exige, portanto, o consentimento escrito, mas, caso assim ele seja colhido, deverá constar em cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Vale lembrar, porém, que, embora não precise necessariamente estar consubstanciado em declaração escrita, o consentimento não poderá ser extraído da omissão do titular, mas tão somente de atos que revelem claramente sua real vontade.³⁸ Outro cuidado expresso na norma é a disposição que estabelece que caberá ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na Lei, conforme orienta o princípio da responsabilização e prestação de contas (Art. 6º, X).

Quanto à eficácia subjetiva, o consentimento está vinculado ao controlador para o qual foi dado. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do art. 7º, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas na Lei. A partir dessa disposição, afirma-se que existiria dever que não se restringiria apenas ao controlador originário, devendo ser observado por todos aqueles que tenham acesso aos dados, dos quais se exigiria o dever de verificar a licitude do procedimento de acesso ou compartilhamento, inclusive no que tange ao consentimento específico do titular.³⁹

Outra disposição relevante afirma que o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. Logo, o consentimento será temporário. Defende-se a possibilidade de revogação incondicional desse tipo de consentimento com base na autodeterminação em relação à construção da esfera privada e na proteção da personalidade, entre cujos atributos se encontra a indisponibilidade. Entretanto, não parece razoável que quem recebeu a autorização para o tratamento dos dados tenha que sofrer risco ilimitado nem que a revogação se dê em flagrante prejuízo ao interesse público. Em caso de abuso do titular do bem, caberá a devida reparação, que será analisada no caso concreto, podendo o intérprete guiar-se por mecanismos como o *venire contra factum proprium* ⁴⁰. Dessa forma, dentro das hipóteses relativas ao término do tratamento dos dados, encontra-se a comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no § 5º do art. 8º da LGPD⁴¹, resguardado o interesse público (art. 15, III).

Quanto aos direitos do titular, no que tange ao consentimento, ele tem direito a obter do controlador, em relação aos seus dados por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: a eliminação dos dados pessoais tratados com seu consentimento, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei. Garante-se também o direito à oposição: o titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD. Além disso, quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos da regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento (Art. 19, § 3º).

Dispensa o legislador a exigência do consentimento previsto no *caput* do artigo 7º para os dados “tornados manifestamente públicos pelo titular”, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos na norma. Assim como na hipótese dos dados de acesso público⁴², aqui, deve ser considerado o contexto em que a informação foi disponibilizada, bem como haver compatibilidade entre o seu uso e as circunstâncias pelas quais tal informação foi tornada pública, tendo em vista a ressalva disposta na lei, que não autoriza o uso indiscriminado desses dados. Esses tipos de dados, ainda que sejam considerados públicos, não deixam de ser pessoais, sendo necessário considerar sempre a finalidade da circulação e o que justifica sua disponibilização.^{43 - 44 - 45}

Vale lembrar que a definição positivada na LGPD para consentimento inspira-se na europeia, pois no GDPR se entendeu por consentimento a “manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento”^{46- 47}. O artigo 7º do diploma europeu, ao tratar das condições aplicáveis ao consentimento, afirma que, quando o tratamento for realizado com base no consentimento, o responsável pelo tratamento deverá poder demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento para o tratamento. Se o consentimento do titular for manifestado no contexto de declaração escrita que diga também respeito a outros assuntos, o pedido de consentimento deverá ser apresentado de forma a distingui-lo claramente das outras matérias, sendo inteligível, de fácil acesso e em linguagem clara e simples. Quanto à revogação, o titular dos dados tem direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não comprometerá a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. Antes de dar o seu consentimento, o titular dos dados será informado desse fato. De acordo com o Regulamento europeu, o consentimento deverá ser tão fácil de retirar quanto de dar. Foi estabelecido também que, quando se avaliar se o consentimento foi dado livremente, deverá ser verificado com a máxima atenção se a execução do contrato ou a prestação do serviço

encontra-se subordinada ao consentimento para o tratamento de dados pessoais não necessários para a execução desse contrato.

Dessa forma, no âmbito do GDPR, o consentimento do titular dos dados deverá ser dado mediante ato positivo claro que indique manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o titular dos dados consente com o tratamento dos mesmos, como, por exemplo, mediante declaração escrita, inclusive em formato eletrônico, ou declaração oral. Segundo o Considerando 32 do Regulamento, o consentimento pode ser manifestado mediante a validação de opção ao visitar site na Internet, selecionando os parâmetros técnicos para os serviços da sociedade da informação, ou através de outra declaração ou conduta que indique claramente que o titular aceita o tratamento proposto para seus dados pessoais. O silêncio, opções pré-validadas ou a omissão não configuram consentimento.

Dispõe o Regulamento europeu também que sempre que o tratamento for realizado com base no consentimento do titular dos dados, o responsável pelo tratamento deverá poder demonstrar que o titular deu o seu consentimento à operação. Em especial, no contexto de uma declaração escrita relativa a outra matéria, deverão existir as devidas garantias de que o titular dos dados se encontra plenamente ciente do consentimento dado e do seu alcance. Para que o consentimento seja dado com conhecimento de causa, o titular dos dados deverá ser informado, pelo menos, da identidade do responsável pelo tratamento e das finalidades a que o tratamento se destina. Não será considerado que o consentimento foi dado de livre vontade se o titular dos dados não dispuser de escolha verdadeira e livre ou se não lhe for assegurada a possibilidade de retirar ou recusar o consentimento sem sofrer prejuízo.

O considerando 43 do GDPR afirma que, a fim de se assegurar que o consentimento seja dado de livre vontade, ele não deverá constituir fundamento jurídico válido para o tratamento de dados pessoais em casos específicos em que exista desequilíbrio manifesto entre o titular dos dados e o responsável pelo seu tratamento, como, por exemplo, quando o responsável pelo tratamento for uma autoridade pública pelo que é improvável que o consentimento tenha sido dado de livre vontade em todas as circunstâncias associadas à situação específica em causa. De acordo com a norma, presume-se que o consentimento não foi dado de livre vontade se não for possível dar consentimento separadamente para diferentes operações.

Traçadas essas considerações sobre o regime geral do consentimento na LGPD, passa-se para o estudo do consentimento nas relações atinentes ao tratamento de dados pessoais sensíveis e de crianças e adolescentes.

3. Tratamento de dados pessoais sensíveis: requisição de consentimento específico e destacado

Os dados sensíveis representam categoria especial de dado pessoal. Eles estão presentes em todos os conjuntos informacionais da pessoa humana e se relacionam com sua intimidade e segredo. Na LGPD, entendeu o legislador que a melhor forma de proteger tal categoria seria trazendo exemplos claros de dados assim considerados.⁴⁸ Dados sensíveis versam, portanto, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. São também sensíveis aqueles referentes à saúde⁴⁹ ou à vida sexual e dados genéticos⁵⁰ ou biométricos.

Encontra-se nos dados sensíveis o “núcleo duro” da privacidade, tendo em vista que, pelo tipo e natureza de informação que trazem, apresentam dados cujo tratamento pode ensejar a discriminação ilícita ou abusiva de seu titular, devendo, por conseguinte, ser protegidos de forma mais rígida e específica.⁵¹ São dados especialmente sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, cujo uso pode gerar riscos significativos para seu titular.⁵²

Dispõe a LGPD que o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: “I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.”⁵³

A primeira possibilidade, portanto, para o tratamento, prevista no art. 11, inciso I, subordina-se ao consentimento do titular ou seu responsável legal, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.⁵⁴ Oferece-se na lei uma camada adicional de proteção para que tais dados não sejam utilizados contra os titulares, trazendo-lhes restrições ao acesso a bens e serviços ou mesmo ao exercício de direitos.⁵⁵ Aqui, um dos desafios é compreender a dimensão e o real significado do consentimento caracterizado como específico e destacado. De acordo com Bioni, deve-se “enxergá-lo como um vetor para que haja mais *assertividade* do titular com relação a esses movimentos “específicos” de seus dados.”⁵⁶ A noção, no caso, aproxima-se da ideia de consentimento expresso⁵⁷, por exigir maior atuação do titular dos dados, além de cuidado mais elevado com o tratamento da informação pelo agente.⁵⁸

Parte da doutrina encontra, no Art. 11, inciso I, a existência de certa preferência à hipótese legal do consentimento, em razão da técnica legislativa utilizada, qual seja, a inserção de dois incisos no art. 11, sendo o primeiro sobre o consentimento e o segundo dispondo que, sem o fornecimento de consentimento do titular, poderá ocorrer o tratamento de dados sensíveis (apenas) nas hipóteses em que for indispensável para as sete situações ali estabelecidas nas alíneas. Todavia, parece mais adequado compreender que tanto na hipótese de tratamento de dados sensíveis por meio do consentimento quanto nos casos que se referem às demais situações que independem de tal manifestação de autonomia, a técnica legislativa utilizada coloca todas as bases legais em posição de igualdade, não havendo prevalência ao consentimento.⁵⁹

Vale lembrar que será aplicada a proteção disposta no artigo 11 a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados sensíveis e que possa causar danos ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Mesmo os dados que, aprioristicamente, não sejam sensíveis podem assim se tornar quando, em determinado contexto fático, levarem a informações sensíveis a respeito dos titulares.^{60 - 61}

Segundo a LGPD, a comunicação ou o uso compartilhado de dados sensíveis entre controladores, com objetivo de obter vantagem econômica, poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da Autoridade Nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.⁶²

Sem esgotar o tema dos dados sensíveis e de seu tratamento, encerra-se essa seção acerca do consentimento ressaltando que tal categoria necessita mais do que nunca de uma tutela diferenciada e especial, de forma a se evitar que informações dessa natureza sejam vazadas, usadas indevidamente, comercializadas ou sirvam para embasar preconceitos e discriminações ilícitas ou abusivas em relação ao titular.

Conforme observado em doutrina, a mera proibição do tratamento de dados sensíveis demonstra-se inviável, pois, em alguns momentos, o uso de tais dados será legítimo e necessário, além do que existem determinados organismos cuja própria razão de ser estaria comprometida caso não pudessem obter informações desse gênero, como, por exemplo, algumas entidades de caráter político, religioso ou filosófico. Dessa forma, entende-se que o tratamento de dados sensíveis é possível e, inclusive, necessário em determinadas circunstâncias. Contudo, deverá ser considerado excepcional, pela relevância dos valores em questão, e autorizado quando não houver possibilidade de utilização discriminatória das informações coletadas.⁶³

4. Dados pessoais de crianças e adolescentes: considerações sobre a norma relativa ao consentimento

A Lei de proteção de dados brasileira, em seu artigo 14, dispõe de forma específica acerca do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Conforme estabelecido, o tratamento deverá ser realizado no melhor interesse desses sujeitos, levando-se em conta especialmente as normas protetivas estabelecidas na Constituição Federal⁶⁴, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança.⁶⁵ Busca-se, assim, assegurar seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade,⁶⁶ reconhecendo a criança e o adolescente não como meras partes integrantes do complexo familiar, mas como protagonistas da dinâmica familiar.⁶⁷

Em relação às crianças⁶⁸ (pessoas até doze anos de idade incompletos), afirma-se que, quando a base legal for o consentimento, o tratamento dos dados desses sujeitos deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por, pelo menos, um dos pais ou pelo responsável legal (§ 1º), devendo esse consentimento ser também livre, informado e direcionado a um tratamento de dados para finalidade determinada.⁶⁹ Dessa forma, o consentimento dado por sujeito fora do requisito legal ou pela própria criança não poderá ser admitido. Sobre a legitimidade da mencionada disposição legal não restam dúvidas, visto que se trata de criança, sujeito hipervulnerável (ou de vulnerabilidade agravada pela idade reduzida⁷⁰) e absolutamente incapaz, o qual deve ser representado sob pena de nulidade absoluta do ato praticado.⁷¹

Todavia, ao não mencionar o adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos de idade incompletos), o § 1º do art. 14 não deixou claro se o consentimento manifestado diretamente por ele e sem assistência ou representação deveria ser considerado plenamente válido, como hipótese de capacidade especial, ou se simplesmente o legislador teria optado por não tratar do tema, por já existir legislação geral sobre a matéria no Código Civil. Ao que parece, o legislador pretendeu reconhecer a validade do consentimento manifestado pelo adolescente. Tomando como base a realidade da utilização da Internet e das mídias sociais, que têm entre seus usuários legiões de adolescentes, é possível que tenha optado por considerar jurídica hipótese fática dotada de ampla aceitação social.

A Internet oferece enormes possibilidades e benefícios para as crianças e adolescentes, facilitando a participação delas em discussões e atividades criativas e o acesso à informação e educação de qualidade. O acesso à Internet nos últimos anos vem se afirmando como direito fundamental, por proporcionar melhor qualidade de vida e promover o desenvolvimento da pessoa. Diante disso, mostra-se necessário estabelecer políticas e normas equilibradas que, de um lado, protejam os menores de riscos e danos a sua integridade e liberdade (como conteúdos nocivos que estimulem violência e automutilação, o vazamento de imagens íntimas e o aliciamento sexual) e, de outro, facilitem o acesso desses sujeitos à rede, de forma segura, responsável e ética.

Segundo pesquisa, em 2018, 86% da população entre 9 e 17 anos era usuária de Internet no país.⁷² No mesmo ano, 83% da população investigada reportou ter assistido a vídeos, programas, filmes ou séries *on-line*. Pela

primeira vez no estudo, essas atividades passaram a ser as mais frequentes entre as crianças e os adolescentes usuários de Internet no Brasil, superando pesquisas na Internet para trabalhos escolares (74%) e o envio de mensagens instantâneas (77%). Ainda considerando atividades multimídia, a pesquisa estima que 82% das crianças e adolescentes usuários de Internet escutaram música *on-line*, 60% jogaram na Internet sem conexão com outros jogadores e 55% jogaram conectados com outros jogadores. O celular segue sendo o principal dispositivo utilizado por crianças e adolescentes. Em 2018 também, cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes (de 9 a 17 anos usuários de Internet) possuíam perfil em redes sociais, o que equivalia a 82% dos usuários nessa faixa etária. O aplicativo WhatsApp foi a plataforma em que crianças e adolescentes reportaram possuir um perfil em maiores proporções (72%), superando o Facebook (66%). Já o Instagram apresentou o maior crescimento em relação ao número de crianças e adolescentes que possuem perfil na plataforma (saltando de 36%, em 2016, para 45%, em 2018).

Com base nessas informações, é possível afirmar que a preocupação não deve se limitar apenas aos dados coletados pelo provedor de aplicações de internet para o acesso e uso da rede social, mas também se destinar àqueles dados inseridos e divulgados diretamente por crianças e adolescentes⁷³, que muitas vezes não conhecem com profundidade as políticas das plataformas, seus direitos relacionados ao tratamento de seus dados pessoais e os reais riscos à sua privacidade nesses ambientes *on-line*.

Vale lembrar que, como regra, as principais mídias sociais determinam a idade mínima de 13 anos para a abertura de contas e utilização desses canais, exigindo-se idade mais elevada a depender das leis do país onde o serviço será oferecido. Como exemplos, basta recordar os termos de uso do Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter e Snapchat para o Brasil, em que a exigência de idade mínima de 13 anos foi mantida. Essa determinação tem como fundo norma norte-americana que considera criança o indivíduo com menos de 13 anos de idade: o *Children's Online Privacy Protection Act* de 1998 (COPPA).⁷⁴ Observa-se que a LGPD, no ponto relativo à proteção de crianças e adolescentes, além de tomar como fonte a norma europeia (GDPR), inspirou-se em grande medida no COPPA. Todavia, não definiu em detalhes determinadas expressões e conceitos adotados, como o fez o regramento norte-americano.

Quanto à idade mínima para a utilização de redes sociais na Europa, há disposições diversas nos termos de uso de algumas ferramentas. Como alguns países ainda vêm se adequando ao artigo 8º do GDPR, é possível encontrar disposições que afirmam que o usuário deverá ter pelo menos 16 anos para usar o serviço.⁷⁵ O artigo 8º dispõe, em síntese, que, quando for aplicável o artigo 6º, n. 1, "a"⁷⁶, quanto à oferta direta de serviços da sociedade da informação para crianças, o tratamento dos dados pessoais de uma criança será legal quando ela tiver pelo menos 16 anos de idade. Caso a criança tenha menos de 16 anos, o tratamento só será lícito se o consentimento for dado ou autorizado pelos titulares da autoridade parental. Contudo, destaca-se que os Estados-Membros poderão estabelecer idade menor para os efeitos referidos, desde que não inferior a 13 anos.⁷⁷ Nesses casos, o responsável pelo tratamento deverá promover todos os esforços adequados para verificar se o consentimento foi dado ou autorizado pelo titular das responsabilidades parentais da criança, tendo em conta a tecnologia disponível.⁷⁸

Ainda quanto ao art. 14 da LGPD, na hipótese do tratamento do § 1º, os controladores deverão manter públicas as informações sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 da Lei (artigo esse que se encontra no capítulo dos direitos do titular). Isso porque o consentimento, por si só, não afasta a responsabilidade do agente de avaliar todos os riscos do processamento dos dados nem seu dever de observar fielmente as disposições protetivas da LGPD. Além disso, os controladores deverão realizar todos os esforços razoáveis para verificar se o consentimento a que se refere o parágrafo 1º foi manifestado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis (Art. 14, § 5º). Identifica-se, aqui, dever de cuidado atribuído ao controlador. Pondera a doutrina que se, por um lado, o controlador não pode tratar dados antes do consentimento, por outro, precisará de tais dados para contatar o responsável legal pela criança. Afirma-se que os controladores deverão estar atentos e passar a exigir a data de nascimento do usuário e até mesmo outras informações adicionais pertinentes, a fim de apurar sua verdadeira idade, para, se for o caso, suspender o tratamento de seus dados até a obtenção do consentimento do responsável.⁷⁹

Assim como no GDPR, em seu art. 8º, a questão do consentimento do responsável pela criança na LGPD levanta muitas questões sobre sua implementação. Por exemplo, como as empresas verificarão se a pessoa que forneceu o consentimento é realmente um dos responsáveis? Não está claro na lei em que se constituirá o "esforço razoável" por parte do controlador e quem avaliará a tecnologia implementada e o esforço desempenhado por ele. Certamente, algumas empresas, pelo porte e poderio econômico, estarão em posição muito melhor para investir nas medidas necessárias do que outras. Outros desafios a se cogitar são as chances de as medidas de implementação ocasionarem maior processamento de dados pessoais, em contrariedade ao princípio da minimização dos dados; além do risco de que crianças desenvolvam estratégias para contornarem a regra relativa ao consentimento parental. Do ponto de vista educacional, questiona-se ainda qual seria a extensão dos espaços de liberdade na Internet a serem assegurados às crianças sem a interferência de seus pais.

O § 4º do artigo 14 da LGPD prevê que os controladores não deverão condicionar a participação de crianças em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade, mostrando-se assim refratário à requisição excessiva de dados de crianças em serviços de divertimento e entretenimento. O dispositivo prestigia o princípio da minimização dos dados, segundo o qual os dados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao que for necessário relativamente às finalidades para as quais serão tratados. Se houver desrespeito a tal previsão, o tratamento dos dados será considerado abusivo,

mesmo tendo havido o consentimento do responsável pela criança.⁸⁰ Por meio dessa disposição, busca-se afastar políticas de tudo ou nada, já comentadas anteriormente nesse artigo, em que o usuário ou aceita todas as disposições e termos do serviço ou não pode utilizá-lo.

Dispõe também a norma que as informações sobre o tratamento de dados referidas no artigo 14 deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível,⁸¹ consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Portanto, as ações direcionadas ao cumprimento dos deveres de informação e de transparência precisarão se adequar inclusive à capacidade de compreensão das crianças e adolescentes, sujeitos tutelados pela doutrina da proteção integral e que apresentam condição peculiar, por se encontrarem em desenvolvimento.

Entende-se que a previsão do artigo 14 deverá ser aplicada especialmente nos casos de produtos e serviços direcionados ou diretamente ofertados a crianças e adolescentes, hipóteses em que quaisquer informações transmitidas para os menores deverão estar em linguagem clara, simples e condizente com a idade do público esperado, devendo-se sempre incentivar o uso de produtos e serviços de forma monitorada e/ou orientada pelos responsáveis do menor. Essa disposição encontra-se em linha com práticas educacionais e com uma perspectiva de reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direito e protagonista de seus direitos.

Observa-se que a norma citada deve ser lida juntamente com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente seus artigos 70 e 71, segundo os quais é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente, sujeitos esses que têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões e produtos e serviços que respeitem suas condições peculiares de pessoas em desenvolvimento.

Há também menção na LGPD a hipóteses de tratamento de dados de menores sem necessidade de consentimento. Como afirmado na primeira parte do texto, o consentimento é uma das bases legais para o tratamento de dados, mas não a única. No caso em tela, que envolve menores de idade, não foi estabelecida norma com rol específico para o tratamento dos dados desses sujeitos, devendo ser aplicadas, como regra, as disposições dos artigos 7º e 11.⁸² Como complemento às hipóteses de autorização legal para o tratamento de dados, afirma-se no § 3º do artigo 14 que poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º do mencionado artigo quando: a) a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, devendo os dados ser utilizados uma única vez e sem armazenamento; ou b) para a proteção da criança. Porém, em nenhum caso, esses dados poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º.

Como visto, a disposição relativa ao tratamento de dados de crianças e adolescentes mostra-se significativa e bastante relevante, exigindo-se interpretação que priorize o melhor interesse desses sujeitos e a constante incorporação à norma infraconstitucional dos valores e princípios constitucionais.

Considerações finais

O desenvolvimento das relações humanas torna inafastável o fornecimento de informações e dados pessoais no ambiente físico e digital. Nessa direção, a Lei Geral de Proteção de Dados, ao disciplinar o uso e a integridade dos dados de cada pessoa, sobretudo aqueles considerados sensíveis, protege e garante o princípio da dignidade da pessoa humana e seus corolários. Ao trazer tutela focada na pessoa e no livre desenvolvimento de sua personalidade, a LGPD assegura o exercício da liberdade existencial e a igualdade material, diante do papel relevante da informação para as escolhas individuais e o estabelecimento de vínculos na sociedade.

Em cenário de elevada circulação de informações, na Lei foram previstas ferramentas específicas de controle em favor do titular. Entre elas, é possível mencionar o consentimento, caracterizado como livre, informado, inequívoco e direcionado a uma finalidade determinada, da mesma forma como tratado no Regulamento europeu. O cuidado e a centralidade oferecidos à figura do consentimento, objeto desse artigo, revelam a preocupação do legislador com a participação do indivíduo no fluxo de suas informações pessoais, incentivando um comportamento ativo da parte do titular e responsável por parte do agente que realizar o tratamento dos dados.

O Regulamento europeu de proteção de dados pessoais funciona como modelo de referência que países como o Brasil deverão levar em conta tanto na interpretação e aplicação de suas leis nacionais quanto na própria elaboração de legislação acerca da temática, em cotejo com o almejado fluxo de informações e convergências derivadas de diplomas em nível internacional. Especialmente no ambiente tecnológico, torna-se elementar o desenvolvimento de normas que apresentem entendimentos mais uniformes, para facilitar a inserção e a regulação de novos sistemas, dispositivos e negócios. Além disso, padrões elevados para a proteção de dados pessoais aumentam a compatibilidade entre sistemas jurídicos, possibilitando melhor fluxo de informações, mais segurança nas transações e relações cada vez mais complexas.

A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira anuncia-se, nessa direção, como passo indispensável no caminho da proteção efetiva e do pleno exercício da autodeterminação existencial e informacional da pessoa humana. Cuida-se de ferramenta que se propõe, em boa hora, à proteção do indivíduo e ao controle específico da circulação de informações, trazendo a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento de renovada cultura de tutela de dados pessoais.

Referências

- BARBOZA, Heloisa Helena. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. *Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família: a família na travessia do milênio*. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
- BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- BORGESIU, Frederik J. Zuiderveen; KRUIKEMEIER, Sanne; BOERMAN, Sophie C.; HELBERGER, Natali. Tracking Walls, Take-It-Or-Leave-It Choices, the GDPR, and the ePrivacy Regulation. *European Data Protection Law Review*, 2017. Disponível em: [www.ivir.nl/publicaties/download/EDPL_2017_03.pdf]. Acesso em: 28.12.2018.
- COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- DONEDA, Danilo. *A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia*. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Brasília: SDE/DPDC, 2010.
- FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. *Jota*, 12 de setembro de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-a-importancia-do-consentimento-para-o-tratamento-dos-dados-pessoais-12092018]. Acesso em: 02.02.2019.
- FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. Os gigantes da internet e a apropriação e exploração de dados pessoais: direitos fundamentais e direito ao esquecimento digital. In: VERONESE, Alexandre et al. (Org.). *A efetividade do direito em face do poder dos gigantes da internet: diálogos acadêmicos entre o Brasil e a França*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. v. 1.
- FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: o tratamento dos dados pessoais sensíveis. *Jota*, 26 de setembro de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018]. Acesso em: 04.02.2019.
- FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: tratamento dos dados de crianças e adolescentes. *Jota*, publicado em 03 de outubro de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-tratamento-dos-dados-de-criancas-e-adolescentes-03102018]. Acesso em: 28.12.2018.
- LEAL, Livia Teixeira. Internet of toys: os brinquedos conectados à internet e o direito da criança e do adolescente. *RBDCivil*, v. 12, n. 2, p. 175-187, 2017.
- MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro: o caso do direito à privacidade. *RBDCivil*, v. 8, p. 47-80, abr.-jun. 2016. Disponível em: [https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/64/58]. Acesso em: 04.03.2019.
- MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MONTEIRO, Renato Leite. Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil: análise contextual detalhada. *Jota*, 14 de julho de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-dados/lgpd-analise-detalhada-14072018]. Acesso em: 28.12.2018.
- MULHOLLAND, Caitlin. Dados pessoais sensíveis e consentimento na Lei geral de proteção de dados pessoais. *REVISTA DO ADVOGADO*, n. 144, nov. 2019, p. 47-53.
- RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância – a privacidade hoje*. Coord. Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- SCHREIBER, Anderson. *A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil: análise a partir do Marco Civil da Internet. *Pensar*, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 108-146, jan.-abr. 2017.
- TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; SOUZA, Carlos Affonso. Infância conectada: direitos e educação digital. *Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC kids online Brasil 2017*. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2018. p. 31-40. Disponível em: [www.academia.edu/37830442/INF%C3%82NCIA_CONECTADA_DIREITOS_E_EDUCA%C3%87%C3%83O_DIGITAL]. Acesso em: 28.12.2018.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; VIOLA, Mario. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 9, n. 1, 2020. Disponível em: <<http://civilistica.com/tratamento-de-dados-pessoais-na-lgpd/>>. Data de acesso: 13.05.20.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Proteção de dados de crianças e adolescentes. *Revista do advogado*, v. 39, p. 1-225, 2019.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. A saúde na sociedade da vigilância: como proteger os dados sensíveis? *Migalhas*, publicado em 14 de abril de 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-vulnerabilidade/324485/a-saude-na-sociedade-da-vigilancia-como-protetor-os-dados-sensiveis>> Acesso em: 21.05.20

TEFFÉ, Chiara Spadaccini. Por que precisamos de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados? *Jota*. Publicado em 07 de janeiro de 2020. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/por-que-precisamos-de-uma-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-07012020>> Acesso em: 20.05.20.

TEPEDINO, Gustavo. Desafios na sociedade da tecnologia (Editorial). *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 19, 2004.

TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo; DONEDA, Danilo. A outra face da liberdade. *Revista O Globo*, 15 de junho de 2010. Disponível em: [<https://oglobo.globo.com/in/a-outra-face-da-liberdade-2993811>]. Acesso: 12.02.2019.

TEPEDINO, Gustavo. Computador bisbilhoteiro. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

Manual Normativo: Lei Geral de Proteção de Dados e GDPR. Disponível em: [https://baptistaluz.com.br/institucional/manual-normativo-lei-geral-de-protecao-de-dados-e-gdpr/?fbclid=IwAR0UlsvjzeGTaAC2_iHspgDDaBA1jyGXjFn2N1-cgywGF62kozYKwoRt3U]. Acesso em: 02.02.2019.

Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC kids online Brasil 2018. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019.

1

.Professor Titular de Direito Civil e ex-Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor em Direito Civil pela Universidade de Camerino (Itália) e Livre-Docente pela Faculdade de Direito da UERJ. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil). Advogado, consultor e parecerista em Direito Privado.

2

.Doutoranda e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente, é professora de Direito Civil e Tecnologia no IBMEC. Leciona também em cursos do CEPED-UERJ, na Pós-graduação da PUC-Rio, na EMERJ, no Instituto New Law, no ITS Rio e na Pós-graduação em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil da EBRADI. Membro do conselho executivo da revista eletrônica *civilistica.com*. Coordenadora da Disciplina "Direito e Internet" na Pós-graduação do Instituto New Law. Membro do Fórum permanente de mídia e liberdade de expressão da EMERJ. Associada ao Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil (IBERC). Foi professora substituta de Direito Civil na UFRJ e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio). Advogada e consultora em proteção de dados. E-mail: chiaradettefe@gmail.com.

3

.Recomenda-se a leitura de estudo da IBM, em colaboração com o Instituto Ponemon, intitulado *2019 Cost of a Data Breach Report*. Disponível em: [<https://databreachcalculator.mybluemix.net/executive-summary>]. Acesso em: 20.05.2020. Desde 2017, casos graves de vazamento de dados tanto em empresas do setor privado quanto em instituições públicas vêm sendo noticiados, como, por exemplo: no Google+, C&A, Uber, Sky Brasil, FIESP, Stone Pagamentos, Banco Inter, Buscapé, Netshoes, Marriott, UNIMED, ProAC, Facebook e Twitter. Informações disponíveis em: [www.tecmundo.com.br/seguranca/137353-hackerspectiva-2018-vazamento-dados-ponto-alarmanete.htm]. Acesso em: 02.02.2019.

4

.Acerca da difusão dos dados e de seus reflexos na atividade jurisdicional, já se afirmou em outra sede que o processo de internacionalização das relações econômicas tende a desencadear dificuldades na prestação jurisdicional. Nesse sentido, "Menos atenção, todavia, vem sendo dedicada a aspecto igualmente inquietante, consistente na incapacidade dos órgãos judicantes em decidir questões mais sofisticadas, que extrapolam o saber jurídico ordinário para enveredar em nuances técnicas, as quais dependem não apenas do recurso a matérias atinentes a outras áreas do conhecimento mas pressupõem, ainda, o domínio de ramos especializados do direito interno ou comparado. [...] A observação, ao revés, sublinha simplesmente o fato de que uma realidade sempre mais complexa tem sido levada ao Judiciário, daí decorrendo a necessidade não apenas de esclarecimento isentos quanto aos fatos controvertidos, mas também quanto ao direito aplicável" (TEPEDINO, Gustavo. Desafios na sociedade da tecnologia (Editorial). *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 19, 2004. p. iii).

5

."This Convention is the first binding international instrument which protects the individual against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and which seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. In addition to providing guarantees in relation to the collection and processing of personal data, it outlaws the processing of "sensitive" data on a person's race, politics, health, religion, sexual life, criminal record, etc., in the absence of proper legal safeguards. The Convention also enshrines the individual's right to know that information is stored on him or her and, if necessary, to have it corrected. Restriction on the rights laid down in the Convention are only possible when overriding interests (e.g. State security, defence, etc.) are at stake. The Convention also imposes some restrictions on transborder flows of personal data to States where legal regulation does not provide equivalent protection." Disponível em: [www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108]. Acesso em: 25.12.2018. Recorda-

se que, em maio de 2018, a mencionada Convenção foi modernizada para lidar adequadamente com os desafios resultantes do uso de novas tecnologias de informação e comunicação e fortalecer sua efetiva implementação. Até o dia 03 de janeiro de 2019, 53 países, inclusive países não pertencentes ao continente europeu, haviam ratificado a Convenção. O Brasil não se encontra nesta lista, mas no âmbito da América do Sul há o Uruguai. Informações disponíveis em: [https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf]. Acesso em: 25.12.2018.

6

.MONTEIRO, Renato Leite. Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil: análise contextual detalhada. *Jota*, 14 de julho de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/lgpd-analise-detalhada-14072018]. Acesso em: 28.12.2018.

7

.Para uma análise mais profunda do tema, permita-se remeter a TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 25-62.

8

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Coord. Maria Celina Bodin de Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 92.

9

.RODOTÀ, Stefano. Op. cit., p. 75.

10

“A excessiva liberdade suscitada pelas tecnologias na sociedade contemporânea apresenta faces antagônicas. Em primeiro lugar, avulta o aspecto emancipador da liberdade, traduzido nas extraordinárias possibilidades oferecidas ao usuário dos engenhos eletrônicos e das redes sociais; da cibernética e dos meios de comunicação. A volta ao mundo sem deslocamento físico é usualmente anunciada, assim como corriqueiros *conference calls*, videoconferências, acessos a bibliotecas de todos os continentes a partir de uma única base. O acesso à informação mostra-se o bem mais valioso ao exercício da cidadania. De outra parte, contudo, tem-se a feição hostil dos engenhos eletrônicos, manifestada pela interferência excessiva e reiterada na esfera privada. O controle dos dados pessoais, especialmente aqueles considerados sensíveis, cujo tratamento pode dar azo à discriminação do seu titular, transmuda-se em ameaça real à liberdade individual. A tecnologia expande o alcance da memória humana, registrando o paradeiro, o itinerário, as referências geográficas e biomédicas, a origem e o destino de cada um, bem como as pessoas com quem se estabelece qualquer tipo de relacionamento, as preferências de consumo, as idiosincrasias. Parece decretado o fim do esquecimento e (por conseguinte?) o fim do perdão. Por vezes, o computador resgata assunto ou mensagem que se supunha esquecido, perdido, inexistente. Como Janus, a tecnologia se constitui em espécie de Deusa inquietantemente bifronte” (TEPEDINO, Gustavo. *Liberdades, tecnologia e teoria da interpretação*. *Revista Forense*, v. 419, p. 77-96, 2014).

11

.No dia 25 de maio de 2018, o GDPR entrou em vigor. Apesar de ser uma norma da União Europeia, ela apresenta eficácia e aplicação extraterritorial. Por essa razão, por exemplo, muitas empresas nacionais que têm filiais na Europa ou oferecem serviços a pessoas localizadas no continente tiveram que se adaptar, sob pena de severas sanções ou de perderem contratos. A norma cria também obstáculos para a transferência internacional de dados pessoais para países que não sejam considerados com um nível adequado de proteção.

12

.Na América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai e Guiana Francesa possuem leis gerais para a proteção dos dados dos titulares. Na Argentina, a Lei de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada em 2000 (Lei n. 25.326 de 2000). No Uruguai, a Lei n. 18.331, que trata da proteção de dados pessoais e da ação de *habeas data*, está publicada desde o ano de 2008.

13

.Até agora, a Comissão Europeia reconheceu Andorra, Argentina, Canadá, Ilhas Faroe, Guernsey, Israel, Ilha de Man, Japão, Jersey, Nova Zelândia, Suíça, Uruguai e Estados Unidos da América (limitado ao Privacy Shield Framework) como fornecendo proteção adequada. As negociações de adequação estão em andamento com a Coreia do Sul. Disponível em: [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en]. Acesso em: 20.05.2020.

14

.O caráter preventivo da LGPD é lembrado, por exemplo, nos seguintes dispositivos: art. 6º, II, VI, VII, VIII e X; art. 46, *caput* e § 2º; e art. 47.

15

“Art. 25 GDPR – Data protection by design and by default. 1. Taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons posed by the processing, the controller shall, both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the processing itself, implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects.

2. The controller shall implement appropriate technical and organisational measures for ensuring that, by default, only personal data which are necessary for each specific purpose of the processing are processed. That obligation applies to the amount of personal data collected, the extent of their processing, the period of their storage and their accessibility. In particular, such measures shall ensure that by default personal data are not made accessible without the individual's intervention to an indefinite number of natural persons. 3. An approved certification mechanism pursuant to Article 42 may be used as an element to demonstrate compliance with the requirements set out in paragraphs 1 and 2 of this Article”. Disponível em: [https://gdpr-info.eu/art-25-gdpr/] Acesso em: 02.02.2019.

16

.Disponível em: [www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf]. Acesso em: 27.12.2018.

17

.A disposição brasileira segue o previsto no GDPR: “Artigo 4º Definições. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: ‘Dados pessoais’, informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (‘titular dos dados’); é considerada identificável uma

pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular”.

18

À vista disso, e antes da elaboração da lei em comento, em outra sede já se difundia o caráter essencial de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como nova face da privacidade. Na ocasião, declarou-se que “as relações existenciais, afetivas, comerciais e profissionais cada vez mais se desenvolvem por meios informatizados – para os quais é imprescindível o fornecimento de informações pessoais. Por isso, franquear ao cidadão brasileiro instrumentos de efetivo controle sobre o uso e a integridade de suas informações torna-se mecanismo de garantia da liberdade, tendo em conta o papel predominante da informação para as escolhas individuais” (TEPEDINO, Gustavo; DONEDA, Danilo. A outra face da liberdade. *Revista O Globo*, 15.06.2010. Disponível em: [\[https://oglobo.globo.com/in/a-outra-face-da-liberdade-2993811\]](https://oglobo.globo.com/in/a-outra-face-da-liberdade-2993811). Acesso: 12.02.2019).

19

Entende-se que a relação entre os usuários das redes sociais e o provedor de aplicações de internet responsável por elas não seria marcada pela gratuidade, havendo uma situação de remuneração indireta entre as partes, visto que, apesar de o provedor não receber um valor financeiro diretamente de seus usuários, ele seria remunerado diretamente pela publicidade, que tem como público-alvo os usuários da rede, e, indiretamente, pelos próprios usuários, que disponibilizam seus dados pessoais para a empresa, ao criarem perfis, interagirem com outros usuários e postarem conteúdos. Há, portanto, uma estrutura de remuneração capaz de assegurar facilmente a manutenção dessas redes, sem haver qualquer contraprestação financeira direta e imediata por parte de seus usuários. É de conhecimento público que o marketing direcionado promovido nas redes sociais vai muito além de *banners* e *links* patrocinados e tem como base o próprio conteúdo inserido pelos usuários (TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil: análise a partir do Marco Civil da Internet. *Pensar*, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 108-146, jan.-abr. 2017.) Esse raciocínio foi chancelado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo ‘mediante remuneração’ contido no art. 3º, § 2º, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor” (STJ, 3ª T., REsp 1.193.764, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 08.08.2011).

20

“A proteção de dados pessoais é tema de fundamental importância na sociedade da informação, à medida que cresce o grau de exposição dos indivíduos e sua sujeição a estruturas tecnológicas pertencentes a empresas que não somente guardam, mas exploram comercialmente tais dados. Mostra-se, nesse sentido, nova dimensão do direito fundamental à privacidade, sendo possível ir além para se afirmar que a proteção de dados consiste propriamente em um novo direito fundamental a ser reconhecido. (p. 306) [...] o âmbito de proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais pode ser vislumbrado em uma dimensão subjetiva, na qual o direito se constitui como um direito subjetivo de defesa contra os riscos que ameaçam a personalidade do indivíduo em face da coleta, processamento, utilização e circulação dos dados pessoais; e uma dimensão objetiva, consubstanciada no dever de proteção estatal que decorre da garantia individual de controle dos fluxos de dados” (FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. Os gigantes da internet e a apropriação e exploração de dados pessoais: direitos fundamentais e direito ao esquecimento digital. In: VERONESE, Alexandre et al (Org.). *A efetividade do direito em face do poder dos gigantes da internet: diálogos acadêmicos entre o Brasil e a França*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. v. 1. p. 310).

21

.RODOTÀ, Stefano. Op. cit., p. 19.

22

LGPD, Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. (...) § 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: (...) § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

23

TEFFÉ, Chiara Spadaccini. Por que precisamos de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Jota. Publicado em 07 de janeiro de 2020. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/por-que-precisamos-de-uma-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-07012020>> Acesso em: 20.05.20.

24

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 134.

25

.Por exemplo, no art. 8º, § 1º e 4º, art. 7º, § 6º, e art. 18, § 2º.

26

Cf. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; VIOLA, Mario. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 9, n. 1, 2020. Disponível em: <<http://civilistica.com/tratamento-de-dados-pessoais-na-lgpd/>>. Data de acesso: 13.05.20.

27

.Nessa direção, já se enfatizou, há três décadas, a importância do consentimento ante as diversas antinomias provenientes do binômio “progresso tecnológico-bem-estar”, afirmando-se que: “ao avançar da tecnologia é preciso contrapor novas formas de controles legais preventivos, que tutelam valores existenciais, como é o caso da intimidade. É razoável estabelecer, de já, que o cruzamento de informações pessoais deva ser subordinado à prévia e expressa autorização do interessado” (TEPEDINO, Gustavo. Computador bisbilhoteiro. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 563 – texto publicado originariamente na página de opinião do *Jornal do Brasil*, em 03 de outubro de 1989.

28

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 377. Para o autor, “a fundamentação deste consentimento reside na possibilidade de autodeterminação em relação aos dados pessoais, e que esta autodeterminação deve o elemento principal a ser levado em conta para caracterizarmos tanto a natureza jurídica bem como os efeitos deste consentimento.”

.DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 379.

.DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 379, para o qual “o consentimento para o tratamento de dados pessoais toca diretamente elementos da própria personalidade, porém não dispõe destes elementos. Ele assume mais propriamente as vestes de um ato unilateral, cujo efeito é o de autorizar um determinado tratamento para os dados pessoais, sem estar diretamente vinculado a uma estrutura contratual” (p. 377-378).

.BIONI, Bruno. Op. cit., p. 197.

“On the internet, we encounter many take-it-or-leave-it choices regarding our privacy. Social network sites and email services typically require users to agree to a privacy statement or to terms and conditions – if people do not agree, they cannot use the service. Some websites use a tracking wall, a barrier that visitors can only pass if they agree to tracking by third parties. When confronted with such take-it-or-leave-it choices, many people might click ‘I agree’ to any request. It is debatable whether people have meaningful control over personal information if they have to consent to tracking to be able to use services or websites.” “For instance, chat and email services often require users to agree to a data use policy – if people do not agree, they cannot use the service. An app might require access to the camera or the contact list on an end-user’s phone, while that access is unnecessary for providing the service. A ‘smart’ TV might listen to the sounds in people’s living rooms, and might only work when people ‘consent’ to that. Internet of Things equipment may only work if people ‘consent’ to data collection for marketing.” (BORGESIUS, Frederik J. Zuiderveen; KRUIKEMEIER, Sanne; BOERMAN, Sophie C.; HELBERGER, Natali. Tracking Walls, Take-It-Or-Leave-It Choices, the GDPR, and the ePrivacy Regulation. *European Data Protection Law Review*. 2017. Disponível em: [www.ivir.nl/publicaties/download/EDPL_2017_03.pdf]. Acesso em: 28.12.2018.)

“Pode-se adotar todos os argumentos historicamente adotados para criticar a “liberdade” do consentimento, na presença de contextos nos quais existem condicionamentos tais que excluem uma real possibilidade de escolha. [...] o condicionamento deriva do fato de que a possibilidade de usufruir de determinados serviços, essenciais ou importantes, ou tidos como tais, depende não somente do fornecimento de determinadas informações por parte do usuário do serviço, mas também do fato de que tais informações (eventualmente com base no consentimento do interessado) podem posteriormente ser submetidas a outras elaborações. Este é o caso de todos os serviços obtidos através das novas mídias interativas, cujos gestores, por evidentes razões de ordem econômica, estão prontos a exercer forte pressão sobre os usuários para que estes autorizem a elaboração (e a eventual transmissão a terceiros) de “perfis” pessoais ou familiares baseados nas informações coletadas por ocasião do fornecimento dos serviços.” (RODOTÀ, Stefano. Op. cit., p. 76).

.BIONI, Bruno. Op. cit., p. 197-198.

“O que precisa ser esclarecido, por ora, é que, com exceção daquilo que possa ser considerado como segredo comercial e industrial, todas as demais informações sobre o tratamento de dados devem ser prestadas ao titular, sem o que não restará observado o requisito do consentimento informado.” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. *Jota*, 12 de setembro de 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-a-importancia-do-consentimento-para-o-tratamento-dos-dados-pessoais-12092018]. Acesso em: 02.02.2019).

.Art. 8º, § 6º “Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.”

.RODOTÀ, Stefano. Op. cit., p. 59.

.FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. *Jota*, 12 de setembro de 2018.

.Idem.

.Sobre o tema, v., por todos, SCHREIBER, Anderson. *A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

“Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. [...] § 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.”

.Art. 7º, § 3º “O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.”

.BIONI, Bruno. Op. cit., p. 269-270.

.A doutrina oferece dois exemplos de utilização que esclarecem as possibilidades desses dados: “[...] a princípio, terceiros não poderiam usar dados de uma rede social, mesmo que de perfis públicos, para fins de *marketing*. As circunstâncias pelas quais tais dados foram tornados públicos pelo seu próprio titular deram-se para uma outra finalidade, que é a de se relacionar com quem integra o seu círculo social. Por outro lado, a princípio, seria compatível o uso de dados de perfis públicos de uma rede profissional (e.g., LinkedIn) por terceiros, como *headhunters*, para aproximar seus usuários às vagas profissionais de seu eventual interesse. Esse uso é compatível com a finalidade não só da plataforma em si, como, principalmente, a razão pela qual tais dados são públicos” (BIONI, Bruno. Op. cit., p. 271.)

45

“(…) afirmou o legislador que o tratamento posterior dos dados pessoais (públicos) a que se referem os §§ 3º e 4º do Art. 7º poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei (§7º). Vale fazer, porém, uma distinção entre as hipóteses do § 3º e do § 4º do Art. 7º da LGPD. Na hipótese do § 4º, pode-se entender que não haveria necessidade de uma nova base legal para o tratamento desses dados, já que se trataria de verdadeira hipótese autorizativa para o tratamento de dados sem o consentimento de seu titular. Já no caso do § 3º, o enquadramento em uma das bases legais autorizativas contidas no rol do Art. 7º ou do Art. 11 se mostraria necessário. Entende-se não ser razoável admitir que dados disponíveis publicamente possam ser tratados sem uma base legal específica, pois isso seria o mesmo que autorizar que qualquer informação publicada, por exemplo, por força de uma obrigação legal, pudesse ser utilizada para uma finalidade distinta sem que o novo controlador precisasse demonstrar que existia uma base legal que autorizava o tratamento de tal dado, especialmente quando ele não foi tornado público por seu titular, tanto é que o referido § 3º não dispensa a exigência de consentimento como faz o §4º.” (TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; VIOLA, Mario. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, a. 9, n. 1, 2020.)

46

.Disponível em: [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>]. Acesso em: 02.02.2019.

47

Acerca do consentimento no GDPR, recomenda-se a seguinte leitura: Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, publicado pelo European Data Protection Board (EDPB) e adotado em 04 de maio de 2020. Disponível em: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_pt Acesso em: 20.05.20.

48

.Como observa Danilo Doneda, “deve-se ter em conta que o próprio conceito de dados sensíveis atende à uma necessidade de delimitar uma área na qual a probabilidade de utilização discriminatória da informação é potencialmente maior – sem deixarmos de reconhecer que há situações onde tal consequência pode advir sem que sejam utilizados dados sensíveis, ou então que a utilização destes dados se preste a fins legítimos e lícitos” (DONEDA, Danilo. *A proteção de dados pessoais nas relações de consumo*: para além da informação creditícia. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Brasília: SDE/DPDC, 2010. p. 27).

49

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. A saúde na sociedade da vigilância: como proteger os dados sensíveis? *Migalhas*, publicado em 14 de abril de 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-vulnerabilidade/324485/a-saude-na-sociedade-da-vigilancia-como-proteger-os-dados-sensiveis>> Acesso em: 21.05.20

50

.Nesse sentido, dispõe o considerando 23 da Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho: “Os dados genéticos deverão ser definidos como todos os dados pessoais relacionados com as características genéticas, hereditárias ou adquiridas, de uma pessoa, e que dão informações únicas sobre a fisionomia ou a saúde do indivíduo, [...] Tendo em conta a complexidade e a natureza sensível das informações genéticas, existe um elevado risco de utilização injustificada e de reutilização para diversos fins não autorizados por parte do responsável pelo tratamento. As discriminações com base em características genéticas deverão ser proibidas.”

51

.RODOTÀ, Stefano. op. cit., p. 78 e 96.

52

.No GDPR, em seu art. 9º, esses dados foram considerados como dentro de uma categoria especial, restando como regra “proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.”

53

.Observa-se o relativo paralelismo entre as hipóteses do art. 7º e aquelas previstas no art. 11 da LGPD, devendo todos os cuidados já previstos para o tratamento dos dados ser aplicados de forma ainda mais intensa ao tratamento dos dados sensíveis, já que para eles se espera um padrão ainda mais rigoroso de proteção. É possível observar que ficaram de fora do tratamento de dados pessoais sensíveis as hipóteses de execução de contratos (art. 7º, V), de legítimo interesse do controlador (art. 7º, IX) e de proteção do crédito (art. 7º, X). No lugar do legítimo interesse do controlador, o art. 11, II, g, da LGPD previu hipótese bem mais restritiva: garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

54

.Esse tipo de consentimento também é requerido no artigo 7º, § 5º (“O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do *caput* deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei”); no art. 14, § 1º (“O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”); e no art. 33, VIII (“quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades”).

55

.”Acresce que discussões mais recentes apontam para a ocorrência de fenômeno de publicidade comportamental voltado à formação de perfis de consumo, fato que se relaciona diretamente à regulação do tratamento de dados pessoais, em especial os dados sensíveis. Na verdade, na seara consumerista, assim como na seara trabalhista, são inúmeros os riscos da utilização de tais dados para praticar toda sorte de discriminações e violações a consumidores, empregados e candidatos a emprego em processos de seleção ou recrutamento” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: o tratamento dos dados pessoais sensíveis. *Jota*, 26 de setembro de 2018. Disponível em:

56

.BIONI, Bruno. Op. cit., p. 202. O autor apresenta a seguinte crítica em relação à adjetivação inserida pelo legislador nacional ao consentimento para o tratamento de dados sensíveis: “[...]sob o ponto de vista de técnica legislativa, teria sido melhor que a LGPD tivesse adotado o adjetivo *expresso*, tal como fez a GDPR, bem como o Marco Civil da Internet e a Lei do Cadastro Positivo, quando se quis prever um tipo de consentimento especial. Esse qualificador é o que semanticamente representaria melhor esse nível de participação mais intenso do cidadão no fluxo dos dados. Apesar dessa diferença semântica, entre os qualificadores *expresso* e *específico*, a consequência normativa tende a ser a mesma. Isso porque o que está em jogo é reservar um tipo de autorização singular em situações igualmente singulares no que tange ao tratamento de dados, sendo esta a racionalidade que percorre a LGPD, a GDPR e parte das leis setoriais brasileiras de proteção de dados pessoais” (BIONI, Bruno. Op. cit., p. 203.)

57

.No direito brasileiro, o consentimento expresso em termos de dados pessoais aparece no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), em seu art. 7º, IX, que dispõe que ao usuário é assegurado o direito ao consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de seus dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais.

58

“*Específico* deve ser compreendido como um consentimento manifestado em relação a propósitos concretos e claramente determinados pelo controlador e antes do tratamento dos dados, havendo também aqui, e com mais ênfase, as obrigações de granularidade. *Destacado* pode ser interpretado no sentido de que é importante que o titular tenha pleno acesso ao documento que informará todos os fatos relevantes sobre o tratamento, devendo tais disposições virem destacadas para que a expressão do consentimento também o seja. Além de se referir a dados determinados e haver declaração de vontade que esteja ligada a objetivo específico, a manifestação de vontade deverá vir em destaque no instrumento de declaração que autoriza o tratamento.” (TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; VIOLA, Mario. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 9, n. 1, 2020.)

59

MULHOLLAND, Caitlin. Dados pessoais sensíveis e consentimento na Lei geral de proteção de dados pessoais. *REVISTA DO ADVOGADO*, n. 144, nov. 2019, p. 47-53. p.52.

60

.Sobre o ponto, anota Ana Frazão: “a linha distintiva entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis pode não ser tão nítida, até porque a perspectiva de análise deve ser dinâmica e não estática. Dessa maneira, há boas razões para sustentar que são sensíveis todos os dados que permitem que se chegue, como resultado final, a informações sensíveis a respeito das pessoas” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: o tratamento dos dados pessoais sensíveis. *Jota*, 26 de setembro de 2018).

61

“Por exemplo, ao fornecer o número do CPF para obter descontos nas farmácias, a lista de medicamentos associada a esse dado pode conter informações delicadas sobre nossa saúde. É possível que essas informações sejam utilizadas de maneira discriminatória por seguradoras de saúde, alterando o valor da franquia de acordo com o perfil. Da mesma forma, nosso histórico de compras *on-line* diz bastante sobre poder aquisitivo e preferências pessoais. Por meio dessas informações, é possível embasar o direcionamento de propagandas compatíveis com o nosso gosto, tentando-nos a comprar algo que não precisamos, bem como cobrar preços mais altos ou limitar o acesso ao crédito para determinados perfis. Dados sobre orientação sexual, em uma sociedade que ainda vive preconceitos contra a diversidade, também podem servir a práticas de segregação, restringindo, por exemplo, as oportunidades de trabalho.” (VARON, Joana. Privacidade e dados pessoais. *Panorama setorial da Internet*, n. 2, junho, 2019, ano 11, p. 12).

62

Art. 11, § 4º, da LGPD: É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.

63

.DONEDA, Danilo. *A proteção de dados pessoais nas relações de consumo*: para além da informação creditícia. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Brasília: SDE/DPDC, 2010. p. 27.

64

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...]”

65

“A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança – Carta Magna para as crianças de todo o mundo – em 20 de novembro de 1989, e, no ano seguinte, o documento foi oficializado como lei internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países.” Disponível em: [www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.html]. Acesso em: 28.12.2018. O Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990.

66

.Diego Carvalho Machado, em estudo acerca do direito à privacidade, em especial paralelo com a temática das incapacidades e dos direitos da personalidade, afirma que “visto que constitui direito da personalidade, o direito à privacidade não tem outro titular senão a pessoa humana, seja maior de idade ou não, sujeito a medida interditiva ou não: capazes de direito que estes são, não há que se pôr em discussão a titularidade desta situação jurídica subjetiva, eis que visa assegurar liberdades existenciais do sujeito.” (MACHADO, Diego

Carvalho. Capacidade de agir e direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro: o caso do direito à privacidade. *RBDCivil*, v. 8, abr.-jun. 2016. p. 74-75. Disponível em: [https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/64/58]. Acesso em: 04.03.2019.

67

Cf. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Proteção de dados de crianças e adolescentes. *Revista do advogado*, v. 39, p. 1-225, 2019.

68

.Lei 8.069/90: “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.”

69

.Acerca do consentimento a ser fornecido pelos pais em ambiente de multiplicação de brinquedos conectados, antes ainda do diploma legislativo específico sobre proteção de dados pessoais, já advertia a doutrina: “certo é que não se pode negar a imprescindibilidade de transparência das informações e dos termos de uso do produto, de modo a viabilizar de fato a manifestação de um consentimento livre e esclarecido por parte dos pais que adquirem o produto. Em termos de privacidade, deve ser reforçado o controle dos indivíduos sobre a forma como os dados estão sendo coletados e tratados, bem como sobre quem realiza o gerenciamento dessas informações” (LEAL, Livia Teixeira. Internet of toys: os brinquedos conectados à internet e o direito da criança e do adolescente. *RBDCivil*, v. 12, n. 2, p. 175-187, 2017).

70

..“No caso da criança, a vulnerabilidade é um estado a priori, considerando que vulnerabilidade é justamente o estado daquele que pode ter um ponto fraco, que pode ser ‘ferido’ (*vulnerare*) ou é vítima facilmente. [...] Estudos recentes demonstram a importância de crianças e adolescentes na definição dos hábitos de consumo dos adultos, tanto em relação a produtos de interesse do menor, quanto da própria família. Esse ‘poder’ da criança e do adolescente nas decisões de compra familiar, por sua vez, contrasta com a vulnerabilidade que apresentam em relação à atuação negocial dos fornecedores no mercado, por intermédio das técnicas de *marketing*. Neste sentido, se os apelos de *marketing* são sedutores aos consumidores em geral, com maior intensidade presume-se que o sejam em relação às crianças e adolescentes. Estes se encontram em estágio da vida em que não apenas permite que se deixem convencer com maior facilidade, em razão de uma formação intelectual incompleta, como também não possuem, em geral, o controle sobre aspectos práticos da contratação, como os valores financeiros envolvidos, os riscos e benefícios do negócio. Daí resulta que estejam em posição de maior debilidade com relação à vulnerabilidade que se reconhece a um *consumidor standard*. Esta vulnerabilidade agravada da criança é reconhecida no âmbito da publicidade, sendo que o próprio CDC estabelece o caráter abusivo da publicidade que venha a aproveitar-se da deficiência de julgamento da criança (artigo 37, § 2º). Mas igualmente, ainda quando não se trate de publicidade, qualquer conduta negocial do fornecedor que venha a prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, em vista, dentre outras condições de sua idade e conhecimento, será considerada prática abusiva (artigo 39, IV), ilícita, podendo ensejar tanto a imposição das sanções cabíveis, quanto eventual ineficácia do contrato (ou ato existencial que resulte desta contratação)” (MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2016. p. 131-132).

71

.Código Civil de 2002: “Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz.”

72

.Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC kids online Brasil 2018. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019. p. 24-25. Disponível em: [https://cetic.br/pesquisa/kids-online/publicacoes]. Acesso em: 20.05.2020.

73

..“Nos últimos anos, verifica-se uma intensa utilização, principalmente pelos jovens, de diversas ferramentas disponíveis on-line para exibir assuntos relativos às suas vidas privadas. Tanto os detalhes mais interessantes quanto os mais irrelevantes vêm sendo expostos em redes sociais e aplicativos interativos. Muitos indivíduos parecem ter vontade, e até mesmo a necessidade, de se manifestar em diferentes plataformas, havendo então a multiplicação da exposição pública da intimidade de todo mundo e qualquer um, por meio de *reality shows*, *webcams*, *blogs* e redes sociais. Percebe-se, assim, a reprodução pelas novas gerações de um crescente desejo “de ser visto”, notado, percebido para além daquela comunidade real em que se encontram (MARICHAL, 2013, p. 4)” (TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil: análise a partir do Marco Civil da Internet., cit., p. 119.)

74

.Part 312 – Children’s Online Privacy Protection Rule: §312.3 Regulation of unfair or deceptive acts or practices in connection with the collection, use, and/or disclosure of personal information from and about children on the Internet. *General requirements*. It shall be unlawful for any operator of a Web site or online service directed to children, or any operator that has actual knowledge that it is collecting or maintaining personal information from a child, to collect personal information from a child in a manner that violates the regulations prescribed under this part. Generally, under this part, an operator must: (a) Provide notice on the Web site or online service of what information it collects from children, how it uses such information, and its disclosure practices for such information (§312.4(b)); (b) Obtain verifiable parental consent prior to any collection, use, and/or disclosure of personal information from children (§312.5); (c) Provide a reasonable means for a parent to review the personal information collected from a child and to refuse to permit its further use or maintenance (§312.6); (d) Not condition a child’s participation in a game, the offering of a prize, or another activity on the child disclosing more personal information than is reasonably necessary to participate in such activity (§312.7); and (e) Establish and maintain reasonable procedures to protect the confidentiality, security, and integrity of personal information collected from children (§312.8). Disponível em: [www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=d9fdda9d81a3e854c8793fd56bd8a059&mc=true&node=pt16.1.312 &rgn=div5#se16.1.312_15]. Acesso em: 02.01.2019.

75

.Como exemplo, vale recordar os termos de uso do WhatsApp: “Se você reside em um país do Espaço Econômico Europeu (que inclui a União Europeia) ou em qualquer outro país ou território incluído (coletivamente, Europa), deve ter pelo menos 16 anos (ou mais, se for exigido em seu país) para se cadastrar e usar o WhatsApp. Se você reside em qualquer outro país, e não nos países pertencentes à Região Europeia, você deve ter pelo menos 13 anos (ou mais, se for exigido em seu país) para se cadastrar e usar o WhatsApp.” Disponível em: [https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/26000151/?category=5245250]. Acesso em: 06.01.2019.

76

..“Artigo 6.º Licitude do tratamento 1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades

específicas; [...]”

77

.No estudo *GDPR: updated state of play of the age of consent across the EU*, de 2018, foram apresentadas as idades mínimas estabelecidas por alguns países europeus para um menor consentir com o tratamento de seus dados por serviços da sociedade da informação. Disponível em: [\[www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751\]](http://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751). Acesso em: 06.01.2019. A lei dinamarquesa de proteção de dados foi adotada oficialmente em maio de 2018. A idade de consentimento para crianças que usam serviços digitais foi fixada em 13 anos. A razão dessa decisão levou em conta os benefícios educacionais e sociais dos serviços *on-line* para crianças, bem como sua participação e inclusão no mundo digital.

Em junho de 2018, a Lei francesa n. 2018-493, relativa à proteção dos dados pessoais, foi adotada e publicada no jornal oficial. Seu artigo 20 declara que um menor pode consentir sozinho com o processamento de seus dados pessoais, quando diante da oferta de serviços da sociedade da informação, a partir dos seus 15 anos. A segunda parte do artigo introduz um consentimento conjunto, afirmando que quando o menor tiver menos de quinze anos, o tratamento será lícito apenas se o consentimento for dado conjuntamente pelo menor em causa e pelo(s) seu(s) pai(s).

Em 18 de abril de 2018, o parlamento sueco adotou a nova lei sueca de proteção de dados, estabelecendo a idade de consentimento para as crianças aos 13 anos.

Nos países baixos, o ato de implementação final do GDPR foi publicado no Jornal Oficial em 22 de maio de 2018. O artigo 5º do ato fixa a idade para o consentimento do uso de serviços digitais em 16 anos.

O Ato de Proteção de Dados do Reino Unido (*UK Data Protection Act 2018*) foi adotado em 23 de maio de 2018. A Seção 9 do Ato determina a idade de consentimento das crianças, em relação aos serviços da sociedade da informação, em 13 anos.

Na Itália, o decreto responsável por alinhar o sistema jurídico italiano ao GDPR estabeleceu que o menor que completou quatorze anos poderá expressar seu consentimento para o processamento de seus dados pessoais, em relação à oferta direta de serviços sociedade da informação. Sendo o titular menor de 14 anos, o consentimento será realizado pelo titular da responsabilidade parental.

78

.Disponível em: [\[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT\]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT) Acesso em: 29.12.2018.

79

.COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de proteção de Dados Pessoais comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 147-148.

80

.FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: tratamento dos dados de crianças e adolescentes. *Jota*, publicado em 03 de outubro de 2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-tratamento-dos-dados-de-criancas-e-adolescentes-03102018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-tratamento-dos-dados-de-criancas-e-adolescentes-03102018)> Acesso em: 28.12.18.

81

.Nesse sentido, o art. 12 do GDPR: “Transparência das informações, das comunicações e das regras para exercício dos direitos dos titulares dos dados. 1. O responsável pelo tratamento toma as medidas adequadas para fornecer ao titular as informações a que se referem os artigos 13.º e 14.º e qualquer comunicação prevista nos artigos 15.º a 22.º e 34.º a respeito do tratamento, de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples, em especial quando as informações são dirigidas especificamente a crianças. As informações são prestadas por escrito ou por outros meios, incluindo, se for caso disso, por meios eletrônicos. Se o titular dos dados o solicitar, a informação pode ser prestada oralmente, desde que a identidade do titular seja comprovada por outros meios.”

82

Há de se questionar, todavia, a aplicação das disposições acerca da tutela do crédito (art. 7º, X) e do atendimento dos interesses legítimos do controlador ou de terceiro (art. 7º, IX) para o tratamento de dados de menores. No caso do legítimo interesse, o legislador ressaltou que a hipótese não será possível “se prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”. Sobre a exceção, é necessário ponderar que, no caso de dados de crianças e adolescentes, será importante considerar tal ressalva com maior cuidado, assim como optou o Regulamento europeu, em seu art. 6º: “Artigo 6º Licitude do tratamento 1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: [...] f) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança.”

Capítulo 11. Potencialidades do direito de acesso na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho ¹

Diana Paiva de Castro ²

1. Introdução

Na sociedade contemporânea, em que o fluxo de dados se intensifica e se agiganta, em inimagináveis velocidade e volume de informações trocadas, os dados pessoais passam a circular por toda parte. Diante dos avanços da capacidade humana em transmitir informações por meio virtual, evidencia-se risco crescente ao direito à privacidade.³

O tema, no direito brasileiro, era objeto de tutela legislativa esparsa. Em 14 de agosto de 2018, contudo, finalmente foi editada, no ordenamento pátrio, a Lei 13.709/2018, que contempla disciplina específica para a proteção dos dados titularizados por pessoa natural identificada ou identificável, objeto de tratamento, em meio físico ou digital, por pessoa física ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. A legislação teve origem em projeto proposto em 2012 na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei 4.060/12) e, em 2018, diante de episódios internacionais de vazamento de dados e da vigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), entrou em regime de urgência, sendo, em seguida, aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pelo presidente da República.

A normativa, posteriormente, sofreu alterações pela edição da Lei nº 13.853/2019, a partir da conversão da Medida Provisória nº 869/2018. A entrada em vigor da legislação ocorreria em 2020, com exceção dos dispositivos discriminados no artigo 65, I. Contudo, diante do advento da pandemia do novo coronavírus, foi editada a Medida Provisória nº 959/2020, que prorrogou a *vacatio legis* da LGPD, estabelecendo como nova data de entrada em vigor 3 de maio de 2021.⁴

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei 13.709/2018) traz, como dois de seus princípios, o de livre acesso, estabelecendo a “garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais” (art. 6º, IV), e o de transparência, assegurando aos titulares “informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de

tratamento, observados os segredos comercial e industrial” (art. 6º, VI). O presente artigo visa a cuidar especificamente do tema do direito de acesso, identificando suas potencialidades funcionais na nova legislação para a proteção do direito à privacidade e, em última análise, do princípio da dignidade da pessoa humana, como se verá adiante.

2. Redefinição do conceito de privacidade na legalidade constitucional

Em um sistema aberto,⁵ as figuras jurídicas passam por alterações em seus sentidos ao longo do tempo, ainda que a terminologia permaneça idêntica. Trata-se do caráter histórico-relativo dos conceitos, que sofrem verdadeira mutabilidade de significado, podendo desempenhar distintas funções, a depender do contexto histórico, geográfico, cultural e social em que se inserem. A privacidade parece constituir boa ilustração de tal característica.⁶

Tradicionalmente, a privacidade era definida como o direito a ser deixado só, isto é, a um espaço reservado de intromissões indesejadas. No contexto em que concebido, vigorava visão rigorosamente patrimonialista, cuidando-se o *right to be left alone* de direito próprio da classe burguesa, que se assemelhava ao direito de propriedade, como aquele que impunha à coletividade um dever de se abster.⁷

Todavia, na sociedade tecnológica, o conceito de privacidade passa a se distinguir do de intimidade e a ser concebido como o direito ao controle dos dados pessoais. Analisa-se a privacidade em perspectiva extrapatrimonial, diante de sua relação essencial com o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do sistema jurídico (art. 1º, III, CRFB/88). Sobressai, nesse sentido, a necessidade de se controlar a manipulação dos dados pessoais, limitando a sua coleta ao mínimo necessário para se atingir as finalidades legítimas. Revela-se, aqui, o princípio da proporcionalidade, devendo-se obter menor sacrifício possível para o objetivo que se quer alcançar.⁸

Assim, partindo-se de uma leitura constitucional do direito civil, não se pode deixar de reconhecer a proteção dos dados pessoais como direito fundamental. Como visto, tal fenômeno decorre da tutela, mais ampla, conferida pela Constituição à pessoa humana.⁹ Em outras palavras, no direito contemporâneo, em que a pessoa humana e a sua plena realização existencial foram alçados a valor supremo, demanda-se a releitura da estrutura e da função do direito à privacidade nas múltiplas situações em que se apresentam. Configura-se, desta feita, linha de ruptura com o sistema patrimonialista e individualista de outrora, e se dá início à redefinição de um direito à privacidade em harmonia com princípios e valores extrapatrimoniais.¹⁰

3. Efetividade do direito de acesso na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais concretiza o referido papel cambiável no tempo exercido pelo conceito de privacidade, concebendo-o como direito fundamental relacionado ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (arts. 1º e 17). A normativa apresenta como fundamentos

expressos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (art. 2º).¹¹

A adequada tutela do direito de controle dos dados pessoais (*rectius*, do direito à privacidade) depende essencialmente da efetividade do que se denomina de *direito de acesso*. De fato, escanteado do tratamento dos dados que lhe pertencem, torna-se inviável qualquer possibilidade de exercício do controle por parte do titular. O direito de acesso se traduz, assim, em pedra angular para a proteção das informações pessoais.¹²

Há, contudo, barreiras que devem ser transpostas para a plena realização das potencialidades funcionais do direito de acesso. A esse respeito, Stefano Rodotà denuncia como principais causas do tímido exercício desse direito na prática: (i) o aspecto do procedimento de acesso, relativo aos custos financeiros e de tempo envolvidos, à carência de alfabetização, à falta de informação e ao desnível de poder entre os titulares dos dados pessoais e os agentes públicos e privados que detêm as informações; (ii) o aspecto do funcionamento do acesso, que diz com a escassa relevância das informações fornecidas quando não se conhece o modo de funcionamento do sistema de tratamento e (iii) o aspecto do âmbito de incidência do acesso, referente ao excesso de vedações de acesso a certas categorias de informações.¹³

Atento a tais questões, o legislador brasileiro trouxe importantes previsões para a efetividade do direito de acesso, buscando superar os ditos obstáculos. No que tange à perspectiva procedimental, contemplou a gratuidade, a facilidade e a possibilidade de tutela individual e coletiva do acesso. No que se relaciona com a perspectiva do funcionamento, permitiu o controle dos dados onde quer que se encontrem, ao longo de todo o processo de uso e compartilhamento de informações, bem como o conhecimento do funcionamento do sistema, e concedeu uma gama de direitos ao titular dos dados pessoais, como correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade de informações, revogação do consentimento, oposição ao tratamento, revisão de decisões, entre outros. No que versa sobre o âmbito de incidência, assegurou o acesso à integralidade dos dados pessoais e em face de pessoa natural ou jurídica de direito privado e de direito público. Passa-se à análise de tais previsões.

3.1.Procedimento do acesso: gratuito, facilitado e tutelado por meio individual ou coletivo

Os custos financeiros envolvidos no exercício do direito de acesso sem dúvida se traduzem em barreira à sua efetividade, sobretudo em países marcados por desigualdades sociais, como no caso brasileiro.¹⁴ Por tal razão, essencial a previsão do artigo 6º, IV, da LGPD, a respeito da gratuidade no exercício do direito, ao dispor sobre o princípio do livre acesso. No mesmo sentido, demanda o artigo 18, § 5º, que o requerimento de acesso seja atendido sem custos para o solicitante. Faz-se mister que, em obediência aos ditames da lei, o

estabelecimento dos procedimentos para o exercício do direito de acesso no âmbito dos tratamentos realizados por agentes públicos e privados, conforme os artigos 32,¹⁵ 50¹⁶ e 51,¹⁷ observem a garantia de gratuidade.

Também no que diz com a superação dos obstáculos referentes à obtenção e à compreensão dos dados pelo titular, bem como à demora do processo, a lei visa a assegurar a facilitação do acesso (art. 6º, IV). Nesse sentido, demanda o artigo 9º que as informações sejam disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva. Além disso, o requerimento de acesso será atendido em formato simplificado, de modo imediato, ou no prazo de 15 dias, contados da data do pedido, por meio de declaração clara e completa, que informe a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e o objetivo do tratamento, ressalvado o sigilo comercial e o industrial (art. 19, I e II).¹⁸ As informações poderão ser obtidas por meio digital, seguro e idôneo, ou por meio físico. A escolha da forma de atendimento do pedido caberá ao requerente (art. 19, § 2º, I e II). Por fim, prevê o artigo 19, em seu § 1º, que os dados pessoais serão armazenados em condições que favoreçam o exercício do direito de acesso.

Sob outro ângulo, os obstáculos descritos, referentes ao desnível de poder entre as partes e à falta de informação do requerente, encontram importante solução na possibilidade de assistência do titular por profissional qualificado bem como de tutela coletiva desse direito. De fato, a assistência do titular por um especialista permite mitigar a disparidade de conhecimentos técnicos e jurídicos entre o titular dos dados e o agente de tratamento público ou privado.¹⁹ No mesmo sentido, a forma coletiva de tutela do direito de acesso assegura uma ação coordenada, sistemática e, por consequência, possivelmente mais assertiva.²⁰ A lei cuida do tema no artigo 18, § 3º, ao dispor que “os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento”, e no artigo 22, ao prever que “a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva”, de modo a dotar de efetividade o direito de acesso.

Segundo Rodotà, trata-se de “reforçar a posição dos indivíduos, seja para tornar mais eficaz o acesso, seja para suprir, no limite do possível, o *gap* de poder entre estes e os ‘senhores da informação’”. Isso pode se dar por meio de um “acesso ‘assistido’ por especialistas” – viabilizando-se “não somente o conhecimento das informações pessoais referentes ao interessado, mas também os ‘critérios utilizados para os tratamentos automáticos’” –, ou mediante “o reconhecimento de um direito de acesso ‘integrado’ pela presença de um sujeito coletivo (sindicato, associação de direitos civis, associação de tutela dos consumidores, e assim por diante)”.²¹

3.2. Funcionamento do acesso: informações a respeito de todo o processo de tratamento, tutela do princípio da não discriminação e gama de direitos do titular

No aspecto do funcionamento, o obstáculo a ser superado diz com a escassa relevância das informações fornecidas quando não se conhece a maneira de

atuação do sistema. A esse respeito, a nova lei permite que o acesso seja estendido, para além do dado pessoal em si, à forma de operação do tratamento, bem como à circulação da informação. Assegura-se, desta feita, que o direito de controle dos dados pessoais seja exercido de modo efetivo, abarcando o modo de desempenho do sistema e alcançando as informações onde quer que estejam, no bojo do processo dinâmico de uso e compartilhamento dos dados.

Nesse sentido, o artigo 9º da LGPD garante o acesso à finalidade específica, à forma e à duração do tratamento, ressalvados os segredos comercial e industrial, à identificação e às informações de contato do controlador, às informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e à finalidade, às responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e aos direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 da lei.

Além disso, no tocante ao acesso ao funcionamento do sistema de tratamento, destaca-se a previsão do artigo 20, que, em tema de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, inclusive com a formação de perfis, permite o pedido de revisão dessas decisões,²² bem como o acesso aos critérios e procedimentos utilizados na operação, observados os segredos comercial e industrial. Neste último caso, se o conhecimento esbarrar na proteção do sigilo, a autoridade nacional zelará pelo princípio da não discriminação, assegurando a isonomia.²³

Consiste a autoridade nacional (ANPD) em órgão especializado na proteção de dados, com amplas prerrogativas previstas no artigo 55-J da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.²⁴ A redação do referido Projeto de Lei 4.060/12 atribuía ao órgão a natureza de autarquia especial, integrante da administração pública indireta, vinculada ao Ministério da Justiça e dotada de independência administrativa, insubordinação hierárquica e autonomia financeira, mas foi, nesse ponto, objeto de veto presidencial. Em seguida, tais características não foram contempladas pela MP 869/2018, que definiu a autoridade nacional como órgão integrante da Presidência da República, com menção apenas à autonomia técnica (arts. 55-A e 55-B).²⁵

A respeito de tal mudança na configuração da entidade, constituía “motivo de preocupação que a ANPD, apesar de suas relevantíssimas atribuições”, apresentasse, “do ponto de vista organizacional, estrutura que revela fragilidade institucional e dependência em relação à Presidência da República”. Esses aspectos, na prática, comprometiam a atuação da autoridade nacional, “subordinando-a indevidamente aos interesses do Poder Executivo”.²⁶ De fato, a conformação dada pela MP 869/2018 se revelava prejudicial, uma vez que o órgão necessita de verdadeira liberdade para o exercício de suas competências, como no caso da realização de auditoria para fins de tutela do princípio da não discriminação no tratamento automatizado de dados pessoais prevista no artigo 20 da LGPD.

A escalada normativa culmina, então, na edição da Lei nº 13.853/2019, resultado da conversão da MP nº 869/2018, a alterar a redação do artigo 55-A da LGPD para prever que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) constitui órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da

República, mas que tal natureza jurídica seria transitória e a ANPD poderia ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República, avaliação que deverá ocorrer em até dois anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Previu-se, ademais, que a ANPD disporia de autonomia técnica e decisória (art. 55-B).

Fechando-se os parênteses abertos para a compreensão do conceito de “autoridade nacional”, deve-se retomar a análise do teor do artigo 20 para destacar que o dispositivo se destina à tutela do livre desenvolvimento da personalidade do titular. Com efeito, constata-se que, na sociedade tecnológica, a construção da identidade do sujeito passa a depender do modo como os dados o descrevem. O corpo se torna eletrônico e a percepção de si se opera de fora para dentro – a personalidade é aquela definida pelo conjunto de informações.²⁷

O controle dos dados pessoais, por meio do acesso aos critérios e procedimentos utilizados e da solicitação de revisão das decisões automatizadas, objetiva evitar que aquela pessoa humana seja indevidamente discriminada com base em característica que lhe foi atribuída por meio do tratamento de dados pessoais. Trata-se de “de um enriquecimento e de um fortalecimento do direito de acesso, que tende a permitir aos interessados conhecer e valorar o contexto no qual têm sido tratadas as informações que lhe digam respeito”.²⁸

Sobre o tema, a lei contempla como princípio basilar de sua incidência o de não discriminação,²⁹ que preconiza a “impossibilidade de realização do tratamento *para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos*” (art. 6º, IX).³⁰ Note-se, portanto, que se admite que os titulares de dados pessoais sejam tratados de modo distinto, como o oferecimento de condições de crédito diferenciadas a partir do perfil de cada consumidor, mas se afigura vedada a discriminação quando ilícita ou abusiva.³¹

Por fim, e tomando-se o direito de acesso como instrumento de efetividade da tutela de diferentes situações jurídicas existenciais,³² cabe destacar a amplitude dos direitos conferidos pela lei ao titular dos dados pessoais, que pode requerer: (i) confirmação da existência de tratamento; (ii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iii) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei; (iv) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;³³ (v) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 da lei; (vi) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; (vii) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; (viii) revogação do consentimento, nos termos do § 5º do artigo 8º da lei³⁴ (art. 18, incisos I a IX³⁵); (ix) informação a respeito de seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional, bem como em face dos organismos de defesa do consumidor (art. 18, §§ 1º e 8º); (x) oposição a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, uma vez descumprida a lei (art. 18, § 2º) e (xi) cópia eletrônica integral de seus dados

peçoais, observados os segredos comercial e industrial, quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato (art. 19, § 3º).^{36 - 37}

3.3.Âmbito de incidência do acesso: integralidade dos dados tratados por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado

Importante obstáculo a ser transposto para o efetivo exercício do direito em análise se relaciona ao excesso de vedações de acesso a certas categorias de informações. Sobre o ponto, fundamental a previsão legislativa de acesso à *integralidade* das informações pessoais, conforme a dicção do artigo 6º, IV.³⁸

Exige-se, ainda, para a superação dessa barreira, que o direito de acesso possa ser exercido em face da sociedade, do mercado e também do Estado, isto é, sem que existam searas sociais em que prevaleça o sigilo em vez do controle. Por essa razão, a nova legislação contempla, logo em seu artigo 1º, sua incidência para o tratamento realizado “por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado”. O tema das operações de dados pessoais levadas a cabo pelo Poder Público é ainda objeto de capítulo específico (Capítulo IV), no qual se demanda que o Estado forneça informações claras e atualizadas, em veículos de fácil acesso, preferencialmente nos *sites* oficiais, sobre os tratamentos de dados pessoais que efetua, sobretudo no que tange à previsão legal, à finalidade, aos procedimentos e às práticas utilizadas para a execução dessas operações (art. 23, I).³⁹

Com efeito, o direito à privacidade deve ser tutelado em toda e qualquer relação intersubjetiva, tanto em face de agentes particulares quanto de agentes públicos (eficácia horizontal e vertical do direito fundamental ao controle dos dados pessoais).⁴⁰ Afasta-se, assim, a concepção do estudo do direito por setores pré-constituídos, tendo como premissa básica a superação das divisões estanques entre as disciplinas jurídicas envolvidas (direito civil, administrativo, constitucional e processo civil), ou seja, uma visão unitária do ordenamento, e, especialmente, o rompimento dos lindes entre o público e o privado.⁴¹

A possibilidade de exercício do direito de acesso em face do Poder Público traduz verdadeira redefinição da ótica de controle da atuação estatal: do segredo à transparência. Como forma de superar qualquer tentativa de instrumentalização do homem aos fins políticos do Estado, e, particularmente, em resposta ao governo ditatorial anterior, de cujos porões, recém-abertos, ainda se ouvia e sentia o vilipêndio por que passaram os opositores do regime,⁴² o constituinte cuidou da dignidade da pessoa humana como fundamento da República,⁴³ das garantias de acesso à informação e de controle dos dados pessoais como direitos fundamentais⁴⁴ e da publicidade como princípio que rege a atuação da Administração Pública.⁴⁵⁻⁴⁶

Por fim, registre-se que o tema do direito de acesso pode ser concebido em duas perspectivas. Uma primeira, objeto deste trabalho, que diz com o exercício do direito pelo titular da informação pessoal (que pode ser representado legalmente ou substituído processualmente), para fins de controle e proteção dos dados que lhe dizem respeito. Há, contudo, uma segunda ótica de apreensão, que versa, de modo mais amplo, sobre o direito de acesso a informações de qualquer natureza.

Quando esse direito é exercido por terceiro com relação a dados de natureza pessoal, pertencentes a outrem, a privacidade pode restar ameaçada.

No que tange ao Estado, essa segunda dimensão do direito de acesso é disciplinada pela Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei 12.527/2011). Esta lei determina a proteção dos dados pessoais confiados ao Poder Público (art. 6º, III e art. 31, *caput* ⁴⁷) e restringe o acesso a informações pessoais aos titulares e aos agentes públicos legalmente autorizados, restrição que perdura pelo prazo máximo de 100 anos, a partir da data da produção do dado, e que independe da classificação de sigilo (art. 31, § 1º, I, Lei 12.527/2011). Além dessas hipóteses, o acesso aos dados pessoais por terceiros só poderá ser realizado por meio de consentimento expresso do titular ou de autorização em lei (art. 31, § 1º, II, Lei 12.527/2011).⁴⁸

Note-se que o advento da Lei 13.709/2018 não elimina a tutela conferida pela Lei 12.527/2011, como, inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ressalva em seus artigos 23, §§ 2º e 3º,⁴⁹ 26, § 1º, I,⁵⁰ e 52, § 3º.⁵¹ A interpretação das normativas deve ser sistemática, promovendo-se o diálogo com fins de tutela do direito à privacidade em duas frentes: (i) uma primeira, que assegura o direito de acesso do titular (que pode ser representado legalmente ou substituído processualmente) para controlar os dados que lhe pertencem e (ii) uma segunda, que, ao mesmo tempo em que assegura o direito à informação, restringe o acesso de terceiros quando a informação for de natureza pessoal e pertencer a outrem, nos referidos termos da lei.⁵²

Com efeito, como ensina Rodotà, “a questão das relações entre leis sobre a proteção de dados e leis sobre a liberdade de informação é seguramente uma das mais delicadas e urgentes”. Nos “diferentes terrenos vão se desenvolvendo técnicas de composição dos diversos interesses considerados nos dois tipos de legislação”. Contudo, “para além das soluções específicas, torna-se cada vez mais evidente que o contexto a ser considerado é unitário, tanto que em algumas legislações a distinção entre os dois tipos de disciplina atualmente é meramente formal”. Demonstra-se, assim, “com clareza que os problemas da proteção de dados podem ao cabo ser enfrentados e resolvidos somente no conjunto das regras gerais sobre a circulação de informações, pessoais e não pessoais”.⁵³

4. Considerações finais

Produto da nova concepção do direito à privacidade e associado à transparência que permeia grande parte das relações sociais na contemporaneidade, o recém-chegado direito de acesso se apresenta, no cenário jurídico nacional, marcado pela busca por efetividade.

Como visto *supra*, o desenvolvimento deste trabalho revelou que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem escorada nos avanços doutrinários sobre os assuntos de que se ocupa, procurou enfrentar as principais barreiras que obstaculizam o controle dos dados pessoais.

Incorporou, assim, poderoso cabedal de ferramentas, ora postas à disposição das pessoas, que se veem convidadas, então, a exercer o direito de controle das

suas informações pessoais.

Em meio às turbulências do mundo líquido do Século XXI, a plena eficácia social do direito de acesso consubstancia gigantesco passo civilizatório a favor da tutela integral da pessoa humana.

5. Referências bibliográficas

ARENDT, Hannah. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.

BARBOZA, Heloisa Helena. Proteção dos vulneráveis na Constituição de 1988: uma questão de igualdade. In: NEVES, Thiago (Coord.). *Direito & justiça social: por uma sociedade mais justa, livre e solidária: estudos em homenagem ao Professor Sylvio Capanema de Souza*. São Paulo: Atlas, 2013.

CANARIS, Claus-Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. *Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A lei geral de proteção de dados do Brasil na era do *big data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). *Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018.

EBERLIN, Fernando Büscher von Teschenhausen. *As alterações na LGPD e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados*. Disponível em: [www.conjur.com.br/2019-jan-05/fernando-eberlin-lgpd-criacao-entidade-protecao-dados]. Acesso em: 12.02.2019.

FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

FACHIN, Luiz Edson. *Direito civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: balanço preliminar da MP 869/2018*. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019). Acesso em: 12.02.2019.

HAMMERSCHMIDT, Denise. Direito e discriminação genética. *Revista de Direito Privado da UEL*, Londrina, v. 1, n. 2, 2008.

LEMOES, Ronaldo; DOUEK, Daniel; ADAMI, Mateus Piva; LANGENEGGER, Natalia; FRANCO, Sofia Lima. *A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela MP n. 869/2018: principais mudanças e considerações iniciais*. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018#_ftn9\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018#_ftn9). Acesso em: 12.02.2019.

MAIA, Roberta Mauro Medina. Vivendo nas nuvens: dados pessoais são objeto de propriedade? In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor Rozatti; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. *Primeiras impressões sobre as alterações da medida provisória 869/2018 na LGPD: medida dá um passo na contramão da convergência normativa internacional*. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-mp-autoridade-dados-pessoais-14012019\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-mp-autoridade-dados-pessoais-14012019). Acesso em: 12.02.2019.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Lesão ao tempo: configuração e reparação nas relações de consumo. *Revista da AJURIS*, Porto Alegre, v. 43, n. 141, p. 87-113, dez. 2016.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. O problema da massificação das demandas consumeristas: atuação do Procon e proposta de solução à luz do direito contemporâneo. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 108, p. 293-313, nov.-dez. 2016.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Subversões hermenêuticas: a Lei da Comissão da Anistia e o direito civil-constitucional. *Civilistica.com*, ano 5, n. 1, 2016.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Reflexões metodológicas: a construção do observatório de jurisprudência no âmbito da pesquisa jurídica. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, jul.-set. 2016.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei

13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *Dal soggetto alla persona*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007.

SANTOS, Fabíola Meira de Almeida; TALIBA, Rita. Lei geral de proteção de dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

TERRA, Aline de Miranda Valverde; CASTRO, Diana Paiva de. A responsabilidade do poder público no tratamento de dados pessoais: análise dos artigos 31 e 32 da Lei n. 13.709/2018. In: MULHOLLAND, Caitlin (Org.). *A LGPD e o novo marco normativo no Brasil*. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2020.

1

.Professor Titular de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Advogado, consultor e parecerista em temas de direito privado.

2

.Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Procuradora do Estado de São Paulo.

3

.Como já se observou em outra sede: “A concepção científica de tempo originou-se a partir de associações com o conceito de espaço. O tempo referia-se à grandeza física necessária para percorrer certo espaço; este último, por sua vez, era o que se podia percorrer em determinado intervalo de tempo. E, no decorrer da história, tempo e espaço, entrecruzados, assemelhavam-se como categorias rígidas e impassíveis de controle artificial pelo homem. As distâncias ligavam-se à capacidade física da vida biológica. Com o advento da modernidade, contudo, meios artificiais criados pelo ser humano pouco a pouco desconstruíram essa estanque relação. Produto da Revolução Industrial, máquinas mais velozes a cada geração, encurtando distâncias, atuam de modo relevante no processo de diminuição do espaço-tempo. Afora isso, a evolução contínua dos meios de comunicação reduziu o espaço entre as pessoas a tal medida que hoje, ao menos virtualmente, as fronteiras sejam eliminadas por completo. A tecnologia, assim, permitiu que se esteja em qualquer local, sem que se faça necessário deslocar-se até ele” (MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Lesão ao tempo: configuração e reparação nas relações de consumo. *Revista da AJURIS*, Porto Alegre, v. 43, n. 141, dez. 2016. p. 88).

4

A redação dada ao artigo 65 da LGPD pela Lei nº 13.853/2019 foi: “Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos”. Todavia, posteriormente, o artigo 4º da MP nº 959/2020

dispôs: "Art. 4º A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 65. (...). II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos".

5

“Deve-se definir o sistema jurídico como ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais. [...] Este sistema não é fechado, mas antes aberto. [...] Da problemática da abertura do sistema deve-se distinguir a sua mobilidade. A mobilidade, no sentido que este termo recebeu de Wilburg, significa a igualdade fundamental de categoria e a mútua substituibilidade dos critérios adequados de justiça, com a renúncia simultânea à formação de previsões normativas fechadas. Também um sistema móvel merece ainda o nome de sistema, pois nele se realizam as características da ordem e da unidade” (CANARIS, Claus-Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 280-282).

6

“Com o transcorrer das experiências históricas, institutos, conceitos, instrumentos, técnicas jurídicas, embora permaneçam nominalmente idênticos, mudam de função, de forma que, por vezes, acabam por servir a objetivos diametralmente opostos àqueles originais” (PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 141).

7

.MAIA, Roberta Mauro Medina. Vivendo nas nuvens: dados pessoais são objeto de propriedade? In: TEPEDINO, Gustavo; MENEZES, Joyceane Bezerra de (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 82.

8

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 68.

9

“Dignidade é mais que um vocábulo, e a igualdade transcende a expressão do signo linguístico. Ser sujeito de direito tem correspondido a ser *eventualmente* sujeito de direito. A susceptibilidade de tal titularidade não tem implicado concreção, efetividade. A proclamação conceitual inverte-se na realidade. Livres e iguais para não serem livres e iguais. Eis, num sentido originariamente desprovido de valor, especialmente da axiologia que recobre a vida em si mesma, a fonte de todos os direitos e princípios” (FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil à luz do novo código civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 40).

10

“Novos parâmetros para a definição da ordem pública, relendo o direito civil à luz da Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não patrimoniais e, em particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais” (TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 22).

11

“A lei aprovada proporciona ao cidadão garantias em relação ao uso dos seus dados, a partir de princípios, de direitos do titular de dados e de mecanismos de tutela idealizados tanto para a proteção do cidadão quanto para que o mercado e setor público possam utilizar esses dados pessoais, dentro dos parâmetros e limites de sua utilização. Esta é uma experiência que vem se mostrando exitosa em diversos outros países, introduzindo o paradigma do controle – pelo qual se garante ao cidadão o controle sobre seus dados, inclusive para que os divulgue e use, em oposição ao paradigma do segredo e do sigilo” (MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. Revista dos Tribunais Online, p. 22).

“A ampliação do conceito de *privacy* se deu, em grande medida, por conta da evolução das formas de divulgação e apreensão de dados pessoais. Com o advento de novas tecnologias, notadamente o desenvolvimento da biotecnologia e da Internet, o acesso a dados sensíveis e, conseqüentemente, a sua divulgação, foram facilitados de forma extrema. Como resultado, existe uma expansão das formas potenciais de violação da esfera privada, na medida em que se mostra a facilidade por meio da qual é possível o acesso não autorizado de terceiros a esses dados. Com isso, a tutela da privacidade passa a ser vista não só como o direito de não ser molestado, mas também como o direito de ter controle sobre os dados pessoais e, com isso, impedir a sua circulação indesejada” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 172).

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*, cit., p. 68.

.Na síntese de CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 18: “De qualquer forma, torna-se claro que os altos custos, na medida em que uma ou ambas as partes devem suportá-los, constituem uma importante barreira ao acesso à justiça”. Sobre o tema, v. também CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. *Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

.Art. 32, LGPD. “A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e *sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público*” (grifo nosso).

.Art. 50, LGPD. “Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, *poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização*, o regime de funcionamento, *os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares*, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. [...]”

Art. 51, LGPD. “A autoridade nacional estimulará a *adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais*”.

.Ressalve-se que, com relação a esses prazos, prevê o artigo 19, § 4º, da LGPD: “A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos I e II do *caput* deste artigo para os setores específicos”.

“Justifica-se por mais essa razão, plenamente, a *tutela geral* (abstrata) da pessoa humana, ontologicamente vulnerável, não só nas relações econômicas, como as de consumo, mas em todas as suas relações, especialmente as de natureza existencial, e a *tutela específica* (concreta), de todos os que se encontrem em situação de desigualdade, por força de circunstâncias que potencializem sua vulnerabilidade, ou que já os tenham vulnerado, como forma de assegurar a igualdade e a liberdade, expressões por excelência da dignidade humana” (BARBOZA, Heloisa Helena. Proteção dos vulneráveis na Constituição de 1988: uma questão de igualdade. In: NEVES, Thiago (Coord.). *Direito & justiça social: por uma sociedade mais justa, livre e solidária: estudos em homenagem ao Professor Sylvio Capanema de Souza*. São Paulo: Atlas, 2013. p. 109).

.Seja consentido remeter a MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. O problema da massificação das demandas consumeristas: atuação do Procon e proposta de solução à luz do direito contemporâneo. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 108, nov.-dez. 2016. p. 293: “A sociedade da informação, descrita por Stefano Rodotà como sociedade de massa, da vigilância e da classificação, impõe novos desafios à resolução dos litígios. A tendência atual é a de privilegiar soluções de autocomposição entre as partes, de conciliação e de mediação, sendo estas compreendidas como etapas necessárias e anteriores à decisão do magistrado. Sobretudo em face do alto dispêndio de recursos financeiros pela estrutura do Poder Judiciário, os meios alternativos de solução de controvérsias representam instrumentos de pacificação social e de afirmação da cidadania”.

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*, cit., p. 68.

.Ponha-se entre parênteses que a redação original da LGPD previa que tal revisão fosse feita por pessoa natural, o que foi revogado pela Lei nº 13.853/2019, destacando-se o veto presidencial ao § 3º do artigo 20.

.“Do Código à Constituição, a igualdade como exigência ética expressou, no Direito, a diferença com o respeito à diversidade. Igualdade e ausência de discriminação assentaram-se na relação da igualdade com direitos fundamentais, preservando-se, por imperativo, na igualdade a diferenciação” (FACHIN, Luiz Edson. *Direito civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 54).

.Confira-se a redação do dispositivo, com as alterações dadas pela Lei nº 13.853/2019: Art. 55-J. Compete à ANPD: I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei; III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade; VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis; IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional; X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial; XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei; XII - elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei; XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento; XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas; XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o

tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; XVII - celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei; XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos; XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; XXII - comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal; XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. § 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei. § 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. § 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei. § 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. § 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei. § 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada.

25

“[...] a Autoridade é elemento indispensável para que os direitos e garantias dos cidadãos sobre seus dados sejam efetivamente implementados e monitorados. Além de a Autoridade ser um ponto de referência e orientação para o cidadão, ocorre que o tratamento de dados pessoais é uma atividade complexa e que muitas vezes acontece de forma opaca, sendo realizado por entidades e corporações cujas práticas não são suficientemente transparentes – e que podem ser abusivas. A existência de uma Autoridade que atue de forma coordenada para prevenir e reprimir abusos, fiscalizando e tutelando tratamentos de dados de inteiras coletividades é fundamental para diminuir a distância abissal entre o cidadão e os entes que tratam seus dados, evitando que sejam abertas demandas individuais pelo caminho geralmente longo (e custoso) da via judicial” (MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil, cit., p. 23-24).

26

.FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: balanço preliminar da MP 869/2018*. Disponível em [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019]. Acesso em: 12.02.2019. V. também EBERLIN, Fernando Büscher von Teschenhausen. *As alterações na LGPD e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados*. Disponível em: [www.conjur.com.br/2019-jan-05/fernando-eberlin-lgpd-criacao-entidade-protecao-dados]. Acesso em: 12.02.2019; LEMOS, Ronaldo; DOUEK, Daniel; ADAMI, Mateus Piva; LANGENEGGER, Natalia; FRANCO, Sofia Lima. *A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela MP n. 869/2018: principais mudanças e considerações iniciais*. Disponível em [www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-

protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018#_ftn9]. Acesso em: 12.02.2019; MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor Rozatti; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. *Primeiras impressões sobre as alterações da Medida Provisória 869/2018 na LGPD: medida dá um passo na contramão da convergência normativa internacional*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-mp-autoridade-dados-pessoais-14012019]. Acesso em: 12.02.2019.

27

.RODOTÀ, Stefano. *Dal soggetto alla persona*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007. p. 35.

28

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*, cit., p. 69.

29

.Tutela-se a igualdade por meio de um direito à diferença que não implique discriminação, concebendo-se o ser humano como individual e plural a um só tempo. Nesse sentido, cf. “No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres singulares. Essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação. Através deles, os homens podem-se distinguir-se, ao invés de permanecerem apenas diferentes; a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homens” (ARENDT, Hannah. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 189).

30

.Ilustre-se: “As companhias de seguro têm notado que as análises genéticas de seus futuros clientes podem ser de capital importância para os chamados seguros de pessoa, de vida, de enfermidade e de acidentes, e com isso estabelecê-los de acordo com as condições mais ou menos rigorosas e inclusive rejeitar a celebração do contrato [...]. O acesso a essa informação poderá gerar uma nova forma de discriminação, que segregaria toda uma categoria de pessoas como ‘não asseguráveis’ [...]. Se conhecessem os dados completos de seus assegurados, as companhias poderiam praticamente eliminar, com um mínimo de incerteza do risco, e desfazer-se dos clientes ‘não convenientes’ [...]” (HAMMERSCHMIDT, Denise. Direito e discriminação genética. *Revista de Direito Privado da UEL*, Londrina, v. 1, n. 2, 2008. p. 15-16). Ainda sobre o tema da discriminação na recusa de contratação pela seguradora, mas sob a perspectiva do perfil de crédito, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que: “No que tange especificamente à recusa de venda de seguro (contratação ou renovação) a quem tenha restrição financeira junto a órgãos de proteção ao crédito, tal justificativa é válida se o pagamento do prêmio for parcelado, a representar uma venda a crédito, a evitar os adquirentes de má-fé, incluídos os insolventes ou maus pagadores, mas essa motivação é superada se o consumidor se dispuser a pagar prontamente o prêmio. De qualquer maneira, há alternativas para o ente segurador, como a elevação do valor do prêmio, diante do aumento do risco, visto que a pessoa com restrição de crédito é mais propensa a sinistros ou, ainda, a exclusão de algumas garantias (cobertura parcial)” (STJ, REsp 1.594.024/SP, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.11.2018).

31

.“Em relação ao princípio da não discriminação, fica vedada a utilização dos dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. O legislador, ao relacionar o uso discriminatório às qualidades de ilicitude e abusividade, parece reconhecer a possibilidade de tratamento distintivo, desde que lícito e não abusivo. Isto é, aparentemente, seria legítimo ao operador de dados realizar tratamentos de segregação, no sentido de diferenciação, sem que, com isso leve a consequências excludentes que poderiam ser consideradas ilícitas. Assim, por exemplo, seria legítimo a um operador de dados que esteja realizando a precificação de um serviço de seguros de automóveis, tratar de maneira diferenciada os dados de mulheres entre 35 e 45 anos e mães, com a finalidade de oferecimento de um valor que reflita os riscos de danos usualmente ocasionados ou sofridos por esse grupo determinado de pessoas. Ou seja, há a possibilidade de tratamentos discriminatórios de dados, desde que não se caracterizem pela ilicitude ou abusividade, o que será determinado segundo critérios definidos tanto pelas regras expressas de direito civil e penal, quanto por princípios como o da boa-fé objetiva” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados

peçoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18), cit., p. 164).

32

.Como observado em outra sede: “A Constituição de 1988 inaugurou, como consabido, nova ordem jurídica orientada à tutela privilegiada das situações existenciais. Em seu art. 1º, III, a Carta erigiu a dignidade da pessoa humana em fundamento de todo o sistema. No que toca ao objeto deste estudo, pode-se dizer que a axiologia constitucional representou (*rectius*, determinou) a pavimentação de uma estrada de mão dupla, interligando a Constituição aos operadores do direito. Se por um ângulo sobressai a consagrada unificação do ordenamento, por irradiação da axiologia constitucional, que não mais comporta separação estanque em diferentes microssistemas, por outro impõe-se distinta incumbência aos operadores de concretizar os comandos constitucionais irradiados — a tornar necessária a redução do distanciamento entre o legislador, o doutrinador e o magistrado, já que igualmente voltados a fazer atuar a vontade constitucional” (MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Reflexões metodológicas: a construção do observatório de jurisprudência no âmbito da pesquisa jurídica. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, jul.-set. 2016. p. 11-12).

33

.Esta foi a redação dada pela Lei nº 13.853/2019. A esse respeito, dispõe o artigo 18, § 7º, da LGPD, que “a portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do *caput* deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador”.

34

.Aqui também há a garantia de gratuidade. Confira-se: “Art. 8º. O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. [...] § 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, *por procedimento gratuito* e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do *caput* do art. 18 desta Lei”.

35

.Importante ressaltar que, consoante o artigo 18, § 6º, da LGPD, “O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional”, conforme redação dada pela Lei nº 13.853/2019.

36

.Isso se dará, segundo o dispositivo, “nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento”.

37

.Por fim, segundo o artigo 21 da LGPD, “os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo”. Na doutrina, cf. “Nessa esteira, a Lei traz direitos claros aos titulares dos dados coletados e tratados. Indubitável que o titular, vulnerável por natureza, principalmente enquanto consumidor, deverá ter conhecimento de que os dados serão coletados e tratados, além de ser garantido o acesso aos dados, a possibilidade de correção, portabilidade, revogação do consentimento e eliminação de dados, a possibilidade de coleta e tratamento anonimizado quando, por exemplo, envolver a necessidade de formação de perfil. Ainda, é certo que o titular tem o direito de obter informações sobre os terceiros com quem os dados serão compartilhados e, principalmente, sobre o direito de não fornecer consentimento nas hipóteses em que esse é exigido” (SANTOS, Fabíola Meira de Almeida; TALIBA, Rita. Lei geral de proteção de dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018. *Revista dos Tribunais Online*, p. 8).

38

.CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A lei geral de proteção de dados do Brasil na era do *big data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). *Tecnologia jurídica & direito digital*: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 357.

39

.“O primeiro eixo diz respeito ao âmbito de aplicação material da Lei, caracterizado pela generalidade e unidade: a Lei concentra-se na proteção dos dados do cidadão, independentemente de quem realiza o seu tratamento, aplicando-se, assim, tanto aos setores privado e público, sem distinção da modalidade de tratamento de dados” (DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. Reflexões iniciais sobre a nova lei geral de proteção de dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. Revista dos Tribunais Online, p. 2).

40

.Seja consentido remeter a TERRA, Aline de Miranda Valverde; CASTRO, Diana Paiva de. A responsabilidade do poder público no tratamento de dados pessoais: análise dos artigos 31 e 32 da Lei n. 13.709/2018. In: MULHOLLAND, Caitlin (Org.). *A LGPD e o novo marco normativo no Brasil*. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2020.

41

.“Existem pontos de confluência tão precisos entre o privado e o público que seria mais correto falar de Direito Civil do que de Direito Privado. Não é somente uma mudança de etiqueta. O Direito Civil não se apresenta em antítese ao Direito Público, mas é apenas um ramo que se justifica por razões didáticas e sistemáticas, e que recolhe e evidencia os institutos atinentes com a estrutura da sociedade, com a vida dos cidadãos como titulares de direitos civis. Retorna-se às origens do direito civil como direito dos cidadãos, titulares de direitos frente ao Estado. Neste enfoque, não existe contraposição entre privado e público, na medida em que o próprio direito civil faz parte de um ordenamento unitário” (PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 54-55).

42

.Como se observou em MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Subversões hermenêuticas: a Lei da Comissão da Anistia e o direito civil-constitucional. *Civillistica.com*, ano 5, n. 1, 2016.

43

.Art. 1º, CRFB/88. “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana (...)”.

44

.Nesse sentido, cf. art. 5º, CRFB/88. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [...] XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [...] LXXII – conceder-se-á *habeas data*: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

45

.Art. 37, CRFB/88. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”.

46

.TERRA, Aline de Miranda Valverde; CASTRO, Diana Paiva de. A responsabilidade do poder público no tratamento de dados pessoais: análise dos artigos 31 e 32 da Lei n. 13.709/2018, cit.

47

.Art. 6º, LAI. “Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: [...] III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; Art. 31, *caput*, LAI. “O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”.

48

.Há hipóteses, contudo, que dispensam tal consentimento. Confira-se: Art. 31, § 3º, LAI. “O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias: I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; III – ao cumprimento de ordem judicial; IV – à defesa de direitos humanos; ou V – à proteção do interesse público e geral preponderante”. V. também: Art. 31, § 4º, LAI: “A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância”.

49

.Art. 23, LGPD. [...] § 2º. “O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)”; § 3º. “Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data), da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo), e da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)”.

50

.Art. 26, LGPD. “O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei. § 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto: I – em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) [...]”.

51

Art. 52, LGPD. “Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO). X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) [...] § 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)".

52

.“A função do sistema na Ciência do Direito reside, por consequência, em traduzir e desenvolver a adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica. A partir daí o pensamento sistemático ganha também a sua justificação que, com isso, se deixa derivar mediatamente dos valores jurídicos mais elevados” (CANARIS, Claus-Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 200). V. também: “não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito no seu todo, marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas” (GRAU, Eros. *Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito*. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 101).

53

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*, cit., p. 70.

Capítulo 12. O direito à portabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados

Daniela Copetti Cravo ¹

1. Introdução

As normas de proteção de dados buscam, entre outros objetivos, empoderar os indivíduos que cedem os seus dados pessoais em troca de serviços no mercado digital. Todavia, de nada adianta conceder vários direitos aos indivíduos sem dotá-los de ferramentas efetivas para que esses busquem serviços que respeitem os seus direitos ou que tenham políticas que mais lhe agradem.

Nesse contexto, surge a portabilidade de dados como um instituto de fomento e de estímulo às migrações e ao livre trânsito dos consumidores entre diferentes serviços ou produtos no mercado digital. A portabilidade, dessa forma, apresenta uma dupla essência: além de permitir que os indivíduos exercitem o seu direito à autodeterminação informacional, busca promover a concorrência em um mercado caracterizado por grandes vencedores monopolistas e com efeitos de rede.

Tal promoção é possível por meio da redução dos custos de troca (*switching costs*) e, pois, do efeito *lock-in*, viabilizada pela portabilidade. Apesar da novidade no que toca ao campo dos dados, a portabilidade não é um instituto novo no nosso ordenamento, já sendo utilizada em outras esferas, como é o caso da telefonia e do mercado financeiro, e até mesmo aplicada como um remédio concorrencial pelas autoridades antitruste.

Com relação à portabilidade de dados, o debate sobre esse direito iniciou globalmente com o reconhecimento da necessidade dos usuários de serviços ou produtos digitais de migrar a sua lista de amigos e de contatos, endereços de *e-mail* e outros dados, que eles passaram horas adicionando, para outros serviços ou *websites*. Com efeito, os indivíduos podem gerenciar seus dados e reutilizá-los, caso assim desejem.

Ao permitir que o titular receba de volta os seus dados pessoais fornecidos a um controlador ou que esses sejam transferidos diretamente ao novo serviço desejado, o direito à portabilidade passou a ser considerado como uma nova ferramenta à luz da legislação de proteção de dados. Adiciona-se que o tema da portabilidade de dados não se encerra nos nomes e endereços de e-mail, ganhando novos contornos e extensões, tendo em vista a intensa coleta dos mais variados dados dos indivíduos.

Analisar esses novos contornos e os desafios inerentes a esses é a proposta do presente capítulo, tendo em vista que, com a edição da Lei 13.709/2018, a portabilidade de dados passou a ser um direito posto no nosso sistema, acompanhando a tendência adotada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu (RGDP)² - ³. Para realizar essa análise, o artigo utilizará o método dedutivo e, como fonte de pesquisa, consultará materiais bibliográficos, jurisprudência e legislações, nacionais e estrangeiras (nomeadamente da União Europeia, tendo em vista a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu – RGDP).

2. Natureza da portabilidade de dados

Houve, no âmbito da União Europeia e acerca do RGPD, uma discussão sobre a verdadeira natureza do direito à portabilidade dos dados, que iniciou antes mesmo da aprovação do Regulamento e quando esse era ainda um projeto. Os debates englobavam dúvidas sobre a pertinência e afinidade do instituto com a proteção de dados. Havia vozes no sentido de que a portabilidade era algo estranho e externo à proteção da privacidade⁴.

Agora, com o RGPD já em aplicação, o Grupo de Trabalho da União Europeia sustenta que o direito à portabilidade diz respeito a uma regulação de dados e não da concorrência, uma vez o novo Regulamento da União Europeia não limita o direito para aqueles que vão trocar de fornecedor⁵ - ⁶. Da mesma forma, Damien Geradin e Monika Kuschewsky⁷ defendem que a portabilidade de dados é um direito na perspectiva individual, não estando relacionada ao direito de outros fornecedores ou concorrentes de acessarem os mesmos dados.

Concorda-se que a portabilidade de dados deve existir independentemente de ser utilizada para a troca entre fornecedores; no entanto, defende-se, com apoio em Peter Gola⁸, que o instituto da portabilidade é mais próximo do direito do consumidor ou da concorrência. Dessa forma, a portabilidade tem implicações técnicas muito maiores⁹, o que não impede que essa seja enxergada como um reforço da proteção de dados, já que efetivamente, como será demonstrado na sequência, tem o condão de possibilitar o controle dos dados pelos indivíduos e a sua autodeterminação informativa.

Nessa senda, não há como deixar de reconhecer que o livre trânsito dos dados pessoais estimula a concorrência¹⁰ e, portanto, possibilita o direito de escolha do consumidor, tutelando de forma inegável o bem-estar desses. Trata-se da tutela do consumidor manejada por meio do direito da concorrência¹¹, reforçando e dando aplicabilidade aos

princípios da Ordem Econômica, nomeadamente ao princípio da livre concorrência (art. 170, inciso IV, da CF) e da defesa do consumidor (art. 170, inciso V, da CF).

Dessarte, a portabilidade, com essa natureza especial, evidencia a existência de uma intersecção entre a proteção de dados, concorrência e a defesa do consumidor. Maior exemplo dessa interface é a redução ou eliminação do *consumer lock-in* e dos *switching costs* proporcionada pela portabilidade de dados.

3. Fundamentos da portabilidade de dados

A portabilidade de dados “goes to the heart of competition policy”^{12 - 13} e tem um impacto significativo ao impedir o aprisionamento do consumidor (*consumer lock-in*) e diminuir os custos de troca (*switching costs*). Esses custos precisam ser eliminados ou reduzidos, uma vez que criam barreiras ao livre trânsito dos consumidores entre as opções disponíveis no mercado, impedindo que esses exerçam seu direito de escolha diante do efeito de aprisionamento (*lock-in effect*). Tais custos são um fator diferencial na oferta de produtos homogêneos¹⁴ e podem ser a razão pela qual não haja uma competição praticável em determinados mercados.

Em decorrência disso, os consumidores podem passar a tolerar aumentos de preços, inclusive com a imposição de preços supraconcorrenciais, ou violações a sua privacidade¹⁵. A consequência é que os consumidores podem contar com a heurística no lugar de serem guiados pela racionalidade.

Tal situação é visualizada em todos os mercados, inclusive nos digitais, ainda que nesses os custos de procura sejam reduzidos e haja certo acesso à informação. Em adição a isso, o comportamento dos consumidores em decorrência de sua vulnerabilidade, às vezes reforçada pelas suas falhas emocionais, torna os efeitos prejudiciais das práticas ainda maiores.

Especificando os custos que geram as situações narradas anteriormente, cabe apontar que existem os custos de troca e os custos de procura. Esses têm muito em comum, podendo ser aplicado o modelo de efeitos daqueles a estes. Há trabalhos que sequer distinguem esses dois tipos de custos¹⁶.

De qualquer forma, podemos definir custos de procura como o tempo e o esforço gasto em pesquisa sobre várias alternativas possíveis antes da tomada de decisão de compra. Adicionalmente, os custos de procura indicam o nível de complexidade que os consumidores enfrentam para adquirir informações sobre vendedores ou prestadores de serviços alternativos¹⁷.

Já os custos de troca são *aqueles custos que surgem quando se deseja mudar de fornecedor, os quais não acontecem quando se permanece com o atual. Com isso, há a oportunidade de o fornecedor adotar comportamentos anticompetitivos, independentemente da quantidade de empresas atuantes no mercado*¹⁸.

O custo de troca clássico é aquele em que o comprador adquire o mesmo produto ou serviço repetidamente, e, em uma nova compra, irá achar custoso trocar de um fornecedor para outro. Além do clássico, há o custo que surge em decorrência da necessidade de compra de produtos ou serviço complementares, como os de manutenção ou reparação. Nesse caso, os custos relacionam-se à mudança de fornecedor no mercado complementar ou secundário, optando-se por um fornecedor diferente daquele do produto original¹⁹.

Em resumo, os custos de troca podem ser decorrentes da confiança gozada pelo fornecedor, pelo apego à marca ou até mesmo pela comodidade. Também reforça esse efeito, o uso de uma tecnologia específica, o desejo de não perder um status particular, a personalização dos produtos, a acomodação, a habitualidade ou a familiarização²⁰. Os custos também podem ser devidos a algum investimento específico, que não seja transferível ao novo fornecedor, como é caso de equipamentos, treinamentos²¹ ou garantias por vícios redibitórios.

Com relação aos dados, fundamental produto do mercado digital, quanto mais fácil for para um consumidor portar seus dados de uma plataforma a outra, mais baixos são os seus custos de troca²². Um ponto específico do mercado digital é que os consumidores, frequentemente, desejam usar várias plataformas ao mesmo tempo (*multihoming*), o que gera mais uma necessidade de se viabilizar a redução dos custos de troca²³.

Associado ao custo de troca (e também aos custos de procura) está o efeito de aprisionamento²⁴, que é a situação na qual o consumidor torna-se dependente de um fornecedor de produto e serviço e não consegue migrar para outro sem custos de transação substanciais ou sem inconveniências, como os custos especificados acima.

Portanto, o *lock-in* é o efeito de permanência do consumidor ao fornecedor originário mesmo quando haja um desejo pela mudança, que pode ser proveniente do aumento de preços, falhas, vícios ou defeitos no fornecimento do produto ou serviço, vazamento de dados ou falta de privacidade²⁵. No entanto, quando esse consumidor faz um cálculo do custo benefício de uma eventual troca, percebe que será mais custoso, seja monetariamente, seja emocionalmente, seja em termos de conforto, trocar para um fornecedor alternativo²⁶.

Ainda, na análise do efeito de aprisionamento decorrente dos custos de troca e de procura, não se pode deixar de abordar os efeitos de rede (*network effects*). A interação desses efeitos com os custos de troca é um tema central na nova economia integrada por indústrias da tecnologia informativa²⁷, situação a qual é atribuída a denominação de *network lock-in*, ou *path-dependence*²⁸.

Esses efeitos guardam relação com a (i) compatibilidade²⁹ entre usuários, para que eles possam interagir, comerciar entre si ou usar os mesmos complementos, o que cria uma economia de escopo entre diferentes usuários³⁰, ou (ii) a situação na qual o aumento do consumo de um produto ou serviço gera o aumento do valor desse³¹, o que atrai novos e futuros usuários, que se sentirão mais atraídos pelo negócio³².

Os efeitos de rede podem ser comparados ao efeito ocorrido ao adquirirmos alguma utilidade, tal como falar uma segunda língua: essa se torna cada vez mais útil, quando outras pessoas também a falam. O mesmo acontece com o efeito de instrumentos de comunicação: o telefone celular e o aparelho de fax não eram tão úteis antes da multiplicação dos proprietários desses aparelhos.

Assim, a utilidade cresce na medida em que cresce o número de consumidores que os utilizam³³. No meio tecnológico, podemos afirmar, oferecendo outro exemplo, que um aplicativo de comunicação por mensagem só adquire relevância se houver outras pessoas que utilizem o serviço³⁴.

São beneficiadas por esses efeitos de rede as mais variadas indústrias que vão de bancos até empresas de telecomunicações. Essas se tornaram dependentes desses efeitos³⁵.

Para um serviço de busca, oferecendo um exemplo, é necessária a união entre os sites indicados e os usuários do sistema de busca. Em um *site* de hospedagem, há a relação entre hóspedes e anfitriões³⁶; em um *marketplace*, entre compradores e vendedores; em uma bandeira de cartão de crédito, entre os vendedores e os titulares dos cartões³⁷.

Cabe observar que os efeitos de rede são tão significativos que possibilitam a manutenção do poder de mercado por um longo lapso temporal, muito embora o produto ou serviço apresente um desempenho ruim ou existam outros concorrentes³⁸. Com isso, mesmo que exista um competidor mais eficiente, com tecnologia superior ou preços mais atraentes, não haverá necessariamente a troca de fornecedor, uma vez que seria necessária a migração da maioria dos usuários, já que a experiência depende desses coletivamente³⁹, ou de uma compatibilidade.

Assim, vê-se que o serviço só tem o desempenho adequado e esperado por causa do número dos usuários desse⁴⁰. Em decorrência disso, reconhece-se um problema: os novos agentes terão muita dificuldade em alcançar um efeito de rede e acabarão por incorrer no problema “do ovo e da galinha”: o serviço deles não tem valor de mercado, pois não tem muitos usuários; por outro lado, o serviço não tem muitos usuários porque não tem valor⁴¹.

A questão concorrencial nos produtos e serviços que seguem esse padrão é peculiar, já que há como regra uma competição por “tudo ou nada”. Nessa estrutura de mercado, os consumidores não buscam produtos que se adequem perfeitamente aos seus gostos pessoais, mas sim, aqueles produtos ou serviços que são vencedores, cabendo ao vencedor o mercado todo (*the winner takes it all*)⁴².

Em última análise, a variedade, importante vetor para o exercício do direito de escolha dos consumidores, resta prejudicada em mercados com efeitos de rede e com custos de troca, os quais decorrem da impossibilidade de um novo fornecedor apresentar um serviço que seja compatível com os *mainstream*⁴³. Ou seja, é difícil que um fornecedor consiga disponibilizar um serviço concorrente que possibilite a interoperabilidade dos seus usuários com os dos serviços dominantes.

Nessa esteira, intuitivo afirmar que a entrada de novos agentes em mercados em que haja efeitos de rede e custos de troca é bastante improvável, o que representa um custo social da incompatibilidade. Essa dificuldade centra-se na inexistência de base instalada para aqueles que desejem entrar e no desinteresse dos consumidores em contratar com as novas empresas, essencialmente considerado o padrão de concorrência “tudo ou nada” e *the winner takes it all*⁴⁴, já citados.

Outro ponto de extrema relevância refere-se à atividade de coleta de dados nos mercados em que há o efeito de rede. Quanto mais consumidores são atraídos pelo valor do produto ou serviço, mais dados poderão ser coletados, o que incrementa o outro lado do mercado, qual seja, os de serviços de publicidade nos modelos de mercado de dois lados⁴⁵, e gera uma vantagem competitiva.

Na maioria dos casos, os dados dos usuários não podem ser extraídos quando esses desejam migrar para um concorrente, uma vez que só será possível a mudança de plataforma ao custo de deixar essa com a consequente perda seus dados⁴⁶. Percebe-se, assim, a situação colocada aos usuários: se houver aumento do preço do serviço, diminuição da proteção de privacidade, perda de qualidade, entre outros casos, o usuário fica totalmente desprotegido, já que reduzido o seu poder de negociação. Assim, ou fica e aceita as novas condições impostas, ou sai sem seus dados abastecidos ao longo do tempo⁴⁷. Eis, portanto, a configuração do aprisionamento, em que os custos de troca se referem à retenção dos dados.

Para agravar ainda mais a situação, relata-se que o risco de aprisionamento é a regra, e não a exceção no que toca a plataformas *on-line*. Há incentivos e interesse das empresas em manter seu sistema fechado, o que gera problemas de acesso a outras empresas que necessitem dos dados dos usuários para competir ou oferecer serviços e produtos complementares⁴⁸.

No serviço de busca, que é aquele em que o consumidor procura informações, sendo exemplos o Google, o Yahoo, o Bing, os custos de troca entre os mecanismos são altos. Cabe ressaltar que o aprisionamento é desejado por essas empresas, já que quanto mais usuários um serviço de busca possui, mais atrativo ele é para publicidade.

Da mesma forma, nos *marketplaces on-line*, que são as plataformas em que o consumidor compra, vende e compartilha produtos e serviços, há custos de troca, especialmente nos lados dos vendedores da plataforma de comércio. A respeito, cita-se a reputação e comentários sobre as vendas, que podem ser considerados como um investimento específico da plataforma, sendo dependentes do número de transações já realizadas⁴⁹.

Para os consumidores, apesar de existir baixos custos de troca, como regra, nos *marketplaces on-line*, esses podem ser impostos por meio da cobrança de taxa para deixar o serviço. Ademais, a familiarização com as regras da plataforma e sua forma de utilização podem gerar o efeito de aprisionamento⁵⁰.

Com relação às redes sociais, que possuem como *main sides* os usuários e as publicidades, os custos de troca são grandes. Apesar de ser possível obter cópia de certos dados, a transferência de um perfil a um serviço concorrente requer tempo e esforço, tendo em vista que não existe a possibilidade de extrair os dados em um formato que possa facilmente ser importado por outra rede social correspondente⁵¹.

Além disso, contatos e informações compartilhadas, como mensagens, comentários e fotografias, como regra, não podem ser transferidos para outras plataformas.

Relevante é constatar a incompatibilidade que gera o *network lock-in*: os usuários não podem se comunicar por meio de diferentes plataformas (interplataformas), com isso eles têm o estímulo de utilizar, como regra, as maiores redes para poder interagir plenamente com o maior número de usuários possíveis⁵². Tais preocupações poderiam, no entanto, ser atenuadas pela disposição por parte das redes sociais de mecanismos que facilitem a exportação de dados, segundo aponta Christopher Yoo⁵³.

No mercado de serviços de nuvem (*Cloud Computing*), que é conceituado como um modelo que permite um acesso ubíquo, conveniente e sob demanda (*on-demand*) a um conjunto de recursos configuráveis de computador, tais como os de infraestrutura, de software e de plataforma⁵⁴, os custos de troca são acentuadamente elevados, sendo necessária uma interoperabilidade e portabilidade para que os usuários possam utilizar outros serviços de nuvem⁵⁵.

Dessa forma, de uma maneira geral e independente do mercado, conforme visto anteriormente, caso um usuário deseje trocar de plataforma ou serviço, precisará fazer investimentos complementares e elevados para fornecer novamente os dados, quando isso for possível. Nesse caso, os custos que serão gerados podem ser considerados como *sunk costs*⁵⁶, que são aqueles custos irrecuperáveis incorridos no passado⁵⁷.

Os efeitos dessa situação podem ser observados não só nos concorrentes diretos (substitutos), mas também nos serviços complementares. Nesses dois cenários, o número de usuários é positivamente correlacionado com o volume e a qualidade dos dados. E o volume e a qualidade dos dados relacionam-se com a variedade e qualidade dos produtos e serviços, uma vez que as empresas podem oferecer melhores produtos ao analisar melhor o comportamento dos usuários e ao extrair os dados obtidos com o oferecimento do serviço⁵⁸.

Aqui emerge a importância e a explicação de por que a portabilidade é importante. Primeiramente, com relação aos serviços substitutos, se não existe a exigibilidade da portabilidade, um agente com grande poder de mercado pode impedir que outros entrem no mercado. Isso ocorre porque os usuários não podem migrar entre plataformas, exceto se incorrerem em altos custos, uma vez que não podem levar consigo os dados⁵⁹.

Portanto, com a portabilidade haverá a inciativa de novos agentes econômicos entrantes, sendo mais fácil atrair novos consumidores, uma vez que esses saberão que os dados investidos em uma plataforma incumbente não serão perdidos. Nesse compasso, é possível afirmar que a criação de novos modelos de negócios passa a ser estimulada a partir do momento em que se facilita a mobilidade de dados entre diferentes fornecedores⁶⁰.

Bárbara Engels⁶¹ ressalta, entretanto, que quando não há abuso de posição dominante no mercado, a portabilidade de dados pode gerar efeitos negativos, no sentido das empresas terem receio de fazer grandes investimentos de longo prazo, já que é muito provável que haja a perda dos consumidores quando um novo competidor atraente entrar no mercado. Além disso, pequenas empresas podem não entrar no mercado diante da impossibilidade de *compliance* com as regras de portabilidade, que podem ser custosas.

Christopher Yoo⁶² expressa preocupação com uma imposição de padronização de formatos de dados, já que isso ameaça a estrutura das interações, podendo limitar a funcionalidade de sistemas como as redes sociais. Ademais, o imediatismo e a curta duração de grande parte da informação disponível nas redes sociais poderia dispensar a necessidade de portar os dados históricos.

No entanto, isso é apenas um possível efeito colateral da portabilidade. De maneira geral, como se viu anteriormente, a portabilidade em muito estimula o mercado e traz inúmeros benefícios, especialmente no que toca ao bem-estar do consumidor.

4.A portabilidade de dados na nova Lei

O direito à portabilidade de dados não estava presente em todos os projetos de lei que versavam sobre a criação de uma lei geral de proteção de dados. Dos projetos em trâmite antes da aprovação final, apenas o PL 5.276/2016 trazia como um direito do titular a portabilidade dos dados⁶³, no seu artigo 18, inciso V.

Em 2018, ocorreu a apreciação do PL 4.060/2012 pela Câmara dos Deputados, estando em apenso à proposição principal o PL 5.276/2016 e o PL 6.291/16. Houve a proposta de um substitutivo e de emendas. Esses restaram prejudicados, sendo aprovada ao final a Subemenda substitutiva global, a qual previa o direito de portabilidade de dados.

Na sequência, o projeto de lei foi aprovado pelo Senado e encaminhado para sanção presidencial. Em 14 de agosto de 2018, esse é transformado na Lei Ordinária 13.709/2018, com veto parcial.

Pois bem, na nova Lei, o direito à portabilidade de dados está previsto no artigo 18, inciso V. A redação originária desse inciso era a seguinte:

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

[...]

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador;

Com a Lei 13.853/2019, que converteu a Medida Provisória 869/2018, a redação do inciso V acabou sofrendo uma pequena modificação. Dessa forma, atualmente, temos a seguinte previsão normativa:

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial⁶⁴;

Trata-se de um dos direitos conferidos ao titular dos dados pessoais. Nesse inciso, consta que a portabilidade será realizada mediante requisição expressa do titular (como também dispõe o § 3º do artigo 18) e operará por meio da transferência dos dados de um fornecedor a outro. Tal disposição dá a entender que a transferência será direta entre os fornecedores.

Constam também, no § 4º do mesmo artigo 18, as medidas a serem tomadas pelo fornecedor caso haja impossibilidade de adoção imediata da portabilidade, podendo inclusive o fornecedor alegar que não é o agente de tratamento dos dados, comunicando, se possível, quem é o agente.

Para que a portabilidade possa produzir todas as suas potencialidades, é indispensável que o usufruto do direito seja facilitado, como coloca Ana Frazão⁶⁵: “o direito à portabilidade, para atingir tais propósitos, deve ser fácil, gratuito e assegurado de modo a permitir a usabilidade dos dados com ciência e segurança”. Seguindo essa linha, o legislador, de maneira pertinente, determinou, no § 5º do artigo 18, que a portabilidade seja realizada sem custos para o titular.

Quanto à abrangência do direito, é possível afirmar que esse se aplica, nos moldes do artigo 3º, às pessoas naturais em qualquer operação de tratamento realizado por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente de sua sede ou país onde estejam localizados os seus dados, desde que (i) a operação seja realizada no território nacional, (ii) a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou (iii) os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

No entanto, não se aplica o direito à portabilidade, já que excluídos do âmbito de aplicação da Lei 13.709/2018 (art. 4º), ao tratamento de dados (i) realizado por pessoa natural para fins exclusivamente pessoais; (ii) realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, ou acadêmicos; (iii) realizado para fins exclusivos de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado ou de atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou (iv) provenientes de fora do território nacional, nos termos previstos no inciso IV do artigo 4º da Lei 13.709/2018.

Da mesma forma como acontece no RGPD (considerando número 26), não estão abrangidos na portabilidade os dados anônimos, conforme dispõe o § 7º do artigo 18 da Lei 13.709/2018. Todavia, defende-se que sempre que for possível identificar o titular dos dados por meio do fornecimento de informações adicionais, tais dados devem ser abrangidos pela portabilidade, como se tem sido defendido no âmbito europeu, com apoio no artigo 11 do Regulamento⁶⁶. Assim, os dados pseudonimizados estariam abrangidos na portabilidade.

Ainda, enquanto o RGDP limitou a abrangência da portabilidade aos dados pessoais “fornecidos”, o que representa significativa mudança do texto final com relação ao projeto inicial⁶⁷, a lei brasileira não trouxe uma previsão específica acerca de quais dados estariam abarcados na portabilidade, muito embora no caput do artigo 18 haja menção que os direitos do titular são relacionados aos “dados tratados” pelo controlador.

Na verdade, será necessária uma maior reflexão no que toca à ausência de definição específica no inciso V do artigo 18. Ainda resta controverso se tal ausência pode ser interpretada como o desejo do legislador de abarcar todos os “dados tratados” (isto é, fornecidos, observados e inferidos), ou se tal definição foi reservada à regulamentação. Quanto à forma de exercício da portabilidade, a lei brasileira limitou-se a disciplinar o direito do titular de ter os dados transmitidos diretamente de um controlador a outro⁶⁸. Diferentemente, o RGDP traz três possibilidades no seu artigo 20, quais sejam: (i) o direito de receber os dados pessoais que foram fornecidos pelo titular desses; (ii) o direito de transmissão desses dados a outro controlador, sem quaisquer obstáculos; e (iii) o direito de ter os dados transmitidos diretamente de um controlador a outro.

Em decorrência disso, indaga-se: será que os indivíduos, à luz da legislação brasileira, teriam direito de receber seus dados, independente de querer utilizar em outro serviço/controlador? Com base em uma interpretação sistemática, a resposta é positiva.

Como elucida Ana Frazão⁶⁹,

o fato de a definição brasileira fazer menção à transferência para outro controlador obviamente não afasta a possibilidade de o usuário obter diretamente tais dados do antigo controlador e gerenciá-los pessoalmente, transferindo ou não, em momento futuro, para um novo controlador.

Quanto à interoperabilidade, que é a adoção ou manutenção de sistemas ou plataformas tecnológicas de tratamento de dados que sejam tecnicamente compatíveis, a Lei possibilita, no seu artigo 40, que a autoridade nacional disponha de padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade. No âmbito europeu, o RGPD (no considerando 68) apenas estimula e encoraja que os responsáveis pelo tratamento de dados desenvolvam formatos interoperáveis que permitam a portabilidade dos dados.

Como, até a edição de uma regulação no Brasil, não há a necessidade da interoperabilidade entre os serviços, se aparecerem barreiras técnicas quando da execução de uma portabilidade, o controlador deverá explicar essas barreiras ao indivíduo requerente de maneira inteligível e clara⁷⁰, à luz do § 4º do artigo 18 da Lei.

Ainda, é possível que o direito de portabilidade entre em conflito com outros direitos, como o de segredo industrial ou de proteção de criações intelectuais. Outro problema que pode emergir refere-se ao direito de privacidade de terceiros, quando, por exemplo, um indivíduo deseja portar uma foto na qual várias pessoas apareçam.⁷¹

Nesse caso, é possível invocar o do § 4º do artigo 18 da Lei, diante de uma razão de direito que impeça a adoção da portabilidade. Há também ressalva expressa no inciso V do artigo 18, que determina que a portabilidade observará os segredos comercial e industrial⁷².

Deve-se ressaltar que a aplicação dessa norma não deve ocorrer em qualquer caso de possível dano aos direitos dos outros, mas sim quando a portabilidade os afete de forma adversa, isto é, de maneira injustificada ou ilegítima. Isso reclama, dessarte, um *case-by-case approach*.⁷³

Uma sensibilidade da portabilidade que merece mais atenção diz respeito aos riscos que a portabilidade possa causar, ainda que de forma indireta, à privacidade. Uma vez que os dados se tornam completamente portáveis, é muito fácil evadir quaisquer restrições de privacidade existentes naquele fornecedor originário, a quem foi solicitada a portabilidade.

Nesse caso, bastaria transferir os dados a uma nova plataforma, que as antigas regras e políticas não precisariam mais ser observadas.⁷⁴ Além disso, pode haver fraudes na identificação dos usuários que permitiriam a um *hacker* facilmente portar os dados entre várias plataformas⁷⁵.

Observa-se, ademais, que o exercício do direito à portabilidade de dados não implica o encerramento da relação estabelecida entre o titular e o controlador (transmissor), exceto se assim manifestar o titular^{76 - 77}. Nesse último caso, o exercício do direito à portabilidade implicará o término do tratamento dos dados, após a sua transferência, razão pela qual pode ser denominada de “portabilidade de dados estrito senso” ou “portabilidade de dados propriamente dita”.

Por fim, o artigo 16 da Lei permite a conservação dos dados, mesmo após o término do seu tratamento, para fins de portabilidade (inciso III do mencionado artigo). Evidentemente, mesmo após a portabilidade, poderá haver a conservação dos dados, caso esteja presente alguma das outras hipóteses previstas nos incisos do artigo 16, tais como a necessidade de cumprimento de obrigação legal.

5. Considerações finais

Ao mesmo tempo em que a portabilidade é uma das maiores inovações trazidas com a Lei 13.709/2018, ela também representa um dos maiores desafios ao mercado. Preocupações quanto à segurança na transmissão dos dados ou quanto à interoperabilidade são inevitáveis.

Há, ainda, o receio de que a observância das regras de portabilidade possa se tornar um ônus muito grande para as pequenas empresas, o que gerará um desestímulo de entrada e também de permanência no mercado. Ao longo prazo, isso poderá ensejar concentração de poder de mercado por grandes empresas, resultado contraditório para um direito que busca reduzir o *lock-in* e promover a concorrência. Espera-se que uma possível resposta a esse problema seja endereçada tempestivamente pela autoridade reguladora.

Adiciona-se que essas e várias outras preocupações só poderão ser bem enfrentadas com o próprio início da aplicação do direito à portabilidade, bem como com a sua eventual regulamentação, o que permitirá uma investigação real e simultânea do fenômeno. De qualquer forma, já se faz o alerta de que qualquer instituto na área de portabilidade de dados deve ser implementado ao lado de políticas de segurança.

Por fim, defende-se que o direito da portabilidade não pode prevalecer e prejudicar direitos e liberdades de terceiros. Ponderação e razoabilidade na regulamentação da lei pela autoridade competente serão não só

necessárias como também desejadas.

Em última análise, privilegiar a escolha dos indivíduos é sempre o melhor caminho. Felizmente, foi o escolhido com a edição da tão necessária e esperada Lei Geral de Proteção de Dados.

6. Referências bibliográficas

AFUAH, Allan. Are network effects really all about size? The role of structure and conduct. *Strategic Management Journal*, v. 34, p. 257-273, 2013.

ALSTYNE, Marshall Van. *A platform strategy: creating new forms of value in the digital age*. Capgemini Consulting, 2016.

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. *Guidelines on the right to data portability*. Brussels: European Commission, 2016.

BALFOUR, Brian. *Achieving the network effect: solving the chicken or the egg*. Disponível em: [https://brianbalfour.com/essays/the-network-effect-marketplaces]. Acesso em: 22.01.2018.

BIONI, Bruno. *Xeque-mate: o tripé da proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil*. São Paulo: GPoPAI/USP, 2015.

BOARDMAN, Ruth; MOLE, Ariane; MALDOFF, Gabe. *The article 29 working party issues final guidelines on the right to data portability*. Disponível em: [www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/article-29-working-party-issues-final-guidelines-on-the-right-to-data-portability]. Acesso em: 14.01.2018.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Nota Conjunta 8/SENACON-CADE. *Análise sobre interface entre política de defesa do consumidor e defesa da concorrência*. Disponível em: [www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-no-08-senacon-e-cade.pdf]. Acesso em: 06.03.2018.

CHEN, Pei-yu; HITT, Lorin. *Information technology and switching costs*. Disponível em: [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.1995&rep=rep1&type=pdf]. Acesso em: 19.01.2018.

CONWAY, Carol Elizabeth. Concorrência: a Lei 12.529/2011 e os e-mercados. In: CARVALHO, Vinicius, Marques. *A Lei 12.529/2011 e a nova política de defesa da concorrência*. São Paulo: Singular, p. 255-268, 2015.

CSERES, Kati J. The impact of consumer protection on competition and competition law the case of deregulated markets. *Amsterdam Center for Law & Economics Working Paper*, n. 05, 2006. p. 4.

DZHAIN, Nikita. *Impact of switching costs and network effects on adoption of mobile platforms*. Dissertação (Mestrado em Sistemas da Informação). Aalto University School of Business, Helsinque, Finlândia, 2014.

ENGELS, Bárbara. Data portability among online platforms. *Internet Policy Review*, 5(2), 2016.

EURICH, Markus; BURTSCHER, Michael. *The business-to-consumer lock-in effect*. Cambridge: University of Cambridge, 2014.

EUROPEAN DATA PROTECTION REGULATION . *Privacy and competitiveness in the age of big data: the interplay between data protection, competition law and consumer protection in the digital economy*. Disponível em: [https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competition_law_big_data_en.pdf]. Acesso em: 26.12.2018.

FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Coordination and lock-in: competition with switching costs and network effects. In: ARMSTRONG, Mark; PORTER, Robert. *Handbook of Industrial Organization*. North-Holland: Elsevier, 2007. v. 3.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: direito à portabilidade*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-direito-a-portabilidade-07112018]. Acesso em: 05.01.2019.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: ainda sobre o direito à portabilidade*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-ainda-sobre-o-direito-a-portabilidade-14112018]. Acesso em: 05.01.2019.

GERADIN, Damien; KUSCHEWSKY, Monika. *Competition law and personal data: preliminary thoughts on a complex issue*. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216088]. Acesso em: 25.12.2017.

GOLA, Peter. *Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/67*. Munich: C.H. Beck, 2018.

GRAEF, Inge. *Data portability at the crossroads of data Protection and competition policy*. Roma: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Osservatorio di Proprietà Intellettuale Concorrenza e Comunicazioni, 2016.

HERT, Paul; PAPAKONSTANTINO, Vagelis; MALGIERI, Gianclaudio; BESLAY, Laurent; SANCHEZ, Ignacio. The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, p. 1-11, 2017.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. *Supporting Data Portability in the Cloud Under the GDPR*. Disponível em: [http://alicloud-common.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/Supporting_Data_Portability_in_the_Cloud_Under_the_GDPR.pdf?spm=a3c0i.170826.889865.14.6a7c5d44kKqXFP&file=Supporting_Data_Portability_in_the_Cloud_Under_the_GDPR.pdf]. Acesso em: 21.01.2018.

MURRAY, Kyle; HÄUBL, Gerald. Explaining cognitive lock-in: the role of skill-based habits of use in consumer choice. *Journal of Consumer Research*, v. 34, p. 1-12, june 2007.

OFFICE OF FAIR TRADE. *Switching costs*. Londres: OFT, 2003.

PARKER, Geoffrey; ALSTYNE, Marshall. Two-Sided Network Effects: A Theory of Information Product Design. *Management Science*, v. 51, n. 10, p. 1494-1504, october 2005.

PUCCINELLI, Oscar. El derecho a la portabilidad de los datos personales. Orígenes, sentido y alcances. *Pensamiento Constitucional* N° 22, p.203-228, 2017.

SWIRE, Peter; LAGOS, Yianni. Why the right to data portability likely reduces consumer welfare: antitrust and privacy critique. *Maryland Law Review*, n. 3, p. 335-380, 2013.

WANG, Henry; YANG, Bill. Fixed and sunk costs revisited. *Journal of Economic Education*, Spring, 2001.

YOO, Christopher. When antitrust met Facebook. *George Mason Law Review*, v. 19:5, p. 1147-1162, 2012.

YOSIFON, David. Consumer lock-in and the theory of the firm. *Seattle University Law Review*, v. 35:1429, p. 1430-1467, 2012.

ZANFIR, Gabriela. The right to data portability in the context of the EU data protection reform. *International Data Privacy Law*, p. 1-14, 2012.

1

Procuradora do Município de Porto Alegre. Doutora em Direito pela UFRGS. Pós-Doutoranda no PPGDir da UFRGS.

2

No âmbito europeu, temos o artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu (RGPD). Esse artigo dispõe que “o titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir”.

3

A portabilidade de dados também está prevista na California Consumer Privacy Act (CCPA) dos Estados Unidos da América. No México, também há o direito à portabilidade de dados, muito embora esse seja limitado ao setor público (PUCCINELLI, Oscar. El derecho a la portabilidad de los datos personales. Orígenes, sentido y alcances. *Pensamiento Constitucional* N° 22, p.222, 2017).

4

GOLA, Peter. *Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/67*. Munich: C.H. Beck, 2018.

5

Article 29 Data Protection Working Party. *Guidelines on the right to data portability*. Brussels: European Commission, 2016. p. 3.

6

Essa ênfase foi criticada por especialistas na área de proteção de dados, que defendem que a concorrência é um elemento do direito de portabilidade e deveria constar no trabalho desempenhado pelo grupo de trabalho. BOARDMAN, Ruth; MOLE, Ariane; MALDOFF, Gabe. *The Article 29 Working Party Issues Final Guidelines on the right to data portability*. Disponível em: [www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/article-29-working-party-issues-final-guidelines-on-the-right-to-data-portability]. Acesso em: 14.01.2018.

7

GERADIN, Damien; KUSCHEWSKY, Monika. *Competition law and personal data*: preliminary thoughts on a complex issue. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216088]. Acesso em: 25.12.2017.

8

GOLA, Peter. Op. cit.

9

ZANFIR, Gabriela. The right to Data portability in the context of the EU data protection reform. *International Data Privacy Law*, p. 1, 2012.

10

.Article 29 Data Protection Working Party. Op. cit., p. 3.

11

.Nesse sentido, a Nota Conjunta da SENACON e do CADE afirma que “as políticas de concorrência e do consumidor compartilham o mesmo objetivo: o bem-estar dos consumidores”. BRASIL. Ministério da Justiça. Nota Conjunta 8/SENACON-CADE. *Análise sobre interface entre política de defesa do consumidor e defesa da concorrência*. Disponível em: [www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-no-08-senacon-e-cade.pdf]. Acesso em: 06.03.2018.

12

.GRAEF, Inge. Op. cit., p. 2.

13

Tradução livre autora: “está no âmago da política da concorrência”.

14

.DZHAIN, Nikita. *Impact of switching costs and network effects on adoption of mobile platforms*. Dissertação (Mestrado em Sistemas da Informação). Aalto University School of Business, Helsinque, Finlândia, 2014. p. 11.

15

.CSERES, Kati J. The impact of consumer protection on competition and competition law the case of deregulated markets. *Amsterdam Center for Law & Economics Working Paper*, n. 5, p. 4, 2006.

16

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Coordination and lock-in: competition with switching costs and network effects. In ARMSTRONG, Mark; PORTER, Robert. *Handbook of industrial organization*. North-Holland: Elsevier, 2007. v. 3. p. 1978.

17

.DZHAIN, Nikita. Op. cit., p. 14.

18

.BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit.

19

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1972.

20

.EURICH, Markus; BURTSCHER, Michael. *The business-to-consumer lock-in effect*. Cambridge: University of Cambridge, 2014. p. 2.

21

.OFFICE OF FAIR TRADE. *Switching Costs*. Londres: OFT, 2003. p. 11.

22

.ENGELS, Bárbara. Data portability among online platforms. *Internet Policy Review*, 5(2), 2016.

23

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

24

.Na pesquisa realizada, encontraram-se estudos que tratam o aprisionamento (*lock-in*) como um desdobramento dos custos de troca e outros que tratam o *lock-in* como sendo sinônimo de custos de troca. Sobre essa última hipótese, cita-se o seguinte estudo: EURICH, Markus; BURTSCHER, Michael. Op. cit., p. 3.

25

.EURICH, Markus; BURTSCHER, Michael. Op. cit., p. 2.

26

.MURRAY, Kyle; HÄUBL, Gerald. Explaining Cognitive Lock-In: The Role of Skill-Based Habits of Use in Consumer Choice. *Journal of Consumer Research*, v. 34, June 2007. p. 2.

27

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1971.

28

.YOSIFON, David. Consumer Lock-In and the Theory of the Firm. *Seattle University Law Review*, vol. 35:1429, 2012. p. 1456.

29

.É o caso de um serviço de *e-mail*, em que o usuário não precisa só que esse seja de fácil uso ou gratuito, mas também depende que outras pessoas tenham *e-mail* e que esses sejam entre si compatíveis. AFUAH, Allan. Are network effects really all about size? The role of structure and conduct. *Strategic Management Journal*, 34, 2013. p. 257.

30

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1971.

31

.CHEN, Pei-yu; HITT, Lorin. *Information technology and switching costs*. Disponível em: [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.1995&rep=rep1&type=pdf]. Acesso em: 19.01.2018. p. 15.

32

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

33

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 2007.

34

.BALFOUR, Brian. *Achieving the network effect: solving the chicken or the egg*. Disponível em: [https://brianbalfour.com/essays/the-network-effect-marketplaces]. Acesso em: 22.01.2018.

35

.AFUAH, Allan. Are network effects really all about size? The role of structure and conduct. *Strategic Management Journal*, v. 34, p. 257, 2013.

36

.ALSTYNE, Marshall Van. *A platform strategy: creating new forms of value in the digital age*. Capgemini Consulting, 2016.

37

.PARKER, Geoffrey; ALSTYNE, Marshall. Two-sided network effects: a theory of information product design. *Management Science*, v. 51, n. 10, p. 1504, october 2005.

38

.BALFOUR, Brian. Op. cit.

39

.CHEN, Pei-yu; HITT, Lorin. Op. cit., p. 15.

40

.Idem.

41

.BALFOUR, Brian. Op. cit.

42

.FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Op. cit., p. 1975.

43

.Ibidem, p. 1972.

44

.Idem.

45

.EUROPEAN DATA PROTECTION REGULATION. *Privacy and competitiveness in the age of big data: the interplay between data protection, competition law and consumer protection in the digital economy*. Disponível em: [https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competition_law_big_data_en.pdf]. Acesso em: 26.12.2018, p. 35.

46

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

47

.Idem.

48

.Idem.

49

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

50

.Idem.

51

.Idem.

52

.Idem.

53

.YOO, Christopher. When antitrust met Facebook. *George Mason Law Review*, v. 19:5, 2012. p. 1155

54

.INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. *Supporting Data portability in the cloud under the GDPR*. Disponível em: [http://alicloud-common.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/Supporting_Data_Portability_in_the_Cloud_Under_the_GDPR.pdf?spm=a3c0i.170826.889865.14.6a7c5d44kKqXFP&file=Supporting_Data_Portability_in_the_Cloud_Under_the_GDPR.pdf]. Acesso em: 21.01.2018.

55

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

56

.DZHAIN, Nikita. Op. cit., p. 74.

57

.WANG, Henry; YANG, Bill. Fixed and sunk costs revisited. *Journal of Economic Education*. Spring, 2001. p. 179.

58

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

59

.Idem.

60

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

61

.Idem.

62

.YOO, Christopher. Op. cit., p. 1155.

63

.BIONI, Bruno. *Xeque-mate: o tripé da proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil*. São Paulo: GPOPAI/USP, 2015, p. 57.

64

Entende-se que a modificação foi positiva, já que com a nova redação não haverá dúvidas se a regulamentação será da portabilidade de dados ou apenas da observância do segredo comercial e industrial.

65

.FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: direito à portabilidade*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-direito-a-portabilidade-07112018]. Acesso em: 05.01.2019.

66

.INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. Op. cit.

67

.HERT, Paul; PAPAKONSTANTINO, Vagelis; MALGIERI, Gianclaudio; BESLAY, Laurent; SANCHEZ, Ignacio. The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services, *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 2017.

68

Cada legislação tem definido de forma diversa o direito à portabilidade de dados. Algumas enfocam no direito à transmissão direta dos dados a um novo controlador, outras no direito de receber os dados e armazená-los em algum dispositivo pessoal.

69

.FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: ainda sobre o direito à portabilidade*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-ainda-sobre-o-direito-a-portabilidade-14112018]. Acesso em: 05.01.2019.

70

.INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. Op. cit.

71

.SWIRE, Peter; LAGOS, Yianni. Why the right to data portability likely reduces consumer welfare: antitrust and privacy critique. *Maryland Law Review*, n. 3, 2013. p. 349.

72

A LGPD não define em que medida ou em que grau esse interesse deve ser observado, nem conceitua o que pode ser considerado como segredos comercial e industrial.

73

.HERT, Paul; PAPAKONSTANTINO, Vagelis; MALGIERI, Gianclaudio; BESLAY, Laurent; SANCHEZ, Ignacio. Op. cit.

74

.YOO, Christopher. Op. cit., p. 1155.

75

.ENGELS, Bárbara. Op. cit.

76

Percebe-se, portanto, que haverá casos que o titular de dados deseja permanecer no serviço, pedindo apenas que os dados sejam “duplicados” e enviados a um outro controlador. Veja que um ponto peculiar do mercado digital é que os consumidores, frequentemente, desejam usar várias plataformas ao mesmo tempo (multihoming), o que gera mais uma necessidade de se viabilizar a redução dos custos de troca (Engels, Bárbara. Data portability among online platforms. *Internet Policy Review*, 5(2), 2016.), a qual é possibilitada por essa forma de exercício do direito à portabilidade de dados pessoais.

Como regra, não há o encerramento do tratamento dos dados pelo simples exercício da portabilidade, exceto se a intenção do titular for pelo encerramento da relação (portabilidade estrito senso) e a eliminação dos dados ou se estiverem presentes quaisquer das hipóteses de término de tratamento dos dados (artigo 15 da LGPD).

Capítulo 13. Direito ao Esquecimento e Proteção de Dados Pessoais na Lei 13.709/2018: distinções e potenciais convergências

Anderson Schreiber ¹

1. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o chamado direito ao esquecimento

Diariamente, cerca de 700 mil pessoas passam por algumas estações de metrô em São Paulo, tendo seus rostos filmados por câmeras que “adivinham” suas emoções. Os passageiros são classificados como “adulto feliz”, “jovem triste”, “mulher com raiva”, entre outros rótulos. O objetivo dessa iniciativa, intitulada *Portas Digitais*, consiste declaradamente em categorizar os usuários do metrô para exibir publicidade personalizada, dirigida ao seu específico estado emocional. “E quase não tem como escapar”, pois, como revela o nome do “projeto”, as câmeras ficam posicionadas justamente nas portas dos vagões.²

A proteção dos dados pessoais é certamente um dos mais sensíveis desafios que o direito contemporâneo enfrenta, em decorrência do extraordinário avanço tecnológico verificado nas últimas décadas. No Brasil, a proteção de dados pessoais encontra seu fundamento normativo na Constituição da República, que proclama no inciso X do artigo 5º a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Doutrina e jurisprudência reconhecem que o direito à privacidade abrange, hoje, não apenas a proteção à vida íntima do indivíduo, mas também a proteção de seus dados pessoais, alcançando qualquer ambiente no qual circulem dados de uma pessoa humana. É certo que, longe de representar “informações sem dono” livremente coletáveis na internet, esse conjunto de dados exprime uma abrangente projeção da personalidade humana, exigindo firme proteção da ordem jurídica.

Até 2018, o direito à proteção de dados pessoais encontrava tutela meramente reflexa em nossa legislação, sendo tangenciado por leis esparsas ou setoriais, como o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014),³ o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990),⁴ e a Lei do *Habeas Data* (Lei 9.507/1997). Já o artigo 21 do Código Civil, embora verse sobre a proteção à privacidade em termos amplos, representa, a rigor, uma inútil duplicação do que já afirma a própria Constituição da República.⁵ Diante da insuficiência dessas disposições, os esforços para a construção sistemática de um direito à proteção de dados pessoais no Brasil acabaram recaindo sobre a doutrina.⁶ Tais esforços, associados a uma bem-sucedida estratégia de articulação política e à confluência de fatores externos,⁷ conduziram, não sem algum atraso, à aprovação da Lei 13.709/2018, a *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. O texto tem sido merecidamente

elogiado pela comunidade científica, representando um importante avanço da ordem jurídica de nosso país na proteção dos direitos fundamentais de seus cidadãos.

Poucos meses antes, em 25 de maio de 2018, entrara em vigor o *Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia*, mais conhecido como *GDPR* (*General Data Protection Regulation*), a mais importante normativa sobre o tema da proteção de dados no mundo. Aprovado pelo Parlamento Europeu em 2016 para substituir a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), o novo *GDPR* manteve-se fiel à tradição europeia de efetiva preocupação com a questão da privacidade e da proteção de dados, significando não uma ruptura com o sistema anterior, mas sim seu aprofundamento. Embora aplicável formalmente apenas no âmbito da União Europeia, a regra tem, na prática, alcance mundial, em razão da integração global típica da internet e da relevância do bloco europeu no contexto econômico internacional.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é marcadamente influenciada pelo *GDPR*. A diferença mais evidente entre os dois conjuntos de normas é o grau de detalhamento: enquanto o Regulamento europeu possui 99 artigos que disciplinam os mais diversos aspectos do tratamento de dados pessoais de modo minucioso, nossa lei conta com 65 artigos (alguns deles inteiramente vetados), muito mais “enxutos”. Longe de evidenciar qualquer defeito, essa distinção explica-se pela diferença de contextos e experiências. O problema da proteção de dados é objeto de atenção pelos países europeus há décadas, já tendo sido, inclusive, tratado em leis anteriores, enquanto, no Brasil, ainda estamos dando os primeiros passos na matéria. Além disso, o *GDPR* é um regulamento comunitário, destinado a vigorar em países com diferentes sistemas e tradições jurídicas, o que exige, muitas vezes, contenções da norma comunitária. Peculiaridades à parte, a proximidade entre os dois conjuntos normativos é notável.

Aspecto relevantíssimo, que consiste no objeto deste breve ensaio, é a referência expressa do *GDPR* europeu a um “direito a ser esquecido” (artigo 17), expressão que não encontra paralelo na lei brasileira. Teria, com isso, o legislador brasileiro se afastado decididamente da tendência europeia de reconhecimento do chamado direito ao esquecimento? Ou, por outro lado, seria possível extrair de outros dispositivos da nova lei brasileira, que asseguram, agora, expressa e abrangente proteção legal aos dados pessoais, o acolhimento do referido direito? A verdade é que diversas polêmicas que envolvem o assim chamado direito ao esquecimento encontram sua fonte justamente na indefinição acerca de seu conceito e significado, questão que demanda uma resposta clara e segura por parte da doutrina nacional.

2. O que é, afinal, o direito ao esquecimento?

As mudanças tecnológicas alteraram significativamente a forma como o ser humano vem lidando com suas memórias. Se, antes, o indivíduo tendia naturalmente a esquecer, distanciando-se progressivamente do passado, hoje ocorre o oposto: computadores e aparelhos eletrônicos permitem a “lembrança de tudo”.⁸ Como afirma Mayer-Schönberger, na era digital, “o equilíbrio entre lembrar

e esquecer começou a se inverter”, pois lembrar tornou-se a regra e “esquecer, a exceção”.⁹ Tais mudanças colocaram em evidência o chamado direito ao esquecimento. Nascido no direito europeu continental (*diritto all’oblio*, na Itália; *droit à l’oubli*, na França; e assim por diante), notadamente a partir de casos de ex-detentos que já haviam cumprido sua pena perante o Estado,¹⁰ o chamado *direito ao esquecimento* passou a ser debatido também na esfera cível, no âmbito das relações entre particulares, especialmente em casos envolvendo a recordação pública pela mídia de crimes do passado.

Enquanto, na experiência europeia, o direito ao esquecimento assumia contornos de mecanismo de defesa contra abusos do Estado ou da mídia, no Brasil, acabou por ganhar sentido mais amplo. Contribuiu para isso, em especial, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.334.097 (Chacina da Candelária). Naquele precedente, o STJ atestou a existência de um “direito ao esquecimento”, mas o definiu como “um direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado”.¹¹

Essa acepção do direito ao esquecimento como um “direito de não ser lembrado contra sua vontade” incorre no grave erro de abordar o tema sob a ótica voluntarista, na qual fatos relativos ao indivíduo passam a se subordinar à sua esfera de vontade individual, à semelhança de bens que passam a integrar seu patrimônio, de modo a excluir o acesso de todos os demais indivíduos àquele acontecimento. O direito ao esquecimento ganha, assim, contornos *proprietários*,¹² incompatíveis com a ordem constitucional brasileira, que tutela a liberdade de informação¹³ e o acesso à informação por toda a sociedade,¹⁴ não apenas como direitos fundamentais, mas como pressupostos do Estado Democrático de Direito.¹⁵

No extremo oposto a essa concepção, situa-se uma vasta gama de autores que nega qualquer valor ao chamado direito ao esquecimento. O direito de todos ao conhecimento da História excluiria qualquer proteção do indivíduo contra a circulação de informações a seu respeito ou a recordação de fatos que o envolvessem, em qualquer circunstância, o que consistiria intolerável restrição à liberdade de expressão. Nessa perspectiva, o direito ao esquecimento seria um *não direito*, na medida em que não encontraria assento na normativa constitucional ou infraconstitucional, nem mesmo por via interpretativa.

Nenhuma das duas abordagens afigura-se cientificamente adequada, à luz dos estudos especializados sobre o tema, no Brasil e no exterior. De um lado, não se pode acolher uma acepção de direito ao esquecimento que, sob a ótica voluntarista, coloque a recordação de fatos pretéritos ao mero sabor do *querer* de cada indivíduo, o que acabaria por criar *proprietários de passados*. De outro lado, contudo, não se pode ignorar que a ordem constitucional brasileira, ao atribuir primazia à proteção da pessoa humana, assegura-lhe tutela em face de uma vinculação tão intensa a fatos pretéritos que impeça o indivíduo de exercer plenamente a liberdade de construir para si uma nova identidade pessoal, dissociando-se de rótulos e emblemas do passado.

Nesse sentido, o direito ao esquecimento não se associa tanto à proteção da intimidade ou privacidade da pessoa humana, mas sim ao seu direito à identidade pessoal, que consiste, por sua vez, no

[...] direito de toda pessoa expressar sua verdade pessoal, “quem de fato é”, em suas realidades física, moral e intelectual. A tutela da identidade impede que se falseie a “verdade” da pessoa, de forma a permanecerem intactos os elementos que revelam sua singularidade como unidade existencial no todo social.¹⁶

Nas palavras do saudoso jurista italiano Stefano Rodotà, o direito ao esquecimento “significa que nem todas as pegadas que deixei na minha vida devem me seguir implacavelmente, em cada momento da minha existência”.¹⁷ Nessa mesma direção, a Corte Suprema de Cassação italiana concluiu, em 2012, que:

[...] o direito ao esquecimento salvaguarda, na realidade, a projeção de ser tutelado contra a divulgação de informações (potencialmente) lesivas em razão da perda (dado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência do fato que constitui seu objeto) da sua própria atualidade, de modo que o seu tratamento resulte não mais justificado e, de fato, suscetível de obstaculizar o sujeito na explicação e na fruição da própria personalidade.¹⁸

Como se vê, a expressão *direito ao esquecimento* talvez não seja a mais exata. Embora consagrada pelo uso doutrinário e jurisprudencial, tal expressão acaba por induzir em erro o intérprete, sugerindo que haveria um direito de fazer esquecer, um direito de apagar os dados do passado ou suprimir referências a acontecimentos pretéritos. Não é disso, todavia, que se trata. O direito ao esquecimento consiste simplesmente de um direito da pessoa humana de se defender contra uma *recordação opressiva de fatos pretéritos*, que se mostre apta a minar a construção e reconstrução da sua identidade pessoal, apresentando-a à sociedade sob falsas luzes (*sotto falsa luce*),¹⁹ de modo a fornecer ao público uma projeção do ser humano que não corresponde à realidade (atual).

Tal *recordação opressiva de fatos pretéritos* pode advir do Poder Público – por meio, por exemplo, de registros civis que guardam informações sensíveis que não podem ser expostas de modo a descontextualizar a pessoa humana, apresentando-a de modo desatual e, nesse sentido, *falso*, tal como, por exemplo, na situação de transexualidade –, mas também pode advir da atuação de agentes privados, como empresas jornalísticas. Daí todo o recente debate em torno do direito ao esquecimento na esfera cível.

Note-se que, na perspectiva ora defendida, o embate usualmente invocado entre, de um lado, a “memória de povo” ou sua “História” e, de outro lado, o direito ao esquecimento torna-se um *falso embate*. Isso porque o direito ao esquecimento não deve ser compreendido como o direito individual de reescrever a História. Não se trata de um direito a efetuar uma projeção qualquer sobre a esfera pública, mas de um direito de defesa contra uma projeção desatualizada (nesse sentido, equivocada) e opressiva da pessoa humana.²⁰

Uma definição tecnicamente correta sobre o que vem sendo chamado direito ao esquecimento afigura-se indispensável para evitar discussões superficiais entre a tutela desse direito e um suposto interesse contrário ao conhecimento do passado

e da História, o que apenas contribui para que o tema permaneça em um plano abstrato e esfumado. A definição que ora se sustenta é aquela que, com base nas lições já citadas da doutrina especializada no Brasil e no exterior, compreende o direito ao esquecimento como *direito de cada pessoa humana de se opor à recordação opressiva de determinados fatos perante a sociedade (recordações públicas nesse sentido), que lhe impeça de desenvolver plenamente sua identidade pessoal, por enfatizar perante terceiros aspectos de sua personalidade que não mais refletem a realidade.*²¹

Tecnicamente, o direito ao esquecimento é, portanto, um direito (a) exercido necessariamente por uma pessoa humana; (b) em face de agentes públicos ou privados que tenham a aptidão fática de promover representações daquela pessoa sobre a esfera pública (opinião social), incluindo veículos de imprensa, emissoras de TV, fornecedores de serviços de busca na internet etc.; (c) em oposição a uma recordação opressiva dos fatos, assim entendida a recordação que se caracteriza, a um só tempo, por ser desatual e recair sobre aspecto sensível da personalidade, comprometendo a plena realização da identidade daquela pessoa humana, ao apresentá-la sob falsas luzes à sociedade.

É emblemático o exemplo da pessoa transexual: tendo mudado de sexo, aquela pessoa não deve ser mais apresentada, quer pelo Estado, em repartições públicas, quer pela mídia privada, em reportagens ou entrevistas, como alguém que nasceu homem e se tornou mulher, ou vice-versa, porque, se esse rótulo for constantemente atrelado àquela pessoa, se esse fato passado, embora verdadeiro e público, for constantemente recordado, a sua apresentação à sociedade será sempre uma apresentação deturpada, por dar excessivo peso a um fato pretérito que obscurece sua identidade atual.

Como se vê, há íntima vinculação entre o direito ao esquecimento e a dignidade da pessoa humana, noção fundante da ordem constitucional brasileira (art. 1º, III, CF). Não se trata, portanto, de um *não direito*. Longe disso, mas tampouco se deve compreender o direito ao esquecimento como um *direito absoluto*. Ao contrário, o direito ao esquecimento, na perspectiva aqui defendida, submete-se a ponderação em caso de colisão com outros direitos fundamentais de mesmo grau hierárquico, como é o caso da liberdade de informação e da liberdade de expressão, entre outros.²²

3. Direito à eliminação de dados versus direito ao esquecimento

Esclarecidos os contornos do direito ao esquecimento, torna-se possível avaliar com maior precisão a sua compatibilidade com os conjuntos normativos voltados à proteção de dados pessoais. Conforme anteriormente destacado, o *GDPR* contempla, em seu artigo 17, preceito que recebe a seguinte epígrafe: “Direito ao apagamento dos dados (‘direito a ser esquecido’)”. O dispositivo confere ao titular o direito de obter o apagamento de seus dados pessoais quando, por exemplo, estes “deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento” ou “foram tratados ilicitamente”, entre outras hipóteses narradas.²³ Nota-se, assim, que as hipóteses de apagamento de dados constantes do regulamento europeu não constituem um mecanismo de tutela da identidade da

peessoa em face de recordações opressivas, mas sim remédio associado à dinâmica específica da proteção de dados pessoais. Nada obstante a controvérsia acerca da exata definição do direito ao esquecimento no próprio cenário europeu, a questão já foi notada pela doutrina especializada, apontando que:

La qualificazione di diritto all'oblio (art 17) tuttavia è del tutto impropria, poiché il GDPR pone l'accento sulla cancellazione dei dati indipendentemente dalla loro circolazione pubblica, senza che la richiesta di cancellazione avanzata dalla persona cui i dati si riferiscono debba essere necessariamente valutata in relazione alla libertà di cronaca degli organi di informazione. La cancellazione dei dati, infatti, può essere richiesta per qualsiasi ragione (non solo per ragioni inerenti alla tutela della reputazione o della corretta rappresentazione pubblica della personalità individuale); può riguardare anche dati non pubblici, ma gestiti solo dal titolare del trattamento; può riguardare informazioni che non sono mai state, nemmeno in passato, di interesse pubblico. [...] Bisogna dunque distinguere fra un'accezione ampia del concetto di diritto all'oblio come diritto ad essere dimenticati, che nell'era di Internet rappresenta più un'aspirazione che una reale possibilità, e un'accezione più ristretta concernente solo il profilo del trattamento dei dati personali, in base alla quale si richiede all'intermediario digitale di cancellare quelli scorretti, distorti o non più rilevanti, cosa che non necessariamente garantisce l'assoluta irreperibilità del dato.²⁴

Daí não parecer tão profunda a distinção em relação à nossa LGPD, que traz, ainda que de modo mais difuso, diversas hipóteses de eliminação dos dados pessoais,²⁵ justificadas pela dinâmica e pelos princípios acolhidos pela legislação. O artigo 16, por exemplo, determina a eliminação dos dados pessoais após o término do tratamento (art. 15)²⁶, “independentemente da razão”²⁷, autorizando a conservação dos dados para finalidades específicas elencadas.²⁸ O artigo 18, por sua vez, garante o direito do titular a obter do controlador a eliminação de “dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei” (inciso IV) e de “dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei” (inciso VI). Essa segunda hipótese – eliminação de dados tratados com o consentimento do titular – parece se confundir com a própria “revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei” (art. 18, IX), que leva ao término do tratamento de dados nos termos do art. 15, III, e, por conseguinte, à eliminação dos dados por força do art. 16.²⁹ O fato é que, à luz desse tecido normativo, pode-se concluir que a LGPD, assemelhando-se, nesse particular, ao regulamento europeu, veicula mecanismos de proteção à privacidade da pessoa, na perspectiva contemporânea da autodeterminação informativa, em conformidade com os princípios consagrados pela nova lei, em especial os da finalidade³⁰, adequação³¹ e necessidade³².

A lei brasileira – tal qual o regulamento europeu, em que pese a nomenclatura empregada nesse último – não trata, a rigor, do direito ao esquecimento, entendido, repita-se, como o direito do indivíduo de se opor à recordação pública e opressiva de fatos que já não mais refletem sua identidade pessoal. O que nossa lei e o regulamento europeu contemplam é o direito à eliminação de dados, que, embora também inspirado na proteção da dignidade da pessoa humana, distancia-se do direito ao esquecimento, quer no tocante ao seu conteúdo, quer no que se refere aos seus fins mais imediatos. Isso não impede, contudo, que o intérprete valore o silêncio do legislador brasileiro sobre a matéria.

4. Conclusão: perspectivas para o direito ao esquecimento a partir da LGPD

O silêncio, por vezes, exprime uma opção do legislador em rejeitar um determinado instituto.³³ Para aqueles que negam o direito ao esquecimento, o silêncio da lei brasileira seguramente soará como negativa de reconhecimento ao instituto. Há, entretanto, elementos que apontam para uma solução diversa. Em primeiro lugar, o próprio fato de o legislador brasileiro ter seguido o modelo europeu, com tamanha fidelidade, há de ter algum significado. No que toca ao direito ao apagamento de dados, por exemplo, o paralelo com o *GDPR* é flagrante: o direito ao apagamento quando os dados deixam de ser necessários para a finalidade justificativa do tratamento (*GDPR*, art. 17 (1) (a)) equivale, com perfeição, ao direito do titular de requisitar a eliminação de dados desnecessários (LGPD, art. 18, IV). A retirada do consentimento (*GDPR*, art. 17 (1) (b)) é, igualmente, espelhada na lei brasileira (LGPD, art. 18, VI). Pode-se citar, ainda, o apagamento de dados tratados ilicitamente (*GDPR*, art. 17 (1) (d)), correspondente à eliminação de dados tratados em desconformidade com o disposto na lei (LGPD, art. 18, IV).

Toda essa lealdade ao regulamento europeu de proteção de dados pessoais exprime, a nosso ver, mais que uma simples fonte de inspiração de caráter operacional, revelando a genuína adoção de um modelo de proteção de dados pessoais que somente se explica e justifica se ancorado sobre uma visão da ordem jurídica comprometida com a realização de uma concepção ampla de privacidade, como expressão da dignidade humana.³⁴ Dessa concepção, mais que de um dispositivo específico da LGPD, é que decorre inevitavelmente a proteção à identidade pessoal, com fundamento direto na cláusula geral de tutela da pessoa humana constante do artigo 1º, III, da Constituição da República. Também o direito ao esquecimento integra esse núcleo axiológico, exprimindo, em última análise, uma manifestação da dignidade humana merecedora de proteção, que se reveste, tecnicamente, da natureza de direito fundamental, ainda que não referido textualmente na Constituição.³⁵

Vale dizer: bem examinada, a LGPD – não só no que ela efetivamente aporta ao tema, mas especialmente nas premissas jurídicas que explicam sua promulgação no direito brasileiro – revela uma maior abertura do legislador em relação ao direito ao esquecimento, capaz de exercer influência sobre o debate atualmente instaurado nesse campo.³⁶ Ao contrário, por exemplo, do Marco Civil da Internet, que em diversas passagens se deixou seduzir por uma suposta prevalência da liberdade de expressão sobre os direitos da personalidade,³⁷ a principiologia da Lei 13.709/2018 revela-se mais equilibrada, apresentando, em posição de igualdade, os múltiplos interesses constitucionalmente relevantes, de caráter individual e transindividual, que atuam na esfera da proteção de dados: (a) o respeito à privacidade; (b) a autodeterminação informativa; (c) a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; (d) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; (e) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; (f) a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e (g) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (art. 2º). Reforça-se, com isso, a constante necessidade de ponderação entre esses interesses, aspecto que, conforme já se ressaltou, assume relevância central no processo de interpretação-aplicação do direito ao esquecimento.

Em suma, a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais possui o extraordinário mérito de ter encerrado o hiato no qual se encontrava o direito à privacidade, no Brasil, desde o promissor tratamento que lhe fora dispensado pela Constituição em 1988. Caso seja bem empregada, pode vir a se tornar instrumento primordial para a construção de uma *cultura da privacidade*, ainda inexistente no Brasil. Interpretada em toda sua potencialidade, inclusive no que diz respeito à contribuição para a afirmação do direito ao esquecimento no Brasil, a LGPD pode ir além, auxiliando a construção de uma *cultura de respeito à pessoa humana*, em todas as suas dimensões.

Referências bibliográficas

ALBERS, Marion. A Imprensa Também Tem Limites. *Revista PUC-RS*, Rio Grande do Sul, v. 173, p. 30-31, mar.-abr. 2015.

ALEGRI, Maria Romana. *Gdpr e diritto di cancellazione dati/rettifica*: come funziona. Disponível em: [www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-e-diritto-di-cancellazione-dati-rettifica-come-funziona].

BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de Expressão *Versus* Direitos da Personalidade. Colisão de Direitos Fundamentais e Critérios de Ponderação. In: *Temas de Direito Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. t. III.

CASSANO, Giuseppe. *I diritti della personalità e le aporie logico dogmatiche di dottrina e giurisprudenza*: brevissimi cenni. Disponível em: [www.diritto.it].

CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O Direito à Identidade na Perspectiva Civil-Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

COSTA, André Brandão Nery. Direito ao Esquecimento: a Scarlet Letter Digital. In: SCHREIBER, Anderson (Org.). *Direito e Mídia*. São Paulo: Atlas, 2013.

COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018.

DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD*: direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-direito-de-anonimizacao-bloqueio-ou-eliminacao-de-dados-31102018].

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*. New Jersey: Princeton, 2009.

OLIVEIRA, Júlia Costa de. Direito ao esquecimento e seus possíveis mecanismos de tutela na internet: como alcançar uma proteção real no universo virtual? Dissertação (Mestrado), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

RODOTÀ, Stefano. *A Vida na Sociedade da Vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *Dai ricordi ai dati l'oblio è un diritto?* Disponível em: [https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html].

SARLET, Ingo Wolfgang; FERREIRA NETO, Arthur M. *O Direito ao "Esquecimento" na Sociedade da Informação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e "Direito ao Esquecimento" na Ordem Constitucional Brasileira. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 7, p. 190-232, 2016.

SCHERTEL, Laura Mendes. *Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor*. São Paulo: Saraiva, 2014.

SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SCHREIBER, Anderson. A Responsabilidade Civil por Dano Derivado do Conteúdo Gerado por Terceiro. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. (Org.). *Direito e Internet III: Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. II.

SCHREIBER, Anderson. Direito ao Esquecimento. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. (Coord.). *Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. São Paulo: Atlas, 2018.

TEPEDINO, Gustavo. Lógica Proprietária e Tutela da Personalidade. *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 49, 2012.

1

.Professor Titular de Direito Civil da UERJ.

2

.*Entidades combatem câmeras do metrô de SP que leem emoções de passageiros para vender publicidade*, reportagem disponível em: [https://theintercept.com/2018/08/31/metro-cameras-acao-civil]. Acesso em: 18.02.2019.

3

.O Marco Civil da Internet prevê a proteção de dados pessoais como um de seus princípios no artigo 3º, III, mas pouco acrescenta nos demais artigos sobre o tema (arts. 7º, VII a X, e 10 a 12).

4

.O CDC traz regras específicas sobre bancos de dados e cadastros de consumidores nos seus artigos 43 e 44.

5

.Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

6

.Merece destaque a obra precursora de DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. Bem como o instigante livro de SCHERTEL, Laura Mendes. *Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor*. São Paulo: Saraiva, 2014.

7

.Entre eles, o escândalo de vazamento de dados envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, bem sintetizado em reportagem do *The New York Times*, “*Facebook and Cambridge Analytica: What You Need to Know as Fallout Widens*”. Disponível em: [www.nytimes.com].

8

.COSTA, André Brandão Nery. Direito ao Esquecimento: a Scarlet Letter Digital. In: SCHREIBER, Anderson (Org.). *Direito e Mídia*. São Paulo: Atlas, 2013. p. 185.

9

.MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*. New Jersey: Princeton, 2009. p. 196: “With our capacity to remember, we are able to compare, to learn, and to experience time as change. Equally important is our ability to forget, to unburden ourselves from the shackles of our past, and to live in the present. For millennia, the relationship between remembering and forgetting remained clear. Remembering was hard and costly, and humans had to choose deliberately what to remember. The default was to forget. In the digital age, in what is perhaps the most fundamental change for humans since our humble beginnings, that balance of remembering and forgetting has become inverted. Committing information to digital memory has become the default, and forgetting the exception.” Em tradução livre: “Com nossa capacidade de relembrar, nós somos capazes de comparar, de aprender e de ter a experiência temporal como mudança. Igualmente importante é nossa capacidade de esquecer, de nos aliviarmos dos grilhões do passado e viver no presente. Por milênios, a relação entre lembrar e esquecer permaneceu clara. Lembrar era difícil e custoso e os humanos tinham que escolher deliberadamente o que lembrar. O padrão era esquecer. Na era digital, talvez a mais fundamental modificação para os humanos desde o início, o balanço entre lembrar e esquecer começou a se inverter. O envio de informações para a memória digital se tornou o padrão e esquecer a exceção.”

10

.Para mais detalhes, ver SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 172-174.

11

.STJ, Quarta Turma, REsp 1.334.097, Ministro Relator Luis Felipe Salomão, j. 28.05.2013. A Corte concluiu, naquela ocasião, que: “A despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado – com muita razão – um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria tolhida nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito.”

12

.Gustavo Tepedino critica a tutela da privacidade com contornos proprietários e aponta como saída adequada a ponderação concreta de interesses conflitantes: “No panorama brasileiro, torna-se relevante analisar criticamente a visão da privacidade, ainda difusa em doutrina e jurisprudência, como espaço de poder (‘proprietário’) do indivíduo, que se encastela em seu território

intransponível contra ingerências externas. [...] Em perspectiva diversa, deve-se definir em que circunstâncias e em face de quais interesses se torna legítimo o controle pessoal de informações da vida privada, impedindo-se assim o seu acesso pelo Estado, cada dia mais invasivo, ou por terceiros, motivados por pressões mercadológicas. Trata-se de ponderação necessária entre interesses colidentes, não sendo possível sacrificar, em abstrato, direitos fundamentais, máxime se o critério balizador for a pertinência proprietária, que acaba por prevalecer, com constrangedora proeminência, quando se pensa na *privacy* como poder de disposição personalíssimo em relação a 'bens' da personalidade." (TEPEDINO, Gustavo. *Lógica Proprietária e Tutela da Personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 49, 2012. p. vi).

13

.Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

14

.O acesso à informação é tutelado pela Constituição brasileira, em seu artigo 5º, incisos XIV e XXXIII: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado."

15

.BARROSO, Luís Roberto. *Liberdade de Expressão Versus Direitos da Personalidade. Colisão de Direitos Fundamentais e Critérios de Ponderação*. In: *Temas de Direito Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. t. III. p. 105: "[...] essas mesmas liberdades [de informação e de expressão] atendem ao inegável interesse público da livre circulação de ideias, corolário e base de funcionamento do regime democrático, tendo, portanto, uma dimensão eminentemente coletiva, sobretudo quando se esteja diante de um meio de comunicação social ou de massa.". Também nesse sentido, destaca Daniel Sarmento: "O acesso à informação é essencial para que as pessoas possam participar de modo consciente da vida pública e fiscalizar os governantes e detentores de poder social. Não é exagero afirmar que o controle do poder tem no direito à informação seu instrumento mais poderoso. A transparência proporcionada pelo acesso à informação é o melhor antídoto para a corrupção, para as violações de direitos humanos, para a ineficiência governamental. [...] Não é por outra razão que os regimes autoritários têm ojeriza à divulgação de informações, buscando censurar a imprensa e criar uma redoma de sigilo sobre as suas atividades. Já nas democracias deve ocorrer o oposto." (SARMENTO, Daniel. *Liberdades Comunicativas e "Direito ao Esquecimento" na Ordem Constitucional Brasileira. Revista Brasileira de Direito Civil*, Rio de Janeiro, v. 7, jan.-mar. 2016. p. 194).

16

.CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O Direito à Identidade na Perspectiva Civil-Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 244.

17

.No original: "diritto all'oblio. Il che significa che non tutte le tracce che io ho lasciato nella mia vita mi devono inseguire implacabilmente in ogni momento della mia esistenza." (RODOTÀ, Stefano. *Privacy: valore e diritto*. Entrevista disponível no *síte* da Enciclopedia Multimedilae dele Scienze Filosofiche). Acrescenta, ainda, Rodotà que "il passato non può essere trasformato in una condanna che esclude ogni riscatto." Em tradução livre: "o passado não pode ser transformado em uma condenação que exclui o resgate" (RODOTÀ, Stefano. *Dai ricordi ai dati l'oblio è un diritto?*

18

.*Corte Suprema di Cassazione*, julgado 5525/2012, j. 11.01.2012. Tradução livre do original em italiano: “il diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione di essere tutelato dalla divulgazione di informazione (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria personalità.”

19

.A expressão é de CASSANO, Giuseppe. *I diritti della personalità e le aporie logico dogmatiche di dottrina e giurisprudenza*: brevissimi cenni. Disponível em: [www.diritto.it].

20

.SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. São Paulo: Atlas, 2011. p. 165. Também nesse sentido, ver ALBERS, Marion. A Imprensa Também Tem Limites. *Revista PUC-RS*, Rio Grande do Sul, v. 173, mar.- abr. 2015. p. 31: “Há o perigo de apagar algo da história de um país? Isso não acontece porque as informações seguem publicadas, estão sempre acessíveis aos pesquisadores. O que não vai ser possível é que qualquer pessoa encontre certas informações em mecanismos de busca. Até porque são sempre informações selecionadas, incompletas, um retrato distorcido das pessoas que nunca vão se livrar desse estigma. Isso é o que se quer evitar, mas em absoluto tem-se o objetivo de impedir pesquisas sobre as fontes que continuam disponibilizadas. O que se busca é um esquecimento social, mas não que individualmente não se possa acessar as informações”.

21

.SCHREIBER, Anderson. Direito ao Esquecimento. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. (Coord.). *Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. São Paulo: Atlas, 2018. p. 70.

22

.Para uma proposta de parâmetros a serem empregados nessa ponderação, seja consentido remeter a SCHREIBER, Anderson. Direito ao Esquecimento. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. (Coord.). *Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. São Paulo: Atlas, 2018. p. 71-79. Recomenda-se, também, a leitura de SARLET, Ingo Wolfgang; FERREIRA NETO, Arthur M. *O Direito ao “Esquecimento” na Sociedade da Informação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019. p. 189-206, e OLIVEIRA, Júlia Costa de. *Direito ao esquecimento e seus possíveis mecanismos de tutela na internet: como alcançar uma proteção real no universo virtual?* Dissertação (Mestrado), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. p. 141-192.

23

.Confira-se a íntegra da norma: “Artigo 17.º Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido») 1. O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique um dos seguintes motivos: a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) O titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), ou do artigo 9.º, n.º 2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento; c) O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.º, n.º 1, e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.º, n.º 2; d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; e) Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; f) Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade da informação referida no artigo 8.º, n.º 1. 2. Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado a apagá-los nos termos do n.º 1, toma as medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico, tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos

da sua aplicação, para informar os responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais de que o titular dos dados lhes solicitou o apagamento das ligações para esses dados pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos mesmos. 3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam na medida em que o tratamento se revele necessário: a) Ao exercício da liberdade de expressão e de informação; b) Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito, ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento; c) Por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, alíneas h) e i), bem como do artigo 9.º, n.º 3; d) Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, nos termos do artigo 89.º, n.º 1, na medida em que o direito referido no n.º 1 seja suscetível de tornar impossível ou prejudicar gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento; ou e) Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.”

24

.ALEGRI, Maria Romana. *GDPR e diritto di cancellazione dati/rettifica*: come funziona. Disponível em: [www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-e-diritto-di-cancellazione-dati-rettifica-come-funziona]. Acesso em: 19.02.2019. Em tradução livre: “A qualificação do direito a ser esquecido (Artigo 17), entretanto, é completamente imprópria, uma vez que o *GDPR* enfatiza a exclusão de dados independentemente de sua circulação pública, sem que o pedido de cancelamento feito pela pessoa a quem os dados se referem seja necessariamente avaliado em relação à liberdade de imprensa dos órgãos de informação. De fato, os dados podem ser excluídos por qualquer motivo (não apenas por razões relacionadas à proteção da reputação ou à correta representação pública da personalidade individual); pode também dizer respeito a dados não públicos, mas apenas geridos pelo controlador de dados; pode dizer respeito a informações que nunca foram do interesse público, nem mesmo no passado. [...] É, portanto, necessário distinguir entre um significado amplo do conceito de direito ao esquecimento como um direito a ser esquecido, que na era da Internet é mais uma aspiração do que uma possibilidade real, e uma abordagem mais restrita, que diz respeito apenas ao perfil do tratamento de dados pessoais, com base nos quais o intermediário digital é solicitado a eliminar os que são incorretos, distorcidos ou não são relevantes, o que não garante necessariamente a absoluta indisponibilidade dos dados.”

25

.O artigo 5º, XIV, da LGPD define “eliminação” como “exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado”.

26

.Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: I – verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; II – fim do período de tratamento; III – comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou IV – determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

27

.COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 152.

28

.Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades: I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

29

.Como destaca Ana Frazão: “nos casos de consentimento, a eliminação dos dados tanto na hipótese de revogação do consentimento, como na hipótese do término do prazo de tratamento de

dados, é medida ainda mais indispensável” (FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados*. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-direito-de-anonimizacao-bloqueio-ou-eliminacao-de-dados-31102018]. Acesso em: 20.02.2019).

30

.Definido como a imposição da “realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades” (art. 6º, I).

31

.Definido como garantia de “compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento” (art. 6º, II).

32

.Definido como exigência de “limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados” (art. 6º, III).

33

.“Nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre o silêncio propositado, que significa recusa de ação, e a deficiência ocasional, que se deve suprir pelos meios regulares – analogia, Direito subsidiário, equidade. Em tal conjuntura surge a oportunidade para se revelar toda a argúcia e demais recursos intelectuais do hermeneuta; seria precipitado pronunciar logo o juiz o *non possumus fatal*.” (MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 43).

34

.Sobre o tema, seja consentido remeter a SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Especialmente, p. 01-29.

35

.Na doutrina, ver SARLET, Ingo Wolfgang e NETO, Arthur M. Ferreira, que defendem expressamente a natureza de direito fundamental do direito ao esquecimento, amparada justamente no fato de que “a capacidade e a possibilidade de esquecimento e a necessidade de seu reconhecimento e proteção na condição de direito especial de personalidade (implícito, ou não) representam condição *sine qua non* para – e daí a principal relação do ponto de vista normativo (moral e jurídico) com a dignidade humana e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade – o que se designou de um ‘direito a um recomeço’ e/ou de um ‘direito a se reinventar’, ou seja, a possibilidade de reformatar (reconstruir) a trajetória existencial pessoal (individual) e social, livre de determinadas amarras provocadas pela confrontação direta e permanente no tempo com aspectos relativos à memória” (SARLET, Ingo Wolfgang; FERREIRA NETO, Arthur M. *O Direito ao “Esquecimento” na Sociedade da Informação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019. p. 49).

36

.Aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cujo tema da repercussão geral (786) é precisamente a “aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares”.

37

.O problema se anuncia já no art. 2º da lei, que, ao elencar os seus fundamentos, afirma o “respeito à liberdade de expressão” de modo destacado no *caput*, pairando sobre “os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais”, que surgem apenas no inciso II. A manifestação mais aguda desta opção legislativa se manifesta no art. 19, que condiciona a reparação, pelo provedor de aplicações, de danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros à inércia do provedor após uma “ordem judicial específica”. Tal

preceito, para que possa preservar alguma eficácia, deve ser objeto de interpretação conforme a Constituição, como defendido em SCHREIBER, Anderson. A Responsabilidade Civil por Dano Derivado do Conteúdo Gerado por Terceiro. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. (Org.). *Direito e Internet III: Marco Civil da Internet* (Lei 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. II. p. 277-304.

Capítulo 14. Os direitos de explicação e de oposição diante das decisões totalmente automatizadas: comparando o RGPD da União Europeia com a LGPD brasileira

Alexandre Veronese¹

1. Introdução

O tema da proteção dos dados pessoais em situações de tratamento automatizado tende a evoluir sobremaneira em importância nos próximos anos. O incremento na capacidade computacional tende a expandir as possibilidades de usos comerciais, políticos e sociais a partir de enormes bases de dados. Assim, é razoável uma radical mudança de contexto ao se pressupor que a possibilidade técnica de coletar e de tratar mais dados será evidenciada nas próximas décadas. Para apreciar esse tema com base na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei 13.709/2018, doravante LGPD) e no Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante RGPD), da União Europeia, cabe, inicialmente, demonstrar duas evoluções. A primeira é a evolução do direito à proteção das informações pessoais para o direito à proteção dos dados pessoais. A segunda é a evolução do tratamento dos dados de um ambiente tecnológico limitado – em alcance e produtividade – para o atual contexto de *Big Data*. Porém, antes de expor essas duas mudanças, é importante firmar alguns conceitos. A produção de análises jurídicas exige precisão conceitual. Dessa forma, há que definir os conceitos de “dados” e de “informação”.

1.1. Dados e informações

O termo “dado” se refere a uma informação existente antes do seu tratamento. A legislação brasileira já vinha protegendo e regulando as informações pessoais. Assim, o inciso I do artigo 4º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) definia que a informação seria composta de dados – tratados ou não – usados para produção ou para transmissão de conhecimentos. Essa definição jurídica é suficiente para explicar a proteção de dados. Um autor da área de ciência da informação, Michael Buckland, explica que o conceito de informação possui ambiguidade. Ele divide o conceito de informação em quatro aspectos (quadrantes), como fica claro no quadro a seguir²:

Quadro 1 – Aspectos do conceito de informação

--	--	--

	Intangível	Tangível
Individualidade	Informação-como-conhecimento. Exemplo: conhecimento	Informação-como-coisa. Exemplos: dados, documentos, conhecimento armazenado
Processos	Informação-como-processo. Exemplo: o ser humano ao ser informado	Processamento de informação. Exemplos: o processamento de dados, documentos e a engenharia do conhecimento

Fonte: formulação do autor.

O que interessa é, portanto, resgatar a diferença entre o conceito de “informação” e o conceito de “dados”. Michael Buckland assim vai expor o conceito de “dados”:

“Dados” (*data*), como a forma plural da palavra em latim *datum*, significa “coisas que são dadas” (*things that have been given*). Ele é, portanto, um termo apto para a classe de informações-como-coisas que não foram ainda processadas (tratadas) de alguma forma. Usualmente, os ‘dados’ se referem a quaisquer registros armazenados em um computador.³

A informação – nessa perspectiva – irá se referir aos dados tratados. Os dados são características dos objetos (documentos⁴) – abstratos ou concretos – que, após a sua classificação (tratamento), dão origem às informações⁵. A altura de uma pessoa, em si mesma, é um dado físico. Porém, uma vez que ela é mensurada, torna-se uma informação. Essa informação pode ser definida com base em vários sistemas de classificação. O sistema internacional de unidades (métrico) é um exemplo de um sistema de mensuração e de classificação. Existem outros sistemas de medidas, como o sistema britânico de unidades. Outro exemplo pode ser retirado do cotidiano. As receitas e os gastos correntes de um indivíduo também são dados – bancários e pessoais, no caso – que podem ser utilizados como informações, para, por exemplo, avaliar a possibilidade de concessão de um crediário. A Lei do *Habeas Data* (Lei 9.507/1996) se refere ao objeto tutelado por ela de forma ambígua: dados e informações. Ela tem o seu foco dirigido aos bancos de dados públicos e, assim, regula vários direitos, tais como o acesso aos dados e a sua retificação. Apesar da provável confusão, essa diferenciação conceitual não criou problemas efetivos. Não obstante, a precisão dos dois conceitos – agora – se torna mais relevante, uma vez que o acesso e proteção aos dados pessoais se tornam tão ou mais importantes do que a proteção e o acesso à informação.

Essa diferença científica e técnica não é irrelevante. Primeiro porque é muito importante ter clara a necessidade de proteção dos dados pessoais e não somente das informações pessoais. E isso ocorre exatamente em razão do incremento na capacidade computacional. Se a proteção for outorgada somente às informações, um vasto conjunto de dados – não classificados e não tratados – poderão estar desprotegidos. Toda e qualquer mineração de dados primários estaria sem

proteção. Um caso muito curioso sobre a proteção de dados foi julgado pela Suprema Corte do Estado da Califórnia, em 1990: *Moore v. Regents of the University of California*⁶. O autor da ação – John Moore – havia recebido tratamento no sistema médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles para combater um tipo raro de leucemia. O tratamento começou em 1976 e se estendeu em revisões até o ano de 1983. Nesse ano de 1983, o autor assinou um termo de consentimento no qual abdicava de quaisquer direitos patrimoniais sobre suas células e sobre o seu material correlacionado, desde que coletado para fins de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Em 1984, os médicos e pesquisadores que o atendiam foram outorgados com uma patente de fármaco. A patente foi licenciada para a indústria e a Universidade reteve uma parcela das receitas futuras. O autor ajuizou a ação com o objetivo de obter parte dos direitos patrimoniais da patente, uma vez que o fármaco teria se baseado em seu material biológico. Para uma analogia, os dados biológicos e pessoais de John Moore foram transformados em informações úteis e proveitosas do ponto de vista pecuniário. A Suprema Corte do Estado da Califórnia reverteu a decisão do Tribunal de Apelação e negou todos os pleitos do autor. Assim, foi considerado que o material biológico dele, uma vez coletado e doado no cerne de um tratamento, perderia o seu liame de personalidade. Um dos fundamentos seria o fato de que esse material poderia ter sido destruído sem afetar o doador, por exemplo. E que a tutela jurídica sobre ele estaria relacionada com a lei estadual que rege as pesquisas científicas. O caso é exposto para evidenciar que a proteção do passado se estendia às informações e não aos dados brutos, ou seja, anteriores ao tratamento.

Exposto o primeiro tema, cabe entender – agora – a evolução da capacidade de tratamento dos dados, a qual acaba por tornar sua proteção mais complicada e, portanto, relevante.

1.2. Do processamento regular ao processamento ampliado (Big Data)

Para entender essa segunda transição, há que se retornar ao conceito de *Big Data*. Como será visto mais à frente, no presente texto, os instrumentos jurídicos para a proteção de informações e de dados remontam aos meados da década de 70 do século passado. Porém, o processo de digitalização, combinado com a expansão da capacidade de processamento computacional, gerou a possibilidade de desenvolver novos meios de coleta e de tratamento de dados. O termo *Big Data* se refere, primariamente, ao seu objeto, ou seja, à possibilidade de estocar uma grande quantidade de dados. Porém, é evidente que não basta estocar os dados, há que tratá-los. Assim, o conceito de *Big Data* se refere, também, ao aumento da capacidade computacional⁷, ou seja, ele se refere à evolução de uma parte dos meios tecnológicos (*hardware*). Além desses dois elementos – estoque e processamento –, o *Big Data* conforma uma dimensão inovadora no tratamento dos dados: o aumento da capacidade de coleta. Essa terceira dimensão inovadora se refere ao conceito de *Big Data* em razão de outra parte do meio tecnológico: os programas de computador (*software*). Por fim, o quarto elemento conceitual se relaciona com as práticas de análise dos dados. Existe inovação no modo de produzir as análises, possibilitado – claro – pelos novos meios tecnológicos, porém, com vitalidade e engenho humano. O quadro a seguir sintetiza a exposição supra:

Quadro 2 – Diferenciação entre *Regular Data* e *Big Data*

	<i>Regular Data</i>	<i>Big Data</i>
Objeto (dados)	Estoques de dados em proporção quantitativa e qualitativa menor	Aumento vertiginoso na capacidade de coleta e de estocagem de dados
Meio tecnológico (<i>hardware</i>)	Processamento de alto desempenho limitado a poucos usuários	Disseminação de equipamentos de alto desempenho
Meio tecnológico (<i>software</i>)	Programas de computador adequados ao processamento limitado	Desenvolvimento de diversos programas de computador novos
Meio intelectual (análise)	Práticas de análise de dados tradicionais em quantidade e qualidade	Inovadoras práticas de análise, incrementais em quantidade e qualidade

Fonte: formulação do autor.

Vale referenciar dois trabalhos. O primeiro é o livro de Viktor Mayer-Schönberger e de Thomas Range sobre o aparecimento de mercados enriquecidos por dados (*data-rich markets*). Para os autores, o funcionamento do próprio capitalismo irá se alterar de forma radical. Dessa forma, eles indicam que haverá a necessidade de atualizar vários campos das práticas sociais, sejam econômicas ou jurídicas. O segundo trabalho é um relatório produzido por Fred H. Cate, Peter Cullen e Viktor Mayer-Schönberger, cujo objetivo é atualizar as *Guidelines* da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) sobre proteção de dados pessoais⁸. As diretrizes da OCDE datam de 1980 e não mais seriam adequadas para oferecer um nível de proteção necessário para a vida social contemporânea, radicalmente vivida em linha (*online*) e em direto (ao vivo):

O mundo do *Big Data* oferece sérios riscos à privacidade das informações, que são agravados pelos frágeis requisitos de ‘aviso e consentimento’ das *OECD Guidelines* de 1980, cujo reflexo se encontra nas mais modernas leis de proteção de dados. Em muitos casos, a coleta de dados pessoais não apenas requer o consentimento do titular dos dados; mas, também, ela é limitada à quantidade mínima de dados, necessária para atingir o propósito definido no aviso usado para demandar o consentimento, bem como que os dados não sejam utilizados para outras finalidades sem relação com a primeira e ausentes de um novo consentimento. Se as *OECD Guidelines* eram razoáveis e úteis em 1980, elas – hoje – oferecem pouco para proteger os indivíduos ou para apoiar novos e valiosos usos dos dados pessoais.⁹

Para que o conceito fique um pouco mais claro, basta compreender elementos da legislação da União Europeia acerca do direito de explicação e de oposição em face de decisões totalmente automatizadas. Afinal, a importância do direito à explicação e do direito à oposição pode ser visualizada nas críticas dirigidas ao *Big Data*. Antes de adentrar as normas jurídicas da União Europeia, um caso explicará o problema.

A *Google* possui uma das mais conhecidas e utilizadas ferramentas de busca na Internet. Porém, para manter-se na liderança, ela acabou por investir em produtos derivados, tais como buscadores especializados e outros serviços. Um produto central para a estratégia comercial da *Google* é o serviço *Google Ads* (antigo *Google Adwords*)¹⁰. Essa ferramenta serve para que empresas contratem a *Google* para impulsionar publicidade dirigida não somente no buscador, mas, também, em sítios eletrônicos de terceiros que recebem uma remuneração em razão da quantidade de visitas recebidas. O problema do serviço é que ele era exclusivamente automatizado. Assim, comerciantes em situação irregular poderiam contratar publicidade para solapar direitos legítimos de outros comerciantes.

O caso concreto contra a *Google* foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, situado em Luxemburgo. O caso envolveu uma conhecida marca europeia de malas e de produtos de luxo: a *Louis Vitton*. Quando se acessava o portal geral *Google* e se buscava pela expressão “louis vitton”, apareciam várias ofertas – no topo da tela – que divulgavam sítios eletrônicos de produtos falsificados ou similares. A *Louis Vitton Malletier SA* acabou por processar a *Google France SARL* e obteve uma primeira vitória junto ao judiciário francês. Porém, a Corte de Cassação, antes de proferir seu acórdão, demandou a análise jurídica do tema ao Tribunal de Justiça da União Europeia por meio de um reenvio especial. O Tribunal de Justiça da União Europeia proferiu um acórdão no qual uniu três casos. Ele reconheceu três questões jurídicas. A primeira foi que as normas jurídicas europeias (Diretiva em matéria de marcas, 84/109/CEE; e Regulamento CE 40/94) garantem que um titular de marca possa proibir um anunciante – em conexão com um buscador da Internet (prestador de serviço de referenciamento na Internet) – de utilizar palavras-chave idênticas àquelas de sua marca com o objetivo de divulgar produtos e serviços de terceiros não autorizados. A segunda foi que um buscador de Internet que armazena uma palavra-chave ou sinal/símbolo de marca registrada viola a legislação europeia citada. Por fim, no que tange à responsabilidade do buscador, deveria ser aplicado o artigo 14º da Diretiva de Comércio Eletrônico (2000/31/CE). Esse artigo estatui que um prestador de serviço da sociedade da informação somente pode ser responsabilizado se, após ter ciência da armazenagem de material ilegal, não tomar as medidas cabíveis. Os §§ 113, 114 e 120 do acórdão são elucidativos desse ponto:

113. Resulta, a este respeito, do considerando 42 da Directiva 2000/31 que situações de exoneração de responsabilidade estabelecidas nesta directiva abrangem exclusivamente os casos em que a actividade da sociedade da informação exercida pelo prestador de serviços reveste carácter ‘puramente técnico, automático e de natureza passiva’, o que implica que o referido prestador de serviços ‘não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta’.

114. Por conseguinte, a fim de verificar se a responsabilidade do prestador do serviço de referenciamento poderia ser limitada com base no artigo 14º da Directiva 2000/31, deve examinar-se se o papel desempenhado pelo referido prestador é neutro, ou seja, se o seu comportamento é puramente técnico, automático e passivo, implicando o desconhecimento ou a falta de controlo dos dados que armazena.

[...]

120. Daqui resulta que há que responder à terceira questão no processo C236/08, à segunda questão no processo C237/08 e à terceira questão no processo C238/08

que o artigo 14º da Directiva 2000/31 deve ser interpretado no sentido de que a regra que enuncia se aplica ao prestador de um serviço de referenciamento na Internet, quando esse prestador não tenha desempenhado um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo dos dados armazenados. Se não tiver desempenhado esse papel, o referido prestador não pode ser considerado responsável pelos dados que tenha armazenado a pedido de um anunciante, a menos que, tendo tomado conhecimento do carácter ilícito desses dados ou de actividades do anunciante, não tenha prontamente retirado ou tornado inacessíveis os referidos dados.¹¹

O maior argumento de defesa utilizado pela *Google France SARL* residuiu exatamente na automatização dos sistemas de contratação e de funcionamento dos anúncios eletrônicos do sistema *Adwords*. Não haveria qualquer ingerência humana no processo e, portanto, a empresa não poderia ser responsabilizada pela inserção de anúncios ilegais. No que fixou o Tribunal de Justiça da União Europeia, a empresa somente se tornaria responsável após a notificação de que o sistema teria produzido alguma ilegalidade. Esse caso introduz o grande problema dos sistemas automatizados. A questão central não se restringe aos buscadores. Ao contrário, existem milhares de outras aplicações e de sistemas que usam dados pessoais para gerar decisões com base em perfis de consumidores ou de cidadãos, o que leva Mireille Hildebrandt a questionar se os sistemas sociais – e os indivíduos – não estariam se tornando escravos do *Big Data*¹².

O problema jurídico e político do *Big Data*, segundo Neil M. Richards e Jonathan H. King, pode ser compreendido a partir de três paradoxos¹³. No seu artigo, os autores criticam uma larga parcela da literatura, a qual demonstra um entusiasmo retumbante com o processamento ampliado de dados pessoais. O primeiro é o paradoxo da transparência. Para que seja possível o processamento ampliado, há a necessidade prévia de coletar uma massa ampla de pequenos dados, que se apresentam dispersos. Dados relativos ao movimento das pessoas, suas compras, cadastros, entre outros. Porém, ao passo em que os sistemas evidenciam – e, nesse sentido, tornam transparentes – as pessoas, eles se tornam mais e mais opacos e difíceis de controlar. É algo como o que Frank Pasquale descreve no seu livro: *The black box society* (a sociedade da caixa-preta¹⁴). Assim, o primeiro paradoxo é sintetizado pela necessidade de proteção à privacidade. O segundo é o paradoxo da identidade. Ao passo em que os sistemas de processamento ampliado prometem gerar uma automatização de respostas customizadas para cada indivíduo, eles também limitam a sua exclusão do perfil no qual foram enquadrados. Logo, quanto mais personalizada a resposta – de busca, por exemplo –, mais padronizada ela também será. Como explicam Neil M. Richards e Jonathan H. King, a operação pode ser entendida a partir da enunciação da expressão “eu sou”, para qual o sistema de processamento ampliado replicaria: “então, gostarás disso”. O problema é que o mesmo sistema também responde: “e aquilo não serás e nem gostarás”. A relação entre a identidade individual e a identidade coletiva acaba por se tornar mais complicada e os indivíduos podem perder autonomia nesse contexto. A resposta para esse paradoxo é complexa. Segundo Julie E. Cohen, a solução passa pela junção regulatória de dois debates acerca da Internet que são travados de forma separada: o controle das informações (e dados) pessoais; e o controle das informações culturais¹⁵. A junção de ambos seria o caminho para construir a possibilidade de que, nos processos de construção coletiva das identidades – no

mundo digital –, não fossem passos em direção à diminuição da liberdade de ação dos indivíduos. O terceiro paradoxo se refere ao poder. Os autores retornam à Primavera Árabe e ao debate das aplicações de Internet como cruciais para a eclosão do movimento¹⁶. Porém, ao passo em que as aplicações – alguns dos gigantes da Internet: *Facebook*, *Twitter* e *YouTube* – foram relevantes para o movimento na Tunísia, as autoridades sírias usaram essas redes sociais para mapear e perseguir os dissidentes políticos. Ao passo em que as ferramentas digitais podem ajudar as ações políticas, elas também podem ser usadas para reprimir e oprimir os dissidentes. Assim, o processamento ampliado em prol da perseguição de dissidentes paira como uma ameaça no mundo contemporâneo. A questão central se traduz – nesse terceiro paradoxo – na contraposição entre as instituições políticas e os indivíduos, bem como, também, no papel das aplicações de Internet. A conclusão de Neil M. Richards e Jonathan H. King reside na necessidade de desenvolver um campo da ética aplicada ao *Big Data*. A opção deles é compreensível, uma vez que eles escrevem no panorama dos Estados Unidos da América, no qual a intervenção do Estado nas relações privadas tem sido uma barreira à regulação direta da Internet¹⁷.

Porém, além do modo de regulação dos Estados Unidos da América, bem indicado pelos autores mencionados no parágrafo anterior, existe outra tradição regulatória, que é a formação de acervos normativos claros para regulação de relações sociais na Internet: a tradição dos países-membros e do governo da União Europeia. Ela será exposta no próximo tópico, com destaque aos direitos de explicação e de oposição às decisões automatizadas.

2.O marco jurídico da União Europeia: o RGPD

A existência de normas nacionais em prol da proteção dos dados pessoais não é algo novo no panorama europeu. No caso francês, a Lei de Informática e Liberdades (*Loi de l'informatique et des libertés*) data de 6 de janeiro de 1978. O direito de explicação e de oposição em face de decisões automatizadas já eram previstos naquela legislação francesa, no final da década de 1970:

Art. 1º. – A informação deve estar ao serviço de cada cidadão. Seu desenvolvimento deve se realizar em um quadro de cooperação internacional. Ela não deve ameaçar nem a identidade humana, nem os direitos dos homens, nem a vida privada, nem as liberdades individuais e públicas.

Art. 2º. – Qualquer decisão judicial que implique a avaliação do comportamento humano não poderá ter por fundamento um tratamento automatizado de informação que forneça uma definição do perfil ou da personalidade do interessado.

Art. 3º. – Toda pessoa tem o direito de conhecer e contestar as informações e as razões utilizadas nos tratamentos automatizados cujos resultados se opõe.

Art. 4º. – São consideradas informações pessoais (*informations nominatives*), para os fins dessa lei, aquelas que permitem, sob qualquer forma, diretamente ou não, identificar as pessoas físicas as quais elas se aplicam, seja o tratamento realizado por uma pessoa física ou jurídica.

Art. 5º. – É denominado como tratamento automatizado de informações pessoais, no sentido da presente lei, todo conjunto de operações realizadas por meio automáticos, relativo a coleta, registro, elaboração, modificação, conservação e

destruição dessas informações pessoais, assim como todo conjunto de operações da mesma natureza que se relacione à exploração de arquivos ou bases de dados e, especialmente, as interconexões ou relacionamentos, consultas ou comunicações de informações pessoais.¹⁸

Assim, podemos localizar que o direito à explicação e à oposição é bem mais antigo do que o Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante RGPD), bem como que esses direitos se referem aos direitos fundamentais, como acabou por ser reconhecido na Europa com a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia¹⁹. A Carta é parte do conjunto de documentos jurídicos que garante o funcionamento institucional e orgânico à União Europeia, como um governo supranacional dos Estados-membros que a compõem²⁰. Ela foi aprovada em 2000 e o seu artigo 8º é dedicado à proteção dos dados pessoais²¹. Pouco antes da aprovação da Carta, porém, havia sido aprovada a Diretiva para proteção dos dados pessoais, em 1995, agora revogada pelo RGPD. O conceito de decisão automatizada é aclarado no próprio RGPD, como será visto a frente. Não obstante, na doutrina existem definições como:

Uma decisão individual automatizada é aquela que produz efeitos jurídicos sobre uma pessoa física ou que, de modo similar, a afeta de uma maneira significativa, sendo tomada com base no único fundamento derivado de um tratamento automatizado de dados pessoais, destinado a avaliar alguns aspectos da personalidade ou do comportamento do titular.²²

Nas próximas subseções será explicado o sistema geral de proteção dos titulares de dados pessoais em face das decisões totalmente automatizadas. Também, a seguir, serão expostos os direitos de explicação e de oposição aos tratamentos automatizados com foco no RGPD.

2.1.A proteção em face de decisões automatizadas

Logo no n.º 1 do artigo 2º do RGPD²³ já existe uma menção expressa à proteção dos dados pessoais em face de tratamentos automatizados, pois a norma jurídica:

[...] aplica-se ao tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados, bem como ao tratamento por meios não automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados.

Esse âmbito material de proteção não é novo, uma vez que a Diretiva 95/46/CE, revogada pelo RGPD, também previa tal proteção no seu art. 11º, estatuidando que:

[...] os princípios da protecção dos direitos e liberdades das pessoas, nomeadamente do direito à vida privada, contidos na presente directiva, precisam e ampliam os princípios contidos na Convenção do Conselho da Europa, de 28 de Janeiro de 1981, relativa à protecção das pessoas no que diz respeito ao tratamento automatizado de dados pessoais.²⁴

A doutrina anterior ao advento do RGPD já indicava a proposta de Regulamento e frisava que ele trazia prescrições jurídicas contrários à formação de perfis no contexto de decisões públicas e privadas:

Quando as medidas de perfilamento (*profiling*), inserindo-se em um quadro de exceções, são aplicadas, o responsável pelo tratamento tem – além de sua obrigação

de respeitar todas as regras constantes do projeto de regulamento – a obrigação de informar a pessoa sobre a existência do perfilhamento (*profiling*) e dos efeitos esperados sobre sua situação [...]. A possibilidade de fazer valer o seu ponto de vista desaparece de exigência sistemática de uma intervenção humana, incluindo uma explicação sobre a decisão. Ainda no quadro de direitos de acesso, é proposta, ademais, a obrigação do responsável pelo tratamento de comunicar elementos sobre ‘as informações úteis relativas à lógica por detrás de todo tratamento automatizado’.²⁵

O n.º 1 do artigo 3º da Diretiva fixava o referido direito de proteção, o qual deveria ser transposto aos direitos nacionais dos Estados-membros. Os *consideranda* 15, 27 e 41 da Diretiva de 1995 também explicitavam a proteção às pessoas em face de tratamentos automatizados de dados. Tanto a Diretiva, quanto o RGPD, estabelecem que os Estados-membros estavam obrigados a observar a jurisdição de direitos humanos do Conselho da Europa. Cabe lembrar que o Conselho da Europa é uma organização internacional que congrega uma gama maior de países do que aqueles que estão unidos na União Europeia. O Conselho da Europa remonta ao Tratado de Londres, de 1949, e ele está sediado em Estrasburgo, na França. O RGPD indica tal submissão no seu *considerandum* 105, que cito:

(105) Além dos compromissos internacionais assumidos pelo país terceiro ou pela organização internacional, a Comissão deverá ter em conta as obrigações decorrentes da participação do país terceiro ou da organização internacional nos sistemas multilaterais ou regionais, em especial no que diz respeito à proteção dos dados pessoais, bem como o cumprimento de tais obrigações. Em especial, há que ter em conta a adesão do país terceiro em causa à Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, de 28 de janeiro de 1981²⁶, e ao seu Protocolo Adicional. A Comissão deverá consultar o Comité quando avaliar o nível de proteção nos países terceiros ou organizações internacionais.²⁷

Recentemente, o Conselho da Europa terminou a revisão da referida Convenção para atualizá-la aos termos da sociedade digital contemporânea. Atualmente, portanto, vigora a Convenção 108+, que trata exatamente da proteção de dados pessoais. O artigo 9(1)(a) dessa Convenção inclui no rol dos direitos daqueles submetidos ao tratamento de dados (*data subjects*) a proteção em face de decisões completamente automatizadas: “[...] não se sujeitar a uma decisão que significativamente lhe afete e que seja baseada somente em um processamento automatizado de dados, sem que suas opiniões sejam levadas em consideração.”²⁸

A explicação sobre o dispositivo jurídico frisa a necessidade de conciliar esse direito específico com o direito de empresas, instituições e governos que precisem realizar tratamentos de dados de forma legítima. Uma vez descrita a proteção em geral em face das decisões completamente automatizadas, cabe entender o direito à oposição, tal como previsto na antiga Diretiva de proteção de dados e no RGPD.

2.2.O direito à oposição em face de decisões automatizadas

O artigo 15º da Diretiva 95/46/CE explicitamente previa o direito de oposição contra decisões totalmente automatizadas:

1. Os Estados-membros reconhecerão a qualquer pessoa o direito de não ficar sujeita a uma decisão que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que a afete de modo significativo, tomada exclusivamente com base num tratamento automatizado de dados destinado a avaliar determinados aspectos da sua personalidade, como por exemplo a sua capacidade profissional, o seu crédito, confiança de que é merecedora, comportamento.

2. Os Estados-membros estabelecerão, sob reserva das restantes disposições da presente directiva, que uma pessoa pode ficar sujeita a uma decisão do tipo referido no nº 1 se a mesma:

a) For tomada no âmbito da celebração ou da execução de um contrato, na condição de o pedido de celebração ou execução do contrato apresentado pela pessoa em causa ter sido satisfeito, ou de existirem medidas adequadas, tais como a possibilidade de apresentar o seu ponto de vista, que garantam a defesa dos seus interesses legítimos; ou

b) For autorizada por uma lei que estabeleça medidas que garantam a defesa dos interesses legítimos da pessoa em causa.²⁹

O RGPD expandiu os instrumentos jurídicos do antigo artigo 15º da Diretiva e os inseriu no artigo 22º. Assim, por meio do RGPD, o legislador europeu inseriu o consentimento explícito como uma possibilidade de autorização para o tratamento de dados pessoais, junto com as imposições contratuais e com a autorização legal.

Artigo 22.º – Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis

1. O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.

2. O n.º 1 não se aplica se a decisão:

a) For necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o titular dos dados e um responsável pelo tratamento;

b) For autorizada pelo direito da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento estiver sujeito, e na qual estejam igualmente previstas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos interesses do titular dos dados; ou

c) For baseada no consentimento explícito do titular dos dados.

3. Nos casos a que se referem o n.º 2, alíneas a) e c), o responsável pelo tratamento aplica medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e legítimos interesses do titular dos dados, designadamente o direito de, pelo menos, obter intervenção humana por parte do responsável, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão.

4. As decisões a que se refere o n.º 2 não se baseiam nas categorias especiais de dados pessoais a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, a não ser que o n.º 2, alínea a) ou g), do mesmo artigo sejam aplicáveis e sejam aplicadas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos interesses do titular.³⁰

Quando do advento do RGPD, em 2016, a totalidade dos Estados-membros da União Europeia já havia realizado a transposição da Diretiva de 1995 para os seus ordenamentos. Dessa forma, a expansão do catálogo de direitos, insertos no artigo 22º do RGPD já estava em razoável conformidade com os sistemas jurídicos dos vários países. Se o artigo 15º da Diretiva corresponde ao artigo 22º do RGPD,

cabe notar que o artigo 21º do RGPD corresponde ao artigo 14º da Diretiva. Esses dispositivos jurídicos da Diretiva visavam a regular o direito à oposição contra alguns tipos de tratamentos de dados:

Artigo 14º - Direito de oposição da pessoa em causa

Os Estados-membros reconhecerão à pessoa em causa o direito de:

a) Pelo menos nos casos referidos nas alíneas e) e f) do artigo 7º, se opor em qualquer altura, por razões preponderantes e legítimas relacionadas com a sua situação particular, a que os dados que lhe digam respeito sejam objecto de tratamento, salvo disposição em contrário do direito nacional. Em caso de oposição justificada, o tratamento efectuado pelo responsável deixa de poder incidir sobre esses dados;

b) Se opor, a seu pedido e gratuitamente, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito previsto pelo responsável pelo tratamento para efeitos de mala directa; ou ser informada antes de os dados pessoais serem comunicados pela primeira vez a terceiros para fins de mala directa ou utilizados por conta de terceiros, e de lhe ser expressamente facultado o direito de se opor, sem despesas, a tais comunicações ou utilizações.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para garantir que as pessoas em causa tenham conhecimento do direito referido no primeiro parágrafo da alínea b).³¹

Os casos mencionados na alínea “a” do artigo 14º da Diretiva se referiam ao tratamento em razão de interesse público e de exercício da autoridade pública (alínea “e” do Art. 7º) e ao tratamento por interesses legítimos, desde que ele não conflite com quaisquer direitos fundamentais da pessoa cujos dados estão sendo tratados (alínea “f” do Art. 7º). O direito de oposição previsto na alínea “b” do artigo 14º era bem restrito. Ele visava a proteger as pessoas contra a formação não consentida de malas directas, bem como da entrega de tais bases de dados para o uso de terceiros. A atual redação do artigo 21º do RGPD possui maior alcance como pode ser conferido a seguir:

Artigo 21.º – Direito de oposição

1. O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no artigo 6.º, n.º 1, alínea e) ou f), ou no artigo 6.º, n.º 4, incluindo a definição de perfis com base nessas disposições. O responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.

2. Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta, o titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito para os efeitos da referida comercialização, o que abrange a definição de perfis na medida em que esteja relacionada com a comercialização direta.

3. Caso o titular dos dados se oponha ao tratamento para efeitos de comercialização direta, os dados pessoais deixam de ser tratados para esse fim.

4. O mais tardar no momento da primeira comunicação ao titular dos dados, o direito a que se referem os n.ºs 1 e 2 é explicitamente levado à atenção do titular dos dados e é apresentado de modo claro e distinto de quaisquer outras informações.

5. No contexto da utilização dos serviços da sociedade da informação, e sem prejuízo da Diretiva 2002/58/CE, o titular dos dados pode exercer o seu direito de oposição por meios automatizados, utilizando especificações técnicas.

6. Quando os dados pessoais forem tratados para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, nos termos do artigo 89.º, n.º 1, o titular dos dados tem o direito de se opor, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, salvo se o tratamento for necessário para a prossecução de atribuições de interesse público.³²

O RGPD expandiu sobremaneira o direito de oposição ao tratamento de dados, em comparação com a Diretiva. Ele não se restringiu apenas a um tipo de tratamento de dados como os automatizados. O n.º 1 do artigo 21º indica que o titular, em princípio, poderia se insurgir contra qualquer tratamento de seus dados pessoais. Não obstante, a redação do dispositivo deixa clara a necessidade de uma ponderação entre as alegações e os interesses dos titulares de dados pessoais e dos responsáveis por ele. O ônus da prova, contudo, é invertido ao responsável pelo tratamento, o qual deverá comprovar que há precedência de suas alegações e interesses em detrimento daquelas do titular. O n.º 2 do artigo 21º não permite essa contraposição do responsável, uma vez que ela abrange a hipótese de insurgência dos titulares contra os tratamentos realizados com finalidades comerciais, inclusive para formação de perfis de clientes.

Em princípio, na União Europeia, esse direito à oposição poderá ser demandado tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. Para concretizar esse intento, já existem autoridades administrativas de proteção de dados nos vários Estados-membros. O maior empecilho para efetivar essa proteção remanesce, contudo, na ciência, por parte dos titulares, sobre os tratamentos, bem como sobre os eventuais danos sofridos. Logo, o RGPD possui diversos dispositivos que cuidam de tutelar o direito à informação que os titulares dos dados pessoais devem ter para se proteger. O direito à explicação é uma expansão conceitual do direito à informação. Ele foi inserido no RGPD exatamente para suprir essa lacuna em relação às decisões automatizadas. Ele será analisado no próximo tópico.

2.3.O direito à explicação sobre a lógica subjacente às decisões automatizadas

Os artigos 10º e 11º da Diretiva 95/46/CE previam a necessidade de garantir a informação aos titulares sobre tratamento. Esse direito deveria ser concretizado nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros após a transposição da norma jurídica da União Europeia. O RGPD ampliou em muito o sistema da antiga Diretiva. O direito de informação foi detalhado em diversos procedimentos ao longo dos artigos 12º, 13º, 14º e 15º, além de estar previsto em vários outros dispositivos esparsos. No rol do direito à informação está contido o direito à explicação em relação às decisões automatizadas. Esse direito determina que o titular dos dados pessoais deve ser informado da lógica subjacente à decisão. Esse direito era previsto, na Diretiva 95/46/CE, no artigo 12º:

Artigo 12.º – Direito de acesso

Os Estados-membros garantirão às pessoas em causa o direito de obterem do responsável pelo tratamento:

a) Livremente e sem restrições, com periodicidade razoável e sem demora ou custos excessivos:

[...]

– o conhecimento da lógica subjacente ao tratamento automatizado dos dados que lhe digam respeito, pelo menos no que se refere às decisões automatizadas referidas no n.º 1 do artigo 15.º; [...].³³

O RGPD continuou a prever esse direito à informação sobre a lógica subjacente à realização de decisões automatizadas na alínea “f” do n.º 1 do artigo 13º. Ele previu ainda que o responsável pelo tratamento possui o dever de informar o titular sobre a importância e as consequências do procedimento automatizado:

Artigo 13.º – Informações a facultar quando os dados pessoais são recolhidos junto do titular

1. Quando os dados pessoais forem recolhidos junto do titular, o responsável pelo tratamento faculta-lhe, aquando da recolha desses dados pessoais, as seguintes informações:

[...]

f) A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, referida no artigo 22.º, n.ºs 1 e 4, e, pelo menos nesses casos, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos dados.³⁴

O tema da explicação da lógica subjacente às decisões automatizadas no direito europeu é detalhado nos *consideranda* 63, 68 e 71 do Regulamento. Não há necessidade de transcrever os longos trechos dos dispositivos do RGPD aqui. Porém, vale mencionar que a preocupação do legislador europeu tem sido permitir que os titulares possam ter controle sobre os seus dados pessoais nas suas mais variadas facetas. A dificuldade para efetivar esse direito à explicação se encontra em duas barreiras. A primeira barreira possui caráter técnico. Avaliar – ou auditar – os algoritmos é uma tarefa muito complexa e que exige um claro dispêndio de recursos. Para tornar a questão mais complicada, as empresas e entidades estatais podem modificar os seus algoritmos, exigindo um redobrado esforço de atualização das autoridades independentes de controle. A segunda barreira tem clara natureza jurídica. Os programas de computador – e os algoritmos – podem ter proteção por direitos da propriedade intelectual. Assim, as avaliações e as auditorias teriam que ser realizadas em contextos de proteção desses direitos, o que torna um pouco mais intrincada a operação. Para entender como as barreiras retro indicadas já foram previstas pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu, há que se analisar dois outros dispositivos do RGPD: o art. 35º e o art. 47º.

2.4.Procedimentos de controle sobre sistemas de decisão automatizados no RGPD

Para que os direitos de proteção aos dados pessoais possam ter efetividade, é clara a necessidade de meios administrativos e judiciais de controle. Essa inteligência já era clara, em França, quando da aprovação da Lei de Informática e de Liberdades, que, no seu capítulo II, criou a CNIL – Comissão Nacional de Informática e de Liberdades (*Commission nationale de l’informatique et des libertés*).

São órgãos ou entidades nacionais como a CNIL que possuem a competência técnica e jurídica de fiscalizar e atuar em prol da concretização do direito à proteção de dados. Nesse quadrante dos meios de proteção, o RGPD dedicou dois dispositivos expressos às decisões automatizados.

O primeiro dispositivo jurídico versa sobre a realização de avaliação de impacto por parte das autoridades nacionais de controle em empresas, entes estatais e demais organizações da vida social. Essa avaliação de impacto torna-se mandatória para todos os responsáveis por tratamentos, os quais as devem realizar para tentar delimitar, previamente, os riscos potenciais e efetivos relacionados aos tratamentos. Uma avaliação prévia é relevante, uma vez que ela poderá servir de parâmetro para elucidar eventuais falhas e dificuldades técnicas inesperadas. Ela servirá, também, para documentar – do ponto de vista formal – o tratamento e, assim, permitir que haja uma eventual supervisão da autoridade de controle, em caso de violações ou de problemas técnicos. Essa obrigação está prevista no art. 35º do RGPD:

Artigo 35.º – Avaliação de impacto sobre a proteção de dados

1. Quando um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única avaliação.

[...]

3. A realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados a que se refere o n.º 1 é obrigatória nomeadamente em caso de:

a) Avaliação sistemática e completa dos aspetos pessoais relacionados com pessoas singulares, baseada no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, sendo com base nela adotadas decisões que produzem efeitos jurídicos relativamente à pessoa singular ou que a afetem significativamente de forma similar³⁵; [...].

Além dessa obrigação dirigida aos responsáveis pelos tratamentos, o RGPD prevê, também, a fixação de regras vinculativas coerentes em todo o mercado único digital. O objetivo da coerência está fixado no art. 63º:

A fim de contribuir para a aplicação coerente do presente regulamento em toda a União, as autoridades de controlo cooperam entre si e, quando for relevante, com a Comissão, através do procedimento de controlo da coerência previsto na presente secção.

As regras vinculativas serão, portanto, derivadas da coerência na aplicação do RGPD. Esse objetivo visa a trazer uma normalização técnica e jurídica em relação à aplicação do regulamento na União Europeia. Um dos elementos centrais da normalização está previsto na alínea “e” do § 2º do art. 47º. Ele se refere ao direito de oposição às decisões automatizadas e, prevê, inclusive, o direito de ação administrativa e judicial daqueles que se sentirem prejudicados:

Artigo 47.º – Regras vinculativas aplicáveis às empresas

1. Pelo procedimento de controlo da coerência previsto no artigo 63.º, a autoridade de controlo competente aprova regras vinculativas aplicáveis às empresas, que devem:

[...]

c) Preencher os requisitos estabelecidos no n.º 2.

2. As regras vinculativas aplicáveis às empresas a que se refere o n.º 1 especificam, pelo menos:

[...]

e) Os direitos dos titulares dos dados relativamente ao tratamento e regras de exercício desses direitos, incluindo o direito de não ser objeto de decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado, nomeadamente a definição de perfis a que se refere o artigo 22.º, o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo competente e aos tribunais competentes dos Estados-Membros nos termos do artigo 79.º, bem como o de obter reparação e, se for caso disso, indemnização pela violação das regras vinculativas aplicáveis às empresas; [...].

O objetivo de mencionar os artigos 35º e 47º do RGPD é evidenciar a necessidade de apreciação sistemática do conjunto normativo do próprio Regulamento – artigos que preveem diretamente os direitos de explicação e de oposição, por exemplo –, bem como demonstrar que a nova legislação europeia nasce no contexto de um conjunto de políticas públicas relacionadas à regulação e ao fomento da Internet em Europa: o Mercado Único Digital³⁶. O panorama brasileiro é bastante diferente. A legislação nacional não emerge de um processo amplo de concatenação de políticas públicas. Ela, assim como ocorreu com o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), se origina de uma conjuntura social e política específica³⁷.

3. O marco jurídico brasileiro

A LGPD possui um marco normativo menos detalhado do que aquele previsto no RGPD. O direito de oposição às decisões automatizadas está fixado no artigo 20 da Lei brasileira. Entre a publicação da Lei 13.709/2018, em 15 de agosto de 2018, até a edição da Medida Provisória (MP) 869/2018, vigorou uma redação pela qual se estatuiu o direito subjetivo daquele afetado pelo tratamento demandar a revisão da decisão exclusivamente automatizada por uma pessoa natural. Quando da época da conversão da Medida Provisória na Lei 13.853/2019, houve a tentativa de manter a redação alterada pela MP; mas, inserir um parágrafo (3º) no artigo 20, o qual previa a obrigatoriedade de revisão por pessoa natural. Esse foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não obstante, quando da sanção presencial, essa disposição foi vetada. Assim, ficou, definitivamente, excluída a obrigação de revisão por pessoa natural. A redação dos §§ 1º e 2º do art. 20 não foi alterada com a edição da Medida Provisória e nem com a sua conversão em lei. Logo, o § 1º continua a prever o direito à informação sobre os critérios e procedimentos para produção das decisões automatizadas, bem como o § 2º determina que a falha em informar poderá dar ensejo à realização de uma auditoria técnica pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem

seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.³⁸

Porém, antes do advento da LGPD, o Brasil já havia aprovado uma lei específica para regular a Internet: o Marco Civil (Lei nº 12.965/2014). Os direitos dos usuários estão listados nos artigos 7º e 8º dessa Lei. Assim, os incisos I, II e III do art. 7º da Lei são dedicados à proteção da privacidade. O direito à informação sobre a prestação de serviços de provedores de acesso e de aplicação é definido pelos incisos VI e XI do mesmo art. 7º. A necessidade de consentimento do usuário também já era prevista no Marco Civil da Internet, conforme depreende-se dos incisos VII e IX do art. 7º. Mais ainda, o Marco Civil da Internet – no inciso VIII do art. 7º – já previa a necessidade de outorga, por parte dos provedores de acesso e de aplicações em relação aos usuários, de “informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais”.

O Marco Civil da Internet ainda explicitava que o uso dos dados pessoais pelos provedores de acesso e de aplicações estaria limitado às situações previstas nas alíneas do inciso, ou seja: justificativa, legalidade e previsão contratual. Parece óbvio, mas é importante ressaltar que as três hipóteses precisam estar presentes. Esse acervo de direitos é ainda acrescido da previsão do art. 8º do Marco Civil da Internet, cujo *caput* prescreve a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão. O inciso I do parágrafo único do mesmo art. 8º prevê que cláusulas contratuais em ofensa ao direito à privacidade serão nulas, bem como serão nulas aquelas que prevejam como compulsório um foro estrangeiro para dirimir conflitos. A única menção ao sistema automatizado de decisões, no Marco Civil da Internet, está no inciso III do art. 25: “Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar: [...] III - compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações”. Essa neutralidade técnica deveria ter sido frisada em relação às demais aplicações, especialmente, tendo-se em conta que o exercício de fiscalização demandará que tais operações sob escrutínio possam ser compreendidas de forma clara.

Não obstante, apesar de a LGPD ser menos detalhada do que o RGPD europeu, ela possui uma nítida intenção de produzir um paralelo, como menciona Ana Frazão na série de artigos que publicou sobre esses dispositivos³⁹. A tarefa de proteger os cidadãos contra os usos mal-intencionados dos seus dados pessoais parece hercúlea. Mesmo no caso do RGPD, que emerge de um contexto social e institucional no qual já existiam normas jurídicas específicas – as leis nacionais que transpuserem a Diretiva 95/46/CE – e entes administrativos específicos – as várias autoridades nacionais de proteção de dados –, residem dúvidas sobre a sua aplicabilidade plena. Em um artigo de 2017, Tal Z. Zarsky considera que existem duas maneiras para lidar com o artigo 22º do RGPD: as empresas mudarão os

seus sistemas para torná-los auditáveis e claros, perdendo eficiência; ou, as empresas criarão sistemas humanos de supervisão⁴⁰. Na verdade, o texto do autor postula que o RGPD oferece vários exemplos de incompatibilidades jurídicas com as práticas contemporâneas de *Big Data*, entre as quais a limitação de propósito das coletas, a minimização da coleta em proporção à quantidade necessária para viabilizar o tratamento, as categorias especiais de dados e, por fim, o sistema de tratamento automatizado. Como pode ser compreendido, existem desafios na União Europeia, mesmo ela contando com um acervo jurídico e institucional bem estabilizado para a proteção dos dados pessoais. No caso brasileiro, haverá a necessidade de muita atenção ao panorama europeu para que seja possível robustecer um marco institucional e jurídico de proteção.

4. Considerações finais

A efetividade das prescrições jurídicas sobre proteção de dados, no contexto atual de *Big Data*, depende largamente dos meios técnicos disponíveis para o monitoramento e para a auditoria. A afirmação de direitos subjetivos na legislação é muito importante, certamente. Não obstante, é evidente que a falta de capacidade técnica pode configurar um empecilho para a efetividade do direito. Além dos meios técnicos, existe um outro problema, de cunho institucional e social. Será necessário um enorme esforço de tradução, por parte das autoridades nacionais de controle, para tornar claras e evidente as intrincadas inferências e processos de análise que caracterizam o *Big Data*. O ceticismo de parte da literatura, como o já mencionado Tal Z. Zasky, reside exatamente na dificuldade técnica de garantir um ambiente pleno de proteção de dados, sem que ele seja danoso ao desenvolvimento econômico. Outro problema é a diferenciação de escala entre empresas e instituições reguladas. Tanto o RGPD, quanto a LGPD, não possuem uma evidente baliza diferenciadora na atribuição de obrigações jurídicas em conformidade com o tamanho da empresa. No caso da LGPD, existe uma distinção evidente entre o poder público e as entidades privadas, ao passo que o RGPD possui algumas exceções específicas para o interesse público. Todavia, ambos os diplomas jurídicos mencionados padecem da indistinção de peso regulatório em relação aos regulados. O risco que esse tratamento uniforme permite é exatamente criar mais um estímulo à concentração empresarial, uma vez que os grandes grupos econômicos poderão fruir de departamentos técnicos especializados para minorar os custos de aderência aos padrões regulatórios do RGPD e da LGPD. As pequenas e médias empresas, ao contrário, correm o risco de sofrer esses custos regulatórios com mais veemência.

A comparação entre o RGPD e a LGPD evidencia que a norma jurídica da União Europeia possui uma grande vantagem em relação à Lei brasileira. Ela advém de um processo social e político que remonta à década de 1970. Assim, uma boa parte dos países europeus já possuía legislação nacional sobre o tema, como é o caso da França, mencionado anteriormente. Com a Diretiva 95/46/CE, todos os Estados-membros caminharam para a situação jurídica e institucional de possuírem leis nacionais; em razão da obrigação de transposição da norma da União Europeia. Desse modo, ainda que haja assimetrias entre os Estados-membros no tocante à tradição e ao funcionamento das suas autoridades nacionais de proteção, fica claro que o processo regulatório europeu já possui

algumas décadas de prática. Esse fortalecimento intrínseco ainda é robustecido pela atuação do Conselho da Europa, como também foi mencionado anteriormente. A Convenção 108 foi aprovada nessa organização internacional na década de 1980 e, ainda, existe uma jurisprudência importante derivada desse documento.

No caso brasileiro, a tradição terá que ser construída sem que tenha existido qualquer processo semelhante. Existe uma jurisprudência nacional baseada no Marco Civil da Internet. Todavia, ela não possui ainda a mesma densidade daquela que existe na União Europeia. Também, o tema da proteção de dados pessoais é estranho ao Sistema Interamericano de Direito Humanos. Assim, seja pelo prisma nacional, seja pelo prisma do direito internacional, bem se compreende que o tema da proteção de dados possui raízes no debate jurídico europeu e, de outro lado, apresenta-se como incipiente no caso brasileiro. Em conclusão, o estudo das experiências estrangeiras de proteção de dados é crucial. Tal pesquisa é imperativa para que esse tema jurídico possa ser bem incorporado no Brasil, seja na literatura jurídica, seja nas práticas institucionais.

5. Referências

ABREU, Joana Covelo. O Mercado Único Digital e o seu desígnio político-constitucional: o impacto da Agenda Eletrónica Europeia nas soluções de interoperabilidade. *UNIO EU Law Journal*, v. 3, n. 1, p. 130-150, jan. 2017.

BENSOUSSAN, Alain (Dir.). *La protection des données personnelles de A à Z*. Bruxelles: Bruylant, 2017.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2018.

BOYLE, James. A theory of law and information: copyright, spleens, blackmail, and insider trading. *California Law Review*, v. 80, n. 6, p. 1413-150, 1992.

BUCKLAND, Michael. *Information and information systems*. Westport, CT: Praeger, 1991.

BUCKLAND, Michael. *Information and society*. Cambridge, MA: MIT Press, 2017.

CASTELLS, Manuel. *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age*. 2. ed. Cambridge, MA: Polity Press, 2015.

CATE, Fred H.; CULLEN, Peter; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. *Data protection principles for the 21st Century: revising the 1980 OECD Guidelines (revised edition)*. Oxford: Oxford Internet Institute, mar. 2014. 24 p.

COHEN, Julie E. *Configuring the networked self: law, code, and the play of everyday practice*. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.

CONSELHO DA EUROPA. *Convention 108+*: Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Strasbourg: Conseil de l'Europe, jun. 2018. 33 p. Disponível em: [rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1]. Acesso em: 14.01.2019.

CONSELHO DA EUROPA. *Treaty No. 108*: Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. Disponível em: [www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108]. Acesso em: 18.01.2018.

DE FILLIPPI, Primavera. Big Data, big responsibilities. *Internet Policy Review: Journal of Internet regulation*, v. 3, n. 1, p. 1-12, jan. 2014.

DEBET, Anne. Les conditions générales de licéité du traitement de données. In: DEBET, Anne. *Informatique et libertés*: la protection des données à caractere personnel em droit français et européen. Paris: Lextenso Éditions, 2015.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

FRANÇA. *LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés* (Lei n.º 70-17 de 6 jan. 1978, relativa à informática, aos arquivos e às liberdades). Paris: Journal Officiel de la République Française: 7 jan. 1978. p. 227-231. Disponível em: [www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886460&pageCourante=00227]. Acesso em: 14.01.2019.

FRAZÃO, Ana. *Controvérsias sobre o direito à explicação e à oposição diante de decisões automatizadas*, 12 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/controversias-sobre-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-diante-de-decisoes-automatizadas-12122018]. Acesso em: 14.01.2018.

FRAZÃO, Ana. *Direito à explicação e à oposição diante de decisões totalmente automatizadas*, 5 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/o-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-diante-de-decisoes-totalmente-automatizadas-05122018]. Acesso em: 14.01.2019.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: ainda sobre a eficácia do direito à explicação e à oposição*, 26 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-ainda-sobre-a-eficacia-do-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-26122018]. Acesso em: 14.01.2019.

HILBERT, Martin; LÓPEZ, Priscila. The world's technological capacity to store, communicate, and compute information. *Science*, v. 332, n. 6025, p. 60-65, 1º abr. 2011.

HILDEBRANDT, Mireille. Slaves to Big Data. or are We? *IDP: Revista de Internet, derecho y política*, n. 17, p. 7-44, 2013. Disponível em: [works.bepress.com/mireille_hildebrandt/52]. Acesso em: 15.01.2019.

HORAN, Catherine Caturano. Ownership of human cell lines: your spleen is not worth what it used to be – Moore v. Regents of UCLA. *Creighton Law Review*, v. 24, n. 4, p. 1423-1448, 1991. Disponível em: [dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/39887]. Acesso em: 08.01.2019.

HOWARD, Phillip N.; HUSSAIN, Muzammil. *Democracy's fourth wave? Digital media and the arab spring*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e direito do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

PAIS, Sofia Oliveira. *Estudos de direito da União Europeia*. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2018.

PASQUALE, Frank. *The black box society: the secret algorithms that control money and information*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

RICHARDS, Neil M.; KING, Jonathan H. Three paradoxes of Big Data. *Stanford Law Review Online*, v. 66, n. p. 41-46, set. 2013. Disponível em: [review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/66_StanLRevOnline_41_RichardsKing.pdf]. Acesso em: 14.01.2019.

SILVEIRA, Alessandra. *Princípios de direito da União Europeia*. Lisboa: Quid Juris, 2012.

UNIÃO EUROPEIA. *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia*. Bruxelas: 18 dez. 2000. Disponível em: [www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf]. Acesso em: 15.01.2019.

UNIÃO EUROPEIA. *Código de redação interinstitucional*. Bruxelas: UE, 2012. Disponível em: [publications.europa.eu/code/pt/pt-000100.htm]. Acesso em: 17.01.2018.

UNIÃO EUROPEIA. *Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML]. Acesso em: 15.01.2019.

UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Seção). *Google France SARL e Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA e Luteciel SARL (C-237/08) e Google*

France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e outros (C-238/08), 23 mar. 2010. Disponível em: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08]. Acesso em: 14.01.2019.

VERONESE, Alexandre. Editorial of January 2018: Article 13 and vigilance dilemma, 7 jan. 2019. *Official Blog UNIO: European Law Journal*. Disponível em: [officialblogofunio.com/2019/01/07/editorial-of-january-2019]. Acesso em: 14.01.2019.

VERONESE, Alexandre; CUNHA, Marcelo Barros da. A utilização das marcas alheias nos algoritmos de geração de palavras-chaves: uma análise sobre a jurisprudência do tribunal de justiça da união europeia para pensar sobre o caso brasileiro. *Revista Brasileira de Direito*, v. 13, p. 232-255, 2017.

VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, p. 71-99, 2018.

ZARSKY, Tal Z. Incompatible: the GDPR in the age of Big Data. *Seton Hall Law Review*, v. 47, p. 995-1020, 2017.

1

.Professor Adjunto de Teoria Social e do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (Unb) e coordenador do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações (GETEL/UnB). Pesquisador associado do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, CEDU (Universidade do Minho, Portugal).

2

.BUCKLAND, Michael. *Information and information systems*. Westport, CT: Praeger, 1991. p. 6.

3

.BUCKLAND, Michael. *Information and information systems*. Westport, CT: Praeger, 1991. p. 45.

4

.Ainda, segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011): “Art. 4.º [...] II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”.

5

.Reitere-se o sentido de informações como coisas e não como processos ou como conhecimento. Cf. BUCKLAND, Michael. *Information and society*. Cambridge, MA: MIT Press, 2017. p. 21-25.

6

.Essa seção é largamente baseada em: BOYLE, James. A theory of law and information: copyright, spleens, blackmail, and insider trading. *California Law Review*, v. 80, n. 6, p. 1413-150, 1992; HORAN, Catherine Caturano. Ownership of human cell lines: your spleen is not worth what it used to be – Moore v. Regents of UCLA. *Creighton Law Review*, v. 24, n. 4, p. 1423-1448, 1991. Disponível em: [dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/39887]. Acesso em: 08.01.2019.

7

.O aumento da capacidade computacional é constantemente mensurado. Um exemplo: HILBERT, Martin; LÓPEZ, Priscila. The world's technological capacity to store, communicate, and compute information. *Science*, v. 332, n. 6025, p. 60-65, abr. 2011.

8

.CATE, Fred H.; CULLEN, Peter; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. *Data protection principles for the 21st Century: revising the 1980 OECD Guidelines* (revised edition). Oxford: Oxford Internet Institute, mar. 2014. 24 p.

9

.CATE, Fred H.; CULLEN, Peter; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. Op. cit., p. 6. Tradução livre do autor. No original: "The world of Big Data poses serious information privacy risks that are exacerbated by the "notice and consent" requirements in the 1980 Guidelines and reflected in most modern data protection laws. In most cases, the collection of personal data not only requires the consent of the data subject but is also limited to the minimum amount of data necessary to achieve the purpose identified in the notice used to solicit consent, and that data may not be used for other, unrelated purposes without new consent. While this approach may have been feasible in 1980, it does little to protect individuals today or support the valuable new uses of personal data".

10

.Um texto explica esse tipo de conflitos ao comparar casos do Tribunal de Justiça da União Europeia com a jurisprudência brasileira. Cf. VERONESE, Alexandre; CUNHA, Marcelo Barros da. A utilização das marcas alheias nos algoritmos de geração de palavras-chaves: uma análise sobre a jurisprudência do tribunal de justiça da união europeia para pensar sobre o caso brasileiro. *Revista Brasileira de Direito*, v. 13, p. 232-255, 2017.

11

.UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia (Grande Seção). *Google France SARL e Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA e Luteciel SARL (C-237/08) e Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e outros (C-238/08)*, 23 mar. 2010. Disponível em: [curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08]. Acesso: 14.01.2019.

12

.HILDEBRANDT, Mireille. Slaves to Big Data. or are We? *IDP: Revista de Internet, derecho y política*, n. 17, p. 7-44, 2013. Disponível em: [works.bepress.com/mireille_hildebrandt/52]. Acesso em: 15.01.2019. No mesmo sentido: DE FILLIPPI, Primavera. Big Data, big responsibilities. *Internet Policy Review: journal of Internet regulation*, v. 3, n. 1, p. 1-12, jan. 2014.

13

.RICHARDS, Neil M.; KING, Jonathan H. Three paradoxes of Big Data. *Stanford Law Review Online*, v. 66, n. p. 41-46, set. 2013. Disponível em: [review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/66_StanLRevOnline_41_RichardsKing.pdf]. Acesso em: 14.01.2019.

14

.PASQUALE, Frank. *The black box society: the secret algorithms that control money and information*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

15

.COHEN, Julie E. *Configuring the networked self: law, code, and the play of everyday practice*. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.

16

.HOWARD, Phillip N.; HUSSAIN, Muzammil. *Democracy's fourth wave? Digital media and the arab spring*. Oxford: Oxford University Press, 2013; CASTELLS, Manuel. *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age*. 2. ed. Cambridge, MA: Polity Press, 2015.

17

.Uma síntese desse ponto: VERONESE, Alexandre. Editorial of January 2018: Article 13 and vigilance dilemma, 7 jan. 2019. *Official Blog UNIO: European Law Journal*. Disponível em: [officialblogofunio.com/2019/01/07/editorial-of-january-2019]. Acesso em: 14.01.2019.

.Tradução livre do autor; o original pode ser consultado: FRANÇA. *Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés* (Lei n.º 70-17 de 6 jan. 1978, relativa à informática, aos arquivos e às liberdades). Paris: Journal Officiel de la République Française: 7 jan. 1978. p. 227-231. Disponível em: [www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886460&pageCourante=00227]. Acesso em: 14.01.2019.

.Essa situação jurídica é bem diferente daquela que existe no Brasil. No caso brasileiro, existe uma construção dogmática para extrair o direito constitucional da proteção de dados pessoais do direito fundamental à privacidade e à vida íntima, bem como dos direitos civis da personalidade. Cf.: BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2018. p. 51-63; DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 27-30; MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e direito do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014.

.A variada gama de tratados fundantes acabou por ser consolidada no Tratado de Lisboa (2007), que remete diretamente à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (2000). Todavia, a conformação do governo supranacional da União Europeia é um tema muito detalhado para ser descrito aqui. Para tanto, confira: SILVEIRA, Alessandra. *Princípios de direito da União Europeia*. Lisboa: Quid Juris, 2012; PAIS, Sofia Oliveira. *Estudos de direito da União Europeia*. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2018.

.UNIÃO EUROPEIA. *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia*. Bruxelles: 18 dez. 2000. Disponível em: [www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf]. Acesso em: 15.01.2019.

.Tradução livre do autor. BENSOUSSAN, Alain (Dir.). *La protection des données personnelles de A à Z*. Bruxelles: Bruylant, 2017. p. 57.

.Será sempre utilizada a versão oficial em português para se referir aos documentos técnicos e jurídicos da União Europeia. Nunca é demais lembrar que a nossa língua consta do rol das línguas oficiais. Dúvidas sobre a redação em português da documentação da União Europeia podem ser dirimidas no seguinte sítio eletrônico: UNIÃO EUROPEIA. *Código de redação interinstitucional*. Bruxelles: UE, 2012. Disponível em: [publications.europa.eu/code/pt/pt-000100.htm]. Acesso em: 17.01.2018.

.UNIÃO EUROPEIA. *Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML]. Acesso em: 15.01.2019.

.DEBET, Anne. Les conditions générales de licéité du traitement de données. In: DEBET, Anne. *Informatique et libertés: la protection des données à caractere personnel em droit français et européen*. Paris: Lextenso Éditions, 2015. p. 380.

.Texto original da Convenção 108. Cf. CONSELHO DA EUROPA. *Treaty No. 108: Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data*. Disponível em: [www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108]. Acesso em: 18.01.2018.

.UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

.Tradução livre do autor. No original: “Article 9 [...] 1. Every individual shall have a right: a. not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on an automated processing of data without having his or her views taken into consideration”. Cf. CONSELHO DA EUROPA. *Convention 108+*: Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Strasbourg: Conseil de l’Europe, jun. 2018. 33 p. Disponível em: [rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1]. Acesso em: 14.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML]. Acesso em: 15.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível

em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML]. Acesso em: 15.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: [eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML]. Acesso em: 15.01.2019.

.UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento

Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

35

.UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho*, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em: 15.01.2019.

36

.ABREU, Joana Covelo. O Mercado Único Digital e o seu desígnio político-constitucional: o impacto da Agenda Eletrónica Europeia nas soluções de interoperabilidade. *UNIO EU Law Journal*, v. 3, n. 1, p 130-150, jan. 2017.

37

.VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 14, p. 71-99, 2018.

38

.BRASIL. *Lei nº 13.709*, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm]. Acesso em: 14.05.2020.

39

.FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD: ainda sobre a eficácia do direito à explicação e à oposição*, 26 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-ainda-sobre-a-eficacia-do-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-26122018]. Acesso em: 14.01.2019; FRAZÃO, Ana. *Controvérsias sobre o direito à explicação e à oposição diante de decisões automatizadas*, 12 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/controversias-sobre-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-diante-de-decisoes-automatizadas-12122018]. Acesso em: 14.01.2018; FRAZÃO, Ana. *Direito à explicação e à oposição diante de decisões totalmente automatizadas*, 5 dez. 2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/o-direito-a-explicacao-e-a-oposicao-diante-de-decisoes-totalmente-automatizadas-05122018]. Acesso em: 14.01.2019.

40

.ZARSKY, Tal Z. Incompatible: the GDPR in the age of Big Data. *Seton Hall Law Review*, v. 47, p. 995-1020, 2017.

Capítulo 15. Segurança e Sigilo dos Dados Pessoais: primeiras impressões à luz da Lei 13.709/2018

Carlos Affonso Pereira de Souza¹⁻²

1. Introdução

A ideia de que os dados pessoais são igualmente essenciais e vulneráveis fez com que as reflexões que se organizaram a sua volta consagassem o termo “proteção”. Fala-se sempre, então, em *proteção de dados pessoais*. A própria Lei 13.709/2018 (chamada “Lei Geral de Proteção de Dados” ou simplesmente “LGPD”) atesta, em sua ementa, que ela dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Não há como negar, então, que proteção e dados pessoais estão intrinsecamente ligados até na forma pela qual se vocaliza o objeto de estudo jurídico.

Fica então a pergunta subsequente: como proteger os dados pessoais? Nesse particular, segurança e sigilo aparecem como dois elementos incontornáveis para que se possa afirmar que dados (pessoais) são protegidos. Dito de outra forma, não existe proteção de dados sem segurança e sigilo.

Antes da aprovação da Lei 13.709/2018, diversos incidentes de segurança envolvendo dados pessoais foram destaque na imprensa geral e especializada. Aliás, se é verdade que o Brasil ainda não conta com uma cultura de proteção de dados pessoais amadurecida, as frequentes notícias sobre incidentes de segurança acabam exercendo um duplo papel. Por um lado, elas evidenciam que empresas, governos e entidades da sociedade civil ainda têm muito que fazer em termos de segurança e sigilo de dados. Por outro, a insistente comunicação sobre a ocorrência de vazamentos de dados pode ajudar na conscientização sobre a importância do tema. Se a mídia tanto comenta sobre o assunto é porque há de existir uma razão para isso.

Esse segundo fator – a formação da conscientização sobre a importância dos dados pessoais – guarda ainda um paradoxo que é a tentativa de se criar uma verdadeira cultura de proteção de dados a partir da maior visibilidade de situações em que justamente essa proteção falhou e os dados foram então acessados e usados indevidamente. Vale questionar se uma cultura de proteção de dados pode mesmo ser criada a partir da comunicação das violações do objeto que se pretende proteger.

Nessa direção, incentivar medidas de segurança e de sigilo de dados que possam ser seguidas pelos agentes de tratamento de dados pessoais é do interesse de todos. Cabe à legislação (e à regulamentação) garantir que as

condições para a implantação dessas medidas sejam estimuladas não apenas pelo receio de futuras sanções, mas também como parte essencial de um dever de cuidado que deve instruir toda relação que envolva tratamento de dados.

Por isso mesmo, a boa-fé desempenha um papel de destaque na formação de uma visão equilibrada entre o quanto se exige dos agentes de tratamento em termos de segurança e sigilo e o quanto os próprios agentes procurarão implementar para garantir que os seus produtos e serviços não sejam atingidos por danos reputacionais – cada vez mais graves – relacionados ao mau tratamento de dados pessoais. Antes de se preocupar com o valor das sanções, governos, empresas e demais entidades devem prestar atenção nesse relevante componente reputacional e como ele se encontra estritamente ligado à boa-fé objetiva e à formação de uma cadeia de confiança no tratamento de dados pessoais.

Um aspecto importante no debate sobre segurança é a compreensão do papel que desempenham os agentes de tratamento para garantir a segurança e o sigilo dos dados que estão sob seu controle. Muito se discute sobre como o sistema de proteção de dados deve garantir que o titular tenha controle sobre os seus dados.³ Para além do controle exercido pelo titular, é necessário analisar como os dados são tratados por terceiros e quais são os deveres que precisam ser observados para que a tutela dos dados não seja frustrada.

A Lei 13.709/2018 dedica uma seção à segurança e ao sigilo de dados pessoais, contendo os artigos 46 a 49. O objetivo do presente estudo é apresentar, de forma introdutória, algumas das principais aplicações desses dispositivos. Antes disso, vale lembrar que mesmo previamente à aprovação da LGPD, a segurança e o sigilo de dados pessoais levaram a questionamentos sobre a conduta adotada por empresas e governos no tratamento de dados. Cumpre assim fazer um rápido percurso pelos outros diplomas legais que tratam da segurança e do sigilo dos dados pessoais.

Em seguida, será explorada a seção respectiva da LGPD que, em quatro artigos, apresenta os contornos do assunto, com destaque para os temas que envolvem a chamada *privacy by design* (decorrente do artigo 46, § 2º, da LGPD) e as obrigações de notificação em caso de incidentes de segurança (art. 48).

2. Segurança e sigilo de dados na legislação brasileira

Quanto mais se consolida a noção de que o acesso a dados é ferramenta primordial para novos negócios – mas também instrumental para a prática de diversos ilícitos – aumentam consideravelmente os episódios de violação da segurança e do sigilo de dados. São casos que envolvem o vazamento de dados pessoais, a invasão de bancos de dados por *crackers* e a prática de crimes, como de falsa identidade e estelionato, tendo por base o acesso indevido a dados pessoais.

A LGPD não detém a exclusividade no tratamento do tema da proteção de dados pessoais, sendo o mesmo igualmente inserido em outros diplomas legais. O que singulariza a regulação presente na Lei 13.709/2018 é a sua abrangência, com a enunciação de princípios, direitos, responsabilidades e demais aplicações

decorrentes do tratamento de dados pessoais. Fora da LGPD, a proteção de dados encontra guarida constitucional e está também inserida no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet, por exemplo.

A Constituição Federal determina que a vida privada e a intimidade são invioláveis no artigo 5º, X, ao passo que o mesmo artigo 5º, XII, dispõe sobre a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. O *habeas data*, segundo o artigo 5º, LXXII, será ainda concedido “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” e para a retificação de dados.

A partir da tutela prevista na Constituição, coube a outros dispositivos na legislação infraconstitucional detalhar o regime de aplicação da proteção de dados, ora dotando-a de medidas práticas para prevenir o dano ou responsabilizar o autor de um ilícito, bem como garantindo ao titular de dados pessoais uma série de deveres. Nesse sentido, o art. 21 do Código Civil determina que o juiz pode tomar medidas para prevenir ou fazer cessar dano à privacidade. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por sua vez, dispõe que o consumidor deve ser comunicado por escrito sobre a abertura de bases de dados, tendo direito a acessar e a retificar os seus dados ali registrados.⁴

Não deixa de ser sintomático o fato de que o mesmo CDC que dedica vários dispositivos ao tema da segurança do consumidor, com especial atenção à segurança dos produtos, serviços e aos impactos da publicidade disseminada no mercado, não tenha feito, em 1990, qualquer menção ao fator segurança na Seção VI, do Capítulo V, denominada “Dos bancos de dados e cadastros de consumidores”.

A preocupação com a segurança e o sigilo dos dados vai aumentar na medida em que a conscientização sobre a relevância dos mesmos dados é disseminada na sociedade. A Internet, nesse aspecto, contribuiu em muito para que usuários comesçassem a perceber valor na segurança dos dados e a exigir padrões mais elevados no tratamento de seus dados por governos e empresas.

O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), em seu artigo 7º, preceitua uma série de regras sobre o tratamento de dados pessoais na rede. O art. 7º, II, assegura aos usuários a “inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações na Internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei”. A inviolabilidade e o sigilo também são reconhecidos para as “comunicações privadas armazenadas”, por força do art. 7º, III.

No que diz respeito aos dados armazenados pelos provedores de conexão e pelos provedores de aplicações, o Marco Civil da Internet já determina que o seu regime de guarda deverá atender a parâmetros de controle e de segurança. Nesse sentido são os artigos 13 e 15, aplicáveis aos provedores de conexão e aos provedores de aplicações, respectivamente:

Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em

ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

[...]

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

No que se refere às instituições financeiras, a Resolução 4658/2018, do Banco Central do Brasil (BACEN), dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem. Nos termos da Resolução (art. 3º), as instituições financeiras devem implantar uma política de segurança cibernética que contemple, entre outras medidas: (i) os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes; (ii) os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis; (iii) o registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos de incidentes relevantes para as atividades da instituição; e (iv) os mecanismos para disseminação da cultura de segurança cibernética na instituição.

Esse conjunto de dispositivos encontrados na legislação brasileira foi aplicado em diversas situações nas quais se procurava reconhecer a proteção de dados pessoais e, ao mesmo tempo, sancionar aqueles que violavam os seus preceitos.

Um caso que vale ser pontuado foi o que levou ao bloqueio do *site* denominado “Tudo sobre Todos”, por meio do qual era possível obter dados como endereço, número de telefone, nome dos ascendentes e demais informações mediante a indicação do nome da pessoa em uma simples chave de busca. Nunca houve qualquer consentimento por parte do titular de dados pessoais (ou aparentemente qualquer outro requisito para tratamento de dados) que legitimasse o funcionamento desse *site*.

Decisão liminar proferida em julho de 2015 pela 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte ordenou a suspensão do acesso ao *site*. De acordo com a petição do Ministério Público, o *site* “comercializava, a quem dispuser a pagar, dados pessoais de todos os brasileiros, como data de nascimento, número de CPF, endereço completo, perfil de parentes e, inclusive, vizinhos”.

Ao decidir a lide, o magistrado precisou aplicar o conjunto de dispositivos que protegem os dados pessoais no ordenamento brasileiro, antes mesmo da aprovação da LGPD. Nessa direção, foi reconhecida que a conduta da empresa era ilícita porque ela violava a proteção dos dados pessoais, contrariando assim o art. 5º, X, da Constituição Federal e os artigos 3º, 7º, 10 e 11 do Marco Civil da Internet.⁵

Com a aprovação e a entrada em vigor da LGPD, o tratamento de dados pessoais passa a receber uma abordagem mais detalhada pela legislação, ofertando a Lei mecanismos que ressaltam a relevância da segurança e do sigilo

dos dados pessoais coletados, armazenados e utilizados especialmente por empresas e governos.

A LGPD designa limites mais rígidos ao tratamento de dados, exigindo, por exemplo, a adoção de seguranças técnicas e administrativas para protegê-los de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito.

3. O tratamento da segurança e do sigilo de dados na LGPD (arts. 46-49)

A Lei Geral de Proteção de Dados é marco regulatório que estabelece as diretrizes para o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Dessa forma, ela supera os entraves que poderiam existir na aplicação de legislações setoriais, que ora se voltam para relações de consumo, ora apenas para as relações travadas por meio da Internet.

O tratamento de dados é definido, de acordo com o art. 5º, X, da LGPD, como:

toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Os responsáveis por praticar qualquer uma das operações descritas anteriormente podem ser *controladores* de dados (a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais) ou *operadores* (que realizam o tratamento de dados pessoais em nome do controlador). Em conjunto, controladores e operadores são designados como “agentes de tratamento”.

Apesar de exercerem funções diversas, tanto o controlador quanto o operador devem obedecer aos dispositivos e aos princípios estabelecidos na LGPD. No campo principiológico, o art. 6º determina que, além da boa-fé, as atividades de tratamento de dados deverão ser pautadas por diversos princípios, sendo oportuno destacar os seguintes que ganham especial destaque para o tema da segurança e do sigilo de dados:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

[...]

VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

[...]

X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.⁶

Por outro lado, ancorada nos princípios de segurança e de prevenção, a LGPD dedica todo um capítulo às medidas de segurança técnicas e administrativas que deverão ser implementadas por empresas, governos e demais entidades de modo a proteger os seus bancos de dados pessoais de acessos não autorizados. Tais medidas se tornam relevantes, sobretudo em um cenário no qual a invasão de bancos de dados e posterior vazamento das informações ali presentes são cada vez mais corriqueiros.

O Capítulo VII da LGPD, cujo título é “Da segurança e das boas práticas”, torna evidente, logo em seu primeiro artigo (art. 46), a influência dos princípios constantes no art. 6º. De acordo com o art. 46:

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

A partir do uso impositivo do verbo “dever”, verifica-se que a proteção adequada dos dados pessoais não é uma faculdade dos agentes de tratamento. Trata-se, na verdade, de uma imposição legal cujo descumprimento enseja a aplicação de sanções administrativas e eventual responsabilização civil.⁷

A LGPD apresenta ainda outra aplicação prática do princípio da segurança. De acordo com o art. 44, o tratamento de dados pessoais é irregular quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. O artigo traz, ainda, algumas circunstâncias relevantes que devem ser observadas. Veja-se:

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – o modo pelo qual é realizado;
- II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Em um primeiro momento, as indefinições sobre a criação e a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderiam levantar dúvidas a respeito da efetividade dos arts. 44 e 46, uma vez que o próprio § 1º do art. 46 determina que:

[a] autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no *caput* deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no *caput* do art. 6º desta Lei.

A nosso ver, esse posicionamento não deveria prevalecer. Os objetivos presentes no *caput* do artigo, bem como toda a *ratio* que permeia o princípio da

segurança, são claros: busca-se, em última instância, garantir o controle de acesso e impedir vazamentos e/ou perda de dados.⁸

Sobre o tema, ressalta-se, ainda, que o Decreto 8.771/16, que regulamenta o Marco Civil da Internet, detalha os padrões de segurança e sigilo dos registros, dados pessoais e comunicações privadas em seu Capítulo III. Na ausência de qualquer manifestação da Autoridade, a redação do Decreto poderá ser utilizada como parâmetro para os agentes de tratamento. Veja-se:

Art. 13. Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança:

I – o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados usuários;

II – a previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;

III – a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela empresa e o arquivo acessado, inclusive para cumprimento do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 12.965, de 2014; e

IV – o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes.

Ademais, a norma da ABNT ISO/IEC 27002, conhecida como “Código de prática para a gestão da segurança da informação”, também pode servir de subsídio aos agentes de tratamento, uma vez que dispõe sobre condutas e medidas para assegurar e preservar os dados sob sua administração. Eventual regulamentação por parte da ANPD sobre padrões de segurança técnicos mínimos não deve se afastar do que já foi previsto pelo Decreto 8.771/16 e pela norma da ISO/IEC 27002 e, se for o caso, deverá conceder prazo para eventual adaptação dos agentes de tratamento às suas disposições.

É oportuno destacar que esses padrões de segurança deverão ser implementados pelos agentes de tratamento e também por qualquer outra pessoa que intervenha em qualquer das fases do tratamento, conforme expressamente previsto no art. 47 da LGPD.

A noção de segurança e de sigilo devem assim permear todas as atividades de tratamento de dados, desde a concepção de um produto ou serviço. A noção de *privacy by design* é um ponto importante trazido pela LGPD e que merece destaque como um dos elementos mais relevantes do capítulo sobre segurança dos dados.

3.1. *Privacy by design*

As medidas de segurança dispostas anteriormente devem ser observadas desde a concepção do produto ou serviço, trazendo a preocupação com o tratamento de dados e com a proteção da privacidade para a prancheta. Não se

deve, assim, incorporar elementos protetivos da privacidade e dos dados pessoais como um adendo ao produto ou ao serviço já acabado, não usualmente apenas após um incidente de segurança.

Nesse sentido, a LGPD recepciona a ideia da chamada *privacy by design*, ou seja, a noção de que produtos e serviços precisam tomar a segurança e o sigilo de dados como um elemento a ser levado em conta em todas as suas fases de concepção, desenvolvimento, aplicação e avaliação. Segundo a redação do art. 46, § 2º, da LGPD:

“As medidas de que trata o *caput* deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.”

Desenvolvido na década de 1990 por Ann Cavoukian, ex-comissária de Informação e Privacidade da Província de Ontário, no Canadá, o conceito de *privacy by design* foi determinante para a transformação de como se enxerga a proteção de dados. O conceito antecipa a ideia de que o futuro da proteção de dados depende idealmente de uma mudança organizacional, transformando o modo de operação padrão de entidades que lidam com produtos ou serviços ancorados no tratamento de dados ou que possam impactar a privacidade de seus usuários e de terceiros.

Um fator importante do conceito de *privacy by design* é o fato de que a proteção de dados não será apenas assegurada pelo cumprimento de parâmetros regulatórios, mas sim por meio de um repensar por parte do agente de tratamento de dados sobre como a sua atividade pode impactar o usuário e terceiros e traduzir isso em medidas que transformam os processos de criação, desenvolvimento, aplicação e avaliação de produtos e de serviços.⁹

Ao comentar sobre a noção de *privacy by design*, Bruno Bioni esclarece que ela é “a ideia de que a proteção de dados pessoais deve orientar a concepção de um produto ou serviços, devendo eles ser embarcados com tecnologias que facilitem o controle e a proteção das informações pessoais.”¹⁰ Assim, mais do que uma ideia, ela se espelha nas ferramentas e nas tecnologias que permitem que o usuário possa ter controle sobre a coleta, sobre o armazenamento e a utilização de seus dados.

Conforme proposto por Ann Cavoukian, os objetivos da metodologia são atingidos a partir de sete princípios fundamentais¹¹: (i) proatividade e prevenção; (ii) privacidade por padrão; (iii) privacidade incorporada ao *design*; (iv) funcionalidade integral; (v) segurança em todo o ciclo de vida da informação; (vi) transparência e (vii) respeito à privacidade do usuário.

A positivação do conceito na LGPD não foi tão explícita como a que ocorreu na legislação europeia, mas é possível extrair a *ratio* criada na década de 1990 do mencionado artigo 46, § 2º. Percebe-se nele a inspiração da metodologia criada na década de 1990.¹²

O primeiro princípio define que a *privacy by design* é caracterizada por medidas mais proativas do que reativas. Isso significa que a concepção deve antecipar os riscos à privacidade, de modo a preveni-los. Ao final, a consequência mais lógica é

evitem-se incidentes de violação à privacidade. Aqui, vale ressaltar que os princípios da LGPD dispostos nos incisos VII e VIII do artigo 6º da Lei, quais sejam segurança e prevenção, estão intimamente relacionados à postura mais proativa da proteção à privacidade no âmbito do tratamento de dados pessoais.

O segundo princípio – a privacidade como configuração padrão – posteriormente transposto ao conceito de *privacy by default*, trata da máxima de que nenhuma ação por parte do indivíduo deve ser necessária para proteger sua privacidade, uma vez que esse cuidado é intrínseco ao sistema. Os dados pessoais seriam, por padrão, protegidos em qualquer sistema de TI ou prática comercial. O artigo 46 da LGPD, ao colocar nos agentes de tratamento o ônus de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de incidentes de segurança, busca atingir a base desse princípio. Seu § 2º, como visto, menciona expressamente a fase de concepção do produto ou serviço.¹³

A privacidade incorporada ao *design* – terceiro princípio – segue a mesma lógica de direcionar as medidas de proteção da privacidade para o *design* do produto. Como consequência, a privacidade se torna um componente essencial de um produto ou serviço.

O quarto princípio – funcionalidade total – busca acomodar todos os interesses e objetivos legítimos de uma maneira positiva. Afasta a ideia de serem necessários *trade-offs* para que se proteja conjuntamente a segurança e a privacidade, buscando essa dupla proteção. Pelo texto da LGPD, parece ter sido essa exatamente uma das intenções da Lei, uma vez que cria um panorama legal em que diferentes princípios e regras devem ser observados simultaneamente.

A segurança de ponta a ponta – quinto princípio – faz referência ao ciclo total de vida dos dados, sendo também um dos principais norteadores da proteção de dados pessoais. A LGPD traz essa ideia não apenas no princípio da necessidade, mas também no direito à eliminação dos dados disposta no artigo 18, IV.

O sexto princípio, que fomenta a visibilidade e a transparência, visa a garantir que todos os *stakeholders*, independentemente da prática comercial ou tecnologia envolvida, operem de acordo com os objetivos e promessas declaradas. Nesse sentido, os componentes e operações permanecem visíveis e transparentes para usuários e provedores. Esse é um dos princípios mais claramente transpostos na LGPD, estando relacionado a quatro de seus dez princípios: finalidade, adequação, livre acesso e transparência.

Sobre o sexto princípio, Camilla do Vale Jimene lembra que “o objetivo central é garantir responsabilidade e confiança, na medida em que quanto mais transparente a operação, mais fácil será a identificação dos responsáveis no caso da ocorrência de incidentes de segurança da informação e, consequentemente maior será a confiança do usuário.”¹⁴

Por último, o respeito à privacidade do usuário exige que os interesses do usuário sejam colocados em primeiro lugar, oferecendo medidas como padrões de privacidade fortes, avisos apropriados e opções fáceis de serem utilizadas pelo

usuário (*user-friendly*). Esse princípio se relaciona com o regime geral de notificação de incidentes de segurança e também com o princípio da transparência (artigo 6º, VI, da LGPD).

3.2. Incidentes de segurança e dever de notificação

O art. 48 da LGPD assenta a obrigação do controlador de comunicar à autoridade nacional a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Antes de passar à descrição dos condicionantes para a notificação, conforme previstos na lei, é preciso entender o conceito de incidente de segurança. Afinal, somente após identificar a ocorrência de um incidente é que será necessário promover a correspondente notificação.

3.2.1. O que são incidentes de segurança

À luz da Lei Geral de Proteção de Dados (art. 46), o termo “incidente de segurança” pode ser definido como a violação das medidas adotadas pelos agentes de tratamento para salvaguardar a integridade e o sigilo dos dados pessoais sob sua administração, resultando em acessos não autorizados e em situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

A definição de incidente de segurança apresentada é extensa e abarca espécies de infrações tais como o *acesso não autorizado*, a *destruição* de dados, a *perda* de dados, a *alteração* de dados e qualquer forma de *tratamento inadequado ou ilícito*.

A compreensão do tema passa pelo entendimento do que significa cada uma dessas espécies de infrações. Entende-se, por exemplo, por acesso não autorizado, a situação na qual um terceiro, sem permissão dos integrantes da cadeia de tratamento, tem acesso às informações de banco de dados dos agentes que participam dessa cadeia.

Por sua vez, destruição de dados é o fim da existência do dado pessoal ou, pelo menos, o fim da existência daquele dado na forma pela qual costuma ser utilizado pelo controlador. O incidente de alteração de dados pessoais é verificado quando as informações armazenadas em determinado banco de dados são corrompidas ou tornam-se incompletas em razão de interferência externa.

Estar-se-á diante de uma situação de perda de dados pessoais quando, embora o banco de dados ainda exista, o controlador, por alguma razão, não consiga acessá-lo, não tendo mais a informação sob seu domínio. Quanto a essa última espécie de incidente de segurança, cumpre ressaltar, a título exemplificativo, os ataques *ransomware*, perpetrados por meio de vírus que afetam redes de computadores e tornam as informações ali presentes inacessíveis, exigindo, para liberar o acesso, o pagamento de resgate.¹⁵

As situações de perda de dados não se limitam tão somente a invasões de terceiros. O apagamento acidental das informações – quando não for possível fazer *backup* e recuperá-las – também é considerado um incidente de perda de

dados. Em um cenário de maior segurança digital, no qual as informações estão criptografadas, por exemplo, a perda da chave criptográfica também se enquadra na hipótese de perda de dados.¹⁶

É possível que a perda de dados ocorra apenas de forma temporária, conseguindo o controlador recuperar o acesso ao seu banco de dados que estava, por qualquer razão, indisponível. Nessa conjuntura, a notificação à autoridade dependerá de uma análise do controlador, que levará em consideração as razões de indisponibilidade, as possíveis consequências daquele incidente e os riscos aos direitos dos titulares daqueles dados pessoais.

Por fim, “qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito” é a espécie de incidente de segurança mais abrangente e pode ser entendida como as situações nas quais o tratamento de dados pessoais, por qualquer que seja o motivo, está sendo realizado em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pela LGPD. Esse incidente pode ser praticado tanto por um terceiro quanto pelos próprios agentes de tratamento. Na primeira situação, verifica-se o incidente quando um terceiro tem acesso a dados pessoais sem preencher qualquer das hipóteses autorizativas previstas pelo art. 7º da LGPD. Por outro lado, os agentes de tratamento dão causa a esse incidente quando, por exemplo, realizam tratamento dos dados pessoais sob sua administração para além das finalidades informadas ao titular dos dados, evidenciando a ilicitude do tratamento.

O Grupo de Trabalho do Artigo 29, que reuniu as autoridades de proteção de dados pessoais dos países-membros da União Europeia, produziu uma série de recomendações sobre como aplicar os dispositivos da legislação europeia sobre proteção de dados. No que se refere especialmente ao tema dos incidentes de segurança, o grupo dividiu os incidentes em três categorias: (i) incidente de confidencialidade: quando há acesso e/ou divulgação não autorizada de dados pessoais; (ii) incidente de integridade: quando há alteração não autorizada de dados pessoais; e (iii) incidente de disponibilidade: quando há perda de acesso ou destruição de dados pessoais.¹⁷

Nesse mesmo documento, o Grupo de Trabalho do Artigo 29 estuda, a partir de situações concretas, os impactos negativos que podem decorrer de cada um desses incidentes. O primeiro caso trata de uma situação hipotética na qual quatro computadores com dados sobre a saúde e a condição social de pacientes são roubados de um hospital infantil. Sob a perspectiva do incidente de confidencialidade, aponta-se a possibilidade de que o acesso indevido de terceiros gere a divulgação dessas informações, podendo impactar de forma negativa as crianças. Além disso, o documento menciona os riscos de chantagem e tentativas de golpe por parte dos terceiros que conseguiram acesso indevido às informações. Sob as óticas dos incidentes de disponibilidade e integridade, o documento destaca uma mesma consequência: a interrupção do tratamento adequado das crianças, podendo representar sérios riscos para sua saúde.

As consequências oriundas de incidentes de segurança podem ser bem diversas, com potencial de gerar danos materiais ou morais aos titulares dos dados pessoais comprometidos. Sobre o tema, o *recital* 75 do GDPR acrescenta ainda que os riscos a direitos e à liberdade dos titulares são ampliados quando os dados

tratados dizem respeito à origem étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e filosóficas, dados genéticos, dados sobre condições de saúde, dados sobre vida sexual, *performance* no local de trabalho, dados de localização e movimentação, entre outros.

Discriminação, roubo de identidade, fraude, limitação de direitos, perdas financeiras, danos à reputação, perda do controle acerca de suas informações são apenas alguns desses exemplos. É justamente para evitar que esses dados sensíveis caiam em mãos de terceiros mal-intencionados que normas do mundo todo (e a LGPD) exigem que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados que tratam.

3.2.2.Implementação de medidas de segurança pelos agentes de tratamento de dados

De acordo com o princípio da segurança (art. 6º, VII, LGPD), os agentes de tratamento deverão se utilizar de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

Redação bem semelhante é dada ao art. 46 da LGPD, que inaugura o capítulo sobre segurança e boas práticas. De acordo com esse dispositivo, a proteção dos dados pessoais – e a consequente aplicação do princípio da segurança – será assegurada por meio da adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas.

Quanto ao aspecto técnico, a norma ISO/IEC 27002 define segurança da informação como “a proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizando os riscos, maximizando o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio”. De acordo com a normativa, são características da segurança da informação, que devem ser preservadas: (i) a confidencialidade, informações acessíveis apenas a quem seja autorizado; (ii) disponibilidade: informações sempre disponíveis a quem deve acessá-las; e (iii) integridade: informações devem ser fidedignas e autênticas.

Segundo Laura Schertel, enquanto

a confidencialidade refere-se à segurança dos dados contra o acesso não autorizado, a integridade diz respeito à proteção contra a manipulação dos dados e dos respectivos sistemas de informação. Já a disponibilidade denota a necessidade de que os dados estejam acessíveis e visa à proteção contra perda dos dados.

Dessa forma, lembra ainda a autora que as medidas a serem implementadas podem ser diversas, “como a utilização da criptografia e antivírus, até medidas organizatórias e procedimentais, destinadas a impedir o acesso e a manipulação dos dados por terceiros não autorizados.”¹⁸

Como já mencionado, o art. 13 do Decreto 8.771/16 oferece alguns exemplos de medidas técnicas que buscam resguardar os dados tratados. Ademais, é preciso que os agentes de tratamento realizem monitoramento constante de suas

bases de dados, bem como tenham um plano de ação predeterminado em caso de comprometimento dessas informações.

Para que os dados pessoais sejam satisfatoriamente protegidos, além das naturais medidas técnicas, é preciso também que o controlador lance mão de expedientes de ordem administrativa. Um exemplo que pode ser mencionado é o de uma hipotética empresa que adote todas as medidas técnicas que cumpram satisfatoriamente com os objetivos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nessa empresa, cada empregado do controlador teria sua própria credencial, que, a depender de sua hierarquia, permitiria diferentes graus de autorizações de acesso. No entanto, por comodidade, diariamente os empregados no exercício de suas funções compartilham as credenciais entre si, superando o sistema de segurança. Nessa situação, um equívoco administrativo se mostra apto a comprometer toda a operação de bases de dados que gozam das melhores condições de segurança técnica.¹⁹

Dessa forma, em boa hora determinou o legislador, no art. 46, que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas. Quanto às medidas administrativas, os dispositivos trazidos pela lei demandarão um esforço coletivo de todos os atores envolvidos e implicarão a criação de novas rotinas de trabalho, de procedimentos de segurança de informação e aumento dos mecanismos de transparência e governança. A cultura de proteção aos dados pessoais precisará ser cada vez mais difundida, em especial entre aqueles que prestam serviços para agentes de tratamento.

No campo da segurança administrativa dos dados pessoais, é recomendado que o agente de tratamento desenvolva uma Política de Segurança de Informação (PSI). Trata-se de documento que apresenta as diretrizes para garantir a segurança das informações, prescrevendo ações, proibições, boas práticas e até mesmo sanções. Em outras palavras, a PSI funciona como um código de conduta a ser seguido pelos funcionários e busca impedir o acesso daquelas informações por parte de terceiros não autorizados.

O artigo 50 da LGPD, ao dispor sobre a possibilidade dos controladores e operadores adotarem regras de boas práticas e governanças, aponta o mínimo a ser seguido pelos agentes de tratamento ao implementar programa de governança em privacidade. Veja-se:

I – implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:

- a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
- b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;
- c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;
- d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;

f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;

g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e

h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas.

Quando as medidas mencionadas nesta seção não são adotadas ou não são suficientes para salvaguardar os dados pessoais, os bancos de dados dos agentes de tratamento estarão sujeitos aos incidentes de segurança. Nessas situações, a LGPD estabelece procedimento a ser seguido de modo a minimizar os potenciais riscos e danos desse incidente.

Outro instrumento importante para avaliar a possibilidade de um tratamento de dados e o risco que ele acarreta para o titular dos dados é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme disposto no artigo 38 da LGPD. Fortemente inspirado em instrumento também constante no Regulamento europeu, o relatório poderá não apenas ser exigido pela autoridade, como mesmo sem esse requerimento, ser proativamente feito pelo controlador como forma de assegurar a melhor compreensão sobre o impacto do tratamento de dados.

Ao se referir ao relatório de impacto no GDPR, Rony Vainzof lembra que, à luz do artigo 35 do Regulamento:

quando determinado tratamento, em particular o que utilize novas tecnologias e de acordo com a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares, o *controller*, antes de iniciar o tratamento, deverá executar uma avaliação de impacto das operações de tratamento.²⁰

3.2.3.A notificação de incidentes de segurança

Segundo o art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador, ao tomar ciência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, deverá informar sua ocorrência tanto à Autoridade quanto aos titulares dos dados. Ressalta-se que, pela literalidade do referido artigo, somente há a obrigação de comunicação quando o incidente acarretar risco ou dano relevante aos titulares, ficando à cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados delinear quais são tais hipóteses. De todo modo, essas comunicações deverão ser realizadas pelo encarregado, definido pela LGPD como a “pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)” (Art. 5º, VIII).

Verificado um incidente de segurança, o controlador estará obrigado a seguir o procedimento previsto no art. 48:

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo:

- I – a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- II – as informações sobre os titulares envolvidos;
- III – a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- IV – os riscos relacionados ao incidente;
- V – os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
- VI – as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como:

- I – ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e
- II – medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los.

Embora não estabeleça prazo específico para notificação, a LGPD dispõe que ela será feita em “prazo razoável”, a ser determinado pela Autoridade Nacional. A contagem desse prazo começará no momento em que o agente de tratamento tomar ciência do incidente de segurança.

A depender da natureza da violação, pode ser difícil mensurar se houve, de fato, incidente ou até mesmo pode ser complexo precisar o momento em que o controlador se deu conta de que dados pessoais sob sua administração foram comprometidos. Para superar essa dificuldade de identificar o início do prazo para notificar a autoridade, o Grupo de Trabalho do Artigo 29 afirma, em seu Parecer WP 250²¹, que se considerará ciente o controlador quando ele possuir um grau razoável de certeza de que um incidente de segurança ocorreu e resultou no comprometimento de dados pessoais.

Para ilustrar esse cenário, o Grupo de Trabalho traz o seguinte exemplo: a perda de *pen drive* não protegido por criptografia contendo dados pessoais. Não é possível afirmar que pessoas não autorizadas o acharam e consequentemente tiveram acesso àquelas informações, o que representaria um incidente de confidencialidade. No entanto, tal caso deve ser notificado à autoridade competente, uma vez que há um grau razoável de certeza de que houve um incidente de disponibilidade. Para os fins desse exemplo, considera-se o controlador ciente do incidente de segurança no momento em que percebe que o *pen drive* foi perdido.

Não se considera, para fins de ciência e contagem de prazo, o tempo gasto pelo controlador investigando se houve de fato incidente de segurança que tenha

comprometido os bancos de dados pessoais que administra.

Como apontado anteriormente, os controladores devem adotar medidas para prevenir incidentes de segurança. No entanto, é preciso também que sejam adotadas medidas técnicas e administrativas para detectar, endereçar e reportar eventual incidente de segurança em prazo razoável. Trata-se de outra incidência do princípio da segurança previsto no art. 6º.

Nas situações em que houver compartilhamento de bancos de dados entre mais de um controlador, estes deverão determinar contratualmente as obrigações de cada um face à LGPD, inclusive acordando qual deles será o responsável em notificar a Autoridade Nacional nos casos de incidentes de segurança.

O art. 48 da LGPD trata somente da figura do controlador, isentando, aparentemente, o operador do dever de comunicar a ocorrência de incidentes de segurança. No entanto, seja por disposição contratual, seja em razão do princípio da boa-fé, o operador que tomar ciência de violação aos bancos de dados pessoais que administra deverá notificar imediatamente o controlador responsável.

A notificação à Autoridade Nacional precisará observar os padrões mínimos estipulados pelo § 1º do art. 48. Nesse sentido, o controlador precisará informar a natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, as medidas de segurança que foram adotadas para salvaguardar o banco de dados, os riscos relacionados ao incidente e as medidas que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. O objetivo da notificação é mapear os possíveis riscos ou danos que poderão ser suportados pelo titular desses dados pessoais.

No caso de incidentes de segurança complexos, que dependem de uma perícia para determinar a razão da violação e a extensão dos dados que foram comprometidos, a notificação poderá ocorrer por etapas, sempre privilegiando a transparência no contato com a Autoridade Nacional.

Na legislação brasileira, em caso de incidente de segurança, o controlador tem obrigação de informar tanto a autoridade nacional quanto o titular dos dados pessoais violados. A comunicação com o titular, embora tenha que respeitar os padrões estabelecidos pela LGPD, deverá ser feita em linguagem clara e direta. Esta última comunicação, como autoriza o art. 52, §7º, da LGPD, poderá ainda, no caso de vazamentos individuais ou acessos não autorizados, oferecer diretamente ao titular proposta de conciliação, de modo que, caso haja acordo entre o titular e o controlador, este último estará isento das sanções administrativas previstas no *caput* do art. 52.

O Grupo de Trabalho do artigo 29, em seu parecer sobre notificações de incidentes de segurança²², determina que as comunicações de incidentes aos titulares deverão conter a descrição da natureza da violação, o nome e o contato do encarregado, as possíveis consequências da violação e a descrição das medidas que foram ou que serão adotadas para mitigar os possíveis efeitos adversos do incidente. Ademais, quando for possível, recomenda-se que os

controladores forneçam conselhos específicos aos titulares, tais como redefinir senha, nas situações em que estas forem comprometidas.

O canal de comunicação adequado para realizar esse tipo de notificação deve ser diverso do canal utilizado para o envio de outras comunicações aos titulares, tais como atualizações e *newsletters*. Dessa forma, é possível conservar uma forma mais clara e transparente de se comunicar. Apesar do § 2º do art. 48 falar em “ampla divulgação do fato em meios de comunicação”, é preciso ressaltar que essa medida não substitui a comunicação individual que deve ser direcionada aos titulares das informações.

A obrigação de comunicar surge somente quando o incidente de segurança é apto a acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Para verificar o potencial lesivo de um incidente de segurança aos titulares, alguns fatores devem ser considerados. Em primeiro lugar, o tipo de incidente. Nesse particular, eventual incidente de confidencialidade que ocasione a divulgação de dados médicos de pacientes tem consequências diversas para os titulares do que um incidente no qual os mesmos dados médicos foram perdidos. A natureza, a sensibilidade e o volume dos dados pessoais comprometidos também devem ser sopesados nessa equação.

Na legislação europeia, o art. 34(3) do GDPR dispõe sobre três requisitos que, se verificados, dispensam a comunicação do incidente ao titular dos dados. São eles: (1) se antes da violação, o controlador tiver implementado medidas técnicas e organizacionais aptas a proteger os dados pessoais, tornando-os inteligíveis para qualquer pessoa que não esteja autorizada a acessar aquele banco de dados; (2) se imediatamente após uma violação, o controlador tomar medidas para garantir que o alto risco para os direitos e liberdades dos indivíduos já não é provável de se materializar; e (3) se a comunicação com os indivíduos demandar esforços desproporcionais. Nesses casos, o GDPR exige uma comunicação pública ou medida similar para informar os lesados com aquele incidente.

4. Conclusão

Como visto, segurança e sigilo dos dados são temas centrais para que se confira efetividade à proteção de dados pessoais. A LGPD inovou ao detalhar em seção específica o conjunto de regras que devem ser atendidas para que se atinja esse objetivo. De forma mais destacada, os dispositivos legais que tratam de segurança e sigilo comandam uma postura ativa por parte dos agentes de tratamento de dados no exercício de um dever de cuidado.

A referência à noção de *privacy by design*, quando a Lei afirma que considerações sobre dados pessoais e sua proteção devem existir desde a concepção de produtos e serviços, ela dá um sinal importante para que empresas e governos não requeiem as preocupações sobre proteção de dados apenas para depois de ocorridos episódios de sua violação.

Da mesma forma, o detalhamento sobre como deverá ser feita a notificação envolvendo incidentes de segurança é um passo adiante para conferir segurança para os agentes de tratamento, indicando o mínimo que precisa ser atingido para

que a autoridade e os titulares de dados estejam a par do ocorrido e possam tomar as medidas necessárias para evitar que o dano potencialmente causado pelo fato seja ainda maior.

Dotados de grande impacto nas atividades de qualquer entidade que trate dados pessoais, esses dispositivos certamente dominarão algumas das mais relevantes discussões sobre a aplicação da LGPD e demandarão uma atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para preencher eventuais lacunas e editar as instruções que se fizerem necessárias.

Bibliografia

ARANHA, Diego. O que é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito. In: DONEDA, Danilo (Org.). *A Regulação da Criptografia no Direito Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2018.

BESSA, Leonardo Roscoe. *O Consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

CAVOUKIAN, Ann. Publicação da *Information and Privacy Commissioner of Ontario*. Publicado em agosto de 2009. Revisado em janeiro de 2011. Disponível em: [www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf].

COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018.

DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

DONEDA, Danilo. Princípios de Proteção de Dados Pessoais. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Pereira de. (Coord.). *Direito & Internet III – Marco Civil da Internet*: Lei nº 12.965/2014. São Paulo: Quartier Latin, 2015, t. I.

EFING, Antônio Carlos. *Bancos de Dados e Cadastro de Consumidores*. São Paulo: Ed. RT, 2001.

JIMENE, Camilla do Vale. Reflexões sobre privacy by design e privacy by default: da idealização à positivação. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coord.). *Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia*. São Paulo: Ed. RT, 2018.

MARTINS, Guilherme. *Responsabilidade Civil por acidente de consumo na Internet*. São Paulo: Ed. RT, 2008.

MENDES, Laura Schertel. A Tutela da Privacidade do Consumidor na Internet: uma análise à luz do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do

Consumidor. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Pereira de. (Coord.). *Direito & Internet III – Marco Civil da Internet*: Lei nº 12.965/2014. São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. I.

VAINZOF, Rony. Dados pessoais, tratamento e princípios. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coord.). *Comentários ao GDPR*: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. São Paulo: Ed. RT, 2018.

VIOLA, Mário; ITAGIBA, Gabriel. Privacidade e Dados Pessoais. In: SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina (Coord.). *Marco Civil da Internet*: Jurisprudência Comentada. São Paulo: Ed. RT, 2017.

1

.Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor da UERJ e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS). Professor Visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa. Pesquisador Afiliado do *Information Society Project* da Faculdade de Direito da Universidade de Yale. Membro da Comissão de Direito Autoral da OAB/RJ.

2

.O autor agradece a Vinicius Padrão e Giovana Carneiro pelo apoio nas pesquisas para a realização deste artigo.

3

.Nesse particular, lembra Danilo Doneda que “a mera atuação do indivíduo para a proteção de seus interesses – o controle individual, como ocorre em algumas das concepções de proteção de dados pessoais que nós verificamos – não é capaz de projetar uma situação na qual o direito fundamental em questão receba a tutela adequada e acaba por espelhar uma determinada concepção ideológica dos interesses em questão que, amenizada por uma aparente concessão de poder ao indivíduo, não acarreta na tutela efetiva de seus interesses.” (DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à Proteção de Dados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 399).

4

.Sobre a proteção de dados pessoais no CDC, vide: BESSA, Leonardo Roscoe. *O Consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito*. São Paulo: Ed. RT, 2003; EFING, Antônio Carlos. *Bancos de Dados e Cadastro de Consumidores*. São Paulo: Ed. RT, 2001; e MARTINS, Guilherme. *Responsabilidade Civil por acidente de consumo na Internet*. São Paulo: Ed. RT, 2008.

5

.JFRN, 1ª Vara Federal, Processo 0805175-58.2015.4.05.8400, Juiz Federal Magnus Augusto Costa Delgado, julgado em 29.07.2015. Ainda em momento anterior a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, empresas já foram acionadas judicialmente por conta de vazamento de informações constantes dos bancos de dados sob sua administração. A título exemplificativo, vale destacar acordo extrajudicial firmado entre a *Netshoes*, loja de artigos esportivos *on-line*, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), após o comprometimento do banco de dados da empresa que resultou na divulgação indevida de informações sobre quase dois milhões de clientes. No termo de ajustamento de conduta assinado, a loja *on-line* se comprometeu a pagar quinhentos mil reais a título de indenização pelos danos morais coletivos, reforçar suas políticas de segurança cibernéticas e promover campanhas de conscientização de modo a divulgar a necessidade de proteção de dados pessoais entre seus clientes. Sobre o acordo, vide: [www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10570-mpdft-e-netshoes-firmam-acordo-para-pagamento-de-danos-morais-coletivos-apos-vazamento-de-dados]. Acesso em: 15.03.2019.

6

.Danilo Doneda lembra que o elenco de princípios constitui “a espinha dorsal das diversas leis, tratados, convenções ou acordos entre privados em matéria de dados pessoais”. Nesse particular, ganha destaque o princípio da segurança física e lógica, segundo o qual “os dados devem ser protegidos contra os riscos de seu extravio, destruição, modificação, transmissão ou acesso não autorizado. Entre os riscos mencionados estão os riscos de acesso físico direto ao sistema tanto como o de acesso remoto (ou lógico).” (DONEDA, Danilo. *Princípios de Proteção de Dados Pessoais*. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Pereira de. (Coord.). *Direito & Internet III – Marco Civil da Internet: Lei nº 12965/2014*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. I. p. 377).

7

.COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 150.

8

.No mesmo sentido, *vide* COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 151.

9

.CAVOUKIAN, Ann. Publicação da *Information and Privacy Commissioner of Ontario*. Publicado em agosto de 2009. Revisado em janeiro de 2011. Disponível em: [www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf]. Acesso em 11.03.2019.

10

.BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 176.

11

.Para maiores informações sobre os princípios, ver, em inglês: [www.ryerson.ca/pbdce/certification/seven-foundational-principles-of-privacy-by-design]. Acesso em: 11.03.2019.

12

.Na Europa, esse conceito também foi transposto pouco a pouco, tomando forma com o GDPR. Em 1995, a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu já considerava, em seu artigo 46, que a proteção dos direitos e liberdades das pessoas ligadas ao tratamento de dados pessoais exige a adoção de medidas técnicas e organizacionais não apenas quando do tratamento em si, mas também de sua concepção. O *General Data Protection Regulation* (GDPR) menciona expressamente a concepção no Considerando 78 e, principalmente, em seu artigo 25.

13

.Bruno Bioni observa que o conceito de *privacy by default* pode ser extraído do princípio da necessidade, ao lado do da responsabilização e prestação de contas da LGPD (BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 200).

14

.JIMENE, Camilla do Vale. Reflexões sobre privacy by design e privacy by default: da idealização à positivação. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coord.). *Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 181.

15

.Em maio de 2017, o *rasonware WannaCry*, explorando uma vulnerabilidade do sistema operacional *Windows*, atingiu mais de 200 mil vítimas em 150 países ao redor do mundo. Para mais informações sobre o que foi considerado o “maior ataque *rasonware* do mundo”, veja:

[<https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2017/05/15/tire-suas-duvidas-sobre-o-maior-ataque-ransomware-do-mundo.htm>]. Acesso em: 11.03.2019.

16

.Diego Aranha lembra que “etimologicamente, o termo criptografia significa escrita secreta, tornando evidente a preocupação clássica com confidencialidade. Técnicas criptográficas modernas não se restringem ao sigilo e incluem quaisquer outras propriedades de segurança relevantes, como verificação de integridade, autenticação, não-repúdio ou irretratabilidade, e anonimato.” (ARANHA, Diego. O que é criptografia fim a fim e o que devemos fazer a respeito. In: DONEDA, Danilo (Org.). *A Regulação da Criptografia no Direito Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 27).

17

.O documento está disponível em: [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp213_en.pdf]. Acesso em: 11.03.2019. A divisão dos incidentes nessas três categorias segue o padrão da norma de segurança da informação ISO/IEC 27002, tratada no próximo item.

18

.MENDES, Laura Schertel. A Tutela da Privacidade do Consumidor na Internet: uma análise à luz do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Pereira de. (Coord.). *Direito & Internet III – Marco Civil da Internet: Lei nº 12965/2014*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. t. I. p. 489.

19

.O exemplo é referido por COTS, Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 150.

20

.VAINZOF, Rony. Dados pessoais, tratamento e princípios. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coord.). *Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 67.

21

.Disponível em: [https://iapp.org/media/pdf/resource_center/WP29-Breach-notification_02-2018.pdf]. Acesso em: 12.03.2019.

22

.Disponível em: [https://iapp.org/media/pdf/resource_center/WP29-Breach-notification_02-2018.pdf]. Acesso em: 12.03.2019. p. 20.

PARTE II - DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO DE DADOS E QUESTÕES ESPECÍFICAS

Capítulo 1. O tratamento de dados sensíveis à luz da Lei 13.709/2018

Carlos Nelson Konder¹

1. Introdução

A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018) positiva, no ordenamento brasileiro, movimento jurídico fundamental que há décadas já se defendia em doutrina e se desenhava no cenário internacional. A previsão legal e regulamentação do exercício do direito ao controle dos dados pessoais, tanto individual como coletivamente, insere o Brasil entre os países que reconhecem e tutelam essa nova perspectiva de proteção da pessoa humana.²

Entre suas diversas inovações, a LGPD traz a diferenciação do tratamento de certa categoria de dados pessoais: os chamados “dados sensíveis”. Com efeito, se o tratamento de qualquer dado pessoal tem o potencial de atingir o seu titular, alguns dados apresentam potencial de dano qualificado no que tange à pessoa humana. A distinção de tratamento normativo, envolvendo a incidência de regras próprias, justifica atenção especial a essa nova categoria normativa.

Para proceder a essa qualificação, propõe-se chave de leitura fundada na abertura e dinamicidade do princípio da dignidade da pessoa humana, em especial com a conjugação de três de suas mais populares manifestações nos últimos tempos: privacidade, identidade pessoal e vedação de discriminação. A partir dessa perspectiva, identifica-se quando determinada informação pode ser considerada dado sensível e passa-se à aplicação do conjunto de normas próprio a reger o seu tratamento.

2. Privacidade, identidade e não discriminação: a chave de leitura dos dados sensíveis

A proteção jurídica da pessoa humana reconstrói-se conforme as circunstâncias que a cercam, tomando formas idôneas a lidar com as ameaças que cada contexto social lhe opõe. Como destaca Perlingieri: “Não existem instrumentos válidos em todos os tempos e em todos os lugares: os instrumentos devem ser construídos pelo jurista levando-se em conta a realidade que ele deve estudar. [...] Cada lugar, em cada época, terá os seus próprios mecanismos”.³ Afinal, a personalidade, concebida como valor e não como direito, “está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessante exigência mutável de tutela”.⁴

Sob a alçada da ideia geral de dignidade da pessoa humana, desenrolam-se manifestações infinitas, insuscetíveis de serem exauridas em modelos típicos, já que ela se transforma e se renova com as transformações da sociedade em que a pessoa se insere.⁵ Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana, para além de princípio, configura-se em cláusula geral, apta a abarcar uma infinidade de formas de proteção e promoção do sujeito.⁶ Consequentemente, deve ser vista com naturalidade a multiplicação de novas formas de manifestação da dignidade, se vierem com o objetivo de combater novos mecanismos de instrumentalização ou subjugação da pessoa humana e promover meios de seu livre desenvolvimento.

Na virada do século XX para o século XXI, o desenvolvimento das telecomunicações e da informática, embora tenha trazido incomparáveis benesses à humanidade, trouxe também novas ameaças à proteção do valor intrínseco da pessoa humana. A internet permite que qualquer informação se torne acessível para a humanidade e para a eternidade, o que, como a dupla face de Janus, pode ser uma conquista para a difusão e democratização do conhecimento, mas pode ser também uma derrota para a proteção da liberdade individual e para o combate de estigmas sociais. Sobre o sistema que induz as pessoas à exposição de seus próprios dados, explica Rodotà: “A pessoa é obrigada a expor seu próprio eu, sua própria persona, com consequências que vão além da simples operação econômica e criam uma espécie de posse permanente da pessoa por parte de quem detém as informações a seu respeito”.⁷

Já na superfície, a rápida pesquisa do nome de alguém em buscadores ou em redes sociais transforma aquela pessoa em uma série de informações sobre as quais ela não tem qualquer controle. Adentrando nas camadas mais profundas da rede, encontra-se inmensurável quantidade de dados – o *big data*⁸ – que, manipulados por algoritmos voltados a criar tendências de mercado e perfis⁹, filtram aquilo que ela verá, aquilo que lhe será oferecido, aquilo a que ela terá acesso, enfim, aquilo que ela é.¹⁰ Em síntese:

(...) parte-se da ideia de que os dados são elemento constituinte da identidade da pessoa e que devem ser protegidos na medida em que compõem parte fundamental de sua personalidade, que deve ter seu desenvolvimento privilegiado, por meio do reconhecimento de sua dignidade.¹¹

A segurança sobre o acesso a esses dados e as formas de sua utilização torna-se, então, objeto de necessária atenção do direito, uma vez que o tratamento de dados pessoais, em particular por processos automatizados, é uma atividade de risco.¹²

Mulholland cita diversos exemplos assustadores de utilização de dados: o vazamento de informações, inclusive sobre comportamento sexual, de milhares de doadores de um banco de sangue australiano (*Red Cross Blood Service*); o acesso, pela *Standard Innovation*, dos dados de utilização do vibrador *We-Vibe 4 Plus* pelos seus usuários; e a construção do sistema

de *social scoring*, na China, voltado a categorizar os cidadãos para acesso a serviços públicos.¹³ Aduz, ainda, em outra ocasião, o caso da *SmartTv Samsung*, que entende tratar-se de “verdadeiro reconhecimento por parte da Samsung de que havia não só a possibilidade, mas a probabilidade do uso e compartilhamento de dados pessoais, sem que para isso houvesse um expresse consentimento da pessoa acerca desta ação”.¹⁴

É possível aduzir a estes outros casos, como o do *site* Ashley Madison, que, voltado a intermediar adultérios, não apagava os dados de seus 37 milhões de usuários como prometido e, em 2015, foram expostos por *hackers*;¹⁵ ou, ainda, o caso brasileiro de exposição de 120 milhões de números de CPF.¹⁶ Todavia, o caso mais notório e de maior repercussão foi o Facebook/Cambridge Analytica, quando informações referentes a 50 milhões de pessoas, obtidas por meio de testes de personalidade veiculados em redes sociais, foram utilizadas para a campanha presidencial de Donald Trump, de modo a viabilizar a construção de um perfil psicológico da população americana.¹⁷

A dignidade da pessoa humana então se renova, para, por meio de novas manifestações, proteger, diante desse contexto, a liberdade de pessoa humana para ser quem ela é, para livremente construir sua própria personalidade. Nessa toada, o direito à privacidade supera o viés individual e passivo do tradicional “direito a ficar só”, cunhado no final do século XIX para defender a esfera íntima contra as invasões da imprensa, para assumir novo papel, restabelecendo ao sujeito o controle sobre suas informações: passa-se do domicílio à rede, do sigilo à circulação, da proteção estática à proteção dinâmica, de um poder de exclusão a um poder de controle.¹⁸ Sob essa perspectiva de empoderamento, a privacidade desdobra-se no direito à autodeterminação informativa¹⁹ e no “espaço (inviolável) da liberdade de escolhas existenciais”.²⁰

Em linha similar, partindo de decisões italianas da década de 1970, que legitimaram a defesa da pessoa contra a imputação de características que não sejam compatíveis com a maneira pela qual ela é conhecida no meio social, o conceito de identidade pessoal cresceu graças à abordagem interdisciplinar, convertendo-se na garantia do próprio processo dinâmico de construção dialógica da identidade.²¹ Na medida em que a identidade se molda pelo reconhecimento do outro, a tutela do livre desenvolvimento da personalidade demanda a proteção da liberdade de escolher os valores, atributos, características e preferências que tornam a pessoa ela mesma no diálogo com os demais.²² Como atributo necessariamente dinâmico, em decorrência do amadurecimento e das experiências de vida da pessoa, deve-se tutelar igualmente o reconhecimento do contínuo processo de reconstrução da própria identidade, como se observa no âmbito do chamado “direito ao esquecimento”, que deve ser compreendido não como a prerrogativa unilateral de apagar informações sobre o seu passado que lhe sejam desagradáveis, mas sim como o direito a não persistir estigmatizado por fatos que não mais refletem a sua identidade.²³

Privacidade como autodeterminação informativa/existencial e reconhecimento da construção dinâmica da identidade pessoal conjugam-se, assim, como novas formas de manifestação da proteção jurídica da pessoa humana contra as ameaças de estigmatização e discriminação oriundas do desenvolvimento tecnológico. Com efeito, a principal preocupação com relação ao armazenamento e circulação de informações relativas à pessoa humana diz respeito à sua utilização para submetê-la a estigmas, viabilizando sua discriminação perante as demais. Entre os diversos dados relativos à pessoa, alguns são especialmente idôneos a facilitar processos sociais de exclusão e segregação, razão pela qual seu controle deve ser ainda mais rigoroso. Essa é a chave de leitura adequada para compreender a qualificação de dados pessoais como sensíveis.

3.A qualificação de dados pessoais como sensíveis

Segundo as definições da Lei Geral de Proteção de Dados, dado pessoal é “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (art. 5º, I) e dado sensível é:

(...) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II).

Observa-se, assim, que o dado sensível é um tipo de dado pessoal, ou seja, todo dado sensível é pessoal, mas nem todo dado pessoal é sensível.

A marca característica do dado pessoal, em geral, é a identificabilidade da pessoa natural a que ele se refere. Ou seja, o dado será considerado pessoal não somente se ele próprio servir a identificar o seu titular (por exemplo, o nome ou o número de CPF), mas também se, a partir da integração com outras informações, essa identificação for possível (por exemplo, o endereço ou o *Internet Protocol* – IP, o número que identifica o computador na rede). Sob esse conceito amplo de dado pessoal, “Há dado pessoal não apenas quando houver a presença de identificadores diretos ou indiretos que diferem precisamente um indivíduo. Os dados que potencialmente conduzem à individuação da pessoa são igualmente tomados como informação pessoal”.²⁴

Assim, o dado pessoal contrapõe-se ao dado anonimizado, que é o “dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento” (LGPD, art. 5º, III). Essa contraposição, todavia, vem sendo destacada pela doutrina como menos rigorosa do que pode parecer à primeira vista: “uma divisão binária e estanque entre dado pessoal e dado anônimo, ao se considerar o atual alcance do conceito de dado anônimo e dos seus diversos perfis normativos, não é mais critério seguro para garantir a privacidade dos titulares de dados”.²⁵ Diversas falhas vêm sendo reveladas em técnicas de anonimização que até poucos anos eram reputadas confiáveis,²⁶ o que conduz à constatação de que a capacidade de efetivamente desidentificar a informação é contingente ao avanço da tecnologia daquela época. Por essa razão, durante o trâmite do projeto de lei na Câmara, a redação do dispositivo foi modificada para fazer referência a técnicas razoáveis, ante a constatação de que a anonimização perfeita é impossível.²⁷

Outro meio utilizado para impedir a identificação do titular do dado é a pseudonimização, que é “o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro” (LGPD, art. 13, § 4º). Assim, o titular do dado pseudonimizado só não é identificável por conta da separação entre ele e outra informação que levaria à identificação, razão pela qual Machado e Doneda defendem que, embora continue a ser reputado informação pessoal, pode se submeter a um regime jurídico modulado ou particularizado.²⁸

Já no que tange à sensibilidade do dado, o legislador optou por conceituação exemplificativa, fazendo referência a informações de caráter racial, étnico, político, sindical, religioso, filosófico, de saúde, sexual, genético ou biométrico. Aponta-se que aqui também transparece novamente a influência da legislação europeia (GDPR) que, posto não utilizar expressamente a terminologia, define da mesma forma os dados submetidos à seção “Tratamento de categorias especiais de dados pessoais”.²⁹ Com efeito, destaca Mulholland que o tratamento diferenciado dos dados sensíveis:

(...) já é conhecido da legislação brasileira desde a promulgação da Lei de Cadastro Positivo – Lei 12.414/11 –, que, em seu artigo 3º, § 3º, II, proíbe anotações em bancos de dados usados para análise de crédito de ‘informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas’.³⁰

A prévia experiência normativa, contudo, não se reflete na prática cotidiana, ausente cultura empresarial de cuidado com o uso de dados de categoria sensível. Destaque-se, nesse sentido, o estudo de Machado e Bioni, referente aos dados pessoais captados pelo programa de cadastro de CPF nas notas fiscais estaduais, que conclui que “no conjunto dos estados onde existe o programa, a análise da transparência ativa das informações denota um cenário desolador. Não há qualquer tipo de informação sobre as políticas de proteção de dados pessoais adotados para garantir a privacidade do cidadão”.³¹

Como destacado, algo une todos esses exemplos: os dados sensíveis são dados pessoais especialmente suscetíveis de utilização para fins discriminatórios, como estigmatização, exclusão ou segregação, de modo que seu tratamento atinja a dignidade de seu titular, lesionando sua identidade pessoal ou privacidade. O próprio anteprojeto da legislação identifica que o fim precípua do tratamento diferenciado dos dados sensíveis é impedir a discriminação da pessoa humana com base nas suas informações.³² Por essa razão, somente podem ser sensíveis os dados referentes à pessoa humana, em virtude do valor intrínseco da sua dignidade.³³

Por conta disso, é inviável conceber rol taxativo de dados sensíveis, já que eles são definidos pelos efeitos potencialmente lesivos do seu tratamento. Nesse sentido, o próprio legislador reconhece que se aplicam as regras relativas ao tratamento de dados sensíveis aos dados pessoais que, posto não serem em si sensíveis, podem vir a revelar dados sensíveis (LGPD, art. 11, § 1º). Assim, por exemplo, dados de localização geográfica, hábitos de compras, preferências de filmes e histórico de pesquisa podem parecer inofensivos isoladamente, mas um rápido tratamento em conjunto pode servir a identificar orientação religiosa, política e mesmo sexual. Doneda e Monteiro trazem o exemplo da nacionalidade, que, embora não seja comumente considerada em si como uma informação sensível, em certo contexto pode indicar tratamento sensível eis que “capaz de estigmatizar, classificar, pré-julgar e mesmo comprometer a segurança dos cidadãos afetados”.³⁴ Sintetiza Frazão:

Dessa maneira, poder-se-ia entender que se incluem no conceito de dados pessoais – e não de dados pessoais sensíveis – os chamados identificadores comuns, como nome, número de identificação, dados de localização, bem como os chamados identificadores eletrônicos, tais como aparelhos, aplicações, ferramentas e protocolos, como o endereço IP (protocolo internet), testemunhos de conexão (cookies) e etiquetas de identificação por radiofrequência. Entretanto, a questão não é tão simples, pois, em muitos casos, os dados sensíveis são unidos aos dados não sensíveis, criando diversas combinações.³⁵

A distinção entre dados pessoais em geral e dados pessoais sensíveis não é puramente conceitual, já que a lei prevê disciplina normativa diversa: ao tratamento dos dados pessoais sensíveis se aplicam normas distintas daquelas aplicadas ao tratamento dos dados pessoais não sensíveis, justamente com o objetivo de impedir a utilização desses dados para fins discriminatórios.³⁶

4. Disciplina normativa aplicável ao tratamento de dados sensíveis

Comparando o regime imposto pela Lei 13.709/2018 ao tratamento dos dados pessoais em geral (art. 7º e ss.) com aquele imposto ao tratamento dos dados pessoais sensíveis (art. 11 e ss.), observa-se a repetição de diversas regras comuns. Em ambos o legislador estipulou o consentimento como base primordial para justificar qualquer tratamento de dados, mas especificou ainda outros interesses legítimos que autorizam o tratamento de dados mesmo sem o consentimento do titular.³⁷ Entre eles, estará justificado o tratamento de dados (sensíveis ou não) sem o consentimento de dados se ele servir: ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ao tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos³⁸; à realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; ao exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral³⁹; à proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; à tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias. Vale observar que o art. 7º, III, admite a ausência de consentimento também para tratamento de dados pessoais voltados à execução de políticas públicas respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, o que não foi reproduzido no art. 11, II, b, que prevê a dispensa de consentimento para tratamento de dados sensíveis voltados à execução de políticas públicas previstas apenas em leis ou regulamentos.

Por outro lado, a comparação entre os dispositivos revela também algumas regras distintas. De plano, o tratamento de dados autorizado pelo “consentimento do titular” dá lugar à necessidade de consentimento pelo titular, “de forma específica e destacada, para finalidades específicas”, ou seja, impondo restrição formal quanto ao consentimento. Também se afasta o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do titular “quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados”; “quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro”⁴⁰ ou “para a proteção do crédito”, hipóteses permitidas para os dados não sensíveis no art. 7º, V, IX e X, respectivamente, e não reproduzidas no art. 11. Para o legislador, os interesses patrimoniais envolvidos nesses casos não justificaram o risco intrínseco ao tratamento de dados sensíveis do titular.

A Lei ressalva, todavia, a possibilidade de tratamento de dados sensíveis, sem consentimento do titular, como medida de segurança do titular e prevenção de fraude, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, como ocorre frequentemente com a utilização de impressão digital e palmar no ambiente bancário. A possibilidade é limitada ao prevalecimento de direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais (art. 11, II, “g”).

Destaca-se, ainda, que a dispensa de consentimento no tratamento de dados sensíveis para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (pessoa a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais) ou para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos deve ser objeto de publicização, “fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos” (art. 23, I, c/c art. 11, § 2º, da Lei 13.709/2018).

Essas limitações não excluem a possibilidade de novas restrições sobre a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores, com objetivo de obter vantagem econômica, serem cominados por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências, conforme autorizado pelo § 3º do art. 11 da Lei de Proteção de Dados.

No tocante a dados sensíveis referentes à saúde do titular, a Lei comina regras ainda mais específicas. É vedado o compartilhamento desses dados para fins econômicos, exceto quando for necessária para a adequada prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica ou mesmo de assistência à saúde, para permitir a portabilidade requerida pelo titular ou quando suplementar ou para transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos referidos serviços (LGPD, art. 11, § 4º). A partir da observação de que “o texto original da LGPD se mostrava restritivo e poderia resultar na precarização da prestação de certos serviços relacionados à saúde, como aqueles oferecidos por planos de saúde, hospitais e clínicas médicas”, o texto do dispositivo foi inicialmente alterado pela Medida Provisória nº 869, de 2018, e ganhou sua redação final com a Lei n. 13.853/2019.⁴¹

Além disso, é permitido o tratamento desses dados para estudo em saúde pública, observadas certas restrições (LGPD, art. 13). Reitera-se, de plano, a incidência do princípio da finalidade, ao determinar que o tratamento dos dados se restrinja à finalidade do estudo. Em proteção à segurança dos dados, determina-se que o tratamento somente ocorra dentro do órgão, impõe-se o respeito a práticas de segurança previstas em regulamento específico e imputa-se ao órgão de pesquisa a responsabilidade pela segurança da informação, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Impõe-se, ainda, que o tratamento deve respeitar os padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas, como aqueles impostos por Códigos de Ética, princípios de Bioética, diretrizes internacionais e procedimentos impostos pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição, ressaltando que o acesso a esses dados deve ser objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Enfim, destaca-se que a divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa poderá revelar dados pessoais e que deve ser buscada, sempre que possível, a anonimização ou, ao menos, a pseudonimização dos dados, entendida como “o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro”.

5. Considerações finais

As observações traçadas servem para constatar que a definição de certo dado pessoal como dado sensível não pode ser estabelecida em abstrato. Deve-se averiguar em concreto, à luz do contexto de utilização daquele dado e da relação que se pode estabelecer com as demais informações disponíveis, a potencialidade de que seu tratamento possa servir como instrumento de estigmatização ou discriminação, à luz da privacidade, identidade pessoal e, de modo geral, da dignidade da pessoa humana.

Realizada a qualificação do dado pessoal como dado sensível, impõe-se a ele, além das restrições já existentes ao tratamento de qualquer dado pessoal, limitações adicionais, como exigência de que o consentimento para seu tratamento se dê mediante forma, destaque e indicação de finalidades específicas. Afasta-se a possibilidade de tratamento não consentido de tais dados para a execução de contrato, para interesse (ainda que legítimo) do controlador ou de terceiro ou ainda para a proteção do crédito. Em se tratando de dados relativos à saúde, a normativa é ainda mais rigorosa, a corroborar a interpretação de que a categoria dos dados sensíveis se destina prioritariamente à tutela dos aspectos existenciais da pessoa humana.

6. Referências

AAVV. Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na aceção do artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE. Disponível em <https://www.gdpd.gov.mo/uploadfile/2015/0803/20150803050042662.pdf>, acesso em 15 fev. 2019.

ALVES, Paulo. Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. *Techtudo*. 24.03.2018. Disponível em: www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghml. Acesso em: 15.02.2019.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. São Paulo: Atlas, 2019.

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Deputado Orlando Silva ao Projeto de Lei 4.060/2012. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1664206&filename=PPP+1+PL406012+%3D%3E+PL+4060/2012, acesso em 25 jan. 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. EMI 73/2016. 29 abr. 2016. https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=62B6CCB8D15F03BD169F7421D3CDB6EE.proposicoi?codteor=1457971&filename=Avulso+-PL+5276/2016, acesso em 26 jan. 2019.

CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O conceito de identidade e a redesignação sexual*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Espaço Jurídico Journal of Law*, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul.-dez. 2011.

DONEDA, Danilo; MONTEIRO, Marília. Acesso à informação e privacidade no caso da Universidade Federal de Santa Maria. *Jota*. 20.07.2015. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/acesso-a-informacao-e-privacidade-no-caso-da-universidade-federal-de-santa-maria-02072015]. Acesso em: 15.02.2019.

FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. *Jota*. 19.09.2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018]. Acesso em: 15.02.2019.

FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: o tratamento dos dados pessoais sensíveis. *Jota*. 19.09.2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018]. Acesso em: 15.02.2019.

HORNUNG, Gerrit; SCHNABEL, Christoph. Data protection in Germany I: The population census decision and the right to informational self-determination. *Computer Law & Security Report*, v. 25, Issue 1, Southampton, UK, p. 84-88, 2009.

LEMO, Ronaldo; DOUEK, Daniel; ADAMI, Mateus Piva; LANGENEGGER, Natalia; FRANCO, Sofia Lima. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela MP nº 869/2018. *Jota*. 29.12.2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018]. Acesso em: 26.01.2018.

LIMBERGER, Têmis. Da evolução do direito a ser deixado em paz à proteção dos dados pessoais. *Revista de Direito da Unisc*, Santa Cruz do Sul, n. 30, p. 138-160, jul.-dez. 2008.

MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, p. 99-128, dez. 2018.

MACHADO, Jorge; BIONI, Bruno Ricardo. A proteção de dados pessoais nos programas de Nota Fiscal: um estudo de caso do "Nota Fiscal Paulista". *LIINC em Revista*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 350-364, nov. 2016.

MAGRANI, Eduardo. *Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento político-democrático*. Curitiba: Juruá, 2014.

MAGRANI, Eduardo; OLIVEIRA, Renan Medeiros de. O *Big Data* somos nós: novas tecnologias e projetos de gerenciamento pessoal de dados. In: TEPEDINO, Gustavo et al. (Coord.). *Anais do VI Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, p. 159-180, set.-dez. 2018.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Mercado, pessoa humana e tecnologias: a internet das coisas a proteção do direito à privacidade. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JÚNIOR, Eroulths (Coord.). *Transformações no direito privado nos 30 anos da Constituição: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas. *Revista da faculdade de direito da UERJ*, Rio de Janeiro, n. 6/7, p. 63-77, 1998/1999.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

SANTOS, Aline Fernandes dos; GOMES, Gabriel Ferreira Ribeiro; ANTONIOL, Juliana Freire; GOLDMAN, Márcia; LINHARES, Mariana Cavalcanti; SILVA, Paula Costa e; GASPARG, Walter e Britto. Dados sensíveis na era da informação: análise dos programas de desconto em medicamentos no Brasil. In: BARROS, Guilherme Smolarek de et al. *Coleção jovem jurista*. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

SARMENTO, Daniel. *Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

SCHREIBER, Anderson. Nossa ordem jurídica não admite proprietários de passado. *Revista consultor jurídico*. 12.06.2017. Disponível em: [https://goo.gl/4SBtJi]. Acesso em: 21.01.2018.

SCHREIBER, Anderson. Proteção de Dados Pessoais no Brasil e na Europa. *Carta Forense*. 05.09.2018. Disponível em: [www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/protecao-de-dados-pessoais-no-brasil-e-na-europa/18269]. Acesso em: 25.01.2019.

SESSAREGO, Carlos Fernández. *Derecho a la identidad personal*. Buenos Aires: Astrea, 1992.

SOLOVE, Daniel J. Conceptualizing privacy. *California law review*, Berkeley, v. 90, p. 1088-1156, 2002.

TAYLOR, Charles. *As fontes do self: a construção da identidade moderna*. São Paulo: Loyola, 1997.

TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

VENTURA, Felipe. CPFs de 120 milhões de brasileiros ficaram expostos na internet por meses. *Tecnoblog*. 13.12.2018. Disponível em: [https://tecnoblog.net/271493/cpf-exposto-internet-servidor-apache]. Acesso em: 15.02.2019.

VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 71-99, jan.-mar. 2018.

VIOLA, Mario; DONEDA, Danilo; ANDRADE, Norberto N. G. de. Dados anônimos e tratamento de dados para finalidades distintas: a proteção de dados pessoais sob uma ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz E. (Org.). *Pensamento crítico do direito civil brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2011.

YADRON, Danny. Hackers target users of infidelity website Ashley Madison. *The Wall Street Journal*. 20.07.2015. Disponível em: [www.wsj.com/articles/affair-website-ashley-madison-hacked-1437402152]. Acesso em: 15.02.2019.

1

.Professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ e do Departamento de Direito da PUC-Rio. Doutor e Mestre em direito civil pela UERJ. Especialista em direito civil pela Universidade de Camerino (Itália). Advogado.

2

.Cf. o pioneiro DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. Mais recentemente, v. MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014; e BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. São Paulo: Atlas, 2019.

3

.PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas. *Revista da faculdade de direito da UERJ*, Rio de Janeiro, n. 6/7, 1998/1999. p. 63-64.

4

.PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 764

5

.Sobre a sistematização das manifestações da dignidade da pessoa humana, v. MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade da pessoa humana. In: *Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 71-120; e SARMENTO, Daniel. *Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

6

.TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. t. I. p. 54.

7

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 113.

8

.Magrani e Oliveira explicam que “Big Data, que é um termo em evolução que descreve qualquer quantidade volumosa de dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados que têm o potencial de ser explorados para obter informações” (MAGRANI, Eduardo; OLIVEIRA, Renan Medeiros de. *O Big Data* somos nós: novas tecnologias e projetos de gerenciamento pessoal de dados. In: TEPEDINO, Gustavo et al. (Coord.). *Anais do VI Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 405) e alertam: “Diante da volumosa quantidade de dados produzida diariamente, isso se torna ainda mais preocupante, sobretudo, porque o *Big Data* vai muito além de um emaranhado de dados. Ele é essencialmente relacional. É preciso termos em mente que o *Big Data* somos nós e, portanto, devemos ter uma consciência crítica sobre isso e pensar sobre possibilidades de retomar o controle sobre nossos dados pessoais” (ibid., p. 400).

9

.Na explicação de Doneda, “Entre estas técnicas está a elaboração de perfis de comportamento de uma pessoa a partir de informações que ela disponibiliza ou que são colhidas. Esta técnica, conhecida como *profiling*, pode ser aplicada a indivíduos, bem como estendida a grupos. Nela, os dados pessoais são tratados, com o auxílio de métodos estatísticos, técnicas de inteligência artificial e outras mais, com o fim de obter uma ‘metainformação’, que consistiria numa síntese dos hábitos, preferências pessoais e outros registros da vida desta pessoa. O resultado pode ser utilizado para traçar um quadro das tendências de futuras decisões, comportamentos e destinos de uma pessoa ou grupo. [...] Um perfil assim obtido pode se transformar numa verdadeira representação virtual da pessoa, pois pode ser o seu único aspecto visível a uma série de outros sujeitos. Este perfil estaria, diversas vezes, fadado a confundir-se com a própria pessoa. A partir do momento em que o perfil eletrônico é a única parte da personalidade de uma pessoa visível a outrem, as técnicas de previsão de padrões de comportamento podem levar a uma diminuição de sua esfera de liberdade, visto que vários entes com os quais ela se relaciona partem do pressuposto de que ela adotará um comportamento predefinido, acarretando uma diminuição de sua liberdade de escolha” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 173-174).

10

.Os efeitos político-sociais nocivos do chamado “filtro-bolha” são analisados por MAGRANI, Eduardo. *Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento político-democrático*. Curitiba: Juruá, 2014.

11

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.- dez. 2018. p. 171.

12

.DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Espaço Jurídico Journal of Law*, Santa Catarina, v. 12, n. 2, jul.- dez. 2011. p. 92.

13

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.- dez. 2018. p. 160-161.

14

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Mercado, pessoa humana e tecnologias: a internet das coisas a proteção do direito à privacidade. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CORTIANO JUNIOR, Eroulths (Coord.). *Transformações no direito privado nos 30 anos da Constituição*: estudos em homenagem a Luiz Edson Fachin. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 107.

15

.YADRON, Danny. Hackers target users of infidelity website Ashley Madison. *The Wall Street Journal*. 20.07.2015. Disponível em: [www.wsj.com/articles/affair-website-ashley-madison-hacked-1437402152]. Acesso em: 15.02.2019.

16

.VENTURA, Felipe. CPFs de 120 milhões de brasileiros ficaram expostos na internet por meses. *Tecnoblog*. 13.12.2018. Disponível em: [https://tecnoblog.net/271493/cpf-exposto-internet-servidor-apache]. Acesso em: 15.02.2019.

17

.ALVES, Paulo. Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. *Techtudo*. 24.03. 2018. Disponível em: [www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghml]. Acesso em: 15.02.2019.

18

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 17; 93.

19

.A expressão tem origem em uma decisão da Corte Constitucional alemã de 15 de dezembro de 1983 sobre a constitucionalidade do censo populacional (Bundesverfassungsgericht, *decisions* v. 65, p. 1 ff. apud HORNUNG, Gerrit; SCHNABEL, Christoph. Data protection in Germany I: The population census decision and the right to informational self-determination. *Computer Law & Security Report*, v. 25, Issue 1, Southampton, UK, p. 84-88, 2009. Disponível em: [http://migre.me/foETX]. Acesso em: 20.08.2013. Na explicação de Rodotà, “[...] a privacidade deve ser vista como ‘a proteção de escolhas de vida contra qualquer forma de controle público e estigma social’ (L. M. Friedman), como a ‘reivindicação dos limites que protegem o direito de cada indivíduo a não ser simplificado, objetivado, e avaliado fora de contexto’ (J. Rosen). [...] Estas definições não são mutuamente exclusivas, marcam uma inclusão progressiva de novos aspectos de liberdade num conceito ampliado de privacidade” (RODOTÀ Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 15).

20

.MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: *Na medida da pessoa humana*: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 148. Solove, por sua vez, entende que não é mais possível definir a privacidade com base em um “núcleo duro”, em requisitos necessários e suficientes, mas com base em semelhanças e familiaridades, sob uma perspectiva pragmática. O autor lista seis linhas de definição da privacidade (o direito a ser deixado só, a limitação de acesso, o segredo, a autodeterminação informativa, a personalidade, intimidade) (SOLOVE, Daniel J. Conceptualizing privacy. *California law review*, Berkeley, v. 90, 2002. p. 1090).

21

.Sobre o tema, v. SESSAREGO, Carlos Fernández. *Derecho a la identidad personal*. Buenos Aires: Astrea, 1992. E, entre nós, CHOERI, Raul Cleber da Silva. *O conceito de identidade e a redesignação sexual*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. E seja consentido remeter a KONDER, Carlos Nelson. O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro. *Pensar* (Unifor), v. 23, p. 1-11, 2018.

22

.TAYLOR, Charles. *As fontes do self*: a construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997. p. 53. Entre nós, v. SARMENTO, Daniel. *Dignidade da pessoa humana*: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 241-298.

23

.SCHREIBER, Anderson. Nossa ordem jurídica não admite proprietários de passado. *Revista consultor jurídico*. 12.06.2017. Disponível em: [https://goo.gl/4SBtJi>]. Acesso em: 21.01.2018.

24

.MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018. p. 106.

25

.VIOLA, Mario; DONEDA, Danilo; ANDRADE, Norberto N. G. de. Dados anônimos e tratamento de dados para finalidades distintas: a proteção de dados pessoais sob uma ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz E. (Org.). *Pensamento crítico do direito civil brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2011. p. 198.

26

.MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018. p. 110.

27

.BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Deputado Orlando Silva. Disponível em: [www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?cod_teor=1664206&filename=PPP+1+PL406012+%3D%3E+PL+4060/2012]. Acesso em: 25.01.2018.

28

.“Muito embora com certa clareza seja reputado informação pessoal na GDPR, o dado pseudonimizado pode se submeter a um regime jurídico modulado ou particularizado, em linha de sintonia com esse mesmo estatuto: abrem-se portas para o tratamento de informações com finalidade diversa da original e não lastreada em consentimento expresso do titular dos dados, desde que o propósito ulterior seja compatível com o inicialmente consentido (GDPR, artigo 6º, 4, e). Semelhante raciocínio pode ter arrimo no sistema jurídico brasileiro a partir da previsão legal do artigo 9º, § 2º, da LGPD” (MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018. p. 113).

29

.Art. 9º, 1. “É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa”. Sobre a influência, v. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 167; SCHREIBER, Anderson. Proteção de Dados Pessoais no Brasil e na Europa. *Carta Forense*. 05.09.2018. Disponível em: [www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/protecao-de-dados-pessoais-no-brasil-e-na-europa/18269]. Acesso em: 25.01.2019; VERONESE, Alexandre; MELO, Noemy. O Projeto de Lei 5.276/2016 em contraste com o novo Regulamento Europeu (2016/679 UE). *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 71-99, jan.-mar. 2018.

30

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 165.

31

.MACHADO, Jorge; BIONI, Bruno Ricardo. A proteção de dados pessoais nos programas de Nota Fiscal: um estudo de caso do “Nota Fiscal Paulista”. *LIINC em Revista*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, nov. 2016. p. 361. Cenário similar é retratado quanto aos programas farmacêuticos de descontos em medicamentos: SANTOS, Aline Fernandes dos; GOMES, Gabriel Ferreira Ribeiro; ANTONIOL, Juliana Freire; GOLDMAN, Márcia; LINHARES, Mariana Cavalcanti; SILVA, Paula Costa e; GASPAR, Walter e Britto. Dados sensíveis na era da informação: análise dos programas de desconto em medicamentos no Brasil. In: BARROS, Guilherme Smolarek de et al. *Coleção jovem jurista*. Rio de Janeiro: FGV, 2012. p. 267-314.

32

.BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. EMI 73/2016. 29.04.2016. Disponível em: [\[www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=62B6CCB8D15F03BD169F7421D3CDB6EE.proposicoesWeb1?codteor=1457971&filename=Avulso+-PL+5276/2016\]](http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=62B6CCB8D15F03BD169F7421D3CDB6EE.proposicoesWeb1?codteor=1457971&filename=Avulso+-PL+5276/2016). Acesso em: 26.01.2019. Sobre o tema, afirma Mulholland: “Este princípio da não discriminação é dos mais relevantes, no que diz respeito ao tratamento de dados sensíveis. É esse o ponto fundamental quando diante do uso de dados sensíveis potencialmente lesivos, em decorrência de sua capacidade discriminatória, seja por entes privados – i.e. fornecedoras de produtos e serviços – seja por entes públicos” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 166).

33

.Durante o trâmite do projeto de lei no congresso nacional, a redação do dispositivo foi modificada para evitar que se pudesse abarcar como dados sensíveis outras informações, como dados genéticos de plantas. Cf. BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer do relator Deputado Orlando Silva. Disponível em: [\[www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1664206&filename=PPP+1+PL406012+%3D%3E+PL+4060/2012\]](http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1664206&filename=PPP+1+PL406012+%3D%3E+PL+4060/2012). Acesso em: 25.01.2018.

34

.DONEDA, Danilo; MONTEIRO, Marília. Acesso à informação e privacidade no caso da Universidade Federal de Santa Maria. *Jota*. 20.07.2015. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/acesso-a-informacao-e-privacidade-no-caso-da-universidade-federal-de-santa-maria-02072015\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/acesso-a-informacao-e-privacidade-no-caso-da-universidade-federal-de-santa-maria-02072015). Acesso em: 15.02.2019.

35

.FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: o tratamento dos dados pessoais sensíveis. *Jota*. 19.09.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018). Acesso em: 15.02.2019.

36

“A proteção do dado sensível tenta prevenir ou eliminar discriminações. Pode-se dizer que é uma nova leitura do princípio da igualdade, e sua intenção é a de que os dados armazenados não sirvam para prejudicar as pessoas” (LIMBERGER, Têmis. Da evolução do direito a ser deixado em paz à proteção dos dados pessoais. *Revista de Direito da Unisc*, Santa Cruz do Sul, n. 30, p. 138-160, jul.-dez. 2008).

37

.A caracterização de “interesse legítimo” para fim de tratamento de dados não consentido vem sendo objeto de diversos estudos no âmbito da aplicação da GDPR, entre os quais se remete a AAVV. Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na aceção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE. Disponível em: [\[www.gdpd.gov.mo/uploadfile/2015/0803/20150803050042662.pdf\]](http://www.gdpd.gov.mo/uploadfile/2015/0803/20150803050042662.pdf). Acesso em: 15.02.2019.

38

.Em crítica ao legislador, afirma Mulholland: “Contudo, a LGPD permite que haja tratamento de dados sensíveis sem a necessidade de fornecimento de consentimento do titular de dados, quando for indispensável para o tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos (artigo 11, II, b, LGPD), além de outras hipóteses que se referem, em grande medida, a interesses públicos. Neste último caso, o consentimento do titular dos dados sensíveis, seja genérico, seja específico, ficaria dispensado em decorrência de uma ponderação de interesses realizada pela lei, aprioristicamente, que considera mais relevantes e preponderantes os interesses de natureza pública frente aos interesses do titular, ainda que estes tenham qualidade de Direito Fundamental. No entanto, críticas devem ser feitas a este posicionamento legislativo, especialmente se considerarmos que a proteção do conteúdo dos dados pessoais sensíveis é fundamental para o pleno exercício de Direitos Fundamentais, tais como os da igualdade, liberdade e privacidade” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 170).

39

.Como explica Frazão, “a proteção aos dados pessoais não compromete o necessário direito que as partes têm de produzir provas umas contra as outras, ainda que estas se refiram a dados pessoais do adversário” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. *Jota*. 19.09.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018). Acesso em: 15.02.2019).

40

.A hipótese, aplicável aos dados pessoais não sensíveis, é obscura, como observa Frazão: “Como se pode observar, a hipótese enseja um duplo desafio: (i) compreender o que pode ser considerado legítimo interesse do controlador ou de terceiro; e (ii) avaliar em que medida esse legítimo interesse pode ser alegado diante dos direitos e liberdades fundamentais do titular” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. *Jota*. 19.09.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018). Acesso em: 15.02.2019).

41

.LEMONS, Ronaldo; DOUEK, Daniel; ADAMI, Mateus Piva; LANGENEGGER, Natalia; FRANCO, Sofia Lima. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela MP nº 869/2018. *Jota*. 29.12.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pela-mp-no-869-2018-29122018). Acesso em: 26.01.2018.

Capítulo 2. Tratamento de dados pessoais por “legítimo interesse do controlador”: primeiras questões e apontamentos

Daniel Bucar¹

Mario Viola²

1. Introdução

O³ ano de 2018 ficou marcado pela aprovação da Lei 13.709/2018, também chamada de Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD, e, e que, posteriormente, foi alterada pela Lei nº 13.853/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 869/2018. A lei modificadora, além de criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - algo que tinha sido vetado pela Presidência da República no texto original da normativa -, altera diversos dispositivos da LGPD. Junto com elas, reflexões existentes ganham perfis mais específicos, dotados de fundamentos constitucionais agrupados por sua essencialidade (art. 2º) e princípios autônomos (art. 6º), além de instrumental próprio voltado à sua concretização. Não por outra razão, a nova disciplina tocará, entre outras disciplinas jurídicas⁴, o direito civil.

Com efeito, o dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, inciso I, LGPD) e o controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, à qual é atribuída a competência – tomada de decisões – para tratar dados pessoais (art. 5º, inciso VI, LGPD), de acordo com os parâmetros desenhados pela nova normativa. Já a atividade de tratamento de dados é constituída por toda operação, desde a coleta até a transferência (art. 5º, inciso X, LGPD), de modo que todo feixe de relações jurídicas em que há troca de informações pessoais será afetado pela novel legislação.

Por outro lado, o sistema de proteção se desenvolve sob a noção de privacidade, afeita a direitos da personalidade, cuja disciplina se desenvolve no seio do Direito Civil em sua axiologia constitucional. Surge a partir da necessidade de regular o crescente desenvolvimento no campo da tecnologia da informação, de forma a assegurar, em alguma medida, a autodeterminação informativa do indivíduo, voltada para o próprio desenvolvimento de sua personalidade, que é impactada pelo tratamento de seus dados pessoais, tanto no âmbito da administração pública quando do setor privado.⁵

A LGPD, contudo, reconhecendo outros valores constitucionais que não apenas a proteção da privacidade, traz um rol de outros princípios que deverão nortear a tutela da proteção de dados pessoais, entre eles a livre-iniciativa, a livre concorrência e o desenvolvimento tecnológico e econômico, sinalizando que esses interesses deverão conviver com a tutela da privacidade e, eventualmente, confrontá-la (arts. 2º, incisos V e VI; 55-J, § 1º, LGPD).

Reforça essa hermenêutica o tratamento de dados na hipótese de legítimo interesse do controlador, mesmo sem consentimento do titular, previsto no art. 7º, inciso IX, LGPD (*quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais*). A cláusula aberta despertou debates no âmbito do direito europeu pelo receio de flexibilização da tutela da proteção de dados, o que não deverá ser diferente no Brasil.

Por essa razão, é essencial traçar algumas linhas sobre o tema, ainda pouco explorado nessa chegada da LGPD, sob pena de não se consolidar bases úteis e seguras de aplicação do dispositivo legal.

Faz-se esse expediente pela inicial análise do “estado atual da arte” na União Europeia, com menção a debates teóricos, resistências sociais e até incidência do instituto em casos concretos, para depois traçar paralelo com a norma brasileira, passível de abranger controvérsias semelhantes. Apresentada a redação e estrutura do dispositivo, pretende-se determinar a competência de preenchimento da “cláusula de interesse legítimo” entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Judiciário, além de apresentar como adequado o método civil-constitucional na avaliação do conflito existente e preenchimento de conteúdo da cláusula aberta.

Propõe-se, igualmente, uma análise funcional do direito que fundamenta a conduta do controlador, questionando-se a quais interesses serve o tratamento de dados, com vistas a traçar alguns parâmetros de prevalência do interesse legítimo.

Diante da oposição entre situações patrimoniais, deverá se valorizar a obrigação como processo polarizado ao adimplemento. No tocante ao tratamento de dados para realização de interesses existenciais, provocado por terceiro, ou grupo de terceiros que o fundamentam sobre esse argumento, será necessário analisar os efeitos do ato de autonomia existencial do titular (resguardo de sua própria esfera informativa).

Distintas ainda aquelas situações em que seja possível visualizar interesse existencial confrontado ao interesse patrimonial, bem definida a resposta pela cláusula geral de proteção à pessoa humana.

2. Legítimo interesse do controlador: um breve contexto

2.1. Origem e controvérsias na legislação da União Europeia

Em que pese o reconhecimento expresso do Direito Fundamental à Proteção de Dados Pessoais na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 8º)⁶, desde 1995, a Diretiva de Proteção de Dados (95/46/CE) já disciplinava a matéria.⁷ Os graus de legitimidade para o tratamento de dados já apareciam no art. 7º da Diretiva, que delineava os requisitos legais para o tratamento de dados sem consentimento⁸.

A possibilidade de tratamento de dados já era integrada por algumas situações abertas, mas sempre fixadas em certas premissas elencadas no aludido art. 7º, cujas alíneas permitiam o manejo⁹ mediante a) consentimento do titular do dado; b) necessidade para realização de contrato; c) cumprimento de obrigação legal; d) proteção de interesse vital do próprio titular dos dados; ou e) do interesse público. Entretanto, a alínea *f* do dispositivo guardava, não sem polêmica, a opção mais aberta: a possibilidade de tratamento de dados em razão de legítimo interesse do responsável pelo cadastro, de terceiro ou terceiros, a quem os interesses sejam comunicados, ponderando-se a permissão do manejo com direitos e liberdades fundamentais da pessoa titular.

A essa previsão, seguiu-se caloroso debate, considerando-a, inclusive, paradoxal à totalidade do diploma: se o sistema era inaugurado pelo reconhecimento de ameaças ao controle, franquear ao controlador a opção de, independentemente de consentimento, tratar os dados por seu interesse poderia eivar a normativa de flagrante ausência de efetividade. A pseudolimitação do tratamento à ponderação apenas expandiria a discricionariedade do controlador, permitindo-lhe, por meio de engenhosas argumentações, tudo tratar.

Em contraposição, o viés econômico do mercado motivava a manutenção do interesse legítimo, tanto com a redução de custos administrativos proporcionada pela circulação de

informação, com perfilhamento de clientes, direcionamento de ofertas e acesso a serviços específicos¹⁰, como, também, com a necessidade de inovação, tópico de fundamental relevância na nossa sociedade da informação. Esse tratamento de dados também geraria benefício ao titular do dado tratado em razão da necessidade de empregos e redução de custos permitir, utilitariamente, um desenvolvimento melhor das relações conflitantes, protegidas, de toda forma, por posterior avaliação¹¹.

O embate dessas duas posições ganhou nova vida com a revisão do arcabouço normativo sobre a proteção de dados na União Europeia, que culminou com a adoção do novo Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados Pessoais (ou simplesmente GDPR)¹². O resultado foi a manutenção do tratamento autorizado pelo interesse legítimo, pontuando-se a necessidade de (a) uma maior proteção aos interesses da criança, quando postos em ponderação; e (b) uma maior exemplificação de incidência da cláusula do interesse legítimo (relação duradoura de clientela subsistente, legítima expectativa de tratamento dos dados recolhidos, controle de fraude, transmissão entre empresas do mesmo grupo e segurança cibernética)¹³.

Judicialmente, a indefinição da cláusula, contudo e curiosamente, foi objeto de pouco debate. Com efeito, escassas foram as oportunidades de manifestação pelo Tribunal de Justiça Europeu sobre o “interesse legítimo” do controlador e, nas hipóteses que o fez, pouco se esclareceu¹⁴.

De todo modo, ainda que sem um posicionamento claro do Judiciário europeu sobre a matéria, o Grupo do Artigo 29 adotou parecer sobre o tema¹⁵ que

(...) não apenas serviu para moldar o texto da GDPR, como também tornou conhecida a aplicação de um teste para avaliar se, no caso concreto, o controlador poderia se valer do requisito dos interesses legítimos para tratar dados pessoais. O *legitimate interest assessment* (“LIA”), previsto no documento elaborado pelo grupo, apresenta quatro fases que devem ser cumpridas de modo a verificar o preenchimento do requisito de interesse legítimo. As fases são: (i) avaliação dos interesses legítimos; (ii) impacto sobre o titular do dado pessoal; (iii) equilíbrio entre os interesses legítimos do controlador e o impacto sobre o titular; e (iv) salvaguardas desenvolvidas para proteger o titular dos dados e evitar qualquer impacto indesejado.¹⁶

Esse teste, apesar de se referir à antiga normativa europeia, pode ser de grande utilidade para traçar as bases da utilização do interesse legítimo como fundamento para o tratamento de dados pessoais de acordo com a nossa LGPD, com as devidas adaptações ao nosso ordenamento jurídico.¹⁷

2.2.A “privacidade-instrumento” e o legítimo interesse do controlador no ordenamento jurídico brasileiro: fixação e lições preliminares

Não se tem dúvidas quanto à inspiração europeia na formulação da LGPD brasileira. Nesse sentido, o art. 7º da normativa brasileira enumera, em dez incisos, as possibilidades do tratamento de dados, entre os quais figura *interesse legítimo do controlador ou de terceiro*¹⁸, enquanto seu art. 10 prescreve as razões possíveis que justificam a atuação da cláusula permissiva.¹⁹

Não obstante a ausência de estudos brasileiros sobre o tema, não se pode negar que as discussões em torno da problemática europeia serão partilhadas pela doutrina nacional.

Inicialmente, a cláusula geral, tal como se defende na Europa, deve ser preenchida no caso concreto²⁰. A experiência de sua aplicação não deve se afastar da prática já aqui desenvolvida quanto a outras já célebres cláusulas gerais, entre as quais se destacam a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a função social dos contratos (art. 421, CC), interpretadas e preenchidas sob a axiologia unitária do ordenamento, as quais, a partir da análise de seus princípios constitucionais norteadores, atuam para dirimir os conflitos concretos e existentes²¹.

Independentemente da ausência de uma previsão expressa do “Direito Fundamental à Proteção de Dados” na Constituição da República, sua tutela se justifica em razão da contemporânea dimensão do “Direito à Privacidade” (art. 5º, inciso X, CR), alinhada à cláusula geral de proteção da pessoa humana. Tal forma de proteção da privacidade é minuciosamente refletida nos princípios fundamentais da LGPD (privacidade, autodeterminação, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício da cidadania – art. 2º, incisos I, II e VII, LGPD), que constituem, dessa forma, o objetivo principal da lei, não se podendo perder de vista, contudo, que outros princípios igualmente de natureza constitucional também formam a base dessa lei, entre eles o desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, a livre-iniciativa e a livre concorrência, conforme aqui já destacado.

O complexo jogo de forças sociopolíticas impõe conciliar valores constitucionais opostos, transfigurando-se esse embate ao discurso jurídico na linha mestra da interpretação e aplicação de normas-princípios: nenhum deles, nem mesmo a privacidade, será taxado de absoluto²². Dessa forma, as liberdades de expressão, de informação, o desenvolvimento tecnológico e econômico, a inovação, a livre-iniciativa, e até os direitos existenciais de terceiros (também presentes nos incisos III, V e VI do art. 2º da LGPD), configuram o arcabouço de conformidade para o tratamento de dados por força do legítimo interesse do controlador ou de terceiros.

Embora – a um primeiro olhar – possa causar antipatia a alguns, a superação do suposto poder absoluto que seria conferido à pessoa sobre seus dados é ponto de partida para uma aproximação da concepção atual da privacidade.

Com efeito, a privacidade não mais guarda relação com o direito burguês de Warren e Brandeis, autores do artigo inaugural *The right to privacy*²³, de cunho egoístico e individualista. Diversamente, a privacidade contemporânea está relacionada à limitação (ou até vedação, dependendo do caso) de acesso a determinados dados, como as informações genéticas, que, se utilizados em determinados contextos, poderão ter efeitos discriminatórios²⁴. Busca-se não um direito subjetivo, transposto dos interesses proprietários liberais, mas uma situação jurídica que se inter-relaciona com a coletividade, mas que, tutelando os espaços e contexto de tratamento, proporcione à pessoa ser plural e livre²⁵.

A possibilidade de sopesamento de outros princípios à privacidade deve ser justificada, portanto, à renovada noção que exige o conceito, pelo que casos haverá em que a finalidade de uso dos dados, mesmo sem consentimento do titular, sem ofensa ao objetivo de sua proteção (mandatório, inclusive, ao cumprimento de justiça social e defesa do consumidor no exercício de livre-iniciativa, previsto no art. 170, caput e inciso V, CF) e com a promoção, inclusive, de outros valores constitucionais²⁶. A cláusula geral de interesse legítimo, portanto, permite essa flexibilidade e sua conformidade se desenvolverá no caso concreto pelo correto uso do ônus argumentativo²⁷, o que revelará um resultado adequado. Essa deverá ser a direção para a futura concretização do legítimo interesse, pois, perante a unidade do ordenamento jurídico, a ponderação será, portanto, indispensável²⁸.

3.A “ponderação de interesses”: provocações metodológicas e parâmetros de aplicação

3.1. Quem controla o controlador?

A aplicação da cláusula do interesse legítimo pelo controlador, ou por terceiro, suscita questionamento acerca de quem poderá sindicá-lo o resultado. Ou, em outras palavras, a quem caberá definir a conformidade do preenchimento da cláusula aberta.

Uma primeira resposta, simples e evidente, será atribuir ao Poder Judiciário esta função, conforme a diretriz de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, CR). Entretanto, a Lei Geral de Proteção de Dados atribui à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a incumbência de controlar o interesse legítimo, na medida em que o órgão poderá solicitar relatório de

tratamentos realizados com fundamento na referida cláusula (art. 10, § 3º, LGPD), o que fará, inclusive, no estrito cumprimento de sua competência (art. 55-J).

Dada a especialidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados²⁹, a ela caberá definir qualitativamente os parâmetros do interesse legítimo, comungando-se o conhecimento técnico das formas de tratamento com sua respectiva juridicidade.

Isso porque, simultaneamente aos impactos técnicos do tratamento, a Autoridade deverá se pautar por questões jurídicas, as quais a obrigam valorar o bem inserido no ordenamento, de forma a desenvolver solução ágil e segura para decisões sobre o tema. Caso assim não seja, as soluções serão centralizadas em conflitos judiciais, acarretando não apenas morosidade na proteção do interesse legítimo, mas também a redução do próprio papel da Autoridade e da aplicação do art. 10, § 3º, da LGPD.

Ainda que judicializada a questão, será essencial a cooperação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no sentido de, no âmbito de sua expertise, detectar ilicitudes em tratamentos e alinhar a informação técnica, fornecendo subsídios para controlar a aplicação da cláusula aberta do interesse legítimo pelo controlador (e terceiros).³⁰

3.2. Afinal, como ponderar? Uma proposição civil-constitucional

O art. 7º, inciso IX, da LGPD fixa uma espécie de “regra de ponderação” ao referir-se à *prevalência de direitos* para syndicar a aplicação do interesse legítimo. Tal previsão expressa, ainda que de forma despicienda, a necessidade de aplicação da técnica de ponderação.

Nesse ponto, não se pode deixar de levar em consideração a lógica proposta por Alexy na ponderação de princípios constitucionais³¹, que também é, inclusive, defendida na doutrina europeia para o preenchimento do interesse legítimo³². Contudo, a técnica parece não ser suficiente, na medida em que sua aplicação transita unicamente entre princípios constitucionais e, também, no binarismo “conflito de princípios-conflito de regras”.

Dessa forma, para melhor subsidiar o preenchimento da debatida cláusula aberta, deve-se aliar o método civil-constitucional, notadamente a análise funcional do direito à privacidade e estabelecer *para que serve*³³ sua tutela na defesa dos dados pessoais. Assim, é possível estender a ponderação e buscar, na axiologia constitucional, o merecimento de tutela nos mais amplos conflitos (regras-regras, regras e princípios), de forma a promover os valores coesos de um ordenamento unitário em qualquer tensão entre direitos igualmente valorados pelo direito. Ao mesmo tempo, pode-se utilizar a ferramenta gradativa do abuso de direito para filtrar casos de contrariedade a valores e princípios, delimitando qual interesse do controlador (ou de terceiro) poderá ser considerado legítimo³⁴.

3.3. Ponderação de interesses stricto sensu: pressupostos, modus operandi e alguns parâmetros

Os princípios elencados no art. 6º da LGPD constituem o pressuposto argumentativo para qualquer das possibilidades de tratamento dos dados pessoais. Uma eventual violação desses princípios importa em tratamento injustificado ou, ao menos, demanda uma necessária adequação antes de discutir quaisquer de suas possibilidades. Semelhante advertência pode-se fazer à legalidade efetiva, presente, clara e articulada do interesse, que não poderá ser parâmetro de ponderação, mas sim passo de verificação anterior.

Nesse âmbito, encontra-se a natureza dos dados (sensível, próxima a aspectos da personalidade), o estatuto aplicável ao titular em causa (uma criança goza de proteção legal específica, segundo o art. 14, LGPD), a utilização de medidas técnicas de redução de impacto do tratamento (torná-los anônimos, assegurar que não possam ser utilizados em tomada de outras decisões e medidas) e a legítima expectativa do titular (*standards* de comportamento do controlador razoavelmente esperado pelo titular, presentes também no art. 10, inciso II,

LGPD). Esses parâmetros devem ser analisados antes de se adentrar na solução de conflitos reais que exijam a ponderação.

Já a técnica de sopesamento deve desenvolver-se em duas etapas. A primeira delas, procedimental, consubstancia-se no ônus de o controlador alegar o interesse legítimo, fundamentando a sua existência adequadamente. Essa etapa se extrai do art. 8º, § 2º, da LGPD, cujo texto, embora específico para o consentimento, pode ser expandido pela assimetria do poder de controle sobre a informação e pelo dever de *accountability*³⁵ de atividades motivadas pela cláusula geral.

Já a segunda etapa, com teor material, consiste em verificar as contrariedades ao ordenamento jurídico quanto aos seus valores e princípios, aplicando-se a efetiva ponderação para os casos em que dois interesses apresentam a mesma força normativa no ordenamento jurídico e são igualmente tutelados em hierarquia. Busca-se, com a ponderação, a efetiva consideração de um interesse legítimo, que se justifica perante a existência de valor superior à proteção do titular de dados. Alcançar essa resposta perpassa a necessidade de utilizar-se do tratamento como único meio de realizar o fim pretendido, sem que haja outro menos gravoso no ordenamento jurídico³⁶.

4.Proposta aberta de sistematização dos conflitos: análise funcional da proteção de dados

Ainda que haja a necessidade de aplicação da técnica do sopesamento, não se pode deixar de propor algum preenchimento de conteúdo ao legítimo interesse do controlador (ou de terceiro). Embora os exemplos de aplicação da cláusula nos Considerandos 47 e 49 da normativa europeia sejam claros, eles não solucionam outras situações mais delicadas; e, apesar de a maioria dos estudos sobre o assunto relegar a solução ao caso concreto³⁷, alguns parâmetros específicos de ponderação e exemplos práticos de debates podem ser desde já delineados. Há necessidade, portanto, de sistematizar algumas situações de modo a definir o *apoio e promoção de atividades do controlador* (art. 10, inciso I, LGPD)³⁸.

Mediante a análise funcional da proteção de dados – resguardar a liberdade da pessoa humana –, será possível designar a qual interesse serve a tutela. Assim, sistematizar os conflitos entre direitos pela natureza existencial ou patrimonial será de grande valia para fixar critérios que operem a prevalência de um deles no conjunto de casos a se avaliar.

Neste texto propõe-se uma primeira reflexão com vistas a auxiliar, em alguma medida, a concretização da delimitação do legítimo interesse como fundamento para o tratamento de dados pessoais no nosso ordenamento jurídico.

4.1.Conflito entre situações patrimoniais: a obrigação polarizada ao adimplemento

Grande parte das relações jurídicas patrimoniais encontra-se conectada ao controle de dados, pois esses são necessários para seu efetivo funcionamento. O tratamento de dados de cunho patrimonial objetiva, sobretudo, minimizar custos e majorar a garantia do adimplemento obrigacional.

Por essa razão, a proteção de dados nesse aspecto recebe tutela diferenciada, pois preponderantemente em questão está a Ordem Econômica, cujo funcionamento é submetido, de toda forma, ao valor personalista e dignitário (art. 170, CR). Significa dizer que o interesse legítimo se aperfeiçoa com o uso de dados relativos a situações eminentemente patrimoniais, sem que se revele qualquer situação existencial de seu titular.

Nesse sentido, deve-se refletir no Brasil o entendimento europeu acerca do papel, por exemplo, das agências de cobrança de crédito, fundamentais à circulação econômica. A fonte da atividade econômica do setor de cobrança é justamente a transferência de dados

patrimoniais, os quais, embora não necessários à execução contratual original, podem ser tratados perante a baixa potencialidade de danos existenciais³⁹ e a já consolidada prática de circulação de crédito, abraçada, inclusive, pela legislação brasileira. Ao contrário de criar obstáculos, o Código Civil permite a cessão de crédito sem necessidade de aprovação do devedor, excepcionadas hipóteses no próprio Código previstas (art. 286, CC).

Portanto, a diretriz de autodeterminação informativa patrimonial atrai diferente espectro de interesses, em que a transmissão de dados do devedor é inerente à atividade econômica, sendo-lhe necessário informar, contudo, os ambientes de tratamento dos dados, em razão da aplicação do princípio da transparência (art. 6º, VI, LGPD). De todo modo, diferente do que ocorre na experiência europeia, na LGPD a proteção do crédito é base legal autorizativa para o tratamento de dados sem o consentimento de seu titular, conforme previsto no inciso X de seu art. 7º. Todavia, outros exemplos de tratamento de dados com viés eminentemente econômico, como o combate a fraudes e a segurança de redes de comunicação e das informações, igualmente se mostrariam justificados pelo legítimo interesse do controlador (nesses exemplos, em algumas situações, até o próprio titular seria beneficiário desse tratamento de dados, já que se veria protegido contra eventuais perdas econômicas decorrentes do uso fraudulento de seus dados por terceiros).⁴⁰

4.2.O legítimo interesse existencial: autonomia privada, influência sobre terceiros

A sistematização mais dificultosa de conflitos é, sem dúvida, aquela que toca o tratamento de dados sensíveis, dotados de alta carga de informação existencial. Quando em “choque”, o tratamento desses dados acaba por definir qual situação existencial será a mais axiologicamente relevante.

Contudo, mostra-se relevante salientar que a LGPD veda o tratamento de dados sensíveis com base no “interesse legítimo” seja do controlador, seja de terceiro, visto que essa hipótese não constou entre aquelas autorizativas do tratamento de dados previstas no art. 11 da LGPD. Apesar dessa ausência, é possível imaginar situações nas quais o legítimo interesse de um terceiro, ou seja, situações que tenham efetiva relevância em sua esfera jurídica, com eminente caráter existencial e pessoal⁴¹, poderia justificar o tratamento de dados com base no seu legítimo interesse. Um exemplo nessa linha seria o tratamento de dados genéticos do doador de sêmen para inseminação heteróloga, feito de forma anônima. O legislador brasileiro, por meio da possibilidade de a pessoa do adotado conhecer sua origem biológica (art. 48, Estatuto da Criança e do Adolescente), de alguma forma legitimou o tratamento de dados genéticos do doador de sêmen, ainda que contrário ao consentimento do seu titular, que buscou o anonimato.

O caminho nessas situações, contudo, não seria o “legítimo interesse”, mas sim o “exercício regular de direitos”, base autorizativa ao tratamento de dados pessoais contida na alínea d do inciso II do art. 11 da LGPD, que será tratada um pouco mais em detalhes no próximo tópico.

De toda sorte, o tratamento de dados sensíveis, que tocam situações tipicamente existenciais, será pano de fundo para a efetiva aplicação da ponderação no caso concreto, pois se trata de terreno que suscita complexidade para uma reflexão apriorística.

4.3.Ponderação (ou superposição) das situações existenciais às patrimoniais?

Nos conflitos entre um interesse que resguarde uma situação existencial e outro patrimonial parece não haver lugar para a ponderação. A regra, aqui, é de prevalência das situações existenciais, não havendo interesse legítimo para tratamento de dados sem consentimento do seu titular ou sem a existência de outra base legal autorizativa do tratamento que não o interesse legítimo. A assertiva confirma a necessidade de atribuir à atividade econômica suporte ao livre desenvolvimento da personalidade⁴² e a incessante

busca do ordenamento constitucionalizado de colocar o *ser* sobre o *ter*, o que impede o compartilhamento de dados sensíveis entre controladores ou terceiros, movidos por interesse patrimonial, excetuadas apenas (i) a transmissão, em benefício do titular, de dados necessários à prestação de serviços referentes à sua saúde, (ii) a portabilidade de dados solicitada pelo titular e (iii) o tratamento de dados para lastrear operações financeiras e administrativas relacionadas à saúde do titular⁴³ (art. 11, §4º, LGPD).⁴⁴

Uma hipótese prevista para o tratamento de dados sensíveis no âmbito econômico é aquela para o exercício regular de direitos contratuais (art. 11, inciso II, alínea *d*, LGPD), já brevemente discutida no tópico anterior. A própria lei se sobrepõe, nessa situação e de forma justificada, ao consentimento do titular. Contudo, tal previsão deve ser objeto de acurado controle de forma a impedir seu uso abusivo, devendo-se compreender quando e para qual finalidade estrita o controlador (ou o terceiro) precisa tratar os dados. Um exemplo usado pela doutrina europeia para o tratamento de dados sensíveis com base no exercício regular de direitos no âmbito contratual é o do plano de saúde que necessita verificar se determinado pedido de reembolso de despesas médicas condiz com o quadro clínico do consumidor.⁴⁵

Importante destacar, contudo, que esse requisito

(...) não se confunde com interesses legítimos do controlador ou de terceiros. Como se trata de dados sensíveis, aqui a legislação impõe um controle maior sobre o que efetivamente poderia contar como requisito que chancela o tratamento, incluindo a análise sobre: (i) se existe um direito envolvido no caso; (ii) se o exercício do mesmo é regular (e não abusivo); e (iii) se o mesmo decorre de uma relação contratual,⁴⁶

ou mesmo existencial, como no caso do doador de sêmen, a justificar o tratamento de dados com base nesse requisito.

5. Conclusão

Traz a Lei Geral de Proteção de Dados afirmação infraconstitucional esmiuçada de um direito que outrora a doutrina se incumbiu de extrair do Direito Fundamental à Privacidade previsto constitucionalmente. Na era do desenvolvimento tecnológico e fluxo de informações sobre as pessoas em diversos espaços, o direito à autodeterminação informativa passa a ser concebido de forma diversa, levando-se em consideração, sobretudo, outros interesses de valor constitucional. Nesse contexto foi examinada a hipótese autorizativa do tratamento de dados pessoais sem o consentimento de seu titular prevista no inciso IX do art. 7º da LGPD.

Devido ao ineditismo da lei sob a ótica do direito brasileiro, buscou-se inspiração na doutrina e legislação europeias para abordar a matéria, em que o tema ainda suscita debates. A partir daí, buscou-se adaptar o interesse legítimo, à luz da experiência europeia, no direito brasileiro, conforme a axiologia constitucional que revela uma tutela da privacidade não como direito absoluto, mas sim funcionalizada ao livre desenvolvimento da personalidade por meio da autodeterminação informativa.

Sustenta-se, assim, na cláusula de legítimo interesse do controlador, apenas a possibilidade de outros valores suplantarem aquele espelhado no interesse do titular, mediante o caso concreto. Nessa análise mostrou-se relevante individuar as entidades competentes para interpretar esse dispositivo legal, assim como se propôs o estabelecimento dos contornos e limites do legítimo interesse. Exsurge, nesse contexto, a necessidade de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados garantir desburocratização e especialização no preenchimento dos casos de interesse legítimo, de modo célere e desjudicializado. No tocante aos limites e contornos, propõe-se, conforme a metodologia civil-constitucional, não se passar à imediata ponderação, mas, primeiramente, na adequada análise do perfil funcional no caso concreto, verificação de inexistência do abuso de direito, contrariedade aos princípios e valores do ordenamento.

Se presente, em tese, a conformidade do tratamento ao próprio direito, vai se cogitar a necessidade do tratamento, sem outras possibilidades mais brandas de satisfazer o interesse, verificando o merecimento de tutela, de forma a encontrar entre dois direitos, de mesma hierarquia e força, o que melhor promove o ordenamento jurídico. Parâmetros específicos desenvolvidos pela doutrina foram citados como forma de auxiliar essa tarefa nos casos de mais difícil confirmação da prevalência.

Em sua última parte, o trabalho sugeriu uma sistematização dos conflitos entre interesse legítimo e interesse do titular, desmembrada função de proteger cada um deles, qual proteção de direito lhes fundamenta, assim eleitos alguns parâmetros. Conflitivos interesses que resguardam direito patrimonial, o mais próximo da proteção do adimplemento será passível de suplantar o outro, incluído o centro de interesse da proteção de dados do devedor no processo obrigacional, no sentido de autodeterminação informativa e não direito subjetivo proprietário à privacidade.

Justapostos os interesses finalizados a direitos existenciais, a decisão deverá tomar em conta efeitos dos atos de autonomia existencial em terceiros e, no confronto entre dois direitos individuais, buscar *ratio* ampliativa do tratamento de algum daqueles nos julgados da jurisdição constitucional, em tentativa de coerência da decisão ao ordenamento complexo, antes de revolver-se completamente às múltiplas potencialidades do caso concreto. Último caso de conflito, entre interesses existenciais e patrimoniais, prevalecem os primeiros, pois a própria atividade econômica deve se funcionalizar à proteção da pessoa humana.

Conclui-se assim este trabalho, no intuito de trazer primeiras luzes ao tratamento possível no caso de interesse legítimo do controlador ou de terceiro, respeitando-se sua elasticidade permissiva à análise de casos concretos, enquanto se afirmam parâmetros de adequação ao ordenamento guiado pelos princípios e valores constitucionais.

6. Referências

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.

BALBONI, Paolo; COOPER, Daniel; IMPERIALI, Rosario; MACENAITE, Milda. Legitimate interest of the data controller new data protection paradigm: legitimacy grounded on appropriate protection. *International Data Privacy Law*, v. 3, n. 4, 2013.

BUCAR, Daniel. *Proteção de dados da pessoa humana na administração pública*. Dissertação (Mestrado em direito). Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

CASTRO, Thamis Dalsenter Viveiros de. A função da cláusula de bons costumes no Direito Civil e a teoria tríplice da autonomia privada existencial. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 14, p. 99-125, out.-dez. 2017.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar 2006.

DONEDA, Danilo; VIOLA, Mario. Relatório sobre a proteção de dados no Brasil. *Policy Paper* (no prelo).

CHUENG, Anne S.Y. China Internet going wild: cyber-hunting versus privacy protection. *Computer Law & Security Review*, Reino Unido, v. 2.

FERRETTI, Federico. Data protection and the legitimate inteires data controllers: much to do about nothing or the winter of rights? *Common Market Law Review*, Inglaterra, v. 51.

FUTURE OF THE PRIVACY FORUM; NIMITY PRIVACY COMPLIANCE SOFTWARE. *Processing Personal Data on the Basis of Legitimate Interests under the GDPR: Practical Cases*. Disponível em: [https://info.nymity.com/hubfs/Landing%20Pages/Nymity%20FPF%20-%20Legitimate%20Interests%20Report/Deciphering_Legitimate_Interests_Under_the_GDPR.pdf?hsCtaTracking=9cf491f2-3ced-4f9c-9ffa-5d73a77a773e%7C7469b2ec-e91c-4887-b5db-68d407654e23]. Acesso em: 29.06.2019.

KAMARA, Irene; HERT, Paul de. Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the controller ground: a pragmatic approach. In: SELINGER, Evan; POLONETSKY, Jules; TENE, Omar. *The handbook of consumer privacy*. Cambridge: Cambridge University Press.

JENTZSCH, Nicola. Secondary use of personal data: a welfare analysis. *European Journal Law and Economics*, v. 44, p. 165-192, 2017.

MENDES, Laura Schertel. O diálogo entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 106, jul.-ago. 2016.

Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na acepção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE, adotado em 9 de abril de 2014. Grupo de Trabalho artigo 29º da Diretiva 95/46/CE.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

SCHREIBER, Anderson. *A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Uma agenda para o direito civil-constitucional. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 10, p. 9-27, out.-dez. 2016.

SOUZA, Carlos Affonso; PADRÃO, Vinícius; VIOLA, Mario. Reflexões sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados: requisitos para o tratamento de dados, legítimo interesse e adequação de bancos de dados já em operação. *Civilística.com* (no prelo).

SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no Direito Civil. In: MORAES, Carlos Eduardo Guerra de; RIBEIRO, Ricardo Lodi (Coord.); MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rego; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz; MEIRELES, Rose Melo Venceslau (Org.). *Direito UERJ 80 anos: direito civil*. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2015. v. 2.

TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. t. II.

TEPEDINO, Gustavo. O papel atual da doutrina do direito civil entre o sujeito e a pessoa. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor. *O direito civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà*. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

USTARAN, Eduardo. *European data protection law and practice*. Portsmouth: IAPP, 2018.

WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. *Harvard Law Review*, Cambridge, v. IV, n. 5, p. 193, dec. 1890.

2

.Doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu (Florença, Itália). Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Pesquisador-Associado do *Centre for Media Pluralism and Media Freedom* do Instituto Universitário Europeu. Advogado.

3

.Os autores registram o agradecimento à inestimável pesquisa de apoio empreendida, para elaboração do presente artigo, por Caio Ribeiro Pires.

4

.Entre as demais disciplinas, destacam-se o direito administrativo (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e o direito processual civil (ao menos no que toca a questões relacionadas aos ônus da prova).

5

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar 2006. p. 140; CHUENG, Anne S. Y. China internet going wild: cyber-hunting versus privacy protection. *Computer Law & Security Review*, Reino Unido, v. 25, p. 275.

6

.Que passou a ter *status* vinculante com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Veja: [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_pt.htm]. Acesso em: 04.03.2019.

7

.Em verdade, sob uma perspectiva do continente Europeu, desde 1981, a matéria já era regulada pela Convenção 108 do Conselho da Europa.

8

.KAMARA, Irene; HERT, Paul de. Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the controller ground: a pragmatic approach. In: SELINGER, Evan; POLONETSKY, Jules; TENE, Omar. *The handbook of consumer privacy*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 5-7.

9

.Discute-se uma certa prevalência do consentimento em doutrina, sendo as outras possibilidades previstas subsidiárias ou, em sentido contrário, hipóteses de mesmo valor. No primeiro sentido, ressalte-se KAMARA, Irene; HERT, Paul de. Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the controller ground: a pragmatic approach. In: SELINGER, Evan; POLONETSKY, Jules; TENE, Omar. *The handbook of consumer privacy*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 9;12; MENDES, Laura Schertel. O diálogo entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 106, jul.-ago. 2016. p. 5, além de afirmação sugestiva, mas não exatamente clara, de FERRETTI, Federico. Data protection and the legitimate interest of data controllers: much to do about nothing or the winter of rights?. *Common Market Law Review*, Inglaterra, v. 51, p. 855. Em sentido contrário: *Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na aceção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE*, adotado em 9 de abril de 2014. Grupo de Trabalho artigo 29º da Diretiva 95/46/CE. p. 3. Tendo em vista a própria lei oferecer o mesmo efeito a todos os níveis de consentimento e possibilidade de tratamento, será melhor atentar para o preenchimento das hipóteses previstas no caso concreto, e não uma tentativa de hierarquia predisposta.

10

.JENTZSCH, Nicola. Secondary use of personal data: a welfare analysis. *European Journal Law and Economics*, v. 44, 2017. p. 179.

11

.BALBONI, Paolo; COOPER, Daniel; IMPERIALI, Rosario; MACENAITE, Milda. Legitimate interest of the data controller new data protection paradigm: legitimacy grounded on appropriate protection. *International Data Privacy Law*, v. 3, n. 4, 2013. p. 257.

12

.KAMARA, Irene; HERT, Paul De. Op. cit., p. 10-11.

13

.Considerandos 47 a 49 da RGPD.

14

.Afora o Caso Espanha x Google, em que a problemática desbordou para o delineamento do controvertido direito ao esquecimento, os demais casos conhecidos pela Corte não suscitaram maiores questionamentos.

Para uma descrição dos casos e os entendimentos fixados, remete-se a KAMARA, Irene; HERT, Paul De. Op. cit., p. 20-26.

15

.Grupo de Trabalho do Artigo 29. Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na acepção do artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE. Adotado em 9 de abril de 2014. Disponível em: [https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_pt.pdf]. Acesso em: 25.02.2019.

16

.SOUZA, Carlos Affonso; PADRÃO, Vinícius; VIOLA, Mario. Reflexões sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados: requisitos para o tratamento de dados, legítimo interesse e adequação de bancos de dados já em operação. *Civilística.com* (no prelo). Nesse artigo trabalha-se a ideia da adaptação do “teste” desenvolvido pelo Grupo do Artigo 29 aos termos da LGPD.

17

.Nesse sentido, veja-se BIONI, Bruno. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2019. p. 253 e ss.; SOUZA, Carlos Affonso; PADRÃO, Vinícius; VIOLA, Mario. Op. cit.

18

.Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII – para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Por tratar-se de obra coletiva destinada a análise desta lei, os outros dispositivos de permissão não serão comentados no escopo ora apresentado.

19

.Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: I – apoio e promoção de atividades do controlador; e II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

20

.A casuística de aferição da legitimidade do interesse é aspecto ressaltado na doutrina estrangeira: KAMARA, Irene; HERT, Paul De. Op. cit., p. 10; BALBONI, Paolo; COOPER, Daniel; IMPERIALI, Rosario; MACENAITE, Milda. Op. cit., p. 253; Grupo de Trabalho Artigo 29. *Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na acepção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE, adotado em 9 de abril de 2014*. p. 81.

21

.TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. t. II. p. 3-20.

22

.KAMARA, Irene; HERT, Paul De. Op. cit., p. 5; ALEX, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 96.

23

.WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. Harvard Law Review, Cambridge, v. IV, n. 5, dec. 1890. p. 193.

24

.DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 140-141.

25

.Ibid., p. 143-146.

26

.MENDES, Laura Schertel. Op. cit., p. 7.

27

.SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Uma agenda para o direito civil-constitucional. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 10, out.-dez. 2016. p. 14-16.

28

.Em incentivo à utilização de ponderação quando se visualiza linha tênue entre o legítimo interesse e outras hipóteses de tratamento: *Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na acepção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE, adotado em 9 de abril de 2014*. Grupo de Trabalho artigo 29º da Diretiva 95/46/CE. p. 23/28. p. 87.

29

.Fortalece a tecnicidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados a composição do órgão por um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade integrado por representantes da sociedade civil, dos setores público e privado e da academia (art. 58-A, LGDPD).

30

.Em relatório produzido para a Unesco, Danilo Doneda e Mario Viola sugerem que o Judiciário estabeleça “canais de cooperação com o órgão técnico responsável (ANPD), inclusive para fins de solicitação de parecer técnico sobre o tema ou a modalidade de tratamento de dados” (DONEDA, Danilo; VIOLA, Mario. Relatório sobre a proteção de dados no Brasil. *Policy Paper* (no prelo)).

31

.A proposta é detalhadamente descrita em ALEXY, Robert. Op. cit., p. 543-574.

32

.Para sua defesa nesses termos: KAMARA, Irene; HERT, Paul De. Op. cit., p. 5-7.

33

.PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 94.

34

.TEPEDINO, Gustavo. O papel atual da doutrina do direito civil entre o sujeito e a pessoa. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor. *O direito civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà*. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 30. Sobre a resolução de conflitos por meio do merecimento de tutela: SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. In: MORAES, Carlos Eduardo Guerra de; RIBEIRO, Ricardo Lodi (Coord.); MONTEIRO, Carlos Edson do Rego Filho; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz; MEIRELES, Rose Melo Venceslau (Org.). *Direito UERJ 80 anos: direito civil*. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2015. v. 2.

35

.Ressaltando a importância desse dever: FERRETTI, Federico. Op. cit., p. 849; BALBONI, Paolo; COOPER, Daniel; IMPERIALI, Rosário; MACENAITE, Milda. Op. cit., p. 261.

36

.A necessidade é também o primeiro passo da ponderação sugerido por Robert Alexy (ALEXY, Robert. Op. cit., p. 116-120). Dentro da estrutura do merecimento de tutela, em que o expediente se encontra contido no direito civil-constitucional, poderá exercer função semelhante e harmoniosa ao método, posto que será o maior exemplo de solução promocional unitária, satisfeitos os dois interesses colidentes.

37

.KAMARA, Irene; HERT, Paul de. Op. cit., p. 10; BALBONI, Paolo; COOPER, Daniel; IMPERIALI, Rosário; MACENAITE, Milda. Op. cit., p. 253; Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na acepção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE, adotado em 9 de abril de 2014. *Grupo de Trabalho artigo 29º da Diretiva 95/46/CE*. p. 81.

38

.A proteção do próprio titular, do inciso II, é restrita e de fácil visualização, como o controle de fraudes bancárias. Destaque-se, contudo, que o *caput* do art. 10 é claro ao afirmar que as situações previstas nos seus incisos são

apenas exemplificativas, podendo ser identificadas outras situações que justifiquem o tratamento de dados com base no legítimo interesse fora daquelas ali listadas.

39

.*Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados na aceção do artigo 7º da Diretiva 95/46/CE*, adotado em 9 de abril de 2014. Grupo de Trabalho artigo 29º da Diretiva 95/46/CE. p. 28. Consta essa hipótese, inclusive, do rol de hipóteses elencadas nesse parecer que configuram interesse legítimo presente nos considerandos (Ibid., p. 28). “Processing personal data on the basis of legitimate interest under the GDPR”. Reportagem realizada pelo *Future of Privacy Forum* e pela *Nymity Innovating Compliance*, p. 33-34.

40

.KAMARA, Irene; HERT, Paul de. Op. cit., p. 27-28.

41

.Apresentando critério de classificação dos direitos existenciais sob a óptica de seus efeitos: CASTRO, Thamis Dalsenter Viveiros de. A função da cláusula de bons costumes no direito civil e a teoria tríplice da autonomia privada existencial. *Revista Brasileira de Direito Civil*, Belo Horizonte, v. 14, out.-dez. 2017. p. 103 e 106.

42

.PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 33.

43

Como exemplo, dado solicitado por operadora de plano de assistência à saúde a certo médico ou instituição hospitalar, para confirmação de tratamento cujo reembolso o paciente deseja haver.

44

De acordo com a redação dada pela Lei 13.853/2019.

45

“Using sensitive data may also be necessary for a controller to establish, exercise or defend legal claims. Reliance on this criterion requires the controller to establish necessity. That is, there must be a close and substantial connection between the processing and the purposes. One example of an activity that would fall under this criterion is processing medical data by an insurance company in order to determine whether a person’s claim for medical insurance is valid. Processing such data would be necessary for the insurance company to consider the claim brought by the claimant under their insurance policy” (USTARAN, Eduardo. *European data protection law and practice*. Portsmouth: IAPP, 2018. p. 88).

46

.SOUZA, Carlos Affonso; PADRÃO, Vinícius; VIOLA, Mario. Op. cit.

Capítulo 3. Primeiras impressões sobre o tratamento de dados pessoais nas hipóteses de interesse público e execução de contratos

Luciana Pedroso Xavier¹

Marília Pedroso Xavier²

Mayara Guibor Spaler³

1. Introdução

A⁴ Era da Informação, também compreendida como Era Digital,⁵ representou uma quebra de paradigma sem precedentes em relação ao valor atribuído a dados e a informações.⁶ O avanço da tecnologia da informação fez com que a economia mundial deixasse de se basear na indústria, passando a se pautar na informação, a qual se transformou em sua principal matéria-prima.⁷

A partir disso, verifica-se o desenvolvimento do *data driving*, fenômeno segundo o qual a sociedade passa a ser dirigida por dados, os quais se tornam um importante ativo financeiro capaz de guiar decisões estratégicas para os agentes do mercado. Nesse sentido, entende-se que dados correspondem aos insumos da nova economia digital, com o potencial de serem transformados em informações economicamente úteis.⁸

Os dados se tornaram imprescindíveis para o desenvolvimento das tecnologias revolucionárias da Era Digital, tais como o Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Sua importância é ressaltada à medida que o desenvolvimento tecnológico viabiliza meios de transformá-los em mercadorias.⁹

Há tempos que se reconhece que a informação, independentemente de sua espécie, converteu-se em um bem jurídico de valor extraordinário e que ‘os Estados, as associações, as empresas são tão ou mais poderosas conforme disponham de grandes volumes de informação’. É por isso que se afirma que o ‘melhor acesso a mais informações é a marca da economia informacional’. O avanço da tecnologia, aliado ao aumento da velocidade das redes e à melhoria dos mecanismos de busca, gera mais atividade econômica baseada na economia da informação.¹⁰

Nas relações de consumo, os dados permitem o direcionamento de estratégias de *marketing* personalizado; na genética, permitem o mapeamento completo do genoma humano; em campanhas eleitorais, permitem a aferição de intenções de votos de acordo com cada perfil; na busca por relacionamentos, permitem a identificação de pessoas com perfis compatíveis,¹¹ entre inúmeras outras aplicações.¹²

Tendo em vista que os avanços tecnológicos “expõem a pessoa humana a novas situações que desafiam o ordenamento jurídico, reclamando nova disciplina, bem como a ressignificação de antigos institutos”,¹³ a comunidade internacional se voltou à análise e regulamentação da proteção de dados pessoais.

Segundo Danilo Doneda e Mario Viola, “o tratamento autônomo da proteção de dados pessoais é uma tendência hoje fortemente enraizada em diversos ordenamentos jurídicos, que veio a formar as bases para o que vem sendo tratado, hoje, como um direito fundamental¹⁴ à proteção de dados”,¹⁵ tamanha a sua relevância.

Assim, seguindo a tendência mundial, e em especial após o advento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (*General Data Protection Regulation*)¹⁶ – que serviu de parâmetro para a elaboração do marco regulatório nacional – o Brasil aprovou, em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), também conhecida como LGPD.

Cabe ressaltar que, antes da referida legislação, a proteção de dados pessoais em âmbito nacional era prevista em legislação esparsa, que não abordava a matéria com a profundidade suficiente, de modo que se faziam necessários métodos hermenêuticos como a analogia e a análise sistemática para viabilizar sua aplicação.

O tema possui relevo constitucional, sendo protegido como direitos fundamentais a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, inciso X, CF), bem como o sigilo de correspondência e comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, CF).

Menciona-se, a título exemplificativo: i) o Código de Defesa do Consumidor, que garante aos consumidores o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre a suas respectivas fontes (art. 43, Lei 8.078/1990); ii) o Código Civil, que garante a privacidade como direito da personalidade (art. 21, Lei 10.406/2002); iii) a Lei de Acesso à Informação, que já considerava informação pessoal aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e regulamentava o tratamento de dados feito em especial pela Administração Pública (art. 4º, inciso IV, Lei 12.527/11); iv) a Lei do Cadastro Positivo, que prevê a criação de bancos de dados¹⁷ com informações relativas ao adimplemento do indivíduo cadastrado para a formação de histórico de crédito (art. 1º, Lei 12.414/2011); v) o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), que disciplina o uso da internet no Brasil e dispõe sobre a proteção da privacidade e de dados pessoais, apesar de não definir o que seriam tais dados e; vi) o Decreto 8.771/2016, que regulamentou o Marco Civil e, baseando-se no conceito europeu¹⁸, considerou como dado pessoal aquele “relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa” (art. 14, inciso I, Decreto 8.771/2016).

Não obstante seja amplamente reconhecida a importância do Marco Civil da Internet no cenário nacional, entende-se que a LGPD abordou a matéria de proteção de dados de forma mais ampla e pormenorizada, dispondo

especificamente sobre direitos e deveres relativos ao tratamento de dados e estendendo também sua aplicação à esfera física e *off-line*. Trouxe ainda relevantes conceitos que viabilizam inclusive a compreensão do Marco Civil da Internet e garantiu a uniformização da legislação a respeito da proteção de dados pessoais, fomentando a criação de um microsistema jurídico próprio perante a nomenclatura de “Lei Geral”.

2.A proteção dos dados pessoais

A Lei Geral de Proteção de Dados versa sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, tanto em meio físico quanto digital, com a finalidade de tutelar seus direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade.¹⁹

O tratamento de dados refere-se a toda operação que for realizada com dados pessoais envolvendo, nos termos da lei (art. 5º, inciso X, Lei 13.709/2018), “a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

São considerados, pela legislação, três categorias de dados: pessoais, sensíveis e anonimizados. Os *dados pessoais* correspondem a quaisquer informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Podem-se classificar como dados de pessoa *identificada* aqueles relativos a informações cadastrais, tais como nome completo, número de registro geral perante institutos de identificação e número de cadastro de pessoa física. Já os dados de pessoa *identificável* correspondem a informações que, quando conjugadas com outras, tornam possível a identificação de alguém, como é o caso de endereços, características físicas, pessoais, profissionais, entre inúmeras outras.

Os *dados pessoais sensíveis*, segundo a literalidade da lei, são os que versam “sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.²⁰ Há hipóteses legais próprias que autorizam o tratamento de tais dados, que, apesar de estarem dispostas em seção própria da lei,²¹ muito se assemelham aos requisitos relativos ao tratamento de dados pessoais em sentido estrito.²² Entende-se que a proteção conferida a esses dados, considerados sensíveis, tem grande importância para evitar práticas discriminatórias em relação a grupos de indivíduos com características semelhantes.

Dado anonimizado, por sua vez, é aquele cujo titular não pode ser identificado em razão de o dado ter sido submetido a um processo técnico de anonimização, em que perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.²³ Eles não serão, portanto, considerados dados pessoais para os fins da LGPD, salvo quando esse processo de anonimização “for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido”.²⁴

A lei tem como fundamentos a livre-iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (fazendo clara remissão ao art. 170 da Constituição Federal), sem desconsiderar a importância da inovação e do desenvolvimento econômico e tecnológico.

Para nortear a possibilidade de tratamento de dados, foram estabelecidos pela legislação de proteção de dados os seguintes princípios: i) finalidade (tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular); ii) adequação (tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento); iii) necessidade (tratamento se limita ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades); iv) livre acesso (ao titular de dados é garantida a consulta facilitada e gratuita sobre a integralidade de seus dados e a forma e duração do tratamento); v) qualidade (garante-se aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados); vi) transparência (titulares dos dados deverão ter fácil acesso a informações claras e precisas sobre a realização do tratamento e seus agentes); vii) segurança (devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais); viii) prevenção (deve-se adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos decorrentes do tratamento de dados); ix) não discriminação (proibido o tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos); e x) responsabilização e prestação de contas (agentes devem demonstrar que adotaram medidas aptas a comprovar o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais).

A lei prevê ainda a criação de categorias de agentes de tratamento de dados, que corresponderão a novas funções que podem ser desempenhadas tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica. Trata-se das figuras do *controlador*, que é aquele a quem compete a tomada de decisões referente ao tratamento de dados, e do *operador*, que será o responsável por realizar o tratamento de dados em nome do controlador e segundo as informações por ele fornecidas.

Em suma, esses profissionais “devem pensar em regras e meios técnicos para proteger os dados pessoais e comprovar sua efetividade nas empresas, seja por aplicação de recursos de anonimização, controle de acesso, procedimentos, políticas de gestão e treinamentos de equipe”.²⁵ Ambos deverão ainda manter registro de suas operações de tratamento de dados e estarão sujeitos à responsabilidade civil se, no exercício de suas atividades, causarem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo a terceiros, em violação às normas de proteção de dados.

Com a vigência da lei haverá também a necessidade de existir um *encarregado* de proteção de dados nas organizações, figura esta que corresponde ao DPO (*Data Protection Officer*) previsto no Regulamento Europeu. Ele será indicado pelo controlador e operador e atuará como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados tratados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – a qual corresponde a órgão da Administração Pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

Ao encarregado será atribuída a função de receber reclamações e comunicações de titulares de dados pessoais e órgãos reguladores, devendo

prestar esclarecimentos e adotar as providências necessárias cabíveis; orientar contratados e treinar funcionários da empresa a respeito de práticas a serem adotadas para proteção de dados pessoais; manter registros de todas as práticas de tratamento de dados pessoais conduzidas pela empresa, contendo informações sobre a sua finalidade (*data mapping*); auxiliar no desenvolvimento de produtos, serviços e práticas por meio da adoção de metodologias como *privacy by design* e *data protection by design*,²⁶ entre outras atribuições que lhe forem estabelecidas.

Em caso de infrações decorrentes do descumprimento das regras impostas aos agentes de tratamento de dados – controlador e operador –, estes estarão sujeitos a penalidades aplicáveis pela autoridade nacional, após procedimento administrativo que garantirá a ampla defesa ao agente e utilizará como parâmetro alguns critérios como a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; boa-fé do infrator; vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; grau do dano; adoção de política de boas práticas e governança; pronta adoção de medidas corretivas; proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, entre outras.

As punições decorrentes de infrações às normas de proteção de dados prevista na lei correspondem a advertência, multa simples e multa diária, publicização da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais em questão, nos seguintes termos:

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:

I) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II) multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III) multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI) eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

VII) (VETADO);

VIII) (VETADO);

IX) (VETADO).

X) suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

XI) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;

XII) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

Destaque-se que as sanções previstas nos incisos X, XI e XII da LGPD haviam sido vetadas do texto original, eis que poderiam gerar insegurança aos responsáveis por essas informações, bem como impossibilitar a utilização e tratamento de bancos de dados essenciais a diversas atividades.²⁷ No entanto, tais vetos foram derrubados e as referidas penalidades foram novamente incluídas pela Lei 13.853/2019.

Reconhece-se que as sanções administrativas de suspensão ou proibição do funcionamento e exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados são rígidas e têm o potencial de afetar gravemente os agentes de tratamento de dados. A proibição dessas atividades, conforme previsto no inciso XII, pode, até mesmo, a depender da situação, impossibilitar o exercício da própria atividade empresarial.

A gravidade dessas punições demonstra a tentativa da lei de “estimular a aplicação de seus dispositivos em caráter preventivo”²⁸ e seu compromisso com a efetividade das normas atinentes à proteção de dados. Isso porque, as penalidades de advertência, multas e publicização de infrações podem, eventualmente, ser consideradas brandas e insuficientes para evitar, por si só, o cometimento de violações às disposições legais relativas à proteção de dados. Já o maior rigor trazido pelas sanções de suspensão ou proibição de atividades relacionadas ao tratamento de dados fortalece o sistema sancionatório, a fim de combater eventual atividade ilícita decorrente do uso indevido de dados pessoais.

3. Análise dos requisitos para tratamento de dados

Importa destacar que, se for respeitada, a Lei Geral de Proteção de Dados terá o potencial de proporcionar grande avanço no modo como os dados pessoais são tratados no cenário brasileiro, tendo em vista que a partir de sua vigência será conferido ao titular dos dados pessoais maior protagonismo em relação à tomada de decisões sobre o tratamento de suas informações. Isso porque, com a nova legislação, o tratamento de dados pessoais estará condicionado ao cumprimento de determinados requisitos, que serão adiante abordados, entre os quais o consentimento é considerado um dos mais importantes.

O art. 7º da LGPD estabelece as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. O primeiro dos requisitos refere-se ao *consentimento* do titular, o qual deve ser livre, informado e inequívoco. Ele precisará ser fornecido ao controlador por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de

vontade do indivíduo, correspondendo a uma finalidade determinada para o tratamento de dados, eis que autorizações genéricas serão consideradas nulas. Ainda, caso eventualmente haja alguma mudança quanto à finalidade do tratamento desses dados que seja incompatível com o consentimento originalmente fornecido pelo titular, este deverá ser previamente informado, podendo revogar o consentimento outrora expressado.

Segundo Ana Frazão, a assimetria entre as partes também é essencial para se aferir se o consentimento se deu, de fato, de forma livre. Nesse sentido, será necessário muito cuidado para se analisar casos envolvendo relações em que uma das partes é presumidamente vulnerável e situações “em que o consentimento é requisito *sine qua non* para o acesso a determinados serviços – o que usualmente se chama de *take-it-or-leave-it choice*”.²⁹

Além disso, entende-se que o consentimento não basta por si só, de modo que precisa estar em consonância com os princípios e garantias constitucionais.

Isso significa, por exemplo, que ainda que haja consentimento do titular do dado pessoal, o seu tratamento não poderá ser realizado caso viole direito seu ou de terceiros.

As outras hipóteses que autorizam o tratamento de dados independem do consentimento do titular referem-se à necessidade de *cumprimento de obrigação legal*, como no caso de provedores de aplicações de internet que precisam manter seus registros de acesso pelo prazo de seis meses, diante de determinação do Marco Civil da Internet (art. 15, Lei 12.965/2014); quando for necessário para realização de *pesquisa*; para *execução de contrato* ou de procedimento preliminar relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados; para *exercício regular de direitos* em processo judicial ou administrativo; para a *Proteção da vida e tutela da saúde*; para a *proteção do crédito*; para atender a *interesses legítimos* do responsável pelo tratamento e para *execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres*.

O Regulamento Europeu de Proteção de Dados, por sua vez, prevê como hipóteses de legalidade o consentimento do titular de dados e casos em que haja necessidade de: execução de contrato no qual o titular de dados seja parte; cumprimento de obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento de dados esteja sujeito; defesa de interesses vitais do titular de dados ou de outra pessoa singular; exercício de funções de interesse público e efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros.

Observa-se, portanto, que as hipóteses legais previstas pela legislação brasileira se assemelham muito às do Regulamento Europeu, apesar de estas serem mais restritas que as da LGPD.

Ao afirmar que os dados pessoais somente podem ser tratados em determinadas hipóteses, presume-se que os dispositivos em questão correspondem a rol taxativo, demonstrando, a princípio, grande preocupação e seriedade com o tratamento do assunto.

No entanto, observa-se uma grande amplitude decorrente de previsões generalizantes que viabilizam o enquadramento de inúmeras situações nas citadas hipóteses da legislação brasileira e do Regulamento Europeu.

É o que acontece, em especial, com previsão da LGPD que confere amplos e discricionários poderes à Administração Pública para realizar o tratamento e uso compartilhado de dados pessoais e sensíveis considerados necessários à execução de *políticas públicas* previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres.

4. Tratamento de dados pelo Poder Público

Ao dispor sobre o tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, a LGPD prevê que seja atendida a sua “finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público” (art. 23, caput, Lei 13.709/2018).

Para isso, estabeleceu algumas condições, tais como: i) observância das hipóteses legais para tratamento de dados e fornecimento de informações claras, em veículos de fácil acesso, sobre tal previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades; e ii) indicação de um encarregado quando da realização de operações de tratamento de dados pessoais.

Na redação original havia ainda condição de proteção e preservação de dados pessoais de requerentes de acesso à informação, no âmbito da Lei nº 12.527/2011, sendo vedado seu compartilhamento na esfera do poder público e com pessoas jurídicas de direito privado. Tal proibição foi vetada pela Lei 13.859/2019, sob a justificativa de que:

A propositura legislativa, ao vedar o compartilhamento de dados pessoais no âmbito do Poder Público e com pessoas jurídicas de direito privado, gera insegurança jurídica, tendo em vista que o compartilhamento de informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, que não deve ser confundido com a quebra do sigilo ou com o acesso público, é medida recorrente e essencial para o regular exercício de diversas atividades e políticas públicas. Sob este prisma, e a título de exemplos, tem-se o caso do banco de dados da Previdência Social e do Cadastro Nacional de Informações Sociais, cujas informações são utilizadas para o reconhecimento do direito de seus beneficiários e alimentados a partir do compartilhamento de diversas bases de dados administrados por outros órgãos públicos, bem como algumas atividades afetas ao poder de polícia administrativa que poderiam ser inviabilizadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.³⁰

É crível que a criação e execução de muitas políticas públicas poderiam ser comprometidas pela falta de informações relevantes pelo Poder Público. No entanto, permitir que haja o compartilhamento de dados pessoais e sensíveis de forma livre e discricionária pela Administração Pública significa retirar a efetividade da legislação de proteção de dados.

Sabe-se que o Estado detém grande poder em relação aos cidadãos e a organizações, com prerrogativas advindas da supremacia do interesse público. Nesse sentido, a LGPD não se aplicará ao Poder Público para tratamento de

dados que envolvam segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, que deverão ser tratados de acordo com legislação específica, a qual deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.³¹

Na mesma linha, critica-se o veto dado ao art. 28 da LGPD, que determinava que se conferisse publicidade à comunicação ou ao uso compartilhado de dados pessoais entre órgãos e entidades de direito público. A razão do veto, no sentido de que o dispositivo poderia *tornar inviável o exercício regular de algumas ações públicas como as de fiscalização, controle e polícia administrativa*,³² também enfrenta dificuldade para se sustentar no contexto de um Estado Democrático de Direito, que tem a publicidade como princípio da Administração Pública (art. 37, caput, CF).

É inequívoco que, com o acelerado desenvolvimento tecnológico que se observa na atualidade, há cada vez mais dispositivos que se propagam pelo espaço urbano, capazes de coletar dados sobre as pessoas, monitorar e vigiar suas atividades e até mesmo manipular seus comportamentos.³³

Não se pode ignorar que muitos desses dados têm o potencial de viabilizar melhoria de serviços públicos, promovendo iniciativas mais assertivas relacionadas à saúde, ao transporte, à segurança pública, entre outros. No entanto, é importante que haja mecanismos que comprovem que o tratamento desses dados é realizado estritamente para as finalidades a que se propõem, atestando-se que não foram cedidos a outras entidades ou órgãos que os utilize para finalidades diversas das que motivaram sua coleta.³⁴

No âmbito *on-line*, caberia também ao Poder Público elaborar políticas de privacidade – para dispor da forma como serão tratadas as informações do cidadão que forem coletadas por meio da internet – como forma de concretizar o princípio da transparência na Administração Pública.

Ainda, tendo em vista que a Administração Pública se submete ao princípio da estrita legalidade, entende-se que, na hipótese de ausência de consentimento, eventual compartilhamento de informações pessoais de interesse público deve ser expressamente autorizado por lei, com base nos critérios da necessidade, proporcionalidade e adequação, de modo a não tornar o direito fundamental à privacidade inócuo.³⁵

Outro ponto importante concerne à execução de contratos. O art. 7º, inciso V, da LGPD prevê como uma das hipóteses autorizadoras do tratamento de dados a necessidade de execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular de dados, a seu pedido.

O Regulamento Europeu, no mesmo sentido, também considera lícito o tratamento de dados quando necessário para execução de contrato no qual o titular dos dados seja parte, ou para diligências pré-contratuais, a pedido do titular (art. 6º, 1, b).

Cabe ressaltar que os contratos são instrumentos essenciais ao trânsito de riquezas e à viabilidade de serviços e negócios, de modo que fazem parte da prática cotidiana. Assim, é imprescindível que a Administração Pública tenha muita prudência e responsabilidade para que, no afã de celebrar contratos, ainda que munidos de objetivos nobres, não pratique violações de direitos do cidadão brasileiro.

5. Considerações Finais

Em um tempo em que dados pessoais passaram a orientar e ditar os rumos da sociedade, transformando-se em um valioso ativo que influencia e determina tomadas de decisões em diferentes setores, torna-se imprescindível avaliar os mecanismos voltados à proteção aos direitos fundamentais de privacidade e de liberdade de seus titulares.

Por meio da análise da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, observa-se a intenção do Brasil de tutelar a proteção de dados pessoais seguindo a tendência mundial e em conformidade com ordenamentos jurídicos de outros países, em especial no que se refere à regulamentação europeia.

Apesar da demora em se promulgar a nova lei – considerando que as discussões sobre o assunto no País iniciaram há quase uma década³⁶ – verifica-se que tal iniciativa representa um relevante avanço, tendo em vista que a legislação pátria que até então versava sobre o assunto era setORIZADA e insuficiente para tutelar as novas demandas contemporâneas, que foram potencializadas pelo desenvolvimento tecnológico.

A nova lei, destinada à tutela de direitos fundamentais de liberdade e privacidade de todos os cidadãos adotou um cunho didático ao trazer definições e conceitos a princípio compreensíveis por toda a sociedade. No entanto, após exame, observa-se que, apesar de ter objetivos honrosos, ela é insuficiente, contraditória e perigosa, pois as hipóteses que autorizam o tratamento de dados sem o consentimento de seus titulares são, em geral, muito amplas e de difícil fiscalização.

A gravidade desse fato se revela em especial pelo poder que a legislação (em seu art. 7º, inciso III) atribuiu ao Estado, cujo poderio é infinitamente superior ao do cidadão comum. Nesse ponto, não se pode deixar de ressaltar que a própria criação dos direitos fundamentais – rememorados inclusive nos arts. 1º e 2º da Lei Geral de Proteção de Dados – tiveram sua gênese justamente para a criação de espaços de respeito ao cidadão frente aos mandos e desmandos do Estado.

Assim, ao permitir que o Estado realize o tratamento de dados sem o consentimento, e até mesmo sem o conhecimento, de seus titulares, sob argumento de que o faz em prol do interesse público, a legislação falha inclusive com os próprios direitos fundamentais de primeira dimensão,³⁷ que são justamente os direitos relacionados à liberdade,³⁸ palavra esta que, paradoxalmente, aparece diversas vezes na nova legislação. Igualmente podem ocorrer violações aos direitos fundamentais de quarta dimensão, os quais estão relacionados à sociedade de informação.

Entre avanços e contradições, verifica-se que a nova legislação acabou por conferir amplos poderes à Administração Pública em relação às possibilidades de tratamento de dados com fundamento na execução de políticas públicas, fato que pode, ao menos em hipótese, permitir arbitrariedades e abusos por parte do próprio Estado. É fundamental, portanto, que o assunto seja enfrentado com responsabilidade pelas instituições públicas e privadas.

6. Referências Bibliográficas

BIONI, Bruno Ricardo; MONTEIRO, Renato Leite. O papel do *Data Protection Officer*. *Jota*. Disponível em: [<https://bit.ly/2EDBoxU>]. Acesso em: 04.03.2019.

BRASIL. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. *A proteção de dados pessoais nas relações de consumo*: para além da informação creditícia. Brasília: SDE/DPDC, 2010. Disponível em: [<https://bit.ly/2tQmZmF>]. Acesso em: 02.03.2019.

BRASIL. Mensagem n. 451, de 14.08.2018. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Presidência da República. Brasília, DF. Disponível em: [<https://bit.ly/2EgQ7ez>]. Acesso em: 04.03.2018.

BRASIL. Mensagem n. 288, de 08.07.2019. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Presidência da República. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-288.htm]. Acesso em: 16.05.2020.

CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil na Era do *Big Data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.) *Tecnologia jurídica e direito digital*: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo; VIOLA, Mario. Risco e informação pessoal: o princípio da finalidade e a proteção de dados no ordenamento brasileiro. *Revista Brasileira Risco e Seguro*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 85-102, out. 2009-mar. 2010.

DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Espaço Jurídico*, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul.-dez. 2011. Disponível em: [[https:// bit.ly/2EGSJzC](https://bit.ly/2EGSJzC)]. Acesso em: 02.03.2019.

FRAZÃO, Ana. Data-driven economy e seus impactos sobre os direitos de personalidade: indo além da privacidade e do controle aos dados pessoais. Disponível em: [[https:// bit.ly/2VI94uM](https://bit.ly/2VI94uM)]. Acesso em: 28.02.2019.

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD*: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. Disponível em: [<https://bit.ly/2SNGGWf>]. Acesso em: 04.03.2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. *Posicionamento sobre a sanção do Projeto de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Disponível em: [https://bit.ly/2C7LGiN]. Acesso em: 04.03.2019.

LEMONS, Ronaldo; ADAMI, Mateus Piva; SUNDFELD, Philippe. *Proteção de dados na Administração Pública: podem dados de mobilidade de indivíduo ser utilizados para fins de segurança pública? É necessária ordem judicial?* Disponível em: [https://bit.ly/2TlEPz]. Acesso em: 04.03.2019.

LEONARDI, Marcel. *Tutela da privacidade na internet*. São Paulo: Saraiva, 2011. MAGRANI, Eduardo. *Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento político-democrático*. Curitiba: Juruá, 2014.

MIRANDA, Jorge. O regime dos direitos sociais. *Revista de Informação Legislativa*. Disponível em: [https://bit.ly/2TryGiY]. Acesso em: 05.03.2019.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito digital*. 5. ed. rev. atual. amp. de acordo com as Leis n. 12.735 e 12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

UNIÃO EUROPEIA. *Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. Disponível em: [https://bit.ly/2tQney5]. Acesso em: 02.03.2019.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.04.2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [https://bit.ly/2Efl4tr]. Acesso em: 02.03.2019.

1

.Advogada. Professora de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Doutora e Mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. luciana@pxadvogados.com.br.

2

Advogada. Professora dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFPR. Coordenadora da Clínica Advocacia Disruptiva. Doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo – USP. Mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná.

3

Advogada. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pós-Graduada em Direito Digital e *Compliance* pelo IBMEC-SP. Membro da Comissão de Inovação e Gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná.

4

As autoras registram seu agradecimento a Daniel Versoza, acadêmico do curso de Direito da UFPR, pelo auxílio na realização de pesquisa para a elaboração do presente artigo.

5

“Diversos autores afirmam que estamos passando por uma era de revolução. As denominações cunhadas ao longo desse processo variam na tentativa de definir esse período inovador: *Revolução Digital*; *Revolução de Entretenimento*; *Era Digital*; *Era da Informação* e *Era da Tecnologia da Informação* são apenas alguns exemplos de expressões criadas por acadêmicos e especialistas” (MAGRANI, Eduardo. *Democracia conectada: a internet como ferramenta de engajamento político-democrático*. Curitiba: Juruá, 2014. p. 57).

6

De acordo com o conceito apresentado por Danilo Doneda, “o *dado* apresenta conotação um pouco mais primitiva e fragmentada, como observamos em um autor que o entende como uma informação em estado potencial, antes de ser transmitida, o dado estaria associado a uma espécie de *pré-informação*, anterior à interpretação e ao processo de elaboração. A informação, por sua vez, alude a algo além da representação contida no dado, chegando ao limiar da cognição. Sem aludir ao seu significado ou conteúdo em si, na informação já se pressupõe uma fase inicial de depuração de seu conteúdo” (DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Espaço Jurídico*, Joaçaba, v. 12, n. 2, jul.-dez. 2011. p. 94. Disponível em: [https://bit.ly/2EGSJzC]. Acesso em: 02.03.2019).

7

DONEDA, Danilo; VIOLA, Mario. Risco e informação pessoal: o princípio da finalidade e a proteção de dados no ordenamento brasileiro. *Revista Brasileira Risco e Seguro*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, out. 2009-mar. 2010. p. 90.

8

FRAZÃO, Ana. Data-driven economy e seus impactos sobre os direitos de personalidade: indo além da privacidade e do controle aos dados pessoais. Disponível em: [https:// bit.ly/2VI94uM]. Acesso em: 28.02.2019.

9

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2016. p. 91.

10

LEONARDI, Marcel. *Tutela da privacidade na internet*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 68.

11

CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil na Era do *Big Data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.) *Tecnologia jurídica e direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 353.

12

“Por meio da agregação de dados isolados e fragmentos de informação aparentemente irrelevantes, é possível montar perfis completos a respeito de um indivíduo, revelando inúmeros aspectos de sua personalidade, sem que se tenham coletado quaisquer informações íntimas de seu exclusivo conhecimento” (LEONARDI, Marcel. *Tutela da privacidade na internet*. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 60).

13

CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil na Era do *Big Data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.) *Tecnologia jurídica e direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 354.

14

“Na União Europeia, a tutela dos dados pessoais tem seu marco fundamental na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que faz referência ao direito fundamental de proteção de dados pessoais: Art. 8º 1. *Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito*” (DONEDA, Danilo; VIOLA, Mario. Risco e informação pessoal: o

princípio da finalidade e a proteção de dados no ordenamento brasileiro. *Revista Brasileira Risco e Seguro*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, out. 2009-mar. 2010. p. 90).

15

BRASIL. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. *A proteção de dados pessoais nas relações de consumo*: para além da informação creditícia. Brasília: SDE/DPDC, 2010. p. 40. Disponível em: [https://bit.ly/2tQmZmF]. Acesso em: 02.03.2019.

16

Regulamento UE 2016/679, aprovado pelo Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia em 27 de abril de 2016, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 (UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: [https://bit.ly/2Efl4tr]. Acesso em: 02.03.2019).

17

Para os efeitos da referida legislação, considera-se banco de dados o “conjunto de dados relativo a pessoa natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro” (Art. 2º, inciso I, Lei 12.414/2011).

18

A Diretiva Europeia 95/46/EC, de 24 de outubro de 1995 – que foi substituída pelo *General Data Protection Regulation* (GDPR) – já trazia conceito semelhante em seu art. 2º, entendendo por dados pessoais: “*shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity*”. Tradução livre: “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável ('titular dos dados'); uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um número de identificação ou a um ou mais fatores específicos de sua identidade física, fisiológica, mental, econômica, cultural ou social” (UNIÃO EUROPEIA. *Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. Disponível em: [https://bit.ly/2tQney5]. Acesso em: 02.03.2019).

19

Para os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoas jurídicas não se enquadram como titulares de dados pessoais, de modo que sua proteção será regida pelos diplomas legais cabíveis a depender da natureza do dano do qual eventualmente seja vítima.

20

Definição contida no art. 5º, inciso II, da Lei 13.709/2018.

21

Art. 11 da LGPD: “O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral (...); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos (...).”

22

Usa-se aqui o termo “dados pessoais em sentido estrito” para se referir aos dados pessoais que não são sensíveis.

23

Nos termos do art. 5º, incisos III e XI, da Lei 13.709/2018.

24

Nos termos do art. 12, *caput*, da Lei 13.709/2018.

25

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Proteção de dados pessoais*: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 43.

26

BIONI, Bruno Ricardo; MONTEIRO, Renato Leite. O papel do *Data Protection Officer*. *Jota*. Disponível em: [<https://bit.ly/2EDBOxU>]. Acesso em: 04.03.2019.

27

BRASIL. Mensagem n. 451, de 14.08.2018. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Presidência da República. Brasília, DF. Disponível em: [<https://bit.ly/2EgQ7ez>]. Acesso em: 04.03.2018.

28

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Proteção de dados pessoais*: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 109.

29

FRAZÃO, Ana. *Nova LGPD*: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. Disponível em: [<https://bit.ly/2SNGGWf>]. Acesso em: 04.03.2019.

30

BRASIL. Mensagem n. 288, de 08.07.2019. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Presidência da República. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-288.htm]. Acesso em: 16.05.2020.

31

Nos termos do art. 4º da Lei 13.709/2018.

32

Sobre o assunto, esclarece Patrícia Peck: “Os principais valores que estão inseridos no Poder de Polícia de um Estado e que têm relação direta com a Segurança Pública Digital são: proteção da ordem pública, da tranquilidade pública, da moralidade pública e da economia popular, tendo como objetivos garantir o bem-estar social, evitar um dano – como regra, o poder de polícia não pretende uma atuação no particular, mas uma abstenção exigindo uma obrigação de *não fazer*, prestando um serviço público –, oferecer comodidade ou utilidade aos cidadãos (utilidade coletiva), vedar um comportamento e evitar uma consequência antissocial. Para que o Poder de Polícia cumpra com sua missão respeitando os direitos civis, deve sempre utilizar meios coativos atendendo ao princípio da proporcionalidade, atuando com cautela. Em hipótese alguma deve se servir de meios mais energéticos que os necessários à obtenção do resultado pretendido pela lei (risco de abuso e responsabilidade administrativa), devendo utilizar o meio coativo somente quando não houver outro meio eficaz para o cumprimento da pretensão jurídica. Por certo há um paradoxo natural entre segurança e privacidade. Por isso, quanto maior a necessidade de proteção de um povo na era digital, maior a necessidade de se poder ter acesso a provas eletrônicas geradas em dispositivos tecnológicos particulares ou de terceiros” (PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito digital*. 5. ed. rev. atual. amp. de acordo com as Leis n. 12.735 e 12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 216).

Como exemplo de manipulação de dados, menciona-se o escândalo envolvendo a empresa britânica de marketing político Cambridge Analytica, que tratou dados pessoais de aproximadamente 50 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento e conhecimento de seus titulares. A finalidade do tratamento foi a de traçar o perfil de eleitores americanos, para influenciar seu comportamento por meio do direcionamento de propagandas eleitorais personalizadas, de acordo com cada perfil, por meio do Facebook. Em março de 2018, os jornais *The Guardian* e *New York Times* revelaram tal fato, o que teria sido determinante para o descrédito da empresa britânica e o término de suas atividades. Da mesma forma, o Facebook foi alvo de muitas críticas e se viu obrigado a revisar suas políticas de privacidade, eis que à época dos fatos permitia a coleta de dados de usuários por aplicativos, com a justificativa de melhorar a experiência do usuário.

LEMOS, Ronaldo; ADAMI, Mateus Piva; SUNDFELD, Philippe. *Proteção de dados na Administração Pública: podem dados de mobilidade de indivíduo ser utilizados para fins de segurança pública? É necessária ordem judicial?*. Disponível em: [<https://bit.ly/2TlkEPz>]. Acesso em: 04.03.2019.

LEMOS, Ronaldo; ADAMI, Mateus Piva; SUNDFELD, Philippe. *Proteção de dados na Administração Pública: podem dados de mobilidade de indivíduo ser utilizados para fins de segurança pública? É necessária ordem judicial?*. Disponível em: [<https://bit.ly/2TlkEPz>]. Acesso em: 04.03.2019.

A primeira consulta pública no Brasil, que versava sobre o tema, ocorreu em 2010. Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), considerado um microssistema de proteção de dados e da privacidade na internet. Em 2015 houve uma segunda consulta pública para discutir uma legislação específica de dados pessoais. Tramitaram, na Câmara e no Senado, alguns projetos de Lei que versavam sobre o assunto: PL 4060/2012; PL 5276/2016 e PLS 330/2013, sendo que o primeiro foi transformado na Lei Ordinária 13.709/2018.

A concepção geracional dos direitos fundamentais – que correspondiam a três ou quatro *gerações* – recebeu melhor tratamento pela doutrina com a nomenclatura *dimensão*, pois “conquanto esta maneira de ver possa ajudar a apreender os diferentes momentos históricos de aparecimento dos direitos, o termo geração, geração de direitos, afigura-se enganador por sugerir uma sucessão de categorias de direitos, umas substituindo-se às outras – quando, pelo contrário, o que se verifica em Estado social de direito é um enriquecimento crescente em resposta às novas exigências das pessoas e das sociedades” (MIRANDA, Jorge. O regime dos direitos sociais. *Revista de Informação Legislativa*. Disponível em: [<https://bit.ly/2TryGiY>]. Acesso em: 05.03.2019).

Os direitos fundamentais de primeira dimensão referem-se aos direitos de liberdade; os de segunda dimensão, aos direitos sociais; os de terceira dimensão, aos direitos ao ambiente, à autodeterminação, aos recursos naturais e ao desenvolvimento; e, ainda, há os considerados direitos de quarta dimensão, que corresponderiam aos direitos relativos à bioética, à engenharia genética, à informática e a outras utilizações das modernas tecnologias, ligados à sociedade de informação e à sociedade de risco (MIRANDA, Jorge. O regime dos direitos sociais. *Revista de Informação Legislativa*. Disponível em: [<https://bit.ly/2TryGiY>]. Acesso em: 05.03.2019).

Capítulo 4. A autoridade parental e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes

Ana Carolina Brochado Teixeira¹

Anna Cristina de Carvalho Rettore²

1. Introdução

Ao mesmo tempo em que o avanço da tecnologia nos traz uma série de facilidades, ele acarreta o surgimento ou a intensificação de algumas dificuldades. Se outrora os dados pessoais – os que se relacionam com uma pessoa identificada ou, pelo menos, identificável – eram disponibilizados principalmente pelo preenchimento de cadastros pelo titular, tem se tornado possível uma construção de perfis pessoais que vai muito além, pois envolve o conhecimento sobre as características e preferências individuais em diversos níveis, a partir da vigilância sobre o comportamento e as escolhas de cada pessoa no ambiente virtual no qual estamos todos cada vez mais presentes.

Nesse contexto, é relevante notar a formação de um revolucionário modelo de negócios no qual, ao invés do oferecimento de um produto ou serviço por uma contrapartida financeira, “os dados pessoais são a moeda de troca pelo bem de consumo”,³ de forma tal que o uso de programas e aplicativos na internet é muitas vezes gratuito exatamente porque são os próprios dados do usuário a *mercadoria* objeto do interesse financeiro do fornecedor.

Assim, a proteção dos dados pessoais é certamente um dos mais sensíveis desafios que o direito contemporâneo enfrenta em decorrência do extraordinário avanço tecnológico verificado nas últimas décadas. No Brasil, a proteção de dados pessoais encontra seu fundamento normativo na Constituição da República, que proclama no inciso X do artigo 5º a inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

Doutrina e jurisprudência reconhecem que o direito à privacidade abrange, hoje, não apenas a proteção à vida íntima do indivíduo, mas também a proteção de seus dados pessoais, pois esses representam uma relevante projeção da personalidade do indivíduo. A doutrina leciona que

[...] na sociedade atual, caracterizada pelas relações remotas, os dados pessoais acabam por se constituir na única forma de representação das pessoas perante as mais diversas organizações estatais e privadas, sendo determinantes para abrir ou fechar as portas de oportunidades e acessos.⁴

Dessa forma, “considerando que se caminha cada vez mais e com maior intensidade para uma sociedade governada por dados”⁵ e que “a proteção de

dados pode ser vista como a soma de um conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo milênio”,⁶ a proteção deve alcançar, pois, qualquer ambiente onde circulem dados do seu titular, e deve envolver – como ocorre com os demais direitos da personalidade – tanto a tutela negativa do direito (direito de ação perante quem o ofenda a fim de que cesse a violação) quanto sua tutela positiva, para que seja garantida ao titular a possibilidade de controle sobre o uso de seus dados.

A tutela positiva das situações jurídicas existenciais permite que a autonomia privada possa ser também instrumento de regulação de interesses existenciais, a fim de garantir o livre desenvolvimento do seu titular. É chamada positiva porque realizada mediante a autodeterminação do titular, muitas vezes, com colaboração de outrem; enquanto que a tutela negativa diz respeito a comportamentos omissivos gerais [...].⁷

Por serem muitos os fornecedores na internet, muitos também são os termos de uso e políticas de privacidade apresentados por cada um deles, tornando impossível ao ser humano memorizar todos os atores envolvidos e a forma individual de tratamento de dados, já que nossas habilidades cognitivas são limitadas.⁸

A isso se soma o problema da tendência humana de focar nos benefícios imediatos em detrimento de prejuízos mediatos – optando por acessar um produto ou serviço *on-line* sem “sopesar os possíveis prejuízos à privacidade, que são temporariamente distantes, [pois] os possíveis danos em relação à perda do controle sobre as informações pessoais só podem ser experimentados no futuro”⁹ – bem como a dependência do usuário que passa a ter perante si apenas as opções de fornecer seus dados ou deixar de acessar o bem de consumo, já que somente poderão manter o controle sobre os dados pessoais os cidadãos eremitas que aceitem o custo social dessa falta de acesso numa sociedade da informação.¹⁰

Daí ser possível falar na existência de uma relação de assimetria de poder entre o usuário de produtos e serviços da internet em relação aos fornecedores desses bens de consumo, como resultado do imenso volume de informações com relação ao qual se presume que o indivíduo teria condições de compreender e avaliar quando, na verdade, a complexidade do fluxo de informações pessoais inviabiliza um processo genuíno de tomada de decisão em prol de seu controle.¹¹ É, por isso, reconhecida a existência de uma *vulnerabilidade* do titular de dados pessoais em meio ao mercado informacional, vulnerabilidade essa que demanda uma resposta normativa apropriada.

Conquanto já exista essa questão objetiva em relação à vulnerabilidade do usuário em geral, em vista da amplitude do alcance da internet sobre todos os cidadãos

[...] emerge uma preocupação ainda maior em relação às crianças e adolescentes, reconhecida sua hipervulnerabilidade, decorrente de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.¹²

É por isso exigida especial atenção dos pais, detentores do dever de cuidado e responsáveis pela assistência, criação e educação dos filhos, especialmente no

momento atual, no qual se identifica o aumento do acesso pela população nessa faixa etária à internet.

Em sua sexta edição, a pesquisa TIC Kids Online Brasil aponta uma tendência de crescimento no número de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que são usuárias de Internet no país, sendo que o telefone celular se consolidou como o dispositivo mais utilizado para o acesso à rede [...]. Dado esse contexto, além de investigar o uso da rede pelas crianças e adolescentes e as habilidades que eles têm desenvolvido para esse uso, também é imprescindível levantar informações acerca da mediação feita por pais, responsáveis e educadores. Esse aspecto é fundamental, tendo em vista o papel que tais atores desempenham na mitigação dos riscos e na potencialização das oportunidades que as crianças e adolescentes podem experimentar online.¹³

A pesquisa aponta que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos utiliza internet,¹⁴ de modo a não deixar dúvidas sobre a necessidade e urgência de que haja uma tutela efetiva para essa camada da população. Além disso, identificou-se que uma grande maioria de crianças e adolescentes (71%) acessa a internet mais de uma vez por dia, sendo que outros 17% acessam pelo menos uma vez ao dia – enquanto apenas 12% acessa a rede com frequência de uma vez por semana ou menos.¹⁵ No entanto, apenas 49% dos entrevistados relataram que seus pais teriam “muito conhecimento” sobre suas atividades *online* – percentual esse que varia entre faixas etárias, por ser de mais de 60% entre crianças de 9 a 12 anos, mas de apenas 36% para adolescentes entre 15 e 17 anos.¹⁶

Ademais, é também corroborado por estudos que 83% dos jovens que cursam entre o quinto ano do Ensino Fundamental e o segundo ano do Ensino Médio no Brasil acessam redes sociais¹⁷ – onde muitos dados pessoais podem ser captados – sendo que 82% utilizam o Whatsapp (que compartilha metadados com o Facebook),¹⁸ 79% o Facebook, 55% o Instagram e 27% o Twitter.¹⁹

Diante da peculiaridade do estágio de desenvolvimento dessa camada da população, e da sua condição de vulnerável na rede, tal como apontado, é importante que seus interesses sejam resguardados pelo Estado, pela sociedade e pela família – em atenção à proteção integral que lhes é constitucionalmente garantida. Conquanto essa proteção já imponha força normativa própria para o atendimento a seus melhores interesses, em se tratando de uma realidade nova e bastante específica do mundo tecnológico, a existência de regras mais específicas e direcionadas sobre o tema se apresenta ainda mais relevante.

O surgimento de normas voltadas à proteção da privacidade dos usuários de internet no Brasil teve início com a Lei 12.965 de 2014 (Marco Civil da Internet), a qual de pronto estabeleceu como princípios para o uso da internet no país a proteção à privacidade e aos dados pessoais – art. 3º, II e III – bem como determinou regras para a coleta dos dados, entre elas a exigência do consentimento do titular para o uso e tratamento das informações – art. 7º, VII a X, entre outros. Foi feita breve referência às crianças e adolescentes no art. 29 da Lei, prevendo responsabilidade conjunta do Poder Público, sociedade civil, provedores de conexão e de aplicações de internet por promover a educação e a inclusão digital desse público por meio de boas práticas, mediante controle parental.

Em 2018, por sua vez, foi publicada a Lei 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), mais diretamente detalhada sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais, aí se incluindo, pela primeira vez, dispositivos de aplicação específica a crianças e adolescentes (art. 14, *caput* e §§ 1º a 6º). Por ora, trata-se de lei ainda no período de *vacatio legis*.

Por meio do presente estudo, pretende-se empreender uma investigação acerca desses dispositivos destinados à regulamentação do tratamento de dados de crianças e adolescentes, a fim de verificar sua adequação tanto à realidade vivenciada no Brasil quanto ao ordenamento jurídico brasileiro como um todo, para assim tecer considerações sobre o efetivo grau de proteção conferida à privacidade e a essa importante projeção da personalidade das crianças e dos jovens brasileiros.

Para tanto, faz-se inicialmente uma análise acerca de quais seriam os contornos do princípio do melhor interesse diante da nova realidade de vivência da criança e do adolescente em uma sociedade tecnológica, para, em seguida, realizar um estudo acerca do conteúdo da própria autoridade parental nesse contexto, uma vez que compete aos pais adaptarem-se ao novo modo como o mundo da vida se apresenta. Por fim, passa-se ao exame do tratamento dispensado a crianças e adolescentes pela Lei Geral de Proteção de Dados, e do art. 14 da Lei 13.709/2018 como um todo, decerto que sem pretensão de esgotamento do tema, mas tecendo-se observações que já se mostram possíveis ainda que antes da vigência da lei.

2.O conteúdo do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente na sociedade de informação

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente ganhou lugar de destaque no âmbito de um direito de família personalista, ao atribuir prioridade à criança e ao adolescente para a maior amplitude possível do exercício de direitos fundamentais (art. 227 do Texto Constitucional). Por essa razão, esse princípio passou a ser o vértice interpretativo do ordenamento, nessa seara.

Segundo a doutrina, “a aplicação do princípio do *best interest* permanece como um padrão considerando, sobretudo, as necessidades da criança em detrimento dos interesses de seus pais, devendo realizar-se sempre uma análise do caso concreto”.²⁰ Não existe uma uniformidade ou uma definição rígida do que seja tal princípio, cujo exame deve ser feito em cada caso. Maria Clara Sottomayor afirma que, embora o interesse da criança ou do adolescente seja um conceito indeterminável pelo seu caráter vago e elástico, facilitando interpretações subjetivas, tem um núcleo conceitual que deve ser preenchido por valorações objetivas. Essas se atrelam à estabilidade de condições de vida da criança, das suas relações afetivas e do seu ambiente físico e social.²¹

Esse princípio foi consagrado no 7º Princípio da Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, e prevê que “os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade

cabe, em primeiro lugar, aos pais”. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, declarou, no art. 3º, 1, que

Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.

O princípio do melhor interesse da criança é corolário da doutrina da proteção integral, inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Tal doutrina prega que a criança e o adolescente, bem como seus direitos, devem ser protegidos de forma especial, além de garantir-lhes as mesmas prerrogativas que cabem aos adultos. O dever de proteção não se limita ao Estado, mas estende-se à sociedade e à família, conforme determina o art. 227 do Texto Constitucional. Sua condição prioritária deve-se ao fato de serem pessoas em desenvolvimento, cuja personalidade deve ser protegida e promovida, mediante o exercício dos direitos fundamentais.

As mudanças de hábito provocadas pela internet geraram a necessidade da criação de novas perspectivas de proteção no ambiente virtual. As atuais relações estabelecidas *on-line*,²² por meio de redes sociais, novos métodos de aprendizagem, motivaram um repensar sobre a tutela integral do público infanto-juvenil nesse novo universo que se descortina.²³ Especificamente sobre a séria implicação do tratamento de dados, por exemplo, pode-se identificar a possibilidade de se extrair padrões de comportamento a partir do estudo sobre os dados de uma enorme quantidade de pessoas (“*Big Data*”) – possibilidade essa que, *a priori*, não exclui crianças e adolescentes, tornando-as induzíveis e manipuláveis a partir da observação de seus cliques e acessos virtuais.

Afinal, esses padrões tornam possível até mesmo a inferência de um provável acontecimento:

“Um dos exemplos mais citados para ilustrar *Big Data* é o da ação por parte da varejista americana Target para identificar consumidoras grávidas. A gravidez é uma fase da vida na qual tais consumidoras consomem uma infinidade de produtos, sendo, por isso, tal informação estratégica. A equipe de análise da Target conseguiu verificar que tal perfil de consumidoras adquiria uma determinada lista de produtos. Isso permitiu não só prever o estado de gravidez, mas, também, o período de gestação para, daí, lhes direcionar produtos de acordo com a respectiva fase da gravidez. Dessa forma, os algoritmos dos bancos de dados foram programados para estabelecer tal correlação, segmentando, entre os milhares de consumidoras, aquelas com tal perfil para fins de ação publicitária. A eficiência da tecnologia em questão foi comprovada quando um pai furioso entrou no estabelecimento comercial de tal empresa, acusando-a de incentivar a sua filha adolescente a engravidar. Passados alguns dias, o gerente da loja, preocupado em perder o cliente, ligou para o furioso pai. Esse último, acanhado do outro lado da linha, informou que tinha tomado conhecimento de fatos até então ignorados: a sua filha estava grávida, desculpando-se pelo ocorrido. [...] Chegou-se ao ponto de o *Big Data* prever até mesmo crises financeiras. E, ainda, da rede social mais popular do mundo ser capaz de prever quando haverá o rompimento de ‘um relacionamento sério’, com base nos *posts* dos seus usuários. Cada vez mais, os dados dos cidadãos, dispersos na rede, dizem mais sobre eles e quem os manipula sabe até mais sobre eles mesmos [...], [o que representa] uma verdadeira ‘mina de ouro’ para a abordagem publicitária.”²⁴

Outro exemplo digno de nota decorre da observação de que muitos aplicativos infantis, ainda em 2017, apresentavam anúncios diversos independentemente da

idade²⁵ – ainda que existam estudos que indiquem que apenas a partir dos 12 anos de idade as crianças começam a desenvolver defesas cognitivas que as permitam compreender as intenções dos anunciantes, isto é, a sua intenção de persuadir por meio do anúncio,²⁶ e a despeito da existência da Resolução 163/2014 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que determina ser considerado abusivo o direcionamento de publicidade à criança com intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço.

Bastante populares em aplicativos gratuitos, os anúncios aparecem de diversas formas: dos velhos clássicos *banners* nos cantos da tela até, e principalmente, os vídeos. Sobre vídeos, aliás, além de aparecerem com frequência entre ‘rodadas’ de atividades nos apps, é digna de nota a prática de utilização de vídeos promocionais como moeda de troca. Em *Once Upon a Tower*, *Perguntados*, *Pou*, *Meu Talking Tom* e *Sweet Baby Girl Doll House – Play, Care & Bed Time*, o usuário ganha funcionalidades restritas, algumas pagas, após assistir aos anúncios.²⁷

Também não se pode deixar de observar a evolução dos brinquedos e jogos, cada vez mais conectados à internet. Em dezembro de 2016, na Noruega, constatou-se que empresas reivindicaram licenças amplas para o uso de *dados de voz de crianças*, captados por meio de brinquedos interativos, sem especificação da finalidade ou comunicação aos usuários sobre potenciais alterações nos termos de uso, e, ainda, com a previsão da possibilidade de transferência desses dados para terceiros, cujas políticas de privacidade poderiam ser distintas.²⁸

A Lei Geral de Proteção de Dados, em seção dedicada especificamente à proteção de dados do público infanto-juvenil, prevê que o tratamento de dados pessoais dos menores de 18 anos deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos do art. 14 e da legislação pertinente. Essa previsão provoca a necessidade de se revisitar o conteúdo desse princípio, sob o contexto do universo digital. A rigor, preservar o melhor interesse desse grupo, que é protegido na fase de maturação e desenvolvimento, é agir de modo a lhes potencializar o exercício de seus direitos fundamentais. A previsão legal de que a salvaguarda dos dados da criança e do adolescente deve ser feita em seu melhor interesse indica que o resguardo das informações relevantes dos menores deve ser sempre em prol do seu desenvolvimento e em atenção aos seus direitos fundamentais.²⁹

Destaca-se aqui, principalmente, o direito à privacidade, entendido como a possibilidade – atual e futura – de ter o controle das próprias informações.³⁰ Entende-se que a privacidade integra o direito ao respeito, previsto expressamente no art. 227 do Texto Constitucional e no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que esse direito “consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

A proteção dos dados dos menores implica evitar que eles sejam mapeados e tenham suas preferências e escolhas pregressas utilizadas e manipuladas, preservando, dessa forma, sua liberdade na construção da própria identidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Todavia, o funcionamento geral da rede ocorre exatamente em sentido contrário, como adverte a doutrina:

A combinação de diversas técnicas automatizadas permitiu a coleta, o registro, o processamento, o cruzamento, a organização e a transmissão de dados, de uma forma anteriormente inimaginável, possibilitando a obtenção de informações valiosas sobre os cidadãos e auxiliando a tomada de decisões econômicas, políticas e sociais. O valor das informações obtidas não reside apenas na capacidade de armazenamento de grande volume de dados, mas, principalmente, na possibilidade de obtenção de novos elementos informativos a respeito dos cidadãos a partir do tratamento desses dados.³¹

Diante desse cenário, pergunta-se se o desenvolvimento das tecnologias da rede leva em consideração as especificidades do público infanto-juvenil, considerando-se o desenvolvimento cerebral e a fase de formação da personalidade em que se encontram. Tudo indica que a vulnerabilidade e a suscetibilidade dos menores não são um dado levado em conta de forma prioritária, por isso é necessário garantir-lhes que o acesso à internet não esteja vinculado a um método violador de sua privacidade.

Além disso, atender ao princípio do melhor interesse significa evitar que os dados das crianças e adolescentes acabem por funcionar como um meio de classificação dos futuros adultos pelas suas preferências e modos de vida, aprofundando uma postura discriminatória que dificulte ainda mais uma igualdade de oportunidades segundo as competências, habilidades reais e condições pessoais, seja para a contratação de um plano de saúde ou para buscar um emprego, por exemplo. Suas memórias digitais devem ser preservadas, para que não se transformem em condicionantes da vida adulta, comandadas pelo mercado.

Em virtude dessa fase dinâmica de desenvolvimento em que crianças e adolescentes se encontram, seus rastros digitais provavelmente não serão sempre os mesmos; os interesses podem mudar – mais rapidamente que os dos adultos – pois estão numa época de curiosidade, de aprendizado, de experimentar novas experiências, gostos e possibilidades. Por isso, os vestígios digitais pretéritos podem não refletir o perfil contemporâneo da criança e adolescente, inserindo-os em “catálogos de classificações” que não necessariamente reproduzirão seus dados futuros.

O desafio é grande, principalmente porque as crianças e os adolescentes atuais são a primeira geração cujos dados estão armazenados desde o nascimento, razão pela qual o cuidado tem que ser maior, em face da própria novidade do tema. O risco de manipulação e classificação desses menores deve ser combatido para que, no exercício de seu direito à privacidade, eles possam ser livres para escolher serem eles mesmos, consumir o que bem entenderem e trilhar suas trajetórias livremente.

Para que isso ocorra, é parte essencial desse debate mapear a atuação dos pais em face do consentimento que a Lei Geral de Proteção de Dados exige seja expresso de crianças, deixando de exigir para adolescentes. Ao gerenciar os dados pessoais e ao mediar a atuação dos filhos menores na internet, os pais estão agindo no exercício da autoridade parental?

3.O conteúdo da autoridade parental e dos dados pessoais da criança e do adolescente

No âmbito da família, além de se valorizar a pessoa humana, relevou-se, também, a coexistência. Por isso, a autoridade parental, antes preponderantemente hierárquica e patriarcal, transmuta-se para uma perspectiva dialogal, perpassada pela compreensão mútua e pelo diálogo, uma vez que a criança e o adolescente – valorizados que foram como ícones da família, em face da vulnerabilidade e por estarem em desenvolvimento – também se tornaram sujeitos ativos no âmbito da própria educação.³²

Além do princípio da dignidade humana, ganha relevância, também, o princípio da solidariedade, como fonte de deveres entre alguns familiares, a fim de potencializar a proteção e promoção de grupos vulneráveis. Isso porque da autoridade parental emanam deveres dos pais, devendo ser exercida exclusivamente em prol do interesse dos filhos e com a finalidade de promover seu desenvolvimento como pessoa, razão pela qual se caracteriza como poder jurídico. A liberdade – realizada no Direito por meio do princípio da autonomia – deve ser cotejada com a corresponsabilidade entre os membros da família, principalmente em relação àqueles que têm algum tipo de vulnerabilidade, tal como pessoa com deficiência, criança, adolescente,³³ idoso, entre outros. Para esses grupos, os deveres são relevantes, pois é a sua efetividade que garantirá a dignidade e a minoração da sua condição de vulnerabilidade.

Justifica-se uma proteção diferenciada para a criança e o adolescente em razão de sua presumida vulnerabilidade e por ainda não apresentarem amadurecimento cerebral completo,³⁴ razão pela qual podem não saber dimensionar riscos e efeitos do tratamento de dados – ou podem ter ainda menos condições de saber, se comparados com os adultos.³⁵ Por esse motivo, é muito importante que o exercício da autoridade parental seja funcionalizado ao princípio do melhor interesse das pessoas menores de idade.

O poder familiar pressupõe a condução do processo educacional dos filhos, a fim de guiá-los para uma vida autônoma e responsável. Trata-se de uma intervenção gradativa, em que os próprios filhos, na medida em que crescem e se desenvolvem, vão fazendo escolhas relativas à própria vida. Juridicamente, o art. 1.634, VII, do Código Civil determina que cabe aos pais a representação até 16 anos e assistência, entre 16 e 18 anos.³⁶ No entanto, há uma dificuldade funcional com a representação e assistência na prática de situações existenciais, em razão da sua própria natureza, em virtude da cisão entre titularidade e exercício por outrem.³⁷ Esses dois atributos deveriam estar sempre concentrados numa mesma pessoa, pois, em relação aos direitos da personalidade do menor, o exercício não pode ser transferido para terceiros, por estarem intimamente ligados à personalidade e a escolhas que reflitam a própria concepção de vida,³⁸ já que uma das formas de concretização da dignidade é por meio da liberdade.

Por essa razão, uma educação que se verte para potencializar a tomada de decisões com autonomia responsável é a que se espera dos pais ou responsáveis legais. No entanto, existem situações em que se faz necessária deliberação, principalmente porque se trata de relevante problema teórico, que, muitas vezes, não dialoga com o *mundo da vida*. Ao refletir sobre o tema, Thais Sêco propõe critério interessante:

Com atenção às dificuldades para se reconhecer a autonomia da criança e do adolescente em face da dúvida sobre o seu discernimento, e tendo em vista a percepção dinâmica de que se trata, de qualquer forma, de um indivíduo em desenvolvimento que tende para a plena autonomia, propõe-se a valoração das decisões existenciais com base nos critérios da reversibilidade ou irreversibilidade, e da adiabilidade ou inadiabilidade.³⁹

Se a decisão for inadiável e irreversível, está-se diante daquelas hipóteses desafiadoras, que colocam em xeque a dogmática dos direitos da personalidade.

Nesse parâmetro, está-se diante de um fato: crianças e adolescentes utilizam a internet e seus dados são coletados durante todo o tempo. O que a lei faz é regulamentar, na tentativa de propor uma forma de tutela eficiente à população infanto-juvenil. Cumpre verificar como a situação em estudo se enquadra na proposta da autora: (i) se fosse adiável, os menores deveriam aguardar até completar 18 anos para ter acesso à rede, o que não corresponde à realidade, tampouco atende ao seu melhor interesse, havendo proposta de emenda constitucional (PEC 8/2020⁴⁰) para incluir a internet como direito fundamental em razão da necessidade de inclusão digital – logo, trata-se de situação inadiável; (ii) também parece ser irreversível, já que, mesmo se os dados eventualmente forem anonimizados (isto é, se forem desvinculados da identificação *direta* do titular, extraindo-se a correlação do dado, por exemplo, com o nome completo ou a localização geográfica), “sempre existirá a possibilidade de uma base de dados anonimizada ser agregada a outra para a sua reidentificação”.⁴¹

Sendo inadiável e, ao que tudo indica, também irreversível, chega-se à conclusão de que o exercício desse direito da personalidade deve ser viabilizado aos titulares crianças e adolescentes para que, desde logo, o exerçam, ainda que sempre mediante observação e participação dos pais, os quais devem atuar como elementos de mediação entre seus filhos e a internet.

Em 2017, 77% das crianças e adolescentes usuários de internet tinham pais ou responsáveis que também faziam uso da rede, número esse que tem se ampliado desde 2014, quando a proporção era de apenas 50%,⁴² tornando-se perceptível que, com o passar dos anos, tem se tornado mais viável a participação parental na vida dos filhos na internet. Por outro lado, estatísticas demonstram que 70% das crianças e adolescentes julgam entender mais de internet do que os próprios pais.⁴³ Portanto, cabe refletir sobre o modo pelo qual os pais vão dirigir a educação digital de seus filhos, que compreendem mais sobre o conteúdo do que se está sendo transmitido do que eles próprios, além de como eles operacionalizarão o dever de fiscalização dos filhos, até para saber com o que vão e com o que não vão consentir no ambiente virtual.

A pesquisa também buscou identificar as estratégias de mediação que vêm sendo adotadas:⁴⁴

MEDIAÇÃO ATIVA DO USO DA INTERNET	Estratégia em que pais ou responsáveis conversam com seus filhos ou tutelados sobre conteúdos presentes na rede e realizam atividades em conjunto online.
MEDIAÇÃO DO USO	Estratégia em que pais ou responsáveis promovem ou

SEGURO DA INTERNET	incentivam o uso seguro e responsável da internet por seus filhos ou tutelados.
MEDIAÇÃO RESTRITIVA	Estratégia em que pais ou responsáveis determinam regras que limitam ou regulam o tempo e local de uso da internet, bem como a realização de atividades online.
RESTRICÇÕES TÉCNICAS	Estratégia em que pais e responsáveis utilizam software ou ferramentas técnicas para filtrar e restringir atividades online de seus filhos ou tutelados.
MONITORAMENTO DE ATIVIDADES	Estratégia em que pais e responsáveis monitoram ou checam o registro de atividades on-line de seus filhos.

Acerca do monitoramento de atividades realizadas na internet, 58% dos usuários de 9 a 17 anos declararam que os pais olham os seus celulares para ver o que estão fazendo ou com quem estão falando, 66% declararam que eles sentam junto enquanto usam a internet, mas sem participar do que estão fazendo, e 67% mencionaram que seus pais ou responsáveis ficam por perto enquanto usam a internet, mas sem olhar o que estão fazendo.⁴⁵

Ainda, segundo a pesquisa, as estratégias de mediação ativa foram as mais frequentemente adotadas por seus pais ou responsáveis. Já as ações de mediação restritiva e o monitoramento de atividades foram realizados em menores proporções, mas vêm sendo cada vez mais adotados, uma vez que o acesso principal à internet tem cada vez mais sido por meio do celular, que pode ser recolhido pelos genitores após determinado tempo de uso. Todavia, é importante observar, nesse último caso, que

[...] medidas restritivas podem gerar impactos sobre o desenvolvimento de habilidades para a gestão de risco, fazendo com que crianças e adolescentes fiquem mais vulneráveis aos danos envolvendo o uso da rede.⁴⁶

No âmbito do dever de fiscalização e educação que compõem o conteúdo da autoridade parental,⁴⁷ não obstante a necessidade de atuar em nome da criança e a dispensa de atuação com relação ao adolescente,⁴⁸ no mundo jurídico, não há dúvida de que a educação deve ser emancipatória, não apenas para que os filhos menores possam viver esse momento tão especial de suas vidas – já que eles não são apenas um “vir a ser”, mas são valorizados e protegidos pelo que são no “aqui e agora” –, como também para resguardar o seu desenvolvimento e prepará-los para a vida adulta, por meio do processo educacional.⁴⁹ Assim, os pais devem desde logo problematizar com as crianças a razão para a exigência de sua interferência naqueles momentos, enquanto com os adolescentes, a despeito da ausência de exigência formal da atuação parental no consentimento, torna-se importante que conscientizem os filhos de participá-los nessa tomada de decisão, buscando auxílio e aconselhamento.

Talvez esse seja o maior desafio para a efetiva participação dos pais na vida digital de seus filhos. Conhecer o objeto específico e as consequências de sua permissão, construindo esse conhecimento em conjunto, para que o filho atue,

jogue, explore determinado lugar na rede, sabendo os reais rastros virtuais que seu consentimento poderá deixar.

4.O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes

A Lei Geral de Proteção de Dados trata diferentemente crianças (pessoas até 12 anos de idade incompletos, art. 2º do ECA) em relação aos adolescentes (pessoas entre 12 e 18 anos de idade). Observa-se que, embora o *caput* do art. 14 determine que o tratamento de dados de ambos deverá atender ao seu melhor interesse, o § 1º da LGPD dita que apenas no caso de crianças se demandará “o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”.

Dessa perspectiva, portanto, os adolescentes são considerados da mesma forma que os adultos, de modo que o consentimento exigido para tratar seus dados pessoais é tão somente o deles mesmos, uma “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (art. 5º, XII, da LGPD).

Como ensina a doutrina, existe diferença entre a implicação dos conceitos de consentimento “específico” (tal como previsto que deve ser o dos pais ou responsável para o tratamento de dados de crianças) e de consentimento “inequívoco” (previsto para o caso dos demais, incluindo os adolescentes). O consentimento *específico* demanda que o titular de dados pessoais indique assertivamente a sua vontade quanto ao trânsito de seus dados, assim garantindo

[...] a carga máxima de participação do cidadão dentro da dinâmica da proteção dos dados pessoais baseada na acepção de que ele deveria seguir seus dados em todos os seus movimentos. Essa adjetivação potencializa ao extremo a concepção da autodeterminação informacional, diferenciando-se, qualitativamente, do qualificador ‘inequívoco’ e da locução ‘para finalidade determinadas’, na medida em que se afasta de qualquer tipo de autorização passiva, tácita ou implícita por parte do titular dos dados pessoais.⁵⁰

Assim, como exposto, no caso da expressão “consentimento específico”, usada pela Lei ao remeter àquele exigido para o tratamento de dados pessoais das pessoas em geral, incluindo-se adolescentes, não se impõe que tenha havido necessariamente uma ação afirmativa por parte do titular do dado, podendo o consentimento ser extraído do contexto de uma relação, admitindo-se que seja tácito e subentendido.⁵¹

É de se questionar se a inexistência de uma transição mais branda de fato atenderia o melhor interesse dos adolescentes, que naturalmente já operam com mais liberdade e têm mais acesso à internet que as crianças. Afinal, se a adolescência é uma fase em que a pessoa adquire, gradualmente, a potencialidade para tomar decisões sobre si mesmo, mediante mediação e acompanhamento dos pais, e especialmente se considerada a dificuldade geral de compreensão sobre o possível alcance e resultados do tratamento de dados, não parece correto que, para autorizar o uso de uma projeção tão expressiva da personalidade como são os dados pessoais, os adolescentes devam poder fazê-lo

desde sempre e prescindindo de qualquer acompanhamento – ou, ainda pior, que se admita o consentimento tácito.

Por outro lado, fica também usurpado dos pais o poder-dever que eles detêm de participar da maturação filial para a tomada de importantes decisões em suas vidas, deixando de fazê-lo apenas gradativamente e segundo a evolução dos próprios filhos. A LGPD, em tanto inspirada na legislação europeia, teria andado melhor se exigisse o consentimento dos pais até os 16 anos:

Se, por um lado, a idade de 12 anos pode parecer muito baixa, desprotegendo jovens de 13 e 14 anos, talvez, por outro lado, seja irreal pensar que a coleta de dados de adolescentes de 17 anos se submeta ao consentimento dos pais. Daí a eleição pela norma europeia de um marco de 16 anos – exemplo que poderia ter sido seguido pelo legislador brasileiro.⁵²

Outrossim, convém perquirir se essa previsão não entra em confronto com a restrição normativa que estabelece incapacidade absoluta e relativa de adolescentes para o exercício pessoal de atos da vida civil, que resulta na exigência de representação e assistência pelos pais pelos arts. 3º e 4º do Código Civil brasileiro. Não se desconhece que diversos atos corriqueiros na vida civil de adolescentes são encarados como um “comportamento socialmente típico”, prestando-lhes eficácia mesmo que sejam atos nulos, pois celebrados por incapazes. Todavia, tais atos – como pequenos contratos de transporte ou de compra e venda – são assim vistos porque, em geral, são simples e necessários ao livre trâmite social, adquirindo por isso legitimidade aos olhos da sociedade.⁵³

No entanto, dada a relevância que o consentimento para uso de dados possui para a vida de uma pessoa, e por não se tratar de uma manifestação de vontade simples ou tão corriqueira, não é necessariamente certo que se deva admitir que a prestação de consentimento entre 12 e 18 anos de idade receba eficácia prescindindo totalmente da participação parental, sendo necessário repensar os termos da legislação nessa seara.

Outras regulamentações específicas, decorrentes do consentimento previsto pelo mencionado § 1º, são vertidas apenas às crianças pelos demais parágrafos do art. 14. O tipo de dado coletado, a forma de sua utilização e os procedimentos para exercício dos direitos previstos pelo art. 18 (por exemplo, para exigir a eliminação de dados) são informações que devem ser mantidas públicas (§ 2º) e devem ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, para serem compreendidas pelos pais – e explicadas em linguagem acessível, pois “consentimento é muito mais do que um clique”⁵⁴ – e adequadas ao entendimento das próprias crianças – “consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado” (§ 6º), já que ainda se encontram em um “processo contínuo e inconcluso do desenvolvimento de suas capacidades, inclusive da compreensão de conceitos abstratos, técnicos ou jurídicos”.⁵⁵

As únicas exceções previstas para a exigência do consentimento parental se dão no caso de necessidade de coleta “para contatar os pais ou o responsável” ou “para sua proteção”, devendo o dado ser utilizado apenas uma vez, sem armazenamento e não repassado a terceiro (§ 3º) – merecendo censura, todavia, a

adoção de expressão genérica de finalidade de “proteção”, tornando possíveis interpretações amplas pelos controladores dos dados.

Prevê-se, ainda, que a participação de crianças em jogos e aplicativos não pode ser condicionada ao fornecimento de informações que não sejam estritamente necessárias à atividade (§ 4º), pois, do contrário, consentir com o fornecimento de dados seria condição para o acesso de crianças a uma significativa seara da internet, não apenas essencial ao seu desenvolvimento quanto uma parte relevante de seu convívio social, o que terminaria por gerar uma assimetria de poder desarrazoada dos pais em relação ao controlador, esvaziando o poder parental de determinar livremente o uso e o fluxo desses dados.

Indo além, passa a prever o art. 14 que é de responsabilidade do controlador a garantia, por meio de todos os esforços razoáveis e consideradas as tecnologias disponíveis, de que o consentimento dado é de fato dos pais ou do responsável (§ 5º). Alguns aplicativos já têm exigido junto à prestação do consentimento, por exemplo, a resolução de uma conta matemática em nível de dificuldade superior ao da idade do participante, para assim assegurar que se trata de um adulto a prestá-lo.

O fato de a exigência do consentimento ser de apenas um dos pais da criança remete, por fim, à indagação sobre a possibilidade de discordância entre os genitores. Afinal, a exigência do consentimento de só um dos dois não exclui do outro o direito de participação nesse tipo de decisão referente ao filho comum. Nesse caso, aplica-se a regra geral do art. 1.631, parágrafo único, do Código Civil para casos de divergência parental quanto ao exercício do poder familiar, assegurando-se a qualquer deles, em último caso, recorrer ao Poder Judiciário para solucionar o desacordo.

5. Considerações finais

Independentemente de haver ou não haver exigência por parte da Lei Geral de Proteção de Dados de participação dos pais ou do responsável no consentimento para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, a participação parental nessa decisão é fundamental como múnus que decorre diretamente da autoridade parental, em vista da relevância desses dados como projeção da personalidade humana.

Aparentemente priorizando a praticidade do trâmite da vida digital, a LGPD optou pela exigência de consentimento parental apenas no caso das crianças, reservando a essas duas camadas de proteção: não apenas a exigência de participação de um dos pais ou responsável, como de que esse consentimento seja expresso ao invés de tácito. Tratou, por outro lado, os adolescentes em condição de igualdade com os adultos.

Diante disso, embora o consentimento deva ser exclusivo dos pais no caso de crianças, compete aos genitores, ainda assim, participá-las do processo de tomada de decisão para fazê-lo, a fim de que desde logo comecem a compreender a relação existente entre seus dados pessoais, sua privacidade e sua liberdade. No caso dos adolescentes, cabe aos pais conscientizá-los de que, mesmo

formalmente dispensada a participação parental no consentimento, devem recorrer a eles para auxílio e aconselhamento.

Assim restará preenchido o conteúdo da autoridade parental segundo seus novos contornos em uma sociedade tecnológica, pautado, como sempre deve ser, pelo atendimento ao melhor interesse dos filhos, sejam crianças ou adolescentes.

Referências

BIONI, Bruno Ricardo. *Xeque-Mate: o tripé da proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas do Brasil*. São Paulo: GPoPAI/USP, 2015, 59p. Disponível em: [www.researchgate.net/publication/328266374_Xeque-Mate_o_tripé_de_protecao_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil]. Acesso em: 17.03.2019.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 314p.

CAPELAS, Bruno. “Consentimento é muito mais do que um clique”, diz Bruno Bioni. *O Estado de São Paulo*, 04.12.2018. Disponível em: [link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital.consentimento-e-muito-mais-do-que-um-clique-diz-bruno-bioni,70002631258]. Acesso em: 17.03.2019.

CEC. The Economist Intelligence Unit. *Os impactos da proibição da publicidade dirigida às crianças no Brasil* – The Economist Intelligence Unit Limited 2017. 60p. Disponível em: [criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Relatorio_TheEconomist_.pdf]. Acesso em: 17.03.2019.

CETIC. Núcleo de informação e coordenação do Ponto BR. *Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil* – TIC Kids online Brasil 2017. São Paulo: Comitê gestor da Internet no Brasil, 2018. 348p. Disponível em: [cetic.br/pesquisa/kids-online/]. Acesso em: 17.03.2019.

CGI.br/NIC.br. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras* – TIC Educação 2017. Disponível em: [cetic.br/tics/educacao/2017/escolas-urbanas-alunos/C4C/]. Acesso em: 17.03.2019.

DE LUCA, Cristina. As crianças, os pais e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 28.08.2018. *Blog Porta 23*. Disponível em: [porta23.blogosfera.uol.com.br/2018/08/28/as-criancas-os-pais-e-a-lei-geral-de-protecao-dados-pessoais/]. Acesso em: 17.03.2019.

DENSA, Roberta. *Proteção jurídica da criança consumidora*. Indaiatuba: Foco, 2018.

DONEDA, Danilo Cesar Maganhoto; MENDES, Laura Schertel; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; ANDRADE, Norberto Nuno Gomes de. Considerações iniciais

sobre inteligência artificial, ética e autonomia pessoal. *Pensar – Revista de ciências jurídicas* (Fortaleza), v. 23, n. 4, p. 1-17, out./dez. 2018.

KNAPP, Katie; MORTON, J. Bruce. Desenvolvimento do Cérebro e Funcionamento Executivo. *Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância*. Disponível em: [www.encyclopedia-crianca.com/funcoes-executivas/segundo-especialistas/desenvolvimento-do-cerebro-e-funcionamento-executivo]. Acesso em: 10.03.2019.

LEAL, Livia Teixeira. Internet of toys: os brinquedos conectados à Internet e a necessária proteção da criança e do adolescente. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana (Org.). *Autoridade parental: dilemas e desafios contemporâneos*. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2019. p. 155-168.

MEIRELES, Rose Melo Vencelau. *Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 336p.

MELLO, Daniel. Pesquisa: 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a Internet. *Agência Brasil*, 10.10.2016. Disponível em: [agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-10/pesquisa-80-da-populacao-brasileira-entre-9-e-17-anos-usam]. Acesso em: 17.03.2019.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. 246p.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18). *Revista de direitos e garantias fundamentais* (Vitória), v. 19, n. 3, set./dez. 2018. p. 158-180. Disponível em: [dx.doi.org/10.18759/rdgf.v19i3.1603]. Acesso em: 17.03.2019.

PEREIRA, Tânia da Silva. O “melhor interesse da criança”. In: PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). *O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 1-101.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes; Tradução de Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 382p.

ROLLEMBERG, Rodrigo. *Proposta de Emenda à Constituição nº 6*, de 2011. Disponível em: [www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/99334]. Acesso em: 17.03.2019.

SCHREIBER, Anderson. Proteção de dados no Brasil e na Europa, 05.09.2018. *Jornal Carta Forense*. Disponível em: [www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/protecao-de-dados-pessoais-no-brasil-e-na-europa/18269]. Acesso em: 18.03.2019.

SÊCO, Thaís. Por uma nova hermenêutica do direito da criança e do adolescente. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. Disponível

em: [civilistica.com/poruma-nova-hermeneutica-do-direito-da-crianca-e-do-adolescente/]. Acesso em: 11.03.2019.

SILVA, Juliana Pedreira da. *Contratos sem negócio jurídico*: crítica das relações contratuais de fato. São Paulo: Atlas, 2011.

SILVA, Rosane Leal da; VERONESE, Josiane Rose Petry. O acesso à cultura, informação e entretenimento e as medidas de prevenção previstas no estatuto da criança e do adolescente. *Sequência*: estudos jurídicos e políticos, n. 59, p. 300-326, dezembro 2009. Disponível em: [vlex.com/vid/222209611]. Acesso em: 10.03.2019.

SOTTOMAYOR, Maria Clara. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos. *Direito e Justiça*: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, v. XVI, t. I, p. 197, 2002.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Perfil dinâmico da invalidez negocial. In: MENEZES, Joyceanne Bezerra de; RODRIGUES, Francisco Luciano Lima (Org.). *Pessoa e mercado sob a metodologia do direito civil-constitucional* [e-book]. Santa Cruz do Sul: Essere nel mondo, 2016. 173p. Disponível em: [www.esserenelmondo.com/pt/direito-pessoa-e-mercado-sob-a-metodologia-do-direito-civil-constitucional-ebook86.php:]. Acesso em: 17.03.2019.

TOMAZ, Kleber. Vítimas de ‘nude selfie’ e ‘sexting’ na Internet dobram no Brasil, diz ONG. 14.04.2014. G1. Disponível em: [g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/04/vitimas-de-nude-selfie-e-sexting-na-internet-dobram-no-brasil-diz-ong.html]. Acesso em: 09.03.2019.

1

.Doutora em Direito Civil pela UERJ. Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Especialista em Direito Civil pela *Università degli Studi di Camerino*. Coordenadora editorial da *Revista Brasileira de Direito Civil* – RBDCivil. Advogada.

2

.Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Advogada.

3

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais*: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 162-163.

4

.DONEDA, Danilo Cesar Maganhoto; MENDES, Laura Schertel; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; ANDRADE, Norberto Nuno Gomes de. Considerações iniciais sobre inteligência artificial, ética e autonomia pessoal. *Pensar* – Revista de ciências jurídicas (Fortaleza), v. 23, n. 4, out./dez. 2018. p. 4.

5

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18). *Revista de direitos e garantias fundamentais* (Vitória), v. 19, n. 3, set./dez. 2018. p. 177. Disponível em: [dx.doi.org/10.18759/rdgf.v19i3.1603]. Acesso em: 17.03.2019.

6

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes; Tradução de Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 17.

7

.MEIRELES, Rose Melo Vencelau. *Autonomia privada e dignidade humana*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 57.

8

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 146-147.

9

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais...* Op. cit., p. 147.

10

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais...* Op. cit., p. 164.

11

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais...* Op. cit., p. 148.

12

.LEAL, Livia Teixeira. Internet of toys: os brinquedos conectados à internet e a necessária proteção da criança e do adolescente. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana (Org.). *Autoridade parental: dilemas e desafios contemporâneos*. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2019. p. 157.

13

.CETIC. Núcleo de informação e coordenação do Ponto BR. *Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids online Brasil 2017*. São Paulo: Comitê gestor da Internet no Brasil, 2018. p. 119. Disponível em: [cetic.br/pesquisa/kids-online/]. Acesso em: 17.03.2019.

14

.MELLO, Daniel. Pesquisa: 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a Internet. *Agência Brasil*, 10.10.2016. Disponível em: [agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-10/pesquisa-80-da-populacao-brasileira-entre-9-e-17-anos-usam]. Acesso em: 17.03.2019.

15

.CETIC. Op. cit., p. 298.

16

.CETIC. Op. cit., p. 145.

17

.CGI.br/NIC.br. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras – TIC Educação 2017*, tabela C4C. Disponível em: [cetic.br/tics/educacao/2017/escolas-urbanas-alunos/C4C/]. Acesso em: 17.03.2019.

18

“Metadados podem não incluir o conteúdo das comunicações, mas eles incluem tudo menos isso – o que pode incluir alguns detalhes muito íntimos. Por exemplo, se o Facebook sabe que você mandou 30 mensagens de WhatsApp para um psicólogo entre as duas e três da manhã, ele sabe muito sobre você. Conforme Edward Snowden afirmou em entrevista à Vice, metadados são o

mesmo tipo de informação que é produzida quando um detetive particular segue você. Ele pode não saber o que você disse ou fez a cada momento, mas ele sabe onde você esteve, quanto tempo você ficou lá, com quem você se encontrou, quanto tempo você conversou e daí por diante. Desnecessário dizer que essa informação pode ser extremamente pessoal” (SUMARES, Gustavo. Entenda o que é o compartilhamento de dados do Whatsapp com o Facebook. *Olhar digital*. Disponível em: [https://olhardigital.com.br/noticia/entenda-o-que-e-o-compartilhamento-de-dados-do-whatsapp-com-o-facebook/62464]. Acesso em: 11.03.2019).

19

.CGI.br/NIC.br. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras – TIC Educação 2017*, tabela E6. Disponível em: [cetic.br/tics/educacao/2017/escolas-urbanas-alunos/C4C/]. Acesso em: 17.03.2019.

20

.PEREIRA, Tânia da Silva. O “melhor interesse da criança”. In: PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). *O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 3.

21

.SOTTOMAYOR, Maria Clara. Quem são os verdadeiros pais? Adopção plena de menor e oposição dos pais biológicos. *Direito e Justiça: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa*, v. XVI, t. I, p. 197, 2002.

22

.A prática de *sexting* tem proliferado entre adolescentes, ou seja, o envio de imagens de *nudes* pela internet. Segundo pesquisa da ONG Safernet, “garotas de 13 a 15 anos representam a maioria das vítimas de ‘*nude selfie*’ e ‘*sexting*’ que buscam ajuda psicológica”. Essa mesma fonte informa que uma jovem de 17 anos se suicidou no Piauí depois que um vídeo seu fazendo sexo começou a circular nas redes sociais (TOMAZ, Kleber. Vítimas de ‘*nude selfie*’ e ‘*sexting*’ na internet dobram no Brasil, diz ONG. 14.04.2014. G1. Disponível em: [g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/04/vitimas-de-nude-selfie-e-sexting-na-internet-dobram-no-brasil-diz-ong.html]. Acesso em: 09.03.2019).

23

.“Outro aspecto que fica totalmente sem supervisão, subtraindo-se às medidas de prevenção estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o fácil acesso de crianças e adolescentes a materiais pornográficos que circulam na *web*, pois, enquanto os proprietários, diretores, gerentes, funcionários de empresas que exploram a venda ou aluguel de fitas ou DVDs têm a obrigação de não disponibilizar material dessa natureza para menores de idade (art. 77 do Estatuto), na internet facilmente se encontra toda a sorte de imagens, vídeos e clipes. Na mesma esteira segue o disposto no art. 78, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que as revistas e publicações que contêm material impróprio devem ser comercializadas com embalagem lacrada, ao passo que na internet se oferecem os mais variados materiais, sem qualquer cuidado a quem se destina” (SILVA, Rosane Leal da; VERONESE, Josiane Rose Petry. O acesso à cultura, informação e entretenimento e as medidas de prevenção previstas no estatuto da criança e do adolescente. *Sequência: estudos jurídicos e políticos*, n. 59, p. 300-326, dezembro 2009. Disponível em: [vlex.com/vid/222209611]. Acesso em: 10.03.2019).

24

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 42-44.

25

.CETIC. Op. cit., p. 51.

26

.CETIC. Op. cit., p. 35.

.CETIC. Op. cit., p. 51.

.LEAL, Livia Teixeira. Internet of toys: os brinquedos conectados à Internet e a necessária proteção da criança e do adolescente. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana (Org.). *Autoridade parental: dilemas e desafios contemporâneos*. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2019. p. 160-161.

“[...] o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, prescrito no art. 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e na Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto 99.710/1990, consagra que, a partir do caso concreto, os aplicadores do direito devem buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança, vulnerável por natureza. Portanto, é de extrema importância garantir a efetividade aos direitos fundamentais da criança e do adolescente [...]” (STJ, REsp 1.713.123/MS, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, j. 06.03.2018, DJ 12.03.2018).

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes; Tradução de Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 15.

.MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 33.

.Sobre o tema, permita remeter a RODRIGUES, Renata de Lima; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Relevância da autonomia privada das crianças e adolescentes: há o direito infantil à autodeterminação? In: *O direito das famílias entre a norma e a realidade*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 45-66.

“A vulnerabilidade é realçada como parte da ontologia do ser-criança e do ser-adolescente, considerando pontos de vista intuitivos que realçam sua menor força física, seu menor conhecimento de mundo, a impossibilidade de promover seu próprio sustento e a impossibilidade de se defender, ou mesmo de saber a quem recorrer para a sua defesa” (SÊCO, Thaís. Por uma nova hermenêutica do direito da criança e do adolescente. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. p. 14. Disponível em: [civilistica.com/poruma-nova-hermeneutica-do-direito-da-crianca-e-do-adolescente/]. Acesso em: 11.03.2019).

“A imagiologia do cérebro e alguns estudos envolvendo pacientes com danos cerebrais sugerem que o córtex pré-frontal é fundamental para o controle da atenção, do raciocínio e do comportamento, em parte devido ao fato de unir os centros de controle da percepção, emocional e motor localizados em outras partes do cérebro. O fato de o córtex pré-frontal ter um desenvolvimento lento e, ao mesmo tempo, ser importante para o controle executivo sugere que o desenvolvimento do funcionamento executivo está intimamente relacionado ao amadurecimento do córtex pré-frontal. Uma implicação disso é que os desafios básicos do dia a dia como não brincar com um brinquedo proibido, serão difíceis, mesmo para as crianças com um desenvolvimento normal” (KNAPP, Katie; MORTON, J. Bruce. Desenvolvimento do Cérebro e Funcionamento Executivo. *Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância*. Disponível em: [www.encyclopedia-crianca.com/funcoes-executivas/segundo-especialistas/desenvolvimento-do-cerebro-e-funcionamento-executivo]. Acesso em: 10.03.2019).

."Dada a *racionalidade limitada* do ser humano, é pouco provável que esteja capacitado para tanto. Com efeito, a *bounded rationality* prescreve justamente que as habilidades cognitivas do ser humano são limitadas, minando a sua capacidade de absorver, memorizar e processar todas as informações relevantes para um processo de tomada de decisão. Já se faz impossível memorizar os inúmeros atores que compõem a referenciada rede social de publicidade, quanto mais compreender como os dados pessoais serão por eles tratados, já que cada um deles tem as suas respectivas políticas de privacidade. Soma-se, ainda, o complicador da compreensão de como a agregação dos dados pessoais desenrolar-se-á a ponto de extrair informações mais detalhadas sobre seus titulares" (BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 146-147, destaque nosso).

36

.Para um crítica a tais categorias, seja consentido remeter ao nosso RODRIGUES, Renata de Lima; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Regime das incapacidades e autoridade parental: qual o legado do estatuto da pessoa com deficiência para o Direito infantojuvenil? In: DADALTO, Luciana; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Coord.). *Autoridade parental: Dilemas e desafios contemporâneos*. Indaiatuba: Foco, 2019. p. 21-36.

37

.RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). *O Código Civil na perspectiva civil-constitucional: parte geral*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 1-34; EBERLE, Simone. *A capacidade entre o fato e o direito*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Integridade psíquica e capacidade de exercício. *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, n. 33, p. 03-36, jan./mar. 2008; MOUREIRA, Diogo Luna; SÁ, Maria de Fátima Freire de. *A capacidade dos incapazes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. Personalidade e capacidade do ser humano a partir do novo Código Civil. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). *Manual de teoria geral do direito civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. p. 117-213.

38

."Decisões existenciais, em geral, são dotadas de caráter personalíssimo. Mas há decisões que por seu conteúdo e por força do princípio da dignidade da pessoa humana se tornam ainda mais personalíssimas. São decisões que potencialmente podem ferir um bem moral relevante para o sujeito e que, dessa forma, só se legitimam por sua escolha pessoal" (SÊCO, Thaís. Por uma nova hermenêutica do direito da criança e do adolescente. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. p. 7. Disponível em: [civilistica.com/poruma-nova-hermeneutica-do-direito-da-crianca-e-do-adolescente/]. Acesso em: 09.03.2019).

39

.SÊCO, Thaís. Por uma nova hermenêutica do direito da criança e do adolescente. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. p. 19. Disponível em: [civilistica.com/poruma-nova-hermeneutica-do-direito-da-crianca-e-do-adolescente/]. Acesso em: 09.03.2019.

40

.ROLLEMBERG, Rodrigo. *Proposta de Emenda à Constituição nº 6*, de 2011. Disponível em: [www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/99334]. Acesso em: 17.03.2019.

41

.BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais...* Op. cit., p. 74. Conferir, ainda: TEIXEIRA, Lucas. Teoricamente impossível: problemas com a anonimização de dados pessoais. *Oficina Antivigilância*, 08.05.2015. Disponível em: [antivigilancia.org/pt/2015/05/anonimizacao-dados-pessoais/]. Acesso em: 17.03.2019.

42

.CETIC. Op. cit., p. 144.

43

“Os dados ainda revelam que, em 2017, permaneceram altas as proporções de usuários de Internet de 11 a 17 anos que tinham a percepção de que sabiam muitas coisas sobre como usar a rede (70%). Também continuou elevada a proporção daqueles que declararam que sabem mais sobre a Internet que seus pais (70%), embora essa percepção tenha apresentado decréscimo em relação à edição anterior da pesquisa (76%). Nos dois casos, as percepções variaram de acordo com a faixa etária. Os usuários de Internet de 15 a 17 anos foram os que melhor avaliaram seu conhecimento sobre o uso da Internet, assim como foram os que declararam mais frequentemente saber mais sobre a Internet que seus pais” (CETIC. Op. cit., p. 275 e p. 307).

44

.CETIC. Op. cit., p. 145.

45

.CETIC. Op. cit., p. 146.

46

.CETIC. Op. cit., p. 145-147.

47

.Sobre o conteúdo constitucional da autoridade parental, aprofundamos anteriormente em *Família, guarda e autoridade parental*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 136-168.

48

.Como se verá no próximo item, o art. 14 da LGPD determina que essa representação se limite apenas a crianças, de modo que o adolescente já pode transitar no ambiente virtual independentemente do consentimento dos pais.

49

“É preciso ensinar crianças e adolescentes a lidar com o dinheiro, a ter educação financeira, a consumir conforme suas necessidades e possibilidades e aprender a lidar com as frustrações daí advindas. Evidentemente, apesar do grande peso da educação familiar, essa responsabilidade não é só parental, estendendo-se também ao Estado e à sociedade” (DENSA, Roberta. *Proteção jurídica da criança consumidora*. Indaiatuba: Foco, 2018. p. 79).

50

.BIONI, Bruno Ricardo. *Xeque-Mate: o tripé da proteção de dados pessoais no jogo de xadrez das iniciativas legislativas do Brasil*. São Paulo: GPoPAI/USP, 2015. p. 45. Disponível em: [www.researchgate.net/publication/328266374_Xeque-Mate_o_tripe_de_protecao_de_dados_pessoais_no_xadrez_das_iniciativas_legislativas_no_Brasil]. Acesso em: 17.03.2019.

51

.Idem.

52

.SCHREIBER, Anderson. Proteção de dados no Brasil e na Europa, 05.09.2018. *Jornal Carta Forense*. Disponível em: [www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/protecao-de-dados-pessoais-no-brasil-e-na-europa/18269]. Acesso em: 18.03.2019.

53

.SOUZA, Eduardo Nunes de. Perfil dinâmico da invalidade negocial. In: MENEZES, Joyceanne Bezerra de; RODRIGUES, Francisco Luciano Lima (Org.). *Pessoa e mercado sob a metodologia do direito civil-constitucional* [e-book]. Santa Cruz do Sul: Essere nel mondo, 2016. p. 85-86. Disponível em: [www.esserenelmondo.com/pt/direito-pessoa-e-mercado-sob-a-metodologia-do-direito-civil-constitucional-ebook86.php:]. Acesso em: 17.03.2019. “Assim, o contato social qualificado pode, verificada a coordenação objetiva dos comportamentos humanos no caso concreto, retratar verdadeiro contrato sem negócio ou, na expressão de Larenz, conduta

socialmente típica, cujo significado jurídico decorrente do tráfego e princípios do ordenamento imputam eficácia obrigacional” (SILVA, Juliana Pedreira da. *Contratos sem negócio jurídico*: crítica das relações contratuais de fato. São Paulo: Atlas, 2011. p. 39).

54

.CAPELAS, Bruno. “Consentimento é muito mais do que um clique”, diz Bruno Bioni. *O Estado de São Paulo*, 04.12.2018. Disponível em: [link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,consentimento-e-muito-mais-do-que-um-clique-diz-bruno-bioni,70002631258]. Acesso em: 17.03.2019.

55

.DE LUCA, Cristina. As crianças, os pais e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 28.08.2018. *Blog Porta 23*. Disponível em: [porta23.blogosfera.uol.com.br/2018/08/28/as-criancas-os-pais-e-a-lei-geral-de-protecao-dados-pessoais/]. Acesso em: 17.03.2019.

Capítulo 5. Proteção dos dados pessoais da pessoa com deficiência

Heloisa Helena Barboza¹

Paula Moura Francesconi de Lemos Pereira²

Vitor Almeida³

*Nel momento in cui l'identità si specifica como concetto relazionale, la protezione dei dati cambia di significato.*⁴

Considerações iniciais

A⁵ Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP), Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, e o Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, constituem passos de todo significativos para a proteção das pessoas no momento em que se vive a denominada “era digital”. Ao dispor sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tem a Lei de Proteção de Dados Pessoais o exposto objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A importância das referidas Leis se potencializa quando se considera que o alcance incomensurável da rede mundial de comunicação (*world wide web*) e a crescente facilidade de acesso a ela modificaram a relação tempo-espço de modo profundo. Entre as diferentes dimensões afetadas, diretamente e a um só tempo, destaca-se a compreensão das noções de memória e permanência. A consequente interferência na vida dos indivíduos atinge suas relações patrimoniais e existenciais para inquestionavelmente facilitá-las, mas acaba por pôr em risco a garantia de direitos internacionalmente consagrados, notadamente no plano dos direitos humanos fundamentais e, em particular, dos direitos da personalidade, ameaçados pela dificuldade, se não pela impossibilidade, pelo menos à primeira vista, de controle do incessante e crescente trânsito dos dados pessoais.

A improbabilidade de controle se vislumbra quando se considera o fornecimento espontâneo de dados pelos indivíduos, dando origem a mais um plano de vulnerabilidade, a exigir pronta ação do Direito para que não se percam conquistas arduamente obtidas. A privacidade torna-se, assim, um dos direitos mais ameaçados nesse cenário, a ponto de o seu resguardo ser considerado um dos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais buscada pela LGDP (art. 2º, I).

A questão da proteção da privacidade ganha novos e complexos aspectos quando se trata da proteção de pessoas com deficiência. Embora a partir da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão – Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, todas as pessoas com deficiência, inclusive mental, tenham assegurado o exercício de seus direitos e liberdades fundamentais, em condições de igualdade, há de se considerar sempre sua situação de vulnerabilidade, para que possam ser atendidas as peculiaridades de cada caso.

A pessoa com deficiência tem, portanto, direito à proteção de seus dados pessoais como qualquer outra pessoa, para que se protejam seus direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento de sua personalidade, como prevê a LGDP. Contudo, as pessoas com deficiência têm proteção especial, de base constitucional, em razão de sua situação de vulnerabilidade, disciplinada pelo EPD. Em consequência, a interpretação e aplicação da LGDP há de ser feita em conjugação com o EPD, sob pena de afronta às diretrizes constitucionais que lhe servem de fundamento.

A proteção da privacidade das pessoas com deficiência, no que tange a dados pessoais sensíveis, exige especial atenção no que se refere a dados médicos, mesmo se tendo superado o entendimento da deficiência como uma questão exclusivamente médica. Merecem, assim, os dados médicos reforçada atenção, estejam ou não na *web*, notadamente no que diz respeito ao consentimento livre e esclarecido por parte da pessoa com deficiência, que tem sido considerado meio de se impedir qualquer tipo de discriminação, mas que nem sempre atinge essa finalidade.

O presente trabalho, elaborado com base em pesquisa bibliográfica, nos seus estreitos limites, procura examinar alguns aspectos da proteção da privacidade e dos dados médicos das pessoas com deficiência, como modesta contribuição para o debate e encaminhamento de soluções para os problemas já postos pela LGDP e pelo EPD.

1. Vulnerabilidade e privacidade: proteção no caso de deficiência

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, fez menção a estarem algumas pessoas em “situação de vulnerabilidade”, para se referir a menores, incapazes, idosos⁶ e ao condenado⁷. Não foi delineada, porém, a definição de vulnerabilidade fora do senso comum para fins jurídicos. Verdade é que o tema está a exigir maior atenção da doutrina no Brasil, na medida em que, a cada momento, se revela mais importante e amplia sua abrangência.⁸

Conforme Fermin Roland Schramm, a partir do conceito de vulnerabilidade, como qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerado (ferido, frágil, prejudicado ou sujeito a ser atacado), esclarece que ele se refere a uma “característica ontológica de todos os seres vivos” (*vulnerabilidade primária geral*), que é universal e não pode ser protegida. Segundo o autor, em determinadas circunstâncias, os indivíduos se tornam suscetíveis ou até vulnerados (*vulnerabilidade secundária ou suscetibilidade*), em razão de sua condição existencial que os impede de ter uma vida digna e de qualidade. Nesse

caso, tem o Estado obrigação de protegê-los. A proteção deve ser conferida em graus diferenciados, em atenção às condições de vulnerabilidade e suscetibilidade.⁹

A utilização do termo, em texto legislativo, constata-se na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, e estabelece o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo” (art. 4º, I), como um dos princípios a serem atendidos pela Política Nacional das Relações de Consumo. A doutrina sobre relações de consumo, de início, identificou a vulnerabilidade com a hipossuficiência econômica, havendo, porém, divergência entre os autores.¹⁰

Em 13 de julho do mesmo ano, a Lei 8.069 institui o Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao dispor sobre a proteção integral à criança e ao adolescente (art. 1º), reconhece expressamente sua “condição peculiar como pessoas em desenvolvimento”, para fins de interpretação daquela Lei (art. 6º). Embora não haja referência à vulnerabilidade, fica patente a preocupação do legislador de atribuir tratamento diferenciado a determinadas pessoas em razão das circunstâncias em que se encontram.

Na verdade, a Constituição da República de 1988, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana, identificou as diferenças sociais e individuais, e o legislador infraconstitucional procura, desde então, proteger os que se encontram em situação de desigualdade (susceptibilidade ou vulnerabilidade), fornecendo-lhes instrumentos jurídicos hábeis a sua proteção.

Embora não tenha utilizado o termo, o legislador constituinte identificou e contemplou diversas formas de vulnerabilidade, das quais são exemplo as crianças, os adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, entre outros, procurando atender suas susceptibilidades e vulnerabilidades específicas. Contudo, na complexidade de uma sociedade plural e diversificada como a brasileira, muitos ainda clamam por proteção especial.

Deve se considerar que, como afirma Maria Celina Bodin de Moraes, a dignidade da pessoa humana concretiza-se na cláusula geral de tutela da pessoa humana.¹¹ Não obstante, essa tutela somente será efetiva e adequada se for considerada a vulnerabilidade inerente às pessoas humanas e as diferenças existente entre elas, para que se possa obter, o quanto possível, a igualdade substancial.¹² A proteção que lhes é assegurada deve dar-se integralmente, em todas as situações, existenciais ou patrimoniais, de modo a contemplar todas e cada uma de suas manifestações.¹³

Desse modo, as pessoas em situação de vulnerabilidade ainda não atendidas podem encontrar amparo na cláusula geral de tutela da pessoa humana, mas para tanto é necessário que sejam reconhecidas como tal e as peculiaridades do caso, para que lhes seja concedida proteção no grau adequado.¹⁴

Esse é o caso das pessoas com deficiência, que somente em 2008, portanto, passados 20 anos da promulgação da Constituição da República de 1988, tiveram seus direitos reconhecidos pelo Brasil, com a assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (CDPD).¹⁵ Sua efetivação se iniciou, porém, 27 anos após a promulgação da Constituição da República, em janeiro de 2016, ao entrar em vigor o EPD, momento em que a comunidade jurídica despertou para as profundas alterações promovidas pela nova Lei. Desde então, desenvolvem-se os debates sobre as inovações promovidas pelo EPD, especialmente quanto ao novo regime de (in)capacidade civil, muito questionado no que se refere à extinção da incapacidade absoluta na hipótese de deficiência mental.¹⁶

Como se vê, as pessoas com deficiência permaneceram – por cerca de três décadas, após instauração de nova ordem jurídica no País – na mesma situação do início do século XX, ou seja, em estado de invisibilidade social e jurídica. Esse “estado” causa discriminação, inclusive legal, sendo constantes as violações aos direitos fundamentais dessas pessoas, que apresentam peculiaridades diversificadas, e que até então eram obrigadas a recorrer ao Poder Judiciário em busca de tutela especial.

Nesse cenário de desproteção, destacam-se as constantes violações da privacidade das pessoas com deficiência. O que se observa é uma estreita vinculação entre a situação de vulnerabilidade e o respeito à privacidade, ou seja, quanto maior o grau de vulnerabilidade, mais suscetível é a pessoa a agressões a sua privacidade. Os efeitos dessas violações no caso das pessoas com deficiência são severos e variados, e vão desde o surgimento do estigma, ou o agravamento do estigma já existente, até comprometimento de sua autonomia e da própria identidade.

Com relação ao estigma, cabe lembrar a clássica concepção de Erving Goffman, para quem o estigma é a atribuição de um traço desonroso à determinada pessoa, que a faz parecer inferior ou perigosa, o que implica degradá-la como algo infra-humano, com base na ideologia existente ou construída.¹⁷ As pessoas com deficiência são historicamente estigmatizadas, fato que persiste e não pode ser desconsiderado quando se trata da proteção de dados, notadamente dados sensíveis, plano em se destacam os dados médicos, que não raro fazem parte da vida dessas pessoas desde seu nascimento. Observe-se que, na era digital, o estigma que se origina de um clique pode afetar indelevelmente e para sempre uma pessoa.¹⁸

A possibilidade de comprometimento da identidade fica evidente quando se considera a concepção de privacidade de Stefano Rodotà. Como esclarece o autor, a construção da identidade se efetiva em condições de dependência crescente do externo, do modo pelo qual vem estruturado o ambiente no qual vivemos, não só da dependência de outras pessoas, mas também do modo pelo qual as coisas que nos circundam ou que são utilizadas para modificar diretamente o nosso próprio corpo. Para Stefano Rodotà, estamos vivendo uma verdadeira revolução da identidade. A construção da identidade tende, assim, a apresentar-se sempre mais como um meio para a comunicação com os outros, pela apresentação do eu (*del sé*) na cena do mundo. Isso modifica a relação entre a esfera pública e a esfera privada e a própria noção de privacidade.¹⁹

De acordo com Stefano Rodotà, a privacidade foi construída como um dispositivo “excludente”, como um instrumento para afastar o olhar indesejado, mas de suas progressivas transformações fizeram emergir um direito cada vez mais destinado a “tornar possível a livre construção da personalidade, a estruturação autônoma da identidade, a proteção na esfera privada dos princípios fundamentais da democracia”. Nesse sentido, a primeira inovação verdadeira consiste em definir a privacidade como “o direito de controlar o uso que outros fazem das informações que me dizem respeito”. Sucessivamente, a privacidade foi considerada “tutela das escolhas de vida contra cada forma de controle público ou de estigmatização social”, “reivindicação das limitações que impedem cada um de ser simplificado, objetivado e avaliado fora de contexto” e, mais diretamente, exatamente como “construção da própria identidade livre de vínculos não razoáveis”. Além disso, a privacidade vem definida como “direito de manter o controle sobre as próprias informações e de determinar a modalidade de construção da própria esfera privada” e, em última análise, como “o direito de escolher livremente o próprio modo de viver”.²⁰

Segundo Stefano Rodotà, estamos diante de uma verdadeira reinvenção do conceito de proteção dos dados pessoais, não apenas porque vem sendo considerado um direito fundamental autônomo, mas porque se apresenta como instrumento indispensável para o livre desenvolvimento da personalidade e para definir o conjunto das relações sociais. Ao referir-se aos denominados “dados sensíveis”, esclarece o autor que eles têm uma tutela muito forte não para garantir uma maior privacidade, mas para tornar possível sua comunicação em público, sem risco de discriminação ou estigmatização social. Em consequência, as opiniões pessoais de natureza política ou religiosa acompanham e constroem minha identidade apenas se posso colocá-las fora da esfera privada, “se posso fazê-las valer na esfera pública”.²¹

Diante da nova concepção da privacidade, a tutela dos dados pessoais cresce em importância e se torna essencial para as pessoas com deficiência que buscam sua inclusão social e cidadania. Embora não haja no EPD um capítulo dedicado ao tema, preocupou-se o legislador em reafirmar a capacidade das pessoas com deficiência, mesmo em caso de curatela, a qual não alcança o direito à privacidade (EPD, art. 85, § 1º).

2. Proteção dos dados pessoais da pessoa com deficiência

Na contemporaneidade, a privacidade expandiu seus domínios e não mais se expressa sob as lentes individualistas consagradas por força de sua construção jurídica burguesa em fins do século XIX. Certamente, foi o atributo da personalidade que sofreu as transformações mais radicais com o acelerado progresso tecnológico. Apesar dos riscos potencializados pela era digital, a tutela da privacidade está em franca expansão, protagonizando os principais dilemas jurídicos contemporâneos que envolvem a proteção da esfera privada, como espaço efetivo de liberdade, destinado ao livre desenvolvimento da personalidade e a afirmação da autonomia existencial, superando a clássica concepção do *right to be alone*.²²

O direito à privacidade assume, na atualidade, importante função no ordenamento brasileiro voltado à tutela das liberdades existenciais na construção da personalidade.²³ Os desafios, contudo, são múltiplos diante da complexidade da atual sociedade de informação, notadamente, em razão dos velozes e potentes mecanismos de coleta e armazenamento de dados pessoais, em especial os denominados dados sensíveis. Indubitável as profundas e contínuas alterações que a tutela da privacidade sofre desde que abandonou a sua tradicional roupagem de “direito dos egoísmos privados”,²⁴ sendo alvejada por novos e importantes dilemas decorrentes do hiperfluxo de dados pessoais, que propiciam maior controle do indivíduo e interferências na construção de sua identidade.

A Constituição da República de 1988 estabeleceu a fundamentalidade do direito à privacidade em seu art. 5º, inciso X, ao dispor que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Por sua vez, o Código Civil de 2002, em seu art. 21, estabelece que “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”²⁵. O lacônico e solitário dispositivo dispensado ao direito à privacidade no Código Civil não corresponde à atual dinâmica da privacidade em tempos atuais, que, conforme visto, deixa de ser exclusivamente um direito a ficar sozinho e não ter seu microcosmo domiciliar violado para alcançar o direito à autodeterminação informativa e à proteção dos dados pessoais.

Stefano Rodotà afirma que a noção de privacidade é fortemente dinâmica e conectada de forma estreita com as mudanças tecnológicas, o que implica a redefinição constante de seu conceito. Defende, nesse viés, que na “sociedade da informação tendem a prevalecer definições funcionais da privacidade que, de diversas formas, fazem referência à possibilidade de um sujeito conhecer, controlar, endereçar, interromper o fluxo de informações”. Nesse sentido, enuncia que a privacidade adquire uma definição mais precisa como o direito de manter o controle sobre as próprias informações.²⁶ Destaca, ainda, que um dos paradoxos da privacidade reside exatamente no fato de que na medida em que a “tecnologia ajuda a moldar uma esfera privada mais rica”, por outro lado, inaugura uma privacidade cada vez mais frágil e exposta a ameaças. Disso resulta a “necessidade do fortalecimento contínuo de sua proteção jurídica, da ampliação das fronteiras do direito à privacidade”.²⁷

Fundamental, nesse contexto, conceber a proteção dos dados pessoais como um direito fundamental, expressão da privacidade, com feição própria que garante a autodeterminação informativa no que tange ao controle da coleta e finalidades sobre suas informações.²⁸ Por isso, durante muito tempo se reclamou por uma tutela mais enérgica da privacidade diante das novas tecnologias, especialmente com o advento e, logo após, a democratização da internet. Após longa espera, finalmente foi promulgada a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet (MCI), que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Com o Marco Civil da Internet, o legislador se posicionou claramente pela necessidade de regulamentação da internet, mas garantindo a liberdade de expressão, a neutralidade da rede, a privacidade e a criação de novos modelos de negócio. Importante passo na direção da proteção

de dados pessoais foi dado pelo legislador ordinário ao preferir *descolar* a tutela deste do conceito mais amplo de privacidade, inserindo-os em incisos distintos.²⁹

Nítido, desse modo, o balanceamento dos valores constitucionais, realizado pelo legislador, eis que, ao mesmo tempo que se preservou a privacidade, os dados pessoais e a neutralidade da rede, por outro lado, o legislador reafirmou o espaço virtual como um *locus* genuíno para o exercício das liberdades fundamentais, constitucionalmente garantidas, mas desde que exercidas dentro do contexto de solidariedade social. Nesse trilho, a doutrina aponta que o art. 3º do Marco Civil da Internet estabelece que a “internet brasileira se encontra alicerçada em um tripé axiológico formado pelos princípios da neutralidade da rede, da privacidade e da liberdade de expressão, que estão ligados entre si”, em clara atenção aos ditames constitucionais. “Enquanto a neutralidade da rede reforça a liberdade de expressão, a privacidade representa seu limite”.³⁰

Stefano Rodotà já sinalizava que a tríade “pessoa-informação-sigilo” cedeu espaço para a sequência “pessoa-informação-circulação-controle”, o que alterou qualitativamente a noção clássica de privacidade.³¹ Hoje, com o foco no controle dos dados pessoais, a tendência é viabilizar formas de “circulação controlada”, em vez de assegurar o sigilo ou a interrupção do fluxo das informações que lhe dizem respeito. Atento a tal desiderato, o MCI consagrou de forma expressa o direito à privacidade nos arts. 3º, II, 8º e 11, enquanto, em outras passagens, assegurou a proteção aos dados pessoais (arts. 3º, III e 11), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 7º, I) e a inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet (art. 7º, II). Demonstra-se, nesse cenário, que a Lei 12.965/2014 se preocupou de forma significativa com a proteção da privacidade do usuário e o direito à informação em relação à coleta, armazenamento e uso dos dados pessoais dos usuários.

Após longo e democrático percurso legislativo,³² em 14 de agosto de 2018 foi promulgada a Lei 13.709, a qual dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), consolidando-se, assim, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)³³. Nos termos do seu art. 1º, a LGPD

dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Estabelece ainda no seu art. 2º os fundamentos da disciplina da proteção dos dados pessoais, realçando a importância do respeito à privacidade e da autodeterminação informativa.

A doutrina aponta que a LGPD adotou o *paradigma do controle*, por meio do qual se garante ao titular o controle sobre seus dados, inclusive para fins de divulgação e uso, em oposição ao chamado paradigma do segredo e do sigilo.³⁴ Segundo Laura Schertel Mendes e Danilo Doneda, a

ideia é a de que, com o empoderamento do cidadão e com a institucionalização de mecanismos de controle e supervisão sobre o uso de seus dados, o cidadão passe a ser protagonista das decisões sobre o uso de seus dados, em linha com o conceito de autodeterminação informativa.

Nessa direção, a referida Lei instituiu o denominado modelo *ex ante* de proteção de dados,³⁵ que se baseia na consideração de que “não existem mais dados irrelevantes diante do processamento eletrônico e ubíquo de dados na sociedade da informação” e que os “dados pessoais são projeções da personalidade”³⁶, fundamentais ao livre desenvolvimento da identidade no ambiente social.

Na linha de fortalecimento da autodeterminação informativa, o consentimento é o ponto central no uso dos dados pessoais. A LGPD define consentimento como “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (art. 5º, XII) e determina que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular ou em razão de cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador (art. 7º, I e II, LGPD). Disso decorre que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, sendo-lhe garantidos os direitos fundamentais de liberdade e privacidade (art. 17, LGPD), o que reforça a preocupação do legislador com a tutela da vida privada e a necessidade de consentimento para o tratamento de seus dados.

Stefano Rodotà já destacava a importância de uma forte tutela para as informações que dizem respeito à pessoa humana, eis que a ameaça é cada vez maior de ser discriminada pelas suas opiniões, crenças religiosas, condições de saúde. Por isso, exalta que a “privacidade se apresenta assim como um elemento fundamental da *sociedade da igualdade*”, “condição essencial para a inclusão na *sociedade da participação*”³⁷. Indispensável, portanto, o reforço da tutela dos dados pessoais numa sociedade cada vez mais estruturada por informações, sobretudo os chamados dados sensíveis, como forma de impedir as finalidades discriminatórias e atentatórias à dignidade da pessoa, que ameaçam a construção das identidades individuais de forma plural. Nesse caminho, afirma-se que “proteger de maneira rigorosa os dados pessoais sensíveis se torna, assim, instrumento para efetivação da liberdade e da igualdade” diante das “assimetria de poderes existente entre os titulares de dados e aqueles que realizam o tratamento dos dados”.³⁸

Atento à imperiosa necessidade de maior rigor na tutela dos dados pessoais sensíveis³⁹, o legislador dedicou uma seção inteira (arts. 11 a 13) para fins de sua tutela especial, que, consoante exposto no art. 5º, II, da LGPD, define-se como todo

dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

A *ratio* da proteção reforçada dos dados sensíveis assenta-se no potencial discriminatório de tais informações, que estigmatiza e exclui determinadas pessoas em razão de suas escolhas existenciais mais íntimas ou de traços biológicos.

Por isso, uma tutela frágil dos dados sensíveis de pessoas vulneráveis aprofunda as desigualdades e cerceia a liberdade existencial, eis que impede a livre construção da identidade e a projeção de sua personalidade da forma que lhe aprouver, livre das âncoras do preconceito e discriminação.

A disciplina dos dados sensíveis na LGPD não é imune às críticas por apresentar redundância e contradição⁴⁰, mas, acima de tudo, por não levar em consideração as vulnerabilidades específicas de cada grupo minoritário⁴¹, restando, de modo geral, disposições bem genéricas. De acordo com a redação do art. 11, I, o consentimento do titular ou responsável legal deve ser obtido de forma específica e destacada e com finalidade específica. Sem dúvida, aplica-se o art. 9º da LGPD no que tange aos requisitos para obtenção do consentimento, devendo os dados sensíveis ter ainda maior destaque do que os demais dados pessoais ordinários. No inciso II do art. 11, o legislador previu o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular, em rol taxativo, repetindo algumas hipóteses já previstas no art. 7º, o que induz à compreensão de que este dispositivo não se aplica aos dados sensíveis. A LGPD, ainda, trouxe regras sobre as limitações ao compartilhamento e comunicação, nos termos dos §§ 3º, 4º⁴² e 5º⁴³ do art. 11, que pode ser objeto de vedação os dados pessoais relativos à saúde de serem compartilhados com finalidades econômicas, exceto nos casos de portabilidade (art. 18).

A preocupação com a proteção de dados pessoais de pessoas em situação de vulnerabilidade é ainda mais acentuada, notadamente em relação aos dados sensíveis. Assegurar os direitos da pessoa de manter o controle sobre seus dados, por meio da autodeterminação informativa, de forma a evitar a não discriminação, é ainda mais difícil para integrantes de grupos vulneráveis. Se já é tormentosa a proteção da liberdade e da igualdade no contexto da proteção de dados diante das assimetrias de poder na sociedade da informação, no caso de pessoas vulneradas é dramática sua tutela. Entre eles, as pessoas com deficiência constituem grupo estigmatizado e inferiorizado socialmente que representa significativa parcela da população e que o Direito brasileiro somente em tempos mais recentes se voltou à sua tutela na medida de suas vulnerabilidades.

Como já salientado, somente a partir de 2008 instaurou-se inovador tratamento constitucional da tutela das pessoas com deficiência, que não só passou a incluir-se entre a agenda dos direitos humanos, como a ter como foco a plena e efetiva participação e inclusão dessas pessoas na sociedade, como decorrência da adoção do modelo social de deficiência, conforme preconizado pela CDPD, que tem envergadura de norma constitucional.

Os fortes impactos da CDPD no ordenamento jurídico nacional só foram sentidos efetivamente após a edição do EPD. Destinado expressamente a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o EPD cria os instrumentos necessários à efetivação dos ditames constitucionais. Preocupou-se especialmente em afirmar a capacidade civil da pessoa com deficiência no art. 6º, sobretudo no campo existencial ao indicar nos incisos diversos atos de natureza privada e íntima, bem como ao limitar a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85).

A lei brasileira não cogitou, contudo, uma tutela específica e enérgica a respeito da privacidade e da proteção dos dados pessoais da pessoa com deficiência, apesar de a diretriz emanada da CDPD, que assegura em seu art. 22 o respeito à privacidade ao estabelecer que

nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Reforçou, contudo, a tutela dos dados pessoais das pessoas com deficiência relativos à saúde e reabilitação ao impor que no mesmo dispositivo, item 2, que os “Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Em sede infraconstitucional, o EPD se preocupou de forma tímida com a tutela da privacidade e dos dados pessoais da pessoa com deficiência ao promover a sua capacidade civil, com destaque à autodeterminação existencial (art. 6º), e reforçar que a curatela não alcança o direito à privacidade (art. 85, § 1º), mas tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Tal preocupação retorna por ocasião da criação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão)⁴⁴, registro público eletrônico, administrado pelo Poder Executivo Federal, que tem por finalidade a “coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos”, nos termos do art. 92 do EPD.⁴⁵

Com o intuito de proteger os dados pessoais coletados para fins desse Cadastro-Inclusão, o legislador mencionou que as salvaguardas estabelecidas em lei devem ser observadas de modo a assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações (art. 92, § 4º). No entanto, como visto, não há na legislação brasileira salvaguardas específicas para a tutela de dados da pessoa com deficiência. Embora se verifique tal carência legal, em diálogo com a LGPD, em especial o disposto no art. 11, II, c, a finalidade do Cadastro-Inclusão deve seguir fielmente o previsto nos incisos I e II do § 5º do art. 92, ou seja, para a “formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos” e a “realização de estudos e pesquisas”, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.

A ausência de regras específicas de proteção e tratamento de dados pessoais para grupos vulneráveis não impede a construção de parâmetros mais rígidos nessa direção e, à luz do unitário ordenamento jurídico brasileiro, guiado pelos ditames constitucionais, impõe-se uma tutela mais enérgica da proteção de dados sensíveis das pessoas vulneráveis. Tal encaminhamento já é sentido na experiência europeia, por exemplo. A União Europeia adotou o *General Data Protection Regulation* (Regulamento Geral de Proteção de Dados) 679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de

2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. Por meio do referido Regulamento foram estabelecidas diversas regras com relação à coleta e ao tratamento de dados pessoais de titulares europeus. O regulamento encontra-se em vigor desde 25 de maio de 2018 e atinge não só as empresas europeias como também pessoas físicas ou jurídicas situadas no Brasil que, de alguma forma, utilizem dados pessoais de europeus para o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Cabe salientar que o Regulamento é sensível à probabilidade e gravidade variáveis do risco para os direitos e liberdade das pessoas, que, inclusive, podem resultar em tratamento de dados pessoais em intensidade diferente. Preocupa-se, nitidamente, com o processamento de dados pessoais, em especial os sensíveis, de pessoas vulneráveis, em particular de crianças⁴⁶. Nessa linha, a lei brasileira também se voltou à proteção especial de dados de crianças e adolescentes, em atenção ao princípio constitucional do melhor interesse, estampado no art. 227 da Constituição de 1988. Reservou-se, desse modo, o art. 14 da LGPD, que reconheceu a vulnerabilidade das pessoas em desenvolvimento (arts. 2º e 6º da Lei 8.069/90) ao estabelecer regras específicas para o tratamento de seus dados pessoais, realizando, entretanto, nítida distinção entre crianças e adolescentes.

Nesse cenário, é de todo indispensável o diálogo entre o EPD e a LGPD, de modo a construir uma efetiva e integral tutela dos dados pessoais da pessoa com deficiência, com fins à promoção de seu consentimento livre e esclarecido acerca do tratamento dos dados, bem como outros mecanismos de proteção, na medida de suas necessidades e circunstâncias de cada caso. Visa-se, com isso, salvaguardar a construção de uma identidade livre de estigmas e sem discriminação por meio da tutela dos dados sensíveis. Sob o manto da diretriz de natureza constitucional prevista no art. 22 da CDPD, proteger os dados pessoais das pessoas com deficiência é concretizar as diretrizes da Convenção e do EPD de igualdade e liberdade, tão caros à plena inclusão social.

3. Dados sensíveis médicos, discriminação e consentimento

Ao tratar dos dados da pessoa com deficiência, ganha relevo a proteção de seus dados médicos, que se inserem dentro da espécie de dados pessoais⁴⁷ sensíveis definidos no art. 5º, II, da LGPD. Os dados médicos abrangem os dados referentes à saúde, à vida sexual, ao dado genético ou biométrico do paciente, informações cujo conteúdo apresenta mais riscos discriminatórios que a média, tanto para a pessoa como para própria coletividade. Isso porque, caso sejam conhecidas e processadas essas informações, os pacientes ficam suscetíveis a condutas de exclusão⁴⁸, que podem comprometer, inclusive, o acesso à saúde, no âmbito público e privado; seu afastamento de meios familiares, sociais e corporativos, entre outras situações, que podem afetar a sua imagem e personalidade, acarretando danos na esfera extrapatrimonial e patrimonial.

Os dados pessoais, incluindo os dados médicos, são utilizados como um ativo econômico (art. 11, § 1º, da LGPD), por isso a falta de meios seguros de tratamento, proteção, guarda e custódia dos dados clínicos e genéticos dos pacientes tem possibilitado sua utilização sem filtros nas redes sociais. Além disso, propiciam a comercialização dos dados, seja para pesquisas científicas⁴⁹, agências de emprego, planos de saúde e seguradoras, na maioria das vezes sem o devido consentimento livre e esclarecido do paciente.

Como já explicitado, os pacientes com deficiência apresentam uma vulnerabilidade especial,⁵⁰ e o uso indevido e sem autorização de seus dados médicos pode ter impactos ainda maiores, afetando seu processo de inclusão e contrariando os princípios constitucionais e os preceitos cunhados pelo EPD na busca em assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Por isso, os dados médicos merecem proteção redobrada, a fim de evitar seu uso indevido nos setores em que lhe deve ser assegurado o acesso prioritário, tais como: saúde, educação, informação, lazer, trabalho, comunicação, locomoção, entre outros (arts. 8º e 9º do EPD).⁵¹

Os dados sensíveis dos pacientes resultantes da prestação de serviços médicos à distância⁵² por meio das mídias sociais⁵³, WhatsApp⁵⁴, Websites, Aplicativos, Facebook, Blogs etc., e o surgimento de prontuários eletrônicos com a migração da forma física de tratamento e controle de dados para a virtual, afeta diretamente a maneira como circulam na internet⁵⁵. Além disso, permite correlacionar uma série de dados que demonstram os perfis comportamentais do paciente, sua orientação sexual, estado de saúde etc.

A biotecnologia, ao mesmo tempo que traz benefícios por permitir maior acesso à informação e à saúde, com novos tratamentos, atendimentos mais céleres e imediatos, rompendo as barreiras do tempo e as fronteiras geográficas, põe em xeque a privacidade do paciente e o livre desenvolvimento de sua personalidade. Isso porque nem sempre são observados o sigilo e a confidencialidade dos dados relacionados à saúde, aos dados genéticos e biomédicos.

É preciso, portanto, diante da fragilidade constatada na era digital, criar mecanismos efetivos de tutela dos dados sensíveis dos pacientes, que alcancem – o quanto possível – todos os partícipes da cadeia de circulação dos dados, desde os profissionais de saúde, médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, provedores de conteúdo, aplicativos na internet, controladores até operadores. A inobservância de medidas de restrição da transmissibilidade dos dados dos pacientes pode acarretar a lesão à dignidade humana, à igualdade, à integridade psicofísica, à privacidade, direitos humanos fundamentais consagrados na Constituição Federal.

Diversas normas, de cunho ético e jurídico, no âmbito nacional e internacional⁵⁶, consagram o direito dos pacientes ao sigilo e à confidencialidade dos seus dados pessoais sensíveis, sendo estes reflexos do aspecto existencial da relação médico-paciente.⁵⁷

Aos pacientes é assegurada a privacidade e o livre desenvolvimento de sua personalidade por meio do sigilo dos seus dados sensíveis, além do acesso às suas informações⁵⁸, o que encontra respaldo na Constituição Federal (arts. 1º, III; 5º,

XIV e X), no Código Civil (arts. 20, 21) e no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III⁵⁹, 43, 44), este aplicável pela maioria da doutrina⁶⁰ e jurisprudência⁶¹ à relação médico-paciente por ser tratada como relação de consumo, apesar de posicionamentos contrários.⁶²

No caso de paciente com deficiência, o direito ao sigilo de suas informações de saúde ganha relevo para evitar tratamento diferenciado, discriminatório, pois a presença de algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial não pode alijá-lo do direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, como preceitua os arts. 4º e 5º do EPD. Em se tratando de pessoa com transtornos mentais, a Lei 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, é expressa ao assegurar o direito ao sigilo de suas informações (artigo 2º, parágrafo único, IV).

Em razão da importância do bem jurídico tutelado, a violação do sigilo configura crime de inviolabilidade dos segredos, tipificado no art. 154 do Código Penal⁶³, constituindo exceção, por exemplo, o caso de necessidade de notificação compulsória de doença,⁶⁴ cuja inobservância também constituirá o crime previsto no art. 269 do Código Penal⁶⁵ ou contravenção penal (art. 66 do Decreto-lei 3.688/1941). Não se afastam, em tais casos, a responsabilidade na esfera cível dos agentes envolvidos – médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, provedores⁶⁶, bem como a responsabilidade ético-disciplinar.⁶⁷

A nova forma de armazenamento dos dados sensíveis do paciente⁶⁸, com a passagem dos prontuários físicos para os eletrônicos, deve observar a Lei 13.787/2018⁶⁹ e a Resolução 1.821/2007 do CFM⁷⁰. A maior possibilidade de sua circulação pela internet, especialmente pelas mídias sociais, não dispensa a observância da confidencialidade das informações médicas e sua individualização. Ao revés, reforça o dever de segurança no recolhimento dos dados, sua conexão, transmissão, utilização e publicação. É por isso que, no campo autorregulatório, os Conselhos Regionais e Federal de Medicina têm editado resoluções que visam proteger os dados dos pacientes sem se afastar das novas tecnologias⁷¹.

A principal questão que deve ser enfrentada é evitar a estigmatização do ser humano, a criação de estereótipos de pessoas, principalmente diante do processo atual de datação da vida, da existência de uma biografia digital⁷². Como ressalta Ana Frazão, os “dados pessoais, os quais, processados por algoritmos, são capazes de fazer diagnósticos e classificações dos usuários que, por sua vez, podem ser utilizados para limitar suas possibilidades de vida”.⁷³

Em se tratando de dados sensíveis de pessoas com deficiência, deve-se melhor compreender o alcance do consentimento e se este é conferido de forma livre, autônoma pelo paciente, e não por mero preenchimento de formulários, termos padronizados disponibilizado nas redes sem dar sequer opções aos consumidor-usuário-paciente. Muitas das vezes, os pacientes concordam por meio de um clique com o acesso aos seus dados por terceiros em *sites* de laboratórios, hospitais, planos de saúde, geralmente, em troca de vantagens imediatas, serviços mais céleres, sem muitas vezes avaliar o conteúdo dos termos e sem ter o devido esclarecimento da dimensão da autorização concedida.

O consentimento livre e esclarecido é uma autorização, qualificada como um fato jurídico humano, mais especificamente, um negócio jurídico unilateral, fruto de uma declaração de vontade que dispensa outra manifestação e, por isso, deve observar os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil.

No caso das pessoas com deficiência, também é assegurado o consentimento para tratamento de seus dados sensíveis, pois a deficiência não impede o livre exercício da personalidade nem é sinônimo de incapacidade decisória, de falta de autonomia. No entanto, é necessário analisar a competência da pessoa com deficiência no ato decisório específico, a fim de avaliar suas habilidades cognitivas para expressar sua vontade de forma válida. O EPD é expresso quanto à necessidade de obter o consentimento livre e esclarecido para realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica (arts. 12, 13), o que se estende para o tratamento de dados pessoais.

A LGPD proíbe o tratamento de dados pessoais obtidos mediante vício de consentimento (art. 8º, § 3º, LGPD) e permite a revogação a qualquer momento nos termos do art. 8º, § 5º, o que demonstra a preocupação com a tutela da autonomia da pessoa, mas ela nem sempre é observada.

Dessa forma, em diversas situações, e em particular no caso de pessoas com deficiência, não basta o consentimento do paciente para permitir o acesso a seus dados médicos para garantir a segurança, guarda e armazenamento das informações. É preciso outros mecanismos de proteção dos dados que garantam a segurança, como a anonimização dos dados, ações regulatórias e ferramentas tecnológicas de privacidade⁷⁴.

É possível, portanto, conciliar a tecnologia, os estudos, o desenvolvimentos de novos tratamentos, técnicas, pesquisas sem expor os pacientes, sem que haja uma classificação das pessoas pelos seus dados pessoais sensíveis, capaz de segregá-los, estigmatizá-los com fins preditivos que não para proteção da saúde, e para fins de pesquisa em que se garante o sigilo. Mas para isso não basta a simples assinatura ou um de acordo no *site* ou no aplicativo, é preciso mais instrumentos de segurança a serem utilizados pelos controladores, operadores, médicos, hospitais, laboratórios, provedores e todos aqueles que têm acesso aos dados sensíveis.

Considerações finais

O tratamento de dados pessoais de pessoas com deficiência deverá sempre ser realizado em seu benefício e proteção, de modo a enaltecer sua autonomia e inclusão social e evitar qualquer traço paternalista. A carência de tratamento específico a respeito das pessoas com deficiência não impede a leitura sistematizada entre a LGPD e os Estatutos protetivos, em especial no caso, o EPD. Mais do que isso, a CDPD dedicou dispositivo específico sobre o respeito à privacidade e proteção dos dados pessoais na área da saúde e de reabilitação e, portanto, tem aplicação

imediate. Cabe ao intérprete empreender uma interpretação das normas infraconstitucionais à luz dos preceitos convencionais (*rectius*: constitucionais) e sistêmica entre a LGPD e o EPD.

É consenso que qualquer tratamento de dados influencia a representação da pessoa na sociedade e, por isso, pode afetar a sua personalidade e seus direitos fundamentais. Sintomático, portanto, o caso das pessoas vulneráveis, uma vez que são vítimas de discriminação e estigma sociais. Uma normativa descuidada em relação às necessidades e demandas específicas de grupos vulneráveis reforça a invisibilidade e potencializa a violação de seus direitos, além de não permitir seu pleno reconhecimento no ambiente social como pessoas dotadas de igual consideração. A utilização de dados sensíveis com finalidade discriminatória, nesse contexto, é a que merece repressão mais imediata e enérgica por parte do Direito.

A obtenção do consentimento para fins médicos deve assegurar a participação da pessoa com deficiência, no grau máximo, em caso de situação de curatela, em estrita observância do art. 12, § 1º, do EPD. O suprimento do consentimento da pessoa com deficiência deve ser sempre excepcional e episódico, bem como temporário, quando feita a interpretação sistemática do parágrafo único do art. 11 do EPD.

Indispensável, no entanto, atentar-se para o conteúdo e a forma das informações sobre o tratamento de dados pessoais, para fins médicos ou não, que deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário/paciente, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária e adequada à pessoa com deficiência, submetidas ou não à curatela, preservando ao máximo sua participação no processo decisório do consentimento.

Com o objetivo de proteger a igualdade e a liberdade das pessoas com deficiência, é fundamental tutelar de forma mais enérgica o núcleo duro dos dados pessoais, ou seja, aquelas que potencialmente causam discriminação em relação ao titular dos dados. A LGPD hipertrofiou o consentimento como principal mecanismo de proteção dos dados pessoais, no entanto, menosprezou que pessoa em situação de vulnerabilidade nem sempre será protegida com o foco na autodeterminação das informações pessoais. Indispensável verificar a habilidade concreta da pessoa com deficiência para controlar seus dados sensíveis, bem como vedar o tratamento de determinadas informações, sempre que isto for necessário para sua proteção.

Referências

- ALMEIDA, Vitor. *A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
- BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (Org.). *Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas* – Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. Rio de Janeiro: Processo, p. 249-274, 2016.
- BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. A tutela das vulnerabilidades na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Org.). *Da dogmática à efetividade do direito civil* – Anais do Congresso Internacional de Direito Civil Constitucional (IV Congresso do IBDCIVIL). Belo Horizonte: Fórum, 2017.
- BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor (Org.). *Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República*. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2018.
- BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de direito do consumidor*. 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- CALIXTO, Marcelo Junqueira. O princípio da vulnerabilidade do consumidor. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Org.). *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- FRANÇA, Genival Veloso de. *Comentários ao Código de Ética Médica*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
- FRANÇA, Genival Veloso de. *Direito médico*. 11. ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
- FRAZÃO, Ana. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Principais repercussões para a atividade empresarial. Parte I. Disponível em: [\[http://anafracao.com.br/files/publicacoes/2018-08-30-A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercucoes_para_a_atividade_empresarial_Parte_I.pdf\]](http://anafracao.com.br/files/publicacoes/2018-08-30-A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercucoes_para_a_atividade_empresarial_Parte_I.pdf). Acesso em: 20.02.2019.
- GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Trad. Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda. La libertad de creación y producción científica en la ley de investigación biomédica: objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la ley. In: SÁNCHEZ-CARO, Javier; ABELLÁN, Fernando (Coord.).

Investigación biomédica en España: aspectos bioéticos, jurídicos y científicos. Granada: Comares, 2007.

KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema diferenciador. *Revista de Direito do Consumidor: RDC*, São Paulo, v. 24, n. 99, p. 101-123, 2015.

MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar ao consumidor. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 827, p. 11-48, 2004.

MENDES; Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120, p. 555-587, nov.-dez. 2018.

MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Desvendando o conteúdo da capacidade civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. *Revista Pensar*, Fortaleza, v. 21, n. 2, maio-ago. 2016.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, p. 159-180, set.-dez. 2018.

NILO, Alessandro Timbó; AGUIAR, Mônica. Responsabilidade civil dos médicos e contratos de tratamento. *Revista dos Tribunais*, v. 997, p. 105-134, nov. 2018.

PEREIRA, André Gonçalo Dias. Formulários para prestação do consentimento: uma proposta para o seu controle jurídico. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis*, Porto Alegre, v. 3, p. 65-90, 2001.

PEREIRA, Paula Moura Francesconi de Lemos. O uso da internet na prestação de serviços médicos. In: MARTINS, Guilherme Magalhães (Org.). *Direito privado e internet*. São Paulo: Atlas, 2014, v. 1.

RODOTÀ, Stefano. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Org., sel. e apr.). *A vida na sociedade de vigilância – A privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *Il diritto di avere diritti*. Roma: Laterza, 2012.

SCHAEFER, Fernanda. *Proteção de dados de saúde na sociedade de informação: a busca pelo equilíbrio entre privacidade e interesse social*. Curitiba: Juruá, 2010.

SCHRAMM, Fermin Roland. Bioética da Proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da globalização. *Revista Bioética*, v. 16, n. 1, 2008.

SOLOVE, Daniel J. *The digital person: technology and privacy in the information age*. New York and London: New York University Press, 2004.

SOUZA, Alex Pereira, COUTO FILHO, Antonio Ferreira. *Responsabilidade civil médica e hospitalar*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SOUZA, Eduardo Nunes de. *Do erro à culpa: na responsabilidade civil do médico*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. *Pensar*, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 108-146, jan.-abr. 2017.

TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade médica na experiência brasileira contemporânea. *Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC*, Rio de Janeiro, ano 1, v. 2, p. 41--75, abr.-jun. 2000.

TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. *Harvard Law Review*. Cambridge, v. IV, n. 5, dez. 1890.

1

.Professora Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Direito pela UERJ e em Ciências pela ENSP/FIOCRUZ. Procuradora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (aposentada). Presidente do Instituto Brasileiro de Biodireito e Bioética (IBIOS). Advogada.

2

.Doutora e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-Graduada em Advocacia Pública pela CEPED-UERJ. Pós-Graduada em Direito da Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra. Professora da Pós-Graduação *Lato Sensu* do Curso de Direito Civil-Constitucional do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino de Direito (CEPED-UERJ) e da Pós-Graduação da Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Professora da Universidade Unilasalle Rio de Janeiro. Tesoureira do Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil e Diretora Financeira do Instituto de Biodireito e Bioética – IBIOS. Advogada.

3

.Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor Adjunto de Direito Civil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (ITR/UFRRJ). Professor convidado da PUC-Rio, EMERJ, ESAP/PGE-RJ e FDC/UNIFLU. Vice-Diretor do Instituto Brasileiro de Biodireito e Bioética (IBIOS). Advogado.

4

.RODOTÀ, Stefano. *Il diritto di avere diritti*. Roma: Laterza, 2012. p. 322.

5

.O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto interdisciplinar e interinstitucional (UFRJ, UFF, UERJ e FIOCRUZ) denominado "Uma perspectiva de justiça mais inclusiva: aplicação do enfoque dos funcionamentos à saúde, à educação, à tecnologia e aos direitos de pessoas com deficiências", aprovado pelo Programa de Apoio à Pós-Graduação e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Tecnologia Assistiva no Brasil (PGPTA), objeto do Edital "Tecnologia Assistiva no Brasil e Estudos sobre Deficiência (PGPTA) 59/ 2014".

6

.STJ, REsp 1681690-SP, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.04.2018, publ. 03.05.2018; STJ, REsp 1682836-SP, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.04.2018, publ. 30.04.2018. O STJ já utilizou ainda a expressão hipervulnerabilidade para designar pessoas em situação de fragilidade agravada: STJ, REsp 1329556-SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2014.

7

.STJ, REsp 1378557-RS, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2013, publ. 21.03.2014.

8

.Sobre o assunto, ver BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. A tutela das vulnerabilidades na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Org.). *Da dogmática à efetividade do direito civil* – Anais do Congresso Internacional de Direito Civil Constitucional (IV Congresso do IBDCIVIL). Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 37-50.

9

.SCHRAMM, Fermin Roland. Bioética da proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da globalização. *Revista Bioética*, v. 16, n. 1, 2008. p. 20.

10

.Há também menção a três espécies de vulnerabilidade: técnica, contábil e fática ou socioeconômica. Cf. CALIXTO, Marcelo Junqueira. O princípio da vulnerabilidade do consumidor. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Org.). *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006., v. 1. p. 323-324. A evolução levou ao reconhecimento de mais uma espécie de vulnerabilidade denominada de informacional. Ver, sobre o assunto, BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de direito do consumidor*. 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 112.

11

.MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 117-128.

12

.Para Maria Celina Bodin de Moraes, a igualdade é a manifestação primeira da dignidade; deve ser considerada, contudo, não em sua formulação inicial, traduzida na afirmativa "todos são iguais perante a lei", mas em sua forma mais avançada, denominada "igualdade substancial", que leva em conta as desigualdades de fato existentes entre as pessoas, em decorrência de suas distintas condições psicofísicas, sociais e econômicas (Op. cit., p. 81-115).

13

.TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*, 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 25-62.

14

.Como todas as pessoas são vulneráveis, é preciso identificar as necessidades de cada grupo, para que seja estabelecida a tutela que lhe é adequada. A proteção que decorre da cláusula geral implícita na Constituição da República protege todos, mas exige provocação individual ou por meio de ações coletivas diante de cada lesão a direitos. O reconhecimento da situação de cada um dos diferentes grupos, como vem sendo feito com as crianças e os adolescentes, com os consumidores e com a pessoa idosa, facilita o acesso e efetiva a proteção constitucional. Vários grupos, de que é exemplo a população LGBTTI, por não terem sido reconhecidos, vêm lutando pontualmente por seus direitos, à espera de leis especiais que possam efetivamente proteger sua dignidade.

15

.Como explicitado pelo EPD, a Convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 09 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

16

.Cf. ALMEIDA, Vitor. *A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 109-193; BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor (Org.). *Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República*. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2018. p. 61-69; BARBOZA, Heloisa Helena.; ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (Org.). *Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas* – Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. Rio de Janeiro: Processo, 2016. p. 249-274; MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Desvendando o conteúdo da capacidade civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. *Revista Pensar*, Fortaleza, v. 21, n. 2, maio-ago. 2016.

17

.GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Trad. Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 11-17.

18

.Observe-se que na era digital a permanência virtual de uma pessoa não cessa necessariamente com sua morte.

19

.RODOTÀ, Stefano. *Il diritto di avere diritti*. Roma: Laterza, 2012. p. 319-320.

20

.RODOTÀ, Stefano. *Il diritto di avere diritti*. Roma: Laterza, 2012. p. 320-321.

21

.RODOTÀ, Stefano. *Il diritto di avere diritti*. Roma: Laterza, 2012. p. 321.

22

.O “direito a estar só ou direito a ser deixado só” aparece como centro da definição da *privacy* consagrada por Warren e Brandeis em 1890 e amplamente difundida, a ponto de ser adotada expressamente pela Suprema Corte Americana (WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. *Harvard Law Review*, Cambridge, v. IV, n. 5, dez. 1890).

23

.Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, “a ampliação dos direitos da personalidade, no nível do Código Civil, deve ser atribuída ao art. 21, interpretando-se a ‘inviolabilidade da vida privada’ não como a tímida tutela do microcosmo da casa, mas como o espaço (inviolável) da liberdade de escolhas existenciais” (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Ampliando os Direitos da Personalidade. In: BODIN DE MORAES, Maria Celina. *Na medida da pessoa humana*: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 148).

24

.DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 23.

25

.O art. 21 do Código Civil foi objeto da Ação Direita de Inconstitucionalidade 4815, que versava sobre a questão das biografias não autorizadas, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, que “julgou procedente o pedido formulado na ação direta para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas)”.

26

.RODOTÀ, Stefano. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Org., sel. e apr.). *A vida na sociedade de vigilância – A privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 92.

27

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância*, cit., p. 95.

28

.“O direito à privacidade atualmente apresenta seu caráter individualista e exclusivista – que o caracterizam basicamente como uma liberdade negativa – diluídos, e assume feições de uma disciplina na qual merecem consideração a liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade. Neste panorama, a proteção de dados pessoais assume caráter de um direito fundamental. A privacidade e a proteção de dados pessoais relacionam-se diretamente com múltiplos valores e interesses, não raro contraditórios entre si” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 408).

29

.Os princípios norteadores da Lei 12.965/2014 encontram-se estampados em seu art. 3º, que estabelece: “I – garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II – proteção da privacidade; III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV – preservação e garantia da neutralidade de rede; V – preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII – preservação da natureza participativa da rede; VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei”.

30

.As autoras criticam a leitura de alguns intérpretes do MCI a respeito da posição preferencial da liberdade de expressão. Afirmam, com razão, que “o Marco Civil realizou uma valorização da liberdade de expressão [...]. Todavia, isso não significa que o intérprete deva atribuir à liberdade de expressão a condição de direito absoluto, imune a qualquer limite, nem mesmo que deva estabelecer uma espécie de hierarquia prévia entre as normas constitucionais” (TEFFÉ, Chiara Spadaccini; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. *Pensar*, Fortaleza, v. 22, n. 1, jan.-abr. 2017. p. 112 e 113-116). Cabe destacar que a disposição estabelecida no art. 3º do Marco Civil da Internet é compatível com o disposto na Resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br/RES/2009/003/P) que estabeleceu dez princípios para a governança e uso da internet no País: “1. Liberdade, privacidade e direitos humanos; 2. Governança democrática e colaborativa; 3. Universalidade; 4. Diversidade; 5. Inovação; 6. Neutralidade da rede; 7. Inimputabilidade da rede; 8. Funcionalidade, segurança e estabilidade; 9. Padronização e interoperabilidade; 10. Ambiente legal e regulatório”.

31

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância*, cit., p. 93.

32

.“A sanção da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no dia 14 de agosto de 2018, é resultado de um esforço de, pelo menos, oito anos de debates e duas consultas públicas, que se iniciaram desde a elaboração da primeira versão do anteprojeto de lei pelo Ministério da Justiça em 2010.¹ A partir de um processo democrático realizado na internet e de forma muito semelhante ao debate público do Marco Civil da Internet, as consultas públicas realizadas em 2010 e 2015 resultaram em um total de quase 2.000 contribuições da sociedade civil, especialistas, órgãos do governo e empresas. Em 2016, o Projeto foi enviado à Câmara dos Deputados e passou a tramitar em paralelo com Projeto de Lei do Senado sobre o mesmo tema (PLS 330/2013). Na Câmara dos Deputados, foi criada a Comissão Especial de Proteção de Dados Pessoais e designado como relator o Deputado Orlando Silva, que, após uma série de audiências públicas, seminários e reuniões intersetoriais, conduziu a matéria para a sua aprovação por unanimidade em plenário. Em seguida, por meio da relatoria do Senador Ricardo Ferraço, o PLC 53/2018 foi aprovado por unanimidade também no Senado Federal” (MENDES; Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120, nov.-dez. 2018. p. 576).

33

.Vale frisar que a lei ainda se encontra no período de *vacatio legis* e de acordo com o art. 65, salvo alguns dispositivos elencados no seu primeiro inciso, todos os demais entram em vigor após 24 meses da data de sua publicação. “Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei 13.853, de 2019) I – dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e; II – 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos”. (Incluído pela Lei 13.853, de 2019)

34

.MENDES; Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 576.

35

.Os autores aduzem que “esse modelo está amparado em três características centrais: i) amplo conceito de dado pessoal; ii) necessidade de que qualquer tratamento de dados tenha uma base legal; e iii) legítimo interesse como hipótese autorizativa e necessidade de realização de um teste de balanceamento de interesses” (Ibid., p. 576).

36

.Ibid., p. 576.

37

.RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância*, cit., p. 233.

38

.MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 176-177.

39

.Cabe lembrar que a Lei 12.414, de 09 de junho de 2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, conhecida como Lei do Cadastro Positivo, já proibia no art. 3º, § 3º, II, para os fins da Lei, as anotações de “informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas”.

40

.COTS, Márcio. *Lei geral de proteção de dados pessoais comentada*. São Paulo: Ed. RT, 2018. p. 135.

41

.Com exceção do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes previsto no art. 14 da LGPD.

42

Cabe frisar que a atual redação do § 4º da LGPD foi dada pela Lei 13.853, de 08 de julho de 2019, após já ter sofrido modificação por força da Medida Provisória 869/2018.

43

O § 5º do art. 11 da LGPD foi incluído pela Lei 13.853/2019.

44

.O Decreto 8.954, de 10 de janeiro de 2017, foi revogado pelo Decreto 10.087, de 05 de novembro de 2019. No entanto, o decreto revogado instituía o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência. Em seu art. 1º estabelecia que a finalidade era “criar instrumentos para a avaliação biopsicossocial da deficiência e estabelecer diretrizes e procedimentos relativos ao Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Cadastro-Inclusão”. O artigo 4º, por sua vez, estabelecia as competências do Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência e sua composição é tratada no art. 5º. O Comitê poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, e especialistas em assuntos relacionados às suas competências (art. 6º). Atualmente, com a revogação por força do Decreto 10.087, em seu inciso CCCXCI, mesmo após mais de 4 (quatro) anos de vigência do EPD o Cadastro-Inclusão ainda não foi implementado. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SNDPD), divulgou que pretende lançar o projeto “Brasil Inclusão” no ano de 2020 com o objetivo de editar regulamentações, criar uma plataforma de cadastro único, adotar medidas no campo de empregabilidade, entre outras ações em benefício das pessoas com deficiência.

45

.BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vítor (Org.). *Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 313-315.

46

.Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, considerando 75.

47

.SCHAEFER, Fernanda. *Proteção de dados de saúde na sociedade de informação: a busca pelo equilíbrio entre privacidade e interesse social*. Curitiba: Juruá, 2010. p. 61.

48

.Nesse sentido: RODOTÀ, Stefano. In: MORAES, Maria Celina Bodin de (Org., sel. e apr.). *A vida na sociedade de vigilância – A privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

49

.A Resolução 466/2012 do CNS, que estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos trata da proteção dos dados dos participantes de pesquisa nos itens III.2, IV.3, e, IV.7, IV.8, X.1, 3, a.

50

.Carlos Nelson Konder critica a criação de novas categorias ou requalificação dos tipos padrão de vulnerabilidade, pois, mais importante do que construir novas terminologias é garantir por meio de instrumentos jurídicos próprios e adequados à tutela das situações existenciais. Cf. KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema diferenciador. *Revista de Direito do Consumidor: RDC*, São Paulo, v. 24, n. 99, 2015. p. 101-123. *passim*.

51

.Cf. BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vítor (Org.). *Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República*. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2018. p. 74-90.

52

.Cf. PEREIRA, Paula Moura Francesconi de Lemos. O uso da internet na prestação de serviços médicos. In: MARTINS, Guilherme Magalhães (Org.). *Direito privado e internet*. São Paulo: Atlas, 2014. p. 259-299.

53

.A Resolução 1.974/2011, que trata da propaganda em Medicina, regula divulgação de imagem nas mídias sociais (art. 13).

54

.Processo-Consulta CFM 50/2016 – Parecer CFM 14/2017. É permitido o uso do WhatsApp e plataformas similares para comunicação entre médicos e seus pacientes, bem como entre médicos e médicos, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo clínico de uma instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as informações passadas tem absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2016/50>. Acesso em: 20.02.2019.

55

Cabe destacar que em razão da pandemia da covid-19, a telemedicina se tornou uma importante ferramenta para o seu enfrentamento. Em 06 de fevereiro de 2020, foi promulgada a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. O Conselho Federal de Medicina enviou ofício em 19 de março de 2020 ao Ministério da Saúde para informar que decidiu aperfeiçoar ao máximo a eficiência dos serviços médicos prestados e, em caráter de excepcionalidade e enquanto durar a batalha de combate ao contágio da covid-19, reconhecer a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, além do disposto na Resolução CFM nº 1.643, de 26 de agosto de 2002. Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde editou a Portaria 467/2020, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19. Em 15 de abril de 2020, foi promulgada a Lei Federal n. 13.989, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). Nos termos do art. 3º da referida Lei, "entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde".

56

.No âmbito internacional destacam-se a Convenção para a proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais – CEDH, art. 8º, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, arts. 3º, 7º, 8º, a Convenção do Conselho da Europa para proteção de pessoas em relação ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal e as Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho, como a Directiva 2002/58/CE, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrônicas; Directiva 2002/58/CE, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações electrónicas; Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados. Ganha destaque o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), que passou a ser aplicado em maio de 2018 (artigo 9(1) e (2), considerando 71 e 51).

57

.Cf. TEPEDINO, Gustavo José Mendes. A responsabilidade médica na experiência brasileira contemporânea. *Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC*, Rio de Janeiro, ano 1, v. 2, abr.-jun. 2000. p. 41-75.

58

.A Lei 12.527/2011 regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 11.111, de 05 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

59

.O Projeto de Lei 281/2012 do Senado Federal, remetido à Câmara dos Deputados, PL 3514/2015, propõe a alteração o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990, sendo relevante para a veiculação de dados de saúde os seguintes dispositivos: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: XI – a privacidade e a segurança das informações e dados pessoais prestados ou coletados, por qualquer meio, inclusive o eletrônico, assim como o acesso gratuito do consumidor a estes e a suas fontes; “Art. 72-A. Veicular, exibir, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou de qualquer forma ceder ou transferir dados, informações ou identificadores pessoais sem a autorização expressa e o consentimento informado de seu titular. Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único. Não constitui crime a prática dos atos previstos no caput: I – entre fornecedores que integrem um mesmo conglomerado econômico; II – em razão de determinação, requisição ou solicitação de órgão público.” Disponível em: [\[www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2052488\]](http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2052488).

60

.Genival Veloso de França, mesmo com o disposto no Código de Ética Médica (Capítulo I, XX), que não trata a relação médico-paciente como de consumo, defende que o médico não pode fugir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de “lei de ordem pública e interesse social” (FRANÇA, Genival Veloso de. *Comentários ao Código de Ética Médica*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 36). Cf. MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar ao consumidor. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 827, 2004. p. 11-48.

61

.BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 969015/SC. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, DJe 28.04.2011.

62

.Em sentido contrário: SOUZA, Eduardo Nunes de. *Do erro à culpa: na responsabilidade civil do médico*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 95-96; SOUZA, Alex Pereira, COUTO FILHO, Antonio Ferreira. *Responsabilidade civil médica e hospitalar*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 44; NILO, Alessandro Timbó; AGUIAR, Mônica. Responsabilidade civil dos médicos e contratos de tratamento. *Revista dos Tribunais*, v. 997, nov. 2018. p. 105-134.

63

.Processo-Consulta CFM 47/2016 – Parecer CFM 21/2017 A Resolução do CFM 1.821/2007 regulamenta as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes. Os profissionais de saúde com acesso ao prontuário eletrônico estão obrigados à proteção do sigilo por força do Art. 154 do Código Penal brasileiro.

64

.Lei 6.259/1975; Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.

65

.Resolução 1.605/2000 do CFM – Art. 2. Nos casos do art. 269 do Código Penal, onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente.

66

.A respeito da responsabilidade, observar o disposto na Lei: arts. 186, 932, III, 951, CC, arts. 14, § 4º, 20, CDC, art. 32, IV, Lei 12.527/2011, arts. 10, 15, Lei 12.965/2014, art. 13, Decreto 8.771/2016, arts. 31, 32, 42 a 45 da Lei 13709/2018 – LGPD.

67

.V. arts. 21 e 22 da Lei 3.268/1957, Resolução 1.617/2001 do CFM, Resolução 2.145/2016, alterada pela Resolução 2.158/2017, ambas do CFM.

68

.O tempo de guarda do prontuário médico, de acordo com a nova Lei 13.787/ 2018, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente, é de 20 anos (art. 6º), assim como prevê a Resolução 1.821/2007 do CFM (artigo 8º). O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) em seu artigo 10, I, estabeleceu o prazo de 18 anos para os hospitais manterem os registros das atividades desenvolvidas por meio de prontuários; já a Lei 9.434/97, referente à remoção de órgãos, tecidos, e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento, prevê o prazo de cinco anos para guarda de prontuários (artigo 3º, § 1º).

69

.A Lei 13.787/2018 foi publicada em 28 de dezembro de 2018 e entrou em vigor nessa data. Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente.

70

.A Resolução 1.821/2007 do CFM aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. (Resolução CFM 2.218/2018 – Revoga o artigo 10º da Resolução CFM 1.821/2007, de 23 de novembro de 2007.)

71

.A título de exemplo, merece citar o Código de Ética Médica, a Resolução 2.178/2017 do CFM, que regulamenta o funcionamento de aplicativos que oferecem consulta médica em domicílio e a Resolução CFM 1.974/2011, que trata da propaganda em Medicina.

72

.V. SOLOVE, Daniel J. *The digital person: technology and privacy in the information age*. New York and London: New York University Press, 2004.

73

.FRAZÃO, Ana. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Principais repercussões para a atividade empresarial. Parte I. Disponível em: [http://anafracao.com.br/files/publicacoes/2018-08-30-A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercussoes_para_a_atividade_empresarial_Parte_I.pdf]. Acesso em: 20.02.2019.

74

.CARVALHAL, Gustavo Franco et al. Recomendações para a proteção da privacidade do paciente. *Revista Bioética*, v. 25, n. 1, 2017. p. 39-43. Disponível em: [http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1133]. Acesso em: 20.02.2019.

Capítulo 6. Tratamento de dados para a concessão de crédito

Milena Donato Oliva¹

Francisco de Assis Viégas²

1. Introdução: impacto da LGPD no mercado de concessão de crédito

A proteção de dados pessoais³ tem sido objeto de grande reflexão na sociedade contemporânea, caracterizada pela coleta indiscriminada de dados e pelo permanente monitoramento das pessoas para atender às crescentes exigências de segurança interna e externa, interesses de mercado e reorganização da gestão pública.⁴ Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018, ou LGPD), o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com disciplina própria voltada à regulamentação da proteção dos dados pessoais, com ampla incidência em todas as operações de tratamento de dados de pessoas físicas.⁵

A LGPD sedimentou novo paradigma de proteção dos dados: estes não são considerados de titularidade de quem os coleta, e sim da pessoa natural à qual se referem.⁶ Essa premissa norteia a disciplina legislativa e a identificação da normativa a ser aplicada ao caso concreto. Aquele que coleta e trata dados, por lidar com bens alheios, passa a ter como dever fundamental prestar contas: como e quais dados são coletados, como são tratados, armazenados etc.⁷

A preocupação legislativa em criar instrumentos efetivos de proteção aos titulares de dados pessoais objeto de tratamento nos mais diversos setores (públicos e privados) reflete a importância dos dados na sociedade da informação.⁸ O fluxo, a coleta e o tratamento dos dados pessoais têm sido verdadeiros combustíveis para as mais variadas atividades, inclusive no âmbito de funções públicas (definição de políticas públicas, auxílio em investigações etc.),⁹ e casos emblemáticos recentes – como o “Sistema de Crédito Social” na China¹⁰ e o modelo de assistência social aos desempregados a partir da criação de perfis pessoais na Polônia¹¹ – demonstram a potencialidade de lesão à pessoa humana pela coleta e utilização de seus dados, cujo tratamento, por isso mesmo, deve se sujeitar a rigoroso controle.¹²

Entre os muitos setores em que o tratamento de dados pessoais assume função relevante, chama atenção, em especial, o mercado de crédito, em que a avaliação do risco de inadimplência possui fundamental importância para a definição do interesse ou não na contratação (ex.: recusa de concessão de crédito para pessoa inscrita em cadastro negativo) e para a delimitação dos termos e das

condições do contrato (concessão de crédito a juros mais baixos para pessoa com alto *rating* de crédito).

A relevância dos dados pessoais no âmbito do mercado de crédito encontra-se refletida, por exemplo, na regulamentação específica dos denominados cadastros positivos (Lei 12.414/2011, recentemente alterada pela Lei Complementar nº. 166/2019, e regulamentada pelo Decreto nº. 9.936/2019), na formação de precedentes vinculantes para pacificar o entendimento dos tribunais acerca dos parâmetros de legalidade do sistema *credit scoring* (REsp 1.457.199 e 1.419.697 e Enunciado 550 da Súmula do STJ) e na disciplina do CDC quanto aos cadastros de inadimplentes.

Com a incidência da LGPD toda vez que se estiver diante de tratamento de dados pessoais,¹³ sua disciplina apresenta relevantes influxos no âmbito de setores de tratamento de dados pessoais já regulamentados em leis específicas. Nesses casos, deve-se proceder à harmonização sistemática da LGPD com a regulamentação vigente, em verdadeiro “diálogo das fontes”.

Diante da pluralidade de fontes normativas, não pode o intérprete levar em conta uma regra isoladamente considerada, ainda que apropriada para a hipótese, mas sim o conjunto das normas inserido no ordenamento.¹⁴ Nessa direção, tem-se destacado a necessidade de se promover “diálogo das fontes” para a busca da solução coerente e harmônica no caso concreto.¹⁵ Com efeito, não existindo propriamente antinomia entre os diversos diplomas, mas apenas prismas regulatórios diversos, deve-se buscar interpretação que os harmonize, de maneira a atender, da melhor forma possível, aos múltiplos mandamentos normativos.

Especificamente no que se refere à regulamentação do tratamento de dados pessoais no mercado de crédito, faz-se necessário examinar de que forma a LGPD – que buscou fortalecer os instrumentos de efetividade para a proteção dos “direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” (art. 1º, LGPD) – dialoga com o CDC, com a Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011), bem como com o sistema *credit scoring*.

2. Tratamento de dados para a formação de cadastros de inadimplentes: o cadastro negativo

O cadastro negativo recebe essa denominação por se caracterizar pelo registro de informações de inadimplência do consumidor. No jargão comum, diz-

-se “negativado” o consumidor que consta como inadimplente nas entidades de proteção ao crédito.¹⁶ O cadastro positivo, por sua vez, difere do negativo não por conter apenas informações positivas, isto é, de adimplemento, mas por apresentar o histórico de crédito completo daquele consumidor (*vide* item 3.1, *infra*).¹⁷ Ao passo que, no cadastro negativo constará, exemplificativamente, que a terceira prestação da compra do televisor está inadimplida, o cadastro positivo terá informações completas acerca da vida creditícia daquele consumidor: quantos contratos de crédito ele possui no mercado, quantas parcelas são devidas em cada um deles, quantas restam pendentes e, inclusive, se houver, quais restam inadimplidas. Dessa sorte, no cadastro positivo, também pode haver informações

negativas. A “positividade” desse cadastro advém da possibilidade de viabilizar aferição concreta do risco de inadimplência relativo àquele consumidor individualizado, o que possibilitaria, em tese, tratamento mais benéfico a consumidores com bom histórico de crédito.

Para a inserção do consumidor no cadastro negativo, não é necessário seu consentimento, mas apenas sua ciência prévia.¹⁸ O CDC não estabelece prazo mínimo entre a notificação ao consumidor e sua inserção no banco de dados de proteção ao crédito, mas, na prática, é comum ser conferido prazo de dez dias para que o consumidor regularize sua situação antes de sua “negativação”.¹⁹ Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de comunicação, por si só, ainda que a informação seja verdadeira, já caracteriza a ilegalidade do registro e, conseqüentemente, a possibilidade de retirada do nome do cadastro negativo, além de ressarcimento por danos eventualmente sofridos.²⁰

Para abertura do cadastro positivo, por sua vez, o consentimento prévio do consumidor deixou de ser imprescindível a partir das alterações promovidas pela Lei Complementar nº. 166/2019, ficando o gestor²¹ autorizado a “abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas”.²² Isso não significa, contudo, que a vontade do titular dos dados tenha se tornado irrelevante no âmbito do tratamento de dados pessoais no cadastro positivo. Ao contrário, exige-se que o gestor, diretamente ou por intermédio de fontes, comunique o titular dos dados acerca da abertura do cadastro positivo em até 30 (trinta) dias da data da abertura, informando-lhe de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados (Lei nº. 12.414/2011, art. 4º, § 4º).²³

Soma-se a tal obrigação imposta ao gestor a previsão de que a disponibilização das informações do cadastrado a consulentes somente é autorizada depois de decorridos 60 (sessenta) dias da abertura do cadastro positivo.²⁴ Assim, o titular dos dados que compõem o cadastro positivo poderá cancelar a abertura do cadastro antes mesmo que a disponibilização dos dados seja possível, sendo-lhe garantido, ainda, o direito de obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro a qualquer momento, desde que solicitado (Lei nº. 12.414/2011, art. 5º, I).²⁵

A diferença para abertura do cadastro positivo e do negativo justifica-se: a informação negativa, pontual, é cadastrada no interesse legítimo dos fornecedores. Já a formação do histórico de crédito implica que o consumidor abra mão de parcela importante da sua privacidade, haja vista que seus hábitos de consumo e seu comportamento creditício constarão no cadastro. Esse histórico de crédito não tem por objetivo tutelar interesse legítimo do fornecedor, mas apenas e tão somente propiciar a formação de “perfil” que poderá ser benéfico ao consumidor caso ele seja reputado um “bom pagador”.

As entidades arquivistas (qualificadas como gestoras sob a ótica da Lei nº. 12.414/2011), embora não sejam fornecedoras *stricto sensu*, por não se enquadrarem na definição constante no art. 3º do CDC – afinal não prestam serviços a consumidores –, são reputadas fornecedoras por equiparação.²⁶ Com efeito, prestam relevante atividade que tem impacto direto no mercado de

consumo, ditando o acesso ao crédito por parte dos consumidores. E agora, com a LGPD, sua responsabilidade fica recrudescida, haja vista o reconhecimento de que sua atividade interfere com direitos fundamentais.

As disposições do CDC e da Lei de Cadastro Positivo devem ser lidas em consonância com a axiologia constitucional, refletida em grande parte na LGPD, que institui novo paradigma de proteção aos dados pessoais. Rompe-se com a lógica de que a propriedade dos dados é do coletor, reconhecendo-se que o titular da informação é aquele ao qual ela se refere. É nesse contexto emancipador que as disposições legais devem ser interpretadas, fomentando o direito ao acesso, à retificação, à veracidade, à objetividade, com vistas a se coibir abusos e violações a garantias fundamentais.²⁷

O CDC aborda, em apenas um dispositivo, o cadastro negativo. Confira-se:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o *caput* deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

O *caput* do artigo trata do relevante direito ao acesso, a possibilitar que o consumidor, gratuitamente, saiba se existem informações suas em determinado cadastro e que informações são essas.²⁸ Essa prerrogativa também é assegurada pela LGPD.²⁹ O § 2º trata da já abordada necessidade de comunicação prévia ao consumidor. O § 3º consagra o direito gratuito de retificação, igualmente reconhecido pela LGPD.³⁰

Quanto à determinação de que, consumada a prescrição, não serão fornecidas quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, bem como a vedação a que se contenham informações negativas referentes a período superior a cinco anos, deve-se interpretar da seguinte maneira: se o prazo prescricional for superior a cinco anos, limita-se a inscrição a cinco anos; se o prazo prescricional for inferior a cinco anos, limita-se a inscrição ao prazo prescricional.³¹ Evidentemente, a prescrição não pode ser de

meios processuais específicos para cobrança da dívida, mas da própria possibilidade de cobrança em si.³²

Controverte-se acerca do termo inicial do prazo de cinco anos: se a contar do vencimento da dívida, isto é, do inadimplemento, ou da negativação do consumidor. Em recente precedente sobre o tema, a Terceira Turma do STJ considerou que,

[...] em razão do respeito à exigibilidade do crédito e ao princípio da veracidade da informação, o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida.³³

O art. 43, § 4º, do CDC estabeleceu que os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres fossem dotados de caráter público. O escopo principal do dispositivo, em uma leitura conjunta com o art. 5º, LXXII, da Constituição, foi permitir aos consumidores o uso do *habeas data* como ferramenta possível de ser utilizada para a consecução judicial das suas informações, bem como para eventual correção ou cancelamento de dados cadastrados de maneira incorreta nos bancos de dados de consumo.³⁴ Preceitua o texto constitucional que o referido remédio pode ser utilizado apenas para obtenção dos dados “constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Ao conferir tal natureza aos arquivos de consumo, portanto, o diploma consumerista materializa mais uma garantia aos consumidores e, ao mesmo tempo, aproxima o interesse público da atuação das entidades arquivistas.³⁵

O consumidor tem direito a que suas informações estejam atualizadas, porque apenas assim serão verdadeiras. Nessa esteira, uma vez paga a dívida, o fornecedor deve solicitar o cancelamento do registro. O CDC não estabelece prazo para tal providência, por parte do fornecedor, de modo que o STJ fixou o entendimento de que,

[...] diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.³⁶

Em seguida, o entendimento foi reproduzido pela Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Importante ressaltar que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380, STJ). A inscrição do devedor, assim, será legítima mesmo que ele tenha ajuizado ação revisional para discutir o débito. Para obstar a inscrição do devedor:

[...] deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado (Temas Repetitivos 31, 32, 33 e 34 do STJ).³⁷

Embora seja dispensada a prévia comunicação ao consumidor quando os dados utilizados para “negativá-lo” tenham sido obtidos publicamente, mediante consulta a registros de distribuição de ações e protestos de títulos,³⁸ deve haver o mesmo engajamento para manutenção da informação atualizada, de maneira que, se a dívida foi paga, a entidade deve envidar esforços para obter essa informação e atualizar seus cadastros. Vale dizer, a coleta de dados vem acompanhada da obrigação de manter esses dados atualizados e, nesse caso, a obrigação não é do fornecedor, que não solicitou a inscrição, mas da entidade arquivista que, de ofício, mediante pesquisa própria, buscou, nos serviços públicos, informação que cadastrou e, portanto, também por meios próprios, deve mantê-la atualizada, sob pena de se responsabilizar por perdas e danos.

O registro, pelo fornecedor, de informação incorreta enseja sua responsabilização nos termos do art. 14 do CDC. Todavia, o STJ tem estendido a defesa consubstanciada na Súmula 385³⁹ ao fornecedor. É ver-se:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler – aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. Recurso especial a que se nega provimento.⁴⁰

De acordo com o art. 39, VII, CDC, “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”. O fornecedor deve observar tal preceito ao inserir informações do consumidor em bancos de dados, de maneira que os dados constantes no cadastro negativo, assim como no positivo, sejam objetivos, sem qualquer informação pessoal ou depreciativa acerca do consumidor,⁴¹ o que vai ao encontro das determinações da LGPD.

Note-se que, a rigor, não é possível separar a atividade de tratamento de informações positivas das informações negativas. Com efeito, consoante ressaltado, o cadastro positivo inclui também informações negativas, haja vista se referir ao histórico de crédito como um todo, com dados positivos e negativos, porque o intuito é se ter um retrato fiel do histórico de crédito daquele consumidor. Entretanto, a Lei do Cadastro Positivo, em seu artigo 14, dispõe que: “As informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados por período superior a 15 (quinze) anos”. Resta a dúvida de como compatibilizar esse preceito com a limitação dos cinco anos constante para cadastro negativo. Ainda que se excluíssem as informações negativas, haveria lacunas no histórico de

crédito, lacunas essas que se referem inevitavelmente a informações negativas. Logo, a não informação, ou seja, a omissão, significa um dado negativo, apenas não explicitado.⁴²

3. Tratamento de dados para a formação de histórico de crédito e atribuição de rating de crédito

3.1. Cadastro positivo

Conforme já apontado no item 2, o denominado cadastro positivo se caracteriza por apresentar (não um cadastro de consumidores inadimplentes, mas) o histórico de crédito completo dos consumidores. Nessa direção, o art. 1º, caput, da Lei 12.414/2011 deixa claro que o cadastro positivo consiste, a rigor, em banco de dados “com informações de adimplemento”, “para formação de histórico de crédito”.⁴³

Desse modo, não obstante tenha se difundido a expressão “cadastro positivo”, apenas os dados concretamente existentes em relação ao histórico de crédito de cada consumidor permitirão a formação de juízo de valor sobre o risco de crédito. Por outras palavras, a existência do histórico de crédito do consumidor, por si só, não indica que seja um “bom pagador” ou um “mau pagador”.

A principal vantagem na difusão dos históricos de crédito diz respeito à previsibilidade do risco na concessão do crédito. Sem o denominado cadastro positivo, limitam-se as informações a que poderia ter acesso o mutuante (aquele que concede o crédito) e a tendência é de que a decisão de conceder o crédito seja realizada com fundamento na existência de informações nos cadastros negativos.

Ademais, ainda que o consumidor não esteja inscrito em cadastros de inadimplentes, a tendência é de que o mutuante, por desconhecer o histórico de crédito do mutuário (aquele que obtém o crédito), exija o máximo possível de garantias que lhe assegurem proteção contra os custos que a eventual inadimplência possa lhe causar. A título ilustrativo, estudo publicado na *Folha de São Paulo* apurou que, no universo de consumidores que apresentavam maior risco de crédito e aderiram ao cadastro positivo, 40% melhoraram sua avaliação, 38% mantiveram o mesmo resultado e 22% tiveram piora na análise de risco de crédito.⁴⁴

Visto que a formação do cadastro positivo envolve a coleta de dados pessoais, a Lei 12.414/2011, em seus arts. 4º e 5º, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº. 166/2019, atribui ao titular dos dados o direito de ser devidamente informado⁴⁵ sobre a formação do seu “cadastro positivo”, a fim de que possa optar livre e gratuitamente pelo cancelamento do cadastro antes que os dados se tornem disponíveis para consulta no banco de dados.

Além disso, diferencia-se a normativa aplicável quanto à possibilidade de disponibilização dos dados constantes no cadastro positivo conforme se trate de: (i) nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; ou (ii) histórico de crédito. Em se tratando da nota ou

pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas, admite-se a disponibilização a consulentes que mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia com o cadastrado após 60 (sessenta) dias da abertura do cadastro, desde que o cadastrado tenha sido devidamente comunicado na forma do art. 4º, § 4º, da Lei nº. 12.414/2011 e não tenha solicitado o cancelamento de seu cadastro:

Lei 12.414/2011, art. 4º, I e IV, “a”: “O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: I – abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas; [...] IV – disponibilizar a consulentes: a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas”.

Lei 12.414/2011, art. 4º, §§ 4º e 7º: “§ 4º. A comunicação ao cadastrado deve: I – ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado; II – ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e III – informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados. [...] § 7º As informações do cadastrado somente poderão ser disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do cadastro, observado o disposto no § 8º deste artigo e no art. 15 desta Lei”.

Já no que se refere ao histórico de crédito propriamente dito, exige-se a “prévia autorização específica do cadastrado” (Lei nº. 12.414/2011, art. 4º, IV, “b”) para que seja lícita a disponibilização a consulentes, cabendo ao gestor o ônus de comprovar a autenticidade e a validade da autorização outorgada pelo cadastro:

Lei 12.414/2011, art. 4º, IV, “b”, e § 8º: “O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: [...] IV – disponibilizar a consulentes: b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado. [...] § 8º. É obrigação do gestor manter procedimentos adequados para comprovar a autenticidade e a validade da autorização de que trata a alínea *b* do inciso IV do *caput* deste artigo”.

Desse modo, a Lei Complementar nº. 166/2019 instituiu o modelo *opt out* para a formação dos bancos de dados contendo o histórico de crédito: em vez de se exigir a manifestação de vontade do consumidor para a abertura do cadastro (modelo *opt in*), o gestor responsável pela administração do banco de dados poderá efetuar a abertura do cadastro positivo mediante comunicação ao consumidor, que poderá optar pelo cancelamento do cadastro (modelo *opt out*).

No entanto, ainda que a criação do cadastro positivo contendo o histórico de crédito seja autorizada sem a necessidade de consentimento prévio do titular dos dados, a efetiva disponibilização do histórico de crédito a consulentes não prescinde da prévia autorização do cadastrado. Sem essa autorização, apenas será possível a disponibilização da nota ou pontuação de crédito elaborada com base no histórico de crédito, mas não do histórico de crédito em si.

Destaca-se, ainda, o fato de que a autorização prévia do cadastrado (imprescindível à disponibilização de seu histórico de crédito) deve ser “específica”, isto é, deve ser formalizada em instrumento específico ou em cláusula apartada, o que se aproxima da norma relativa às cláusulas que, nos contratos de adesão, traduzam limitação do direito do consumidor (CDC, art. 54).⁴⁶ Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a abusividade da cláusula contratual inserta em contrato de adesão que impeça ao

consumidor de optar, válida e livremente, pelo compartilhamento dos dados que fornece por ocasião da contratação de serviço de cartão de crédito.⁴⁷

De modo geral, pode-se dizer que, à luz das normas contidas na Lei 12.414/2011, são exigidos os seguintes requisitos para o tratamento de dados no âmbito dos bancos de formação de histórico de crédito: (i) comunicação ao cadastrado em até trinta dias após a abertura do cadastro, sem custo (art. 4º, § 4º, I); (ii) informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados (art. 4º, § 4º, III); (iii) concessão da possibilidade de cancelamento do cadastro em até 30 dias após a sua abertura e no mínimo 30 dias antes da disponibilização da nota ou pontuação de crédito elaborada com base no cadastro (art. 4º, IV, e §§ 4º e 7º); (iv) utilização de informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, e desde que sejam necessárias para a avaliação da situação econômica do consumidor (art. 3º, § 1º); (v) acesso ao histórico de crédito pelos consulentes apenas quando houver prévia autorização específica do cadastrado (art. 4º, IV, “b”) e interesse justificável na avaliação do risco de crédito do consumidor (arts. 7º e 15); (vi) utilização de informações que não digam respeito a eventos de adimplemento ocorridos há mais de 15 anos (art. 14); (vii) vedação à utilização de informações sensíveis, pertinentes à origem social, étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas, bem como informações de pessoas que não tenham com o cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica (arts. 3º, § 3º, e 7º-A).

A LGPD reforça a tutela protetiva já concedida pela Lei 12.414/2011. O art. 8º, *caput*, e § 1º, da LGPD, por exemplo, corrobora com o que dispõem o art. 4º, IV, “b”, da Lei 12.414/2011 e o art. 54 do CDC.⁴⁸

LGPD, art. 8º: “O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais”.

Lei 12.414/2011, art. 4º: “O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: [...] IV – disponibilizar a consulentes: [...] b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado”.

CDC, art. 54: “[...] § 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Do mesmo modo, a exigência de transparência no âmbito dos cadastros e bancos de dados relacionados à proteção ao crédito, mediante obrigação de fornecimento de informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão (CDC, art. 43, § 1º; Lei 12.414/2011, art. 3º, § 1º),⁴⁹ encontra-se contemplada na LGPD em diversos dispositivos, do que são exemplos o art. 6º, VI, e o art. 9º:

Art. 6º: “As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: [...] VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial”.

Art. 9º: “O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva [...]”.

A utilização de informações sensíveis (Lei 12.414/2011, art. 3º, § 3º, II)⁵⁰ ou que não guardem relação com a finalidade para a qual foi realizado o tratamento de dados (Lei 12.414/2011, art. 3º, § 3º, I),⁵¹ vedada no âmbito dos cadastros positivos, também foi objeto de regulamentação específica na LGPD, que estabeleceu o conceito de dado sensível nos seguintes termos:

Art. 5º. Para os fins desta Lei, considera-se: [...] II – dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II).⁵²

Para fins de concessão de crédito, não se admite o tratamento de dados pessoais sensíveis, seja porque os dados sensíveis não guardam relação com a análise de risco de inadimplemento, seja porque a LGPD regulamentou de forma rigorosa as hipóteses em que tal tratamento será admitido (LGPD, art. 11, I e II).⁵³ Nessa perspectiva, tendência normativa que merece destaque diz respeito ao princípio da finalidade e seus corolários, consagrados no art. 6º, I, II e III, da LGPD, que vão ao encontro do que dispõem os arts. 7º e 15 da Lei 12.414/2011:⁵⁴

LGPD, art. 6º: “As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados”.

Como se percebe, a normativa da LGPD se mostra compatível – e, em relação aos aspectos mencionados, verdadeiramente harmônica – com a Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011), mesmo após a implementação do denominado modelo *opt out*. Nessa direção, revela-se sintomático que a LGPD tenha estabelecido como hipótese autônoma – independentemente de consentimento pelo titular dos dados (LGPD, art. 7º, I)⁵⁵ – a possibilidade de tratamento de dados “para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente” (art. 7º, X).⁵⁶ Nota-se que a LGPD reconheceu que há legítimo interesse no tratamento de dados pessoais para a finalidade de análise de risco para concessão de crédito.⁵⁷

Com efeito, diante da expressa remissão “ao disposto na legislação pertinente”, a LGPD atribuiu às leis específicas – notadamente o CDC e a Lei 12.414/2011 – a regulamentação quanto à necessidade ou não de consentimento para a realização do tratamento de dados,⁵⁸ inclusive no que diz respeito à autorização para a criação do cadastro positivo independentemente de prévio consentimento e à exigência de prévio consentimento informado para a disponibilização do histórico de crédito, o que denota uma tentativa de alcançar delicado e benfazejo equilíbrio entre a imprescindível tutela dos interesses dos titulares de dados e o legítimo interesse social no fomento ao tratamento de dados pessoais visando à depuração dos critérios para a concessão de crédito, essencial para que se evite o

superendividamento e para que os adimplentes possam se beneficiar de condições mais vantajosas.

Nota-se, a propósito do tema, que a LGPD buscou afastar a exigência de consentimento para uma série de hipóteses de tratamento de dados pessoais.⁵⁹ Enquanto o art. 7º, I, prevê o “fornecimento de consentimento pelo titular” como uma das hipóteses em que poderá realizado o tratamento de dados,⁶⁰ há outros nove incisos contendo hipóteses em que, a princípio, seria dispensado o consentimento, quais sejam: “para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador” (inciso II);⁶¹ “pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres” (inciso III);⁶² “para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais” (inciso IV); “quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados” (inciso V);⁶³ “para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral” (inciso VI); “para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro” (inciso VII);⁶⁴ “para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária ” (inciso VIII); “quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais” (inciso IX);⁶⁵ “para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente” (inciso X).

Além dessas hipóteses, o art. 7º, § 4º, da LGPD dispensa a exigência de consentimento em relação aos “dados tornados manifestamente públicos pelo titular”.⁶⁶ Ainda carecem de definição os contornos a serem outorgados à autorização de tratamento dos dados tornados manifestamente públicos pelo titular,⁶⁷ mas é certo que, “mesmo nesses casos, o tratamento de tais dados continua sujeito ao respeito aos direitos do titular”,⁶⁸ tendo a LGPD estabelecido, por exemplo, que “o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização” (art. 7º, § 3º).

Como se percebe, a LGPD concebeu a exigência de consentimento como apenas uma de muitas hipóteses em que poderá ocorrer o tratamento de dados pessoais. O marco regulatório da proteção de dados pessoais no Brasil revela maior preocupação com a função a que se destina o tratamento dos dados, destacando que, independentemente da exigência ou não de consentimento, devem ser observados os princípios previstos no art. 6º da LGPD,⁶⁹ garantindo-se a efetividade dos direitos do titular dos dados, como evidenciam os §§ 3º e 6º do art. 7º da LGPD.⁷⁰

3.2.O sistema credit scoring

Em 12 de novembro de 2014, no julgamento dos Recursos Especiais 1.457.199/RS⁷¹ e 1.419.697/RS,⁷² ambos submetidos à sistemática dos recursos

repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil,⁷³ aprovando as seguintes teses:

1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo).

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da 12.414/2011.

4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.

O denominado sistema *credit scoring* tem por objetivo atribuir pontuação ao potencial tomador de crédito que permita identificar, a partir de métodos estatísticos, o risco de crédito relacionado a determinada operação.⁷⁴ Para que os cálculos levem ao resultado pretendido, permitindo aferir o risco de inadimplemento do potencial tomador de crédito, devem ser incluídos os dados pessoais em determinada fórmula, na qual serão atribuídos diferentes “pesos” a cada informação e, ao final, o produto será o *score* de crédito.

Em monografia sobre o tema, Renan Soares Cortazio observa que “a seleção das variáveis a serem consideradas em determinada fórmula e os respectivos pesos para cada uma delas só é possível através de *softwares* estatísticos, devido ao grande número de variáveis (informações que podem ser consideradas)”.⁷⁵ As informações utilizadas para alimentar os *softwares*, permitindo a realização dos cálculos estatísticos que levarão ao *score* de crédito podem ser as mais variadas, incluindo desde dados pessoais básicos, como local de nascimento, idade, profissão, estado civil, até informações patrimoniais e financeiras, como renda mensal, propriedade de bens imóveis e de veículos automotores, existência de protestos em aberto, situação dos créditos eventualmente tomados anteriormente etc.

Como visto, de acordo com a jurisprudência consolidada sobre o tema (Recursos Especiais Repetitivos 1.457.199 e 1.419.697), a utilização do sistema *scoring* para efeitos de avaliação do risco de inadimplemento do tomador de crédito independe de consentimento por parte do titular dos dados pessoais, o que não afasta nem diminui a importância de que sejam respeitados os “limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais”, sob pena de

“responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente”.

Em especial, não se pode ignorar que, embora o *credit scoring* não constitua tecnicamente banco de dados, é certo que as fórmulas estatísticas dependem da utilização dos dados pessoais para que possam se tornar operantes. Dessa feita, importa perquirir, à luz da LGPD e da Lei nº. 12.414/2011, a origem e a qualidade dos dados que alimentam a fórmula, de modo a aferir eventual emprego de dados cujo tratamento, a princípio, dependeria de consentimento do titular, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 7º, incisos II a X, e § 4º, da LGPD.⁷⁶ Em definitivo, tem-se que, independentemente de se tratar ou não de banco de dados, o *credit scoring* evidentemente promove o tratamento de dados pessoais (LGPD, art. 5º, X),⁷⁷ sendo imprescindível que o acesso e a coleta aos dados utilizados na fórmula estatística sejam realizados de acordo com os termos e as condições estabelecidos na LGPD.

Nessa perspectiva, a LGPD vem reforçar a rede normativa de proteção ao titular dos dados, tendo como principal característica a criação de mecanismos que visam resguardar a efetividade da tutela conferida à proteção dos dados pessoais, de modo a assegurar transparência, inclusive, no âmbito de procedimentos técnicos e complexos, como aqueles empregados nos modelos estatísticos do sistema *credit scoring*.

De uma parte, não há dúvida de que o *credit scoring*, embora não configure banco de dados, para efeitos da Lei 12.414/2011, constitui método de tratamento de dados pessoais e, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4º da LGPD,⁷⁸ está submetido à normativa nela contida.

Desse modo, independentemente da inexigibilidade de consentimento, deve ser garantido ao titular dos dados pessoais, por exemplo, o livre acesso sobre a forma do tratamento de dados realizado pelo sistema *scoring* e sobre a integralidade dos dados considerados no cálculo estatístico (LGPD, art. 6º, IV). Ao propósito, o art. 9º da LGPD, plenamente aplicável no âmbito do sistema *credit scoring*, prevê que o titular dos dados pessoais tem “direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva”, englobando, entre outros aspectos, a “finalidade específica do tratamento” (I), a “identificação do controlador” (III) e as “informações de contato do controlador” (IV).⁷⁹ Na mesma direção, o art. 19 da LGPD estabelece que a confirmação de existência e o acesso a dados pessoais, caso requeridos pelo titular, deverão ser providenciados (i) imediatamente, em formato simplificado; e (ii) no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular, em versão clara e completa contendo a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento.⁸⁰

Vale registrar, ainda, que a Lei nº. 12.414/2011 cuidou de regulamentar de modo específico o tratamento de dados com a finalidade de atribuição de nota ou pontuação de crédito elaborada com base em informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, estabelecendo, em consonância com a LGPD, o direito do titular dos dados de acessar gratuitamente, independentemente de justificativa e no prazo de 10 (dez) dias, a sua nota ou pontuação de crédito (art.

5º, II), conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial (art. 5º, IV), solicitar a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados (art. 5º, VI) e até mesmo solicitar gratuitamente o cancelamento de cadastro e dos dados nele constantes para fins de composição de nota ou pontuação de crédito (art. 5º, I e § 8º).

Notadamente no que se refere ao livre acesso e à transparência no tratamento de dados pessoais no sistema *credit scoring*, cuidou a LGPD, em absoluta harmonia com os dispositivos da Lei nº. 12.414/2011 *supra* mencionados, de regulamentar expressamente o direito do titular dos dados pessoais de obter do controlador, a qualquer momento e mediante simples requisição gratuita: (i) confirmação sobre a existência ou não do tratamento de seus dados pessoais para efeitos de atribuição de nota de crédito (LGPD, art. 18, I); (ii) informação acerca dos dados utilizados para a formação do *scoring* (LGPD, art. 18, II); (iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados (LGPD, art. 18, III); (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD, como dados sensíveis ou irrelevantes à avaliação do risco de inadimplemento (LGPD, art. 18, IV); (v) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, desde que resguardados os segredos comercial e industrial (LGPD, art. 18, V).

Repercutem sobre o sistema *credit scoring*, ainda, as normas introduzidas pela LGPD para robustecer o direito do titular de dados à não discriminação,⁸¹ sendo vedado o tratamento de dados que consubstancie prática discriminatória ilícita ou abusiva (LGPD, art. 6º, IX). Com isso, torna-se mais incisiva a vedação a que o sistema *credit scoring* inclua como variáveis da fórmula estatística dados pessoais sensíveis, conforme definição do art. 5º, II, da LGPD e, mesmo em relação a dados pessoais que, *a priori*, não sejam sensíveis, mas possam gerar distorções discriminatórias, diferenciando potenciais tomadores de crédito apenas com base em seu gênero ou sua idade, por exemplo.⁸²

Do mesmo modo, é expressamente apontada ilicitude da eventual utilização, no sistema *scoring*, de dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular (LGPD, art. 21),⁸³ o que ocorreria, por exemplo, se viesse a ser incluída como variável de determinada fórmula informação a respeito da existência de ação ajuizada pelo titular para compensação por dano moral em virtude de cadastro indevido.

Nessa mesma toada, a Lei Complementar nº. 166/2019 introduziu na Lei nº. 12.414/2011 o art. 7º-A, justamente com o escopo de regulamentar as restrições à natureza dos dados que podem ser objeto de tratamento para fins de composição da nota ou pontuação de crédito, estabelecendo a vedação à utilização de informações que: (i) não estejam vinculadas à análise de risco de crédito; (ii) se relacionem à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, ao sexo e às convicções políticas, religiosas e filosóficas; (iii) digam respeito a pessoas que não tenham com o cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica; (iv) estejam relacionadas ao exercício regular de direito pelo cadastrado, inclusive o direito de requerer acesso gratuito ao histórico ou pontuação de crédito. Ademais, o aludido art. 7º-A estatui, em seu § 1º, que o gestor do banco de dados possui o dever de “disponibilizar em seu sítio eletrônico,

de forma clara, acessível e de fácil compreensão, a sua política de coleta e utilização de dados pessoais para fins de elaboração de análise de risco de crédito”.

Destaca-se, ainda, com especial repercussão no âmbito do sistema *credit scoring*, o direito do titular dos dados "O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil [...] de crédito" (LGPD, art. 20, *caput*),⁸⁴ o que, como visto, também se encontra expressamente contemplado no art. 5º, VI, da Lei nº. 12.424/2011.

Portanto, não obstante o entendimento do STJ quanto à inexigibilidade de consentimento para a formação do *scoring* de crédito mediante fórmulas estatísticas, bem como a implementação do modelo *opt out* na Lei nº. 12.424/2011, tanto a LGPD quanto a aludida Lei nº. 12.424/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº. 166/2019, criaram mecanismos efetivos para garantir transparência a esse sistema automatizado de atribuição de notas de crédito, impondo ao responsável pela operação do tratamento de dados que dá origem ao *scoring* a obrigação de fornecer ao titular dos dados, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a atribuição da nota, resguardados os segredos comercial e industrial,⁸⁵ sem prejuízo de realização de auditoria por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

A efetividade dos direitos e das garantias previstos na LGPD, inclusive no que se refere ao tratamento de dados pessoais no sistema *credit scoring*, deve ser garantida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD),⁸⁶ com competência para implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD, fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle e proteção dos titulares sobre seus dados pessoais, consideradas as especificidades das atividades, bem como o porte dos controladores, entre outras (LGPD, art. 55-J).

4. Notas conclusivas

A LGPD inaugurou benfazejo paradigma de proteção dos dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo tendência consolidada na Europa com a edição, em 2016, do *General Data Protection Regulation* – ou GDPR (Regulamento (UE) 2016/679). No cenário normativo brasileiro, a disciplina da LGPD veio reforçar a tutela à proteção dos dados pessoais, em harmonia com a axiologia constitucional e com os dispositivos do CDC (Lei 8.078/1990), da Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011) e do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) sobre o tema.

No âmbito do mercado de concessão de crédito, o tratamento de dados assume papel de extrema relevância para viabilizar a análise de risco de inadimplemento por parte dos potenciais tomadores de crédito, o que repercute não apenas no interesse dos potenciais tomadores de crédito na obtenção de melhores condições de financiamento mas também no interesse social de: (i) aquecimento da economia a partir do incremento de oportunidades para o exercício da livre-iniciativa (CRFB, art. 1º, IV); e, no outro vértice, (ii) contenção do fenômeno do superendividamento, atribuindo-se aos mutuantes a responsabilidade de, mediante análise dos dados pessoais, negar crédito àqueles que não possuem condições mínimas de adimplemento.

Atualmente, o tratamento dos dados pessoais no mercado de concessão de crédito se exterioriza principalmente nas figuras do Cadastro Negativo, do Cadastro Positivo e do sistema *Credit Scoring*. Anteriormente à LGPD, já havia regulamentação e entendimentos consolidados dos tribunais brasileiros acerca dos limites e das possibilidades do tratamento dos dados pessoais no âmbito de tais instrumentos de análise do risco de crédito, mas, com o advento da nova Lei Geral de Proteção de Dados, há importantes repercussões no tratamento de dados no setor.

Como visto, a LGPD cuidou de contemplar expressamente o tratamento de dados “para a proteção do crédito” (art. 7º, X) como hipótese autônoma em que há autorização legal para o tratamento. Isso não significa, contudo, uma “carta branca” para o tratamento de dados no aludido contexto de proteção ao crédito, uma vez que sua interpretação não prescinde do diálogo com as leis específicas que regulamentam os bancos de dados de consumidores contendo informações de adimplemento e inadimplemento, histórico de crédito, bem como os métodos de apuração do *rating* de crédito.

Pode-se afirmar que a LGPD contribui decisivamente para a efetividade da tutela dos direitos do titular de dados pessoais empregados no âmbito dos bancos de dados de consumidores e das fórmulas estatísticas de atribuição de *rating* de crédito, criando instrumentos voltados a garantir o acesso livre e gratuito aos dados pelos consumidores, assegurando-se ao titular dos dados o direito de confirmar a existência do tratamento, de ser informado acerca de quais dados são utilizados e sobre a forma como são utilizados, a transparência no tratamento dos dados, independentemente de se tratar ou não de banco de dados, inclusive na hipótese de tratamento automatizado.

Desse modo, até que se torne vigente a normativa contida na LGPD,⁸⁷ será necessária expressiva readequação das práticas hoje em curso no setor, especialmente mediante a adoção de novas políticas de privacidade claras e objetivas, a garantia de sistema de acesso livre e gratuito por parte dos titulares dos dados e a implementação de bancos de dados e sistemas transparentes.

1

Professora de Direito Civil e do Consumidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogada.

2

Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogado.

Nos termos do art. 5º da LGPD, conceitua-se dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. Danilo Doneda observa que, “em relação à utilização dos termos ‘informação’ e ‘dado’, é necessário notar preliminarmente que o conteúdo de ambos os vocábulos se sobrepõe em várias circunstâncias, o que justifica uma certa promiscuidade na sua utilização. Não obstante, cada um carrega um peso particular a ser levado em conta. Assim, o ‘dado’ apresenta conotação um pouco mais primitiva e fragmentada, como observamos por exemplo em um autor que o entende como uma informação em estado potencial, antes de ser transmitida; o dado estaria associado a uma espécie de pré-informação, anterior à interpretação e ao processo de elaboração. A informação, por sua vez, alude a algo além da representação contida no dado, chegando ao limiar da cognição, e mesmo nos efeitos que esta pode apresentar para seu receptor. Sem aludir ao significado ou conteúdo em si, na informação já se pressupõe uma fase inicial de depuração de seu conteúdo – daí que a informação carrega em si também um sentido de uma redução de um estado de incerteza. A doutrina, não raro, trata estes dois termos indistintamente” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 152).

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 13.

LGPD, art. 5º, X: “Para os fins desta Lei, considera-se: [...] X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

Cf. art. 5º, V, LGPD. “A LGPD criou a figura do Titular, que é a ‘pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento’ (art. 5º, V). Assim, por mais que outrem se sinta proprietário de dados pessoais de terceiros, essa cessão total de direitos não existe e a LGPD se dedicou a tornar isso bastante claro, penalizando quem trata dados pessoais fora das previsões da nova Lei” (OLIVEIRA, Ricardo Alexandre de. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus impactos no ordenamento jurídico. *Revista dos Tribunais*, v. 998. dez. 2018. p. 241-261). Essa mudança de paradigma ocorreu na esteira da regulamentação europeia, notadamente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais aprovado em abril de 2016 pelo Parlamento Europeu, também conhecido por sua sigla GDPR (*General Data Protection Regulation*). Conforme destaca Mario Viola, “o modelo europeu de proteção de dados é o que vem prevalecendo na grande maioria das legislações sobre proteção de dados no mundo, inclusive dos países membros do Mercosul, bloco econômico do qual o Brasil é estado parte” (VIOLA, Mario. Combate à fraude e proteção de dados: inimigos ou aliados?. *Revista Brasileira de Risco e Seguro*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 12, out. 2010-mar. 2011. p. 40). Sobre os relevantes impactos do GDPR no âmbito das práticas empresariais de tratamento de dados pessoais, v. TIKKINEN-PIRI, Christina; ROHUNEN, Anna; MARKKULA, Jouni. EU General Data Protection Regulation: Changes and implications for personal data collecting companies. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice* (2017): “The GDPR brings considerable changes to personal data intensive companies’ privacy protection implementation. Due to these changes, companies need to review their strategies, information systems and documentation to ensure their alignment with the GDPR provisions. [...]. For compliance with the GDPR, some of its requirements have to be taken into account in the companies’ policy planning. Their policies should support the data protection by design and by default principles through a proactive implementation of technical and organisational privacy protection measures and procedures, including data-minimising mechanisms”.

V., em especial, arts. 6º, IV, VI, X, 9º e 18 da LGPD.

Segundo Stefano Rodotà, “a proteção de dados pode ser vista como a soma de um conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo milênio” (RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância*: privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 14). Do ponto de vista econômico, há, inclusive, quem afirme que os dados pessoais seriam o novo petróleo (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data. *The Economist*. 06.05.2017. Disponível em: [www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data]. Acesso em: 15.03.2019).

9

Conforme destaca Laura Schertel Mendes, “a utilização massiva de dados pessoais a partir da segunda metade do Século XX pode ser associada a duas características principais do Estado pós-industrial: a burocratização (dos setores público e privado) e o desenvolvimento da tecnologia da informação. Ambos os fenômenos, que podem ser considerados transnacionais, suscitaram o processamento dos dados pessoais por governos das mais variadas ideologias políticas e por grandes corporações empresariais, com finalidades estatísticas, administrativas, negociais e investigativas” (MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*. linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 33).

10

“The idea for social credit came about back in 2007, with projects announced by the government as an opt-in system in 2014. But there’s a difference between the official government system and private, corporate versions, though the latter’s scoring system that includes shopping habits and friendships is often conflated with the former. [...] China’s social credit system expands that idea to all aspects of life, judging citizens’ behaviour and trustworthiness. Caught jaywalking, don’t pay a court bill, play your music too loud on the train — you could lose certain rights, such as booking a flight or train ticket” (*The complicated truth about China’s social credit system*. Disponível em: [www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained]. Acesso em: 24.03.2019).

11

“In May 2014 the Polish Ministry of Labor and Social Policy (MLSP) introduced a scoring system to distribute unemployment assistance. Citizens are divided into three categories by their ‘readiness’ to work, the place they live, disabilities and other data. Assignment to a given category determines the type of labor market programs that a particular person can receive from the local labor offices (e.g. job placement, vocational training, apprenticeship, activation allowance). The Panoptikon foundation argues that the system’s default criteria of profiling assistance are leading to discrimination and is not transparent” (*Poland profiles unemployed to determine access to job search assistance*. Disponível em: [https://privacyinternational.org/examples-abuse/1893/poland-profiles-unemployed-determine-access-job-search-assistance]. Acesso em: 24.03.2019).

12

Observa Ricardo Villas Bôas Cueva que “o direito à proteção dos dados pessoais, que nasce como direito de defesa perante o Estado, hoje tem alcance muito maior. Os milhares de registros eletrônicos gerados em catracas automatizadas, pedágios eletrônicos, câmeras, aparelhos de GPS, eletrodomésticos (a ‘internet das coisas’), bem como inúmeras outras transações diariamente mediadas pela informática com técnicas avançadas de análise (‘big data’, por exemplo), deixam claro que o tratamento desarrazoado de dados pessoais pode fomentar a criação de pequenos Leviatãs, cujo potencial ofensivo à vida privada e à dignidade humana pode se igualar ou até mesmo exceder aquele representado pelo Estado” (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, ano 4. out.-dez. 2017. p. 63-64). Conforme adiantava Stefano Rodotà, “viviamo davvero nella società dell’informazione e quindi l’informazione diventa la materia prima più importante. Il sistema delle imprese vive di notizie sui suoi attuali e potenziali clienti. Perciò la gestione delle informazioni non è solo privacy, ma anche libertà personale: non diventare prigionieri di chi possiede informazioni su di noi e può invadere in ogni momento la nostra sfera privata” (RODOTÀ, Stefano. *Intervista su privacy e libertà*, Roma: Laterza, 2005. p. 116).

13

Exclui-se da regulamentação da LGPD, nos termos do disposto no seu art. 4º, apenas o tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos, de

segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, bem como o realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Dispõe o art. 4º, IV, ainda, que a LGPD “(...) não se aplica ao tratamento de dados pessoais: (...) IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei”.

14

OLIVA, Milena Donato. Desafios contemporâneos da proteção do consumidor: codificação e pluralidade de fontes normativas. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, v. 16, abr.-jun. 2018. p. 15-33.

15

“Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face do atual ‘pluralismo pós-moderno’ de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurgiu a necessidade de coordenação entre as leis no mesmo ordenamento [...]. O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou restaurada’ (*cohérence dérivée ou restaurée*), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’” (MARQUES, Claudia Lima. Diálogo das fontes. In: BENJAMIN, Antônio Herman V. *Manual de direito do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 135).

16

Segundo Leonardo Roscoe Bessa, as entidades de proteção ao crédito são espécie de bancos de dados de consumo: “a distinção entre bancos de dados e cadastros de consumo se faz a partir da fonte e do destino da informação. Os bancos de dados, em regra, coletam informações do mercado para oferecê-las ao próprio mercado (fornecedores). No cadastro, a informação é obtida diretamente do consumidor para uso de um fornecedor específico, a exemplo do que ocorre em diversos estabelecimentos comerciais quando se solicitam dados pessoais (nome, endereços postal e eletrônico, telefone, data de aniversário entre outros), independentemente de a compra ser à vista ou mediante crediário. [...]. Os propósitos dos bancos de dados de consumo podem variar bastante. No Brasil, todavia, os mais desenvolvidos são os bancos de dados de consumo que coletam, armazenam e divulgam informações para análise de riscos de concessão de crédito. Em razão desse propósito específico, as entidades de proteção ao crédito, tanto no tratamento de informações positivas como negativas, são espécie de bancos de dados de consumo” (BESSA, Leonardo Roscoe. *Cadastro positivo: comentários à Lei 12.414/2011*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 77). Bruno Ricardo Bioni, por sua vez, observa criticamente que, “atualmente, devido ao seu processo de automatização, uma mesma base de dados tende a acumular, ao mesmo tempo, características de um banco de dados e de um cadastro de consumo, havendo uma ‘promiscuidade’ entre tais espécies de arquivos de consumo. Essa ambivalência desnatura tal taxonomia construída pela doutrina consumerista” (BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 47-48).

17

Art. 1º, *caput*, da Lei 12.414/2011: “Esta Lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”.

18

Art. 43, § 2º, CDC: “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros” (Súmula 404, STJ).

A título ilustrativo, a “Carta Comunicado” expedida pela Serasa Experian confere ao consumidor o prazo de dez dias para “regularizar a situação” e, apenas após o decurso de tal prazo, há a disponibilização da informação de inadimplemento no banco de dados. O modelo da “Carta Comunicado” da Serasa Experian encontra-se disponível em [www.serasaconsumidor.com.br/carta/] (acesso em: 24.03.2019).

“É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC” (STJ, REsp 1.061.134/RS, 2ª S., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2008). De acordo com o STJ, a responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da entidade mantenedora do banco de dados. “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição” (Súmula 359, STJ). Ressalte-se, quanto ao ressarcimento de danos sofridos pela negativação sem prévia comunicação, o teor da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Sobre esse enunciado, seja consentido remeter a Milena Donato Oliva (Dano moral e inadimplemento contratual nas relações de consumo. *Revista de direito do consumidor*, ano 23, v. 93, maio-jun. 2014. p. 17).

Nos termos do art. 2º, II, da Lei nº. 12.414/2011, o gestor é o “responsável pela administração de banco de dados, bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo acesso de terceiros aos dados armazenados”.

Art. 4º da Lei 12.414/2011: “O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: I – abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas; II – fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I do *caput* deste artigo; III – compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados; e IV – disponibilizar a consulentes: a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; e b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado”.

Art. 4º, § 4º, da Lei 12.414/2011: “A comunicação ao cadastrado deve: I – ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado; II – ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e III – informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados”.

Art. 4º, § 7º, da Lei 12.414/2011: “As informações do cadastrado somente poderão ser disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do cadastro, observado o disposto no § 8º deste artigo e no art. 15 desta Lei”.

Art. 5º, I, da Lei 12.414/2011: “São direitos do cadastrado: I – obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, quando solicitado”.

“Até a edição da Lei 8.078/90, as atividades desenvolvidas pelos bancos de dados de proteção ao crédito (SPC, Serasa, CCF) não possuíam qualquer disciplina legal. A regulamentação integral de tais atividades surgiu justamente com o Código de Defesa do Consumidor, considerando sua vinculação direta com a crescente oferta e concessão de crédito no mercado. Portanto, não há como sustentar, ainda que se verifique que a entidade arquivista não atenda a todos pressupostos do conceito de fornecedor do *caput* do 3º, que não se aplica o CDC. Ora, a lei surgiu justamente para disciplinar a atividade! Pouco importa que a atividade dos bancos de dados de proteção ao crédito seja remunerada (direta ou indiretamente), vez que o art. 43, ao contrário do § 2º do art. 3º,

não exige a presença de tal pressuposto” (BESSA, Leonardo Roscoe. Fornecedor equiparado. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 61, jan.-mar. 2007. p. 137).

27

Creditada pioneiramente ao matemático britânico Clive Humby, popularizou-se a máxima de que “informação é o novo petróleo” (HUMBY, Clive. Data is the new oil. *Proc. ANA Sr. Marketer’s Summit*, Evanston, 2006). Em seu relatório anual de 2011, o Fórum Econômico Mundial afirmou: “Os dados pessoais estão se tornando em uma nova classe de ativos econômicos, um recurso valioso para o século XXI que vai tocar todos os aspectos da sociedade”.

28

“Trata-se, à evidência, de faculdade imprescindível para evitar, ou fazer cessar, ofensa a direitos da personalidade, pois só é possível exercer certo controle sobre as informações pessoais obtidas por terceiros se garantido o direito de acesso a elas” (BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de direito do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 385). No mesmo sentido, Bruno Miragem afirma que “o direito de acesso à informação possui assento constitucional (artigo 5º, XIV e LXXII). Neste sentido, o CDC, com relação aos bancos de dados de consumidores, estendeu às relações de consumo a garantia constitucional expressa de acesso por qualquer cidadão, das informações referentes a si, em quaisquer bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” (MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 266). Na jurisprudência, “O CDC, em seu art. 43, ao regular os arquivos de consumo, deixou expresso: a) direito de acesso do consumidor às informações existentes sobre ele nesses cadastros e bancos de dados, além das respectivas fontes” (STF, Plenário, ARE 867.326/SC RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.04.2015).

29

Art. 19 da Lei 13.709: “A *confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular*: I – em formato simplificado, imediatamente; ou II – por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular. § 1º *Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso*” (grifou-se).

30

Art. 18 da Lei 13.709: “O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: [...] III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados”.

31

GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN; Antonio Herman de V. e; FINK, Daniel Roberto; FILOMENO, José Geraldo Brito; WATANABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nery; DENARI, Zelmo. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos autores do Anteprojeto*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 465; BENJAMIN, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno *Manual de Direito do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 395-396; MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 269.

32

Nessa direção, cf. Súmula 323 do STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Assim, por exemplo, o decurso do prazo prescricional trienal relativo à ação de execução de dívida constante em nota promissória ou letra de câmbio (Decreto 57.663/1966, Lei Uniforme de Genebra, Anexo I, art. 70) não significa a perda da pretensão de cobrança, limitando-se à prescrição da via executiva.

33

STJ, 3ª T., REsp 1.630.889/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.09.2018. No entanto, conforme destacado no voto da Ministra Relatora, "a jurisprudência em relação ao termo inicial do prazo máximo de duração da anotação em cadastro de inadimplentes ainda não foi consolidada pelas Turmas de Direito Privado desta Corte. Realmente, de um lado, há julgados nos quais se adota a orientação de que 'o cômputo do prazo prescricional, nos termos da Súmula 323/STJ, deve observar a efetiva inscrição no cadastro restritivo de crédito, não o vencimento da dívida' (AgRg no Ag 713.629/ES, Terceira Turma, DJe 04/08/2009; e, no mesmo sentido: AgRg no Ag 1.271.123/RS, Rel. Quarta Turma, DJe 30/08/2010; REsp 615.639/RS, Terceira Turma, DJ 02/08/2004; e mais recentemente REsp 1.196.699/RS, Quarta Turma, DJe 20/10/2015). De outro, há julgado que segue a linha de que 'interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do § 1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo *a quo* do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora' (REsp 1.316.117/SC, Terceira Turma, DJe 19/08/2016, sem destaque no original)".

34

Cf. MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 266; MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 547.

35

BENJAMIN, Antonio Herman; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual do direito do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 379.

36

STJ, REsp 1.424.792/BA, 2ª S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.09.2014.

37

"A Segunda Seção desta Corte consolidou entendimento segundo o qual o deferimento do pedido de antecipação de tutela para cancelar a inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito depende da presença concomitante de três elementos: (a) contestação total ou parcial do débito, (b) demonstração da plausibilidade jurídica da ação, e (c) em caso de controvérsia sobre parte do débito, realização do depósito da parte incontroversa ou garantia por caução idônea (REsp 527.618-RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 24.11.2003)" (STJ, 4ª T., AgRg no AREsp 376.490, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.11.2013). No mesmo sentido, cf. STJ, 4ª T., AgRg nos EDcl no AREsp 256.878, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.09.2013; STJ, 3ª T., AgRg no REsp 1.102.001, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.04.2011.

38

Conforme tese firmada no julgamento de Recurso Especial sob o rito dos recursos repetitivos, "diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito – ainda que sem a ciência do consumidor – não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos" (STJ, REsp 1.344.352/SP, 2ª S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014). Consolidou-se, assim, o entendimento que "o § 2º do art. 43 do CDC não se aplica a dados e informações de natureza pública, como os fornecidos pelos tabelionatos de protesto e distribuidores judiciais, porque nesses casos, já existe prévia publicidade do ato" (STJ, REsp 1.344.352/SP, 2ª S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014).

39

Registre-se que o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ é objeto de críticas por parte da doutrina. Segundo Claudia Lima Marques "mesmo o consumidor superendividado ou com os anteriores e preexistentes problemas de cadastro negativo tem honra (ou *quid*) e sofre dano moral (o *quantum* é que poderia ter sido diminuído), ou teria feito esta exceção. A Súmula ressaltou o direito de cancelar o erro do fornecedor, mas não trouxe qualquer incentivo para que os fornecedores cuidem com os 'registros irregulares' que fazem e denigrem a imagem do consumidor" (MARQUES, Claudia Lima. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 833). Bruno Miragem destaca que "a crítica mais eloquente parece situar-se justamente na ausência de resposta do Direito ao ilícito, portanto no âmbito da efetividade da norma que assegura o direito à prévia notificação, mas que fica sem sanção. A

exclusividade de cancelamento da inscrição indevidamente realizada não serve para desestimular, mas ao contrário, incentiva o comportamento ilícito, uma vez que não afasta o objetivo econômico pretendido pelo ofensor” (MIRAGEM, Bruno. Inscrição indevida em banco de dados restritivo de crédito e dano moral. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 81, jan.-mar. 2012. p. 323-335).

40

STJ, 2ª S., REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2016.

41

“A valoração das informações constantes nos cadastros das entidades arquivistas é tarefa a ser realizada pelo destinatário final, qual seja, o consultor dos arquivos. De outro modo, os bancos de dados estariam extrapolando suas atividades. Veda-se, deste modo, informações que façam qualquer análise de risco acerca da concessão de crédito, bem como as depreciativas do tipo, ‘mal pagador’” (PINCINATO, Marcelo Frossard. Histórico, natureza jurídica e responsabilidade civil dos bancos de dados e cadastros de consumidores. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 60, out.-dez. 2006. p. 103-121).

42

Ao propósito, Leonardo Roscoe Bessa problematiza: “o que fazer se, em meio ao registro de informações positivas, o consumidor deixou de pagar algumas prestações antigas (vencidas há sete anos, por exemplo)? É possível manter o registro desse inadimplemento (informação negativa)? [...]. O ideal seria que fosse estabelecido um limite temporal único para registro tanto de informações positivas como negativas, pois, invariavelmente, em meio a anotações de histórico de crédito (informação positiva), poderá haver situações de atrasos ou até mesmo não pagamento de algumas parcelas (informações negativas). Se esses atrasos ou parcelas não pagas superarem o prazo de cinco anos, não poderá haver o respectivo registro, mas ausência de informação de pagamento dessas parcelas irá sugerir a existência de informação negativa” (BESSA, Leonardo Roscoe. *Cadastro positivo: comentários à Lei 12.414/2011*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 141).

43

O conceito de histórico de crédito foi contemplado no art. 2º, VII, da Lei 12.414/2011: “histórico de crédito: conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica”. Conforme observa Leonardo Roscoe Bessa, “são dados que permitem ao consulente verificar a data de vencimento e de pagamento efetivo de parcelas de operações creditícias, bem como o valor da prestação. As informações que integram o histórico de crédito devem permitir também verificar o valor emprestado, as parcelas vincendas e o saldo devedor para análise do comprometimento da renda do consumidor e consequente concessão de crédito responsável, evitando situações de superendividamento e todos os seus efeitos negativos” (BESSA, Leonardo Roscoe. *Cadastro positivo: comentários à Lei 12.414/2011*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 84).

44

“Quatro em cada dez consumidores que aderiram ao Cadastro Positivo melhoraram a pontuação [no score de crédito], o que pode facilitar a tomada de empréstimos a juros menores. No entanto, 22% pioraram o score após incluírem o nome na lista, mostra levantamento da Serasa Experian obtido pela *Folha*. Para o restante 38%, nada mudou” (Cadastro positivo ajuda 4 em 10 devedores. *Folha de S. Paulo*, 15.02.2018. Disponível em: [www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/cadastro-positivo-ajuda-4-em-10-devedores.shtml]).

45

Como destaca Bruno Ricardo Bioni, “pouco adianta atentar o destinatário da informação sobre algo que lhe é útil, se o conteúdo informativo não é completo o suficiente para nele desencadear um entendimento completo que coloque em curso um processo genuíno de tomada de decisão. Veja-se, nesse sentido, que a LGPD segue tal lógica ao: a) prescrever que a informação deve ser clara, adequada e ostensiva (aspecto qualitativo); e b) elencar quais seriam os tipos de informação que deveriam constar do processo comunicativo (aspecto quantitativo). [...]. O dever-direito à informação deve propiciar, portanto, ao usuário os elementos necessários para o início de um processo de tomada de decisão no que tange ao fluxo de seus dados. A prestação de uma

informação clara, adequada e suficiente é o portal de entrada para capacitar o cidadão com o controle dos seus dados” (BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 194-196). O autor examina analiticamente cada uma das “adjetivações do consentimento” (informado, livre, inequívoco, específico e expresso), explorando seus significados e repercussões práticas à luz do ordenamento jurídico brasileiro (BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 190-204).

46

Art. 54. [...]. § 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

47

“Deveras, é plenamente aceitável a alegação de que a instituição financeira necessita do conhecimento de determinados dados do consumidor para lhe prestar o serviço, programação e análise de custos e riscos, por exemplo. Não se justifica, por outro lado, a necessidade do repasse, para a viabilidade de seus serviços, dos dados que obtém do consumidor a outras instituições, até mesmo para mantenedoras de cadastros positivos e negativos. [...] por óbvio, não se estende essa abusividade à inscrição do nome e CPF daquelas mesmas pessoas em cadastros negativos de consumidores (SPC, SERASA, entre outros), por inadimplência, uma vez que dita providência encontra amparo em lei (Lei n. 8.078/1990, arts. 43 e 44)” (STJ, 4ª T., REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2017).

48

O GDPR define o consentimento do titular dos dados como “uma manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento” (art. 4º, 11), e, em seu art. 7º, 2, dispõe que, “se o consentimento do titular dos dados for dado no contexto de uma declaração escrita que diga também respeito a outros assuntos, o pedido de consentimento deve ser apresentado de uma forma que o distinga claramente desses outros assuntos de modo inteligível e de fácil acesso e numa linguagem clara e simples. Não é vinculativa qualquer parte dessa declaração que constitua violação do presente regulamento”.

49

CDC, art. 43, § 1º: “Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”. Lei 12.414/2011, art. 3º, § 1º: “Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado”.

50

Lei 12.414/2011, art. 3º, § 3º, II: “Ficam proibidas as anotações de: [...] II – informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas”.

51

Lei 12.414/2011, art. 3º, § 3º, I: “Ficam proibidas as anotações de: [...] I – informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor”.

52

Sobre o tema, v. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). *R. Dir. Gar. Fund.*, Vitória, v. 19, n. 3, set.-dez. 2018. p. 159-180.

53

LGPD, art. 11: “O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I – quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; II – sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais” [...]. Comentando o artigo, Patricia Peck Pinheiro afirma que “os dados sensíveis merecem tratamento especial porque em algumas situações a sua utilização mostra-se indispensável, porém o cuidado, o respeito e a segurança com tais informações devem ser assegurados, haja vista que – seja por sua natureza, seja por suas características – a sua violação pode implicar riscos significativos em relação aos direitos e às liberdades fundamentais da pessoa. O GDPR explicita essa preocupação no artigo 9º, 2, afirmando que o consentimento é essencial no tratamento de dados sensíveis, embora haja exceções cujos procedimentos devem respeitar com a mesma seriedade e garantia da segurança ao tratamento. O regulamento europeu ainda pontua que as informações sensíveis que foram tornadas públicas pelo próprio titular também podem ter seu consentimento dispensado” (PINHEIRO, Patricia Peck. *Proteção de dados pessoais: comentários à Lei 13.709/2018*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 70).

54

Lei 12.414/2011, art. 7º: “As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para: I – realização de análise de risco de crédito do cadastrado; ou II – subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente” [...]. Lei 12.414/2011, art. 15: “As informações sobre o cadastrado constantes dos bancos de dados somente poderão ser acessadas por consulentes que com ele mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia”.

55

LGPD, art. 7º, I: “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular”.

56

LGPD, art. 7º, X: “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: [...] X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente”.

57

A legitimidade do interesse para o tratamento de dados constitui requisito necessário à observância do princípio da finalidade, positivado no art. 6º, I, da LGPD: “As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades”.

58

Segundo Ana Frazão, “trata-se de dispositivo que, reconhecendo as peculiaridades da proteção do crédito, ressalta a necessidade de observância das regras específicas do assunto, embora a questão já viesse dando margem a muitas controvérsias e discussões sob a luz das normas específicas e consumeristas” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demas-hipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018). Acesso em: 16.03.2019).

Bruno Ricardo Bioni afirma que, “em termos de técnica legislativa, o consentimento não só deixou de ser a única base legal para o tratamento de dados, como também foi alocado topograficamente sem ser hierarquicamente superior às demais bases legais por estarem todas elas horizontalmente elencadas em incisos do art. 7º da LGPD” (BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 133-134).

60

A exemplo do que ocorre no GDPR, trata-se da primeira hipótese em que se considera lícito o tratamento de dados pessoais. O art. 6º, 1, a, prevê que “o tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas”.

61

No GDPR, tal hipótese está prevista no art. 6º, 1, c: “O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: [...] O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito”.

62

No GDPR, admite-se o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 6º, 1, e, sempre que “for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento”.

63

No GDPR, autoriza-se igualmente o tratamento de dados pessoais quando for “necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados” (art. 6º, 1, b). Sobre essa hipótese, o Considerando 44 prevê que “o tratamento deverá ser considerado lícito caso seja necessário no contexto de um contrato ou da intenção de celebrar um contrato”.

64

No GPDR, o art. 6º, 1, d, autoriza o tratamento de dados pessoais sempre que “for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular”.

65

O art. 6º, 1, f, do GDPR permite o tratamento de dados pessoais nas hipóteses em que “o tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança”. Ressalva, contudo, que “o primeiro parágrafo, alínea f), não se aplica ao tratamento de dados efetuado por autoridades públicas na prossecução das suas atribuições por via eletrônica”. No caso da LGPD, todavia, o conceito de “interesses legítimos” para efeitos da autorização para o tratamento de dados pessoais contida no art. 7º, IX, não foi devidamente delimitado pelo legislador, sendo útil o recurso hermenêutico ao GDPR no ponto. Conforme observa Ana Frazão, “os Considerandos do RGPD ajudam a entender melhor a delimitação do interesse legítimo, definindo-o como ‘uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento, em situações como aquela em que o titular dos dados é cliente ou está a serviço do responsável pelo tratamento’ (Considerando 47). O mesmo considerando adverte que ‘a existência de um interesse legítimo requer uma avaliação cuidada, nomeadamente a questão de saber se o titular dos dados pode razoavelmente prever, no momento e no contexto em que os dados pessoais são recolhidos, que esses poderão vir a ser tratados com essa finalidade’. Acresce que outros Considerandos mencionam hipóteses de casos de interesses legítimos, como a (i) de responsáveis por tratamento de dados que façam parte de um grupo empresarial ou de uma instituição associada a um organismo central, que poderão ter interesse legítimo em transmitir dados pessoais no âmbito do grupo de empresas para fins administrativos internos, incluindo o tratamento de dados pessoais de clientes ou funcionários (Considerando 48) ou (ii) de tratamento de dados pessoais para assegurar a segurança da rede e das informações, especialmente para o

fim de resistir a eventos acidentais ou a ações maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais conservados ou transmitidos, bem como a segurança dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e sistemas (Considerando 49). Os critérios e os exemplos dos Considerandos do RGPD condicionam, pois, a existência do legítimo interesse do controlador a critérios de relevância e de adequação, bem como às expectativas razoáveis dos titulares de dados de que estes poderiam ser usados para tais finalidades. Dessa forma, consegue-se, com tais parâmetros, atribuir maior densidade ao conceito de interesse legítimo do controlador em face das necessárias preocupações com os direitos dos titulares de dados. Todavia, subsiste considerável margem interpretativa para a aplicação de tais normas, assim como permanecem nebulosas as hipóteses em que se poderia cogitar de interesses legítimos de terceiros que justificariam o tratamento de dados mesmo sem o consentimento do titular” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demaishipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018]. Acesso em: 16.03.2019).

66

O GDPR igualmente prevê a possibilidade de tratamento de dados pessoais, inclusive os dados sensíveis, “se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular” (art. 9º, 2, e).

67

Sobre o tema, o Article 29 Data Protection Working Party (Art. 29 WP) – constituído sob a égide da Diretiva Europeia de Proteção de Dados (Diretiva 95/46/EC) e sucedido em 2018, à luz do GDPR, pela European Data Protection Board (EDPB) – expressou-se especificamente sobre a questão da autorização ao tratamento de dados pessoais tornados manifestamente públicos pelo titular: “The WP29 wishes to emphasize that this has to be interpreted to imply that the data subject was aware that the respective data will be publicly available which means to everyone including authorities. In case of doubt, a narrow interpretation should be applied, as the assumption is that the data subject has voluntarily given up the special protection for sensitive data by making them available to the public including authorities. In cases such as the publishing of personal data in a biography, in the press or on a public website the intention is clear. In other cases, this is more difficult to decide. For example, registering for a social network might include the acceptance of certain data protection rules which provide that all the partners of the provider (including national police authorities) have access to personal data. In such cases most of the users probably do not actively take notice of this and are in fact not aware that their data are available to police authorities” (Disponível em: [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610178]. Acesso em: 16.03.2019). Vale destacar, ainda, que o parlamento escocês endereçou a questão do tratamento dos dados tornados manifestamente públicos pelo titular em diretrizes relacionadas ao cumprimento do GDPR (Guidance on Motions: Data Protection. Disponível em: [www.parliament.scot/S5ChamberOffice/2018_06_01_Motions_Guidance_Final.pdf]. Acesso em: 16.03.2019). Consta nas aludidas diretrizes: “there is no definition of ‘manifestly made public’ under GDPR, however, simply because personal data is in the public domain (for example, in a newspaper article), or has been provided directly to a Member, does not necessarily mean it has been manifestly made public by the person. This exemption can only be relied upon in circumstances where it is clear that the data subject has themselves put their personal data into the public domain, for example, on their own social media account or on a charity fundraising page that they have set up themselves)”. O documento apresenta, ainda, alguns exemplos ilustrativos, por meio dos quais se extraem alguns indicativos hermenêuticos, entre os quais o de que o simples fato de os dados pessoais serem veiculados na mídia (jornais, revistas, *websites*) não significa que foram tornados manifestamente públicos pelo titular. Sobre a exigência de consentimento para o tratamento de dados pessoais no ambiente virtual, à luz da disciplina da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), v.: MENDES, Laura Schertel. O diálogo entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 106. jul.-ago. 2016. p. 37-69.

68

FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: as demais hipóteses de tratamento de dados pessoais. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-as-demaishipoteses-de-tratamento-de-dados-pessoais-19092018]. Acesso em: 16.03.2019.

LGPD, art. 6º: “As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; V – qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas”.

70

LGPD, art. 7º, §§ 3º e 6º: “§ 3º. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. [...] § 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular”.

71

STJ, 2ª S., REsp 1.457.199/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2014.

72

STJ, 2ª S., REsp 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2014. Em 2015, foi aprovado pela Segunda Seção do STJ também o Enunciado 550 da Súmula da Jurisprudência Dominante do STJ, com o seguinte teor: “A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo”.

73

CPC, art. 927, III: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

74

Destaca Nelson Nery Junior que “o *score* consiste na análise estatística e probabilística de dados que permitem estimar o comportamento futuro de um determinado grupo de indivíduos dentro do qual o sujeito consultado foi inserido, indicando um índice de probabilidade de inadimplência naquele momento e para aquele negócio em específico. O *score* agrupa os indivíduos em grupos de faixas de risco, tendo como parâmetro o comportamento médio esperado em termos de inadimplência para esse grupo de pessoas, baseando-se no histórico de informações de mercado objetivas, públicas e compartilhadas e legalmente coletados e armazenados. Tais *scores* ou *ratings* enquadram o consumidor em uma determinada categoria a partir da análise de seus dados públicos em confronto com os dados de mercado desses grupos de indivíduos. Ao identificar a categoria em que o consultor foi enquadrado, os concedentes de crédito podem avaliar se a probabilidade de inadimplência atribuída ao grupo em que inserido o consumidor (a partir da análise estatística) é adequada aos objetivos inerentes ao exercício de suas atividades econômicas. O

score, portanto, é a geração de um resultado estatístico que é apresentado em uma escala numérica ou em um conceito, que pretende estimar um comportamento futuro de probabilidade de inadimplência de um determinado grupo de pessoas no qual o sujeito da consulta foi inserido” (NERY JUNIOR, Nelson. O serviço de análise estatística de dados [*score* ou *rating*]. Serviço distinto e que não se confunde com banco de dados [negativo ou positivo] e cadastros de consumidores. *Soluções práticas de direito*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. IV. p. 467).

75

“Por exemplo, pode-se utilizar uma função do tipo: $Z = 25 + 2 \times X1 - 5 \times X2 - 8 \times X3 - 6 \times X4$. Em que: Z = escore; X1 = idade; X2 = comprometimento da renda; X3 = número de protestos em aberto e X4 = número de parcelas do financiamento. As fórmulas e os pesos atribuídos a cada variável podem ser diversos do exemplo apresentado, pois segundo Abraham Sicsú: ‘Várias são as técnicas quantitativas que podem ser utilizadas para calcular os escores’. Contudo, a tendência é buscar uma ‘simplificação’ dessas fórmulas, ou melhor, dos resultados delas, de maneira que todos os resultados variem numa escala de 0 a 1.000, facilitando a análise de quem lidará com esses dados” (CORTAZIO, Renan Soares. *Bancos de dados no Brasil: uma análise do sistema credit scoring*. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito. Rio de Janeiro, 2017. p. 70).

76

LGPD, art. 7º: “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: [...]; II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII – para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. [...]. § 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no *caput* deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei”. Acerca dos dados tornados manifestamente públicos pelo titular, remeta-se ao item 2 deste artigo, em que foram destacadas dificuldades nessa delimitação.

77

LGPD, art. 5º, X: “Para os fins desta Lei, considera-se: [...] X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

78

LGPD, art. 4º: “Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I – realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; II – realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; III – realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou IV – provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei” [...].

LGPD, art. 9º: “O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: I – finalidade específica do tratamento; II – forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial; III – identificação do controlador; IV – informações de contato do controlador; V – informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade; VI – responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e VII – direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei” [...].

LGPD, art. 19: “A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular: I – em formato simplificado, imediatamente; ou II – por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular” [...].

Para que o consumidor possa efetivamente verificar a legalidade do tratamento de seus dados, é fundamental que lhe seja franqueado amplo acesso às informações utilizadas e aos critérios empregados para a obtenção da “nota de crédito”. Como observa Leonardo Roscoe Bessa, “ganha dimensão especial o atributo da objetividade. Ora, a própria lei estabelece que as informações devem ser objetivas: descritivas dos fatos e que não envolvam juízo de valor (art. 3.º, § 2º, I, da Lei 12.414/2011). A razão é simples. Em face de informação subjetiva, há dificuldade, senão impossibilidade, do exercício do direito de correção (art. 43, § 3º, do CDC e art. 5º, III, da Lei 12.414/2011). Afinal, como pode o consumidor refutar ou exigir correção de avaliação de risco de crédito sem conhecer todos os critérios utilizados? Da forma como está, o consumidor acaba sendo julgado e discriminado pelo computador e, pior, sem qualquer real possibilidade de infirmar a conclusão da máquina, já que não possui acesso a todos elementos que serviram para sua avaliação. É o mesmo que se permitir recurso ou revisão de nota atribuída a uma prova (faculdade, concurso etc.) sem indicar os critérios utilizados para avaliação” (BESSA, Leonardo Roscoe. Cadastro positivo: algumas anotações à Lei 12.414/2011. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 79. jul.-set. 2011. p. 379). Há quem sustente, nessa direção, que, embora o STJ tenha dispensado o consentimento em relação ao *credit scoring*, “não podem as companhias manterem tais cadastros sem, ao menos, notificarem antecipadamente o consumidor. O dever de comunicação antecipada é um requisito para o exercício de outros direitos, como por exemplo, o direito de acesso e o direito de retificação. Trata-se de um problema lógico: como o consumidor vai se opor a uma eventual incorreção ou exercer seu direito de acesso se nem ao menos sabe da existência do cadastro? Por isso que o direito à comunicação é cronologicamente anterior ao direito de acesso. Igualmente, a comunicação deve ser feita não apenas quando da abertura, mas também em situações de alteração ou inclusão de novos dados nos cadastros ou bancos” (GOULART, Guilherme Damasio. Por uma visão renovada dos arquivos de consumo. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 107. set.-out. 2016. p. 478).

Caitlin Sampaio Mulholland destaca, citando Stefano Rodotà, que a LGPD também tutela o tratamento de dados “aparentemente não sensíveis” que podem se tornar sensíveis a depender do modo como são utilizados: “Rodotà sustenta que a formação de perfis baseados em dados pessoais sensíveis pode gerar discriminação [...] seja porque dados pessoais, aparentemente não ‘sensíveis’, podem se tornar sensíveis se contribuem para a elaboração de um perfil; seja porque a própria esfera individual pode ser prejudicada quando se pertence a um grupo do qual tenha sido traçado um perfil com conotações negativas. Para o autor italiano, '[...] para garantir plenitude à esfera pública, determinam-se rigorosas condições de circulação destas informações, que recebem um fortíssimo estatuto ‘privado’, que se manifesta sobretudo pela proibição de sua coleta por parte de determinados sujeitos (por exemplo, empregadores) e pela exclusão de legitimidade de certas formas de coleta e circulação’. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira segue esta tendência, ao estabelecer limitações específicas para o tratamento de dados sensíveis” (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). *R. Dir. Gar. Fund.*, Vitória, v. 19, n. 3, set. dez. 2018. p. 159-180). Laura Schertel Mendes alude, nessa perspectiva, a “novas

formas de discriminação” por meio de fórmulas estatísticas que tendem a reproduzir estereótipos: “Novas formas de discriminação passam a ser possíveis a partir da associação entre tecnologias da informação e o armazenamento de enormes quantidades de dados pessoais, fenômeno também conhecido como *Big Data*. É o caso, por exemplo, da discriminação estatística, segundo a qual grupos de consumidores recebem tratamentos diferenciados (preços ou condições de contratação diferentes), em razão de atributos aparentemente inofensivos, como idade, gênero, nacionalidade ou endereço. Essa prática se baseia em informações estatísticas, que associam esses atributos a outras características, cuja identificação pelo fornecedor é mais difícil, como nível de renda, risco de inadimplência etc. O principal problema da discriminação estatística é a atribuição de uma suposta característica do grupo ao indivíduo, sem levar em conta as suas características e condições individuais. Isto é, muitas vezes a justiça do caso individual fica prejudicada a partir de um resultado meramente probabilístico, segundo o qual um percentual de determinado grupo de pessoas agiria de determinada maneira” (MENDES, Laura Schertel. O diálogo entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 106, jul.-ago. 2016. p. 37-69). A questão assume contornos ainda mais complexos diante do tratamento de dados anonimizados (LGPD, art. 12). Sobre o tema, v. VIOLA, Mario; DONEDA, Danilo; ANDRADE, Norberto Nuno Gomes de. Dados anônimos e tratamento de dados para finalidades distintas: a proteção de dados pessoais sob uma ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. *Pensamento crítico do direito civil brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2011. p. 198: “os últimos avanços no campo da tecnologia da informação têm colocado em xeque alguns dos conceitos fundamentais da proteção de dados e, principalmente, a sua taxonomia. A tendência de não considerar os dados anônimos ou estatísticos como dados pessoais e, portanto não sujeitos à incidência das normas de proteção de dados, está presente na grande maioria das normas gerais de proteção de dados. A possibilidade de anonimização dos dados, em conjunto com a grande oferta de dados pessoais resultantes dos processos de *Data Mining* criaram, não apenas uma nova categoria – *Big Data* – mas também modificaram a compreensão do conceito de dado anônimo ou estatístico, exigindo uma mudança na natureza de alguns instrumentos e institutos clássicos da proteção de dados. Como consequência, novos critérios devem reger a utilização de dados, sejam eles anônimos ou não, bem como a sua utilização para finalidades distintas daquelas para as quais foram coletados. Assim, uma divisão binária e estanque entre dado pessoal e dado anônimo, ao se considerar o atual alcance do conceito de dado anônimo e dos seus diversos perfis normativos não é mais um critério seguro para garantir a privacidade dos titulares de dados”.

83

LGPD, art. 21: “Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo”.

84

LGPD, art. 20: “O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade”.

85

Nos termos do art. 20, § 2º, da LGPD, em caso de não oferecimento das informações baseado na observância de segredo comercial e industrial, “a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais”.

86

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi criada em dezembro de 2018 por meio da Medida Provisória 869/2018, convertida na Lei nº. 13.853/2019. Há importantes ressalvas à estrutura atribuída à ANPD no âmbito da estrutura da Administração Pública, notadamente no que diz respeito à garantia de autonomia da ANPD em relação ao Poder Executivo. Ana Frazão anota que “o fato de a autoridade ser criada sem aumento de despesa – tanto que o art. 55-H prevê que ‘os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal’ – e a sua integração à Presidência da República. Tais aspectos podem comprometer, na prática, a autonomia financeira e técnica da autoridade nacional, subordinando-a indevidamente aos interesses do Poder Executivo. Verdade seja dita que o art. 55-B expressamente dispõe que ‘é assegurada autonomia técnica à ANPD’. Entretanto, em se

tratando de autonomia, é saber comum que não basta prevê-la como princípio; é necessário assegurar as garantias institucionais sem as quais ela não tem como ser implementada. Sob essa perspectiva, é motivo de preocupação que a ANPD, apesar de suas relevantíssimas atribuições, apresente, do ponto de vista organizacional, estrutura que revela fragilidade institucional e dependência em relação à Presidência da República” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: balanço preliminar da MP 869/2018. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019]. Acesso em: 16.03.2019).

87

Registra-se, contudo, a existência de Projeto de Lei (PL nº. 5.762/2019) que propõe a entrada em vigor da LGPD apenas em agosto de 2022.

Capítulo 7. A utilização econômica de rastreadores e identificadores on-line de dados pessoais

Aline de Miranda Valverde Terra¹

Caitlin Mulholland²

*Les stats, c'est moi*³

Introdução: um caso emblemático

Em 18 de junho de 2018, em decisão inédita no Brasil, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministério da Justiça, condenou a fornecedora Decolar.com ao pagamento de multa de R\$ 7.500.000,00 por diferenciação de preço de acomodações bem como negativa de oferta de vagas, quando existentes, de acordo com a localização geográfica do consumidor, técnicas conhecidas, respectivamente, como *geo pricing* e *geo blocking*. O valor da condenação⁴ considerou a gravidade da infração (balizada a partir do artigo 39, II, V e X, do CDC); a extensão do dano, que, *in casu*, enquadrou-se como difuso; e a condição econômica do fornecedor, considerada empresa de grande porte.

A decisão foi proferida no âmbito de representação apresentada pela empresa concorrente *Booking*, que colacionou aos autos pesquisa de simulação simultânea de reserva de hospedagem no *site* da empresa Decolar, por meio da qual se constatou que computadores localizados na cidade de São Paulo obtinham preços até 29% superiores àqueles ofertados em computadores situados em Buenos Aires para as mesmas reservas (*i.e.*, acomodações iguais, na mesma data). A pesquisa, ainda, demonstrou a indisponibilidade de algumas acomodações para o consumidor de São Paulo, enquanto, em Buenos Aires, ao mesmo tempo, igual acomodação se apresentava disponível. A *Booking* anexou, ademais, cópias de correspondências eletrônicas nas quais alguns estabelecimentos hoteleiros lhe indagavam sobre a possibilidade de a empresa trabalhar com “diferença tarifária em mercados específicos”, a fim de adotar “tarifas mais agressivas no Brasil”, prática comum no setor hoteleiro e utilizada pela Decolar.

A despeito de essa última empresa alegar que a diferença cambial e o regime jurídico seriam suficientes para dar ao *geo pricing* a conotação de prática “justa”, e que a disponibilidade de vagas seria realizada por meio de uma “extranet” (interface por meio da qual os hotéis administram seus anúncios), entendeu o DPDC, na Nota Técnica 92/2018, que houve, sim, discriminação da empresa com consumidores por conta da etnia e localização geográfica, o que configura prática abusiva, além de causar verdadeiro desequilíbrio no mercado e nas relações de consumo. Na fundamentação que acompanha a decisão, o DPDC afirmou que, a

despeito de não haver dúvidas acerca da possibilidade de a Decolar estabelecer os preços dos serviços oferecidos em sua plataforma da maneira que mais lhe aprouver,

ao precificar – ou permitir que se precifique – o serviço de acomodação de acordo com a localização geográfica do usuário, a Decolar se conduz de forma a extrapolar o direito de precificar (ou permitir que serviço por ele anunciado seja precificado) de acordo com as práticas do mercado. Com efeito, não se justifica, e nem é prática usual, o estabelecimento de preços diferentes de serviços que são prestados no mesmo local e nas mesmas condições a qualquer consumidor que esteja disposto a pagar por esses serviços.⁵

Em relação à não exibição da disponibilidade total de acomodações, entendeu o DPDC que a infração à ordem jurídica se afigurava ainda mais evidente:

a Decolar extrapola de seu direito de praticar o comércio e de ofertar o produto, prejudicado o consumidor brasileiro, ao não mostrar serviço que não queira vender a determinado consumidor (no caso, o consumidor brasileiro). Isso porque o favorecimento (ou desfavorecimento), bem como a discriminação por conta de etnia, localização geográfica ou qualquer outra característica extrínseca ao ato comercial causa desequilíbrio no mercado e nas relações de consumo.⁶

O caso em comento bem demonstra o quão vulneráveis estão os usuários diante das plataformas digitais, que podem coletar e utilizar seus dados pessoais, muitas vezes, sem sua autorização e mesmo ciência, com finalidade discriminatória. Nesse cenário, os rastreadores e identificadores *on-line* se revelam poderosas ferramentas a serviço de tais práticas, ao permitir que o uso abusivo dos dados pessoais possa concretizar a violação tanto do direito ao tratamento igualitário quanto do direito à privacidade. Para que se analise adequadamente referida questão, faz-se necessário, preliminarmente, passar em revista o conceito de privacidade, a fim de verificar a contemporânea extensão da proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro. É o que se faz a seguir.

1.A proteção de dados e o conceito de autodeterminação informativa

No ordenamento jur⁷ídico brasileiro, o artigo 5º, X, da Constituição da República, e o artigo 21, do Código Civil, fundamentam a proteção da esfera privada da pessoa, referindo-se tanto à vida privada quanto à intimidade.

Em sua origem, o direito à privacidade e, mais especificamente, o direito à intimidade, aludia exclusivamente à proteção da esfera privada ou íntima da pessoa humana contra ingerências externas, alheias e não requisitadas, protegendo seu titular da divulgação, sem sua autorização, de informação ou dado a ele referente. Conferia-se, com efeito, interpretação restrita e sob viés exclusivamente negativo ao direito à privacidade, tutelando-a apenas contra a atuação de terceiros, de modo a impedi-los de nela ingressar sem autorização de seu titular. Em verdade, associado à ideia de casa, de moradia, o princípio foi, de início, utilizado para proteger a vida privada das pessoas dentro de seu próprio lar. A propósito, foi com base nessa noção de privacidade que, em 1890, os *Justices Warren e Brandeis*, da *Supreme Court* Americana, determinaram a necessidade de tutela dessa esfera existencial.

Referida noção de privacidade está, contudo, superada. Se, tradicionalmente, o direito à privacidade (*right to privacy*) estava vinculado ao direito de ser deixado só, contemporaneamente se pode afirmar que o conceito evoluiu para incluir em seu conteúdo situações de tutela de dados sensíveis, de seu controle pelo titular e, especialmente, de “respeito à liberdade das escolhas pessoais de caráter existencial” (LEWICKI: 2003, 9). Essa transformação conceitual foi especialmente motivada pelo reconhecimento da necessidade de proteção qualificada e abrangente da dignidade da pessoa humana, bem como da promoção da livre realização da personalidade. Para Stefano Rodotà, “a privacidade pode ser definida mais precisamente, em uma primeira aproximação, como o direito de manter o controle sobre as próprias informações” sendo a esfera privada “aquele conjunto de ações, comportamentos, opiniões, preferências, informações pessoais, sobre os quais o interessado pretende manter um controle exclusivo” (RODOTÀ: 2008, 92). Significa, em síntese, que “privacy is a fundamental right, essential for freedom, democracy, psychological well-being, individuality, and creativity” (SOLOVE: 2008, 5).

Reconhecem-se, em conclusão, três concepções sobre o direito à privacidade, quais sejam: (i) o direito de ser deixado só; (ii) o direito de ter controle sobre a circulação dos dados pessoais; e (iii) o direito à liberdade de realizar escolhas pessoais de caráter existencial. Dito de outro modo, a privacidade deve ser considerada, para além da noção tradicional, também como o “direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÀ: 2008, 15), conferindo às pessoas autodeterminação informativa e a realização plena de sua liberdade existencial (RODOTÀ: 2008, 92).

Seminal para o desenvolvimento da noção de autodeterminação informativa foi a decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, de 25 de dezembro de 1983, acerca da utilização dos dados obtidos por meio de censo. Em 1982, o Parlamento federal alemão aprovou lei que permitia que dados colhidos no censo fossem empregados para outras finalidades que não o recenseamento, de modo a autorizar sua utilização, por exemplo, por autoridades locais para corrigir cadastros de moradores municipais. A lei sofreu ampla crítica pública e foi objeto de questionamento no Tribunal Constitucional Federal que, embora apoiando os propósitos estatísticos da lei, declarou a necessidade de se salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos contra eventuais abusos, reconhecendo, assim, a inconstitucionalidade da transferência de dados obtidos no recenseamento do governo federal para autoridades locais. A corte alemã forjou, assim, a noção do direito constitucional à autodeterminação informativa, reconhecendo que toda pessoa é livre para decidir sobre as ações a serem implementadas ou omitidas em relação a seus dados.

Ao propósito, Rodotà identifica que “a presença de riscos conexos ao uso das informações coletadas, e não uma natural vocação ao sigilo de certos dados pessoais, foi o que levou ao reconhecimento de um ‘direito à autodeterminação informativa’ como direito fundamental do cidadão”, e conduziu à construção do que chamou de direito à privacidade informática (RODOTÀ: 2008, 64). Ainda para o autor italiano, “a proteção de dados pode ser vista como a soma de um conjunto de

direitos que configuram a cidadania do novo milênio” (RODOTÀ: 2008, 12). Rodotà reconhece que:

o direito fundamental à proteção de dados é continuamente desgastado ou simplesmente desconsiderado por alegações de prevalência de interesses de segurança e da lógica de mercado. Para controlar esta reinvenção regressiva, precisamos de estratégias políticas e legais para não só defender o que foi formalmente reconhecido, mas também para desenvolver seu inerente potencial (RODOTÀ: 2008, 12).

Na esteira da advertência do autor, editou-se, no Brasil, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018, dedicada especificamente à proteção de dados pessoais, sistematizando a matéria que, até então, encontrava-se disciplinada de forma esparsa na legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados ratifica a compreensão da privacidade como direito fundamental, assegurando a seu titular o controle sobre os próprios dados com vistas à promoção do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa humana (art. 1º, LGPD), tornando-o protagonista das decisões acerca do uso de seus dados (MENDES; DONEDA: 2018, 22). A propósito, em decisão emblemática proferida em 7 de maio de 2020, o Plenário do STF reconheceu, no âmbito de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 6387, ADI 6388, ADI 6389, ADI 6390, e ADI 6393), que a proteção de dados encerra, como já alertado por Rodotà, direito fundamental.⁹

Para os fins da LGPD, dado pessoal é composto de informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável (artigo 5º, I), e dado pessoal sensível se refere à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (art. 5º, II).

Apesar de a lei ter trazido conceito ampliado de dados pessoais sensíveis, o seu tratamento jurídico já é conhecido da legislação brasileira desde a promulgação da Lei de Cadastro Positivo (Lei 12.414/11) que, em seu artigo 3º, § 3º, II, proíbe anotações em bancos de dados usados para análise de crédito de “informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas”. A lei tutela, a toda evidência, os princípios da finalidade e da não discriminação, uma vez que, para fins de análise de concessão de crédito, estão vedadas inclusões nas bases de dados de quaisquer informações de natureza personalíssima e que não se relacionem à finalidade almejada com a análise de crédito, com o objetivo de evitar o tratamento discriminatório.¹⁰

A LGPD ratifica, com efeito, a principiologia já insculpida na Lei de Cadastro Positivo e, em seu art. 6º, incisos I e IX, respectivamente, prevê, entre outros, os princípios da finalidade e da não discriminação. O primeiro impõe, nos termos da lei, a “realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades”.

Já o princípio da não discriminação estabelece, também consoante a disposição legal referida, a “impossibilidade de realização do tratamento para fins

discriminatórios ilícitos ou abusivos”. Cuida-se, a rigor, de um dos princípios mais relevantes informadores da LGPD no que diz respeito ao tratamento de dados sensíveis,¹¹ tendo em vista sua elevada capacidade discriminatória, seja quando tratados por entes privados – *i.e.*, fornecedoras de produtos e serviços –, seja por entes públicos. Não por outra razão, a LGPD lhe conferiu disciplina diferenciada nos artigos 11 a 13. Trata-se, em verdade, de disposição que vai ao encontro do artigo 5º, *caput*, da Constituição da República, que tutela o direito ao tratamento sem distinções de qualquer natureza; e do artigo 3º, que elenca entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inc. IV).

Nesse sentido, entende Danilo Doneda que dados sensíveis “seriam determinados tipos de informação que, caso sejam conhecidas e processadas, prestar-se-iam a uma potencial utilização discriminatória ou particularmente lesiva” (DONEDA: 2006, 160-161). A categoria é, portanto, determinada de acordo com o efeito de seu tratamento em relação aos demais dados pessoais, e os valores tutelados, a igualdade material – acima do conteúdo tradicional da privacidade – e a liberdade – a permitir ao titular dos dados o exercício de direitos de maneira autônoma, sem limitações abusivas ou indevidas.

Alguns casos emblemáticos expõem a enorme dificuldade que se enfrenta relativamente ao tratamento indevido desses dados sensíveis. Cohen relata algumas hipóteses em que seu tratamento inadequado, no mais das vezes em violação ao princípio da finalidade, gera discriminação e segregação abusiva no âmbito das relações de consumo:

consumer data can be used for many purposes to which consumers might not so blithely agree: employment decisions and classifications by health insurance providers that exclude or disadvantage genetic or medical “have-nots”; employment or housing decisions based on perceived personality risks; employment or housing decisions based on sexual or religious preferences; and so on (COHEN: 2000, 27).

Em sentido semelhante, Rodotà chama atenção para o fato de que a formação de perfis baseados em dados pessoais sensíveis pode gerar discriminação,

[...] seja porque dados pessoais, aparentemente não “sensíveis”, podem se tornar sensíveis se contribuem para a elaboração de um perfil; seja porque a própria esfera individual pode ser prejudicada quando se pertence a um grupo do qual tenha sido traçado um perfil com conotações negativas (RODOTÀ: 2008, 56).

Para o autor italiano,

[...] para garantir plenitude à esfera pública, determinam-se rigorosas condições de circulação destas informações, que recebem um fortíssimo estatuto “privado”, que se manifesta sobretudo pela proibição de sua coleta por parte de determinados sujeitos (por exemplo, empregadores) e pela exclusão de legitimidade de certas formas de coleta e circulação (RODOTÀ: 2008, 64).

Por esse entendimento, pode-se concluir que, ainda que os dados coletados pelo agente de tratamento não estejam qualificados no artigo 5º, II, da LGPD, e, portanto, não sejam, *a priori* e essencialmente, considerados dados sensíveis, a correlação que pode ser realizada entre dados pessoais não sensíveis – comumente denominado cruzamento de dados – pode levar a um tratamento

discriminatório, que é justamente o que se pretende coibir, quando o legislador qualifica os dados pessoais como sensíveis. Em definitivo, a depender do tratamento recebido, dados pessoais não sensíveis podem revelar dados sensíveis, razão pela qual Doneda adverte que “um dado, em si, não é perigoso ou discriminatório – mas o uso que dele se faz, pode sê-lo” (DONEDA: 2006, 162).

Afigura-se, por conseguinte, inquestionável que o conceito de dados sensíveis depende, fundamentalmente, da função atribuída ao tratamento que lhe é concedido. Significa dizer que dados sensíveis são qualificados como tais não por conta de sua natureza intrinsecamente personalíssima, de forma apriorística e abstrata, mas apenas em razão do uso e da finalidade que lhe são atribuídos por meio de tratamento, que podem ser ilegítimamente discriminatórios. Nesse mesmo sentido, entende Bioni que “um dado ‘trivial’ pode também se transmutar em um dado sensível; particularmente, quando se têm disponíveis tecnologias (e.g., *Big Data*) que permitem correlacionar uma série de dados para prever comportamentos e acontecimentos” (BIONI, 2018, p. 84). Serve bem a demonstrar referida mudança de qualificação dos dados conhecido estudo que utilizou o Facebook como laboratório, levado a cabo pela Universidade de Cambridge, de acordo com o qual seria possível identificar, de forma fidedigna, aspectos existenciais e sensíveis dos usuários da rede social, tais como a orientação sexual, a raça e a tendência político-partidária, a partir da análise de “curtidas” em determinados *posts* (BIONI, 2018, p. 85).

A propósito, o advento de novas tecnologias facilitou, de forma extrema, o acesso e o tratamento não autorizados a dados pessoais, a expandir as potenciais formas de violação da esfera privada, vale dizer, as situações lesivas. Diante desse novo cenário tecnológico, torna-se imperioso analisar e discutir a utilização de rastreadores e identificadores *on-line*, muitas vezes em flagrante violação à privacidade, sobretudo quando tais dados são organizados em perfis destinados à utilização econômica, como se passa a analisar.

2. Dos cookies ao Google Analytics: o que são identificadores e rastreadores on-line

Aumenta exponencialmente a capacidade de tratamento de dados pessoais de consumidores das mais diversas ordens, sobretudo diante do advento de tecnologias avançadas de inteligência artificial, por meio do uso de algoritmos sofisticados e da possibilidade de aprendizado por máquinas (*machine learning*), que não apenas simplificam a coleta de dados como tornam mais barato e rápido todo o processo, desde sua efetiva coleta até seu armazenamento, tratamento, recombinação e manipulação.

Em verdade, dados pessoais sempre estiveram expostos em transações de consumo, mesmo quando realizadas fora da rede: em qualquer compra com cartão de crédito em estabelecimento comercial coleta-se, ao menos, o nome do consumidor e o número do cartão. No entanto, o desenvolvimento tecnológico e a redução de custos permitiram a coleta de novos dados e o seu manejo para diversas outras finalidades, propiciando a criação e o desenvolvimento de mercado próprio de exploração de perfis de consumidores, processo conhecido como

“mineração de dados”, ou *data mining* (HUANG: 1998, 3).¹² Um dos principais instrumentos utilizados no ambiente da internet com referida finalidade é, justamente, o *cookie*.¹³

Originalmente concebidos para otimizar a experiência na rede, os *cookies* – pequenos arquivos de textos que normalmente contêm uma cadeia de números que podem ser usados para identificar um computador (AYENSON; WAMBACH; SOLTANI; GOOD; HOOFNAGLE: 2012, 276) – permitem que, uma vez feito o registro de dados pelo usuário no *site*, a ele regresse em outra oportunidade sem que precise reinserir tais informações. Com o tempo, a ferramenta se revelou imprescindível para o desenvolvimento do comércio virtual, tendo sido utilizada, de acordo com Lessig, já em 1994 pela empresa Netscape, que passou a se valer de protocolo para possibilitar que um servidor, quando acessado pelo usuário, depositasse pequeno arquivo de dados – o *cookie* – em seu computador, permitindo-lhe reconhecê-lo mesmo quando navegasse por página diferente da originalmente acessada (LESSIG: 2006, 48). Cuida-se, com efeito, de pequeno passo em direção à “identidade autenticada: o seu computador não é você (ainda)”, provoca Lessig. No entanto, os ¹⁴*cookies* de armazenamento de informação permitem que o computador confirme, para o servidor, que é a mesma máquina que acessara certo *site* anteriormente (LESSIG: 2006, 48). De todo modo, importa sublinhar que as informações pessoais armazenadas pelos *cookies* são fornecidas pelo próprio usuário, quando por ele inseridas em formulários de pedidos, páginas de pagamento e qualquer outro formulário *on-line*.

Análise estrita revela, portanto, que essa modalidade de *cookie* nada mais é do que uma tecnologia que permite ao servidor seguir a máquina e reconhecê-la pelas páginas em que navega na *web*, não só otimizando, mas, muitas vezes, viabilizando a experiência do usuário: não fossem os *cookies*, por exemplo, o usuário que pretendesse comprar qualquer produto em *site* de compras teria sérias dificuldades em fazê-lo, pois ao incluir o produto no carrinho e em seguida clicar no ícone referente ao pagamento, o carrinho apareceria vazio. Isso porque a arquitetura original da rede não permitia que o servidor se “lembrasse” do usuário quando houvesse mudança de página; o que, a toda evidência, afigura-se totalmente inútil para o comércio eletrônico.

Embora a utilização de *cookies* de armazenamento de informações seja, hoje, o padrão de atuação da Internet (LESSIG: 2006, 49), o emprego dessa tecnologia suscita diversas questões relativas à tutela da privacidade do usuário, razão pela qual o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia (GDPR) passou a exigir que *sites* que deles se utilizam informem sobre seu uso e obtenham o consentimento do usuário previamente ao acesso ao *site*.¹⁵

Pari passu com a evolução da tecnologia de propaganda de *websites*, a tecnologia dos *cookies* também evoluiu, e desenvolveu-se modalidade voltada para rastreamento de usuários, que atua sem a sua autorização ou mesmo conhecimento e opera de diversas formas, entre as quais se destaca o rastreamento de preferências de perfil/*website* do usuário. Pense-se, por exemplo, no amplamente utilizado mecanismo de busca do Google. O sistema de veiculação de anúncios do Google dispõe de tecnologia por meio da qual, quando o usuário visita certos *sites* ou lê determinado conteúdo, lhe são veiculados anúncios

correspondentes às suas preferências de navegação de conteúdo. Essas preferências não são apontadas expressamente pelo usuário, mas modeladas de acordo com seu comportamento na *web*: seu histórico de navegação, a visualização de páginas etc. Assim, se o usuário procurar por “carrinho de bebê” no Google, o sistema registrará essa informação – mesmo sem o seu conhecimento – e, ao acessar outra página cujo conteúdo não tenha qualquer relação com aquela pesquisa, ainda assim anúncios sobre “carrinhos de bebê” lhe serão veiculados. A atividade do usuário é, com efeito, permanentemente vigiada e analisada pela sub-reptícia onipresença dos *cookies*.

Distinguem-se os *cookies* em *first-party* e *third-party cookies* (TPCs). Na primeira modalidade, o *cookie* é implantado pelo próprio *website* que o usuário está visitando, enquanto, na segunda, a implantação é feita por *website* diverso. Como observam Hoofnagle, Soltani, Good e Wambach, TPCs são mecanismos de rastreamento utilizados por empresas que não estabelecem qualquer relação com o consumidor, o que, a toda evidência, suscita relevantes questões atinentes à privacidade, sobretudo quando se agrega ao sistema de rastreamento a formação de perfis – técnica conhecida como *profiling*, por meio da qual se elabora perfis de comportamento de pessoa, família ou grupos definidos, a partir de informações que eles próprios disponibilizam ou que são colhidas em *sites* – e a vinculação desse perfil à identidade do usuário (AYENSON; WAMBACH; SOLTANI; GOOD; HOOFNAGLE: 2012, 276). Ao rastrear esses identificadores em *sites* visitados pelos usuários, os anunciantes podem inferir não apenas seus interesses, mas identificar, inclusive, dados sensíveis, como condições médicas e opiniões políticas.

A situação se torna ainda mais delicada quando os anunciantes passam a lançar mão de *cookies* adaptados, que dificultam ou mesmo impedem sua remoção do computador. Estudo desenvolvido em Berkeley demonstrou que os *sites* mais populares utilizavam os *Flash cookies*. Tecnicamente designados *local shared objects*, os *Flash cookies* são arquivos usados pelos desenvolvedores do Adobe Flash para armazenar dados nos computadores dos usuários, como informações sobre suas preferências (configurações de volume para vídeos da internet, por exemplo), ou para armazenar identificadores de rastreamento. O estudo revelou que a preferência dos anunciantes pelos referidos *cookies* decorre do fato de serem relativamente desconhecidos, mais difíceis de serem removidos e mais eficazes no rastreamento do que os *cookies* padrão ou “HTTP”. Outra grande “vantagem” dos *Flash cookies* sobre os demais – e extremamente nociva à privacidade – é a sua forma de armazenamento que, permitindo que todos os navegadores em um computador o acessem, torna praticamente inevitável o rastreamento, mesmo que o usuário alterne navegadores, os *Flash cookies* viabilizarão seu rastreamento (AYENSON; WAMBACH; SOLTANI; GOOD; HOOFNAGLE: 2012, 277).¹⁶

Nota-se, portanto, como observado por Rodotà, que os meios interativos alteram significativamente a capacidade de coleta de dados e instituem comunicação eletrônica contínua e direta entre gestores de novos serviços e usuários, tornando possível não apenas o controle e direcionamento direto de seu comportamento como também a identificação fidedigna e atualizada de hábitos, inclinações, interesses, preferências. Viabilizam-se, assim, diversos usos

secundários dos dados, na forma de “perfis” relativos a indivíduos, famílias, grupos. Trata-se, nas palavras do autor, de nova “mercadoria”, cuja comercialização pode determinar “os tradicionais riscos para a privacidade: mas pode, sobretudo, modificar as relações entre fornecedores e consumidores de bens e serviços, reduzindo a autonomia destes últimos de tal forma que pode chegar a incidir sobre o modelo global de organização social e econômica” (RODOTÀ: 2008, 42), como se verá com mais profundidade no item seguinte.

Para Doneda, o *profiling*¹⁷ é a forma mais eficiente de segmentação de mercado e direcionamento publicitário. Como explica o autor, “os dados pessoais são tratados, com o auxílio de métodos estatísticos, técnicas de inteligência artificial e outras mais, com o fim de obter uma ‘metainformação’, que consistiria numa síntese dos hábitos, preferências pessoais e outros registros a vida desta pessoa” (DONEDA: 2006, 173). Nesse cenário, o tratamento de *big data* – literalmente, grandes bases de dados – pode conduzir a análises probabilísticas e a resultados que, se, por um lado, promovem os interesse de certo nicho do mercado, incrementando e personalizando a venda de produtos e serviços, de outro, aumentam o controle sobre a pessoa, mitigam sua autonomia e o seu direito de livre acesso ao consumo de bens e serviços e a determinadas políticas públicas, além de dificultar sua participação no processo decisório relativo ao tratamento de seus dados pessoais.¹⁸

Um dos mais emblemáticos casos de utilização de *cookies* no tratamento de dados por meio de análise de *big data* por fornecedores de produtos na Internet envolveu a loja de departamentos americana *Target*, que, a partir da análise do perfil de consumo de suas clientes, conseguiu identificar não apenas aquelas que estavam grávidas, mas o estado da gravidez e o período de gestação, o que permitiu lhes direcionar produtos de acordo com sua particular situação. O caso se tornou conhecido quando um pai indignado procurou uma das lojas da varejista atribuindo a ela a conduta de estimular sua filha adolescente a engravidar, tendo em vista a lista de sugestões de produtos de maternidade com a qual o genitor se deparou no computador pessoal da família. A surpresa veio quando o pai descobriu que, de fato, sua filha já se encontrava grávida.¹⁹

Resta evidente, com efeito, que *cookies* e outros identificadores eletrônicos – i.e., estatísticas fornecidas por análise de *big data* (*data analytics*) – encerram verdadeiros mecanismos de identificação pessoal. Não por outro motivo, o artigo 4, 1, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia (GDPR), ao relacionar os conceitos nele utilizados, considera também como dado pessoal a informação relativa à pessoa singular identificável, direta ou indiretamente, por meio de identificadores por via eletrônica. Dito de outro modo, para fins de aplicação da GDPR, consideram-se dados pessoais as informações obtidas por meio de identificadores eletrônicos capazes de revelar, ainda que indiretamente, a identidade de seu titular.

Em complementação, a GDPR reconhece o uso de *cookies* e outros identificadores pessoais em seu comentário (26), e os identifica como possível instrumento de reconhecimento pessoal. Ao propósito, estabelece o comentário que:

as pessoas singulares podem ser associadas a identificadores por via eletrônica, fornecidos pelos respectivos aparelhos, aplicações, ferramentas e protocolos, tais como endereços IP (protocolo internet) ou testemunhos de conexão (*cookie*) ou outros identificadores, como as etiquetas de identificação por radiofrequência. Estes identificadores podem deixar vestígios que, em especial quando combinados com identificadores únicos e outras informações recebidas pelos servidores, podem ser utilizados para a definição de perfis e a identificação das pessoas singulares.

Eis, portanto, a razão pela qual os rastreadores e identificadores *on-line* assumem crescente importância no cenário atual: a economia contemporânea gira em torno, em grande medida, de tratamento de dados pessoais. Não por outro motivo, tem-se identificado nos dados pessoais uma das principais fontes de riqueza do século XXI.

3. Data as the new oil: precificação dos dados e o novo insumo da relação de consumo

Fica evidente que o uso de identificadores eletrônicos para fins de construção de perfis de consumo baseados em dados pessoais é resultado de uma nova forma de organização econômica.

A evolução de uma economia agrária para uma industrial e, então, para uma pós-industrial (baseada em serviços) revela a substituição dos insumos econômicos e financeiros ao longo dos anos. De uma economia estruturada em produtos agrícolas para uma fundamentada em bens industrializados, foram necessárias décadas ou mesmo séculos, se se considerar o início do desenvolvimento da atividade agrícola economicamente relevante.

Contudo, levou pouco mais de 30 anos para emergir nova estrutura econômica²⁰ baseada não mais em produção material fundamentada em trocas financeiras, mas em insumos intangíveis constituídos pelos dados pessoais. Esse novo modelo econômico, calcado na coleta e tratamento de dados pessoais, representa avanço sem precedentes para o sistema capitalista, na medida em que propicia a apreensão do insumo dado pessoal de forma gratuita, em grande medida. O surgimento dessa nova economia – *Infonomics*²¹ – só se tornou possível devido ao desenvolvimento de tecnologias que criaram as condições para coleta, processamento e compartilhamento de informações – ou dados – em quantidade e velocidade inimagináveis anteriormente (BIONI: 2018, 3).

Os dados pessoais passam a ser considerados um ativo dentro dessa nova estrutura econômica. Por meio da coleta e tratamento dos dados pessoais se tornou possível não só segmentar o mercado de consumo por meio da criação de perfis, como destacado anteriormente, mas também promover de forma eficiente a publicidade direcionada de produtos e serviços, baseada justamente no *profiling* realizado com base na reunião daqueles dados. O titular dos dados fornecidos passa a ser um “consumidor de vidro”, que, de acordo com Susanne Lace, é aquele que “others know so much about us, they can almost see through us”. (LACE: 2005, 1, apud BIONI: 2018, 22-23).

A economia da informação baseia-se, dessa maneira, na possibilidade de precificar os dados coletados e tratados, isto é, na capacidade de conceder aos

dados valor monetário a ser explorado pelos atores que se valem desse insumo em seus modelos de negócio. Para Doneda, a chamada monetização dos dados justificaria o reconhecimento da qualidade de bem jurídico à informação, sendo possível se utilizar, dentro da sistemática do direito privado, das normas protetivas do direito de propriedade para a sistematização de sua tutela (DONEDA: 2006, 164).

Dentro dessa nova economia da informação, os maiores beneficiados da monetização são as cinco sociedades que possuem, juntas, o maior valor de mercado no mundo, quais sejam, Facebook, Amazon, Google, Microsoft e Apple. O modelo de negócios dessas sociedades é baseado substancialmente na coleta e tratamento de dados pessoais de seus usuários, sob o argumento de que os dados apreendidos servem para propiciar uma experiência singular, feita sob medida para os interesses do titular de dados, otimizando, assim, a fruição da atividade, produto ou serviço oferecido. Considerando-se que a Amazon arrecada metade de todos os dólares gastos em compras *on-line* nos EUA, e que o Google e Facebook, sozinhos, foram responsáveis quase que exclusivamente pelo incremento da receita em publicidade digital nos EUA no ano de 2018,²⁴ conclui-se que o uso de dados pessoais para o desenvolvimento da economia da informação representa um modelo de organização econômica de estrondoso sucesso.

A apreensão desses dados, por si só, não conduziria a maiores benefícios para esse modelo de negócios se não houvesse, ao lado da coleta em massa, o aperfeiçoamento de técnicas de análise de dados em grande escala, a gerar resultados estatísticos eficientes para fins de publicidade direcionada. Entre as técnicas utilizadas, o uso de Inteligência Artificial (IA), Algoritmos e de *Data Analytics* despontam como as mais eficientes. Considerando que toda atividade pessoal realizada *on-line* deixa rastro digital, pode-se concluir, sem muito esforço, que o “Google can see what people search for, Facebook what they share, Amazon what they buy”²⁵.

Como apontado por Doneda, referido modelo de negócio só se afigura viável porque possibilita a monetização dos dados pessoais. O desafio atual consiste, justamente, em conciliar as práticas desse modelo de negócio com as disposições legais protetivas dos dados pessoais, bem como com as expectativas legítimas dos seus titulares no que tange ao seu tratamento e eventual divulgação (DONEDA: 2012, 11-12).

4. Considerações finais

“Nascida como exigência essencialmente individual, a privacidade requer cada vez mais uma construção social” (RODOTÀ: 2008, 91). A afirmação contundente de Rodotà se torna cada vez mais atual diante das infinitas situações lesivas produzidas pelo desenvolvimento tecnológico.

A utilização de *cookies* de identificação e rastreamento, muitas vezes sem o conhecimento e consentimento do usuário, permite a formação de diversos perfis sobre a mesma pessoa, aos quais se atribuem uma miríade de finalidades, entre as quais se destacou o direcionamento de anúncios, a reduzir significativamente a

autonomia do consumidor, que sofre significativa limitação na sua liberdade de escolha e passa a ser submetida a processo de decisão automatizada.

Ademais, o modelo de negócio utilizado por cinco empresas – Facebook, Amazon, Google, Microsoft e Apple, que não apenas somam o maior valor de mercado do mundo, mas certamente fazem parte do dia a dia de quase todas as pessoas do mundo –, está calcado na coleta e tratamento de dados pessoais de seus usuários por meio de *cookies*, a revelar a institucionalização de um caminho sem volta designado monetização dos dados.

Não há dúvidas de que a evolução tecnológica continuará a aprimorar, a passos largos, as funções dos *cookies*, maximizando a experiência do usuário, por um lado, mas pondo em xeque sua privacidade sem que ele próprio tenha, muitas vezes, qualquer percepção da ameaça. A tecnologia está aí, e é um caminho sem volta. Ela não é intrinsecamente boa nem ruim. Bom ou ruim é o uso que se lhe atribui. Cabe aos operadores do direito reforçar a tutela da privacidade, impedindo que a utilização da tecnologia se volte para a sua violação por meio do uso indevido dos dados pessoais. Como já advertiu Rodotà, “as estratégias de tutela da privacidade, portanto, exigem múltiplos instrumentos, que não são incompatíveis entre si e que, ao menos em algumas situações, podem funcionar em conjunto” (RODOTÀ: 2008, 90). É tudo uma questão de inovação: tecnológica e jurídica. Afinal, *cookies are dead. Long live cookies!*

5. Bibliografia

AYENSON, Mika D; WAMBACH, Dietrich James; SOLTANI, Ashkan; GOOD, Nathan; HOOFNAGLE, Chris Jay. Flash Cookies and privacy II: now with HTML5 and ETag Respawning, 2011. Disponível em: [<https://ssrn.com/abstract=1898390>]. Acesso em: 14.02.2019.

AYENSON, Mika D; WAMBACH, Dietrich James; SOLTANI, Ashkan; GOOD, Nathan; HOOFNAGLE, Chris Jay. Behavioral advertising: the offer you can't refuse. *Harvard Law & Policy Review*, n. 6, v. 273, p. 274-296, 2012. Disponível em: [<http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2086>]. Acesso em: 14.02.2019.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. São Paulo: Forense, 2018.

COHEN, Julie. Examined lives, informational privacy and the subject as object. *52 Stan. L. Rev.*, 1373-1438, 2000.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DONEDA, Danilo. Reflexões sobre proteção de dados pessoais em redes sociais. *Revista de la Red Académica Internacional de Protección de Datos Personales*. n. 1, jul.-dic. 2012.

DUHHIG, Charles. How Companies Learn your secrets. *New York Times*. Disponível em: [www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html]

pagewanted=1&_r=1&hp]. Acesso em: 07.02.2019.

HUANG, Peter H. The law and economics of consumer privacy versus data mining. *Social Science Research Network*. maio 1998. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94041]. Acesso em: 13.02.2019.

LACE, Susanne. *The glass consumer: life in a surveillance society*. Bristol: Policy Press, 2005.

LESSIG, Lawrence. *Code (version 2.0)*. Nova York: Basic Books, 2006.

LEWICKI, Bruno. *A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho*. Rio de Janeiro, Renovar, 2003.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova lei de proteção de dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor* (Revista dos Tribunais *on-line*), v. 120, 2018.

MORAES, Maria Celina Bodin de; TEFFÉ, Chiara. Redes sociais virtuais, privacidade e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. *Revista Pensar*, v. 22, n. 1, 2017.

MULHOLLAND, Caitlin. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18). *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, v. 19, p. 159-180, 2018.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

SOLOVE, Daniel J. *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Links:

The worlds most valuable resource is no longer oil but data. Disponível em: [www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data]. Acesso em: 07.02.2019.

Data is giving rise to a new economy. Disponível em: [www.economist.com/briefing/ 2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy]. Acesso em: 07.02.2019.

[https://portalnovarejo.com.br/2018/07/amazon-50-por-cento-vendas-on-line-eua-2018-emarketer/]. Acesso em: 07.02.2019.

[www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/05/03/anuncio-digital-supera-tv-nos-eua.html]. Acesso em: 07.02.2019.

2

.Professora Associada de Direito Civil da PUC-Rio. Professora Pesquisadora do Núcleo Legalite da PUC-Rio. Doutora em Direito Civil (UERJ).

3

.*How to think about data in 2019*. Disponível em: [www.economist.com/leaders/2018/12/22/how-to-think-about-data-in-2019]. Acesso em: 22.12.2018.

4

.Em 25 de janeiro de 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública contra a Decolar.com em razão das mesmas práticas de *geo-blocking* e *geo-pricing*. A pedido da defesa da Decolar.com, a Justiça decretou o sigilo da ação, alegando que a publicidade das informações poderia comprometer o modelo de negócio da empresa, razão pela qual não se teve acesso aos autos até a conclusão deste artigo. Cuida-se da Ação Civil Pública 0018051-27.2018.8.19.0001, que tramita perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

5

.Ministério da Justiça, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Nota Técnica 92/2018/CSA-SENACON/CGCTSA/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ. p. 10. Disponível em: [www.cmlagoasanta.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/PRATICAS_ABUSIVAS_DECOLARCOM?cdLocal=2&arquivo=%7BBBCA8E2AD-DBCA-866A-C8AA-BDC2BDEC3DAD%7D.pdf]. Acesso em: 18.01.2019.

6

.Ministério da Justiça, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Nota Técnica 92/2018/CSA-SENACON/CGCTSA/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ. p. 10. Disponível em: [www.cmlagoasanta.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/PRATICAS_ABUSIVAS_DECOLARCOM?cdLocal=2&arquivo=%7BBBCA8E2AD-DBCA-866A-C8AA-BDC2BDEC3DAD%7D.pdf]. Acesso em: 18.01.2019.

7

.Partes desenvolvidas neste item foram publicadas originalmente no artigo Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da lei geral de proteção de dados (Lei 13.709/18), de autoria de Caitlin Mulholland, publicado na *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, v. 19, 2018.

8

.Mencionem-se, exemplificativamente: o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que cuida dos bancos de dados e cadastros de consumidores; a Lei do *Habeas Data* (Lei 9.507/1997), que garante o conhecimento, a retificação e a anotação de dados pessoais constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; o artigo 21 do Código Civil, que prevê a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural; a Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011), que trata dos bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito; a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), destinada a regular o acesso a dados; e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, tratando, em linhas gerais, da proteção de dados pessoais.

9

A decisão suspendeu a eficácia da MP 954/20, que estabelece o compartilhamento de dados dos por empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefônico fixo comutado e de serviço móvel pessoal com o IBGE, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a pandemia decorrente do covid-19.

10

.Em pesquisa realizada em 14.05.2020, utilizando-se como parâmetro de busca termos da Lei 12.414/11, há, no Superior Tribunal de Justiça, 1 Súmula (550), dois acórdãos de repetitivos e doze acórdãos que tratam da temática relacionada ao sistema de *credit scoring*. As decisões, de uma maneira geral, reconhecem o direito do consumidor de ter o acesso aos dados que foram

utilizados pelas financeiras ou bancos para a negativa do direito ao crédito. Ver por todos, nesse sentido, o julgamento do Recurso Especial 1.304.736/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.02.2016.

11

.Particularmente sensíveis são os dados genéticos que, “por seu caráter *estrutural e permanente*, [...] constituem a parte mais dura do “núcleo duro” da privacidade, fornecem o perfil mais definido da pessoa e estão, assim, na base de ações discriminatórias” (grifos no original) (RODOTA: 2008, 70).

12

.Para Huang, “Like any type of information, consumer data has both costs and benefits. The costs of consumer data include the loss of privacy and all of its attendant problems, such as the potential for either criminal misuse or state abuse. The benefits of consumer data include the matching of consumers with businesses which can satisfy their preferences and better safety or security for consumers in verifying identification or detecting criminals” (HUANG: 1998, 5-6).

13

.Há duas possíveis teorias para explicar o uso do termo *cookies*. A primeira é de que o nome é derivado de *magic cookies*, que era uma parte do sistema operacional UNIX. Outros entendem que sua origem se deu devido ao conto “João e Maria”, que, como se sabe, usavam migalhas de biscoitos para conseguir rastrear sua saída da floresta de volta para casa.

14

.Na versão original: *authenticated identity: your computer isn't you (yet)*.

15

.Normalmente, os *sites* usam cláusulas com conteúdo semelhante a este: “We use cookies to tailor your experience, measure site performance and present relevant offers and advertisements. By clicking on ‘Allow’ or any content on this site, you agree that cookies can be placed”.

16

.Afirmam os autores, em outra oportunidade: “We documented other tracking advantages of Flash cookies as well—they are more persistent than HTTP cookies, they can store 100KB of information by default (HTTP cookies only store 4KB), and they are stored such that all browsers on an computer can access them, meaning that even if a user switches browsers, Flash cookies enables the user to be tracked” (AYENSON; WAMBACH; SOLTANI; GOOD; HOOFNAGLE: 2011, 2).

17

.De acordo com o artigo 4º, 4, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (GDPR), “Definição de perfis” se caracteriza por “qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspetos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações”.

18

.Sobre o tema, confira-se BODIN, TEFFÉ: 2016, 21.

19

.Para uma descrição do caso, ver o artigo de Charles Duhhig (How companies learn your secrets. *New York Times*. Disponível em: [www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shoppinghabits.html?pagewanted=1&_r=1&hp]. Acesso em: 07.02.2019).

20

.Esse período tem seu termo inicial na popularização do comércio eletrônico, via internet, que se deu em meados da década de 1990. O gigante Amazon, por exemplo, foi fundado em 1994.

21

.O termo foi cunhado por Douglas B. Laney, Vice-Presidente da Gartner Inc. e autor do livro *Infonomics: how to monetize, manage, and measure information as an asset for competitive advantage*.

22

As 5 maiores empresas de tecnologia dos EUA valem, juntas, mais de US\$ 5 trilhões. Informação obtida em <https://computerworld.com.br/2020/01/20/as-5-maiores-empresas-de-tecnologia-dos-eua-valem-juntas-mais-de-us-5-trilhoes/>. Acesso em 14.05.2020.

23

.Dados obtidos em: [<https://portalnovarejo.com.br/2018/07/amazon-50-por-cento-vendas-on-line-eua-2018-emarketer/>]. Acesso em: 07.02.2019.

24

.Dados obtidos em: [www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/05/03/anuncio-digital-supera-tv-nos-eua.html]. Acesso em: 07.02.2019.

25

.Disponível em: [www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data].

Capítulo 8. Transferência internacional de dados na Lei Geral de Proteção de Dados – Força normativa e efetividade diante do cenário transnacional

Angelo Gamba Prata de Carvalho¹

1. Introdução

A disponibilização de dados pessoais para que se possa usufruir dos diversos serviços privados e públicos é característica inafastável da era digital. Seja para a confecção de documentos, para a utilização de sistemas GPS, seja mesmo para a participação em redes sociais e jogos eletrônicos, o cadastro de dados é requisito para a constituição do sujeito digital de cada indivíduo. Daí dizerem Introna e Nissenbaum que, nos dias de hoje, existir é estar indexado em um mecanismo de busca.²

Diante disso, a preocupação a ser levada em consideração quando do tratamento de dados pessoais não se limita à tutela da privacidade de acordo com as diretrizes do ordenamento jurídico interno, mas também integra, necessariamente, os riscos envolvidos na transferência internacional de dados, já que a maioria esmagadora dos servidores destinados a armazenar tais informações se encontra no exterior. Nesse sentido, sugere Marcelo Neves que, com o tempo, o incremento das relações transterritoriais com implicações normativas fundamentais levou à necessidade de abertura da proteção de direitos fundamentais para além do Estado, de tal maneira que o direito doméstico passou a ser uma instituição limitada para enfrentar tais problemas.³

Em estudo elaborado enquanto a internet ainda dava seus primeiros passos, Reinhard Ellger já demonstrava que os fluxos de dados mais intensamente transferidos internacionalmente seriam advindos de: (i) departamentos de pessoal; (ii) bancos, companhias de seguros, companhias de cartões de crédito e *bureaus* de crédito; (iii) *marketing* direto; (iv) linhas aéreas e outros agentes da indústria do turismo; (v) empresas com clientes estrangeiros; (vi) entidades do setor público.⁴

Não é por outra razão que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), na esteira do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (RGPD), previu uma série de normas destinadas a garantir a higidez de operações de transferência internacional de dados, que serão expostas e comentadas sistematicamente no presente trabalho. No entanto, é importante notar que a recalcitrância do direito norte-americano em adimplir a padrões elevados de proteção de dados tem motivado grandes polêmicas em nível internacional, motivando, inclusive, a celebração de tratado bilateral de proteção de dados entre os Estados Unidos e a

União Europeia. Contudo, acordos como esse não são privilégio – ao menos até o presente momento – de países como o Brasil. Daí a relevância da exposição, também, das dificuldades oriundas da inexistência de normas gerais de proteção de dados dos Estados Unidos e da incompatibilidade daquele ordenamento com o patamar protetivo instaurado em outras jurisdições.

Por fim, o presente trabalho buscará, a partir da contraposição entre o estado de coisas inaugurado pela LGPD com o risco de ineficácia oriundo da resistência à aplicação de normas de proteção de dados por parte de determinados países, apontar possíveis caminhos para a construção, a partir da autoridade nacional e dos próprios agentes econômicos, de bases normativas capazes de garantir a efetividade da LGPD para transferências internacionais mesmo com todas as dificuldades existentes.

II. A transferência internacional de dados na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira

A edição de uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil não poderia deixar de tratar da transferência internacional de dados, seja em virtude da globalização econômica, seja em razão do fato de que transações envolvendo dados pessoais muito dificilmente deixam de ter dimensão internacional relevante.⁵ Cabe, por conseguinte, analisar de maneira sistemática os elementos e âmbitos de aplicação previstos pela LGPD para a transferência internacional de dados, campo ainda pouco explorado mesmo pela legislação brasileira, a ser preenchido pela atuação da autoridade nacional de proteção de dados.

No inciso XV de seu art. 5º, a LGPD define, de maneira quase tautológica, que transferência internacional de dados é a “transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro”. De maneira diversa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu abriu mão de uma definição de transferência internacional de dados que tão somente reafirma o óbvio – de que é transferência internacional aquela que envia dados para outro país – para estabelecer um princípio geral das transferências que agrega à sua definição o próprio patamar protetivo plasmado no RGPD.⁶

À semelhança do que se fez no Regulamento europeu, a LGPD brasileira estrutura três regimes relativamente distintos de tutela das transferências internacionais de dados, a saber: (i) a declaração de existência de grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD; (ii) a existência de garantias de cumprimento dos preceitos da LGPD; (iii) derrogações específicas do regime da LGPD, casuisticamente listados com vistas a promover algum objetivo de interesse público. Como se verá a seguir, a manutenção de três regimes distintos está – ao menos em tese – em consonância com o ponto de vista de que a proteção de dados pessoais está intimamente relacionada à proteção de direitos fundamentais,⁷ o que não apenas enseja a aplicação extraterritorial das disposições a respeito do tema,⁸ como também requer uma reflexão mais aprofundada sobre situações de colisão do direito à privacidade com outros direitos fundamentais. Nesse sentido, os itens a seguir buscarão esclarecer e sistematizar os detalhes dos três regimes que constam da LGPD.

II.1. Transferência internacional para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei brasileira

A hipótese de permissão de transferência internacional de dados prevista no inciso I do art. 33 da LGPD certamente é a mais críptica de todos os regimes existentes, na medida em que a lei silenciou sobre os detalhes para a qualificação de determinado ordenamento ou corpo normativo como “adequado” aos preceitos da lei brasileira, relegando tal tarefa à autoridade nacional em seu art. 34. É nos incisos do art. 34, aliás, que são exemplificativamente arrolados os parâmetros a serem levados em consideração pela autoridade nacional ao realizar o aludido juízo, a saber: (i) as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional; (ii) a natureza dos dados; (iii) a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos na LGPD; (iv) a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; (v) a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e (vi) outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

Pode-se, já em um primeiro momento, traçar distinção fundamental entre a LGPD brasileira e o RGPD europeu, que orienta a Comissão Europeia a decidir pela adequação do nível de proteção em torno de três pilares ainda bastante abertos, porém com um maior nível de especificação, como se depreende do item 2 do art. 45 do Regulamento europeu:

a) O primado do Estado de direito, o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a legislação pertinente em vigor, tanto a geral como a setorial, nomeadamente em matéria de segurança pública, defesa, segurança nacional e direito penal, e respeitante ao acesso das autoridades públicas a dados pessoais, bem como a aplicação dessa legislação e das regras de proteção de dados, das regras profissionais e das medidas de segurança, incluindo as regras para a transferência ulterior de dados pessoais para outro país terceiro ou organização internacional, que são cumpridas nesse país ou por essa organização internacional, e a jurisprudência, bem como os direitos dos titulares dos dados efetivos e oponíveis, e vias de recurso administrativo e judicial para os titulares de dados cujos dados pessoais sejam objeto de transferência;

b) A existência e o efetivo funcionamento de uma ou mais autoridades de controlo independentes no país terceiro ou às quais esteja sujeita uma organização internacional, responsáveis por assegurar e impor o cumprimento das regras de proteção de dados, e dotadas de poderes coercitivos adequados para assistir e aconselhar os titulares dos dados no exercício dos seus direitos, e cooperar com as autoridades de controlo dos Estados-Membros; e

c) Os compromissos internacionais assumidos pelo país terceiro ou pela organização internacional em causa, ou outras obrigações decorrentes de convenções ou instrumentos juridicamente vinculativos, bem como da sua participação em sistemas multilaterais ou regionais, em especial em relação à proteção de dados pessoais.

Espera-se, por óbvio, que o que está contido na supramencionada alínea a do diploma europeu seja o material a ser analisado pela autoridade brasileira de proteção de dados quando da avaliação da adequação de determinados sistemas jurídicos. Não obstante, a LGPD entabula interessante critério reflexivo, na medida em que não se importa com a existência e a efetividade de normatização de

proteção de dados, mas com a observância dos princípios contidos na própria lei brasileira, em nítida tentativa de extensão extraterritorial dos efeitos da lei nacional. Não se verifica, na lei brasileira, assim, a exigência de que ordenamentos estrangeiros contem com um arcabouço normativo específico de proteção de dados, mas sim que, em última análise, o núcleo fundamental da LGPD possa ser encontrado, ainda que difusamente, no ordenamento destinatário dos dados a serem transferidos.

Naturalmente, como já se afirmou, caberá à autoridade nacional aquilatar os elementos concretos dos ordenamentos de destino dos dados para que se verifique o grau de proteção fornecido. Contudo, o que importa aqui assinalar é que a análise prevista pelo inciso I do art. 33 da LGPD não é pontual ou casuísta, mas, sim, diz respeito à aptidão do ordenamento como um todo para garantir nível adequado de proteção de dados, de sorte que cada decisão da autoridade nacional sobre determinada jurisdição deverá ser tida como declaração de idoneidade daquele ordenamento, ao menos por certo período de tempo. Em outras palavras, o inciso I representa uma decisão da autoridade com efeitos amplos e gerais, demonstrando o posicionamento da autoridade quanto à determinada jurisdição.

II.2. Garantias de cumprimento dos preceitos da LGPD

Ainda que o ordenamento destinatário dos dados não forneça todas as salvaguardas necessárias ao atendimento dos padrões protetivos estabelecidos pela LGPD, é possível que o controlador específico ofereça e comprove garantias de cumprimento dos preceitos da lei brasileira, seja por meio de cláusulas contratuais (padrão ou específicas), normas corporativas globais, ou selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos (art. 33, II, da LGPD).

Em que pese a relevância da existência de uma autoridade central de proteção de dados, não se pode olvidar que a regulação não se efetiva tão somente por intermédio da normatização estatal, mas também pode se dar – muitas vezes, com maior efetividade – a partir de uma iniciativa de particulares que, com maior razão, têm interesse em alterar a cultura do ambiente de negócios em que se encontram,⁹ a partir e para além da conformidade com as normas aplicáveis.¹⁰ Não é por outros motivos que autores como Hugh Collins defendem que o direito contratual deve ter por objetivo regular mercados, práticas comerciais e práticas sociais de contratação, de modo a ressaltar os valores fundantes do ordenamento e, ao mesmo tempo, proteger as esferas de autorregulação estruturadas pelas partes no âmbito de sua autonomia privada.¹¹

Naturalmente, há grande interesse econômico nos fluxos internacionais de dados, motivo pelo qual a transferência de dados é também matéria de interesse de diversos tratados internacionais, cuja exequibilidade está diretamente relacionada a um equacionamento adequado entre autonomia privada e proteção do interesse público.¹² Nem se argumente, porém, que a possibilidade aberta pela LGPD de que seus preceitos sejam protegidos por intermédio de instrumentos privados significaria uma flexibilização dos princípios nela entabulados. Pelo contrário, é importante que o ordenamento forneça um quadro regulatório capaz de incentivar a liberdade contratual e a autonomia privada e que, ao mesmo tempo,

atenda aos imperativos das normas cogentes, especialmente as protetivas de interesses difusos.¹³

Ademais, não se pode deixar de notar que as iniciativas privadas de proteção à LGPD – isto é, aquelas aptas a levar a cabo transferências internacionais de dados pessoais – precisam, em alguma medida, orientar-se por parâmetros mais ou menos previsíveis que autorizem identificar cláusulas contratuais que confirmem patamar adequado de proteção de dados. Daí o motivo pelo qual o art. 35 da LGPD determina que a verificação das cláusulas contratuais para uma determinada transferência, bem como normas corporativas globais ou selos, fica a cargo da autoridade nacional de proteção de dados, que considerará os requisitos, as condições e as garantias mínimas previstos pela lei brasileira para a viabilização de soluções privadas. Por certo, a definição de padrões pode também, sob os auspícios da autoridade nacional, vir do próprio mercado, que poderá desenvolver certificações para o reconhecimento da adesão a um padrão corporativo de conduta legítima.¹⁴

A tarefa da autoridade nacional, cabe ressaltar, é naturalmente difícil pelo fato de lidar diretamente com direitos de privacidade, contendo o inafastável elemento de cogência que é próprio da proteção de direitos fundamentais. Nesse sentido, a natureza comercial de alguns acordos não pode jamais derrogar a importância do seu conteúdo, como ocorre com os contratos de *cloud computing*, técnica capaz de gerar muito mais eficiência ao armazenamento de dados por empresas e consumidores que, obviamente, podem optar por guardar qualquer conteúdo que lhes aprouver em servidores que muito dificilmente ficarão instalados na mesma jurisdição em que se encontram ou, no mínimo, serão “espelhados” em outros países.¹⁵

No entanto, por mais profunda que possa ser a análise da autoridade nacional quanto às garantias específicas fornecidas por instrumentos contratuais, ela irremediavelmente se agrava quando a proteção de dados se entrelaça com outros interesses relevantes, como direitos trabalhistas, que abrem todo um novo panorama de riscos a direitos fundamentais,¹⁶ ou condições concorrenciais, considerando a potencialização dos processos decisórios na economia movida a dados.¹⁷

Assim, o segundo regime de transferência internacional de dados previsto pela LGPD revela uma nova dimensão de análise da higidez da transmissão de informações, já que autoriza, ainda que em um ordenamento pouco protetivo, a transferência segura de dados, autorizada, antes de tudo, pelas salvaguardas apresentadas pela autonomia privada das partes e avalizadas pela autoridade nacional, seja à luz da própria LGPD, seja à luz de *standards* fixados por autoridades privadas independentes.

II.3. Derrogações específicas

Por fim, a LGPD prevê um terceiro regime autorizativo da transferência internacional de dados, que se caracteriza, em verdade, pelo afastamento do manto de proteção do diploma, porém sempre em homenagem a outros objetivos de interesse público previstos de maneira taxativa pelos incisos III a VIII do art. 33

da LGPD, a saber: (i) quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; (ii) quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; (iii) quando a autoridade nacional autorizar a transferência; (iv) quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional; (v) quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público; (vi) quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; (vii) quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º da LGPD (cumprimento de obrigação legal ou regulatória, cumprimento de termos contratuais e para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral).

A existência dessas exceções, contudo, não pode significar um completo afrouxamento do manto protetivo da LGPD, sendo incabível argumentar que o simples fato de se tratar de situação de aplicação de outros direitos fundamentais derogaria por completo a necessidade de proteção da privacidade. Basta notar, nesse sentido, que muito se tem desenvolvido no campo de sistemas de segurança na intercomunicação entre plataformas de prontuários médicos eletrônicos,¹⁸ na transmissão de dados relativos ao *doping* de atletas,¹⁹ bancos de dados de genoma²⁰ e de informações médicas,²¹ entre muitos outros exemplos de mecanismos de proteção à saúde e à vida humanas que, ainda assim, buscam proteger a privacidade dos sujeitos envolvidos.

Contudo, não se pode negar que as disposições contidas nos incisos supramencionados constituem situações residuais, nas quais nem a autoridade nacional de proteção de dados certificou a higidez da sistemática protetiva dos ordenamentos de origem nem há mecanismos que assegurem a proteção adequada de direitos fundamentais. Importa acrescentar que, naturalmente, há situações em que o afastamento da LGPD decorre, por mais irônico que pareça, de sua própria aplicação, já que constam, entre as derrogações específicas, a influência de acordos internacionais e a análise casuística da autoridade nacional sobre determinada situação.

Não obstante, alguns dos dispositivos anteriormente aludidos levantam altíssima indagação, inclusive a nível constitucional. Basta notar, nesse sentido, que, muito embora a LGPD preveja a sua derrogação na hipótese de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, não se pode deixar de notar que o regramento de proteção de dados representa verdadeiramente a densificação do direito constitucional à privacidade, de sorte que sua leitura à luz da Constituição deve impedir a flexibilização indevida de direitos fundamentais ou mesmo o seu sacrifício, devendo a norma legal prevalente ser definida à luz das circunstâncias concretas e da relevância dos direitos fundamentais envolvidos.²²

Em outras palavras, a aplicação das derrogações deve, necessariamente, estar atenta à proteção dos direitos fundamentais. Nesse sentido, é importante apontar o acerto da LGPD brasileira ao deixar de fazer referência ao “interesse público”,

como fez o RGPD europeu, noção que atualmente é controversa inclusive entre os administrativistas.²³ No entanto, ainda que a tradição jurídica brasileira fatalmente faça a aplicação da LGPD convergir para a utilização da noção de interesse público²⁴ – nomeadamente na aplicação do inciso que trata de execução de políticas públicas – faz-se necessária a sua adaptação aos imperativos de racionalidade democrática exigidos pela ordem constitucional vigente. É por essa razão que parece acertado o ponto de vista de Gustavo Binenbojm,²⁵ para quem o “melhor interesse público só pode ser obtido a partir de um procedimento racional que envolve a disciplina constitucional de interesses individuais e coletivos específicos”.²⁶

Por fim, com maior razão se deve levar em consideração a vigência dos direitos fundamentais na aplicação da LGPD quando sua derrogação envolve interesses de vulneráveis, que ganham especial fragilidade quando a lei autoriza o afastamento de seu manto tuitivo na hipótese de o titular dos dados anuir expressa e destacadamente a isso. Nesse caso, trata-se de norma destinada a franquear o afastamento da LGPD em contratos de adesão, motivo pelo qual cláusulas dessa espécie devem necessariamente ser interpretadas por intermédio dos mecanismos hermenêuticos próprios a contratos como esses.²⁷

Dessa maneira, verifica-se que a LGPD, ao prever o seu próprio afastamento em situações como as anteriormente descritas, não determina simplesmente o esquecimento do arcabouço protetivo fornecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas exige uma reflexão acerca do *modus operandi* da proteção a direitos fundamentais e interesses relevantes em situações limítrofes, motivo pelo qual, mesmo nessas circunstâncias, é imprescindível que a autoridade nacional de proteção de dados fixe padrões de proteção mínima a serem observados quando da aplicação das hipóteses supramencionadas.

III. Exceptio probat regulam? Percalços e perspectivas da garantia de proteção adequada na transferência internacional de dados

O famoso discurso de Cícero em defesa de Lúcio Cornélio Balbo (*Pro Balbo*) notabilizou a expressão popular segundo a qual “a exceção confirma a regra” (*exceptio probat regulam*). Não obstante, a história retirou do texto clássico apenas metade da frase de Cícero, que, em verdade, afirmou que a exceção confirma a regra nos casos não excepcionados (*exceptio probat regulam in casibus non exceptis*), isto é, a existência de uma exceção serve para demonstrar que uma determinada norma cogente está sendo violada, uma vez que, na ausência de exceções, a ação deve necessariamente ser legítima (*quod si exceptio facit ne liceat, ubi non sit exceptum, ibi necesse est licere*).²⁸ Séculos mais tarde, em uma análise aritmética do mundo, Feynman viria a dizer que, se há uma exceção a alguma regra e esta pode ser provada pela observação, a regra está errada.²⁹

A proteção de dados pessoais tem por fundamento a proteção de direitos individuais de sujeitos extremamente frágeis diante do poderio dos agentes econômicos capazes de manipular e processar suas informações pessoais para além de fronteiras nacionais. Por esse motivo, é essencial não somente garantir textualmente a proteção de dados inclusive nas transferências internacionais de

informações como também é necessário assegurar a efetividade da norma, motivo pelo qual exceções à regra devem ser vistas com muita cautela.

Ao tratar da transferência internacional de dados, o legislador brasileiro adotou critério já existente no direito europeu desde a Diretiva de proteção de dados editada pelo parlamento europeu em 1995, em que se afirmava que “a protecção das pessoas garantida na Comunidade pela presente directiva não obsta às transferências de dados pessoais para países terceiros que assegurem um nível de protecção adequado”. Em sentido semelhante, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, editado em 2017, estabeleceu que “A Comissão pode reconhecer que um país terceiro, um território ou um setor específico de um país terceiro, ou uma organização internacional, deixou de assegurar um nível adequado de proteção de dados”, e, conseqüentemente, poderá proibir que se transfiram dados àquela jurisdição. Em que pesem as inovações trazidas pelo RGPD, as transferências internacionais ainda são realizadas “com base numa decisão de adequação”, nos termos do art. 45 do Regulamento europeu.³⁰ Passa-se a indagar, com isso, o que significaria “nível de proteção adequado” ao arcabouço protetivo europeu, especialmente diante da dificuldade de aquilatar os graus de proteção oriundos de ordenamentos diversos e com culturas jurídicas diversas e, antes de tudo, disparidades de poder geopolítico e econômico. Da mesma forma, é possível, desde logo, pôr em dúvida a efetividade de tal disposição, considerando a trajetória da regulação europeia sobre o tema diante das pressões norte-americanas.

Não é demais notar, nesse ponto, que mesmo no âmbito da interpretação da própria Diretiva europeia já foram levantadas inúmeras controvérsias, como a distinção entre “nível de proteção adequado” e o “nível de proteção equivalente” esperado dos Estados-membros, sendo o primeiro interpretado como menos rigoroso do que o segundo.³¹ Analogamente, a LGPD, em seu art. 33, estabelece que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida em casos específicos, nomeadamente, em seu inciso I, “para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei”. Com isso, importa-se para o direito brasileiro a controvérsia sobre o que seria um nível adequado de proteção de dados, o que o art. 34 da LGPD vem supostamente esclarecer ao determinar que tal questão deverá ser deslindada pela autoridade nacional de proteção de dados, levando em consideração: (i) as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional; (ii) a natureza dos dados; (iii) a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei; (iv) a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; (v) a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; (vi) outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

Com efeito, à luz da antiga Diretiva europeia, a Corte de Justiça da União Europeia decidiu, no conhecido caso Schrems, que o sentido de adequação exigido do país para o qual se transferem dados pessoais de cidadãos europeus deve ser apreendido a partir da observância de garantias essenciais que assegurem que o sistema jurídico destinatário seja “essencialmente equivalente” ao da União Europeia, o que se obteria não a partir de uma avaliação profunda do ordenamento, mas de uma análise superficial dos mecanismos à disposição.³² O

RGPD europeu, por sua vez, como já se viu anteriormente, fixou três requisitos básicos para que se considere o nível de proteção de determinado país adequado: (i) o primado do Estado de Direito; (ii) a existência de autoridade independente de proteção de dados; e (iii) a assunção de compromissos internacionais quanto à proteção de dados.

Abre-se, por conseguinte, amplíssima margem de discricionariedade para que a autoridade nacional determine quais transferências internacionais de dados poderão ser consideradas adequadas ao patamar estabelecido pela LGPD. Tais disposições, porém, são desafiadas pela realidade dos fatos, na medida em que o estatuto europeu de proteção de dados foi notoriamente flexibilizado, desde a década de 1990 até muito recentemente, para amoldar-se à demanda norte-americana pela manutenção de um quadro praticamente inexistente de proteção. Trata-se, naturalmente, da polêmica decorrente do casuísmo na aplicação da Diretiva europeia no que diz respeito aos Estados Unidos, que, a partir de ameaças de retaliação econômica, levaram a Comunidade Europeia a anuir ao conhecido acordo *Safe Harbor*, que garantiu aos norte-americanos a possibilidade de continuar, incólumes, sem um arcabouço normativo de proteção de dados pessoais.³³ Assim, os Estados Unidos foram expressamente eximidos de atender ao patamar “adequado” de proteção.³⁴

Cabe salientar que, apesar da gritante disparidade entre o regime aplicável aos Estados Unidos e aquele vigente para os demais países do globo, tal acordo foi somente invalidado em 2014, quando, no Caso C-362/14 do Tribunal de Justiça da União Europeia, reconheceu-se a insuficiência do regime de proteção de dados norte-americano face à forte ingerência exercida pelo poder público sobre os dados pessoais em atividades de vigilância, especialmente por parte de agências de inteligência como a *National Security Agency* (NSA).³⁵

Em razão da invalidação do acordo *Safe Harbor*, recentemente os Estados Unidos e a Comissão Europeia celebraram novo acordo com a finalidade de preencher a lacuna deixada pelo anterior. O *EU-US Privacy Shield* foi celebrado no dia 02 de fevereiro de 2016 e prevê, em primeiro lugar, uma extensa carta de princípios a serem respeitados pelas partes, a saber: (i) a transparência (*notice*), seja na informação dos usuários quantos aos seus direitos e às vias para reclamá-los, seja no que diz respeito aos propósitos de eventual coleta de dados ou de investigação levada a cabo pelas autoridades competentes; (ii) a liberdade de escolha (*choice*), princípio que informa que empresas devem dar aos usuários a possibilidade de escolher se seus dados podem ser divulgados a terceiros ou, no caso de informação sensível, mesmo se podem ser coletados ou armazenados; (iii) transparência na transmissão de informações (*accountability for onward transfer*), que impõe o respeito aos dois primeiros princípios, inclusive para a fiscalização do uso dos dados transmitidos a terceiros; (iv) segurança (*security*), à medida que as companhias devem tomar as devidas precauções para a proteção dos dados dos usuários contra o extravio ou o acesso não autorizado; (v) integridade dos dados e limitação de propósitos (*data integrity and purpose limitation*), pois os dados pessoais devem se limitar às informações relevantes ao processamento, não podendo as empresas ultrapassarem os limites com os quais concordaram os usuários; (vi) acesso (*access*), garantindo aos usuários a possibilidade de correção, complementação ou supressão das informações incorretas ou lesivas; (vii)

proteção efetiva (*recourse, enforcement and liability*), mediante o fornecimento de mecanismos eficazes que garantam a anuência (*compliance*) aos princípios, produzindo obrigações de reparação dos danos e de cessação de condutas através de um sistema gratuito de interpelação do aparelho estatal.³⁶

Atesta a Comissão Europeia que, pela primeira vez, os Estados Unidos garantiram, por escrito, à União Europeia, garantias de que o acesso de autoridades públicas aos dados pessoais dos usuários para fins de proteção da segurança nacional e defesa da lei sofrerá limitações claras, além de ser objeto de fiscalização³⁷. Tanto é assim que a vigilância governamental passa, agora, a obedecer a critérios mais rigorosos de necessidade e razoabilidade. Além disso, as empresas não somente devem agir em consonância com os princípios do acordo, mas devem publicar seus programas de *compliance* e deixá-los disponíveis a todos os usuários e entidades reguladoras.

No entanto, por mais resolvida que possa estar a questão entre União Europeia e Estados Unidos, é importante salientar que o acordo supramencionado é bilateral, de sorte que, ainda que a União Europeia garanta a proteção de dados ali processados por intermédio do RGPD, nada assegura que os Estados Unidos forneçam aos demais países o patamar de proteção que conferem aos países europeus – basta notar que o *Privacy Shield* apenas cria obrigações entre Estados Unidos e União Europeia. Pelo contrário, à semelhança do que fez com a Europa por vários anos, não impressionaria se os Estados Unidos simplesmente não oferecessem proteção alguma. Trata-se de fenômeno estudado por Marcelo Neves ao estudar as colisões entre ordens constitucionais marcadas pela lógica neocolonial da oposição entre países centrais e países periféricos, em que ordens jurídicas e culturas jurídicas dos “Estados fortes” no contexto da sociedade mundial atual destrutivamente em relação ao desenvolvimento de formas de direito em outros Estados.³⁸

Não é por outro motivo que, desde o advento da sociedade da informação, diversos autores advogam por uma transformação do conceito de soberania em virtude do enfraquecimento dos Estados nacionais subdesenvolvido diante do chamado “colonialismo eletrônico” ou “imperialismo cibernético”, fenômenos que dificultam a implementação de graus superiores de proteção a direitos individuais justamente em virtude da falta de interesse de determinados *players*.³⁹ Em outras palavras, a realidade dos fatos subverte a ainda incipiente dogmática do direito fundamental à proteção de dados, de maneira a solapar o objetivo de criar uma verdadeira carta de direitos da internet a nível global.⁴⁰ Assim, a existência de uma poderosa exceção à tendência mundial de fortalecimento das legislações de proteção de dados enfraquece o campo como um todo, criando verdadeira esfera de incerteza – ou, ainda, de indecidibilidade⁴¹ – no cenário jurídico global, que desde o pós-Guerra se caracterizou por intensa cooperação que levou a um estado de interdependência que, na atualidade, não pode ser simplesmente derogado, levando a verdadeiros bloqueios (*gridlocks*) à efetividade de normas com eficácia tendencialmente transnacional.⁴²

Dessa forma, o grande desafio para o direito brasileiro da proteção de dados, no que tange à transferência internacional, consistirá na definição de parâmetros adequados e exequíveis para a garantia dos direitos tutelados pela LGDP, tendo

em vista as pressões internacionais pela retração da proteção de direitos no que diz respeito especialmente aos Estados Unidos. O próximo tópico, nesse sentido, buscará traçar as diretrizes centrais da racionalidade que deverá orientar a autoridade nacional de proteção de dados, com especial atenção à experiência internacional sobre o tema.

IV. Considerações finais a um tema em aberto: projeto de construção da força normativa transnacional da LGPD

Os tópicos anteriores expuseram o dilema fundamental da LGPD no que diz respeito à contraposição entre a existência de um modelo normativo robusto e atual para a tutela da transferência internacional de dados e a recalculância de determinados *players*, o que produz substanciais impactos à efetividade da LGPD sob a perspectiva transnacional. A ironia se agrava quando se verifica que o continente europeu se articula como um todo para garantir a higidez de seu regulamento de proteção de dados no que tange aos fluxos transfronteiriços, inclusive firmando acordos com os Estados Unidos para a salvaguarda eficaz dos dados dos cidadãos europeus, ao passo que o diploma brasileiro vem a lume sem qualquer indício de arranjos preliminares de garantia da eficácia da lei brasileira.

Naturalmente, seria temerário pretender, por intermédio deste trabalho, decálogos de soluções a serem implementadas pelo legislador brasileiro ou pela autoridade nacional de proteção de dados para que tais dificuldades sejam sanadas. Não obstante, tendo em vista premissas já expostas e o estado da arte dos arranjos de proteção de privacidade a nível internacional, é fundamental traçar diretrizes básicas para a construção de um modelo normativo capaz de atender a seus objetivos mais básicos, ainda que não se passe necessariamente pela óbvia importância da edição de acordos bilaterais que garantam a lei de proteção de dados inclusive por países cuja legislação interna não oferece grau de proteção adequado ao patamar estabelecido pela lei brasileira.

A noção de que a privacidade é boa para os negócios há muito já foi disseminada em manuais de boas práticas ao redor do mundo, na medida em que a promoção dos fluxos de dados detém relação direta com o crescimento do comércio.⁴³ Nesse sentido, pode-se mencionar a iniciativa levada a cabo em 2006 para a criação de um padrão global de privacidade, isto é, o estabelecimento de um patamar mínimo universal fundado no consentimento, na transparência, na clareza quanto aos motivos, na minimização e limitação da coleta de dados, da limitação ao uso, retenção e divulgação, entre outros elementos capazes de incutir a proteção à privacidade não somente ao escopo de análise das autoridades públicas, mas também dos agentes econômicos.⁴⁴

Importantes passos no sentido da construção de um arcabouço transnacional para a proteção de dados têm sido dados pela ICDPPC (*International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners*) mediante a edição de resoluções sobre temas centrais à garantia da privacidade. É imperioso mencionar, nesse sentido, a conhecida Resolução de Madri, que fixou padrões internacionais para a proteção de dados e da privacidade, mediante o estabelecimento de princípios gerais destinados tanto a fixar definições como a incentivar a adoção voluntária e

proativa de medidas por parte dos agentes econômicos, além de recomendar a cooperação e coordenação das autoridades de proteção de dados para a obtenção de uma proteção internacional mais uniforme.⁴⁵

Vale citar, ainda, a Resolução editada em 2013 com o objetivo de vincular a proteção de dados e da privacidade às disposições normativas do direito internacional, recomendando, inclusive, a adoção de protocolo adicional ao artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas (internalizado ao direito brasileiro pelo Decreto 592/1992),⁴⁶ de maneira a dar às disposições do tratado interpretação conforme aos *standards* internacionais de proteção de dados. Com isso, seria possível, inclusive, incutir ao direito norte-americano diretrizes de proteção de dados mais consentâneas com os padrões estabelecidos pelas recentes legislações latino-americanas e pelo RGPD europeu.

Em outras palavras, a difusão de um patamar ideal de privacidade a nível global tem o condão de demonstrar que a ausência de salvaguardas efetivas importa em uma redução dos negócios, de sorte que a proteção dos dados pessoais deve advir não somente da regulação estatal, como também deve estar plasmada às noções de inovação e de produtividade, com vistas a produzir o consenso de que a tecnologia somente pode evoluir e ser desenvolvida se trazer consigo determinado nível de proteção da privacidade.⁴⁷

Trata-se do conceito de *Privacy by design*, baseado em sete princípios fundamentais: (i) proatividade e prevenção, de forma a resolver questões relativas à privacidade antes que elas se tornem problemas reais; (ii) privacidade como padrão, tornando desnecessária a alteração de modelos de negócio para a adequação a regimes específicos de proteção de dados; (iii) privacidade plasmada ao próprio projeto; (iv) funcionalidade total, transformando custos de transação em valor econômico; (v) proteção completa do ciclo de vida dos processos; (vi) visibilidade e transparência; (vii) respeito ao usuário.⁴⁸

Além disso, tal conjunto de princípios pode ser lido juntamente das diretrizes estabelecidas pela norma técnica ISO/IEC 29100, que tratou de especificar uma terminologia comum de privacidade e de descrever requisitos básicos de garantia da privacidade, constituindo-se em um conjunto de normas operacionais que permitem que a privacidade deixe de ser apenas política pública para tornar-se especificação técnica relevante, desejável a processos produtivos de todo e qualquer agente econômico que lide com dados pessoais.⁴⁹

Por mais que a legislação brasileira ainda não preveja incentivos concretos à adoção espontânea de mecanismos de regulação privada da privacidade,⁵⁰ trata-se de tendência promissora tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nomeadamente para o endereçamento de falhas relevantes no que diz respeito à proteção de dados, ocorrências que já têm levado as grandes companhias a reestruturarem seus processos produtivos de maneira a incorporar preocupações com a privacidade, inclusive diante das exigências de países com ordenamentos mais sensíveis à questão.⁵¹

Diante disso, verifica-se que o desafio referente à garantia da efetividade da LGPD passa tanto pelo fortalecimento da autoridade nacional de proteção de

dados – inclusive mediante a celebração de tratados internacionais – quando pela difusão dos ideais de proteção da privacidade e dos dados pessoais entre os *players* do cenário econômico internacional, por intermédio da introjeção da privacidade aos seus próprios processos produtivos.

É necessário, contudo, que, embora a própria LGPD preveja seu afastamento em determinados momentos, a autoridade nacional de proteção de dados mantenha-se vigilante em busca de violações aos princípios gerais da norma, que tem por finalidade precípua a de proteger direitos fundamentais. Não se pode ignorar, além disso, as claras exceções à racionalidade da norma para a entrada de lógicas econômicas e geopolíticas que subvertem por completo a dinâmica da proteção de dados, sob pena de tornar verdadeira a afirmação de Walter Benjamin segundo a qual o estado de exceção em que vivemos não é a exceção, mas, sim, a regra.⁵² Urge, conseqüentemente, que a privacidade deixe de ser apenas política pública e torne-se verdadeira especificação técnica necessária à própria inserção de determinado produto ou serviço no mercado.

Referências

ACCIOLY, Clara Lacerda. A proteção de dados do trabalhador: o direito do trabalho constitucionalizado e seu diálogo com o direito à privacidade. *Revista dos Estudantes de Direito da UnB*. n. 15, p. 255-264, 2018.

ALBERS, Marion. Privatheitsschutz als Grundrechtsproblem. In: HALFT, Stefan KRAH, Hans. *Privatheit: Strategien und Transformationen*. Passau: Stutz, 2013.

BENJAMIN, Walter. Theses on the philosophy of history. In: BENJAMIN, Walter. *Illuminations*. Nova York: Schocken Books, 1969.

BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. In: SARMENTO, Daniel (Org.) *Interesses públicos versus Interesses privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? *Interesse Público*, v. 8, n. 37, maio-jun. 2006.

BURRI, Mira. The governance of data and data flows in trade agreements: the pitfalls of legal adaptation. *University of California, Davis*, v. 51, p. 65-132, 2017.

CAVOUKIAN, Ann. Creation of a global privacy standard. Disponível em: [www.ehcca.com/presentations/privacysymposium1/cavoukian_2b_h5.pdf]. Acesso em: 23.02.2019.

CAVOUKIAN, Ann; TAYLOR, Scott; ABRAMS, Martin E. Privacy by design: essential for organizational accountability and strong business practices. *Identity in the Information Society*, v. 3, n. 2, p. 405-413, ago. 2010.

CÍCERO. *Pro Balbo*. Londres: Clive, 1900.

COLLINS, Hugh. *The law of contract*. 4. ed. Londres: LexisNexis, 2003.

DERRIDA, Jacques. The principle of reason: the University in the eyes of its pupils. *Diacritics*, v. 13, n. 3, p. 2-2, 1983.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DOVE, Edward. The EU general data protection regulation: implications for international scientific research in the digital era. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, v. 46, p. 1013-1030, 2018.

DOWNS, George Wm. Enforcement and the evolution of cooperation. *Michigan Journal of International Law*, v. 19, p. 319-344, 1998.

DWORKIN, Ronald. Terror & the attack on civil liberties. *The New York Review of Books*. 06.11.2003.

EGER, John M. The global phenomenon of teleinformatics: an introduction. *Cornell International Law Journal*, v. 14, p. 203-236, 1981.

ELLGER, Reinhard. *Der Datenschutz im grenzüberschreitenden Datenverkehr*. Berlim: Nomos Verlagsgesellschaft, 1990.

ENISA. Privacy and data protection by design – From policy to engineering. União Europeia. Heraklion: União Europeia, 2014.

ESAYAS, Samson Yoseph. A walk in to the cloud and cloudy it remains: The challenges and prospects of “processing” and “transferring” personal data. *Computer Law & Security Review*, v. 28, p. 662-678, 2012.

FEYNMAN, Richard. *The meaning of it all*. Nova York: Perseus Books, 1999.

FISS, Owen. The war against terrorism and the rule of law. *Oxford Journal of Legal Studies*, v. 26, n. 2, p. 235-256, 2006.

FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Responsabilidade social empresarial. In: FRAZÃO, Ana (Org.). *Constituição, empresa e mercado*. Brasília: FD/UnB, 2017.

FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Corrupção, cultura e compliance: o papel das normas jurídicas na construção de uma cultura de respeito ao ordenamento. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Os gigantes da internet e a apropriação e exploração de dados pessoais: direitos fundamentais e direito ao esquecimento digital. In: VERONESE, Alexandre et al. *A efetividade do direito em face do poder dos gigantes da internet: diálogos acadêmicos entre o Brasil e a França*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

GIMÉNEZ, Alfonso Ortega. El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho a la protección de datos desde la perspectiva del derecho internacional privado: redes sociales de internet y cloud computing. *Perfiles de las Ciencias Sociales*, v. 16, n. 11, p. 150-193, jul.-dez. 2018.

GUNNINGHAM, Neil; KAGAN, Robert A.; THORNTON, Dorothy. Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance. *Law & Social Inquiry*, v. 29, p. 307-341, 2004.

HALE, Thomas; HELD, David; YOUNG, Kevin. *Gridlock: why global cooperation is failing when we need it most*. Malden: Polity, 2013.

ICDPPC. International standards on the protection of personal data and privacy. The Madrid Resolution. Disponível em: [<https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Madrid-Resolution.pdf>]. Acesso em: 23.02.2019.

INTRONA, Lucas; NISSENBAUM, Helen. Shaping the web: why the politics of search engines matters. *The Information Society*, v. 16, p. 169-185, 2000.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2008.

KUMM, Matias. The cosmopolitan turn in constitutionalism: an integrated conception of public law. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, v. 20, n. 2, p. 605-628, 2013.

KUNER, Christopher. Reality and illusion in EU data transfer regulation post Schrems. *German Law Journal*, v. 18, n. 4, p. 881-918, 2017.

KUNER, Christopher. Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law. *University of Cambridge Legal Studies Research Paper Series*. n. 49, ago. 2015.

LINDOSO, Maria Cristine Branco. O processo decisório na era do *big data*: como novos mecanismos de processamento de dados através de algoritmos interferem nas tomadas de decisão. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. *Tecnologia jurídica e direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MEDAUAR, Odete. *Direito administrativo moderno*. São Paulo: Ed. RT, 2007.

NEVES, Marcelo. *Transconstitucionalismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. A função regulatória dos contratos: regulação e autonomia privada na organização do poder econômico. *Revista de Direito Setorial e Regulatório* (no prelo).

RODOTÀ, Stefano. Perché è necessario un Internet Bill of Rights. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, a. 4, n. 2, p. 1-6, 2015.

RUBINSTEIN, Ira S.; GOOD, Nathaniel. Privacy by design: a counterfactual analysis of Google and Facebook privacy incidents. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 28, p. 1333-1414, 2013.

RUBINSTEIN, Ira S. Regulating privacy by design. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 26, p. 1409-1456, 2011.

RULE, James B. *Privacy in peril: how we are sacrificing a fundamental right in Exchange for security and convenience*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

RUOTSALAINEN, Pekka. A cross-platform model for secure electronic health record communication. *International Journal of Medical Informatics*, v. 73, p. 291-295, 2004.

SCHWARTZ, Paul M. European Data Protection Law and restrictions on international data flows. *Iowa Law Review*, v. 80, p. 471-496, 1995.

SENÉCAL, François. La protection des données de santé des athlètes dans le cadre de la lutte contre le dopage. *Lex Electronica*, v. 11, n. 2, 2006.

TAMBOU, Olivia. L'introduction de la certification dans le règlement général de la protection des données personnelles: quelle valeur ajoutée? *Revue Lamy Droit de L'immatériel*, v. 125, p. 51-55, 2016.

TEUBNER, Gunther. Transnational economic constitutionalism in the varieties of capitalism. *The Italian Law Journal*, v. 1, n. 2, p. 219-248, 2015.

YACOBAZZO, Juan Eduardo Gil; RODRÍGUEZ, María José Viega. Historia clínica electrónica: confidencialidad y privacidad de los datos clínicos. *Revista Médica Uruguaya*, v. 34, n. 4, p. 228-233, 2018.

1

.Advogado. Professor voluntário na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (PPGD/UnB). Integrante do Grupo de Pesquisa Constituição, Empresa e Mercado (GECM/UnB).

2

.INTRONA, Lucas; NISSENBAUM, Helen. Shaping the web: why the politics of search engines matters. *The Information Society*, v. 16, 2000. p. 169-185.

3

.NEVES, Marcelo. *Transconstitucionalismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 120.

4

.Ver: ELLGER, Reinhard. *Der Datenschutz im grenzüberschreitenden Datenverkehr*. Berlim: Nomos Verlagsgesellschaft, 1990.

5

.Nesse sentido: "A dimensão internacional da disciplina dos dados pessoais deve ser levada em consideração não somente quando a tarefa a se fazer é obter uma perspectiva global da matéria.

Uma normativa em matéria de proteção de dados pessoais é a tal ponto permeável a influências exógenas de outros sistemas – bem como é propensa a exercer uma influência de idêntica ordem – que assim revela-se a escassa eficácia de iniciativas isoladas e em desalinho com outras normativas, como também ocorre nas disciplinas de outros interesses relacionados a bens imateriais, como a proteção da propriedade intelectual, um tradicional tema de tratados internacionais, ou então o controle de fluxos financeiros” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 307-308).

6

.Art. 44 do RGPD: “Qualquer transferência de dados pessoais que sejam ou venham a ser objeto de tratamento após transferência para um país terceiro ou uma organização internacional só é realizada se, sem prejuízo das outras disposições do presente regulamento, as condições estabelecidas no presente capítulo forem respeitadas pelo responsável pelo tratamento e pelo subcontratante, inclusivamente no que diz respeito às transferências ulteriores de dados pessoais do país terceiro ou da organização internacional para outro país terceiro ou outra organização internacional. Todas as disposições do presente capítulo são aplicadas de forma a assegurar que não é comprometido o nível de proteção das pessoas singulares garantido pelo presente regulamento”.

7

.ALBERS, Marion. Privatheitsschutz als Grundrechtsproblem. In: HALFT, Stefan KRAH, Hans. *Privatheit: Strategien und Transformationen*. Passau: Stutz, 2013; KUMM, Matias. The cosmopolitan turn in constitutionalism: an integrated conception of public law. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, v. 20, n. 2, 2013. p. 605-628; TEUBNER, Gunther. Transnational economic constitutionalism in the varieties of capitalism. *The Italian Law Journal*, v. 1, n. 2, 2015. p. 219-248.

8

.Ver: KUNER, Christopher. Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law. *University of Cambridge Legal Studies Research Paper Series*. n. 49, ago. 2015.

9

.FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Corrupção, cultura e *compliance*: o papel das normas jurídicas na construção de uma cultura de respeito ao ordenamento. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

10

.GUNNINGHAM, Neil; KAGAN, Robert A.; THORNTON, Dorothy. Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance. *Law & Social Inquiry*, v. 29, 2004. p. 307-341.

11

.COLLINS, Hugh. *The law of contract*. 4. ed. Londres: LexisNexis, 2003. p. 35.

12

.BURRI, Mira. The governance of data and data flows in trade agreements: the pitfalls of legal adaptation. *University of California, Davis*, v. 51, 2017. p. 65-132.

13

.Ver: PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. A função regulatória dos contratos: regulação e autonomia privada na organização do poder econômico. *Revista de Direito Setorial e Regulatório* (no prelo).

14

.FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Responsabilidade social empresarial. In: FRAZÃO, Ana (Org.). *Constituição, empresa e mercado*. Brasília: FD/UnB, 2017; TAMBOU, Olivia. L'introduction de la certification dans le règlement général de la protection des données personnelles: quelle valeur ajoutée ?. *Revue Lamy Droit de L'immatériel*, v. 125, 2016. p. 51-55.

15

.Nesse sentido: ESAYAS, Samson Yoseph. A walk in to the cloud and cloudy it remains: the challenges and prospects of “processing” and “transferring” personal data. *Computer Law & Security Review*, v. 28, 2012. p. 662-678; GIMÉNEZ, Alfonso Ortega. El impacto de las uevas tecnologías en el derecho a la protección de datos desde la perspectiva del derecho internacional privado: redes sociales de internet y cloud computing. *Perfiles de las Ciências Sociales*, v. 16, n. 11, jul.-dez. 2018. p. 150-193.

16

.ACCIOLY, Clara Lacerda. A proteção de dados do trabalhador: o direito do trabalho constitucionalizado e seu diálogo com o direito à privacidade. *Revista dos Estudantes de Direito da UnB*, n. 15, 2018. p. 255-264.

17

.LINDOSO, Maria Cristine Branco. O processo decisório na era do *big data*: como novos mecanismos de processamento de dados através de algoritmos interferem nas tomadas de decisão. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. *Tecnologia jurídica e direito digital*: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

18

.RUOTSALAINEN, Pekka. A cross-platform model for secure electronic health record communication. *International Journal of Medical Informatics*, v. 73, 2004. p. 291-295.

19

.SENÉCAL, François. La protection des données de santé des athlètes dans le cadre de la lutte contre le dopage. *Lex Electronica*, v. 11, n. 2, 2006.

20

.DOVE, Edward. The EU general data protection regulation: implications for international scientific research in the digital era. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, v. 46, 2018. p. 1013-1030.

21

.YACOBABAZZO, Juan Eduardo Gil; RODRÍGUEZ, María José Viega. Historia clínica electrónica: confidencialidad y privacidad de los datos clínicos. *Revista Médica Uruguaya*, v. 34, n. 4, 2018. p. 228-233.

22

.A flexibilização de direitos de privacidade em nome de interesses da coletividade, nomeadamente diante de casos de terrorismo, foi tema abordado por diversos autores norte-americanos no pós-11 de Setembro. Ver: FISS, Owen. The war against terrorism and the rule of law. *Oxford Journal of Legal Studies*, v. 26, n. 2, 2006. p. 235-256; DWORKIN, Ronald. Terror & the attack on civil liberties. *The New York Review of Books*. 06.11.2003.

23

.Nesse sentido, ver: JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2008; MEDAUAR, Odete. *Direito administrativo moderno*. São Paulo: Ed. RT, 2007.

24

.Segundo Alice Gonzalez Borges, não se pode confundir a supremacia do interesse público, alicerce das estruturas democráticas, “com suas manipulações e desvirtuamentos em prol do autoritarismo retrógrado e reacionário de certas autoridades administrativas”. É por essa razão que o interesse público não pode ser percebido como expressão da vetusta e antidemocrática noção francesa de *puissance publique*, mas deve conformar os direitos consagrados pela Constituição de 1988, inclusive no que diz respeito à ordem econômica (BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? *Interesse Público*, v. 8, n. 37, maio-jun. 2006).

25

.BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. In: SARMENTO, Daniel (Org.) *Interesses públicos versus Interesses privados*: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 151.

26

.Ressalte-se que, apesar de o presente trabalho seguir a linha crítica ao interesse público expressa por autores como Binenbojm, não se está aqui a concordar com a solução adotada pelo autor, isto é, a aplicação do postulado da proporcionalidade.

27

.Ver, por todos: MARQUES, Claudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

28

.CÍCERO. *Pro Balbo*. Londres: Clive, 1900.

29

.FEYNMAN, Richard. *The meaning of it all*. Nova York: Perseus Books, 1999. p. 11.

30

.Art. 45, item 1 do RGPD: “Pode ser realizada uma transferência de dados pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional se a Comissão tiver decidido que o país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos desse país terceiro, ou a organização internacional em causa, assegura um nível de proteção adequado. Esta transferência não exige autorização específica”.

31

.SCHWARTZ, Paul M. European Data Protection Law and restrictions on international data flows. *Iowa Law Review*, v. 80, 1995. p. 471-496.

32

.KUNER, Christopher. Reality and illusion in EU data transfer regulation post Schrems. *German Law Journal*, v. 18, n. 4, 2017. p. 881-918.

33

.Ver: RULE, James B. *Privacy in peril*: how we are sacrificing a fundamental right in Exchange for security and convenience. Oxford: Oxford University Press, 2007. p. 135-139.

34

.“No direito doméstico norte-americano não há legislação específica a respeito da proteção de dados, apesar de existirem projetos de lei nesse sentido em tramitação no legislativo, como é o caso do *Personal Data Privacy and Security Act* (2007). A proteção de dados nos EUA é regulada por diplomas já antigos, como o *Electronic Communications Privacy Act* de 1986, referente especialmente ao sigilo de comunicações e à vedação a escutas telefônicas (*wiretaps*) implantadas sem autorização judicial, objeto que não abarca a dimensão mais geral do direito à proteção de dados, como já se comentou anteriormente” (FRAZÃO, Ana; PRATA DE CARVALHO, Angelo Gamba. Os gigantes da internet e a apropriação e exploração de dados pessoais: direitos fundamentais e direito ao esquecimento digital. In: VERONESE, Alexandre et al. *A efetividade do direito em face do poder dos gigantes da internet*: diálogos acadêmicos entre o Brasil e a França. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 303-342).

35

.A invalidação do pacto Safe Harbor partiu de um caso concreto no qual um usuário da rede social Facebook, na Irlanda, insurgiu-se contra a transferência de seus dados pessoais aos Estados

Unidos, onde o governo desenvolvia práticas invasivas de vigilância por meio da exigência de abertura de tais informações por parte das empresas que operam da internet.

36

.O *E.U.-U.S. Privacy Shield Agreement* está disponível no endereço virtual do Departamento de Comércio norte-americano. Disponível em: [www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/media/files/2016/eu_us_privacy_shield_full_text.pdf.pdf]. Acesso em: 29.02.2016. Do último princípio, inclusive, decorre a obrigação imposta às companhias de estabelecer caminhos alternativos para a resolução de conflitos, inclusive com o comprometimento das empresas que trabalham com o trânsito intercontinental de dados com a arbitragem – gratuita aos usuários – como forma de remediação dos danos. O acordo se submete à fiscalização recíproca das entidades reguladoras das partes celebrantes e procura fortalecer a transparência das operações que utilizem dados pessoais, a esfera de proteção ao usuário e a informação dos usuários com relação a seus direitos, inclusive para coibir a vigilância cibernética por parte de entidades governamentais.

37

.Informações disponíveis em *press release* da Comissão Europeia. Disponível em: [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm]. Acesso em: 03.02.2016.

38

.NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 282. De acordo com o autor: “Quando surgem formas desviantes de relações jurídicas concernentes ao mercado, à distribuição do poder, à identidade cultural, à educação etc., medidas de intervenção são frequentemente propostas e executadas, para que a compreensão jurídica do Estado dominante passe novamente a valer. Isso implica uma concepção marcadamente assimétrica da ‘soberania’: enquanto essa vale de maneira quase absoluta para o portador de determinadas formas jurídicas, é demasiadamente relativizada ou inteiramente desconsiderada no caso de formas de direito que se desviam da dominante em suas experiências com o poder, o dinheiro e o saber” (NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 282).

39

.Nesse sentido: EGER, John M. The global phenomenon of teleinformatics: an introduction. *Cornell International Law Journal*, v. 14, 1981. p. 203-236.

40

.Stefano Rodotà recomenda que, diante do poder exercido pelos “gigantes da Internet” – como as empresas Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook ou Yahoo – sem qualquer controle sobre a vida de todos, seja desenvolvida uma iniciativa “constitucional” para que se garantam os direitos fundamentais dos usuários da rede. Afirmar Rodotà que o desenvolvimento de uma *Internet Bill of Rights* deve se dar a partir da promoção da participação de múltiplos sujeitos, em níveis diversos, em um modelo com baixa formalização, de modo a incluir o maior número possível de indivíduos para a criação de regras comuns do espaço virtual. Vale transcrever a lição de Stefano Rodotà: “Ma nel momento in cui si entra in una dimensione completamente diversa, come quella di Internet, anche queste aperture si rivelano del tutto insufficienti. Nascono così altre iniziative che, appunto, vedono una partecipazione di una molteplicità di soggetti, si svolgono a livelli diversi, conoscono una bassa formalizzazione che tuttavia non porta inevitabilmente con sé una minore efficacia. È indispensabile far sì che una pluralità di attori, ai livelli più diversi, possa dialogare e mettere a punto regole comuni, secondo un modello definito appunto *multistakeholder* e *multilevel*. Soggetti diversi, a livelli diversi, con strumenti diversi negoziano e si legano con impegni reciproci per individuare e rendere effettivo un patrimonio comune di diritti.” (RODOTÀ, Stefano. Perché è necessario un Internet Bill of Rights. *Civiltistica.com*, Rio de Janeiro, ano 4, n. 2, 2015. p. 2). Tradução livre: “Mas no momento em que se entra em uma dimensão completamente diversa, como a da Internet, essas experiências se mostram insuficientes. Nascem outras iniciativas que, exatamente, preveem uma participação de uma multiplicidade de sujeitos que atuam em níveis diversos e conhecem uma baixa formalização que, todavia, não traz inevitavelmente consigo uma menor eficácia. É indispensável admitir que uma pluralidade de atores, nos níveis mais diversos, possa dialogar e estabelecer regras comuns segundo um modelo definido de forma *multistakeholder* e *multilevel*. Sujeitos diversos, em níveis diversos, com instrumentos diversos

negociam e se relacionam com compromissos recíprocos para encontrar e tornar efetivo um patrimônio comum de direitos”.

41

.DERRIDA, Jacques. The principle of reason: the University in the eyes of its pupils. *Diacritics*, v. 13, n. 3, 1983. p. 2.

42

.Ver, por todos: HALE, Thomas; HELD, David; YOUNG, Kevin. *Gridlock: why global cooperation is failing when we need it most*. Malden: Polity, 2013; DOWNS, George Wm. Enforcement and the evolution of cooperation. *Michigan Journal of International Law*, v. 19, 1998. p. 319-344.

43

.CAVOUKIAN, Ann; TAYLOR, Scott; ABRAMS, Martin E. Privacy by design: essential for organizational accountability and strong business practices. *Identity in the Information Society*, v. 3, n. 2, ago. 2010. p. 406.

44

.CAVOUKIAN, Ann. Creation of a global privacy standard. Disponível em: [www.ehcca.com/presentations/privacysymposium1/cavoukian_2b_h5.pdf]. Acesso em: 23.02.2019.

45

.ICDPPC. International standards on the protection of personal data and privacy. The Madrid Resolution. Disponível em: [https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Madrid-Resolution.pdf]. Acesso em: 23.02.2019.

46

“1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas.”

47

.CAVOUKIAN, Ann; TAYLOR, Scott; ABRAMS, Martin E. Op. cit., p. 408.

48

.CAVOUKIAN, Ann; TAYLOR, Scott; ABRAMS, Martin E. Op. cit., p. 409-410.

49

.Ver: ENISA. Privacy and data protection by design – From policy to engineering. União Europeia. Heraklion: União Europeia, 2014.

50

.Sobre a necessidade de adoção de incentivos à *privacy by design*, ver: RUBINSTEIN, Ira S. Regulating privacy by design. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 26, 2011. p. 1409-1456.

51

.RUBINSTEIN, Ira S.; GOOD, Nathaniel. Privacy by design: a counterfactual analysis of Google and Facebook privacy incidents. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 28, 2013. p. 1333-1414.

52

.BENJAMIN, Walter. Theses on the philosophy of history. In: BENJAMIN, Walter. *Illuminations*. Nova York: Schocken Books, 1969.

Capítulo 9. Fluxo de informação no âmbito dos grupos societários e proteção dos dados pessoais

Raul Murad¹

Rodrigo Requena²⁻³

1. Introdução

A promulgação da LGPD⁴ tem como principal norte a tutela da privacidade, liberdade e autodeterminação informativa⁵ da pessoa humana,⁶ direitos em alta posição na ordem constitucional brasileira que se encontram notoriamente afetados pelo progresso tecnológico.⁷ Assim, a LGPD promove avanço no marco legal, cujas bases foram instituídas com a Lei do *Habeas Data*⁸ e com o Marco Civil da Internet (MCI)⁹⁻¹⁰ – e, em alguma extensão, por meio do Código de Defesa do Consumidor.¹¹

Com tal intuito, a LGPD regulamenta práticas relacionadas ao fluxo de dados entre pessoas jurídicas, – que, a depender do mercado de atuação, podem permitir a coleta de informações¹² suficientes a assegurar posição de dominância em outros setores mercadológicos. Esse não é um fenômeno recente, tendo sido apenas exponencialmente intensificado com o avanço tecnológico. Não à toa, o escopo regulatório da LGPD não se destina apenas aos bancos de dados em meio automatizado mas também àqueles mantidos de forma manual – obrigando todos que coletam e processam dados pessoais a se adequar, independentemente da complexidade de seus sistemas e registros.¹³

Não se ignora as vantagens econômicas que podem ser obtidas pelos insumos (conjunto suficiente de informações e pelas técnicas de tratamento associadas aos chamados *Big Data* e *Data Mining*)¹⁴ e pelos produtos (inferidos com os dados coletados). Por sinal, em certos segmentos de maior concentração do poder econômico, a falta de acesso a banco de dados dessa natureza pode representar verdadeira *barreira de entrada* (quiçá uma *essential facility*)¹⁵ a concorrentes: cogite-se, por exemplo, o uso do *e-commerce*, dos serviços de proteção ao crédito, das seguradoras, das ferramentas de busca na Internet (*search engines*), das redes sociais, entre outros. E tal distância entre as sociedades empresárias que titularizam um banco com os referidos dados e aquelas que não os possuam apenas tende a aumentar, conforme seus meios de aplicação são desenvolvidos. Dados coletados em um mercado podem ser extremamente úteis para o exercício de outra atividade – por exemplo, informações sobre sinistros reunidas por seguradoras podem ter valor para a indústria automobilística, dados coletados por companhias aéreas auxiliariam hotéis. Padrões de consumo, dados de

geolocalização, hábitos pessoais: todos os conjuntos de dados têm alguma importância para diferentes mercados. Aqui não se delimita a importância das informações inferidas pela coleta de dados apenas a uma questão de eficiência (para aqueles que delas disponham), mas de um entrave que pode majorar a distorção concorrencial já antes existente.¹⁶

Portanto, os negócios jurídicos entre diferentes pessoas jurídicas para o compartilhamento, a transmissão e o processamento de dados tendem a se tornar mais e mais comuns. Há uma tendência no sentido da criação de bancos de dados acessados por um conjunto de sociedades empresárias, ou mesmo na prestação de tais serviços a diversos setores por entes societários especializados.¹⁷ Trata-se, afinal, de novo formato da prática já consolidada pelos supracitados sistemas de proteção ao crédito e por sua vertente “oposta”, o sistema de *Crediscore* (“cadastro positivo”): dados de identificação e adimplência coletados por diferentes agentes no mercado são agregados e disponibilizados para diferentes entes, que obtêm vantagem econômica.¹⁸⁻¹⁹

E, por tais razões, a LGPD prevê normas relativas ao compartilhamento de dados entre pessoas jurídicas, exigindo o consentimento específico do titular dos dados (art. 7º, § 5º), a disponibilização “[...] de forma clara, adequada e ostensiva [...]” das “[...] informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade [...]” (art. 9º, *caput* e V), a possibilidade de restrições ao compartilhamento de dados pessoais sensíveis (art. 11, §§ 3º e 4º), assim como dispositivos que estipulam o direito do titular de obter, a qualquer momento, informações sobre o destino dos dados compartilhados (art. 18, VII) e a obrigação de o controlador imediatamente informar aos agentes com quem compartilhou dados quaisquer providências solicitadas para correção, eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados (art. 18, § 6º). Veja-se que há um dever fiduciário-informacional substancialmente oneroso – porém justo – para aquele que tem o *bônus* de administrar dados (quiçá sensíveis) alheios.

Provavelmente mais comum do que os acordos de compartilhamento de dados entre sociedades empresárias concorrentes ou de diferentes setores; contudo, seria o fluxo de informações entre as sociedades que compõem o mesmo grupo²⁰ empresarial. Nota-se que uma das próprias razões que fundamentam a formação de grupos de empresas seria a sinergia²¹ entre suas diferentes atividades, a possibilidade de extrair vantagens econômicas para uma sociedade empresária do grupo a partir da atuação de outra,²² em linha com o art. 265 da Lei das S.A.,²³ que prevê a combinação de atividades ou esforços do grupo empresarial.

Ademais, em muitos casos, tal hipótese reflete a realidade. Tome-se, por exemplo, o contexto da rede social Facebook. Depois que essa macroempresa²⁴ adquiriu o WhatsApp, atualmente o aplicativo mais utilizado para a troca de mensagens instantâneas,²⁵ os termos de serviço deste foram modificados para incluir a possibilidade de compartilhamento de dados com seu grupo empresarial, o que se destina, entre outras funções, ao direcionamento de publicidade aos usuários da rede social associados à conta.²⁶

Noutras palavras, o WhatsApp assume que poderia, por exemplo, agregar palavras-chave contidas nas conversas trocadas privadamente pelo aplicativo e

disponibilizá-las ao Facebook, que exibirá publicidade direcionada ao usuário de acordo com tais marcadores.²⁷ E, quando tal política foi introduzida pelo aplicativo, os usuários puderam exercer seu direito de recusa (*opt out*) no prazo de 30 dias²⁸ – ou seja, o consentimento expresso não foi obtido, o que, possivelmente, contrariaria o disposto no art. 7º da LGPD (que, todavia, à ocasião, não estava vigente).

Ainda assim, a LGPD pouco trata especificamente dos grupos empresariais, com a notável exceção de seu art. 52, II e § 4º, que apenas faz referência para estabelecer o faturamento do grupo como critério para a definição de multa, caso não seja possível segregar o “[...] faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração [...]” para definição do valor-base.

Verifica-se, assim, que o fluxo de dados pessoais *intercompany*, ou seja, entre as pessoas jurídicas integrantes de grupo empresarial, qualifica-se como matéria complexa, com expressão na realidade e, porém, não tratada de forma específica pela LGPD. Diante desse cenário, surgem alguns questionamentos, sobre os quais será feita embrionária reflexão, tais como: (i) a legitimidade da livre circulação de dados dos usuários entre as sociedades empresárias do grupo; (ii) a compreensão acerca da posição do grupo de sociedades empresárias para os fins de aplicação da LGPD, *i.e.*, se este figuraria como um ente autônomo;²⁹ e (iii) o fato de a coligação e a cooperação interempresarial poderem impactar a gestão de dados pessoais.

2. Restrições ao compartilhamento de dados *intercompany*

Inicialmente, será necessário observar os próprios termos da LGPD e interpretá-los de acordo com seus princípios norteadores (art. 6º).³⁰ Seu art. 5º, VI, conceitua, para seus fins, o termo “controlador” como a “[...] pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais [...]”. A especificação legal é, *a priori*, bem delimitada, identificando o controlador como pessoa específica, indicada com clareza ao titular, em consecução do *princípio da transparência* (art. 6º, VI). Todavia, há que se notar que o controlador é *apenas* a parte que *toma as decisões* a respeito dos procedimentos de tratamento. Por outro lado, é o operador (art. 5º, VII, LGPD) que se volta a realizar as determinações do controlador, empregando os meios técnicos necessários a tal tratamento.

Ademais, nota-se que a concordância do titular com a coleta e o tratamento de seus dados pessoais importa em limitação voluntária a direitos enquanto desdobramento de seus direitos da personalidade, em linha com o art. 20 do Código Civil.³¹ Logo, a interpretação de qualquer avença que envolva a disposição de seus dados pessoais deverá ser estrita, consequência reservada pelo ordenamento a todas as cláusulas restritivas de direito³² – como, inclusive, prevê o art. 114 da mesma Lei. E, por extensão, a eventual coleta de dados sem o consentimento do titular (em alguma das demais hipóteses do art. 7º da LGPD) encerrará restrição ainda mais intensa a tais direitos, considerando que sequer lhe é oportunizado o exercício de sua autodeterminação informativa.³³

Isso implicaria, então, que os dados coletados possam ser tratados exclusivamente para o uso, acesso e armazenamento por pessoa indicada como controladora, com efetivação do operador, assim como para a finalidade especificamente declarada. Quaisquer outras finalidades ou recipientes distintos – independentemente da inclusão destes no grupo empresarial da controladora ou não – devem constar do instrumento firmado com o titular, de forma clara, ou ser autorizadas por este, mediante novo consentimento, consubstanciado em qualquer forma suficiente para sua prova.³⁴

Não obstante, a LGPD demanda o consentimento específico do titular em qualquer instância de compartilhamento de dados entre entes privados, o que implica que o controlador apenas poderá transmitir (ou melhor, instruir que o operador o faça) tais dados ou conceder acesso a terceiros caso o titular assim consinta, consoante seus arts. 5º, XVI, e 7º, § 5º. Logo, mesmo entre integrantes de grupo empresarial, será necessário o consentimento específico do titular, ou que tal circunstância conste com destaque entre os termos por ele aceitos.

E tal cuidado não é trivial nem se dá por mero formalismo. A restrição à irrestrita circulação de dados pessoais entre as integrantes de grupo empresarial se deve ao controle sobre o destino e a motivação para o tratamento de dados, evitando a disseminação desnecessária – em compatibilidade com a axiologia decorrente dos princípios da necessidade (art. 6º, III), da transparência (VI) e da prevenção (VIII).³⁵

Com efeito, a composição do grupo poderá variar drasticamente, considerando que, no país, existem praticamente apenas grupos empresariais de fato (sem o registro previsto no art. 265 da Lei das S.A.),³⁶ e que a coligação empresarial, ademais, exige somente a influência significativa de investidora nas decisões de natureza financeira ou operacional de investida (art. 243, §§ 1º e 4º, da mesma lei).

O fato de duas pessoas jurídicas comporem o mesmo grupo empresarial não constituiria, portanto, bom critério para autorizar a veiculação livre, sem quaisquer parâmetros delineadores, de dados pessoais de seus clientes, uma vez que tais grupos poderão variar significativamente. E tal dinâmica poderá se dar de modo ágil e pouco claro, sobretudo ao titular. Seria assim forma de assegurar, inclusive, que o titular tenha seus direitos tutelados, impedindo a disseminação descontrolada de seus dados – que, na hipótese contrária, poderiam ser remetidos à sociedade empresária do grupo que logo deixa de sê-lo, passando a integrar outro grupo e podendo compartilhar dados com outro conjunto de pessoas jurídicas, e assim por diante.

Aqui a tese de Pietro Perlingieri³⁷ sobre as teorias das relações jurídicas se mostra particularmente útil: deve-se falar em vínculos entre núcleos de interesse, e não apenas entre pessoas jurídicas. É extremamente comum que, dentro de uma mesma *pessoa*, haja mais de um sujeito de direito (a exemplo de uma sociedade de capital disperso), havendo, ainda, uma disparidade e até conflitos de interesses. Reflita-se sobre a hipótese de o grupo controlador optar por uma estratégia ousada, lucrativa e ilegal no trato do tráfego de dados pessoais, enquanto os acionistas minoritários de uma das sociedades do grupo econômico sequer têm ciência a respeito dessa prática. A titularidade dos dados obtidos pode ser da

sociedade, mas o *controle* e o bom manuseio de tais dados podem escapar aos demais sujeitos de direito do plexo intrassocietário.³⁸ Adicionalmente, resumir-se-ia também à compatibilização da expressa previsão do art. 5º, VI, da LGPD com a do art. 266 da Lei das S.A., preservando-se a personalidade jurídica de cada integrante de grupo empresarial.

E, para os fins da LGPD, a manifestação do titular deverá atender aos requisitos de seu art. 5º, XII, que define “consentimento” como a “[...] manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada [...]”.³⁹ Tal enunciado torna necessária a declaração de vontade expressa do titular (salvo nas hipóteses elencadas na própria LGPD), afastando o regime do art. 111 do Código Civil, que, noutras hipóteses, aceita a presunção da anuência do contratante pelo silêncio. Ou seja, a partir da vigência da LGPD, o sistema de adesão tácita ou *opt out*⁴⁰ estaria, para a maioria dos casos e ainda que dentro do mesmo grupo empresarial, vedado.

Indaga-se, porém, se seria possível que mais de uma sociedade que integre grupo empresarial figure como operadora e/ou controladora de certa operação de tratamento ou banco de dados e até que ponto seria factível segregar cada integrante de grupo de empresas, para fins da LGPD e nas premissas anteriores. De fato, os efeitos serão, a princípio, análogos aos do compartilhamento de dados, propiciando eventual disseminação dos dados do titular. Todavia, tal disseminação poderia já se dar naturalmente, pelas circunstâncias concretas do grupo, a depender de sua integração – desde equipamentos, funcionários e recursos compartilhados até a própria integração do estabelecimento comercial.⁴¹

Inclusive, a multiplicidade de operadores ou controladores nos termos da LGPD não se dá, necessariamente, em prejuízo do titular. Pelo contrário, o grupo empresarial poderá assumir diretrizes de segurança da informação padronizadas. É comum, como apontado anteriormente, que a separação empresarial se dê por circunstância apenas formal, funcionando o grupo como se uma sociedade empresária só fosse. Ademais, o titular, bem como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e demais órgãos competentes terão mais pessoas para quem pleitear esclarecimentos e responsabilizar por descumprimentos da LGPD. Tal conclusão, porém, excepciona frontalmente o caráter restritivo dado à LGPD anteriormente, para além de potencializar a disseminação de dados do titular, em especial com a eventual variação das integrantes do grupo.

Ainda assim, deve-se notar que essa opção não é sinônima à possibilidade de irrestritamente circular informações de caráter pessoal entre as integrantes de grupo de empresas, desde que se observem alguns pressupostos: (i) que a existência de diversas pessoas jurídicas que constem em alguma medida como controladoras e/ou operadoras seja objeto do consentimento específico do titular; (ii) que tal contexto seja concretamente justificado por necessidade operacional, seja pelo nível de integração do grupo, seja pela natureza da operação de tratamento empreendida, respeitando-se, assim, os princípios da finalidade, adequação, necessidade e transparência (art. 6º, I, II, III e VI, respectivamente);⁴² (iii) que caso essa justificativa se altere, que os dados sejam restritos ao mínimo de pessoas possível, também ante o princípio da necessidade; (iv) que o grupo tome

medidas para, em respeito aos princípios da segurança e da prevenção (art. 6º, VII e VIII), evitar que essa qualificação abrangente não represente maiores riscos ao titular; e (v) que, em homenagem ao princípio da transparência, não exista mais de uma pessoa (física ou jurídica) qualificada como encarregada da operação (arts. 5º, VIII, e 41), uma vez que sua identificação e contato devem ser de fácil percepção.⁴³ Qualificação tão ampla de diferentes operadores e/ou controladores, embora possa facilitar a gestão de dados de grupo, poderá também implicar em diversos riscos.⁴⁴

Para a coleta de dados realizada por conexão e acesso a aplicações de internet – modalidade que certamente representa parte maciça do tratamento de dados –, há, ainda, aparente antinomia entre a disposição do art. 52, II, da LGPD e do art. 12, II, do MCI. Nesse sentido, enquanto o art. 52, II c/c § 4º, da LGPD prescreve a supracitada multa de até 2% do faturamento do infrator no ramo de atividade em que a infração se deu – e limitada a R\$ 50 milhões –, o MCI prevê, para análoga conduta (desde que conduzida por meio da internet), a aplicação pura e simples de multa de até 10% do faturamento do grupo no Brasil. Ademais, ao passo que a multa prevista na LGPD é de competência exclusiva da ANPD, a do MCI seria aplicada judicialmente, na esteira de seu art. 30.

Tem-se, assim, previsão muito mais contundente e que não é segregada por ramo de atividade. Aplicar ambas as sanções indistintamente, de idêntica natureza e *ratio*, visando punir a exatamente mesma conduta, poderia conduzir ao *bis in idem*, vedado no ordenamento pátrio.⁴⁵ Difícil definir qual seria a sanção aplicável, buscando recurso nos critérios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:⁴⁶ a LGPD poderia ser definida como lei mais especial (à tutela dos dados pessoais) e posterior – todavia, o MCI poderia ser entendido como norma específica para as infrações efetuadas pela internet. Ainda, a imputação da LGPD é mais benéfica ao infrator, razão que deve assegurar sua prevalência no caso concreto.⁴⁷ Ademais, sempre “[d]eve haver uma relação direta entre a sanção administrativa e o desestímulo específico à conduta tipificada como infracional”.⁴⁸ Possível sustentar, assim, que o liame direto entre a proporção da multa e a especificidade do ato justificaria sua aplicação suplementar: o MCI cominaria sanção mais firme perante o potencial que as infrações tomam quando amplificadas pela massificação proporcionada pela coleta de dados *on-line*.⁴⁹

3. Potencialidades do grupo empresarial no tratamento de dados pessoais

É de se ressaltar, inicialmente, que a própria LGPD prevê hipótese alternativa ao consentimento para o tratamento de dados pessoais, nos termos de seu art. 7º, IX. De fato, o consentimento opera como regra geral, conforme apresentado no item 2. Entretanto, a legislação também estabelece ser possível o compartilhamento “[...] quando *necessário* para atender aos interesses legítimos do controlador *ou de terceiro*, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades *fundamentais* do titular que exijam a proteção dos dados pessoais” (g.n.).⁵⁰ O art. 10, I e II, da lei, ao descrever o que comporia o legítimo interesse do controlador, enumera rol curto e manifestamente exemplificativo,⁵¹ relacionando o “[...] apoio e promoção de atividades do controlador [...]” e a “[...] prestação de serviços que

beneficiem [o titular], respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais [...]”.

Assim, a LGPD abarca exceção potencialmente ampla à imprescindibilidade da concordância do “originador” dos dados. O legítimo interesse que fundamenta a coleta e o tratamento de dados sem consentimento pode ser, como disposto no art. 7º, IX, “[...] do controlador ou de terceiro [...]”, o que poderia compreender outras pessoas de grupo empresarial, e poderá ter teor comercial, como assevera o art. 10. Como únicos limites, colocam-se (a) os direitos e liberdades do titular que possuam teor “fundamental”, expressão com significado controverso, mas que poderia ser compreendido como aqueles de ordem constitucional ou existencial;⁵² (b) a “necessidade” do tratamento dos dados para o cumprimento da finalidade de atendimento aos legítimos interesses; e (c) caso o tratamento se dê para a prestação de serviços, que revertam em “benefício” do titular, outra exigência de pouca densidade semiótica.

Com relação à menção que a LGPD faz a “[...] direitos e liberdades fundamentais [...]” do titular, tem-se remissão, no mínimo, curiosa. Isso porque os direitos e as liberdades do titular que se contrapõem ao uso não autorizado de seus dados pessoais por terceiros seriam praticamente todos de índole fundamental: privacidade, intimidade, imagem, autodeterminação informativa – manifestações dos valores da personalidade, não à toa listados no próprio art. 2º como fundamentos da tutela imposta pela LGPD e invocados pelo art. 5º, X e LXXII, da Constituição da República. Possivelmente, do trecho final do art. 7º, XI, possa se entender que o núcleo de tais garantias fundamentais do titular deva sempre ser preservado e priorizado, em medidas como o tratamento de seus dados a ponto de se conferir o maior anonimato possível para o uso proposto, a menor exposição possível de seus dados ao escrutínio humano, o direcionamento de ofertas de serviços da forma menos invasiva possível etc.

Por outro lado, da palavra “necessidade” se extrai que o legítimo interesse deve depender do (ou seja, tenha como única alternativa o) tratamento de dados pessoais do titular para sua consecução, em uso restrito ao mínimo possível. Igualmente, de “benefício” se infere que o tratamento proposto, se direcionado à prestação de serviços, deverá comprovadamente gerar vantagens ao titular, como o aprimoramento do serviço prestado pelo controlador dos dados sem custos adicionais (seja com aumento de sua eficiência, personalização do atendimento, diminuição de despesas com repasse de descontos, seja com a redução dos riscos sofridos pelo titular).

Ainda assim, tais exceções ao regime da disposição consentida pelo titular não incluem a possibilidade de compartilhamento de dados, o qual sempre requer a anuência específica do titular, a teor do art. 5º, XVI, da LGPD, e deve, além disso, constar das informações demandadas por seu art. 9º (inciso V). Com efeito, conjugando tais disposições aos supracitados arts. 7º, IX, e 10, não é vedado que o controlador empregue base de dados pessoais para atender ao interesse legítimo de terceiro, desde que não compartilhe dados com este. Ilustrando esse ponto, o controlador poderia utilizar os dados para direcionar ofertas de serviços de terceiros ao titular, assumindo que não conceda acesso à base de dados ou não transmita dados aos terceiros.

Nesse sentido, um grupo de empresas cumpriria as disposições da LGPD caso indique qualquer sociedade de seu grupo (possivelmente, a sociedade *holding*, que centralize suas decisões) como controladora do tratamento de dados pessoais, ainda que essa pessoa jurídica realize o tratamento em benefício de outras pessoas do grupo, e desde que não os transmita ou conceda acesso às demais.⁵³

Além disso, inexistente impedimento na LGPD para que um operador colete dados advindos das diferentes atividades do grupo, em atendimento às decisões da controladora, desde que tal circunstância seja esclarecida mediante instrumento ou consentimento próprio, que vincule os titulares. Tal arquitetura de atuação poderia ser efetivada desde que apenas os prepostos dos agentes efetivamente tenham contato com os dados pessoais coletados. Em si, é possível que cada sociedade subsidiária do grupo, que se destine a certa atividade ou segmento, seja listada como operadora, ao passo que a *holding* poderia figurar como controladora. Desse modo, esta poderá guardar a coordenação das decisões atinentes à gestão de dados do grupo.⁵⁴

Ainda, nas hipóteses em que o grupo empresarial efetive suas atividades em mesma estrutura organizada de bens, é também viável que a sociedade designada como operadora capte dados em diferentes setores da atuação do grupo – pressupondo-se que, novamente, apenas os agentes de tratamento tenham acesso aos dados, e que sua identificação conste nas informações fornecidas aos titulares (arts. 9º e 18 da LGPD).

Igualmente, a base de dados anonimizados, pseudonimizados ou vertidos em base puramente estatística (como na expressão “87% dos nossos clientes da filial do Rio de Janeiro utilizaram nossos serviços entre as 14 e as 18 horas no ano passado” ou “2 em cada 5 clientes que adquirem o produto X têm mais de 35 anos e são casados”) poderia ser compartilhada sem alerta específico ou consentimento, uma vez que não se enquadraria mais na delimitação legal de “dado pessoal”.⁵⁵⁻⁵⁶ Inclusive, tais informações, já não mais verificando relação direta com a esfera pessoal dos “originadores”, se possuírem valor econômico e se tratadas como sigilosas,⁵⁷ passariam a compor segredo de comércio do controlador ou do grupo empresarial, tutela prevista no ordenamento nos arts. 195, XI e XII, e 206 da Lei de Propriedade Industrial,⁵⁸ e reiteradamente mencionada pela LGPD, que assegura sua proteção.⁵⁹

Dessa forma, um grupo de empresas poderia, como boa prática de *compliance*, segregar sua atividade de tratamento de dados em pessoa jurídica própria, que controlaria também toda a sua estrutura física de armazenamento dos dados, licenciaria o *software* necessário, e manteria acesso restrito à base de dados completa, bem como as chaves necessárias para reverter processos de anonimização ou pseudonimização. A referida pessoa jurídica poderia compartilhar os dados já desvinculados da identidade de seus titulares às demais, para além de tratar os dados no “legítimo interesse” das demais componentes do grupo.⁶⁰

4. Gestão de dados pessoais e operações de reorganização societária

Ainda sobre o tema dos grupos de sociedades, há segunda questão importante, a respeito da qual a LGPD é potencialmente omissa. É comum que as pessoas jurídicas efetuem operações de reorganização societária – notadamente, a incorporação, a fusão e a cisão, previstas no Capítulo XVIII da Lei das S.A., ou mesmo a dissolução, nos termos da lei civil. Nesse sentido, caso a controladora do tratamento de dados pessoais seja sucedida por pessoa jurídica diversa, ou mesmo caso seja extinta, os elementos de sua gestão de dados pessoais serão impactados.

Como regra geral, entende-se que, se a controladora for sucedida a título universal por outra sociedade, os originadores dos dados deverão ser notificados a respeito, e o consentimento deverá ser obtido para eventuais novas finalidades de tratamento.⁶¹ Inclusive, tal conclusão decorreria de leitura *a contrario sensu* do art. 16, III, da LGPD, que permite a manutenção de base de dados após o período de tratamento para transferência a terceiro. Tampouco uma cláusula padronizada de autorização *ex ante* seria suficiente para superar tal obstáculo jurídico, já que a própria *atualidade* da operação de fluxo informacional deve ser levada em conta pelo controlador dos dados.

Na específica hipótese da cisão empresarial, interpreta-se que a responsabilidade com relação ao tratamento dos dados (o que inclui seu acesso e armazenamento) deverá seguir com a sucessora, desde que esta continue a empregá-los para a mesma finalidade relativa ao consentimento anteriormente conferido pelo titular. Entretanto, caso a base de dados seja replicada, de modo a permanecer com número maior de sociedades, verifica-se que haveria, nessa hipótese, o compartilhamento de dados com novas pessoas jurídicas. Desse modo, demandar-se-ia o consentimento específico do titular, em atendimento ao art. 7º, § 5º, da LGPD.

A dissolução societária nesse contexto, porém, apresenta desafios de outra natureza. Caso a base de dados seja mantida após a dissolução da controladora, com a manutenção da finalidade autorizada e a sucessão por única pessoa jurídica, é possível compreender que dependeria de mera notificação aos titulares. Verifica-se que a própria LGPD qualifica o consentimento como a concordância do titular para “[...] tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada [...]” (art. 5º. XII), enfocando, em si, na finalidade consentida, e não no sujeito especificamente que promove o tratamento. Não o bastante, há que se ressaltar que previsões na LGPD, como a do art. 7º, § 5º, poderiam obstar essa interpretação, dado que a legislação não promoveria um inteiro descolamento entre o tratamento dos dados e o agente designado para tanto pelo consentimento. Por outro lado, se, da mesma forma que na hipótese da cisão, a base de dados for replicada ou novas finalidades forem previstas, o consentimento far-se-á necessário. Porém, se a controladora for cessar a finalidade para a qual o tratamento de dados tenha sido estipulado, e caso não preveja sua transferência a terceiro para sua aplicação em igual finalidade, esta deverá ser eliminada (art. 16 da LGPD).

Por fim, outra operação que dependeria da aquiescência expressa dos titulares seria o *trespasse*⁶² (transferência do estabelecimento empresarial, conforme art. 1.143 e seguintes do Código Civil). Em tal hipótese, existindo sucessão de caráter

singular e considerando que o estabelecimento⁶³ (ou parte dele) é alienado de forma dissociada da própria pessoa jurídica, o mais consentâneo com a *ratio* da legislação pertinente, em termos de respeito à LGPD, seria tratar a operação como compartilhamento de dados.

5. Breves reflexões a respeito do possível impacto concorrencial provocado pelo compartilhamento de dados intercompany

Há derradeira reflexão sobre o tema do fluxo de dados pessoais entre integrantes de grupo de sociedades empresárias. Como mencionado ao início do presente texto, o acesso a certas bases de dados representa considerável vantagem concorrencial ao controlador, que poderá empregar os dados de forma a constituir posição dominante em certos segmentos de mercado. Como exemplo hipotético, cogite-se que grande operadora de telefonia celular, com os dados de geolocalização de todos os seus clientes ao longo de um ano, os empregasse em atividade de transporte coletivo. Assim, poderia ajustar suas rotas de acordo com os padrões de deslocamento, o número de veículos disponíveis, a precificação de tarifas, entre outros, obtendo considerável vantagem.

A questão concorrencial não é o foco da LGPD, obtendo tratamento distinto pela fonte normativa de regência. A LGPD visa tutelar o titular dos dados pessoais, em caráter individual, enquanto os efeitos concorrenciais do tratamento e compartilhamento de dados seriam matéria atinente à Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, mais comum e impropriamente chamada de “Lei do CADE”.⁶⁴ Nesse sentido, o compartilhamento de dados poderia ser compreendido como um “contrato associativo”, nos termos do art. 90, IV, devendo ser submetido à análise do regulador como ato de concentração, se dentro dos critérios de seu art. 88 e da Resolução CADE n. 17/2016.

Contudo, o CADE compreende que não se afiguram como atos de concentração – não sendo, portanto, submetidos a seu escrutínio – aqueles que ocorram dentro do mesmo grupo de empresas,⁶⁵ de acordo com o conceito estipulado pela Resolução CADE 2/2012. Logo, caso uma integrante de grupo empresarial compartilhe dados com outra sociedade do grupo, tal operação não será analisada pelo CADE. Na hipótese de tal base de dados, coletada em atividade diversa, garantir ao grupo grande vantagem concorrencial na consecução de novo objeto social, tais efeitos não serão apreciados. Por óbvio, esse cenário envolveria a gênese de nova entrante no mercado, o que mitiga alguns dos efeitos competitivos eventualmente perniciosos⁶⁶ – com efeito, caso o grupo adquira *player* do novo segmento antes de lhe transferir os dados, tal compra seria apreciada pelo CADE, que poderia valorar o impacto do acesso aos dados obtidos pelo grupo adquirente. Todavia, ainda assim, a base de dados poderia representar tamanho benefício, apto a impactar todo um setor de mercado.

Há também dificuldade de valoração de sociedade empresária cujo principal modelo de negócios envolva os dados pessoais agregados, muitas vezes sem resultado financeiro imediato. Novamente, cabe mencionar a aquisição do WhatsApp pelo Facebook: à época, o WhatsApp não tinha fontes de faturamento consideráveis, mas o acesso à sua base de dados (dados de localização,

mensagens e listas de contatos) justificaria os \$ 19 bilhões pagos pelo Facebook.⁶⁷ Como observado anteriormente, a operação que inseriu o WhatsApp no grupo empresarial do Facebook indiscutivelmente lhe assegurou benefício considerável, mas sequer se enquadraria nos critérios para a análise pelo CADE se fosse efetivada no Brasil, já que estes se baseiam apenas no faturamento dos grupos econômicos envolvidos.

A análise concorrencial das operações que envolvem dados pessoais mostra-se, assim, extremamente desafiadora, especialmente se praticadas dentro do mesmo grupo empresarial, tratando-se de ativo de difícil valoração, sem parâmetros claramente estabelecidos para sua contabilização. Nesse sentido, vale breve digressão: como apontado anteriormente, a base de dados reunida por certa pessoa jurídica poderia compor segredo de negócio, o qual, por sua vez e em tese, é suscetível de contabilização, como os demais bens que formam seu ativo intangível, com reconhecimento contábil.

Todavia, usualmente, tal tipo de ativo costuma ser contabilizado por seu preço de aquisição, se adquirido de terceiros pela sociedade, ou, em caso contrário, passível de ativação por seu valor de mercado (sendo o conceito de *fair market value*, ou *valor justo*, usualmente empregado para tal fim),⁶⁸ de acordo com os diversos limites impostos pelo Pronunciamento nº. 4 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Se de duração limitada, tais normas contábeis preveem sua amortização – ou seja, a perda de valor dividida pelo número de períodos de duração,⁶⁹ conferindo-lhes maior precisão contábil.

Diferentemente de outras categorias de propriedade intelectual, porém, a doutrina de Denis Borges Barbosa reconhece que, se gerados internamente pela própria entidade (“ativos *autogerados*”), o segredo de negócio não atende, normalmente, ao determinado pelo Pronunciamento CPC 4 para que se promova seu reconhecimento contábil, ausente o parâmetro objetivo do preço de aquisição, o que se dá se adquirido de terceiro (ou seja, “ativos *heterogerados*”).⁷⁰ Tal perspectiva atenderia, sobretudo, aos princípios fundamentais da Ciência Contábil, como o conservadorismo e a materialidade.⁷¹ Todavia, esses obstáculos ao reconhecimento contábil também refletem as dificuldades de quantificar o *valor justo* de tais ativos intangíveis. Há, portanto, evidente incompatibilidade com a própria natureza dos ativos e os mecanismos aplicados para fins de “filtrar” as operações submetidas ao escrutínio concorrencial.

Para além das dificuldades apontadas anteriormente, nota-se que há carência de remédios práticos ao eventual desequilíbrio competitivo que o acesso a certos conjuntos de dados possa conferir a grupo empresarial. A concessão de compartilhamento com concorrentes dificilmente figurará como uma opção, uma vez que dependeria do consentimento dos próprios titulares e que poderia esbarrar na proteção aos segredos de comércio, apontados anteriormente. Por outro lado, operação do tipo, teoricamente, sempre estaria apta a promover sinergias eficientes,⁷² cujos benefícios, se repassados aos consumidores, podem preencher o disposto no art. 88, § 6º, da Lei do CADE.

6. Conclusão

O fluxo de dados entre integrantes do mesmo grupo empresarial pode parecer, à primeira vista, antinômico às disposições da LGPD, o que se revela falso em análise mais atenta. A devida observação de suas prescrições, que se delineiam como autêntica moldura, permite a coexistência da dinâmica do agrupamento empresarial e a devida tutela dos dados identificadores da pessoa natural – desde que sempre instruída por firmes práticas de *compliance*, fiéis às suas expressas disposições.

O conjunto agregado de dados pessoais, especialmente após seu devido tratamento, merece ser tratado como valioso e útil ativo empresarial, vocacionado não apenas à maior lucratividade mas também à prestação de serviço mais eficiente aos próprios titulares – como verdadeiro corolário da inovação no mercado brasileiro. Todavia, o aspecto existencial de tais dados também não poderá ser perdido de vista, e os cuidados deverão permear sua abordagem, em especial perante operações societárias entre grupos empresariais. Nesse contexto, a atenção e o rigor na transferência da guarda dos dados e na eventual obtenção de novo consentimento pelos titulares serão primordiais para prevenir sanções e contornar riscos. Trata-se, assim, de elemento que poderá compor o fundo de comércio empresarial, impulsionado pela sinergia própria de um grupo de empresas, ao passo que possui, também, dimensão única, que envolve os valores mais caros ao ordenamento e que, portanto, impõe autênticos deveres fiduciários a quem se propõe a tratar dados pessoais.

Em resumo, o aproveitamento empresarial dos dados pessoais implica autêntica situação jurídica dúplice,⁷³ que inspira diversos cuidados e gera aparentes conflitos na aplicação de regras próprias às situações existenciais e àquelas atinentes ao contexto das relações patrimoniais. Todavia, como exposto, o aspecto existencial atinente aos titulares sempre virá em primeiro plano, reservando-se as disposições patrimoniais à interação entre empresas, quando assumem sua roupagem como segredo de comércio.

Finalmente, apenas o tempo e a prática responderão a algumas das indagações mais instigantes, particularmente as atinentes à interação da LGPD – e do substrato fático que lhe motivou – com outras normas. São desafios naturais e inevitáveis, que mais se originam (e sempre se renovarão) das novas realidades do que de inovações legislativas.

7. Bibliografia

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito da internet e sociedade da informação*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC 4*. Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/ativos2009.pdf]. Acesso em: 15.03.2019.

BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual. *RABPI*, Rio de Janeiro, n. 77, jul.-ago. 2005.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018.

BARBOZA, Heloisa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coord.). *O direito & o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

BINENBOJM, Gustavo. *Poder de polícia, ordenação e regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador*. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito societário*. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

CABRAL, Filipe Fonteles. *O relatório de impacto à proteção de dados pessoais como um instrumento para o gerenciamento de riscos na Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais*. Dissertação defendida como requisito parcial para obtenção do título de mestre em direito junto à UERJ, orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias e coorientada pelo Prof. Dr. Carlos Affonso Pereira de Souza, 2019.

CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. t. II.

CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil na Era do *Big Data*. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Org.). *Tecnologia Jurídica & Direito Digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2.

COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO, Calixto Filho. *O poder de controle na sociedade anônima*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

CORREIA, Ferrer A. *Reivindicação do estabelecimento comercial como unidade jurídica*. Coimbra, 1962.

COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das obrigações*. 9. ed. Coimbra: Almedina, 2006.

CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, 2017.

DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. *A regulação da criptografia no direito brasileiro*. v. 1, 2018.

DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

ECK, Ulrich. *Sociedade de risco*. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010.

FEKETE, Elizabeth Kaznar. *O Regime jurídico do segredo de indústria e de comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FRANCO, Vera Helena de Mello. *Direito empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

FRAZÃO, Ana. *Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017.

GONÇALVES, Thatiane Rabelo. *O Patrimônio incorpóreo das sociedades empresárias na era da informação: big data, redes sociais e streaming*. Dissertação defendida como requisito parcial para obtenção do título de mestra em direito junto à UFMG, orientada pelo Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Milagres, 2019.

MARION, José Carlos. *Contabilidade empresarial*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MAXIMILIANO, Carlos, *Hermenêutica e aplicação do direito*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 79, 2011.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014.

NARAYANAN, Arvind; SHMATIKOV, Vitaly. *Robust De-anonymization of Large Datasets (How to Break Anonymity of the Netflix Prize Dataset)*, University of Texas: Austin, 2008. Disponível em: [<https://arxiv.org/pdf/cs/0610105.pdf>]. Acesso em: 12.02.2019.

OHM, Paul. Broken promises of privacy: responding to the surprising failure of anonymization. 57 *UCLA Law Review*, 2010, p. 1.701 e ss. Disponível em: [www.uclalawreview.org/pdf/57-6-3.pdf]. Acesso em: 15.03.2019.

OSÓRIO, Fábio Medina. *Direito administrativo sancionador*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

PARENTONI, Leonardo. *Lei Geral de Proteção de Dados v. Marco Civil da Internet: Antinomias*, coluna publicada em 02.09.2018 em [www.dtibr.com/single-post/2018/09/10/LEI-GERAL-DE-PROTE%C3%87%C3%83O-DE-DADOS-V-MARCO-CIVIL-DA-INTERNET-ANTINOMIAS]. Acesso em: 15.03.2019.

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Coligação e grupamento de sociedades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). *Direito das companhias*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; GHISI, Silvano. A manipulação de dado pessoais nas relações de consumo e o sistema “crediscor”. *Civilistica.com*, n. 1, 2015.

PIZZOLATO, Nélio Domingues. *Introdução à contabilidade gerencial*. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

REZEK, Francisco; GUIDI, Guilherme Berti de Campos. Jurisdição na Era da Internet: continências necessárias. *Caderno Especial – Cooperação Jurídica Internacional*, v. 1, abr. 2018.

RODOTÀ, Stefano. *Tecnologie e diritti*. Bologna: Mulino, 1995.

RUBINSTEIN, Ira. *Big Data: a pretty good privacy solution*. New York University School of Law: Nova York, 2013. Disponível em: [https://fpf.org/wp-content/uploads/TECH-Rubinstein-Big-Data-A-Pretty-Good-Privacy-Solution.pdf]. Acesso em: 15.03.2019.

SALOMÃO, Calixto Filho. *Direito concorrencial: as estruturas*. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1994.

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson. Situações jurídicas dúplices: controvérsias na nebulosa fronteira entre patrimonialidade e extrapatrimonialidade. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. *Diálogos sobre direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. v. III.

VERHULST, Stefaan G. Mapping the next frontier of open data: corporate data sharing. In: GASSER, Urs et al. (Coord.). *Internet Monitor 2014: reflections on the digital world*. Cambridge: Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, 2014.

WATSON, Sara M. Mapping the data ecosystem. In: GASSER, Urs et al. (Coord.). *Internet Monitor 2014: reflections on the digital world*. Cambridge:

Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, 2014.

WILLIAMSON, Oliver E. *The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting*. New York: The Free Press, 1985.

YAKOWITZ, Jane. Tragedy of the data commons. *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 25, n. 1, 2011. Disponível em: [http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v25/25HarvJLTech1.pdf]. Acesso em: 15.03.2019.

1

Doutor e Mestre em Direito Civil (UERJ). Professor da Especialização em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. raulmurad@nbb.com.br.

2

Mestre em Direito Civil (UERJ). Especialista em Direito da Propriedade Intelectual (PUC-Rio). Advogado de Gustavo Tepedino Advogados. rlr@tepedino.adv.br.

3

Os autores agradecem a valiosa revisão do Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, que em muito contribuiu para as conclusões alcançadas neste trabalho.

4

Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 – a Lei Geral de Proteção de Dados.

5

Nesse sentido, *vide* as recentes dissertações de GONÇALVES, Thatiane Rabelo. *O patrimônio incorpóreo das sociedades empresárias na era da informação: big data, redes sociais e streaming*. Dissertação defendida como requisito parcial para obtenção do título de mestra em direito junto à UFMG, orientada pelo Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Milagres, 2019; e CABRAL, Filipe Fonteles. *O relatório de impacto à proteção de dados pessoais como um instrumento para o gerenciamento de riscos na Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais*. Dissertação defendida como requisito parcial para obtenção do título de mestre em direito junto à UERJ, orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias e Coorientada pelo Prof. Dr. Carlos Affonso Pereira de Souza, 2019.

6

A Lei 13.709/18 utiliza, em si, o termo “pessoa natural”. Entretanto, acredita-se que a expressão “pessoa humana” possui maior harmonia com o referencial axiológico, decorrente da Constituição da República, em especial o artigo 1º, III, da CRFB.

7

Conclusão alcançada por RODOTÀ, Stefano. *Tecnologie e diritti*. Bologna: Mulino, 1995. p. 36-37. Como o próprio Stefano Rodotà afirma, porém, são “ideias velhas e problemas novos”: direitos há muito estabelecidos em ordenamentos em todo o mundo, que enfrentam novos desafios, culminados pelo avanço tecnológico (ibidem, p. 50).

8

Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997

9

Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, acrescida das disposições de seu decreto regulamentar, o Decreto 8.771, de 11 de maio de 2016.

10

Em termos ditos alguns anos antes da LGPD: “Como se viu, a Constituição Federal tutela a intimidade e a vida privada, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (art. 5º, X e XII) e assegura a concessão de *habeas data* [e mandado de segurança] (art. 5º, LXIX e LXXII). Além disso, o Código de Defesa do Consumidor contém regras específicas sobre bancos de dados e cadastros de consumidores, a Lei 12.414/2011 disciplina o cadastro positivo e a Lei 12.527/2011 regula o acesso a informações públicas. Há, portanto, alguma proteção aos dados pessoais. Mas a limitada aplicabilidade da lei consumerista nesse aspecto, a jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal acerca do *habeas data* e do sigilo de dados, bem como a ausência de princípios claros a nortear a proteção de dados pessoais indicam que ainda há muito a fazer nos planos doutrinário, legislativo e jurisprudencial para que a proteção de dados pessoais se torne efetiva no Brasil. A edição de lei nacional de proteção dos dados pessoais é essencial para suprir as omissões hoje existentes e garantir um nível adequado de proteção” (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 13, 2017. p. 66).

11

Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, em especial a previsão do artigo 43 e seus parágrafos.

12

A assimetria informacional pode ser catalisada por tal fator, gerando, de um lado, a hipersuficiência que pode engendrar o oportunismo, e, de outro, um distanciamento entre o fornecedor menos forte e a freguesia/clientela em disputa. Entre outros, vide WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting*. New York: The Free Press, 1985, p. 47.

13

E tal razão é explicitada por Laura Schertel Mendes, em estudo que antecedeu a LGPD e segue plenamente aplicável: “É correto o entendimento segundo o qual a proteção de dados pessoais deve abranger ambos os tipos de bancos de dados [manuais e automatizados], na medida em que a potencialidade dos danos à personalidade reside não na informatização, mas no tratamento dos dados em si e na obtenção de informações que representem de forma objetiva o indivíduo perante a sociedade, gerando consequências para a sua vida. Afinal, também os bancos de dados manuais podem apresentar erros quanto aos dados pessoais, bem como possibilitar a transferência desses dados a terceiros” (MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 52-53).

14

“Uma outra técnica ainda diz respeito à uma modalidade de coleta dos dados pessoais, conhecida como *data mining*. Ela consiste na busca de correlações, recorrências, formas, tendências e padrões significativos a partir de quantidades muito grandes de dados, com o auxílio de instrumentos estatísticos e matemáticos. Assim, a partir de uma grande quantidade de informações em estado bruto e não classificada, podem ser identificadas informações de potencial interesse” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 176).

15

“Esse primeiro elemento da doutrina das infra-estruturas essenciais, qual seja, que o consumidor merece tratamento sem discriminação e um preço razoável, é complementado pelo impacto do acesso exclusivo de um agente econômico junto a certos competidores, qualificado pela situação especial de que são concorrentes parciais do titular num mercado *dependente* [...] a doutrina *concorrencial* das *essential facilities* se interpenetra com as noções de domínio eminente do Estado e do dever de assegurar livre acesso, ainda que remunerado, aos meios essenciais à população e à economia” (BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual. *RABPI*, Rio de Janeiro, n. 77, jul.-ago. 2005).

16

Mutatis mutandi, vide SALOMÃO, Calixto Filho. *Direito concorrencial: as estruturas*. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 146.

Em comentário a respeito dessa tendência: “Corporate data sharing refers to the emerging trend whereby companies are sharing anonymized and aggregated data for third-party users to mine for patterns and trends that can inform better policies and lead to greater public good” (VERHULST, Stefaan G. Mapping the next frontier of open data: corporate data sharing. In: GASSER, Urs et al. (Coord.). *Internet Monitor 2014: reflections on the digital world*. Cambridge: Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, 2014. p. 72). Igualmente, “[d]ata-driven companies like Facebook, Google, Acxiom, and others are building out their proprietary walled gardens of data. They are doing everything they can to control for privacy and security while also keeping control over their greatest assets. Still, they aren’t held accountable for the ads individuals purchase and target on their platforms, or for tertiary uses of data once it leaves their kingdom. [...] Before we can start to discuss normative judgments about the appropriate uses of data, we have to understand the extent of what is technically possible. We cannot hope to regulate the misuse of data without means to hold all interconnected parties accountable for the uses and flows of data. We need to map these relationships and data patterns. Who are the parties involved? How are they collecting, cleansing, inferring and interpreting data? To what ends is the data being used?” (WATSON, Sara M. Mapping the data ecosystem. In: GASSER, Urs et al. (Coord.). Op. cit., p. 71-72).

A respeito, ver PEZZELLA, Maria Cristina Cereser e GHISI, Silvano. A manipulação de dados pessoais nas relações de consumo e o sistema “crediscore”. *Civilistica.com*, n. 1. 2015. p. 13

Nota-se, ademais, que há lei específica aplicável aos cadastros de proteção ao crédito, a Lei 12.414, de 09 de junho de 2011.

Sobre grupos societários, *vide* BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito societário*. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 548; e COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2. p. 503.

Sobre as vantagens da utilização dos grupos societários, *vide* COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO, Calixto Filho. *O poder de controle na sociedade anônima*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 129.

“A razão e ser do grupo de sociedades são os benefícios que podem resultar da cooperação das sociedades que o integram, sob a direção da sociedade controladora. [...] Todas as sociedades que integram o grupo de fato – principais ou acessórias, líderes ou lideradas, maiores ou menores – auferem benefícios da vinculação ao grupo porque este – como todo – é maior do que a soma das partes; e são várias as modalidades de cooperação e apoio mútuos que uma sociedade pode prestar a outra sem prejuízo para seu patrimônio nem redução dos lucros de que participam os acionistas minoritários. Se a formação do grupo permite que o conjunto obtenha benefícios econômicos que não podem ser alcançados de outro modo, o único limite à cooperação e apoio mútuo que se justifica, como meio de proteger os acionistas minoritários e credores, é o de que não sejam causados prejuízos a uma sociedade para atender ao interesse de outra” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Coligação e grupamento de sociedades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Org.). *Direito das companhias*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1.405-1.406).

Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial (que, por sua vez, cita o agregador de dados *Statista*), em 2017 o Facebook era a mais popular rede social, com 1,8 bilhão de usuários

ativos/mês (ver: [www.weforum.org/agenda/2017/03/most-popular-social-networks-mapped/]. Acesso em: 15.03.2019).

25

Ainda conforme o Fórum Econômico Mundial, em 2017 foram enviadas uma média de 29 milhões de mensagens a cada 60 segundos pelo WhatsApp, o que equivale a 40 bilhões de mensagens por dia. É a segunda rede social do mundo (dados de 2017), atrás apenas do Facebook, com cerca de 1 bilhão de usuários ativos por mês (idem, e ver, também, [www.weforum.org/agenda/2018/03/internet-minute-whatsapp-facebook-emails/]. Acesso em: 15.03.2019).

26

Nesse sentido, trecho dos termos de uso do WhatsApp, vigente em 10.02.2019: “Passamos a fazer parte da família de empresas do Facebook em 2014. Como parte desta família, o WhatsApp recebe e compartilha dados com os demais membros. Podemos usar os dados fornecidos por eles e eles podem usar os dados compartilhados por nós para nos ajudar a operar, executar, aprimorar, entender, personalizar, dar suporte e anunciar nossos Serviços e as ofertas deles”.

27

O exemplo é dado para fins didáticos: ainda que o WhatsApp e o Facebook já realizem tal operação, não é claro qual seria a técnica empregada (*profiling*, *data-mining* etc.).

28

A respeito, veja-se: [https://techcrunch.com/2016/08/25/whatsapp-to-share-user-data-with-facebook-for-ad-targeting-heres-how-to-opt-out/]. Acesso em: 10.02.2019.

29

A indagação não seria, *a priori*, absurda. Colocar-se-ia em orientação com as anotações da doutrina, de que, em termos sociais e econômicos, o grupo de empresas pode agir como único ente empresarial, com interesses próprios, distintos dos interesses próprios de cada componente do grupo. Nesse sentido: “Cada sociedade empresária isolada (não integrante de grupo) tem uma empresa distinta; no grupo de sociedades há (no plano jurídico) diversas sociedades empresárias personificadas a que corresponde, ou pode corresponder, no plano econômico e social, uma única empresa. [...] No grupo de sociedades, tanto de direito quanto de fato, existe um interesse do grupo que não se confunde com o interesse de cada sociedade. [...] O interesse do grupo não substitui, mas se superpõe ou acresce ao interesse social de cada membro do grupo: é o interesse do conjunto das sociedades de mediante cooperação, otimizar os resultados de cada uma na realização do seu fim e objeto e participar dos benefícios criados pela atividade em comum” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Op. cit., p. 1.404). Ver, ainda: “Ora, essa perda da autonomia de gestão empresarial traduz-se, frequentemente, senão sempre, pelo sacrifício dos interesses de cada sociedade ao interesse global do grupo. Os patrimônios sociais tendem a confundir-se, e tudo se passa nesse campo, como frisou um autor, analogamente ao princípio dos vasos comunicantes” (COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO, Calixto Filho Op. cit., p. 357-358).

30

Os princípios adotam relevante papel na proteção de dados pessoais ao redor do mundo, sendo adotados por inúmeras jurisdições com base nos quase universais *Fair Information Principles* formulados nas décadas de 1970 e 1980 (a respeito, ver MENDES, Laura Schertel. Op. cit., p. 68; e CAVALCANTI, Natália Peppi e SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. *A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil na Era do Big Data*, in FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Org.). *Tecnologia Jurídica & Direito Digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia* – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 375).

31

“A partir da década de 1960, o conceito de informação pessoal passou de algo que era meramente pressuposto (pois a garantia da privacidade deveria necessariamente compreender a proteção dos documentos e informações de natureza privada) para gradativamente emergir como conceito central para a tutela jurídica da privacidade. Isso tem direta correspondência com a transformação

do sentido social de privacidade a que Stefano Rodotà faz alusão: de um sentido negativo, de confidencialidade e reserva sobre a esfera privada – logo, atinente a dados necessariamente vinculados ao indivíduo e suas relações particulares –, para compreender o controle dinâmico sobre as próprias informações” (DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego. *Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. A regulação da criptografia no direito brasileiro*, 2018. v. 1. p. 100). Ver, ainda, MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 79, 2011. p. 45-81.

32

MAXIMILIANO, Carlos, *Hermenêutica e aplicação do direito*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 225.

33

A respeito do ato de autonomia privada, em especial aquele dotado de conteúdo não patrimonial, ver BARBOZA, Heloisa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coord.). *O direito & o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 413-416.

34

Nessa direção, vale mencionar também o art. 107 do Código Civil, “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

35

“O *princípio da necessidade* impõe ‘limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados’. Essa diretriz está atrelada à ideia de *data minimization*, segundo a qual o tratamento deve valer-se apenas de dados absolutamente necessários para realizar com êxito o objetivo proposto. Isso implica na restrição da coleta, do armazenamento e da análise de dados pessoais aos relevantes e apropriados. [...] O *princípio da segurança* estipula a ‘utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão’. Corroborando com essa orientação, o *princípio da prevenção* preconiza a ‘adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais’” (CAVALCANTI, Natália Peppi; SANTOS, Luiza Mendonça da Silva Belo. Op. cit., p. 358).

36

Os grupos empresariais de fato são reconhecidos enquanto fenômeno jurídico no art. 243 e seguintes da Lei das S.A., que prescreve diversas normas voltadas à situação de coligação empresarial, como nota CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. t. II. p. 39 e ss.

37

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 732.

38

Para um profundo e clássico estudo sobre a dicotomia titularidade/controle, vide BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

39

Sobre as questões atinentes ao consentimento e ao seu verdadeiro papel na ordem da tutela dos dados pessoais, ver DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 370-377.

40

Mutatis mutandi, o sistema *opt out* do Código Civil, no art. 1.147, quanto à vedação à concorrência no trespasse, já é extremamente criticado pela doutrina, v.g., FRANCO, Vera Helena de Mello. *Direito empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 141. Se tal já beira a inconstitucionalidade no ambiente interempresarial, certamente atinge a ilegalidade, a abusividade e a incompatibilidade com a CRFB em ambiente marcado por clara assimetria de poder.

41

“[O] grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade. Os três elementos fundamentais de toda relação societária – a saber, a contribuição individual com esforços ou recursos, a atividade para lograr fins comuns e a participação em lucros ou prejuízos – encontram-se em todo grupo. Ainda que o legislador não reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade de segundo grau, que é um grupo personalizado, a relação societária que se estabelece entre as empresas ou sociedades agrupadas implica, necessariamente, uma unidade de direção e uma intercomunicação patrimonial. [...] A confusão patrimonial, nos grupos societários de fato, é, assim, nitidamente profligada” (COMPARATO, Fabio Konder; SALOMÃO, Calixto Filho. Op. cit., p. 360-362).

42

“Um princípio fundamental que todas as atividades de processamento de dados devem seguir é o *princípio da finalidade*, que indica a correlação necessária que deve existir entre o uso dos dados pessoais e a finalidade comunicada aos interessados quando da coleta dos dados. Esse princípio é essencial para se limitar o acesso de terceiros ao banco de dados. De forma semelhante, ele também serve como parâmetro para julgar se determinado uso dos dados pessoais é adequado e razoável, de acordo com a finalidade informada no primeiro momento ao interessado. Por fim, esse princípio exige que o responsável pelo tratamento dos dados estabeleça de forma expressa e limitada a finalidade do tratamento de dados, sob pena de se considerar ilegítimo o tratamento realizado com base em finalidades amplas ou genéricas” (MENDES, Laura Schertel, Op. cit., p. 70-71).

43

“O direito geral de informação consiste no direito que as pessoas têm de conhecer sobre a existência dos bancos de dados, bem como dos seus objetivos e de seu conteúdo. Para que o indivíduo possa proteger a sua personalidade, é preciso que todo o processo de tratamento de dados pessoais seja transparente. Assim, o direito à informação consiste no direito do indivíduo cujos dados são coletados de conhecer a identidade do responsável pelo tratamento, o objetivo do tratamento e os destinatários dos dados em caso de transferência” (MENDES, Laura Schertel. Op. cit., p. 67).

44

Para além de necessitar tomar medidas adicionais para que os princípios supracitados sigam respeitados, o grupo poderá, após eventual descumprimento das disposições da LGPD, expor-se mais ao risco de aplicação da sanção cominada pelo art. 52, II, de acordo com valor-base calculado sobre todo o seu faturamento, considerando que, possivelmente, será, nesse caso, mais difícil segregar o ramo de atividade empresarial no qual a violação se deu (em linha com o art. 52, § 4º). Trata-se, ao final, de uma decisão empresarial. Sobre a relação umbilical entre capitalismo e risco, vide ECK, Ulrich. *Sociedade de risco*. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 23.

45

OSÓRIO, Fábio Medina. *Direito administrativo sancionador*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 281 e ss. Observa-se, porém, que o fato de a competência para a aplicação da multa ser distinta poderia contribuir, na esteira de antiga posição doutrinária e jurisprudencial brasileira calcada na separação e independência de poderes, para o entendimento de que inexistiria *bis in idem*, conforme relata e critica Fábio Medina Osório (ibidem, p. 289 e 309).

46

Decreto-lei 4.657, de 04 de setembro de 1942.

Em comentário a respeito das antinomias entre MCI e LGPD, afirma Leonardo Parentoni: “é bastante provável que a jurisprudência não admita a gradação da multa com base no MCI, até porque as disposições especiais da LGPD são mais benéficas e *estão em vigor*, ao contrário das sanções examinadas anteriormente” (*Lei Geral de Proteção de Dados v. Marco Civil da Internet*: antinomias, coluna publicada em 02.09.2018. Disponível em: [www.dtibr.com/single-post/2018/09/10/lei-geral-de-prote%C3%87%C3%83o-de-dados-v-marco-civil-da-internet-antinomias]. Acesso em: 15.03.2019).

BINENBOJM, Gustavo. *Poder de polícia, ordenação e regulação*: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 109.

Em que pese tal assertiva, a infração no tratamento ou guarda de dados pessoais pela internet não deixa de ser uma espécie “qualificada” da mesma violação prevista em termos mais genéricos na LGPD. Então, sendo impossível permitir a supracitada e indevida duplicidade de sanções, é possível cogitar, porém, da aplicação da multa prevista na LGPD pela ANPD a qual, se foi a violação efetuada *on-line*, poderia ser majorada em ação judicial própria, até que eventualmente se alcance o patamar máximo de 10% do MCI. Para tanto, seriam avaliadas as particularidades do caso concreto e permitir-se-ia o exercício do contraditório e das prerrogativas recursais comuns a qualquer processo judicial.

LGPD: artigo 7º, IX.

Ao apresentar o rol delimitador do artigo 10 da LGPD, o *caput* é permeado pela expressão “[...] mas não se limitam [...]”.

“Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, *no nível do direito positivo*, aquelas prerrogativas e instituições que eles concretizam em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo *fundamentais* acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as (quais) a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive” (SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1994. p. 161-164). Ver, também: BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 99-105.

Ou, como apontado anteriormente, desde que o faça de acordo com expressa previsão contratual e, novamente, apenas para o estritamente necessário para que se atinja a finalidade proposta (princípio da necessidade): “Um dos princípios centrais nesse panorama é o da necessidade: os dados pessoais, confidenciais por natureza, devem ser acessados e utilizados pela empresa apenas quando estritamente necessário para a prestação dos serviços. Se as subsidiárias não ofertam o serviço nem de qualquer forma nele atuam precisando de ter algum acesso aos dados dos usuários, os princípios gerais de proteção de dados, estabelecidos desde a década de 1980 e incorporados a diversas ordens jurídicas, não permitem que a subsidiária tenha acesso a tais dados” (REZEK, Francisco; GUIDI, Guilherme Berti de Campos. *Jurisdição na era da internet: continências necessárias*. *Caderno Especial – Cooperação Jurídica Internacional*, v. 1, abr. 2018. p. 136).

O que já aconteceria, conforme relatam REZEK, Francisco; GUIDI, Guilherme Beri de Campos. Op. cit., p. 135: “Não é raro, entretanto, que certas atividades específicas e auxiliares ou complementares do serviço principal sejam delegadas a subsidiárias. É o caso, tomando como exemplo o modelo de serviço gratuito suportado por anúncios, da venda de espaços publicitários. Enquanto a empresa central oferece e controla determinado serviço *on-line*, suas subsidiárias, localizadas em mercados relevantes, oferecem a possíveis anunciantes a oportunidade de veicular peças publicitárias em espaços predefinidos na plataforma oferecida e mantida pela empresa central. Fala-se aqui de empresas distintas: a empresa-mãe, sediada no exterior, responsável pelo serviço digital, tem personalidade jurídica própria, sendo responsável por seus atos; a empresa subsidiária, sediada no Brasil, responsável pela prestação de serviços acessórios e não do serviço principal – detentora de personalidade jurídica própria, à luz de outra ordem jurídica nacional e sob outra bandeira. Não há como confundir uma com outra, nem como exigir desta a conduta exigível daquela. Normal, a enfatizar tal separação, é que a subsidiária sequer tenha acesso aos dados dos usuários e os servidores que operam o serviço. Isto se explica tanto pela centralização do processamento de dados quanto pelo empenho na proteção do consumidor”.

55

Art. 5º, I, da LGPD: “dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. A tal previsão deve se conjugar a do art. 12, § 2º: “Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada”, o que compreenderá, por exemplo, hábitos de consumo, inserções em mecanismo de busca ou formulários, mensagens trocadas com outros usuários, anotações guardadas por sistema etc. Sobre o *profiling*, método de elaboração de perfis de comportamento de uma pessoa, ver DONEDA, Danilo. Op. cit., p. 173.

56

Ainda, deve-se notar a ressalva do art. 12 da LGPD: os dados anonimizados não são assim considerados se seu processo de anonimização puder ser revertido com esforços razoáveis. Nesse sentido, observa-se que a anonimização de dados compõe verdadeiro dilema na doutrina jurídica internacional, como se vê no debate entre diversos autores a respeito da insuficiência dos procedimentos de anonimização contrapostos à importância da pesquisa com dados anonimizados. Por exemplo, veja-se discussão entre Ira Rubinstein (Big Data: a pretty good privacy solution. New York University School of Law: Nova York, 2013. Disponível em: [https://fpf.org/wp-content/uploads/TECH-Rubinstein-Big-Data-A-Pretty-Good-Privacy-Solution.pdf]. Acesso em: 15.03.2019), Jane Yakowitz (Tragedy of the data commons. *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 25, n. 1, 2011. Disponível em: [http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v25/25HarvJLTech1.pdf]. Acesso em: 15.03.2019) e Paul Ohm (Broken promises of privacy: responding to the surprising failure of anonymization. *57 UCLA Law Review*, 2010. p. 1.701 e ss. Disponível em: [www.uclalawreview.org/pdf/57-6-3.pdf]. Acesso em: 15.03.2019). Ademais, com muitas bases de dados públicas disponíveis na Internet, é possível reverter a maior parte dos processos de anonimização ou mesmo pseudonimização, cruzando as bases de dados, como ocorreu no caso do “Netflix Prize”, no qual foi publicizada pelo Netflix base pseudonimizada com dados indicando o acesso a filmes e séries por seus usuários, com o fim de promover competição pública para o aprimoramento de seu algoritmo de recomendação. Todavia, ao cruzar a base de dados com comentários públicos feitos no *site* IMDB (no qual usuários avaliavam filmes e séries), dois pesquisadores da Universidade do Texas demonstraram ser possível identificar usuários listados (NARAYANAN, Arvind; SHMATIKOV, Vitaly. *Robust de-anonymization of large datasets (how to break anonymity of the Netflix Prize dataset)*. University of Texas: Austin, 2008. Disponível em: [https://arxiv.org/pdf/cs/0610105.pdf]. Acesso em: 12.02.2019). A respeito, veja-se OHM, Paul. Op. cit., p. 1.720. Logo, tais processos de anonimização e pseudonimização devem ser vistos com cautela e deverão observar técnicas suficientes para garantir sua desvinculação com os titulares.

57

FEKETE, Elizabeth Kaznar. *O Regime jurídico do segredo de indústria e de comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 61-91.

58

Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Inclusive, já foi intenso o debate em torno da possibilidade de tutela das bases de dados por direito de autor ou direito de propriedade intelectual *sui generis*, noções que mereceram a crítica de José Oliveira Ascensão, dada sua ameaça ao direito à informação e de expressão (ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito da internet e sociedade da informação*. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 305-322).

Alerta-se, por fim, que a ressalva mencionada, que autoriza a exploração comercial de dados pessoais sem consentimento expresso para a consecução de “interesses legítimos” do controlador ou de terceiro, não compreende os dados pessoais sensíveis, delimitados pelo art. 5º, II, da LGPD. Curiosamente, a LGPD não inclui os dados de geolocalização entre os dados pessoais sensíveis. Logo, dados fornecidos por sistema de GPS (*Global Positioning System*) ou semelhante poderão ser economicamente explorados em benefício de terceiro, mesmo sem específico consentimento, nos termos dos arts. 7º e 10. Isso inclui direcionar publicidade de estabelecimentos próximos, mapear padrões de deslocamento, entre outras possibilidades quase “distópicas” que já são efetivadas por alguns aplicativos de navegação e transporte e viabilizadas pela ampla disponibilidade de celulares com sistema de GPS.

Essencialmente, ocorre situação análoga à cessão da posição contratual do controlador, com a sucessão dos termos pré-acordados com o titular, e até então vigentes – ver COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das obrigações*. 9. ed. Coimbra: Almedina, 2006. p. 777-780.

Tangenciando as hipóteses de trespasse no comércio eletrônico, *vide* BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018.

CORREIA, Ferrer A. *Reivindicação do estabelecimento comercial como unidade jurídica*. Coimbra, 1962. p. 8.

Por exemplo, veja-se “Condutas anticoncorrenciais e a Lei do Cade”, artigo veiculado no periódico *Valor Econômico* (Disponível em: [www.valor.com.br/legislacao/2682210/condutas-anticoncorrenciais-e-lei-do-cade]. Acesso em: 15.03.2019).

O ato de concentração 08700.006518/2016-47, que tratou da aquisição de 51% das ações da Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A. pela QGOG Participações S.A., não foi conhecido pela Superintendência do CADE, uma vez que se tratou de operação realizada dentro do mesmo grupo econômico.

“Independentemente da linha ideológica do intérprete, a avaliação de uma operação de concentração envolve a análise de seu *impacto sobre o mercado*, para determinar em que medida foi este ‘concentrado’ (ou seja, diminuiu o grau de concorrência ali existente)” (FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 432).

A respeito, ver notícia em [www.investopedia.com/articles/personal-finance/040915/how-whatsapp-makes-money.asp]. Acesso em: 11.02.2019.

Como estabelece o Pronunciamento CPC 46, em seu item 9: “Este Pronunciamento define valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela

transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”.

69

Para tal pormenorização, veja-se: MARION, José Carlos. *Contabilidade empresarial*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 358-359.

70

“Temos assim que o segredo de empresa, o *know-how* e outros objetos de mesmo gênero não são suscetíveis de ser conferido ao capital, salvo quando parte de um conjunto organizado de bens de natureza concorrencial, e de forma que se assegure uma razoável oportunidade de mercado. Como dissemos quanto a outros contratos bilaterais, se houver simultaneamente uma cessão de clientela, representada, por exemplo, por pactos de não concorrência, e transferência de outros ativos pertinentes à manutenção do fluxo de receita, importando numa antecipação razoável da receita futura proveniente de tal parcela do mercado” (BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC n. 4*. Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/ativos2009.pdf]. Acesso em: 15.03.2019. p. 31).

71

Ver MARION, José Carlos. Op. cit., p. 153. Veja-se, ainda, PIZZOLATO, Nélcio Domingues. *Introdução à contabilidade gerencial*. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 9.

72

No controle de estruturas efetuado pelo CADE, a análise das eficiências geradas pela operação é efetuada para verificar se seus efeitos anticoncorrenciais se justificam. Importante é que, “além de todos os cuidados relacionados à avaliação das eficiências que poderão ser aceitas, há que se verificar em que medida elas se convertem em benefícios a serem compartilhados com o consumidor e em que medida se mantêm níveis mínimos de concorrência no mercado” (FRAZÃO, Ana. *Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 155).

73

“Constata-se que inúmeras hipóteses da vida concreta, a partir do diálogo fato e norma, estão em uma zona de obscuridade, de modo a dificultar a classificação em existenciais ou patrimoniais. Por isso, faz-se essencial a busca da funcionalidade concreta e casuística que exerce naquele recorte fático: se realiza direta e imediatamente a dignidade humana por meio do livre desenvolvimento da personalidade, trata-se de situação existencial; se a realização da dignidade humana é mediata, visando, em primeiro plano, a efetivação da livre iniciativa, trata-se de situação patrimonial” (TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson. Situações jurídicas dúplices: controvérsias na nebulosa fronteira entre patrimonialidade e extrapatrimonialidade. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. *Diálogos sobre direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. v. III. p. 24).

Capítulo 10. Compliance de dados pessoais

Ana Frazão¹

Milena Donato Oliva²

Vivianne da Silveira Abilio³

1. Introdução: características gerais da LGPD e o papel da concretização prática da tutela dos dados pessoais

O aprofundamento dos debates em torno dos dados pessoais nas últimas décadas reflete a expressão de sua extrema relevância como direito fundamental autônomo para a tutela da pessoa humana.⁴ Com o acelerado desenvolvimento tecnológico e a consolidação de espaços públicos virtuais, a gestão da informação sobre si próprio tornou-se expressão fundamental do indivíduo. Por conseguinte, revela-se impossível cogitar de proteção integral à liberdade, à privacidade e ao desenvolvimento da pessoa natural sem que se lhe garanta eficaz defesa e controle de seus próprios dados – o que se traduz na expressão autodeterminação informativa.⁵ Daí a expressa referência do legislador brasileiro de que a proteção conferida tem o objetivo de “[...] proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” (art. 1º), verdadeira premissa que deve orientar a interpretação de todos os preceitos da LGPD.⁶

A tal importância contrapõe-se o crescente interesse comercial sobre os dados pessoais, que se tornaram fundamental ativo para o desempenho e aprimoramento de inúmeras atividades,⁷ a desafiar novos mecanismos de tutela para garantir, em meio ao fomento à inovação e à livre-iniciativa, a autodeterminação do titular dos dados. Ressalta-se que tal arquitetura protetiva precisa ser endereçada igualmente ao Estado, para o qual os dados são também importantes para inúmeras finalidades públicas.

Na esteira da regulamentação europeia, e aprofundando perspectivas já contempladas em normas anteriores, a nova lei enuncia diversos fundamentos (art. 2º) e princípios (art. 6º), atribuindo ao titular⁸ instrumentos para garantir o controle de seus dados a despeito de serem utilizados por terceiros. Muito mais que apenas impedir o acesso indesejado às informações pessoais, a LGPD preocupa-se também – como revela a alusão, no art. 2º, inciso II, à autodeterminação informativa como fundamento – com o aspecto dinâmico da proteção dos dados,⁹ a garantir tutela, por exemplo, em face da utilização dos dados pessoais para a construção de perfis (arts. 12, § 2º, e 20).

Daí a previsão de extenso rol de direitos atribuídos ao titular, cujo objetivo central consiste em concretizar sua participação ativa na gestão dos dados.¹⁰ Determina, assim, o art. 18 da LGPD que o controlador deverá atender, de forma gratuita (§5º) às solicitações do titular realizadas mediante requerimento a qualquer agente de tratamento, garantindo-lhe (i) a confirmação da existência de tratamento de dados; (ii) acesso aos dados tratados; (iii) correção dos dados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em contrariedade à lei, ainda que o tratamento seja baseado em hipótese que dispensa o consentimento (§ 2º); (v) portabilidade; (vi) eliminação de dados tratados sem consentimento, quando esse for necessário ao tratamento; (vii) informação a respeito de com quais entidades houve compartilhamento; (viii) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências de negá-lo; e (ix) revogação do consentimento.

O exercício dessas importantes prerrogativas deve ser objeto de regulamentação específica, haja vista a necessidade de se especificarem os procedimentos e prazos para atendimento das solicitações, a fim de que os agentes econômicos possam implementar sistemas que atendam adequadamente às demandas.

O foco da proteção conferida pela LGPD consiste na pessoa natural, cujos dados são tutelados em dois patamares, a depender de serem ou não sensíveis. “Dado pessoal” assume perspectiva extremamente abrangente, caracterizando-se (art. 5º, inciso I) como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. O “dado pessoal sensível” (art. 5º, II) é definido como o “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.¹¹

O dado pessoal sensível é objeto de proteção recrudescida tendo em conta o potencial lesivo de sua utilização. Com efeito, por se referir a informações relacionadas aos aspectos mais íntimos da pessoa, pode propiciar discriminações abusivas. Importante atentar que um dado *prima facie* não sensível pode o ser por revelar, indiretamente, aspectos relacionados à origem étnica (ex., com o sobrenome), à orientação sexual (ex., com o nome do companheiro), a convicções religiosas (ex., com os nomes atribuídos aos filhos).

Qualquer dado vinculado ou potencialmente vinculável a uma determinada pessoa natural, portanto, encontra-se englobado no escopo protetivo da LGPD (observadas as exceções do art. 4º), independentemente do meio de armazenamento (art. 5º, IV), o que, em conjunto com a definição de “tratamento de dados” (art. 5º, X) – “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” – evidencia a ampla incidência da LGPD às mais diversas atividades.

Outra fundamental característica da nova legislação consiste no significativo fomento ao aspecto preventivo, estabelecendo procedimentos mandatórios para os controladores e operadores de dados pessoais, tais como os deveres atinentes à implementação de severas políticas de segurança para proteção dos dados de acessos não autorizados.¹² Cuida-se de perspectiva alvissareira, na medida em que as características inerentes ao “meio digital” – entre elas a velocidade das transformações tecnológicas, a capacidade de propagação de informações e a dificuldade na contenção do fluxo de dados –, associadas à expansão da coleta e do tratamento implicam desafios à lógica repressiva, ainda mais quando esta decorre do

modelo comando-controle.¹³ O engajamento espontâneo dos titulares dos deveres e a prevenção na tutela do direito fundamental aos dados pessoais afiguram-se essenciais e, não à toa, no que diz respeito a este último aspecto, cuida-se de princípio plasmado no art. 6º, VIII, da LGPD.

Nesse cenário em que, por um lado, vislumbram-se profundas alterações na lógica até então vigente quanto ao tratamento de dados¹⁴ e, por outro, objetiva-se conferir papel primordial na efetividade dos direitos e na prevenção de danos, a adoção de mecanismos de *compliance* consubstancia valioso instrumento desse viés operacional e preventivo, auxiliando na promoção de condutas compatíveis com a regulamentação legal.¹⁵ No âmbito da proteção de dados pessoais, como se abordará a seguir (item III, a), seja por seu inerente dinamismo, seja por haver diversas lacunas para se viabilizar o cumprimento dos preceitos legais, o papel das ações dos agentes econômicos robustece-se ainda mais.

A implementação de boas práticas no tratamento de dados pessoais possui estrondoso potencial para auxiliar no atendimento aos comandos gerais da lei de acordo com as particularidades de determinados agentes econômicos, bem como prevenir a ocorrência de violações aos direitos dos titulares, na medida em que permite orientar os agentes de tratamento, traduzindo para suas atividades cotidianas as premissas principiológicas da LGPD e concretizando vários dos seus *standards* e conceitos abertos. Por se tratar de complemento à regulação estatal, apresenta, ainda, a capacidade de gerar incentivos que agregam e aprofundam controles, adaptando-lhes diante da natureza extremamente dinâmica das evoluções tecnológicas em matéria de dados.¹⁶

É diante desse contexto que o presente artigo pretende explorar o papel dos programas de *compliance* para a proteção de dados pessoais, analisando-os tanto a partir das reflexões mais gerais sobre os programas de conformidade como também a partir das perspectivas mais específicas do problema relacionado à tutela de dados pessoais, conferindo especial relevo às inovações introduzidas pela LGPD.

II. Breves considerações sobre função e conteúdo de programas de compliance

Para compreender a relevância que os programas de *compliance* assumem na tutela da proteção dos dados pessoais e no direcionamento dos agentes de tratamento a respeito das condutas necessárias para atender aos preceitos legais (item III, a), bem como determinar as linhas gerais que devem ser observadas no que se refere à LGPD (item III, b), afigura-se fundamental determinar o que se entende por *compliance*, suas funções e o conteúdo de tais programas.

a) programas de compliance, autorregulação e correção

Como já se definiu anteriormente, *compliance* refere-se “ao conjunto de ações a serem adotadas no ambiente corporativo para que se reforce anuência da empresa à legislação vigente, de modo a prevenir a ocorrência de infrações ou, já tendo ocorrido o ilícito, propiciar o imediato retorno ao contexto de normalidade e legalidade”.¹⁷ Trata-se da estruturação de políticas e procedimentos corporativos que se traduzam em ações sistemáticas com o objetivo de atender ao cumprimento aos preceitos normativos,¹⁸ a permitir a prevenção do ato ilícito ou, caso tal não seja possível, minorar seus efeitos e sancionar eventuais responsáveis.

Os programas de *compliance* relacionam-se à fixação de controles internos que, em reforço à regulação estatal, auxiliem os agentes econômicos a se manter em conformidade com a lei (e, de forma mais ampla, também com suas políticas corporativas).¹⁹ Sua relevância aprofundou-se nas últimas décadas diante da ampliação do papel sancionador do Estado: paradoxalmente, ao mesmo tempo que se os agentes econômicos passaram a se preocupar com as (cada vez mais elevadas) sanções aplicadas pelo Estado, passou-se a denotar que apenas essa perspectiva era incapaz de apresentar as soluções necessárias. Como consequência, vislumbra-se cada vez mais a incorporação dos programas de *compliance* nos ordenamentos jurídicos, como no caso brasileiro.²⁰

Regulação e *compliance* consistem em fenômenos complementares, aduzindo-se à “autorregulação regulada” em que “há, na verdade, uma espécie de correção, pois as disposições estatais estabelecem preceitos, que podem ser mais ou menos detalhados, ou criam estruturas que estimulam a autorregulação e/ou tornam vinculantes medidas de autorregulação”.²¹ Em outras palavras, verifica-se uma recíproca influência: enquanto as normas corporativas possuem o cumprimento das determinações legais como paradigma na construção de suas políticas de *compliance*, o Estado influencia sua modelagem, na medida em que procura fixar (seja mediante expressa previsão legal, seja valorando os programas de *compliance* na aplicação de sanções) fórmulas e conteúdos mínimos a serem observados pelas normas corporativas, seja estabelecendo formas de estímulo à sua adoção.²²

Essa característica de complementaridade fica ainda mais evidente na proteção de dados, uma vez que a LGPD apresenta grande plasticidade, utilizando-se de diversos *standards* e conceitos abertos, que precisam ser necessariamente contextualizados diante da realidade de cada agente econômico, do contexto social e econômico e da evolução tecnológica do momento em que forem aplicados. Logo, é fundamental que, ao lado do papel regulamentador da autoridade nacional, os agentes econômicos possam também ter a iniciativa de dar concretude aos comandos legais, adaptando-os à sua realidade a partir dos incentivos e dos esclarecimentos que recebem do próprio Estado.

Sobre o assunto, não é demais lembrar as lições de Diane Rowland, Uta Kohl e Andrew Charlesworth²³ de que o problema da regulação, especialmente no ambiente digital, não é, na prática, uma escolha rígida entre o modelo “comando-controle” e a autorregulação, até porque os dois não são polos extremos que se excluem mutuamente. Daí a discussão atual sobre um terceiro gênero – o da correção – que combinaria diferentes categorias de práticas regulatórias e exigiria o envolvimento central dos agentes privados e dos governos, a fim de propiciar muitas vantagens da autorregulação sem as mesmas desvantagens.

Embora não seja finalidade do presente artigo ingressar no exame mais aprofundado sobre eventuais distinções entre autorregulação e correção, é inequívoco que, quando se fala em *compliance* de dados, deve-se ter presente que, nessa seara, a atuação complementar entre a iniciativa privada e o Estado é ainda mais relevante. Daí por que a autorregulação ou, caso se prefira, a correção, tem papel central para dar concretude à lei, contribuindo para a efetividade da autovigilância, na

medida em que permite certa flexibilidade na composição das práticas corporativas para que se amoldem às especificidades de cada atividade, do tamanho da sociedade e dos riscos por ela assumidos.²⁴

Sob essa perspectiva, percebe-se facilmente que, às vantagens tradicionalmente atribuídas aos programas de *compliance* – (i) permitir a adequada gestão do risco da atividade – na medida em que identifica os pontos sensíveis em que há exposição ao descumprimento – e, por consequência, auxiliar na prevenção de ilícitos; (ii) viabilizar a pronta identificação de eventual descumprimento, bem como a remediação de danos daí decorrentes, auxiliando, assim, na minoração dos prejuízos; (iii) fomentar a criação de uma cultura corporativa de observância às normas legais; e (iv) servir potencialmente como atenuante no caso de punições administrativas²⁵ –, na tutela de dados soma-se à vantagem adicional de adaptar e operacionalizar diversos dos comandos gerais e conceitos abertos da LGPD. Podem-se enumerar, ainda, benefícios, ainda que indiretos, concernentes ao desenvolvimento em qualidade e inovação, além de incrementos reputacionais.

Para que tais vantagens sejam efetivamente materializadas em decorrência da adoção de sistemas de *compliance*, não é suficiente a adoção de “cartas de intenção” ou “programas de fachada”, a tornar necessário identificar os elementos que caracterizam um programa robusto.

b) programas de compliance: requisitos mínimos para sua efetividade

A mera elaboração de políticas de *compliance* que carecem de efeitos na prática corporativa – os chamados “programas de papel” – não consiste em mecanismo de efetivo autocontrole. Por consequência, a tendência é que sejam desconsiderados pelos órgãos regulatórios, sem que resultem na atenuação das sanções a serem aplicadas. Um “programa de fachada, que não preencha os requisitos mínimos ou que preencha apenas formalmente, pode de fato resultar em penalidades maiores do que aquelas que seriam aplicáveis em sua ausência”.²⁶ Com efeito, ressalta-se que um programa de *compliance* mal concebido, que não envolva suficientemente as lideranças corporativas ou careça do suporte financeiro para seu regular desempenho dissemina entre os funcionários de que o programa é um embuste.²⁷

Nesse sentido, é profícua a definição dos elementos mínimos para a estruturação de programa de *compliance* efetivo. À luz da experiência brasileira²⁸ e estrangeira,²⁹ enumeram-se dez pontos centrais:³⁰

i) Avaliação contínua de riscos e atualização do programa

Em primeiro lugar, há que se avaliar os riscos a que se submete a empresa, uma vez que, para prevenir o descumprimento, deve-se identificar os pontos de vulnerabilidades a que está submetida a organização.³¹ A análise de riscos constitui um dos elementos essenciais de um programa de *compliance*: caso não executada de forma adequada, poderá representar a inefetividade dos mecanismos implementados. O objetivo é tentar antecipar as principais áreas de exposição da pessoa jurídica para que sejam tomadas medidas preventivas proporcionais aos riscos identificados. A análise pormenorizada dos riscos – que deve ser realizada a partir do contato com todos os setores da sociedade, análise de documentos, do objeto e local das atividades empreendidas – permite a elaboração de programa de *compliance* personalizado que efetivamente se contraponha aos pontos mais sensíveis para a entidade.

Como já se viu, a noção de tratamento de dados utilizada pela LGPD é ampla, de forma que é difícil se imaginar algum agente econômico que não esteja sujeito à atividade e aos riscos respectivos. Entretanto, o tipo e a intensidade do tratamento de dados, bem como os riscos a ele inerentes, podem variar consideravelmente entre os agentes econômicos, a exigirem uma atenta e individualizada análise. Não é sem razão que a própria LGPD já oferece uma importante referência desse tipo de avaliação, ao definir o relatório de impacto à proteção de dados como a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco (art. 5º, XVII).

Nessa direção, a complexidade e a estrutura da organização também devem ser avaliados adequadamente, sendo, em geral, maiores os riscos envolvidos em corporações mais complexas, nas quais se torna mais delicado o monitoramento do cumprimento das normas, a resultar no necessário reforço das ferramentas de controle interno capazes de inibir a prática de atos ilícitos.

Em síntese, sem a correta avaliação dos riscos envolvidos não é possível elaborar um efetivo programa de *compliance*. Tal identificação pressupõe profundo conhecimento das especificidades da entidade empresarial e, para auxiliar nessa tarefa, recorre-se a um conjunto de questionamentos, variáveis a depender do objeto do programa a ser implementado.

Conquanto o primeiro passo seja de extrema relevância, não esgota as diligências necessárias para garantir a efetividade do programa de *compliance*, sendo, ainda, necessário manter constante reavaliação dos riscos, atualizando e adaptando as normas internas.

ii) Elaboração de Códigos de Ética e Conduta³²

Uma vez identificados os riscos, passa-se à elaboração do Código de Ética e de Conduta – documentos escritos que consubstanciam os valores e princípios da entidade, a serem observados por todos (inclusive terceiros), bem como orienta quais as condutas são aceitas e quais são vedadas. Para garantir sua efetividade, tais instrumentos devem fixar deveres expressos e concretos, bem como ser de simples leitura, valendo-se de linguagem clara e direta. Afinal, destinam-se a todos os setores da pessoa jurídica e, sem que seus funcionários sejam capazes de compreender os preceitos ali contidos, não será viável sua observância.

Recomenda-se, ainda, que os documentos sejam de fácil e constante acesso, sem prejuízo de sua disponibilização periódica, ainda que não haja mudanças, e que se estrutrem canais para dúvidas e esclarecimentos.

iii) Organização compatível com o risco da atividade

Para garantir o efetivo cumprimento das normas fixadas nos programas de *compliance*, afigura-se igualmente necessário estabelecer uma organização com procedimentos e controles internos compatível com a avaliação de riscos. Cuida-se de implementar as reestruturações necessárias ao atendimento dos riscos identificados, inclusive estabelecendo um setor independente e com recursos para exercer a função de vigilância e assegurar o respeito ao programa, além de representar importante padrão de conduta dos próprios administradores.³³

iv) Comprometimento da alta administração

Ao lado da adequada avaliação de riscos, o efetivo envolvimento da alta administração na execução é essencial para o êxito do programa de *compliance*. Isso requer que os administradores da sociedade tornem inequívoco, mediante adoção de atos concretos, que a organização está empenhada na observância das leis e normas internas, conferindo-lhe papel primordial – inclusive em confronto com as metas empresariais. A relevância do requisito é de fácil percepção: caso a gerência da pessoa jurídica manifeste-se de forma contraditória com os planos constantes no programa de *compliance*, a mensagem recebida pelos funcionários será de que esse não passa de simples instrumento de fachada.

Em conjunto com mensagens e ações cotidianas, o comprometimento da alta administração revela-se também na existência de apoio concreto para a implementação de uma estrutura de *compliance* adequada, na qual sejam assegurados os recursos necessários para sua efetividade, o que inclui a disponibilidade de profissionais qualificados e treinados. Além disso, a alta administração deve participar ativamente da supervisão do programa de *compliance*, mantendo-se informada sobre os pontos de atenção identificados, de modo a assegurar que as decisões sobre o funcionamento e adequação dos programas de *compliance* não fiquem sujeitas àqueles que não possuem poderes para agir em nome da sociedade.

v) Autonomia e independência do setor de compliance

O estabelecimento de setor com poderes para supervisionar e executar as normas consubstanciadas no programa de *compliance* também consiste em elemento fundamental para garantir sua efetividade. Para tanto, deve-se assegurar ao setor autonomia e independência para implementar as políticas, procedimentos e controles adequados, o que inclui acesso aos recursos necessários para o desempenho dessa atividade e a possibilidade de tomar decisões sem que seja necessário consultar outras áreas.

Caso os responsáveis pelo setor de *compliance* não exerçam apenas essa função (o que pode não ser adequado para algumas sociedades de maior porte), deve-se garantir que a cumulação não obste o regular desempenho das atividades relacionadas ao programa de conformidade.

vi) Treinamentos periódicos

A eficácia de um programa de *compliance* depende do fornecimento do adequado treinamento aos funcionários, por meio do qual se permite a integral compreensão de todos os envolvidos do comportamento que deles se espera. Os treinamentos serão particularmente importantes naquelas áreas em que as normas legais aplicáveis não são tão claras ou em que a inexistência de regulação estatal acaba deixando margem para a exposição da empresa a riscos mais acentuados.

Deve-se observar o emprego de expressões claras e didáticas, observando-se o público-alvo do treinamento. É ideal que sejam segregados os funcionários de acordo com as áreas de risco a que estão sujeitos e ao setor a que pertencem – de modo a permitir abordar as especificidades de cada um sem que se deixe de lado a essência do programa. Assim como o programa, para ser efetivo, demanda construção direcionada para as particularidades de cada pessoa jurídica, também os treinamentos podem se revelar mais adequados se adaptados aos funcionários de cada setor e nível de especialidade, em atenção às especificidades de linguagem que, por vezes, caracterizam setores específicos.

De todo modo, os treinamentos devem ser constantes, tanto para garantir a transmissão de adaptações e alterações no programa como para reiterar suas premissas e contribuir para minimizar o risco de esquecimentos e incompreensões pelo funcionário.

vii) Criação de uma cultura corporativa de respeito à ética e às leis

A despeito da realização de pormenorizada análise de riscos e da implementação de programa de *compliance* que atenda a todos os elementos anteriormente narrados, é possível que não se consiga alcançar todas as exposições a que está sujeita a sociedade. Daí afirmar-se que a instituição de uma cultura de *compliance* – isto é, que as ações dentro da organização sejam sempre direcionadas no sentido da observância das normas legais – é particularmente importante para garantir que a conduta corporativa e o cumprimento da lei sejam indissociáveis.

No caso da LGPD, esse aspecto é particularmente importante, porque a sua efetiva implementação exige uma própria mudança de cultura, a fim de reconhecer que a titularidade e o controle dos dados pertencem aos respectivos titulares, de forma que as práticas empresariais deverão ser reestruturadas com esse propósito.

viii) Monitoramento constante dos controles e processos, inclusive para fins de atualização do programa

Para que seja possível alcançar o principal objetivo do programa de *compliance* – a prevenção de ilícitos – é fundamental que haja o monitoramento contínuo, para checar se seus destinatários estão efetivamente cumprindo o previsto no programa. A partir dessa vigília, observar-se-á também se há a adequada reação às falhas e violações legais, bem como eventuais pontos e/ou setores que precisam ser reforçados ou revistos por causar distúrbios à cultura corporativa. O emprego do resultado dessa vigilância na constante atualização e aprimoramento do programa de *compliance* indica o compromisso da pessoa jurídica com o cumprimento da lei – quanto mais célere a mudança, maior o comprometimento.

Esse monitoramento deve ser efetivamente comprovado, ainda que não decorra dele a identificação de novas situações de risco ou a prática de ilícitos. É necessário, ainda, que os resultados de tal vigilância repercutam de forma prática nas normas internas, a demonstrar que se trata de verdadeiro compromisso da pessoa jurídica.

Os resultados do monitoramento devem ser utilizados para revisão do programa sempre que isso se mostrar necessário. Outra peculiaridade do *compliance* de dados é que certamente precisará de atualizações conforme evolua o estado das tecnologias utilizadas para a proteção de dados.

O monitoramento deve incluir também avaliação permanente dos parceiros comerciais e das práticas por eles adotadas. Deve-se certificar que os dados recebidos foram adequadamente coletados e tratados, bem como que os dados legitimamente compartilhados estão sendo cuidados nos termos da LGPD. A perspectiva vem inspirando normas regulamentares específicas, como, a título exemplificativo, a Resolução CMN 4.658/2018, que impõe às instituições financeiras o implemento e a manutenção de política de segurança cibernética “formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados” (art. 2º).

ix) Canais seguros e abertos de comunicação de infrações e mecanismos de proteção dos informantes

A existência de meio de comunicação especificamente direcionado para o cumprimento do programa de *compliance* afigura-se de suma importância, tanto para garantir que os funcionários poderão solicitar esclarecimentos e sanar dúvidas sobre comportamentos que pretendem adotar quanto para a promoção de denúncias. Tal mecanismo, por um lado, auxilia a difundir os comportamentos de conformidade e prevenir a ocorrência de ilícito (no que tange ao canal direcionado a dúvidas e questionamentos) e, por outro, facilita que as empresas tomem conhecimento dos atos ilícitos, permitindo que adotem, prontamente, as medidas necessárias para prevenir e/ou para impedir que novas condutas semelhantes sejam praticadas.

Seu funcionamento, à evidência, depende das garantias que são oferecidas ao funcionário, sendo fundamental a confiança de que não será prejudicado por recorrer ao canal e que sua manifestação, especialmente no segundo cenário, será mantida permanentemente sob sigilo. Para que se evite o emprego malicioso de tais canais, é necessário instruir os funcionários, sem que isso represente desestímulo. É salutar também estabelecer procedimentos a serem adotados no caso de recebimento de denúncia para identificar aquelas que não possuem plausibilidade.

A construção de canal de comunicação confiável é o primeiro passo, devendo, ainda, ser acompanhado de atuação imediata da entidade sempre que o canal for acionado – seja para identificar que não há sequer o mínimo de plausibilidade nas acusações, seja para se aprofundar na apuração dos fatos, aplicando, ao final, as medidas disciplinares cabíveis, caso fique constatada a prática da infração.

x) Detecção, apuração e punição de condutas contrárias ao programa de compliance

Como elemento final para a composição de um efetivo programa de *compliance*, deve-se assegurar rápida e adequada punição às condutas a ele contrárias. Uma vez identificado que, mesmo diante das regras e mecanismos de controle estabelecidos, ocorreu um ilícito, a reação adotada pela organização demonstra o grau de comprometimento com o cumprimento das normas. Além de viabilizar a detecção imediata do descumprimento, a entidade deve ser célere na determinação de procedimentos de adaptação e/ou reforço de suas normas, bem como aplicar as penalidades cabíveis ao infrator. Nesse ponto, é fundamental garantir, além da observância à legalidade nos procedimentos de investigação e julgamento, o tratamento igualitário a todos os envolvidos, a evitar que o programa perca sua credibilidade.

III. Compliance de dados pessoais

À luz das características centrais da LGPD (item I), do conceito de *compliance* (item II, a) e dos elementos de programas de *compliance* eficazes (item II, b), é possível identificar o papel de tal mecanismo na garantia do cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.

a) o papel do compliance na LGPD

Conforme exposto anteriormente, a LGPD representa a consolidação de relevante paradigma: atribuir a titularidade dos dados à pessoa natural a eles referente, conferindo-lhe extensa miríade de direitos para empreender efetivo controle sobre as suas informações. A LGPD implica novo marco regulatório – a ponto de se estruturar agência reguladora própria, a ANPD. A despeito da existência de normas anteriores que contemplavam perspectiva similar,³⁴ a prática em matéria de proteção de dados pessoais no Brasil ainda é muito distante dos comandos da nova lei.³⁵

O mercado tratava os dados coletados como ativo próprio, que poderia ser livremente utilizado e comercializado por quem deles se apropriasse. Agora, a perspectiva é inversa: os dados coletados continuam a pertencer às pessoas às quais se referem, de modo que o coletor dos dados deve prestar contas do uso que deles é feito. Prerrogativas, direitos e princípios contidos na LGPD se reconduzem a essa ideia básica: dever de prestar contas, já que o agente de tratamento de dados lida com bens alheios e de extrema relevância. Esse dever fundamentalmente é gratuito e envolve também a obrigação de retificar informações para que os dados reflitam a realidade e não obstem o exercício de direitos fundamentais da pessoa natural.

Em um cenário de mudanças tão robustas, o recurso ao estabelecimento de procedimentos de boas práticas pelos agentes econômicos privados torna-se passo fundamental para propiciar a adequação à nova realidade com alguma segurança.³⁶ O *compliance* de dados pessoais volta-se justamente para auxiliar os agentes de tratamento a aplicar de forma eficaz as normas de proteção de dados e “conduzirá a pessoa jurídica a manter esses dados e toda sua atividade dentro dos ditames legais, utilizando a segurança da informação em prol da minimização de incidentes que impliquem na responsabilidade empresarial”.³⁷

É possível apontar três fatores que contribuem para robustecer o papel dos mecanismos de *compliance* no âmbito da proteção de dados pessoais. Em primeiro lugar, o amplo escopo de incidência da LGPD (decorrência, como visto, do conceito de dado pessoal, de tratamento e de banco de dados) torna necessária a adaptação não apenas de atividades centralizadas na coleta e/ou tratamento de dados, mas também de qualquer operação que perpassse, ainda que indiretamente, a utilização de informações relacionadas ou relacionáveis a pessoas naturais. À luz do conceito de dado pessoal, até mesmo as mais simples atividades terão que se adequar à lei, uma vez que demandam, em alguma medida, o armazenamento de informações tuteladas pela lei – basta cogitar das informações atinentes aos empregados ou, ainda, das listas de clientes. Mesmo

operações laterais – como o que ocorre nos condomínios edifícios ao coletarem e armazenarem dados de condôminos, visitantes, funcionários – também se sujeitam à LGPD.

Nesse contexto, observa-se que o *compliance* de dados não se limita apenas ao relacionamento com consumidores, mas acaba por repercutir em várias esferas da atividade empresarial, a demandar adaptação também de setores que, inicialmente, não estariam diretamente relacionados com a LGPD. O *compliance* de dados assume caráter transversal, a tornar necessário rever os padrões de conduta estabelecidos para o cumprimento de outras normas. Remeta-se, mais uma vez, à relação de trabalho: as regras de conformidade adotadas nesse setor deverão ser atualizadas para contemplar também os preceitos da LGPD, evitando-se, por exemplo, a coleta de dados desnecessários ou cujo emprego possa ser considerado discriminatório.

O segundo fator está associado ao primeiro: uma vez que são diversas as entidades que deverão cumprir os preceitos da LGPD, há, dentro de cada comando da lei, níveis de exigência distintos e adaptações necessárias à luz das hipóteses de tratamento de dados envolvidas,³⁸ até mesmo com vistas a evitar que a proteção termine por inviabilizar a exploração econômica de certas atividades.³⁹

A proteção de dados não tem por objetivo inviabilizar a coleta de dados para conhecimento do público-alvo e aprimoramento das atividades empresariais. Todo empresário tem legítimo interesse de conhecer quem são seus consumidores, empregados e candidatos a emprego. Entretanto, a LGPD esclarece que os dados coletados para essa finalidade legítima pertencem às pessoas físicas às quais os dados se referem e precisam ser tratados e coletados em respeito a essa relação de pertencimento.

Nessa direção, importante papel pode ser assumido pelas entidades de classe, também autorizadas pelo art. 50 a formularem regras de boas práticas, na medida em que, conhecedoras das especificidades da atividade, podem contribuir para o estabelecimento de critérios adequados à cada hipótese, para além de traduzir os preceitos legais em ações concretas a serem tomadas pelos agentes econômicos.⁴⁰ Esses, a seu turno, beneficiar-se-iam da segurança decorrente da (adequada) estruturação de normas de governança fixadas pela entidade, capaz de sugerir uniformização dos padrões aplicáveis àquele mercado. A efetiva atribuição de valor a esses parâmetros por terceiros (incluindo-se a ANPD e o Poder Judiciário) é essencial para que se construa a segurança com eles pretendida.

Por fim, um terceiro fator consiste na necessidade de conferir concretude a alguns preceitos empregados pela LGPD e, assim, permitir que sejam adotados comportamentos em conformidade com a lei. Como consequência do (necessário) recurso a cláusulas gerais pelo legislador,⁴¹ muitos dos comandos legais comportam significativa margem interpretativa. É o caso, por exemplo, do conceito de “legítimo interesse do controlador” (empregado no artigo 7º, inciso IX, como hipótese autorizativa para o tratamento de dados);⁴² muito embora o artigo 10 tenha procurado delimitar seu conteúdo e o art. 37, a seu turno, recrudescer o controle sob as operações realizadas com base em tal exceção ao consentimento, verifica-se margem de discricionariedade cuja avaliação, no comum dos casos, será feita *a posteriori* pelos órgãos competentes. Abre-se, assim, mais um espaço de complementação a ser realizada pelos programas de *compliance*. Em observância dos deveres de transparência exigidos pela LGPD – no que concerne ao legítimo interesse, bastante reforçado – as regras de governança podem dispor sobre as hipóteses específicas em que o tratamento será considerado pela entidade como fundamentado no seu legítimo interesse.⁴³

Todos esses elementos corroboram a extrema relevância de se estabelecerem normas de governança no âmbito do tratamento de dados pessoais que sejam bem estruturadas e atendam aos comandos legais. Apenas a partir da concreta identificação das necessidades específicas de adaptação de cada agente será possível garantir a conformidade com a nova legislação.

b) as diretrizes dos programas de compliance na LGPD

Dúvidas não há, diante do cenário de mudança já delineado no presente artigo, de que a atuação em conformidade com a LGPD demandará a estruturação de mecanismos (técnicos e organizacionais) robustos direcionados exclusivamente a assegurar o respeito à legalidade no tratamento de dados pessoais. Além de garantir a conformidade com as demais normas da LGPD, os agentes de tratamento devem construir estruturas que permitam o atendimento a diversos outros deveres específicos, associados a boas práticas corporativas. É o caso (i) do dever de manter registro de todas as atividades de tratamento realizadas (art. 37); (ii) da apresentação, pelo controlador, quando requisitado, de relatório de impacto à proteção de dados pessoais (art. 38); (iii) da observância, por ambos os agentes de tratamento, das normas de segurança (art. 46) – que, se não comprovadas, induzem à sua automática responsabilização (art. 44, parágrafo único); e, ainda, (iv) da comprovação da efetividade do programa de governança em privacidade adotado, nos termos do art. 50, §2º, inciso II.

Identificar quais medidas organizacionais e técnicas deverão ser adotadas na construção de um programa de *compliance* de dados pessoais não consiste em tarefa simples e, na ausência de outros parâmetros,⁴⁴ parece adequado recorrer às orientações extraídas da própria LGPD, bem como às bases previamente estabelecidas em áreas, como a legislação antitruste e anticorrupção, em que se debatem os requisitos de programas de *compliance* efetivos.

Considerando as matrizes principiológicas da LGPD, um dos pontos mais relevantes que deve ser observado na estrutura técnica e organizacional implementada é garantir o cumprimento de todos os direitos dos titulares dos dados previstos no art. 18. A viabilização desses direitos, em conjunto com a concretização dos fundamentos (art. 2º) e princípios (art. 7º) enumerados pela norma consiste no eixo orientativo para a definição dos mecanismos a serem adotados pela pessoa jurídica.

Quanto ao primeiro, ao se esmiuçarem os elementos básicos de regras de boas práticas corporativas (item II, b), observou-se que, em linhas gerais, bons programas de *compliance* baseiam-se na correta identificação dos riscos e implementação de procedimentos que a eles respondam adequada e proporcionalmente; na reavaliação periódica dos riscos, com o implemento de adaptações; no comprometimento da alta administração; na capacidade de a organização identificar e agir para minimizar os riscos; e no estabelecimento de eficientes canais de comunicação (internos e externos).

O primeiro passo na construção de programa de *compliance* de proteção de dados efetivo perpassa, como não poderia deixar de ser, a *identificação dos riscos* relacionados à atividade do agente de tratamento.

Para tanto, deve-se procurar ter integral ciência do fluxo de dados existente na organização, o que pode até mesmo demandar, a depender da complexidade e do tamanho da pessoa jurídica, bem como da quantidade de dados tratados, a realização de auditoria específica. O importante, de todo modo, é mapear todo o ciclo dos dados e suas principais características,⁴⁵ já que são inúmeros os fatores que podem influenciar no nível de risco – notadamente a característica dos dados tratados, a forma como são coletados, utilizados e armazenados, bem como a destinação que lhes é conferida. Nessa direção, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, na medida em que possui como conteúdo mínimo exatamente tais elementos (art. 38), funciona como valiosa ferramenta de *compliance*,⁴⁶ sendo recomendável que se efetue tal procedimento, ainda que não seja mandatário.

Em apertada síntese, será necessário avaliar (i) em que momentos há a utilização de dados pessoais; (ii) que dados são esses; (iii) como e por quem esses dados foram coletados; (iv) como a utilização desses dados se relaciona com a atividade desenvolvida; (v) o que ocorre com esses dados, uma vez que ingressam e, por fim, (vi) se e como saem do controle da organização.

Para garantir o sucesso do passo seguinte – a definição das condutas que devem ser observadas no tratamento de dados – a avaliação deve ser o mais completa e abrangente possível. Afinal, o tratamento de dados sensíveis requer a observância de condutas mais rígidas para a mitigação dos riscos, diversas das existentes no tratamento de dados não sensíveis;⁴⁷ do mesmo modo ocorre com a utilização de dados de crianças e adolescentes, regulamentada especificamente no art. 14. Igualmente relevante é a hipótese autorizativa do tratamento empreendido: enquanto as hipóteses que dependem do consentimento do titular implicam espécie de procedimento (obtenção regular, comprovada e por escrito do consentimento), as demais bases legais, muito embora não demandem esses elementos, requerem condutas diversas (como a comprovação do dever regulatório que justifica o tratamento, na hipótese do inciso II do art. 7º).⁴⁸

Outro importante risco que deve ser abordado no programa de *compliance* consiste em garantir que o sistema de tratamento permitirá o pleno exercício dos direitos dos titulares. Ou seja, deve-se investigar se os dados são acessíveis pelos titulares, se a tecnologia empregada permite o efetivo apagamento, se é possível identificar a totalidade dos dados de uma mesma pessoa tratados dentro da entidade.

Os riscos envolvidos no tratamento de dados pessoais tornam-se mais robustos quanto maior for a quantidade de dados tratados, notadamente considerando-se que, nos termos do art. 44, há tratamento irregular quando não for observada a LGPD ou quando não se forneça a segurança esperada no tratamento. Também sob a perspectiva da organização, o princípio da necessidade – tratar apenas os dados essenciais para a finalidade que legitimou o tratamento – auxilia na minoração da exposição. Dito de outro modo, é necessário avaliar se os dados tratados são efetivamente essenciais para a atividade empresarial.

Identificar a que título se realiza o tratamento dos dados – como operador ou como controlador – é outro elemento de elevada importância, já que a LGPD atribui muito mais deveres ao controlador. Até mesmo no momento em que se volta às regras corporativas a lei as segmenta em “regras de boas práticas e de governança” – previstas no *caput* do art. 50 – e o “programa de governança em privacidade” – previsto exclusivamente para os controladores no § 2º, I. Enquanto o primeiro parece preocupar-se mais com os aspectos operacionais do processo de tratamento dos dados, de modo a servir como instrumento de definição dos padrões técnicos e dos mecanismos em que se estruturarão o sistema a ser empregado; ao segundo foi conferido escopo mais amplo (como sói acontecer na elaboração das normas de governança corporativa), cogitando-se também das garantias aos titulares dos dados.⁴⁹ Em qualquer dos casos, ressalta-se no *caput*, no § 1º e no §2º o fator risco é primordial.

A avaliação dos riscos envolvidos, como já ressaltado no item II, deve ser continuamente atualizada. A LGPD determina que antes do início de qualquer nova operação de tratamento, sejam, à luz dos riscos levantados, implementadas as medidas necessárias para a garantia da conformidade com as normas de proteção de dados.⁵⁰

A partir da identificação dos riscos, as entidades poderão voltar-se à elaboração de documentos corporativos – *Código de Conduta (e/ou de Boas Práticas)* – para especificar detalhadamente os procedimentos a serem adotados pela pessoa jurídica no tratamento de dados. Podem contar também com as instruções gerais e valores que devem guiar os funcionários e a alta administração nas decisões que envolvam o tratamento de dados pessoais, a incorporar condutas que traduzam sua política de privacidade.⁵¹ O art. 50, *caput*, enumera como requisitos mínimos a serem observados pelo operador o estabelecimento de condições de organização, do regime de funcionamento, dos procedimentos (inclusive de reclamações e petições de titulares), das normas de segurança, dos padrões técnicos, das obrigações específicas para todos os envolvidos, das ações educativas a serem empreendidas, dos mecanismos de supervisão e de mitigação de riscos.

O controlador, a seu turno, além dos elementos apresentados, pode formular programa de governança em privacidade. A LGPD determina que tal instrumento deve demonstrar o efetivo comprometimento com a observância das normas de proteção de dados pessoais (art. 50, § 2º, inciso I, a). Assim, o Código de Conduta deve explicitar quais dados podem ser coletados ou tratados, em quais hipóteses e para que finalidades. Impõe-se que preveja pormenorizada e concretamente os comportamentos que devem ser adotados para cada hipótese de tratamento, ressaltando passo a passo os procedimentos a serem realizados. Por exemplo, no caso de tratamento com base no consentimento do titular, o código deve guiar os funcionários, determinando a obtenção de consentimento nos moldes dos arts. 8º e 9º, bem como assegurando-se que o tratamento se limitará à finalidade para a qual se destina. Os documentos devem estabelecer mecanismos de alerta para as hipóteses mais sensíveis de tratamento, ou seja, aquelas em que há mais risco para o titular, permitindo aos funcionários identificar quais são essas hipóteses, bem como demonstrando cuidado intensificado nesses casos.

Afigura-se importante, ainda, que oriente os funcionários no sentido de sempre revelarem a realização da coleta dos dados – e de seu tratamento – e que ela seja realizada apenas quando necessário, bem como recomendar o período de armazenamento autorizado – além da forma que tal guarda deverá ser realizada. Se possível, é interessante estabelecer quais funcionários estão autorizados a realizar coleta e tratamento de dados, bem como segmentar que funcionários podem acessar que espécie de informações.⁵²

Também devem indicar a necessidade de manter registro de todo tratamento empreendido, com especial destaque no caso de operações justificadas com base no interesse legítimo do controlador – que devem contemplar informações ainda mais detalhadas. Ademais, é interessante que destaque as hipóteses em que o compartilhamento de dados é permitido, bem como os requisitos de tal compartilhamento.

Além de se destinar à orientação de seus funcionários, como visto anteriormente, o Código de Conduta configura instrumento balizador da relação da entidade com terceiros. Nesse sentido, pode-se prever os requisitos necessários que devem ser atendidos para a contratação de agentes de tratamento – tais como cláusulas-padrão, a necessidade de prévia certificação ou adoção de política de governança como requisito para a celebração de contratos.

Outra relevante perspectiva refere-se ao relacionamento com o titular dos dados. A LGPD reitera em inúmeras passagens a valorização da transparência, inclusive mediante estímulo da participação ativa dos titulares. É o caso, por exemplo, do artigo 51 – que destaca a valorização, pela ANPD, de técnicas que facilitem o controle pelos titulares – e, ainda, do art. 50, § 2º, inciso I, alínea e – ao prever que um dos requisitos do programa de governança em privacidade deve ter como objetivo “[...] estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular”. É importante elemento na avaliação das normas corporativas a busca por assegurar ao titular dos dados de que seus direitos são respeitados e que exerce influência nas decisões tomadas a seu respeito, observadas as peculiaridades da atividade desempenhada.

Nessa direção, recomenda-se que o Código de Conduta – ou outro instrumento corporativo destinado à divulgação ao público (como a política de privacidade) indique as escolhas da pessoa jurídica em termos de coleta e tratamento de dados, ainda que com base em princípios orientadores, bem como enumere de forma clara e transparente as cautelas adotadas para a proteção do dado, os procedimentos assumidos no caso de eventual brecha (quais as ocasiões em que os titulares são notificados, por exemplo), as medidas tomadas para eventual recuperação de dados perdidos. Do mesmo modo afigura-se essencial que se transmita com máxima clareza todas as opções do titular quanto a eventuais dados coletados nos serviços prestados e qual o emprego lhes será dado.⁵³ É salutar que se descrevam as formas por meio das quais os titulares poderão exercer os direitos garantidos pela LGPD e que se garanta a qualidade do dado,⁵⁴ além de constar a indicação clara, expressa e destacada a respeito do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. A participação do titular deverá influenciar na valoração positiva das normas de *compliance* pela ANPD, de modo que o envolvimento da sociedade civil na própria construção das normas corporativas e revisão da política de privacidade pode ser um relevante indício da robustez do programa.⁵⁵ À evidência, deve-se ponderar quais medidas podem ser implementadas sem prejuízo do regular desempenho da atividade.

A adoção de normas corporativas globais – como a adesão a códigos de conduta publicados pela Comissão Europeia nos termos do art. 40º, 10 – pode se revelar interessante para as pessoas jurídicas que possuam relacionamento com parceiros estrangeiros e/ou realizem transferência internacional de dados. A LGPD indica que tal adoção – que, no âmbito do Regulamento Europeu, vem acompanhada de monitoramento pelo órgão competente – é uma forma de garantir e comprovar o “cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nessa Lei”, a denotar seu enorme potencial, até mesmo no que tange a eventual exoneração de responsabilidade dos agentes de tratamento mediante demonstração de que não houve tratamento ilícito. O recurso a certificações e selos por entidades especializadas e independentes pode servir como comprovação da efetividade das normas corporativas.⁵⁶

Também no *compliance* de dados pessoais o estabelecimento de *organização compatível com o risco da atividade* é elemento fundamental da robustez do programa, conforme estabelece o art. 50, § 2º, inciso I, c. Cuida-se de assegurar que a estrutura corporativa será capaz de cumprir as determinações legais (manutenção do registro das operações, elaboração de relatório de impacto etc.) mediante a adoção de procedimentos especificamente desenhados para as hipóteses de tratamento. Inserem-se aqui o estabelecimento de estruturas técnicas que assegurem que

os sistemas de informação sejam estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, confidencialidade e integridade dos dados armazenados, oferecendo, sempre que possível e conforme o caso, mecanismos de proteção previamente instalados contra os riscos do processamento de dados pessoais.⁵⁷

A estrutura adotada pelo controlador deve garantir, ademais, a aplicação uniforme das regras de governança em privacidade para “todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta” (art. 50, § 2º, inciso I, b).

Outro relevante elemento, na esteira do apontado no item II, b, do presente artigo, consiste no efetivo *envolvimento da alta administração*. Consoante destaca a ICO – *Information Commissioner’s Office*, a autoridade independente de proteção de dados do Reino Unido – o programa deve garantir que as pessoas centrais da organização estejam envolvidas na implementação das práticas de conformidade.⁵⁸ Os administradores devem, portanto, tomar a frente do processo de adaptação e participar intensamente na definição dos riscos envolvidos, empenhando-se na construção de *cultura corporativa* de respeito à LGPD.

Como não poderia deixar de ser, o estabelecimento de *setor* direcionado ao exercício da função de *compliance* contribui para a efetividade do programa de proteção de dados. A LGPD orienta os controladores a inserirem as políticas de governança em privacidade em sua estrutura geral de *compliance*, com a previsão de mecanismos de supervisão internos e externos (art. 50, § 2º, inciso I, f). A indicação de membro da alta administração como responsável pelo setor de *compliance* (*o compliance officer ou chief compliance officer*), com atribuição para controlar e supervisionar o dia a dia do programa,⁵⁹ o que inclui constante monitoramento e a implementação das políticas necessárias para garantir o sucesso do programa (com autonomia para tomar decisões e realizar investigações), consiste em elemento que confere robustez ao programa. Recomenda-se, ainda, que se garanta um canal de comunicação direto entre o *compliance officer* e os órgãos de administração da companhia e, sempre que possível, sua independência dos demais setores. Especificamente no que tange à LGPD, caberá ao *compliance officer* garantir a observância dos parâmetros legais no tratamento de dados, buscando constante aprimoramento em segurança de dados, procurando manter a companhia conectada com os últimos desenvolvimentos tecnológicos do setor.

À evidência, tais medidas devem ser sopesadas diante dos custos e de sua viabilidade para a manutenção da atividade econômica. Também se afigura importante estratégia para a construção de uma cultura corporativa de cumprimento da LGPD o fomento à implementação de processos que garantam desde a concepção a proteção dos dados pessoais (*privacy by design*), além do estabelecimento de exigências de conformidade com a LGPD na definição dos parceiros comerciais.

Uma vez mais é necessário compatibilizar a estrutura a ser implementada com os riscos envolvidos: caso o diagnóstico empreendido resulte em elevado perigo para a entidade, recomenda-se a contratação de profissional externo, com independência – sem prejuízo da implementação de outros controles internos. Nessa direção, a LGPD (art. 41) torna, a princípio, impositiva a identificação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, cujas funções, além de servir de canal de comunicação entre o titular e o agente de tratamento, abrangem também o esclarecimento dos funcionários a respeito das normas de proteção de dados. Ainda que tal mecanismo venha a se tornar opcional,⁶⁰ como autoriza o § 3º, deve ser considerado pelas pessoas jurídicas diante de seu potencial na construção de práticas conformes à LGPD, uma vez que representará a implementação de *canal de comunicação*, tanto *interno*, para fins de esclarecimentos sobre as condutas a serem adotadas no caso concreto, como *externo*, isto é, direcionado ao titular do dado, concentrando as requisições por ele realizadas, analisando a pertinência dos pedidos, instruindo os funcionários sobre como proceder, bem como garantindo o respeito aos ritos e prazos previstos na LGPD. Ademais, diante da abrangência do inciso IV, nada impede que sua função seja robustecida, permitindo-lhe estabelecer constante vigilância sobre as operações de tratamento de dados.⁶¹

Tal canal de comunicação (externo) deve assumir, ainda, postura proativa, no sentido de buscar transmitir ativamente ao titular dos dados as informações contempladas nos arts. 9º, § 1º, e 8º, § 6º – alteração dos elementos nos quais se baseou o consentimento/tratamento.

O programa deve prever, ainda, a promoção constante de *treinamentos* para orientar seus funcionários a respeito das práticas de governança na proteção de dados pessoais. É especialmente sensível a realização de robusto treinamento nos funcionários que trabalham com tecnologia da informação, que devem estar cientes dos elevados requisitos de segurança contemplados na lei (art. 46) e da necessidade de aprimoramento constante dos sistemas diante de falhas – ocorridas interna ou externamente.

A relevância da garantia da segurança dos dados, inclusive, reflete-se na ainda maior importância que o *monitoramento* exerce no programa de *compliance* de dados pessoais. Determina-se que o programa de governança seja continuamente monitorado e atualizado com informações daí decorrentes (art. 50, I, alínea *h*), com o estabelecimento de “salvaguardas adequadas” em decorrência de “avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade” (art. 50, I, alínea *d*). Na fixação desses mecanismos de salvaguarda, deve ser considerado o emprego de técnica capaz de tornar os dados indecifráveis a terceiros (prática recomendada no art. 48, § 3º). Uma vez mais, o recurso ao relatório de impacto previsto no art. 38 da LGPD e, ainda, a submissão do sistema à avaliação por auditoria externa independente e especializada podem se revelar práticas bastante recomendáveis.

Por fim, estabelece o art. 50, § 2º, I, *g*, que o programa de governança em privacidade deve contar com “planos de resposta a incidentes e remediação”, ou seja, deve prever instrumentos de *detecção e remediação das condutas incompatíveis com (o programa e) a LGPD*. O mecanismo deve contemplar a comunicação tempestiva à ANPD (art. 48)⁶² nos casos em que o incidente de segurança “[...] possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares”, nos moldes requisitados pelo § 1º: identificando a natureza dos dados, os titulares afetados, quais as medidas tomadas para a proteção dos dados, os riscos decorrentes do incidente, as medidas de reversão ou mitigação dos danos e, se for o caso, porque a comunicação não foi imediata. Além de identificar a verificação de conduta de não conformidade, o programa deve apresentar mecanismos de apuração dos responsáveis e sua adequada punição.

Por fim, há um outro importante aspecto dos programas de *compliance* de dados, que diz respeito à *regulação pela tecnologia*. Isso porque, embora se saiba que a LGPD se estende a qualquer tipo de tratamento de dados, seus maiores desafios relacionam-se precisamente ao ciberespaço, onde acaba se deparando com as dificuldades naturais que o meio digital apresenta para a eficácia de instrumentos tradicionais de regulação jurídica.

Como aponta Lawrence Lessig,⁶³ o papel da arquitetura, ou seja, do código, é fundamental para a regulação jurídica do ciberespaço, pois de nada adianta que a lei e outras formas de regulação, como os programas de *compliance*, contemplem determinadas regras se a arquitetura pode torná-las ineficazes ou mesmo levar a resultados opostos.

Daí a necessidade de que os programas de *compliance* de dados não se limitem apenas à previsão de princípios ou regras de comportamento, mas visem também à adoção de tecnologias que possam ser compatíveis com a eficácia de tais regras. É essa uma das principais preocupações decorrentes da ideia de *privacy by design*, em que a escolha da tecnologia utilizada na oferta de produtos e serviços é pensada, desde o início, para a proteção dos dados pessoais.

Logo, a escolha da tecnologia passa a ser um ponto fundamental para os programas de *compliance* de dados. É precisa a advertência de Bruno Bioni⁶⁴ no sentido de que há que se dar especial atenção às chamadas *privacy enhancing technologies* – PETs, a fim de que o titular dos dados, diante da sua hipervulnerabilidade, possa ser empoderado por meio da arquitetura da rede e de tecnologias amigáveis (*usable-friendly*) que possam assegurar o seu controle sobre os dados pessoais e as suas escolhas.

IV. À guisa de conclusão: complexidade, custos e necessidade de efetivo estímulo à adoção de programas de compliance de dados pessoais

Como se pode denotar das considerações anteriores, a implementação de efetivo programa de *compliance* em matéria de proteção de dados consiste em tarefa mais que desafiadora. Apenas se garantindo intensa colaboração de inúmeros setores das pessoas jurídicas – exemplificativamente, recursos humanos, tecnologia da informação, jurídico – e a construção de estruturas (até mesmo de *softwares*) capazes de atender a todos os rígidos padrões estabelecidos pela LGPD se poderá pavimentar caminho de conformidade com a norma. Os custos, por consequência, certamente serão significativos.⁶⁵ Daí a necessidade de se contrapor aos elevados gastos incentivos concretos à implantação dos mecanismos de governança.

À evidência, já é possível identificar algumas interessantes vantagens para os agentes econômicos:

A) a adoção de programas de *compliance* robustos, além de garantir o cumprimento das normas de proteção de dados, contribui para a construção de ambiente de confiança entre os titulares – essencial em um mundo em que o disseminado uso de dados pessoais aparenta ser processo irreversível – e representa diferencial competitivo;

B) a implementação de mecanismos de *compliance* também configura elemento de demonstração do tratamento regular dos dados pessoais pelo agente de tratamento – especialmente relevante para buscar (i) afastar sua responsabilidade com base no art. 43, inciso II; e/ou (ii) comprovar o cumprimento de determinados deveres cujo ônus da prova pode lhe ser imposto (arts. 8º, § 2º; e 42, § 2º);

C) diante do contexto atual – de mudanças contundentes, mas muita insegurança sobre quais serão os padrões aceitáveis pela ANPD –, alguns mecanismos podem garantir orientações e salvaguardas mínimas – como selos e certificados de entidades independentes, os quais podem ser também exigidos de parceiros comerciais;

D) o recurso à elaboração de códigos de conduta por associações – na esteira do procedimento europeu – pode se traduzir em relevante mecanismo de autorregulação regulada (notadamente se acompanhado do reconhecimento e da divulgação da ANPD, nos termos do art. 50 § 3º), a permitir que os setores se organizem para buscar implementar práticas mais adequadas às suas atividades; e

E) a adoção de boas práticas e governança consiste em critério (atenuante) no estabelecimento das sanções administrativas pela ANPD.

Este último ponto requer especial atenção. Para que as práticas de *compliance* sejam difundidas e estruturadas de maneira robusta – o que, ao fim e ao cabo, implicará vantagens não apenas para as sociedades, mas também para seus usuários – é fundamental que haja o efetivo estímulo,⁶⁶ também sob a perspectiva econômica (especificamente em como os investimentos na implementação dos programas de *compliance* refletem na atenuação de multa por eventual descumprimento) para sua implantação. Cuida-se de questão central a ser endereçada pela ANPD no exercício das competências que lhe foram conferidas pelos arts. 50, § 3º e 53 da LGPD. Ao fixar a metodologia da aplicação das sanções administrativas, o peso da adoção de boas práticas de governança corporativa deve ser efetivamente significativo, especialmente valorizando os programas que foram objeto de reconhecimento e publicização – devendo, a rigor, poder até mesmo representar a ausência de responsabilização da pessoa jurídica.⁶⁷

V. Referências

- BASRI, Carole Basri. Corporate compliance. Carolina Academic Press. Edição do Kindle, 2017.
- BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. A função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- BLUM, Renato M. S. Opice. GDPR – General Data Protection Regulation: destaques da regra europeia e seus reflexos no Brasil. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 107, n. 994, p. 205-221, ago. 2018.
- BLUM, Renato Opice; ZAMPERLIN, Emelyn. Compliance, responsabilidade empresarial e segurança da informação. *Lex Magister*. Disponível em: [https://www.lex.com.br/doutrina_27159943_COMPLIANCE_RESPONSABILIDADE_EMPRESARIAL_E_SEGURANCA_DA_INFOR]. Acesso em: 20.05.2020.
- CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 13, p. 59-67, out-dez. 2017.
- CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Funções e finalidades dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
- DONEDA, Danilo Doneda. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar. 2006.
- DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. Reflexões Iniciais sobre a Nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, p. 469-483, nov.-dez. 2018.
- FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: principais repercussões para a atividade empresarial. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018]. Acesso em: 20.05.2020.
- FRAZÃO, Ana. Programas de *compliance* e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas por ilícitos administrativos. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. *Governança corporativa: avanços e retrocessos*. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
- FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez. Desafios para a efetividade dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
- FRAZÃO, Ana. Dever de diligência: Novas perspectivas em face de programas de *compliance* e de atingimento de metas. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/dever-de-diligencia-15022017]. Acesso em: 20.05.2020.
- FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. Corrupção, cultura e *compliance*: o papel das normas jurídicas na construção de uma cultura de respeito ao ordenamento. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. Compliance:

perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

HIRSH, Dennis D. Going dutch? Collaborative dutch privacy regulation and the lessons it holds for U.S. privacy law. *Michigan State Law Review*, v. 2013:1, p. 83-166. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2393707]. Acesso em: 20.05.2020.

LESSIG, Lawrence. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

MARTINEZ, Maria Beatriz Martinez. Programas de *compliance* e a defesa da concorrência: perspectivas para o Brasil. *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional*, v. 12, p. 153-178, jan. 2015.

MENDES, Laura Schertel Ferreira. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*: linhas gerais de um novo direito fundamental (Série IDP: linha pesquisa acadêmica), São Paulo: Saraiva, 2014.

OLIVA, Milena Donato; SILVA, Rodrigo da Guia. Origem e evolução histórica do *compliance* no direito brasileiro. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar. 2008.

ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. *Information technology law*. 5. ed. Taylor & Francis, 2016.

SANTOS, Fabiola Meira de Almeida; TALIBA, Rita. Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, p. 225-239, dez. 2018.

TEPEDINO, Gustavo. Direitos humanos e relações jurídicas privadas. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

1

.Professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília – UnB. Advogada.

2

.Professora de Direito Civil e do Consumidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogada.

3

.Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogada.

4

“Daí, a proteção de dados contribui para a ‘constitucionalização da pessoa’ – o que pode ser considerado como uma das mais significativas conquistas, e não apenas da Carta. Estamos diante da verdadeira reinvenção da proteção de dados – não somente porque ela é expressamente considerada como um direito fundamental autônomo, mas também porque se tornou uma ferramenta essencial para o livre desenvolvimento da personalidade. A proteção de dados pode ser vista como a soma de um conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo milênio” (RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 17).

5

A expressão traduz os elementos da gestão dos dados pessoais. Como, uma vez mais, explicita Rodotà, abrange tanto o controle da utilização dos dados pessoais por terceiros como a capacidade de determinar a visão de si próprio, do seu “corpo eletrônico” (v., entre outras passagens na obra anteriormente citada, p. 92-93). Remeta-se, ainda, às palavras de Danilo Doneda: “Uma esfera privada, na qual a pessoa tenha condições de desenvolvimento da própria personalidade, livre de ingerências externas, ganha hoje ainda mais em importância; passa a ser um pressuposto para que ela não seja submetida a formas de controle social que, em última análise, anulariam sua individualidade, cerceariam sua autonomia privada (para tocar em um conceito caro ao direito privado) e, em última análise, inviabilizariam o livre desenvolvimento de sua personalidade” (DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 142).

6

“a Lei Geral de Proteção de Dados deixa claro que pretende proteger o usuário-cidadão plenamente, em todos os aspectos da sua autonomia pública e privada, valorizando e preservando sua autodeterminação informativa e sua capacidade decisória. Trata-se, portanto, de eixo valorativo em torno do qual devem ser compreendidas e interpretadas todas as demais disposições previstas pela lei” (FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: principais repercussões para a atividade empresarial. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018]. Acesso em: 20.05.2020).

7

“Os milhares de registros eletrônicos gerados em catracas automatizadas, pedágios eletrônicos, câmeras, aparelhos de GPS, eletrodomésticos (a “internet das coisas”), bem como inúmeras outras transações diariamente mediadas pela informática com técnicas avançadas de análise (“big data”, por exemplo), deixam claro que o tratamento desarrazoado de dados pessoais pode fomentar a criação de pequenos Leviatãs, cujo potencial ofensivo à vida privada e à dignidade humana pode se igualar ou até mesmo exceder aquele representado pelo Estado” (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. A insuficiente proteção de dados pessoais no Brasil. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 13, out-dez. 2017, consultado por meio da plataforma Revista dos Tribunais On-line. p. 3).

8

Dúvidas não há de que a LGPD consolidou a perspectiva de que os dados pertencem ao indivíduo ao qual estão relacionados, como se extrai do art. 17, *in verbis*: “Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei”.

9

“O direito ao respeito da vida privada e familiar reflete, primeira e principalmente, um componente individualista: este poder basicamente consiste em impedir a interferência na vida privada e familiar de uma pessoa. Em outras palavras, é um tipo de proteção estático, negativo. Contrariamente, a proteção de dados estabelece a legitimidade para a tomada de medidas – i.e. é um tipo de proteção dinâmico, que segue o dado em todos os seus movimentos. Adicionalmente, a supervisão e outros poderes não são somente às pessoas interessadas (os sujeitos dos dados), mas são também entregues a uma autoridade independente (artigo 8.3)” (RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. p. 17).

“O terceiro eixo da LGPD é composto pelos princípios e direitos do titular. O estabelecimento de uma série de princípios de proteção de dados e de direitos do titular dos dados pela Lei procura garantir, por um lado, um arcabouço de instrumentos que proporcionem ao cidadão meios para o efetivo controle do uso de seus dados por terceiros” (DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. Reflexões Iniciais sobre a Nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. Consultado por meio da plataforma Revista dos Tribunais *On-line*. p. 3).

A definição aproxima-se da prevista na Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011), cujo art. 3º, § 3º, II estabelece o conceito de “informações sensíveis” como “aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas”.

Conforme prevê o art. 46, *in verbis*: “Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”. Na esteira da regulamentação europeia (art. 25 do RGPD), o § 2º incorpora, ainda, o conceito de privacidade desde a concepção: “As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução”.

“Na era dos contratos de massa e na sociedade tecnológica, pouco eficazes mostram-se os mecanismos tradicionalmente empregados pelo direito civil, como a responsabilidade fundada na culpa, sendo indiscutíveis os riscos sociais decorrentes da atividade econômica, mais e mais sofisticada, impondo-se a busca de soluções indóle objetiva, preferencialmente preventivas, não meramente ressarcitórias, em defesa de uma melhor qualidade de vida e da realização da personalidade” (TEPEDINO, Gustavo. Direitos humanos e relações jurídicas privadas. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 65).

Com efeito, o cenário atual encontra-se significativamente distante do paradigma imposto pela LGPD. Como descreve Renato Opice Blum: “Na atualidade, informações absolutamente sensíveis, como as de saúde, por exemplo, são coletadas e tratadas sem maiores cautelas por muitas instituições, empresas e, inclusive, pelo Poder Público. Detalhes da vida pessoal registrados em fotos e vídeos nas Redes Sociais (como orientação religiosa, política ou sexual) podem estar sendo compartilhados entre empresas e tratados sem conhecimento de seus titulares. Daí serem cada vez mais frequentes as notícias e os escândalos sobre compartilhamento indevido, vazamento de dados e acesso ilegal à comunicação de dirigentes de Estados” (BLUM, Renato M. S. Opice. GDPR – General Data Protection Regulation: destaques da regra europeia e seus reflexos no Brasil. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 107, n. 994, ago. 2018, consulta pela plataforma Revista dos Tribunais *On-line*. p. 1).

Já se anotou a relevância dos programas de *compliance* sob esse viés: “Eis o potencial do *compliance* como mecanismo de atuação da função promocional do direito, em complemento da sua função repressiva” (OLIVA, Milena Donato; SILVA, Rodrigo da Guia. Origem e evolução histórica do *compliance* no direito brasileiro. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 47).

“A proteção dos dados pessoais, embora sempre fundamentada pelo preceito constitucional, deve valer-se de uma estratégia integrada na qual são utilizados diversos instrumentos de tutela, que representam manifestações específicas em diversas áreas de um mesmo direito. A maleabilidade e facilidade de adaptação a novos cenários e à inovação suscitados pela ação da tecnológica é uma característica de instrumentos mais “fracos”, como normas deontológicas, códigos de autorregulação e outros, das quais o direito deve se utilizar, especialmente quando os instrumentos tradicionais ao seu alcance podem se demonstrar demasiado lentos ou desproporcionais para uma tutela eficaz” (DONEDA, Danilo Doneda. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar. 2006. p. 409-410).

FRAZÃO, Ana. Programas de *compliance* e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas por ilícitos administrativos. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. *Governança corporativa: avanços e retrocessos*. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 42.

“Os programas de *compliance*, também chamados de programas de conformidade, de cumprimento ou de integridade, são instrumentos de governança corporativa tendentes a garantir que as políticas públicas sejam implantadas com maior eficiência” (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Funções e finalidades dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 53).

Consoante define Carole Basri: “*Compliance programs are formal systems of policies and procedures adopted by corporations and other organizations that are designed to detect and prevent violations of law by employees and other agents and to promote ethical business cultures*” (BASRI, Carole Basri. *Corporate compliance*. Carolina Academic Press. Edição do Kindle, 2017. p. 4).

Como já se ressaltou em doutrina: “no Brasil, assiste-se, progressivamente, à atribuição de efeitos jurídicos ao *compliance*, que é tratado na legislação como: (i) prática incentivada por meio da previsão legal de consequências favoráveis (v.g. dosimetria da pena) ou (ii) obrigação legal em sentido estrito (como no caso da imposição, pela legislação federal, da obrigatoriedade de as empresas estatais adotarem programas de *compliance*). Além disso, verifica-se uma gradual expansão, por parte da jurisprudência, da utilização da noção de *compliance* como parâmetro interpretativo para a resolução de questões mais variadas envolvendo a atividade empresarial” (OLIVA, Milena Donato; SILVA, Rodrigo da Guia. Origem e evolução histórica do *compliance* no direito brasileiro. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 33).

FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez., Desafios para a efetividade dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 75).

No âmbito da legislação Anticorrupção (Lei 12.846/2013, art. 7º), a adoção de programa efetivo de conformidade é considerada circunstância atenuante na fixação de sanções. O mesmo ocorre, mesmo na ausência de previsão legal, na seara Antitruste, conforme se extrai do Guia de Programas de *Compliance* do CADE.

ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. *Information technology law*. 5. ed. Taylor & Francis, 2016.

.FRAZÃO, Ana. Programas de *compliance* e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas por ilícitos administrativos. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. *Governança corporativa: avanços e retrocessos*. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 42.

25

“In essence, an effective compliance program can help insulate a company, and its officers, directors and employees from criminal and civil penalties; protect its officers and directors from personal liability; and create a culture of a “good citizen” corporation. In fact, an effective compliance program can be a mitigating factor even if it failed to prevent a criminal offense” (BASRI, Carole Basri. *Corporate compliance*. Carolina Academic Press. Edição do Kindle, 2017. p. 8-9).

26

.CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Funções e finalidades dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 61.

27

.Em tradução livre das ponderações de Carole Basri: “However, a poorly constructed compliance program can serve as a roadmap for prosecutors; damage employee morale; and encourage fraud and unethical conduct to continue. Moreover, a poorly constructed program lacking in sufficient leadership, funding and resources will create the view, among employees, that the code of conduct/ethics, and, indeed, the whole compliance program, is a sham” (BASRI, Carole Basri. *Corporate compliance*. Carolina Academic Press. Edição do Kindle, 2017. p. 9).

28

.Como já mencionado, o CADE desenvolveu orientações específicas sobre o tema no âmbito do Guia Programas de *Compliance*; por sua vez, o Decreto 8.420/2015 apresenta parâmetros de avaliação de programas de conformidade no que tange às normas Anticorrupção (art. 42).

29

.Na experiência britânica e norte-americana, identificam-se, respectivamente, o Guia do Governo sobre o *UK Bribery Act* e a *U.S. Sentencing Guidelines*.

30

.Estudo mais detalhado de tais elementos pode ser verificado em: FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez., Desafios para a efetividade dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 90-104.

31

.Maria Beatriz Martinez identifica tal primeiro passo com a “análise prévia das operações e da estrutura da empresa. Isso permite identificar os principais focos de potencial violação” (MARTINEZ, Maria Beatriz Martinez. Programas de *compliance* e a defesa da concorrência: perspectivas para o Brasil. *Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional*, v. 12, jan. 2015, consulta pela plataforma Revista dos Tribunais On-line. p. 2).

32

.Embora, em regra, ao discutir temas afetos ao *compliance*, costuma-se conferir maior ênfase à política anticorrupção e à política de defesa da concorrência, um programa de conformidade deve ser adotado sempre que verificado um risco razoável de violação à legislação e/ou da implementação de condutas antiéticas, estabelecendo valores e padrões de comportamento específicos para aquele setor.

33

“Consequentemente, o *compliance* reforça a dimensão organizacional do dever de diligência, a fim de que controladores e administradores estruturam a organização empresarial de forma compatível com as atividades da companhia e com o risco por ela assumido. Para isso, torna-se necessário criar adequados sistemas de vigilância, supervisão e investigação sobre as atividades da sociedade, de modo a assegurar o respeito às obrigações legais e possibilitar a intervenção adequada diante da identificação de problemas e ameaças. Não é sem razão que um aspecto fundamental dos programas de *compliance* é a necessidade de comprometimento da alta administração. Logo, é inequívoco o potencial do *compliance* para ampliar o núcleo básico do dever de diligência, abrindo margem para que, ao lado do dever de agir bem informado, acrescente-se igualmente a importante obrigação de instituir e manter uma organização idônea para lidar com o risco assumido, inclusive no que diz respeito à prevenção de ilícitos” (FRAZÃO, Ana. Dever de diligência: Novas perspectivas em face de programas de *compliance* e de atingimento de metas. Disponível em: [www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/dever-de-diligencia-15022017]. Acesso em: 20.05.2020).

34

.De fato, a LGPD aprofunda preceitos já extraídos de outros diplomas normativos (como o Marco Civil da Internet e a Lei do Cadastro Positivo), em especial diante da interpretação sistemática à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sua consolidação e, principalmente, o tratamento direto e específico de diversos pontos na LGPD auxiliam na intensificação da proteção dos dados pessoais, conferindo-lhes maior efetividade.

35

.Não muito tempo atrás, tornou-se notória a investigação promovida pelo MPDFT contra o site “Tudo sobre Todos”, que vendia acesso a dados pessoais que incluíam até mesmo o nome de vizinhos (conforme noticiado no jornal *O Globo*: [https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/ministerio-publico-investiga-venda-de-dados-pessoais-pelo-site-tudo-sobre-todos-22875842], acesso em 20.05.2020). Pense-se, ainda, na quantidade de dados solicitados para qualquer compra on-line, no mais das vezes desassociados com a própria operação realizada; ou, ainda, a ausência de informação sobre as práticas de privacidade e dados coletados nas páginas da internet.

36

.Como já se ressaltou, importante função das práticas de *compliance* vislumbra-se exatamente na “mudança de comportamento, por meio de padrões de conduta a serem observados e monitorados pelas empresas, administradores e funcionários, a fim de evitar o cometimento de ilícito” (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Funções e finalidades dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 54).

37

.BLUM, Renato Opice; ZAMPERLIN, Emelyn. Compliance, responsabilidade empresarial e segurança da informação. *Lex Magister*. Disponível em: [https://www.lex.com.br/doutrina_27159943_COMPLIANCE_RESPONSABILIDADE_EMPRESARIAL_E_SEGURANCA_DA_INFORMACAO.aspx]. Acesso em: 20.05.2020.

38

.Cuida-se de perspectiva contemplada no Considerando 98 do Regulamento Europeu: “(98) As associações ou outras entidades que representem categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontratantes deverão ser incentivadas a elaborar códigos de conduta, no respeito do presente regulamento, com vista a facilitar a sua aplicação efetiva, tendo em conta as características específicas do tratamento efetuado em determinados setores e as necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas. Esses códigos de conduta poderão nomeadamente regular as obrigações dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes, tendo em conta o risco que poderá resultar do tratamento dos dados no que diz respeito aos direitos e às liberdades das pessoas singulares”.

A LGPD, também atenta à questão, conferiu à ANPD competência para flexibilizar determinadas exigências à luz do tamanho do agente de tratamento – como no caso da indicação do encarregado (art. 41, § 3º).

39

. Interessante exemplo pode ser extraído do estudo realizado por Dennis D. Hirsch (Going dutch? Collaborative dutch privacy regulation and the lessons it holds for U.S. privacy law. *Michigan State Law Review*, v. 2013:1, p. 83-166. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2393707]. Acesso em: 20.05.2020). Com o objetivo de analisar a então recente proposta norte-americana do *Safe Harbor Act*, Hirsch debruçou-se sobre a experiência holandesa durante a primeira e a segunda geração de normas europeias sobre dados pessoais. Segundo descreve, a autoridade nacional holandesa (DPA) atribuiu aos representantes dos setores da economia a tarefa de especificar os termos empregados pela legislação, adaptando-lhes a cada atividade (p. 115-116). O processo resultou na aprovação (sob a perspectiva das leis que precederam o RGPD) de ao menos 20 (vinte) códigos de conduta pela DPA – aprovação que significava que as sociedades que seguiam tais códigos eram consideradas como em conformidade (p. 119).

Ao ponderar as vantagens e as desvantagens desse sistema, identifica como uma das primeiras a possibilidade de, ao final do processo de negociação, construir normas mais customizadas (*tailored*) e práticas (*workable*) – como ocorreu para os investigadores privados holandeses. A norma então em vigor impunha que houvesse a notificação prévia dos titulares dos dados sobre a coleta a ser realizada – o que, à evidência, inviabilizaria a continuidade da atividade investigativa, baseada na ausência de conhecimento da pessoa a quem se investiga (p. 135). A solução, prevista no Código de Conduta daquela atividade, foi notificar o titular após a investigação: “After the negotiation, the industry and the DPA agreed that investigators could notify the data subject after the investigation, rather than before, and memorialized this arrangement in the code. Assuming that investigators do provide such notice, this should enable the notification requirement to serve its intended purpose – i.e., allowing data subjects to exercise their rights of access and correction – without unduly harming the private investigator business” (p. 136).

40

.Essa é, inclusive, a orientação do regulamento europeu, que atribui às associações e a outros organismos de representação de categorias de controladores e operadores a faculdade de ampliar, emendar ou elaborar Código de Conduta especificando as previsões do RGPD (art. 40.(2)). Em seguida, a norma é avaliada pela autoridade competente – a depender da amplitude da atividade disciplinada no código no que tange aos estados-membros: se estiver limitado a um único, cabe à autoridade nacional daquele país aprová-lo, registrá-lo e conferir-lhe publicidade; se envolver mais de um estado-membro, a autoridade nacional deverá submeter o código ao comitê para que este confirme sua aderência ao Regulamento para, então, submetê-lo ao escrutínio da Comissão que poderá lhe conferir aplicabilidade geral (art. 40(5)-(10)).

41

.Aludida técnica legislativa, como expõe Pietro Perlingieri, permite deixar ao intérprete “uma maior possibilidade de adaptar a norma a situações de fato” (PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 237). E arremata: “A vagueza da referência contida na cláusula é superada com o reenvio não à consciência ou à valoração social, mas ao complexo de princípios que fundam o ordenamento jurídico, única garantia de pluralismo e democracia. As cláusulas gerais, portanto, são uma técnica legislativa que consente a concretização e especificação das múltiplas possibilidades de atuação de um princípio, agindo contemporaneamente como critério de controle da compatibilidade entre princípio e regras” (p. 239-240)

42

.“A previsão da hipótese de tratamento para a realização de interesses legítimos do controlador ou de terceiro (art. 7º, IX) se afigura como uma espécie de cláusula geral, na qual opera-se um teste de proporcionalidade entre os interesses na utilização dos dados pessoais, que são do controlador ou de terceiro, e os direitos do titular” (DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel. Reflexões Iniciais sobre a Nova Lei Geral de Proteção de Dados. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018. p. 3).

43

.Trata-se, inclusive, de ponto indicado no art. 40.º, 2, b, do Regulamento Geral Europeu.

44

.No contexto europeu, como se extrai do considerando (77) do Regulamento, indica-se que tais orientações podem ser extraídas de Códigos de Condutas e Certificações aprovadas pelas Agências de Proteção de Dados, bem como pelas orientações fornecidas pelo Comitê ou às indicações fornecidas por um encarregado da proteção de dados.

45

.Aludido procedimento foi expressamente indicado na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, concernente a “Orientações relativas à aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados a partir de 25 de maio de 2018”: “É importante que os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes realizem revisões rigorosas aos respectivos ciclos da política de dados, por forma a identificarem claramente quais os dados que conservam, para que fins e que base jurídica (por exemplo, ambiente nuvem; operadores do setor financeiro)” (p. 6, disponível em [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0043], acesso em 20.05.2020).

46

.“o relatório de impacto é a documentação que contém todo o ciclo de vida dos dados tratados, os procedimentos e riscos envolvidos, e as medidas que visam mitigar os riscos e/ou remediar os incidentes” (SANTOS, Fabiola Meira de Almeida; TALIBA, Rita. Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e os possíveis impactos. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 998, dez. 2018., acesso pela plataforma Revista dos Tribunais On-line. p. 4).

47

.A LGPD apenas autoriza o tratamento de dados sensíveis nas hipóteses do art. 11. Embora o consentimento seja uma delas, ele é reforçado pela necessidade de ser “específico e destacado” e “para finalidades específicas” (inciso I). A necessidade de robustecer a proteção aos dados sensíveis também é indicada no art. 46, § 1º, e no próprio art. 50, § 2º.

48

.A ICO – *Information Commissioner’s Office*, a autoridade independente de proteção de dados do Reino Unido –, por exemplo, disponibiliza uma série de checklists para auxiliar na avaliação de conformidade com o Regulamento Europeu. O questionamento é mais simples quando direcionado a “small business owners and sole traders” (Disponível em: [https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-self-assessment/assessment-for-small-business-owners-and-sole-traders/]. Acesso em: 20.05.2020); e, mais detalhado para “small to medium sized organizations” – hipótese em que, além de apresentar questionários para auxiliar na avaliação de cumprimento do RGPD tanto para controladores e para operadores, inclui alguns temas específicos – como segurança da informação (checklists disponíveis em: [https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-self-assessment/]. Acesso em: 20.05.2020).

49

.Conforme o já mencionado art. 46, § 2º. Recorra-se, ainda uma vez, aos preceitos do Regulamento Europeu, cujo considerando (78) exemplifica medidas que contribuem para a concretização dos princípios de *privacy by design* e *by default*: “Para poder comprovar a conformidade com o presente regulamento, o responsável pelo tratamento deverá adotar orientações internas e aplicar medidas que respeitem, em especial, os princípios da proteção de dados desde a concepção e da proteção de dados por defeito. Tais medidas podem incluir a minimização do tratamento de dados pessoais, a pseudonimização de dados pessoais o mais cedo possível, a transparência no que toca às funções e ao tratamento de dados pessoais, a possibilidade de o titular dos dados controlar o tratamento de dados e a possibilidade de o responsável pelo tratamento criar e melhorar medidas de segurança”.

50

.A atualização das políticas de privacidade divulgadas aos titulares à LGPD consiste em passo obrigatório na adaptação das novas regras.

51

.Aludido procedimento foi expressamente indicado na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, concernente a “Orientações relativas à aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados a partir de 25 de maio de 2018”: “É importante que os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes realizem revisões rigorosas aos respectivos ciclos da política de dados, por forma a identificarem claramente quais os dados que conservam, para que fins e que base jurídica (por exemplo, ambiente nuvem; operadores do setor financeiro)” (p. 6, disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0043&qid=1517578296944&from=em]. Acesso em: 20.05.2020).

52

.A Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal, após a entrada em vigor do Regulamento Europeu, aplicou multa ao hospital por, entre outras questões, deixar de restringir o acesso aos dados médicos dos pacientes. Além de qualquer médico, independentemente de sua especialidade, poder acessar os dados clínicos, havia quase 1000 (mil) logins atribuídos a “médicos” enquanto o hospital possuía apenas pouco menos de 300 (trezentos) em seus quadros. A multa, no valor de quatrocentos mil euros, foi aplicada por 3 (três) violações distintas: (i) ao princípio da minimização (já que não controlou o acesso aos dados dos pacientes); (ii) ao princípio da integridade e confidencialidade (já que não se empregou meios técnicos para impedir o acesso indevido aos dados – deixando, por exemplo, de eliminar contas antigas de médicos que não estavam mais em seus quadros); e (iii) incapacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos dados. (Como se extrai em [https://iapp.org/news/a/first-gdpr-fine-in-portugal-issued-against-hospital-for-three-violations/]. Acesso em: 20.05.2020).

53

.A ausência de clareza quanto às opções de privacidade levou a agência de proteção de dados holandesa a investigar e reputar ilegal prática da Microsoft quando do lançamento do Windows 10. Confira-se: “The company does not clearly inform users that it continuously collects personal data about the usage of apps and web surfing behaviour through its web browser Edge, when the default settings are used. These data are called ‘telemetry data’. With telemetry Microsoft – as it were – takes pictures of the behaviour of Windows users, and continuously sends these pictures to itself. Due to Microsoft’s approach users lack control of their data. They are not informed which data are being used for what purpose, neither that based on these data, personalised advertisements and recommendations can be presented, if those users have not opted out from these default settings on installation or afterwards. Microsoft processes data from both levels of telemetry in order to fix errors, to keep devices up-to-date and secure and to improve its own products and services” (v. sobre o assunto: [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/privacy-windows-users-greatly-improved-following-dutch-dpa-investigation]; [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/dutch-dpa-microsoft-breaches-data-protection-law-windows-10]. Acesso em: 20.05.2020).

54

“Ele se refere à exigência de que os dados constantes de um banco sejam objeto de um tratamento leal e lícito, sejam adequados pertinentes e não excessivos em relação à finalidade declarada, além de serem objetivos, exatos e atualizados. Tal princípio enseja cautela na formação do banco de dados, assim como demanda a sua constante atualização, de forma a impedir que os dados contidos restem ultrapassados com o passar do tempo. Para a efetividade do princípio da qualidade dos dados, é fundamental a garantia dos direitos de acesso, retificação e cancelamento dos dados” (MENDES, Laura Schertel Ferreira. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*. linhas gerais de um novo direito fundamental (Série IDP: linha pesquisa acadêmica), São Paulo: Saraiva, 2014. Edição Kindle).

55

.A valorização da participação da sociedade, em especial do titular dos dados que serão tratados é vivamente recomendada pelo RGPD, como se extrai do considerando (99): “Durante o processo de elaboração de um código de conduta, ou na sua alteração ou aditamento, as associações e outros organismos representantes de categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontratantes *deverão consultar as partes interessadas, nomeadamente os titulares dos dados, se possível, e ter em conta os contributos recebidos e as opiniões expressas em resposta a essas consultas*”.

Tal elemento – participação dos próprios titulares – é expressamente destacado pela autoridade nacional sueca, que, embora ainda não tenha concluído a elaboração das orientações mínimas para o estabelecimento de código de conduta, asseverou: “The Swedish Data Protection Authority, meanwhile, can already today list some criteria that a code of conduct must satisfy for it to be considered to contain sufficient guarantees:

•A code of conduct must focus on a well-defined category of data controller or processor. It must thus clearly state what types of organisation or sector the code will apply in.

•A code of conduct must be aimed at specific, well-defined, kinds of processing that are typical for the above-stated categories of data controller and processor.

•A code of conduct must be prepared carefully. This includes holding consultations with the relevant stakeholders, including as far as possible the data subjects or their representatives” (Disponível em: [www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/the-general-data-protection-regulation-gdpr/codes-of-conduct-and-certification]. Acesso em: 20.05.2020.

56

.Muito embora, por ora, tais mecanismos estejam previstos apenas no capítulo de transferência internacional de dados, a experiência europeia identifica-lhes com tal função.

57

.MENDES, Laura Schertel Ferreira. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*. linhas gerais de um novo direito fundamental (Série IDP: linha pesquisa acadêmica), São Paulo: Saraiva, 2014. Edição Kindle.

58

.Conforme consta nas explicações do item 3.7 (*Management Responsibility*) do Checklist para Controladores do *Data Protection Self Assessment* disponibilizado pela entidade: “Decision makers and key people should lead by example, demonstrating accountability for compliance with the GDPR and promoting a positive culture, within your business, for data protection” (Disponível em: [https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-self-assessment/controllers-checklist/]. Acesso em: 20.05.2020).

59

“Finally, ‘specific high-level personnel,’ which usually consists of the compliance officers in the compliance office, should be designated with the responsibility for the day-to-day operation of the compliance program. The chief compliance officer is critical to the success of the compliance program. For the compliance effort to succeed, the chief compliance officer should be afforded access to the CEO/President and the Board of Directors, as well as sufficient funding and staff” (BASRI, Carole Basri. *Corporate compliance*. Carolina Academic Press. Edição do Kindle, 2017. p. 33).

60

.No Regulamento Europeu, a nomeação de encarregado é obrigatória apenas (art. 37.1) quando: “a) O tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público, excetuando os tribunais no exercício da sua função jurisdicional; b) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito e/ou finalidade, exijam um controle regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala; ou c) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados nos termos do artigo 9º e de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações a que se refere o artigo 10º”.

61

.No RGPD, por exemplo, também se atribui ao encarregado o controle da “[...] conformidade com o presente regulamento, com outras disposições de proteção de dados da União ou dos Estados-Membros e com as políticas do responsável pelo tratamento ou do subcontratante relativas à proteção de dados pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados, e as auditorias correspondentes” (art. 39, 1.b).

62

.A pronta comunicação pode se revelar essencial na remediação do dano. A título exemplificativo, o descumprimento do prazo legal levou a agência holandesa de proteção de dados a punir em seiscentos mil euros o Uber no caso de vazamento de dados de usuários do aplicativo: [<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/dutch-dpa-fine-data-breach-uber>]. Acesso em: 20.05.2020.

63

.LESSIG, Lawrence. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

64

.BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais*. A função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 204-207.

65

“A implementação de programas de *compliance* impõe uma série de custos. A instituição de um programa robusto exige a contratação de especialistas, a elaboração de um código de ética e conduta, a avaliação perante dos riscos, o investimento contínuo no treinamento dos empregados, a contratação de *compliance officers externos* e de auditoria externa, o investimento em mecanismos de controle interno, inclusive em tecnologia da informação, para aprimorar os mecanismos de gerenciamento dos riscos, despesas relacionadas à manutenção do comitê de *compliance* etc.” (FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez. Desafios para a efetividade dos programas de *compliance*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 80).

66

.Sob a perspectiva da lei anticorrupção, já se asseverou que: “a mera redução da pena, em percentuais não tão expressivos e ainda sujeitos à discricionariedade da autoridade administrativa, dificilmente compensará os investimentos necessários para um bom programa de *compliance*” (FRAZÃO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. *Corrupção, cultura e compliance: o papel das normas jurídicas na construção de uma cultura de respeito ao ordenamento*. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana. *Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 146).

67

.Pois, como já se aduziu em outra sede, observando todos os parâmetros de legalidade, careceria a reprovabilidade necessária para as punições administrativas: “Daí a superioridade de um sistema punitivo segundo o qual o injusto da pessoa jurídica decorre de defeito de organização e em que a culpabilidade estaria relacionada à cultura empresarial desviante dos padrões de legalidade, sendo que os programas de *compliance* passam a ter uma importância chave. [...] Dessa maneira, não apenas haveria o adequado incentivo para a adoção de rigorosos programas de *compliance* – já que eles seriam idôneos a afastar a responsabilidade penal ou administrativa das pessoas jurídicas –, como haveria fundamentos mais consistentes para definir a culpabilidade das pessoas jurídicas e, conseqüentemente, sujeita-las a punições, em observância às garantias elementares do Direito Penal que também se aplicam ao Direito Administrativo Sancionador” (FRAZÃO, Ana. *Programas de compliance e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas por ilícitos administrativos*. In: ROSSETTI, Maristela Abila; PITTA, Andre Grunspun. *Governança corporativa: avanços e retrocessos*. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 52).

Capítulo 11. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados: origem, avanços e pontos críticos à luz das mudanças recentes

Beto Vasconcelos¹

Felipe de Paula²

1. Nota à Segunda Edição

O sucesso do livro *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas Repercussões no Direito Brasileiro*, coordenado por Gustavo Tepedino, Ana Frazão e Milena Donato Oliva, fez com que seus coordenadores pensassem em uma 2ª edição, atualizada à luz dos acontecimentos recentes. Honrados tanto com o sucesso da obra, quanto com o novo convite para atualização, optamos por manter a estrutura e o conteúdo básico de sua primeira versão, tendo especialmente em vista a relevância e o registro histórico relativo ao processo de elaboração normativa pelo Poder Executivo e ao processo legislativo que envolveu a criação da LGPD brasileira. Trazemos ao novo texto, contudo, alguns desdobramentos da aprovação da MP 869/2018 (convertida na Lei 13.853, de 08 de julho de 2019) e recentes questionamentos acerca da ausência de efetiva instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2. Introdução

Dados, informações e referências pessoais são hoje relevantes produtos da economia global. Com essa matéria-prima, bruta na origem, é possível alcançar importantes resultados de eficiência empresarial ou de atuação governamental. No entanto, a partir do mesmo conjunto de dados e informações, surgem os principais casos de abusos e distorções hoje debatidos nos ambientes acadêmicos, empresariais e de formuladores de políticas públicas.

O acúmulo de dados e o desenvolvimento de tecnologia para sua agregação, tratamento e uso têm proporcionado uma infinidade de oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. Há intensificação e identificação recíproca de grupos de pessoas e suas afinidades, customização e maior eficiência na oferta de produtos e serviços mais adequados à demanda individualizada; tem-se o alcance de prognósticos médicos mais precisos e de diagnósticos mais eficazes, a formulação e a avaliação de políticas públicas direcionadas às necessidades mais prementes da população, a possibilidade de serviços públicos efetivamente prestados conforme a demanda de determinadas localidades.

Por outro lado, também são recorrentes e cada vez mais frequentes irregularidades, abusos e distorções perpetradas por corporações empresariais e instituições públicas à medida que avança o domínio de tecnologias capazes de reunir, processar e conferir uso aos dados e informação pessoais. Cresce, em especial, o tratamento de dados pessoais sem o consentimento de seu titular ou sem que tal uso seja abarcado por finalidade legítima, seja adequado ou mesmo necessário.

Recorde-se, por exemplo, o já conhecido uso irregular da imensa base de dados da maior rede social do ocidente por empresa de coleta, customização e comercialização de informação para fins eleitorais; o direcionamento de produtos e serviços a partir de bases de dados privados obtidas sem consentimento informado de seus titulares; a restrição ilegal da oferta de serviços ou produtos em razão de segmentação discriminatória de perfil obtido no tratamento de base de dados pessoais de clientes; a definição de política pública de segurança a partir de algoritmo não auditado que indica maior probabilidade de reincidência de ilicitude. Todos esses são exemplos conhecidos e debatidos intensamente nos últimos anos³.

Em suma, a relevância do tema da proteção de dados pessoais – seja perante atores públicos, seja perante atores privados – é inequívoca. Permeia não somente o direito à privacidade, mas também o direito à informação, o direito de opinião e liberdade de expressão, o direito à opção e autodeterminação e o direito à isonomia e igualdade de tratamento.

O mundo experimentou período de inexistente ou reduzida regulação sobre o uso de dados pessoais. Contudo, em vista da intensificação e da diversidade de usos de dados e de suas bases, da construção acelerada de algoritmos e, sobretudo, dos impactos negativos advindos de usos abusivos, têm sido construídos modelos regulatórios capazes de reduzir as falhas na atuação de agentes de mercado e da atividade de governos e instituições públicas.

É nesse contexto que vários países ao redor do mundo implementaram ou aprimoraram sua legislação interna sobre proteção de dados⁴. Referência mundial, a regulamentação da União Europeia (*General Data Protection Regulation* – GDPR⁵) foi editada em maio de 2016 e entrou em vigor dois anos depois, em maio de 2018.

O debate no Brasil não é novo, e autores como Danilo Doneda e Laura Schertel Mendes, entre outros, debatem o assunto há anos⁶. Sob a ótica pública, ganha corpo desde que o Ministério da Justiça elaborou proposta de projeto de lei em 2010 (cf. item 3, adiante), em contexto que também envolvia debate sobre proposta de regulamentação do chamado *cadastro positivo*⁷. Com o avanço da experiência estrangeira e a partir da ocorrência de uma das maiores crises sobre o assunto neste início de século – a denúncia de vigilância estatal por *Edward Snowden* e as sucessivas publicações por renomados periódicos do mundo, em especial, o *The Guardian*⁸ – o Ministério da Justiça retomou o assunto sob outras bases em 2015/2016. Aprimorou a proposta legislativa, submetendo-a novamente a processo de consulta pública⁹, com posterior encaminhamento ao Congresso Nacional, em maio de 2016, do Projeto de Lei n. 5276/2016¹⁰.

Como se verá em detalhes adiante, o projeto do Executivo foi apensado a outros projetos na Câmara dos Deputados, sendo um deles finalmente aprovado e, após aprovação no Senado Federal, encaminhado à sanção do Presidente da República¹¹.

Após alguns vetos, foi sancionado e convertido na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018¹², a chamada Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Naquele momento, boa parte dos debates recaiu sobre o veto, por suposta inconstitucionalidade formal, ao artigo 55 e seguintes, que previam a criação e as competências da denominada Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. Tratava-se da autoridade prevista para, entre inúmeras outras competências, zelar pela aplicação da lei, por sua fiscalização, proteção, desenvolvimento e avaliação.

Para muitos, o cerne do desenvolvimento de uma boa política de proteção de dados está justamente na definição do responsável institucional pelo seu fomento, fiscalização e *enforcement*. Equívocos quanto à adequada independência e especialização técnica do responsável pela tarefa e quanto à correta alocação de competências poderiam condenar o desenrolar da política em si. Mais: a própria Lei trazia competências essenciais à Autoridade que, uma vez vetadas, inviabilizavam boa parte das previsões.

A questão teve nova rodada com a edição da Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, no apagar das luzes da gestão do então Presidente Michel Temer. A nova medida que, segundo sua Exposição de Motivos, criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ganhou contornos diferentes daqueles originalmente debatidos ao longo de todo o processo de tramitação da LGPD: foi criada como órgão vinculado à Presidência da República. A decisão não escapou de críticas acaloradas.

Após avaliação do Congresso Nacional, o modelo resultante do debate legislativo – hoje posto na LGPD, a partir da promulgação da Lei 13.853/19 – manteve a vinculação da Autoridade à Presidência da República, mas lhe atribuiu um caráter transitório, com a possibilidade de transformação em autarquia após 2 anos de funcionamento. Ainda, e até o presente momento, os passos necessários à sua efetiva implementação, como a nomeação de seus diretores, não ocorreram a contento.

Diante de todo esse cenário, o presente artigo se propõe a expor as razões e a conjuntura na qual se deu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como os debates e questões jurídicas atinentes ao veto presidencial à criação da Agência por projeto de lei de iniciativa parlamentar. Também abordará sua posterior criação por Medida Provisória e aprovação do projeto de lei de conversão pelo Congresso Nacional, suas principais características e fragilidades, avançando ainda nos debates recentes acerca da (não) efetivação da ANPD até o presente momento.

Em ressalva similar à realizada na 1ª edição da presente obra, como a real implementação da ANPD ainda está em curso, a presente exposição corre o risco de ficar parcialmente datada. A minorar tal dificuldade, ela não se destina a expor em detalhes ou a avaliar as competências que a ANPD potencialmente exercerá em seu novo modelo. O presente texto deve ser recebido em contexto temporal e sempre sob a ressalva de que ajustes devem ocorrer a partir da nomeação de seus diretores e de seus primeiros atos regulamentares. A opção aqui feita, para além do registro histórico, é colaborar com os debates em curso e o de destacar a relevância, os riscos e as oportunidades da definição do desenho institucional da entidade.

O texto está dividido da seguinte forma: primeiro, apresentamos a relevância do debate sobre o desenho institucional que deve acompanhar a implementação de qualquer política pública, bem como a reflexão sobre diferentes arquiteturas regulatórias. Depois, abordamos brevemente o processo de definição do modelo dentro do Executivo, sua tramitação legislativa e, também, o debate sobre o veto da Autoridade Nacional por um alegado vício de iniciativa. Em um terceiro momento, tratamos da MP 869/2018, que desenhava a Autoridade sob pressupostos diferentes daqueles originalmente rascunhados e de sua aprovação final pelo Congresso Nacional (Lei 13.853/19), apontando suas características hoje vigentes. Finalmente, e sempre sob a ressalva do tema ainda estar em aberto, apontamos riscos e oportunidades perdidas decorrentes dessa opção, bem como alguns problemas decorrentes de sua não implementação.

3.A Relevância dos Arranjos Institucionais: por quais motivos se defendeu a criação de uma Autoridade Nacional e de um Conselho Nacional de Proteção de Dados?

Um dos papéis contemporâneos do direito, em geral, e do ato normativo, em especial, é o de estruturar arranjos institucionais que permitam a boa execução de políticas públicas (COUTINHO, 2013a, 2013b)¹³. Partindo do pressuposto de que bons modelos regulatórios, aptos ao gerenciamento de determinada política pública, dependem de adequada produção de normas com vistas a direcionar comportamentos (*standard setting*), de monitoramento e tratamento de informações para implantação e avaliação de efeitos (*information gathering*), assim como de mecanismos de aplicação e cumprimento da norma (*enforcement*)¹⁴, a definição de responsáveis pelas funções inerentes a tal atuação tem centralidade em qualquer norma que determine uma política pública.

Há políticas públicas que, por características de fato e de direito, podem ser formuladas, implementadas, fiscalizadas e avaliadas pela própria Administração direta, de forma mais ou menos descentralizada. Algumas políticas sociais ou boa parte da política educacional e de saúde, por exemplo, umbilicalmente ligadas à razão de ser de estruturas estatais, exemplificam a opção (em alguns casos, por mandamento constitucional, a obrigação).

Há outras cujos atributos – falta de competitividade no setor, necessidade de desconcentração, necessidade de alta especialização técnica, proteção diante de eventuais inflexões políticas, rápida mutação e consequente exigência de atuação mais ágil etc. – recomendam arranjos institucionais distintos. A existência de entidades autônomas e independentes tanto no mérito de suas decisões quanto em sua gestão administrativo-financeira, com corpo burocrático técnico e especializado, e com bom grau de abertura à participação de atores relevantes ao processo, coloca-se como uma das alternativas possíveis.

No caso da política de proteção de dados, os pressupostos não são diferentes. Não há dúvidas de que o desenho institucional para o monitoramento, a execução, a garantia de cumprimento e a avaliação tanto da nova Lei quanto da política pública que ela estrutura é extremamente relevante ao seu sucesso. Por isso, o tema se fez e se faz extremamente presente.

Embora o padrão de uma entidade autônoma, independente e de alta *expertise* técnica tenha soado em uníssono ao longo de todo o debate sobre proteção de dados no Brasil, quase que como evidência inescapável, o fato é que tal modelo não é

único ou necessário (LEMOS *et al*, 2018). Com vantagens e desvantagens, e sob a ressalva prática de que apenas 12 de mais de 120 países não criaram autoridade independente para gerir a nova política (MENDES; DONEDA, 2018), em teoria seria possível conceber diferentes arranjos institucionais, sem a criação de uma entidade específica.

Tais modelos poderiam variar sob diferentes perspectivas. Quanto à centralidade e à independência, pode haver arranjos mais ou menos próximos de núcleos decisórios, com maior ou menor grau de proteção aos decisores – como mandatos fixos. Quanto à unicidade, vislumbram-se arranjos mais ou menos fragmentados. Quanto à autonomia, arranjos com maior ou menor liberdade na gestão de seu orçamento e de seu RH. Finalmente, quanto à capacidade normativa e sancionadora, instituições com maior ou menor poder de atuação direta. A diferença entre o modelo americano – fragmentado – e o modelo europeu – especializado e centralizado – demonstra cabalmente não haver solução única.

Não obstante, em linha com a confortável maioria das experiências internacionais, houve inequívoca inclinação no debate brasileiro – especialmente naquele travado na sociedade civil – pelo desenho de uma estrutura autônoma, independente e de alta *expertise*, temperada por robustos mecanismos de monitoramento e participação da sociedade civil. Inúmeras motivações ajudam a explicar o fenômeno, com potenciais explicativos distintos.

Em linhas gerais, inescapável apontar o isomorfismo institucional (por vezes acrítico) que marca países em desenvolvimento. Seja pela pressão de cartilhas internacionais, seja pela sólida formação daqueles que se debruçam sobre temas inovadores a partir de experiências estrangeiras, desenhos existentes e testados no exterior, especialmente em países da Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE), rapidamente emergem como aptos a serem transplantados ao nosso cenário.

De outro lado, houve de fato enorme e efetiva aprendizagem com os exemplos existentes. Ele aponta que especialização, qualificação técnica, velocidade e consistência decisória (com consequente segurança jurídica aos agentes), aprofundamento temático e, essencialmente, autonomia administrativa e financeiro-orçamentária das entidades gestoras de políticas de proteção de dados pessoais seriam fundamentais à sua implementação, fiscalização e *enforcement*. A rápida mutação no setor exige tecnicidade, atualização constante, conhecimento de ponta e garantia de atuação independente.

A defesa também tinha objetivos mais mundanos, decorrentes do cenário brasileiro. Primeiro, almejava evitar a atuação difusa e descentralizada existente em outros setores, com claras situações de sobreposição e descoordenação – vide a ainda confusa situação institucional dos acordos de leniência relativos à Lei Anticorrupção, um jogo institucional ainda inacabado, conforme já tratamos (VASCONCELOS; SILVA, 2018)¹⁵. A propósito, não era outro o cenário relativo à proteção de dados pessoais no país: em que pese a louvável e qualificada atuação de Procons, Ministérios Públicos e da própria Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), episódios de duplicidade ou de ausência de responsável definido a depender da função em causa eram recorrentes.

Depois, era importante garantir que a nova Lei de proteção de dados pessoais fosse válida e efetiva tanto para o setor privado quanto para o setor público. É que, como bem alertou por diversas vezes Carlos Affonso Souza (2018a, 2018b), entre outros, o tratamento de dados pelo Estado também precisa estar sob os crivos de finalidade, proporcionalidade e transparência¹⁶. Dado o volume de tratamento de dados pessoais realizado por agentes estatais, é fundamental que o Estado esteja sob a ótica de monitorado / fiscalizado, não de mero controlador. Assim, a correta alocação da entidade responsável dentro do aparato estatal importa. O grau de autonomia e a independência tem impacto direto na efetiva proteção e tutela da privacidade dos cidadãos.

É possível dizer, então, que a defesa da criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados replicou, de um lado, aprendizados de um modelo de amplo sucesso internacional e, de outro, dado o diagnóstico brasileiro, atacou problemas que lhe eram especificamente inerentes. De forma a garantir independência e técnica, almejou congrega em um único ente uma série bastante ampla de funções. Em rol longo, porém não exaustivo, viu-se na Autoridade potencial responsável pela normatização, pela implementação, pela formulação, pelo fomento, pela sanção, pela educação e pela oitiva da sociedade. As atividades específicas que o debate lhe sugeriu variaram desde uma ampla capacidade normativo-regulatória até competências de auditoria e de gerenciamento de transferência internacional de dados.

Finalmente, em linha com a percepção de que informações atualizadas e de ponta são insumo essencial a qualquer atividade reguladora, o necessário monitoramento e a necessária participação da sociedade civil na definição dos rumos da política não foram esquecidos. Para tanto, propôs-se também um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais¹⁷.

4.O Debate no Executivo e a Construção da Autoridade Nacional

O Brasil demorou a ter uma lei de proteção de dados pessoais aprovada e sancionada pelo Presidente da República. No entanto, como adiantado, o debate não é novo no país. Inúmeras vezes já se punham a favor de uma lei de proteção de dados pessoais, e já em 2010 houve o primeiro movimento institucional de peso do governo federal em prol do tema, em contexto marcado pelo debate do chamado cadastro positivo e de seu potencial impacto no direito de consumidores.

Por meio das então denominadas Secretaria de Assuntos Legislativos (hoje extinta) e Secretaria de Direito Econômico (hoje cindida e sucedida pela Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça, em parceria com o Observatório Brasileiro de Políticas Digitais do Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi proposta a primeira consulta pública governamental sobre o tema. Ela teve duração de cinco meses, recebeu mais de 14 mil visitas e 800 contribuições.

Após longo acúmulo de experiências internacionais, de escândalos de vigilância e de vazamento de dados, de Brasil e Alemanha terem apresentado à ONU Resolução Direito à Privacidade na Era Digital¹⁸ e, finalmente, a partir de nova janela de oportunidade governamental, o debate de um anteprojeto voltou à pauta do Ministério da Justiça em 2015. Naquele momento, e naquilo que importa ao presente texto, a discussão sobre qual a “*estrutura administrativa responsável pela garantia da correta aplicação da lei de proteção de dados e quais seriam as suas competências*” foi explicitamente abordado¹⁹.

O debate dentro do Poder Executivo Federal contou com mais de 50 mil visitas ao site e mais de 1.100 contribuições da sociedade civil. Finalmente, deu ensejo ao PL 5276/2016, apresentado ao Congresso em 13 de maio de 2016²⁰. Ele não criou a Autoridade de forma explícita. Não tratou de sua composição ou de sua vinculação, embora tenha estabelecido competências, com o perdão da repetição, “ao órgão competente designado para zelar pela implementação e pela fiscalização desta lei”.

Em sua Exposição de Motivos, lacunosamente adiantou:

“16. Com o objetivo de dar efetividade à regulamentação sugerida, a proposta prevê um órgão competente para a proteção de dados pessoais no país. Será sua responsabilidade elaborar diretrizes de uma Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, promover entre a população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais, bem como das medidas de segurança, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, entre outras medidas”.

“17. Como auxiliar deste órgão, propõe-se a criação de um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, composto por representantes do poder público, setor privado, academia, comunidade técnica e organizações não-governamentais”

Inúmeras explicações relativas à indefinição da Autoridade no Projeto de Lei do Executivo podem ser aventadas.

Uma delas, bastante forte, reside na necessidade de se avançar com o Projeto, que tramitava há anos dentro do Executivo, ainda que sem uma definição final do responsável pela política. Não é segredo que, embora o desenho institucional de Autoridade nova, especializada, autônoma e independente fosse voz corrente na sociedade civil e nos defensores primários do Projeto de Lei – leia-se Ministério da Justiça –, inúmeros outros atores governamentais com algum protagonismo em temas conexos – caso, por exemplo, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – foram colocados (ou se colocaram) como aptos às funções vindouras.

Outra hipótese, não excludente da primeira, reside no peso de um momento de intensa restrição orçamentária e financeira que constrangia as decisões governamentais. A luta pela criação de nova entidade poderia prolongar o debate interno no Governo Federal, carregando riscos inerentes a eventual nova paralização do trâmite da proposta.

Sob qualquer dessas duas hipóteses não excludentes, parece ter sido solucionado o *trade-off*: perdeu-se no desenho institucional adequado à governança da política pública, mas se avançou na construção do marco regulatório propriamente dito.

5.A Tramitação Legislativa

Àquela altura, a proposta do Executivo não era a única em pauta no Congresso Nacional. Outros Projetos de Lei tramitavam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal²¹. Em especial, já tramitava o Projeto de Lei nº 4.060/2012 da Câmara dos Deputados, ao qual, após pedido de apensamento pelo Deputado Alexandre Leite (DEM-SP) em julho de 2016, foi apensado o Projeto do Poder Executivo, bem como outras proposições²².

As propostas foram, então, avaliadas em Comissão Especial na Câmara que, como bem demonstra seu ato de criação, foi constituída para “proferir parecer ao PL 4060/12”, tido então como projeto de lei principal, de inequívoca autoria parlamentar²³. Após sua aprovação tanto na Comissão Especial quanto no plenário da Casa, tramitou como PLC nº 53/2018 no Senado Federal e acabou aprovado em 10 de julho de 2018. Após republicações e reenvio do autógrafa²⁴ ao Presidente da República, a norma foi finalmente sancionada e promulgada como a Lei n. 13.079, de 14 de agosto de 2018²⁵.

Não há dúvida de que a redação aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, cujo relator foi o Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), valeu-se fortemente do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo, dos debates e consultas ali realizadas. Também contou com o amplo apoio obtido ao longo do processo de construção do Projeto de Lei para garantir que o tema avançasse na agenda pública. Nada afasta, contudo, a situação de que o Projeto de Lei originário em avaliação pela Comissão era, ao fim e ao cabo, de iniciativa parlamentar.

No que tange à criação da Autoridade Nacional, e como bem diz o parecer da Comissão Especial da Câmara relativo à redação final votada naquela Casa Legislativa, era notório o consenso técnico sobre a necessidade de um órgão centralizado, independente e autônomo para gerir o assunto. Inseriu-se então no texto do projeto o inciso XIX do art. 5º, que definia como competente “órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei”.

Para além de inúmeras outras referências específicas ao órgão competente ao longo de todo o texto, o art. 54 e seguintes do relatório aprovado (art. 55 e seguintes de sua versão final) também foram ao encontro dos anseios de ampla maioria dos partícipes do debate público. Criou-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério da Justiça; colocou-se a gestão de seus recursos humanos sob a égide da lei aplicável às agências reguladoras; criou-se Conselho Diretor e Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com os respectivos mandatos, competências e receitas.

6.O Veto Presidencial: a questão do vício de iniciativa

A LGPD foi sancionada e promulgada com vetos pelo então Presidente da República, que incluíram toda a previsão relativa à criação da Autoridade Nacional. A ANPD foi vetada sob a alegação de vício de iniciativa²⁶. Em curta síntese: por ser de iniciativa parlamentar e em que pese toda a inspiração no texto do Executivo, bem como a tramitação conjunta com o Projeto elaborado pelo Executivo, o fato é que sua sanção, nesse ponto, esbarraria na competência privativa do Presidente da República em criar órgãos e entidades.

A Constituição Federal de 1988 é clara: são de iniciativa privativa do Presidente da República leis que criem ou extingam Ministérios e outros órgãos da Administração Pública, ou que criem cargos na Administração direta ou autárquica (art. 61, par. 1, II, “a” e “e”). A interpretação corrente da previsão propugna por sua aplicação a toda a Administração (abrange, pois, tanto órgãos quanto entidades administrativas).

Como se defendeu outrora²⁷, e por mais que importantes vozes dissonantes tenham defendido leitura contrária²⁸, é preciso lembrar que mérito, relevância ou mesmo forte concordância com determinada medida não são aptos a afastar ou a burlar o crivo constitucional. Por mais que se queira ou que se deseje exatamente o oposto, medidas extremamente valorosas que contrariem o texto constitucional também estão eivadas de inconstitucionalidade. É esse o funcionamento básico de democracias constitucionais, que ao final do dia protege as regras do jogo e garante que minorias não sejam atropeladas por maiorias de ocasião, ainda que estejamos inseridos nela.

No mais, a reserva de lei ao Presidente da República tem razão de ser. Tem forte lastro na separação de poderes e garante ao Executivo duas prerrogativas que, se porventura questionáveis, compõem pilar de desenho constitucional que ainda não foi alterado: (i) o controle da forma e do modo de funcionamento da Administração e, em especial, (ii) o juízo de oportunidade quanto ao momento de determinada alteração administrativa.

Nesse sentido, e em que pese a frustração para grande parte dos apoiadores da nova lei, parece-nos que, à luz do texto da Constituição, projeto de lei de iniciativa parlamentar que cria órgão (ou entidade) da Administração Pública de fato atinge o desenho de competências legislativas posto e, por isso, teria elevadas chances de ser declarado inconstitucional.

Saliente-se que a jurisprudência do STF é seguramente majoritária nesse sentido. Há pacífico entendimento de que sanção presidencial não convalida vício de iniciativa.²⁹ Isso significa, em termos práticos, que nem o aval presidencial explícito à suposta usurpação de sua competência é apto a alterar o desenho constitucional que lhe garantiu prerrogativas exclusivas. Também é frequente a não aceitação de leis que, embora não afrontem diretamente a competência privativa do executivo, utilizam subterfúgios como dar prazo ou obrigar o Executivo a legislar em temas de sua própria competência: tais tentativas também têm sido majoritariamente derrubadas, por motivos similares.³⁰ O Executivo não poderia ser compelido a tomar decisão que lhe é reservada; o juízo de oportunidade integra a competência privativa.

Os argumentos em defesa da higidez da lei aprovada não nos pareceram suficientes ou, dito de outra forma, assumiram riscos demasiado altos. Em suma, havia muita insegurança jurídica ao modelo regulatório recém criado. Veja-se o que tentou o relator da Comissão Especial que, já ciente das dificuldades quanto à iniciativa da lei, afirmou que *“a proposta do Executivo já previa a designação de um órgão competente para fiscalizar o setor, o que autoriza a apresentação de emendas parlamentares nesta área”*, e que *“o texto foi amplamente discutido e se baseia [no mérito e em parte da tramitação] em um projeto de origem do Executivo [por isso não haveria vício]”*. Também foi o que pontuaram importantes apoiadores da lei desde o seu início quando em tentativa de salvar todo o trabalho até então realizado³¹.

Por mais meritórias que fossem as defesas e os ajustes ao texto legal – o que, aos nossos olhos, de fato eram –, o risco de eventual sanção da lei na forma como aprovada deixava-a em condição de constante questionamento. Era bastante razoável supor que a lei teria sua constitucionalidade formal questionada na primeira sanção imposta pela ANPD a um agente privado. Eventual declaração posterior de inconstitucionalidade da previsão da Autoridade – e consequentemente, de sua atuação – colocaria por terra todo o seu trabalho e devolveria o debate relativo ao desenho institucional à estaca zero.³²

A propósito, no mesmo risco incorreu a tentativa de resgatar o texto aprovado em sua íntegra a partir da derrubada do veto presidencial. Aos nossos olhos, a opção poderia significar vitória política, mas em nada alteraria o cenário de risco jurídico então instalado.

Assim, por mais doloroso ao mérito e àqueles que lutaram pela aprovação de uma lei com arranjo institucional bem desenhado, forçoso concluir que, no limite, o veto era medida jurídica cabível e adequada, de modo a evitar problemas futuros ainda mais graves. Restava, pois, lutar pelo estabelecimento de novo arranjo institucional que devolvesse cabeça, corpo e dentes à política então estabelecida pela nova lei.

Há, contudo, ressalva a ser feita. É que defender o veto como juridicamente defensável e protetor de toda a lei não equivale a dizer que ele não trouxe problemas, inclusive novos, para o bom funcionamento do sistema. O dado de realidade é que o veto à Autoridade trouxe dilemas insolúveis ao desenvolvimento do sistema.

A LGDP sancionada trazia – e ainda traz – em seu texto, por exemplo, inúmeras referências a *regulamento a ser emitido por órgão competente* – é dizer, pela Autoridade então vetada e naquele momento não mais existente. Ora, a doutrina tradicional enxerga em tal referência expressa uma espécie de condição suspensiva da execução legal. Sem os requeridos regulamentos não haveria produção completa de efeitos e, com o veto, não haveria ente competente para expedir-los.

No mais, como já defendemos (PAULA, 2018b), a ausência de veto ao inciso XIX do art. 5º da Lei, que explicitamente definia a Autoridade como componente da Administração Pública indireta, comprometia soluções que atribuísem, ainda que temporariamente, os poderes da Autoridade a órgão ou entidade preexistente por decreto presidencial.

Finalmente, temas centrais ao bom funcionamento da política simplesmente não avançariam sem a definição de entidade competente para tal. A transferência internacional de dados – e eventuais medidas de segurança a serem observadas – é um deles, assim como a aplicação das sanções administrativas previstas na lei. Em suma, era essencial solucionar o problema.

7. A Criação de Autoridade Nacional via Medida Provisória n. 869/2018: riscos envolvidos e oportunidades perdidas

Como adiantado na Introdução, em 27 de dezembro de 2018, poucos dias antes do fim de sua gestão e do início do atual mandato presidencial, o então Presidente da República editou a Medida Provisória n. 869/2018, cujo conteúdo alterou dispositivos da LGPD a fim de criar a Autoridade e promover outros ajustes que entendia pertinentes.

O texto originalmente proposto não seguiu a linha anteriormente debatida. Ao contrário da criação de entidade com independência, autonomia técnico-administrativa e orçamentária e alta *expertise*, previu a criação da referida Autoridade com as seguintes características:

- natureza de órgão da *Administração direta, integrante da Presidência da República*;

- composta de Conselho Diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, órgão jurídico próprio e unidades administrativa e especializadas necessárias à execução da Lei;
- embora com espécie de “mandato”, nomeação do Conselho Diretor e do Conselho Nacional diretamente *pelo Presidente da República*;
- autonomia técnica declarada por enunciado normativo;
- ausência de aumento despesa declarada por enunciado normativo.

O desenho institucional proposto ao Congresso Nacional recebeu fortes críticas referentes a aspectos tidos como essenciais ao longo do debate de sua concepção. De todas, alinhamo-nos em especial a algumas delas.

Em primeiro lugar, o modelo proposto pela MP original à evidência não garantia suficiente autonomia e independência funcional, administrativa e financeira defendida no debate prévio e assumida em outros desenhos de autoridades reguladoras instituídas a partir da década de 1990. O disposto na proposta do art. 55-B – “*é assegurada autonomia técnica à ANPD*” – não era, por si só, suficiente para assegurar a independência e a autonomia esperadas, e sua nova forma aprovada pela Lei 13.853/19 – “autonomia técnica e *decisória*” – também não resolveu por completo os problemas apontados. Mero enunciado normativo de autonomia técnica e decisória não afasta as exigências fáticas que caracterizam uma entidade de fato autônoma.

Efetiva autonomia e independência, que garanta que a atividade técnica não esteja sujeita a intempéries político-orçamentárias, verifica-se também por meio de, no mínimo, (i) instituição de autarquia pública integrante da Administração indireta, (ii) supervisão ministerial por parte de órgão da Administração Pública direta com competência institucional relacionadas à matéria, (iii) modelo de responsabilidade compartilhada com indicação dos nomes do Conselho Diretor feita pelo Presidente da República e sabatina, votação e aprovação, pelo Senado Federal; (iv) competência para proposição de orçamento, conforme modelos autárquicos de outras agências reguladoras, (v) carreira própria de servidores públicos ou concurso público de carreira existente com seleção específica para a ANPD, tendo em vista o perfil altamente especializado que a missão institucional requer e (vi) previsão legal de boas práticas de participação e controle social.

Aliás, a vinculação à Presidência da República, por si só problemática, também carrega em si dificuldades específicas: pode não haver suficiente autonomia e independência institucional exigidas por outros países de modo a assegurar a cooperação jurídica internacional para transferência de dados pessoais entre nações. Pode ser o caso, em especial, para os Estados-Membros da União Europeia sob disciplina da GDPR.³³

Outra crítica com a qual nos alinhamos, diretamente relacionada à primeira, diz respeito à inescapável redução da capacidade de regulação e fiscalização, por parte da ANPD, do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. Se na proposta original da MP o ente perdeu importante parcela de sua autonomia e independência, em especial dada a inexistência de alguns dos mecanismos mínimos estabelecidos internacionalmente, como garantir que haverá proteção de direitos individuais perante a atuação do próprio Poder Público?

O modelo proposto por meio da MP 869/2018, enfim, trazia uma autoridade com baixa independência e autonomia. Com isso, corria-se o risco de permanente insegurança em relação aos propósitos institucionais da regulação futura, bem como de perigosa falta de garantia do controle estatal em tema tão sensível, cuja espinha dorsal regulatória diz respeito a direitos fundamentais. Não há como pressupor excelência na condução de uma entidade pública que já nasce sob dúvidas quanto ao grau de independência.

Para além da razão anteriormente exposta, há que se atentar para a sutil – e relevantíssima – alteração feita na LGPD quando da edição da MP 869/2018, mantida em seu texto final aprovado pelo Congresso: a revogação dos parágrafos primeiro e segundo do art. 7º da Lei. Sob o pretexto de efetivamente criar a ANPD, o Governo Federal alterou disposição normativa e, na prática, afrouxou amarras referentes ao tratamento e uso de dados pessoais pelo Poder Público.³⁴

O parágrafo primeiro do referido artigo determinava que o *titular dos dados deveria ser informado pelo Poder Público acerca das hipóteses em que seria admitido o tratamento de seus dados*, necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. O parágrafo segundo, por sua vez, estabelecia um poder dever ao definir que *a ANPD poderia especificar a forma de disponibilização das informações (notificação, ciência) aos respectivos titulares dos dados, acerca do tratamento de seus dados pelo Poder Público*.

Ao revogar, em uma tacada só, os dois dispositivos previstos na LGPD original, eliminou-se o comando legal que previa importante mecanismo de informação e transparência ao titular dos dados pessoais para a garantia de seus direitos. Revogou-se, também, competência regulamentar prevista à ANPD, que poderia disciplinar de forma eficiente e eficaz a forma pela qual o direito à informação do titular de dados pessoais seria protegido sem inviabilizar o bom desenvolvimento de políticas públicas. A MP 869/2018 criou, dessa maneira, assimetria regulatória injustificável e perigosa, ao exigir do Poder Público reduzido grau de *accountability* diante de eventual tratamento de dados pessoais.

A crítica que se colocou ao debate naquele momento era, portanto, no sentido de se alertar para a reduzida capacidade legal de a ANPD regular e fiscalizar a atuação do próprio Poder Público no tratamento de dados pessoais. Essa deficiência não nos parece casual, mas, sim, desenhada com claro intuito limitador. Apontava preocupante possibilidade de propósitos distorcidos no tratamento de dados de cidadãos e cidadãs por órgãos ou entidades públicas.

Nunca é demais lembrar elemento básico do nascedouro do constitucionalismo: o Estado contemporâneo fomenta e tenta proteger e garantir direitos, mas também é seu potencial violador. É preciso, pois, que sua atuação esteja sob forte escrutínio legal, como ocorre, aliás, com boa parte da legislação que tangencia direitos fundamentais. Entendemos que a equivocada tentativa de retirar o dever de informar previsto nos dispositivos citados pode acabar no controle constitucional que primeiro sobrevier acerca da LGPD, tendo em vista flagrante ofensa aos preceitos mais basilares da Constituição Federal.

Finalmente, naquele momento também pedimos cautela com a previsão do parágrafo 1º do art. 55-J, cujo conteúdo determinava que a ANPD, “na edição de suas normas, deverá observar a exigência de mínima intervenção (...)”, essencialmente mantida na versão final da lei aprovada. Não há dúvidas de que políticas regulatórias contemporâneas – que rapidamente se desenvolvem ao menos desde os documentos de *Better Regulation* da OCDE de 1995 e 1997³⁵ – são marcadas por ideais de redução e simplificação regulatória, intervenção apenas e tão somente se justificável e, especialmente, lastro empírico que dê base às medidas propostas. No entanto, o transplante de desenhos e de ferramentas precisa sempre ser colocado em contexto.

Não há que se defender regulação pesada, complexa e descolada da realidade fática. No entanto, e especialmente em tema tão sensível como o de proteção constitucional de direitos individuais fundamentais, o equilíbrio entre princípios constitucionais como o da livre-iniciativa e a garantia de direitos fundamentais básicos dificilmente será concretizado partindo-se da quantificação *a priori* de grau de intervenção (estatal, como parece sugerir a MP).

Quanto às normas a serem expedidas pela ANPD, pressupõe-se serem elas simples, empiricamente embasadas, tecnicamente atualizadas e que considerem custos e benefícios aos mais diferentes atores. No entanto, pressupõe-se também cumprimento integral da lei e da Constituição. Requer-se, portanto, a atuação regulatória *necessária*, não mínima ou máxima, observados, claro, os amplos requisitos de participação na construção regulatória de todos os envolvidos no tema.

8.A Aprovação da MP 869: base legal da Autoridade, atraso na implementação e questões ainda pendentes

Sancionada com vetos que recaíram apenas e tão somente sobre emendas parlamentares ao texto da MP original – como a possibilidade de cobrança de taxas por serviços prestados pela Autoridade ou partes da ampliação do rol de penalidades, entre outras inclusões –, a MP 869/2018 foi finalmente convertida na Lei 13.853, de 08 de julho de 2019, que alterou a LGPD.

No que importa ao presente artigo, foi relativamente alterado o desenho institucional da ANPD proposto pelo Executivo, discutido no item anterior. Após amplo processo legislativo e 176 emendas parlamentares avaliadas pelo Congresso Nacional, tanto em Comissão Mista quanto em plenário das casas, o desenho legal da ANPD manteve sua vinculação à Presidência da República, mas apontou para uma natureza transitória, podendo a ANPD ser transformada em autarquia após dois anos, a critério do governo. Quanto a esse ponto, e não obstante a transitoriedade, continuam válidas todas as ressalvas referentes à baixa independência, autonomia técnico-administrativa e orçamentária do modelo outrora proposto e agora aprovado.

Mudança relevante foi a previsão de sabatina pelo Senado aos nomes indicados pelo Executivo para a diretoria da Autoridade. Embora a prática de sabinas no Brasil ainda aponte para poucas rejeições, o desenho inequivocamente permite maior escrutínio público dos nomes indicados. Contudo, exige algum grau de negociação e transação do Executivo com os demais atores políticos envolvidos no processo de nomeação – com os aspectos positivos e negativos inerentes a esse tipo de ajuste.

O Congresso Nacional ainda incluiu algumas competências adicionais à Autoridade, como a elaboração de diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade e a disposição sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, observado o respeito aos segredos comercial e industrial, entre outras.

Não obstante as enormes dificuldades inerentes ao desenho, no presente momento é possível afirmar que os problemas relativos à criação da ANPD não param por aí. É que, com mais de 9 meses da aprovação da lei, ainda não foi publicado decreto regulamentador da lei nem foram indicados à sabatina os diretores da Autoridade. Considerando o impacto que a pandemia do Covid-19 já traz ao andamento das atividades parlamentares, difícil crer que tais nomes serão indicados e sabatinados em curto prazo.

Sem ANPD, diretores e regulamentação, os problemas relativos à falta de uma Autoridade Nacional acentuam-se sobremaneira. Há falta de regras e diretrizes claras, de linhas interpretativas e orientações mínimas de cumprimento, bem como de competências bem consolidadas a partir do início dos trabalhos da autoridade.

Ainda, fica especialmente em risco o *enforcement* da Lei que entraria em vigor, em sua totalidade, em agosto de 2020 (destaque-se que várias propostas legislativas já almejam ampliar sua *vacatio legis* e que recentemente o governo federal editou a MP 959/20, ainda em tramitação no momento de finalização do presente texto, que ampliou tal prazo para 3 de maio de 2021).³⁶ Para além da impossibilidade de aplicação das multas administrativas ali expostas, visto não haver autoridade constituída para tanto, o principal problema já posto é o da fragmentação do *enforcement*, que já dá as caras mesmo com a Lei ainda não em vigor.

Por todo o país, ganham terreno ações patrocinadas pelos Ministérios Públicos e por órgãos e entidades de defesa do consumidor que, ao final do dia, tangenciam ou atingem diretamente assuntos diretamente relacionados à LGPD, sobre os quais poderia recair a competência da ANPD. Não se defende aqui a impossibilidade de Ministérios Públicos ou de órgãos e entidades de defesa do consumidor atuarem dentro de suas respectivas competências. Não obstante, a falta de diretrizes claras e de garantia da competência da ANPD podem levar o microsistema de proteção de dados pessoais à custosa sobreposição de atuação, à multiplicidade de jurisdições e à insegurança jurídica daí decorrente aos agentes públicos e privados.

Problemas de fragmentação de *enforcement* não são novos nem desconhecidos no Brasil. A área ambiental é exemplo bastante tradicional nesse sentido, com problemas federativos ainda não equacionados. A questão da sobreposição de atuação entre agências reguladoras e órgãos e entidades de defesa do consumidor em setores regulados, idem. Mais recentemente, a elevada insegurança e o verdadeiro caos institucional gerado pela multiplicidade de atores com alegada competência nos temas relativos à legislação anticorrupção, especialmente quanto à capacidade de firmar acordos de leniência, também deixaram isso claro.

Os efeitos decorrentes de desenhos de competência mal delineados são conhecidos. De um lado, há elevado custo para a máquina pública, que não raro atua em duplicidade e se vê frequentemente às voltas com decisões judiciais que tentam

reajustar a atuação dos órgãos públicos ou evitar o *bis in idem*. De outro, há enorme insegurança ao agente privado, que também se vê às voltas com custos diretos e indiretos de ter que atuar nas mais diferentes esferas em temas idênticos.

Nesse sentido, é fundamental que a efetiva implementação da ANPD se dê o quanto antes, sob pena de potencialização dos problemas já postos. No mais, como bem indicou Ivo Corrêa em artigo recente, é essencial que o governo federal adote algumas ações básicas que, mesmo não resolvendo o problema, contribuiriam para elevar a segurança jurídica desse processo. São exemplos (i) a definição imediata da autoridade responsável pelo tema no governo federal até o efetivo funcionamento da ANPD, encarregando-a da interlocução com o setor privado, ou, ainda, (ii) a publicação de cronograma de implementação da LGPD em seus órgãos e entidades, com marcos claros que permitam avaliar sua progressão.³⁷

9. Conclusão

A criação de uma Autoridade Nacional apta a zelar pela aplicação da lei, por sua fiscalização, proteção, desenvolvimento e avaliação é passo imprescindível para a efetiva aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Elementos ausentes na sua concepção até o momento, entendemos essencial garantir sua independência, autonomia e alta *expertise* técnica, de modo a convergir com boa parte dos exemplos internacionais e, tendo em vista o cenário brasileiro, de modo a garantir um mínimo de coerência regulatória, agilidade e controle da própria atividade estatal. São esses elementos essenciais, mas não suficientes. É necessário ainda manter sua aplicação na prática cotidiana da entidade e, sobretudo, assegurar mecanismos eficazes de participação e controle social.

Em que pese acreditarmos que o veto presidencial ao texto originalmente aprovado relativo à ANPD, embora frustrante, tenha sido juridicamente correto e protetivo ao futuro da lei, o novo desenho institucional escolhido a partir da edição da MP 869/2018 e complementado pelo Congresso Nacional em seu projeto de lei de conversão subestima a magnitude das competências da ANPD e a complexidade inerente à LGPD. Impõe, na prática, enorme desafio àqueles que vierem a assumir a tarefa³⁸.

A lista de atribuições expressas no novo art. 55-J dá a dimensão das dificuldades. Em linha com boa parte das funções discutidas desde o início dos debates sobre a ANPD, há agora 24 incisos que apontam as competências mais diversas possíveis. As obrigações vão de “zelar pela proteção de dados pessoais [...]” a “fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso”, ou ainda “promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança”. Passam por competências específicas como as de “editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação[...]”, ou a de “implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei”.

Não se pode esquecer de que tais competências se desdobram no emaranhado de comandos que a LGPD prevê aos atores envolvidos no sistema nacional de proteção de dados. O atual arranjo limitado de governança deverá ser capaz de “editar normas”, “fiscalizar” e “aplicar sanções”, para ficarmos em apenas três atribuições, destinadas à correta regulação do tratamento de dados pessoais – incluindo dados sensíveis –, do tratamento de dados pelo Poder Público, da garantia dos direitos dos titulares de dados, dos deveres de controladores e operadores de tratamento de dados, bem como da definição de níveis de segurança e boas práticas quanto ao tema. Não é tarefa simples nem de rápida execução.

É, portanto, de elevado risco regulatório a instituição de uma ANPD com estrutura reduzida, criada sob o enunciado político de ausência de “aumento de despesa”, com comando de regulação de “intervenção mínima”, desenhada com limitada autonomia e independência técnica, administrativa e financeira, seja com relação aos agentes privados regulados, seja, sobretudo, com relação ao Poder Público.

O atraso em sua efetiva implementação, especialmente a partir da não indicação de nomes à diretoria para sabatina no Senado Federal, agravam sobremaneira os problemas apontados. E mais: dão espaço para que conhecidos problemas como o da fragmentação do *enforcement* se instalem com peso, força e resiliência no novo microssistema, a despeito da boa vontade daqueles que já atuam a partir das diretrizes postas na lei.

Um cenário como esse tem o condão de aumentar o grau de violações de direitos fundamentais, seja por agentes privados, seja por órgãos ou entidades públicas. Pode também significar a perda de oportunidade, impondo ao país perda de espaço no competitivo cenário global. Sem a adequada governança regulatória sobre tema tão sensível, que perpassa todos os setores da economia, perde-se não somente credibilidade relativa à garantia de direitos fundamentais como, também, a oportunidade de se criar melhor ambiente de negócio aos agentes privados que precisam de segurança jurídica, institucional e regulatória para a concretização de investimentos.

Bibliografia

ABRAMOVAY, Ricardo. **Inteligência artificial pode trazer desemprego e fim da privacidade**. Disponível em: [https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/04/1871569-inteligencia-artificial-pode-trazer-desemprego-e-fim-da-privacidade.shtml]. Acesso em 18.02.2019.

BRASIL. **A Proteção de Dados Pessoais nas Relações de Consumo: para além da informação creditícia**. Escola Nacional de Defesa do Consumidor; elaboração Danilo Doneda. – Brasília: SDE/DPDC, 2010.

CORREA, Ivo. A LGPD na Encruzilhada. Valor Econômico, Opinião. 26.02.2020. Disponível em: [https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-lgpd-na-encruzilhada.ghtml].

COUTINHO, Diogo. O Direito nas Políticas Públicas. In MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Alberto P. de (ed). **Política Pública como Campo Interdisciplinar**. São Paulo: Editora UNESP, 2013. Disponível em

[http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/item_766/14_05_12_16O_direito_nas_politicas_publicas_FINAL.pdf]. Acesso em 20 fev. 2019.

_____. **Roles of Law in Development Policies: decentralization and coordination in the Bolsa Familia program.** 2013. Disponível em: [https://media.law.wisc.edu/s/c_638/2ngrk/diogo_paper_7-17.pdf]. Acesso em 16 fev. 2019.

DONEDA, Danilo. **Da privacidade à proteção de dados pessoais.** Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

_____. *Privacidade, Vida Privada e Intimidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro.* Da emergência de uma revisão conceitual e da tutela de dados pessoais". *Âmbito Jurídico*, v. 52, 2008.

Executive Office of the President National Science and Technology Council. Committee on Technology. **Preparing for the future of Artificial Intelligence.** Disponível em: [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf] Acesso em 18 fev. 2019.

FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: balanço preliminar da MP 869/2018. **Jota**, 06.02.2019. Disponível em: [<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019>]. Acesso em 16 fev. 2019.

GALVÃO, Ilmar; GALVÃO, João Octávio Lavocat. Parecer. **Jota**, 31.07.2018. Disponível em [<https://www.jota.info/docs/ex-ministro-diz-que-nao-ha-vicio-de-inconstitucionalidade-na-criacao-da-anpd-31072018>]. Acesso: 16.02.2019.

LEMONS, Ronaldo *et al.* O Brasil Precisa de uma Autoridade de Proteção de Dados? **Jota**, 20.03.2018. Disponível em: [<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-brasil-precisa-de-uma-autoridade-de-protecao-de-dados-20032018>]. Acesso: 15.02.2019.

LODGE, Martin; WEGRICH, Wai. **Managing Regulation: regulatory analysis, politics and policy.** London: Palgrave MacMillan, 2012.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Lei de Proteção de Dados não Pode Morrer na Praia. *Folha de São Paulo, Opinião*, 20.07.2018. Disponível em: [<https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/laura-schertel-mendes-e-danilo-doneda-lei-de-protecao-de-dados-nao-pode-morrer-na-praia.shtml>]. Acesso em 24 fev. 2019.

MORGAN, Bronwen; YEUNG, Karen. **An Introduction to Law and Regulation.** Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

_____. **Cutting Red Tape: national strategies for administrative simplification.** Paris: OECD Publishing, 2006. DOI: 10.1787/9789264029798-en.

_____. **From Red Tape to Smart Tape: administrative simplification in OECD countries.** Paris: OECD Publishing, 2003. DOI: 10.1787/9789264100688-en.

_____. **OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis.** Paris: OECD Publishing, 1997. Disponível em [<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf>]. Acesso em 26 fev. 2019.

_____. **Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation.** Paris: OECD Publishing, 1995. Disponível em [[http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD\(95\)95](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95)]. Acesso em 24 fev. 2019.

PAYÃO, Felipe. Bancos, militares e Temer podem melar a Lei de Dados Pessoais no Brasil. *Tec Mundo*. Disponível em: [<https://www.tecmundo.com.br/seguranca/132337-bancos-militares-temer-melar-lei-dados-pessoais-brasil.htm>]. Acesso em 25 fev. 2019.

PAULA, Felipe de. Há Vício de Iniciativa na Criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? **Jota**, 26.07.2018. Disponível em: [<https://www.jota.info/tributos-e-empresas/regulacao/ha-vicio-de-iniciativa-na-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-26072018>]. Acesso em 16 fev. 2019.

_____. E se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não Vier? **Jota**, 11.12.2018. Disponível em [<https://www.jota.info/tributos-e-empresas/regulacao/e-se-a-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-nao-vier-11122018>]. Acesso: 17 fev. 2019.

SOUZA, Carlos Affonso. O Estado Quer Seus Dados Pessoais, mas sem Transparência ne Direitos. **Tecfront, UOL**, 10.04.2018. Disponível em: [<https://tecfront.blogosfera.uol.com.br/2018/04/10/o-estado-quer-seus-dados-pessoais-mas-sem-transparencia-nem-direitos/>]. Acesso: 16 fev. 2019.

_____. Senado vota projeto que transforma Estado em caixa-preta de dados. **Tecfront, UOL**, 08.05.2018. Disponível em: [<https://tecfront.blogosfera.uol.com.br/2018/05/08/senado-vota-projeto-que-transforma-estado-em-caixa-preta-de-dados-pessoais/?cmpid=copiaecola>]. Acesso: 16 fev. 2019.

VASCONCELOS, Beto Ferreira Martins. SILVA, Marina Lacerda e. Acordo de Leniência – A prática de um jogo ainda em andamento. In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Org.). **Colaboração Premiada.** São Paulo: Revista dos tribunais, 2018. pp 275-301.

2

Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Leiden, Holanda. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Advogado. Professor do FGVLaw.

3

Inteligência artificial pode trazer desemprego e fim da privacidade. **Folha de S. Paulo**. Disponível em: [https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/04/1871569-inteligencia-artificial-pode-trazer-desemprego-e-fim-da-privacidade.shtml]. Acesso em 16 fev. 2019.

4

Legislação de proteção de dados já é realidade em outros países. **Globo**. Disponível em: [https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/05/legislacao-de-protecao-de-dados-ja-e-realidade-em-outros-paises.html]. Acesso em 20 fev. 2019.

5

Regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeu e do conselho de 27 de abril de 2016. **EUR-Lex**. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em 18 fev. 2019.

6

Cf., por exemplo, DONEDA (2006, 2009).

7

Projeto de Lei de Conversão. PLV 12/2011 => MPV 518/2010. **Portal Câmara dos Deputados**. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=501565]. Acesso em 20 fev. 2019. Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina a formação e a consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. **Planalto**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm]. Acesso em 20 fev. 2019. Cf. também estudo feito patrocinado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (2010).

8

Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations. **The Guardian**. Disponível em: [https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance]. Acesso em 24 fev. 2019.

9

Proteção de dados pessoais. Consulta pública. **Ministério da Justiça**. Disponível em: [http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/]. Acesso em 20 fev. 2019. Anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Disponível em: [http://www.justica.gov.br/news/mj-apresenta-nova-versao-do-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-pessoais/apl.pdf]. Acesso em 20 fev. 2019.

10

Projeto de Lei nº 5276/2016. **Portal Câmara dos Deputados**. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016]. Acesso em 20 fev. 2019.

11

Para tramitação, conferir: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066 . Acesso em 11 mai. 2020.

12

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). **Planalto**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm]. Acesso em 20 fev. 2019.

13

Diogo Coutinho (2013a, 2013b) defende que o direito e, em especial, o ato normativo, apresenta distintas funções em sua relação com as políticas públicas. Em apertado resumo, o direito pode servir (i) como objetivo – dá caráter cogente às finalidades e situa a decisão política no ordenamento –, (ii) como ferramenta – apresenta meios para a consecução das finalidades –, (iii) como arranjo institucional – estrutura os desenhos institucionais que permitem a execução da política –, ou, ainda, (iv) como vocalização de demandas – cria condições de participação democrática ao longo de seu ciclo.

14

Os elementos tradicionais da atividade regulatória foram propostos por Hood *et alli*. Para histórico e desenvolvimentos recentes, cf. Lodge e Wegrich (2012) e, também, Morgan e Yeung (2007).

15

Há intenso debate atual relativo à multiplicidade de atores supostamente responsáveis pela condução e pela assinatura de acordos de leniência no âmbito da lei anticorrupção, bem como pela efetiva proteção de determinada empresa em todas as esferas em que o acordo poderia gerar efeitos. Embora com avanços recentes, o fato é que Ministérios Públicos, Cortes de Contas e diferentes órgãos do Poder Executivo travaram embate relativo ao papel de cada um, diminuindo fortemente a segurança jurídica para aqueles que se dispunham a assinar tais acordos – em especial quanto a eventuais efeitos penais a seus dirigentes.

16

Cf., por exemplo, matéria que demonstra a preocupação de pesquisadores com a alocação do órgão ou da entidade. Como explicitou Bruna Martins dos Santos ao discutir a hipótese da Polícia Federal ou da Agência Brasileira de Inteligência responderem pelo tema: “*temos as suspeitas recentes de vigilância do estado, especialmente nesse período de eleições. Então seria não só ignorar a necessidade de uma autoridade independente, como colocá-la sob as competências de órgãos que possivelmente não valorizam muito a privacidade*”. Bancos, militares e Temer podem melar a Lei de Dados Pessoais no Brasil. **Tec Mundo**. Disponível em: [https://www.tecmundo.com.br/seguranca/132337-bancos-militares-temer-melar-lei-dados-pessoais-brasil.htm]. Acesso em 25 fev. 2019.

17

O PL 5276/16, de autoria do Poder Executivo, já previa um Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, com 15 membros. A Medida Provisória n. 869 manteve a previsão com alterações em sua composição. Além de representantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Comitê Gestor da Internet, prevê, em seu texto original, a participação de 4 entidades da sociedade civil, 4 instituições científicas, tecnológicas e de inovação, além de 4 entidades empresariais.

18

ONU aprova resolução sobre o Direito à Privacidade na Era Digital. **Ministério das Relações Exteriores**. Disponível em: [http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3436-resolucao-sobre-o-direito-a-privacidade-na-era-digital]. Acesso em 18 fev. 2019.

19

Como assegurar estes direitos, garantias e deveres? – art. 50. **Ministério da Justiça**. Disponível em: [http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/eixo-de-debate/como-assegurar-estes-direitos-garantias-e-deveres/]. Acesso em 18 fev. 2019.

20

Projeto de Lei nº 5276/2016. Portal Câmara dos Deputados. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DF0E296F767C732B074E57546EAAF95F.proposicoesWebExterno2?codteor=1457459&filename=PL+5276/2016]. Acesso em 18 fev. 2019. Tramitação do Projeto de Lei nº 5276/2016 na Câmara dos Deputados. Portal Câmara dos Deputados. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378]. Acesso em 18 fev. 2019.

21

Cf., por exemplo, PL 4060/2012 (Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras providências); PLS 330/2013 (Dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso dos dados pessoais, e dá outras providências).

22

Requerimento para apensamento dos Projetos de Lei nº 4.060/2012 e 5.276/2016, por se tratar de Matérias correlatas. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DF0E296F767C732B074E57546EAAF95F.proposicoesWebExterno2?codteor=1477478&filename=Tramitacao-PL+5276/2016]. Acesso em 18 fev. 2019.

23

Ato da presidência. Câmara dos Deputados. Portal Câmara dos Deputados. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1501981&filename=Tramitacao-PL+4060/2012]. Acesso em 18 fev. 2019.

24

O “Autógrafo” é nome técnico dado ao documento com o texto de uma lei aprovada em definitivo por uma das Casas do Legislativo, ou em sessão conjunta do Congresso, posteriormente enviado à sanção.

25

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). **Planalto**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm]. Acesso em 18 fev. 2019.

26

Foram as razões de veto: “Os dispositivos incorrem em inconstitucionalidade do processo legislativo, por afronta ao artigo 61, § 1º, II, ‘e’, cumulado com o artigo 37, XIX da Constituição”. Mensagem nº 451, de 14 de agosto de 2018. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Planalto**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-451.htm]. Acesso em 18 fev. 2019.

27

Há vício de iniciativa na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? **Jota**. Disponível em: [https://www.jota.info/tributos-e-empresas/regulacao/ha-vicio-de-iniciativa-na-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-26072018]. Acesso em 18 fev. 2019.

28

Cf., por exemplo, posicionamento do ex Ministro do Supremo Tribunal Federal Ilmar Galvão e de João Octavio Lavocat Galvão. Ex-ministro diz que não há vício de inconstitucionalidade na criação da ANPD. **Jota**. Disponível em: [https://www.jota.info/docs/ex-ministro-diz-que-nao-ha-vicio-de-inconstitucionalidade-na-criacao-da-anpd-31072018]. Acesso em 18 fev. 2019.

29

Cf., por exemplo, ADI 700/RJ, Relator: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ em 24/08/2001; ADI 2867/ES, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ em 09/02/2007; e ADI 2417/SP, Relator: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ em 05/12/2003.

30

ADI 546/DF, Relator: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ em 14/04/2000; e MS 22690/CE, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ em 07/12/2006. Também são correntes, embora com exceções recentes, decisões que derrubam leis de iniciativa parlamentar que criam competências, atribuições e políticas públicas (ADI 2329/AL, ADI 2857/ES, ADI 3180/AP; como exceções recentes, com peculiaridades em cada caso, ADI 5293/SC; ARE 878911 RG/RJ; RE 290549 AgR/RJ).

31

Cf., por todos, MENDES e DONEDA (2018), em defesa que em verdade é mais de mérito e de *policy*.

32

Vale lembrar que declarações de inconstitucionalidade têm, como regra, efeitos *ex tunc*, salvo se houver modulação de efeitos tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99.

33

General Data Protection Regulation. Regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeu e do conselho de 27 de abril de 2016. **EUR-Lex**. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32016R0679]. Acesso em 18 fev. 2019.

34

Alterações apontadas por autores como Ana Frazão ([https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-balanco-preliminar-da-mp-869-2018-06022019]) e Ronaldo Lemos ([https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2019/02/lei-de-dados-deve-evitar-jabuticabas.shtml?fbclid=IwAR3HT0-1VPaRvq01bDeRkYSx_NfbHI2SBrvXqP4odHvQ2apvrlr_ClxixM]).

35

OCDE (1995, 1997, 2003, 2006).

36

Nota do Editorial: Prezado leitor, os arts. 52, 53 e 54 da LGPD receberam novo prazo de vigência (01.08.2021) após o advento da Lei 14.010/2020..

37

Disponível em: [https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-lgpd-na-encruzilhada.ghtml]. Acesso em 13.04.2020.

38

A efetiva regulação de setores imbuídos de alta e especializada tecnologia exige arranjos institucionais adequados e servidores intensivamente treinados e capacitados, como já alertava relatório preparatório para ambientes e investimentos em inteligência artificial elaborada pela Casa Branca, sob a administração de Barak Obama, em 2016. Cf. Preparing for the future of Artificial Intelligence. Executive Office of the President National Science and Technology Council. Committee on Technology. Disponível em: [https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf]. Acesso em 18 fev. 2019.

Capítulo 12. A tutela processual dos dados pessoais na LGPD

Andre Vasconcelos Roque¹

Bernardo Barreto Baptista²

Henrique de Moraes Fleury da Rocha³

1. Introdução

A Lei 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), veio para implementar verdadeira revolução na proteção dos dados pessoais no Brasil.⁴ Claramente inspirada na regulação europeia sobre o tema – *General Data Protection Regulation* (GDPR), aprovada pelo Parlamento europeu em 2016 e em vigor desde maio de 2018 –, a LGPD brasileira enuncia, entre suas finalidades, “proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” (art. 1º).

Os dados pessoais, na sociedade contemporânea, assumem importância estratégica cada vez maior. Podem ser utilizados em inúmeras aplicações, como o direcionamento de propagandas e anúncios específicos para o perfil de determinado consumidor, com base nas páginas que este visita na internet, para a identificação de preferência ideológica ou mesmo sexual, mediante análise dos gastos realizados pelo cartão de crédito, ou para a investigação de doenças com maior probabilidade de se manifestarem durante a vida de determinado indivíduo, por meio do exame de seu material genético. Os exemplos são praticamente inesgotáveis e, cada vez mais, presentes no cotidiano – basta lembrar do seu *smartphone*, que sugere trajetos para o trabalho mesmo nos feriados.

O problema nesse panorama é o risco de utilização dos dados pessoais – eventualmente colhidos sem o consentimento de seus titulares – para promover verdadeira devassa na vida privada. Ademais, não raras vezes esses dados são submetidos a tratamento por meio de algoritmos, a fim de realizar classificações, prognósticos ou mesmo julgamentos – potencialmente discriminatórios, ainda mais porque algoritmos frequentemente se baseiam em padrões passados, que podem ser resultado de alguma distorção ou de injustiças da vida social.⁵

Por outro lado, esse tipo de tratamento de dados muitas vezes terá impacto direto na vida das pessoas, que poderão ter acesso facilitado ou dificultado a crédito, empregos ou serviços. Isso sem falar da possibilidade de que os dados pessoais tenham sido colhidos de forma incompleta, estejam desatualizados ou se encontrem equivocados.⁶

Diante de todos esses riscos significativos, que vão muito além da violação à privacidade, representando ameaça a diversos outros direitos da personalidade, surge a necessidade de controle na coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, armazenamento e eliminação dos dados pessoais,⁷ o que se busca no Brasil por meio da LGPD. Trata-se de assunto recorrente em inúmeras espécies de relações – presenciais ou virtuais – que se estabelecem na sociedade, sejam elas de consumo, trabalhistas, com a Administração Pública, empresariais, entre muitas outras.

Dada a amplitude da esfera de incidência da LGPD, é intuitivo afirmar que o assunto em discussão se relaciona com muitas áreas do Direito – e as variadas perspectivas adotadas pelos artigos que compõem esta coletânea é uma eloquente evidência dessa constatação. Como não poderia deixar de ser, as repercussões da LGPD sob o aspecto processual também são variadas e dificilmente poderiam ser esgotadas em apenas um artigo. Sem embargo, propõe-se o presente trabalho a discutir os mais relevantes aspectos da tutela processual dos dados pessoais na LGPD, com especial enfoque para os seguintes temas, a serem abordados nos próximos itens: (i) competência para as medidas judiciais fundadas na lei em referência; (ii) produção de provas relativas à proteção dos dados pessoais; e (iii) tutela coletiva em juízo dos dados pessoais.

2. Competência para as medidas judiciais fundadas na LGPD

2.1. Jurisdição do Poder Judiciário brasileiro (competência internacional)

Dispõe o art. 3º da LGPD:

Art. 3º Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

- I – a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
- II – a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou
- III – os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Ademais, segundo os §§ 1º e 2º do aludido art. 3º, respectivamente, “consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta”, e “excetua-se do disposto no inciso I d[o] artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do *caput* do art. 4º d[a] Lei”.

Como se percebe, o alcance da LGPD é bastante amplo.⁸ As exceções para a sua aplicação, por sua vez, estão estabelecidas no art. 4º. Interessa ao presente trabalho, especificamente, a previsão de seu inciso IV, segundo a qual a LGPD:

[...] não se aplica ao tratamento de dados pessoais: [...] provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com

outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto n[a] Lei.

A redação do dispositivo não é das melhores. De toda maneira, de acordo com o art. 4º, IV, podemos afirmar que a LGPD não será aplicável, ainda que a operação de tratamento de dados pessoais seja realizada no território nacional (v. art. 3º, I, e § 2º), quando, além de provenientes de fora do território nacional, tais dados (i) não sejam objeto de comunicação; (ii) não sejam objeto de uso compartilhado de dados⁹ com agentes de tratamento¹⁰ brasileiros; ou (iii) não sejam objeto de transferência internacional de dados¹¹ com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto.¹²

O art. 4º, IV, da LGPD deve ser interpretado em conjunto com os artigos 21 a 25 do CPC/2015, que dispõem sobre os limites da jurisdição nacional. O assunto é de extrema relevância, uma vez que o tratamento de dados pessoais desconhece fronteiras. Daí a importância de saber as hipóteses em que o Poder Judiciário brasileiro terá jurisdição sobre a matéria quando houver algum elemento de estraneidade – por exemplo, se os dados forem armazenados fora do país.

Como é cediço, os arts. 21 e 22 do CPC/2015 versam sobre hipóteses de alcance não excludente da jurisdição brasileira, ao passo que o art. 23 do CPC/2015 busca resguardar casos de jurisdição exclusiva da autoridade judiciária brasileira.¹³

O art. 21, I, é aplicável sem qualquer ressalva para os casos abrangidos pela LGPD. Sempre, portanto, que o réu estiver domiciliado no Brasil, independentemente de sua nacionalidade, o Poder Judiciário brasileiro terá jurisdição sobre o caso. Destaque-se ainda que o art. 61 da LGPD determina que:

(...) a empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos n[a] Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.

Trata-se de medida que denota a preocupação do legislador com a duração razoável do processo, dispensando a necessidade de remessa de carta rogatória para o país da sede da empresa estrangeira.

Os incisos II e III do art. 21 do CPC/2015 são igualmente aplicáveis às questões disciplinadas pela LGPD. Quanto ao inciso II, basta pensar no caso do cumprimento de obrigação por parte do agente de tratamento com relação a dados pessoais armazenados no Brasil – por exemplo, para fins de anonimização, eliminação etc. Por outro lado, dados pessoais que tenham sido colhidos no Brasil (ainda que armazenados no exterior) poderiam ensejar a incidência do art. 21, III, do CPC/2015, sempre que a causa de pedir deduzida em juízo esteja relacionada à coleta inadequada de dados pessoais.

De forma inversa, se o fundamento da demanda disser respeito ao armazenamento indevido de dados em território nacional, o Poder Judiciário brasileiro também terá jurisdição, ainda que eles tenham sido colhidos no estrangeiro.

O art. 22 do CPC/2015 também incide sem peculiaridades, excetuada apenas a hipótese do inciso I, relativo a demandas de alimentos – inaplicável a questões relacionadas à LGPD. Perceba-se, aliás, a importância conferida pelo inciso II do art. 22 do CPC/2015 quanto à tutela do consumidor residente ou domiciliado no Brasil, especialmente nos dias atuais, em que o comércio eletrônico se tornou uma realidade, assim como muitas outras relações de consumo estabelecidas por meio da rede mundial de computadores.¹⁴

Nesses casos, nem sempre o fornecedor terá agências, filiais ou sucursais no Brasil – o que afasta a incidência do art. 21, I, do CPC/2015 –, a reforçar a importância do art. 22, II, do CPC/2015 para assegurar o acesso à justiça, visto que o consumidor muitas vezes não teria condições de suportar as despesas de uma demanda judicial em outro país.

Por fim, o art. 23 do CPC/2015, em princípio, não encontra espaço para aplicação em matéria de tutela de dados pessoais, dado que regula apenas questões relativas a imóveis, direito de sucessões e direito de família.

2.2. Competência doméstica

Dispõe o art. 18, § 1º, da LGPD que “o titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional”. O mesmo direito pode ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor (art. 18, § 8º, da LGPD).

Verifica-se, assim, que a LGPD estabeleceu procedimento administrativo específico para permitir que o titular de dados pessoais exerça seus direitos em face do controlador, o qual tramitará perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)¹⁵ – ou, facultativamente, perante o órgão de defesa do consumidor competente, em se tratando de relação consumerista.

Da mesma forma, eventuais infrações à LGPD cometidas por agentes de tratamento de dados são passíveis de sanção pela ANPD, mediante procedimento administrativo próprio (v. arts. 52, § 1º,¹⁶ e 55-J, IV),¹⁷ sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais definidas no Código de Defesa do Consumidor e em legislação específica (art. 52, § 2º).

Além disso, a LGPD prevê expressamente, em seu art. 22, que “a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva”.

Observa-se, portanto, que não foram estipuladas regras específicas de competência para as medidas judiciais fundadas na LGPD.¹⁸ Optou o legislador, ao contrário, por prestigiar a legislação existente sobre a matéria, a ser aplicada de acordo com as particularidades do caso concreto, notadamente a natureza dos direitos em discussão.

Desse modo, por exemplo, em se tratando de consumidor que pretenda responsabilizar determinado agente de tratamento de dados pessoais por danos sofridos, aplicar-se-á o regime do art. 101, I, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), podendo a demanda ser proposta no domicílio do autor.

Nessa direção, aliás, a LGPD expressamente prevê que “as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente” (art. 45).

Ainda a título de exemplo, no que tange à competência para a propositura de eventual demanda de produção antecipada de prova pelo titular de dados pessoais em face do agente de tratamento – por exemplo, para demonstrar eventual irregularidade no tratamento de dados –, deve-se aplicar o disposto no art. 381, § 2º, do CPC/2015.

No caso de relações de natureza não consumerista, incidirá a regra geral do CPC/2015, devendo ser ajuizada a demanda, em regra, perante o foro do domicílio do réu, uma vez que fundada em direito pessoal. Especialmente nos casos de demandas com pedidos indenizatórios, será competente também, à escolha do autor, o foro do lugar do ato ou fato (leia-se, local em que ocorreu o dano), nos termos do art. 53, IV, alínea “a” do CPC/2015.¹⁹

A mesma ideia se aplica a demandas que, embora não visem diretamente à tutela de dados pessoais, relacionem-se à matéria objeto da LGPD. Basta imaginar o caso de controladores e operadores solidariamente responsáveis por danos causados ao titular de dados (v. art. 42, § 1º, da LGPD). Nos termos do art. 42, § 4º, da LGPD, “aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso”. A ação de regresso, em regra, será proposta no foro de domicílio do réu.

Caso o réu seja integrante do Poder Público:

os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular [de dados pessoais][...] observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data), da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo), e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) (art. 23, § 3º, da LGPD).

Por fim, tratando-se de demanda coletiva (v. item 4, *infra*), aplicam-se as regras gerais do art. 2º da Lei 7.347/1985 e do art. 93 do CDC, os quais devem ser lidos em conjunto.²⁰ Estabelece-se, dessa maneira, a competência absoluta²¹ do lugar do dano, se este for de âmbito local, e a competência – igualmente absoluta – das capitais dos Estados e do Distrito Federal, se o dano for de âmbito regional ou nacional.

3. Direito probatório e a LGPD

Como visto, a LGPD possui abrangência bastante ampla na tutela dos dados pessoais. Apesar disso, são escassos os dispositivos da referida lei que disciplinam a questão sob o aspecto processual, sendo que as principais regras são extraídas de outros diplomas, sobretudo do CPC/2015.

Sem embargo, como será visto adiante, há na LGPD dispositivo que prevê hipótese específica de inversão do ônus da prova. Além disso, há expressa remissão à legislação consumerista, na qual, como se sabe, busca-se facilitar a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus probatório.

Devido à natureza muitas vezes precária ou volátil dos dados pessoais, cujo tratamento não é facilmente acessível ao titular, importante mecanismo para a tutela judicial dos seus direitos, embora sem remissão expressa na LGPD, é o instituto da produção antecipada de prova (art. 381 e seguintes do CPC/2015) – contando, ainda, com previsão extraordinária com fundamento no art. 22 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

3.1. Produção antecipada de prova

O art. 381 do CPC/2015 reestruturou a ação de produção antecipada de prova, não mais relegada a um simples procedimento especial cautelar, o qual pressupunha situação de urgência, normalmente relacionada ao risco de perecimento da prova. Nos termos do dispositivo citado, referida demanda ganhou autonomia, sendo admitida quando “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”, caso “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” ou, ainda, se “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

A partir daí, devido à sua autonomia com relação ao antigo processo cautelar, a doutrina passou a identificar tal medida com a tutela do direito autônomo à prova.²²

Os direitos que a LGPD visa a proteger, por sua vez, envolvem fatos não raras vezes de difícil comprovação pelo titular de dados pessoais. Nessa direção, muitos dados são obtidos e tratados internamente pelo agente de tratamento, sem que o titular tenha informações suficientes para verificar se houve alguma violação aos dispositivos da LGPD e, caso esta tenha ocorrido, para identificar qual a medida judicial mais eficiente para a tutela de seus direitos.

Assim, a produção antecipada de prova assume relevante papel à luz da LGPD,²³ na medida em que permite ao titular de dados pessoais, caso tenha motivos para acreditar que seus direitos foram ou possam vir a ser lesionados, buscar a colheita de provas antecipadamente a eventual demanda judicial, permitindo preparar substrato probatório para avaliar a pertinência do ajuizamento da demanda, evitar a instauração de litígio desnecessário ou, ainda, viabilizar a autocomposição.²⁴

A produção antecipada de prova pode se revelar fundamental, ainda, porque o titular não está em contato com os seus dados pessoais armazenados, que muitas vezes são de fácil eliminação. Dessa maneira, caso tenha motivos para desconfiar que o agente de tratamento eliminá-los-á contra o seu interesse, poderia se valer da medida em comento para, com base no inciso I do art. 381 do CPC/2015, produzir a prova necessária para demonstrar seu direito antes do seu perecimento.

Apesar de a LGPD, em si, não possuir nenhum dispositivo tratando da produção antecipada de prova, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) introduziu em nosso ordenamento um instrumento que pode ser considerado – apesar de previsto antes mesmo da promulgação do CPC/2015 – como hipótese típica de produção antecipada de prova.

Trata-se do art. 22 da aludida lei, que prevê que:

(...) [a] parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

O parágrafo único do citado dispositivo traz como exigências, “[s]em prejuízo dos demais requisitos legais”, que haja “fundados indícios da ocorrência do ilícito”, “justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória”, assim como a informação do “período ao qual se referem os registros”. Observe-se que, mesmo na vigência do CPC/1973, cuidou-se de prever uma espécie de demanda de produção antecipada de prova independentemente de urgência.

Como se vê, o próprio legislador reconheceu a dificuldade do titular em obter tais informações (registros de conexão ou registros de acesso a aplicações de internet), prevendo hipótese específica na qual o juiz deverá ordenar ao responsável pela guarda de dados o fornecimento dos registros em questão.²⁵ Cabe ainda “ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro” (art. 23 do Marco Civil da Internet).

3.2. Ônus da prova na tutela de dados pessoais

Como se sabe, o *caput* do art. 373 do CPC/2015 estabelece a distribuição tradicional (estática) do ônus da prova no processo civil: incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.²⁶

Já o § 1º traz o que a doutrina convencionou chamar de “distribuição dinâmica do ônus da prova”,²⁷ prevendo que:

(...) [n]os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do *caput* ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.²⁸

O § 2º, por sua vez, prevê que a decisão que altera a distribuição do ônus da prova “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”,²⁹ havendo ainda a possibilidade de que as partes, por convenção, distribuam diversamente o ônus, antes ou durante o processo, salvo quando a prova “recair sobre direito indisponível da parte” ou “tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito” (§§ 3º e 4º).³⁰

A distribuição do ônus da prova também tem grande relevância para os direitos tutelados pela LGPD. Conforme já exposto, muitas vezes os dados coletados são de difícil acesso ao seu titular ou, ainda, este não tem meios para, por conta própria, comprovar o seu tratamento para fins alheios ao seu consentimento, fazendo com que a distribuição tradicional – ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito – não seja suficiente para oferecer a proteção necessária.

Nesse sentido, o art. 7º da LGPD prevê que o “tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado”, entre outras hipóteses, “mediante o fornecimento de consentimento pelo titular” (inciso I). O art. 8º, por sua vez, prevê que o “consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular”, enquanto seu § 1º prevê que, “[c]aso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais”.

O relevante aqui, contudo, é o § 2º, segundo o qual “[c]abe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei”.

Ou seja, a LGPD prevê uma regra (ainda estática) específica de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao controlador o ônus de demonstrar, em eventual demanda judicial, que obteve o regular consentimento do titular para o tratamento de seus dados pessoais. Trata-se de regra especial que afasta a geral estabelecida no art. 373 do CPC/2015, a qual parte das premissas de que (i) a produção de tal prova é mais fácil para o controlador do que para o titular dos dados pessoais; e (ii) o controlador possui obrigação de guardar toda a documentação comprobatória de que obteve o regular consentimento do titular dos dados pessoais.

O § 2º do artigo 42 da LGPD traz, ainda, previsão expressa de inversão do ônus da prova, ao dispor que o “juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa”.

Referido dispositivo possui redação bastante semelhante àquela do art. 6º, VIII, do CDC, segundo o qual um dos direitos básicos do consumidor consiste na “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ao contrário da regra de redistribuição do ônus do CPC, a qual pode favorecer tanto o autor quanto o réu, a técnica da inversão do ônus da prova tem destinatários certos – o titular de dados pessoais na LGPD e o consumidor no CDC. Ou seja, a inversão do ônus da prova da LGPD e do CDC não exclui a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015 e que pode se operar até mesmo em favor do agente de tratamento.

Ademais, a interpretação consolidada em relação ao art. 6º, VIII, do CDC se mostra útil para avaliar os contornos do art. 42 da LGPD. Para que ocorra a inversão do ônus da prova, devem estar preenchidos determinados requisitos, não se cogitando de inversão automática em favor do titular dos dados pessoais.

Nessa linha, (i) as alegações do titular devem ser verossímeis sob a perspectiva do direito material;³¹ (ii) o titular de dados pessoais deve ser tecnicamente hipossuficiente para produzir a prova (não bastando, portanto, a simples discrepância econômica, financeira ou política entre as partes);³² ou (iii) embora possível, a produção da prova seria excessivamente onerosa para o titular de dados – aproximando-se esta última situação da excessiva dificuldade prevista no art. 373, § 1º, do CPC/2015.

Destaque-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não deve ser concedida liminarmente, antes mesmo da citação do réu, pois sequer se sabe nesse momento quais serão os fatos controvertidos que necessitarão ser provados em juízo.³³ Em regra, tal providência será determinada na fase de saneamento e organização do processo, aplicando-se a regra do art. 357, III, do CPC/2015, a fim de que possa a parte sobre a qual recaiu o ônus produzir a prova necessária para dele se desincumbir.³⁴

Ainda, não deve a inversão ser determinada de forma genérica contra o agente de tratamento, sem a discriminação específica do fato em relação ao qual se refere a medida, sob pena de se criar situação em que a desincumbência do encargo será impossível ou excessivamente difícil, em violação ao art. 373, § 2º, do CPC/2015.

Em outras palavras, deverá o juiz indicar explicitamente sobre qual fato recairá a inversão do ônus probatório.³⁵

Destaque-se, por fim, que a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 42, § 2º, da LGPD, é agravável de imediato, ainda que proferida em processo de conhecimento, incidindo o art. 1.015, XI, do CPC/2015, que contempla o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova.³⁶

4. Tutela coletiva dos dados pessoais

Como se viu, de acordo com o art. 22 da LGPD, a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, não só de forma individual, mas também coletivamente. Ainda, o art. 42, *caput*, da LGPD faz menção ao fato de que a violação à legislação de proteção de dados pessoais pode acarretar danos patrimoniais ou morais, inclusive coletivos. Por fim, o § 3º do mesmo artigo estabelece que as demandas de reparação por danos coletivos decorrentes da violação à proteção de dados pessoais podem ser exercidas coletivamente em juízo.

Como se percebe, não só a tutela coletiva dos dados pessoais é admitida pela legislação pertinente – notadamente, pela Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e pelos arts. 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) –, como encontra-se contemplada expressamente pela LGPD.

Evidentemente, tendo em vista os limites do presente estudo, não seria possível esgotar todos os aspectos da tutela coletiva de dados pessoais. Nada obstante, cabe aqui analisar três questões que, à primeira vista, despertam dúvidas: (i) em que categoria de direitos coletivos (difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos) se enquadraria a tutela coletiva de dados pessoais; (ii) quem seriam os legitimados para ingressar em juízo na defesa coletiva da proteção de dados pessoais; e (iii) de que forma seria cumprida uma decisão judicial que eventualmente viesse a determinar alterações estruturais no tratamento de dados pessoais.

4.1. Categorias de direitos coletivos e a LGPD

Nos termos do art. 81, parágrafo único, do CDC, a tutela coletiva será admitida quando se tratar da defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.³⁷ Em qual dessas categorias se enquadra a tutela coletiva da proteção de dados pessoais?

Os direitos difusos são caracterizados pela indivisibilidade da tutela jurisdicional postulada para sua proteção,³⁸⁻³⁹ bem como pelo fato de os seus titulares encontrarem-se vinculados apenas por circunstâncias fáticas – como residirem em uma mesma região afetada por um vazamento prejudicial de resíduos ou estarem expostos à propaganda enganosa promovida por determinado fornecedor.⁴⁰ Em razão disso, como a composição do grupo interessado na tutela de tais direitos apresenta-se instável – porque suscetível de modificação segundo as circunstâncias fáticas, como a simples mudança de domicílio de alguns de seus integrantes –, seus titulares são indeterminados e indetermináveis. Não existe aqui, portanto, relação jurídica base entre os integrantes do grupo ou com a parte contrária que proporcione alguma estabilidade à composição do grupo.

Os direitos coletivos em sentido estrito, por sua vez, são caracterizados também pela indivisibilidade, mas diferem dos direitos difusos na medida em que os titulares compartilham entre si ou com a parte contrária uma relação jurídica base independente do fato gerador da ação coletiva.⁴¹

Essa relação é responsável por conferir maior grau de estabilidade ao grupo – quando comparado com os direitos difusos –, cuja configuração não fica exposta às vicissitudes das alterações das circunstâncias fáticas. Por isso, ao contrário dos direitos difusos, seus titulares são indeterminados, mas determináveis.⁴² É o caso de ofensa, por exemplo, aos direitos de uma classe ou categoria profissional (relação jurídica base entre os membros do grupo) ou de discussão acerca da qualidade de ensino em uma escola (relação jurídica base com a parte contrária).

O sistema jurídico protege uniformemente e de modo unitário os direitos difusos e coletivos em sentido estrito,⁴³ visto que por definição a sua tutela não é passível de fracionamento.⁴⁴ É clássico o exemplo de poluição de um rio pelo despejo de resíduos: eventual ação que busque coibir a prática – sob o fundamento de ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado – afetará, da mesma maneira, todos os povos ribeirinhos. Outra não é a situação, por exemplo, se a discussão disser respeito à qualidade de ensino em determinada escola, o que trará repercussão para todos os seus alunos.

No que diz respeito aos direitos individuais homogêneos, embora exista quem tenha adotado a concepção de que tais direitos seriam materialmente coletivos,⁴⁵ tem prevalecido amplamente o entendimento de que se trata de direitos substancialmente individuais,⁴⁶ apesar de reunidos para fins de defesa processual, por expressa autorização legislativa. As razões para se autorizar a agregação de direitos essencialmente individuais em uma só ação coletiva são variadas: proporcionar acesso à justiça (já que poderia não valer a pena a tutela individual em hipóteses de pretensões pulverizadas, que não passam de alguns poucos reais), economia processual (uma vez que a tutela será prestada a inúmeras pessoas de uma só vez, racionalizando a distribuição da jurisdição e evitando o desperdício de tempo e recursos para examinar questões já resolvidas), isonomia (na medida em que todos terão uma decisão uniforme para suas pretensões individuais, promovendo maior segurança jurídica) e paridade de armas (pois a agregação de pretensões estimula a participação de entidades e profissionais capacitados em defesa do grupo, que terão uma visão global do litígio).⁴⁷

Sob tal perspectiva, os direitos individuais homogêneos são compreendidos como técnica processual, como um passaporte para que direitos individuais em sua essência possam ingressar no campo da tutela coletiva. Pelo ponto de vista estritamente material, os direitos em voga permanecem individuais, ainda que processualmente agregados.⁴⁸ Homogeneidade é somente um atributo necessário para que, verificando-se a existência de questão comum de fato ou de direito (*commonality*), sem a qual sequer faria sentido a tutela coletiva, tais direitos possam ser processados conjuntamente.

Os direitos individuais homogêneos, pois, são individuais – e, por isso, marcados pela divisibilidade, ou seja, pela possibilidade de tutela mediante processos individuais, sem que esta necessariamente repercuta sobre a esfera jurídica dos demais titulares.⁴⁹ Apesar de individuais, esses direitos podem ser tutelados conjuntamente quando tenham origem comum e se observe suficiente homogeneidade na pretensão formulada pelos diversos titulares.

A origem comum não implica necessariamente unidade factual e temporal,⁵⁰ de modo que é possível que o(s) fato(s) que gere(m) a lesão aos diversos jurisdicionados ocorra(m) em mais de um momento ou local, sem comprometer a viabilidade da tutela coletiva. Não obstante, exige-se, somada à origem comum, homogeneidade suficiente para caracterizar os direitos individuais homogêneos, como o próprio nome antecipa. É necessário que haja preponderância das questões comuns em relação às individuais para que seja possível a proteção coletiva.⁵¹ Forma-se, também quanto aos direitos individuais homogêneos, um grupo, ainda que temporário, e para os fins da tutela postulada em juízo.

O sistema de tutela coletiva brasileiro alberga, portanto, a proteção a direitos essencialmente coletivos e acidentalmente coletivos. Trata-se da célebre distinção entre a tutela de direitos coletivos (direitos coletivos em sua essência – difusos e coletivos em sentido estrito) e a tutela coletiva de direitos (individuais homogêneos).⁵²

A importância de se investigar em qual categoria encontra-se a tutela coletiva de dados pessoais, em que pese possíveis críticas à sua excessiva abstração,⁵³ está no fato de que a lei estabelece distintos regimes jurídicos para cada uma delas. Nesse sentido, por exemplo, a publicação de edital para que eventuais interessados ingressem no processo coletivo como litisconsortes (art. 94 do CDC) é prevista apenas para os direitos individuais homogêneos. Da mesma forma, o art. 103, I, II e III, do CDC disciplina diferentes regimes de coisa julgada para cada uma das categorias de direitos coletivos estabelecidas pela legislação brasileira.

Advirta-se, entretanto, ser inapropriado atribuir aprioristicamente determinada categoria de direitos coletivos a alguma matéria em abstrato – como a tutela de dados pessoais. Nem sempre, por exemplo, questões envolvendo direito ambiental acarretarão a tutela de direito difuso.⁵⁴ Basta imaginar o caso de atividades poluidoras exercidas por determinada indústria: tal ocorrência pode proporcionar, ao mesmo tempo, lesões relativas a direito difuso (para as pessoas que vivem na localidade e que titularizam o direito ao meio ambiente equilibrado), coletivo em sentido estrito (para os empregados da indústria, que podem ter sua saúde comprometida) e individual homogêneo (para os pescadores na localidade, que podem ter sua fonte de sustento comprometida pela mortandade de peixes decorrente da poluição).

O mesmo se passa com a tutela coletiva de dados pessoais, suscetível de envolver direitos difusos (por exemplo, no caso em que se pretende corrigir algum tratamento inadequado de dados pessoais, realizado por autoridades públicas, relativamente a todos os que vivem em certa localidade – tutela indivisível e sem que exista uma relação jurídica base prévia que delimite o grupo), coletivos em sentido estrito (ilustrativamente, na hipótese em que se pede a adequação do tratamento de dados pessoais realizado por uma empresa, relativamente a seus consumidores – tutela também indivisível, mas referente a uma relação jurídica de consumo base) e individuais homogêneos (por exemplo, pleito de danos morais e materiais veiculado contra certa empresa decorrente do vazamento de dados de um grupo de pessoas – tutela que poderia ser postulada em ações individuais, existindo uma origem comum para os danos alegados).

A categorização de um direito coletivo, portanto, dependerá invariavelmente da análise da causa de pedir e do pedido de tutela jurisdicional concretamente formulado.⁵⁵ Para tanto, uma vez estabelecida a existência de direito coletivo, devem ser respondidas duas perguntas fundamentais. Primeira indagação: a tutela postulada é divisível, ou seja, passível de cisão em processos individuais, sem repercutir necessariamente na esfera jurídica de outros titulares? Se a resposta for positiva, estará configurada a presença de direitos individuais homogêneos. Caso negativo, deve-se passar para a próxima pergunta, qual seja: sendo a tutela indivisível, existe alguma relação jurídica base responsável pela conformação do grupo? Caso haja, estará configurado um direito coletivo em sentido estrito. Na hipótese inversa, sendo o grupo formado por meras circunstâncias fáticas, o que existirá será um direito difuso.

4.2. Legitimados para a tutela coletiva de dados pessoais

Para saber quem são os legitimados coletivos para a tutela de dados pessoais em juízo, na ausência de regra específica na LGPD, é necessário recorrer à legislação sobre processos coletivos – notadamente, aos arts. 5º da Lei 7.347/1985 e 82 do CDC, que são os principais dispositivos sobre o assunto.⁵⁶

O Ministério Público possui legitimação para a tutela dos direitos coletivos em geral, ostentando papel relevante em matéria de proteção aos dados pessoais na esfera coletiva,⁵⁷ inclusive para a instauração de inquéritos civis e a celebração de compromissos de ajustamento de conduta.⁵⁸

A Defensoria Pública também detém legitimidade ampla, desde que a questão envolva potencialmente o interesse de hipossuficientes – não sendo necessária, todavia, a comprovação de que apenas hipossuficientes sejam beneficiados.⁵⁹ Desse modo, a Defensoria Pública poderia atuar em juízo, por exemplo, genericamente na defesa dos interesses de clientes de uma companhia telefônica, mas não em defesa dos consumidores de uma marca de automóveis de luxo.

A Administração Pública igualmente é dotada de legitimidade universal em matéria de tutela coletiva, valendo destacar que, nos termos do art. 82, III, do CDC, ela abrange até mesmo órgãos sem personalidade jurídica – o que inclui a ANPD, órgão integrante da Presidência da República (art. 55-A da LGPD, inserido pela Lei 13.853/2019).

Quanto às associações civis, para que ostentem legitimidade, devem obedecer aos requisitos da pré-constituição de um ano (o qual poderá ser dispensado pelo juiz se houver manifesto interesse social) e da pertinência temática, ou seja, a matéria

discutida na ação coletiva deve se inserir nos fins institucionais da associação (art. 5º, V e § 4º, da Lei 7.347/1985 e art. 82, IV e § 1º, do CDC). Contudo, como apontado por alguns precedentes, não podem as associações se habilitar a tutelar qualquer direito coletivo, indicando em suas finalidades institucionais a defesa genérica de todos os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, sob pena de comprometerem sua representatividade adequada.⁶⁰ Essa preocupação é ainda mais relevante na tutela coletiva dos dados pessoais, uma vez que, como apontado na introdução deste estudo, a LGPD repercute em diferentes matérias e áreas do ordenamento jurídico brasileiro.

O indivíduo, em matéria de tutela coletiva, possui legitimidade restrita à ação popular (art. 1º, caput, da Lei 4.717/1965). No entanto, dificilmente tal medida será adequada para a proteção de dados pessoais, tendo em vista que seu cabimento se limita à proteção do patrimônio público – ainda que esse seja considerado de forma ampla, abrangendo a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal), assim como os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/1965).

4.3. Decisões estruturantes e a tutela coletiva de dados pessoais

Ações coletivas em matéria de tutela de dados pessoais podem, em tese, envolver uma grande diversidade de pedidos. É possível, por exemplo, que em uma ação civil pública seja pleiteado que dados pessoais armazenados indevidamente sejam apagados, ou então que cesse a sua transmissão a outras empresas, ou ainda que os dados pessoais sejam submetidos a processo de anonimização e não possam mais ter seus titulares identificados (art. 5º, XI, da LGPD).

Pode ser, ainda, postulado o simples pagamento de uma indenização por danos morais e materiais. Todas essas são providências pontuais, que podem ser implementadas de forma relativamente simples.

A situação se complica quando forem, por exemplo, determinadas modificações estruturais na forma de tratamento de dados pessoais, principalmente nos casos em que estiver no polo passivo a Administração Pública. Nessas hipóteses, tem-se uma decisão que deve dialogar com as burocracias – estatais ou mesmo privadas. Trata-se de uma decisão estruturante, a qual busca implantar uma reforma estrutural (*structural reform*) em um ente, organização ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, realizar determinada política pública ou resolver litígios complexos – ou seja, que envolve múltiplos interesses sociais, todos dignos de tutela.⁶¹

A complexidade decorre do fato de que uma decisão estruturante possui conteúdo aberto – ostentando verdadeiro caráter normativo⁶² (por exemplo, determinação para que o tratamento de dados pessoais sensíveis seja ajustado aos limites da LGPD). Como consequência, as medidas concretas a serem tomadas, os prazos a serem observados pelo demandado e o controle de efetividade das providências realizadas necessitam ser constantemente ajustados à realidade do ente submetido à reforma estrutural.

Trata-se do que já foi denominado em doutrina de decisões em cascata,⁶³ a serem proferidas sobretudo na fase de cumprimento de sentença.

Como é impossível ao legitimado coletivo determinar, por ocasião da postulação inicial, quais serão exatamente as providências a serem adotadas para a implementação da reforma estrutural – uma vez que isso dependerá, frequentemente, de um debate com a parte contrária e com setores da sociedade –,⁶⁴ deve-se admitir a formulação de pedido genérico, na forma do art. 324, § 1º, do CPC/2015.

Há quem sustente tratar-se de atenuação da regra da congruência objetiva externa, que exige correlação entre a decisão e a demanda que ela resolve,⁶⁵ mas a questão em tela parece ser mais bem enquadrada – até porque pode ser reconduzida a um dispositivo legal – como mais uma possibilidade de formulação de pedido genérico (de reforma estrutural), cujas providências serão concretamente determinadas no curso do processo.

O fundamento legal para que sejam determinadas as medidas estruturantes reside nos arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC/2015,⁶⁶ que abrem margem para que sejam adotados meios executivos atípicos para o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer. Como já discutido em outra oportunidade,⁶⁷ os limites para essas medidas no processo civil serão os seguintes: (i) não se pode adotar meio executivo proibido pela lei (por exemplo, prisão civil); (ii) a utilização do meio executivo não pode acarretar impossibilidade do cumprimento voluntário da obrigação; (iii) o meio executivo escolhido não pode implicar sacrifício de bem jurídico mais relevante; (iv) o meio executivo empregado deve passar no teste de proporcionalidade (considerados os seus subprincípios – adequação, vedação do excesso e proporcionalidade em sentido estrito); e, por fim, (v) o meio executivo utilizado não pode implicar prejuízo a terceiros.

Para assegurar que tais limites foram observados, deve a decisão judicial que determinar a utilização de meio executivo atípico – inclusive na reforma estrutural – ser devidamente fundamentada (arts. 93, IX, da Constituição e 489, II, do CPC/2015) e submeter-se ao contraditório, ainda que excepcionalmente diferido, quando necessário para assegurar a efetividade da medida.⁶⁸ As partes, enfim, devem ser ouvidas – em regra, previamente – para a adoção de qualquer medida estruturante.

5. Conclusão

A LGPD trará profundas transformações em matéria de proteção dos dados pessoais no Brasil, acarretando impactos para inúmeras empresas, independentemente do porte econômico, e também para outras instituições não empresárias, inclusive para a Administração Pública.

Não é difícil imaginar, nessas circunstâncias, que diversas demandas judiciais venham a ser propostas com amparo na LGPD, o que reforça a importância do estudo de seus diversos aspectos processuais – assunto este que, até o momento, não recebeu a devida atenção da doutrina.

Ainda que não seja possível esgotar a temática em apenas um artigo, para os fins do presente estudo, foram selecionadas três questões mais relevantes: (i) a competência para as medidas judiciais amparadas na LGPD, tanto sob a perspectiva dos

limites da jurisdição do Poder Judiciário brasileiro quanto à luz das regras de distribuição de competência interna; (ii) a produção de provas nos processos judiciais com fundamento na LGPD, com especial destaque para o instituto da produção antecipada de prova e para a distribuição do ônus da prova; e (iii) a tutela coletiva de dados pessoais, no âmbito da qual foram verificados que espécies de direitos coletivos estariam em jogo, quem seriam os legitimados coletivos para a atuação em juízo e de que maneira poderiam ser implementadas medidas estruturantes, sobretudo na fase de cumprimento de sentença das ações coletivas relacionadas à LGPD.

Espera-se, com isso, que o presente estudo possa contribuir para a adequada compreensão dos aspectos processuais envolvidos na tutela de dados pessoais.

6. Referências bibliográficas

- ABELHA, Marcelo. *Ação civil pública e meio ambiente*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
- ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um novo ramo do direito processual*. São Paulo: Saraiva, 2003.
- AMARAL, Paulo Osternack. *Provas: atipicidade, liberdade e instrumentalidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela coletiva de interesses individuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
- ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 225, pp. 389-410, nov. 2013.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *et al.* (Org.). *Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- BENJAMIN, Antônio Herman. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a liberação judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Org.). *Processo coletivo: Do surgimento à atualidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- BENJAMIN, Antônio Herman. *Manual de direito do consumidor*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
- BRASIL JR., Samuel Meira; CUNHA, Gabriel Sardenberg. Inversão do ônus da prova e o Código de Processo Civil de 2015: retrato da distribuição dinâmica. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 283, pp. 257-284, set. 2018.
- CALDAS, Adriano; JOBIM, Marco Félix. A produção antecipada de prova e o novo CPC. In: FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix. (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015.
- CARVALHO NETO, Inacio de. *Manual de processo coletivo*. Curitiba: Juruá, 2008.
- CAVALIERI FILHO, Sérgio. *Programa de direito do consumidor*. São Paulo: Atlas, 2008.
- CUNHA, Alcides Munhoz da. Evolução das ações coletivas no Brasil. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 77, pp. 224-235, jan.-mar. 1995.
- DIDIER JR, Fredie. Produção antecipada de prova. In: MACÊDO, Lucas Buril de. *et al.* (Org.). *Novo CPC doutrina selecionada – processo de conhecimento, provas*. Salvador: Juspodivm, 2015.
- DIDIER JR, Fredie *et al.* Notas sobre as decisões estruturantes. *Civil Procedure Review*, v. 8, n. 1, pp. 46-64, jan.-apr. 2017.
- DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes *Curso de direito processual civil: processo coletivo*. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.
- FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015.
- FISS, Owen. Two models of adjudication. In: Fredie Didier Jr., Eduardo Ferreira Jordão (Org.). *Teoria do Processo – panorama doutrinário mundial*. Salvador: Juspodivm, 2007.
- FLEURY DA ROCHA, Henrique de Moraes. Cabimento do agravo de instrumento segundo o Código de Processo Civil brasileiro de 2015: aspectos polêmicos. *Revista de Processo*, v. 282, p. 299-317, ago. 2018.
- FRAZÃO, Ana. Data-driven economy e seus impactos sobre os direitos de personalidade. *Jota*, publicado em 17.7.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/data-driven-economy-e-seus-impactos-sobre-os-direitos-de-personalidade-17072018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/data-driven-economy-e-seus-impactos-sobre-os-direitos-de-personalidade-17072018). Acesso em: 26.3.2020.
- FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: principais repercussões para a atividade empresarial. *Jota*, publicado em 29.8.2018. Disponível em: [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018). Acesso em: 26.3.2020.
- GODINHO, Robson Renault. *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *A marcha do processo*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Seoul Conference 2014 – Constitution and proceedings – The Judiciary as an Organ of Political Control. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 249, pp. 19-30, nov. 2015.

GRINOVER, Ada Pellegrini. *et al. Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*: Processo Coletivo (arts. 81 a 104 e 109 a 119). Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

JOBIM, Marco Félix. *Medidas estruturantes – Da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

JOBIM, Marco Félix. A previsão das medidas estruturantes no artigo 139, IV, do novo Código de Processo Civil brasileiro. In: ZANETI JR, Hermes (Org.). *Repercussões do novo CPC – processo coletivo*. Salvador: Juspodivm, 2016.

LAUX; Francisco de Mesquita; RODRIGUES, Daniel Colnago. Antecipação da prova sem o requisito da urgência: primeiras reflexões à luz do novo CPC. In: FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015.

LEONEL, Ricardo de Barros. *Manual do Processo Coletivo*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Comentários ao art. 373. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

MACHADO, Marcelo Pacheco. Ônus estático, ônus dinâmico e inversão do ônus da prova: análise crítica do Projeto de novo CPC. *Revista de Processo*, n. 208, pp. 295-316, jun. 2012.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 1º ao 69. Vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 369 ao 380. Vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 381 ao 484. Vol. VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MAZZILI, Hugo Nigro. *A defesa dos interesses difusos em juízo*. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. *Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; ÁVILA, Henrique. Comentários ao art. 22. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER. Teresa *et al.* (Org.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MENDES, Laura Schertel; DONEDA; Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, n. 120, pp. 555-587, nov.-dez. 2018.

MENDONÇA JUNIOR, Delosmar. Requisição judicial de registro. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Org.). *Marco Civil da Internet*. São Paulo: Atlas, 2014.

MILLER, Marcello. Comentários ao art. 23. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A expressão competência funcional no art. 2º da Lei da Ação Civil Pública. In: MILARÉ, Edis (Org.). *A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Notas sobre a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, n. 22, pp. 135-149, abr.-jun. 1997.

NEGRÃO, Ricardo. *Ações coletivas: enfoque sobre a legitimidade ativa*. São Paulo: LEUD, 2004.

NERY JR, Nelson. O processo civil no Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Processo*, n. 61, pp. 24-35, jan.-mar. 1991.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. Salvador: Juspodivm, 2016.

OLIVEIRA JR, Zulmar Duarte de. Comentários aos arts. 373 e 381. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *et al. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015*. 2. ed. São Paulo: Método, 2018.

OSNA, Gustavo. *Direitos individuais homogêneos*. Pressupostos, fundamentos e aplicação no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

RAMOS, Vitor de Paula. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

ROQUE, Andre Vasconcelos. *Class actions – Ações coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles?* Salvador: Juspodivm, 2013.

ROQUE, Andre Vasconcelos. Em busca dos limites para os meios executivos atípicos: até onde pode ir o art. 139, IV do CPC/2015? In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Org.). *Repercussões do novo CPC – Medidas executivas atípicas*. Salvador: Juspodivm, 2018.

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 22. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca *et al.* *Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015*. 3. ed. São Paulo: Método, 2019.

ROQUE, Andre Vasconcelos; Duarte, FRANCISCO CARLOS. Aspectos polêmicos do mandado de segurança coletivo: evolução ou retrocesso? *Revista de Processo*, São Paulo, n. 203, pp. 39-72, jan. 2012.

SOUSA, Miguel Teixeira de. *Proteção de dados: aspectos da tutela administrativa e jurisdicional no RGPD*, publicado em 20.2.2019. Disponível em: [\[www.academia.edu/38415354/TEIXEIRA_DE_SOUSA_M._Protec%C3%A7%C3%A3o_de_dados_aspectos_da_tutela_administrativa\]](http://www.academia.edu/38415354/TEIXEIRA_DE_SOUSA_M._Protec%C3%A7%C3%A3o_de_dados_aspectos_da_tutela_administrativa) Acesso em: 26.3.2020.

TALAMINI, Eduardo. Comentários ao art. 381. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito do consumidor: direito material e processual*. Rio de Janeiro, Forense, 2012.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

VENTURI, Elton. *Processo civil coletivo: a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil, Perspectivas de um código brasileiro de processos coletivos*. São Paulo: Malheiros, 2007.

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. *Ação Civil Pública*. São Paulo: Atlas, 2001.

VIOLIN, Jordão. *Protagonismo judiciário e processo coletivo estrutural: o controle jurisdicional de decisões políticas*. Salvador: JusPodivm, 2013.

VITORELLI, Edilson. Tipologia dos litígios transindividuais: um novo ponto de partida para a tutela coletiva. In: Hermes Zaneti Jr. (Org.). *Repercussões do novo CPC – Processo Coletivo*. Salvador: Juspodivm, 2016.

VITORELLI, Edilson. Litígios estruturais: decisão e implementação de mudanças socialmente relevantes pela via processual. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Processos estruturais*. Salvador: Juspodivm, 2017.

ZAVASCKI, Teori Albino. Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos. *Revista de Processo*, São Paulo, n. 78, pp. 32-49, abr.-jun. 1995.

ZAVASCKI, Teori Albino. *Processo coletivo – Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

1

.Doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ. Professor Adjunto de Direito Processual Civil da UERJ. Sócio de Gustavo Tepedino Advogados.

2

.Mestre em Direito Processual pela UERJ. Sócio de Gustavo Tepedino Advogados.

3

.Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela PUC-RJ (Especialização). Sócio de Gustavo Tepedino Advogados.

4

.A LGPD define dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (art. 5º, I).

5

.Nesse sentido, imagine-se que um algoritmo busque correlacionar os índices de ocorrência policial em vários bairros de uma cidade com a necessidade de maior aparato policial. Após apontar os bairros com maior número de ocorrências, mais policiais são deslocados para a região, o que provavelmente fará com que se incrementem os números de ocorrências, em um verdadeiro círculo vicioso.

6

.Ana Frazão. *Data-driven economy* e seus impactos sobre os direitos de personalidade. *Jota*, publicado em 17.7.2018. Disponível em [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/data-driven-economy-e-seus-impactos-sobre-os-direitos-de-personalidade-17072018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/data-driven-economy-e-seus-impactos-sobre-os-direitos-de-personalidade-17072018). Acesso em: 26.3.2020.

7

.Tratamento de dados, nos termos do art. 5º, X, da LGPD, consiste em “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.

8

.Ana Frazão. Nova LGPD: principais repercussões para a atividade empresarial. *Jota*, publicado em 29.8.2018. Disponível em [\[www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018\]](http://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-principais-repercussoes-para-a-atividade-empresarial-29082018). Acesso em: 26.3.2020.

9

“[...] XVI – uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados” (art. 5º, XVI, da LGPD).

“[...] VI – controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; VII – operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; [...] IX – agentes de tratamento: o controlador e o operador” (art. 5º, VI, VII e IX, da LGPD).

“[...] XV – transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro” (art. 5º, XV, da LGPD). Note-se que o art. 33 da LGPD estabelece limites à transferência internacional de dados.

Compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD avaliar o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional que venha a ser destinatário de transferência internacional de dados (art. 34 da LGPD).

“O art. 23, cujo correspondente imperfeito no Código de 1973 era o art. 89, veicula os casos antes conhecidos como de ‘competência exclusiva’ da autoridade judiciária brasileira. Trata-se de óbvio contrassenso: o Brasil não tem meios de impedir que, nos casos em exame, juiz estrangeiro conheça de ação proposta em seu foro. O que a autoridade judiciária brasileira competente pode fazer, nessas condições, é negar homologação à sentença estrangeira” (Marcello Miller. Comentários ao art. 23. In: Antonio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer (Org.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 75).

ROQUE, Andre Vasconcelos. Comentários ao art. 22. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca *et al.* *Teoria Geral do Processo – Parte geral: comentários ao CPC de 2015*. 3. ed. São Paulo: Método, 2019, p. 151; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 1º ao 69*. Vol. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 404; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; ÁVILA, Henrique. Comentários ao art. 22. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa *et al.* (Org.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 128; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 48.

Sobre a importância da ANPD, é ver-se: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Comentário à nova Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): o novo paradigma da proteção de dados no Brasil. *Revista de Direito do Consumidor*, n. 120, pp. 555-587, nov.-dez. 2018.

Art. 52, § 1º, da LGPD: “As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: I – a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; II – a boa-fé do infrator; III – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; IV – a condição econômica do infrator; V – a reincidência; VI – o grau do dano; VII – a cooperação do infrator; VIII – a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei; IX – a adoção de política de boas práticas e governança; X – a pronta adoção de medidas corretivas; e XI – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção”.

Art. 55-J, IV, da LGPD: “Compete à ANPD: [...] IV – fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso”.

Situação distinta é verificada na regulação europeia sobre o tema – *General Data Protection Regulation*. Sobre o assunto, remeta-se a: Miguel Teixeira de Sousa. *Proteção de dados: aspectos da tutela administrativa e jurisdicional no RGPD*, publicado em 20.2.2019. Disponível em: [\www.academia.edu/38415354/TEIXEIRA_DE_SOUSA_M._Protec%C3%A7%C3%A3o_de_dados_aspectos_da_tutela_administrativa_e_jurisdicional_no_R Acesso em: 26.3.2020.

Nessa direção: “Estabelece-se o local do ato ou do fato para as ações indenizatórias deles decorrentes em virtude da óbvia necessidade de proximidade do processamento do feito com o cenário componente da causa de pedir para fins de escorreita instrução probatória, evitando-se, assim, a morosa e complexa utilização de cartas precatórias. Pretende-se o quanto possível aproximar o juízo da causa de pedir em prestígio à economia processual e à atribuição de maior qualidade à instrução processual, o que culmina por contribuir com a própria qualidade da jurisdição que se prestará” (ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa *et al.* (Org.). *Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 120).

Entre outros, fundamentando tal conclusão na existência de um microsistema de tutela coletiva e nas interações recíprocas entre a Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor (arts. 21 da Lei 7.347/1985 e 90 do CDC), LEONEL, Ricardo de Barros. *Manual do processo coletivo*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 277; DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. *Curso de direito processual civil: processo coletivo*. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pp. 133-134.

O art. 2º da Lei 7.347/1985 dispõe, de forma atécnica, tratar-se de competência “funcional”, o que deve ser entendido como competência territorial absoluta. Sobre o tema, MOREIRA, José Carlos Barbosa. A expressão competência funcional no art. 2º da Lei da Ação Civil Pública. In: MILARÉ, Edis (Org.). *A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 247-255.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 958; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Comentários ao art. 381. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca *et al.* *Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015*. 2. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 308; TALAMINI, Eduardo. Comentários ao art. 381. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 589; CALDAS, Adriano; JOBIM, Marco Félix. A produção antecipada de prova e o novo CPC. In: FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015, pp. 452-456.

Entendendo, contudo, que a produção antecipada de prova não se aplicaria “às hipóteses em que há um *direitomaterial* de acesso a (ou ciência de) documento, coisa ou informação (exemplos: CF, art. 5º, XXXIII, XXXIV, ‘b’, e LXXII, ‘a’; CC, art. 1.021; Lei 6.404/1976, art. 105 etc.)”, justificando que tais casos seriam “protegidos ou por mecanismos específicos (exemplo: *habeas data* – CF, art. 5º, LXXII) ou pelas vias gerais de tutela (inclusive tutela provisória – eventualmente até em caráter antecedente)”, TALAMINI, Eduardo. Comentários ao art. 381..., cit., p. 589.

THEODORO JÚNIOR, Humberto, cit., pp. 960-961; DIDIER JR., Fredie. Produção antecipada de prova. In: MACÊDO. Lucas Buril de *et al.* (Org.). *Novo CPC doutrina selecionada – processo de conhecimento, provas*. Salvador: Juspodivm, 2015, pp. 532-533; LAUX, Francisco de Mesquita; RODRIGUES,

Daniel Colnago. Antecipação da prova sem o requisito da urgência: primeiras reflexões à luz do novo CPC. In: FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015, pp. 489-490; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 381 ao 484. Vol. VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 42-43.

25

“A requisição de registros pode ser requerida incidentalmente ou em ação autônoma [...] sempre com o objetivo de formar conjunto probatório em processo jurisdicional. [...] Tem, portanto, a natureza de diligência probatória que deve seguir o procedimento previsto em lei para a formação da prova na esfera cível ou criminal. Os registros entram no processo na categoria de prova documental” (MENDONÇA JUNIOR, Delosmar. Requisição judicial de registro. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Org.). *Marco Civil da Internet*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 850).

26

Para maiores aprofundamentos acerca das regras de distribuição do ônus da prova e suas especificidades à luz do CPC/2015, veja-se, entre outros: FERREIRA, William Santos; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Grandes temas do Novo CPC – Direito probatório*. Salvador: Juspodivm, 2015; MACÊDO, Lucas Buril de et al. (Org.). *Novo CPC doutrina selecionada – processo de conhecimento, provas*. Salvador: Juspodivm, 2015.

27

AMARAL, Paulo Osternack. *Provas: atipicidade, liberdade e instrumentalidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 55; RAMOS, Vitor de Paula. Ônus da prova no processo civil: do ônus ao dever de prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 52; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Comentários ao art. 373. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 578; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Comentários ao art. 373. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. *Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença*: comentários ao CPC de 2015. 2. ed. São Paulo: Método, 2018, pp. 273-277. No entanto, para BRASIL JR., Samuel Meira; CUNHA, Gabriel Sardenberg. Inversão do ônus da prova e o Código de Processo Civil de 2015: retrato da distribuição dinâmica. *Revista de Processo*, n. 283, pp. 257-284, set. 2018, somente haveria distribuição dinâmica se não houvesse uma regra geral de distribuição estática, sendo o art. 373, § 1º do CPC/2015 melhor compreendido como mais uma hipótese de inversão do ônus da prova. No mesmo sentido, MACHADO, Marcelo Pacheco. Ônus estático, ônus dinâmico e inversão do ônus da prova: análise crítica do Projeto de novo CPC. *Revista de Processo*, n. 208, pp. 295-316, jun. 2012.

28

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 369 ao 380. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 249-250. v. VI.; THEODORO JÚNIOR, Humberto, cit., pp. 931-933.

29

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 369 ao 380..., cit., p. 249; Theodoro Júnior, HUMBERTO, cit., p. 933.

30

GODINHO, Robson Renault. *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 258; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao Código de Processo Civil*: artigos 369 ao 380..., cit., pp. 263-264; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Comentários ao art. 373..., cit., pp. 278-279; THEODORO JÚNIOR, Humberto. cit., pp. 943-944.

31

Veja-se a esse respeito: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto: Processo Coletivo (arts. 81 a 104 e 109 a 119). Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 154; BENJAMIN, Antônio Herman. *Manual de direito do consumidor*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 93; CAVALIERI FILHO, Sérgio. *Programa de direito do consumidor*. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 94-95; SOUZA, Sílvyo Capanema de. et al. *Direito do consumidor*. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 77; MIRAGEM, Bruno. *Curso de direito do consumidor*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 187.

32

Nesse sentido, TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito do consumidor: direito material e processual*. Rio de Janeiro, Forense, 2012, pp. 31-32; MIRAGEM, Bruno, *Curso de direito do consumidor*..., cit., p. 183.

33

A esse respeito, confirmam-se os seguintes precedentes: TJSP, Ap. Cív. 9075869-06.2006.8.26.0000, 20ª CDPriv., Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 13.9.2010; TJMG, AgInt. 1.0024.09.747867-1/0011, 17ª CC., Rel. Desig. Des. Marcia de Paoli Balbino, j. 11.2.2010; TRF2, Ap. Cív. 0010152-84.1999.4.02.5001, 5ª T., Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 13.7.2011.

34

Mesmo na vigência do CPC/1973, essa já era a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, após ter sido pacificada antiga divergência entre as turmas de Direito Privado naquele tribunal: “A inversão *ope judicis* do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. Recurso Especial desprovido” (STJ, REsp 802.832, 2ª S., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.4.2011). V. tb. STJ, EREsp 422.778, 2ª S., Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.2.2012.

35

“Uma observação final se impõe: a inversão se refere a fato específico, e não a quaisquer fatos que ao consumidor interesse demonstrar. Se o reconhecimento judicial do seu direito depender da constatação de uma pluralidade de fatos uns, facilmente demonstráveis; outros, não, a inversão só abrangerá aqueles que, por outros meios probatórios, não puderem ser provados de maneira adequada” (MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. Notas sobre a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, n. 22, pp. 135-149, abr./jun. 1997, p. 149).

36

Nesse sentido, considerando agravável decisão que apreciou a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, em raciocínio inteiramente aplicável à hipótese: “Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, § 1º, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica” (STJ, REsp 1.729.110, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2.4.2019). Sobre a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, permita-se a referência a: FLEURY DA ROCHA, Henrique de Moraes. Cabimento do agravo de instrumento segundo o Código de Processo Civil brasileiro de 2015: aspectos polêmicos. *Revista de Processo*, v. 282, p. 299-317, ago. 2018.

37

Art. 81, parágrafo único, do CDC: “A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo,

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.

38

“Na conceituação dos interesses ou direitos ‘difusos’, optou-se pelo critério da indeterminação dos titulares e da inexistência entre eles de relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade do bem jurídico, no aspecto objetivo” (GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.*, cit., p. 69).

39

“Difusos – como conceitua o CDC – são interesses ou direitos ‘transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato’. Os interesses difusos compreendem grupos menos determinados de pessoas (melhor do que pessoas *indeterminadas*, são antes pessoas *indetermináveis*), entre as quais inexistente vínculo jurídico ou fático preciso. São como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontrem unidas por circunstâncias de fato conexas” (MAZZILI, Hugo Nigro. *A defesa dos interesses difusos em juízo*. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 55).

40

“Assim, sendo os interesses difusos despidos de apoio em uma relação-base, com vínculo entre seus titulares decorrente de fatores conjunturais, acidentais e mutáveis, são exemplos desta ideia o fato de habitar a mesma região, consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições socioeconômicas, sujeita-se a determinados empreendimentos etc. Acabam figurando como interesses dispersos e informais à tutela de necessidades concernentes à qualidade de vida” (LEONEL, Ricardo de Barros. cit., p. 112). V. tb. CARVALHO NETO, Inacio de. *Manual de processo coletivo*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 24.

41

“A diferenciação entre as duas espécies deverá levar em conta, sim, com fulcro no art. 81, parágrafo único, I, da Lei 8.078/90, se as pessoas são ou não determinadas e se estão ligadas por meras circunstâncias de fato ou por vínculo jurídico relevante para o caso” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. *Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 219); “A característica determinante dos interesses coletivos *stricto sensu* é a indeterminação relativa dos sujeitos. A ligação entre os vários titulares coletivos decorre de uma relação jurídica-base, tais como o fato de pertencerem a uma mesma classe profissional” (CARVALHO NETO, Inacio de. cit., p. 36); “Assim, não podem as pretensões genuinamente coletivas ser identificáveis em relação a apenas alguns dos membros da classe, pois são comuns a toda uma categoria, grupo ou classe social (v.g., dos trabalhadores de determinado ramo produtivo, dos pais e alunos do sistema de ensino fundamental de certo Município, dos usuários de determinado plano de saúde). Daí deriva a natureza indivisível da pretensão coletiva” (VENTURI, Elton. *Processo civil coletivo*: a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil, Perspectivas de um código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 50).

42

“De pronto é possível identificar dois dados diferenciadores: maior limitação dos interesses coletivos, em virtude da existência do dado organizativo do grupo interessado (ausente nos difusos), e existência de uma relação jurídica embasando o liame existente entre os interessados. Estes interesses são também inerentes a pessoas indeterminadas a princípio, mas determináveis, pois o vínculo entre elas é mais sólido, decorrente de uma relação jurídica comum. Aqui também o objeto ao qual se volta o interesse é indivisível, satisfazendo a todos ao mesmo tempo, sendo todo o grupo lesado coetaneamente na hipótese de violação” (LEONEL, Ricardo de Barros. cit., p. 113). V. tb. ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Direito Processual Coletivo Brasileiro* – Um novo ramo do direito processual. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 487-488.

43

“No Brasil, o caráter essencialmente coletivo de uma demanda está relacionado com a indivisibilidade do objeto, situação esta que, se constatada, implicará no tratamento unitário, ou seja, não comportando soluções diversas para os interessados, tal qual ocorre, em situação análoga, com o litisconsórcio unitário” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. cit., p. 212).

44

“Levando-se em consideração a definição dos interesses essencialmente coletivos, percebe-se que o nosso legislador teve grande inclinação pelo critério objetivo. Pelo critério objetivo – a indivisibilidade do bem – o legislador fez crer que a necessidade individual de cada um dos titulares é irrelevante na fruição e proteção desse mesmo bem. Se o bem é indivisível, pode-se dizer que, independentemente do vínculo que possa existir entre os sujeitos titulares, o fato é que a satisfação de um sujeito implica a satisfação de todos eles. Em outros termos, significa afirmar que a indivisibilidade do bem faz com que todos os seus titulares se encontrem em posição idêntica sobre o objeto do interesse” (ABELHA, Marcelo. *Ação civil pública e meio ambiente*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 39-40).

45

.Como CUNHA, Alcides Munhoz da. Evolução das ações coletivas no Brasil. *Revista de Processo*, n. 77, pp. 224-235, jan./mar. 1995.

46

“O tratamento processual coletivo conferido a estes interesses decorre da conveniência da aplicação a eles das técnicas da tutela coletiva. Sua implementação configura opção de política legislativa. Na essência, são interesses individuais, e nada impede a demanda atomizada de cada qual dos titulares, como, v. g., obtenção de indenização a título pessoal pelos danos sofridos” (LEONEL, Ricardo de Barros. cit., p. 116). Nesse sentido, José Marcelo Menezes Vigliar destaca que são “divisíveis, cindíveis, passíveis de ser atribuídos a cada um dos interessados na proporção que sabe a cada um deles, mas que, por terem origem comum (a homogeneidade decorre dessa origem comum), são tratados coletivamente. [...] Os interesses individuais homogêneos, com o próprio nome sugere, são individuais na essência, ou seja, essa é sua natureza jurídica. Contudo, são tratados de forma coletiva, para fins de defesa em juízo, desde que portadores das características ressaltadas e desde que decorrem de origem comum” (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. *Ação Civil Pública*. São Paulo: Atlas, 2001, p. 54); Kazuo Watanabe, ao falar de direitos individuais homogêneos, afirma que estes são “individuais em sua essência, sendo coletivos apenas na forma em que são tutelados” (GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.*, cit., p. 81). No mesmo sentido: NEGRÃO, Ricardo. *Ações coletivas*: enfoque sobre a legitimidade ativa. São Paulo: LEUD, 2004, p. 253.

47

.GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.*, cit., p. 4; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. cit. 2012, pp. 31 e ss.; ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela coletiva de interesses individuais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 124-127 e Elton Venturi, cit., pp. 104 e ss.

48

.ARENHART, Sérgio Cruz. cit., p. 137 (“Olhados sob o prisma do direito material, permanecem com sua natureza própria e individual”). V. tb. GRINOVER, Ada Pellegrini. *A marcha do processo*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 20; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. cit., p. 220; BENJAMIN, Antônio Herman. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a liberação judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Org.). *Processo coletivo*: Do surgimento à atualidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 323-324; OSNA, Gustavo. *Direitos individuais homogêneos*. Pressupostos, fundamentos e aplicação no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 74 e ss.

49

“A falta de indivisibilidade é a principal característica dos interesses individuais homogêneos. Sendo possível o fracionamento, não haverá, a priori, tratamento unitário obrigatório, sendo factível a adoção de soluções diferenciadas para os interessados” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. cit., p. 220); “Ao contrário dos anteriormente citados, os interesses individuais homogêneos são divisíveis, isto é, podem ser satisfeitos ou lesados em forma diferenciada e individualizada” (CARVALHO NETO, Inacio de. cit., p. 36).

.Conforme ensina Kazuo Watanabe, a expressão “não significa, necessariamente, uma unidade factual e temporal. As vítimas de uma publicidade enganosa veiculada por vários órgãos de imprensa e em repetidos dias de um produto nocivo à saúde adquirido por vários consumidores num largo espaço de tempo e em várias regiões têm, como causa de seus danos, fatos de uma homogeneidade tal que os tornam a ‘origem comum’” (GRINOVER, Ada Pellegrini. *et al.*, cit., p. 76). V. tb.: “O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum; ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão, em que a relação jurídica entre as partes é *post facto* (fato lesivo). Não é necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar ou momento histórico, *mas que dele decorra a homogeneidade entre os direitos dos diversos titulares de pretensões individuais*” (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. cit., p. 76, grifou-se).

“A proteção coletiva dos direitos individuais deve obedecer, no entanto, aos requisitos da prevalência das questões de direito e de fato comuns sobre as questões de direito ou de fato individuais e da superioridade da tutela coletiva sobre a individual, em termos de justiça e eficácia da sentença. Assemelha-se, assim, ao previsto na legislação norte-americana para as *class actions*” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. cit., p. 221); “A *prevalência das questões comuns sobre as individuais*, que é condição de admissibilidade no sistema das ‘*class actions for damages*’ norte-americanas, também o seria no ordenamento brasileiro, que só possibilita a tutela coletiva dos direitos individuais quando estes forem *homogêneos*. Prevalendo as questões individuais sobre as comuns, os direitos individuais seriam heterogêneos e o pedido de tutela coletiva se tornaria juridicamente impossível” (GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.*, cit., pp. 133-134).

“É preciso que não se confunda defesa de direitos coletivos (e difusos) com defesa coletiva de direitos (individuais). Direito coletivo é direito transindividual (= sem titular determinado) e indivisível. Pode ser difuso ou coletivo *stricto sensu*. Já os direitos individuais homogêneos são, na verdade, simplesmente direitos subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos não desvirtua essa sua natureza, mas simplesmente os relaciona a outros direitos individuais assemelhados, permitindo a defesa coletiva de todos eles” (ZAVASCKI, Teori Albino. Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos. *Revista de Processo*, n. 78, pp. 32-49, abr./jun. 1995, p. 33). Mais recentemente, ZAVASCKI, Teori Albino. *Processo coletivo* – Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 23-51.

.Sobre o ponto, reconhecendo a excessiva abstração do direito brasileiro e sugerindo, de *lege ferenda*, que a categorização se limitasse a distinguir apenas os pedidos indivisíveis (essencialmente coletivos) dos divisíveis (acidentalmente coletivos), ROQUE, Andre Vasconcelos. *Class actions – Ações coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles?* Salvador: Juspodivm, 2013, pp. 542-545. Também nessa direção, sugerindo uma nova classificação conforme duas variáveis – (i) conflituosidade, relativa à maior ou menor uniformidade de posição dos membros do grupo diante do conflito, e (ii) complexidade, de acordo com a maior ou menor variedade de formas pelas quais o conflito pode ser resolvido – Edilson Vitorelli separa os litígios coletivos em três grupos: (i) de difusão global (por exemplo, vazamento de óleo em pequena quantidade no meio do oceano, em que todos os membros são atingidos de forma mais ou menos uniforme, praticamente não havendo interesse pessoal no conflito: (ii) de difusão local (quando a lesão ou ameaça de lesão atinge diretamente grupo de indivíduos que compartilham de uma identidade própria comum ou de uma mesma perspectiva social, por exemplo, comunidades tradicionais – Índios ou quilombolas –, minorias e trabalhadores) e (iii) de difusão irradiada (conflitos de maior complexidade, em que a lesão ou ameaça de lesão atinge diretamente os interesses de diversas pessoas ou segmentos sociais, mas essas pessoas não compõem uma comunidade, não têm a mesma perspectiva social e não serão atingidas, na mesma medida, pelo resultado do litígio, o que faz com que suas visões sejam divergentes e, não raramente, antagônicas). Veja-se em VITORELLI, Edilson. Tipologia dos litígios transindividuais: um novo ponto de partida para a tutela coletiva *in* Hermes Zaneti Jr. (Org.). *Repercussões do novo CPC – Processo Coletivo*. Salvador: Juspodivm, 2016, pp. 49-108.

“Observamos o erro metodológico utilizado por doutrina e jurisprudência para qualificação de um direito como sendo difuso, coletivo ou individual. Correntemente vê-se a afirmação de que o direito ao meio ambiente é difuso, o do consumidor é coletivo e o que o de indenização por prejuízos particulares seria individual. A afirmação não está correta nem errada. Apenas há engano na utilização do método para a definição qualificadora do direito ou interesse posto em jogo. A pedra de toque do método classificatório é o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a competente ação judicial. Da ocorrência de um mesmo fato podem originar-se pretensões difusas, coletivas e individuais. O acidente com o ‘Bateau Mouche IV’, que teve lugar no Rio de Janeiro há alguns anos, pode ensejar ação de indenização individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu (direito individual), ação de obrigação de fazer movida por associação das empresas de turismo que têm interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia (direito coletivo), bem como ação ajuizada pelo Ministério Público, em favor da vida e segurança das pessoas, para que seja interdita a embarcação a fim de se evitarem novos acidentes (direito difuso)” (NERY JR., Nelson. O processo civil no Código de Defesa do Consumidor. *Revista de Processo*, n. 61, pp. 24-35, jan./mar. 1991, p. 25).

“Por conseguinte, é de se consignar aqui o posicionamento de Nelson Nery Junior, que ressalta o engano da doutrina ao tentar classificar o direito segundo a matéria genérica, como se por exemplo, o meio ambiente fosse direito difuso e o consumidor, coletivo. Esclarece o mencionado autor que o que determina se o direito é difuso, coletivo ou individuais homogêneos é o *tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a ação*. É aqui que se aferirá o tipo de pretensão deduzida juridicamente, já que o mesmo fato poderá dar ensejo ao ajuizamento de ação com base em direito difuso, coletivo, individual homogêneo ou individual puro” (ALMEIDA, Gregório Assagra de. cit., p. 482).

.O presente artigo não abordará as controvérsias acerca da legitimação para o mandado de segurança coletivo (arts. 5º, LXX, da Constituição e 21, *caput*, da Lei 12.016/2009), muito embora tal medida processual possa eventualmente ser utilizada, especialmente contra a Administração Pública, uma vez que a tutela dos dados pessoais na esfera coletiva não traz consigo qualquer discussão específica sobre o assunto. A respeito da legitimação no mandado de segurança coletivo, ROQUE, Andre Vasconcelos; DUARTE, Francisco Carlos. Aspectos polêmicos do mandado de segurança coletivo: evolução ou retrocesso? *Revista de Processo*, n. 203, pp. 39-72, jan. 2012.

.Nesse sentido, estabelece o Enunciado 601 da Súmula do STJ, em matéria de relações de consumo: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”. Além disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em iniciativa pioneira, criou a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, que possui, entre suas atribuições, “promover a defesa dos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos titulares de dados pessoais” (art. 2º, XV, da Portaria Normativa PGJ n.º 539/2018).

.O que já vem acontecendo, mesmo na vacância da LGPD. Nesse sentido, confira-se o TAC celebrado em 16.1.2019 entre MPDFT e a Netshoes, decorrente de incidente de segurança envolvendo a base de dados dos clientes da empresa. Disponível em: [www.mpdft.mp.br/portal/pdf/tacs/espec/TAC_Espec_2019_001.pdf]. Acesso em: 26.3.2020.

.Sobre a legitimidade coletiva da Defensoria Pública, nesses termos, STF, ADI 3.943, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 7.5.2015.

.Nesse sentido: “As associações civis necessitam, portanto, ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo. Entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente genérica; não é preciso que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na hipótese concreta. [...] Essa generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado” (STJ, AgRg no REsp 901.936, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2008). V. tb.: “As finalidades estatutárias

da associação são exacerbadamente genéricas, de modo que a sua atuação poderia se dar, em princípio, em prol de todo e qualquer interesse transindividual, o que não se coaduna com o requisito da pertinência temática exigido pelo artigo 5º, V, b, da Lei nº 7347/1985. Sentença de extinção precoce do processo, com fundamento nos artigos 330, II, e 485, I, e ambos do CPC/2015, mantida. Apelação e reexame necessário desprovidos" (TJSP, Ap. Cív. 0003842-40.2014.8.26.0602, 1ª CDPúbl., Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 22.5.2018).

61

.DIDIER JR., Fredie. *et al.* Notas sobre as decisões estruturantes, *Civil Procedure Review*, v. 8, n. 1, pp. 48-49, jan./apr. 2017. Para Edilson Vitorelli, litígios estruturais são aqueles que envolvem conflitos multipolares, de elevada complexidade, cujo objetivo é promover valores públicos pela via jurisdicional, mediante transformação de uma instituição pública ou privada (VITORELLI, Edilson. Litígios estruturais: decisão e implementação de mudanças socialmente relevantes pela via processual. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Org.). *Processos estruturais*. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 372). O *leading case* sobre o tema foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso *Brown v. Board of Education*, 347 U.S. 483 (1954), o qual encerrou o sistema de segregação racial nas escolas públicas norte-americanas, determinando a aceitação da matrícula de estudantes negros numa escola até então dedicada à educação de pessoas brancas. Sobre o contexto desse paradigmático julgamento, JOBIM, Marco Félix. *Medidas estruturantes – Da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, pp. 75 e ss. Nas décadas seguintes, outros julgamentos se sucederam nos Estados Unidos, ampliando a reforma estrutural para prisões, hospitais, abrigos públicos, agências de serviço social, entre muitas outras instituições públicas, como apontado em Owen Fiss. Two models of adjudication. In: DIDIER JR., Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (Org.). *Teoria do Processo – Panorama doutrinário mundial*. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 761.

62

.Daí a noção de que uma rígida separação de poderes não se sustenta no Estado Democrático de Direito contemporâneo, como apontado por DIDIER JR., Fredie *et al.*, cit., p. 55; ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. *Revista de Processo*, n. 225, pp. 389-410, nov. 2013, p. 397. V. tb. VIOLIN, Jordão. *Protagonismo judiciário e processo coletivo estrutural: o controle jurisdicional de decisões políticas*. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 146.

63

.ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais..., cit., p. 400.

64

.Apontando a necessidade de admissão de *amicus curiae*, realização de audiências públicas e outras formas atípicas de participação nos processos estruturais, GRINOVER, Ada Pellegrini. Seoul Conference 2014 – Constitution and proceedings – The Judiciary as an Organ of Political Control. *Revista de Processo*, n. 249, pp. 19-30, nov. 2015, p. 26.

65

.DIDIER JR., Fredie *et al.*, cit., p. 56; ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais..., cit., p. 398. V. tb. VITORELLI, Edilson. Litígios estruturais..., cit., p. 411 (sustentando o afastamento de regras como a estabilização da demanda do processo estrutural, permitindo que o pedido e a decisão sejam progressivamente adequados às modificações da realidade, resguardado o contraditório).

66

.DIDIER JR., Fredie. *et al.*, cit., p. 57; JOBIM, Marco Félix. A previsão das medidas estruturantes no artigo 139, IV, do novo Código de Processo Civil brasileiro. In: ZANETI JR., Hermes. (Org.). *Repercussões do novo CPC – Processo Coletivo*. Salvador: Juspodivm, 2016, pp. 230-232.

67

.ROQUE, Andre Vasconcelos. Em busca dos limites para os meios executivos atípicos: até onde pode ir o art. 139, IV do CPC/2015? In: TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Org.). *Repercussões do novo CPC – Medidas executivas atípicas*. Salvador: Juspodivm, 2018, pp. 749-750.

68

.Sobre o ponto, confira-se a parte final do Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) – uma vez que a parte inicial não diz respeito diretamente à reforma estrutural, já que inexistem medidas tipificadas em lei para esse fim: “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.

Capítulo 13. Repercussões do RGPD sobre a responsabilidade civil

A. Barreto Menezes Cordeiro ¹

1. Introdução

I. O Direito da proteção de dados nasceu dentro das fronteiras do Direito público. A dimensão publicista originária do Direito da proteção de dados manifesta-se, por exemplo, no conteúdo dos diplomas pioneiros aprovados pelos Estados alemães na década de 70 do século passado. Aos primeiros legisladores germânicos interessava, em primeiro lugar, limitar a intervenção das entidades governativas na recolha e na utilização de dados pessoais.

Cedo, o Direito da proteção de dados rompeu com essa concepção limitadora da sua função social, assumindo-se, hoje, como um Direito eclético de base privatística.² A dimensão personalista do Direito da proteção de dados, presente na D 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, surge fortalecida no RGPD:³ o novo Regulamento europeu reconhece aos titulares de dados pessoais um conjunto novo e reforçado de direitos subjetivos;⁴ o consentimento mantém o seu papel enquanto causa principal de tratamento de dados pessoais,⁵ é mesmo a única causa de tratamento expressamente reconhecida no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.⁶ Em suma, o RGPD contribuiu, apesar das críticas crescentes de que tem sido alvo, para um aprofundamento do direito à identidade informacional.^{7 - 8}

Também o artigo 82.º ⁹ se insere nesse movimento de densificação da dimensão privatística do Direito da proteção de dados e do direito à identidade informacional. O preceito permite a responsabilização direta dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes por danos causados na esfera jurídica dos titulares de dados e na decorrência de violações do RGPD. Estamos no campo, por excelência, do Direito Privado.

II. O presente estudo pretende ser uma análise integrada do artigo 82.º. A primeira parte será dedicada a explorar os três elementos da responsabilidade civil: ilicitude, dano e nexo de causalidade. A segunda, aos sujeitos que podem recorrer a esse mecanismo e contra os quais pode ser invocado. E, por fim, na terceira parte, abordaremos alguns aspetos mais práticos, com destaque para a responsabilidade solidária e para o direito de regresso.

Daremos, ainda, especial atenção ao processo legislativo que culminou na versão final do artigo 82.º. Apenas por meio dessa apreciação é possível identificar as *rationes* subjacentes a cada um dos seus números.

2. Illicitude

I. O artigo 82.º do RGPD assume um campo de aplicação tendencialmente irrestrito, na medida em que permite as proposituras de ações de responsabilidade civil por qualquer “violação do presente regulamento” (n. 1).

Essa solução não é nova, encontrando um evidente paralelo na D 95/46/CE. O artigo 23.º/1 desse diploma admitia ações de responsabilidade civil fundadas em tratamentos ilícitos de dados, mas também em quaisquer outros atos violadores dos diplomas nacionais que transpusessem a Diretriz. O texto legal da D 95/46/CE foi aproveitado pela Comissão Europeia, na Proposta original do RGPD (Proposta): “tratamento ilícito ou outro ato incompatível com o presente regulamento”.¹⁰ Essa primeira versão passou incólume às observações promovidas pelo Parlamento Europeu, pelas várias Comissões Parlamentares, chamadas a pronunciarem-se individualmente, e pelas demais entidades europeias que emitiram pareceres sobre o RGPD.

A unanimidade foi quebrada pela Comissão, ao propor a circunscrição da responsabilidade civil ao tratamento de dados que violassem o RGPD.¹¹ Apenas a Grécia mostrou algumas reservas em relação a essa alteração.¹²

Durante as negociações tripartidas, e por insistência do Parlamento Europeu,¹³ a versão final viria a assumir, em consonância com a D 95/46/CE e com a Proposta, um alcance mais vasto, extensível a toda e qualquer violação do RGPD.

II. A versão final do artigo 82.º/1 contrasta com o conteúdo do artigo 82.º/2. Esse último preceito circunscreve (i) a responsabilidade dos responsáveis pelo tratamento aos danos causados em virtude de tratamentos em que estejam envolvidos; e (ii) a responsabilidade dos subcontratantes a duas situações concretas: pelo não cumprimento de instruções emitidas pelos responsáveis pelo tratamento ou pelo não cumprimento de obrigações legais específicas – sempre no âmbito do tratamento de dados pessoais. Da leitura desse n. 2 parece resultar que nem todas as violações do RGPD permitem acionar a responsabilidade do 82.º, mas somente as que sejam cometidas na decorrência de tratamentos de dados. Ora, as preocupações do Parlamento Europeu, assumidas por todas as partes nas discussões tripartidas, sustentam uma interpretação mais alargada: o artigo 82.º abrange tratamentos ilícitos, bem como violações de direitos, de obrigações ou de proibições legais que estejam indiretamente relacionadas com as atividades desenvolvidas pelos responsáveis e pelos subcontratantes.

III. O campo de aplicação material do artigo 82.º compreende, para além de violações dos RGPD, todos os outros tratamentos – na mesma aceção ampla – que violem os atos delegados e de execução adotados nos termos do RGPD, bem como o Direito dos Estados-Membros que dê execução a regras do RGPD.¹⁴

Por fim, o artigo 82.º não esgota os mecanismos de defesa que os lesados têm à sua disposição. Eles podem intentar ações de responsabilidade por violação de

outras disposições legais, europeias ou nacionais, ou por violação de obrigações contratuais.¹⁵

3. Danos

I. Não consta do RGPD e dos extensos considerandos que o acompanham qualquer definição de dano. Essa ausência foi especialmente evidenciada no seio do Conselho, com vários Estados-Membros indagando se o Direito da União não havia já desenvolvido e consolidado esse conceito. Na discussão que se seguiu, foram manifestadas duas posições antagónicas: (i) cabe aos Direitos internos determinar o que se entende por dano, tanto em uma perspectiva teórica como em uma perspectiva prática – posição assumida por vários Estados-Membros; e (ii) cabe ao TJUE interpretar o artigo 82.º e os conceitos aí contidos – posição assumida pela Comissão.¹⁶

À ausência de um conceito consolidado de dano, no Direito europeu, acrescem-se dois outros fatores que dificultam a aplicação do artigo 82.º: (i) a complexidade inerente à própria quantificação dos danos efetivamente causados, partilhada por todos os sistemas jurídicos; e (ii) a atribuição de competência jurisdicional aos tribunais dos Estados-Membros, para dirimir esse tipo de litígio, nos termos do artigo 82.º/6.

II. A atividade de interpretação dos tribunais dos Estados-Membros não é, todavia, livre. O RGPD estabelece algumas balizas que devem a todo o tempo ser respeitadas: (i) o conceito de dano deve ser interpretado em sentido lato, à luz da jurisprudência do TJUE;¹⁷ (ii) os objetivos do RGPD devem ser plenamente respeitados;¹⁸ e (iii) todos os danos devem ser ressarcidos,¹⁹ incluindo os danos materiais e os danos imateriais.²⁰

III. Em matéria de responsabilidade civil, o TJUE há muito que impõe, aos tribunais dos Estados-Membros, o cumprimento de dois princípios nucleares: o da equivalência e o da efetividade.²¹ O primeiro determina que os órgãos jurisdicionais nacionais, ao aplicarem Direito europeu, não podem colocar os sujeitos lesados em uma situação pior do que a que estariam se fosse aplicada uma disposição interna análoga. O segundo impede que sejam colocados entraves que obstaculizem o exercício efetivo dos direitos reconhecidos pelo Direito europeu.

Em uma perspectiva concretizadora, o valor da indemnização deve adequar-se ao prejuízo sofrido²² e compensar integralmente os danos efetivamente causados.²³ Isso mesmo é reconhecido no Considerando 146, p. 6: “Os titulares dos dados deverão ser integral e efetivamente indemnizados pelos danos que tenham sofrido”.

A decisão do tribunal deve, ainda, produzir um efeito dissuasor real sem, todavia, assumir uma função punitiva,²⁴ salvo se o Direito nacional em concreto aplicável conhecer esse tipo de sanção para situações similares.²⁵

IV. A Proposta da Comissão, no seguimento da D 95/46/CE, limitava-se a afirmar que os lesados tinham direito a ser indemnizados pelos prejuízos sofridos, sem se pronunciar, em concreto, quanto à natureza dos danos abrangidos.²⁶

Foram várias as entidades europeias, chamadas a pronunciar-se sobre a Proposta, que defenderam a expressa referência aos danos morais: o Parlamento Europeu – “inclusive de natureza não-pecuniária”;²⁷ a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores – “material ou imaterial” e “qualquer dano emocional”;²⁸ e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados – “immaterial damage or distress”.²⁹

A menção aos danos morais (danos imateriais) justifica-se plenamente, em face dos bens jurídicos acautelados pelo Direito da proteção de dados.³⁰ A sua positivação veio para pôr termo às dúvidas existentes, durante a vigência da D 95/46/CE.³¹

V. Como exemplos de danos materiais (patrimoniais), contam-se: (i) o aumento dos custos finais cobrados por um serviço prestado, na decorrência da transmissão ilícita de dados por um terceiro para o prestador;³² (ii) a não celebração de um contrato de trabalho ou o despedimento na decorrência da recolha ilícita de dados pessoais, pela entidade patronal, relativos ao candidato;³³ (iii) a utilização ilícita de dados pessoais por entidades financeiras, com um impacto negativo nas condições apresentadas ao titular, por exemplo, nos juros cobrados ou no valor do prêmio do seguro;³⁴ e (iv) a não retificação (artigo 16.º) ou o não apagamento de dados (artigo 17.º).

Quanto aos danos imateriais (morais) mais comuns, são idênticos aos conhecidos do universo do direito à intimidade da vida privada: a exposição pública não pretendida,³⁵ a ansiedade³⁶ e a discriminação daí decorrentes, a objetivação do ser humano, enquanto mero dado, ou a inibição do desenvolvimento da personalidade.³⁷

4. Causalidade

I. A responsabilidade civil por violação do RGPD apenas poderá ocorrer se entre essa violação e os danos produzidos na esfera jurídica do lesado existir um nexo de causalidade. A utilização das expressões “devido a”,³⁸ “causados pelo”³⁹ e “em virtude de”⁴⁰ é esclarecedora.

Apesar de do Considerando 146, p. 3, apenas constar o termo dano, é evidente que o conceito de causalidade deve igualmente “ser interpretado (*pelos tribunais dos Estados-Membros* ⁴¹) em sentido lato e à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça, de uma forma que reflita plenamente os objetivos do presente regulamento”.⁴² Também, nesse âmbito, devem os órgãos jurisdicionais nacionais atuar no estrito cumprimento dos princípios da equivalência e da efetividade, acima analisados.⁴³

O TJUE, sem se imiscuir das competências dos tribunais nacionais, é claro em rejeitar a necessidade de um nexo causal direto entre o dano e a violação do RGPD.⁴⁴

§ 2º Sujeitos

5. Lesados

I. O artigo 82.º/1 inicia-se com a expressão “qualquer pessoa que tenha sofrido danos”. O legislador europeu podia ter optado por utilizar os termos “qualquer titular” ou mesmo “qualquer pessoa singular”, mas não o fez. Do ponto de vista interpretativo, não pode o intérprete-aplicador ignorar a escolha dessas palavras.

Em abstrato, são possíveis, como resulta do que ora se afirmou, três interpretações distintas: o artigo 82.º pode ser invocado (i) por todas as pessoas coletivas e singulares; (ii) apenas por pessoas singulares; ou (iii) somente pelos titulares de dados visados.

A doutrina especializada alemã mostra-se dividida entre as duas últimas soluções: pessoas singulares⁴⁵ ou titulares de dados,⁴⁶ conquanto a maioria dos autores pareça inclinar-se para essa segunda hipótese. Não encontramos qualquer autor que defendesse a extensão do artigo 82.º às pessoas coletivas.

II. Os defensores da solução mais restrita – apenas os titulares dos dados podem invocar o artigo 82.º – sustentam a sua posição nos seguintes argumentos principais:⁴⁷ (i) o Considerando 146, p. 6 apenas menciona os titulares dos dados; (ii) o RGPD tem como propósito último proteger os direitos dos titulares de dados pessoais; (iii) o legislador poderia ter utilizado as expressões “pessoas singulares e coletivas”, como o fez, por exemplo, no do artigo 78.º/1, mas optou por uma expressão distinta; (iv) o n. 2 do artigo 82.º circunscreve as ações de responsabilidade a danos causados por tratamentos de dados pessoais, o que pressupõe uma ligação intrínseca entre os danos causados e o titular lesado; (v) as obrigações impostas aos responsáveis pelo tratamentos e aos subcontratantes visam proteger os interesses dos titulares de dados e não os interesses de terceiros; e (vi) a referência, no n. 2 do artigo 82.º, aos danos morais exclui, por maioria de razão, as pessoas coletivas.

III. Apesar dos ponderosos argumentos apresentados, não conseguimos acompanhar essa interpretação, pelas seguintes razões:⁴⁸ (i) se é verdade que o Considerando 146, p. 6, apenas menciona pessoas singulares, é igualmente inegável que a p. 1 do mesmo considerando refere que “o responsável pelo tratamento ou o subcontratante deverão reparar quaisquer danos de que *alguém* possa ser vítima”; (ii) os propósitos do RGPD não se circunscrevem à proteção dos dados pessoais dos titulares, o artigo 1.º é claro quanto aos objetivos prosseguidos: proteção dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o seu direito à proteção de dados pessoais e a promoção da livre circulação de dados pessoais no interior da União Europeia; (iii) no artigo 32.º/4 é utilizada a expressão “qualquer pessoa singular”, enquanto no artigo 82.º/1 é empregado “qualquer pessoa”, termo necessariamente mais genérico e abrangente; (iv) a passagem “pelos danos causados por um tratamento” (82.º/2) não exclui, só por si, danos causados a terceiros, em virtude de um tratamento, embora se reconheça que a demonstração dessa causalidade é, aqui, mais complexa e delicada; (v) o RGPD impõe, aos responsáveis e aos subcontratantes, deveres específicos para com cada titular de dados, mas também deveres genéricos, nomeadamente de organização interna, cuja imposição visa acautelar um número indeterminado de sujeitos; e (vi) da análise às várias versões

preliminares do RGPD dificilmente se pode retirar que a inclusão do termo "danos imateriais" teve como propósito excluir as pessoas coletivas do campo de aplicação do artigo 82.º/2, mas apenas esclarecer que também esses danos devem ser tidos em consideração.

Não encontramos qualquer argumento decisivo, de índole literal, sistemática, histórica ou teleológica que justifique circunscrever o artigo 82.º aos titulares de dados, pelo contrário. Tanto o texto como o espírito do RGPD apontam no sentido da proteção de todos os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares, sem exceção. Em caso de dúvida, como manifestamente parece ser o caso, cabe aos tribunais assumirem a solução que melhor acautele os direitos das pessoas singulares. Naturalmente, como já se referiu, que o preenchimento dos elementos do artigo 82.º, em especial o nexo de causalidade, são, em relação a terceiros, de mais difícil preenchimento.

Em relação às pessoas coletivas, e embora nos inclinemos para a sua exclusão, não vemos qualquer benefício em assumir essa posição em absoluto. A novidade da matéria aconselha que se aguarde pelos casos reais que vão certamente chegar aos tribunais nacionais e europeus e, só então, pesar as vantagens e as desvantagens da sua invocação.

6. Agentes prevaricadores: enquadramento

I. O recurso ao artigo 82.º está limitado a danos causados por duas categorias de sujeitos: os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes.

Essa circunscrição não impossibilita que os lesados interponham ações por violações do seu direito à identidade informacional contra outros, mas somente que não o poderão fazer por intermédio desse preceito. Poderão sempre recorrer a demais legislações europeia ou nacional.⁴⁹ No caso do Direito português, o artigo 483.º do CC apresenta-se como o caminho mais evidente.

II. Por responsável pelo tratamento entende-se, nos termos do artigo 4.º, 1), (i) a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo; (ii) que, individualmente ou em conjunto; (iii) determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.⁵⁰

O primeiro elemento deve ser interpretado de forma lata: é indiferente à natureza da pessoa – singular ou coletiva, privada ou pública –, à forma que em concreto assuma⁵¹ ou sequer se, em uma perspectiva formal, as finalidades e os meios de tratamento foram determinados pelo sujeito com as competências necessárias,⁵² i.e., pode ser um responsável de direito ou de fato. A identificação do responsável é determinante para saber a quem imputar os deveres e as responsabilidades previstas no RGPD.⁵³ No caso das pessoas coletivas, o responsável é a própria pessoa e não o funcionário ou o representante que em concreto determina as finalidades ou os meios de tratamento. Naturalmente, que contra esse funcionário ou representante podem ser invocados os mecanismos civis, criminais e contraordenacionais disponibilizados pelo sistema, em especial se se demonstrar tratar do responsável de fato.⁵⁴

No âmbito do segundo elemento, que se apresenta como um corolário lógico da realidade contemporânea e da extensão assumida pelo conceito de tratamento,⁵⁵ importa distinguir os tratamentos desenvolvidos em conjunto, *i.e.*, com as mesmas finalidades, dos tratamentos autónomos relativos aos mesmos dados pessoais. Apenas os primeiros são reconduzíveis à ideia de “conjunto”.⁵⁶

O terceiro elemento, para além do papel que assume na identificação do sujeito que efetivamente assume a posição de responsável pelo tratamento, é decisivo para a concretização de inúmeros preceitos do RGPD; p. ex.: os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, 5.º/1, *b*); o consentimento deve ser manifestado a propósito de finalidades específicas, 6.º/1, *a*); ou o titular dos dados tem o direito a conhecer as finalidades que subjazem ao seu tratamento, 15.º/1. A parte final do preceito remete-nos para a possibilidade de as finalidades serem determinadas por lei.

III. A pessoa do subcontratante – cuja definição consta do artigo 4.º, 8) – não se confunde com a do responsável pelo tratamento. Trata-se de sujeitos distintos, com autonomia jurídica e fática. De modo idêntico ao que se verifica para o responsável pelo tratamento, a natureza jurídica ou a forma assumida pelo subcontratante é irrelevante, para efeitos de aplicação do RGPD.

O subcontratante é, na realidade, um mandatário do responsável pelo tratamento, atuando por conta desse último.⁵⁷ O subcontratante desempenhará, ainda, por maioria de razão, uma função fiduciária: está obrigado a atuar sempre no melhor interesse do beneficiário da relação – o responsável pelo tratamento.⁵⁸

Nem sempre é fácil determinar se um sujeito em concreto é um responsável ou um subcontratante. Os seguintes indícios apontam no sentido da primeira categoria:⁵⁹ (i) a liberdade para utilizar os dados pessoais segundo a sua própria vontade; (ii) a conjugação dos dados recebidos com dados anteriormente já detidos; (iii) a possibilidade de utilizar os dados para outros fins que não os inicialmente estabelecidos; (iv) a recolha direta dos dados junto dos respectivos titulares; e (v) a assunção de responsabilidades autónomas pelo tratamento dos dados.

IV. Por terceiro entende-se todo aquele que não seja parte integrante de um contrato relativo a dados pessoais, ou que seja estranho ao seu processamento. À luz do artigo 4.º, 10, não são terceiros: os titulares dos dados, os responsáveis pelo tratamento, os subcontratantes e todos os demais sujeitos que se encontrem, formal ou substancialmente, na dependência ou na estrutura desses dois últimos. Apesar de, por princípio, os terceiros serem estranhos às relações sujeitas ao RGPD, o diploma atribui, pontualmente, juridicidade aos seus interesses.⁶⁰

7.A responsabilidade do responsável pelo tratamento

O responsável pelo tratamento é, nos termos da primeira parte do artigo 82.º/2, passível de ser responsabilizado desde que esteja envolvido em um tratamento que viole o RGPD. O sistema não exige que o responsável assuma um papel nuclear na produção dos danos causados, nem sequer decisivo. Na prática, o responsável pelo tratamento poderá ser responsabilizado mesmo não tendo

causado qualquer dano ao sujeito lesado. Assim, a transmissão lícita de dados para um terceiro que os processa de modo ilícito, bem com a recepção de dados obtidos ilicitamente, sem o seu conhecimento diligente, pode sustentar a responsabilidade do responsável pelo tratamento.⁶¹

Naturalmente, em ambos os casos, poderá o responsável recorrer ao número 3 do artigo 82.º.

8.A responsabilidade do subcontratante

I. A responsabilidade dos subcontratantes é uma das novidades do RGPD. O artigo 23.º da D 95/45/CE apenas previa a responsabilidade dos responsáveis pelo tratamento. A extensão da responsabilidade aos subcontratantes, que constava já da Proposta da Comissão, foi acolhida sem especiais críticas. Apenas a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia se mostrou contrária a essa solução.⁶²

II. Os subcontratantes, ao contrário do que se verifica com os responsáveis, apenas podem ser responsabilizados em duas situações concretas: (i) por violação de obrigações decorrentes do RGPD, que lhes sejam especificamente dirigidas; e (ii) por incumprimento das instruções lícitas recebidas por parte do responsável pelo tratamento.

O grosso das obrigações específicas dos subcontratantes encontra-se positivado no artigo 28.º, mas, também, sem propósitos exaustivos, nos artigos 29.º, 32.º, 37.º e 38.º. A violação desses e de outros preceitos, desde que imponham ou proíbam determinadas condutas diretamente aos subcontratantes, permitem que o sujeito lesado faça uso do mecanismo de responsabilidade civil previsto no artigo 82.º.

III. Atuando o subcontratante sempre por conta do responsável, justifica-se, por inteiro, que a sua atuação se encontre condicionada às instruções do responsável, nos termos do artigo 28.º/3, a).

O subcontratante não é, todavia, um autómato: cabe-lhe respeitar as obrigações impostas pelo RGPD e os direitos dos titulares dos dados, se necessário contrariando as instruções recebidas. De resto, o artigo 28.º/3 impõe, ao subcontratante, a obrigação de informar o responsável se considerar que as instruções violam o RGPD ou outras disposições europeias ou nacionais. O subcontratante apenas poderá ser responsabilizado se não cumprir instruções lícitas, artigo 82.º/2.

O subcontratante que, seguindo as instruções do responsável, viole o RGPD ou demais legislação extravagante poderá ser responsabilizado, desde que dessa atuação resulte a violação de uma obrigação específica.

§ 3º Aspectos probatórios

9.O afastamento da culpa

I. A Proposta da Comissão previa já a possibilidade de o responsável pelo tratamento ou o subcontratante se exonerarem da responsabilidade decorrente do artigo 82.º – então artigo 77.º –, total ou parcialmente, se provassem que o fato que causou o dano não lhes era imputável.⁶³ Pretende-se, desse modo, acautelar a posição da parte mais frágil.⁶⁴

Essa primeira versão, não modificada pelo Parlamento Europeu, foi objeto de importantes alterações no seio do Conselho: (i) foi retirada a referência ao “total ou parcialmente” – deixando, na prática, de ser admitida uma desresponsabilização meramente parcial; e (ii) a exoneração da responsabilidade apenas passa a ser admitida na medida em que se provar que o fato causador do dano não possa ser, de todo, imputável ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante.⁶⁵ Ambas as sugestões seriam, com ligeiros aperfeiçoamentos linguísticos, conservadas na versão final do RGPD.

II. A utilização, na versão portuguesa, da expressão “não é de modo algum responsável pelo evento” pode causar algumas dificuldades interpretativas, em face do preenchimento específico que o termo responsável assume no âmbito do RGPD.⁶⁶ A locução assume, aqui, o sentido de imputabilidade em tudo semelhante ao contido no artigo 799.º/1 do CC. Todavia, da mesma forma que a presunção prevista no artigo 799.º/1 do CC não consubstancia apenas uma presunção de culpa,⁶⁷ também o alcance do artigo 82.º/3 não se circunscreve a esse universo.⁶⁸ A não responsabilização, em concreto, dos responsáveis pelo tratamento ou dos subcontratantes ocorrerá sempre que consigam afastar a ilicitude e a culpa dos seus atos e omissões ou demonstrar não terem os seus comportamentos contribuído (nexo causal), de forma alguma, para a ocorrência dos danos.

Vejamos alguns exemplos: (i) um terceiro acede, ilicitamente, aos dados recolhidos, mas o responsável ou o subcontratante demonstram terem cumprido todas as regras de segurança previstas no artigo 32.º; (ii) um terceiro divulga os dados transmitidos pelo responsável, mas prova, em juízo, ter sido feito com o consentimento dos respectivos titulares e no estrito cumprimento de todas as exigências impostas pelo RGPD; ou (iii) os danos podem mesmo não poder, de todo, ser imputáveis a qualquer pessoa: *Act of God* ⁶⁹.

10. Responsabilidade solidária e direito de regresso

I. A Proposta da Comissão previa, de forma direta e inequívoca, a responsabilidade conjunta e solidária de todos os responsáveis pelo tratamento e subcontratantes envolvidos no tratamento de dados.

O Parlamento Europeu, embora concordando com essa solução, sugere um acrescento: a possibilidade de os sujeitos envolvidos no tratamento acordarem, por escrito e nos termos do então artigo 24.º – artigo 26.º da versão final do RGPD –, em uma divisão das responsabilidades.⁷⁰ Essa mesma alteração foi suportada, individualmente, pela Comissão Parlamentar da Indústria, da Investigação e da Energia.⁷¹

O texto da Proposta da Comissão seria totalmente revisto pelo Conselho que, sem qualquer razão aparente, decide afastar as expressões “conjunta e solidária”,

⁷² já com uma sólida tradição no Direito Europeu. Durante as negociações tripartidas, o Parlamento Europeu viria a concordar com a não inclusão de ambas as locuções.⁷³

II. Apesar de no texto legal não constarem as expressões “conjunta e solidária”, é manifesto ser essa a intenção do legislador, tanto à luz de uma interpretação literal como de uma interpretação teleológica. O preceito permite que um sujeito que tenha sido lesado por vários responsáveis ou subcontratantes, no âmbito do mesmo tratamento, responsabilize apenas um dos agentes.⁷⁴ Pretende-se, desse modo, acautelar a posição jurídica dos titulares dos dados, necessariamente mais frágil.

O Considerando 146, p. 8 consagra uma importante exceção ao artigo 82.º/4:

Porém, se os processos forem associados a um mesmo processo judicial, em conformidade com o direito dos Estados-Membros, a indemnização poderá ser repartida em função da responsabilidade que caiba a cada responsável pelo tratamento ou subcontratante pelos danos causados em virtude do tratamento efetuado, na condição de ficar assegurada a indemnização integral e efetiva do titular dos dados pelos danos que tenha sofrido.⁷⁵

Contudo, temos dúvidas, por se tratar de uma exceção ao texto legal não acompanhada de qualquer justificação, que esse Considerando possa ser invocado pelos tribunais nacionais.

III. O artigo 82.º/5 atribui, tanto aos responsáveis como aos subcontratantes, um direito de regresso sobre os demais agentes.

Esse preceito não constava da Proposta da Comissão nem da revisão do Parlamento Europeu. O direito de regresso foi primeiro avançado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, mas somente para os subcontratantes.⁷⁶ Coube ao Conselho sugerir a sua extensão aos responsáveis pelo tratamento.⁷⁷

11. Conclusões

O artigo 82.º introduziu importantes novidades no regime da responsabilidade civil do Direito europeu da proteção de danos: (i) os lesados podem responsabilizar diretamente os subcontratantes pelos danos causados; (ii) a exoneração da responsabilidade, pelos responsáveis ou pelos subcontratantes, tornou-se mais complicado: exige-se hoje um afastamento de qualquer relação com os danos causados (“não é de modo algum”); (iii) e o n. 4 prevê um mecanismo de responsabilidade solidária. Todas essas alterações vieram beneficiar os titulares de dados e os demais sujeitos prejudicados por violações do RGPD.

Apesar dessas evidentes melhorias, o artigo 82.º continua a demonstrar importantes fragilidades, nomeadamente, a de caber aos lesados provar o preenchimento dos três requisitos da responsabilidade civil – ilicitude, dano e nexo de causalidade – o que poderá não ser tarefa fácil, e o fato de o regime apenas cobrir os danos *per se*, não tendo qualquer função punitiva. A esses fatores, intrínsecos à própria modalidade positivada no artigo 82.º e que desincentivam a sua invocação, acresce o fato de os lesados terem à sua disposição os regimes

nacionais de responsabilidade obrigacional. Por fim, as pesadas coimas previstas no RGPD tornam as ações de responsabilidade contraordenacional mais propícias a dissuadir a repetição das atuações ilícitas.

Bibliografia

BARBOSA, Mafalda Miranda. Data controllers e data processors: da responsabilidade pelo tratamento de dados à responsabilidade civil. *RDCom*, p. 416-486, 15.03.2018.

BRINK, Stefan; WOLFF, Heinrich Amadeus (Coord.). *BeckOK Datenschutzrecht*. 25. ed. Munique: Beck, 2018.

BULL, Hans Peter. *Informationelle Selbstbestimmung – Vision oder illusion?*. 2. ed. Tübinga: Mohr Siebeck, 2011.

CORDEIRO, A. Barreto Menezes. *Relações fiduciárias: por uma doutrina unitária*, 2017 (blook).

CORDEIRO, A. Barreto Menezes. O consentimento do titular dos dados no RGPD, 3 *RDC*, p. 783-807, 2018.

CORDEIRO, A. Barreto Menezes. In: BARBOSA Mafalda Miranda; MUNIZ, Francisco (Coord.). *Responsabilidade civil do intermediário financeiro em Responsabilidade civil – Cinquenta anos em Portugal, quinze anos no Brasil*, II. Coimbra: IJ, 2018.

EHMANN; SELMAYR. *Datenschutz-Grundverordnung Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018.

FUSTER, Gloria González. *The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU*. Springer 2014.

GOLA, Peter. *Schöner Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 12. ed. Munique: Beck, 2015.

GOLA, Peter. *Datenschutz-Grundverordnung Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018.

HARTUNG, Jürgen; BÜTTGEN, Lisa. *Sanktionen und Haftungsrisiken nach der DSGVO*. WPg, 2017.

KOOPS, Bert-Japp. The trouble with European Data Protection Law. 4 *IDPL*, p. 250-261, 2014.

KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018.

LAUE, Philip; NINK, Judith; KREMER, Sascha, *Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis*. Baden-Baden: Nomos, 2017.

MONREAL, Manfred. “Der für die Verarbeitung Verantwortliche” – das unbekannte Wesen des deutschen Datenschutzrechts – Mögliche Konsequenzen aus einem deutschen Missverständnis. 4 *ZD*, p. 611-616, 2014.

PAAL; PAULY. *Datenschutz-Grundverordnung* – Bundesdatenschutzgesetz Kompakt-Kommentare. 2. ed. Munique: Beck, 2018.

PINHEIRO, Alexandre Sousa. *Privacy e proteção de dados pessoais: a construção do direito à identidade informacional*. AAFDL, Lisboa, 2015.

PLATH. *DSGVO/BDGS Kommentar*. 3. ed. Colónia: Dr. Otto Schmidt, 2018.

SIMITIS, Spiros. Introdução em Simitis. *Bundesdatenschutzgesetz*. 8. ed. Baden-Baden: Nomos, 2014.

SLOOT, Bart van der. Do Data Protection Rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation. 4 *IDPL*, p. 307-325, 2014.

SOLOVE, Daniel J. Introduction: privacy self-management and the consent dilemma. 126 *Harv L Rev*, p. 1880-1903, 2013.

SYDOW. *Europäische Datenschutzgrundverordnung*. 2. ed. Baden-Baden: Nomos, 2018.

VOIGT, Paul; BUSSCHE, Axel von dem. *The EU General Data Protection Regulation (RGPD): a practical guide*. Springer 2017.

WYBITUL, Tim; HAß, Detlef; ALBRECHT, Jan Philipp. *Abwehr von Schadensersatzansprüchen nach der Datenschutz-Grundverordnung*. NJW, 2018.

1

.Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2008), LLM pelo King's College London (2009) e Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2014). Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

2

.Sobre a evolução do Direito da proteção de dados: SIMITIS, Spiros. Introdução em Simitis. *Bundesdatenschutzgesetz*. 8. ed. Baden-Baden: Nomos, 2014; FUSTER, Gloria González. *The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU*. Springer 2014. p. 55.

3

.Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretriz 95/46/CE.

4

.Os direitos dos titulares de dados pessoais têm sido objeto de sucessivos reforços legislativos: SLOOT, Bart van der. Do Data Protection Rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation. 4 *IDPL*, 2014. p. 314 e ss.

5

.Veja-se o nosso O consentimento do titular dos dados no RGPD. 3 *RDC*, 2018. p. 783-807.

6

.Artigo 8.º/2: “Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei”.

7

.SOLOVE, Daniel J. Introduction: privacy self-management and the consent dilemma. 126 *Harv L Rev*, 2013. p. 1880-1903; KOOPS, Bert-Japp. The trouble with European Data Protection Law. 4 *IDPL*, 2014. p. 251-254.

8

.Como ponto de partida para a análise ao direito à identidade informacional: BULL, Hans Peter. *Informationelle Selbstbestimmung – Vision oder illusion?*. 2. ed. Tübinga: Mohr Siebeck, 2011. Em língua portuguesa: PINHEIRO, Alexandre Sousa. *Privacy e proteção de dados pessoais: a construção do direito à identidade informacional*. AAFDL, Lisboa, 2015.

9

.As disposições legais, não acompanhadas de fonte, correspondem a artigos do RGPD.

10

.Artigo 77.º/1 da Proposta.

11

.Conselho da União Europeia. *General Data Protection Regulation Proposal: Preparation of a General Approach*, doc. 9657/15 (*General Approach*), 11.06.2015, 244: *damage as a result of a processing which is not in compliance with this Regulation*.

12

.Ibidem, 244, Nota 594: “EL raised strong concerns that the notion of ‘unlawful processing’ as used in the 1995 Directive were not repeated here and feared that this would lower the level of protection”.

13

.Conselho da União Europeia, *General Data Protection Regulation; Written debrief on Chapter VIII*, doc. 13606/15, de 30.10.2015, 3: “The European Parliament asks to have a reference to ‘or of an action’ in Article 77(1) to have a broader scope. In order to avoid confusion with the term ‘processing’, the co-legislators tentatively agreed on a redrafting of this paragraph and refer to ‘an infringement of this Regulation’”.

14

.Considerando 146. p. 5.

15

.Considerando 146. p. 4.

16

.*General Approach*, 244, nota 592.

17

.Considerando 146. p. 3.

18

.Considerando 146. p. 3.

19

.Considerando 146. p. 1.

20

.Artigo 82.º/1.

21

.TJUE 17.11.1998, proc. C-228/96 (*Aprile*), [18]; TJUE 6-out.-2015, proc. C-228/96 (*Târşia*), [27]; TJUE 07.03.2018, proc. C-494/16 (*Santoro*), [30].

22

.TJUE 05.03.1996, proc. C-46/93 e C-48/93 (*Brasserie du pêcheur*), [90].

23

.TJUE 02.08.1993, proc. C-271/91 (*Marshall*), [26]; TJUE 17.12.2015, proc. C-407/14 (*Arjona Camacho*), [31].

24

.TJUE 10.04.1984, proc. C-14/83 (*von Colson e Kamann*), [23]; TJUE 02.08.1993, proc. C-271/91 (*Marshall*), [24]; TJUE 22.04.1997, proc. C-180/95 (*Draehmpaehl*), [25]; TJUE 17.12.2015, proc. C-407/14 (*Arjona Camacho*), [37].

25

.TJUE 13.07.2006, C-295/04 a C-298/04 (*Manfredi*), [93].

26

.*Proposta*, artigo 77.º/1.

27

.Parlamento Europeu. *Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (regulamento geral de proteção de dados)*. 21.11.2013. p. 182.

28

.Ibidem, 532.

29

.Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. *Opinion on the data protection reform package*. 07.03.2012, 44, [272].

30

.Ibidem, 44, [272].

31

.GOLA, Peter; KLUG, Christoph; KÖRFFE, Barbara. Anotação ao artigo 7 do BDSG. In: GOLA, Peter. *Schöner Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 12. ed. Munique: Beck, 2015. Rn. 12: com referências doutrinárias defensoras das duas posições: apenas danos patrimoniais ou também danos morais.

32

.NEMITZ, Paul. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: EHMANN; SELMAYR. *Datenschutz-Grundverordnung Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 12.

33

.KREßE, Bernhard. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: SYDOW. *Europäische Datenschutzgrundverordnung*. 2. ed. Baden-Baden: Nomos, 2018. Rn. 5.

34

.BERGT, Matthias. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 19.

35

.NEMITZ, Paul. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: EHMANN; SELMAYR. *Datenschutz-Grundverordnung Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 13.

36

.Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, *Opinion*, cit., p. 272.

37

.LAUE, Philip; NINK, Judith; KREMER, Sascha. *Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis*. Baden-Baden: Nomos, 2017. § 11. Rn. 6; WYBITUL, Tim; HAß, Detlef; ALBRECHT, Jan Philipp. *Abwehr von Schadensersatzansprüchen nach der Datenschutz-Grundverordnung*. NJW, 2018. p. 114.

38

.Artigo 82.º/1.

39

.Artigo 82.º/2.

40

.Considerando 146. p. 1.

41

.Artigo 82.º/6.

42

.Em idêntico sentido: BERGT, Matthias. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 41.

43

.TJUE 5-jun.-2014, proc. C-557/12 (*Kone*), [24] ss.

44

.TJUE 5-jun.-2014, proc. C-557/12 (*Kone*), [33].

45

.BERGT, Matthias. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 13-15; QUAAS, Sabine. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: BRINK, Stefan; WOLFF, Heinrich Amadeus (Coord.). *BeckOK Datenschutzrecht*. 25. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 37; LAUE, Philip; NINK, Judith; KREMER, Sascha, *Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis*. Baden-Baden: Nomos, 2017. § 11, Rn. 7.

46

.GOLA, Peter; PLITZ, Carlo. Anotação ao artigo 82.º do BDSG. In: GOLA, Peter. *Datenschutz-Grundverordnung Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 10; KREßE, Bernhard. *Anotação ao artigo 82.º do RGPD* In: SYDOW. *Europäische Datenschutzgrundverordnung*. 2. ed. Baden-Baden: Nomos, 2018. Rn. 9-11; FRENZEL, Eike Michael. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: PAAL; PAULY. *Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz Kompakt-Kommentare*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 7; BECKER, Thomas. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: PLATH. *DSGVO/BDGS Kommentar*. 3. ed. Colónia: Dr. Otto Schmidt, 2018. p. 645. Rn. 2;

HARTUNG, Jürgen; BÜTTGEN, Lisa. *Sanktionen und Haftungsrisiken nach der DSGVO*. WPg, 2017. p. 1156.

47

.KREßE, Bernhard. *Anotação ao artigo 82.º do RGPD*. In: SYDOW. *Europäische Datenschutzgrundverordnung*. 2. ed. Baden-Baden: Nomos, 2018. Autor que melhor sustenta essa posição.

48

.BERGT. *Anotação ao artigo 82.º do RGPD*. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Autor que melhor sustenta essa posição.

49

.BARBOSA, Mafalda Miranda. Data controllers e data processors: da responsabilidade pelo tratamento de dados à responsabilidade civil. *RDCom*, 15.03.2018. p. 443 ss.

50

.GT29, *Opinion 1/2010 on the concepts of “controller” and “processor”* (WP 169), 16.02.2010. p. 7 ss.; MONREAL, Manfred. “Der für die Verarbeitung Verantwortliche” – das unbekannte Wesen des deutschen Datenschutzrechts – Mögliche Konsequenzen aus einem deutschen Missverständnis. 4 *ZD*, 2014. p. 612 ss.

51

.O Considerando 22 pode aqui ser invocado.

52

.GT29, *Opinion 1/2010*, cit., p. 15.

53

.Em especial, artigos 24.º e ss.

54

.GT29, *Opinion 1/2010*, cit., p. 16.

55

.Veja-se o disposto no artigo 4.º, 2).

56

.GT29, *Opinion 1/2010*, cit., p. 18 ss.: com vários exemplos esclarecedores.

57

.Artigo 1157.º do CC: “Mandato é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais atos jurídicos por conta da outra”.

58

.CORDEIRO, A. Barreto Menezes. *Relações fiduciárias: por uma doutrina unitária*, 2017 (blook).

59

.VOIGT, Paul; BUSSCHE, Axel von dem. *The EU General Data Protection Regulation (RGPD): a practical guide*. Springer 2017. p. 19.

60

.Artigos 6.º/1, f); 13.º/1, d) ou 14.º/2, d).

61

.FRENZEL, Eike Michael. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: PAAL; PAULY. *Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz Kompakt-Kommentare*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 13.

62

.*Relatório*, cit., p. 400.

63

.Artigo 77.º/3 da Proposta.

64

.BARBOSA Mafalda Miranda. Data controllers e data processors: da responsabilidade pelo tratamento de dados à responsabilidade civil. *RDCom*, 15.03.2018. p. 432.

65

.*General Approach*, cit., p. 245.

66

.Essa dificuldade é partilhada, de forma algo mitigada, pela versão alemã: BERGT, Matthias. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 49; FRENZEL, Eike Michael. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: PAAL; PAULY. *Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz Kompakt-Kommentare*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 15.

67

.Veja-se, sobre esse ponto, o nosso Responsabilidade civil do intermediário financeiro. In: BARBOSA Mafalda Miranda; MUNIZ, Francisco (Coord.). *Responsabilidade civil do intermediário financeiro em Responsabilidade civil – Cinquenta anos em Portugal, quinze anos no Brasil*, II. Coimbra: IJ, 2018.

68

.A maioria da doutrina alemã tende a resumir o artigo 82.º/3 a um problema de culpa: BERGT, Matthias. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: KÜHLING; BUCHNER. *Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar*. 2. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 51 ss.; QUAAS, Sabine. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: BRINK, Stefan; WOLFF, Heinrich Amadeus (Coord.). *BeckOK Datenschutzrecht*. 25. ed. Munique: Beck, 2018. Rn. 17. Com posição idêntica à por nós defendida: KREßE, Bernhard. Anotação ao artigo 82.º do RGPD. In: SYDOW. *Europäische Datenschutzgrundverordnung*. 2. ed. Baden-Baden: Nomos, 2018. Rn. 18.

69

.Considerando 55 da D 95/46/CE: “força maior”.

70

.*Relatório*, cit., p. 183.

71

.*Relatório*, cit., p. 400.

72

.*General Approach*, cit., p. 245.

73

.Conselho da União Europeia. *General Data Protection Regulation: Chapter VIII*, doc. 12965/15, 16.10.2015. p. 3.

74

.Considerando 146, p. 7.

75

.Sugerido pelo Reino Unido: *General Approach*, cit., p. 245, nota 596.

76

.*Relatório*, cit., p. 640.

77

.*General Approach*, cit., p. 245.

Capítulo 14. Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e a Lei Geral brasileira de Proteção de Dados: mapeando convergências na direção de um nível de equivalência

Bruno R. Bioni ¹

Laura Schertel Mendes ²

1. Introdução

Historicamente, a agenda de padronização de normas é um elemento que se confunde com a própria gênese das leis gerais de proteção de dados pessoais. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico/OCDE e o Conselho da Europa/CoE, ao formularem, respectivamente, diretrizes e uma convenção internacional, pautaram toda a produção normativa que lhes é posterior. É, por isso, que se experimentou um alto de grau de convergência das leis de proteção de dados pessoais ao redor do mundo, uma vez que estão estruturadas sobre fundações comuns e fincadas desde o início da década de 1980.

Hoje, no entanto, vive-se um momento singular de uma nova ebulição regulatória. Organismos internacionais como a própria OCDE e o CoE, blocos regionais como a União Europeia/UE e diversos países estão modernizando ou editando, pela primeira vez, suas leis de proteção de dados pessoais. Tais variações normativas abrem necessariamente uma nova rodada de discussão sobre o nível de convergência dessas normas recentemente promulgadas.

Esse é exatamente o caso brasileiro e europeu. Ambos passaram recentemente por um (re)ajuste de suas infraestruturas regulatórias, o que aconteceu no curto espaço de tempo dos últimos 02 (dois) anos. Em 2016, a UE aprovou o Regulamento de Proteção de Dados/RGPD em substituição à antiga diretiva de meados da década de 1990. Por sua vez, o Brasil editou, em agosto de 2018, a sua primeira Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Nesse contexto, o presente artigo se presta a mapear convergências entre as leis brasileira e europeia com o objetivo de fornecer critérios de análise para uma futura decisão de adequação por ambos os lados. Alerta-se, por isso, que o texto não se presta a uma mera entabulação da LGPD e do RGPD, mas, pelo contrário, a alçar diretrizes capazes de fazer uma radiografia estrutural a seu respeito.

Em vista de que tais normas foram talhadas com técnicas legislativas completamente distintas, tal exercício mostra-se ainda mais pertinente. Eventual nível de equivalência deve ser calibrado por uma análise qualitativa, e não quantitativa. Ao partir desse racional, o artigo conclui que: i) a investigação em torno da convergência de regimes regulatórios passa a ser cada vez mais orientada por qual é a racionalidade regulatória que estrutura o seu corpo normativo; e, ii) diante da proeminência do princípio da *accountability*, acoplado a ferramentas de correção, o arranjo institucional e a atuação das autoridades de proteção de dados tornam-se ainda mais relevantes para verificar a aproximação do nível de proteção de dados.

2. Instrumentos de direito internacional e convergência regulatória: uma tensão permanente no campo da proteção de dados

Ao fazer uma radiografia sobre a convergência regulatória no campo da proteção de dados pessoais, o cientista político Colin Bennett não só fornece um quadro analítico composto por quatro possíveis forças motoras mas também, e principalmente, pistas de que, historicamente, a agenda de padronização normativa é um elemento que se confunde com a própria gênese da arena regulatória em si.³ Nesse sentido, o jurista Viktor Mayer-Schönberger, em outro texto igualmente com perfil analítico-histórico, dá grande ênfase à atuação de organismos internacionais, como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico/OCDE e a Convenção Internacional de Proteção de Dados Pessoais, ao longo do progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais.⁴

Por essa razão, chama a atenção o curto espaço de tempo entre a elaboração dos *Fair Information Practice Principles/FIPPs* pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar do governo estadunidense em 1973 (subitem *infra* 3.2.1),⁵ a elaboração das diretrizes sobre privacidade da OCDE em 1980⁶ e a abertura para adesões à Convenção Internacional de Proteção de Dados do Conselho da Europa em 1981.⁷ Tão importante quanto notar esse desdobramento histórico, é o diagnóstico de que tais instrumentos internacionais mencionados foram impulsionados como vetores para integração econômica entre seus países aderentes.

No que diz respeito à OCDE, as *guidelines* são intituladas para a “proteção da privacidade e do fluxo transfronteiriço de dados pessoais”. Nota-se, portanto, que as normas em questão são nomeadas com vistas a atingir dois objetivos de forma concomitante. Em linha similar, para potencializar o livre⁸ fluxo informacional, a Convenção Internacional 108 estabelece, como regra, a *proibição* de que os países signatários imponham restrições uns aos outros, sob o argumento puro e abstrato da proteção da privacidade, no que diz respeito à transferência internacional de dados.⁹ Portanto, a penetração de padrões internacionais é, em grande medida, resultado da pressão pela criação de regimes jurídicos interoperáveis, como deixam transparecer o texto da Convenção Internacional e a própria nomenclatura das diretrizes da OCDE.

O país ou bloco econômico que não incorporasse tais padrões internacionais poderia ser penalizado com a sua não inclusão no mapa global de livre fluxo de

dados. Nesse sentido, a emergência de leis nacionais e regionais, em sua grande maioria,¹⁰ veio acompanhada de regras duras sobre transferência internacional, o que, em princípio, somente seria possível se o país destinatário tivesse um nível equivalente de proteção. É o que até hoje se costuma referenciar se um país possui ou não um nível adequado de proteção de dados, cuja análise se equaciona com base nos referidos padrões internacionais. Em vista de que tais instrumentos internacionais antecederam muitas das leis nacionais de proteção de dados pessoais, reforça-se, mais uma vez, o indicativo que o fenômeno de convergência regulatória se confunde em si com a própria disseminação e produção normativa sobre proteção de dados pessoais.¹¹

Décadas depois, principalmente a partir dos anos 2000, após a emergência e consolidação de tais padrões internacionais, atestada por um alto nível de convergência entre leis de proteção de dados pessoais ao redor do mundo,¹² depara-se com uma nova movimentação em busca de facilitar o livre fluxo de dados.

Em 2005, o fórum para Cooperação Econômica Ásia-Pacífico/APEC estabeleceu um sistema de certificação para transferência internacional – Regras Transfronteiriças de Privacidade/CBPR, pelo qual organizações poderiam aderir voluntariamente a tais regras, sendo certificados os seus respectivos programas de conformidade para viabilizar transferência internacional de dados entre os países que fazem parte do programa. Em 2015, a APEC editou um conjunto de diretrizes sobre proteção de dados buscando a criação de padrões normativos “interoperáveis” com o objetivo de reforçar o fluxo transfronteiriço de dados.

Em 2013 e em 2018, respectivamente, OCDE e CoE revisitaram suas normas de proteção de dados, passando a prever ou reforçar a importância de compromissos voluntários por parte das organizações para fins de transferência internacional. Como uma válvula de escape ao sistema que averiguava e se o país destinatário teria um nível equivalente de proteção de dados, selos e códigos de boas condutas passaram a compor um cardápio mais amplo de opções para destravar o livre fluxo de dados. Nota-se, inclusive, um movimento semelhante no cenário brasileiro e da União Europeia acerca do alargamento da caixa de ferramentas para fins de transferência internacional¹³:

OCDE 2013	CoE 2018	EU 2016	Brasil 2018
Ao destacar a importância dos programas corporativos de privacidade, acaba por interligá-los ao movimento da APEC, CBPRs, que respalda a transferência	Ao prever que a transferência internacional de dados poderá se dar de forma <i>ad hoc</i> ou mediante salvaguardas padronizadas por meio de instrumento vinculante por	Enquanto a diretiva reconhecia apenas expressamente cláusulas contratuais-padrão como um compromisso voluntário para respaldar	Selos e códigos de boas condutas não constavam na versão do então anteprojeto de lei, tendo sido incorporados somente no desenho final da lei aprovada no

internacional de dados em compromissos voluntários firmados pelas organizações e certificados por terceiros	parte, o novo texto da Convenção abre espaço para que códigos de boas condutas e selos sejam veículos para transferência internacional de dados	transferência internacional, o Regulamento previu também códigos de boas condutas e selos	Congresso Nacional
---	---	---	--------------------

Em síntese, desde a década de 1980, há uma tensão permanente em se arquitetarem arranjos normativos a âmbito regional e transnacional, convergentes, que não restrinjam o fluxo de informações transfronteiriço. As últimas gerações de leis de proteção de dados pessoais reforçaram essa tônica ao ampliarem os mecanismos pelos quais se pode ativar a transferência internacional de dados, criando ou reforçando válvulas de escape com base em compromissos privados de organizações que dependem desse livre-trânsito de dados para suas operações.

Cabe investigar se, diante desse novo cenário, abre-se uma nova agenda de investigação em torno de uma nova rodada de convergência regulatória, principalmente quando se nota um movimento que vai além dos FIPPs e, no contexto brasileiro e europeu, há, em perspectiva, normas talhadas com técnicas legislativas bastante distintas.

3.LGPD vs. RGPD: desafios e perspectivas para uma análise de equivalência

3.1.Divergência na técnica legislativa

Ainda que seja inegável a influência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais/RGPD sobre a Lei Geral brasileira de Proteção de Dados/LGPD,¹⁴ há diferenças substanciais entre tais regimes jurídicos. Uma das mais significativas delas se dá com relação à técnica legislativa utilizada para talhar ambas as leis.

O RGPD é o ponto de chegada de uma longa jornada europeia no campo da proteção de dados pessoais. Após ter sido incluído o direito à proteção de dados como um direito fundamental na Carta de Direitos Fundamentais da UE¹⁵ e anos de vigência da Diretiva 95/46, houve o diagnóstico¹⁶ em torno da necessidade de uma abordagem mais consistente e uniforme da proteção de dados por todo o bloco econômico europeu.

A diretiva consistia em orientações de como os países-membros da UE deveriam formular suas respectivas leis nacionais, havendo, por conseguinte, bastante espaço para *variação jurídica* por cada um dos países-membros. Já o regulamento é um mecanismo do direito comunitário europeu com eficácia imediata, sem a necessidade de internalização dos seus países-membros, e muito mais prescritivo.¹⁷ Como apontam os considerandos do RGPD, o objetivo principal mira na criação de um regime jurídico harmônico e uniforme sobre proteção de dados por toda a UE:

[...]

(8) Considerando que, para eliminar os obstáculos à circulação de dados pessoais, o nível de protecção dos direitos e liberdades das pessoas no que diz respeito ao tratamento destes dados deve ser equivalente em todos os Estados-membros; que a realização deste objectivo, fundamental para o mercado interno, não pode ser assegurada unicamente pelos Estados-membros, tendo especialmente em conta a dimensão das divergências que se verificam actualmente a nível das legislações nacionais aplicáveis na matéria e a necessidade de coordenar as legislações dos Estados-membros para assegurar que a circulação transfronteiriça de dados pessoais seja regulada de forma coerente e em conformidade com o objectivo do mercado interno nos termos do artigo 7º A do Tratado; que é portanto necessária uma acção comunitária com vista à aproximação das legislações;

(9) Considerando que, devido à protecção equivalente resultante da aproximação das legislações nacionais, os Estados-membros deixarão de poder levantar obstáculos à livre circulação entre si de dados pessoais por razões de protecção dos direitos e liberdades das pessoas, nomeadamente do direito à vida privada; que é deixada aos Estados-membros uma margem de manobra que, no contexto da aplicação da directiva, poderá ser utilizada pelos parceiros económicos e sociais; que os Estados-membros poderão, pois, especificar na sua legislação nacional as condições gerais de licitude do tratamento de dados; que, ao fazê-lo, os Estados-membros se esforçarão por melhorar a protecção actualmente assegurada na respectiva legislação nacional; que, nos limites dessa margem de manobra e em conformidade com o direito comunitário, poderão verificar-se disparidades na aplicação da directiva, o que poderá reflectir-se na circulação de dados quer no interior de um Estado-membro, quer na Comunidade; [...].

Por essa razão, em termos quantitativos, o RGPD é um corpo normativo mais consolidado em comparação à LGPD. Enquanto o primeiro é composto por 173 (cento e setenta e três) “considerandos” e 99 (noventa e nove) artigos; a segunda possui 65 (sessenta e cinco) artigos e não conta com orientações interpretativas. Fazendo uma interseção entre o direito comunitário europeu e o brasileiro, o RGPD seria um código de proteção de dados que conta com uma quantidade maior de dispositivos e com uma espécie de exposição de motivos, ao passo que a LGPD seria uma lei mais enxuta e sem pistas interpretativas deixadas por parte do legislador.

Nesse cenário, verificar qual é o nível de convergência entre o RGPD e a LGPD não é um exercício trivial. É necessário ir além do mero entabulamento das leis em questão, fazendo-se necessário um olhar *qualitativo* sobre a racionalidade regulatória que orienta cada uma das normas. A partir desse referencial analítico, pavimenta-se a via para ensaiar a constatação de eventual nível de equivalência entre a lei brasileira e a europeia.

3.2.LGPD vs. GDPR: racionalidades regulatórias convergentes

Na análise comparativa ora realizada, sobressai a convergência em três aspectos importantes, quais sejam, nos princípios enunciados por ambas as regulamentações, no modelo *ex ante* de proteção, bem como no papel central da *accountability* em ambos os modelos regulatórios. No que diz respeito ao *enforcement* foi positivado pela Medida Provisória 869, posteriormente convertida na Lei 13.853/2019.

3.2.1.FIPPs: práticas justas e direitos dos titulares como pilares

Apesar das diferentes técnicas legislativas, há uma convergência perceptível entre os princípios previstos no RGPD e na LGPD. Essa convergência pode ser atribuída menos a uma influência direta do processo legislativo europeu na lei brasileira do que a um longo processo de construção de um consenso transnacional acerca dos princípios básicos que regem essa matéria.

Ao longo do desenvolvimento da temática da proteção de dados pessoais, estabeleceu-se, por meio de instrumentos internacionais e transnacionais, um consenso em torno de um quadro básico de princípios que devem nortear a atividade de tratamento de dados. Esses princípios têm como finalidade impor limitações ao tratamento de dados, bem como atribuir poder de controle ao indivíduo sobre o fluxo de seus dados.

A convergência internacional estabelecida acerca dos princípios é marcante: mesmo os ordenamentos jurídicos mais diversos preveem praticamente os mesmos princípios de proteção de dados, com mínimas diferenças. Esse quadro comum de princípios é conhecido por “*Fair Information Practice Principles*” e teve a sua origem na década de 1970 de forma quase simultânea nos EUA, na Inglaterra e na Alemanha.¹⁸

Em 1972, no âmbito do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar (*Department of Health, Education, and Welfare*),¹⁹ deu-se a primeira ação do Poder Executivo americano em relação ao tratamento dos dados pessoais.²⁰ Nesse ano, foi designado pelo então Secretário desse departamento um comitê consultivo de sistemas automatizados de dados pessoais (“*Advisory Committee on Automated Personal Data Systems*”), para o estudo da questão. Em 1973, o comitê emitiu um relatório sobre “Registros, Computadores e Direitos do Cidadão”, que propunha a redefinição do conceito de privacidade, além de cinco princípios fundamentais que todo o processamento de dados deveria seguir:

1. Não deve existir nenhum banco de dados pessoais, cuja existência seja secreta;
2. Deve haver um meio para o indivíduo conhecer quais informações a seu respeito estão armazenadas e de que forma elas são usadas;
3. Deve existir um meio pelo qual o indivíduo possa impedir que uma informação obtida para uma finalidade seja utilizada para outros fins, sem o seu consentimento;
4. Deve existir um meio pelo qual o indivíduo possa corrigir ou emendar uma informação pessoal armazenada a seu respeito;
5. Qualquer organização que crie, mantenha, use ou dissemine dados de pessoas identificadas deve assegurar que a informação somente será usada da forma pretendida e deverá tomar as precauções razoáveis para prevenir o abuso do dado.²¹

No mesmo período, já estava em andamento na Grã-Bretanha a análise pelo Comitê de Privacidade, coordenado por Kenneth Younger, a respeito dos riscos do

tratamento automatizado de dados realizado por organizações privadas. O comitê emitiu um relatório que sugeria dez princípios para a proteção da privacidade:

1. A informação deve ser armazenada para uma finalidade específica e não deve ser utilizada para outras finalidades, sem a devida autorização.
2. O acesso à informação deve ser conferido àqueles que têm a autorização de mantê-la com os fins pelos quais elas foram coletadas.
3. A quantidade de informações coletadas e armazenadas deve ser o mínimo necessário para se atingir um objetivo específico.
4. Em sistemas computadorizados que processam dados pessoais com fins estatísticos, medidas adequadas devem ser tomadas em seu *design* e programas para separar a identidade do restante dos dados.
5. Deve haver mecanismos pelos quais o sujeito possa ser comunicado sobre a informação armazenada a seu respeito.
6. O nível de segurança a ser atingido por um sistema deve ser especificado previamente pelo usuário e deve incluir precauções contra abusos deliberados ou mau uso da informação.
7. Um sistema de monitoramento deve ser provido para facilitar a detecção de qualquer violação da segurança do sistema.
8. No *design* de sistemas de informação, devem ser especificados períodos para além dos quais a informação não pode mais ser armazenada.
9. Os *data* armazenados devem ser corretos. Deve haver instrumentos para a retificação de incorreções e para a atualização da informação.
10. Deve ser tomado cuidado na codificação de julgamentos válidos.²²

Em 1975, é publicada a primeira lei de proteção de dados do mundo, a lei do Estado de Hesse, na Alemanha, na qual constam princípios muito semelhantes àqueles previstos no relatório da comissão Younger.²³ Desde então, esse quadro comum de princípios foi positivado em diversos tratados, convenções e legislações nacionais.

A Diretiva 95/46/CE e, posteriormente, o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (RGPD) acabou incorporando também esse consenso em torno dos FIPPs. O RGPD é essencialmente mais abrangente do que a Diretiva: ele contém 99 artigos, enquanto a Diretiva possui 34. No que tange à análise da legalidade, a proposta não difere fundamentalmente da Diretiva. As exigências feitas pela Diretiva à qualidade dos dados foram conservadas, só que sob outro título no RGPD: princípios do tratamento de dados.

Continuam sendo previstos os princípios da necessidade, lealdade, finalidade e proporcionalidade, bem como exatidão e atualidade dos dados. Estes podem ser encontrados no art. 5 do RGPD, que passou a abranger três novos princípios: a

transparência (art. 5, n. 1, alínea “a”), a minimização dos dados (art. 5, n. 1, alínea “c”) e a responsabilidade (art. 5, n. 2).

Também o legislador brasileiro optou por estabelecer uma série de princípios no texto da lei, que, na sua topografia, constam do art. 6º. Esse recurso se deve, entre outros fatores, à necessidade de estabelecer as principais balizas para as suas normas, que são, em essência, normas abertas e cuja interpretação deverá ser concretizada no ato de aplicação da Lei.

A LGPD prevê todos os princípios presentes no Regulamento europeu e estabelece ainda outros três: segurança, prevenção e não discriminação. O princípio da boa-fé merece destaque no texto legal ao constar do próprio *caput* do art. 6º, e, embora dialogue com o princípio da lealdade do RGPD, tem o diferencial de remeter a toda uma tradição do direito civil germânico, que permite o controle de situações subjetivas a partir de parâmetros legais objetivos.

Esses novos princípios previstos na LGPD evidenciam a preocupação da Lei com aspectos contemporâneos da proteção de dados e com novas demandas sociais, como o princípio da não discriminação pelo tratamento de dados, abordando o potencial discriminatório do uso de dados gerado por mecanismos de decisão automatizada, ou mesmo o princípio da prevenção – que pode ser utilizado para o desenvolvimento de medidas relacionadas à privacidade na concepção, como os conceitos de *Privacy by Design* e *Security by Design*.

No que diz respeito aos direitos dos titulares, é possível se observar uma convergência entre RGPD e LGPD, especialmente no que tange aos direitos consolidados nessa temática desde a sua origem, como os direitos de acesso, notificação, retificação e cancelamento de seus dados. Semelhante também é a previsão do direito à portabilidade, que constitui uma inovação em ambos os ordenamentos.

No RGPD, esses direitos estão previstos no capítulo 3, a partir do art. 12. Na LGPD, os direitos constam curiosamente também do capítulo III da Lei e são regulados entre os art. 18 e 22.

Apesar da semelhança da previsão de grande parte dos direitos do titular, há divergências importantes que merecem destaque. Em primeiro lugar, o direito à oposição parece ter uma abrangência maior no direito europeu do que no direito brasileiro, uma vez que o RGPD trata da possibilidade de oposição à comercialização direta de dados pessoais (art. 21, n. 2 e 3).

Outra questão digna de nota é a regulação de decisões automatizadas. Apesar das diferentes técnicas de redação empregadas,²⁴ em ambos os sistemas devem ser resguardados os direitos de explicação e a possibilidade de auditoria caso haja um potencial discriminatório.

A maior controvérsia reside, contudo, no direito de “obter intervenção humana por parte do responsável, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão”, previsto no art. 22, n. 3, do RGPD. Isso porque a LGPD, em sua versão original, previa a revisão por pessoa natural, o que foi alterado com a Lei 13.853/2019.

Mesmo com a Lei 13.853/2019, poder-se-ia inferir, a partir da principiologia da Lei, que a intervenção humana continua a ser uma exigência em alguma fase do processo de contestação da decisão automatizada, ainda que não no primeiro pedido de revisão. A prevalecer essa interpretação no direito brasileiro, as normas se aproximariam bastante. É cedo, contudo, para o deslinde dessa questão.

Destaca-se ainda outra diferença entre os dois sistemas jurídicos na regulação das decisões automatizadas que é o art. 21 da LGPD. Este estabelece que “os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo”. Um exemplo de aplicação desse artigo seria o caso em que o exercício do direito de acesso pelo titular ao seu histórico de crédito é utilizado em seu prejuízo, reduzindo o seu *credit score*. O RGPD não prevê tal norma de forma expressa.

Por fim, vale mencionar que o RGPD se diferencia da LGPD ao estabelecer expressamente o direito ao esquecimento (art. 17), previsão que não está clara no texto brasileiro. Nesse ponto, a norma europeia inovou em relação à diretiva, que não trazia expressamente o direito ao esquecimento, mas que foi utilizada como base para o desenvolvimento desse direito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Google Spain vs. Costeja.

Uma questão interessante e que certamente suscitará amplo debate é se o direito previsto no art. 18, IV, da LGPD poderia levar ao desenvolvimento de um direito ao esquecimento, da forma como ocorreu no direito europeu durante a vigência da Diretiva 95/46.

Como se viu, há, de modo geral, grande convergência quanto aos princípios e aos direitos previstos no sistema europeu e brasileiro, ainda que diferenças normativas possam ser encontradas em temas específicos, como direito ao esquecimento e decisões automatizadas.

3.2.2.Racionalidade ex ante de proteção

Característica marcante do modelo europeu de proteção de dados é a exigência de que o controlador só possa tratar dados se estiver amparado em uma base legal, o que pode ser compreendido como uma racionalidade *ex ante* de proteção de dados. Essa concepção do direito europeu está presente desde a edição da Diretiva 95/46 e não é uma racionalidade oriunda invariavelmente dos instrumentos transnacionais de proteção de dados anteriormente mencionados.

Esse modelo *ex ante* de proteção foi consolidado com o RGPD, que prevê, em seu art. 6º, os requisitos de licitude para o tratamento de dados, elencando, ao todo, 6 (seis) bases legais: consentimento, execução de um contrato, obrigação jurídica, defesa de interesses vitais, exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública e legítimo interesse.

Há grande semelhança quando se comparam os direitos europeu e brasileiro sob esse ponto de vista. Afinal, a grande inovação que a LGPD operou no ordenamento jurídico brasileiro pode ser compreendida exatamente na instituição de um modelo *ex ante* de proteção de dados.

Fundamenta-se esse conceito no fato de que não existem mais dados irrelevantes diante do processamento eletrônico e ubíquo de dados na sociedade da informação²⁵. Considerando que os dados pessoais são projeções diretas da personalidade²⁶, qualquer tratamento de dados acaba por influenciar a representação da pessoa na sociedade, podendo afetar a sua personalidade e, portanto, tem o potencial de violar os seus direitos fundamentais.

Esse modelo está amparado em três características centrais: i) um conceito amplo de dado pessoal²⁷, e ii) necessidade de que qualquer tratamento de dados tenha uma base legal e iii) legítimo interesse como hipótese autorizativa e a necessidade de realização de um teste de balanceamento de interesses.

Ao se comparar as bases legais presentes no direito europeu e no direito brasileiro, percebe-se grande semelhança entre elas, com a diferença de que a lei brasileira possui quatro bases legais adicionais, totalizando dez bases para o tratamento de dados. Essas estão também previstas no art. 7º da LGPD e são a realização de estudos por órgão de pesquisa (IV), o exercício regular de direitos em processo judicial (VI), a tutela da saúde (VIII), a proteção do crédito (X).

Vale ressaltar que a base legal relacionada à proteção do crédito tem como finalidade harmonizar as diferentes normas que tratam do tema, ao fazer referência expressa a outras normas que regulam o tratamento de dados no contexto do crédito, como a Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/1990). O termo “inclusive” busca explicitar que, nessa hipótese, não haveria exclusão da aplicação da LGPD, mas sim que as leis específicas serão aplicadas em diálogo com a lei geral.

No que diz respeito à base legal do serviço público, percebe-se uma diferença entre a LGPD e o RGPD, visto que a base da lei brasileira tem uma finalidade mais restrita ao tratar apenas de execução de políticas públicas. Tal base não abrange toda a gama de serviços executados pelo Estado em que se faz necessário o tratamento de dados, o que poderia gerar, à primeira vista, problemas para fundamentar legalmente diversas outras atividades estatais que exigem o processamento de informações pessoais.

Um olhar atento à lei, todavia, permite corrigir tal déficit, visto que o art. 23 da LGPD acaba por enunciar uma base legal mais ampla para o tratamento de dados pelo setor público, podendo, portanto, também ser considerada uma base legal para o tratamento de dados pelos controladores públicos.

Do exposto, percebe-se, ainda, no que se refere à racionalidade *ex ante* de proteção de dados, grande convergência entre os sistemas europeu e brasileiro. Algumas diferenças aqui analisadas são pontuais e se referem a bases legais específicas.

3.2.3.A guinada da accountability²⁸

Ao se estabelecer metas²⁹ como de *privacy by design*, aos agentes da cadeia de tratamento de dados, as novas leis de proteção de dados pessoais apostam, cada vez mais, na colaboração de quem está “prototipando” produtos e serviços

para mitigar os riscos das suas próprias atividades. Ao contrário de toda e qualquer atividade de tratamento de dados ser notificada às autoridades fiscalizadoras,³⁰ hoje a regulação europeia só exige algum tipo de comunicação quando tal atividade atrai um risco elevado para os titulares dos dados. Todo o sistema é calibrado por esse voto de confiança e por uma série de ferramentas pelas quais os agentes de tratamento de dados demonstrem a eficácia das medidas tomadas para estarem em conformidade com as regras de proteção de dados pessoais.

Uma das principais ferramentas diz respeito aos chamados relatórios de impacto à proteção de dados pessoais,³¹ pelos quais o controlador – quem tem poder de tomada de decisão na cadeia de tratamento de dados – deve, obrigatoriamente, executá-los quando houver um *alto risco em jogo*. A regulação europeia, além de trazer uma lista exemplificativa dessas situações, exige que os órgãos fiscalizadores sejam comunicados apenas quando o próprio agente econômico não encontrar meios de mitigar os prováveis malefícios da sua respectiva atividade, devendo, nesse caso, aguardar “luz verde” da autoridade para seguir em frente.

Portanto, diferentemente da diretiva em que qualquer atividade deveria ser comunicada, a GDPR estabelece um regime totalmente novo de reunião de informação cujo gargalo é torneado por quem está tratando os dados. Os “considerandos” do Regulamento deixam claro essa mudança da mentalidade regulatória:

[...]

(89) Diretiva 95/46/EC estipulava a obrigação geral de notificar o tratamento de dados para as autoridades supervisoras [...] essas notificações gerais indiscriminadas devem ser abolidas, sendo substituídas por procedimentos e mecanismos efetivos com foco em quais tipos de operações são de alto risco para os direitos e liberdades fundamentais [...] ao envolver o uso de novas tecnologias.

(84) [...] quando uma relatório de impacto à proteção de dados pessoais indicar que o tratamento envolve um alto risco, o qual não pode ser mitigado por meio de medidas adequadas em acordo com a tecnologia disponível e os custos de implementação, uma consulta à autoridade de proteção de dados deve ser realizada antes de processamento de dados.

Nessa mesma linha, a LGPD também adotou o instrumento de avaliação de impacto. O chamado “relatório de impacto à proteção de dados” é definido como “documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco” (art. 5º, XVII). No entanto, ele não é obrigatório para atividades de alto risco, como definido na legislação europeia, sendo apenas mencionado como algo exigível *a posteriori* por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Portanto, enquanto o Regulamento sistematiza os relatórios de impacto em um capítulo próprio, apontando quais seriam os casos de obrigatoriedade e em que momento deveriam ser estabelecidas “conversas regulatórias”³² com o órgão fiscalizador, a LGPD não lista, por exemplo, em quais casos os relatórios de

impacto seriam obrigatórios nem define quais atividades de tratamento de dados seriam de alto risco.

Além dos relatórios de impacto, a previsão de códigos de boas condutas e certificações seriam outras ferramentas pelas quais os agentes de tratamento demonstrariam ser responsivos às regras de proteção de dados pessoais. Respectivamente, pares de um mesmo setor verticalizaram normas transversais às realidades e aos desafios dos seus respectivos setores³³ e, ainda, haveria terceiros imparciais que certificariam³⁴ os programas corporativos de privacidade das demais diversas organizações.

Todos esses mecanismos seriam um cardápio de opções à disposição dos agentes de tratamento de dados pessoais para demonstrar a sua aderência às normas de proteção de dados pessoais, o que deveria ser obrigatoriamente contabilizado na imposição de qualquer penalidade como resultado das ações de fiscalização.³⁵

Na linha da GDPR, a lei brasileira também previu o princípio específico da *accountability*,³⁶ ao lado dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais,³⁷ selos³⁸ e códigos de boas condutas.³⁹ Tudo isso pode dar roupagem à “boa-fé” dos agentes de tratamento de dados pessoais, o que deve calibrar a imposição de eventuais penalidades.⁴⁰

Há, no entanto, uma diferença significativa entre tais legislações e que decorre do próprio tipo de técnica legislativa de uma lei, mais geral, em relação a um regulamento, mais prescritivo. A legislação brasileira *não procedimentaliza minimamente* como tais mecanismos deveriam ganhar vida, deixando para posterior regulação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Apesar, portanto, de um sistema de correção, por meio do princípio da *accountability*, ser uma tendência que aproxima o modelo brasileiro do europeu, deve-se ter em mente a diferença em torno não só da estrutura normativa em questão mas também, e principalmente, do contexto socioeconômico em que serão aplicados. Dessa forma, eventual equivalência entre o quadro regulatório brasileiro e europeu tende a ser calibrada pela atuação da futura Autoridade brasileira de Proteção de Dados Pessoais, já que regulamentações posteriores sinalizarão, de maneira mais precisa, qual será o espaço ocupado por tais ferramentas de correção e, em última análise, como ganhará vida o princípio da *accountability*.

3.2.4. Arranjo institucional: do texto frio da lei ao sistema de enforcement

O sistema europeu tem como um de seus pilares centrais a autoridade de proteção de dados. Isto é, entende-se que a regulação de proteção de dados não pode ser efetiva sem uma autoridade técnica e independente para aplicá-la. Essa ideia que estava expressa na Convenção 108 do Conselho da Europa é reforçada na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê a exigência de

uma autoridade no âmbito de proteção do próprio direito fundamental à proteção de dados, conforme se extrai do seu art. 8º:

Proteção de dados pessoais: 1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação. 3. *O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma autoridade independente.* (grifo nosso)

A referida concepção de independência acabou por se consolidar também no RGPD, especialmente nos seus considerandos:

[...]

(121) a fim de assegurar a independência da autoridade de controlo, *os membros que a integram deverão exercer as suas funções com integridade, abster-se de qualquer ato incompatível com as mesmas e, durante o seu mandato, não deverão exercer nenhuma atividade, seja ou não remunerada, que com elas seja incompatível.* A autoridade de controlo deverá dispor do seu próprio pessoal, selecionado por si mesma ou por um organismo independente criado nos termos do direito do Estado-Membro, que deverá estar exclusivamente sujeito à orientação do membro ou membros da autoridade de controlo. (grifo nosso)

[...]

(123) As autoridades de controlo *deverão controlar a aplicação das disposições do presente regulamento e contribuir para a sua aplicação coerente em toda a União, a fim de proteger as pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais e facilitar a livre circulação desses dados a nível do mercado interno.* Para esse efeito, as autoridades de controlo deverão cooperar entre si e com a Comissão, sem necessidade de qualquer acordo entre os Estados-Membros quer sobre a prestação de assistência mútua quer sobre tal cooperação. (grifo nosso)

[...]

(125) A autoridade principal deverá ser competente para adotar decisões vinculativas relativamente a medidas que deem execução às competências que lhe tenham sido atribuídas nos termos do presente regulamento. *Na sua qualidade de autoridade principal, a autoridade de controlo deverá implicar no processo decisório e coordenar as autoridades de controlo interessadas.* Nos casos em que a decisão consista em rejeitar no todo ou em parte a reclamação apresentada pelo titular dos dados, esta deverá ser adotada pela autoridade de controlo à qual a reclamação tenha sido apresentada. (grifo nosso)

[...]

(129) A fim de assegurar o controlo e a aplicação coerentes do presente regulamento em toda a União, as autoridades de controlo deverão ter, em cada Estado-Membro, as mesmas funções e poderes efetivos, incluindo poderes de investigação, poderes de correção e de sanção, e poderes consultivos e de autorização, nomeadamente em caso de reclamação apresentada por pessoas singulares, sem prejuízo dos poderes das autoridades competentes para o exercício da ação penal ao abrigo do direito do Estado-Membro, tendo em vista levar as violações ao presente regulamento ao conhecimento das autoridades judiciais e intervir em processos judiciais. Essas competências deverão incluir o poder de impor uma limitação temporário ou definitiva ao tratamento, ou mesmo a sua proibição. (grifo nosso)

A análise do caso brasileiro referente ao modelo de autoridade que irá aplicar a LGPD é bastante intrigante. Não obstante a previsão legal da ANPD, os dispositivos relacionados à sua criação foram vetados no ato da sanção da Lei. Como se lê da motivação do veto, os artigos 55 a 59, que tratavam da criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e de um Conselho de Proteção de Dados, foram vetados em razão de vício de iniciativa.

A Lei 13.853/2019, que recriou a autoridade, não estabeleceu o modelo original que havia sido vetado; ao contrário, em vez de estabelecer uma autoridade na administração indireta, acabou o fazendo debaixo do Ministério da Casa Civil. A constituição dessa autoridade é fundamental, assim como, e principalmente, qual será o seu modelo jurídico, de modo a lhe assegurar independência, poder sancionatório e *expertise*.

Em primeiro lugar, a autoridade é elemento indispensável para que os direitos e as garantias dos cidadãos sobre seus dados sejam efetivamente implementados e monitorados. Uma autoridade independente é igualmente importante para o setor regulado, pois para fins de adequação ao marco normativo, será o ente responsável por manter padrões de aplicação da lei, diferentemente de Tribunais, que são, em geral, chamados a decidir sobre situações particulares.

Para que se caracterize essa necessária independência, as atividades fiscalizatória, sancionatória e decisória da autoridade não poderão estar subordinadas hierarquicamente a outros órgãos. A autoridade ainda deverá contar com as prerrogativas necessárias, como o mandato de seus membros, para que execute suas funções de forma isonômica, para quaisquer modalidades e setores de tratamento de dados pessoais. Desse imperativo, aliás, deriva a opção de a LGPD originariamente estabelecer a natureza de autarquia especial à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Uma autoridade independente, com autonomia de fato e dotada dos meios necessários para realizar suas funções, é, portanto, condição fundamental para que as garantias presentes na LGPD sejam eficazes. Ademais, é uma peça essencial para que o Brasil obtenha as vantagens econômicas e políticas derivadas da LGPD: por exemplo, a obtenção da adequação europeia – garantindo livre fluxo de dados entre o Brasil e os países do bloco – depende invariavelmente do estabelecimento de uma autoridade independente, assim como também o ingresso do Brasil na OCDE.

Dessa forma, embora, na aprovação da LGPD, os modelos de *enforcement* europeu e brasileiro convergissem bastante, com o veto à autoridade e a construção de outro modelo via Lei 13.853/2019, vinculado à administração direta, rompe-se com tal movimento de aproximação. Tão importante quanto um arranjo normativo equivalente é a existência de um arranjo institucional que faça uma fiscalização e aplicação uniforme e eficiente da lei.

Ainda mais quando se nota um modelo de regulação que delega uma série de atividades aos próprios atores regulados, os quais, por sua vez, devem prestar contas – princípio da *accountability* – acerca da eficiência das suas ações para estarem em conformidade com as normas de proteção de dados.

3.2.5. Conclusão – Voltando ao básico: qual é o sentido de equivalência?

O sistema normativo de proteção de dados pessoais emerge, no âmbito da sociedade de informação, como forma de proteger a personalidade do indivíduo contra os potenciais riscos a serem causados pelo tratamento de dados pessoais. Esse sistema exerce uma dupla função, ao buscar proteger a pessoa que é titular desses dados, ao mesmo tempo que fomenta o livre fluxo de informações entre países com nível de proteção equivalente.

Em um contexto tecnológico em que os dados podem fluir, sem qualquer obstáculo, de um país para outro, ou mesmo em que bases de dados podem ser utilizadas de forma compartilhada por controladores e operadores residentes em países diferentes, sujeitos a regulações com níveis de proteção completamente diferentes, fundamenta-se que, sem tal exigência de equivalência, qualquer regulação nacional sobre regulamento da informação pessoal seria completamente inócua.

Nesse sentido, vê-se que não só os instrumentos transnacionais aqui abordados mas também a exigência da equivalência no âmbito nacional, e em especial do Regulamento europeu, acabaram por criar incentivos para que os regimes nacionais de proteção de dados fossem continuamente criados ou modificados de modo a permitir algum grau de interoperabilidade entre eles. Sem essa interoperabilidade, não se poderia falar nem em proteção de dados em âmbito nacional ou transnacional, menos ainda em um livre fluxo de dados entre países.

Considerando a aprovação da LGPD e o seu sistema de *enforcement* ainda em formação, a discussão sobre o grau de equivalência entre ela e o RGPD adquire importância por dois motivos centrais e, ao mesmo tempo, bastante diversos. Em primeiro lugar, para se saber a probabilidade de o Brasil ser considerado um país “adequado” sob o ponto de vista do sistema europeu de proteção de dados e obter uma decisão da Comissão Europeia favorável a um eventual pleito nesse sentido, o que constituiria uma importante vantagem para as entidades públicas e privadas no Brasil que tratam e transferem dados.

Em segundo lugar, porque, em razão do teor do art. 33, I, da LGPD, o Brasil também terá que desenvolver os seus próprios critérios para examinar o grau de adequação de normas estrangeiras à LGPD. Essa norma deve ser interpretada com a do art. 34, que estabelece que o nível de proteção de dados do país estrangeiro será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração diversos critérios, entre eles: as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino; a natureza dos dados; a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares; a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais.

Se, por um lado, a limitação da transferência de dados a países com proteção equivalente é uma regra do regime europeu desde pelo menos a Diretiva Europeia 95/46 de 1995, tendo sido confirmada pelo Regulamento europeu de proteção de

dados pessoais, para o ordenamento brasileiro esse conceito constitui uma grande novidade e trará certamente um desafio em sua implementação. Tendo em vista a tendência natural da proteção de dados na busca pela interoperabilidade entre os diversos ordenamentos jurídicos nacionais, o estabelecimento das variáveis para tal análise comparativa no Brasil deverá usar como parâmetro, além da própria norma brasileira, o contexto transnacional da proteção de dados, conforme exposto no presente artigo.

Por fim, em vista de que tais normas foram talhadas com técnicas legislativas completamente distintas, eventual nível de equivalência deve ser calibrado por uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa. A investigação em torno da convergência desses regimes regulatórios deve ser orientada: i) por qual é a racionalidade regulatória que estrutura os seus respectivos corpos normativos (*regulação ex ante*); e, ii) em vista da proeminência do princípio da *accountability*, acoplado a ferramentas de correção, qual é o arranjo institucional, a atuação das autoridades de proteção de dados, que dará *normatividade* a instrumentos como relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, códigos de boa conduta, selos etc.

Bibliografia

BENNETT, Colin. *Regulating Privacy: data protection and public policy in Europe and the United States*. Ithaca, New York: Cornell University, 1992.

BENNETT, Colin e RAAB, Charles. *The Governance of Privacy: policy instruments in global perspective*. Cambridge: MIT, 2006.

BENNETT, Colin e RAAB, Charles. *Revisiting “The Governance of Privacy”*: Contemporary Policy Instruments in Global Perspective, 2018. Disponível em: [<https://ssrn.com/abstract=2972086>]. Acesso em: 12 maio 2019.

BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019.

BIONI, Bruno Ricardo; ZANATTA, Rafael A. F. *Direito e Economia Política dos Dados: um guia introdutório (no prelo)*. In: Economia de Dados. Org. DOWBOR, Ladislau.

BIONI, Bruno Ricardo; GOMES, Maria Cecilia Oliveira; MONTEIRO, Renato Leite. GDPR matchup: Brazil’s General Data Protection Law. Disponível em: [<https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-brazils-general-data-protection-law/>]. Acesso em: 12 maio 2019.

BIONI, Bruno Ricardo. A produção normativa a respeito da privacidade na economia da informação e do livre fluxo informacional transfronteiriço. In: *Direitos e novas tecnologias: XXIII Encontro Nacional do Conpedi*, Florianópolis: Conpedi, 2014, v. 1, p. 59-82.

BLACK, Julia. What is regulatory innovation? In: BLACK, Julia; LODGE, Martin; THATCHER, Mark (Orgs.), *Regulatory innovation: a comparative analysis*.

Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2005, p. 1-16.

DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

GELLERT, Raphaël. *Understanding the risk-based approach to data protection: an analysis of the links between law, regulation, and risk*. Bruxelas: Vrije University Brussel, 2017.

MAYER-SCHONEBERGER, Viktor. Generational development of data protection in Europe. In: AGRE, Philip; ROTENBERG, Marc (Orgs.), *Technology and privacy: the new landscape*, 1st paperback ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998, p. 219-242.

MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*. Linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

MENDES, Laura Schertel e DONEDA, Danilo. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. In: *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 120, nov.-dez. 2018, p. 469-483.

POLIDO, Frabricio Pasquot. *GDPR e suas repercussões no direito brasileiro: primeiras impressões de análise comparativa*. Instituto de Referência em Internet e Sociedade/IRIS: Belo Horizonte, São Paulo, 2018. p. 05-11.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Luciana Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

WRIGHT, David; DE HERT, Paul (Orgs.). *Privacy Impact Assessment*, Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

1

Doutorando em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade/LAVITS e Fundador do *Data Privacy Brasil*. Atualmente, é consultor jurídico na área de regulação e tecnologia com ênfase em privacidade e proteção de dados.

2

Professora de Direito Civil da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim. Mestre em Direito, Estado e Constituição pela UnB. Foi uma das autoras do anteprojeto de lei de proteção de dados que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Autora do livro *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental* (Saraiva, 2014). Advogada, especialista em proteção de dados pessoais.

3

Os quatro elementos de análise são: *a) determinismo tecnológico*: ainda que países tivessem aspectos culturais socioeconômicos e jurídicos distintos, acabaram por enfrentar problemas e desafios comuns que os aproximaram a adotar soluções regulatórias similares; *b) emulação*: a criação de normas sobre a matéria que acabaram por serem adaptadas ou copiadas por regulações posteriores. Nesse sentido, os *Fair Information Practice Principles* foram gestados no contexto estadunidense, mas acabaram cruzando o Atlântico e influenciando toda a jornada

européia; c) *harmonização*: por questões de interesses econômicos e de relações exteriores, percebeu-se a necessidade da articulação de padrões normativos para não inviabilizar integração entre diferentes países e blocos econômicos sob o argumento de normas conflitantes; d) *penetração*: a ação de atores políticos no processo de construção de regimes jurídicos que forçaram essa agenda de padronização. BENNETT, Colin J.; RAAB, Charles D. Revisiting the governance of privacy: Contemporary policy instruments in global perspective: Revisiting the governance of privacy, *Regulation & Governance*, 2018.

4

MAYER-SCHONEBERGER, Viktor, Generational development of data protection in Europe. In: AGRE, Philip; ROTENBERG, Marc (Orgs.), *Technology and privacy: the new landscape*, 1st paperback ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998, p. 219-242.

5

Disponível em: [www.justice.gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf].

6

É importante destacar que a OCDE já vinha com atuação fortemente na agenda de padrões normativas pelo menos desde o final dos anos 1960: “*The OECD established its first expert group, the Data Bank Panel, as early as 1969. In 1978, a new Group of Experts on Transborder Data Barriers and Privacy Protection was established and instructed to draft a set of recommendations. The resulting ‘Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data’ (Guidelines) were adopted by the OECD in 1980*”. BING, Jon. The Council of Europe Convention and OECD Guidelines on Data Protection. *Michigan Legal Studies*, v. 5, p. 271, 1984.

7

Disponível em: [www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108].

8

Esse é um adjetivo que se desdobra constantemente ao longo das *guidelines* da OCDE e que até hoje é repetido em seus documentos, como a *Privacy Framework* de 2013. Disponível em: [www.oecd.org/internet/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf]. Acesso em:

9

Trata-se do artigo 12 da Convenção cuja proibição foi mantida na versão revisada de 2018: “*A Party shall not, for the sole purpose of the protection of personal data, prohibit or subject to special authorisation the transfer of such data to a recipient who is subject to the jurisdiction of another Party to the Convention. Such a Party may, however, do so if there is a real and serious risk that the transfer to another Party, or from that other Party to a non-Party, would lead to circumventing the provisions of the Convention. A Party may also do so, if bound by harmonised rules of protection shared by States belonging to a regional international organisation*”.

10

Uma das exceções é o modelo canadense pelo qual as transferências internacionais de dados são permitidas, pouco importante uma análise do regime jurídico do país destinatário. Veja-se, nesse sentido, seção 4.1.3 do Personal Information Protection and Electronic Documents Act/PIPEDA.

11

BIONI, Bruno Ricardo, A produção normativa a respeito da privacidade na economia da informação e do livre fluxo informacional transfronteiriço. In: *Direitos e novas tecnologias: XXIII Encontro Nacional do Conpedi*, Florianópolis: Conpedi, 2014, v. 1, p. 59-82.

12

Exemplo disso é a quantidade de países signatários da Convenção 108 de Proteção de Dados Pessoais, os quais estão localizados em continentes e com perfis socioeconômicos bastante distintos um dos outros. A lista pode ser encontrada aqui: Disponível em: [www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=5jUUyWW2].

13

Esse quadro foi elaborado em um trabalho anterior: BIONI, Bruno Ricardo; ZANATTA, Rafael A. F. Direito e Economia Política dos Dados: um guia introdutório (no prelo). In: Economia de Dados (Organizador Ladislau Dowbor).

14

BIONI, Bruno Ricardo. GOMES, Maria Cecília Oliveira; MONTEIRO, Renato Leite. GDPR matchup: Brazil's General Data Protection Law. Disponível em: [<https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-brazils-general-data-protection-law/>]. Cf. também MENDES, Laura Schertel e DONEDA, Danilo. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. In: *Revista de Direito do Consumidor*, v. 120, nov.-dez 2018, p. 469-483.

15

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje*. Trad. Danilo Doneda e Luciana Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 175.

16

EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, "A comprehensive approach on personal data protection in the European Union", Brussels, 2010.

17

Sobre tais técnicas normativas, veja-se: POLIDO, Frabricio *et al.* GDPR e suas repercussões no direito brasileiro: primeiras impressões de análise comparativa. Instituto de Referência em Internet e Sociedade/IRIS: Belo Horizonte, 2018. p. 05-11. E, também, as definições constantes no *site* da própria União Europeia: [https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en].

18

BENNETT, Colin. *Regulating Privacy: data protection and public policy in Europe and the United States*. Op. cit., p. 96 a 99.

19

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE. Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data Systems, 1973. Disponível em: [www.justice.gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf].

20

Ibidem, p. 70 e 71.

21

EUA, HEW, "Records, Computers, and the Rights of Citizens. Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data Systems." Julho, 1973, tradução livre. O relatório pode ser acessado na seguinte página: [<http://epic.org/privacy/hew1973report/c3.htm>]. Acesso em: 24.02.2012.

22

BENNETT, Colin. *Regulating Privacy: data protection and public policy in Europe and the United States*. Op. cit., p. 98 e 99, tradução livre.

23

Ibidem, p. 99.

24

O direito europeu trata de um "direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar" (art. 22, n. 1, RGPD), enquanto a norma brasileira trata de um direito de "solicitar a revisão de decisões

tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses” (art. 21).

25

A constatação foi feita pelo Tribunal Constitucional alemão na decisão que consagrou a autodeterminação informativa (ver nota de rodapé 3). A respeito cf.: MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor*. Linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

26

DONEDA, Danilo. *Da Privacidade à proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

27

É o que se convencionou chamar de conceito expansionista de dado pessoal: BIONI, Bruno. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

28

Parte das conclusões deriva de um trabalho anterior: BIONI, Bruno Ricardo; ZANATTA, Rafael A. F. *Direito e Economia Política dos Dados: um guia introdutório* (no prelo). In: *Economia de Dados* (Organizador Ladislau Dowbor).

29

GELLERT, Raphaël, *Understanding the risk-based approach to data protection: an analysis of the links between law, regulation, and risk*. Bruxelas: Vrije University Brussel, 2017.

30

Veja, por exemplo, a obrigação de notificação de qualquer atividade de tratamento de dados pessoais às autoridades europeias na antiga diretiva de proteção de dados pessoais, a qual deixou de existir no novo regulamento europeu (artigo 18 da Diretiva 95/46/EC).

31

WRIGHT, David; DE HERT, Paul (Orgs.). *Privacy Impact Assessment*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

32

BLACK, Julia, What is regulatory innovation? In: BLACK, Julia; LODGE, Martin; THATCHER, Mark (Orgs.). *Regulatory innovation: a comparative analysis*. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2005, p. 1-16.

33

Considerando 98 da GDPR.

34

Considerando 77 da GDPR.

35

O Regulamento Europeu de Proteção de Dados ressalta que a fixação das penalidades deve levar em consideração as medidas técnicas e organizacionais implementadas para se evitar o dano, especificamente *privacy by design* e padrões de segurança da informação, bem como a aderência a códigos de boas condutas e selos (artigo 83, “d” e “j”, da GDPR).

36

Artigo 6º, X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Artigo 5º, XVII – relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; [...].

Artigo 33, II, “d”.

Artigo 50: Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Artigo 52, § 1º, II e IX, da LGPD.